

JOSÉ AFONSO DA SILVA

**CURSO
DE DIREITO
CONSTITUCIONAL POSITIVO**

*25ª edição, revista e atualizada
nos termos da Reforma Constitucional,
Lei Constitucional n. 48, de 10.8.2005*

 **MALHEIROS
EDITORES**

CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO

© JOSÉ AFONSO DA SILVA

1ª edição, 1976 – 2ª edição, 1984 – 3ª edição, 1985 – 4ª edição,
1ª tiragem, 1987, 2ª tiragem, 1988 – 5ª edição, 1989 – 6ª edição,
1ª tiragem, 03.1990; 2ª tiragem, 08.1990 – 7ª edição, 1991 –
8ª edição, 1992 – 9ª edição, 1ª tiragem, 08.1992; 2ª tiragem, 03.1993;
3ª tiragem, 04.1993 e 09.1993; 4ª tiragem, 02.1994,
04.1994, 07.1994 e 09.1994 – 10ª edição, 1995 – 11ª edição, 02.1996 –
12ª edição, 05.1996 – 13ª edição, 01.1997 – 14ª edição, 08.1997 –
15ª edição, 01.1998 – 16ª edição, 01.1999 – 17ª edição, 01.2000;
18ª edição, 03.2000; 19ª edição, 01.2001; 20ª edição, 01.2002;
21ª edição, 08.2002; 22ª edição, 01.2003; 23ª edição, 01.2004;
24ª edição, 01.2005

ISBN 85.7420.686-5

Direitos reservados desta edição por
MALHEIROS EDITORES LTDA.
Rua Paes de Araújo, 29, conjunto 171
CEP 04531-940 — São Paulo — SP
Tel.: (0xx11) 3078-7205 – Fax: (0xx11) 3168-5495
URL: WWW.malheiroseditores.com.br
e-mail: malheiroseditores@terra.com.br

Composição
Scripta

Capa
Nadia Basso

Impresso no Brasil
Printed in Brazil
08.2005

À HELENA AUGUSTA,
*minha filha, encanto que o mistério
da divindade pôs na minha vida.*

Em memória do sempre lembrado
RONALDO PORTO MACEDO
*que até na dor e no sofrimento ensinou
felicidade e esperança; no
morrer ensinou a viver; até no
momento da morte nos deu, a nós seus
amigos, profunda lição de vida; e,
assim, perpetuou-se entre nós.*

INFORMAÇÃO AO LEITOR

Esta 25ª edição do nosso *Curso* corresponde à 21ª em face da Constituição de 1988, que já sofreu 6 Emendas Constitucionais de Revisão, em 1994, e mais 48 Emendas Constitucionais desde 1992.¹ As edições anteriores, às vezes com mais de uma tiragem, tiveram extraordinária aceitação, tanto que se esgotaram rapidamente. Esta edição foi submetida a uma revisão cuidadosa, para adequá-la às alterações do texto constitucional e para correção de defeitos que as anteriores ainda apresentavam — e, por certo, alguns ainda serão encontrados pelo leitor atento. Substituímos algumas passagens e suprimimos outras em decorrência da atualização procedida, procurando clarear textos que ainda manifestavam obscuridade, sempre na tentativa de aperfeiçoar o livro, mantendo, porém, suas características básicas de livro destinado a estudantes e a estudiosos do Direito Constitucional, fundado nos conceitos mais modernos e atuais da disciplina. Devemos, no entanto, ponderar que a multiplicidade de Emendas agem retalhando a Constituição, com dificuldade para uma atualização impecável. Só após terminar esse processo de retalhação, chamado reforma constitucional, é que teremos a oportunidade de reelaborar o texto a fim de lhe dar coerência em face do que sobrar da Constituição. Esforçamo-nos, por isso, no sentido de não alongar demasiadamente o volume.

A *Constituição da República Federativa do Brasil* de 1988 suscita transformações formais e de fundo que importam a adoção de *nova idéia de direito* que informa uma concepção do Estado e da Sociedade diferente da que vigorava no regime constitucional revogado. Quer um *Estado Democrático de Direito* e uma *Sociedade livre, justa e solidária*. Tudo isso exigia um tratamento novo da matéria constitucional, que tentamos traduzir neste volume. Por certo que múltiplos problemas, postos pelo novo texto, mereceriam, quem sabe, uma reflexão mais

1. Observe-se que o essencial das emendas foram incorporadas ao texto, exceto quando apenas introduziram mudanças no ADCT, como, p. ex., a parte da EC-37/2002 que prorrogou a CPMF e modificou textos sobre precatórios, e a EC-38/2002, que dispôs sobre a incorporação dos policiais militares do antigo Território de Rondônia aos quadros da União.

aprofundada e mais demorada. Isso demandaria mais tempo, sem que, assim mesmo, tivéssemos a certeza de que defeitos fossem evitados. Por essa razão, não quisemos retardar mais a publicação desta edição, com esperança mesmo de que os professores, estudantes, estudiosos e leitores em geral nos apontem as falhas para que sobre elas reflitamos nas próximas edições deste volume que tem merecido boa acolhida dos meios jurídicos. Pareceu-nos ainda conveniente dar uma visão global do conteúdo da Constituição, pelo quê o livro continua abrangente, de modo a que cada professor, que o honrar com sua adoção em seus cursos, possa encontrar informações básicas para os respectivos programas de ensino, ao mesmo tempo em que os estudantes tenham nele fonte de seus estudos e de esclarecimentos de suas dúvidas mais comuns, e juízes, promotores e advogados possam dele servir-se no exercício de suas atividades.

O constituinte fez uma opção muito clara por uma Constituição abrangente. Rejeitou a chamada constituição sintética, que é *constituição negativa*, porque construtora apenas de liberdade-negativa ou liberdade-impedimento, oposta à autoridade, modelo de constituição que, às vezes, se chama de *constituição-garantia* (ou constituição-quadro). A *função garantia* não só foi preservada como até ampliada na Constituição, não como mera garantia do existente ou como simples garantia das liberdades negativas ou liberdades-limite. Assumiu ela a característica de *constituição-dirigente*, enquanto define fins e programa de ação futura, menos no sentido socialista do que no de uma orientação social democrática, imperfeita, reconheça-se. Por isso, não raro, foi minuciosa e, no seu compromisso com a garantia das conquistas liberais e com um plano de evolução política de conteúdo social, nem sempre mantém uma linha de coerência doutrinária firme. Abre-se, porém, para transformações futuras, tanto seja cumprida. E aí está o drama de toda constituição dinâmica: *ser cumprida*.

JAS

SUMÁRIO

PRIMEIRA PARTE

DOS CONCEITOS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

TÍTULO I

DO DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CONSTITUIÇÃO

Capítulo I

Do Direito Constitucional

1. Natureza e conceito 33
2. Objeto 34
3. Conteúdo científico 35

Capítulo II

Da Constituição

- I. CONCEITO, OBJETO E ELEMENTOS
 1. Conceito de constituição 37
 2. Concepções sobre as constituições 38
 3. Classificação das constituições 40
 4. Objeto e conteúdo das constituições 43
 5. Elementos das constituições 44
- II. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO
 6. Rigidez e supremacia constitucional 45
 7. Supremacia material e supremacia formal 45
 8. Supremacia da Constituição Federal 46
- III. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
 9. Inconstitucionalidades 46
 10. Inconstitucionalidade por ação 47
 11. Inconstitucionalidade por omissão 47
 12. Sistemas de controle de constitucionalidade 49
 13. Critérios e modos de exercício do controle jurisdicional 49
 14. Sistema brasileiro de controle de constitucionalidade 50
 15. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade 52
- IV. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
 16. A questão constitucional 56

17. Finalidade e objeto da ação declaratória de constitucionalidade	57
18. Legitimação e competência para a ação	59
19. Efeitos da decisão da ação declaratória de constitucionalidade	60

V. EMENDA À CONSTITUIÇÃO

20. Terminologia e conceito	61
21. Sistema brasileiro	63
22. Poder constituinte e poder reformador	64
23. Limitações ao poder de reforma constitucional	65
24. Controle de constitucionalidade da reforma constitucional	68

Capítulo III

Da Evolução Político-Constitucional do Brasil

I. FASE COLONIAL

1. Capitanias hereditárias	69
2. Governadores-gerais	70
3. Fragmentação e dispersão do poder político na colônia	70
4. Organização municipal na colônia	72
5. Efeitos futuros	72

II. FASE MONÁRQUICA

6. Brasil, Reino Unido a Portugal	72
7. Influência das novas teorias políticas e o movimento constitucional	73
8. A Independência e o problema da unidade nacional	74
9. A Constituição imperial	74
10. Centralização monárquica	75
11. Mecanismo político do poder central	76
12. Os liberais e o ideal federalista	76
13. Vitória das forças republicano-federalistas	77

III. FASE REPUBLICANA

14. Organização do regime republicano	77
15. A Constituição de 1891	78
16. A Revolução de 1930 e a questão social	81
17. A Constituição de 1934 e a ordem econômica e social	81
18. O Estado Novo	82
19. Redemocratização do país e a Constituição de 1946	83
20. Regime dos Atos Institucionais	86
21. A Constituição de 1967 e sua Emenda 1	86
22. A Nova República e a Constituição de 1988	88
23. O plebiscito, a revisão e emendas constitucionais	90

TÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Capítulo I

Dos Princípios Constitucionais

1. Princípios e normas	91
2. Os princípios constitucionais positivos	92

3. Conceito e conteúdo dos princípios fundamentais	93
4. Princípios fundamentais e princípios gerais do Direito Constitucional	95
5. Função e relevância dos princípios fundamentais	95

Capítulo II

Dos Princípios Constitucionais do Estado Brasileiro

I. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1. O País e o Estado brasileiros	97
2. Território e forma de Estado	98
3. Estado Federal: forma do Estado brasileiro	99
4. Forma de Governo: a República	102
5. Fundamentos do Estado brasileiro	104
6. Objetivos fundamentais do Estado brasileiro	105

II. PODER E DIVISÃO DE PODERES

7. O princípio da divisão de poderes	106
8. Poder político	106
9. Governo e distinção de funções do poder	107
10. Divisão de poderes	108
11. Independência e harmonia entre os poderes	109
12. Exceções ao princípio	111

III. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

13. Democracia e Estado de Direito	112
14. Estado de Direito	112
15. Estado Social de Direito	115
16. O Estado Democrático	117
17. Caracterização do Estado Democrático de Direito	119
18. A lei no Estado Democrático de Direito	121
19. Princípios e tarefa do Estado Democrático de Direito	122

Capítulo III

Do Princípio Democrático e Garantia dos Direitos Fundamentais

I. REGIME POLÍTICO

1. Conceito de regime político	123
2. Regime político brasileiro	125

II. DEMOCRACIA

3. Conceito de democracia	125
4. Pressupostos da democracia	126
5. Princípios e valores da democracia	129
6. O poder democrático e as qualificações da democracia	133
7. Conceito de povo e democracia	134
8. Exercício do poder democrático	136
9. Democracia representativa	137
10. O mandato político representativo	138
11. Democracia participativa	141
12. Democracia pluralista	143
13. Democracia e direito constitucional brasileiro	145

SEGUNDA PARTE

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

TÍTULO I

A DECLARAÇÃO DE DIREITOS

Capítulo I

Formação Histórica das Declarações de Direitos

1. Generalidades	149
2. Antecedentes das declarações de direitos	149
3. Cartas e declarações inglesas	151
4. A Declaração de Virgínia	153
5. A Declaração Norte-Americana	155
6. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão	157
7. A Declaração do Povo Trabalhador e Explorado	159
8. Universalização das declarações de direitos	161
9. Declaração de direitos nas constituições contemporâneas	166
10. Declaração de direitos nas constituições brasileiras	170

Capítulo II

Teoria dos Direitos Fundamentais do Homem

1. Inspiração e fundamentação dos direitos fundamentais	172
2. Forma das declarações de direitos	175
3. Conceito de direitos fundamentais	175
4. Natureza e eficácia das normas sobre direitos fundamentais	179
5. Caracteres dos direitos fundamentais	180
6. Classificação dos direitos fundamentais	182
7. Integração das categorias de direitos fundamentais	184
8. Direitos e garantias dos direitos	186

TÍTULO II

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Capítulo I

Fundamentos Constitucionais

1. Conceito de direito individual	190
2. Destinatários dos direitos e garantias individuais	191
3. Classificação dos direitos individuais	193
4. Direitos coletivos	195
5. Deveres individuais e coletivos	195

Capítulo II

Do Direito à Vida e do Direito à Privacidade

I. DIREITO À VIDA

1. A vida como objeto do direito	197
2. Direito à existência	198

3. Direito à integridade física	199
4. Direito à integridade moral	201
5. Pena de morte	201
6. Eutanásia	202
7. Aborto	203
8. Tortura	203

II. DIREITO À PRIVACIDADE

9. Conceito e conteúdo	205
10. Intimidade	206
11. Vida privada	208
12. Honra e imagem das pessoas	209
13. Privacidade e informática	209
14. Violação à privacidade e indenização	210

Capítulo III

Direito de Igualdade

1. Introdução ao tema	211
2. Igualdade, desigualdade e justiça	212
3. Isonomia formal e isonomia material	214
4. O sentido da expressão "igualdade perante a lei"	215
5. Igualdade de homens e mulheres	217
6. O princípio da igualdade jurisdicional	218
7. Igualdade perante a tributação	221
8. Igualdade perante a lei penal	222
9. Igualdade "sem distinção de qualquer natureza"	223
10. Igualdade "sem distinção de sexo e de orientação sexual"	223
11. Igualdade "sem distinção de origem, cor e raça"	224
12. Igualdade "sem distinção de idade"	225
13. Igualdade "sem distinção de trabalho"	225
14. Igualdade "sem distinção de credo religioso"	226
15. Igualdade "sem distinção de convicções filosóficas ou políticas"	226
16. O princípio da não discriminação e sua tutela penal	227
17. Discriminações e inconstitucionalidade	227

Capítulo IV

Direito de Liberdade

I. O PROBLEMA DA LIBERDADE

1. Liberdade e necessidade	230
2. Liberdade interna e liberdade externa	231
3. Conteúdo histórico da liberdade	232
4. O problema da conceituação	232
5. Liberdade e liberação	233
6. Liberdade e democracia	234

II. LIBERDADE E LIBERDADES

7. Formas da liberdade	234
8. Liberdade de ação e legalidade	235

III. LIBERDADE DA PESSOA FÍSICA	
9. Noção e formas	236
10. Liberdade de locomoção	237
11. Liberdade de circulação	239
12. A segurança pessoal — Remissão	240
IV. LIBERDADE DE PENSAMENTO	
13. Conceito e formas de expressão	241
14. Liberdade de opinião	241
14.1 Escusa de consciência	242
14.2 Formas de expressão	243
15. Liberdade de comunicação	
15.1 Noção e princípios	243
15.2 Liberdade de manifestação do pensamento	244
15.3 Liberdade de informação em geral	245
15.4 Liberdade de informação jornalística	246
15.5 Meios de comunicação	248
16. Liberdade religiosa	248
17. Liberdade de expressão intelectual, artística e científica e direitos conexos	253
18. Liberdade de expressão cultural	255
19. Liberdade de transmissão e recepção do conhecimento	255
V. LIBERDADE DE AÇÃO PROFISSIONAL	
20. Liberdade de escolha profissional: conceito e natureza	256
21. Acessibilidade à função pública	257
22. Regras de contenção	258
VI. OS DIREITOS COLETIVOS	
23. Direitos coletivos e liberdade de expressão coletiva	258
24. Direito à informação	259
25. Direito de representação coletiva	260
26. Direito de participação	261
27. Direito dos consumidores	262
28. Liberdade de reunião	263
29. Liberdade de associação	266
VII. REGIME DAS LIBERDADES	
30. Técnica de proteção das liberdades	268
31. Eficácia das normas constitucionais sobre as liberdades	269
32. Sistemas de restrições das liberdades individuais	269

Capítulo V

Direito de Propriedade

I. DIREITO DE PROPRIEDADE EM GERAL	
1. Fundamento constitucional	270
2. Conceito e natureza	271
3. Regime jurídico da propriedade privada	272
4. Propriedade e propriedades	274
5. Propriedade pública	275

II. PROPRIEDADES ESPECIAIS	
6. Considerações gerais	275
7. Propriedade autoral	275
8. Propriedade de inventos, de marcas e de nome de empresas	277
9. Propriedade-bem de família	278
III. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE	
10. Conceito e classificação	279
11. Restrições	279
12. Servidões e utilização de propriedade alheia	280
13. Desapropriação	281
IV. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE	
14. Questão de ordem	281
15. Conceito e natureza	281
16. Função social e transformação do regime de propriedade	283

Título III

DIREITOS SOCIAIS

Capítulo I

Fundamentos Constitucionais dos Direitos Sociais

1. Ordem social e direitos sociais	285
2. Direitos sociais e direitos económicos	286
3. Conceito de direitos sociais	286
4. Classificação dos direitos sociais	287

Capítulo II

Direitos Sociais Relativos aos Trabalhadores

I. QUESTÃO DE ORDEM	
1. Espécies de direitos relativos aos trabalhadores	288
II. DIREITOS DOS TRABALHADORES	
2. Destinatários	288
3. Direitos reconhecidos	289
4. Direito ao trabalho e garantia do emprego	289
5. Direitos sobre as condições de trabalho	292
6. Direitos relativos ao salário	293
7. Direitos relativos ao repouso e à inatividade do trabalhador	295
8. Proteção dos trabalhadores	295
9. Direitos relativos aos dependentes do trabalhador	297
10. Participação nos lucros e co-gestão	298

III. DIREITOS COLETIVOS DOS TRABALHADORES

11. Caracterização	300
12. Liberdade de associação ou sindical	
12.1 Associação e sindicato	301
12.2 Liberdade e autonomia sindical	301
12.3 Participação nas negociações coletivas de trabalho	302

12.4 Contribuição sindical	303
12.5 Pluralidade e unicidade sindical	303
13. Direito de greve	304
14. Direito de substituição processual	305
15. Direito de participação laboral	306
16. Direito de representação na empresa	306

Capítulo III

Direitos Sociais do Homem Consumidor

I. DIREITOS SOCIAIS RELATIVOS À SEGURIDADE

1. Considerações gerais	307
2. Seguridade social	307
3. Direito à saúde	308
4. Direito à previdência social	310
5. Direito à assistência social	310

II. DIREITOS SOCIAIS RELATIVOS À EDUCAÇÃO E À CULTURA

6. Significação constitucional	311
7. Objetivos e princípios informadores da educação	311
8. Direito à educação	312
9. Direito à cultura	313

III. DIREITOS SOCIAIS RELATIVOS À MORADIA

10. Fundamento constitucional	314
11. Significação e conteúdo	314
12. Condição de eficácia	315

IV. DIREITO AMBIENTAL

13. Direito ao lazer	315
14. Direito ao meio ambiente	316

V. DIREITOS SOCIAIS DA CRIANÇA E DOS IDOSOS

15. Proteção à maternidade e à infância	316
16. Direitos dos idosos	317

TÍTULO IV

DIREITO DE NACIONALIDADE

Capítulo I

Teoria do Direito de Nacionalidade

1. Conceito de nacionalidade	318
2. Natureza do direito de nacionalidade	319
3. Nacionalidade primária e nacionalidade secundária	320
4. Modos de aquisição da nacionalidade	320
5. O polipátrida e o "heimatlos"	321

Capítulo II

Direito de Nacionalidade Brasileira

1. Formação do povo brasileiro	324
2. Fonte constitucional do direito de nacionalidade	325

3. Os brasileiros natos	326
4. Os brasileiros naturalizados	330
5. Condição jurídica do brasileiro nato	331
6. Condição jurídica do brasileiro naturalizado	332
7. Perda da nacionalidade brasileira	332
8. Reaquisição da nacionalidade brasileira	333

Capítulo III

Condição Jurídica do Estrangeiro no Brasil

1. O estrangeiro	335
2. Especial condição jurídica dos portugueses no Brasil	335
3. Locomoção no território nacional	337
4. Aquisição e gozo dos direitos civis	338
5. Gozo dos direitos individuais e sociais	339
6. Não aquisição de direitos políticos	339
7. Asilo político	340
8. Extradicação	341
9. Expulsão	342
10. Deportação	342

TÍTULO V

DIREITO DE CIDADANIA

Capítulo I

Dos Direitos Políticos

1. Conceito e abrangência	344
2. Direitos políticos, nacionalidade e cidadania	345
3. Modalidades de direitos políticos	346
4. Aquisição da cidadania	346

Capítulo II

Dos Direitos Políticos Positivos

I. CONCEITO E INSTITUIÇÕES

1. Conceito	348
2. Instituições	348

II. DIREITO DE SUFRÁGIO

3. Conceito e funções do sufrágio	349
4. Formas de sufrágio	350
5. Natureza do sufrágio	355
6. Titulares do direito de sufrágio	355
7. Capacidade eleitoral ativa	356
8. Exercício do sufrágio: o voto	356
9. Natureza do voto	357
10. Caracteres do voto	358
11. Organização do eleitorado	364
12. O corpo eleitoral	365
13. Elegibilidade e condições de elegibilidade	366
14. Os eleitos e o mandato político — Remissão	367

III. SISTEMAS ELEITORAIS	
15. As eleições	368
16. Reeleição	369
17. O sistema majoritário	370
18. O sistema proporcional	371
19. O sistema misto	376
IV. PROCEDIMENTO ELEITORAL	
20. Noção e fases	378
21. Apresentação das candidaturas	378
22. O escrutínio	379
23. O contencioso eleitoral	379

Capítulo III
Dos Direitos Políticos Negativos

I. SIGNIFICADO	
1. Conceito	381
2. Conteúdo	381
3. Interpretação	382
II. PRIVAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS	
4. Modos de privação dos direitos políticos	382
5. Perda dos direitos políticos	383
6. Suspensão dos direitos políticos	384
7. Competência para decidir sobre perda e suspensão de direitos políticos	386
III. REAQUISIÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS	
8. Condições de re aquisição dos direitos políticos	386
9. Reaquisição dos direitos políticos perdidos	387
10. Reaquisição dos direitos políticos suspensos	387
IV. INELEGIBILIDADES	
11. Conceito de inelegibilidade	388
12. Objeto e fundamentos das inelegibilidades	388
13. Eficácia das normas sobre inelegibilidades	389
14. Inelegibilidades absolutas e relativas	390
15. Desincompatibilização	392

Capítulo IV
Dos Partidos Políticos

I. IDÉIA DE PARTIDO POLÍTICO	
1. Noção de partido político	394
2. Origem e evolução dos partidos	395
3. Sistemas partidários	397
4. Institucionalização jurídico-constitucional dos partidos. Controles	399
5. Função dos partidos e partido de oposição	401
6. Natureza jurídica dos partidos	403
II. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA	
7. Liberdade partidária	404

8. Condicionamentos à liberdade partidária	405
9. Autonomia e democracia partidária	405
10. Disciplina e fidelidade partidária	406
11. Sistema de controles dos partidos brasileiros	407
III. PARTIDOS E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA	
12. Partidos e elegibilidade	408
13. Partido e exercício do mandato	408
14. Sistema partidário e sistema eleitoral	409

TÍTULO VI
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

Capítulo I
Direitos e suas Garantias

1. Garantias dos direitos	412
2. Garantias constitucionais dos direitos	412
3. Confronto entre direitos e garantias: a lição de Ruy Barbosa	413
4. Classificação das garantias constitucionais	417

Capítulo II
Garantias Constitucionais Individuais

I. BASES CONSTITUCIONAIS	
1. Conceito	419
2. Classificação	419
II. O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE	
3. Conceito e fundamento constitucional	420
4. Lei e a expressão "em virtude de lei"	421
5. Legalidade e reserva de lei	422
6. Legalidade e legitimidade	424
7. Legalidade e poder regulamentar	425
8. Legalidade e atividade administrativa	427
9. Legalidade tributária	428
10. Legalidade penal	429
11. Princípios complementares do princípio da legalidade	429
12. Controle de legalidade	430

III. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIÁRIA	
13. Fundamento	430
14. Monopólio judiciário do controle jurisdicional	431
15. Direito de ação e de defesa	431
16. Direito ao devido processo legal	431
17. Direito a uma duração razoável do processo	432

IV. ESTABILIDADE DOS DIREITOS SUBJETIVOS	
18. Segurança das relações jurídicas	433
19. Direito adquirido	434
20. Ato jurídico perfeito	435
21. Coisa julgada	436

V. DIREITO À SEGURANÇA

22. Considerações gerais	437
23. Segurança do domicílio	437
24. Segurança das comunicações pessoais	438
25. Segurança em matéria penal	438
26. Segurança em matéria tributária	441

VI. REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS

27. Remédios, ações e garantias	442
28. Direito de petição	442
29. Direito a certidões	444
30. "Habeas corpus"	444
31. Mandado de segurança individual	446
32. Mandado de injunção	448
33. "Habeas data"	453

Capítulo III**Garantias dos Direitos Coletivos, Sociais e Políticos****I. GENERALIDADES**

1. Colocação do tema	458
----------------------------	-----

II. GARANTIAS DOS DIREITOS COLETIVOS

2. Esclarecimentos prévios	458
3. Mandado de segurança coletivo	459
4. Mandado de injunção coletivo	461
5. Ação popular	462

III. GARANTIAS DOS DIREITOS SOCIAIS

6. Normatividade dos direitos sociais	465
7. Tutela jurisdicional dos hipossuficientes	465
8. Sindicalização e direito de greve	465
9. Decisões judiciais normativas	466
10. Garantias de outros direitos sociais	466

IV. GARANTIAS DOS DIREITOS POLÍTICOS

11. Definição do tema — Remissão	466
12. Eficácia dos direitos fundamentais	467

TERCEIRA PARTE**DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E DOS PODERES****TÍTULO I****DA ESTRUTURA BÁSICA DA FEDERAÇÃO****Capítulo I****Das Entidades Componentes da Federação Brasileira**

1. Questão de ordem	471
2. Componentes do Estado Federal	471
3. Brasília	472

4. A posição dos Territórios	473
5. Formação dos Estados	473
6. Os Municípios na federação	474
7. Vedações constitucionais de natureza federativa	476

Capítulo II**Da Repartição de Competências**

1. O problema da repartição de competências federativas	477
2. O princípio da predominância do interesse	478
3. Técnicas de repartição de competências	478
4. Sistema da Constituição de 1988	479
5. Classificação das competências	479
6. Sistema de execução de serviços	482
7. Gestão associada de serviços públicos	483

Capítulo III**Da Intervenção nos Estados e nos Municípios**

I. AUTONOMIA E INTERVENÇÃO	
1. Autonomia e equilíbrio federativo	484
2. Natureza da intervenção	484
II. INTERVENÇÃO FEDERAL NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL	
3. Pressupostos de fundo da intervenção. Casos e finalidades	485
4. Pressupostos formais. O ato de intervenção: limites e requisitos	486
5. Controle político e jurisdicional da intervenção	487
6. Cessação da intervenção: consequências	488
7. O interventor. Responsabilidade civil	489
III. INTERVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS	
8. Fundamento constitucional	489
9. Motivos para a intervenção nos Municípios	490
10. Competência para intervir	490

TÍTULO II**DO GOVERNO DA UNIÃO****Capítulo I****Da União como Entidade Federativa**

I. NATUREZA DA UNIÃO	
1. Significado e conceito de União	492
2. União federal e Estado federal	493
3. Posição da União no Estado federal	493
4. União e pessoa jurídica de Direito Internacional	494
5. União como pessoa jurídica de direito interno	495
6. Bens da União	495
II. COMPETÊNCIAS DA UNIÃO	
7. Noção e classificação	496
8. Competência internacional e competência política	496
9. Competência administrativa	497
10. Competência na área de prestação de serviços	497

11. Competência em matéria urbanística	499
12. Competência econômica	500
13. Competência social	500
14. Competência financeira e monetária	501
15. Competência material comum	501
16. Competência legislativa	502

III. ORGANIZAÇÃO DOS PODERES DA UNIÃO

17. Poderes da União	504
18. Sistema de governo	505

Capítulo II Do Poder Legislativo

I. ORGANIZAÇÃO

1. O Congresso Nacional	509
2. A Câmara dos Deputados	510
3. O Senado Federal	511
4. Organização interna das Casas do Congresso: Regimento Interno — Mesa — Comissões — Polícia — Serviços Administrativos	511
5. Comissão representativa	516

II. FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES

6. Funcionamento do Congresso Nacional: Legislatura — Sessões Legislativas — Reuniões — <i>Quorum</i> para deliberações	517
7. Atribuições do Congresso Nacional	520
8. Atribuições privativas da Câmara dos Deputados	521
9. Atribuições privativas do Senado Federal	521
10. Convocação e comparecimento de Ministros	523

III. PROCESSO LEGISLATIVO

11. Conceito e objeto	524
12. Atos do processo legislativo: Iniciativa legislativa — Emendas — Votação — Sanção e veto — Promulgação e publicação da lei	524
13. Procedimentos legislativos: Procedimento legislativo ordinário — Procedimento legislativo sumário — Procedimentos legislativos especiais	529

IV. ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS

14. Conteúdo	534
15. Prerrogativas: Inviolabilidade — Imunidade — Privilégio de foro — Isenção do serviço militar	534
16. Direitos: subsídio	537
17. Incompatibilidades	538
18. Perda do mandato: Cassação — Extinção	539

Capítulo III Do Poder Executivo

1. Noção e formas	542
2. Chefe de Estado e Chefe de Governo	542
3. Eleição e mandato do Presidente da República	543

4. Substitutos e sucessores do Presidente	545
5. Subsídios	546
6. Perda do mandato do Presidente e do Vice	547
7. Atribuições do Presidente da República	548
8. Classificação das atribuições do Presidente da República	549
9. Responsabilidade do Presidente da República	550

Capítulo IV Do Poder Judiciário

I. JURISDIÇÃO

1. A função jurisdicional	553
2. Jurisdição e legislação	554
3. Jurisdição e administração	555
4. Órgãos da função jurisdicional	556

II. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

5. Jurisdição constitucional, guarda da Constituição e Corte Constitucional	557
6. Composição do STF	559
7. Competência	559
8. Descumprimento de preceito constitucional fundamental	562

III. SÚMULAS VINCULANTES

9. Súmulas vinculantes, súmulas impeditivas de recursos e efeito vinculante	563
10. Súmulas vinculantes e assentos da jurisprudência	564
11. Disciplina das súmulas vinculantes	565
12. Súmulas impeditivas de recurso	566
13. Efeito vinculante	566

IV. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

14. Controle externo do Poder Judiciário	567
15. Composição do Conselho	568
16. Funcionamento	568
17. Competência	569
18. Ouvidorias	570

V. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

19. Composição	570
20. Competência	571
21. Conselho da Justiça Federal	573

VI. JUSTIÇA FEDERAL

22. Seus órgãos	573
23. Tribunais Regionais Federais: Composição — Competência	574
24. Juízes Federais: Organização da justiça federal de primeira instância — Competência — Foro das causas de interesse da União	575

VII. JUSTIÇA DO TRABALHO	
25. Organização	577
26. Competência	579
27. Recorribilidade das decisões do TST	580
VIII. JUSTIÇA ELEITORAL	
28. Organização e competência	580
29. Recorribilidade de suas decisões	581
IX. JUSTIÇA MILITAR	
30. Composição	582
31. Competência	582
X. JUIZADOS ESPECIAIS E DE PAZ	
32. Juizados especiais	583
33. Justiça de paz	583
XI. ESTATUTO DA MAGISTRATURA E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO	
34. Princípios estatutários da magistratura	583
35. Espécies de garantias do Judiciário	588
36. Garantias institucionais do Judiciário	588
37. Garantias funcionais do Judiciário	590
38. Mecanismos de aceleração dos processos	591
39. Escolas de magistrados	592
 <i>Capítulo V</i> Das Funções Essenciais à Justiça 	
I. FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA	
1. "Nemo iudex sine actore"	594
2. Carreiras jurídicas e isonomia concreta	595
II. ADVOGADO	
3. Uma profissão	595
4. O advogado e a administração da justiça	596
5. Inviolabilidade	597
III. O MINISTÉRIO PÚBLICO	
6. Natureza e princípios institucionais	597
7. Estrutura orgânica	599
8. Garantias	601
9. Funções institucionais	602
10. Conselho Nacional do Ministério Público	603
IV. A ADVOCACIA PÚBLICA	
11. Advocacia-Geral da União	605
12. Representação das unidades federadas — Remissão	606
13. Defensorias Públicas e a defesa dos necessitados	606

TÍTULO III DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL

Capítulo I **Dos Estados Federados**

I. FORMAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ESTADOS	
1. Autonomia dos Estados	608
2. Auto-organização e Poder Constituinte Estadual	609
3. Formas de expressão do Constituinte Estadual	610
4. Limites do Poder Constituinte dos Estados	611
5. Princípios constitucionais sensíveis	612
6. Princípios constitucionais estabelecidos	613
7. Interpretação dos princípios limitadores da capacidade organizadora dos Estados	617
II. COMPETÊNCIAS ESTADUAIS	
8. Questão de ordem	617
9. Competências reservadas aos Estados	618
10. Competências vedadas aos Estados	618
11. Competência exclusiva especificada	619
12. Competências estaduais comuns e concorrentes	619
13. Competências estaduais materiais: Econômicas — Sociais — Administrativas — Financeiras	620
14. Competência legislativa	622
III. ORGANIZAÇÃO DOS GOVERNOS ESTADUAIS	
15. Esquema constitucional	622
16. Poder Legislativo estadual	622
17. Poder Executivo estadual	627
18. Poder Judiciário estadual	631
19. Funções essenciais à Justiça estadual	634
IV. CONTEÚDO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL	
20. Considerações gerais	636
21. Elementos limitativos	637
22. Elementos orgânicos	637
23. Elementos sócio-ideológicos	638
24. Conclusão	638

Capítulo II **Dos Municípios**

I. REPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO NA FEDERAÇÃO	
1. Fundamentos constitucionais	639
2. Município, entidade federada?	640
II. AUTONOMIA MUNICIPAL	
3. Base constitucional da autonomia municipal	640

4. Capacidade de auto-organização municipal	642
5. Lei Orgânica própria	642
6. Competências municipais	643

III. GOVERNO MUNICIPAL

7. Poderes municipais	644
8. Poder Executivo municipal	644
9. Poder Legislativo municipal	646
10. Subsídio de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores	647

Capítulo III Do Distrito Federal

I. PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS

1. Natureza	649
2. Autonomia	649
3. Auto-organização	650
4. Competências	650

II. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

5. Poder Legislativo	651
6. Poder Executivo	651
7. Poder Judiciário	652
8. Funções essenciais à Justiça no Distrito Federal	653

TÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Capítulo I Estruturas Básicas da Administração Pública

I. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1. Noção de Administração	654
2. Organização da Administração	655
3. Administração direta, indireta e fundacional	655

II. ÓRGÃOS SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

4. Natureza e posição	657
5. Os Ministros no parlamentarismo e no presidencialismo	657
6. Atribuições dos Ministros	658
7. Condições de investidura no cargo	658
8. Responsabilidade dos Ministros	659
9. Juízo competente para processar e julgar os Ministros	659
10. Os Ministérios	659

III. CONSELHOS

11. Generalidades	660
12. Conselho da República	661
13. Conselho de Defesa Nacional	661
14. Conselho de Comunicação Social	662

IV. ÓRGÃOS SUPERIORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS

15. Organização administrativa de Estados e Municípios	662
16. Secretários de Estado	663
17. Órgãos superiores municipais	663

V. REGIÕES

18. Regiões e microrregiões	664
19. Organismos regionais	664
20. Regionalização orçamentária	664
21. Regiões metropolitanas	665

Capítulo II Dos Princípios Constitucionais da Administração Pública

1. Colocação do tema	666
2. Princípios da legalidade e da finalidade	667
3. Princípio da impessoalidade	667
4. Princípio da moralidade e da probidade administrativas	668
5. Princípio da publicidade	669
6. Princípio da eficiência	671
7. Princípio da licitação pública	672
8. Princípio da prescritibilidade dos ilícitos administrativos	673
9. Princípio da responsabilidade civil da Administração	673
10. Princípio da participação	675
11. Princípio da autonomia gerencial	675

Capítulo III Dos Servidores Públicos

I. AGENTES ADMINISTRATIVOS

1. Agentes políticos e administrativos	677
2. Acessibilidade à função administrativa	678
3. Investidura em cargo ou emprego	679
4. Contratação de pessoal temporário	681
5. Sistema remuneratório dos agentes públicos	681
6. Acréscimos pecuniários e regras de sua singeleza	687
7. Isonomia, paridade, vinculação e equiparação de vencimentos	687
8. Vedação de acumulações remuneradas	689
9. Servidor investido em mandato eletivo	689

II. SERVIDORES PÚBLICOS

10. Execução de serviços na Federação e organização do funcionalismo	691
11. Aposentadoria, pensão e seus proventos	691
12. Efetividade e estabilidade	697
13. Vitaliciedade	699

14. Sindicalização e greve de servidores públicos	699
15. Direitos trabalhistas extensivos aos servidores	700
III. DOS MILITARES	
16. Conceito	701
17. Direitos e garantias constitucionais dos servidores militares	702
18. Direitos trabalhistas extensivos aos servidores militares	705

TÍTULO V

BASES CONSTITUCIONAIS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Capítulo I

Do Sistema Tributário Nacional

I. DISPOSIÇÕES GERAIS DA TRIBUTAÇÃO

1. Questão de ordem	706
2. Componentes	706
3. Empréstimo compulsório	707
4. Contribuições sociais	708
5. Normas de prevenção de conflitos tributários	709
6. Elementos do sistema tributário nacional	712

II. LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

7. Poder de tributar e suas limitações	712
8. Princípios constitucionais da tributação e sua classificação	712

III. DISCRIMINAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RENDAS TRIBUTÁRIAS

9. Natureza e conceito	719
10. Sistema discriminatório brasileiro	720

IV. DISCRIMINAÇÃO DAS RENDAS POR FONTES

11. Atribuição constitucional de competência tributária	721
12. Competência tributária da União	722
13. Competência tributária dos Estados	725
14. Competência tributária dos Municípios	728

V. DISCRIMINAÇÃO DAS RENDAS PELO PRODUTO

15. Repartição de receitas e federalismo cooperativo	730
16. Técnicas de repartição da receita tributária	730
17. Normas de controle e disciplina da repartição de receita tributária	732

Capítulo II

Das Finanças Públicas e do Sistema Orçamentário

I. NORMAS SOBRE FINANÇAS PÚBLICAS

1. Colocação do tema	734
2. Normas gerais	734
3. Função do Banco Central	735

II. ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS

4. Instrumentos normativos do sistema orçamentário	735
5. Orçamento-programa	737

III. PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

6. Conteúdo dos orçamentos	738
7. Formulação dos princípios orçamentários	738
8. O princípio da exclusividade	739
9. O princípio da programação	740
10. O princípio do equilíbrio orçamentário	740
11. O princípio da anualidade	741
12. O princípio da unidade	742
13. O princípio da universalidade	743
14. O princípio da legalidade	744
15. Princípios da não-vinculação e da quantificação dos créditos orçamentários	745

IV. ELABORAÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS

16. Leis orçamentárias	746
17. Processo de formação das leis orçamentárias	746
18. Rejeição do projeto de orçamento anual e suas consequências	747

Capítulo III

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

I. FISCALIZAÇÃO E SISTEMAS DE CONTROLE

1. A função de fiscalização	749
2. Formas de controle	750
3. O sistema de controle interno	751
4. O sistema de controle externo	752

II. TRIBUNAIS DE CONTAS

5. Instituição do Tribunal de Contas da União	753
6. Organização e atribuições do Tribunal de Contas da União	754
7. Participação popular	757
8. Tribunais de Contas estaduais e municipais	757
9. Natureza do controle externo e do Tribunal de Contas	758
10. Prestação de contas	759

TÍTULO VI

DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

Capítulo I

Do Estado de Defesa no Estado de Sítio

I. SISTEMA CONSTITUCIONAL DAS CRISES

1. Defesa do Estado e compromissos democráticos	760
2. Defesa das instituições democráticas	761
3. Tipos de estados de exceção vigentes	763

II. ESTADO DE DEFESA	
4. Defesa do Estado e estado de defesa	763
5. Pressupostos e objetivo	764
6. Efeitos e execução do estado de defesa	765
7. Controles	765

III. ESTADO DE SÍTIO	
8. Pressupostos, objetivos e conceito	766
9. Efeitos do estado de sítio	768
10. Controles do estado de sítio	769

Capítulo II
Das Forças Armadas

1. Destinação constitucional	771
2. Instituições nacionais permanentes	772
3. Hierarquia e disciplina	773
4. Componentes das Forças Armadas	773
5. Fixação e modificação dos efetivos das Forças Armadas	774
6. A obrigação militar	774
7. Organização militar e seus servidores	776

Capítulo III
Da Segurança Pública

1. Polícia e segurança pública	777
2. Organização da segurança pública	779
3. Polícias federais	780
4. Polícias estaduais	781
5. Guardas municipais	781

QUARTA PARTE
DA ORDEM ECONÔMICA E DA ORDEM SOCIAL

TÍTULO I
DA ORDEM ECONÔMICA

Capítulo I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

I. BASES CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA	
1. Questão de ordem	785
2. Constitucionalização da ordem econômica	786
3. Elementos sócio-ideológicos	787
4. Fundamento e natureza da ordem econômica instituída	788
5. Fim da ordem econômica	788

II. CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E SEUS PRINCÍPIOS	
6. Idéia de constituição econômica	790
7. Princípios da constituição econômica formal	791
8. Soberania nacional econômica	792
9. Liberdade de iniciativa econômica	793
10. Livre concorrência e abuso do poder econômico	795
11. Princípios de integração	796
12. Empresa brasileira e capital estrangeiro	797

III. ATUAÇÃO ESTATAL NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
13. Capitalismo, socialismo e estatismo	799
14. Serviço público e atividade econômica estatal	801
15. Modos de atuação do Estado na economia	804
16. Exploração estatal de atividade econômica	804
17. Monopólios	805
18. Intervenção no domínio econômico	807
19. Planejamento econômico	809

Capítulo II
Das Propriedades na Ordem Econômica

1. O princípio da propriedade privada	812
2. Propriedade dos meios de produção e propriedade socializada	812
3. Função social da empresa e condicionamento à livre iniciativa	813
4. Propriedade de interesse público	815
5. Propriedade do solo, do subsolo e de recursos naturais	815
6. Propriedade de embarcações nacionais	816
7. Política urbana e propriedade urbana	816
8. Propriedade rural e reforma agrária	819

Capítulo III
Do Sistema Financeiro Nacional

1. Generalidades	824
2. As alterações da EC-40/2003	824
3. Lei complementar e recepção constitucional	825
4. Sentido e objetivos	826
5. Participação do capital estrangeiro nas instituições financeiras	826
6. Cooperativas de crédito	827

TÍTULO II
DA ORDEM SOCIAL

Capítulo I
Introdução à Ordem Social

1. Considerações gerais	828
2. Base e objetivo da ordem social	828
3. Conteúdo e princípios da ordem social	828

Capítulo II
Da Seguridade Social

1. Conteúdo, princípios e financiamentos da seguridade social	830
2. Saúde	831
3. Previdência social	832
4. Assistência social	836

Capítulo III
Da Ordem Constitucional da Cultura

1. Questão de ordem	837
2. Educação	837
3. Princípios básicos do ensino	838
4. Autonomia universitária	838
5. Ensino público	839
6. Ensino pago e ensino gratuito	840
7. Cultura e direitos culturais	842
8. Desporto	844
9. Ciência e tecnologia	844
10. Comunicação social	844
11. Meio ambiente	845

Capítulo IV
Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

1. A família	848
2. Tutela da criança e do adolescente	849
3. Tutela dos idosos	849

Capítulo V
Dos índios

1. Fundamentos constitucionais dos direitos indígenas	851
2. Organização social dos índios: comunidade, etnia e nação	851
3. Direitos sobre as terras indígenas	854
4. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios	855
5. O indigenato	856
6. Posse permanente	858
7. Usufruto exclusivo	859
8. Mineração em terras indígenas	859
9. Demarcação das terras indígenas	860
10. Defesa dos direitos e interesses dos índios	860

QUINTA PARTE
CONCLUSÃO GERAL

<i>Capítulo Único</i>	865
BIBLIOGRAFIA	867
ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO	893

PRIMEIRA PARTE

**DOS CONCEITOS
E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS**

Título I

Do Direito Constitucional e da Constituição

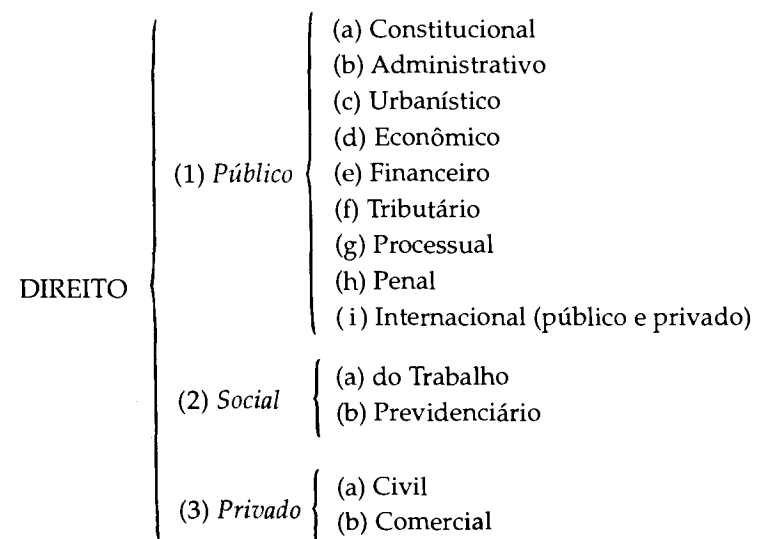
Capítulo I

DO DIREITO CONSTITUCIONAL

1. Natureza e conceito. 2. Objeto. 3. Conteúdo científico.

1. Natureza e conceito

O *Direito* é fenômeno histórico-cultural, realidade ordenada, ou ordenação normativa da conduta segundo uma conexão de sentido. Consiste num *sistema normativo*. Como tal, pode ser estudado por unidades estruturais que o compõem, sem perder de vista a totalidade de suas manifestações. Essas unidades estruturais ou dogmáticas do sistema jurídico constituem as *divisões do Direito*, que a doutrina denomina *ramos da ciência jurídica*, comportando subdivisões conforme mostra o esquema seguinte:



O *Direito Constitucional*, como se vê, pertence ao setor do *Direito Público*. Distingue-se dos demais ramos do *Direito Público* pela natureza específica de seu objeto e pelos princípios peculiares que o informam. Configura-se¹ como *Direito Público fundamental* por referir-se diretamente à organização e funcionamento do Estado, à articulação dos elementos primários do mesmo e ao estabelecimento das bases da estrutura política. "Suas normas constituem uma ordem 'em que repousam a harmonia e a vida do grupo, porque estabelece equilíbrio entre seus elementos' (Sánchez Agesta) e na qual todas as demais disciplinas jurídicas centram seu ponto de apoio. Daí que o *Direito Constitucional* se manifesta como um tronco do qual se separam os demais ramos do *Direito*, que nele encontram suas 'têtes de capítulo' (Pellegrino-Rossi)".²

Podemos defini-lo como o ramo do *Direito Público* que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. Como esses princípios e normas fundamentais do Estado compõem o conteúdo das constituições (*Direito Constitucional Objetivo*), pode-se afirmar, como o faz Pinto Ferreira, que o *Direito Constitucional* é a ciência positiva das constituições.³

2. Objeto

Maurice Hauriou declara que o *Direito Constitucional* tem por objeto a constituição política do Estado. Esta assertiva seria essencialmente verdadeira não fosse o sentido tão restrito que ele empresta ao conceito de constituição política.⁴

Acima, admitimos, de modo geral, que cabe ao *Direito Constitucional* o estudo sistemático das normas que integram a constituição do Estado. Sendo ciência, há de ser forçosamente um conhecimento sistematizado sobre determinado objeto, e este é constituído pelas normas fundamentais da organização do Estado, isto é, pelas normas relativas à estrutura do Estado, forma de governo, modo de aquisição e exercício do poder, estabelecimento de seus órgãos, limites de sua atuação, direitos fundamentais do homem e respectivas garantias e regras básicas da ordem econômica e social.

Mas esse estudo sistematizado não há de ser tomado em sentido estrito de mera exposição do conteúdo dessas normas e regras fundamentais. Compreenderá também a investigação de seu valor, sua efi-

1. Cf. Jorge Xifras Heras, *Curso de derecho constitucional*, t. I/95.

2. Cf. Jorge Xifras Heras, *ob. cit.*, p. 95.

3. Cf. Pinto Ferreira, *Princípios gerais do direito constitucional moderno*, p. 13.

4. Cf. *Princípios de derecho público y constitucional*, p. 2.

cácia, o que envolve critérios estimativos de interpretação, sempre correlacionando os esquemas normativos escritos, ou costumeiros, com a dinâmica sócio-cultural que os informa.

3. Conteúdo científico

O conteúdo científico do *Direito Constitucional* abrange três aspectos, que dão lugar às seguintes disciplinas: (a) *Direito Constitucional Positivo ou Particular*; (b) *Direito Constitucional Comparado*; (c) *Direito Constitucional Geral*.

Direito Constitucional Positivo ou Particular é o que tem por objeto o estudo dos princípios e normas de uma constituição concreta, de um Estado determinado; compreende a interpretação, sistematização e crítica das normas jurídico-constitucionais desse Estado, tal como configuradas na Constituição vigente, nos seus legados históricos e sua conexão com a realidade sócio-cultural existente (ex.: *Direito Constitucional brasileiro*, francês, inglês, mexicano etc., de acordo com as respectivas constituições).

Direito Constitucional Comparado, "cuja missão é o estudo teórico das normas jurídico-constitucionais positivas (mas não necessariamente vigentes) de vários Estados, preocupando-se em destacar as singularidades e os contrastes entre eles ou entre grupos deles",⁵ é um método, mais que uma ciência especial, que consiste em "cotejar instituições políticas e jurídicas para, através do cotejo, extrair a evidência de semelhanças entre elas. Mas essa evidência, por si só, não é, ainda, uma conclusão científica. A conclusão está um passo mais além. Está na relação que se estabelece em função da comparação; na afirmação de um tipo genérico de órgão ou de função, cuja existência pode ser assegurada pela observação de várias semelhanças nos sistemas comparados, e assim por diante. Na medida em que o método comparativo permite a formulação de leis ou relações gerais e a verificação de estruturas governamentais semelhantes, ele concorre para as conclusões do chamado *Direito Constitucional Geral* e, indubitavelmente, para o aprimoramento do *Direito Constitucional interno*, ou particular".⁶

5. Cf. Manuel Garcia-Pelayo, *Derecho constitucional comparado*, p. 20; Jorge Xifras Heras, *ob. cit.*, t. I/99. Ainda sobre o *Direito Constitucional Comparado*, cf. Giuseppe de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, 3ª ed., Padova, CEDAM, 1991; Paolo Biscaretti di Ruffia, *Introduzione al diritto costituzionale comparato*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1970; Luis Sánchez Agesta, *Curso de derecho constitucional comparado*, 5ª ed., 2ª reimpressão, Madrid, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, 1974.

6. Cf. Afonso Arinos de Melo Franco, *Curso de direito constitucional brasileiro*, I/35 e 36.

Direito Constitucional Geral “é aquela disciplina que delinea uma série de princípios, de conceitos e de instituições que se acham em vários direitos positivos ou em grupos deles para classificá-los e sistematizá-los numa visão unitária”.⁷ “Se o Direito Constitucional Comparado [diz Afonso Arinos] é apenas um método de trabalho, já o Direito Constitucional Geral é uma ciência, que visa generalizar os princípios teóricos do Direito Constitucional particular e, ao mesmo tempo, constatar pontos de contato e interdependência do Direito Constitucional Positivo dos vários Estados que adotam formas semelhantes de governo”.⁸

Constituem objeto do Direito Constitucional Geral: o próprio conceito de Direito Constitucional, seu objeto genérico, seu conteúdo, suas relações com outras disciplinas, suas fontes, a evolução do constitucionalismo, as categorias gerais do Direito Constitucional, a teoria da constituição (conceito, classificação, tipos, formação, mudanças, extinção, defesa, natureza de suas normas, estrutura normativa etc.), hermenêutica, interpretação e aplicação das normas constitucionais, a teoria do poder constituinte etc.

7. Cf. Garcia-Pelayo, *ob. cit.*, p. 21.

8. Cf. *ob. cit.*, v. I/36. Obra clássica de Direito Constitucional Geral é a de Carl Schmitt, *Teoria da Constituição (Verfassungslehre)*, München, 1928, de que existe tradução espanhola, *Teoría de la constitución*, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, s.d.); igualmente famosa é a obra de Santi Romano, *Principii di diritto costituzionale generale*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1947 (tradução brasileira de Maria Helena Diniz, *Princípios de direito constitucional geral*, São Paulo, Ed. RT, 1977); no mesmo sentido, Karl Loewenstein, *Teoría de la constitución*, Barcelona, ed. Ariel, 1965, trad. espanhola de Alfredo Gallego Anabitarte (original alemão, *Verfassungslehre*, Tübingen, J. C. Mohr, 1959); Pinto Ferreira, *Princípios gerais do direito constitucional moderno*, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 1983, 2 vols.; Jorge Reinaldo A. Vanossi, *Teoría constitucional*, Buenos Aires, Depalma, 1975, 2 vols.; Ernesto Saa Velasco, *Teoría constitucional geral*, Barraquilla, Ediciones Universidades Simon Bolivar, Libre de Pereira y Medellin, 1977. Podemos ainda acrescentar o famoso livro de Benjamin Constant, *Cours de politique constitutionnelle*, Paris, Guillaume, 1872 (edição espanhola, *Curso de política constitucional*, Madrid, Taurus, 1968, trad. de F. L. de Yturbe); também, Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, *O Federalista*, Brasília, Ed. UnB, 1984, trad. de Heitor Almeida Herrera (original, *The Federalist*, New York, Modern Library, s.d.); também Geoffrey Marshall, *Constitutional theory*, Oxford, Oxford University Press, 1971 (tradução espanhola, *Teoría constitucional*, Madrid, Editorial Espasa-Calpe, 1982, trad. de Ramon García Cotarelo), e Carl J. Friedrich, *La Démocratie constitutionnelle*, Paris, PUF, 1958, trad. francesa de d'Andrée Martinerie e outros.

Capítulo II

DA CONSTITUIÇÃO

I. CONCEITO, OBJETO E ELEMENTOS: 1. Conceito de constituição. 2. Concepções sobre as constituições. 3. Classificação das constituições. 4. Objeto e conteúdo das constituições. 5. Elementos das constituições. II. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO: 6. Rigidez e supremacia constitucional. 7. Supremacia material e supremacia formal. 8. Supremacia da Constituição Federal. III. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: 9. Inconstitucionalidades. 10. Inconstitucionalidade por ação. 11. Inconstitucionalidade por omissão. 12. Sistemas de controle de constitucionalidade. 13. Critérios e modos de exercício do controle jurisdicional. 14. Sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. 15. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. IV. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE: 16. A questão constitucional. 17. Finalidade e objeto da ação declaratória de constitucionalidade. 18. Legitimação e competência para a ação. 19. Efeitos da decisão da ação declaratória de constitucionalidade. V. EMENDA À CONSTITUIÇÃO: 20. Terminologia e conceito. 21. Sistema brasileiro. 22. Poder constituinte e poder reformador. 23. Limitações ao poder de reforma constitucional. 24. Controle de constitucionalidade da reforma constitucional.

I. CONCEITO, OBJETO E ELEMENTOS

1. Conceito de constituição

A palavra *constituição* é empregada com vários significados, tais como: (a) “Conjunto dos elementos essenciais de alguma coisa: a *constituição* do universo, a *constituição* dos corpos sólidos”; (b) “Temperamento, compleição do corpo humano: uma *constituição* psicológica explosiva, uma *constituição* robusta”; (c) “Organização, formação: a *constituição* de uma assembléia, a *constituição* de uma comissão”; (d) “O ato de estabelecer juridicamente: a *constituição* de dote, de renda, de uma sociedade anônima”; (e) “Conjunto de normas que regem uma corporação, uma instituição: a *constituição* da propriedade”; (f) “A lei fundamental de um Estado”.

Todas essas acepções são analógicas. Expressam, todas, a idéia de *modo de ser de alguma coisa* e, por extensão, a de organização interna de seres e entidades. Nesse sentido é que se diz que *todo Estado tem constituição*, que é o simples *modo de ser do Estado*.

A *constituição do Estado*, considerada sua lei fundamental, seria, então, a organização dos seus elementos essenciais: *um sistema de*

*normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado.*¹

2. Concepções sobre as constituições

Essa noção de constituição estatal, contudo, não expressa senão uma idéia parcial de seu conceito, porque a toma como algo desvinculado da realidade social, quando deve ser concebida como uma estrutura normativa, uma conexão de sentido, que envolve um conjunto de valores. Mas aqui surge um campo de profundas divergências doutrinárias: em que *sentido* se deve conceber as constituições: no *sociológico*, no *político* ou no *puramente jurídico*?

Ferdinand Lassalle as entende no *sentido sociológico*. Para ele, a constituição de um país é, em essência, a *soma dos fatores reais do poder que regem nesse país*, sendo esta a *constituição real e efetiva*, não passando a constituição escrita de uma “folha de papel”.² Outros, como Carl Schmitt, emprestam-lhes *sentido político*, considerando-as como *decisão política fundamental, decisão concreta de conjunto sobre o modo e forma de existência da unidade política*, fazendo distinção entre *constituição e leis constitucionais*; aquela só se refere à decisão política fundamental (estrutura e órgãos do Estado, direitos individuais, vida democrática etc.); as leis constitucionais são os demais dispositivos inscritos no texto do documento constitucional, que não contenham matéria de decisão política fundamental.³ Outra corrente, liderada por Hans

Kelsen, vê-as apenas no *sentido jurídico*; constituição é, então, considerada *norma pura*, puro *dever-ser*, sem qualquer pretensão a fundamentação sociológica, política ou filosófica. A concepção de Kelsen toma a palavra constituição em dois sentidos: no *lógico-jurídico* e no *jurídico-positivo*; de acordo com o primeiro, constituição significa *norma fundamental hipotética*, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da constituição *jurídico-positiva* que equivale à norma positiva suprema, conjunto de normas que regula a criação de outras normas, lei nacional no seu mais alto grau.⁴

Essas concepções pecam pela unilateralidade. Vários autores, por isso, têm tentado formular conceito unitário de constituição, concebendo-a em sentido que revele conexão de suas normas com a totalidade da vida coletiva; *constituição total*, “mediante a qual se processa a integração dialética dos vários conteúdos da vida coletiva na unidade de uma ordenação fundamental e suprema”.⁵

Busca-se, assim, formular uma *concepção estrutural de constituição*, que a considera no seu aspecto normativo, não como norma pura, mas como norma em sua conexão com a realidade social, que lhe dá o conteúdo fático e o sentido axiológico. Trata-se de um complexo, não de partes que se adicionam ou se somam, mas de elementos e membros que se enlaçam num todo unitário. O sentido jurídico de constituição não se obterá, se a apreciarmos desgarrada da totalidade da vida social, sem conexão com o conjunto da comunidade. Pois bem, certos modos de agir em sociedade transformam-se em condutas humanas valoradas historicamente e constituem-se em fundamento do existir comunitário, formando os *elementos constitucionais* do grupo social, que o constituinte intui e revela como preceitos normativos fundamentais: a *constituição*.

A constituição é algo que tem, *como forma*, um complexo de normas (escritas ou costumeiras); *como conteúdo*, a conduta humana motivada pelas relações sociais (econômicas, políticas, religiosas etc.); *como fim*, a realização dos valores que apontam para o existir da comunidade; e, finalmente, *como causa criadora e recriadora*, o poder que emana do povo. Não pode ser compreendida e interpretada, se não se tiver em mente essa estrutura, considerada como *conexão de sentido*, como é tudo aquilo que integra um conjunto de valores. Isso não

1. A doutrina distingue três elementos constitutivos do Estado: *território, população e governo*. Certos autores, como Alexandre Groppali, admitem outro elemento — a *finalidade* (cf. *Doutrina do Estado*, pp. 123 e ss.). Parece-nos cabível a consideração da finalidade, concebido o Estado como uma entidade de fins precisos e determinados: regular globalmente em todos os seus aspectos, a vida social de dada comunidade (cf. Giorgio Balladore Pallieri, *Diritto costituzionale*, p. 10), visando a realização do bem comum. O Estado é, assim, uma *ordenação* que tem por *fin* específico e essencial a regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma dada *população* sobre um dado *território* (cf. Balladore Pallieri, *ob. cit.*, p. 14), destacando, na definição, os quatro elementos constitutivos, entre os quais o termo *ordenação* dá a idéia de poder institucionalizado, governo constitucional. Cf. também Dalmo de Abreu Dallari, *Elementos de teoria geral do Estado*, pp. 64 a 104.

2. Cf. *Que es una constitución?*, pp. 61 e 62; sociológica também é a posição de Charles A. Bear, *Una interpretación económica de la constitución de los Estados Unidos*, Buenos Aires, Ed. Araiú, 1953, trad. de Héctor Sáenz y Quesada; de Harold J. Laski, *Le gouvernement parlementaire en Angleterre*, Paris, PUF, 1950, trad. de Jacques Cadart e Jacqueline Prélôt, e *La crisis de la democracia*, Buenos Aires, Ed. Siglo Veinte, 1950, trad. de Armando Bazan, bem como a concepção marxista.

3. Cf. *Teoría de la constitución*, pp. 20 e ss.

4. Cf. *Teoria Pura do Direito*, v. I/1, 2, 7 e ss. e v. II/12, 19 e ss.; *Teoría General del derecho y del Estado*, pp. 5 e ss., 65 e ss., 135 e 147.

5. Cf. Pinto Ferreira, *Princípios gerais do direito constitucional moderno*, t. I/31, e *Da Constituição*, p. 24; no mesmo sentido, embora sob orientação diferente, Manuel García-Pelayo, *Derecho constitucional comparado*, pp. 20, 100, 101 e 111; Hermann Heller, *Teoría del Estado*, pp. 269 a 290; nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, pp. 20 a 25.

impede que o estudioso dê preferência a dada perspectiva. Pode estudá-la sob o ângulo predominantemente formal, ou do lado do conteúdo, ou dos valores assegurados, ou da interferência do poder.

3. Classificação das constituições

A doutrina apresenta vários modos de classificar as constituições, não havendo uniformidade de pontos de vista sobre o assunto. Adotamos a seguinte:

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES	1. quanto ao conteúdo	(a) materiais (b) formais
	2. quanto à forma	(a) escritas (b) não escritas
	3. quanto ao modo de elaboração	(a) dogmáticas (b) históricas
	4. quanto à origem	(a) populares (democráticas) (b) outorgadas
	5. quanto à estabilidade	(a) rígidas (b) flexíveis (c) semi-rígidas

A *constituição material* é concebida em sentido amplo e em sentido estrito. No primeiro, identifica-se com a organização total do Estado, com regime político. No segundo, designa as normas constitucionais escritas ou costumeiras, inseridas ou não num documento escrito, que regulam a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos e os direitos fundamentais.⁶ Neste caso, constituição só se re-

fere à matéria essencialmente constitucional; as demais, mesmo que integrem uma constituição escrita, não seriam constitucionais.⁷

A *constituição formal* é o peculiar modo de existir do Estado, reduzido, sob forma escrita, a um documento solenemente estabelecido pelo poder constituinte e somente modificável por processos e formalidades especiais nela própria estabelecidos.

Considera-se *escrita* a *constituição*, quando codificada e sistematizada num texto único, elaborado reflexivamente e de um jato por um órgão constituinte, encerrando todas as normas tidas como fundamentais sobre a estrutura do Estado, a organização dos poderes constituídos, seu modo de exercício e limites de atuação, os direitos fundamentais (políticos, individuais, coletivos, econômicos e sociais).

Não escrita, ao contrário, é a *constituição* cujas normas não constam de um documento único e solene, mas se baseie principalmente nos costumes, na jurisprudência e em convenções e em textos constitucionais esparsos, como é a Constituição inglesa.

O conceito de *constituição dogmática* é conexo com o de *constituição escrita*, como o de *constituição histórica* o é com *constituição não escrita*. *Constituição dogmática*, sempre escrita, é a elaborada por um órgão constituinte, e sistematiza os *dogmas* ou idéias fundamentais da teoria política e do Direito dominantes no momento. *Constituição histórica* ou *costumeira*, não escrita, é, ao contrário, a resultante de lenta formação histórica, do lento evoluir das tradições, dos fatos sócio-políticos, que se cristalizam como normas fundamentais da organização de determinado Estado, e o exemplo ainda vivo é o da Constituição inglesa.

São *populares* (ou democráticas) as *constituições* que se originam de um órgão constituinte composto de representantes do povo, eleitos para o fim de as elaborar e estabelecer, como são exemplos as Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1946 e 1988. *Outorgadas* são as elaboradas e estabelecidas sem a participação do povo, aquelas que o governante — Rei, Imperador, Presidente, Junta Governativa, Ditador — por si ou por interposta pessoa ou instituição, outorga, impõe, concede ao povo, como foram as Constituições brasileiras de 1824, 1937, 1967 e 1969. Poder-se-ia acrescentar aqui outro tipo de constituição, que não é propriamente outorgada, mas tampouco é democrática, ainda que criada com participação popular. Podemos

6. Nesse sentido é que a Constituição do Império do Brasil, nos termos de seu art. 178, definia como *constitucional* só o que dissesse respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos, e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Não se consideravam constitucionais as demais normas nela inseridas que não tratassem daquela *matéria*.

7. Lembre-se da concepção de Carl Schmitt, que distingue constituição de *leis constitucionais*. Para ele, em real verdade, constituição só existe no conceito material (decisões políticas fundamentais); o mais entra no conceito de leis constitucionais (cf. o art. 178 da Constituição do Império, acima mencionado).

chamá-la *constituição cesarista*, porque formada por plebiscito popular sobre um projeto elaborado por um Imperador (plebiscitos napoleônicos) ou um Ditador (plebiscito de Pinochet, no Chile). A participação popular, nesses casos, não é democrática, pois visa apenas ratificar a vontade do detentor do poder. Não destacamos esse tipo no esquema, porque bem pode ser considerado um modo de outorga por interposta pessoa.

Rígida é a *constituição* somente alterável mediante processos, solenidades e exigências formais especiais, diferentes e mais difíceis que os de formação das leis ordinárias ou complementares. Ao contrário, a *constituição* é *flexível* quando pode ser livremente modificada pelo legislador segundo o mesmo processo de elaboração das leis ordinárias. Na verdade, a própria lei ordinária contrastante muda o texto constitucional. *Semi-rígida* é a *constituição* que contém uma parte rígida e outra flexível, como fora a Constituição do Império do Brasil, à vista de seu art. 178.⁸

A estabilidade das constituições não deve ser absoluta, não pode significar imutabilidade. Não há constituição imutável diante da realidade social cambiante, pois não é ela apenas um instrumento de ordem, mas deverá sê-lo, também, de progresso social. Deve-se assegurar certa estabilidade constitucional, certa permanência e durabilidade das instituições, mas sem prejuízo da constante, tanto quanto possível, perfeita *adaptação das constituições às exigências do progresso, da evolução e do bem-estar social*. A rigidez relativa constitui técnica capaz de atender a ambas as exigências, permitindo emendas, reformas e revisões, para adaptar as normas constitucionais às novas necessidades sociais, mas impondo processo especial e mais difícil para essas modificações formais, que o admitido para a alteração da legislação ordinária.⁹

Cumpre, finalmente, não confundir o conceito de constituição rígida com o de constituição escrita, nem o de constituição flexível com o de constituição histórica. Têm havido exemplos de constituições escritas flexíveis, embora o mais comum é que sejam rígidas. As constituições históricas são juridicamente flexíveis, pois podem ser modificadas pelo legislador ordinário, mas normalmente são política e socialmente rígidas. Raramente são modificadas.

8. Diz o citado art. 178: "É só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivos dos poderes políticos, e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos; tudo o que não é constitucional pode ser alterado, sem as formalidades referidas (nos arts. 173 a 177), pelas legislaturas ordinárias".

9. Cf. J. H. Meirelles Teixeira. *Curso de Direito Constitucional*, pp. 106 e 108.

4. Objeto e conteúdo das constituições

As constituições têm *por objeto* estabelecer a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos, o modo de aquisição do poder e a forma de seu exercício, limites de sua atuação, assegurar os direitos e garantias dos indivíduos, fixar o regime político e disciplinar os fins sócio-econômicos do Estado, bem como os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais.

Nem sempre tiveram as constituições objeto tão amplo. Este vem estendendo-se com o correr da história. A cada etapa desta, algo de novo entra nos textos constitucionais, "cujo conteúdo histórico é variável no espaço e no tempo, integrando, na expressão lapidar de Bergson, a 'multiplicidade no uno' das instituições econômicas, jurídicas, políticas e sociais na 'unidade múltipla' da lei fundamental do Estado".¹⁰

A ampliação do conteúdo da constituição gerou a distinção, já vista, entre constituição em sentido material e constituição em sentido formal. Segundo a doutrina tradicional, as prescrições das constituições, que não se referiam à estrutura do Estado, à organização dos poderes, seu exercício e aos direitos do homem e respectivas garantias, só são constitucionais em virtude da natureza do documento a que aderem; por isso, diz-se que *são constitucionais apenas do ponto de vista formal*. Quase a unanimidade dos autores acolhe essa doutrina. A despeito disso, permitimo-nos ponderar que esse apego ao tradicional revela incompreensão das dimensões do Direito Constitucional contemporâneo. Tal fato se verifica, além do mais, em consequência de não se arrolarem os fins e os objetivos do Estado entre os elementos essenciais que o *constituem*. Ora, concebido que a *finalidade* (fins e objetivos a realizar) se insere entre os elementos constitutivos do Estado e, considerando a ampliação das funções estatais atualmente, chegaremos à conclusão inelutável de que o conceito de Direito Constitucional também se ampliou, para compreender as normas fundamentais da ordenação estatal, ou, mais especificamente, para regular os princípios básicos relativos ao território, à população, ao governo e às finalidades do Estado e suas relações recíprocas. Diante disso, perde substância a doutrina que pretende diferenciar constituição material e constituição formal e, pois, direito constitucional material e direito constitucional formal.¹¹

10. Cf. Pinto Ferreira, *Princípios gerais do direito constitucional moderno*, p. 12.

11. Cf. Georges Burdeau, *Droit constitutionnel et institutions politiques*, p. 67, referindo-se às disposições sociais (legislação do trabalho notadamente) e às econômicas das constituições atuais, diz que: "On les considere souvent comme étrangère au contenu logique d'une constitution, mais c'est à tort, car la constitution n'a pas

5. Elementos das constituições

Em decorrência do que acaba de ser dito, as constituições contemporâneas apresentam-se recheadas de normas que incidem sobre matérias de natureza e finalidades as mais diversas, sistematizadas num todo unitário e organizadas coerentemente pela ação do poder constituinte que as teve como fundamentais para a coletividade estatal. Essas normas, geralmente agrupadas em títulos, capítulos e seções, em função da conexão do conteúdo específico que as vincula, dão caráter polifacético às constituições, de que se originou o tema denominado *elementos das constituições*.

A doutrina diverge quanto ao número e à caracterização desses elementos. De nossa parte, entendemos que a generalidade das constituições revela, em sua estrutura normativa, *cinco categorias de elementos*,¹² que assim se definem:

(1) *elementos orgânicos*, que se contêm nas normas que regulam a estrutura do Estado e do poder, e, na atual Constituição, concentram-se, predominantemente, nos Títulos III (*Da Organização do Estado*), IV (*Da Organização dos Poderes e do Sistema de Governo*), Capítulos II e III do Título V (*Das Forças Armadas e da Segurança Pública*) e VI (*Da Tributação e do Orçamento*, que constituem aspectos da organização e funcionamento do Estado);

(2) *elementos limitativos*, que se manifestam nas normas que consubstanciam o elenco dos direitos e garantias fundamentais: direitos individuais e suas garantias, direitos de nacionalidade e direitos políticos e democráticos; são denominados *limitativos* porque limitam a ação dos poderes estatais e dão a tônica do Estado de Direito; acham-se eles inscritos no Título II de nossa Constituição, sob a rubrica *Dos Direitos e Garantias Fundamentais*, excetuando-se os *Direitos Sociais* (Capítulo II), que entram na categoria seguinte;

(3) *elementos sócio-ideológicos*, consubstanciados nas normas sócio-ideológicas, que revelam o caráter de compromisso das constituições modernas entre o Estado individualista e o Estado Social, intervencionista, como as do Capítulo II do Título II, sobre os *Direitos*

seulement à définir le statut organique de l'État, mais encore à exprimer l'idée de droit directrice de l'activité étatique. Or, si elle ressort implicitement du choix des organes, elle sera plus nette encore si l'on indique, par quelques exemples concrets, les prescriptions qu'elle commande". Cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 33.

12. Cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, pp. 164 e ss., onde mostramos que esses elementos foram integrando-se nas constituições no decorrer da evolução histórica e à medida que o Estado ia absorvendo novas finalidades. Conforme também J. H. Meirelles Teixeira, *ob. cit.*, pp. 82 e ss.

Sociais, e as dos Títulos VII (*Da Ordem Econômica e Financeira*) e VIII (*Da Ordem Social*);

(4) *elementos de estabilização constitucional*, consagrados nas normas destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da constituição, do Estado e das instituições democráticas, premunindo os meios e técnicas contra sua alteração e infringência, e são encontrados no art. 102, I, *a* (*ação de inconstitucionalidade*), nos arts. 34 a 36 (*Da Intervenção nos Estados e Municípios*), 59, I, e 60 (*Processo de emendas à Constituição*), 102 e 103 (*Jurisdição constitucional*) e Título V (*Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas*, especialmente o Capítulo I, porque os Capítulos II e III, como vimos, integram os elementos orgânicos);

(5) *elementos formais de aplicabilidade*, são os que se acham consubstanciados nas normas que estatuem regras de aplicação das constituições, assim, o preâmbulo, o dispositivo que contém as cláusulas de promulgação e as disposições constitucionais transitórias, assim também a do § 1º do art. 5º, segundo o qual *as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata*.

II. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO

6. Rigidez e supremacia constitucional

A rigidez constitucional decorre da maior dificuldade para sua modificação do que para a alteração das demais normas jurídicas da ordenação estatal. Da rigidez emana, como primordial consequência, o *princípio da supremacia da constituição* que, no dizer de Pinto Ferreira, "é reputado como uma pedra angular, em que assenta o edifício do moderno direito político".¹³ Significa que a constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria estruturação deste e a organização de seus órgãos; é nela que se acham as *normas fundamentais* de Estado, e só nisso se notará sua superioridade em relação às demais normas jurídicas.

7. Supremacia material e supremacia formal

A doutrina distingue *supremacia material* e *supremacia formal* da constituição.

13. *Ob. cit.*, p. 90.

Reconhece a primeira até nas constituições costumeiras e nas flexíveis.¹⁴ Isso é certo do ponto de vista sociológico, tal como também se lhes admite rigidez sócio-política. Mas, do ponto de vista jurídico, só é concebível a supremacia formal, que se apóia na regra da rigidez, de que é o primeiro e principal corolário.

O próprio Burdeau, que fala na supremacia material, realça que é somente no caso da rigidez constitucional que se pode falar em supremacia formal da constituição, acrescentando que a previsão de um modo especial de revisão constitucional dá nascimento à distinção de duas categorias de leis: as *leis ordinárias* e as *leis constitucionais*.¹⁵

8. Supremacia da Constituição Federal

Nossa Constituição é rígida. Em consequência, é a lei fundamental e suprema do Estado brasileiro. Toda autoridade só nela encontra fundamento e só ela confere poderes e competências governamentais. Nem o governo federal, nem os governos dos Estados, nem os dos Municípios ou do Distrito Federal são soberanos, porque todos são limitados, expressa ou implicitamente, pelas normas positivas daquela lei fundamental. Exercem suas atribuições nos termos nela estabelecidos.¹⁶

Por outro lado, todas as normas que integram a ordenação jurídica nacional só serão válidas se se conformarem com as normas da Constituição Federal.

III. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

9. Inconstitucionalidades

O princípio da supremacia requer que todas as situações jurídicas se conformem com os princípios e preceitos da Constituição. Essa conformidade com os ditames constitucionais, agora, não se satisfaz apenas com a atuação positiva de acordo com a constituição. Exige mais, pois omitir a aplicação de normas constitucionais, quando a Constituição assim a determina, também constitui conduta inconstitucional.

14. Cf. Georges Burdeau, *ob. cit.*, p. 75.

15. *Idem*, p. 76. Agora, também, as leis complementares, cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 32.

16. Igualmente para a Federação mexicana, cf. Miguel Lanz Duret, *Derecho constitucional mexicano*, 5ª ed., México, Companhia Editorial Continental, 1959, p. 1.

De fato, a Constituição de 1988 reconhece duas formas de inconstitucionalidades: a *inconstitucionalidade por ação* (atuação) e a *inconstitucionalidade por omissão* (art. 102, I, a, e III, a, b e c, e art. 103 e seus §§ 1º a 3º).

10. Inconstitucionalidade por ação

Ocorre com a produção de atos legislativos ou administrativos que contrariem normas ou princípios da constituição. O fundamento dessa inconstitucionalidade está no fato de que do princípio da supremacia da constituição resulta o da *compatibilidade vertical* das normas da ordenação jurídica de um país, no sentido de que as normas de grau inferior somente valerão se forem compatíveis com as normas de grau superior, que é a constituição. As que não forem compatíveis com ela são inválidas, pois a *incompatibilidade vertical* resolve-se em favor das normas de grau mais elevado, que funcionam como fundamento de validade das inferiores.¹⁷

Essa incompatibilidade vertical de normas inferiores (leis, decretos etc.) com a constituição é o que, tecnicamente, se chama *inconstitucionalidade das leis ou dos atos do Poder Público*, e que se manifesta sob dois aspectos: (a) *formalmente*, quando tais normas são formadas por autoridades incompetentes ou em desacordo com formalidades ou procedimentos estabelecidos pela constituição; (b) *materialmente*, quando o conteúdo de tais leis ou atos contraria preceito ou princípio da constituição.

Essa incompatibilidade não pode perdurar, porque contrasta com o princípio da coerência e harmonia das normas do ordenamento jurídico, entendido, por isso mesmo, como *reunião de normas vinculadas entre si por uma fundamentação unitária*.¹⁸

11. Inconstitucionalidade por omissão

Verifica-se nos casos em que não sejam praticados atos legislativos ou administrativos requeridos para tornar plenamente aplicáveis normas constitucionais. Muitas destas, de fato, requerem uma lei ou uma providência administrativa ulterior para que os direitos ou situações nelas previstos se efetivem na prática. A Constituição, por exemplo, prevê o direito de participação dos trabalhadores nos

17. Cf. Enrique A. Aftalión, Fernando García Olano e José Vilanova, *Introducción al derecho*, p. 201; nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, cit., pp. 200 e ss.

18. Para mais pormenores sobre o tema, nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, pp. 196 e ss.

lucros e na gestão das empresas, *conforme definido em lei*, mas, se esse direito não se realizar, *por omissão* do legislador em produzir a lei aí referida e necessária à plena aplicação da norma, tal omissão se caracterizará como inconstitucional. Ocorre, então, o pressuposto para a propositura de uma *ação de inconstitucionalidade por omissão*, visando obter do legislador a elaboração da lei em causa. Outro exemplo: a Constituição reconhece que a saúde e a educação são direitos de todos e dever do Estado (arts. 196 e 205), mas, se não se produzirem os atos legislativos e administrativos indispensáveis para que se efetivem tais direitos em favor dos interessados, aí também teremos uma *omissão inconstitucional* do Poder Público que possibilita a interposição da ação de inconstitucionalidade por omissão (art. 103).

A inconstitucionalidade por omissão já existe em outros países. A Constituição portuguesa a prevê no seu art. 283. *In verbis*:

“1. A requerimento do Presidente da República, do Provedor de Justiça ou, com fundamento em violação de direitos das regiões autónomas, dos presidentes das assembleias regionais, o Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exequíveis as normas constitucionais .

“2. Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência de inconstitucionalidade por omissão, dará disso conhecimento ao órgão legislativo competente.”

Aí a vigente Constituição foi abeberar-se. Mas perdeu uma boa oportunidade de ir além. Ficou mesmo aquém, por não ter instituído o Tribunal Constitucional. Prevê as autoridades, pessoas e entidades que a podem propor, mas aí não incluiu o cidadão, o que é uma falha, pois a ação popular de inconstitucionalidade é conhecida em outros países (Alemanha, p. ex.). Foi tímida também a Constituição nas conseqüências da decretação da inconstitucionalidade por omissão. Não avançou muito mais do que a Constituição portuguesa. Apenas dispôs no § 2º do art. 103 que, *declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias*. É, sem dúvida, um grande passo. Contudo, a mera ciência ao Poder Legislativo pode ser ineficaz, já que ele não está obrigado a legislar. Nos termos estabelecidos, o princípio da discricionariedade do legislador continua intacto, e está bem que assim seja. Mas isso não impediria que a sentença que reconhecesse a omissão inconstitucional já pudesse dispor normativamente sobre a matéria até que a omissão legislativa fosse suprida. Com isso, conciliar-se-iam o princípio po-

lítico da autonomia do legislador e a exigência do efetivo cumprimento das normas constitucionais.

12. Sistemas de controle de constitucionalidade

Para defender a supremacia constitucional contra as inconstitucionalidades, a própria Constituição estabelece técnica especial, que a teoria do Direito Constitucional denomina *controle de constitucionalidades das leis*, que, na verdade, hoje, é apenas um aspecto relevante da *Jurisdição Constitucional*.

Há três sistemas de controle de constitucionalidade: o *político*, o *jurisdicional* e o *misto*.

O *controle político* é o que entrega a verificação da inconstitucionalidade a órgãos de natureza política, tais como: o próprio *Poder Legislativo*, solução predominante na Europa no século passado; ou um *órgão especial*, como o *Presidium do Soviete Supremo* da ex-União Soviética (Constituição da URSS, art. 121, n. 4) e o *Conseil Constitutionnel* da vigente Constituição francesa de 1958 (arts. 56 a 63).

O *controle jurisdicional*, generalizado hoje em dia, denominado *judicial review* nos Estados Unidos da América do Norte, é a faculdade que as constituições outorgam ao Poder Judiciário de declarar a inconstitucionalidade de lei e de outros atos do Poder Público que contrariem, formal ou materialmente, preceitos ou princípios constitucionais.

O *controle misto* realiza-se quando a constituição submete certas categorias de leis ao controle político e outras ao controle jurisdicional, como ocorre na Suíça, onde as leis federais ficam sob controle político da Assembleia Nacional, e as leis locais sob o controle jurisdicional.

13. Critérios e modos de exercício do controle jurisdicional

Os sistemas constitucionais conhecem dois critérios de controle da constitucionalidade: o *controle difuso* (ou jurisdição constitucional difusa) e o *controle concentrado* (ou jurisdição constitucional concentrada). Verifica-se o primeiro quando se reconhece o seu exercício a todos os componentes do Poder Judiciário, e o segundo, se só for deferido ao tribunal de cúpula do Poder Judiciário ou a uma corte especial.¹⁹

19. Cf. José Luiz de Anhaia Mello, *Da separação de poderes à guarda da Constituição*, São Paulo, Ed. RT, 1968, todo dedicado ao controle de constitucionalidade das leis, mas, de modo especial, ao sistema jurisdicional das Cortes Constitucionais, que

O controle jurisdicional subordina-se ao princípio geral de que não há juízo sem autor (*nemo iudex sine actore*), que é rigorosamente seguido no sistema brasileiro, como geralmente ocorre nos países que adotam o critério de controle difuso. Admite-se, nos sistemas de critério concentrado, o controle por *iniciativa do juiz* (*Richterklage* dos alemães, ou por *elevação da causa*, na indicação de Bidart Campos)²⁰ e por *iniciativa popular* (*Popularklage*, ação popular). Com essas observações, podemos resumir que se reconhecem no Direito Constitucional Comparado três modos de exercício do controle de constitucionalidade: (a) *por via de exceção*, ou *incidental*, segundo o qual cabe ao demandado argüir a inconstitucionalidade, quando apresenta sua defesa num caso concreto, isto é, num processo proposto contra ele; por isso, é também chamado *controle concreto*; (b) *por via de ação direta de inconstitucionalidade*, de iniciativa do interessado, de alguma autoridade, ou instituição ou pessoa do povo (ação popular); (c) *por iniciativa do juiz* dentro de um processo de partes.

Vê-se, desde logo, que o exercício por via de exceção é próprio do controle difuso e os outros, do controle concentrado.

14. Sistema brasileiro de controle de constitucionalidade

O sistema é o jurisdicional instituído com a Constituição de 1891 que, sob a influência do constitucionalismo norte-americano, acolhera o *critério de controle difuso por via de exceção*, que perdurou nas constituições sucessivas até a vigente.

As constituições posteriores à de 1891, contudo, foram introduzindo novos elementos, de sorte que, aos poucos, o sistema se afastara do puro critério difuso com a adoção de aspectos do *método concentrado*, sem, no entanto, aproximar-se do europeu. A Constituição de 1934, mantendo as regras do critério difuso em seu art. 76, *a e b*, trouxe três inovações importantes: a *ação direta de inconstitucionalidade interventiva* (art. 7º, I, *a e b*), a regra de que só por *maioria absoluta* de votos dos seus

sustenta deveria ser adotado no Brasil; cf. também nosso "Jurisdição constitucional no Brasil e na América Latina", *RPGE*, São Paulo, n. 13-15, pp. 105 e ss., "Tribunais constitucionais e jurisdição constitucional", na *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, Belo Horizonte, 1985, pp. 60 e 61, ambos defendendo a criação de Corte Constitucional no Brasil; em sentido contrário, veja-se Oscar Dias Correia, *Supremo Tribunal Federal: Corte Constitucional do Brasil*, Rio de Janeiro, Forense, 1987; cf. ainda sobre o tema, Gian Galeazzo Stendardi, *La corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1955; Eduardo García de Enterría, *La constitución como norma y el Tribunal Constitucional*, Madrid, Editorial Civitas, 1981.

20. Cf. Germán José Bidart Campos, *El Derecho constitucional del poder*, v. II/321 e ss.

membros os tribunais poderiam declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público (art. 179) e a atribuição ao Senado Federal de competência para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou ato declarado inconstitucional em decisão definitiva.

Essas três inovações se incorporaram definitivamente no Direito Constitucional brasileiro. Sob a Constituição de 1946 foram introduzidas duas outras novidades por meio da EC 16, de 6.12.65, que criou uma nova modalidade de *ação direta de inconstitucionalidade*, de caráter genérico, ao atribuir competência ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, apresentada pelo Procurador-Geral da República (art. 2º, *k*), e estatuiu que a lei poderia estabelecer processo, de competência originária do Tribunal de Justiça, para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal, em conflito com a constituição estadual (art. 19). Esta última inovação não prosperou tal como previsto, mas a Constituição de 1969 instituiu a *ação direta interventiva* para a defesa de princípios da constituição estadual, promovida pelo Chefe do Ministério Público do Estado e de competência do Tribunal de Justiça (art. 15, § 3º, *d*).

A Constituição de 1988 introduziu mais duas novidades: previu a *inconstitucionalidade por omissão* (art. 103, § 2º) e ampliou a legitimação para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, por ação ou omissão (art. 103). Antes, essa legitimação só pertencia ao Procurador-Geral da República. Agora, além dele, cabe também ao Presidente da República, às Mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados das Assembléias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao governador de Estado e do Distrito Federal, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Pena não ter incluído o cidadão. Outra novidade veio com a EC 3, de 17.3.93: a *ação declaratória de constitucionalidade*, que merecerá consideração em tópico separado adiante.

Em suma, à vista da Constituição vigente, temos a inconstitucionalidade por ação ou por omissão, e o controle de constitucionalidade é o jurisdicional, combinando os *critérios difuso e concentrado*, este de competência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, temos o exercício do controle *por via de exceção* e *por ação direta de inconstitucionalidade* e ainda a referida *ação declaratória de constitucionalidade*. De acordo com o controle por exceção, *qualquer interessado poderá suscitar a questão de inconstitucionalidade, em qualquer processo, seja de que natureza for, qualquer que seja o juízo*. A ação direta de inconstitucionalidade compreende três modalidades: (1) a *interventiva*, que pode ser federal por proposta exclusiva do Procurador-Geral da República e de com-

petência do Supremo Tribunal Federal (arts. 36, III, 102, I, *a*, e 129, IV), ou *estadual* por proposta do Procurador-Geral da Justiça do Estado (arts. 36, IV, e 129, IV); interventivas, porque destinadas a promover a intervenção federal em Estado ou do Estado em Município, conforme o caso; (2) *a genérica*: (a) de competência do Supremo Tribunal Federal, destinada a obter a decretação de inconstitucionalidade, *em tese*, de lei ou ato normativo, *federal* ou *estadual*, sem outro objetivo senão o de expurgar da ordem jurídica a incompatibilidade vertical; é ação que visa exclusivamente a defesa do princípio da supremacia constitucional (arts. 102, I, *a*, e 103, incisos e § 3º); (b) de competência do Tribunal de Justiça em cada Estado, visando a declaração de inconstitucionalidade, *em tese*, de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual (art. 125, § 2º), dependendo da previsão nesta; (3) *a supridora de omissão*: (a) do *legislador*, que deixe de criar lei necessária à eficácia e aplicabilidade de normas constitucionais, especialmente nos casos em que a lei é requerida pela Constituição;²¹ (b) do *administrador*, que não adote as providências necessárias para tornar efetiva norma constitucional (art. 103, § 2º).

A Constituição mantém a regra segundo a qual *somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público* (art. 97), regra salutar que vem, como foi visto, do art. 179 da Constituição de 1934.

15. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade

Problema debatido é o dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, cujo deslinde depende da solução da grave controvérsia sobre a *natureza do ato inconstitucional*: se é inexistente, nulo ou anulável. Buzaid acha que toda lei, adversa à Constituição, é *absolutamente nula*, não *simplesmente anulável*.²² Ruy Barbosa, calcado na

doutrina e jurisprudência norte-americanas, também dissera que toda medida, legislativa ou executiva, que desrespeite preceitos constitucionais é, de sua essência, nula.²³ Francisco Campos sustenta que um ato ou uma lei inconstitucional é inexistente.²⁴

A nós nos parece que essa doutrina privatística da invalidade dos atos jurídicos não pode ser transposta para o campo da inconstitucionalidade, pelo menos no sistema brasileiro, onde, como nota Themístocles Brandão Cavalcanti, a declaração de inconstitucionalidade em nenhum momento tem efeitos tão radicais, e, em realidade, não importa por si só na ineficácia da lei.²⁵

A questão demanda distinções que faremos mais adiante, mas, por princípio, achamos que o constitucionalismo brasileiro estruturou técnica peculiar de controle, que não comporta a teoria norte-americana. Milita presunção de validade constitucional em favor de leis e atos normativos do Poder Público, que só se desfaz quando incide o mecanismo de controle jurisdicional estatuído na Constituição. Essa presunção foi reforçada pela Constituição pelo teor do art. 103, § 3º, que estabeleceu um contraditório no processo de declaração de inconstitucionalidade, *em tese*, impondo o dever de audiência de Advogado-Geral da União que obrigatoriamente defenderá o ato ou texto impugnado. A declaração de inconstitucionalidade, na via indireta, não anula a lei nem a revoga; teoricamente, a lei continua em vigor, eficaz e aplicável, até que o Senado Federal suspenda sua executividade nos termos do art. 52, X;²⁶ a declaração na via direta tem efeito diverso, importa suprimir a eficácia e aplicabilidade da lei ou ato, como veremos nas distinções feitas em seguida.

Em primeiro lugar, temos que discutir *a eficácia da sentença que decide a inconstitucionalidade na via da exceção*, e que se resolve pelos princípios processuais. Nesse caso, a arguição da inconstitucionalidade é questão prejudicial e gera um procedimento *incidenter tantum*, que busca a simples verificação da existência ou não do vício alega-

rada inconstitucional é nenhuma e portanto deve ser tida como inexistente", e logo adiante, à p. 87, afirma que a função do Judiciário não é declarar nula a lei, mas subtrair-lhe a aplicação.

23. Cf. *A Constituição e os atos inconstitucionais*, p. 49.

24. Cf. *Direito Constitucional*, v. 1/430. Eis o texto: "Um ato ou uma lei inconstitucional é um ato ou uma lei inexistente; uma lei inconstitucional é lei aparente, pois que, de fato ou na realidade, não o é. O ato ou lei inconstitucional nenhum efeito produz, pois que inexistente de direito ou é para o Direito como se nunca houvesse existido".

25. *Ob. cit.*, pp. 169 e 170.

26. Diz o art. 52: "Compete privativamente ao Senado Federal: X — suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal".

21. A Constituição traz inúmeros exemplos de normas dependentes de lei, como o art. 7º, X (*a lei protegerá o salário*, se a lei não for criada o salário não terá a proteção), XI (participação no lucro, dependente de definição legal) e XXIII (adicional de remuneração para atividades penosas, dependente da forma da lei) etc. Cf., a propósito do assunto, nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, cit.

22. *Ob. cit.*, p. 128. Aí, o professor é explícito no dizer, como posição própria: "Sempre se entendeu entre nós, de conformidade com a lição dos constitucionalistas norte-americanos, que toda lei, adversa à Constituição, é *absolutamente nula*; não *simplesmente anulável*. A eiva de inconstitucionalidade a atinge no berço, fere-a *ab initio*. Ela não chegou a viver. Nasceu morta. Não teve, pois, nenhum único momento de validade". À p. 132, a mesma doutrina é reafirmada. Contudo, à p. 85, conclui: "Por isso não se deve dizer, adotando uma fórmula simplista, que uma lei decla-

do. E a sentença é declaratória. Faz coisa julgada no caso e entre as partes. Mas, no sistema brasileiro, qualquer que seja o tribunal que a proferiu, não faz ela coisa julgada em relação à lei declarada inconstitucional, porque qualquer tribunal ou juiz, em princípio, poderá aplicá-la por entendê-la constitucional, enquanto o Senado Federal, por resolução, não suspender sua executoriedade, como já vimos.

O problema deve ser decidido, pois, considerando-se dois aspectos. No que tange ao *caso concreto*, a declaração surte efeitos *ex tunc*, isto é, fulmina a relação jurídica fundada na lei inconstitucional desde o seu nascimento. No entanto, a lei continua eficaz e aplicável, até que o Senado suspenda sua executoriedade; essa manifestação do Senado, que não revoga nem anula a lei, mas simplesmente lhe retira a eficácia, só tem efeitos, daí por diante, *ex nunc*. Pois, até então, a lei existiu. Se existiu, foi aplicada, revelou eficácia, produziu validamente seus efeitos.²⁷

Qual a eficácia da sentença proferida no processo da ação direta de inconstitucionalidade genérica? Essa indagação foi respondida, nas edições anteriores, do seguinte modo: "Essa ação, como vimos, tem por objeto a própria questão de constitucionalidade. Portanto, qualquer decisão, que decreta a inconstitucionalidade, deverá ter eficácia *erga omnes* (genérica) e obrigatória. Mas a Constituição não lhe deu esse efeito, explicitamente, como seria desejável" – e o texto prosseguia na demonstração daquela afirmação, apesar da indefinição da Constituição. Agora o novo enunciado do § 2º do art. 102 da Constituição, segundo a EC-45/2004, deu solução expressa à questão, acolhendo nossa tese, ao estatuir que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, produzirão eficácia contra todos (*erga omnes*) e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. O objeto do julgamento consiste em desfazer os efeitos normativos (efeitos gerais) da lei ou ato – a eficácia da sentença tem exatamente esse efeito, e isto tem valor geral, evidentemente, e vincula a todos. Em suma, a sentença, aí, faz coisa julgada material, que vincula as autoridades aplicadoras da lei, que não poderão mais dar-lhe execução sob pena de arrostar a eficácia da coisa julgada, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade em tese visa precisamente a atingir o efeito imediato de retirar a aplicabilidade da lei. Se não fosse assim,

seria praticamente inútil a previsão constitucional de ação direta de inconstitucionalidade genérica.

Diferente é o efeito da sentença proferida no processo da ação de inconstitucionalidade interventiva que é proposta pelo Procurador-Geral da República ou pelo Procurador-Geral da Justiça do Estado, conforme se trate de intervenção federal em algum Estado ou de intervenção estadual em Município. Visa não apenas obter a declaração de inconstitucionalidade, mas também restabelecer a ordem constitucional no Estado, ou Município, mediante a intervenção. A sentença já não será meramente declaratória, pois, então, já não cabe ao Senado a suspensão da execução do ato inconstitucional. No caso, a Constituição declara que o decreto (do Presidente da República ou do Governador do Estado, conforme o caso) se limitará a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Daí se vê que a decisão, além de decretar a inconstitucionalidade do ato, tem um efeito condenatório, que fundamenta o decreto de intervenção. Pelo texto constitucional, nota-se que a suspensão da execução do ato impugnado não é o objeto do decreto. O objeto do decreto é a intervenção, que não ocorrerá se o ato for suspenso. E isso é o que se dá na prática. Nisso tudo, parece inequívoco que a condenação na intervenção acaba transmudando em verdadeiro efeito constitutivo da sentença que faz coisa julgada material *erga omnes*.

Resta, agora, enfrentar a nova questão relativa aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por omissão. O efeito está traduzido no § 2º do art. 103 da Constituição, ao estatuir que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. Não se trata de verificar inconstitucionalidade em tese, mas in concreto, ou seja, a de que não se produziu uma medida (lei, decreto etc.) concretamente requerida pela norma constitucional. Não se cogitará, portanto, de efeito *erga omnes*, mas determinação diretamente dirigida a um Poder. Daí provém que a sentença que reconhece a inconstitucionalidade por omissão é declaratória quanto a esse reconhecimento, mas não é meramente declaratória, porque dela decorre um efeito ulterior de natureza *mandamental* no sentido de exigir do Poder competente a adoção das providências necessárias ao suprimimento da omissão. Esse sentido mandamental é mais acentuado em relação a órgão administrativo. Mas ele existe também no tocante à ciência ao Poder Legislativo. Não há de se limitar à mera ciência sem consequência. Se o Poder Legislativo não responder ao mandamento judicial, incidirá em omissão ainda mais grave. Pelo menos terá que dar alguma satisfação ao Judiciário. É certo que, se não o fizer, prati-

27. Foi o que escrevemos anteriormente; cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 144. Sobre o tema, cf. Alfredo Buzaid, *ob. cit.*, p. 132; Themístocles Brandão Cavalcanti, *ob. cit.*, pp. 168 e ss.; Lúcio Bittencourt, *ob. cit.*, p. 136; Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. III, 621.

camente nada se poderá fazer, pois não há como obrigar o legislador a legislar. Por isso é que, no caso de inconstitucionalidade por omissão, propugnávamos por uma decisão judicial normativa, para valer como lei se após certo prazo o legislador não suprisse a omissão. A sentença normativa teria esse efeito. Mas o legislador constituinte não quis dar esse passo à frente.

IV. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

16. A questão constitucional

A ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal foi introduzida pela EC 3/93 na alínea *a* do inc. I do art. 102, com a eficácia estabelecida no § 2º, acrescentado ao mesmo artigo, e a legitimação conferida às autoridades referidas no art. 103, com a redação da EC-45/2004. A inovação imediatamente suscitou controvérsias sobre sua legitimidade político-constitucional. Viram-se nela inúmeras inconstitucionalidades, por violação dos princípios do acesso à justiça (art. 5º, XXXV), do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV), do princípio da separação dos poderes, todos protegidos pelas malchamadas cláusulas pétreas da Constituição (art. 60, § 4º, III e IV).²⁸ Tal como Celso Bastos, não sustentamos que a ação declaratória de constitucionalidade seja de per se e para sempre inconstitucional.²⁹ Também não a descartamos por completo como o fez Gilmar Ferreira Mendes.³⁰ Trata-se de uma ação que tem a característica de um meio paralisante de debates em torno de questões jurídicas fundamentais de interesse coletivo. Terá como pressuposto fático a existência de decisões de constitucionalidade, em processos concretos, contrárias à posição governamental. Seu exercício, portanto, gera um *processo constitucional contencioso*, de fato, porque visa desfazer decisões proferidas entre partes, mediante sua propositura por uma delas. Nesse sentido, ela tem verdadeira natureza de meio de impugnação antes que de ação, com o mesmo objeto das contestações apresentadas nos processos concretos, sustentando a constitucionalidade da lei ou ato normativo federal, e sem as contra-razões das partes contrárias. Então, a rigor não se trata de processo sem partes e só aparentemente é *processo*

28. Cf., para amplo debate sobre a matéria, Ives Gandra da Silva Martins e Gilmar Ferreira Mendes (coords.), *Ação declaratória de constitucionalidade*, São Paulo, Saraiva, 1994.

29. Cf. "Ação declaratória de constitucionalidade", na *ob. cit.* na nota anterior, p. 36.

30. Cf. "A ação declaratória de constitucionalidade: a inovação da Emenda Constitucional n. 3, de 1993", no mesmo volume citado supra, pp. 51 e ss.

objetivo, porque, no fundo, no substrato da realidade jurídica em causa, estão as relações materiais controvertidas que servem de pressupostos de fato da ação.

Tendo isso em consideração é que se afirma que o exercício da ação pode gerar ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Se isso acontecer, tem-se uma aplicação inconstitucional da ação. Vale dizer que a questão constitucional se desloca para a hipótese de *decisão* constitucional interpretativa. Se houver decisão de rejeição da ação, não há inconstitucionalidade. Se houver decisão de acolhimento, haverá, se a ação declaratória de constitucionalidade for um instrumento de decisão definitiva que paralise processos concretos sem o contraditório e o devido processo legal.³¹ Essa é a idéia que subjaz no voto do Min. Ilmar Galvão no julgamento da constitucionalidade da EC 3/93, que é constitucional, mas pode ter aplicação inconstitucional se, no seu processamento, não se atender a um mínimo de contraditório; "é indispensável na ação de constitucionalidade", segundo o voto do Min. Carlos Veloso, e "indispensável à configuração de qualquer processo judicial", reforça o voto do Min. Ilmar Galvão. Contudo, contra esses votos e mais o voto do Min. Marco Aurélio, o STF julgou constitucional a referida emenda constitucional, sem essas restrições, nos termos do voto do Min. Moreira Alves.³²

17. Finalidade e objeto da ação declaratória de constitucionalidade

A ação declaratória de constitucionalidade, como lembrado, "presupõe controvérsia a respeito da constitucionalidade da lei, o que é aferido diante da existência de um grande número de ações onde a constitucionalidade da lei é impugnada" e sua finalidade imediata consiste na rápida solução dessas pendências. Esse o pressuposto de sua criação, daí a idéia que deixamos expressa acima de que ela se caracteriza como um meio de paralisação de debates em torno de questões jurídicas de interesse coletivo, precisamente porque seu exercício pressupõe a existência de decisões generalizadas em processos concretos reconhecendo a inconstitucionalidade de lei em situação oposta a interesses governamentais. Visa ela, pois, solucionar esse estado de controvérsia generalizado por via da coisa julgada vinculante, quer confirme as decisões proferidas concluindo-se, em definitivo, pela inconstitucionalidade da lei, com o que se encerram

31. Em síntese, foi o que escrevemos em "Nota de Atualização" para a 4ª tiragem da 9ª edição deste volume.

32. Cf. o teor do venerando Acórdão em Ives Gandra Martins e Gilmar Ferreira Mendes, *ob. cit.*, pp. 183 e ss.

os processos concretos em favor dos autores, quer reforme essas decisões com a declaração da constitucionalidade da lei. O termo *reformular* não é sem propósito, porque a declaração de constitucionalidade, no caso, tem o efeito de inverter o sentido daquelas decisões. Daí certo sentido avocatório que persiste nessa ação, bem sabido, aliás, que ela veio como substitutivo da avocatória que existiu no sistema constitucional revogado e que mereceu sempre muita repulsa dos meios jurídicos.

O *objeto da ação* é a verificação da constitucionalidade da lei ou ato normativo federal impugnado em processos concretos. Nisso ela corta o *iter* de controle de constitucionalidade pelo método difuso que se vinha desenvolvendo naqueles processos. Esse corte não me parece que seja infringente de regras ou princípios constitucionais. Mas parece certo que essa ação, mais do que a ação genérica de inconstitucionalidade, põe um problema relevante relativamente à compreensão das normas e valores constitucionais em correlação com a realidade social, porque suscita somente um confronto abstrato de normas, um confronto formal, que não leva em conta a possível influência dos valores sociais no sentido das normas constitucionais, de modo que uma lei que formalmente aparece como em contraste com enunciados constitucionais pode não estar em conflito com um sentido axiológico das normas supremas, com prejuízo, eventualmente, de ajustes dialéticos do ordenamento ao viver social, vale dizer, em prejuízo de uma visão material da justiça.

O controle de constitucionalidade pelo critério difuso tem inúmeros defeitos, incluindo efeitos desiguais a litigantes em processos diferentes, mas certamente a aferição da constitucionalidade em face de um caso concreto possibilita um confronto de sentidos, de conteúdos normativos. É tal a importância disso que hoje se reconhece a existência de *iter* de inconstitucionalização, que consiste no fato de uma lei existente adquirir inconstitucionalidade em face de mudanças constitucionais semânticas. O sistema europeu resolveu a questão, admitindo um elemento do controle difuso no sistema de jurisdição concentrada. Em princípio não há ação genérica de inconstitucionalidade, salvo por razões de competência entre entidades interestatais. O controle concentrado não é, a rigor, sobre a lei em tese, mas suscitado a partir da questão de inconstitucionalidade num processo concreto de partes. Por isso é que, de certo modo, a ação declaratória de constitucionalidade equivale a um meio de fazer subir ao Pretório Excelso o conhecimento da questão constitucional controvertida em processos concretos, daí a sua natureza mais de meio de impugnação do que de ação. O voto vencedor do Min. Moreira Alves, no v. Acórdão já citado, entende que a ação declaratória de constitucionalida-

de se insere “no sistema de controle em abstrato da constitucionalidade de normas, cuja finalidade única é a defesa da ordem jurídica, não se destinando diretamente à tutela de direitos subjetivos”. Essa é uma doutrina que encara a questão de um ponto de vista puramente processual formalista, porque, na verdade, se ela, num caso concreto, se opõe a decisões proferidas em processos concretos, objetivando desfazer seus efeitos, então não é um controle abstrato da constitucionalidade da norma, até porque, nesses termos, ela se destina a tutelar direito subjetivo da União, já que a declaração de constitucionalidade da lei ou ato normativo impugnado naqueles processos concretos serve a seus interesses.

Não tem ela por objeto a verificação da constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual nem municipal, nem está prevista a possibilidade de sua criação nos Estados.

18. Legitimação e competência para a ação

A EC-45/2004 revogou o § 4º do art. 103 da Constituição e incluiu a ação declaratória de constitucionalidade no *caput* desse artigo, ficando, assim, definido que a podem propor as mesmas pessoas ali arroladas, não cabendo intervenção do Advogado-Geral da União no seu processo, como já decidiu o STF. A propósito, declara o voto vencedor do Min. Moreira Alves:

“No processo da ação declaratória de constitucionalidade, por visar à preservação da presunção de constitucionalidade do ato normativo que é seu objeto, não há razão para que o Advogado-Geral da União atue como curador dessa mesma presunção. Alias, o silêncio da Emenda Constitucional n. 3 a esse respeito, não obstante tenha incluído um § 4º no art. 103 da Carta Magna, é um silêncio eloquente, a afastar a idéia de que houve omissão, a propósito, por inadvertência”.

Tem razão o Eminentíssimo Ministro, porque a intervenção do Advogado-Geral da União só tem cabimento na ações que visem à declaração de inconstitucionalidade, com a finalidade de defender a legitimidade do ato impugnado. Ora, a ação declaratória não impugna a lei ou ato normativo federal. Ao contrário, sustenta a sua validade constitucional. A participação do Advogado-Geral da União, em tal caso, não formaria o contraditório que justifica a sua intervenção no processo que tenha por objeto a declaração de inconstitucionalidade. Tem razão também o Eminentíssimo Ministro quando afirma que também na ação declaratória de constitucionalidade faz-se mister a prévia audiência do Procurador-Geral da República, pois essa audiência é

exigida “em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal” (CF, art. 103, § 1º).

A *competência* para processar e julgar a ação declaratória de constitucionalidade é exclusivamente do Supremo Tribunal Federal. Ela se insere, segundo ainda o voto do Min. Moreira Alves, “no sistema de controle concentrado de constitucionalidade das normas, em que o Supremo Tribunal Federal aprecia a controvérsia em tese, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, com eficácia *erga omnes*”.

19. Efeitos da decisão da ação declaratória de constitucionalidade

Diz o § 2º do art. 102, acrescido pela EC 3/93, que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. A eficácia *erga omnes* significa que declaração da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da lei se estende a todos os feitos em andamento, paralisando-os com o desfazimento dos efeitos das decisões neles proferidas no primeiro caso ou com a confirmação desses efeitos no segundo caso. Mas quer dizer também que o ato, dali por diante, vale na medida mesma da declaração proferida na ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, é constitucional, sem possibilidade de qualquer outra declaração em contrário, ou inconstitucional, com o que se apaga de vez sua eficácia no ordenamento jurídico.

O *efeito vinculante* relativamente à função jurisdicional dos demais órgãos do Poder Judiciário, portanto, já decorreria da própria afirmativa da eficácia contra todos, mas, assim mesmo, o texto quis ser expresse para alcançar também os atos normativos desses órgãos que eventualmente tenham sido objeto de uma decisão em ação declaratória de constitucionalidade. Assim nenhum juízo ou Tribunal poderá conhecer de ação ou processo em que se postule uma decisão contrária à declaração emitida no processo da ação declaratória de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal nem produzir validamente ato normativo em sentido contrário àquela decisão. Como o texto fala em efeito vinculante relativamente aos *demais* órgãos do Poder Judiciário, cabe indagar se também fica o Pretório Excelso vinculado à sua decisão. A questão é processual e se resolve com a teoria da coisa julgada material oponível a todos os órgãos judiciários, inclusive o que proferiu a decisão. Logo o STF não poderá conhecer de processo em que se pretenda algo contrário à sua de-

claração, nem mesmo em ação rescisória, incabível na espécie. Ele “fica jungido à sua decisão, devendo seguir a mesma linha ainda quando se trate de julgamento de constitucionalidade incidental pelo Plenário”.³³

A novidade está na vinculação da Administração Pública em geral aos efeitos da decisão. Para entender essa vinculação, um esclarecimento é necessário, qual seja, o de que a decisão que profere a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo importa na supressão *erga omnes* da eficácia do ato normativo seu objeto. Mas não alcança outro ato de igual teor produzido posteriormente, de sorte que, para objetar-se a declaração de inconstitucionalidade deste, mister se faz propor outra ação. Pois bem, o efeito vinculante da ação declaratória de constitucionalidade atinge também os atos de igual teor produzidos no futuro, para o fim de, independentemente de nova ação, serem tidos como constitucionais ou inconstitucionais, adstrita essa eficácia aos atos normativos emanados dos demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública direta ou indireta, uma vez que ela não alcança os atos editados pelo Poder Legislativo.³⁴

V. EMENDA À CONSTITUIÇÃO

20. Terminologia e conceito

As constituições brasileiras usaram os termos *reforma*, *emenda*, *revisão* e até *modificação* constitucional. A questão terminológica nessa matéria começa pela necessidade de fazer distinção entre *mudança constitucional* e *reforma constitucional*.³⁵ A primeira consiste num *processo não formal de mudança* das constituições rígidas, por via da tradição, dos costumes, de alterações empíricas e sociológicas, pela interpretação judicial e pelo ordenamento de estatutos que afetem a estrutura orgânica do Estado.³⁶ A segunda é o processo formal de mudança das constituições rígidas, por meio de atuação de certos ór-

33. Cf. Nagib Slaibi Filho, *Ação declaratória de constitucionalidade*, p. 179.

34. É mais uma passagem precisa do voto vencedor do Min. Moreira Alves, proferido no Acórdão que decidiu questão de ordem, por ele suscitada, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 1-1— Distrito Federal.

35. Cf. Diego Valades, “Problemas de la reforma constitucional en el sistema mexicano”, in Andueza Acuña *et al.*, *Los cambios constitucionales*, México, pp. 191 e 192.

36. Cf. Pinto Ferreira, *Da Constituição*, pp. 100 e 101. Sobre o tema, cf. Anna Cândida da Cunha Ferraz, *Processos informais de mudança da Constituição: mutações constitucionais e mutações inconstitucionais*, São Paulo, Max Limonad, 1986, e também Cármen Lúcia Antunes Rocha, “Constituição e mudança constitucional: limites ao exercício do poder de reforma constitucional”, *Separata da Revista de Informação Legislativa*, Brasília, n. 120, outubro/dezembro 1993.

gãos, mediante determinadas formalidades, estabelecidas nas próprias constituições para o exercício do poder reformador.

A doutrina brasileira ainda vacila no emprego dos termos *reforma*, *emenda* e *revisão* constitucional. Ainda que haja alguma tendência em considerar o termo *reforma* como gênero, para englobar todos os métodos de mudança formal das constituições, que se revelam especialmente mediante o *procedimento de emenda* e o *procedimento de revisão*, a maioria dos autores, contudo, em face de constituições anteriores, empregou indiferentemente os três termos.

Como Pinto Ferreira e Meirelles Teixeira, entendemos que a expressão *reforma*, genérica, abrange a *emenda* e a *revisão*, com significações distintas. “A reforma é qualquer alteração do texto constitucional, é o caso genérico, de que são subtipos a emenda e a revisão. A emenda é a modificação de certos pontos, cuja estabilidade o legislador constituinte não considerou tão grande como outros mais valiosos, se bem que submetida a obstáculos e formalidades mais difíceis que os exigidos para a alteração das leis ordinárias. Já a revisão seria uma alteração anexável, exigindo formalidades e processos mais lentos e dificultados que a emenda, a fim de garantir uma suprema estabilidade do texto constitucional”.³⁷ Na Constituição Federal de 1934 e, em certo sentido, na de 1946 essa distinção terminológica era particularmente expressiva. Houve proposta no mesmo sentido para a Constituição vigente, mas não vingou.

A Constituição manteve, como princípio permanente, a técnica da constituição revogada, mencionando apenas as *emendas*, agora como único sistema de mudança formal da Constituição, já que a revisão constitucional, prevista no art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já se realizou, não sendo mais possível outra revisão nos termos ali previstos, simplesmente porque, como norma transitória, foi aplicada, esgotando-se em definitivo. Portanto, qualquer mudança formal na Constituição só deve ser feita legitimamente com base no seu art. 60, ou seja, pelo procedimento das emendas com os limites dali decorrentes.

A rigidez e, portanto, a supremacia da constituição repousam na técnica de sua reforma (ou emenda), que importa em estruturar um procedimento mais dificultoso, para modificá-la.

O procedimento varia de país para país. Nos Estados Unidos da América do Norte é previsto no art. V da Constituição nos termos seguintes: “O Congresso, sempre que dois terços de ambas as Câma-

ras julgarem necessário, poderá propor emendas a esta Constituição, ou, a pedido dos Legislativos de dois terços dos vários Estados, convocará uma assembléia para propor emendas que, em qualquer caso, serão válidas para todos os objetivos e propósitos como parte desta Constituição, se ratificadas pelos Legislativos de três quartos dos diversos Estados ou por assembléias reunidas para este fim em três quartos destes, podendo o Congresso propor um ou outro modo de ratificação”.

Na Suíça, além da aprovação de emenda pela Assembléia Nacional (Congresso federal), deverá ainda ser ratificada por referendo popular, admitida também a iniciativa popular (arts. 118 a 123 da Constituição). Na Itália, as leis de revisão da Constituição e as outras leis constitucionais são adotadas pelas duas Câmaras após duas deliberações sucessivas, separadas por um intervalo de três meses ou mais, e serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros das Câmaras na segunda votação. Essas leis serão submetidas a um referendo popular se, três meses após sua publicação, isso for solicitado por um quinto dos membros de uma das Câmaras ou por quinhentos mil eleitores ou ainda por cinco conselheiros regionais, e só serão consideradas aprovadas quando obtiverem a maioria dos votos válidos. Contudo, não caberá o referendo se a emenda for aprovada pela maioria de dois terços dos membros das duas Câmaras na segunda votação (art. 138 da Constituição).

21. Sistema brasileiro

A Constituição não introduziu inovação de realce no sistema de sua modificação. Até a votação no Plenário, anteprojeto e projeto admitiam, expressa e especificamente, a iniciativa e o referendo populares em matéria de emenda constitucional. No Plenário, contudo, os conservadores derrubaram essa possibilidade clara que constava do § 2º do art. 74 do Projeto aprovado na Comissão de Sistematização. Não está, porém, excluída a aplicação desses institutos de participação popular nessa matéria. Está expressamente estabelecido que o poder que emana do povo será exercido por meio de representantes ou *diretamente* (art. 1º, parágrafo único), que a soberania popular será exercida também por referendo e iniciativa populares (art. 14, II e III) e que cabe ao Congresso Nacional autorizar referendo sem especificação (art. 49, XV), o que permite o referendo facultativo constitucional. Vale dizer, pois, que o uso desses institutos, em matéria de emenda constitucional, vai depender do desenvolvimento e da prática da democracia participativa que a Constituição alberga como um de seus princípios fundamentais.

37. Cf. Pinto Ferreira, *Da Constituição*, cit., p. 102; J. H. Meirelles Teixeira, *ob. cit.*, p. 132.

A inovação explícita consiste na ampliação do núcleo imodificável por emendas, como consta do art. 60, § 4º, que merecerá consideração logo mais.

Pelo citado art. 60, I, II e III, vê-se que a Constituição poderá ser emendada por proposta de *iniciativa*: (1) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; (2) do Presidente da República; (3) de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, retomando, aqui, uma regra que vinha desde a Constituição de 1891, suprimida pela de 1969, regra que não teve uma única aplicação nesses cem anos de República; (4) *popular*, aceita a interpretação sistemática referida acima, caso em que as percentagens previstas no § 2º do art. 61 serão invocáveis, ou seja, a proposta de emenda terá que ser subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em cinco Estados, com não menos de zero vírgula três por cento dos eleitores de cada um deles. Repita-se que esse tipo de iniciativa popular pode vir a ser aplicado com base em normas gerais e princípios fundamentais da Constituição, mas ele não está especificamente estabelecido para emendas constitucionais como o está para as leis (art. 61, § 2º).

A elaboração de emendas à Constituição é simples. Apresentada a proposta, será ela discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, *em dois turnos*, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, *três quintos* dos votos dos membros de cada uma delas (art. 60, § 2º). Veja-se que, diferentemente da Constituição anterior, que previa discussão e votação da emenda em sessão conjunta das duas Casas, a Carta Magna vigente prevê que elas atuem separadamente.

Finalmente, uma vez aprovada, a emenda será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Acrescenta-se que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa (art. 60, § 5º).

22. Poder constituinte e poder reformador

A Constituição, como se vê, conferiu ao Congresso Nacional a competência para elaborar emendas a ela. Deu-se, assim, a um órgão *constituído* o poder de emendar a Constituição. Por isso se lhe dá a denominação de *poder constituinte instituído* ou *constituído*. Por outro lado, como esse seu poder não lhe pertence por natureza, primariamente, mas, ao contrário, deriva de outro (isto é, do poder constituinte originário), é que também se lhe reserva o nome de *poder constituinte derivado*, embora pareça mais acertado falar em *competência constituinte*

te derivada ou *constituente de segundo grau*. Trata-se de um problema de técnica constitucional, já que seria muito complicado ter que convocar o constituinte originário todas as vezes em que fosse necessário emendar a Constituição. Por isso, o próprio poder constituinte originário, ao estabelecer a Constituição Federal, instituiu um *poder constituinte reformador*, ou *poder de reforma constitucional*, ou *poder de emenda constitucional*.

No fundo, contudo, o agente, ou sujeito da reforma, é o *poder constituinte originário*, que, por esse método, atua em segundo grau, de modo indireto, pela outorga de competência a um órgão constituído para, em seu lugar, proceder às modificações na Constituição, que a realidade exige. Nesse sentido, cumpre lembrar, com o Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que poder de reforma constitucional ou, na sua terminologia, poder constituinte de revisão "é aquele poder, inerente à Constituição rígida que se destina a modificar essa Constituição segundo o que a mesma estabelece. Na verdade, o Poder Constituinte de revisão visa, em última análise, permitir a mudança da Constituição, adaptação da Constituição a novas necessidades, a novos impulsos, a novas forças, sem que para tanto seja preciso recorrer à revolução, sem que seja preciso recorrer ao Poder Constituinte originário".³⁸

23. Limitações ao poder de reforma constitucional

Discute-se, em doutrina, sobre os limites do poder de reforma constitucional. É inquestionavelmente um poder limitado, porque regrado por normas da própria Constituição que lhe impõem procedimento e modo de agir, dos quais não pode arredar sob pena de sua obra sair viciada, ficando mesmo sujeita ao sistema de controle de constitucionalidade. Esse tipo de regramento da atuação do poder de reforma configura *limitações formais*, que podem ser assim sinteticamente enunciadas: o *órgão do poder de reforma* (ou seja, o Congresso Nacional) *há de proceder nos estritos termos expressamente estatuídos na Constituição*.

A doutrina costuma distribuir as limitações do poder de reforma em três grupos: as *temporais*, as *circunstanciais* e as *materiais* (explícitas e implícitas).

As *limitações temporais* não são comumente encontráveis na história constitucional brasileira. Só a Constituição do Império estabeleceu esse tipo de limitação, visto que previra que tão-só após *quatro*

38. Cf. *Direito constitucional comparado*, I — O Poder Constituinte, pp. 155 e 156.

anos de sua vigência poderia ser reformada (art. 174). A Constituição de Portugal declara que pode ser revista decorridos *cinco anos* sobre a data da publicação de qualquer lei de revisão (art. 284). É desnecessário lembrar que a revisão constitucional, que era prevista no art. 3º das Disposições Transitórias da Constituição de 1988, não revelava limitação temporal, a qual, aliás, se esgotou com a malfeita revisão empreendida e concluída com apenas seis modificações no texto constitucional. Não cabe mais falar em revisão constitucional. A revisão terminou e não há como revivê-la legitimamente. Agora só existe o processo das emendas do art. 60.

Desde a Constituição de 1934, tornou-se prática corrente estatuir um tipo de *limitação circunstancial* ao poder de reforma, qual seja a de que *não se procederá à reforma da Constituição na vigência do estado de sítio*. A Constituição vigente mudou um pouco nesse particular. Veda emendas na vigência de *intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio*. Introduziu a vedação referente à intervenção federal nos Estados, que não era prevista antes (art. 60, § 1º).

A controvérsia sobre o tema mais se aguça, quanto a saber quais os *limites materiais* do poder de reforma constitucional. Trata-se de responder à seguinte questão: o poder de reforma pode atingir qualquer dispositivo da Constituição, ou há certos dispositivos que não podem ser objeto de emenda ou revisão?

Para solucionar a questão, a doutrina distingue entre *limitações materiais explícitas* e *limitações materiais implícitas*.

Quanto às primeiras, compreende-se facilmente que o constituinte originário poderá, expressamente, excluir determinadas matérias ou conteúdos da incidência do poder de emenda. As constituições brasileiras republicanas sempre contiveram um *núcleo imodificável*, preservando a Federação e a República. A atual Constituição não incluiu a República expressamente entre as matérias imodificáveis por emenda. Não o fez, porque previu um plebiscito para que o povo decidisse sobre a forma de governo: República ou Monarquia constitucional. O povo, em votação direta, optou por maioria esmagadora pela República, legitimando-a de uma vez por todas, já que a sua proclamação não contou com sua participação. Assim, popularmente consolidada, é de se perguntar se, não estando ela expressamente no rol das cláusulas intangíveis, pode ser objeto emenda a sua abolição com instauração da forma monárquica de governo. Inicialmente tive dúvidas e cheguei mesmo a escrever, nas edições anteriores deste manual, que, por não ser vedada emenda tendente a abolir a República, ficava reconhecida o direito de formação de partido monarquista que atuasse no sentido de instaurar a Monarquia mediante emenda constitucional. Assim o disse, embora destacasse que a Constituição inscreve a *forma republicana* como um princípio constitucional a ser assegurado e obser-

vado (art. 34, VII, *a*). o que significa dizer, por um lado, que certos elementos do conceito de República, como a periodicidade de mandato, devem ser assegurados e observados. Ora, meditando melhor sobre a questão, verifiquei que meu texto, naqueles termos, era contraditório. Se a forma republicana constitui um princípio constitucional que tem que ser assegurado, como admitir que emenda constitucional possa abolir-lo? Os fundamentos que justificam a inclusão da República entre as cláusulas intangíveis continuam presentes na Constituição, que só os afastou por um momento, a fim de que o povo decidisse sobre ela. Como o povo o fez no sentido de sua preservação, todos aqueles fundamentos readquiriram plena eficácia de cláusulas intocáveis por via de emenda constitucional. Não se trata, no caso, de simples limitação implícita, mas de limitação que encontra no contexto constitucional seus fundamentos, tanto quanto o encontraria se a limitação fosse expressa.

A Constituição, como dissemos antes, ampliou o núcleo explicitamente imodificável na via da emenda, definindo no art. 60, § 4º, que *não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais*.

É claro que o texto não proíbe apenas emendas que expressamente declarem: "fica abolida a Federação ou a forma federativa de Estado", "fica abolido o voto direto...", "passa a vigorar a concentração de Poderes", ou ainda "fica extinta a liberdade religiosa, ou de comunicação...", ou o *habeas corpus*, o mandado de segurança...". A vedação atinge a pretensão de modificar qualquer elemento conceitual da Federação, ou do voto direto, ou indiretamente restringir a liberdade religiosa, ou de comunicação ou outro direito e garantia individual; basta que a proposta de emenda se encaminhe ainda que remotamente, "tenda" (emendas *tendentes*, diz o texto) para a sua abolição.

Assim, por exemplo, a autonomia dos Estados federados assenta na capacidade de auto-organização, de autogoverno e de auto-administração. Emenda que retire deles parcela dessas capacidades, por mínima que seja, indica *tendência* a abolir a forma federativa de Estado.³⁹ Atribuir a qualquer dos Poderes atribuições que a Constituição só outorga a outro importará tendência a abolir o princípio da separação de Poderes.

Quanto às *limitações materiais implícitas* ou *inerentes*, a doutrina brasileira as vinha admitindo, em termos que foram bem expostos por Nelson de Sousa Sampaio.⁴⁰ Há, no entanto, uma tendência a ampliar

39. Cf. nosso artigo "Limitações ao poder de reforma constitucional", RF 159/75.

40. Cf. *O poder de reforma constitucional*, pp. 93 e ss.; também Pinto Ferreira, *Da Constituição*, pp. 109 e 110; Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *ob. cit.*, pp. 141 e ss. e 169 e ss.; Paulo Bonavides, *Curso de direito constitucional*, pp. 178 e ss. Mais recente-

as hipóteses de limitações materiais expressas que, por certo, tem a consequência de não mais reconhecer-se a possibilidade de limitações materiais implícitas. É o caso, por exemplo, da Constituição portuguesa que arrolou como limites materiais de sua revisão enorme relação de matérias (art. 188). Assim também, quando a Constituição Federal enumera matérias de direitos fundamentais como insuscetíveis de emendas, há de se tomar essa postura como inadmitindo hipóteses de limitação implícita. Todavia, das quatro categorias de normas constitucionais que, segundo Nelson de Sousa Sampaio, estariam implicitamente fora do alcance do poder de reforma, as três seguintes ainda nos parece que o estão, por razões lógicas, como sejam: se pudessem ser mudadas pelo poder de emenda ordinário, de nada adiantaria estabelecer vedações circunstanciais ou materiais a esse poder. São elas:

(1) “as concernentes ao titular do poder constituinte”, pois uma reforma constitucional não pode mudar o titular do poder que cria o próprio poder reformador;

(2) “as referentes ao titular do poder reformador”, pois seria despautério que o legislador ordinário estabelecesse novo titular de um poder derivado só da vontade do constituinte originário;

(3) “as relativas ao processo da própria emenda”, distinguindo-se quanto à natureza da reforma, para admiti-la quando se tratar de tornar mais difícil seu processo, não a aceitando quando vise a atenuá-lo.

24. Controle de constitucionalidade da reforma constitucional

Toda modificação constitucional, feita com desrespeito do procedimento especial estabelecido (iniciativa, votação, *quorum* etc.) ou de preceito que não possa ser objeto de emenda, padecerá de vício de inconstitucionalidade formal ou material, conforme o caso, e assim ficará sujeita ao controle de constitucionalidade pelo Judiciário, tal como se dá com as leis ordinárias. Mas não se tem exemplo desse controle em relação às emendas que desrespeitem as limitações implícitas. Por certo que deriva desse fato a tendência já assinalada de se ampliar, mais e mais, as matérias insuscetíveis de emendas constitucionais, como fez a Constituição portuguesa, e agora a nossa.

mente, cf. o artigo citado de Cármen Lúcia Antunes Rocha, *Separata da Revista de Informação Legislativa*, n. 120/171 e ss.

Capítulo III

DA EVOLUÇÃO POLÍTICO-CONSTITUCIONAL DO BRASIL

I. FASE COLONIAL: 1. Capitânias hereditárias. 2. Governadores-gerais. 3. Fragmentação e dispersão do poder político na colônia. 4. Organização municipal na colônia. 5. Efeitos futuros. II. FASE MONÁRQUICA: 6. Brasil, Reino Unido a Portugal. 7. Influência das novas teorias políticas e o movimento constitucional. 8. A Independência e o problema da unidade nacional. 9. A Constituição imperial. 10. Centralização monárquica. 11. Mecanismo político do poder central. 12. Os liberais e o ideal federalista. 13. Vitória das forças republicano-federalistas. III. FASE REPUBLICANA: 14. Organização do regime republicano. 15. A Constituição de 1891. 16. A Revolução de 1930 e a questão social. 17. A Constituição de 1934 e a ordem econômica e social. 18. O Estado Novo. 19. Redemocratização do país e a Constituição de 1946. 20. Regime dos Atos Institucionais. 21. A Constituição de 1967 e sua Emenda 1. 22. A Nova República e a Constituição de 1988. 23. O plebiscito, a revisão e emendas constitucionais.

I. FASE COLONIAL

1. Capitânias hereditárias

A colonização do Brasil começou efetivamente pela organização das *capitânias hereditárias*, sistema que consistiu na divisão do território colonial em doze porções irregulares, todas confrontando com o oceano, e sua doação a particulares (escolhidos entre a melhor gente), que estivessem decididos a morar no Brasil e fossem suficientemente ricos para colonizá-lo e defendê-lo.¹

Das doze capitânias, poucas prosperaram, mas serviram para criar núcleos de povoamento dispersos e quase sem contato uns com os outros, contribuindo para a formação de centros de interesses econômicos e sociais diferenciados nas várias regiões do território da colônia, o que veio a repercutir na estruturação do futuro Estado brasileiro.

1. A primeira concessão se deu pela carta de doação expedida por D. João III, a 10 de março de 1534, em favor de Duarte Coelho, a quem coube a Capitania de Pernambuco.

As capitanias eram organizações sem qualquer vínculo umas com as outras. Seus titulares — os *donatários* — dispunham de poderes quase absolutos. Afinal de contas, elas constituíam seus domínios, onde exerciam seu governo com *jurisdição cível e criminal*, embora o fizessem por ouvidores de sua nomeação e juizes eleitos pelas vilas. A dispersão do poder político e administrativo era assim completa, sem elo que permitisse qualquer interpenetração, salvo apenas a fonte comum que era a metrópole.

2. Governadores-gerais

Em 1549, institui-se o sistema de *governadores-gerais*. Introduz-se, com isso, um elemento unitário na organização colonial, coexistente com as capitanias diversificadas. O primeiro governador nomeado — Tomé de Sousa — vem munido de um documento de grande importância: o *Regimento do Governador-Geral*.

“Os regimentos dos governadores-gerais têm, de fato, a maior importância para a história administrativa do país: antecipavam-se às cartas políticas, pelo menos na delimitação das funções e no respeito exigido das leis, forais e privilégios, atenuando o arbítrio, fixando a ordem jurídica”.² Foram eles, pois, cartas organizatórias do regime colonial, que conferiam ao governador-geral poderes atinentes ao “governo político” e ao “governo militar” da colônia. “Em torno desse órgão central agrupavam-se outros órgãos elementares e essenciais à administração: o ‘ouvidor-mor’, encarregado geral dos negócios da justiça; o ‘procurador da fazenda’, encarregado das questões e interesses do fisco real; o ‘capitão-mor da costa’, com a função da defesa do vasto litoral, infestado de flibusteiros”.³

3. Fragmentação e dispersão do poder político na colônia

O sistema unitário, inaugurado com Tomé de Sousa, rompe-se em 1572, instituindo-se o duplo governo da colônia, que retoma a unidade cinco anos depois. Em 1621, é a colônia dividida em dois “Estados”: o *Estado do Brasil*, compreendendo todas as capitanias, que se estendiam desde o Rio Grande do Norte até São Vicente, ao sul; e o *Estado do Maranhão*, abarcando as capitanias do Ceará até o extremo norte. Sob o impulso de fatores e interesses econômicos, sociais e geográficos esses dois “Estados” fragmentam-se e surgem novos

centros autônomos subordinados a poderes político-administrativos regionais e locais efetivos. As próprias capitanias se subdividem tangidas por novos interesses econômicos, que se vão formando na evolução colonial.

Assim, por exemplo, Piauí erige-se em capitania independente do Maranhão; Minas destaca-se de São Paulo; Rio Grande do Sul torna-se capitania etc.

Enfim, o governo geral divide-se em governos regionais (Estado do Maranhão e Estado do Brasil), e estes, em várias capitanias gerais, subordinando capitanias secundárias, que, por sua vez, pouco a pouco, também se libertam das suas metrópoles, erigindo-se em capitanias autônomas. Cada capitania divide-se em comarcas, em distritos e em termos. “Em cada um desses centros administrativos o capitão-general distribui os representantes da sua autoridade, aos órgãos locais do governo geral: os ‘ouvidores’, os ‘juizes de fora’, os ‘capitães-mores’ das vilas e aldeias, os ‘comandantes de destacamentos’ dos povoados, os ‘chefes de presídios’ fronteirinhos, os ‘capitães-mores regentes’ das regiões recém-descobertas, os regimentos da ‘tropa de linha’ das fronteiras, os batalhões de ‘milicianos’, os terços de ‘ordenanças’, as ‘patrulhas volantes’ dos confins das regiões do ouro”.⁴

“Estes centros de autoridade local, subordinados, em tese, ao governo-geral da capitania, acabam, porém, tornando-se praticamente autônomos, perfeitamente independentes do poder central, encarregado na alta autoridade do capitão-general”.⁵ Formam-se “governículos locais, representados pela autoridade todo-poderosa dos capitães-mores das aldeias; os próprios caudilhos locais, insulados nos seus latifúndios, nas solidões dos altos sertões, eximem-se, pela sua mesma inacessibilidade, à pressão disciplinar da autoridade pública; e se fazem centros de autoridade efetiva, monopolizando a autoridade política, a autoridade judiciária e a autoridade militar dos poderes constituídos. São eles que guerreiam contra as tribos bárbaras do interior, em defesa das populações que habitam as convizinhas das suas casas fazendeiras, que são como que os seus castelos feudais e as cortes dos seus senhorios”.⁶

Nas zonas de mineração, por influência da forma econômica, surgem autoridades especiais: “capitães-mores das minas”, “junta de arrecadação da fazenda real”, “intendências do ouro” ou “dos diamantes”, “guardamorias das minas”, “casas de fundição”, condicionando uma organização administrativa peculiar.

2. Cf. Pedro Calmon, *História do Brasil*, nota 2, v. I/222.

3. Cf. Oliveira Vianna, *Evolução do povo brasileiro*, p. 199.

4. Cf. Oliveira Vianna, *ob. cit.*, pp. 214 e 215.

5. Idem, p. 215.

6. Idem, p. 217.

4. Organização municipal na colônia

Nas zonas de exploração agrícola, floresceu uma organização municipal, que teve profunda influência no sistema de poderes da colônia. O Senado da Câmara ou Câmara Municipal constituiu-se no órgão do poder local. Era composto de vários "oficiais", à imitação do sistema de Portugal. Seus membros eram eleitos dentre os "homens bons da terra", que, na realidade, representavam os grandes proprietários rurais. Assim foi nas zonas açucareiras. Mas, nas zonas pastoris e mineradoras, essa organização municipal não encontrou condições para prosperar, salvo no fim da colônia com a decadência da mineração e maior estabilidade populacional.

5. Efeitos futuros

Nesse sumário, já se vê delinear a estrutura do Estado brasileiro que iria constituir-se com a Independência. Especialmente, notamos que, na dispersão do poder político durante a colônia e na formação de centros efetivos de poder locais, se encontram os fatores reais do poder, que darão a característica básica da organização política do Brasil na fase imperial e nos primeiros tempos da fase republicana, e ainda não de todo desaparecida: a formação coronelística oligárquica.

II. FASE MONÁRQUICA

6. Brasil, Reino Unido a Portugal

A fase monárquica inicia-se, de fato, com a chegada de D. João VI ao Brasil em 1808, e vai-se efetivando aos poucos. Instalada a corte no Rio de Janeiro, só isso já importa em mudança do *status* colonial. Em 1815, o Brasil é elevado, pela lei de 16 de dezembro, à categoria de *Reino Unido* a Portugal, pondo em consequência fim ao Sistema Colonial, e monopólio da Metrópole. Um passo à frente foi a proclamação da Independência a 7.9.1822, da qual surgiu o Estado brasileiro sob a forma de governo imperial, que perdurou até 15.11.1889.

Transferida a sede da Família Reinante para o Rio de Janeiro, era preciso instalar as repartições, os tribunais e as comodidades necessárias à organização do governo; cumpria estabelecer a ordem, com a polícia, a justiça superior, os órgãos administrativos, que tinham até aí faltado à colônia. Assim se fez a partir de 1º de abril. Foram instituídos, criados e instalados o Conselho de Estado, a Intendência Geral de Polícia, o Conselho da Fazenda, a Mesa da Consciência e

Ordens, o Conselho Militar, o Desembargo do Paço, a Casa da Suplicação, a Academia de Marinha; a Junta-Geral do Comércio, o juízo dos falidos e conservador dos privilégios; o Banco do Brasil, para auxiliar o Erário, a Casa da Moeda, a Impressão Régia etc. Abriam-se antes os portos, decretara-se a liberdade da indústria, possibilitara-se a expansão comercial.⁷

Mas essa organização de poder não teve efetiva atuação além dos limites do Rio de Janeiro. Pouca influência exerceu no interior do país, onde a fragmentação e diferenciação do poder real e efetivo perduravam, sedimentadas nos três séculos de vida colonial. Nem se poderia mudar, da noite para o dia, essa relação de poder que estava em consonância com a realidade existente, que apresentava um povo disseminado por um amplíssimo território, formando, socialmente, "um conjunto ainda incoerente de núcleos humanos, ganglionarmente distribuídos pela orla de um litoral vastíssimo e pelos campos e sertões do interior"; e "um amontoado de quase vinte capitanias dispersas, muitas delas com uma tradição mais que secular de autonomia e independência".⁸

7. Influência das novas teorias políticas e o movimento constitucional

Mas aqui já se constituía uma nobreza brasileira "assentada sobre a base dos grandes latifúndios, numerosa, rica, orgulhosa, esclarecida pelas idéias novas, que revolucionam os centros cultos do Rio e de Pernambuco", bem como "uma aristocracia intelectual, graduada na sua maioria pelas universidades européias, especialmente a Universidade de Coimbra",⁹ que acorre ao Rei, domina o Paço, como elemento catalisador, que haveria de influir na formação política desses primeiros tempos, que coincidem com o aparecimento de um novo fator, um novo modificador da estrutura política, que são as novas teorias políticas que então agitavam e renovavam, desde os seus fundamentos, o mundo europeu: o Liberalismo, o Parlamentarismo, o Constitucionalismo, o Federalismo, a Democracia, a República.¹⁰ Tudo isso justifica o aparecimento do movimento constitucional, no Brasil, ainda quando D. João VI mantinha a sua corte no Rio de Janeiro. Cogitou-se até de aplicar aqui, *salvo as modificações que as circunstâncias locais tornassem necessárias*, a própria constitui-

7. Cf. Pedro Calmon, *História do Brasil*, cit., v. II/1.377 a 1.379.

8. Cf. Oliveira Vianna, *ob. cit.*, p. 245.

9. Idem, p. 247.

10. Idem, pp. 245 e 246.

ção elaborada pelas Cortes portuguesas, chamada Constituição do Porto.¹¹

8. A Independência e o problema da unidade nacional

Proclamada a Independência, o problema da *unidade nacional* impõe-se como o primeiro ponto a ser resolvido pelos organizadores das novas instituições. A consecução desse objetivo dependia da estruturação de um poder centralizador e uma organização nacional que freassem e até demolissem os poderes regionais e locais, que efetivamente dominavam no país, sem deixar de adotar alguns dos princípios básicos da teoria política em moda na época.

O constitucionalismo era o princípio fundamental dessa teoria, e realizar-se-ia por uma constituição escrita, em que se consubstanciasse o liberalismo, assegurado por uma declaração constitucional dos direitos do homem e um mecanismo de divisão de poderes, de acordo com o postulado do art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, segundo o qual *não tem constituição a sociedade onde não é assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separação dos poderes*.

Os estadistas do Império e construtores da nacionalidade tinham pela frente uma tarefa ingente e difícil: conseguir construir a unidade do poder segundo esses princípios que não toleravam o absolutismo. E conseguiram-no dentro dos limites permitidos pela realidade vigente, montando, através da Constituição de 1824, um mecanismo centralizador capaz de propiciar a obtenção dos objetivos pretendidos, como provou a história do Império. “É [como nota Oliveira Vianna] uma edificação possante, sólida, maciça, magnificamente estruturada, constringindo rijamente nas suas malhas resistentes todos os centros provinciais e todos os nódulos de atividade política do país: *nada escapa, nem o mais remoto povoado do interior, à sua compressão poderosa*”.¹²

9. A Constituição imperial

O sistema foi estruturado pela *Constituição Política do Império do Brasil de 25.3.1824*. Declara, de início, que o Império do Brasil é a

11. Cf. Eduardo Espínola, *Constituição dos Estados Unidos do Brasil*, v. I/5; Afonso Arinos de Melo Franco, *Curso de direito constitucional brasileiro*, p. 17, que é o melhor livro sobre a formação constitucional do Brasil. Excelente por sua abundante documentação é a *História constitucional do Brasil* de Paulo Bonavides e Paes de Andrade, já em 3ª edição. Importante também é a obra de Paulo Bonavides e R. A. Amaral Vieira, *Textos políticos da história do Brasil*, publicada pela Imprensa Universitária do Ceará.

12. Cf. *ob. cit.*, p. 258.

associação política de todos os cidadãos brasileiros, que formam uma nação livre e independente que *não admite, com qualquer outro, laço de união ou federação, que se oponha à sua independência* (art. 1º). O território do Império foi dividido em províncias, nas quais foram transformadas as capitanias então existentes (art. 2º). Seu governo era monárquico hereditário, constitucional e representativo (art. 3º). O princípio da divisão e harmonia dos poderes políticos foi adotado como “princípio conservador dos direitos dos cidadãos, e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece” (art. 9º), mas segundo a formulação quadripartita de Benjamin Constant: *Poder Legislativo, Poder Moderador, Poder Executivo e Poder Judiciário* (art. 10).¹³ O Poder Legislativo era exercido pela assembleia geral, composta de duas câmaras: a dos deputados, eletiva e temporária, e a dos senadores, integrada de membros vitalícios nomeados pelo Imperador dentre componentes de uma lista tríplice eleita por província (arts. 13, 35, 40 e 43). A eleição era indireta e censitária. O Poder Moderador, considerado a chave de toda a organização política, era exercido privativamente pelo Imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente velasse sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos (art. 98). O Poder Executivo, exercido pelos ministros de Estado, tinha como chefe também o Imperador (art. 102). O Poder Judiciário, independente, era composto de juizes e jurados (art. 151). No art. 179, a Constituição trazia uma declaração de direitos individuais e garantias que, nos seus fundamentos, permaneceu nas constituições posteriores.

10. Centralização monárquica

As províncias foram subordinadas ao poder central, através do seu presidente, escolhido e nomeado pelo Imperador, e do chefe de polícia, também escolhido e nomeado pelo Imperador, com atribuições não só policiais como judiciais até 1870, do qual dependiam órgãos menores, com ação nas localidades, cidades, vilas, lugarejos, distritos: os “delegados de polícia”, os “subdelegados de polícia”, os “inspetores de quarteirões”, os “carcereiros” das cadeias públicas e o pessoal subalterno da administração policial. É ainda o poder central que nomeia o “juiz de direito”, o “juiz municipal”, o “promotor público”. E há também a “Guarda Nacional”, em que se transformaram as milícias locais, a qual, a partir de 1850, passou a ser subordinada ao poder central.

13. Cf. Benjamin Constant, *Curso de política constitucional*, pp. 13 e ss.

“Este poder [lembra Oliveira Vianna] não se limita a agir através desses órgãos locais: opulenta-se com atribuições, que lhe dão meios de influir sobre os próprios órgãos da autonomia local. Ele pode anular as eleições de vereadores municipais e juizes de paz. Ele pode reintegrar o funcionário municipal demitido pela Câmara. Ele pode suspender mesmo as resoluções das Assembléias provinciais”.¹⁴

11. Mecanismo político do poder central

Mas a chave de toda a organização política estava efetivamente no Poder Moderador, concentrado na pessoa do Imperador. “Realmente, criando o Poder Moderador, enfeixado na pessoa real, os estadistas do antigo regime armam o soberano de faculdades excepcionais. Como Poder Moderador, ele age sobre o Poder Legislativo pelo direito de dissolução da Câmara, pelo direito de adiamento e de convocação, pelo direito de escolha, na lista tríplice, dos senadores. Ele atua sobre o Poder Judiciário pelo direito de suspender os magistrados. Ele influi sobre o Poder Executivo pelo direito de escolher livremente seus ministros de Estado e livremente demiti-los. Ele influi sobre a autonomia das províncias. E, como chefe do Poder Executivo, que exerce por meio dos seus ministros, dirige, por sua vez, todo o mecanismo administrativo do país”.¹⁵ Aqui, o *Rei reinava, governava e administrava*, como dissera Itaborai, ao contrário do sistema inglês, onde vigia e vige o princípio de que o *Rei reina, mas não governa*.

No aparelho político do governo central, dois órgãos concorriam para reforçar a ação do poder soberano: o Senado e o Conselho de Estado. Aquele, essencialmente conservador, funcionava como órgão de reação contra os movimentos liberais da Câmara dos Deputados. O Conselho de Estado era um órgão consultivo, que tinha enormes atribuições: aconselhava o Imperador nas medidas administrativas e políticas e era o supremo intérprete da Constituição.

12. Os liberais e o ideal federalista

Os liberais lutaram quase sessenta anos contra esse mecanismo centralizador e sufocador das autonomias regionais. A realidade dos poderes locais, sedimentada durante a colônia, ainda permanecia regurgitante sob o peso da monarquia centralizante. A idéia descentralizadora, como a republicana, despontara desde cedo na história político-constitucional do Império. Os federalistas surgem no âmago

14. Cf. *ob. cit.*, p. 260.

15. *Idem*, p. 262.

da Constituinte de 1823, e permanecem durante todo o Império, provocando rebeliões como as “Balaíadas”, as “Cabanadas”, as “Sabina-das”, a “República de Piratini”. Tenta-se implantar, por várias vezes, a *monarquia federalista* do Brasil, mediante processo constitucional (1823, 1831), e chega-se a razoável descentralização com o Ato Adicional de 1834, esvaziado pela lei de interpretação de 1840. O republicanismo irrompe com a Inconfidência Mineira e com a revolução pernambucana de 1817; em 1823, reaparece na constituinte, despontando outra vez em 1831, e brilha com a República de Piratini, para resurgir com mais ímpeto em 1870 e desenvolver-se até 1889.

13. Vitória das forças republicano-federalistas

Em 1889, vencem as forças descentralizadoras, agora organizadas, mais coerentes, e não mera fragmentação e diferenciação de poder como existentes na colônia, mas certamente como projeção daquela realidade colonial que gerou, no imenso território do país, os poderes efetivos e autônomos locais, agora também aliados aos novos fatores que apareceram e se firmaram na vida política brasileira: o *federalismo*, como princípio constitucional de estruturação do Estado, a *democracia*, como regime político que melhor assegura os direitos humanos fundamentais.

Tomba o Império sob o impacto das novas condições materiais, que possibilitaram o domínio dessas velhas idéias com roupagens novas, e “um dia, por uma bela manhã, uma simples passeata militar” proclama a *República Federativa* por um decreto (o de n. 1, de 15.11.1889, art. 1º).

II. FASE REPUBLICANA

14. Organização do regime republicano

Assumindo o poder, os republicanos, civis e militares, cuidaram da transformação do regime. Instala-se o *governo provisório* sob a presidência do Marechal Deodoro da Fonseca. A primeira afirmação constitucional da República foi o Decreto n. 1, de 15.11.1889. Nele se traduz velha aspiração brasileira com a adoção do federalismo que “responde a condições econômicas, sociais e políticas e fora já anteriormente reivindicação e realidade, da Colônia até a Regência. O segundo Reinado abafa-o momentaneamente, jogando com os partidos e cortando os elementos mais exaltados”.¹⁶ As províncias do Bra-

16. Cf. Edgar Carone, *A Primeira República*, pp. 14 e 15.

sil, reunidas pelo laço da federação, constituíram os Estados Unidos do Brasil, e cada um desses Estados, no exercício de sua legítima “soberania” — disse o decreto — decretaram oportunamente a sua constituição definitiva e elegeram seus corpos deliberantes e os seus governos (arts. 1º, 2º e 3º). As províncias aderiram logo ao novo regime. Não houve resistência.

Não tardou, o governo provisório providenciou a organização do regime. Logo, a 3 de dezembro, nomeou uma comissão de cinco ilustres Republicanos para elaborar o projeto de constituição, que serviria de base para os debates na assembléia constituinte a ser convocada. O projeto foi publicado pelo Decreto n. 510, de 22.6.1890, como *Constituição aprovada pelo Executivo*. No dia 15 de setembro do mesmo ano foi eleita a Assembléia-Geral Constituinte (em verdade, *Congresso Constituinte*), que se instalara no Palácio São Cristóvão, a 15 de novembro. Presidiu-a o paulista Prudente de Moraes, mais tarde Presidente da República. Conveio-se em autolimitar-se, restringindo-se-lhe a competência “ao objeto e termos de sua convocação”. “Proibia-se-lhe qualquer interferência no governo (razão do descrédito da primeira constituinte imperial) e a discussão de dois pontos pacíficos: República e federação”.¹⁷ Pouco mais de três meses de trabalho e a primeira Constituição republicana ficara aprovada, com pequenas alterações introduzidas no projeto do Executivo.

15. A Constituição de 1891

A *Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil* fora promulgada no dia 24.2.1891. Estabeleceu que a Nação Brasileira adotava como *forma de governo* a *República Federativa*, e constituía-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias, em *Estados Unidos do Brasil* (art. 1º). Cada uma das antigas províncias formara um Estado e o antigo Município neutro se transformara no Distrito Federal, que continuou a ser a capital da União (art. 2º). Perfilhou-se o regime representativo (art. 1º). Optou-se pelo presidencialismo à moda norte-americana. “Equilibravam-se, nos freios e contrapesos (como nos Estados Unidos), os poderes — e afinal, a clareza, a síntese, a limpidez verbal da Constituição [...] lhe garantiam uma duração razoável. Estabilizava a autoridade, franqueara aos Estados vida própria, proclamara as liberdades democráticas. Tanto fosse cumprida!”¹⁸ Rompera com a divisão quadripartita vigente no Império de inspiração de Benjamin Constant, para agasalhar a doutrina tripartita

de Montesquieu, estabelecendo como “órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e independentes entre si” (art. 15). Firmara a autonomia dos Estados, aos quais conferira competências remanescentes: “todo e qualquer poder ou direito, que lhes não fosse negado por cláusula expressa ou implicitamente contida nas cláusulas expressas da Constituição”, era-lhes facultado (art. 65, n. 2). Previra a autonomia municipal (art. 68).

Constituíra-se formoso arcabouço formal. Era — como nota Amaro Cavalcânti — o “texto da Constituição norte-americana completado com algumas disposições das Constituições suíça e argentina”.¹⁹ Faltara-lhe, porém, vinculação com a realidade do país. Por isso, não teve eficácia social, não regeu os fatos que previra, não fora cumprida.

Não demorou o conflito de poderes. A Constituinte, promulgada a Constituição, elegera Presidente da República a Deodoro da Fonseca e Vice-Presidente a Floriano Peixoto, este de chapa oposta à daquele, que tinha como companheiro Almirante Wandenkolk. Concluída a eleição, convertera-se a Constituinte em Congresso, separando-se em Câmara e Senado. A oposição, liderada por Prudente de Moraes, não conseguira impedir a eleição do Pai da República, mas impusera um Vice-Presidente, em que se escorasse. Consumado o fato, pretendeu-se destruir o governo pelo *impeachment*, que dependia ainda de regulamentação. Aparelhará-se, então, um projeto que definisse os crimes de responsabilidade do Presidente. O governo vetara-o. Prudente de Moraes, Vice-Presidente do Senado, no exercício da Presidência deste (porque Floriano estava afastado), resolveu submeter o veto ao Senado, que o rejeitara e assim também a Câmara. Em represália, Deodoro dissolvera o Congresso (3.11.1891). Reagira a Armada, à frente o Almirante Custódio José de Mello. A 23 de novembro, Deodoro, “para evitar corresse o sangue generoso dos brasileiros”, renuncia à Presidência da República. Sobe o Vice-Presidente, Floriano Peixoto. E revela-se. “O poder transformou-o: assim ‘modesto e vulgar’ como o retrataria Quintino — ‘esquivo, indiferente, impassível’”.²⁰ Considerado o *consolidador da República*, começou derrubando os governadores dos Estados. Pouco depois, a reação contra Floriano. Estala a guerra civil: Custódio J. de Mello, deixando o Ministério da Marinha, junta-se à revolta da Armada com Saldanha da Gama, Gumerindo Saraiva e outros. Floriano dominou, e só entregou o poder ao Presidente eleito para o quadriênio de 1894/1898, que foi Prudente de Moraes. Com este, a oligarquia, que mandaria nos Estados, se instala no poder.

17. Cf. Pedro Calmon, *ob. cit.*, v. VI/1.920.

18. *Idem*, p. 1.922.

19. Cf. *Anais da Constituinte*, v. I/160.

20. Cf. Pedro Calmon, *ob. cit.*, p. 1.934.

rendas tributárias entre União, Estados e Municípios, outorgando a estes base econômica em que se assentasse a autonomia que lhes assegurava. Aumentou os poderes do Executivo. Rompeu com o bica-meralismo rígido, atribuindo o exercício do Poder Legislativo apenas à Câmara dos Deputados, transformando o Senado Federal em órgão de colaboração desta (arts. 22 e 88 e ss.). Definiu os direitos políticos e o sistema eleitoral, admitindo o voto feminino (arts. 108 e ss.) Criou a Justiça Eleitoral, como órgão do Poder Judiciário (arts. 63, d, 82 e ss.). Adotou, ao lado da representação política tradicional, a representação corporativa de influência fascista (art. 23). Instituiu, ao lado do Ministério Público e do Tribunal de Contas, os Conselhos Técnicos, como órgãos de cooperação nas atividades governamentais. Ao lado da clássica declaração de direitos e garantias individuais, *inscreveu um título sobre a ordem econômica e social* e outro sobre *família, a educação e a cultura*, com normas quase todas programáticas, sob a influência da Constituição alemã de Weimar. Regulou os problemas da segurança nacional e estatuiu princípios sobre o funcionalismo público (arts. 159 e 172). Fora, enfim, um documento de compromisso entre o liberalismo e o intervencionismo.

18. O Estado Novo

O país já se encontrava sob o impacto das ideologias que grassavam no mundo do pós-guerra de 1918. Os partidos políticos assumiam posições em face da problemática ideológica vigente: surge um partido fascista, barulhento e virulento — a Ação Integralista Brasileira, cujo chefe, Plínio Salgado, como Mussolini e Hitler, se preparava para empolgar o poder;²⁵ reorganiza-se o partido comunista, aguerrido e disciplinado, cujo chefe, Luís Carlos Prestes, também queria o poder. Getúlio Vargas, no poder, eleito que fora pela Assembleia Constituinte para o quadriênio constitucional, à maneira de Deodoro, como este, dissolve a Câmara e o Senado, revoga a Constituição de 1934, e outorga a Carta Constitucional de 10.11.37.

Fundamentou o golpe deitando proclamação ao povo brasileiro, onde disse entre outras coisas: “Por outro lado, as novas formações partidárias, surgidas em todo o mundo, por sua própria natureza refratária aos processos democráticos, oferecem perigo imediato para as instituições, exigindo, de maneira urgente e proporcional à virulência dos antagonismos, o reforço do poder central”. Assim se implantou a nova ordem denominada *Estado Novo*. Prometeu plebiscito

25. Sobre o Integralismo, cf. Hégio Trindade, *Integralismo: o fascismo brasileiro da década de 30*, São Paulo, Difel, 1974.

para aprová-lo, mas nunca o convocou. Instituiu-se pura e simplesmente a ditadura.

Em síntese, teve a *Constituição dos Estados Unidos do Brasil*, de 1937, como principais preocupações: fortalecer o Poder Executivo, a exemplo do que ocorria em quase todos os outros países, julgando-se o chefe do governo em dificuldades para combater pronta e eficientemente as agitações internas; atribuir ao Poder Executivo uma intervenção mais direta e eficaz na elaboração das leis, cabendo-lhe, em princípio, a iniciativa e, em certos casos, podendo expedir decretos-leis; reduzir o papel do parlamento nacional, em sua função legislativa, não somente quanto à sua atividade e funcionamento, mas ainda quanto à própria elaboração da lei; eliminar as causas determinantes das lutas e dissídios de partidos, reformando o processo representativo, não somente na eleição do parlamento, como principalmente em matéria de sucessão presidencial; conferir ao Estado a função de orientador e coordenador da economia nacional, declarando, entretanto, ser predominante o papel da iniciativa individual e reconhecendo o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo; reconhecer e assegurar os direitos de liberdade, de segurança e de propriedade do indivíduo, acentuando, porém, que devem ser exercidos nos limites do bem público; a nacionalização de certas atividades e fontes de riqueza, proteção ao trabalho nacional, defesa dos interesses nacionais em face do elemento alienígena.²⁶

A Carta de 1937 não teve, porém, aplicação regular. Muitos de seus dispositivos permaneceram letra morta. Houve ditadura pura e simples, com todo o Poder Executivo e Legislativo concentrado nas mãos do Presidente da República, que legislava por via de decretos-leis que ele próprio depois aplicava, como órgão do Executivo.

Vinte e uma emendas sofreu essa Constituição, através de *leis constitucionais*, que a alteravam ao sabor das necessidades e conveniências do momento e, não raro, até do capricho do chefe do governo.

19. Redemocratização do país e a Constituição de 1946

Terminada a II Guerra Mundial, de que o Brasil participou ao lado dos Aliados contra as ditaduras nazi-fascistas, logo começaram os movimentos no sentido da redemocratização do país: Manifesto dos Mineiros, entrevista de José Américo de Almeida etc. Havia, também, no mundo do pós-guerra, extraordinária recomposição dos princípios constitucionais, com reformulação de constituições existentes

26. Cf. Eduardo Espínola, *ob. cit.*, v. I/28 e 29.

ou promulgação de outras (Itália, França, Alemanha, Iugoslávia, Polônia, e tantas outras), que influenciaram a reconstitucionalização do Brasil.

O Presidente da República tomou, então, as providências necessárias à recomposição do quadro constitucional brasileiro. Expediu a Lei Constitucional 9, de 28.2.45, em que são modificados vários artigos da Carta então vigente, a fim de propiciar aquele desiderato, mediante a eleição direta do Presidente da República e do parlamento.

Nos considerando dessa lei constitucional, no entanto, o ditador manifesta o entendimento de que o parlamento a ser eleito teria função ordinária, não se cogitando de convocar Assembléia Constituinte. Aquele parlamento ordinário é que, se julgasse cabível, faria durante a legislatura as modificações na Constituição. O art. 4º dessa lei constitucional é que determinou a fixação da data das eleições e estabeleceu os princípios a serem observados no processo eleitoral.

A questão evoluiu, com alguma incerteza, para a eleição de uma assembléia constituinte. Convocaram-se as eleições para Presidente da República, Governadores de Estado, Parlamento e Assembléias Legislativas Estaduais, fixando-se-lhes a data de 2.12.45. As forças opostas à ditadura apresentaram, para Presidente, uma candidatura militar, o Brigadeiro Eduardo Gomes, com a clara intenção de respaldar na Força Aérea Brasileira o êxito do processo eleitoral. Houve euforia. As forças situacionistas não deram por menos e apresentaram também um militar, ex-Ministro da Guerra de Getúlio, General Eurico Gaspar Dutra, de inegável prestígio nas Forças Armadas. A campanha da oposição foi brilhante e entusiástica. Apuradas as eleições, o candidato vitorioso foi o General e não o Brigadeiro, o qual assumiu o poder, recebendo a faixa presidencial do Min. José Linhares, do Supremo Tribunal Federal, que vinha ocupando a Presidência, desde que, a 29.10.45, os Ministros Militares derrubaram Getúlio Vargas, desconfiados de que estaria ele tramando sua permanência no poder.

Instalou-se a Assembléia Constituinte no dia 2.2.46. Nela estavam representadas várias correntes de opinião: direita, conservadora, centro-democrático, progressistas, socialistas e comunistas, predominando a opinião conservadora.²⁷ "Sentira-se, de início" [informa José

27. O Min. Aliomar Baleeiro, que foi constituinte, diz o seguinte: "A Constituinte de 1946 — se for objeto de estudos quanto à composição social e profissional de seus membros, a exemplo da aguda investigação de Charles Beard sobre a Convenção de Filadélfia — revelará que congregava maciçamente titulares da propriedade. Mais de 90% dos constituintes eram pessoalmente proprietários, ou vinculados por seus parentes próximos — pais e sogros — à propriedade sobretudo imobiliária. Compreende-se que desse corpo coletivo jamais poderia brotar texto oposto à propriedade [...]". Cf. *Limitações constitucionais ao poder de tributar*, p. 238.

Duarte] "que as correntes de opinião tinham a preocupação de assentar, com nitidez, sem artifícios, as fórmulas, os princípios cardeais do regime representativo, e estabelecer com precisão os rumos próprios à harmonia e independência dos poderes; a redução das possibilidades de hipertrofia do Poder Executivo; a conservação do equilíbrio político do Brasil, pelo regime de seus representantes no Senado e na Câmara; a fixação da política municipalista, capaz de dar ao Município o que lhe era indispensável, essencial, à vida, à autonomia; a revisão do quadro esquemático da declaração de direitos e garantias individuais; o tratado, em contornos bem definidos, do campo econômico e social, onde se teriam de construir, em nome e por força da evolução e da justiça, os mais legítimos postulados constitucionais".²⁸

Esse sentimento ficou traduzido nas normas da *Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil*, de 18.9.46, que, ao contrário das outras, não foi elaborada com base em um projeto preordenado, que se oferecesse à discussão da Assembléia Constituinte. Serviu-se, para sua formação, das Constituições de 1891 e 1934. Voltou-se, assim, às fontes formais do passado, que nem sempre estiveram conformes com a história real, o que constituiu o maior erro daquela Carta Magna, que nasceu de costas para o futuro, fitando saudosamente os regimes anteriores, que provaram mal. Talvez isso explique o fato de não ter conseguido realizar-se plenamente. Mas, assim mesmo, não deixou de cumprir sua tarefa de redemocratização, propiciando condições para o desenvolvimento do país durante os vinte anos em que o regeu.

Sob sua égide, sucederam-se crises políticas e conflitos constitucionais de poderes, que se avultaram logo após o primeiro período governamental, quando se elegeu Getúlio Vargas com um programa social e econômico que inquietou as forças conservadoras, que acabaram provocando formidável crise que culminou com o suicídio do chefe do governo. Sobe o Vice-Presidente Café Filho, que presidiu às eleições para o quinquênio seguinte, sendo derrotadas as mesmas forças opostas a Getúlio. Nova crise. Adoece Café Filho. Assume o Presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, que é deposto por um movimento militar liderado pelo General Teixeira Lott (11.11.55), que também impede Café Filho de retornar à Presidência (21.11.55). Assume o Presidente do Senado, Sen. Nereu Ramos, que entrega a Presidência a Juscelino Kubitschek de Oliveira, contra o qual espocam rebeliões golpistas, mas sem impedirem conclusse seu mandato.

Elege-se Jânio Quadros, para suceder a Juscelino. Sete meses depois, renuncia. Reação militar contra o Vice-Presidente João Gou-

28. Cf. *Constituição brasileira de 1946*, v. 1/105 e 106.

lart, visando impedir sua posse na Presidência. Vota-se, às pressas, uma emenda constitucional parlamentarista (EC n. 4, de 2.9.61, denominada Ato Adicional), retirando-lhe ponderáveis poderes, com o que não se conformaria. Consegue um plebiscito que se pronuncia contra o parlamentarismo e, pois, pela volta ao presidencialismo, razão por que o Congresso aprova a EC n. 6, de 23.1.63, revogando o Ato Adicional. Jango Goulart tenta equilibrar-se no poder acariciando a direita, os conservadores e a esquerda. Apesar de tudo, a economia nacional prospera, e a inflação muito mais.

Jango, despreparado, instável, inseguro e demagogo, desorienta-se. Perde o estribo do poder. Escora-se no peleguismo, em que fundamentara toda a sua carreira política. Perde-se. Sem prestar atenção aos mais sensatos, que, aliás, despreza, cai no dia 1º de abril de 1964, com o Movimento Militar instaurado no dia anterior.

20. Regime dos Atos Institucionais

Domina o poder um Comando Militar Revolucionário, que efetua prisões políticas de todos quantos seguiram o Presidente deposto ou simplesmente com ele simpatizavam, ou com as idéias de esquerda, ou apenas protestavam contra o autoritarismo implantado.

Expediu-se um Ato Institucional (9.4.64), mantendo a ordem constitucional vigente, mas impondo várias cassações de mandatos e suspensões de direitos políticos. Elege-se Presidente o Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, para um período complementar de três anos. Governou com base no ato institucional referido e em atos complementares.

Nova crise culminou com o AI 2, de 27.10.65, e outros atos complementares. Vieram ainda os AI 3 e 4. Este regulando o procedimento a ser obedecido pelo Congresso Nacional, para votar nova Constituição, cujo projeto o governo apresentou. A 24.1.67, fora ela outorgada, o que veio resumir as alterações institucionais operadas na Constituição de 1946, que findava após sofrer vinte e uma emendas regularmente aprovadas pelo Congresso Nacional com base em seu art. 217, e o impacto de quatro atos institucionais e trinta e sete atos complementares, que tornaram compulsável o Direito Constitucional positivo então vigente.

21. A Constituição de 1967 e sua Emenda 1

Essa Constituição, promulgada em 24.1.67, entrou em vigor em 15.3.67, quando assumia a Presidência o Marechal Arthur da Costa e

Silva. Sofreu ela poderosa influência da Carta Política de 1937, cujas características básicas assimilou. Preocupou-se fundamentalmente com a segurança nacional. Deu mais poderes à União e ao Presidente da República. Reformulou, em termos mais nítidos e rigorosos, o sistema tributário nacional e a discriminação de rendas, ampliando a técnica do federalismo cooperativo, consistente na participação de uma entidade na receita de outra, com acentuada centralização. Atualizou o sistema orçamentário, propiciando a técnica do orçamento-programa e os programas plurianuais de investimento. Instituiu normas de política fiscal, tendo em vista o desenvolvimento e o combate à inflação. Reduziu a autonomia individual, permitindo suspensão de direitos e de garantias constitucionais, no que se revela mais autoritária do que as anteriores, salvo a de 1937. Em geral, é menos intervencionista do que a de 1946, mas, em relação a esta, avançou no que tange à limitação do direito de propriedade, autorizando a desapropriação mediante pagamento de indenização por títulos da dívida pública, para fins de reforma agrária. Definiu mais eficazmente os direitos dos trabalhadores.

Durou pouco, porém. As crises não cessaram. E veio o AI 5, de 13.12.68, que rompeu com a ordem constitucional, ao qual se seguiram mais uma dezena e muitos atos complementares e decretos-leis, até que insidiosa moléstia impossibilitara o Presidente Costa e Silva de continuar governando. É declarado temporariamente impedido do exercício da Presidência pelo AI 12, de 31.8.69, que atribuiu o exercício do Poder Executivo aos Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, que completaram o preparo de novo texto constitucional, afinal promulgado em 17.10.69, como EC n. 1 à Constituição de 1967, para entrar em vigor em 30.10.69.

Teórica e tecnicamente, não se tratou de emenda, mas de nova constituição. A emenda só serviu como mecanismo de outorga, uma vez que verdadeiramente se promulgou texto integralmente reformulado, a começar pela denominação que se lhe deu: *Constituição da República Federativa do Brasil*, enquanto a de 1967 se chamava apenas *Constituição do Brasil*. Ela foi modificada por outras vinte e cinco emendas, afora a de n. 26, que, a rigor, não é emenda constitucional. Em verdade, a EC n. 26, de 27.11.85, ao convocar a Assembléia Nacional Constituinte, constitui, nesse aspecto, um ato político. Se convocava a Constituinte para elaborar Constituição nova que substituiria a que estava em vigor, por certo não tem a natureza de emenda constitucional, pois esta tem precisamente sentido de manter a Constituição emendada. Se visava destruir esta, não pode ser tida como emenda, mas como ato político.

22. A Nova República e a Constituição de 1988

A luta pela normalização democrática e pela conquista do Estado Democrático de Direito começou assim que se instalou o golpe de 1964 e especialmente após o AI 5, que foi o instrumento mais autoritário da história política do Brasil. Tomara, porém, as ruas, a partir da eleição dos Governadores em 1982. Intensificara-se, quando, no início de 1984, as multidões correram entusiasmadas e ordeiras aos comícios em prol da eleição direta do Presidente da República, interpretando o sentimento da Nação, em busca do reequilíbrio da vida nacional, que só poderia consubstanciar-se numa nova ordem constitucional que refizesse o pacto político-social. Frustrou-se, contudo, essa grande esperança.

Não desanimaram, ainda desta vez, as forças democráticas. Lançam a candidatura de Tancredo Neves, então Governador de Minas Gerais, à Presidência da República. Concorreria pela via indireta no Colégio Eleitoral com o propósito de destruí-lo.

Em campanha, deita as bases da Nova República em famoso discurso pronunciado em Maceió. Propôs construí-la usando metodologia clara, conforme mostramos, de outra feita, nesta síntese:

“A Nova República pressupõe uma fase de transição, com início a 15 de março de 1985, na qual serão feitas, ‘com prudência e moderação’, as mudanças necessárias: na legislação opressiva, nas formas falsas de representação e na estrutura federal, fase que ‘se definirá pela eliminação dos resíduos autoritários’, e o que é mais importante ‘pelo início, decidido e corajoso, das transformações de cunho social, administrativo, econômico e político que requer a sociedade brasileira’. E, assim, finalmente, a Nova República ‘será iluminada pelo futuro Poder Constituinte, que, eleito em 1986, substituirá as malogradas instituições atuais por uma Constituição que situe o Brasil no seu tempo, prepare o Estado e a Nação para os dias de amanhã’”.²⁹

O povo emprestou a Tancredo Neves todo o apoio para a execução de seu programa de construção da Nova República, a partir da derrota das forças autoritárias que dominaram o país durante vinte anos (1964 a 1984). Sua eleição, a 15.1.85, foi, por isso, saudada como o início de um novo período na história das instituições políticas brasileiras, e que ele próprio denominara de a *Nova República*, que haveria de ser democrática e social, a concretizar-se pela Constituição que seria elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, que ele convocaria assim que assumisse a Presidência da República. Prometeu, também, que nomearia uma Comissão de Estudos Cons-

titucionais a que caberia elaborar estudos e anteprojeto de Constituição a ser enviado, como mera colaboração, à Constituinte.

Sua morte, antes de assumir a Presidência, comoveu o Brasil inteiro. Foi chorado. O povo sentiu que suas esperanças eram outra vez levadas para o além. Assumiu o Vice-Presidente, José Sarney, que sempre esteve ao lado das forças autoritárias e retrógradas. Contudo, deu sequência às promessas de Tancredo Neves. Nomeou, não com boa vontade, a Comissão referida, que começou seus trabalhos sob intensa crítica da esquerda. Por muito tempo, a Comissão foi o único foro de debates sobre os temas constituintes e constitucionais. Logo que seu anteprojeto se delineara, viu-se que era estudo sério e progressista. Era a vez de a direita e de os Conservadores agredirem-na, e o fizeram com virulência.

Enquanto isso, o Presidente José Sarney, cumprindo mais uma etapa dos compromissos da transição, enviou ao Congresso Nacional proposta de emenda constitucional convocando a Assembleia Nacional Constituinte. Aprovada como EC n. 26 (promulgada em 27.11.85), em verdade, convocara os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para se reunirem, em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1.2.87, na sede do Congresso Nacional. Dispôs, ainda, que seria instalada sob a Presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, que também dirigiria a sessão de eleição do seu Presidente. Finalmente, estabeleceu que a Constituição seria promulgada depois da aprovação de seu texto, em dois turnos de discussão e votação, pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Nacional Constituinte. Assim se fez. Mas ao convocar os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a rigor, o que se fez foi convocar, não uma Assembleia Nacional Constituinte, mas um Congresso Constituinte. Deve-se, no entanto, reconhecer que a Constituição por ele produzida constitui um texto razoavelmente avançado. É um texto moderno, com inovações de relevante importância para o constitucionalismo brasileiro e até mundial. Bem examinada, a *Constituição Federal*, de 1988, constitui, hoje, um documento de grande importância para o constitucionalismo em geral.

Sua estrutura difere das constituições anteriores. Compreende nove títulos, que cuidam: (1) dos *princípios fundamentais*; (2) dos *direitos e garantias fundamentais*, segundo uma perspectiva moderna e abrangente dos *direitos individuais e coletivos*, dos *direitos sociais dos trabalhadores*, da *nacionalidade*, dos *direitos políticos* e dos *partidos políticos*; (3) da *organização do Estado*, em que estrutura a federação com seus componentes; (4) da *organização dos poderes*: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, com a manutenção do sistema presidencialista, derrotado o parlamentarismo, seguindo-se um ca-

29. Cf. nosso “Um sistema de equilíbrio”, *Jornal da Tarde*, de 8.12.84, p. 6.

pítulo sobre as *funções essenciais à Justiça*, com ministério público, advocacia pública (da União e dos Estados), advocacia privada e defensoria pública; (5) da *defesa do Estado e das instituições democráticas*, com mecanismos do estado de defesa, do estado de sítio e da segurança pública; (6) da *tributação e do orçamento*; (7) da *ordem econômica e financeira*; (8) da *ordem social*; (9) das *disposições gerais*. Finalmente, vem o *Ato das Disposições Transitórias*. Esse conteúdo distribui-se por 245 artigos na parte permanente, e mais 73 artigos na parte transitória, reunidos em capítulos, seções e subseções.

É a *Constituição Cidadã*, na expressão de Ulysses Guimarães, Presidente da Assembleia Nacional Constituinte que a produziu, porque teve ampla participação popular em sua elaboração e especialmente porque se volta decididamente para a plena realização da cidadania.

23. O plebiscito, a revisão e emendas constitucionais

A Constituição preordenou dois dispositivos, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que geram controvérsia e debates. Um foi o art. 2º, que determinou que no dia 7.9.93 o eleitorado definiria, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que deveriam vigorar no País. A data, como vimos, foi antecipada para 21.4.93 pela EC-2/92. O plebiscito teve lugar nessa data, com expressiva maioria a favor da República Presidencialista. O outro dispositivo foi o art. 3º, prevendo a realização de revisão constitucional após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. A revisão já se realizou, sem êxito. Só conseguiu seis alterações constitucionais, mediante o que se chamou de *Emendas Constitucionais de Revisão* (ECR).

Como se nota, a revisão constitucional foi um verdadeiro e retumbante fracasso, apesar de as elites brasileiras, com todos os meios de comunicação social, se empenharem muito para sua realização. Acontece que o povo percebeu que esse empenho visava a retirar da Carta Magna conquistas populares que foram o resultado de longas e penosas lutas. O povo não se sensibilizou pela revisão, daí o seu rotundo fracasso. Contudo, o desejo dessas elites vem se realizando por meio de um processo de reforma constitucional mediante emendas nos termos do art. 60. Já são 42, que, acrescidas das seis de revisão, perfazem um total de quarenta e oito alterações. Todas elas, incorporadas ao texto original, serão objeto de consideração, nos lugares próprios, neste volume.

Título II

Dos Princípios Fundamentais

Capítulo I

DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

1. Princípios e normas. 2. Os princípios constitucionais positivos. 3. Conceito e conteúdo dos princípios fundamentais. 4. Princípios fundamentais e princípios gerais do Direito Constitucional. 5. Função e relevância dos princípios fundamentais.

1. Princípios e normas

A palavra *princípio* é equívoca. Aparece com sentidos diversos. Apresenta a acepção de *começo*, de *início*. *Norma de princípio* (ou *disposição de princípio*),¹ por exemplo, significa norma que contém o início ou esquema de um órgão, entidade ou de programa, como são as *normas de princípio institutivo* e as *de princípio programático*.² Não é nesse sentido que se acha a palavra *princípios* da expressão *princípios fundamentais* do Título I da Constituição. *Princípio* aí exprime a noção de “mandamento nuclear de um sistema”.³

As *normas* são preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, ou seja, reconhecem, por um lado, a pessoas ou a entidades a faculdade de realizar certos interesses por ato próprio ou exigindo ação ou abstenção de outrem, e, por outro lado, vinculam pessoas ou entidades à obrigação de submeter-se às exigências de realizar uma prestação, ação ou abstenção em favor de outrem.

1. V., a propósito, Vezio Crisafulli, *La costituzione e le sue disposizioni di principio*, p. 27.

2. Cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, pp. 107 e ss.

3. Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello, “Criação de secretarias municipais”, RDP, n. 15, jan/mar 1971 e *Curso de direito administrativo*, pp. 450 e 451, onde define o *princípio jurídico* como: “mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico”.

Os *princípios* são ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de normas, são [como observam Gomes Canotilho e Vital Moreira] ‘núcleos de condensações’ nos quais confluem *valores e bens* constitucionais”. Mas, como disseram os mesmos autores, “os princípios, que começam por ser a base de *normas jurídicas*, podem estar positivamente incorporados, transformando-se em normas-princípio e constituindo preceitos básicos da organização constitucional.”⁴

Há, no entanto, quem concebe *regras e princípios* como espécies de *norma*, de modo que a distinção entre regras e princípios constitui uma distinção entre duas espécies de normas.⁵ A compreensão dessa doutrina exige conceituação precisa de *normas* e *regras*, inclusive para estabelecer a distinção entre ambas, o que os expositores da doutrina não têm feito, deixando assim obscuro seu ensinamento. Esse manual não comporta entrar a fundo nessa questão, razão por que nos contentamos com a singela distinção apresentada acima entre normas e princípios.

2. Os princípios constitucionais positivos

Quer-se aqui apenas caracterizar os princípios que se traduzem em normas da Constituição ou que delas diretamente se inferem. Não precisamos entrar, neste momento, nas graves discussões sobre a tipologia desses princípios.⁶ A doutrina reconhece que não são homogêneos e revestem natureza ou configuração diferente.⁷

A partir daí, podemos resumir, com base em Gomes Canotilho,⁸ que os *princípios constitucionais* são basicamente de duas categorias:

4. *Fundamentos da Constituição*, p. 49. Observe-se que *normas-princípio* significam *normas-matriz*. Não se confundem com a outra noção lembrada de *normas de princípio*.

5. Cf. J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional*, p. 172. Contudo, em outra obra, escrita em parceria com Vital Moreira, com edição do mesmo ano, a doutrina é diversa. Nela se afirma que a norma se distingue do princípio porque contém uma regra, instrução, ou imposição imediatamente vinculante para certo tipo de questões (cf. *Fundamentos da Constituição*, p. 49). Vale dizer, então, que a distinção é feita entre princípios e normas, e estas diferem daqueles porque contém uma regra.

6. Para uma ampla consideração sobre o assunto, cf. Gomes Canotilho, *Direito constitucional*, pp. 171 e ss., em geral, e depois com mais pormenores, sobre os *princípios do Estado de Direito Democrático*, pp. 352 e ss.; igualmente, *Constituição dirigente e vinculação do legislador*, pp. 279 e ss.; e, ainda, do mesmo autor em co-autoria com Vital Moreira, *Constituição da República Portuguesa anotada*, pp. 47 e ss.; Jorge Miranda, *Manual de Direito Constitucional*, t. II/195 e ss. A leitura desses autores portugueses é muito importante para a boa compreensão de nossa própria Constituição, que sofreu, como dissemos, profunda influência da Constituição da República Portuguesa de 1976.

7. Cf. Jorge Miranda, *ob. cit.*, p. 200.

8. *Ob. cit.*, pp. 177 e ss.

os *princípios político-constitucionais* e os *princípios jurídico-constitucionais*.

Princípios político-constitucionais — Constituem-se daquelas decisões políticas fundamentais concretizadas em normas conformadoras do sistema constitucional positivo, e são, segundo Crisafulli, *normas-princípio*, isto é, “normas fundamentais de que derivam logicamente (e em que, portanto, já se manifestam implicitamente) as normas particulares regulando imediatamente relações específicas da vida social”.⁹ Manifestam-se como *princípios constitucionais fundamentais*, positivados em *normas-princípio* que “traduzem as opções políticas fundamentais conformadoras da Constituição”, segundo Gomes Canotilho,¹⁰ ou, de outro quadrante, são decisões políticas fundamentais sobre a particular forma de existência política da nação, na concepção de Carl Schmitt.¹¹ São esses princípios fundamentais que constituem a matéria dos arts. 1º a 4º do Título I da Constituição, cujo conteúdo geral veremos mais abaixo.

Princípios jurídico-constitucionais — São *princípios constitucionais gerais* informadores da ordem jurídica nacional. Decorrem de certas normas constitucionais e, não raro, constituem desdobramentos (ou princípios derivados) dos fundamentais, como o princípio da supremacia da constituição e o conseqüente princípio da constitucionalidade, o princípio da legalidade, o princípio da isonomia, o princípio da autonomia individual, decorrente da declaração dos direitos, o da proteção social dos trabalhadores, fluente de declaração dos direitos sociais, o da proteção da família, do ensino e da cultura, o da independência da magistratura, o da autonomia municipal, os da organização e representação partidária, e os chamados princípios-garantias (o do *nullum crimen sine lege* e da *nulla poena sine lege*, o do devido processo legal, o do juiz natural, o do contraditório entre outros, que figuram nos incs. XXXVIII a LX do art. 5º),¹² os quais serão destacados e examinados nos momentos apropriados.

3. Conceito e conteúdo dos princípios fundamentais

Os *princípios constitucionais fundamentais*, pelo visto, são de natureza variada. Não será fácil, pois, fixar-lhes um conceito preciso em

9. Cf. *ob. cit.*, p. 38.

10. Cf. J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, *Fundamentos da Constituição*, p. 50. Cf., também, *Direito constitucional*, p. 178, no qual Gomes Canotilho lembra que os *princípios politicamente conformadores* são *princípios constitucionais que explicitam as valorações políticas fundamentais do Constituinte*.

11. Cf. *Teoría de la constitución*, p. 24.

12. Cf., sobre essa temática, Gomes Canotilho, *Direito constitucional*, p. 179.

um enunciado sintético. Recorreremos, no entanto, mais uma vez, à expressiva lição de Gomes Canotilho e Vital Moreira, segundo a qual os "princípios fundamentais visam essencialmente definir e caracterizar a colectividade política e o Estado e enumerar as principais opções político-constitucionais". Relevam a sua importância capital no contexto da constituição e observam que os artigos que os consagram "constituem por assim dizer a síntese ou matriz de todas as restantes normas constitucionais, que àquelas podem ser directa ou indirectamente reconduzidas".¹³ No mesmo sentido, já nos tínhamos pronunciado antes, em monografia publicada em 1968, a propósito da lição de Crisafulli sobre as normas-princípio. Então, escrevemos que "mais adequado seria chamá-las de *normas fundamentais*, de que as normas particulares são mero desdobramento analítico", e demos como exemplo as normas dos arts. 1º a 6º da Constituição de 1969.¹⁴

Para Gomes Canotilho, constituem-se dos *princípios definidores da forma de Estado*, dos *princípios definidores da estrutura do Estado*, dos *princípios estruturantes do regime político* e dos *princípios caracterizadores da forma de governo* e da *organização política em geral*.¹⁵

A análise dos princípios fundamentais da Constituição de 1988 nos leva à seguinte discriminação:

(a) princípios relativos à existência, forma, estrutura e tipo de Estado: *República Federativa do Brasil*, *soberania*, *Estado Democrático de Direito* (art. 1º);

(b) princípios relativos à forma de governo e à organização dos poderes: *República* e *separação dos poderes* (arts. 1º e 2º);

(c) princípios relativos à organização da sociedade: *princípio da livre organização social*, *princípio de convivência justa* e *princípio da solidariedade* (art. 3º, I);

(d) princípios relativos ao regime político: *princípio da cidadania*, *princípio da dignidade da pessoa*, *princípio do pluralismo*, *princípio da soberania popular*, *princípio da representação política* e *princípio da participação popular direta* (art. 1º, parágrafo único);

(e) princípios relativos à prestação positiva do Estado: *princípio da independência e do desenvolvimento nacional* (art. 3º, II), *princípio da justiça social* (art. 3º, III) e *princípio da não discriminação* (art. 3º, IV);

(f) princípios relativos à comunidade internacional: *da independência nacional*, *do respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana*,

13. Ob. cit., p. 66.

14. Cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 108, cuja 1ª ed. é de 1968.

15. Cf. *Direito Constitucional*, p. 178.

da autodeterminação dos povos, *da não-intervenção*, *da igualdade dos Estados*, *da solução pacífica dos conflitos* e *da defesa da paz*, *do repúdio ao terrorismo e ao racismo*, *da cooperação entre os povos* e *o da integração da América Latina* (art. 4º).

4. Princípios fundamentais e princípios gerais do Direito Constitucional

Temos que distinguir entre princípios constitucionais fundamentais e princípios gerais do Direito Constitucional. Vimos já que os primeiros integram o Direito Constitucional positivo, traduzindo-se em normas fundamentais, normas-síntese ou normas-matriz, "que explicitam as valorações políticas fundamentais do legislador constituinte",¹⁶ normas que contêm as decisões políticas fundamentais que o constituinte acolheu no documento constitucional. Os princípios gerais formam temas de uma teoria geral do Direito Constitucional, por envolver conceitos gerais, relações, objetos, que podem ter seu estudo destacado da dogmática jurídico-constitucional.

A ciência do direito constitucional [diz Pinto Ferreira] induz da realidade histórico-social os lineamentos básicos, os grandes *princípios constitucionais*, que servem de base à estruturação do Estado. Os princípios essenciais assim estabelecidos são os *summa genera* do direito constitucional, fórmulas básicas ou postos-chaves de interpretação e construção teórica do constitucionalismo, e daí se justifica a atenção desenvolvida pelos juristas na sua descoberta e elucidação. Eles podem ser reduzidos a um grupo de princípios gerais, nos quais se subsumem os princípios derivados, de importância secundária".¹⁷

Os temas que discutimos no Título I são integrados por conceitos e princípios gerais, como a classificação das constituições, o princípio da rigidez constitucional, o da supremacia da constituição, os referentes ao poder constituinte e ao poder de reforma constitucional etc., que são temas do chamado Direito Constitucional geral. É certo, contudo, que tais princípios se cruzam, com frequência, com os princípios fundamentais, na medida em que estes possam ser positivamente daqueles.

5. Função e relevância dos princípios fundamentais

Jorge Miranda ressalta a *função ordenadora* dos princípios fundamentais, bem como sua ação imediata, enquanto diretamente aplicá-

16. Cf. Gomes Canotilho, *Direito constitucional*, p. 178.

17. Cf. *Princípios gerais do direito constitucional moderno*, v. II/16.

veis ou diretamente capazes de conformarem as relações político-constitucionais, aditando, ainda, que a “ação imediata dos princípios consiste, em primeiro lugar, em funcionarem como critério de interpretação e de integração, pois são eles que dão coerência geral ao sistema”.¹⁸ Isso é certo.

Temos, no entanto, que fazer algumas distinções, por reconhecermos que as normas que integram os princípios fundamentais têm relevância jurídica diversa, e aqui valemo-nos, outra vez, do ensinamento de Gomes Canotilho e Vital Moreira. Algumas são *normas-síntese* ou *normas-matriz* cuja relevância consiste essencialmente na integração das normas de que são súmulas, ou que as desenvolvem,¹⁹ mas têm eficácia plena e aplicabilidade imediata,²⁰ como as que contêm os princípios da soberania popular e da separação de poderes (arts. 1º, parágrafo único, e 2º). A expressão “República Federativa do Brasil” é, em si, uma declaração normativa, que sintetiza as formas de Estado e de governo, sem relação predicativa ou de imputabilidade explícita, mas vale tanto quanto afirmar que o “Brasil é uma República Federativa”. É uma norma implícita, e norma-síntese e matriz de ampla normatividade constitucional. A afirmativa de que a “República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito” não é uma mera promessa de organizar esse tipo de Estado, mas a proclamação de que a Constituição está fundando um novo tipo de Estado, e, para que não se atenha a isso apenas em sentido formal, indicam-se-lhe objetivos concretos, embora de sentido teleológico,²¹ que mais valem por explicitar conteúdos que tal tipo de Estado já contém, como discutiremos mais adiante. Outras normas dos princípios fundamentais são indicativas dos fins do Estado,²² como a do inc. III do art. 3º. Outras são definições precisas de comportamento do Brasil como pessoa jurídica de Direito internacional, como as que integram o art. 4º.

Capítulo II

DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO BRASILEIRO

I. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: 1. O País e o Estado brasileiros. 2. Território e forma de Estado. 3. Estado Federal: forma do Estado brasileiro. 4. Forma de Governo: a República. 5. Fundamentos do Estado brasileiro. 6. Objetivos fundamentais do Estado brasileiro. II. PODER E DIVISÃO DE PODERES: 7. O princípio da divisão de poderes. 8. Poder político. 9. Governo e distinção de funções do poder. 10. Divisão de poderes. 11. Independência e harmonia entre os poderes. 12. Exceções ao princípio. III. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: 13. Democracia e Estado de Direito. 14. Estado de Direito. 15. Estado Social de Direito. 16. O Estado Democrático. 17. Caracterização do Estado Democrático de Direito. 18. A lei no Estado Democrático de Direito. 19. Princípios e tarefa do Estado Democrático de Direito.

I. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1. O País e o Estado brasileiros

País é palavra que se refere aos aspectos físicos, ao *habitat*, ao torrão natal, à *paisagem* territorial. O termo *país* (de *pagus*, pagos) manifesta a unidade geográfica, histórica, econômica e cultural das terras ocupadas pelos brasileiros.¹ O nome do país pode ou não coincidir com o nome do respectivo Estado: *Espanha* (nome de país e de Estado); *Portugal* (país), *República Portuguesa* (nome do Estado); *Estados Unidos da América do Norte* (nome do Estado e do país). Por outro lado, mesmo quando não haja coincidência, não raro se utiliza o nome do país para indicar o Estado. Pois bem, ao *país* brasileiro chamou-se, inicialmente, Monte Pascoal, Terra de Santa Cruz e, por fim, *Brasil* (terra do pau cor de brasa).

Estado é, na justa definição de Balladore Pallieri, uma *ordenação* que tem por *fin* específico e essencial a regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma dada *população* sobre um *dado território*,² na qual a palavra *ordenação* expressa a idéia de poder

18. Cf. *Manual de Direito constitucional*, t. II/199.

19. Cf. *Fundamentos da Constituição*, p. 72.

20. Sobre essa temática, cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, 1982.

21. Nas edições anteriores, estava “embora programáticas”, que agora substituímos por “embora de sentido teleológico”, porque o termo “programático” não exprime com rigor o sentido dessas normas e porque se trata de expressão comprometida com teorias ultrapassadas que viam na Constituição normas sem valor jurídico que davam aquela denominação.

22. Também aqui se usava antes “programáticas”, substituída por “indicativas dos fins do Estado”.

1. Sobre a noção de *país*, cf. Juan Ferrando Badía, *El Estado unitario, el federal y el Estado autonómico*, pp. 158 e ss.

2. Cf. *Diritto costituzionale*, p. 14.

soberano, institucionalizado. O *Estado*, como se nota, constitui-se de quatro elementos essenciais: um *poder soberano* de um *povo* situado num *território* com certas *finalidades*. E a *constituição*, como dissemos antes, é o conjunto de normas que organizam estes elementos constitutivos do Estado: *povo, território, poder e fins*.

Uma coletividade territorial, pois, só adquire a qualificação de Estado, quando conquista sua capacidade de autodeterminação, com a independência em relação a outros Estados. Foi o que se deu com o Estado brasileiro, proclamado independente em 1822, assumindo a condição de ente com poder soberano num território de mais de oito milhões e meio de quilômetros quadrados, com população superior a cento e setenta milhões de pessoas, com os fundamentos, objetivos (finalidades) e estrutura previstos nos arts. 1º, 2º e 3º da Constituição, que analisaremos no correr deste curso.

República Federativa do Brasil condensa o nome do Estado brasileiro — República Federativa do Brasil —, o nome do país — *Brasil* —, a forma de Estado, mediante o qualificativo *Federativa*, que indica tratar-se de Estado Federal, e a forma de governo — *República*. *Pátria* é termo que exprime sentimentos cívicos (*Pátria*: terra dos pais, terra que amamos; "*Patria est ubicumque est bene*", *Pátria* é o lugar onde se sente bem).

2. Território e forma de Estado

Território é o limite espacial dentro do qual o Estado exerce de modo efetivo e exclusivo o poder de império sobre pessoas e bens.³ Ou, como expressa Kelsen: é o âmbito de validade da ordenação jurídica chamada Estado.⁴

Forma de Estado. O modo de exercício do poder político em função do território dá origem ao conceito de *forma de Estado*.⁵ Se existe unidade de poder sobre o território, pessoas e bens, tem-se *Estado unitário*. Se, ao contrário, o poder se reparte, se divide, no espaço territorial (divisão espacial de poderes), gerando uma multiplicidade de organizações governamentais, distribuídas regionalmente, en-

contramo-nos diante de uma *forma de Estado composto*, denominado *Estado federal* ou *Federação de Estados*.

A repartição regional de poderes autônomos constitui o cerne do conceito de Estado federal. Nisso é que ele se distingue da *forma de Estado unitário* (França, Chile, Uruguai, Paraguai e outros), que não possui senão um centro de poder que se estende por todo o território e sobre toda a população e controla todas as coletividades regionais e locais. É certo que o *Estado unitário* pode ser descentralizado e, geralmente, o é, mas essa descentralização, por ampla que seja, não é de tipo federativo, como nas federações, mas de tipo autárquico, gerando uma forma de *autarquia territorial* no máximo, e não uma *autonomia político-constitucional*, e nele as coletividades internas ficam na dependência do poder unitário, nacional e central. É certo, também, que, entre o Estado federal e o unitário, vem-se desenvolvendo outra forma de Estado: o *Estado regional* ou *Estado autônomo* (Itália, Espanha).⁶

3. Estado Federal: forma do Estado brasileiro

O *federalismo*, como expressão do Direito Constitucional, nasceu com a Constituição norte-americana de 1787. Baseia-se na união de coletividades políticas autônomas. Quando se fala em federalismo, em Direito Constitucional, quer-se referir a uma *forma de Estado*, denominada *federação* ou *Estado federal*, caracterizada pela união de coletividades públicas dotadas de autonomia político-constitucional, autonomia federativa.

O Brasil, como vimos, assumiu a *forma de Estado federal*, em 1889, com a proclamação da República, o que foi mantido nas constituições posteriores, embora o federalismo da Constituição de 1967 e de sua Emenda 1/69 tenha sido apenas *nominal*. A Constituição de 1988 recebeu-a da evolução histórica do ordenamento jurídico. Ela não instituiu a federação. Manteve-a mediante a declaração, constante do art. 1º, que configura o Brasil como uma *República Federativa*. Vale afirmar que a *forma do Estado brasileiro* é a *federal*, cujas características e conteúdo serão objeto de consideração mais ampla, quando formos estudar a *organização do Estado*, conforme os arts. 18 a 43. Agora, releva apenas lembrar os princípios fundamentais relativos ao Estado federal.

A *federação* consiste na *união* de coletividades regionais autônomas que a doutrina chama de *Estados federados* (nome adotado pela

3. Cf. Alexandre Groppali, *Doutrina do Estado*, p. 140. Oskar Georg Fischbach, *Teoría general del Estado*, p. 108; A. de Lyra Tavares, *Território nacional*, p. 15.

4. Cf. *Teoría general del derecho y del Estado*, p. 247.

5. Cumpre observar que o conceito de forma de Estado aqui é o estrutural, como se vê do texto. Fala-se em forma de Estado em outros sentidos, que, em verdade, são tipos históricos de Estado: *Estado patrimonial*, *Estado de polícia* e *Estado de direito*, ou forma de regime político: *Estado de democracia clássica*, *Estado autoritário* e *Estado de democracia progressiva* ou *marxista*. Sobre o tema, cf. Paolo Biscaretti di Ruffia, *Diritto costituzionale*, pp. 177 e ss.

6. Cf. Juan Ferrando Badía, *ob. cit.*, e "*Teoría y realidad del Estado autonómico*", separata da *Revista de Política Comparada*, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, n. III, 1980-1981.

Constituição, cap. III do tit. III), *Estados-membros* ou simplesmente *Estados* (muito usado na Constituição).⁷ Veremos que, nessa composição, às vezes, entram outros elementos, como os *Territórios Federais* e o *Distrito Federal*, e, no sistema brasileiro, há que destacar-se ainda os Municípios, agora também incluídos na estrutura político-administrativa da Federação brasileira (arts. 1º e 18). O cerne do conceito de Estado federal está na configuração de dois tipos de entidades: a *União* e as coletividades regionais autônomas (*Estados federados*).⁸

Estado federal é o todo, dotado de personalidade jurídica de Direito Público internacional. A *União* é a entidade federal formada pela reunião das partes componentes, constituindo pessoa jurídica de Direito Público interno, autônoma em relação aos Estados e a que cabe exercer as prerrogativas da soberania do Estado brasileiro. Os *Estados-membros* são entidades federativas componentes, dotadas de autonomia e também de personalidade jurídica de Direito Público interno. A posição dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios será examinada depois.

No Estado federal há que distinguir *soberania* e *autonomia* e seus respectivos titulares. Houve muita discussão sobre a natureza jurídica do Estado federal,⁹ mas, hoje, já está definido que o Estado federal, o todo, como pessoa reconhecida pelo Direito internacional, é o único titular da soberania, considerada *poder supremo consistente na capacidade de autodeterminação*. Os Estados federados são titulares tão-só de autonomia, compreendida como *governo próprio dentro do círculo de competências traçadas pela Constituição Federal*.

A *autonomia federativa* assenta-se em dois elementos básicos: (a) na existência de *órgãos governamentais próprios*, isto é, que não dependam dos órgãos federais quanto à forma de seleção e investidura; (b) na *posse de competências exclusivas*, um mínimo, ao menos, que não seja ridiculamente reduzido. Esses pressupostos da autonomia federativa estão configurados na Constituição (arts. 18 a 42).

A *repartição de competências* entre a União e os Estados-membros constitui o fulcro do Estado Federal, e dá origem a uma estrutura esta-

tal complexa, que apresenta, a um tempo, aspectos unitário e federativo. É *unitário*, enquanto possui *um único território* que, embora dividido entre os Estados-membros, está submetido ao poder da União no exercício da competência federal, e ainda *uma só população*, formando um único corpo nacional, enquanto regida pela constituição e legislação federais. É *federativo* (associativo), enquanto cabe aos Estados-membros participar na formação da vontade dos órgãos federais (especialmente no Senado Federal, que se compõe de representantes dos Estados, art. 46 da Constituição, e também pela participação das Assembléias Legislativas estaduais no processo de formação das emendas constitucionais, art. 60, III) e enquanto lhes é conferida competência para dispor sobre as matérias que lhes reserva a Constituição Federal, com incidência nos respectivos territórios e populações. Com isso constituem-se no Estado federal duas esferas governamentais sobre a mesma população e o mesmo território: a da União e a de cada Estado-membro. No Brasil, ainda há a esfera governamental dos Municípios.

Mas o Estado federal é considerado uma unidade nas relações internacionais.

Apresenta-se, pois, como *um Estado que, embora aparecendo único nas relações internacionais, é constituído por Estados-membros dotados de autonomia, notadamente quanto ao exercício de capacidade normativa sobre matérias reservadas à sua competência*.¹⁰ O Estado federal brasileiro está constitucionalmente concebido como a união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal (art. 1º). Foi equívoco do constituinte incluir os Municípios como componente da federação. Município é divisão política do Estado-membro. E agora temos uma federação de Municípios e Estados, ou uma federação de Estados? Faltam outros elementos para a caracterização de federação de Municípios. A solução é: o Município é um componente da federação, mas não entidade federativa. O texto constitucional, contudo, explicita um princípio fundamental do Estado federal: *o princípio da indissociabilidade*. Ele integra o conceito de federação. Não precisava ser expresso, mas alguns constituintes não sossegaram enquanto não viram o texto expresso, enxundiando e afeiando o art. 1º, sem nada acrescentar, até porque o art. 18 já indica quais os componentes da federação, que são aqueles mesmos indicados no art. 1º: Estados, Municípios e Distrito Federal.

Os limites da repartição de poderes dependem da natureza e do tipo histórico de federação. Numa descentralização é mais acentuada, dando-se aos Estados-membros competências mais amplas,

7. Essas coletividades denominam-se *Estados* no Brasil, Estados Unidos, México e Venezuela; *Provincias*, na Argentina; *Cantões*, na Suíça; *Repúblicas*, na antiga União Soviética; *Länders*, na Alemanha.

8. Sobre o assunto, e sobre o princípio federativo, cf. Cármen Lúcia Antunes Rocha, *República e Federação no Brasil*, pp. 171 e ss.

9. Cf. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, *Natureza jurídica do Estado federal*, Publicação da Prefeitura do Município de São Paulo (nova impressão), 1948, e bibliografia ali citada; José Alfredo de Oliveira Baracho, *Teoria Geral do Federalismo*, especialmente pp. 35 e ss.; Juan Ferrando Badía, *El Estado unitario, el federal y el Estado autonómico*, pp. 92 e ss.

10. Cf. Charles Durand, "El Estado federal en el Derecho positivo", in Gaston Berger e outros, *El federalismo*, p. 190.

como nos Estados Unidos da América do Norte. Noutras, a área de competência da União é mais dilatada, restando reduzido campo de atuação aos Estados, como o Brasil no regime da Constituição de 1967-1969, que construiu mero federalismo nominal. A Constituição de 1988 buscou resgatar o princípio federalista e estruturou um sistema de repartição de competências que tenta refazer o equilíbrio das relações entre o poder central e os poderes estaduais e municipais. As federações de formação centrípeta costumam ser mais descentralizadas e as de formação centrífuga, menos.

4. Forma de Governo: a República

Conceito — O termo *República* tem sido empregado no sentido de forma de governo contraposta à monarquia. No entanto, no dispositivo em exame, ele significa mais do que isso. Talvez fosse melhor até considerar República e Monarquia não simples formas de governo, mas *formas institucionais do Estado*. Aqui ele se refere, sim, a uma determinada *forma de governo*, mas é, especialmente, designativo de uma coletividade política com características da *res publica*, no seu sentido originário de coisa pública, ou seja: coisa do *povo* e para o *povo*,¹¹ que se opõe a toda forma de tirania, posto que, onde está o tirano, não só é viciosa a organização, como também se pode afirmar que não existe espécie alguma de República.¹²

Forma de governo, assim, é conceito que se refere à maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados. Responde à questão de quem deve exercer o poder e como este se exerce.

Aristóteles concebeu três formas básicas de governo: a *monarquia*, governo de um só; a *aristocracia*, governo de mais de um, mas de poucos, e a *república*, governo em que o povo governa no interesse do povo.¹³

11. Cf. Cícero, *Da República*, III, §§ XXI e XXII. É de lembrar que *público* do latim *publicum*, quer dizer *do povo* (*populum* deu *populicum*, e daí, público). Lembra Jhering que *res publica*, como personalidade, na concepção do Estado da época posterior à sociedade gentílica, implica, originariamente, o que é comum a todos: *res publicae* são as diversas coisas da sociedade pública, às quais todos têm igual direito. Cf. *L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement*, § 18, t. I/212.

12. Cf. Cícero, *Da República*, III, §§ XXI e XXII.

13. Cf. *Política*, III, 5, 1279b. Alguns autores mencionam esta última como *democracia*; pareceu-nos mais correto chamá-la de *república*, que é a forma que se contrapõe à monarquia e também à aristocracia ainda nos nossos dias. Ademais, seria o equivalente mais próximo da tradução literal do grego *Politia* ou *Politéia*, que não têm correspondentes na língua portuguesa e também porque *democracia*, para Aristóteles, seria o desvio do governo da maioria. Cf., neste sentido, *Politique d'Aristote*, texto francês apresentado e anotado por Marcel Prélot, p. 86.

Essas três formas, adverte Aristóteles, podem degenerar-se: a monarquia, em *tiranía*; a aristocracia, em *oligarquia*; a república, em *democracia*.¹⁴ Essa doutrina prevaleceu até que Maquiavel declarou que todos os Estados, todos os domínios que exerceram e exercem poder sobre os homens, foram, e são, ou *repúblicas* ou principados.¹⁵ Daí por diante, tem prevalecido a classificação dualista de formas de governo em *república* e *monarquia*, ou governo republicano e governo monárquico. Aquele caracterizado pela eletividade periódica do chefe de Estado, e este por sua hereditariedade e vitaliciedade.

O princípio republicano — O art. 1º da Constituição não instaura a República. Recebe-a da evolução constitucional, desde 1889. Mantém-na como princípio fundamental da ordem constitucional. Desde a Constituição de 1891, a *forma republicana de governo* figura como princípio constitucional, hoje não mais protegido contra emenda constitucional, como nas constituições anteriores, já que a forma republicana não mais constitui núcleo imodificável por essa via; só a forma federativa continua a sê-lo (art. 60, § 4º, I). Mas o princípio é protegido *contra os Estados*, prevista a intervenção federal naquele que o desrespeitar (art. 34, VII, a).

O princípio republicano não deve ser encarado do ponto de vista puramente formal, como algo que vale por sua oposição à forma monárquica. Ruy Barbosa já dizia que o que discrimina a forma republicana não é apenas a coexistência dos três poderes, indispensáveis em todos os governos constitucionais, mas, sim, a condição de que, sobre existirem os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, os dois primeiros derivem, realmente, de eleições populares.¹⁶ Isso significa que a forma republicana implica a necessidade de legitimidade popular do Presidente da República, Governadores de Estado e Prefeitos Municipais (arts. 28, 29, I e II, e 77), a existência de assembleias e câmaras populares nas três órbitas de governos da República Federativa (arts. 27, 29, I, 44, 45 e 46), eleições periódicas por tempo limitado que se traduz na temporariedade dos mandatos eletivos (arts. cit.) e, conseqüentemente, não vitaliciedade dos cargos políti-

14. Cf. *Política*, III, 5, 1279b. Para Aristóteles, *democracia* seria, portanto, uma forma desviada de governo. Atualmente, no entanto, *democracia* é considerada como regime e não forma de governo. Por este motivo, em algumas edições, a forma desviada do governo da maioria é chamada de *demagogia*.

15. Cf. *Il principe*, p. 31: "Tutti gli stati, tutti e' dominii che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o republiche o principati. E' principati sono, o ereditarii, de' quali el sangue del loro signore ne sia suto lungo tempo principe, o é sono nuovio".

16. Cf. *Comentários à Constituição Federal brasileira*, v. I/165. Sobre o princípio republicano, cf. Cármen Lúcia Antunes Rocha, *ob. cit.*, pp. 91 e ss.

como base das prestações positivas que venham a concretizar a democracia econômica, social e cultural, a fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana.

II. PODER E DIVISÃO DE PODERES

7. O princípio da divisão de poderes

Esse é um princípio geral do Direito Constitucional que a Constituição inscreve como um dos princípios fundamentais que ela adota. Consta de seu art. 2º que *são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário*. Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário são expressões com duplo sentido.

Exprimem, a um tempo, as funções legislativa, executiva e jurisdicional e indicam os respectivos órgãos, conforme descrição e discriminação estabelecidas no título da *organização dos poderes* (respectivamente, nos arts. 44 a 75, 76 a 91 e 92 a 135).²²

Algumas considerações sobre o poder são necessárias para melhor compreensão do princípio.

8. Poder político

O *poder* é um fenômeno sócio-cultural. Quer isso dizer que é fato da vida social. Pertencer a um grupo social é reconhecer que ele *pode* exigir certos atos, uma conduta conforme com os fins perseguidos; é admitir que *pode* nos impor certos esforços custosos, certos sacrifícios; que *pode* fixar, aos nossos desejos, certos limites e prescrever, às nos-

22. O princípio da separação ou divisão de poderes foi sempre um princípio fundamental do ordenamento constitucional brasileiro. Recorde-se que a Constituição do Império adotara a separação quadripartita de poderes segundo a formulação de Benjamin Constant: *poderes Moderador, Legislativo, Executivo e Judiciário*. As demais constituições assumiram a formulação tripartita de Montesquieu. A Constituição de 1988 manteve o princípio com o enunciado um pouco diferente. O texto foi aprovado no segundo turno sem a cláusula *independentes e harmônicos entre si*, porque estava sendo adotado o parlamentarismo, que é um regime mais de colaboração entre poderes que de separação independente. Aquela cláusula é adequada e conveniente no presidencialismo. Como, no final, este é que prevaleceu, na Comissão de Redação o Prof. e então Dep. Michel Temer sugeriu a reinserção da regra da harmonia e independência que figura no art. 2º, sem porém indicar as ressalvas ao princípio que sempre constavam nas constituições anteriores, do teor seguinte: "Salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições; quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro". Ressalva desnecessária.

sas atividades, certas formas.²³ Tal é o *poder* inerente ao grupo, que se pode definir como *uma energia capaz de coordenar e impor decisões visando à realização de determinados fins*.

O Estado, como grupo social máximo e total, tem também o seu poder, que é o *poder político* ou *poder estatal*. A sociedade estatal, chamada também sociedade civil, compreende uma multiplicidade de grupos sociais diferenciados e indivíduos, aos quais o poder político tem que coordenar e impor regras e limites em função dos fins globais que ao Estado cumpre realizar. Daí se vê que o poder político é superior a todos os outros poderes sociais, os quais reconhece, rege e domina, visando a ordenar as relações entre esses grupos e os indivíduos entre si e reciprocamente, de maneira a manter um mínimo de ordem e estimular um máximo de progresso à vista do bem comum. Essa superioridade do poder político caracteriza a *soberania do Estado* (conceituada antes), que implica, a um tempo, *independência* em confronto com todos os poderes exteriores à sociedade estatal (soberania externa) e *supremacia* sobre todos os poderes sociais interiores à mesma sociedade estatal²⁴ (soberania interna).

Disso decorrem as três características fundamentais do poder político: *unidade, indivisibilidade e indelegabilidade*, de onde parecer impróprio falar-se em *divisão* e *delegação de poderes*, o que fica esclarecido com as considerações que seguem.

9. Governo e distinção de funções do poder

O Estado, como estrutura social, carece de vontade real e própria. Manifesta-se por seus *órgãos* que não exprimem senão vontade exclusivamente humana. Os órgãos do Estado são *supremos* (constitucionais) ou *dependentes* (administrativos). Aqueles são os a quem incumbe o exercício do poder político, cujo conjunto se denomina *governo* ou *órgãos governamentais*. Os outros estão em plano hierárquico inferior, cujo conjunto forma a Administração Pública, considerados de natureza administrativa. Enquanto os primeiros constituem objeto do Direito Constitucional, os segundos são regidos pelas normas do Direito Administrativo. E aí se acha o cerne da diferenciação entre os dois ramos do Direito.

23. Cf. Jean-William Lapierre, *Le pouvoir politique*, p. 5.

24. Cf. Jean-William Lapierre, *ob. cit.*, pp. 62 e 63; German José Bidart Campos, *Derecho político*, pp. 324 e ss.; Paulo Bonavides, *Teoria do Estado*, pp. 61 e ss.; Marcello Caetano, *ob. cit.*, p. 167, para quem o *poder político* "é a *faculdade exercida por um povo de, por autoridade própria (não recebida de outro poder), instituir órgãos que exerçam o senhorio de um território e nele criem e imponham normas jurídicas, dispondo dos necessários meios de coação*", e para quem a *soberania* (*majestas, summum imperium*) significa *um poder político supremo e independente* (p. 169).

O governo é, então, o conjunto de órgãos mediante os quais a vontade do Estado é formulada, expressada e realizada, ou o conjunto de órgãos supremos a quem incumbe o exercício das *funções do poder político*.²⁵ Este se manifesta mediante suas *funções* que são exercidas e cumpridas pelos órgãos de governo. Vale dizer, portanto, que o poder político, *uno, indivisível e indelegável*, se desdobra e se compõe de *várias funções*, fato que permite falar em *distinção das funções*, que fundamentalmente são três: a *legislativa*, a *executiva* e a *jurisdicional*.

A *função legislativa* consiste na edição de regras gerais, abstratas, impessoais e inovadoras da ordem jurídica, denominadas *leis*. A *função executiva* resolve os problemas concretos e individualizados, de acordo com as leis; não se limita à simples *execução das leis*, como às vezes se diz; comporta prerrogativas, e nela entram todos os atos e fatos jurídicos que não tenham caráter geral e impessoal; por isso, é cabível dizer que a função executiva se distingue em *função de governo*, com atribuições políticas, co-legislativas e de decisão, e *função administrativa*, com suas três missões básicas: *intervenção, fomento e serviço público*. A *função jurisdicional* tem por objeto aplicar o direito aos casos concretos a fim de dirimir conflitos de interesse.²⁶

10. Divisão de poderes

Cumprido, em primeiro lugar, não confundir *distinção de funções do poder* com *divisão ou separação de poderes*, embora entre ambas haja uma conexão necessária. A distinção de funções constitui especialização de tarefas governamentais à vista de sua natureza, sem considerar os órgãos que as exercem; quer dizer que existe sempre distinção de funções, quer haja órgãos especializados para cumprir cada uma delas, quer estejam concentradas num órgão apenas. A *divisão de poderes* consiste em confiar cada uma das funções governamentais (legislativa, executiva e jurisdicional) a órgãos diferentes, que tomam os nomes das respectivas funções, menos o Judiciário (órgão ou poder Legislativo, órgão ou poder Executivo e órgão ou poder Judiciário). Se as funções forem exercidas por um órgão apenas, tem-se *concentração de poderes*.

25. Em sentido estrito e habitual, considera-se *governo* apenas o órgão que exerce a *função executiva*, em oposição ao legislativo. Nos sistemas de governo parlamentar, reserva-se o termo *governo* para o poder executivo, que é exercido pelo Conselho de Ministros (cf. cap. III do tit. IV). Em sentido amplo e próprio, o conceito de governo é o oferecido no texto.

26. Cf. Maurice Duverger, *Droit constitutionnel et institutions politiques*, v. I/150 e ss.; German José Bidart Campos, *ob. cit.*, pp. 333 e ss.; Jorge Xifras Heras, *Curso de derecho constitucional*, t. II/126 e ss.

A *divisão de poderes* fundamenta-se, pois, em dois elementos: (a) *especialização funcional*, significando que cada órgão é especializado no exercício de uma função; assim, às assembleias (Congresso, Câmaras, Parlamento) se atribui a função Legislativa; ao Executivo, a função executiva; ao Judiciário, a função jurisdicional; (b) *independência orgânica*, significando que, além da especialização funcional, é necessário que cada órgão seja efetivamente independente dos outros, o que postula ausência de meios de subordinação. Trata-se, pois, como se vê, de uma forma de organização jurídica das manifestações do Poder.

O princípio da separação de poderes já se encontra sugerido em Aristóteles,²⁷ John Locke²⁸ e Rousseau,²⁹ que também conceberam uma doutrina da separação de poderes, que, afinal, em termos diversos, veio a ser definida e divulgada por Montesquieu.³⁰ Teve objetivação positiva nas Constituições das ex-colônias inglesas da América, concretizando-se em definitivo na Constituição dos Estados Unidos de 17.9.1787. Tornou-se, com a Revolução Francesa, um dogma constitucional, a ponto de o art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 declarar que não teria constituição a sociedade que não assegurasse a separação de poderes, tal a compreensão de que ela constituiu técnica de extrema relevância para a garantia dos Direitos do Homem, como ainda o é.

Hoje, o princípio não configura mais aquela rigidez de outrora. A ampliação das atividades do Estado contemporâneo impôs nova visão da teoria da separação de poderes e novas formas de relacionamento entre os órgãos legislativo e executivo e destes com o judiciário,³¹ tanto que atualmente se prefere falar em *colaboração de poderes*, que é característica do parlamentarismo, em que o governo depende da confiança do Parlamento (Câmara dos Deputados), enquanto, no presidencialismo, desenvolveram-se as técnicas da *independência orgânica e harmonia dos poderes*.

11. Independência e harmonia entre os poderes

A Constituição manteve a cláusula "independentes e harmônicos entre si", própria da divisão de poderes no presidencialismo, acrescentada, aliás, na Comissão de Redação.

27. Cf. *Política*, IV, 11, 1298a.

28. Cf. *Ensayo sobre el gobierno civil*, XII, §§ 143 a 148.

29. Cf. *Du contrat social*, III, 1.

30. Cf. *De l'esprit des lois*, XI, 5.

31. Cf. nosso *Princípios do processo de formação das leis no direito constitucional*, p. 34.

A *independência dos poderes* significa: (a) que a investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos do governo não dependem da confiança nem da vontade dos outros; (b) que, no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares consultar os outros nem necessitam de sua autorização; (c) que, na organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições constitucionais e legais; assim é que cabe ao Presidente da República prover e extinguir cargos públicos da Administração federal, bem como exonerar ou demitir seus ocupantes, enquanto é da competência do Congresso Nacional ou dos Tribunais prover os cargos dos respectivos serviços administrativos, exonerar ou demitir seus ocupantes; às Câmaras do Congresso e aos Tribunais compete elaborar os respectivos regimentos internos, em que se consubstanciam as regras de seu funcionamento, sua organização, direção e polícia, ao passo que ao Chefe do Executivo incumbe a organização da Administração pública, estabelecer seus regimentos e regulamentos. Agora, a independência e autonomia do Poder Judiciário se tornaram ainda mais pronunciadas, pois passou para a sua competência também a nomeação de juízes e tomar outras providências referentes à sua estrutura e funcionamento, inclusive em matéria orçamentária (arts. 95, 96 e 99).

A *harmonia entre os poderes* verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia no trato recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm direito. De outro lado, cabe assinalar que nem a divisão de funções entre os órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há interferências, que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um em detrimento do outro e especialmente dos governados.

Se ao Legislativo cabe a edição de *normas* gerais e impessoais, estabelece-se um processo para sua formação em que o Executivo tem participação importante, quer pela iniciativa das leis, quer pela sanção e pelo veto. Mas a iniciativa legislativa do Executivo é contrabalançada pela possibilidade que o Congresso tem de modificá-lhe o projeto por via de emendas e até de rejeitá-lo. Por outro lado, o Presidente da República tem o poder de veto, que pode exercer em relação a projetos de iniciativa dos congressistas como em relação às emendas aprovadas a projetos de sua iniciativa. Em compensação, o Congresso, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, poderá rejeitar o veto, e, pelo Presidente do Senado, promulgar a lei, se o Presidente da República não o fizer no prazo previsto (art. 66).

Se o Presidente da República não pode interferir nos trabalhos legislativos, para obter aprovação rápida de seus projetos, é-lhe, porém, facultado marcar prazo para sua apreciação, nos termos dos parágrafos do art. 64.

Se os Tribunais não podem influir no Legislativo, são autorizados a declarar a inconstitucionalidade das leis, não as aplicando neste caso.

O Presidente da República não interfere na função jurisdicional, em compensação os ministros dos tribunais superiores são por ele nomeados, sob controle do Senado Federal, a que cabe aprovar o nome escolhido (art. 52, III, a).

São esses alguns exemplos apenas do mecanismo dos freios e contrapesos, caracterizador da harmonia entre os poderes. Tudo isso demonstra que os trabalhos do Legislativo e do Executivo, especialmente, mas também do Judiciário, só se desenvolverão a bom termo, se esses órgãos se subordinarem ao princípio da harmonia, que não significa nem o domínio de um pelo outro nem a usurpação de atribuições, mas a verificação de que, entre eles, há de haver consciente colaboração e controle recíproco (que, aliás, integra o mecanismo), para evitar distorções e desmandos. A desarmonia, porém, se dá sempre que se acrescentam atribuições, faculdades e prerrogativas de um em detrimento de outro.

12. Exceções ao princípio

As constituições anteriores estabeleciam o princípio da divisão de poderes, especificando que era vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições, e quem fosse investido na função de um deles não poderia exercer a de outro, salvas as exceções nelas previstas. Essas especificações realmente são desnecessárias, até porque a Constituição, agora como antes, estabelece incompatibilidades relativamente ao exercício de funções dos poderes (art. 54), e porque os limites e exceções ao princípio decorrem de normas que comporta pesquisar no texto constitucional.

Exceção ao princípio é, por exemplo, a permissão de que Deputados e Senadores exerçam funções de Ministro de Estado, que é agente auxiliar do Presidente da República, Chefe do Executivo, bem como de Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Prefeitura de Capital ou de missão diplomática temporária (art. 56); também o é a regra do art. 50 que autoriza a convocação de Ministros de Estado perante o plenário das Casas do Congresso ou de suas comissões, bem como o seu comparecimento espontâneo para expor assunto relevante do seu

Ministério. As exceções mais marcantes, contudo, se acham na possibilidade de adoção pelo Presidente da República de *medidas provisórias*, com força de lei (art. 62), e na autorização de *delegação de atribuições legislativas* ao Presidente da República (art. 68).

III. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

13. Democracia e Estado de Direito

A *democracia*, como realização de valores (igualdade, liberdade e dignidade da pessoa) de convivência humana, é conceito mais abrangente do que o de *Estado de Direito*, que surgiu como expressão jurídica da democracia liberal. A superação do liberalismo colocou em debate a questão da sintonia entre o Estado de Direito e a sociedade democrática. A evolução desvendou sua insuficiência e produziu o conceito de Estado Social de Direito, nem sempre de conteúdo democrático. Chega-se agora ao *Estado Democrático de Direito* que a Constituição acolhe no art. 1º como um conceito-chave do regime adotado, tanto quanto o são o conceito de *Estado de Direito Democrático* da Constituição da República Portuguesa (art. 2º) e o de *Estado Social e Democrático de Direito* da Constituição Espanhola (art. 10).³²

O Estado Democrático de Direito reúne os princípios do Estado Democrático e do Estado de Direito, não como simples reunião formal dos respectivos elementos, porque, em verdade, revela um conceito novo que os supera, na medida em que incorpora um componente revolucionário de transformação do *status quo*. Para compreendê-lo, no entanto, teremos que passar em revista a evolução e as características de seus elementos componentes, para, no final, chegarmos ao conceito síntese e seu real significado.

14. Estado de Direito

Na origem, como é sabido, o *Estado de Direito* era um conceito tipicamente liberal; daí falar-se em Estado Liberal de Direito, cujas características básicas foram: (a) *submissão ao império da lei*, que era a nota primária de seu conceito, sendo a *lei* considerada como ato ema-

32. A propósito, cf. J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, *ob. cit.*, p. 62. A doutrina portuguesa, espanhola e alemã sobre o *Estado Democrático de Direito* já fornece uma configuração desse conceito que foi, por certo, o que influenciou a Constituinte a acolhê-la na nova Constituição. É por isso que, aqui, recorreremos, amiúde, a essa doutrina, a fim de defini-lo com a devida precisão, para que se compreenda que não se trata de mero conceito formal, mas de um conceito tendente à realização de uma democracia socialista.

nado formalmente do Poder Legislativo, composto de representantes do povo, mas do povo-cidadão; (b) *divisão de poderes*, que separe de forma independente e harmônica os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, como técnica que assegure a produção das leis ao primeiro e a independência e imparcialidade do último em face dos demais e das pressões dos poderosos particulares; (c) *enunciado e garantia dos direitos individuais*.³³ Essas exigências continuam a ser postulados básicos do Estado de Direito, que configura uma grande conquista da civilização liberal.

A concepção liberal do Estado de Direito servira de apoio aos direitos do homem, convertendo os súditos em cidadãos livres, consoante nota Verdú,³⁴ a qual, contudo, se tornara insuficiente, pelo que a expressão *Estado de Direito* evoluíra, enriquecendo-se com conteúdo novo.

Houve, porém, concepções deformadoras do conceito de Estado de Direito, pois é perceptível que seu significado depende da própria idéia que se tem do Direito. Por isso, cabe razão a Carl Schmitt quando assinala que a expressão “Estado de Direito” pode ter tantos significados distintos como a própria palavra “Direito” e designar tantas organizações quanto as a que se aplica a palavra “Estado”. Assim, acrescenta ele, há um Estado de Direito feudal, outro estamental, outro burguês, outro nacional, outro social, além de outros conformes com o Direito natural, com o Direito racional e com o Direito histórico.³⁵ Disso deriva a ambigüidade da expressão *Estado de Direito*, sem mais qualificativo que lhe indique conteúdo material. Em tal caso a tendência é adotar-se a concepção formal do Estado de Direito à maneira de Forsthoff,³⁶ ou de um *Estado de Justiça*, tomada a justiça como um conceito absoluto, abstrato, idealista, espiritualista, que, no fundo, encontra sua matriz no conceito hegeliano do *Estado Ético*, que fundamentou a concepção do Estado fascista: “totalitário e ditatorial em que os direitos e liberdades humanas ficam praticamente anulados e totalmente submetidos ao arbítrio de um poder político onipotente e incontrolado, no qual toda participação popular é sistematicamente negada em benefício da minoria [na verdade, da elite] que controla o poder político e econômico”.³⁷ Diga-se, desde logo,

33. Cf. Elías Díaz, *Estado de Derecho y sociedad democrática*, pp. 29 e ss.

34. Cf. *La lucha por el Estado de Derecho*, p. 94.

35. Cf. *Legalidad y legitimidad*, p. 23.

36. Cf. Ernst Forsthoff, *Stato di diritto in trasformazione*, p. 6, onde, respondendo às críticas, reafirma que continua a sustentar que o Estado de Direito deve ser entendido no sentido formal.

37. Cf. Elías Díaz, *ob. cit.*, pp. 57 e ss., ampla discussão sobre o Estado Ético. O texto citado acha-se à p. 77. Ressalve-se o texto “na verdade, da elite” que é nosso.

que o Estado de Justiça, na formulação indicada, nada tem a ver com Estado submetido ao Poder Judiciário, que é um elemento importante do Estado de Direito. Estado submetido ao juiz é Estado cujos atos legislativos, executivos, administrativos e também judiciais ficam sujeitos ao controle jurisdicional no que tange à legitimidade constitucional e legal. É também uma abstração confundir Estado de Direito com uma visão jusnaturalista do Estado.

Por outro lado, se se concebe o Direito apenas como um conjunto de normas estabelecidas pelo Legislativo, o Estado de Direito passa a ser Estado de Legalidade, ou Estado legislativo,³⁸ o que constitui uma redução deformante. Se o princípio da legalidade é um elemento importante do conceito de Estado de Direito, nele não se realiza completamente.

A concepção jurídica de Kelsen também contribuiu para deformar o conceito de Estado de Direito. Para ele Estado e Direito são conceitos idênticos. Na medida em que ele confunde Estado e ordem jurídica, todo Estado, para ele, há de ser Estado de Direito.³⁹ Por isso, vota significativo desprezo a esse conceito. Como, na sua concepção, só é Direito o direito positivo, como norma pura, desvinculada de qualquer conteúdo, chega-se, sem dificuldade, a uma idéia formalista do Estado de Direito ou Estado Formal de Direito, que serve também a interesses ditatoriais, como vimos. Pois, se o Direito acaba se confundindo com mero enunciado formal da lei, destituído de qualquer conteúdo, sem compromisso com a realidade política, social, econômica, ideológica enfim (o que, no fundo, esconde uma ideologia reacionária), todo Estado acaba sendo Estado de Direito, ainda que seja

ditatorial. Essa doutrina converte o Estado de Direito em mero Estado Legal.⁴⁰ Em verdade, destrói qualquer idéia de Estado de Direito.

15. Estado Social de Direito

O individualismo e o abstencionismo ou neutralismo do Estado liberal provocaram imensas injustiças, e os movimentos sociais do século passado e deste especialmente, desvelando a insuficiência das liberdades burguesas, permitiram que se tivesse consciência da necessidade da justiça social, conforme nota Lucas Verdú, que acrescenta: "Mas o Estado de Direito, que já não poderia justificar-se como liberal, necessitou, para enfrentar a maré social, despojar-se de sua neutralidade, integrar, em seu seio, a sociedade, sem renunciar ao primado do Direito. O Estado de Direito, na atualidade, deixou de ser formal, neutro e individualista, para transformar-se em Estado material de Direito, enquanto adota uma dogmática e pretende realizar a justiça social".⁴¹ Transforma-se em *Estado Social de Direito*, onde o "qualificativo social refere-se à correção do individualismo clássico liberal pela afirmação dos chamados direitos sociais e realização de objetivos de justiça social".⁴² Caracteriza-se no propósito de compatibilizar, em um mesmo sistema, anota Elías Díaz, dois elementos: o capitalismo, como forma de produção, e a consecução do bem-estar social geral, servindo de base ao neocapitalismo típico do *Welfare State*.⁴³

Os regimes constitucionais ocidentais prometem, explícita ou implicitamente, realizar o *Estado Social de Direito*, quando definem um capítulo de direitos econômicos e sociais. Expressas são as Constituições da República Federal Alemã e da Espanha, definindo os respectivos Estados como sociais e democráticos de Direito.⁴⁴

Mas ainda é insuficiente a concepção do Estado Social de Direito, ainda que, como *Estado Material de Direito*, revele um tipo de Estado que tende a criar uma situação de bem-estar geral que garanta o desenvolvimento da pessoa humana. Sua ambigüidade, porém, é manifesta. Primeiro, porque a palavra *social* está sujeita a várias interpretações.⁴⁵ Todas as ideologias, com sua própria visão do *social* e

38. Cf. Carl Schmitt, *ob. cit.*, p. 4: "Por 'Estado Legislativo' se entiende aquí un determinado tipo de comunidad política, cuya peculiaridad consiste en que ve la expresión suprema y decisiva de la voluntad común en la proclamación de una especie cualificada de normas que pretenden ser Derecho".

39. Kelsen é expresso, nesse sentido, como se pode ver destas palavras da versão francesa de sua obra clássica: "Des lors que l'on reconnaît que l'État est un État de droit, et ce terme d'État de droit représente un pléonasme". É certo que, em seguida, ele dá o sentido em que o termo é empregado: "En fait cependant, on répond aux postulats de la démocratie et de la sécurité juridique. En ce sens spécifique, l'État de droit est un ordre juridique relativement centralisé qui présente les traits suivants: la juridiction et l'administration y sont liées par des lois, c'est-à-dire par des normes générales qui sont décidées par un Parlement élu par le peuple, avec ou sans la collaboration d'un chef d'État qui est placé à la tête du gouvernement; les membres du gouvernement y sont responsables de leurs actes; les tribunaux y sont indépendants; et les citoyens y voient garantir certains droits de liberté, en particulier la liberté de conscience et de croyance, et la liberté d'exprimer leurs opinions". Cf. *Théorie pure du droit*, p. 411; cf., do mesmo autor, *Teoría general del derecho y dello Stato*, p. 186. A propósito, cf. Antonio Enrique Pérez Luno, "Estado de Derecho y Derecho fundamental", in Pérez Luño et al., *Los derechos humanos, significación, estatuto jurídico y sistema*, p. 165.

40. Sobre a diferença entre Estado de Direito e Estado Legal, cf. Carré de Malberg, *Contribution a la théorie générale de l'état*, t. I/490 a 494.

41. Cf. *La lucha por el Estado de Derecho*, p. 94.

42. Cf. Elías Díaz, *ob. cit.*, p. 96; Verdú, *ob. cit.*, pp. 95 e ss.

43. *Ob. cit.*, p. 106.

44. "A República Federal da Alemanha é um Estado Federal, democrático e social" (art. 20, 1). "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho [...]" (art. 1, 1).

45. Cf. Ernst Forsthoff, *Stato di diritto in trasformazione*, p. 53.

do *Direito*, podem acolher uma concepção do Estado Social de Direito, menos a ideologia marxista que não confunde o social com o socialista. A Alemanha nazista, a Itália fascista, a Espanha franquista, Portugal salazarista, a Inglaterra de Churchill e Attlee, a França, com a Quarta República, especialmente, e o Brasil, desde a Revolução de 30 — bem observa Paulo Bonavides — foram “Estados sociais”, o que evidencia, conclui, “que o Estado social se compadece com regimes políticos antagônicos, como sejam a democracia, o fascismo e o nacional-socialismo”.⁴⁶ Em segundo lugar, o importante não é o *social*, qualificando o Estado, em lugar de qualificar o Direito. Talvez até por isso se possa dar razão a Forsthoft quando exprime a idéia de que Estado de Direito e Estado Social não podem fundir-se no plano constitucional.⁴⁷ O próprio Elías Díaz, que reconhece a importância histórica do Estado Social de Direito, não deixa de lembrar a suspeita quanto a “saber se e até que ponto o neocapitalismo do Estado Social de Direito não estaria em realidade encobrindo uma forma muito mais matizada e sutil de ditadura do grande capital, isto é, algo que no fundo poderia denominar-se, e se tem denominado, neofascismo”.⁴⁸ Ele não descarta essa possibilidade, admitindo que “o grande capital encontrou fácil entrada nas novas estruturas demoliberais, chegando assim a constituir-se como peça chave e central do *Welfare State*. Ainda que institucionalizado no chamado Estado Social de Direito, permanece sempre sob este — representada por seus grupos políticos e econômicos mais reacionários e violentos — essa tendência e propensão do capitalismo ao controle econômico monopolista e à utilização de métodos políticos de caráter totalitário e ditatorial, visando a evitar, sobretudo, qualquer eventualidade realmente socialista”.⁴⁹

Por tudo isso, a expressão *Estado Social de Direito* manifesta-se carregada de suspeição, ainda que se torne mais precisa quando se lhe adjunta a palavra *democrático* como fizeram as Constituições da República Federal da Alemanha e da Monarquia Espanhola para chamá-lo *Estado Social e Democrático de Direito*. Mas aí, mantendo o qualificativo *social* ligado a *Estado*, engasta-se aquela tendência neocapitalista e a petrificação do *Welfare State*, com o conteúdo mencionado acima, delimitadora de qualquer passo à frente no sentido socialista. Talvez, para caracterizar um Estado não socialista preocupado, no entanto, com a realização dos direitos fundamentais de caráter social, fosse melhor manter a expressão *Estado de Direito*, que já tem

uma conotação democratizante, mas, para retirar dele o sentido liberal burguês individualista, qualificar a palavra Direito com o *social*, com o que se definiria uma concepção jurídica mais progressista e aberta, e então, em lugar de Estado Social de Direito, diríamos *Estado de Direito Social*. Assim dizíamos nas edições anteriores deste livro, com base na Constituição de 1969. Mas, não satisfeitos, acrescentamos: por que não avançar um pouco mais e chegar a um conceito de *Estado de Direito Econômico*?”.

16. O Estado Democrático

As considerações supra mostram que o Estado de Direito, quer como Estado Liberal de Direito quer como Estado Social de Direito, nem sempre caracteriza *Estado Democrático*. Este se funda no princípio da soberania popular, que “impõe a participação efetiva e operante do povo na coisa pública, participação que não se exaure, como veremos, na simples formação das instituições representativas, que constituem um estágio da evolução do Estado Democrático, mas não o seu completo desenvolvimento”.⁵⁰ Visa, assim, a realizar o princípio democrático como garantia geral dos direitos fundamentais da pessoa humana. Nesse sentido, na verdade, contrapõe-se ao Estado Liberal, pois, como lembra Paulo Bonavides, “a idéia essencial do liberalismo não é a presença do elemento popular na formação da vontade estatal, nem tampouco a teoria igualitária de que todos têm direito igual a essa participação ou que a liberdade é formalmente esse direito”.⁵¹

O Estado de Direito, como lembramos acima, é uma criação do liberalismo. Por isso, na doutrina clássica, repousa na concepção do Direito *natural*, *imutável* e *universal*, daí decorre que a *lei*, que realiza o princípio da legalidade, essência do conceito de Estado de Direito, é concebida como norma jurídica geral e abstrata. A *generalidade da lei* constituía o fulcro do Estado de Direito. Nela se assentaria o justo conforme a razão. Dela e só dela defluiria a igualdade. “Sendo regra geral, a lei é regra para todos”.⁵² O postulado da generalidade das leis foi ressuscitado por Carl Schmitt sob a Constituição de Weimar, após ter sido abandonado sob a influência de Laband, surgindo, em seu lugar, a divisão das leis em formais e materiais.⁵³ Essa restauração tem sentido ideológico preciso, pois que, como lembra Franz

46. Cf. *Do Estado Liberal ao Estado Social*, pp. 205 e 206.

47. *Ob. cit.*, p. 70.

48. *Ob. cit.*, p. 121, também p. 123.

49. *Idem*, pp. 122 e 123.

50. Cf. Emilio Crosa, *Lo Stato democratico*, p. 25.

51. Cf. *Do Estado Liberal ao Estado Social*, p. 16.

52. Cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Estado de Direito e Constituição*, p. 21.

53. Cf. Franz Neumann, *Estado democrático e Estado autoritário*, pp. 60 e 61.

Neumann, a teoria de que o Estado só pode governar por meio de leis gerais se aplica a um sistema econômico de livre concorrência,⁵⁴ e "o renascimento, sob a Constituição de Weimar, da noção da generalidade das leis e sua aplicação indiscriminada às liberdades pessoais, políticas e econômicas, foi assim usado como um dispositivo para restringir o poder do Parlamento que já não mais representava exclusivamente os interesses dos grandes latifundiários, dos capitalistas, do exército e da burocracia. Então, o direito geral, dentro da esfera econômica, era usado para conservar o sistema de propriedade existente e para protegê-lo contra intervenção sempre que esta fosse julgada incompatível com os interesses dos grupos mencionados acima".⁵⁵

Invoca-se, com frequência, a doutrina da vontade geral de Rousseau para fundamentar a afirmativa de que a igualdade só pode ser atingida por meio de normas gerais; esquece-se que ele discutia o direito geral com referência a uma sociedade em que só haveria pequenas propriedades ou propriedades comuns.⁵⁶ Não é, pois, fundamento válido para o postulado da generalidade que embasa o liberalismo capitalista. De fato, a propriedade particular, que é sagrada e inviolável, de acordo com Rousseau, só é propriedade até onde permanece como um direito individual e discriminado. "Se for considerada comum a todos os cidadãos, ficará sujeita à *volonté générale* e poderá ser infringida ou negada. Assim o soberano não tem o direito de tocar na propriedade de um ou de diversos cidadãos, embora possa legitimamente tomar a propriedade de todos".⁵⁷

Conclui-se daí que a igualdade do Estado de Direito, na concepção clássica, se funda num elemento puramente formal e abstrato, qual seja a generalidade das leis. Não tem base material que se realize na vida concreta. A tentativa de corrigir isso, como vimos, foi a construção do Estado Social de Direito, que, no entanto, não foi capaz de assegurar a justiça social nem a autêntica participação democrática do povo no processo político.⁵⁸ Aonde a concepção mais recente do Estado Democrático de Direito, como Estado de legitimidade justa (ou Estado de Justiça material), fundante de uma sociedade democrática, qual seja a que instaure um processo de efetiva incorporação de todo o povo nos mecanismos do controle das decisões, e de sua real participação nos rendimentos da produção.⁵⁹

54. Idem, p. 61.

55. Franz Neumann, *ob. cit.*, p. 63.

56. Idem, p. 61.

57. Idem, p. 62, citando, sob nota 27, *Émile*, livro V.

58. Cf. Pablo Lucas Verdú, *Curso de derecho político*, v. II/230 e 231.

59. Cf. Elías Díaz, *ob. cit.*, pp. 139 e 141.

17. Caracterização do Estado Democrático de Direito

A configuração do Estado Democrático de Direito não significa apenas unir formalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. Consiste, na verdade, na criação de um conceito novo, que leva em conta os conceitos dos elementos componentes, mas os supera na medida em que incorpora um componente revolucionário de transformação do *status quo*. E aí se entremostra a extrema importância do art. 1º da Constituição de 1988, quando afirma que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito, não como mera promessa de organizar tal Estado, pois a Constituição aí já o está proclamando e fundando.

A Constituição portuguesa instaura o Estado de Direito Democrático, com o "democrático" qualificando o Direito e não o Estado. Essa é uma diferença formal entre ambas as constituições. A nossa emprega a expressão mais adequada, cunhada pela doutrina, em que o "democrático" qualifica o Estado, o que irradia os valores da democracia sobre todos os elementos constitutivos do Estado e, pois, também sobre a ordem jurídica. O Direito, então, imantado por esses valores, se enriquece do sentir popular e terá que ajustar-se ao interesse coletivo. Contudo, o texto da Constituição portuguesa dá ao Estado de Direito Democrático o conteúdo básico que a doutrina reconhece ao Estado Democrático de Direito, quando afirma que ele é "baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais, que tem por objectivo a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa" (art. 2º, redação da 2ª revisão, 1989).

A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de ser um processo de convivência social numa sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I), em que o poder emana do povo, e deve ser exercido em proveito do povo, diretamente ou por representantes eleitos (art. 1º, parágrafo único); participativa, porque envolve a participação crescente do povo no processo decisório e na formação dos atos de governo;⁶⁰ pluralista, porque respeita a pluralidade de idéias, culturas e etnias⁶¹ e pressupõe assim o diálogo entre opiniões e pensamentos divergentes e a possibilidade de convivência de formas de organização e interesses diferentes da sociedade; há de ser um pro-

60. Cf. arts. 10; 14, I a III; 29, XII e XIII; 31, § 3º; 49, XV; 61, § 2º; 198, III; 204, II.

61. Cf. arts. 1º, V; 17; 206, III.

cesso de liberação da pessoa humana das formas de opressão que não depende apenas do reconhecimento formal de certos direitos individuais, políticos e sociais, mas especialmente da vigência de condições econômicas suscetíveis de favorecer o seu pleno exercício.

É um tipo de Estado que tende a realizar a síntese do processo contraditório do mundo contemporâneo, superando o Estado capitalista para configurar um Estado promotor de justiça social que o personalismo e o monismo político das democracias populares sob o influxo do socialismo real não foram capazes de construir. Nesse quadrante, é ainda pertinente lembrar o pronunciamento de Elías Díaz, que se revelou profético: "Desta forma, e sem querer chegar com isso apressadamente 'à grande síntese final' ou a qualquer outra forma de 'culminação da História' (isto deve ficar bem claro), cabe dizer que o Estado Democrático de Direito aparece como a fórmula institucional em que atualmente, e sobretudo para um futuro próximo, pode vir a concretizar-se o processo de convergência em que podem ir concorrendo as concepções atuais da democracia e do socialismo. A passagem do neocapitalismo ao socialismo nos países de democracia liberal e, paralelamente, o crescente processo de despersonalização e institucionalização jurídica do poder nos países de democracia popular, constituem em síntese a dupla ação para esse processo de convergência em que aparece o Estado Democrático de Direito".⁶² O mesmo autor, em outra obra, define-o como "a institucionalização do poder popular ou, como digo, a realização democrática do socialismo".⁶³ Talvez um novo tipo de socialismo, que não seja uma nova forma de estatismo, já que o difícil no socialismo marxista consiste em resolver que organismo administra os bens de produção, uma vez que o Estado falhou nesse desidério.

O certo, contudo, é que a Constituição de 1988 não promete a transição para o socialismo com o Estado Democrático de Direito, apenas abre as perspectivas de realização social profunda pela prática dos direitos sociais, que ela inscreve, e pelo exercício dos instrumentos que oferece à cidadania e que possibilita concretizar as exigências de um Estado de justiça social, fundado na dignidade da pessoa humana.⁶⁴

62. Ob. cit., p. 133.

63. Cf. *Legitimidad-legalidad en el socialismo democrático*, p. 184.

64. O texto já constava, em essência, de nosso artigo "O Estado Democrático de Direito", publicado na *Revista da PGE-SP* 30:70, onde expressamente está que a Constituição não chegou a estruturar um Estado Democrático de Direito de conteúdo socialista, assim como também dissemos ao enunciar seus princípios que "a Constituição não prometeu a transição para o socialismo mediante a realização da democracia

18. A lei no Estado Democrático de Direito

O princípio da legalidade é também um princípio basilar do Estado Democrático de Direito. É da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se, como todo Estado de Direito, ao império da lei, mas da lei que realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da igualização das condições dos socialmente desiguais. Deve, pois, ser destacada a relevância da lei no Estado Democrático de Direito, não apenas quanto ao seu conceito formal de ato jurídico abstrato, geral, obrigatório e modificativo da ordem jurídica existente, mas também à sua função de regulamentação fundamental, produzida segundo um procedimento constitucional qualificado. A lei é efetivamente o ato oficial de maior realce na vida política. Ato de decisão política por excelência, é por meio dela, enquanto emanada da atuação da vontade popular, que o poder estatal propicia ao viver social modos predeterminados de conduta, de maneira que os membros da sociedade saibam, de antemão, como guiar-se na realização de seus interesses.

É precisamente no Estado Democrático de Direito que se ressalta a relevância da lei, pois ele não pode ficar limitado a um conceito de lei, como o que imperou no Estado de Direito clássico.⁶⁵ Pois ele tem que estar em condições de realizar, mediante lei, intervenções que impliquem diretamente uma alteração na situação da comunidade.⁶⁶ Significa dizer: a lei não deve ficar numa esfera puramente normativa, não pode ser apenas lei de arbitragem, pois precisa influir na realidade social. E se a Constituição se abre para as transformações políticas, econômicas e sociais que a sociedade brasileira requer, a lei se elevará de importância, na medida em que, sendo fundamental expressão do direito positivo, caracteriza-se como desdobramento necessário do conteúdo da Constituição e aí exerce função transformadora da sociedade, impondo mudanças sociais democráti-

econômica..., como o fez a Constituição portuguesa", textos também repetidos neste volume desde sua 5ª ed. (1ª sob a Constituição de 1988). Não obstante a clareza desses textos, o Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho me atribui declaração em sentido oposto, quando escreve: "José Afonso da Silva sustenta, porém, o contrário, afirmando que Estado Democrático de Direito significa na Constituição brasileira Estado em transição para o socialismo" (cf. *Comentários à Constituição brasileira*, v. 1/18). Por mais vontade que tivesse que assim fosse, meu senso jurídico (se é que tenho algum) não me permitiria dar uma tal interpretação, que não seria correta. Não leu bem o meu texto o ilustre professor.

65. A propósito, cf. Christian Starck, *El concepto de ley en la constitución alemana*, p. 249.

66. Idem, p. 300.

cas, ainda que possa continuar a desempenhar uma função conservadora, garantindo a sobrevivência de valores socialmente aceitos.

19. Princípios e tarefa do Estado Democrático de Direito

Limitar-nos-emos a indicar esses princípios⁶⁷ sem entrar em pormenores, porque ao longo deste curso serão estudados no momento próprio, se já não foram. São os seguintes:

(a) *princípio da constitucionalidade*, que exprime, em primeiro lugar, que o Estado Democrático de Direito se funda na legitimidade de uma Constituição rígida, emanada da vontade popular, que, dotada de supremacia, vincule todos os poderes e os atos deles provenientes, com as garantias de atuação livre de regras da jurisdição constitucional;

(b) *princípio democrático*, que, nos termos da Constituição, há de constituir uma democracia representativa e participativa, pluralista, e que seja a garantia geral da vigência e eficácia dos direitos fundamentais (art. 1º);

(c) *sistema de direitos fundamentais*, que compreende os individuais, coletivos, sociais e culturais (títulos II, VII e VIII);

(d) *princípio da justiça social*, referido no art. 170, *caput*, e no art. 193, como princípio da ordem econômica e da ordem social; como dissemos, a Constituição não prometeu a transição para o socialismo mediante a realização da democracia econômica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa, como o faz a Constituição portuguesa, mas com certeza ela se abre também, timidamente, para a realização da democracia social e cultural, sem avançar significativamente rumo à democracia econômica;

(e) *princípio da igualdade* (art. 5º, *caput*, e I);

(f) *princípios da divisão de poderes* (art. 2º) e da *independência do juiz* (art. 95);

(g) *princípio da legalidade* (art. 5º, II);

(h) *princípio da segurança jurídica* (art. 5º, XXXVI a LXXIII).

A tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social.

67. Mais uma vez recorreremos ao magistério de Gomes Canotilho, que desenvolveu os princípios do Estado de Direito Democrático português com pormenores no livro *Direito constitucional*, pp. 373 e ss. Todos são aplicáveis ao Estado Democrático de Direito brasileiro. Haverá alguma diferença, que o leitor, em comparando, logo perceberá.

Capítulo III

DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

I. REGIME POLÍTICO: 1. Conceito de regime político. 2. Regime político brasileiro. II. DEMOCRACIA: 3. Conceito de democracia. 4. Pressupostos da democracia. 5. Princípios e valores da democracia. 6. O poder democrático e as qualificações da democracia. 7. Conceito de povo e democracia. 8. Exercício do poder democrático. 9. Democracia representativa. 10. O mandato político representativo. 11. Democracia participativa. 12. Democracia pluralista. 13. Democracia e direito constitucional brasileiro.

I. REGIME POLÍTICO

1. Conceito de regime político

O regime político não tem encontrado conceituação uniforme na doutrina.¹ Constitui, segundo Duverger, um conjunto de instituições políticas que, em determinado momento, funcionam em dado país, em cuja base se acha o fenômeno essencial da autoridade, do poder, da distinção entre governantes e governados, aparecendo, assim, como um conjunto de respostas a quatro problemas fundamentais relativos à: (a) *autoridade dos governantes* e sua *obediência*; (b) *escolha dos governantes*; (c) *estrutura dos governantes*; (d) *limitação dos governantes*,² o que envolve, como se percebe, toda a problemática constitucional. Regime político, nessa concepção, será pouco mais ou menos sinônimo de regime constitucional.

Já Jiménez de Parga concebe-o como a solução que se dá, de fato, aos problemas políticos de um povo, acrescentando que: (a) como solução *efetiva*, o regime pode coincidir ou não com o sistema de soluções estabelecidas pela Constituição; (b) como solução *política*, um regime poderá valorar-se sempre com normas jurídicas e com critérios

1. Sobre a orientação metodológica que fundamenta as tendências das modernas investigações a respeito do regime político, cf. Raul Machado Horta, "Regime político e a doutrina das formas de governo", RF 176/6.

2. Cf. *Droit constitutionnel et institutions politiques*, v. I/15 e 16; *Os regimes políticos*, pp. 9 e 11 e ss.

rios morais.³ Diversa é a concepção de Guelli, para quem “o regime político é a realização de uma concepção política fundamental nas instituições jurídicas constitucionais de um Estado”.⁴ Segundo essa idéia, a característica de determinado regime político encontra-se principalmente na solução do problema da justificação do poder e, portanto, das relações entre governantes e governados. Isso permite destacar os vários tipos históricos de Estado: Estado liberal, Estado corporativo, Estado socialista. Todavia, não satisfaz, porque configura um conceito estático.

Preferimos, por isso, adotar a concepção de um grupo de professores da Universidade de Barcelona, que parte do princípio de que o *regime político*, antes de tudo, pressupõe a existência de um conjunto de instituições e princípios fundamentais que informam determinada concepção política do Estado e da sociedade, mas é também um conceito ativo, pois, ao fato estrutural há que superpor o elemento funcional, que implica uma atividade e um fim, supondo dinamismo, sem redução a uma simples atividade de governo, para concluir que o *regime é um complexo estrutural de princípios e forças políticas que configuram determinada concepção do Estado e da sociedade, e que inspiram seu ordenamento jurídico*.⁵ Não é diferente o pensamento de Santi Romano, segundo o qual por regime se entende o governo enquanto se quer pôr em relevo, com uma fórmula sintética, o princípio ou diretriz política fundamental (p. ex., o princípio liberal, o princípio democrático, o princípio socialista etc.) que informa todas as instituições do Estado e constitui também a suprema diretiva de sua atividade.⁶ Assim, em verdade, o conceito de regime político configura a estrutura global da realidade política com todo o seu complexo institucional e ideológico, como quer Jorge Xifras: conceito amplo que se baseia numa semelhança de ideologia e de instituições, envolvendo sistemas de governo (presidencialismo, parlamentarismo etc.) e até forma de Estado (unitário e federal) e de governo (república, monarquia), mostrando a síntese integradora das instituições, das forças e das idéias que operam numa sociedade.⁷ Segundo Xifras, a atual situação dos regimes políticos resume-se na dicotomia *autocracia-democracia*: diante dos *regimes autocráticos*, estruturados de cima para baixo (soberania do governante; princípio do chefe), existem os *regimes democráticos*, organizados de baixo para cima (soberania do

povo).⁸ E aí já se percebe a relação entre regime político e direitos humanos fundamentais. Regimes há que lhes são garantias — os democráticos — instrumentos de sua realização no plano prático; outros — os autocráticos — ao contrário, lhes recusam guarida, tolhem-lhes a realização.

2. Regime político brasileiro

O regime brasileiro da Constituição de 1988 funda-se no *princípio democrático*. O preâmbulo e o art. 1º o enunciam de maneira insofismável. Só por aí se vê que a Constituição institui um Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, livre, justa e solidária e sem preconceitos (art. 3º, II e IV), com fundamento na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político. Trata-se assim de um regime democrático fundado no princípio da soberania popular, segundo o qual todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, ou diretamente (parágrafo único do art. 1º).

Teremos a oportunidade de ver mais adiante que se constituem aí os princípios fundamentais da democracia *representativa*,⁹ *participativa* e *pluralista*, garantia dos direitos fundamentais do homem: *individuais e coletivos* (arts. 5º, 8º, 9º, 10 e 11), *sociais* (arts. 6º, 7º, 193-214, 226-230), *culturais* (arts. 215 a 217), *ambiental* (art. 225) e *indigenista* (arts. 231 e 232). Uma democracia, pois, com forte conteúdo social.

II. DEMOCRACIA

3. Conceito de democracia

Democracia é conceito histórico. Não sendo por si um valor-fim, mas meio e instrumento de realização de valores essenciais de convi-

8. Ob. cit., p. 79. No mesmo sentido, Georges Burdeau, *Traité de science politique*, t. V/439 e ss.

9. O *regime representativo* traduz um tipo de democracia: a *democracia representativa*, sempre que a representação signifique técnica de subordinação dos governantes à vontade do povo, vale dizer, sempre que o regime representativo constitua modo de realização da soberania popular. Em verdade, nem todo regime representativo é democrático. Há democracia sem representação (democracia direta, p. ex.) e representação sem democracia (assim representação funcional ou profissional e representação corporativa que servem as organizações autoritárias e fascistas). Cf. Burdeau, ob. cit., pp. 275 e ss. e 332 e ss., especialmente; Jorge Reinaldo A. Vanossi, *El misterio de la representación política*, pp. 83 e ss.

3. Cf. *Los regímenes políticos contemporáneos*, p. 59.

4. Cf. *O regime político*, p. 29.

5. Cf. Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior-Universidad de Barcelona (org.), *La estructura del Estado*, pp. 110 e 111.

6. Cf. *Principii di diritto costituzionale generale*, p. 143.

7. Cf. *Curso de derecho constitucional*, t. II/77 e ss.

vência humana, que se traduzem basicamente nos direitos fundamentais do homem, compreende-se que a historicidade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o conteúdo a cada etapa do evoluir social, mantido sempre o princípio básico de que ela revela um regime político em que o poder repousa na vontade do povo. Sob esse aspecto, a democracia não é um mero conceito político abstrato e estático, mas é um *processo* de afirmação do povo e de garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no correr da história.

Nesse processo vai-se configurando também a noção histórica de povo, pois, como adverte Burdeau, “se é verdade que não há democracia sem governo do povo pelo povo, a questão importante está em saber o que é preciso entender por povo e como ele governa”.¹⁰ A concepção de povo tem variado com o tempo, “porque, se sempre é o povo que governa, não é sempre o mesmo povo”.¹¹ “Por isso é que a democracia da antiguidade grega não é a mesma dos tempos modernos; nem a democracia burguesa capitalista corresponde à democracia popular. Voltaremos a especificações ulteriores, mas, com essas observações preliminares, é que podemos aceitar a concepção de Lincoln de que a *democracia*, como regime político, é *governo do povo, pelo povo e para o povo*. Podemos, assim, admitir que a *democracia* é um *processo de convivência social em que o poder emana do povo, há de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo e em proveito do povo*. Diz-se que é um processo de convivência, primeiramente para denotar sua historicidade, depois para realçar que, além de ser uma relação de poder político, é também um modo de vida, em que, no relacionamento interpessoal, há de verificar-se o respeito e a tolerância entre os conviventes.

4. Pressupostos da democracia

Uma visão elitista antepõe diversos tipos de pressupostos que julga necessários à existência e realização da democracia. Elitismo, governo de poucos, não é apenas uma posição distinta da democracia, governo do povo, mas é algo a ela oposto.¹² Apesar disso, nota Bachrach que, “no pensamento político contemporâneo, há uma for-

10. Cf. *Traité de science politique*, t.V/571.

11. Cf. Burdeau, *La democracia*, pp. 29 e 30 (versão portuguesa, *A democracia*, p. 15).

12. “Todas las teorías de la *élite* descansan en dos supuestos básicos: primero, que las masas son intrínsecamente incompetentes, y segundo, que son, en el peor, seres ingobernables, y desenfrenados con una proclividad insaciable a minar la cultura y la libertad”. Cf. Peter Bachrach, *Crítica de la teoría elitista de la democracia*, p. 20.

te tendência (talvez predominante) a incorporar à teoria democrática os princípios fundamentais da teoria elitista”, que ele denomina “elitismo democrático”,¹³ que é fora de dúvida uma expressão contraditória. É a doutrina do Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, para quem a “democracia que é possível na realidade consiste no governo por uma minoria democrática, ou seja, por uma elite formada conforme a tendência democrática, renovada de acordo com o princípio democrático, imbuída do espírito democrático, voltada para o interesse popular: o bem comum”.¹⁴

Esta foi também a doutrina da segurança nacional que fundamentou o constitucionalismo do regime militar que a atual Constituição suplantou. Segundo ela, compete às elites a tarefa de promover o bem comum, “mediante um processo de ‘interação’ com a massa. Auscultando o povo, as elites nacionais identificam seus anseios e aspirações. Possuindo um maior conhecimento da realidade histórico-cultural e dos dados conjunturais, elas têm uma visão mais elaborada dos autênticos interesses nacionais. Cabe-lhes, assim, interpretar os anseios e aspirações, difusos no meio ambiente, harmonizando-os com os verdadeiros interesses da Nação e com o Bem Comum, apresentando-os, de volta, ao povo que, desse modo sensibilizado, poderá entender e adotar os novos padrões que lhe são propostos”.¹⁵

É equívoco pensar que esse chamado “elitismo democrático” se contenta com a tese do governo da minoria, que se limita a sustentar um “elitismo de dirigentes”. Coerente com sua essência antidemocrática, o elitismo assenta-se em sua inerente desconfiança do povo, que reputa intrinsecamente incompetente. Por isso sua “democracia” sempre depende de pressupostos notoriamente elitistas, tais como os de que o povo precisa ser preparado para a democracia, de que esta pressupõe certo nível de cultura, certo amadurecimento social, certo desenvolvimento econômico, e reclama que o povo seja educado para ela,¹⁶ e outros semelhantes que, no fim das contas, preparam os fundamentos doutrinários do voto de qualidade e restritivo.

13. “Prólogo”: in *ob. cit.*, p. 17; Cf. Germán J. Bidart Campos, *Las elites políticas*, p. 164, letra i, segundo o qual: “El elitismo no es incompatible con la democracia, en cuanto responde a la naturaleza de las cosas y articula la reciprocidad de mando y obediencia”.

14. Cf. *A democracia possível*, p. 29.

15. Cf. José Alfredo Amaral Gurgel, *Segurança e democracia*, p. 95, baseado nos manuais da Escola Superior de Guerra.

16. Cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de direito constitucional*, pp. 51 e ss., em capítulo sobre os pressupostos e condições da democracia. Idem, *A democracia possível*, caps. I e II da Segunda Parte, dedicados a elaborar esses pressupostos e condições.

A contradição é evidente, pois supõe que o povo deve obter tais requisitos para o exercício da democracia dentro de um regime não democrático; que as elites devem conduzi-lo a uma situação que justamente se opõe aos interesses delas e as elimina. Teremos, enfim, a singularidade de aprender a fazer democracia em um laboratório não democrático.

Ora, em verdade, a tese inverte o problema, transformando, em pressupostos da democracia, situações que se devem ter como parte de seus objetivos: educação, nível de cultura, desenvolvimento, que envolva a melhoria de vida, aperfeiçoamento pessoal, enfim, tudo se amalgama com os direitos sociais, cuja realização cumpre ser garantida pelo regime democrático. Não são pressupostos desta, mas objetivos. Só numa democracia pode o povo exigí-los e alcançá-los.

A democracia não precisa pressupostos especiais. Basta a existência de uma sociedade. Se seu governo emana do povo, é democrática; se não, não o é. A sociedade primitiva fora democrática.¹⁷ A sociedade política — estatal — passara a não ser. Por isso, nesta “a democracia pressupõe luta incessante pela justiça social”.¹⁸ Não pressupõe que todos sejam instruídos, cultos, educados, perfeitos, mas há de buscar distribuir a todos instrução, cultura, educação, aperfeiçoamento, nível de vida digno. Bem o disse Claude Julien: “A democracia não pode resignar-se com os *bidonvilles*, os alojamentos insalubres, os salários miseráveis, as condições de trabalho miseráveis”.¹⁹ Fundamenta-se na garantia da igualdade, por isso não pode tolerar a extrema desigualdade entre trabalhadores e classe dominante. Por isso, também, é contraditória a tese de uma democracia elitista, que assenta precisamente na existência da desigualdade.

A Constituição estrutura um regime democrático consubstanciando esses objetivos de igualização por via dos direitos sociais e da universalização de prestações sociais (seguridade, saúde, previdência e assistência sociais, educação e cultura).²⁰ A democratização dessas prestações, ou seja, a estrutura de modos democráticos (universalização e participação popular), constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, instituído no art. 1º. Resta, evidentemente, esperar que essa normatividade constitucional se realize na prática.

Finalmente, os que reclamam que a democracia nunca fora realizada em sua pureza em lugar algum concebem-na como um con-

ceito estático, absoluto, como algo que há que instaurar-se de uma vez e assim perdurar para sempre. Não percebem que ela é um processo, e um processo dialético que vai rompendo os contrários, as antíteses, para, a cada etapa da evolução, incorporar conteúdo novo, enriquecido de novos valores. Como tal, ela nunca se realiza inteiramente, pois, como qualquer vetor que aponta a valores, a cada nova conquista feita, abrem-se outras perspectivas, descortinam-se novos horizontes ao aperfeiçoamento humano, a serem atingidos.

5. Princípios e valores da democracia

A doutrina afirma que a democracia repousa sobre três princípios fundamentais: o *princípio da maioria*, o *princípio da igualdade* e o *princípio da liberdade*.²¹ Aristóteles já dizia que a democracia é o governo onde domina o número,²² isto é, a maioria, mas também disse que a alma da democracia consiste na liberdade, sendo todos iguais.²³ A igualdade, diz, é o primeiro atributo que os democratas põem como fundamento e fim da democracia.²⁴ E assim ele acaba concluindo que toda democracia se funda no direito de igualdade, e tanto mais pronunciada será a democracia quanto mais se avança na igualdade.²⁵

Aristóteles, como se nota, não chega a declarar que a igualdade e a liberdade sejam *princípios* da democracia. Coloca-as, acertadamente, como fundamentos (valores) dela; ressalve-se, contudo, que essa democracia do Estagirita só se destinava aos homens livres, a uma minoria, porque o *povo*, então, era tão-só essa minoria.²⁶

21. Para uma discussão mais ampla sobre tema, cf. Pinto Ferreira, *Princípios gerais do direito constitucional moderno*, t. 1/171 e ss. O conceito desse ilustre constitucionalista reflete essa doutrina: “a democracia é a forma constitucional de governo da maioria, que, sobre a base da liberdade e igualdade, assegura às minorias no parlamento o direito de representação, fiscalização e crítica” (p. 189). Conceito de democracia, não como processo de convivência, mas como relação governamental, e, pois, de democracia política.

22. Cf. *Política*, IV, 3, 1290b.

23. Idem, IV, 4, 1292a.

24. Idem, VI, 1, 1317b.

25. Idem, VI, 1, 1318a.

26. Mas em Aristóteles, como na prática do regime na antigüidade, a democracia era classista; a maioria, em verdade, era uma minoria de homens livres; a igualdade só entre eles se aferia; a liberdade só a eles competia. Cf. C. Leclercq, *Le principe de la majorité*, p. 11; “A democracia antiga era um governo de classe. Conforme já assinalamos, era apenas uma aristocracia mais ampla. Suas franquias eram, quando muito, privilégio limitado, estendendo-se apenas a uma minoria. Abaixo dessa minoria estavam os escravos, havendo, porem, os libertos, que jamais poderiam aspirar à cidadania. A subordinação de classes era da essência de sua constituição”. Cf. Jerome Hall, *Democracia e direito*, p. 75, n. 79.

17. Cf. Lewis H. Morgan, *La sociedad primitiva*, p. 145; Friedrich Engels, *A origem da família, da propriedade privada e do Estado*, p. 85.

18. Cf. Claude Julien, *O suicídio das democracias*, p. 23.

19. *Ob. cit.*, p. 26.

20. Cf. arts. 6º e 7º e 194, 196, 201, 203, 205, 215, 228 e 230, todos acompanhados de normas e mecanismos tendentes a fazer valer os direitos neles previstos.

A questão dos princípios da democracia precisa ser reelaborada, porque, no fundo, ela contém um elemento reacionário que escamoteia a essência do conceito, mormente quando apresenta a *maioria* como princípio do regime.²⁷ Maioria não é princípio. É simples técnica de que se serve a democracia para tomar decisões governamentais no interesse geral, não no interesse da maioria que é contingente. O interesse geral é que é permanente em conformidade com o momento histórico. É certo também que, na democracia representativa, se utiliza também a técnica da maioria para a designação dos agentes governamentais. Mas, precisamente porque não é princípio nem dogma da democracia, senão mera técnica que pode ser substituída por outra mais adequada, é que se desenvolveu a da representação proporcional, que amplia a participação do povo, por seus representantes, no poder. Mesmo assim o elemento maioria é amplamente empregado nos regimes democráticos contemporâneos. Uma análise mais acurada, porém, mostra que essa maioria, representada nos órgãos governamentais, não corresponde à maioria do povo, mas a uma minoria dominante. Esta situação fica muito clara no processo de formação das leis, que é aspecto importante do regime político, notadamente nas estruturas sociais divididas em classes de interesses divergentes, onde dificilmente se consegue atinar com o que seja o interesse geral. Aí é que as leis exercem um papel de arbitragem importante, nem sempre mais democrático, porque, no mais das vezes, tem por interesse geral o da classe dominante. Foi tendo em vista a técnica da maioria e a importância da lei que escrevemos certa vez o seguinte, que nos parece quadrar nas preocupações que nos ocupam aqui: "quanto mais divergentes são os interesses das classes sociais, quanto mais aguçadas são as contradições do sistema social vigente, tanto mais acirrados são os debates e as lutas no processo de formação das leis, já que estas é que vão estabelecer os limites dos interesses em jogo, tutelando uns e coibindo outros. Daí também a luta prévia relativa à composição dos órgãos incumbidos da função legislativa, pois que, no regime de representação popular e decisão

27. Charles E. Merriam, *Que é democracia?*, pp. 29 e 30, dá um conceito de democracia em que reduz a soberania popular a esse princípio da maioria. Agora, se se combina isso com aquela posição corrente de que povo é o conjunto dos cidadãos capazes (cf. A. Sampaio Dória, *Direito constitucional*, t. I/179), tem-se a extensão do reacionarismo que reduz a democracia a um regime de minoria, tanto quanto na Grécia antiga. Também não se pode aceitar a doutrina de Sampaio Dória de que os princípios da democracia são apenas: *consentimento dos governados na investidura do poder* (que condensa a igualdade política e o sufrágio universal) e *consentimento dos governados no exercício do poder*, mormente quando concebe governados ou povo como simples conjunto dos cidadãos capazes (corpo eleitoral), mas também porque tais elementos não são princípios mas simples técnica da democracia representativa.

por maioria, os titulares de interesses que conseguirem maior representação terão a possibilidade de domínio. Essa luta prévia se traduz no procurar evitar-se que os interesses dominados, ou que se quer dominar, venham a participar da legislação. A história registra esse embate, que tem culminado nas grandes revoluções, sempre com a consequência de novas conquistas democráticas".²⁸

Por isso, acrescentamos que "a verdade, a que se chega através da lei, é apenas formal, como na sentença judicial, pois que a lei jurídica nem sempre corresponde ao direito sócio-cultural, nem sempre interpreta a realidade social segundo um princípio de justiça. Várias vezes, o Direito legislado representa tão-só um compromisso entre os interesses em choque".

"O regime representativo, no Estado burguês [concluimos, então] procura resolver o conflito de interesses sociais por decisões da maioria parlamentar. Maioria que nem sempre exprime a representação da maioria do povo, porque o sistema eleitoral opõe grandes obstáculos a parcela ponderável da população, quanto ao direito de voto, para a composição das Câmaras Legislativas. Daí decorre que a legislação nem sempre reflete aquilo a que a maioria do povo aspira, mas, ao contrário, em grande parte, busca sustentar os interesses da classe que domina o poder e que, às vezes, está em contraste com os interesses gerais da Nação. As classes dirigentes, embora constituindo concretamente uma minoria, conseguem, pelo sistema eleitoral, impedir a representação, nos Parlamentos, da maioria do povo, razão por que, fazendo a maioria parlamentar, obtêm uma legislação favorável".²⁹

A democracia, em verdade, repousa sobre *dois princípios fundamentais* ou *primários*, que lhe dão a essência conceitual: (a) o da *soberania popular*, segundo o qual o povo é a única fonte do poder, que se exprime pela regra de que *todo o poder emana do povo*; (b) a *participação, direta ou indireta, do povo no poder*, para que este seja efetiva expressão da *vontade popular*; nos casos em que a participação é indireta, surge um princípio derivado ou secundário: o da *representação*. As técnicas que a democracia usa para concretizar esses princípios têm variado, e certamente continuarão a variar, com a evolução do processo histórico, predominando, no momento, as técnicas eleitorais com suas instituições e o sistema de partidos políticos, como instrumentos de expressão e coordenação da vontade popular.

Igualdade e liberdade, também, não são princípios, mas valores democráticos, no sentido de que a democracia constitui instrumento

28. Cf. nosso *Princípios do processo de formação das leis no direito constitucional*, pp. 24 e 28.

29. *Ob. cit.*, p. 29.

de sua realização no plano prático. A igualdade é o valor fundante da democracia, não a igualdade formal, mas a substancial. Como bem exprime Pinto Ferreira:

“Evidentemente, se a igualdade é a essência da democracia, deve ser uma igualdade substancial, realizada, não só formalmente no campo jurídico, porém estendendo a sua amplitude às demais dimensões da vida sócio-cultural, inclusive na zona vital da economia”.³⁰

É o valor fundante porque, sem sua efetiva realização, os demais não se verificarão. A forma qualitativamente diferente de realizar esses valores é que distingue as duas versões atuais da democracia — democracia capitalista ou burguesa e democracia popular ou marxista.³¹

Nesse aspecto, também, cremos que é necessário empreender a reelaboração da matéria, tendo em vista que falar pura e simplesmente em igualdade e liberdade pode dar a idéia tradicional do formalismo com que tais termos são empregados na literatura constitucional e política. Assim, preferimos dizer que a *democracia é o regime de garantia geral para a realização dos direitos fundamentais do homem*. Como, no entanto, os direitos econômicos e sociais são conhecidos, hoje, como indispensáveis à concretização dos direitos individuais, chega-se à conclusão de que garanti-los é missão de um regime democrático eficiente.

Assim, a democracia — governo do povo, pelo povo e para o povo — aponta para a realização dos direitos políticos, que apontam para a realização dos direitos econômicos e sociais, que garantem a realização dos direitos individuais, de que a liberdade é a expressão mais importante. Os direitos econômicos e sociais são de natureza igualitária, sem os quais os outros não se efetivam realmente. É nesse sentido que também se pode dizer que os direitos humanos fundamentais são valores da democracia. Vale dizer: ela deve existir para realizá-los, com o que estará concretizando a justiça social.

A insuficiência da democracia em realizar esses valores até o momento, no plano concreto, não retira sua validade, pois, como dissemos, ela é um conceito histórico, tanto quanto os valores que busca garantir, o que ela nem sempre consegue pacificamente. Ao contrário, por ser governo do povo, pelo povo e para o povo, só se firma na luta incessante, no embate constante, não raro na via revolucionária, inclusive quanto ao próprio conceito de povo que é essencial à idéia de democracia.

30. Cf. *Princípios gerais do direito constitucional moderno*, t. I/181.

31. Cf., para pormenores, Ernesto Saa Velasco, *Teoría constitucional general*, pp. 197 e ss.

6. O poder democrático e as qualificações da democracia

O que dá essência à democracia é o fato de o poder residir no povo. Toda democracia, para ser tal, repousa na vontade popular no que tange à fonte e exercício do poder, em oposição aos regimes autocráticos em que o poder emana do chefe, do caudilho, do ditador.

Vale dizer, portanto, que o conceito de democracia fundamenta-se na existência de um vínculo entre povo e poder. Como este recebe qualificações na conformidade de seu objeto e modo de atuação, chamando-se *poder político*, *poder econômico*, *poder social*, a liberação democrática vai-se estendendo, com o correr do tempo, a esses modos de atuação do poder. Isto é, a democratização do poder é fenômeno histórico, daí o aparecimento de qualificações da democracia para denotar-lhe uma nova faceta: democratização do poder político, *democracia política*; democratização do poder social, *democracia social*; democratização do poder econômico, *democracia econômica*. São incrementos e ajustamentos no conteúdo da democracia. Jorge Xifras Heras anota, contudo, que o simples reconhecimento desse vínculo significa bem pouco, porquanto a relação *povo-governo* oferece várias possibilidades de interpretação, não só distintas, mas até mesmo contraditórias.

Assim, se se considera o vínculo sob a perspectiva formal, a relação *povo-governo* refere-se apenas à formação do governo; se se parte do critério substancial, a relação *povo-governo* converte-se numa relação de poder, e a democracia num governo de ação popular; se tivermos em vista o critério teleológico, a relação *povo-governo* pode concentrar-se no propósito de garantir a liberdade e a *democracia será puramente política*, ou poderá visar à consolidação da soberania do povo através da instituição de um regime de *democracia social*.³²

Foi com base nas transformações populares e nesse vínculo *povo-poder* que Burdeau construiu sua doutrina das três formas de democracia: (a) a *democracia governada*; (b) a *democracia governante de tipo ocidental*; (c) a *democracia governante de tipo marxista*.³³ A democracia governada, que corresponde à democracia política burguesa do Estado Liberal, foi “construída racionalmente, porque nasceu, não de uma rebelião da fome, mas da especulação de escritores políticos, o impulso moral é o civismo, a virtude mais heróica; o impulso político do cidadão, quer dizer, um tipo de homem que só a cultura e a razão produzem. Disso resulta que, em tal regime, quem governa é o cidadão, enquanto os homens reais, com suas vinculações pessoais, seus interesses e suas ambições, são governados”.³⁴ A *democracia*

32. Cf. *Derecho constitucional*, t. II/21 e 22.

33. Cf. *Traité de science politique*, t. V/581

34. Cf. Burdeau, *La democracia*, p. 40.

governante de tipo ocidental, que se filia à governada por seu caráter essencial de respeito ao pluralismo das idéias de direito graças ao ordenamento constitucional de um poder aberto, constitui-se com base na vontade do povo real, coletividade sociológica, enquanto a *democracia governante de tipo marxista*, que também se fundamenta na vontade do povo real e da massa trabalhadora, adota uma idéia de direito oficial, marxista, e uma estrutura de poder fechado, consequência de sua afetação a uma ideologia única e homogênea.³⁵ Esses tipos de democracia governante tendem respectivamente à democracia de conteúdo social (chamada democracia social) e de conteúdo econômico (chamada democracia econômica), respectivamente, embora, na concepção de Burdeau, o conceito de democracia social abranja a ambas, em termos que podemos aceitar, porque trazem implícita a historicidade, quando salienta que seu objetivo se resume na libertação do indivíduo de todas as formas de opressão, para concluir especificamente:

“Politicamente, o objetivo da democracia é a liberação do indivíduo das coações autoritárias, a sua participação no estabelecimento da regra, que, em todos os domínios, estará obrigado a observar. Econômica e socialmente, o benefício da democracia se traduz na existência, no seio da coletividade, de condições de vida que assegurem a cada um a segurança e a comodidade adquirida para a sua felicidade. Uma sociedade democrática é, pois, aquela em que se excluem as desigualdades devidas aos azares da vida econômica, em que a fortuna não é uma fonte de poder, em que os trabalhadores estejam ao abrigo da opressão que poderia facilitar sua necessidade de buscar um emprego, em que cada um, enfim, possa fazer valer um direito de obter da sociedade uma proteção contra os riscos da vida. A democracia social tende, assim, a estabelecer entre os indivíduos uma igualdade de fato que sua liberdade teórica é impotente para assegurar”.³⁶

É preciso, contudo, que fique claro que isso não pode ser entendido como se a democracia fosse um sistema assistencial, que simplesmente visasse suavizar a miséria da massa trabalhadora, mas há de ser concebida como um meio de superar essa miséria, quaisquer que sejam os recursos que ela empregue.

7. Conceito de povo e democracia

O conceito, que se deve a Lincoln, de que a *democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo*, tem suas limitações, mas é essencial-

mente correto, se dermos interpretação real aos termos que o compõem. As limitações se acham especialmente no definir democracia como *governo*, quando ela é muito mais do que isso: é regime, forma de vida e, principalmente, processo. É também *formal*, mas essa limitação desaparece com aquela interpretação, que tentaremos empreender rapidamente em seguida.

Governo *do povo* significa que este é fonte e titular do poder (*tudo poder emana do povo*), de conformidade com o princípio da soberania popular que é, pelo visto, o princípio fundamental de todo regime democrático. Governo *pelo povo* quer dizer governo que se fundamenta na vontade popular, que se apóia no *consentimento popular*; governo democrático é o que se baseia na adesão livre e voluntária do povo à autoridade, como base da legitimidade do exercício do poder, que se efetiva pela técnica da *representação política* (*o poder é exercido em nome do povo*). Governo *para o povo* há de ser aquele que procure liberar o homem de toda imposição autoritária e garantir o máximo de segurança e bem-estar.³⁷

A insuficiência é, não obstante, manifesta pelas limitações apontadas no conceito, que fica ainda incompreendido e incompleto se não se tiver em mente o que se entende por *povo*. Repetimos sempre: toda democracia assenta suas bases no povo. Mas que se entende por povo? Para a democracia grega, *povo* era apenas o conjunto dos homens livres, excluída ainda a massa dos libertos. Como a maioria dos indivíduos era escrava e libertos, os quais não gozavam da cidadania, não entravam no conceito de povo, aquela democracia era o regime da minoria e em seu favor existia. Para a democracia liberal, povo era equiparado a uma construção ideal, alheia a toda realidade sociológica, não era o ser humano situado, mas um povo de *cidadãos*, isto é, indivíduos abstratos e idealizados, frutos do racionalismo e do mecanicismo, que, prescindindo de toda consideração histórica, informa o constitucionalismo do século XIX.³⁸ A democracia liberal deforma o conceito de povo. Nela o povo real, concreto, com seus defeitos e qualidades, permanece alheio ao exercício do poder, e na realidade não é mais que um poder sobre o povo, como observa Xifras Heras.³⁹

Há uma tendência reacionária para reduzir o povo ao conjunto dos cidadãos, ao corpo eleitoral, como se os membros deste fossem entidades abstratas, desvinculadas da realidade que os cerca, como se ao votar o cidadão não estivesse sob a influência de suas cir-

35. Burdeau, *ob. cit.*, pp. 581 e 608 e ss.

36. Cf. *La democracia*, p. 61 (edição portuguesa, *A Democracia*, p. 44).

37. Sobre essa temática, cf. Xifras Heras, *ob. cit.*, t. II/21 a 38.

38. Cf. Xifras Heras, *ob. cit.*, p. 28, e Burdeau, *La democracia*, p. 30, e *Traité de science politique*, t. V/113 e ss., onde discute amplamente a noção de povo.

39. *Ob. cit.*, p. 28.

cunstâncias de fato e ideológicas, não estivesse fazendo-o sob a influência de seus filhos, seu cônjuge, seu amante, namorado, namorada, noivo, noiva, e também de seu grupo, oficina, fábrica, escritório, mais ainda: de seus temores, da fome dos seus, das alegrias e das tristezas. O corpo eleitoral não constitui o povo, mas simples técnica de designação de agentes governamentais. Povo são os trabalhadores. Os titulares do poder dominante (político, econômico e social) não podem entrar no conceito de povo, pois, numa democracia, teriam que ser simplesmente representantes do povo, isto é, os que exercem o poder em nome do povo. O fato de não ser assim na prática concreta das democracias vigentes demonstra apenas que a democracia ainda não atingiu as culminâncias a que sua historicidade aponta.

8. Exercício do poder democrático

A forma pela qual o povo participa do poder dá origem a três tipos de democracia, qualificadas como *direta*, *indireta* ou *representativa* e *semidireta*.

Democracia direta é aquela em que o povo exerce, por si, os poderes governamentais, fazendo leis, administrando e julgando; constitui reminiscência histórica.

Democracia indireta,⁴⁰ chamada *democracia representativa*, é aquela na qual o povo, fonte primária do poder, não podendo dirigir os negócios do Estado diretamente, em face da extensão territorial, da densidade demográfica e da complexidade dos problemas sociais, outorga as funções de governo aos seus representantes, que elege periodicamente.

Democracia semidireta é, na verdade, democracia representativa com alguns institutos de participação direta do povo nas funções de governo, institutos que, entre outros, integram a *democracia participativa*.

A democracia não teme, antes requer, a participação ampla do povo e de suas organizações de base no processo político e na ação governamental. Nela, as restrições a essa participação não de limitar-se tão-só às situações de possível influência antidemocrática, como as irreelegibilidades e inelegibilidades por exercício de funções, empregos ou cargos, ou de atividades econômicas, que possam impedir a liberdade do voto, a normalidade e a legitimidade das eleições (art.

40. Anote-se, de passagem, que democracia indireta é conceito diverso de eleições indiretas.

14, §§ 5º a 9º). Por outro lado, é sabido que o povo há de ser concebido como o conjunto de indivíduos concretos, situados, com suas qualidades e defeitos, e não como entes abstratos. Embora os tempos atuais não permitam, dada a complexidade da organização social, que se retorne ao mandato imperativo, é certo que há mecanismos capazes de dar à representação política certa concreção. Tais mecanismos são a atuação partidária livre, a possibilidade de participação permanente do povo no processo político e na ação governamental por meio de institutos de democracia direta, que veremos. Não se há de pretender eliminar a representação política para substituí-la por representação orgânica ou profissional antidemocrática, mas se deverá possibilitar a atuação das organizações populares de base na ação política.

9. Democracia representativa

É no regime de democracia representativa que se desenvolvem a *cidadania* e as questões da *representatividade*, que tende a fortalecer-se no regime de democracia participativa. A Constituição combina representação e participação direta, tendendo, pois, para a democracia participativa. É o que, desde o parágrafo único do art. 1º, já está configurado, quando, aí, se diz que *todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos* (democracia representativa), *ou diretamente* (democracia participativa). Consagram-se, nesse dispositivo, os princípios fundamentais da ordem democrática adotada. Outros preceitos, que veremos, oferecem os desdobramentos para seu funcionamento.

É uma temática que merece reflexão crítica. Pois, se toda democracia importa na *participação do povo no processo do poder*, nem toda democracia é *participativa*, no sentido contemporâneo da expressão.

A *democracia representativa* pressupõe um conjunto de instituições que disciplinam a participação popular no processo político, que vem a formar os direitos políticos que qualificam a cidadania, tais como as eleições, o sistema eleitoral, os partidos políticos etc., como constam dos arts. 14 a 17 da Constituição, que merecerão consideração especial, mais adiante, quando formos tratar dos direitos políticos.

Na democracia representativa a participação popular é indireta, periódica e formal, por via das instituições eleitorais que visam a disciplinar as técnicas de escolha dos *representantes do povo*. A ordem democrática, contudo, não é apenas uma questão de eleições periódicas, em que, por meio do voto, são escolhidas as autoridades governamentais. Por um lado, ela consubstancia um procedimento técnico

co para a designação de pessoas para o exercício de funções governamentais. Por outro, eleger significa expressar preferência entre alternativas, realizar um ato formal de decisão política. Realmente, nas democracias de partido e sufrágio universal, as eleições tendem a ultrapassar a pura função designatória, para se transformarem num instrumento, pelo qual o povo adere a uma política governamental e confere seu consentimento, e, por consequência, legitimidade, às autoridades governamentais. Ela é, assim, o modo pelo qual o povo, nas democracias representativas, participa na formação da vontade do governo e no processo político.⁴¹

10. O mandato político representativo

A eleição gera, em favor do eleito, o *mandato político representativo*, que constitui o elemento básico da democracia representativa.

Nele se consubstanciam os *princípios da representação e da autoridade legítima*. O primeiro significa que o poder, que reside no povo, é exercido, em seu nome, por seus representantes periodicamente eleitos, pois uma das características do mandato é ser temporário.⁴² O segundo consiste em que o mandato realiza a técnica constitucional por meio da qual o Estado, que carece de vontade real e própria, adquire condições de manifestar-se e decidir, porque é pelo mandato que se constituem os órgãos governamentais, dotando-os de titulares e, pois, de vontade humana, mediante os quais a vontade do Estado é formulada, expressada e realizada, ou, por outras palavras, o poder se impõe.

O mandato se diz *político-representativo* porque constitui uma situação jurídico-política com base na qual alguém, designado por via eleitoral, desempenha uma função política na democracia representativa. É denominado *mandato representativo* para distinguir-se do *mandato de direito privado* e do *mandato imperativo*. O primeiro é um contrato pelo qual o outorgante confere ao outorgado poderes para

representá-lo em algum negócio jurídico, praticando atos em seu nome, nos termos do respectivo instrumento (procuração); nele o mandatário fica vinculado ao mandante, tendo que prestar contas a este, e será responsável pelos excessos que cometer no seu exercício, podendo ser revogado quando o mandante assim o desejar. O mandato imperativo vigorou antes da Revolução Francesa, de acordo com o qual seu titular ficava vinculado a seus eleitores, cujas instruções teria que seguir nas assembleias parlamentares; se aí surgisse fato novo, para o qual não dispusesse de instrução, ficaria obrigado a obtê-la dos eleitores, antes de agir; estes poderiam cassar-lhe a representação. Aí o princípio da revogabilidade do mandato imperativo.

O *mandato representativo* é criação do Estado liberal burguês, ainda como um dos meios de manter distintos Estado e sociedade, e mais uma forma de tornar abstrata a relação povo-governo. Segundo a teoria da representação política, que se concretiza no mandato, o representante não fica vinculado aos representados, por não se tratar de uma relação contratual; é *geral, livre, irrevogável* em princípio, e não comporta ratificação dos atos do mandatário. Diz-se *geral*, porque o eleito por uma circunscrição ou mesmo por um distrito não é representante só dela ou dele, mas de *todas as pessoas* que habitam o território nacional. É *livre*, porque o representante não está vinculado aos seus eleitores, de quem não recebe instrução alguma, e se receber não tem obrigação jurídica de atender, e a quem, por tudo isso, não tem que prestar contas, juridicamente falando, ainda que politicamente o faça, tendo em vista o interesse na reeleição. Afirma-se, a propósito, que o exercício do mandato decorre de poderes que a Constituição confere ao representante, que lhe garantem a autonomia da vontade, sujeitando-se apenas aos ditames de sua consciência. É *irrevogável*, porque o eleito tem o direito de manter o mandato durante o tempo previsto para sua duração (cf. nota 42), salvo perda nas hipóteses indicadas na própria Constituição (arts. 55 e 56). Em alguns países é possível a revogação do mandato por certo número de votos dos eleitores, é o caso de *recall* nos EUA e era o da revocação na antiga União Soviética. Os constituintes recusaram incluir a destituição de mandatos em certos casos, conforme várias propostas apresentadas. Ficamos, pois, com o princípio do mandato irrevogável.

Há muito de ficção, como se vê, no mandato representativo. Pode-se dizer que não há representação, de tal sorte que a designação de mandatário não passa de simples técnica de formação dos órgãos governamentais. E só a isso se reduziria o princípio da participação popular, o princípio do governo pelo povo na democracia representativa. E, em verdade, não será um governo de expressão da vontade popular, desde que os atos de governo se realizam com base na vonta-

41. Cf. Nils Diederich, "Elecciones, sistemas electorales", in *Marxismo y democracia* (Enciclopedia de conceptos básicos): política 3, p. 1.

42. Essas exigências do mandato representativo decorrem de normas expressas da Constituição. Assim, o princípio da forma representativa consta do parágrafo único do art. 1º, quando diz que o *poder é exercido* diretamente ou *em seu nome por representantes eleitos* e no art. 34, VII, *a*, quando destaca a *forma republicana, representativa e democrática* como um dos princípios constitucionais. A temporariedade do mandato é explicitamente fixada em *quatro anos* para Deputados, Governadores, Vice-Governador, Prefeito e Vice-Prefeito (arts. 27, 28, 29, I, 32, §§ 1º e 2º, 44, parágrafo único), em *oito anos* para Senadores (art. 46, § 1º) e em *quatro anos* para Presidente e Vice-Presidente da República (art. 82).

de autônoma do representante. Nesses termos, a democracia representativa acaba fundando-se numa idéia de igualdade abstrata perante a lei, numa consideração de homogeneidade, e assenta-se no princípio individualista que considera a participação, no processo do poder, do eleitor individual no momento da votação, o qual “não dispõe de mais influência sobre a vida política de seu país do que a momentânea de que goza no dia da eleição, por certo relativizada por disciplina ou automatismo partidário e pela pressão dos meios de informação e da desinformação da propaganda; que, uma vez produzida a eleição, os investidos pela representação ficam desligados de seus eleitores, pois não os representam a eles em particular, mas a todo o povo, à nação inteira”.⁴³ A representação é montada sobre o mito da “identidade entre povo e representante popular” que tende “a fundar a crença de que, quando este decide é como se decidisse aquele, que o segundo resolve pelo primeiro, que sua decisão é a decisão do povo;... que, em tal suposição, o povo se autogoverna, sem que haja desdobramento, atividade, relação intersubjetiva entre dois entes distintos; o povo, destinatário das decisões, e o representante, autor, autoridade, que decide para o povo”.⁴⁴

Contudo, a evolução do processo político vem incorporando outros elementos na democracia representativa que promovem uma relação mais estreita entre os mandatários e o povo, especialmente os instrumentos de coordenação e expressão da vontade popular: partidos políticos, sindicatos, associações políticas, comunidades de base, imprensa livre, de tal sorte que a opinião pública — *expressão da cidadania* — acaba exercendo um papel muito importante no sentido de que os eleitos prestem mais atenção às reivindicações do povo, mormente às de suas bases eleitorais. O sistema de partidos políticos, especialmente, tende a dar feição imperativa ao mandato político, na medida em que os representantes partidários estejam comprometidos com o cumprimento de programa e diretrizes de sua agremiação. É claro que essa natureza de mandato imperativo, em função da orientação do partido, se tornará cada vez mais uma vinculação ao povo, na proporção em que os partidos se façam mais democráticos, com seus órgãos dependentes de mais ampla vontade de seus filiados. Então, a questão se apresenta com duas faces: em relação aos partidos de massa e de estrutura interna democrática, o *mandato partidário* (pois, assim deverá ser chamado o mandato representativo que se faça por meio de partido político) realizará uma tendência de mandato imperativo de caráter popular e democrático,

43. Cf. Luis Carlos Sáchica, *Democracia, representación, participación*, p. 14.

44. Idem, p. 15.

especialmente se a infidelidade partidária causar a perda do mandato; em relação, porém, aos partidos de quadro, ao contrário, realizará uma função de mandato imperativo de caráter oligárquico, o que, em certo sentido, ainda acontece entre nós, com alguma propensão ao primeiro tipo, que só não se efetiva dada a interferência constante do poder na estrutura partidária.

O tipo de sistema eleitoral também exerce influência na representatividade, especialmente se tivermos em conta que forma com o sistema de partidos políticos dois mecanismos de expressão da vontade popular na escolha dos governantes. O sistema de representação proporcional, especialmente, consoante veremos, favorece a melhor e mais equitativa representatividade do povo, visto como, por ele, a representação, em determinada circunscrição, se distribui em proporção às correntes ideológicas ou de interesse integradas nos partidos políticos.

11. Democracia participativa

O que se quis acentuar com as considerações supra é que o sistema de partidos, com o sufrágio universal e a representação proporcional, dá à democracia representativa um sentido mais concreto, no qual desponta com mais nitidez a *idéia de participação*, não tanto a individualista e isolada do eleitor no só momento da eleição, mas a coletiva organizada. Mas será ainda participação representativa, que assenta no princípio eleitoral. Ora, qualquer forma de participação que dependa de eleição não realiza a democracia participativa no sentido atual dessa expressão. A eleição consubstancia o princípio representativo, segundo o qual o eleito pratica atos em nome do povo.

O *princípio participativo* caracteriza-se pela participação direta e pessoal da cidadania na formação dos atos de governo.

As primeiras manifestações da democracia participativa consistem nos institutos de *democracia semidireta*, que combinam instituições de participação direta com instituições de participação indireta, tais como:

— a *iniciativa popular* pela qual se admite que o povo apresente projetos de lei ao legislativo, desde que subscritos por número razoável de eleitores, acolhida no art. 14, III, e regulada no art. 61, § 2º; o projeto precisa ser subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional (cerca de 800.000 eleitores), distribuídos pelo menos em cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles; estatui-se também que lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual, enquanto que, em relação aos Municípios, já se dispôs que a sua lei orgânica adota-

rá a iniciativa popular de leis de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; pena, não ter sido acolhida a iniciativa popular em matéria constitucional;

— o *referendo popular* que se caracteriza no fato de que projetos de lei aprovados pelo legislativo devam ser submetidos à vontade popular, atendidas certas exigências, tais como pedido de certo número de eleitores, de certo número de parlamentares ou do próprio chefe do executivo, de sorte que o projeto se terá por aprovado apenas se receber votação favorável do corpo eleitoral, do contrário, reputar-se-á rejeitado; está previsto no mesmo art. 14, II, sendo da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizá-lo (art. 49, XV), mas a Constituição não estabeleceu as condições de seu exercício; fica livre o Congresso Nacional de autorizá-lo também em matéria constitucional; ele pode mesmo expedir uma lei definindo critérios e requisitos para seu exercício;

— o *plebiscito* é também uma consulta popular, semelhante ao referendo; difere deste no fato de que visa a decidir previamente uma questão política ou institucional, antes de sua formulação legislativa, ao passo que o referendo versa sobre aprovação de textos de projeto de lei ou de emenda constitucional, já aprovados; o referendo ratifica (confirma) ou rejeita o projeto aprovado; o plebiscito autoriza a formulação da medida requerida; alguma vez fala-se em *referendo consultivo* no sentido de plebiscito, o que não é correto.⁴⁵ O plebiscito está previsto no art. 14, I, podendo ser utilizado pelo Congresso Nacional nos casos que este decidir seja conveniente, mas já também indicado em casos específicos, para a formação de novos Estados e de novos Municípios (art. 18, §§ 3º e 4º);⁴⁶

— a *ação popular*, já existente no constitucionalismo brasileiro, desde o Império, mantida no art. 5º, LXXIII, da Constituição, à qual dedicaremos maior espaço mais adiante.

A Constituição adotou outras formas de democracia participativa, como as consagradas nos arts. 10, 11, 31, § 3º, 37, § 3º, 74, § 2º, 194, VII, 206, VI, 216, § 1º.

45. Típico nesse sentido é o referendo consultivo previsto no art. 92 da Constituição Espanhola sobre “decisiones políticas de especial transcendencia”, errônea técnica observada por Juan A. Santamaría, em comentário ao referido dispositivo, in Fernando Garrido Falla e outros, *Comentarios a la constitución*, p. 1.317, nota 4.

46. Importante foi o plebiscito realizado em 21.4.1993, pelo qual o eleitorado definiu a forma de Estado (república e não monarquia constitucional) e o sistema de governo (presidencialismo e não parlamentarismo). Note-se que o *veto popular*, modo de consulta ao eleitorado sobre uma lei existente, visando revogá-la pela votação direta, aprovado no 1º turno pela Assembléia Nacional Constituinte, não vingou ao final.

12. Democracia pluralista

O Estado Democrático de Direito, em que se constitui a República Federativa do Brasil, assegura os valores de uma *sociedade pluralista* (Preâmbulo) e fundamenta-se no *pluralismo político* (art. 1º, V).

A Constituição opta, pois, pela *sociedade pluralista* que respeita a pessoa humana e sua liberdade, em lugar de uma *sociedade monista* que mutila os seres e engendra as ortodoxias opressivas.⁴⁷ O pluralismo é uma realidade, pois a sociedade se compõe de uma pluralidade de categorias sociais, de classes, grupos sociais, econômicos, culturais e ideológicos.⁴⁸ Optar por uma *sociedade pluralista* significa acolher uma sociedade conflitiva, de interesses contraditórios e antinômicos. O problema do pluralismo está precisamente em construir o equilíbrio entre as tensões múltiplas e por vezes contraditórias, em conciliar a sociabilidade e o particularismo, em administrar os antagonismos e evitar divisões irreduzíveis. Aí se insere o papel do poder político: “satisfazer pela edição de medidas adequadas o pluralismo social, contendo seu efeito dissolvente pela unidade de fundamento da ordem jurídica”.⁴⁹

O caráter pluralista da sociedade se traduz, no constitucionalismo ocidental, como nota André Hauriou, “pelo *pluralismo das opiniões* entre os cidadãos, a *liberdade de reunião* onde as opiniões não ortodoxas podem ser publicamente sustentadas (somente, em princípio, a passagem às ações contrárias à ordem pública são vedadas); a *liberdade de associação* e o *pluralismo dos partidos políticos*, o pluralismo das candidaturas e o pluralismo dos grupos parlamentares com assento nos bancos das Assembléias”.⁵⁰ Daí falar-se em pluralismo social, pluralismo político (art. 1º), pluralismo partidário (art. 17), pluralismo econômico (livre iniciativa e livre concorrência, art. 170), pluralismo de idéias e de instituições de ensino (art. 206, III), pluralismo cultural que se infere dos arts. 215 e 216 e pluralismo de meios de informação (art. 220, *caput*, e § 5º). Enfim, a Constituição consagra, como um de seus princípios fundamentais, o princípio pluralista, o que vale dizer encaminha-se para a construção de uma *democracia pluralista*.

É imprescindível, contudo, notar que uma sociedade pluralista conduz à *poliarquia*, conforme ressalta Burdeau com as seguintes palavras: “Politicamente a realidade do pluralismo de fato conduz à

47. Nesse sentido, cf. Georges Burdeau, *Traité de science politique*, t. VII/559.

48. Cf. Burdeau, *ob. cit.*, t. III/169; José Joaquim Gomes Canotilho, *Direito constitucional*, pp. 407 a 409; André Hauriou, *Droit constitutionnel et institutions politiques*, p. 226.

49. Sobre tudo isso, cf. Burdeau, *ob. cit.*, t. VII/560 e 562, e t. I/185.

50. *Ob. cit.*, pp. 225 e 226.

ma de democracia participativa, no qual encontramos *participação por via representativa* (mediante representantes eleitos através de partidos políticos, arts. 1º, parágrafo único, 14 e 17; associações, art. 5º, XXI; sindicatos, art. 8º, III; eleição de empregados junto aos empregadores, art. 11) e *participação por via direta do cidadão* (exercício direto do poder, art. 1º, parágrafo único; iniciativa popular, referendo e plebiscito, já indicados; participação de trabalhadores e empregadores na administração, art. 10, que, na verdade, vai caracterizar-se como uma forma de participação por representação, já que certamente vai ser eleito algum trabalhador ou empregador para representar as respectivas categorias, e, se assim é, não se dá participação direta, mas por via representativa; participação na administração da justiça pela ação popular; participação da fiscalização financeira municipal, art. 31, § 3º; participação da comunidade na seguridade social, art. 194, VII; participação na administração do ensino, art. 206, VI).⁵⁹

A esse modelo, a Constituição incorpora princípios da justiça social e do pluralismo. Assim o modelo é o de uma *democracia social, participativa e pluralista*. Não é, porém, uma democracia socialista, pois o modelo econômico adotado é fundamentalmente capitalista. É preciso, porém, esclarecer que democracia pluralista não é incompatível com socialismo. Reconhece-se que “se possa efetivamente instaurar um sistema socialista em que sejam mantidas as características de uma democracia pluralista: vale dizer, um socialismo operante numa sociedade onde continuem a existir mais formações sociais, habilitadas a exprimir os seus interesses, ideais e materiais, e buscar inseri-los, através dos canais democráticos, na vida política e na ação dos poderes públicos”.⁶⁰

SEGUNDA PARTE

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

59. Sobre o tema, cf. Manuel Ramírez, *ob. cit.*, pp. 66 e ss.

60. Essa é a opinião corrente no campo da “esquerda mediterrânea”, consoante anota Carlo Lavagna, *Costituzione e socialismo*, p. 83, que, no entanto, não parece compartilhar inteiramente com aquela opinião (cf. pp. 83 a 85). Burdeau diz que a democracia pluralista é um regime ao mesmo tempo *liberal*, na medida em que permanece ligado à autonomia da pessoa humana, consagrando todas as liberdades graças às quais o indivíduo se libertou progressivamente da tutela estatal, *socializante*, porque sua legislação estará preocupada em satisfazer imperativos econômicos e sociais do nosso tempo, atribuindo ao Estado tarefas que exigem um aumento da sua autoridade, um reforço de seu controle, o estabelecimento de diretivas e de limitações que excluem o liberalismo econômico (cf. *A democracia*, pp. 72 e 73).

Título I

A Declaração de Direitos

Capítulo I

FORMAÇÃO HISTÓRICA DAS DECLARAÇÕES DE DIREITOS

1. Generalidades. 2. Antecedentes das declarações de direitos. 3. Cartas e declarações inglesas. 4. A Declaração de Virgínia. 5. A Declaração Norte-Americana. 6. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 7. A Declaração do Povo Trabalhador e Explorado. 8. Universalização das declarações de direitos. 9. Declaração de direitos nas constituições contemporâneas. 10. Declaração de direitos nas constituições brasileiras.

1. Generalidades

Iniciamos aqui o estudo dos *direitos fundamentais do homem*, expressão que, na atual Constituição, abrange direitos individuais, políticos, sociais. Teremos que considerar, também, os direitos econômicos. Não nos preocupará, por enquanto, contudo, a questão do conceito e da terminologia respeitante aos direitos do homem. A isso dedicaremos o Capítulo II deste Título, depois que examinarmos as declarações de direitos, cuja evolução e conteúdo nos orientarão na formulação de sua teoria e certamente ajudarão a compreender o conteúdo do nosso Direito positivo sobre a matéria.

2. Antecedentes das declarações de direitos

O reconhecimento dos direitos fundamentais do homem, em enunciados explícitos nas declarações de direitos, é coisa recente, e está longe de se esgotarem suas possibilidades, já que cada passo na etapa da evolução da Humanidade importa na conquista de novos direitos. Mais que conquista, o reconhecimento desses direitos caracteriza-se como reconquista de algo que, em termos primitivos, se perdeu, quando a sociedade se dividira entre proprietários e não proprietários.

Efetivamente, na sociedade primitiva, gentílica, os bens pertenciam, em conjunto, a todos os gentílicos e, então, se verificava uma comunhão democrática de interesses.¹ Não existia poder algum dominante, porque o poder era interno à sociedade mesma. Não ocorria subordinação nem opressão social ou política. O homem buscava liberar-se da opressão do meio natural, mediante descobertas e invenções. Com o desenvolvimento do sistema de apropriação privada, contudo, aparece uma forma social de subordinação e de opressão, pois o titular da propriedade, mormente da propriedade territorial, impõe seu domínio e subordina tantos quanto se relacionem com a coisa apropriada. Surge, assim, uma forma de poder externo à sociedade, que, por necessitar impor-se e fazer-se valer eficazmente, se torna político. E aí teve origem a escravidão sistemática, diretamente relacionada com a aquisição de bens.² O Estado, então, se forma como aparato necessário para sustentar esse sistema de dominação. O homem, então, além dos empecilhos da natureza, viu-se diante de opressões sociais e políticas, e sua história não é senão a história das lutas para delas se libertar, e o vai conseguindo a duras penas. E chegará o dia — ainda segundo Morgan — “em que o intelecto humano se eleva até dominar a propriedade e defina as relações do Estado com a propriedade que salvaguarda e as obrigações e limitações de direitos do seu dono. Os interesses da sociedade são maiores que os dos indivíduos e devem ser colocados em uma relação justa e harmônica. [...] A democracia no governo, a fraternidade na sociedade, a igualdade de direitos e privilégios e a educação universal antecipam o próximo plano mais elevado da sociedade, ao qual a experiência, o intelecto e o saber tendem firmemente. Será uma ressurreição, em forma mais elevada, da liberdade, igualdade e fraternidade das antigas gentes”.³

Certo é que, no correr dessa evolução, alguns antecedentes formais das declarações de direitos foram sendo elaborados, como o veto do tribuno da plebe contra ações injustas dos patrícios em Roma, a lei de Valério Públicola proibindo penas corporais contra cidadãos em certas situações até culminar com o *Interdicto de Homine Libero Exhibendo*, remoto antecedente do *habeas corpus* moderno, que o Direito Romano instituiu como proteção jurídica da liberdade.⁴ Não nos iludamos, contudo, porque essas medidas tinham alcance limitado

1. Cf. Rudolf von Jhering, *L'esprit du Droit Romain dans les diverses phases de son développement*, t. 1/203, § 17; Lewis H. Morgan, *La sociedad primitiva*, p. 531; Friedrich Engels, *A origem da família, da propriedade e do Estado*, p. 150.

2. Cf. Morgan, *ob. cit.*, p. 534.

3. *Ob. cit.*, pp. 543 e 544.

4. Cf. Domingo García Belaunde, *El “habeas corpus” en el Peru*, p. 2.

aos membros da classe dominante, mas, em Atenas, já se lutava pelas liberdades democráticas.⁵ Foi, no entanto, no bojo da Idade Média que surgiram os antecedentes mais diretos das declarações de direitos. Para tanto contribuiu a teoria do direito natural que condicionou o aparecimento do princípio das leis *fundamentais do Reino* limitadoras do poder do monarca, assim como o conjunto de princípios que se chamou *humanismo*. Aí floresceram os *pactos*, os *forais* e as *cartas de franquias*,⁶ outorgantes de proteção de direitos reflexamente individuais, embora diretamente grupais, estamentais, dentre os quais mencionam-se, por primeiro, os espanhóis: de León e Castela de 1188, pelo qual o Rei Afonso IX jurara sustentar a justiça e a paz do reino, articulando-se, em preceitos concretos, as garantias dos mais importantes direitos das pessoas, como a segurança, o domicílio, a propriedade, a atuação em juízo etc.; de Aragão, que continha reconhecimento de direitos, limitados aos nobres, porém (1265);⁷ o de Viscaia (1526), reconhecendo privilégios, franquias e liberdades existentes ou que por tal acordo foram reconhecidos.⁸ O mais famoso desses documentos é a *Magna Carta* inglesa (1215-1225), a que faremos referência mais devagar em seguida. Agora, além do *Mayflower Compact* de 1620, por si só um documento de garantia de governo limitado, cumpre recordar também as várias Cartas de direitos e liberdades das Colônias Inglesas na América: *Charter of New England*, 1620; *Charter of Massachusetts Bay*, 1629; *Charter of Maryland*, 1632; *Charter of Connecticut*, 1662; *Charter of Rhode Island*, 1663; *Charter of Carolina*, 1663; *Charter of Georgia*, 1732; e ainda: *Massachusetts Body of Liberties*, 1641; *New York Charter of Liberties*, 1683; *Pennsylvania Charter of Privileges*, 1701.⁹

3. Cartas e declarações inglesas

Na Inglaterra, elaboraram-se cartas e estatutos assecuratórios de direitos fundamentais, como a *Magna Carta* (1215-1225), a *Petition of Rights* (1628), o *Habeas Corpus Amendment Act* (1679) e o *Bill of Rights* (1688). Não são, porém, declarações de direitos no sentido moderno, que só apareceram no século XVIII com as Revoluções americana e francesa. Tais textos, limitados e às vezes estamentais, no entanto,

5. Cf. Gustave Glotz, *A cidade grega*, pp. 99 e ss.

6. Sobre eles, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de direito constitucional*, pp. 12 e ss.

7. Cf. José Castán Tobeñas, *Los derechos del hombre*, pp. 85 e ss.

8. García Belaunde, *ob. cit.*, pp. 5 a 7.

9. Cf. Bernard Schwartz, *The great rights of mankind: a history of the American Bill of Rights*, pp. 27 e 35.

condicionaram a formação de regras consuetudinárias de mais ampla proteção dos direitos humanos fundamentais. Realmente a estabilidade e o sempre firme desenvolvimento das instituições inglesas bastaram para tornar ociosa uma lista maior das liberdades públicas.¹⁰ A constante afirmação do Parlamento inglês e dos precedentes judiciais, formando a *common law*, fora suficiente, com aqueles documentos históricos, para assentar o mais firme respeito pelos direitos fundamentais do homem.

É dispensável descer à análise dos citados textos. Lembremos apenas que a *Magna Carta*, assinada em 1215 mas tornada definitiva só em 1225, não é de natureza constitucional, “longe de ser a Carta das liberdades nacionais, é, sobretudo, uma carta feudal, feita para proteger os privilégios dos barões e os direitos dos homens livres. Ora, os homens livres, nesse tempo, ainda eram tão poucos que podiam contar-se, e nada de novo se fazia a favor dos que não eram livres”.¹¹ Essa observação de Noblet é verdadeira, mas não exclui o fato de que ela se tornasse um símbolo das liberdades públicas, nela consubstanciando-se o esquema básico do desenvolvimento constitucional inglês e servindo de base a que juristas, especialmente Edward Coke com seus comentários, extraíssem dela os fundamentos da ordem jurídica democrática do povo inglês.¹²

A *Petição de Direitos* (*Petition of Rights*, 1628), como o nome indica, é um documento dirigido ao monarca em que os membros do Parlamento de então pediram o reconhecimento de diversos direitos e liberdades para os súditos de sua majestade. A petição constituiu um meio de transação entre Parlamento e rei, que este cedeu, porquanto aquele já detinha o poder financeiro, de sorte que o monarca não poderia gastar dinheiro sem autorização parlamentar. Então, precisando de dinheiro, assentiu no pedido, respondendo-o nos termos seguintes: “*Qua quidem petitione lecta et plenius intellecta per dictum dominium regem taliter est responsum in pleno parlamento, viz. Soi droit fait come est desiré*”.¹³ Na verdade, a petição pede a observância de direitos e liberdades já reconhecidos na própria *Magna Carta*, espe-

10. Cf. D. C. M. Yardley, *Introduction to british constitutional law*, pp. 84 e ss.

11. Cf. Albert Noblet, *A democracia inglesa*, p. 28.

12. Cf., a propósito, Roscoe Pound, *Desenvolvimento das garantias constitucionais da liberdade*, pp. 17 e ss. Sobre o valor da *Magna Carta*, idem, pp. 35 e ss. Sobre os comentários de Coke, em *Segundo Instituto*.

13. “Petição que, de fato, tendo sido lida e inteiramente compreendida pelo dito senhor rei foi respondida em Parlamento pleno, isto é: Seja feito o direito conforme se deseja”. Cf. texto da petição e dessa resposta em Pound, *ob. cit.*, pp. 134-137, e nota 108. Cf. também Maurice Duverger, *Constitutions et documents politiques*, pp. 463 a 465.

cialmente no seu art. 39: “Nenhum homem livre será detido nem preso, nem despojado de seus direitos nem de seus bens, nem declarado fora da lei, nem exilado, nem prejudicada a sua posição de qualquer outra forma; tampouco procederemos com força contra ele, nem mandaremos que outrem o faça, a não ser por um julgamento legal de seus pares e pela lei do país”. O fato denota que tais mandamentos, entre outros, não eram respeitados pelo poder monárquico, que só aos poucos, com o crescimento e afirmação das instituições parlamentares e judiciais, foi cedendo às imposições democráticas.

O *Habeas Corpus Act* reforçou as reivindicações de liberdade, trazendo-se, desde logo, e com as alterações posteriores, na mais sólida garantia de liberdade individual, e tirando aos déspotas uma das suas armas mais preciosas, suprimindo as prisões arbitrárias.¹⁴

O documento mais importante é a *Declaração de Direitos* (*Bill of Rights*, 1688) que decorreu da Revolução de 1688, pela qual se firmara a supremacia do Parlamento, impondo a abdicação do rei Jaime II e designando novos monarcas, Guilherme III e Maria II, cujos poderes reais limitavam com a declaração de direitos a eles submetida e por eles aceita. Daí surge, para a Inglaterra, a monarquia constitucional, submetida à soberania popular (superada a realeza de direito divino), que teve em Locke seu principal teórico e que serviu de inspiração ideológica para a formação das democracias liberais da Europa e da América nos séculos XVIII e XIX. O *Act of Settlement* (Ato de Sucessão no Trono), votado pelo Parlamento em 1707, completa o conjunto de limitações ao poder monárquico nesse período.

4. A Declaração de Virgínia

A primeira declaração de direitos fundamentais, em sentido moderno, foi a *Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia*, que era uma das treze colônias inglesas na América. Essa declaração é de 12.1.1776, anterior, portanto, à Declaração de Independência dos EUA. Ambas, contudo, inspiradas nas teorias de Locke, Rousseau e Montesquieu, versadas especialmente nos escritos de Jefferson e Adams, e postas em prática por James Madison, George Mason e tanto outros.¹⁵

A Declaração de Virgínia consubstanciava as bases dos direitos do homem, tais como: (1) todos os homens são por natureza igual-

14. Cf. Noblet, *ob. cit.*, p. 85. Sobre o desenvolvimento do *habeas corpus* inglês, cf. O. Hood Phillips, *Constitutional and administrative law*, pp. 401 e ss.; igualmente, R. J. Sharpe, *The Law of Habeas Corpus*, London, Clarendon Press, 1976.

15. Sobre a formação da Declaração de Virgínia, cf. Schwartz, *ob. cit.*, pp. 67 e ss.

mente livres e independentes; (2) todo o poder está investido no povo e, portanto, dele deriva, e os magistrados são seus depositários e servos, e a todo tempo por ele responsáveis; (3) o governo é, ou deve ser, instituído para o comum benefício, proteção e segurança do povo, nação ou comunidade; (4) ninguém tem privilégios exclusivos nem os cargos ou serviços públicos serão hereditários; (5) os Poderes Executivo e Legislativo do Estado deverão ser separados e distintos do Judiciário e, para garantia contra a opressão, os membros dos dois primeiros teriam que ter investidura temporária e as vagas seriam preenchidas por eleições freqüentes, certas e regulares; (6) as eleições dos representantes do povo devem ser livres; (7) é ilegítimo todo poder de suspensão da lei ou de sua execução, sem consentimento dos representantes do povo; (8) assegurado o direito de defesa nos processos criminais, bem como julgamento rápido por júri imparcial, e que ninguém seja privado de liberdade, exceto pela lei da terra ou por julgamento de seus pares; (9) vedadas fianças e multas excessivas e castigos cruéis e extraordinários; (10) vedada a expedição de mandados gerais de busca ou de detenção, sem especificação exata e prova do crime; (11) a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da liberdade; (12) “que a milícia bem regulada, composta de elementos do povo, com prática das armas, constitui a defesa própria, natural e segura de um Estado livre; que os exércitos permanentes, em tempo de paz, devem ser evitados, como perigosos para a liberdade; e que, em todos os casos, o militar deve ficar sob rigorosa subordinação ao poder civil e por ele governado”; (13) todos os homens têm igual direito ao livre exercício da religião com os ditames da consciência.

Vê-se que, basicamente, a Declaração se preocupava com a estrutura de um governo democrático, com um sistema de limitação de poderes. Os textos ingleses apenas tiveram por finalidade limitar o poder do rei, proteger o indivíduo contra a arbitrariedade do rei e firmar a supremacia do Parlamento. As Declarações de Direitos, iniciadas com a da Virgínia, importam em limitações do poder estatal como tal, inspiradas na crença na existência de direitos naturais e imprescritíveis do homem.¹⁶ Contudo a Declaração de Independência, de autoria de Thomas Jefferson e posterior à Declaração de Virgínia, pois é de 4.7.1776, teve maior repercussão, ainda que não tivesse natureza jurídica como esta última. Nela se destaca especialmente o seguinte trecho: “Consideramos estas verdades como evidentes de per si, que todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de

certos direitos inalienáveis; que, entre estes, estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade; que, a fim de assegurar esses direitos, instituem-se entre os homens os governos, que derivam seus justos poderes do consentimento dos governados; que, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para lhe realizar a segurança e a felicidade”.¹⁷

5. A Declaração Norte-Americana

A Constituição dos EUA aprovada na Convenção de Filadélfia, em 17.9.1787, não continha inicialmente uma declaração dos direitos fundamentais do homem. Sua entrada em vigor, contudo, dependia da ratificação de pelo menos nove dos treze Estados independentes, ex-colônias inglesas na América, com que, então, tais Estados soberanos se uniriam num Estado Federal, passando a simples Estados-membros deste. Alguns, entretanto, somente concordaram em aderir a esse pacto se se introduzisse na Constituição uma *Carta de Direitos*, em que se garantissem os direitos fundamentais do homem. Isso foi feito, segundo enunciados elaborados por Thomas Jefferson e James Madison, dando origem às dez primeiras Emendas à Constituição de Filadélfia, aprovadas em 1791, às quais se acrescentaram outras até 1975, que constituem o *Bill of Rights* do povo americano, em que se asseguram os seguintes direitos fundamentais:

- (1) liberdade de religião e culto, de palavra, de imprensa, de reunião pacífica e direito de petição (Emenda 1ª);
- (2) inviolabilidade da pessoa, da casa, de papéis e posses de objetos (Emenda 4ª);
- (3) direito de defesa e de um julgamento por juiz natural e de acordo com o devido processo legal, isto é, com garantias legais suficientes (Emenda 5ª);
- (4) garantia do direito de propriedade, de que não se poderá privar senão para uso público e com justa compensação (Emenda 5ª);
- (5) direito a julgamento público e rápido por júri imparcial do Estado e distrito em que o crime tenha sido cometido, com direito a provas de defesa e assistência de um advogado (Emenda 6ª);
- (6) vedação de exigências de fiança e multas excessivas, bem como de infligência de penas cruéis ou inusitadas (Emenda 8ª), tal como já previa a Declaração de Virgínia;

16. Cf. Léon Duguit, *Traité de droit constitutionnel*, t. III/601; Georges Burdeau, *Traité de science politique*, t. IV/79.

17. Cf. Thomas Jefferson, *Escritos políticos*, p. 4.

(7) proibição da escravatura e servidão involuntária (Emenda 13^a);

(8) garantia de que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos são cidadãos norte-americanos qualquer que seja sua raça ou cor (Emenda 14^a);

(9) garantia de igual proteção das leis, ou seja: igualdade perante a lei (Emendas 14^a e 27^a);

(10) garantia ao direito de sufrágio igual a todos os cidadãos, que, por isso, não poderá ser restringido por motivo de raça ou cor (Emenda 15^a); como os Estados segregacionistas contornavam essa vedação por meio de um imposto eleitoral, em valor tal que os negros, em geral, não podiam pagar,¹⁸ vem a Emenda 24^a de 1964, para declarar que nem os Estados Unidos nem os Estados-membros poderão denegar ou cercear o direito dos cidadãos ao sufrágio em qualquer eleição para presidente, vice-presidente, senador ou representante no Congresso, por motivo de não haverem pago um imposto eleitoral ou qualquer outro imposto;

(11) direito de voto às mulheres (Emenda 19^a);

(12) proibição de leis retroativas, leis *ex post facto* (constante do corpo da Constituição, n.3 da Seção IX e n.1 da Seção X do Art. I);

(13) proibição de *bill of attainder*, lei de proscrição, que significa considerar ilegítima qualquer medida legislativa colocando pessoas fora da lei, proibindo-as de gozar de qualquer direito (constante do corpo da Constituição, n.3 da Seção IX do Art. I);

(14) proibição de suspensão do *habeas corpus*, a menos que a ordem pública o exija nos casos de rebelião ou de invasão (corpo da Constituição, n. 2 da Seção IX do Art. I);

(15) garantia de que a enumeração de certos direitos na Constituição não seja interpretada como denegação ou diminuição dos outros direitos que o povo se reservou (Emenda 9^a).

Cumprir observar que a Emenda 2^a consignou o direito do povo de possuir e portar armas, mas, à evidência, não se pode considerar tal faculdade como um direito fundamental do homem, e tende mesmo a ser revogada nos EUA. A Emenda 3^a também veda que qualquer soldado seja, em tempo de paz, alojado em qualquer casa sem o consentimento do proprietário, nem em tempo de guerra, salvo na forma estabelecida em lei. Isso era importante na época, mas é claro que, hoje, a garantia está consignada na inviolabilidade do domicí-

18. Sobre isso, cf. Frederic Ogg e P. Orman Ray, *Le gouvernement des États-Unis d'Amérique*, pp. 124 e ss.

lio. A Emenda 10^a contém um princípio federativo: o dos poderes reservados aos Estados.¹⁹

6. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

Os autores costumam ressaltar a influência que a *Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão*, adotada pela Assembléia Constituinte francesa em 27.8.1789, sofreu da Revolução Americana, especialmente da Declaração de Virgínia, já que ela precedeu a Carta dos Direitos, contida nas dez primeiras emendas à Constituição norte-americana, que foi apresentada em setembro de 1789. Na verdade, não foi assim, pois os revolucionários franceses já vinham preparando o advento do Estado Liberal ao longo de todo o século XVIII. As fontes filosóficas e ideológicas das declarações de direitos americanas como a francesa são européias, como bem assinalou Mirkine-Guetzévitch, admitindo que os franceses de 1789 somente tomaram de empréstimo a técnica das declarações americanas, “mas estas não eram, por seu turno, senão o reflexo do pensamento político europeu e internacional do século XVIII — dessa corrente da filosofia humanitária cujo objetivo era a liberação do homem esmagado pelas regras caducas do absolutismo e do regime feudal. E porque essa corrente era geral, comum a todas as Nações, aos pensadores de todos os países, a discussão sobre as origens intelectuais das Declarações de Direitos americanas e francesas não tem, a bem da verdade, objeto. Não se trata de demonstrar que as primeiras Declarações “provêm” de Locke ou de Rousseau. Elas provêm de Rousseau, e de Locke, e de Montesquieu, de todos os teóricos e de todos os filósofos. As Declarações são obra do pensamento político, moral e social de todo o século XVIII”.²⁰

A Declaração de Virgínia e a de outras ex-colônias inglesas na América eram mais concretas, preocupadas mais com a situação particular que afligia aquelas comunidades, enquanto a Declaração francesa de 1789 é mais abstrata, mais “universalizante”, de onde seus três caracteres fundamentais, consoante Jacques Robert: a) *intelectualismo*, porque a afirmação de direitos imprescritíveis do homem e a restauração de um poder legítimo, baseado no consentimento popular, foi uma operação de ordem puramente intelectual que se desenrolaria no plano unicamente das idéias; é que, para os homens de

19. Um bom comentário atualizado da Declaração Americana de Direitos encontra-se em Edward S. Corwin, *A Constituição norte-americana e seu significado atual*, pp. 228 e ss.

20. Cf. Boris Mirkine-Guetzévitch, *Les constitutions européennes*, v. 1/126 e 127; Burdeau, *Traité de science politique*, t. IV/119.

1789, a Declaração dos direitos era antes de tudo um documento filosófico e jurídico que devia anunciar a chegada de uma sociedade ideal; b) *mundialismo*, no sentido de que os princípios enunciados no texto da Declaração pretendem um valor geral que ultrapassa os indivíduos do país, para alcançar *valor universal*; c) *individualismo*, porque só consagra as liberdades dos *indivíduos*, não menciona a liberdade de associação nem a liberdade de reunião; preocupa-se com defender o indivíduo contra o Estado.²¹ É, por isso, o documento marcante do Estado Liberal, e que serviu de modelo às declarações constitucionais de direitos dos séculos XIX e XX, com evoluções que assinalaremos a seu tempo.

Seu título — “Declaração dos Direitos do *Homem* e do *Cidadão*” — dá a impressão de que contém dois tipos de direitos: *Direitos do Homem* e *Direitos do Cidadão*, que seriam distintos. Os primeiros, de caráter pré-social, concernentes ao homem independentemente de sua integração em uma sociedade política, são, nos seus termos, a *liberdade*, a *propriedade* e a *segurança*, isto é: tudo aquilo que os franceses chamam hoje, com duvidosa pertinência, de *liberdades públicas*. Os segundos são direitos que pertencem aos indivíduos enquanto participantes de uma sociedade política,²² e são o direito de resistência à opressão, o direito de concorrer, pessoalmente ou por representantes, para a formação da lei, como expressão da vontade geral, o direito de acesso aos cargos públicos, a despeito de Duguít declarar que os direitos do cidadão, segundo a Declaração de 1789, não são os que nós hoje denominamos direitos políticos, mas, antes, são aquilo que se nomeia, por vezes, direitos civis.²³ Esse autor, todavia, sustenta que os direitos do cidadão não são distintos dos direitos do homem,²⁴ questão que temos que enfrentar mais adiante quando formos cuidar da teoria dos direitos fundamentais do homem.

O texto da Declaração de 1789 é de estilo lapidar, elegante, sintético, preciso e escorreito, que, em dezessete artigos, proclama os princípios da *liberdade*, da *igualdade*, da *propriedade* e da *legalidade* e as garantias individuais liberais que ainda se encontram nas declarações contemporâneas, salvas as liberdades de reunião e de associação que ela desconhecera, firmado que estava numa rigorosa concepção individualista.²⁵

21. Cf. Jacques Robert, *Libertés publiques*, pp. 44 e ss.

22. Cf. Duguít, *ob. cit.*, 3ª ed., t. III/623; Robert, *ob. cit.*, pp. 42 e 43.

23. *Ob. cit.*, p. 625.

24. *Idem*, p. 624.

25. Cf. texto da Declaração em Duverger, *Constitutions et documents politiques*, p. 9.

7. A Declaração do Povo Trabalhador e Explorado

As declarações dos séculos XVIII e XIX voltam-se basicamente para a garantia formal das liberdades, como princípio da democracia política ou democracia burguesa. Isso se explica no fato de que a burguesia, que desencadeara a revolução liberal, estava oprimida apenas politicamente, não economicamente. Daí por que as liberdades da burguesia liberal se caracterizam como *liberdades-resistência* ou como meio de limitar o poder, que, então, era absoluto.²⁶ No entanto, o desenvolvimento industrial e a conseqüente formação de uma classe operária logo demonstraram insuficiência daquelas garantias formais, caracterizadoras das chamadas *liberdades formais*, de sentido negativo, como resistência e limitação ao poder. Pois a opressão não era, em relação a ela, apenas de caráter político formal, mas basicamente econômico. Não vinha apenas do poder político do Estado, mas do poder econômico capitalista. De nada adiantava as constituições e leis reconhecerem liberdades a todos, se a maioria não dispunha, e ainda não dispõe, de condições *materiais* para exercê-las. Sintetiza bem a questão Juan Ferrando Badía, quando escreve: “A burguesia liberal aparenta conceder a todos a liberdade de imprensa, a liberdade de associação, os direitos políticos, as possibilidades de oposição política: mas, de *fato*, tais direitos e liberdades não podem ser exercidos realmente senão pelos capitalistas, que são os que têm os meios econômicos indispensáveis para que tais liberdades sejam reais. E assim, no caso do direito do sufrágio, este serve para camuflar diante dos olhos dos proletários uma *papeleta de voto*, mas a propaganda eleitoral se encontra nas mãos das forças do dinheiro. Simula-se conceder-lhes o direito de formar sindicatos e partidos políticos, mas as oligarquias capitalistas conservam, direta ou indiretamente, o controle”.²⁷

O indivíduo era uma abstração. O homem era considerado sem levar em conta sua inserção em grupos, família ou vida econômica. Surgia, assim, o cidadão como um ente desvinculado da realidade da vida. Estabelecia-se igualdade abstrata entre os homens, visto que deles se despojavam as circunstâncias que marcam suas diferenças no plano social e vital.²⁸ Por isso, o Estado teria que abster-se. Apenas deveria vigiar, ser simples gendarme.

Os socialistas, primeiro os utopistas (Saint-Simon, Fourier, Louis Blanc, Owen e outros), depois os cientistas (Marx, Engels), submetem

26. Sobre a temática, cf. Juan Ferrando Badía, *Democracia frente a autocracia*, pp. 39-50, especialmente.

27. *Ob. cit.*, p. 49.

28. A propósito, cf. Bernard Chenot, *Organization économique de l'État*, pp. 41 e 42.

ram essas concepções abstratas da liberdade, da igualdade e, enfim, do homem a severas críticas, pois, apesar de retoricamente afirmadas e reconhecidas, permitiam medrassem a injustiça e a iniquidade na repartição da riqueza, e prosperasse a miséria das massas proletárias, enquanto o processo acumulativo favorecia, de um lado, o enriquecimento de poucos e, de outro, as crises econômicas ainda mais empobrecedoras e geradoras de desemprego. O *Manifesto Comunista*,²⁹ que, pela sua influência, é comparado por Harold Laski com a Declaração de Independência americana e com a Declaração dos Direitos de 1789,³⁰ foi o documento político mais importante na crítica socialista ao regime liberal-burguês. A partir dele, essa crítica fundamentou-se em bases teóricas e numa concepção da sociedade e do Estado, e se tornou, por isso, mais coerente, provocando, mesmo, o aparecimento de outras correntes e outros documentos, como as encíclicas papais, a começar pela de Leão XIII, *Rerum Novarum*, de 1891.

No plano jurídico, a Revolução de 1848, em Paris, inscreveu, em sua constituição de curta duração, o direito do trabalho,³¹ mas foi a Constituição mexicana de 1917 que, por primeiro, sistematizara o conjunto dos direitos sociais do homem, restrita, no entanto, ao critério de participação estatal na ordem econômica e social, sem romper, assim, em definitivo, com o regime capitalista. A Declaração dos Direitos Sociais (trabalho e previdência social) consta do extenso art. 123 daquele documento constitucional, ainda em vigor.³² No mesmo sentido, seguiu-se a Constituição alemã de Weimar, de 1919, abrindo seu Livro II com a rubrica dos *Direitos e Deveres Fundamentais dos Alemães*, sob a qual inclui os *direitos da pessoa individual* (cap. I), os *direitos da vida social* (cap. II), os da *vida religiosa* (cap. III), os da *educação e escola* (cap. IV) e os da *vida econômica* (cap. V). Os direitos sociais e econômicos, dentro do regime capitalista, estão reconhecidos e garantidos ao lado dos direitos individuais, como na Constituição mexicana, que é mais avançada do que aquela. Mas foi a de Weimar que exercera maior influência no constitucionalismo de pós-Primeira Guerra Mundial, até na brasileira de 1934.

29. Como é sabido, o *Manifesto Comunista* foi elaborado por Marx e Engels e publicado em janeiro de 1848 como plataforma da Liga Comunista.

30. Cf. O *Manifesto Comunista* de Marx e Engels, p. 27.

31. A previsão acha-se no art. 13, pelo qual a Constituição garante "aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie. La société favorise et encourage le développement du travail par l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité de rapports entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance..."

32. Sobre o tema, cf. Jorge Carpizo, *La Constitución mexicana de 1917*, pp. 135 e ss.; Porfirio Marquet Guerrero, *La estructura constitucional del Estado mexicano*, pp. 126 a 141.

Outro sentido, contudo, há de reconhecer-se à *Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado*, aprovada em janeiro de 1918 pelo Terceiro Congresso Panrusso dos Soviéticos. Fundada nas teses socialistas de Marx-Engels-Lênin e consequente da Revolução Soviética de outubro de 1917, não se limitara a reconhecer direitos econômicos e sociais, dentro do regime capitalista, mas a realizar uma nova concepção da sociedade e do Estado e, também, uma nova idéia de direito, que buscasse libertar o homem, de uma vez por todas, de qualquer forma de opressão. Daí começar por constituir a "República dos Soviéticos Obreiros, Soldados e Camponeses", fundada sobre o princípio da livre união de nações livres, propondo suprimir toda exploração do homem pelo homem, abolir definitivamente a divisão da sociedade em classes, esmagar sem piedade todos os exploradores, realizar a organização socialista da sociedade e fazer triunfar o socialismo em todos os países.³³ Essa declaração não reconhece as garantias dos direitos individuais, sendo certo que, em si, não tivera a repercussão e influência universal que se esperava. Isso, talvez, se explique no fato de que logo viera a Constituição Soviética de 10.7.1918, que exprime nela ter-se inspirado, e especialmente no surgimento do estalinismo que dera rumo despótico ao regime estabelecido e, ainda, na circunstância de a Constituição Soviética de 1936 tê-la superado com nova formulação dos direitos fundamentais do homem segundo a concepção socialista soviética. Aliás, dentro de uma visão marxista é plenamente justificada a superação daquela declaração, pois admitir sua eficácia permanente seria pôr-se em posição antimarxista, já que tal postura significaria uma imutabilidade estática e o domínio formalista relativamente a uma realidade dinâmica que não pode conter-se em formas de tal natureza.

8. Universalização das declarações de direitos

O que diferenciou a Declaração de 1789 das proclamadas na América do Norte foi sua vocação universalizante. Sua visão universal dos direitos do homem constituiu uma de suas características marcantes, que já assinalamos com o significado de seu *mundialismo*.³⁴ Essa preocupação repete-se expressamente na Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, da Revolução Soviética, que

33. Cf. texto da Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado in Segundo V. Linares Quintana, *Derecho constitucional soviético*, pp. 33 e ss., e Duverger, *Constitutions et documents politiques*, pp. 612 e ss.

34. Cf. Robert, *Libertés publiques*, p. 46; Castán Tobeñas, *Los derechos del hombre*, p. 99; Philippe de la Chapelle, *La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et le catholicisme*, p. 12.

proclama, como seu objetivo básico: “suprimir toda exploração do homem pelo homem, abolir definitivamente a divisão da sociedade em classes, arrasar, sem piedade, todos os exploradores, realizar a organização socialista da sociedade e fazer triunfar o socialismo em todos os países”. Aliás, as declarações de direitos do século XX procuram consubstanciar duas tendências fundamentais: *universalismo*, implícito já na Declaração francesa de 1789, e *socialismo* (tomada essa expressão em sentido amplo, ligado a social, e não técnico-científico), com a extensão do número dos direitos reconhecidos, o surgimento dos *direitos sociais*, uma inclinação ao condicionamento dos direitos de propriedade e dos demais direitos individuais,³⁵ propensão que refletiu no Direito Constitucional contemporâneo.

O sentido universalizante das declarações de direitos, de caráter estatal, passou a ser objeto de reconhecimento supra-estatal em documentos declaratórios de feição multinacional ou mesmo universal. As primeiras manifestações nesse sentido foram propostas de organismos científicos internacionais, visando estender a defesa dos direitos humanos a todos os países e a todos os indivíduos de todas as nacionalidades, como noticia José Castán Tobeñas,³⁶ de que é exemplo o projeto de “Declaração dos Direitos Internacionais do Homem”, redigido pelo Instituto de Direito Internacional, em 1928-1929.³⁷ Um passo concreto foi dado quando os vinte e um países da América se reuniram em Chapultepec (México) no início do ano de 1945, firmando a tese de que um dos primeiros objetivos das Nações Unidas deveria ser a redação de uma carta dos direitos do homem.³⁸ Daí que a Carta das Nações Unidas (26.6.45) ficara impregnada da idéia do respeito aos *direitos fundamentais do homem*, desde o seu segundo considerando, onde afirma “a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana, na igualdade dos direitos de homens e mulheres e das nações grandes e pequenas”, até as referências contidas nos arts. 1º, item 2; 13, item 1, b; 55, c; 62, item 2; e 76, c.

Delineada na Carta das Nações Unidas, assim, a preocupação com os direitos fundamentais do homem, cumpria dar-lhe consequência sistemática, mediante a redação de uma *Declaração Universal dos Direitos do Homem*. Com esse propósito, criou-se, na ONU, uma Comissão dos Direitos do Homem, cuja presidência coube à Sra. Eleo-

35. Cf. Castán Tobeñas, *ob. cit.*, p. 101, citando Carlos Ollero, *El derecho constitucional de la posguerra*, cap. V.

36. *Ob. cit.*, p. 109.

37. *Idem*, p. 109.

38. Cf. Chapelle, *ob. cit.*, p. 22, que menciona também a proposta do Episcopado americano no mesmo sentido, quando da abertura da Conferência de S. Francisco, em abril de 1945.

nora Roosevelt, esposa do Presidente Franklin D. Roosevelt. Durante a elaboração do texto, com base especialmente em projeto de autoria do Prof. René Cassin, várias questões teóricas se configuraram, como, por exemplo, se deveria ser uma Declaração ou uma Convenção, o que tinha importância para a sua maior ou menor efetividade, pois a primeira forma não dotava o instrumento, segundo alguns, de força obrigatória. Foi, no entanto, a que prevaleceu. Questão mais importante, contudo, foi a de saber como chegar, numa mesma Declaração, a defender os direitos individuais tradicionais e, ao mesmo tempo, destacar a importância dos novos direitos sociais.³⁹ Sobre isso, Philippe de la Chapelle ressalta a colaboração de Bogomolov, representante soviético, que deu eficaz ajuda na redação dos artigos concernentes aos direitos econômicos, sociais e culturais da Declaração, que fora aprovada na noite de 10.12.48, na terceira sessão ordinária da Assembléia Geral da ONU, realizada em Paris.

A *Declaração Universal dos Direitos do Homem* contém trinta artigos, precedidos de um Preâmbulo com *sete considerandos*, em que reconhece solenemente: a *dignidade da pessoa humana*, como base da liberdade, da justiça e da paz; o *ideal democrático* com fulcro no progresso econômico, social e cultural; o direito de *resistência à opressão*; finalmente, a *concepção comum desses direitos*. Constitui o Preâmbulo com a proclamação, pela Assembléia Geral da ONU, da referida Declaração, “o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da Sociedade, tendo esta Declaração constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensinamento e pela educação, a desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e assegurar-lhes, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o reconhecimento e a aplicação universais e efetivos [...]”.

Os trinta artigos reconhecem os direitos fundamentais do homem. Do art. 1º ao art. 21 encontramos a proclamação dos tradicionalmente chamados *direitos e garantias individuais*, certamente impregnados de conotações mais modernas, tais como: igualdade, dignidade, não discriminação; direito à vida, à liberdade (de locomoção, de pensamento, de consciência, de religião, de opinião, de expressão, de reunião e de associação), à segurança pessoal, à nacionalidade, de asilo, de propriedade; condenação da escravidão, da servidão, da tortura, de penas ou tratamentos cruéis, inumanos ou degradantes; reconhecimento da personalidade jurídica; respeito à intimidade (pessoal, familiar, epistolar e do domicílio); direito de constituição de família; direito de circular e de escolher a residência; proteção igual

39. Cf. Chapelle, *ob. cit.*, p. 41.

perante os tribunais, garantia contra medidas arbitrárias; de plena defesa, de não retroatividade da lei penal e presunção de inocência até julgamento final; direitos políticos de participação no governo, de votar e ser votado, de acesso às funções públicas; garantia de eleições autênticas, periódicas, mediante sufrágio universal e igual, e voto secreto ou procedimento equivalente. Do art. 22 até o art. 28, o documento consubstancia os *direitos sociais do homem*, assim: direito à segurança social e à satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à dignidade da pessoa humana e ao livre desenvolvimento de sua personalidade; direito ao trabalho, à escolha do trabalho, a condições satisfatórias de trabalho e proteção contra o desemprego, a salário condigno, à liberdade sindical; direito à limitação razoável da duração do trabalho, a férias, a descanso remunerado e ao lazer; direito à previdência e seguro social no caso de desemprego, enfermidade, invalidez, viuvez, velhice etc.; direito à educação, à instrução técnica e profissional, e à cultura; direito a uma ordem social e internacional em que os direitos fundamentais sejam plenamente efetivos. O art. 29 proclama os deveres da pessoa para com a comunidade, e o art. 30 estabelece o princípio de interpretação da Declaração sempre em benefício dos direitos e liberdades nela proclamados.⁴⁰

O enunciado desse conjunto de direitos confirma a lição de Dalmo de Abreu Dallari, segundo a qual a Declaração consagrou três objetivos fundamentais: “a certeza dos direitos, exigindo que haja uma fixação *prévia* e *clara* dos direitos e deveres, para que os indivíduos possam gozar dos direitos ou sofrer imposições; a *segurança* dos direitos, impondo uma série de normas tendentes a garantir que, em *qualquer circunstância*, os direitos fundamentais serão respeitados; a *possibilidade* dos direitos, exigindo que se procure assegurar a todos os indivíduos os meios necessários à fruição dos direitos, não se permanecendo no formalismo cínico e mentiroso da afirmação de igualdade de direitos onde grande parte do povo vive em condições subumanas”.⁴¹ Mas, como ainda anota o referido autor, o grande problema é o da *eficácia* das normas de Declaração de Direitos.⁴² O problema é ainda mais agudo em se tratando de uma Declaração Uni-

versal, que não dispõe de um aparato próprio que a faça valer, tanto que o desrespeito acintoso e cruel de suas normas, nesse mais de meio século de sua existência, tem constituído uma regra trágica, especialmente no nosso continente e também no nosso país. Não é, pois, sem razão que se afirma que o regime democrático se caracteriza, não pela inscrição dos direitos fundamentais, mas por sua efetividade, por sua realização eficaz.⁴³ À vista disso é que se tem procurado firmar vários Pactos e Convenções internacionais, sob patrocínio da ONU, visando assegurar a proteção dos direitos fundamentais do homem, pelos quais as altas partes pactuantes — reconhecendo: (a) que tais direitos derivam da dignidade inerente à pessoa humana; (b) que, com relação à Declaração Universal de Direitos Humanos, não pode realizar-se o ideal do ser humano livre, no desfrute das liberdades civis e políticas, e liberado do temor e miséria, se não se criarem condições que permitam a cada pessoa gozar de seus direitos civis, tanto como de seus direitos econômicos, sociais e culturais; (c) que a Carta das Nações Unidas impõe aos Estados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos direitos fundamentais do homem — comprometem-se a respeitar e garantir a todos os indivíduos, no seu território e sob sua jurisdição, esses direitos reconhecidos naqueles instrumentos internacionais, dentre os quais, além dos já referidos, são expressivos o *Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos* e o *Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais*, aprovados pela Assembleia Geral, em Nova York, em 16.12.66, submetidos à firma e ratificação dos Estados interessados. Surgiram eles, como observa Gregorio Peces-Barba Martínez, com o fim de conferir dimensão jurídica à Declaração de 1948 e, assim, eficácia jurídica que supere a obrigatoriedade apenas moral que a caracteriza.⁴⁴ O Brasil só deu sua adesão a esses pactos em 24.1.92, entrando em vigência aqui apenas em 24.4.92. O retardamento dessa adesão se deveu ao regime autoritário que nos regia antes.

No entanto, na Europa, têm-se desenvolvido instrumentos eficientes para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais do homem reconhecidos na Declaração Universal de 1948, por influência do Conselho da Europa, que promoveu a elaboração da *Convenção de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais*, aprovada em Roma no dia 4.11.50, ratificada por dezessete Estados euro-

40. Cf. sobre a Declaração, Chappelle, *ob. cit.*; Alcalá-Zamora y Castillo e outros, *Veinte años de evolución de los derechos humanos*, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1974; Antonio Truyol y Serra, *Los derechos humanos*, Madrid, Tecnos, 1971.

41. Cf. *Elementos de Teoria Geral do Estado*, p. 179.

42. *Ob. cit.*, p. 185. A propósito, cf. também Alcalá-Zamora, “La protección procesal internacional de los derechos humanos”, e René Cassin, “El problema de la realización efectiva de los derechos humanos en la sociedad universal”, ambos in *Veinte años de evolución de los derechos humanos*, pp. 275 a 384 e 387 a 398, respectivamente.

43. Cf. Germán José Bidart Campos, *Doctrina del Estado democrático*, p. 298; Héctor Fix-Zamudio, “Introducción interna de los derechos humanos”, in *Veinte años de evolución de los derechos humanos*, p. 169.

44. Cf. *Textos básicos sobre derechos humanos*, nota 1, p. 250; Truyol y Serra, *ob. cit.*, pp. 31 e 32.

peus e em vigor desde 3.9.53. Seu art. 19 instituiu dois órgãos de extrema importância, para assegurar o respeito dos compromissos contidos na Convenção, quais sejam uma *Comissão Européia de Direitos do Homem* e um *Tribunal Europeu de Direitos do Homem*, cujo prestígio já se impõe à admiração de todos. A essa Convenção seguiram-se vários Protocolos Adicionais reforçando e ampliando suas normas, culminando com uma *Carta Social Européia*, aprovada pelo Conselho da Europa, em Turim, em 18.10.61, na qual se articulam normas sobre os direitos e garantias econômicos e sociais do homem europeu.

Antes de todos esses documentos internacionais e multinacionais citados, o primeiro, de caráter multinacional, declarando os direitos do homem foi a *Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem*, cujo texto agasalha a maioria dos direitos individuais e sociais inscritos na Declaração Universal de 1948. Ela foi aprovada pela IX Conferência Internacional Americana, reunida em Bogotá, de 30 de março a 2 de maio de 1948, antecedendo, assim, à da ONU cerca de 8 meses. Na mesma Conferência foi aprovada também a *Carta Internacional Americana de Garantias Sociais*, consubstanciando os direitos sociais do homem americano. Mais importante, no entanto, é a *Convenção Americana de Direitos Humanos*, chamada *Pacto de San José de Costa Rica*, adotada nesta cidade em 22.11.69, e também institucionaliza, como meios de proteção daqueles direitos, a *Comissão Interamericana de Direitos Humanos*, prevista na Resolução VIII, da V Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores (Santiago do Chile, agosto de 1959), e a *Corte Interamericana de Direitos Humanos*, que vigora desde 18.6.78, mas, no Brasil, só entrou em vigor em 1992 por via de adesão, já que nem tinha sido assinada ainda por nós.⁴⁵ Não obstante isso, a ineficácia desses documentos interamericanos está retratada na tragédia dos países latino-americanos, sempre submetidos ao mais feroz desrespeito aos mais elementares direitos da pessoa humana, embora se observe uma forte reação democrática no continente, como a nossa com esta Constituição.

9. Declaração de direitos nas constituições contemporâneas

A questão técnica que se apresenta na evolução das declarações de direitos foi a de assegurar sua efetividade através de um conjunto de meios e recursos jurídicos, que genericamente passaram a cha-

mar-se *garantias* constitucionais dos direitos fundamentais. Tal exigência técnica, no entanto, determinou que o reconhecimento desses direitos se fizesse segundo formulação jurídica mais caracterizada positivamente, mediante sua inscrição no texto das constituições, visto que as declarações de direitos careciam de força e de mecanismos jurídicos que lhe imprimissem eficácia bastante.

Biscaretti di Ruffia denotou esse fenômeno com as seguintes palavras: "No curso do século XIX, a enunciação dos direitos e deveres dos indivíduos sofreu uma dupla transformação: passou para o próprio texto das Constituições, imprimindo às suas fórmulas, até então abstratas, o caráter concreto de *normas jurídicas positivas* (ainda que de conteúdo geral e de princípio), válidas para os indivíduos dos respectivos Estados (dita *subjetivação*), e, não raro, integrou-se também de outras normas destinadas a atuar uma completa e pormenorizada regulamentação jurídica de seus pontos mais delicados, de modo a não requerer ulteriormente, a tal propósito, a intervenção do legislador ordinário (ou seja, sua *positivação*)".⁴⁶

Acrescenta que essa dupla transformação encontrou a primeira e integral afirmação na Constituição Belga de 1831, cujo Título II efetivamente inscreve os direitos fundamentais dos belgas. Daí por diante, as constituições liberais democráticas passaram a trazer um capítulo em que são *subjetivados e positivados* os direitos fundamentais do homem da respectiva vinculação estatal.

Cumpre, no entanto, observar que Biscaretti di Ruffia não conhece a Constituição do Império do Brasil, de 1824, se não verificaria que a primazia da subjetivação e da positivação dos direitos do homem não cabe à Constituição belga, mas a ela, que os enuncia, com as garantias pertinentes, em seu art. 179, cujo *caput* é bem característico, quando declara que a "inviolabilidade dos Direitos Cíveis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros",⁴⁷ que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte" (segue-se o rol de direitos em 35 incisos).⁴⁸

Além dessa transformação, deu-se outra, como já observamos, com o surgimento de um capítulo sobre os direitos econômicos e sociais do homem, cuja positivação constitucional, mais ou menos eficaz, importa sempre conferir nova dimensão e novo sentido aos direitos individuais tradicionais.

46. Cf. *Diritto Costituzionale*, pp. 695 e 696.

47. Aí a *subjetivação*: reconhecimento dos direitos do homem brasileiro.

48. Aí está a *positivação*: garantia pela *Constituição* dos direitos do homem brasileiro: inviolabilidade estabelecida nos incisos que se seguem ao *caput*.

45. Sobre a batalha para a adesão do Brasil, expressivos os pareceres de Antônio Augusto Cançado Trindade que se podem ler no seu livro *A proteção internacional dos direitos humanos*, São Paulo, Saraiva, 1991.

Não cabe aqui fazer um exame exaustivo das declarações constitucionais de direitos nas constituições contemporâneas. Limitar-nos-emos a apresentar simples esquema geral.⁴⁹ Primeiramente temos que separar as constituições em dois grupos: as que contêm uma declaração e as que não a contêm. Não é mais possível generalizar, a todos os regimes constitucionais, o esquema de Henri Puget em relação à Ásia, que os divide em três grupos: os de tipo *liberal*, os de tipo *ditatorial* ou *quase ditatorial* e os de *democracia popular*,⁵⁰ porque as democracias populares ruíram sob o peso de seu personalismo autoritário, restando apenas Cuba. Demais, seria de ponderar que, entre as de tipo liberal, se haveriam de incluir as em que se confere predominância à idéia de liberdade individual, compreendendo, pois, desde constituições que só enunciam os tradicionais direitos do homem, como a dos EUA, até as que trazem também um capítulo e compromisso com as prestações positivas do Estado, mediante reconhecimento de direitos econômicos e sociais, como é o caso da maioria do hemisfério ocidental. Entre as de regime ditatorial, entrarão não só as que não enunciam uma declaração de direitos (nem liberais nem econômico-sociais) como as que o fazem, mas, por qualquer outro tipo de mecanismo formal ou não, a tornem inócuas, como são as das monarquias tradicionais asiáticas e arábicas, informadas por culturas e crenças antigas, que nulificam o reconhecimento formal dos direitos do homem, que, porventura, suas constituições enunciem. Devido às profundas transformações recentes, com a fragmentação do socialismo real e autoritário sob o influxo da desaparecida URSS, um esquema mais próximo da realidade vigente pode ser assim resumido:

(1) *constituições liberais*, as que consubstanciam primordialmente os elementos liberais individuais, que são de dois tipos: (a) *liberais*

49. Mirkine-Guetzévitch, "Essai synthétique", in *Les constitutions européennes*, p. 136, apresentou o seguinte esquema: "nous proposons de classer les nouvelles Déclarations de Droit en nous basant sur le critère social des libertés individuelles:

1) Les Déclarations qui reconnaissent, à côté des libertés individuelles "classiques", certains droits sociaux et qui accordent aux droits sociaux la même importance et la même valeur qu'aux droits individuels;

2) Les Déclarations des *Républiques populaires* qui établissent la primauté "fonctionnelle" du social sur l'individu;

3) Les Déclarations des *Républiques soviétiques* qui établissent la primauté politique du social sur l'individu". Acrescenta, contudo, logo em seguida, que a "realidade é mais rica, bem entendido, e mais matizada que esse esquema rígido. Mas, descontando-se as exceções e os tipos transitórios, esta classificação nos parece corresponder à prática constitucional de hoje". Talvez se pudesse, à vista de constituições mais recentes (Portugal, Espanha, Peru, Guatemala, Brasil), aditar um quarto grupo: as *Declarações de Direitos* sem primazia entre o individual e o social, mas que, sem denotarem esta primazia, buscam realizar o individual com dimensão social e o social com visão do individual, tentando um equilíbrio entre ambos.

50. Cf. "Préface", in *Les Constitutions d'Asie et d'Australasie*, pp. 9 e 10.

típicas — não contêm declaração de direitos sociais, como a dos Estados Unidos e da Bélgica; (b) *liberais com reconhecimento de direitos sociais*, como as da Itália, da República Federal da Alemanha, da Suécia, da Dinamarca, do México e dos países da América Latina em geral, com observação que aditaremos logo mais; também a da França, ainda que só de modo indireto, ao estabelecer no preâmbulo o reconhecimento dos direitos do homem estabelecidos pela Declaração de 1789, "confirmada e integrada pelo preâmbulo da Constituição de 1946", que enunciava, nessa integração, os direitos sociais;

(2) *constituições transformistas*, que prometem explícita ou implicitamente a transição para o socialismo democrático pluralista, como a de Portugal, de 1976 com a revisão de 1982, a da Espanha, de 1978, a do Brasil (por seu conteúdo social, sem prometer o socialismo), mais distante um pouco a do Peru, de 1993, e a da Guatemala;

(3) *constituições socialistas* (socialismo real, autoritário), as que consubstanciam elementos sociais da igualdade, restando ainda com essa pretensão as da Argélia, de Cuba, da China Popular, da Coreia do Norte, da Mongólia e a do Viet-Nam; mas esses Estados e respectivas constituições passam, neste momento, por profundas transformações, mais se aproximando hoje do tipo ditatorial, do que de um sistema conceitualmente socialista, desde que a URSS desapareceu no dia 21 de dezembro de 1991, com a independência de várias de suas Repúblicas, surgindo em seu lugar uma Comunidade de Estados Independentes (CEI) integrada pela Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia; a República Democrática da Alemanha integrou-se na República Federal da Alemanha, unificando-se num único Estado de caráter social de direito; as demais Repúblicas Populares desfazem-se em dissídios internos tendendo para a constituição de um novo regime, não socialista-estatista, mas talvez nem capitalista, possivelmente social-democrático, ou até simplesmente ditatorial;

(4) *constituições ditatoriais*, as que não reconhecem formalmente nem permitem se desenvolvam substancialmente os direitos do homem, nem nas suas dimensões liberais nem nas sociais, assim como as que, embora formalmente os enunciem, contenham elementos formais que os nulifiquem ou são simplesmente ineficazes por via de uma estrutura de poder dominante; temos, pois, nesse grupo: (a) constituições que não enunciam os direitos do homem ou o fazem muito vagamente, como as de Gana, da África do Sul, de Tanganica, do Ceilão, do Afeganistão (de 1930), do Brunei, do Camboja (de 1959), de Sabá, de Sarawak, de Cingapura; (b) constituições que trazem uma afirmação dos princípios, mas introduzem longa enumeração de exceções e de pormenores de aplicação, que nulificam aqueles princípios, como as dos Estados árabes e africanos em geral, assim as da Arábia Saudita, do Iraque, do Irã, do Egito, da Etiópia, do Marrocos,

da Nigéria, de Uganda, de Serra Leoa, e também algumas da Ásia, como as da Birmânia, do Nepal; (c) constituições que reconhecem os direitos individuais e sociais do homem, mas dominadas por estrutura de poder que torna de pouca valia suas normas e princípios, como, não raro, têm sido os regimes da América Latina em geral, felizmente também em processo de democratização. Cumpre, ainda, ter em mente que a instabilidade constitucional dos Estados do Terceiro Mundo tem sido tão grande que raramente se pode afirmar, com precisão, a vigência, em dado momento, dos direitos fundamentais do homem.

10. Declaração de direitos nas constituições brasileiras

As constituições brasileiras sempre inscreveram uma declaração dos direitos do homem brasileiro e estrangeiro residente no país. Já observamos, antes, até, que a primeira constituição, no mundo, a *subjetivar e positivar* os direitos do homem, dando-lhes concreção jurídica efetiva, foi a do Império do Brasil, de 1824, anterior, portanto, à da Bélgica de 1831, a que se tem dado tal primazia.

Não descereamos a pormenores a respeito dos direitos enunciados em cada uma das constituições que o Brasil já teve. Quando formos estudar esses direitos, mais adiante, mencionaremos o que for pertinente dessa evolução. Aqui apenas mencionaremos algumas questões gerais a respeito do conteúdo dessas declarações de direitos, lembrando, desde logo, que, em verdade, ao menos no referente aos direitos individuais, a Constituição do Império já os consignava quase integralmente, havendo, nesse aspecto, pouca inovação de fundo, salvo quanto à Constituição vigente que incorpora novidades de relevo. Ela, contudo, não trazia a rubrica *Declaração de Direitos*; continha um título sob rubrica confusa *Das Disposições Gerais, e Garantias dos Direitos Cíveis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros*, com disposições sobre a aplicação da Constituição, sua reforma, natureza de suas normas e o art. 179, com 35 incisos, dedicados aos direitos e garantias individuais especialmente.

Já a Constituição de 1891 abria a Seção II do Título IV com uma *Declaração de Direitos*, onde assegurava a brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à *liberdade*, à *segurança* e à *propriedade* nos termos dos 31 parágrafos do art. 72, acrescentando algumas garantias funcionais e militares nos arts. 73 a 77 e indicando no art. 78 que a enumeração não era exaustiva, regra que passou para as constituições subsequentes. Basicamente, pois, a declaração de direitos na Constituição de 1891 contém só os chamados direitos e garantias individuais. Essa metodologia modificou-se a partir da Constituição de 1934, que, como as sucessivas, fora a Carta ditatorial de 1937, abriu um título especial para a *Declaração de Direitos*, nele inscrevendo não só os direitos e garantias individuais,

mas também os de nacionalidade e os políticos. Além disso, essa Constituição incorporou, como já notamos, outra novidade, que se constituiu no Título "Da Ordem Econômica e Social", na esteira das constituições de pós-Primeira Guerra Mundial, reconhecendo os direitos econômicos e sociais do homem, ainda que de maneira pouco eficaz. Aliás, já no *caput* do art. 133 que arrola os tradicionais direitos e garantias individuais, à inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, adita também a inviolabilidade aos direitos à *subsistência*, elevando, por conseguinte, esta também à categoria dos direitos fundamentais do homem. Essa Constituição durou pouco mais de três anos, pelo que nem teve tempo de ter efetividade. A ela sucedeu a Carta de 1937, ditatorial na forma, no conteúdo e na aplicação, com integral desrespeito aos direitos do homem, especialmente os concernentes às relações políticas.

A Constituição de 1946 trouxe o Título IV sobre a *Declaração dos Direitos*, com dois capítulos: um sobre a *Nacionalidade e a Cidadania* e outro sobre os *Direitos e Garantias Individuais* (arts. 129 a 144). No *caput* do art. 141, sobre os direitos e garantias individuais, não incluiu o direito à subsistência. Em seu lugar, colocara o *direito à vida*. Assim fixou o enunciado que se repetiria na Constituição de 1967 (art. 151) e sua Emenda 1/69 (art. 153), assegurando os direitos concernentes à *vida*, à *liberdade*, à *segurança individual* e à *propriedade* nos parágrafos que se seguiam ao *caput* do artigo. Na de 1946, o *direito à subsistência* se achava inscrito no parágrafo único do art. 145, onde se assegurava a todos trabalho que possibilitasse existência digna. Aparecem nela, como nas de 1967 e 1969, os direitos econômicos e sociais, mais bem estruturado do que na de 1934, em dois títulos: um sobre a ordem econômica e outro sobre a família, a educação e a cultura. O Título II cuidava da *Declaração de Direitos*, com cinco capítulos: I — *Da Nacionalidade*; II — *Dos Direitos Políticos*; III — *Dos Partidos Políticos*; IV — *Dos Direitos e Garantias Individuais*; V — *Das Medidas de Emergência, do Estado de Sítio e do Estado de Emergência*. Os direitos econômicos e sociais constavam de dois títulos: III — *Da Ordem Econômica e Social* e IV — *Da Família, da Educação e da Cultura*.

A Constituição de 1988 adota técnica mais moderna. Abre-se com um título sobre os princípios fundamentais, e logo introduz o Título II — *Dos Direitos e Garantias Fundamentais*, nele incluindo os *Direitos e Deveres Individuais e Coletivos* (Cap. I), os *Direitos Sociais* (Cap. II), os *Direitos da Nacionalidade* (Cap. III), os *Direitos Políticos* (Cap. IV) e os *Partidos Políticos* (Cap. V). É essa a matéria que nos ocupará nesta segunda parte, mas teremos que recorrer também, ainda que referencialmente, ao Título VII — *Da Ordem Econômica e Financeira*, e especialmente ao Título VIII — *Da Ordem Social*, onde se localizam conteúdos dos direitos sociais referidos no Cap. II do Tít. II (art. 6º).

Capítulo II

TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO HOMEM

1. Inspiração e fundamentação dos direitos fundamentais. 2. Forma das declarações de direitos. 3. Conceito de direitos fundamentais. 4. Natureza e eficácia das normas sobre direitos fundamentais. 5. Caracteres dos direitos fundamentais. 6. Classificação dos direitos fundamentais. 7. Integração das categorias de direitos fundamentais. 8. Direitos e garantias dos direitos.

1. Inspiração e fundamentação dos direitos fundamentais

A doutrina francesa indica o pensamento cristão e a concepção dos direitos naturais como as principais fontes de inspiração das declarações de direitos.¹ Fundada na insuficiente e restrita concepção das *liberdades públicas*, não atina com a necessidade de envolver nessa problemática também os *direitos econômicos, sociais e culturais*, aos quais se chama brevemente *direitos sociais*.

Temos, pois, que ampliar nossa visão do problema para admitir outras fontes de inspiração das declarações de direitos, sem deixar de reconhecer que as primeiras abeberaram no cristianismo e no jusnaturalismo sua idéia do homem abstrato. Mas não é uma observação correta esta de atribuir, ao surgimento de uma nova idéia de direito, tão profundamente revolucionária, inspiração de natureza basicamente ideal, sem levar em conta as condições históricas objetivas, que, na verdade, constituem a sua fundamentação primeira. As doutrinas e concepções filosóficas têm relevância enorme no processo. Mas elas próprias são condicionadas por aquelas condições materiais. Surgem precisamente para ordená-las numa compreensão ideológica coerente, interpretando-as, para definirlhes as leis a elas imanentes, já que, em tais momentos agudos da

evolução social, se percebe a superação de situações caducas pelo despontar de algo novo.²

Pelo que se vê, não há propriamente uma inspiração das declarações de direitos. Houve reivindicações e lutas para conquistar os direitos nelas consubstanciados. E quando as condições materiais da sociedade propiciaram, elas surgiram, conjugando-se, pois, condições objetivas e subjetivas para sua formulação.

As *condições reais* ou *históricas* (objetivas ou materiais), em relação às declarações do século XVIII, manifestaram-se na contradição entre o regime da monarquia absoluta, estagnadora, petrificada e degenerada, e uma sociedade nova tendente à expansão comercial e cultural, como observa Del Vecchio, que acrescenta: "Mas às suas exigências vitais era arrebatada qualquer possibilidade de fazer-se valer na legislação e na administração; enquanto toda a sua atividade era exposta à arbitrariedade e à opressão jurídica e econômica das classes privilegiadas. Essa contradição entre uma superestrutura atrofiada e uma sociedade progressista não poderia deixar de provocar uma crise muito grave na vida da nação; ela produziu-se em efeito e tornou-se tão forte que, em certo ponto, as autoridades estabelecidas se encontraram na impossibilidade de ir adiante no governo. A convocação dos Estados Gerais marca precisamente esse momento. A monarquia feudal, em convidando o Terceiro Estado para colaborar com o governo, cedia à necessidade histórica que lhe impunha o desaparecimento enquanto poder absoluto".³

As *condições subjetivas* ou *ideais* ou *lógicas* consistiram precisamente nas fontes de inspiração filosófica anotadas pela doutrina francesa: (1) O *pensamento cristão*, como fonte remota, porque, na verdade, a interpretação do cristianismo que vigorava no século XVIII era favorável ao *status quo* vigente, uma vez que o clero, especialmente o alto clero, apoiava a monarquia absoluta, e até oferecia a ideologia que a sustentava com a tese da origem divina do poder; o pensamento cristão vigente, portanto, não favorecia o surgimento de uma declaração de direitos do homem; o cristianismo primitivo, sim, continha uma mensagem de libertação do homem, na sua afirmação da *dignidade eminente da pessoa humana*, porque o homem é uma criatura formada à imagem de Deus, e esta dignidade pertence a *todos* os homens sem distinção, o que indica uma *igualdade fundamental de na-*

1. Cf. Jacques Robert, *Libertés publiques*, pp. 32 e ss.; Jean Rivero, *Les libertés publiques* — 1. *Les droits de l'Homme*, pp. 33 e ss. Parcialmente no mesmo sentido, Georges Burdeau, *Les libertés publiques*, pp. 13 e ss. Na Espanha, José Castán Tobeñas, *Los derechos del hombre*, pp. 38 e ss. No Brasil, João Oliveira Filho, *Origem cristã dos direitos fundamentais do homem*, Rio de Janeiro, Forense, 1968.

2. Giorgio del Vecchio, que é de tendência jusnaturalista, percebeu isso, quando admitiu que a origem das declarações do direito do homem da Revolução francesa se deveu a dois princípios: um *real* ou *histórico* e outro *ideal* ou *lógico*. Cf. *La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dans la Révolution Française*, p. 17.

3. *Ob. cit.*, pp. 17 e 18.

tureza entre eles;⁴ há, no entanto, “quem afirme que o cristianismo não supôs uma mensagem de liberdade, mas, especialmente, uma aceitação conformista do fato da escravidão humana”;⁵ (2) A *doutrina do direito natural dos séculos XVII e XVIII*, de natureza racionalista, fundada assim na natureza racional do homem, faz descer a este o fundamento do poder político e também do Direito positivo em contraposição à “divinização” que sustentava o regime absolutista vigente; doutrina puramente instrumental e lógica, como concepção do mundo, do Estado e da sociedade, destinada a substituir e a se opor coerentemente à vigente, com força bastante para sustentar as transformações sociais que as condições materiais impunham; sustentando teses de direitos inatos (de caráter também instrumental: meio de opor-se à concepção vigorante), encontrou-se base para o reconhecimento de um conjunto de direitos tidos, então, como inerentes à pessoa humana. Disse-o bem Pérez Luño: “Mediante a afortunada metáfora de uns direitos comuns a todos os homens situados no plano dos valores absolutos, universais e intemporais, o pensamento jusnaturalista do século XVIII achou uma fórmula de capital importância para uma nova legislação do poder político. Com ela se pretendia situar determinadas esferas da convivência humana por cima das possíveis arbitrariedades de quem determinara o poder. Tratava-se, em suma, de fazer da autoridade e da própria associação política instrumentos destinados à consecução daquelas faculdades que se reputavam inerentes *por natureza* a todo o gênero humano”;⁶ (3) *Pensamento iluminista*, com suas idéias sobre a ordem natural, sua exaltação às liberdades inglesas e sua crença nos valores individuais do homem acima dos valores sociais, firmando o *individualismo* que exala dessas primeiras declarações dos direitos do homem.

Todos esses fundamentos foram sendo superados pelo processo histórico-dialético das condições econômicas, que deram nascimento a novas relações objetivas com o desenvolvimento industrial e o aparecimento de um proletariado amplo sujeito ao domínio da burguesia capitalista. Essas novas condições materiais da sociedade teriam que fundamentar a origem de outros direitos fundamentais — os *direitos econômicos e sociais* — e concomitantemente a transforma-

4. Cf. Robert, *ob. cit.*, p. 34. Também Antonio Enrique Pérez Luño, “Delimitación conceptual de los derechos humanos”, in Pérez Luño, José Cascajo Castro, Benito de Castro Cid e Carmelo Gómez Torres, *Los derechos humanos, significación, estatuto jurídico y sistema*, p. 15.

5. Cf. Pérez Luño, *ob. cit.*, p. 15.

6. Cf. *ob. cit.*, pp. 37 e 38. Ainda sobre essa temática, Manuel Peris, *Juez, Estado y derechos humanos*, pp. 141 e ss.; Gregorio Peces-Barba, *Derechos fundamentales*, pp. 26 e ss.; Burdeau, *ob. cit.*, pp. 13 e ss.; Robert, *ob. cit.*, pp. 35 e ss.; Rivero, *ob. cit.*, pp. 36 e ss.

ção do conteúdo dos que serviam à burguesia em sua luta contra o absolutismo. Daí também sobreviriam novas doutrinas sociais, postulando a transformação da sociedade no sentido da realização ampla e concreta desses direitos. Essas novas fontes de inspiração dos direitos fundamentais são: (1) o *Manifesto Comunista* e as *doutrinas marxistas*, com sua crítica ao capitalismo burguês e ao sentido puramente formal dos direitos do homem proclamados no século XVIII, postulando *liberdade e igualdade materiais* num regime socialista; (2) a *doutrina social da Igreja*, a partir do Papa Leão XIII, que teve especialmente o sentido de fundamentar uma ordem mais justa, mas ainda dentro do regime capitalista, evoluindo, no entanto, mais recentemente, para uma Igreja dos pobres que aceita os postulados sociais marxistas; (3) o *intervencionismo estatal*, que reconhece que o Estado deve atuar no meio econômico e social, a fim de cumprir uma missão protetora das classes menos favorecidas, mediante prestações positivas, o que é ainda manter-se no campo capitalista com sua inerente ideologia de desigualdades, injustiças e até crueldades.

2. Forma das declarações de direitos

As declarações de direitos assumiram, inicialmente, a forma de proclamações solenes em que, em articulado orgânico especial, se enunciam os direitos. Depois, passaram a constituir o preâmbulo das constituições, na França especialmente. Atualmente, ainda que nos documentos internacionais assumam a forma das primeiras declarações, nos ordenamentos nacionais integram as constituições, adquirindo o caráter concreto de *normas jurídicas positivas constitucionais*, por isso, subjetivando-se em direito particular de cada povo, como já vimos, configuram *declarações constitucionais de direito*, o que tem consequência jurídica prática relevante, como diremos mais adiante.

3. Conceito de direitos fundamentais

A ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem no evoluir histórico dificulta definir-lhes um conceito sintético e preciso. Aumenta essa dificuldade a circunstância de se empregarem várias expressões para designá-los, tais como: *direitos naturais*, *direitos humanos*, *direitos do homem*, *direitos individuais*, *direitos públicos subjetivos*, *liberdades fundamentais*, *liberdades públicas e direitos fundamentais do homem*.⁷

7. Para as dificuldades assinaladas e a variedade de terminologia, cf. Peces-Barba, *ob. cit.*, pp. 21 e ss.; Castán Tobeñas, *ob. cit.*, pp. 9 e ss.; Pérez Luño, *ob. cit.*, pp.

Direitos naturais diziam-se por se entender que se tratava de direitos inerentes à natureza do homem; *direitos inatos* que cabem ao homem só pelo fato de ser homem. Não se aceita mais com tanta facilidade a tese de que tais direitos sejam naturais, provenientes da razão humana ou da natureza das coisas. São *direitos positivos*, que encontram seu fundamento e conteúdo nas relações sociais materiais em cada momento histórico. Sua *historicidade* repele, por outro lado, a tese de que nascem pura e simplesmente da vontade do Estado, para situá-los no terreno político da soberania popular, que lhes confere o sentido apropriado na dialética do processo produtivo.

Direitos humanos é expressão preferida nos documentos internacionais. Contra ela, assim, como contra a terminologia *direitos do homem*, objeta-se que não há direito que não seja humano ou do homem, afirmando-se que só o ser humano pode ser titular de direitos. Talvez já não mais assim, porque, aos poucos, se vai formando um direito especial de proteção dos animais.

Direitos individuais dizem-se os direitos do indivíduo isolado. Ressombra *individualismo* que fundamentou o aparecimento das declarações do século XVIII. É terminologia que a doutrina tende a desprezar cada vez mais. Contudo, é ainda empregada para denotar um grupo dos direitos fundamentais, correspondente ao que se tem denominado direitos civis ou liberdades civis.⁸ É usada na Constituição para exprimir o conjunto dos direitos fundamentais concernentes à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade.

Direitos públicos subjetivos constituem um conceito técnico-jurídico do Estado liberal, preso, como a expressão “direitos individuais”, à concepção individualista do homem; por isso também se tornara insuficiente para caracterizar os direitos fundamentais. *Direito subjetivo* conceitua-se como prerrogativas estabelecidas de conformidade com regras de Direito objetivo.⁹ Nesse sentido, seu exercício, ou não, depende da simples vontade do titular, que deles pode dispor como melhor lhe parecer, até mesmo renunciá-los ou transferi-los, além de serem prescritíveis, situações essas incompatíveis com os direitos fun-

damentais do homem. Cunhou-se, depois, a expressão *direitos públicos subjetivos* para exprimir a situação jurídica subjetiva do indivíduo em relação ao Estado, visando colocar os direitos fundamentais no campo do Direito Positivo.¹⁰ “A figura do Direito Público subjetivo [alerta Pérez Luño com razão] é uma categoria histórica adaptada ao funcionamento de determinado tipo de Estado, o liberal, e a umas condições materiais que foram superadas pelo desenvolvimento econômico-social de nosso tempo”.¹¹ Entendida como *autolimitação estatal* em benefício de determinadas esferas privadas, tal categoria acha-se superada pela própria dinâmica econômico-social do nosso tempo, em que o desfrute de qualquer direito fundamental exige atuação ativa dos poderes públicos.¹² Pois, ainda na lição do citado autor, tudo aquilo que, para a ideologia liberal, aparecia como direitos públicos subjetivos, ou como esferas de atividade privada contraposta à atividade pública, ou como liberdades limitadoras do poder, passa a ser considerado, sob o prisma do Estado Democrático de Direito superador da involução do Estado Social de Direito, como momentos do exercício do próprio poder, a este coexistencial e não a ele contraposto.¹³ Cumpre, no entanto, advertir, para recusar razão a uma corrente reacionária que nega valor jurídico eficaz aos enunciados dos direitos fundamentais, neles vendo apenas valor moral, que a eles se aplica a expressão *direitos subjetivos*, sem importar com qualificativo de privado ou público, quando ela é empregada no sentido de direitos oponíveis ou exigíveis, isto é, quando considerada *situação jurídica subjetiva de vantagem* dotada de eficácia jurídica, porque devidamente garantida como capaz de ser efetivada em favor de seu titular. *Direito subjetivo* no sentido de *permissão concedida* pelo Direito Constitucional objetivo ao homem.¹⁴

Liberdades fundamentais e *liberdades públicas* são também expressões usadas para exprimir direitos fundamentais. São conceitos limitativos e insuficientes. A primeira é ainda mais restrita, referindo-se apenas a algumas liberdades. A última é empregada pela doutrina francesa, onde não faltam esforços para dar-lhe significação ampla abrangente dos direitos fundamentais em geral, especialmente jogando com os conceitos *liberdade-autonomia* (igual aos direitos individuais clássicos) e *liberdade-participação* (também chamada *liberdades políticas*, que correspondem ao gozo livre dos direitos políticos).¹⁵ Con-

22 e ss.; Castro Cid, “Dimensión científica de los derechos del hombre”, in *Los derechos humanos, significación, estatuto jurídico y sistema*, pp. 99 e ss.; Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Ada Pellegrini Grinover e Anna Cândida da Cunha Ferraz, *Liberdades públicas: Parte geral*, pp. 1 e ss., no qual justificam a preferência por “liberdades públicas”, justamente por entender que essa terminologia se refere ao Direito positivo, enquanto “direitos fundamentais do homem” seria expressão ligada ao direito natural.

8. Ainda que essa não seja a postura unânime da doutrina brasileira, Pimenta Bueno, p.ex., distingue bem *direitos individuais* e *direitos civis*. Cf. *Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império*, pp. 379 e ss.

9. Cf. Pérez Luño, *ob. cit.*, p. 25.

10. Idem, p. 26

11. Idem, p. 27.

12. Idem, pp. 27 e 28.

13. Idem, p. 27.

14. Cf. Goffredo Telles Júnior, *Direito quântico*, pp. 389 e ss., no qual expõe sua concepção do *direito subjetivo como permissão* dada por meio de normas jurídicas ou concedida pelo direito objetivo.

15. Cf. Burdeau, *ob. cit.*, p. 10.

sideradas na doutrina francesa como direitos do homem despidos de sua concepção jusnaturalista pela positivação estatal, as liberdades públicas não têm o mesmo conteúdo deles, como observa Rivero, não se incluindo no seu conceito os direitos econômicos e sociais.¹⁶ É um conceito ainda pobre de conteúdo, muito ligado à concepção dos direitos públicos subjetivos e dos direitos individuais na sua formulação tradicional individualista.

Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no *nível do direito positivo*, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas.¹⁷ No qualificativo *fundamentais* acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; *fundamentais do homem* no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do *homem*, não como o macho da espécie, mas no sentido de *pessoa humana*. *Direitos fundamentais do homem* significa *direitos fundamentais da pessoa humana* ou *direitos fundamentais*. É com esse conteúdo que a expressão *direitos fundamentais* encabeça o Título II da Constituição, que se completa, como *direitos fundamentais da pessoa humana*, expressamente, no art. 17.

A expressão *direitos fundamentais do homem*, como também já deixamos delineado com base em Pérez Luño, não significa esfera privada contraposta à atividade pública, como simples limitação ao Estado ou autolimitação deste, mas *limitação imposta pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado que dela dependem*.¹⁸ Ao situar-

16. Cf. *Les Libertés publiques*, pp. 17 e 18; Claude-Albert Colliard, *Libertés publiques*, pp. 23 e 24.

17. Inspiramo-nos mais uma vez no magnífico estudo de Pérez Luño, já tantas vezes citado, in *ob. cit.*, pp. 23 e 24.

18. Não é fácil concretizar a riqueza multifária da expressão *direitos fundamentais do homem*, ou *direitos fundamentais da pessoa humana*, ou *direitos humanos fundamentais*, numa definição lógica e sintética. Alguns autores o tentaram, parecendo-nos que a de Pérez Luño se aproxima mais daquele conteúdo que outros, utilizando a terminologia *derechos humanos* “como conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nível nacional e internacional” (*ob. cit.*, p. 43). Peces-Barba, empregando a expressão *derechos subjetivos fundamentales*, define-os como “facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en una

mos sua fonte na soberania popular, estamos implicitamente definindo sua historicidade, que é precisamente o que lhes enriquece o conteúdo e os deve pôr em consonância com as relações econômicas e sociais de cada momento histórico. A Constituição, ao adotá-los na abrangência com que o fez, traduziu um desdobramento necessário da concepção de Estado acolhida no art. 1º: *Estado Democrático de Direito*. O fato de o direito positivo não lhes reconhecer toda a dimensão e amplitude popular em dado ordenamento (restou dar, na Constituição, conseqüências coerentes na ordem econômica) não lhes retira aquela perspectiva, porquanto, como dissemos acima, na expressão também se contêm princípios que resumem uma concepção do mundo que orienta e informa a luta popular para a conquista definitiva da efetividade desses direitos.

4. Natureza e eficácia das normas sobre direitos fundamentais

A natureza desses direitos, em certo sentido, já ficou insinuada antes, quando procuramos mostrar que a expressão *direitos fundamentais do homem* são situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana. Desde que, no plano interno, assumiram o caráter concreto de *normas positivas constitucionais*, não tem cabimento retomar a velha disputa sobre seu valor jurídico, que sua previsão em declarações ou em preâmbulos das constituições francesas suscitava.¹⁹ Sua natureza passara a ser constitucional, o que já era uma posição expressa no art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, a ponto de, segundo este, sua adoção ser um dos elementos essenciais do próprio conceito de constituição.²⁰

Mas também não são normas de valor supraconstitucionais ou de natureza supra-estatal como querem Duguit²¹ e Pontes de Mi-

comunidad de hombres libres, exigiendo el respecto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo de Estado en caso de infracción” (*ob. cit.*, p. 80).

19. É certo que, no nível das declarações universais ou supranacionais, a questão se configura à falta de instrumentos que as façam efetivas. Cf. Eduardo Muylaert Antunes, “Natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos”, *RT* 4467 a 36.

20. É de recordar o famoso art. 16, citado: “Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution”. Mais recentemente, parte da doutrina italiana nega valor jurídico e eficácia às normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais. Nesse sentido, cf. Paolo Barile, *Le libertà nella costituzione*, pp. 20 e 21.

21. Cf. *Traité de droit constitutionnel*, pp. 603 e ss.

randa,²² embora o sejam cada vez mais de dimensão internacional, como lembramos antes.

São *direitos constitucionais* na medida em que se inserem no texto de uma constituição ou mesmo constem de simples declaração solenemente estabelecida pelo poder constituinte. São direitos que nascem e se fundamentam, portanto, no princípio da soberania popular.

A *eficácia e aplicabilidade* das normas que contêm os direitos fundamentais dependem muito de seu enunciado, pois se trata de assunto que está em função do Direito positivo. A Constituição é expressa sobre o assunto, quando estatui que *as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata*. Mas certo é que isso não resolve todas as questões, porque a Constituição mesma faz depender de legislação ulterior a aplicabilidade de algumas normas definidoras de direitos sociais, enquadrados dentre os fundamentais. Por regra, as normas que consubstanciam os direitos fundamentais democráticos e individuais são de eficácia contida e aplicabilidade imediata, enquanto as que definem os direitos econômicos e sociais tendem a sê-lo também na Constituição vigente, mas algumas, especialmente as que mencionam uma lei integradora, são de eficácia limitada, de princípios programáticos e de aplicabilidade indireta,²³ mas são tão jurídicas como as outras e exercem relevante função, porque, quanto mais se aperfeiçoam e adquirem eficácia mais ampla, mais se tornam garantias da democracia e do efetivo exercício dos demais direitos fundamentais.²⁴

5. Caracteres dos direitos fundamentais

Esse tema desenvolveu-se à sombra das concepções jusnaturalistas dos direitos fundamentais do homem, de onde promana a tese

22. Cf. *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. IV/617 e ss., sendo certo que, para ele, nem todos são dotados de supra-estatalidade.

23. Sobre essa temática, que não comporta maior desenvolvimento aqui, cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, pp. 91 a 147, especialmente.

24. Cf. Pérez Luño, "El proceso de positivación de los derechos fundamentales", in *ob. cit.*, pp. 216 e 217; cf., também, Cascajo Castro, "El problema de la protección de los derechos humanos", in Pérez Luño et al., *Los derechos humanos, significación, estatuto jurídico y sistema*, pp. 261 e ss., que envolve a questão de sua efetividade no plano prático. Igualmente, Héctor Fix-Zamudio, "Introducción al estudio procesal comparativo de la protección interna de los derechos humanos"; Alcalá-Zamora y Castillo, "La protección procesal internacional de los derechos humanos", e René Cassin, "El problema de la realización efectiva de los derechos humanos en la sociedad universal" e "Protección nacional e internacional de los derechos humanos", todos in *Veinte años de evolución de los derechos humanos*, pp. 169 a 407. Centre d'Études Européennes / Université Catholique de Louvain / Département des Droits de l'Homme, *Vers une protection efficace des droits économiques et sociaux*, Bruxelles, Bruylant et Vander-Éditeur, 1973; Ferreira Filho, Grinover e Cunha Ferraz, *ob. cit.*, pp. 271 e ss.

de que tais direitos são *inatos, absolutos, invioláveis (intransferíveis) e imprescritíveis*. Expurgando-se a conotação jusnaturalista que informara a matéria, ainda é possível reconhecer certos caracteres desses direitos. É o que discutiremos sinteticamente em seguida, para denotar neles os seguintes:

(1) *Historicidade*. São históricos como qualquer direito. Nascem, modificam-se e desaparecem. Eles apareceram com a revolução burguesa e evoluem, ampliam-se, com o correr dos tempos. Sua historicidade rechaça toda fundamentação baseada no direito natural, na essência do homem ou na natureza das coisas;²⁵

(2) *Inalienabilidade*. São direitos intransferíveis, inegociáveis, porque não são de conteúdo econômico-patrimonial. Se a ordem constitucional os confere a todos, deles não se pode desfazer, porque são indisponíveis;

(3) *Imprescritibilidade*. O exercício de boa parte dos direitos fundamentais ocorre só no fato de existirem reconhecidos na ordem jurídica. Em relação a eles não se verificam requisitos que importem em sua prescrição. Vale dizer, nunca deixam de ser exigíveis. Pois prescrição é um instituto jurídico que somente atinge, coarctando, a *exigibilidade* dos direitos de caráter patrimonial, não a exigibilidade de direitos personalíssimos, ainda que não individualistas, como é o caso. Se são sempre exercíveis e exercidos, não há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela prescrição;

(4) *Irrenunciabilidade*. Não se renunciam direitos fundamentais. Alguns deles podem até não ser exercidos, pode-se deixar de exercê-los, mas não se admite sejam renunciados.

Quanto ao caráter *absoluto* que se reconhecia neles no sentido de imutabilidade, não pode mais ser aceito desde que se entenda que tenham caráter histórico. Pontes de Miranda, contudo, sustenta que há direitos fundamentais absolutos e relativos. Os primeiros são os que existem *não conforme os cria ou regula a lei*, mas a despeito das leis que os pretendam modificar ou conceituar (assim: a liberdade pessoal, a inviolabilidade do domicílio ou da correspondência), enquanto os relativos existem, mas valem *conforme a lei* (assim: os direitos de contrato, de comércio e indústria e o direito de propriedade).²⁶ É também inaceitável essa doutrina, posto que ela está fundamentada na

25. Cf. Bernhard Pfaffenberg e Georg Brunner, "Derechos fundamentales", in C. D. Kernig, *Marxismo y Democracia — Enciclopedia de conceptos básicos: Política 2*, pp. 79 e 80.

26. Cf. *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. IV/18, 619 e 625. Também Carl Schmitt, *Teoría de la Constitución*, p. 192.

conhecida opinião do autor sobre a existência de direitos fundamentais supra-estatais, o que não é muito diferente da posição jusnaturalista. Assim, absolutos seriam os supra-estatais, cuja validade, segundo o autor, independe de positivação interna constitucional, enquanto os relativos seriam aqueles que somente teriam validade se previstos no Direito Positivo interno. Se a questão, no entanto, fosse posta em termos de relação norma constitucional e conteúdo integral do direito previsto, ainda se poderia admitir a distinção. Assim, seriam direitos fundamentais absolutos aqueles cujo conteúdo e incidência decorressem inteiramente das normas constitucionais que os estatuem, enquanto relativos seriam aqueles cujo conteúdo e incidência somente se preencheriam conforme previsão de lei.

6. Classificação dos direitos fundamentais

Esse é outro tema no qual não queremos embrenhar-nos à profundidade. Encontram-se nos autores classificações e mais classificações dos direitos fundamentais sob variados critérios que mais confundem que esclarecem. Como entendemos esses direitos do ponto de vista positivo, a classificação que deles se faça há que conformar-se ao ordenamento jurídico particular ou internacional de que se cogita. Assim, por exemplo, a Constituição italiana reconhece quatro classes desses direitos, agrupados segundo o tipo de relação que fundamentam: (a) direitos que estabelecem *relações civis*, correspondentes basicamente aos nossos direitos individuais; (b) direitos que fundamentam *relações ético-sociais*; (c) direitos prevendo *relações econômicas*; (d) direitos fundamentando *relações políticas*.

A classificação que decorre do nosso Direito Constitucional é aquela que os agrupa com base no critério de seu conteúdo, que, ao mesmo tempo, se refere à natureza do bem protegido e do objeto de tutela.²⁷ O critério da fonte leva em conta a circunstância de a Constituição mesma admitir outros direitos e garantias fundamentais não enumerados, quando, no § 2º do art. 5º, declara que os *direitos e garantias previstos neste artigo não excluem outros decorrentes dos princípios e do regime adotado pela Constituição e dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte*. Daí, as três fontes dos direitos e garantias: (a) os *expressos* (art. 5º, I a LXXVIII); (b) os *decorrentes*

dos *princípios e regime* adotados pela Constituição; (c) os *decorrentes de tratados e convenções internacionais* adotados pelo Brasil.²⁸ Aqui se tem uma hipótese de incorporação de normas internacionais de direitos humanos no ordenamento constitucional interno.²⁹ Entendia-se que essa incorporação era automática,³⁰ diferentemente do que ocorre com outros tipos de tratados e acordos internacionais, dependentes sempre de referendo congressual e ratificação governamental. Entendia-se que essa incorporação se fazia com a natureza de normas constitucionais. Essa questão precisa ser repensada em face do § 3º que a EC-45/2004 inseriu no art. 5º, para estabelecer que *os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais*. Isso quer dizer que as normas internacionais de direitos humanos só serão recepcionadas como direito constitucional interno, *formal*, se o decreto legislativo que as referendarem for aprovado nas condições indicadas, de acordo com o processo de formação de emendas constitucionais previsto no art. 60 da Constituição. *Direito constitucional formal*, dissemos, porque só nesse caso adquirem a supremacia própria da Constituição, pois de *natureza constitucional material* o serão sempre, como o são todas as normas sobre direitos humanos. A diferença importante está aí: as normas infraconstitucionais que violarem as normas internacionais acolhidas na forma daquele § 3º são inconstitucionais, e ficam sujeitas ao sistema de controle de constitucionalidade na via incidente como na via direta; as que não forem acolhidas desse modo, ingressam no ordenamento interno no nível da lei ordinária e eventual conflito se resolverá, no nosso entender, pelo modo de apreciação da relação entre *lei especial e lei geral*.

De acordo com critério do conteúdo, teremos: (a) direitos fundamentais do *homem-indivíduo*, que são aqueles que reconhecem autonomia aos particulares, garantindo iniciativa e independência aos indivíduos diante dos demais membros da sociedade política e do próprio Estado;³¹ por isso são reconhecidos como *direitos individuais*, como é de tradição do Direito Constitucional brasileiro (art. 5º), e ainda por *liberdades civis e liberdades-autonomia* (liberdade, igualdade, segurança, propriedade); (b) direitos fundamentais do *homem-nacio-*

28. Cf. a propósito e para pormenores, Valério de Oliveira Mazzuoli, *Tratados Internacionais*, 2ª ed., p. 359. Do mesmo autor, cf. repetição, *Direitos Humanos, Constituição e Tratados Internacionais*, p. 235. Nas duas obras há vários capítulos repetidos.

29. Cf. Flávia Piovesan, *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*, 3ª ed., pp. 114 e ss.

30. Cf. José Afonso da Silva, *Poder Constituinte e Poder Popular*, p. 195.

31. Cf. Castro Cid, *ob. cit.*, p. 110.

27. Para pormenores e minúcias desta e outras classificações, Castro Cid, *ob. cit.*, pp. 101 e ss., especialmente pp. 147 a 150, onde oferece pormenorizado e exaustivo esquema da classificação dos direitos fundamentais do homem, apresentando, ainda, em nota 144 à p. 112, classificações de vários autores. Cf. também as classificações de Schmitt, *ob. cit.*, p. 197. Jacques Maritain, *Os direitos do homem*, pp. 96 e ss. Pietro Virga, *Libertà giuridica e diritti fondamentali*, pp. 218 e ss.

nal, que são os que têm por conteúdo e objeto a definição da nacionalidade e suas faculdades; (c) direitos fundamentais do *homem-cidadão*, que são os direitos políticos (art. 14, direito de eleger e ser eleito), chamados também *direitos democráticos* ou *direitos de participação política* e, ainda, inadequadamente, liberdades políticas (ou *liberdades-participação*), pois estas constituem apenas aspectos dos direitos políticos; (d) direitos fundamentais do *homem-social*, que constituem os direitos assegurados ao homem em suas relações sociais e culturais (art. 6º: saúde, educação, seguridade social etc.); (e) direitos fundamentais do *homem-membro de uma coletividade*, que a Constituição adotou como *direitos-coletivos* (art. 5º); (f) uma nova classe que se forma é a dos direitos fundamentais ditos de terceira geração, direitos fundamentais do homem-solidário, ou direitos fundamentais do gênero humano (direito à paz, ao desenvolvimento, comunicação, meio ambiente, patrimônio comum da humanidade).

Em síntese, com base na Constituição, podemos classificar os direitos fundamentais em cinco grupos:

- (1) *direitos individuais* (art. 5º);
- (2) *direitos à nacionalidade* (art. 12);
- (3) *direitos políticos* (arts. 14 a 17);
- (4) *direitos sociais* (arts. 6º e 193 e ss.);
- (5) *direitos coletivos* (art. 5º);
- (6) *direitos solidários* (arts. 3º e 225)

A Constituição não inclui os direitos fundados nas relações econômicas entre os direitos fundamentais sociais. Mas os direitos econômicos existem. Teremos que reservar-lhes espaço, quando tratarmos da *ordem econômica e financeira* estabelecida nos arts. 170 a 192.

Cumpramos observar que a classificação acima não esgota o tema, mas simplesmente apresenta o agrupamento geral, pois que cada classe comporta subclasses que serão examinadas a seu tempo.

7. Integração das categorias de direitos fundamentais

A Constituição suplanta a tendência para entender os direitos individuais como contrapostos aos direitos sociais, que as constituições anteriores, de certo modo, justificavam, o que resultava da persistência da visão individualista e liberalista dos direitos individuais. Tratava-se de deformação de perspectiva, pois só o fato de estabelecer-se um rol de direitos econômicos, sociais e culturais já importava, necessariamente, em conferir-se conteúdo novo àquele conjunto de direitos chamados liberais.

A Constituição, agora, fundamenta o entendimento de que as categorias de direitos humanos fundamentais, nela previstos, inte-

gram-se num todo harmônico, mediante influências recíprocas, até porque os direitos individuais, consubstanciados no seu art. 5º, estão contaminados de dimensão social, de tal sorte que a previsão dos direitos sociais, entre eles, e os direitos de nacionalidade e políticos, lhes quebra o formalismo e o sentido abstrato. Com isso, transita-se de uma democracia de conteúdo basicamente político-formal para a democracia de conteúdo social, se não de tendência socializante. Quanto mais precisos e eficazes se tornem os direitos econômicos, sociais e culturais, mais se inclina do liberalismo para o socialismo. Transforma-se a pauta de valores: o liberalismo exalta a *liberdade individual*, formalmente reconhecida, mas, em verdade, auferida por pequeno grupo dominante; o socialismo realça a *igualdade material* de todos como a única base sólida em que o efetivo e geral gozo dos direitos individuais de liberdade encontra respaldo seguro. A antítese inicial entre direitos individuais e direitos sociais tende a resolver-se numa síntese de autêntica garantia para a democracia, na medida em que os últimos forem enriquecendo-se de conteúdo e eficácia. Todavia, não nos iludamos, porque a Constituição agasalhou ainda os postulados do liberalismo econômico, com intervenção estatal, mais garantia dele do que caminho para superá-lo.

Há certamente um desequilíbrio entre uma ordem social socializante e uma ordem econômica liberalizante. Vejamos, na prática, em que essa contradição dará.

O certo é que a Constituição assumiu, na sua essência, a doutrina segundo a qual há de verificar-se a integração harmônica entre todas as categorias dos direitos fundamentais do homem sob o influxo precisamente dos direitos sociais, que não mais poderiam ser tidos como uma categoria contingente. Nem é preciso fundamentá-los em bases jusnaturalistas, como se esforça em fazê-lo,³² para compreender que eles constituem, em definitivo, os novos direitos fundamentais do homem, e, com toda razão, "se estima que, mais que uma categoria de direitos fundamentais, constituem um meio positivo para dar um conteúdo real e uma possibilidade de exercício eficaz a todos os direitos e liberdades"³³ e sua proclamação supõe uma autêntica garantia para a democracia, ou seja: "para o efetivo desfrute das liberdades civis e políticas".³⁴

32. Cf., nesse sentido, Pérez Luño, "El proceso de positivación de los derechos fundamentales", in *ob. cit.*, p. 216.

33. Cf. Pérez Luño, *ob. cit.*, p. 217. Também Burdeau, *Les libertés publiques*, pp. 19 e 20; Ignacio Burgoa, *Las garantías individuales*, p. 261; Ferreira Filho, Grinover e Cunha Ferraz, *ob. cit.*, p. 7; Mauro Cappelletti, *Proceso, ideologia, sociedad*, pp. 118 a 121.

34. Cf. Pérez Luño, *ob. cit.*, p. 217.

8. Direitos e garantias dos direitos

A afirmação dos direitos fundamentais do homem no Direito Constitucional positivo reveste-se de transcendental importância, mas, como notara Maurice Hauriou, não basta que um direito seja reconhecido e declarado, é necessário garanti-lo, porque virão ocasiões em que será discutido e violado.³⁵ Ruy Barbosa já dizia que uma coisa são os direitos, outra as *garantias*, pois devemos separar, “no texto da lei fundamental, as disposições *meramente declaratórias*, que são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as disposições *assecuratórias*, que são as que, em defesa dos direitos, limitam o poder. Aquelas instituem os *direitos*; estas, as *garantias*: ocorrendo não raro juntar-se, na mesma disposição constitucional, ou legal, a fixação da garantia, com a declaração do direito”.³⁶ Não são nítidas, porém as linhas divisórias entre direitos e garantias, como observa Sampaio Dória, para quem “os direitos são garantias, e as garantias são direitos”, ainda que se procure distingui-los.³⁷ Nem é decisivo, em face da Constituição, afirmar que os direitos são *declaratórios* e as garantias *assecuratórias*, porque as garantias em certa medida são declaradas e, às vezes, se declaram os direitos usando forma assecuratória.

A Constituição, de fato, não consigna regra que aparte as duas categorias, nem sequer adota terminologia precisa a respeito das garantias. Assim é que a rubrica do Título II enuncia: “*Dos direitos e garantias fundamentais*”, mas deixa à doutrina pesquisar onde estão os direitos e onde se acham as garantias. O Capítulo I desse Título traz a rubrica: “*Dos direitos e deveres individuais e coletivos*”, não menciona as garantias, mas boa parte dele constitui-se de garantias.³⁸ Ela se vale de verbos para declarar direitos que são mais apropriados para enunciar garantias. Ou talvez melhor diríamos, ela reconhece alguns direitos garantindo-os. Por exemplo: “*é assegurado o direito*

35. Cf. *Derecho público y constitucional*, p. 120. Também Rodrigo Octávio e Paulo Viana, *Elementos de direito público e constitucional brasileiro*, pp. 62 e 63.

36. Cf. *República: teoria e prática (Textos doutrinários sobre direitos humanos e políticos consagrados na primeira Constituição da República)*, pp. 121 e 124. Cf. também Virga, *ob. cit.*, p. 222. É preciso anotar que a Constituição não seguiu, exatamente, o conselho de Ruy, pois ela não separa rigorosamente os direitos de suas garantias. Houve várias propostas nesse sentido, mas o Relator, constituinte Bernardo Cabral, não teve sensibilidade para uma sistematização constitucional que organizasse os direitos e suas garantias em capítulos separados. Preferiu, influenciado por Relatores coadjuvantes, arrolar tudo num dispositivo só em forma de incisos. Bem verdade que, aí, tentou arranjar em conjuntos, em função de sua natureza.

37. Cf. *Direito constitucional*, t. II/57.

38. Com efeito, dito capítulo só tem um artigo (o 5º) que se compõe de 77 incisos. Destes, talvez a metade constitui garantias. Veremos isso mais adiante, mas praticamente do incs. XXXV ao LXXVII são garantias.

de resposta [...]” (art. 5º, V), “*é assegurada [...]* a prestação de assistência religiosa [...]” (art. 5º, VII), “*é garantido o direito de propriedade*” (art. 5º, XXII), “*é garantido o direito de herança*” (art. 5º, XXX). Outras vezes, garantias são enunciadas pela *inviolabilidade* do elemento assecuratório. Assim, “a casa é o asilo *inviolável* do indivíduo” (art. 5º, XI), “*é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas [...]*” (art. 5º, XII); ora, nesses casos, a inviolabilidade do lar e do sigilo constitui garantia do direito à intimidade pessoal e familiar e da liberdade de transmissão pessoal do pensamento, mas a Constituição mesma fala em direitos de sigilo de correspondência e de sigilo de comunicação (art. 136, § 1º, I, b e c). Já noutro dispositivo está que “*são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas [...]*” (art. 5º, X); aqui o direito e a garantia se integram: *inviolabilidade* = garantia; *intimidade, vida privada, honra, imagem pessoal* = direito de privacidade. Temos ainda *garantias expressas neste artigo* (art. 5º, § 2º), *garantias da magistratura* (art. 95). O art. 138 menciona *garantias constitucionais*. Fica difícil distinguir as diferenças ou semelhanças entre o que sejam garantias fundamentais, garantias individuais e garantias constitucionais.

A doutrina não auxilia muito no descortinar o sentido dessas expressões. Ela emprega a expressão *garantias constitucionais* em três sentidos: (1) reconhecimento constitucional dos direitos fundamentais; assim, a declaração de direitos seria simplesmente um compromisso de respeitar a existência e o exercício desses direitos, “que não provém de lei alguma, senão diretamente da qualidade e dos atributos naturais do ser humano”;³⁹ parte-se da idéia de que os direitos preexistem à Constituição, que não os cria nem outorga, reconhece-os apenas e os garante; é uma idéia vinculada à concepção do direito natural ou da supra-estatalidade dos direitos fundamentais; (2) “prescrições que vedam determinadas ações do poder público”,⁴⁰ ou “*formalidades* prescritas pelas Constituições, para abrigarem dos abusos do poder e das violações possíveis de seus concidadãos os *direitos constitutivos da personalidade individual*”;⁴¹ (3) “proteção prática da liberdade levada ao máximo de sua eficácia”⁴² ou “recursos jurídicos destinados a fazer efetivos os direitos que assegura”.⁴³

39. Cf. Luiz Bazdresch, *Curso elemental de garantías constitucionales*, p. 14; Alejandro Silva Bascuñán, *Tratado de derecho constitucional*, t. II/05; Ferreira Filho, Grinover e Cunha Ferraz, *ob. cit.*, p. 119.

40. Cf. Ferreira Filho, Grinover e Cunha Ferraz, *ob. cit.*, p. 119.

41. C. Leovigildo Filgueiras, *Discurso no Congresso Nacional em 1.9.1892*, citado por Ruy Barbosa, *ob. cit.*, p. 123.

42. Cf. Carlos Sánchez Viamonte, *Manual de derecho constitucional*, p. 123.

43. Cf. Bascuñán, *ob. cit.*, p. 208.

Há, ainda, um conceito mais amplo de *garantia constitucional*: “meios predispostos para assegurar a observância, e, portanto, a conservação, de um determinado ordenamento constitucional”.⁴⁴ Mas aqui já não se trata mais de garantia dos direitos fundamentais, mas de defesa de dado regime político constitucional, sendo mesmo até contrário, às vezes, aos direitos, porquanto são meios que importam na suspensão destes e de algumas de suas garantias (estado de defesa e estado de sítio, que estudaremos a seu tempo).

Interessam-nos apenas as *garantias dos direitos fundamentais*, que distinguiremos em dois grupos:

(1) *garantias gerais*, destinadas a assegurar a existência e a efetividade (eficácia social) daqueles direitos, as quais “se referem à organização da comunidade política, e que poderíamos chamar condições econômico-sociais, culturais e políticas que favorecem o exercício dos direitos fundamentais”;⁴⁵ o “conjunto dessas garantias gerais formará a estrutura social que permitirá a existência real dos direitos fundamentais”;⁴⁶ trata-se da estrutura de uma sociedade democrática, que conflui para a concepção do Estado Democrático de Direito, consagrada agora no art. 1º, de que já falamos;

(2) *garantias constitucionais*, que consistem nas instituições, determinações e procedimentos mediante os quais a própria Constituição tutela a observância ou, em caso de inobservância, a reintegração dos direitos fundamentais.⁴⁷ São, por seu lado, de dois tipos: (a) *garantias constitucionais gerais*, que são instituições constitucionais que se inserem no mecanismo de freios e contrapesos dos poderes e, assim, impedem o arbítrio com o que constituem, ao mesmo tempo, técnicas de garantia e respeito aos direitos fundamentais; são garantias gerais precisamente porque consubstanciam salvaguardas de um regime de respeito à pessoa humana em toda a sua dimensão; (b) *garantias constitucionais especiais*, que são prescrições constitucionais estatuinto técnicas e mecanismos que, limitando a atuação dos órgãos estatais ou de particulares, protegem a eficácia, a aplicabilidade e a inviolabilidade dos direitos fundamentais de modo especial;

44. Cf. Ferruccio Pergolesi, *Diritto costituzionale*, v. I/57.

45. Cf. Peces-Barba, *ob. cit.*, p. 194.

46. *Idem*, p. 197.

47. Rosah Russomano define as garantias constitucionais, em sentido estrito, como “as determinações e os procedimentos mediante os quais os direitos inerentes à pessoa humana obtêm uma tutela concreta”, cf. *Curso de Direito Constitucional*, p. 333; Luiz Carlos Sábica, *Derecho constitucional de la libertad*, onde oferece o seguinte conceito: “Todo mecanismo, prestación, servicio, procedimiento de vigilancia o intervención, que tiendan a dar seguridad, vigencia real y eficacia a una libertad, es una garantía”.

são técnicas preordenadas com o objetivo de assegurar a observância desses direitos considerados em sua manifestação isolada ou em grupos. São destas que cuidaremos de modo mais pormenorizado no Título VI.

O conjunto das garantias dos direitos fundamentais forma o sistema de proteção deles: proteção social, proteção política e proteção jurídica.

As *garantias constitucionais* em conjunto caracterizam-se como imposições, positivas ou negativas, aos órgãos do Poder Público, limitativas de sua conduta, para assegurar a observância ou, no caso de violação, a reintegração dos direitos fundamentais.

As *garantias constitucionais especiais* são normas constitucionais que conferem, aos titulares dos direitos fundamentais, meios, técnicas, instrumentos ou procedimentos para impor o respeito e a exigibilidade de seus direitos. Nesse sentido, essas garantias não são um fim em si mesmas, mas instrumentos para a tutela de um direito principal. Estão a *serviço* dos direitos humanos fundamentais,⁴⁸ que, ao contrário, são um fim em si, na medida em que constituem um conjunto de faculdades e prerrogativas que asseguram vantagens e benefícios diretos e imediatos a seu titular. Podem-se auferir tais vantagens e benefícios sem utilizar-se das garantias. Mas estas não conferem vantagens nem benefícios em si. São instrumentais, porque servem de meio de obtenção das vantagens e benefícios decorrentes dos direitos que visam garantir. Assim, é fácil perceber que tais normas constitucionais de garantia são também *direitos* — direitos *conexos* com os direitos fundamentais — porque são *permissões* concedidas pelo Direito Constitucional objetivo ao homem para a defesa desses outros direitos principais e substanciais.⁴⁹ Então, podemos afirmar que as *garantias constitucionais especiais* — e não *direitos fundamentais* — é que são os autênticos *direitos públicos subjetivos*, no sentido da doutrina clássica, porque, efetivamente, são concedidas pelas normas jurídicas constitucionais aos particulares para exigir o respeito, a observância, o cumprimento dos direitos fundamentais em concreto, importando, aí sim, imposições do Poder Público de atuações ou vedações destinadas a fazer valer os direitos garantidos.

48. Vale a esse propósito o que disse Cappelletti sobre o direito processual: “El derecho procesal no es en verdad un fin en sí mismo, sino instrumento para el fin de la tutela del derecho *substancial*, público y privado; está, en suma, por decirlo así, al *servicio* del derecho *sustancial*, del cual tiende a garantizar la *efectividad*, o sea la observancia, y, para el caso de inobservancia, la reintegración”, cf. *Proceso, ideología, sociedad*, p. 5. Assim é toda garantia de direitos, certamente, instrumento a serviço de outro direito, principal, substancial.

49. Cf. Goffredo Telles Júnior, *Direito Quântico*, p. 410.

Título II

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Capítulo I

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS

1. Conceito de direito individual. 2. Destinatários dos direitos e garantias individuais. 3. Classificação dos direitos individuais. 4. Direitos coletivos. 5. Deveres individuais e coletivos.

1. Conceito de direito individual

O art. 5º da Constituição arrola o que ela denomina de *direitos e deveres individuais e coletivos*. Não menciona aí as garantias dos direitos individuais, mas estão também lá. O dispositivo começa enunciando o *direito de igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza*. Embora seja uma declaração formal, não deixa de ter sentido especial essa primazia ao direito de igualdade, que, por isso, servirá de orientação ao intérprete, que necessitará de ter sempre presente o princípio da igualdade na consideração dos direitos fundamentais do homem. Em seqüência, o dispositivo assegura aos *brasileiros* e aos estrangeiros residentes no País a *inviolabilidade* do direito à *vida*, à *liberdade*, à *igualdade*, à *segurança* e à *propriedade*, nos termos dos incisos que integram o artigo. Na verdade, essa segunda parte do dispositivo mantém uma tradição obtusa e inadequada. Não tem sentido dizer só nesse artigo que a Constituição assegura aos *brasileiros* os direitos ali indicados, pois ela é feita para o Brasil e para os brasileiros, exatamente para assegurar-lhes todos os direitos nela positivados. É limitativa, em relação aos estrangeiros residentes no País, como se a eles apenas fossem reconhecidos os direitos arrolados no art. 5º, como se, por exemplo, a eles fosse sonegado o gozo dos direitos sociais, que não constam deste artigo. O artigo assegura “a inviolabilidade do *direito à vida* nos termos seguintes [...]”, mas, nos termos seguintes, constantes dos incisos e parágrafos, nada mais se diz sobre a vida, a não ser da inviolabilidade da *vida privada*, que não é

direito à vida,¹ mas direito à privacidade. E muitas outras observações se poderiam fazer à obtusidade que se configura nessa segunda parte do *caput* em nome de uma tradição que, desde a Constituição de 1934, perdeu sua razão de ser, porque, de lá para cá, outros direitos fundamentais foram acolhidos e reconhecidos aos brasileiros e estrangeiros residentes no País, além dos individuais e suas garantias.

A Constituição *garante* a inviolabilidade dos direitos referidos, mas não é nisso que se encontram as garantias individuais, que ela não menciona na rubrica do capítulo, como faziam as anteriores. Mas essas garantias estão entre os direitos arrolados, melhor sistematizadas desta vez, e delas trataremos no Título VI juntamente com outras, onde voltaremos, com pormenores mais concretos, sobre a distinção entre garantias e direitos.²

Já demos antes uma *noção de direito individual*.³ Então, concebêmo-los como *direitos fundamentais do homem-indivíduo*, que são aqueles que reconhecem autonomia aos particulares, garantindo a iniciativa e independência aos indivíduos diante dos demais membros da sociedade política e do próprio Estado. Por isso, a doutrina (francesa, especialmente) costuma englobá-los na concepção de *liberdade-autonomia*.

2. Destinatários dos direitos e garantias individuais

Viu-se que o art. 5º da Constituição assegura os direitos ali indicados tanto aos *brasileiros* como aos *estrangeiros* residentes no País.

A propósito, cabem três indagações: sendo direitos e garantias *individuais*, pessoas jurídicas não os auferem a nenhum? Aos *estrangeiros residentes* só se reconhecem esses direitos e garantias constantes daquele artigo? Os *estrangeiros não residentes*, mesmo estando no País, estão excluídos de incidência de qualquer deles ou delas?

O princípio é o de que os direitos e garantias assegurados nos incisos do art. 5º se dirigem às *pessoas físicas*, ao indivíduo, e não às pessoas jurídicas. Assim pensava Pontes de Miranda,⁴ em comentário ao art. 153 da Constituição de 1967/1969, conquanto em outra

1. Di-lo o art. 227, ainda genericamente, para assegurar o direito à vida da criança e ao adolescente. Só.

2. Cf. n. 8 do Capítulo II do Título I desta Segunda Parte, onde já esboçamos uma teoria da distinção entre direitos e suas garantias.

3. Cf. n. 6 do Capítulo II do Título I desta Segunda Parte, onde tratamos da classificação dos direitos fundamentais.

4. Cf. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969, t. IV/696 e 697.

passagem de sua obra diga que determinado direito ampara também as pessoas jurídicas.⁵ Manoel Gonçalves Ferreira Filho, já em face da Constituição vigente, admitira que beneficiam também pessoas jurídicas brasileiras e estrangeiras que atuem no Brasil.⁶ O princípio é o mencionado acima, mas a pesquisa no texto constitucional mostra que vários dos direitos arrolados nos incisos do art. 5º se estendem às pessoas jurídicas, tais como o princípio da isonomia, o princípio da legalidade, o direito de resposta, o direito de propriedade, o sigilo da correspondência e das comunicações em geral, a inviolabilidade do domicílio, a garantia do direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, assim como a proteção jurisdicional e o direito de impetrar mandado de segurança. Há até direito que é próprio de pessoa jurídica, como o direito à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos (logotipos, fantasias, p. ex.). Mas as empresas de capital estrangeiro, incluindo as multinacionais, não se beneficiam desses direitos e garantias constitucionais individuais, salvo, no que tange a marcas, nomes e signos, proteção de direito internacional.

O *estrangeiro residente* não tem só os direitos arrolados no art. 5º, apesar de somente ali aparecer como destinatário de direitos constitucionais. Cabem-lhe os direitos sociais, especialmente os trabalhistas. Ao outorgar direitos aos *trabalhadores urbanos e rurais*, por certo que aí a Constituição alberga também o trabalhador estrangeiro residente no País, e assim se há de entender em relação aos outros direitos sociais; seria contrário aos direitos fundamentais do homem negá-los aos estrangeiros residentes aqui.

A posição do *estrangeiro não residente* em face dos direitos e garantias assegurados no art. 5º não é fácil de delinear, tendo em vista que aí só se mencionam os *brasileiros e estrangeiros residentes no País*. Houve, no seio da Constituinte, tentativa para definir, com clareza, a condição jurídica do estrangeiro, mas o douto Relator Bernardo Cabral não foi sensível ao tema.

Se se entender o texto do art. 5º, *caput*, ao pé da letra, o estrangeiro não residente não gozará de nenhum dos direitos e garantias nele enunciados. Pontes de Miranda não pensava assim, pois, sobre o tema, em face da Constituição revogada, achava que “alguns parágrafos [do então art. 153] modificam a extensão da parte inicial do artigo, ou para diminuí-la, ou para levá-la além. Só o exame das questões pode guiar-nos na análise das espécies, utilizados os conceitos de

5. Assim o afirma em relação ao princípio da igualdade perante a lei e ao direito de propriedade (*ob. cit.*, pp. 691 e 697).

6. Cf. *Comentários à Constituição brasileira de 1988*, v. 1/26.

supra-estatalidade e infra-estatalidade, de que antes falamos”.⁷ Conclui que direitos, que ele reputava supra-estatais e absolutos, são assegurados a *qualquer ser humano*.⁸

Já discutimos essa concepção sobre a supra-estatalidade de certos direitos, que não aceitamos. Vimos, ao contrário, que uma das características das declarações constitucionais de direitos está na *positivação* e *subjetivação* destes, justamente para indicar sua validade em relação aos indivíduos do Estado, salvo enunciado expresse noutro sentido. Por isso, quando a Constituição, como as anteriores, assegura tais direitos aos *brasileiros e estrangeiros residentes no País*, indica, concomitantemente, sua positivação em relação aos *sujeitos* (subjetivação) a que os garante. Só eles, portanto, gozam do *direito subjetivo* (poder ou permissão de exigibilidade) relativamente aos enunciados constitucionais dos direitos e garantias individuais. Se a Constituição aponta os destinatários desses direitos, isso há de ter consequências normativas. Isso não quer dizer que os estrangeiros não residentes, quando regularmente se encontrem no território nacional, possam sofrer o arbítrio, e não disponham de qualquer meio, incluindo os jurisdicionais, para tutelar situações subjetivas. Para protegê-los, há outras normas jurídicas, inclusive de Direito Internacional, que o Brasil e suas autoridades têm que respeitar e observar, assim como existem normas legais, traduzidas em legislação especial, que definem os direitos e a condição jurídica do estrangeiro não residente, que tenha ingressado regularmente no território brasileiro. Ocorre, ademais, que o fato de a Constituição não incluir os estrangeiros não residentes não justifica sequer a possibilidade de legislação ordinária abusiva em relação a eles, pois, além da existência de normas de Direito Internacional vinculantes, o Brasil é, ainda, subscritor das declarações universal e americana dos direitos humanos, o que, agora até por força do § 2º do art. 5º, lhe impõe, quando nada, a consideração de que a pessoa humana tem uma dimensão supranacional que mereceu um mínimo de respeito e postula um tratamento condigno, ao menos no que tange àqueles direitos de natureza personalíssima. Quando o art. 1º põe a *dignidade da pessoa humana* como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito faz uma proclamação de valor universal, aí sim, abrangente do *ser humano*.

3. Classificação dos direitos individuais

A Constituição dá-nos um critério para a classificação dos direitos que ela enuncia no art. 5º, quando assegura a inviolabilidade do

7. *Ob. cit.*, t. IV/695.

8. *Ob. cit.*, pp. 622, 625 e 626.

direito à *vida*, à *igualdade*, à *liberdade*, à *segurança* e à *propriedade*. O critério é o do *objeto imediato* do direito assegurado.⁹ A dificuldade está em que, nesse agrupamento, se acham direitos e garantias, que teremos que distinguir, positivamente, mais adiante. Os direitos que têm por objeto imediato a segurança, por exemplo, parece incluir-se todos no campo das garantias individuais, e como tal serão estudados em outro lugar. Mas é necessário ter em mente que o direito à segurança aí enunciado contém implícito um direito fundamental do indivíduo, que, assim, não aparece nas classes indicadas no *caput* do artigo. Teremos, pois, que tentar aflorá-los aqui, já que são de extrema importância para o respeito à personalidade. Faremos isso, contudo, mantendo a base da classificação constitucional, pois outra seria tão relativa e imperfeita como ela.¹⁰ Levaremos em conta também a circunstância de a Constituição mesma admitir outros direitos e garantias individuais não enumerados, quando, no § 2º do art. 5º, declara que os *direitos e garantias previstos neste artigo não excluem outros decorrentes dos princípios e do regime adotado pela Constituição e dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte*. Daí, primeiramente, a divisão desses direitos individuais (deixemos as garantias para depois) em dois grupos: *direitos individuais expressos* e *direitos individuais decorrentes do regime*.

Preferimos, no entanto, fazer uma distinção em três grupos sob esse aspecto: (1) *direitos individuais expressos*, aqueles explicitamente enunciados nos incisos do art. 5º; (2) *direitos individuais implícitos*, aqueles que estão subentendidos nas regras de garantias, como o direito à identidade pessoal, certos desdobramentos do direito à vida, o direito à atuação geral (art. 5º, II); (3) *direitos individuais decorrentes do regime e de tratados internacionais* subscritos pelo Brasil, aqueles que não são nem explícita nem implicitamente enumerados, mas provêm ou podem vir a provir do regime adotado, como o *direito de resistência*, entre outros de difícil caracterização *a priori*. Por isso as categorias adiante indicadas somente incluirão os direitos individuais expressos e implícitos, conforme seu objeto imediato.

Com esses esclarecimentos e deixando desdobramentos para o capítulo correspondente, podemos classificar os direitos individuais nos grupos seguintes: (1) direito à vida; (2) direito à intimidade; (3) direito de igualdade; (4) direito de liberdade; (5) direito de propriedade.

9. Cf. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de Direito Constitucional*, p. 254.

10. Para outras classificações, além da citada do Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *ob. cit.*, pp. 254 e 255, cf. Claude-Albert Colliard, *Libertés publiques*, p. 199; Jean Rivero, *Les libertés publiques* — 1. *Les droits de l'homme*, p. 23; J. Cretella Júnior, *Liberdades públicas*, p. 43; Ruy Barbosa, *República: teoria e prática*, pp. 90 e ss.

4. Direitos coletivos

A rubrica do Capítulo I do Título II anuncia uma especial categoria dos direitos fundamentais: os coletivos, mas nada mais diz a seu respeito. Onde estão, nos incisos do art. 5º, esses direitos coletivos?

Houve propostas, na Constituinte, de abrir-se um capítulo próprio para os *direitos coletivos*. Nele seriam incluídos direitos tais como o de acesso à terra urbana e rural, para nela trabalhar e morar, o de acesso de todos ao trabalho, o direito a transporte coletivo, à energia, ao saneamento básico, o direito ao meio ambiente sadio, o direito à melhoria da qualidade de vida, o direito à preservação da paisagem e da identidade histórica e cultural da coletividade, o direito às informações do Poder Público a requerimento de sindicatos e associações em geral (que o Senador José Paulo Bisol chamou de *visibilidade e corregedoria social dos poderes*), os direitos de reunião, de associação e de sindicalização, o direito de manifestação coletiva, incluindo-se aí o direito de greve, o direito de controle do mercado de bens e serviços essenciais à população e os direitos de petição e de participação direta.

Muitos desses ditos direitos coletivos sobrevivem ao longo do texto constitucional, caracterizados, na maior parte, como direitos sociais, como a liberdade de associação profissional e sindical (arts. 8º e 37, VI), o direito de greve (arts. 9º e 37, VII), o direito de participação de trabalhadores e empregadores nos colegiados de órgãos públicos (art. 10), a representação de empregados junto aos empregadores (art. 11), o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225); ou caracterizados como instituto de democracia direta nos arts. 14, I, II e III, 27, § 4º, 29, XIII, e 61, § 2º; ou, ainda, como instituto de fiscalização financeira, no art. 31, § 3º. Apenas as liberdades de reunião e de associação (art. 5º, XVI a XX), o direito de entidades associativas de representar seus filiados (art. 5º, XXI) e os direitos de receber informações de interesse coletivo (art. 5º, XXXIII) e de petição (art. 5º, XXXIV, *a*) restaram subordinados à rubrica dos direitos coletivos. Alguns deles não são propriamente direitos coletivos, mas *direitos individuais de expressão coletiva*, como as liberdades de reunião e de associação.

5. Deveres individuais e coletivos

A rubrica do artigo agora menciona também *deveres individuais e coletivos*. Os conservadores da Constituinte clamaram mais pelos deveres que pelos direitos. Sempre reclamaram que a Constituição

só estava outorgando direitos e perguntavam onde estariam os deveres? Postulavam, até que se introduzissem aí deveres individuais e coletivos. Não era isso que queriam, mas uma declaração constitucional de deveres, que se impusessem ao povo. Ora, uma Constituição não tem que fazer declaração de deveres paralela à declaração de direitos. Os deveres decorrem destes na medida em que cada titular de direitos individuais tem o dever de reconhecer e respeitar igual direito do outro, bem como o dever de comportar-se, nas relações inter-humanas, com postura democrática, compreendendo que a dignidade da pessoa humana do próximo deve ser exaltada como a sua própria.

Na verdade, os deveres que decorrem dos incisos do art. 5º, têm como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades e detentores de poder. Alguns exemplos esclarecem o tema: o dever de propiciar ampla defesa aos acusados, o dever de só prender alguém por ordem escrita de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressões militares e crimes propriamente militares, o dever de comunicar a prisão de alguém e o local onde se encontra ao juiz competente e à família do preso, o dever de informar ao preso os seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, assegurada a assistência da família e de advogado, o dever de identificação, ao preso, dos responsáveis por sua prisão ou interrogatório, o dever de respeitar a integridade física do preso etc. (art. 5º, XLIX, LXII, LXIII e LXIV).

Capítulo II

DO DIREITO À VIDA E DO DIREITO À PRIVACIDADE

I. DIREITO À VIDA: 1. A vida como objeto do direito. 2. Direito à existência. 3. Direito à integridade física. 4. Direito à integridade moral. 5. Pena de morte. 6. Eutanásia. 7. Aborto. 8. Tortura. II. DIREITO À PRIVACIDADE: 9. Conteúdo e conteúdo. 10. Intimidade. 11. Vida privada. 12. Honra e imagem das pessoas. 13. Privacidade e informática. 14. Violação à privacidade e indenização.

I. DIREITO À VIDA

1. A vida como objeto do direito

Não intentaremos dar uma definição disto que se chama vida, porque é aqui que se corre o grave risco de ingressar no campo da metafísica supra-real, que não nos levará a nada. Mas alguma palavra há de ser dita sobre esse *ser* que é objeto de direito fundamental. *Vida*, no texto constitucional (art. 5º, *caput*), não será considerada apenas no seu sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, peculiar à matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica mais compreensiva. Sua riqueza significativa é de difícil apreensão porque é algo dinâmico, que se transforma incessantemente sem perder sua própria identidade. É mais um processo (processo vital), que se instaura com a concepção (ou germinação vegetal), transforma-se, progride, mantendo sua identidade, até que muda de qualidade, deixando, então, de ser vida para ser morte. Tudo que interfere em prejuízo deste fluir espontâneo e incessante contraria a vida.

Todo ser dotado de vida é *indivíduo*, isto é: algo que não se pode dividir, sob pena de deixar de *ser*. O homem é um indivíduo, mas é mais que isto, *é uma pessoa*.¹ "Além dos caracteres de indivíduo biológico tem os de unidade, identidade e continuidade substanciais."² No dizer de Ortega y Gasset, mencionado por Recaséns Siches, "la

1. Cf. Recasén Siches, *Vida humana, sociedad y derecho*, p. 254.

2. Idem, p. 254.

vida consiste em *la compresencia, en la coexistencia del yo con un mundo, de un mundo conmigo*, como elementos inseparables, inescindibles, correlativos”.³ A *vida humana*, que é o objeto do direito assegurado no art. 5º, *caput*, integra-se de elementos materiais (físicos e psíquicos) e imateriais (espirituais). A “vida é intimidade conosco mesmo, saber-se e dar-se conta de si mesmo, um assistir a si mesmo e um tomar posição de si mesmo”.⁴ Por isso é que ela constitui a fonte primária de todos os outros bens jurídicos. De nada adiantaria a Constituição assegurar outros direitos fundamentais, como a igualdade, a intimidade, a liberdade, o bem-estar, se não erigisse a vida humana num desses direitos. No conteúdo de seu conceito se envolvem o direito à dignidade da pessoa humana (de que já tratamos),⁵ o direito à privacidade (de que cuidaremos no capítulo seguinte), o direito à integridade físico-corporal, o direito à integridade moral e, especialmente, o direito à existência.

No dizer de Jacques Robert: “O respeito à vida humana é a um tempo uma das maiores idéias de nossa civilização e o primeiro princípio da moral médica. É nele que repousa a condenação do aborto, do erro ou da imprudência terapêutica, a não-aceitação do suicídio. Ninguém terá o direito de dispor da própria vida, *a fortiori* da de outrem e, até o presente, o feto é considerado como um ser humano”.⁶

2. Direito à existência

Consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria vida, de permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o processo vital senão pela morte espontânea e inevitável. Existir é o movimento espontâneo contrário ao estado morte. Porque se assegura o direito à vida é que a legislação penal pune todas as formas de interrupção violenta do processo vital. É também por essa razão que se considera legítima a defesa contra qualquer agressão à vida, bem como se reputa legítimo até mesmo tirar a vida a outrem em estado de necessidade da salvação da própria.

Tentou-se incluir na Constituição o *direito a uma existência digna*.⁷ Esse conceito de existência digna consubstancia aspectos generosos

3. Idem, p. 61.

4. Idem, p. 60.

5. Cf. Primeira Parte, Título II, Capítulo II, n. 8, quarto parágrafo.

6. Cf. *Libertés publiques*, p. 234. Não se tome essa citação senão como um realce ao valor da vida, não como nossa opinião sobre o aborto, que discutiremos mais adiante em face do nosso direito.

7. O Anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais (conhecida como Comissão Afonso Arinos, nome de seu presidente) dispôs, no art. 6º: “To-

de natureza material e moral; serviria para fundamentar o desligamento de equipamentos médico-hospitalares, nos casos em que o paciente estivesse vivendo artificialmente (mecanicamente), a prática da eutanásia, mas trazia implícito algum risco como, por exemplo, autorizar a eliminação de alguém portador de deficiência de tal monta que se viesse a concluir que não teria uma existência humana digna. Por esses riscos, talvez tenha sido melhor não acolher o conceito.

3. Direito à integridade física

Agredir o corpo humano é um modo de agredir a vida, pois esta se realiza naquele. A integridade físico-corporal constitui, por isso, um bem vital e revela um direito fundamental do indivíduo. Daí por que as lesões corporais são punidas pela legislação penal. Qualquer pessoa que as provoque fica sujeita às penas da lei. Mas a Constituição foi expressa em *assegurar o respeito à integridade física dos presos* (art. 5º, XLIX). As constituições anteriores já o consignavam, com pouca eficácia. Utilizam-se habitualmente várias formas de agressão física a presos, a fim de extrair-lhes confissões de delitos. Fatos esses que já estão abolidos desde a Constituição de 1824, quando, em seu art. 179, XIX, suprimiu os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis, o que foi completado pelo art. 72, § 20, da Constituição de 1891, ao abolir a pena de galés e o banimento judicial.

Não bastou, porém, simplesmente abolir. Precisou vedar expressamente. Nem assim se tem evitado a prática de tais formas de tortura e crueldade, sem que os agentes sofram qualquer punição pelo crime que, com isso, cometem. Agora, a Constituição vai mais longe: além de garantir o respeito à integridade física e moral, declara que *ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante* (art. 5º, III). A fim de dotar essas normas de eficácia, além de cominação de penas, a atual Carta Magna preordena várias garantias penais apropriadas, como o dever de comunicar, imediatamente, ao juiz competente e à família ou pessoa indicada, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre; o dever também da autoridade policial de informar ao preso seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, assegurada a assistência da família e de advogado; e o direito do preso à identificação dos responsáveis por sua prisão e interrogatório policial.

dos têm direito à existência digna”. O relatório da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, de autoria do Sen. José Paulo Bisol, também consignava o direito à existência digna, com providências materiais como o mínimo necessário ao seu exercício (art. 3º, I), o qual não figurara sequer no Projeto submetido ao Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

Se a integridade física é um direito individual, surge a questão de saber se é lícito ao indivíduo alienar membros ou órgãos de seu corpo. O problema é delicado. Se essa alienação, onerosa ou gratuita, se faz para extração após a morte do alienante, não parece que caiba qualquer objeção. É que, em tal caso, não ocorre ofensa à vida, que já inexistirá.

É inusitada a situação, que, às vezes, se manifesta na imprensa, de pessoas que oferecem rim ou olho, para extração imediata, em vida, por determinada importância em dinheiro. A doação sempre foi admitida, visando a suprir deficiência e até salvar a vida de doentes. A questão da licitude da alienação está agora submetida a norma constitucional explícita (art. 199, § 4º), segundo a qual a lei é que define as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue, *vedado, porém, todo tipo de comercialização*. São, pois, bens fora do comércio. Este é uma atividade de intermediação na circulação da riqueza. *Comercialização* consiste, portanto, na prática de atos de comércio, ou seja: na prática de atos medianeiros entre a produção e o consumo com intuito de lucro.⁸ A lei, referida no dispositivo constitucional, já foi promulgada (Lei 9.434, de 4.2.1997, regulamentada pelo Decreto 2.268, de 30.6.1997, que instituiu o Sistema Nacional de Transplante — SNT). Ao contrário do que as edições anteriores supunham possível: a doação onerosa de órgão diretamente do seu titular ao utente, a lei só admitiu a disposição *gratuita* de tecidos, órgãos e partes do corpo humano em vida ou *post mortem*, para fins de transplante e tratamento. Para os efeitos da referida lei, o *sangue*, o *esperma* e o *óvulo* não estão compreendidos entre os tecidos mencionados no seu art. 1º. Procedeu bem a lei ao estabelecer a gratuidade para o caso. É que a vida, além de ser um direito fundamental do indivíduo, é também um interesse que, não só ao Estado, mas à própria humanidade, em função de sua conservação, cabe preservar. Do mesmo modo que a ninguém é legítimo alienar outros direitos fundamentais, como a liberdade, por exemplo, também não se lhe admite alienar a própria vida, em nenhuma de suas dimensões. É de observar, contudo, que a lei só permite a disposição de tecidos, órgãos ou partes do próprio corpo vivo para fins de transplante, quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e não cause mu-

8. Cf. Waldemar Ferreira, *Instituições de Direito Comercial*, v. I, t. I/145; Rubens Requião, *Curso de Direito Comercial*, v. I/36 e 37.

tilação ou deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora (art. 9º). Dá-se que a doação, em tela, tem por objetivo salvar vida, e não teria justificativa sacrificar a vida ou a vitalidade do doador extinguindo ou mutilando a própria vida. Por essa razão, também a doação, em vida, depende de autorização do doador, de preferência por escrito e diante de testemunhas. Já a disposição *post mortem* de tecidos, órgãos e partes do corpo para fins de transplante presume-se autorizada, salvo manifestação de vontade em contrário. Por isso, a lei prevê que a manifestação em contrário conste da Carteira de Identidade e da Carteira Nacional de Habilitação, mediante a expressão “não-doador de órgãos e tecidos”, gravada de forma indelével e inviolável (art. 4º). A lei fala em gravação cumulativa naqueles dois documentos. É exagero, pois, se constar de uma, a manifestação de vontade em contrário à doação já foi expressada.

4. Direito à integridade moral

A vida humana não é apenas um conjunto de elementos materiais. Integram-na, outrossim, valores imateriais, como os morais. A Constituição empresta muita importância à moral como valor ético-social da pessoa e da família, que se impõe ao respeito dos meios de comunicação social (art. 221, IV). Ela, mais que as outras, realçou o valor da moral individual, tornando-a mesmo um bem indenizável (art. 5º, V e X). A moral individual sintetiza a honra da pessoa, o bom nome, a boa fama, a reputação que integram a vida humana como dimensão imaterial. Ela e seus componentes são atributos sem os quais a pessoa fica reduzida a uma condição animal de pequena significação. Daí por que o respeito à integridade moral do indivíduo assume feição de direito fundamental. Por isso é que o Direito Penal tutela a honra contra a calúnia, a difamação e a injúria.

Mas há formas de ofensa à moral que se revelam como tortura praticada por autoridades, daí por que a Constituição destaca esse aspecto, para *assegurar aos presos o respeito à sua integridade moral*, tanto quanto à integridade física (art. 5º, XLIX). As constituições anteriores o consignavam também, mas não impediram os abusos. Oxalá, esta seja mais eficaz.

5. Pena de morte

Ao direito à vida contrapõe-se a pena de morte. Uma constituição que assegure o direito à vida incidirá em irremediável incoerên-

cia se admitir a pena de morte. É da tradição do Direito Constitucional brasileiro vedá-la, admitida só no caso de guerra externa declarada, nos termos do art. 84, XIX (art. 5º, XLVII, *a*), porque, aí, a Constituição tem que a sobrevivência da nacionalidade é um valor mais importante do que a vida individual de quem porventura venha a trair a pátria em momento cruciante.⁹

6. Eutanásia

Este termo tem vários sentidos: “morte bela”, “morte suave, tranqüila”, sem dor, sem padecimento. Hoje, contudo, de *eutanásia* se fala quando se quer referir à morte que alguém provoca em outra pessoa já em estado agônico ou pré-agônico, com o fim de liberá-la de gravíssimo sofrimento, em consequência de doença tida como incurável, ou muito penosa, ou tormentosa.¹⁰ Chama-se, por esse motivo, *homicídio piedoso*. É, assim mesmo, uma forma não espontânea de interrupção do processo vital, pelo que implicitamente está vedada pelo direito à vida consagrado na Constituição, que não significa que o indivíduo possa dispor da vida, mesmo em situação dramática. Por isso, nem o consentimento lúcido do doente exclui o sentido delituoso da eutanásia no nosso Direito. É que — como lembra Aníbal Bruno — a “vida é um bem jurídico que não importa proteger só do ponto de vista individual; tem importância para a comunidade. O desinteresse do indivíduo pela própria vida não exclui esta da tutela penal. O Estado continua a protegê-la como valor social e este interesse superior torna inválido o consentimento ao particular para que dela o privem. Nem sequer quando ocorrem as circunstâncias que incluíram o fato na categoria da eutanásia, ou homicídio piedoso”.¹¹

Dá-se o caso, ainda, que a eutanásia geralmente tem aplicação sem o consentimento do doente, que nem sempre está em condições de outorgá-lo validamente. Há muita discussão em torno do tema, que sempre se aguça, emocionalmente, quando algum caso de doloroso padecimento atrai a compaixão pública. No entanto, as palavras de Remo Pannain sobre a razão de punibilidade da eutanásia são de ponderar devidamente, quando ele diz que, além dos motivos religiosos, opõem-se à impunidade da eutanásia: (a) motivos científicos e de conveniência, tais como a possibilidade de um erro de diagnóstico, da descoberta de um remédio, bem como a eventualida-

de de pretexto e de abusos; (b) motivos morais (e mesmo jurídicos), pois que, dado o valor atribuído à vida humana pela consciência comum e pelo ordenamento jurídico, não se pode privar a criatura humana nem de um só átomo de existência; (c) de resto, a prevalência do motivo de piedade sobre a natural aversão à supressão de um semelhante revela, em quem pratica a eutanásia, uma personalidade sanguinária ou, pelo menos, propensa ao delito.¹² A eutanásia não mereceu maior atenção na Constituinte.

Cumpra observar que não nos parece caracterizar eutanásia a consumação da morte pelo desligamento de aparelhos que, artificialmente, mantêm vivo o paciente, já clinicamente morto. Pois, em verdade, a vida já não existiria mais, senão vegetação mecânica. Ressalve-se, é evidente, culpa ou dolo na apreciação do estado do paciente.

7. Aborto

É outro tema controvertido, que a Constituição não enfrentou diretamente. Houve três tendências no seio da Constituinte. Uma queria assegurar o direito à vida, *desde a concepção*, o que importava em proibir o aborto. Outra previa que a condição de sujeito de direito se adquiria pelo nascimento com vida, sendo que a vida intra-uterina, inseparável do corpo que a concebesse ou a recebesse, é responsabilidade da mulher, o que possibilitava o aborto. A terceira entendia que a Constituição não deveria tomar partido na disputa, nem vedando nem admitindo o aborto. Mas esta não saiu inteiramente vencedora, porque a Constituição parece inadmitir o abortamento. Tudo vai depender da decisão sobre quando começa a vida. A nós, nos parece que, no feto, já existe vida humana. Demais, numa época em que há muitos recursos para evitar a gravidez, parece injustificável a interrupção da vida intra-uterina que se não evitou. No fundo, a questão será decidida pela legislação ordinária, especialmente a penal, a que cabe definir a criminalização e descriminalização do aborto. E, por certo, há casos em que a interrupção da gravidez tem inteira justificativa, como a necessidade de salvamento da vida da mãe, o de gravidez decorrente de cópula forçada e outros que a ciência médica aconselhar.

8. Tortura

Trata-se de um conjunto de procedimentos destinado a forçar, com todos os tipos de coerção física e moral, a vontade de um impu-

9. Houve renitentes propostas dos Deputados Amaral Netto e Farabulini Júnior no sentido da adoção da pena de morte. Todas foram fragorosamente derrotadas.

10. Cf. Remo Pannain, “Omicídio”, in *Novissimo Digesto Italiano*, v. XI/882 e ss.

11. Cf. *Direito Penal*, v. I, t. II/21.

12. Cf. *ob. cit.*, in *Novissimo Digesto Italiano*, v. XI/884.

tado ou de outro sujeito, para admitir, mediante confissão ou depoimento, assim extorquidos, a verdade da acusação. Houve até o século dezoito sistemas jurídicos da tortura, nos quais esta consistia num meio lícito e válido de obtenção de provas contra o imputado. O sistema foi combatido pelos iluministas, dentre os quais Beccaria e Montesquieu.¹³ Essa prática está expressamente condenada pelo inciso III do art. 5º da Constituição, segundo o qual *ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante*. A condenação é tão incisiva que o inciso XLIII do mesmo art. 5º determina que *a lei considerará a prática da tortura crime inafiançável e insuscetível de graça, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem* (cf. Lei 9.455, de 7.4.1997).

Em verdade, ela já era condenada nas constituições anteriores, como o é nas constituições modernas em geral, o que, no entanto, não tem impedido seu uso nos cárceres brasileiros e de outros povos, como freqüentemente se divulga. Aliás, a tecnologia da tortura se torna requintada: espetos sob as unhas, queimaduras de cigarros, choques elétricos no reto, na vagina, no pênis, espancamentos, aparelhos de tormentos de variada espécie, de que sobressai o famoso “pau-de-arara”, ameaças contra mulher, filhas e filhos etc. As coisas mais pavorosas que a mente doentia pode engendrar.

Beccaria, que escreveu famoso libelo contra as penas cruéis, deixou páginas impressionantes na condenação da tortura. Para ele, ela é uma forma de terror, pelo qual se exige que “um homem seja ao mesmo tempo acusador e acusado”, enquanto a “dor se torna o cadinho da verdade, como se o critério desta residisse nos músculos e na fibra de um miserável”; que ela “é o meio seguro de absolver os robustos celerados, e de condenar os frágeis inocentes”.¹⁴

“Uma estranha consequência [diz Beccaria], que necessariamente deriva do uso da tortura, é que o inocente é posto em pior condição que o culpado; porque se ambos os dois são submetidos ao tormento, o primeiro tem todas as combinações contrárias; porque ou con-

13. Cf. Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, pp. 212 e ss.; Montesquieu, *De l'esprit des lois*, VI, 17. Quem quiser conhecer o tormento atroz que é a tortura, leia o velho livro de Pietro Verri, *Observaciones sobre la tortura*, Buenos Aires, Depalma, 1977, trad. de Manuel de Rivacoba y Rivacoba. O livro foi escrito em 1777, na Itália, e esta tradução publicada na Argentina num momento em que a tortura era instrumento político terrível como o fora no Brasil. Narra a história de uma tortura, em Milão, de inocentes acusados de causar peste na cidade. Aí ele diz que a tortura é um suplício infernal. “Con el nombre de tortura no entiendo una pena impuesta por sentencia a un reo, sino, más bien, la pretendida investigación de la verdad mediante tormentos. *Quaestio es veritatis indagatio per tormentum, seu per torturam; et potest tortura appellari quaestio a querendo, quod iudex per tormenta inquirat veritatem*” (p. 76).

14. *Ob. cit.*, pp. 215, 216 e 218.

fessa o delito, e é condenado, ou é declarado inocente, e sofreu pena indevida. Mas o culpado tem uma hipótese favorável por si, qual seja: quando, resistindo à tortura com firmeza, deve ser absolvido como inocente, trocou uma pena maior por uma menor. Portanto, o inocente não pode senão perder, e o culpado pode ganhar”.¹⁵

Note-se que Beccaria está condenando uma prática admitida nos sistemas legais de sua época.¹⁶ A crueldade se torna incomensurável quando praticada sob a égide de sistemas constitucionais que a condenam tanto quanto a consciência humana. Pior ainda se apresenta a tortura quando usada como forma de obtenção de confissão, depoimento ou de dedo-durismo nos chamados crimes políticos, já que estes mesmos são, no mais das vezes, forjados em satisfação de autoritarismo.

“A condenação da tortura pelas constituições de quase todos os Estados do mundo [lembra Lamberto Pasolli] não tem significado seu definitivo desaparecimento. Não mais usada como meio de prova regulada pela lei, tem sido aplicada, todavia, sistematicamente como instrumento infame de domínio político, por parte de monstruosas tiranias, como a nazista ou comunista, assinaladamente na idade stalinista, ou mesmo de nações que se definem como civis, como a França (durante a guerra da Argélia) ou o hodierno Brasil. É de indagar-se atemorizado se esta barbárie não terá mais fim”.¹⁷

A tortura não é só um crime contra o direito à vida. É uma crueldade que atinge a pessoa em todas as suas dimensões, e a humanidade como um todo.

II. DIREITO À PRIVACIDADE

9. Conceito e conteúdo

A Constituição declara invioláveis a *intimidade*, a *vida privada*, a *honra* e a *imagem das pessoas* (art. 5º, X).¹⁸ Portanto, erigiu, expressamente, esses valores humanos à condição de direito individual, mas

15. *Idem*, pp. 220 e 221.

16. *Dei delitti e delle pene* de Beccaria saiu a lume pela primeira vez em 1764.

17. Cf. “Tortura”, in *Novissimo Digesto Italiano*, v. XIX/428. A referência ao Brasil diz respeito às torturas com motivações políticas, que envergonham, mas felizmente desapareceram. Resta a tortura como meio de prova, não regulada por lei, mas, de fato, existente nos calabouços policiais, que, esperamos, a veemente condenação constitucional venha sufocar.

18. Sobre o assunto, cf. Paulo José da Costa Júnior, *Agressões à intimidade*, Malheiros Editores, 1997.

não o fez constar do *caput* do artigo. Por isso, estamos considerando-o um direito conexo ao da vida. Assim, ele figura no *caput* como reflexo ou manifestação deste.

O dispositivo põe, desde logo, uma questão, a de que a *intimidade* foi considerada um direito diverso dos direitos à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, quando a doutrina os reputava, com outros, manifestação daquela. De fato, a terminologia não é precisa. Por isso, preferimos usar a expressão *direito à privacidade*, num sentido genérico e amplo, de modo a abarcar todas essas manifestações da esfera íntima, privada e da personalidade, que o texto constitucional em exame consagrou. Toma-se, pois, a privacidade como "o conjunto de informação acerca do indivíduo que ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem a isso poder ser legalmente sujeito".¹⁹ A esfera de inviolabilidade, assim, é ampla, "abrange o modo de vida doméstico, nas relações familiares e afetivas em geral, fatos, hábitos, local, nome, imagem, pensamentos, segredos, e, bem assim, as origens e planos futuros do indivíduo".²⁰ A doutrina sempre lembra que o Juiz americano Cooley, em 1873, identificou a privacidade como o direito de ser deixado tranqüilo, em paz, de estar só: *Right to be alone*. "O *right of privacy* compreende, decidiu a Corte Suprema dos Estados Unidos, o direito de toda pessoa tomar sozinha as decisões na esfera da sua vida privada".²¹

10. Intimidade

O direito à *intimidade* é quase sempre considerado como sinônimo de *direito à privacidade*. Esta é uma terminologia do direito anglo-americano (*right of privacy*), para designar aquele, mais empregada no direito dos povos latinos. Nos termos da Constituição, contudo, é plausível a distinção que estamos fazendo, já que o inciso X do art. 5º separa *intimidade* de outras manifestações da privacidade: vida privada, honra e imagem das pessoas, que trataremos, por isso, em tópicos apartados.

19. Cf. J. Matos Pereira, *Direito de Informação*, p. 15.

20. Cf. Moacyr de Oliveira, "Intimidade", in *Enciclopédia Saraiva do Direito*, v. 46/100. Note-se que esse autor está referindo-se à *intimidade* em concepção ampla, nos parecendo, desse modo, possível utilizar seu conceito em referência à privacidade segundo a posição assumida no texto.

21. Cf. Pierre Kayser, *La protection de la vie privée: protection du secret de la vie privée*, p. 49. Carlos Francisco Sica Diniz, "Privacidade", in *Enciclopédia Saraiva do Direito*, v. 61/170.

Segundo René Ariel Dotti a *intimidade* se caracteriza como "esfera secreta da vida do indivíduo na qual este tem o poder legal de evitar os demais", o que é semelhante ao conceito de Adriano Cupis que define a *intimidade* (*riservatezza*) como o modo de ser de uma pessoa que consiste na exclusão do conhecimento de outrem de que se refira à pessoa mesma.²² Abrange, nesse sentido mais restrito, a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência, o segredo profissional.

À inviolabilidade do domicílio e ao sigilo da correspondência, ainda voltaremos mais adiante como formas de direito à segurança pessoal.

Aqui cumpre lembrar que, ao estatuir que *a casa é o asilo inviolável do indivíduo* (art. 5º, XI), a Constituição está reconhecendo que o homem tem direito fundamental a um lugar em que, só com sua família, gozará de uma esfera jurídica privada e íntima, que terá que ser respeitada como sagrada manifestação da pessoa humana. *A casa como asilo inviolável* comporta o direito de vida doméstica livre de intromissão estranha, o que caracteriza a liberdade das relações familiares (a liberdade de viver junto sob o mesmo teto), as relações entre pais e seus filhos menores, as relações entre os dois sexos (a intimidade sexual).²³ Tem-se perguntado se está compreendida também a liberdade de relações homossexuais. Não temos dúvida em responder que sim. No recesso da casa, por consequência, que esta é também uma esfera íntima, um segredo da vida privada, que está protegido pelo direito à *intimidade*. Acha-se também reconhecida a *liberdade de domicílio*, no sentido de que a pessoa tem o direito de mudar seu asilo individual e familiar segundo sua conveniência e conveniência, o que, aliás, é manifestação também da liberdade de locomoção, que veremos.

O *sigilo da correspondência* alberga também o direito de expressão, o direito de comunicação, que é, outrossim, forma da liberdade de expressão do pensamento, como examinaremos a seu tempo. O que nele é que se encontra a proteção dos segredos pessoais, que se limitam apenas aos correspondentes. Aí é que, não raro, as pessoas expõem suas confissões íntimas na confiança de que se deu a *confidência*.

O *segredo profissional* "obriga a quem exerce uma profissão regulamentada, em razão da qual há de tomar conhecimento do segredo

22. Cf. René Ariel Dotti, *Proteção da vida privada e liberdade de informação*, Adriano de Cupis, "Riservatezza e segreto (Diritto a)", in *Novissimo Digesto Italiano*, p. 115.

23. Cf. Pierre Kayser, *ob. cit.*, p. 26.

de outra pessoa, a guardá-lo com fidelidade”²⁴ O titular do segredo é protegido, no caso, pelo direito à intimidade, pois o profissional, médico, advogado e também o padre-confessor (por outros fundamentos) não pode liberar o segredo, devassando a esfera íntima, de que teve conhecimento, sob pena de violar aquele direito e incidir em sanções civis e penais.

11. Vida privada

É, também, inviolável a *vida privada* (art. 5º, X). Não é fácil distinguir *vida privada* de *intimidade*. Aquela, em última análise, integra a esfera íntima da pessoa, porque é repositório de segredos e particularidades do foro moral e íntimo do indivíduo. Mas a Constituição não considerou assim. Deu destaque ao conceito, para que seja mais abrangente, como conjunto de modo de ser e viver, como direito de o indivíduo viver sua própria vida.²⁵ Parte da constatação de que a vida das pessoas compreende dois aspectos: um voltado para o exterior e outro para o interior. A vida exterior, que envolve a pessoa nas relações sociais e nas atividades públicas, pode ser objeto das pesquisas e das divulgações de terceiros, porque é pública. A *vida interior*, que se debruça sobre a mesma pessoa, sobre os membros de sua família, sobre seus amigos,²⁶ é a que integra o conceito de *vida privada*, inviolável nos termos da Constituição.

A tutela constitucional visa proteger as pessoas de dois atentados particulares: (a) ao *segredo da vida privada*; e (b) à *liberdade da vida privada*. O segredo da vida privada é condição de expansão da personalidade. Para tanto, é indispensável que a pessoa tenha ampla liberdade de realizar sua vida privada, sem perturbação de terceiros. São duas variedades principais de atentados ao *segredo da vida privada*, nota Kayser: a *divulgação*, ou seja, o fato de levar ao conhecimento do público, ou a pelo menos de um número indeterminado de pessoas, os eventos relevantes da vida pessoal e familiar; a *investigação*, isto é, a pesquisa de acontecimentos referentes à vida pessoal e familiar; envolve-se aí também a proteção contra a *conservação* de documento relativo à pessoa, quando tenha sido obtido por meios ilícitos. O autor ressalta o fato hoje notório de que o segredo da vida privada é cada vez mais ameaçado por investigações e divulgações ilegíti-

mas por aparelhos registradores de imagem, sons e dados, infinitamente sensíveis aos olhos e ouvidos.²⁷

12. Honra e imagem das pessoas

O mesmo dispositivo em análise (art. 5º, X) declara invioláveis a honra e a *imagem das pessoas*. O direito à preservação da honra e da imagem, como o do nome, não caracteriza propriamente um direito à privacidade e menos à intimidade. Pode mesmo dizer-se que sequer integra o conceito de direito à vida privada. A Constituição, com razão, reputa-os valores humanos distintos. A honra, a imagem, o nome e a identidade pessoal constituem, pois, objeto de um direito, independente, da personalidade.²⁸

A *honra* é o conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom nome, a reputação. É direito fundamental da pessoa resguardar essas qualidades. A pessoa tem o direito de preservar a própria dignidade — adverte Adriano de Cupis — mesmo fictícia, até contra ataques da verdade, pois aquilo que é contrário à dignidade da pessoa deve permanecer um segredo dela própria.²⁹ Esse segredo entra no campo da privacidade, da vida privada, e é aqui onde o direito à honra se cruza com o direito à privacidade.

A *inviolabilidade da imagem da pessoa* consiste na tutela do aspecto físico, como é perceptível visivelmente, segundo Adriano de Cupis, que acrescenta: “Essa reserva pessoal, no que tange ao aspecto físico — que, de resto, reflete também personalidade moral do indivíduo —, satisfaz uma exigência espiritual de isolamento, uma necessidade eminentemente moral”.³⁰

13. Privacidade e informática

O intenso desenvolvimento de complexa rede de fichários eletrônicos, especialmente sobre dados pessoais, constitui poderosa ameaça à privacidade das pessoas. O amplo sistema de informações computadorizadas gera um processo de esquadrinhamento das pessoas, que ficam com sua individualidade inteiramente devassada. O perigo é tão maior quanto mais a utilização da informática facilita a interconexão de fichários com a possibilidade de formar grandes

24. Cf. Eduardo Novoa Monreal, *Derecho a la vida privada y libertad de información*, p. 80.

25. Cf. Eduardo Novoa Monreal, *ob. cit.*, pp. 36 a 38.

26. Sobre isso, cf. Pierre Kayser, *ob. cit.*, p. 11

27. *Ob. cit.*, pp. 10 a 12.

28. Nesse sentido, cf. Eduardo Novoa Monreal, *ob. cit.*, p. 66.

29. Cf. *ob. cit.*, p. 117.

30. *Ob. cit.*, p. 115.

bancos de dados que desvendem a vida dos indivíduos, sem sua autorização e até sem seu conhecimento.

A Constituição não descurou dessa ameaça. Tutela a privacidade das pessoas, como vimos acima. Mais do que isso, acolheu um instituto típico e específico para a efetividade dessa tutela, que é o *habeas data*, que merecerá nossa consideração mais adiante.

14. Violação à privacidade e indenização

A violação da privacidade, portanto, encontra no texto constitucional remédios expeditos. Essa violação, em algumas hipóteses, já constitui ilícito penal. Além disso, a Constituição foi explícita em assegurar, ao lesado, direito a indenização por dano material ou moral decorrente da violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, em suma, do direito à privacidade.

Capítulo III

DIREITO DE IGUALDADE

1. Introdução ao tema. 2. Igualdade, desigualdade e justiça. 3. Isonomia formal e isonomia material. 4. O sentido da expressão "igualdade perante a lei". 5. Igualdade de homens e mulheres. 6. O princípio da igualdade jurisdicional. 7. Igualdade perante a tributação. 8. Igualdade perante a lei penal. 9. Igualdade "sem distinção de qualquer natureza". 10. Igualdade "sem distinção de sexo e de orientação sexual". 11. Igualdade "sem distinção de origem, cor e raça". 12. Igualdade "sem distinção de idade". 13. Igualdade "sem distinção de trabalho". 14. Igualdade "sem distinção de credo religioso". 15. Igualdade "sem distinção de convicções filosóficas ou políticas". 16. O princípio da não discriminação e sua tutela penal. 17. Discriminações e inconstitucionalidade.

1. Introdução ao tema

O direito de igualdade não tem merecido tantos discursos como a liberdade. As discussões, os debates doutrinários e até as lutas em torno desta obnubilaram aquela. É que a igualdade constitui o signo fundamental da democracia. Não admite os privilégios e distinções que um regime simplesmente liberal consagra. Por isso é que a burguesia, cônica de seu privilégio de classe, jamais postulou um regime de igualdade tanto quanto reivindicara o de liberdade. É que um regime de igualdade contraria seus interesses e dá à liberdade sentido material que não se harmoniza com o domínio de classe em que assenta a democracia liberal burguesa.

As constituições só têm reconhecido a igualdade no seu sentido jurídico-formal: *igualdade perante a lei*. A Constituição de 1988 abre o capítulo dos direitos individuais com o princípio de que *todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza* (art. 5º, caput). Reforça o princípio com muitas outras normas sobre a igualdade ou buscando a igualização dos desiguais pela outorga de direitos sociais substanciais. Assim é que, já no mesmo art. 5º, I, declara que *homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações*. Depois, no art. 7º, XXX e XXXI, vêm regras de igualdade material, regras que proíbem distinções fundadas em certos fatores, ao vedarem *diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil e qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência*. A previsão, ainda que

programática, de que a República Federativa do Brasil tem como um de seus objetivos fundamentais *reduzir as desigualdades sociais e regionais* (art. 3º, III), veemente repulsa a qualquer forma de discriminação (art. 3º, IV), a universalidade da seguridade social, a garantia ao direito à saúde, à educação baseada em princípios democráticos e de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, enfim a preocupação com a justiça social como objetivo das ordens econômica e social (arts. 170, 193, 196 e 205) constituem reais promessas de busca da igualdade material.

2. Igualdade, desigualdade e justiça

O conceito de igualdade provocou posições extremadas. Há os que sustentam que a desigualdade é a característica do universo. Assim, os seres humanos, ao contrário da afirmativa do art. 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, nascem e perdem-se desiguais. Nesse caso, a igualdade não passaria de um simples nome, sem significação no mundo real, pelo que os adeptos dessa corrente são denominados *nominalistas*. No pólo oposto, encontram-se os *idealistas*, que postulam um *igualitarismo* absoluto entre as pessoas. Afirmam-se, em verdade, uma igual liberdade natural ligada à hipótese do estado de natureza, em que reinava uma igualdade absoluta.¹

Era, em essência, também a posição de Rousseau que, no entanto, admitia *duas espécies de desigualdades* entre os homens: uma, que chamava *natural* ou *física*, porque estabelecida pela natureza, consistente na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito e da alma; outra, que denominava *desigualdade moral* ou *política*, porque depende de uma espécie de convenção, e é estabelecida, ou ao menos autorizada, pelo consentimento dos homens, consistindo nos diferentes privilégios que uns gozam em detrimento dos outros, como ser mais ricos, mais nobres, mais poderosos.²

Uma posição, dita *realista*, reconhece que os homens são desiguais sob múltiplos aspectos, mas também entende ser supremamente exato descrevê-los como criaturas iguais, pois, em cada um deles, o mesmo sistema de características inteligíveis proporciona, à realidade individual, aptidão para existir.³ Em essência, como seres humanos, não se vê como deixar de reconhecer igualdade entre os homens.

1. Cf. Locke, *Ensayo sobre el gobierno civil*, II, §§ 4 a 6, especialmente; Montesquieu, *De l'esprit des lois*, I, 2 e 3.

2. Cf. "Quel'est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée", *Discours*, Paris, Éditions Sociales, s.d.

3. Cf. Anacleto de Oliveira Faria, *Do Princípio da Igualdade Jurídica*, p. 43.

Não fosse assim, não seriam seres da mesma espécie. A igualdade aqui se revela na própria identidade de essência dos membros da espécie. Isso não exclui a possibilidade de inúmeras desigualdades entre eles. Mas são desigualdades fenomênicas: naturais, físicas, morais, políticas, sociais etc., e "não se aspira [lembra Cármen Lúcia Antunes Rocha] uma igualdade que frustre e desbaste as desigualdades que semeiam a riqueza humana da sociedade plural, nem se deseja uma desigualdade tão grande e injusta que impeça o homem de ser digno em sua existência e feliz em seu destino. O que se quer é a igualdade jurídica que embase a realização de todas as desigualdades humanas e as faça suprimimento ético de valores poéticos que o homem possa desenvolver. As desigualdades naturais são saudáveis, como são doentes aquelas sociais e econômicas, que não deixam alternativas de caminhos singulares a cada ser humano único".⁴

Aristóteles vinculou a *idéia de igualdade* à *idéia de justiça*, mas, nele, trata-se de igualdade de justiça relativa que dá a cada um o seu,⁵ uma igualdade — como nota Chomé — impensável sem a desigualdade complementar e que *é satisfeita se o legislador tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais*.⁶ Cuida-se de uma justiça e de uma igualdade formais, tanto que não seria injusto tratar diferentemente o escravo e seu proprietário; sê-lo-ia, porém, se os escravos, ou seus senhores, entre si, fossem tratados desigualmente. No fundo, prevalece, nesse critério de igualdade, uma injustiça real. Essa verificação impôs a evolução do conceito de igualdade e de justiça, a fim de se ajustarem às concepções formais e reais ou materiais.

A *justiça formal* consiste em "um princípio de ação, segundo o qual os seres de uma mesma categoria essencial devem ser tratados da mesma forma".⁷ Aí a justiça formal se identifica com a igualdade formal. A *justiça concreta* ou *material* seria, para Perelman, a especificação da justiça formal, indicando a característica constitutiva da categoria essencial, chegando-se às formas: a cada um segundo a sua necessidade; a cada um segundo seus méritos; a cada um a mesma coisa.⁸ Porque existem desigualdades, é que se aspira à igualdade real ou material

4. Cf. *O princípio constitucional da igualdade*, p. 118.

5. Cf. *Éthique à Nicomaque*, V, 6, 1131a.

6. Cf. "Le principe de l'égalité en droit de la République Fédérale Allemande", in Charles Perelman et al., *L'égalité*, v. I/39.

7. Cf. Charles Perelman, "De la justice", in *Justice et raison*, p. 26 (na tradução italiana, *La giustizia*, pp. 37 e 57).

8. Cf. Charles Perelman, "Le principe de l'égalité en droit de la République Fédérale Allemande", pp. 15 e ss.; idem, "De la Justice", cit., pp. 23 e ss. (pp. 38 e ss., na tradução italiana); também Marc Vanquickenborne, "La structure de la notion d'égalité en droit", in Charles Perelman et al., *L'égalité*, v. I/187.

que busque realizar a igualização das condições desiguais,⁹ do que se extrai que a lei geral, abstrata e impessoal que incide em todos igualmente, levando em conta apenas a igualdade dos indivíduos e não a igualdade dos grupos, acaba por gerar mais desigualdades e propiciar a injustiça, daí por que o legislador, sob “o impulso das forças criadoras do direito [como nota Georges Sarotte], teve progressivamente de publicar leis setoriais para poder levar em conta diferenças nas formações e nos grupos sociais: o direito do trabalho é um exemplo típico”.¹⁰ Pois, como diz Cármen Lúcia Antunes Rocha:

“Igualdade constitucional é mais que uma expressão de Direito; é um modo justo de se viver em sociedade. Por isso é princípio posto como pilar de sustentação e estrela de direção interpretativa das normas jurídicas que compõem o sistema jurídico fundamental”.¹¹

3. Isonomia formal e isonomia material

A afirmação do art. 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão cunhou o princípio de que os homens nascem e permanecem *iguais em direito*. Mas aí firmara a igualdade jurídico-formal no plano político, de caráter puramente negativo, visando a abolir os privilégios, isenções pessoais e regalias de classe. Esse tipo de igualdade gerou as desigualdades econômicas, porque fundada “numa visão individualista do homem, membro de uma sociedade liberal relativamente homogênea”.¹²

Nossas constituições, desde o Império, inscreveram o princípio da *igualdade*, como *igualdade perante a lei*, enunciado que, na sua literalidade, se confunde com a mera *isonomia formal*, no sentido de que a lei e sua aplicação tratam a todos igualmente, sem levar em conta as distinções de grupos. A compreensão do dispositivo vigente, nos termos do art. 5º, *caput*, não deve ser assim tão estreita. O intérprete há que aferi-lo com outras normas constitucionais, confor-

9. Cf. L. Ingber, “A propos de l’égalité dans la jurisprudence belge”, in Charles Perelman *et al.*, *L’égalité*, v. I/3 e ss.

10. Cf. *O materialismo histórico no estudo do direito*, p. 316.

11. *Ob. cit.*, p. 118.

12. Cf. L. Ingber, *ob. cit.*, in *L’égalité*, v. I/34. Georges Sarotte, *ob. cit.*, p. 316: “Os revolucionários de 1789 estabeleceram o princípio da igualdade perante a lei. Ora, a lei, em virtude da existência de classes sociais, quer no seu enunciado, quer na sua aplicação, não impediu a formação de desigualdades de fato entre os cidadãos, de maneira que, por isso mesmo, a igualdade perante a lei não tem na realidade grande significado. Essa proclamação era uma reação necessária contra as desigualdades oriundas do regime feudal, sem contudo impedir que do novo regime nascessem eventualmente outras desigualdades”.

me apontamos supra e, especialmente, com as exigências da justiça social, objetivo da ordem econômica e da ordem social. Considerá-lo-emos como isonomia formal para diferenciá-lo da *isonomia material*, traduzido no art. 7º, XXX e XXXI, que já indicamos no n. 1 supra.

A Constituição procura aproximar os dois tipos de isonomia, na medida em que não se limitara ao simples enunciado da igualdade perante a lei; menciona também igualdade entre homens e mulheres e acrescenta vedações a distinção de qualquer natureza e qualquer forma de discriminação. O valor disso será examinado no correr deste capítulo.

4. O sentido da expressão “igualdade perante a lei”

No Direito estrangeiro, faz-se distinção entre o princípio da igualdade *perante a lei* e o da igualdade *na lei*. Aquele corresponde à obrigação de aplicar as normas jurídicas gerais aos casos concretos, na conformidade com o que elas estabelecem, mesmo se delas resultar uma discriminação, o que caracteriza a isonomia puramente formal, enquanto a igualdade *na lei* exige que, nas normas jurídicas, não haja distinções que não sejam autorizadas pela própria constituição. Enfim, segundo essa doutrina, a igualdade *perante a lei* seria uma exigência feita a todos aqueles que aplicam as normas jurídicas gerais aos casos concretos, ao passo que a igualdade *na lei* seria uma exigência dirigida tanto àqueles que criam as normas jurídicas gerais como àqueles que as aplicam aos casos concretos.¹³

Entre nós, essa distinção é desnecessária,¹⁴ porque a doutrina como a jurisprudência já firmaram, há muito, a orientação de que a igualdade perante a lei tem o sentido que, no exterior, se dá à expressão igualdade *na lei*, ou seja: *o princípio tem como destinatários tanto o legislador como os aplicadores da lei*. O princípio significa, para o legislador — consoante observa Seabra Fagundes — “que, ao elaborar a lei, deve reger, com iguais disposições — os mesmos ônus e as mesmas vantagens — situações idênticas, e, reciprocamente, distinguir, na repartição de encargos e benefícios, as situações que sejam entre si distintas, de sorte a quinhó-las ou gravá-las em proporção às suas diversidades”.¹⁵ Aliás, Francisco Campos, com razão, sustentara mes-

13. Cf. Hermann Petzold, “Le principe de l’égalité devant la loi dans le droit de certain état d’Amérique Latin”, in Charles Perelman *et al.*, *ob. cit.*, v. I/100.

14. No entanto, ementa de Acórdão do STF (RDA 183/143), por influência de voto do Min. Celso de Mello, introduz a distinção, útil talvez no direito estrangeiro, mas absolutamente inútil e desvantajosa no sistema brasileiro.

15. Cf. “O princípio constitucional da igualdade perante a lei e o Poder Legislativo”, RT 235/3.

mo que o legislador é o destinatário principal do princípio, pois se ele pudesse criar normas distintivas de pessoas, coisas ou fatos, que devessem ser tratados com igualdade, o mandamento constitucional se tornaria inteiramente inútil,¹⁶ concluindo que, “nos sistemas constitucionais do tipo do nosso não cabe dúvida quanto ao principal destinatário do princípio constitucional de igualdade perante a lei. O mandamento da Constituição se dirige particularmente ao legislador e, efetivamente, somente ele poderá ser o destinatário útil de tal mandamento. O executor da lei já está, necessariamente, obrigado a aplicá-la de acordo como os critérios constantes da própria lei. Se esta, para valer, está adstrita a se conformar ao princípio de igualdade, o critério da igualdade resultará obrigatório para o executor da lei pelo simples fato de que a lei o obriga a executá-la com fidelidade ou respeito aos critérios por ela mesma estabelecidos”.¹⁷

Mas, como já vimos, o princípio não pode ser entendido em sentido individualista, que não leve em conta as diferenças entre grupos. Quando se diz que o legislador não pode distinguir, isso não significa que a lei deva tratar todos abstratamente iguais, pois o tratamento igual — esclarece Petzold — não se dirige a pessoas integralmente iguais entre si, mas àquelas que são iguais sob os aspectos tomados em consideração pela norma, o que implica que os “iguais” podem diferir totalmente sob outros aspectos ignorados ou considerados como irrelevantes pelo legislador. Este julga, assim, como “essenciais” ou “relevantes”, certos aspectos ou características das pessoas, das circunstâncias ou das situações nas quais essas pessoas se encontram, e funda sobre esses aspectos ou elementos as categorias estabelecidas pelas normas jurídicas; por consequência, as pessoas que apresentam os aspectos “essenciais” previstos por essas normas são consideradas encontrar-se nas “situações idênticas”, ainda que possam diferir por outros aspectos ignorados ou julgados irrelevantes pelo legislador; vale dizer que as pessoas ou situações são iguais ou desiguais de modo relativo, ou seja, sob certos aspectos.¹⁸ Nesse sentido, já se pronunciou, também, Seabra Fagundes, para lembrar que os “conceitos de igualdade e de desigualdade são relativos, impõem a confrontação e o contraste entre duas ou várias situações, pelo que onde uma só existe não é possível indagar de tratamento igual ou discriminatório”.¹⁹

Esses fundamentos é que permitem, à legislação, tutelar pessoas que se achem em posição econômica inferior, buscando realizar o

princípio de igualização, como salienta Pontes de Miranda, *in verbis*: “A desigualdade econômica não é, de modo nenhum, desigualdade de fato, e sim a resultante, em parte, de desigualdades artificiais, ou desigualdades de fato *mais* desigualdades econômicas mantidas *por leis*. O direito que em parte as fez, pode amparar e extinguir as desigualdades econômicas que produziu. Exatamente aí é que se passa a grande transformação da época industrial, com a tendência a maior igualdade econômica, que há de começar, como já começou em alguns países, pela atenuação mais ou menos extensa das desigualdades”.²⁰

5. Igualdade de homens e mulheres

Essa igualdade já se contém na norma geral da igualdade perante a lei. Já está também contemplada em todas as normas constitucionais que vedam discriminação de sexo (arts. 3º, IV, e 7º, XXX). Mas não é sem consequência que o Constituinte decidiu destacar, em um inciso específico (art. 5º, I), que *homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição*. Era dispensável acrescentar a cláusula final, porque, ao estabelecer a norma, por si, já estava dito que seria “nos termos desta Constituição”. Isso é de somenos importância. Importa mesmo é notar que é uma regra que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações. Mais relevante ainda é que não se trata aí de mera isonomia formal. Não é igualdade perante a lei, mas igualdade em direitos e obrigações. Significa que existem dois termos concretos de comparação: *homens* de um lado e *mulheres* de outro. Onde houver um homem e uma mulher, qualquer tratamento desigual entre eles, a propósito de situações pertinentes a ambos os sexos, constituirá uma infringência constitucional.

Aqui a igualdade não é apenas no confronto marido e mulher. Não se trata apenas da igualdade no lar e na família. Abrange também essa situação, que, no entanto, recebeu formulação específica no art. 226, § 5º: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. Vale dizer: nenhum pode mais ser considerado cabeça de casal, ficando revogados todos os dispositivos da legislação ordinária que outorgava primazia ao homem.

Só valem as discriminações feitas pela própria Constituição e sempre em favor da mulher, como, por exemplo, a aposentadoria da mulher com menor tempo de contribuição e de idade (arts. 40, § 1º,

16. Cf. “Igualdade perante a lei”, in *Direito constitucional*, v. II/16.

17. Idem, p. 18.

18. Cf., *ob. cit.*, in *L'égalité*, v. I/122 e 123, quase *ipsis litteris*.

19. Cf., *ob. cit.*, RT 235/7.

20. Cf. *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. IV/689.

III, *a e b*, e 201, § 7º, I e II). Justifica-se essa norma discriminatória? Achamos que sim, na medida em que à mulher incumbem as tarefas básicas da casa, pouco ajudada aí pelo marido. Ela tem assim uma sobrecarga de serviços que é justo seja compensada pela aposentadoria com menor tempo de serviço e de idade.

6. O princípio da igualdade jurisdicional

A concepção de que o princípio da igualdade perante a lei se dirige primariamente ao legislador avulta a importância da igualdade jurisdicional. Pois, se o princípio se dirigisse apenas ao aplicador da lei, bastaria a este respeitar o princípio da legalidade e o da igualdade estaria também salvo. No sentido da concepção exposta, que é a correta e pacificamente aceita, o princípio da igualdade consubstancia uma limitação ao legislador, que, sendo violada, importa na inconstitucionalidade da lei, em termos que especificaremos mais adiante. Constitui, por outro lado, uma regra de interpretação para o juiz, que deverá sempre dar à lei o entendimento que não crie distinções.²¹

A igualdade perante o juiz decorre, pois, da igualdade perante a lei, como garantia constitucional indissoluvelmente ligada à democracia.²²

O princípio da igualdade jurisdicional ou perante o juiz apresenta-se, portanto, sob dois prismas: (1) como interdição ao juiz de fazer distinção entre situações iguais, ao aplicar a lei; (2) como interdição ao legislador de editar leis que possibilitem tratamento desigual a situações iguais ou tratamento igual a situações desiguais por parte da Justiça.

Sob o primeiro prisma, o princípio da igualdade da Justiça consiste na condenação de juízos ou tribunais de exceção (art. 5º, XXXVII). As constituições anteriores vedavam, também, foro privilegiado, embora o estabelecessem em alguns casos, em razão da qualidade dos imputados. A atual igualmente prevê foro privilegiado nesses casos. Assim é privilegiado o foro para julgamento do Presidente e Vice-Presidente da República, de Ministros de Estado, membros do Congresso Nacional, de seus próprios Ministros e do Procurador-Geral da República (STF, art. 102, I, *b*), dos Governadores de Estado e do Distrito Federal, dos Desembargadores de Tribunal de Justiça, dos membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal,

21. Cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de direito constitucional*, p. 242.

22. Cf. Ada Pellegrini Grinover, *Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil*, p. 25.

dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, do Ministério Público da União e dos membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios (STJ, art. 105, I, *a*), dos Prefeitos (TJ, art. 29, X). Afora os casos de foro privilegiado, expressamente estabelecidos na Constituição e situação correspondente nas constituições estaduais, será inconstitucional a previsão de outros.

A vedação de juízo de exceção caracteriza o *juiz natural*, consubstanciado, hoje, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo art. 10 estabelece que todo homem tem direito, em *plena igualdade*, a uma justa e pública audiência por parte de um *tribunal independente e imparcial*, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. *Juiz natural*, assim, é o juiz pré-constituído, competente (art. 5º, LIII: *ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente*), e no gozo das garantias de *independência e imparcialidade*. Onde qualquer das garantias da magistratura faltar, pode-se afirmar que o princípio da igualdade da Justiça estará sacrificado, pois o juiz, sem independência, é juiz amedrontado, e juiz amedrontado é juiz potencialmente parcial e sujeito à influência de poderosos, pois a independência do juiz é necessária para assegurar sua imparcialidade.²³ Esta requer ainda que o juiz respeite os princípios *No man is a judge in his own case* e *audiat alteram partem*, não condenando sem ouvir o imputado, princípio ao qual se ligam as garantias do contraditório e de ampla defesa do acusado (art. 5º, LV) e do tratamento igualitário das partes e procuradores (CPC, art. 125, I). O princípio do juiz natural recebeu ponderável reforço na Constituição pela adoção da centenária regra do *devido processo legal* (art. 5º, LIV).

A existência das Justiças Especiais não ofende o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII). Ao contrário, reforça-o na medida em que são estruturadas para atender à regra do "juiz apropriado às diferentes matérias", como se dá com a *Justiça Eleitoral*, a *Justiça do Trabalho* e a *Justiça Militar*.

O outro prisma da igualdade e da Justiça manifesta-se quando a lei cria situações de desigualdades em confronto concreto com outras, que lhes sejam iguais, como o dispositivo que trata de forma desigual a entes que devam litigar em igualdade de condições.

Formalmente, a igualdade perante a Justiça está assegurada pela Constituição, desde a garantia de acessibilidade a ela (art. 5º, XXXV). Mas *realmente* essa igualdade não existe, "pois está bem claro

23. Cf. Enrico Tullio Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, v. 1/4.

hoje que tratar 'como igual' a sujeitos que econômica e socialmente estão em desvantagem, não é outra coisa senão uma ulterior forma de desigualdade e de injustiça".²⁴ Os pobres têm acesso muito precário à justiça. Carecem de recursos para contratar bons advogados. O *patrocínio gratuito* se revelou de alarmante deficiência. A Constituição tomou, a esse propósito, providência que pode concorrer para a eficácia do dispositivo, segundo o qual o *Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos* (art. 5º, LXXIV). Referimo-nos à institucionalização das Defensorias Públicas, a quem incumbirá a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV (art. 134).

Quem sabe se fica revogada, no Brasil, a persistente frase de Ovídio: *Cura pauperibus clausa est*.²⁵ Ou as Defensorias Públicas federais e estaduais serão mais uma instituição falha? Cabe aos Defensores Públicos abrir os tribunais aos pobres, é uma missão tão extraordinariamente grande que, por si, será uma revolução, mas, também, se não cumprida convenientemente, será um aguilhão na honra dos que a receberam e, porventura, não a sustentaram.

A realização da igualdade perante a justiça, assim, exige a busca da igualização de condições dos desiguais, o que implica conduzir o juiz a dois imperativos, como observa Ingber: de um lado, cumpre-lhe reconhecer a existência de categorias cada vez mais numerosas e diversificadas, que substituem a idéia de homem, entidade abstrata, pela noção mais precisa de indivíduo caracterizada pelo grupo em que se insere de fato; de outro lado, deve ele apreciar os critérios de relevância que foram adotados pelo legislador.²⁶ É essa doutrina que orienta o princípio da igualdade da justiça na imposição de pena para o mesmo delito. Seria injusto fosse aplicada a mesma pena sempre em atendimento a uma igualdade abstrata. Aplicando-se matematicamente a mesma pena para o mesmo crime, que, por regra, é praticado em circunstâncias diferentes por pessoas de condições distintas. Para que tal abstração não ocorra é que, além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, se impõe a regra da individualização da pena (art. 5º, XLVI).²⁷ Mas ainda é certo que as profundas diferenças de condições materiais não se igualizam por essas poucas regras de justiça penal. É muito difundida, ainda, a idéia de que cadeia é só para pobre.

24. Cf. Cappelletti, *Proceso, ideología, sociedad*, p. 67.

25. "O tribunal está fechado para os pobres", cf. *Amores*, Liv. III, VIII, 55, citado por Cappelletti, *ob. cit.*, p. 155.

26. *Ob. cit.*, in *L'égalité*, v. 1/34.

27. Cf. Paulino Jacques, *Da igualdade perante a lei*, p. 216.

7. Igualdade perante a tributação

O princípio da igualdade tributária relaciona-se com a justiça distributiva em matéria fiscal. Diz respeito à repartição do ônus fiscal do modo mais justo possível. Fora disso a igualdade será puramente formal. Diversas teorias foram construídas para explicar o princípio, divididas em *subjetivas* e *objetivas*.²⁸

As teorias *subjetivas* compreendem duas vertentes: a do princípio do benefício e a do princípio do sacrifício igual. O primeiro significa que a carga dos impostos deve ser distribuída entre os indivíduos de acordo com os benefícios que desfrutam da atividade governamental; conduz à exigência da tributação *proporcional* à propriedade ou à renda; propicia, em verdade, situações de real injustiça, na medida em que agrava ou apenas mantém as desigualdades existentes. O princípio do sacrifício ou do custo implica que, sempre que o governo incorre em custos em favor de indivíduos particulares, estes custos devem ser suportados por eles. Esse princípio foi defendido por Stuart Mill, segundo o qual a igualdade tributária é o corolário lógico do princípio geral de igualdade e o imposto se reparte segundo este critério de justiça quando cada contribuinte suporta um sacrifício igual ao suportado por qualquer outro, e ninguém sofre mais que outro como consequência do pagamento do imposto.²⁹ Esse critério de sacrifício igual redundaria, na verdade, numa injustiça, porque, numa sociedade dividida em classes, não é certo que todos se beneficiem igualmente das atividades governamentais.

As teorias *objetivas* convergem para o princípio da capacidade contributiva, expressamente adotada pela Constituição (art. 145, § 1º), segundo o qual a carga tributária deve ser distribuída na medida da capacidade econômica dos contribuintes, critério que implica: (a) uma base impositiva que seja capaz de medir a capacidade; (b) alíquotas que igualem verdadeiramente essas cargas.³⁰ A dificuldade está na determinação correta da "capacidade tributária individual". A doutrina fixou alguns critérios para isso, que são: o de "sacrifício igual", o de "sacrifício proporcional", o de "menor sacrifício" e o de "não alterar a desigualdade das rendas pela tributação", a respeito dos quais Hugh Dalton oferece a seguinte síntese:

"De acordo com o princípio de sacrifício igual, o ônus monetário direto da tributação deveria ser distribuído de modo que fosse

28. Para pormenores, incabíveis aqui, cf. nosso *Tributos e normas de políticas fiscal na Constituição do Brasil*, pp. 86 e ss.

29. Cf. Lello Gangemi, *Tratado de hacienda pública*, v. 1/472.

30. Cf. Philip E. Taylor, *Economía de la hacienda pública*, p. 268; Lello Gangemi, *ob. cit.*, p. 479.

igual o ônus real para todos os contribuintes; consoante ao princípio de sacrifício proporcional, ao bem-estar econômico que o mesmo auferir de sua renda; de acordo com o princípio do 'menor sacrifício', a que já nos referimos, de modo que o ônus total direto, real, para os contribuintes em conjunto, fosse o menor possível; segundo o princípio de "deixe-os como estão", de modo que a desigualdade das rendas não aumentasse nem diminuísse em consequência da tributação".³¹

A respeito desses critérios, já escrevemos que são todos abstratos, de tal modo que, submetidos a meticolosa análise, revelam resultados inesperados, e, por vezes, contrários ao princípio de justiça. "É necessário [dizíamos, então] ter em vista que o sistema tributário é parte de um sistema econômico-social concreto, e qualquer teoria de uma tributação justa que não leve em conta a totalidade do sistema social cai na abstração metafísica".³²

Não basta, pois, a regra de isonomia estabelecida no *caput* do art. 5º, para concluir que a igualdade perante a tributação está garantida. O constituinte teve consciência de sua insuficiência, tanto que estabeleceu que é vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos (art. 150, II). Mas também consagrou a regra pela qual, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte (art. 145, § 1º). É o princípio que busca a justiça fiscal na distribuição do ônus fiscal na capacidade contributiva do contribuinte, já discutido antes. Aparentemente, as duas regras se chocam. Uma veda tratamento desigual; outra o autoriza. Mas em verdade ambas se conjugam na tentativa de concretizar a justiça tributária. A graduação, segundo a capacidade econômica e personalização do imposto, permite agrupar os contribuintes em classes, possibilitando tratamento tributário diversificado por classes sociais, e, dentro de cada uma, que constituem situações equivalentes, atua o princípio da igualdade.

8. Igualdade perante a lei penal

Essa igualdade não há de ser entendida, já dissemos, como aplicação da mesma pena para o mesmo delito. Mas deve significar que a mesma lei penal e seus sistemas de sanções não de se aplicar a

31. Cf. *Princípios de finanças públicas*, p. 79.

32. Cf. nosso *Tributos e normas de política fiscal na Constituição do Brasil*, p. 89, onde desenvolvemos observações sobre o tema que descabem aqui.

todos quantos pratiquem o fato típico nela definido como crime. Sabe-se por experiência, contudo, que os menos afortunados ficam muito mais sujeitos aos rigores da justiça penal que os mais aquinhoados de bens materiais. As condições reais de desigualdade condicionam o tratamento desigual perante a lei penal, apesar do princípio da isonomia assegurado a todos pela Constituição (art. 5º).

Afora isso, existem casos de privilégio reconhecido na Constituição, de que se destaca o da *inviolabilidade* e o da *imunidade* parlamentar, de que trataremos depois. Nesse caso, contudo, o privilégio não é da pessoa, mas atributo da função, justificado assim por um valor mais elevado.

9. Igualdade "sem distinção de qualquer natureza"

Além da base geral em que assenta o princípio da igualdade perante a lei, consistente no tratamento igual a situações iguais e tratamento desigual a situações desiguais, a Constituição veda distinções de qualquer natureza (art. 5º, *caput*). As constituições anteriores enumeravam as razões impeditivas de discrimine: *sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas*. Esses fatores continuam a ser encarecidos como possíveis fontes de discriminações odiosas e, por isso, desde logo, proibidas expressamente, como consta do art. 3º, IV, onde se dispõe que, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, está: promover o bem de todos, *sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação*. Proíbe-se, também, diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de *sexo, idade, cor, estado civil ou posse de deficiência* (art. 7º, XXX e XXXI). A Constituição assim o faz porque essas razões preconceituosas são as que mais comumente se tomam como fundamento de discrimine.³³

A Constituição vigente é mais veemente e mais abrangente na condenação nas desigualdades entre pessoas. Confere a igualdade perante a lei, *sem distinções de qualquer natureza*, de sorte que as hipóteses que indicaremos a seguir são simplesmente exemplificativas, tanto quanto o são na própria Constituição.

10. Igualdade "sem distinção de sexo e de orientação sexual"

O sexo sempre foi um fator de discriminação. O sexo feminino esteve sempre inferiorizado na ordem jurídica, e só mais recentemente

33. Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello, *O conteúdo jurídico do princípio da igualdade*, pp. 24 e 25, onde oferece orientação geral dessas razões impeditivas de discrimine.

te vem ele, a duras penas, conquistando posição paritária, na vida social e jurídica, à do homem. A Constituição, como vimos, deu largo passo na superação do tratamento desigual fundado no sexo, ao equiparar os direitos e obrigações de homens e mulheres. Ao fazê-lo, dir-se-ia desnecessário manifestar expressas proibições de discrimine com base no sexo (art. 3º, IV, e art. 7º, XXX), embora ela própria o tenha feito, como lembramos acima, a favor das mulheres (arts. 40, III, e 202).

A questão mais debatida feriu-se em relação às discriminações dos homossexuais. Tentou-se introduzir uma norma que a vedasse claramente, mas não se encontrou uma expressão nítida e devidamente definida que não gerasse extrapolações inconvenientes. Uma delas fora conceder igualdade, sem discriminação de *orientação sexual*, reconhecendo, assim, na verdade, não apenas a igualdade, mas igualmente a liberdade de as pessoas de ambos os sexos adotarem a orientação sexual que quisessem. Teve-se receio de que essa expressão albergasse deformações prejudiciais a terceiros. Daí optar-se por vedar distinções de qualquer natureza e qualquer forma de discriminação, que são suficientemente abrangentes para recolher também aqueles fatores, que têm servido de base para discriminações e preconceitos.

11. Igualdade “sem distinção de origem, cor e raça”

O texto constitucional, que proíbe preconceito de *origem, cor e raça* e condena discriminações com base nesses fatores, consubstancia, antes de tudo, um repúdio à barbárie de tipo nazista que vitimara milhares de pessoas, e consagra a condenação do *apartheid*, por parte de um povo mestiço, com razoável contingente de negros. O repúdio ao racismo nas relações internacionais foi, também, expressamente estabelecido (art. 4º, VIII).

Nele se encontra, também, o reconhecimento de que o preconceito de origem, raça e cor especialmente contra os negros não está ausente das relações sociais brasileiras. Disfarçadamente ou, não raro, ostensivamente, pessoas negras sofrem discriminação até mesmo nas relações com entidades públicas.

O dispositivo, finalmente, significa que a “lei penal tem de inserir regras jurídicas sobre crime de preconceito de raça, para que, no plano do direito penal, não possam ficar sem punição os atos — positivos ou negativos — que ofendam a outrem, porque a acusação se prende aos preconceitos de raça”, como salientou Pontes de Miranda.³⁴

A Constituição é mais abrangente do que as anteriores; veda preconceito e discriminação com base na *origem, raça e cor*. Empregava-

se *raça* que não é termo suficientemente claro, porque, com a miscigenação, vai perdendo sentido. O *racismo* indica teorias e comportamentos destinados a realizar e justificar a supremacia de uma raça.³⁵ O preconceito e discriminação são conseqüências da teoria. A *cor* só não era elemento bastante, porque dirigida à cor negra. Nem *raça* nem *cor* abrangem certas formas de discriminações com base na *origem*, como, por exemplo, discriminações de nordestinos e de pessoas de origem social humilde.

Além das normas gerais contrárias às discriminações de origem, a Constituição inseria uma hipótese específica, para dizer o óbvio: que *a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos na Constituição* (art. 12, § 2º).

12. Igualdade “sem distinção de idade”

A idade tem sido motivo de discriminação, mormente no que tange às relações de emprego. Por um lado, recusa-se emprego a pessoas mais idosas, ou quando não, dão-se-lhes salários inferiores aos dos demais trabalhadores. Por outro lado, paga-se menos a jovens, embora para a execução de trabalho idêntico ao de homens feitos. A Constituição traz norma expressa proibindo diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de idade (art. 7º, XXX). À vista desse texto fica interdito estabelecer idade máxima para o ingresso no serviço, como tem ocorrido até agora.

É evidente que a não discriminação em razão de idade há de considerar situações concretas que comportem comparação entre pessoas de idades diferentes: adultos, menores e idosos. A Constituição mesma admite distinção quando, por exemplo, estabelece a idade mínima de dezesseis anos para admissão ao trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (arts. 7º, XXXIII, e 227, § 3º, I).

13. Igualdade “sem distinção de trabalho”

Em primeiro lugar, o princípio significa que a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, reconhecida no art. 5º, XIII, da Constituição, pertine a qualquer pessoa em igual condição. Assim, o acesso ao emprego privado como aos cargos, funções e empregos públicos há de ser igual para homens e mulheres que demonstrem igualdade de condição.

35. Cf. “Razzismo”, in *Enciclopedia del diritto e dell'economia* Garzanti, Milano, Edizioni Garzanti, 1985.

34. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969, t. IV/709.

A regra completa-se com as normas de igualdade que se encontram inscritas no já citado inciso XXX do art. 7º, mas especialmente no inciso XXXII do mesmo artigo, que veda distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. A paridade de tratamento aqui garantida diz respeito às condições de exercício de funções e de critério de admissão que têm que ser as mesmas para todos, quanto ao valor do trabalho, não se exigindo a paridade de resultado produtivo. Enfim, lembra Pontes de Miranda: "Todos os direitos que tiverem os trabalhadores manuais tê-lo-ão os trabalhadores intelectuais, ou vice-versa. Dentre os trabalhadores manuais, o princípio da isonomia também prevalece".³⁶

Ressalve-se, contudo, que a própria Constituição impõe discriminação entre a retribuição do trabalho diurno e noturno, determinando que este tenha remuneração mais elevada (art. 7º, IX).

14. Igualdade "sem distinção de credo religioso"

Estado leigo, a República Federativa do Brasil sempre reconheceu a liberdade de religião e de exercício de cultos religiosos (art. 5º, VI), agora sem as limitações da cláusula "que não contrariem a ordem pública e os bons costumes" que figurava nas constituições anteriores. Afirma-se que "ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa [...]", salvo escusa de consciência (art. 5º, VIII).

O corolário disso, sem necessidade de explicitação, é que todos hão de ter igual tratamento nas condições de igualdade de direitos e obrigações, sem que sua religião possa ser levada em conta. E realmente, nesse particular, parece que o povo brasileiro se revela profundamente democrático, respeitando a religião dos demais, e não parece que o fator religião venha sendo base de discriminações privadas ou públicas.

15. Igualdade "sem distinção de convicções filosóficas ou políticas"

Esse é o ponto crucial do princípio da isonomia. É aqui que ele tem sido constantemente desrespeitado.

De fato, a razão de ser do princípio está em "impedir que os órgãos do Estado operem discriminações em prejuízo dos oponentes políticos ou apenas baseadas sobre razões políticas".³⁷ Por outro lado, alerta Pontes de Miranda, o "princípio nada tem com os pressupos-

tos para a organização, funcionamento ou extinção dos partidos. A convicção pode ser contrária ao regime representativo, ou contra a própria democracia, ou contra a pluralidade de partidos e até mesmo contra a garantia de direitos fundamentais".³⁸ Espera-se que, de agora em diante, não mais se discriminem pessoas em função de sua ideologia política ou filosófica, como sempre se fez, negando-se-lhes a possibilidade de exercício de funções públicas, impedindo-se-lhes até mesmo de realizar concursos públicos em igualdade de situação com outros candidatos, com base em informações de órgãos de segurança. Se tal discriminação já era vedada em face da constituição revogada, diante da atual será uma violência sem nome.

A igualdade do voto sempre foi reconhecida e praticada, mesmo sem previsão constitucional específica. Agora a Constituição prevê a soberania popular *com voto igual para todos* (art. 14).

16. O princípio da não discriminação e sua tutela penal

Existe lei (Lei 7.716, de 5.1.89) que pune, com penas variáveis de um a cinco anos de *reclusão*, as diversas modalidades de preconceito de raça ou cor, que ela define como *crime*, e não apenas como contravenção, como previa a chamada Lei Afonso Arinos, Lei 1.390/51, por ela revogada. A Lei 5.473/68 reputa nulas, e sujeita a prisão simples, disposições e providências que, direta ou indiretamente, criem discriminações entre brasileiros de ambos os sexos, para o provimento de cargos sujeitos a seleção, assim nas empresas privadas, como nos quadros do funcionalismo público. Mas sabe-se que essas normas têm tido pouca eficácia.

A Constituição traz agora dois dispositivos que fundamentam e, mais do que isso, exigem normas penais rigorosas contra discriminações. Diz-se num deles que *a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais*, e o outro, mais específico porque destaca a forma mais comum e não menos odiosa de discriminação, para estabelecer que *a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei* (art. 5º, respectivamente, incisos XLI e XLII).

17. Discriminações e inconstitucionalidade

São inconstitucionais as discriminações não autorizadas pela Constituição.³⁹ O ato discriminatório é inconstitucional.

38. Ob. cit., t. IV/708.

39. "Não cabe invocar o princípio da isonomia onde a Constituição, implícita ou explicitamente, admitiu a desigualdade" (STF, voto do Min. Cunha Peixoto, aco-

36. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969, t. VI/228.

37. Cf. Paolo Barile, *Le libertà nella costituzione: lezioni*, p. 110.

Há duas formas de cometer essa inconstitucionalidade. Uma consiste em outorgar benefício legítimo a pessoas ou grupos, discriminando-os favoravelmente em detrimento de outras pessoas ou grupos em igual situação. Neste caso, não se estendeu às pessoas ou grupos discriminados o mesmo tratamento dado aos outros. O ato é inconstitucional, sem dúvida, porque feriu o princípio da isonomia. O ato é, contudo, constitucional e legítimo, ao outorgar o benefício a quem o fez. Declará-lo inconstitucional, eliminando-o da ordem jurídica, seria retirar direitos legitimamente conferidos, o que não é função dos tribunais. Como, então, resolver a inconstitucionalidade da discriminação? Precisamente estendendo o benefício aos discriminados que o solicitarem perante o Poder Judiciário, caso por caso. Tal ato é insuscetível de declaração genérica de inconstitucionalidade por via de ação direta.⁴⁰ Gilmar Ferreira Mendes, a esse propósito, opta também pelo reconhecimento do direito dos segmentos eventualmente discriminados, mas pondera que, na impossibilidade, se tem que suprimir o tratamento discriminatório incompatível com a ordem constitucional pela declaração da inconstitucionalidade. “Não se há de perder de vista, porém [conclui], que o desenvolvimento da declaração de inconstitucionalidade sem a consequência da nulidade tem por objetivo evitar, exatamente, a declaração de inconstitucionalidade total, deixando ao legislador a possibilidade de sanar eventuais defeitos. É que, como observado, tal solução (nulidade), como acentuado, além de traduzir possível injustiça com os beneficiados, pode levar a uma situação de ausência de normas, a um vácuo de direito (*Rechtsvakuum*), ou, até mesmo, ao chamado caos jurídico (*Rechtschaos*)”.⁴¹

A outra forma de inconstitucionalidade revela-se em se impor obrigação, dever, ônus, sanção ou qualquer sacrifício a pessoas ou

grupos de pessoas, discriminando-as em face de outros na mesma situação que, assim, permaneceram em condições mais favoráveis. O ato é inconstitucional por fazer discriminação não autorizada entre pessoas em situação de igualdade. Mas aqui, ao contrário, a solução da desigualdade de tratamento não está em estender a situação jurídica detrimetosa a todos, pois não é constitucionalmente admissível impor constrangimentos por essa via. Aqui a solução está na declaração de inconstitucionalidade do ato discriminatório em relação a quantos o solicitarem ao Poder Judiciário, cabendo também a ação direta de inconstitucionalidade por qualquer das pessoas indicadas no art. 103.

lhido unanimemente, embora o texto não tenha sido destacado na ementa, cf. RDA 128/220).

40. É pertinente, contudo, lembrar que a Súmula 339 do STF dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores, sob fundamento de isonomia”; cf. também Acórdão do STJ, RDA 186/157: “O princípio da isonomia de vencimentos, em face de preceito expresso da Constituição Federal, só pode ser concedido através de lei, vedado ao Judiciário, que não tem função legislativa, atribuí-la por via de decisão judicial a funcionário de qualquer categoria (CF, art. 39, § 1º)”. No caso, não cabia a isonomia, porque havia desigualdade de situação que a não comportava, mas a manifestação genérica da ementa não se compadece com as exigências constitucionais, pois, se uma lei concede vantagens a grupos discriminando pessoas na mesma situação, não se trata de conceder isonomia por decisão judicial, mas de corrigir a inconstitucionalidade da discriminação. E isso é função jurisdicional, uma vez que a função legislativa não o fez nos termos da Constituição.

41. Cf. *Controle de constitucionalidade, aspectos jurídicos e políticos*, p. 70.

Capítulo IV

DIREITO DE LIBERDADE

I. O PROBLEMA DA LIBERDADE: 1. *Liberdade e necessidade*. 2. *Liberdade interna e liberdade externa*. 3. *Conteúdo histórico da liberdade*. 4. *O problema da conceituação*. 5. *Liberdade e liberação*. 6. *Liberdade e democracia*. II. LIBERDADE E LIBERDADES: 7. *Formas da liberdade*. 8. *Liberdade de ação e legalidade*. III. LIBERDADE DA PESSOA FÍSICA: 9. *Noção e formas*. 10. *Liberdade de locomoção*. 11. *Liberdade de circulação*. 12. *A segurança pessoal — Remissão*. IV. LIBERDADE DE PENSAMENTO: 13. *Conceito e formas de expressão*. 14. *Liberdade de opinião*: 14.1. *Escusa de consciência*; 14.2 *Formas de expressão*. 15. *Liberdade de comunicação*: 15.1 *Noção e princípios*; 15.2 *Liberdade de manifestação do pensamento*; 15.3 *Liberdade de informação em geral*; 15.4 *Liberdade de informação jornalística*; 15.5 *Meios de comunicação*. 16. *Liberdade religiosa*. 17. *Liberdade de expressão intelectual, artística e científica e direitos conexos*. 18. *Liberdade de expressão cultural*. 19. *Liberdade de transmissão e recepção do conhecimento*. V. LIBERDADE DE AÇÃO PROFISSIONAL: 20. *Liberdade de escolha profissional: conceito e natureza*. 21. *Acessibilidade à função pública*. 22. *Regras de contenção*. VI. OS DIREITOS COLETIVOS: 23. *Direitos coletivos e liberdade de expressão coletiva*. 24. *Direito à formação*. 25. *Direito de representação coletiva*. 26. *Direito de participação*. 27. *Direito dos consumidores*. 28. *Liberdade de reunião*. 29. *Liberdade de associação*. VII. REGIME DAS LIBERDADES: 30. *Técnica de proteção das liberdades*. 31. *Eficácia das normas constitucionais sobre as liberdades*. 32. *Sistemas de restrições das liberdades individuais*.

I. O PROBLEMA DA LIBERDADE

1. Liberdade e necessidade

Não cabe discutir a fundo as bases filosóficas¹ do problema da liberdade num trabalho sobre direito positivo. Contudo, alguma coisa deve ser dita a esse propósito, que esteve, no mais das vezes, sujeito a considerações idealistas (sentido filosófico) e metafísicas, que mais confundiram que esclareceram. O debate correlaciona *liberdade e necessidade*. Opunha-se uma à outra. Uns negavam a existência de liberdade humana, afirmando uma necessidade, um determinismo abso-

luto; outros, ao contrário, afirmavam o livre-arbítrio, liberdade absoluta, negando a necessidade. Ora, de um lado, a liberdade era simples desvio do determinismo necessário; de outro, desvio daquela.

Essas posições colocam o homem fora do processo da natureza. Mas é necessário resolver o problema a partir da consideração de que o homem faz parte dela. Está, por isso, sujeito às leis objetivas da necessidade. Mas, além disso, ele é também um ser social; “é criador e produto da história, e suas relações com a natureza, seu conhecimento da natureza e sua ação sobre ela estão condicionados por suas relações sociais com os outros homens”.² Assim, o homem se torna cada vez mais livre na medida em que amplia seu domínio sobre a natureza e sobre as relações sociais. O homem domina a necessidade na medida em que amplia seus conhecimentos sobre a natureza e suas leis objetivas.³ Então, não tem cabimento a discussão sobre a existência e não existência da liberdade humana com base no problema da necessidade, do determinismo ou da metafísica do livre-arbítrio, porque o homem se liberta no correr da história pelo conhecimento e conseqüente domínio das leis da natureza, na medida em que, conhecendo as leis da necessidade, atua sobre a natureza real e social para transformá-la no interesse da expansão de sua personalidade.

2. Liberdade interna e liberdade externa

Esse é outro campo de discussão muito orientada pelo idealismo e pela metafísica. *Liberdade interna* (chamada também *liberdade subjetiva*, *liberdade psicológica* ou *moral* e especialmente *liberdade de indiferença*) é o *livre-arbítrio*, como simples manifestação da vontade no mundo interior do homem. Por isso é chamada igualmente *liberdade do querer*. Significa que a decisão entre duas possibilidades opostas pertence, exclusivamente, à vontade do indivíduo; vale dizer, é *poder de escolha*, de *opção*, entre fins contrários. E daí outro nome que se lhe dá: *liberdade dos contrários*.⁴ O debate não leva a nada. Toda gente sabe que, internamente, é bem possível escolher entre alternativas contrárias, se se tiver *conhecimento* objetivo e correto de ambas. A questão fundamental, contudo, é saber se, feita a escolha, é possível determinar-se em função dela. Isto é, se se têm condições objetivas para atuar no sentido da escolha feita, e, aí, se põe a questão da *liberdade externa*.

Esta, que é também denominada *liberdade objetiva*, consiste na expressão externa do querer individual, e implica o afastamento de

1. Para maior profundidade sobre o tema, cf. Roger Garaudy, *La libertad*, Buenos Aires, Lautaro, 1960, trad. de Sara Manso; Rose-Marie Mossé-Bastide, *La liberté*, Paris, PUF, 1974; Harold J. Laski, *A liberdade*, Salvador, Progresso Ed., s.d., trad. de Pinto de Aguiar; Arturo Carlo Jemolo, *I problemi pratici della libertà*, Milano, Giuffrè, 1972.

2. Cf. Garaudy, *ob. cit.*, p. 232.

3. Idem, p. 196; cf. também Caio Prado Jr., *Dialética do conhecimento*, t. II/551 a 553.

4. Cf., p. ex., Rose-Marie Mossé-Bastide, *ob. cit.*, pp. 16 e 128.

obstáculo ou de coações, de modo que o homem possa agir livremente. Por isso é que também se fala em *liberdade de fazer*, “*poder de fazer tudo o que se quer*”. Mas um tal poder [como observa R.-M. Mossé-Bastide] se não tiver freio, importará no esmagamento dos fracos pelos fortes e na ausência de toda liberdade dos primeiros”.⁵ É nesse sentido que se fala em *liberdades* no plural, *liberdades públicas* (sentido estrito) e *liberdades políticas*.

3. Conteúdo histórico da liberdade

Já delineamos que a liberdade tem um caráter histórico, porque “depende do poder do homem sobre a natureza, a sociedade, e sobre si mesmo em cada momento histórico”.⁶ Realmente, a História mostra que o conteúdo da liberdade se amplia com a evolução da humanidade. Fortalece-se, estende-se, à medida que a atividade humana se alarga. Liberdade é conquista constante.

4. O problema da conceituação

Muitas teorias definem a liberdade como resistência à opressão ou à coação da autoridade ou do poder. Trata-se de uma concepção de liberdade no *sentido negativo*, porque se opõe, *nega*, à autoridade. Outra teoria, no entanto, procura dar-lhe *sentido positivo*: é livre quem participa da autoridade ou do poder. Ambas têm o defeito de definir a liberdade em função da autoridade. Liberdade opõe-se a autoritarismo, à deformação da autoridade; não, porém, à autoridade legítima.

Esta provém do exercício da liberdade, mediante o consentimento popular. Nesse sentido, autoridade e liberdade são situações que se complementam. É que a autoridade é tão indispensável à ordem social — condição mesma da liberdade — como esta é necessária à expansão individual. Um mínimo de coação há sempre que existir. “O problema está em estabelecer, entre a liberdade e a autoridade, um equilíbrio tal que o cidadão médio possa sentir que dispõe de campo necessário à perfeita expressão de sua personalidade”.⁷ Portanto, não é correta a definição de liberdade como ausência de coação. O que é válido afirmar é que a liberdade consiste na ausência de toda coação *anormal*, *ilegítima* e *imoral*. Daí se conclui que toda lei que limita a liberdade precisa ser lei normal, moral e legítima, no sentido de que seja consentida por aqueles cuja liberdade restringe.

5. *Ob. cit.*, p. 127

6. Cf. Garaudy, *ob. cit.*, p. 200.

7. Cf. Harold Laski, *ob. cit.*, p. 8.

Montesquieu já dizia que “a liberdade política não consiste em fazer o que se quer. Num Estado, isto é, numa sociedade onde há leis, a liberdade não pode consistir senão em poder fazer o que se deve querer, e a não ser constrangido a fazer o que não se deve querer”, e logo acrescenta seu conceito de liberdade como “o direito de fazer tudo o que as leis permitem”.⁸ Essa noção de liberdade, contudo, é perigosa, se não se aditar que tais leis devem ser consentidas pelo povo. Assim, a definição da Declaração de 1789 é mais aceitável: “A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique a outrem: assim, o exercício dos direitos naturais do homem não tem outros limites senão os que asseguram aos demais membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites somente a lei poderá determinar”. Mas acrescenta: “A lei não pode proibir senão as ações nocivas à sociedade”.

O conceito de liberdade humana deve ser expresso no sentido de *um poder de atuação do homem em busca de sua realização pessoal, de sua felicidade*. É boa, sob esse aspecto, a definição de Rivero: “a liberdade é um poder de autodeterminação, em virtude do qual o homem escolhe por si mesmo seu comportamento pessoal”.⁹ Vamos um pouco além, e propomos o conceito seguinte: *liberdade consiste na possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à realização da felicidade pessoal*.

Nessa noção, encontramos todos os elementos objetivos e subjetivos necessários à idéia de liberdade; é *poder* de atuação sem deixar de ser resistência à opressão; não se dirige contra, mas *em busca*, em perseguição de alguma coisa, que é a felicidade pessoal, que é subjetiva e circunstancial, pondo a liberdade, pelo seu fim, em harmonia com a consciência de cada um, com o interesse do agente. Tudo que impedir aquela possibilidade de coordenação dos meios é contrário à liberdade. E aqui, aquele sentido histórico da liberdade se insere na sua acepção jurídico-política. Assim, por exemplo, deixar o povo na ignorância, na falta de escola, é negar-lhe a possibilidade de coordenação consciente daqueles meios; oprimir o homem, o povo, é retirar-lhe aquela possibilidade etc. Desse modo, também, na medida em que se desenvolve o conhecimento, se fornecem informações ao povo, mais se amplia a sua liberdade com abrir maiores possibilidades de coordenação de meios necessários à expansão da personalidade de cada um.

5. Liberdade e liberação

O assinalado aspecto histórico denota que a liberdade consiste, em suma, num processo dinâmico de *liberação* do homem de vários

8. Cf. *De l'esprit des lois*, XI, 3.

9. Cf. *Les libertés publiques: I — Les droits de l'homme*, p. 14.

obstáculos que se antepõem à realização de sua personalidade: obstáculos naturais, econômicos, sociais e políticos. É hoje função do Estado promover a liberação do homem de todos esses obstáculos, e é aqui que autoridade (poder) e liberdade se ligam. García-Pelayo o disse bem, ao escrever que “a experiência histórica tem mostrado que não é o Estado o único que oprime o desenvolvimento da personalidade; que não é a única entidade que impõe relações coativas de convivência, e que as mesmas liberdades liberais estão condicionadas em sua realização a situações e poderes extra-estatais. Tais poderes podem ser de índole muito diversa; por exemplo, raciais, eclesiais etc. e variáveis segundo os países; mas de um modo geral e comum se destacam os poderes econômicos. São destes poderes, ou, melhor dizendo, das pressões econômicas destes poderes, que interessa, em primeiro lugar, liberar os grupos a que estamos aludindo, pois são a eles, e não ao Estado, que sentem como obstáculo imediato para o desenvolvimento de sua personalidade.

“Ainda mais: o Estado se mostra justamente como o meio apropriado para realizar a liberação dessas pressões, o que, naturalmente, supõe a ampliação de sua atividade e a intervenção em territórios sociais que antes permaneciam à sua margem, o que indubitavelmente produz lesões a liberdades até então consideradas intangíveis. Mas o processo de democratização sucessiva, com a subsequente pugna com os princípios liberais, se acentua, ademais, enquanto a democracia passa a informar campos alheios ao do novo procedimento de formação e realização da vontade estatal.”¹⁰

6. Liberdade e democracia

Já vimos que o regime democrático é uma garantia geral da realização dos direitos humanos fundamentais. Vale dizer, portanto, que é na democracia que a liberdade encontra campo de expansão. É nela que o homem dispõe da mais ampla possibilidade de coordenar os meios necessários à realização de sua felicidade pessoal. Quanto mais o processo de democratização avança, mais o homem se vai libertando dos obstáculos que o constroem, mais liberdade conquista.

II. LIBERDADE E LIBERDADES

7. Formas da liberdade

Já deixamos claro que ao Direito positivo interessa cuidar apenas da *liberdade objetiva* (liberdade de fazer, liberdade de atuar). É nesse

sentido que se costuma falar em *liberdades* no plural, que, na verdade, não passa das várias expressões externas da liberdade. *Liberdades*, no plural, são *formas da liberdade*,¹¹ que, aqui, em função do Direito Constitucional positivo, vamos distinguir em cinco grandes grupos:

(1) *liberdade da pessoa física* (liberdades de locomoção, de circulação);

(2) *liberdade de pensamento*, com todas as suas *liberdades* (opinião, religião, informação, artística, comunicação do conhecimento);

(3) *liberdade de expressão coletiva* em suas várias formas (de reunião, de associação);

(4) *liberdade de ação profissional* (livre escolha e de exercício de trabalho, ofício e profissão);

(5) *liberdade de conteúdo econômico e social* (liberdade econômica, livre iniciativa, liberdade de comércio, liberdade ou autonomia contratual, liberdade de ensino e liberdade de trabalho), de que trataremos entre os *direitos econômicos e sociais*, porque não integram o campo dos direitos individuais, mas o daqueles.

8. Liberdade de ação e legalidade

Antes de entrar no estudo dessas liberdades, cabe considerar aquela que constitui, por assim dizer, a *liberdade-matriz*, a *liberdade-base*, que é a *liberdade de ação em geral*, a *liberdade geral de atuar*, que decorre do art. 5º, II, da Constituição, segundo o qual *ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei*. É um modo de dizer diferente daquele de Montesquieu. Para este, a liberdade consistiria no direito de fazer tudo o que as leis permitissem. O texto constitucional supra, ao contrário, prevê a *liberdade de fazer*, a *liberdade de atuar* ou *liberdade de agir*, como princípio. Vale dizer, o princípio é o de que *todos têm a liberdade de fazer e de não fazer o que bem entender*, salvo quando a lei determine em contrário. A extensão dessa liberdade fica, ainda, na dependência do que se entende por *lei*. Se se considerar a *lei* qualquer norma elaborada pelo Poder Público, independentemente da origem desse poder, então o princípio constitucional vale bem pouco. Não é esse, porém, o sentido da palavra *lei*. Como vimos, a liberdade não é incompatível com um sistema coativo, e até se pode acrescentar que ela pressupõe um sistema dessa ordem, traduzido no ordenamento

11. Pimenta Bueno já dizia: “A liberdade é sempre uma e a mesma, mas como ela pode ser considerada em diferentes relações, por isso costuma-se dividi-la ou classificá-la como liberdade do pensamento e sua comunicação, de consciência ou religião, de locomoção, viagem ou imigração, de trabalho ou indústria, de contratar e de associação”. Cf. *Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império*, p. 384.

10. Cf. Manuel García-Pelayo, *Derecho constitucional comparado*, p. 203.

jurídico. A questão está na legitimidade do sistema coativo, do ordenamento jurídico. Desde que a lei, que obrigue a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, seja legítima, isto é, provenha de um legislativo formado mediante consentimento popular e seja formada segundo processo estabelecido em constituição emanada também da soberania do povo, a liberdade não será prejudicada. Nesse caso, os limites a ela opostos pela lei são legítimos. A Constituição, em vigor, preenche as condições de legitimidade para embasar uma lei legítima, desde que se harmonize com ela.

O art. 5º, II, em análise, revela duas dimensões. Uma muito clara e explícita, que consubstancia o *princípio da legalidade*, que, por ser uma *garantia individual*, merecerá consideração aprofundada mais adiante. Outra, nem sempre considerada pela doutrina,¹² que é essa regra de direito fundamental, de *liberdade de ação*, que estamos estudando. Por isso, esse dispositivo é um dos mais importantes do direito constitucional brasileiro, porque, além de conter a previsão da liberdade de ação (liberdade-base das demais), confere fundamento jurídico às liberdades individuais e correlaciona *liberdade* e *legalidade*. Dele se extrai a idéia de que a liberdade, em qualquer de suas formas, só pode sofrer restrições por *normas jurídicas preceptivas* (que impõem uma conduta positiva) ou *proibitivas* (que impõem uma abstenção), provenientes do Poder Legislativo e elaboradas segundo o procedimento estabelecido na Constituição. Quer dizer: *a liberdade só pode ser condicionada por um sistema de legalidade legítima*.

O grande Pimenta Bueno já dizia no século passado que “a liberdade não é pois exceção, é sim a regra geral, o princípio absoluto, o Direito positivo; a proibição, a restrição, isso sim é que são as exceções, e que por isso mesmo precisam ser provadas, achar-se expressamente pronunciadas pela lei, e não por modo duvidoso, sim formal, positivo; tudo o mais é sofisma.

“Em dúvida [conclui] prevalece a liberdade, porque é o direito, que não se restringe por suposições ou arbítrio, que vigora, porque é *facultas ejus, quod facere licet, nisi quid jure prohibet*.”¹³

III. LIBERDADE DA PESSOA FÍSICA

9. Noções e formas

A *liberdade da pessoa física* (também impropriamente chamada *liberdade individual*, já que todas o são) constitui a primeira forma de

12. O Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho deu-lhe atenção: cf. *Curso de direito constitucional*, 17ª ed., p. 260.

13. *Ob. cit.*, pp. 382 e 383.

liberdade que o homem teve que conquistar. Ela se opõe ao estado de escravidão e de prisão. A revolta de Espártaco tinha por objetivo a conquista dessa liberdade elementar do ser humano. A Guerra dos Palmares durante cem anos¹⁴ foi a mais expressiva batalha dos negros brasileiros contra o seu cativeiro.

Resta, porém, a outra forma de oposição à liberdade da pessoa física, que é a detenção, a prisão ou qualquer impedimento à locomoção da pessoa, inclusive a doença.

Assim, podemos oferecer a seguinte noção de liberdade da pessoa física (excluindo-se as hipóteses de doenças, causas naturais que não interessam ao nosso estudo): *é a possibilidade jurídica que se reconhece a todas as pessoas de serem senhora de sua própria vontade e de locomoverem-se desembaraçadamente dentro do território nacional*.¹⁵ Inclui, outrossim, no conceito, a possibilidade de sair e entrar no território nacional, como veremos.

Os franceses indicam, como conteúdo dessa liberdade, três prerrogativas: (a) liberdade de ir e vir; (b) segurança individual; (c) liberdade de intimidade.¹⁶

Para nós as formas de expressão da liberdade da pessoa física se revelam apenas na *liberdade de locomoção* e na *liberdade de circulação*, não sendo esta, aliás, mais do que manifestação especial daquela, que consideraremos separadamente tão-só para destacar peculiaridades. Mencionaremos igualmente o problema da segurança, não como forma de liberdade da pessoa física em si, mas como forma de garantir a efetividade destas.

10. Liberdade de locomoção

Esta constitui o cerne da liberdade da pessoa física no sistema jurídico, abolida que foi a escravidão. A Constituição reservou-lhe um dispositivo, o que não era feito pelas anteriores. Ressaía, antes, como primeira manifestação da liberdade geral de ação. Agora, o art. 5º, XV, declara *livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens*. Explicitam aí duas situações: uma é a *liberdade de locomoção no território nacional*; a outra é a *liberdade de a pessoa entrar no território nacional, nele permanecer e dele sair com seus bens*.

14. Cf. Edison Carneiro, *O Quilombo dos Palmares*, pp. 43 e 44.

15. Em sentido semelhante, Georges Burdeau, *Les libertés publiques*, p. 111.

16. Cf. Burdeau, *ob. cit.*, p. 111; Claude-Albert Colliard, *Libertés publiques*, p. 205; Jacques Robert, *Libertés publiques*, p. 159.

A liberdade de locomoção no território nacional em tempo de paz contém o direito de *ir e vir* (viajar e migrar) e de *ficar e de permanecer*, sem necessidade de autorização. Significa que “podem todos locomover-se livremente nas ruas, nas praças, nos lugares públicos, sem temor de serem privados de sua liberdade de locomoção”, dizia Sampaio Dória no regime da Constituição de 1946.¹⁷ Temos aí a noção essencial da liberdade de locomoção: poder que todos têm de coordenar e “dirigir suas atividades e de dispor de seu tempo, como bem lhes parecer, em princípio, cumprindo-lhes, entretanto, respeitar as medidas impostas pela lei, no interesse comum, e abster-se de atos lesivos dos direitos de outrem”.¹⁸

A lei referida no dispositivo não se aplica à hipótese de locomoção dentro do território nacional em *tempo de paz*. Portanto, será inconstitucional lei que estabeleça restrições nessa locomoção. Em *tempo de guerra*,¹⁹ no entanto, isso será possível, desde que não elimine a liberdade como instituição.

A liberdade de, em tempo de paz, entrar no território nacional, nele permanecer e dele sair é direito de *ir e vir* através das fronteiras nacionais. Envolve o direito de *migrar* (*emigrar e imigrar*). Por referir-se a situações ligadas a estrangeiros, esse particular direito de *ir, vir e permanecer* é cercado de maiores limitações, sujeitando-se a preceitos legais especiais, e fica dependendo dos “termos da lei” referida a seu propósito no inciso constitucional em exame. O texto não quer dizer que em *tempo de guerra* a entrada e permanência no território nacional ou a saída dele estejam vedadas. Não o estão, mas não será um direito, uma liberdade do indivíduo, salvo se for brasileiro que esteja retornando à Pátria. Se for brasileiro que queira sair ou estrangeiro que deseje entrar, sair ou ficar, as autoridades poderão aceder ou não

17. Cf. *Direito Constitucional: comentários à Constituição de 1946*, v. IV/651.

18. Cf. Eduardo Espínola, *Constituição dos Estados Unidos do Brasil* (18.9.46), v. II/562.

19. O conceito jurídico de *tempo de guerra*, expressão usada algumas vezes na Constituição, deve ser fixado à vista também de normas constitucionais sobre o assunto. Não basta o *estado de beligerância*. É necessário que esse estado de fato tenha passado para o campo jurídico, o que se dá pela *declaração de guerra*, segundo os requisitos constitucionais para sua efetivação. Ora, cabe à União *declarar a guerra*, assim como *celebrar a paz* (art. 21, II), e ela o faz pelo Presidente da República, depois de autorizado pelo Congresso Nacional ou por ele referendado nos termos dos arts. 41, II, e 84, XIX e XX. Portanto, o *tempo de guerra* começa com essa declaração, e termina com a paz. Não basta também aqui a cessação do estado de beligerância. Juridicamente, a guerra termina quando o Presidente da República celebra a paz autorizado pelo Congresso Nacional ou por ato por este referendado (incisos citados supra). *Tempo de guerra*, portanto, é o período de beligerância entre o Brasil e um país estrangeiro compreendido entre a declaração de guerra e a assinatura da paz nos termos constitucionais indicados. Fora do tempo de guerra, todo tempo é *tempo de paz*.

à sua vontade, de acordo com os critérios discricionários de conveniência e oportunidade, tendo em vista não apenas a segurança do país como também a segurança do próprio interessado.

Foi a essa liberdade que, desde o século XVII, se deu uma garantia específica: o *habeas corpus*. E a Constituição, como as anteriores, procurou resguardar com um conjunto de medidas que formam o chamado *direito de segurança*, que examinaremos noutro lugar.

11. Liberdade de circulação

Direito à circulação é manifestação característica da liberdade de locomoção: *direito de ir, vir, ficar, parar, estacionar*. O *direito de circular* (ou liberdade de circulação) *consiste na faculdade de deslocar-se de um ponto a outro através de uma via pública ou afetada ao uso público*. Em tal caso, a utilização da via “não constituirá uma mera possibilidade, mas um poder legal exercitável *erga omnes*. Em consequência, a Administração não poderá impedir, nem geral nem singularmente, o trânsito de pessoas de maneira estável, a menos que desafete a via, já que, de outro modo, se produziria uma transformação da afetação por meio de uma simples atividade de polícia”.²⁰

“Isso quer dizer [acrescenta Escribano em nota] que, independentemente do meio através do qual se circula por uma via pública, o transeunte terá um direito de passagem e de deslocamento por ela, por constituir esta forma de deslocamento a manifestação primária e elementar do direito de uso de uma via afetada. Em consequência, a menos que circunstâncias excepcionais o obriguem (a ruína iminente de um edifício), a Administração não poderá legalmente impedir esta utilização, sempre deixando a salvo os direitos dos confinantes”.²¹ Daí concluir com base na doutrina e na jurisprudência do Conselho de Estado francês que “é possível definir a circulação pública mediante três elementos: 1. um conjunto anônimo e indeterminado de usuários que atuam *iure proprio* em virtude de um poder legal conferido; 2. uma atividade ordenadora da Administração Pública titular da via afetada; 3. uma via afetada ao uso público”.²²

20. Cf. Pedro Escribano Collado, *Las vías urbanas*, p. 358. A lição do autor refere-se particularmente à circulação nas vias urbanas, mas pode ser generalizada a todas as vias terrestres não ferroviárias (ruas, avenidas, praças, caminhos, rodovias).

21. Idem, p. 358, nota 22. *Jurisprudência*: “Qualquer cidadão [em verdade, qualquer indivíduo] tem direito público subjetivo de transitar por estradas públicas municipais e, conseqüentemente, o direito de exigir da administração municipal que se abstenha de perturbar-lhe ou impedir-lhe livre trânsito por via que, de longa data, vem sendo usada pelo povo” (TASP, rel. Alcides Faro, 16.4.52, RT 203/412).

22. Idem, p. 359.

A atividade ordenadora da via pela Administração ocorre num duplo sentido: na *criação* (ou autorização da criação) da rede viária necessária ao exercício da função e do direito de circulação, e na regulamentação *do uso* da mesma. Reconhece-se à Administração “uma faculdade geral para regulamentar a circulação, que se define como a competência que determina os meios, através dos quais se exercita o direito de circular em cada via urbana [*e não-urbana*], e as normas que regulam a circulação reconhecida”.²³

Sob esse aspecto, cumpre lembrar que cabe à União estabelecer os *princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação* (art. 21, XXI) e *legislar privativamente sobre trânsito e transportes* (art. 22, XI), restando aos Estados e Municípios disciplinar o tráfego nas respectivas vias públicas.

12. A segurança pessoal — Remissão

Benjamin Constant dizia que todas as constituições francesas reconheciam a liberdade individual; contudo, esta nunca deixara de ser constantemente violada, “e isso porque uma simples declaração não basta; são necessárias salvaguardas positivas”.²⁴ É que a liberdade da pessoa física, para ter efetividade, precisa de *garantias* contra a prisão, a detenção e a penalização arbitrárias, mediante mecanismos constitucionais denominados, em conjunto, *direito de segurança*.²⁵ Essas regras de segurança pessoal exigem que as medidas tomadas contra os indivíduos sejam conformes com o direito, isto é, anterior e regularmente estabelecidas, vale dizer, atendam ao *princípio da legalidade*, ao *devido processo legal*.²⁶

As normas constitucionais que definem o direito de segurança pessoal acham-se inscritas nos incisos XLV a LXIX do art. 5º da Constituição. Como se trata daquilo que denominamos de direito instrumental, o direito de segurança se inclui no conceito de *garantia constitucional*. Por isso, desenvolvemos o tema no título correspondente, ao qual remetemos o leitor, não sem antes recordar uma passagem de Montesquieu que vem a calhar: “A liberdade política de um cidadão é essa tranquilidade de espírito que provém da opinião que cada qual tem de sua segurança; e, para que se tenha essa liberdade, é preciso que o governo seja tal que um cidadão não possa temer outro cidadão”.²⁷

23. Idem, p. 359. Cf. também nosso *Direito urbanístico brasileiro*, pp. 226 e ss.

24. Cf. *Curso de política constitucional*, p. 142.

25. Cf. Georges Burdeau, *Les libertés publiques*, p. 129.

26. Idem, *ibidem*.

27. Cf. *De l'esprit des lois*, XI, 6.

IV. LIBERDADE DE PENSAMENTO

13. Conceito e formas de expressão

A *liberdade de pensamento* — segundo Sampaio Dória — “é o direito de exprimir, por qualquer forma, o que se pense em ciência, religião, arte, ou o que for”.²⁸ Trata-se de liberdade de conteúdo intelectual e supõe o contacto do indivíduo com seus semelhantes,²⁹ pela qual “o homem tenda, por exemplo, a participar a outros suas crenças, seus conhecimentos, sua concepção do mundo, suas opiniões políticas ou religiosas, seus trabalhos científicos”.³⁰

Nesses termos, ela se caracteriza como exteriorização do pensamento no seu sentido mais abrangente. É que, no seu sentido interno, como pura consciência, como pura crença, mera opinião, a liberdade de pensamento é plenamente reconhecida, mas não cria problema maior. Pimenta Bueno já dizia que a “liberdade de pensamento em si mesmo, enquanto o homem não manifesta exteriormente, enquanto o não comunica, está fora de todo poder social, até então é do domínio somente do próprio homem, de sua inteligência e de Deus”.³¹ É Pimenta Bueno que arremata:

“O homem porém não vive concentrado só em seu espírito, não vive isolado, por isso mesmo que por sua natureza é um ente social. Ele tem a viva tendência e necessidade de expressar e trocar suas idéias e opiniões com os outros homens, de cultivar mútuas relações, seria mesmo impossível vedar, porque fora para isso necessário dissolver e proibir a sociedade”.³²

14. Liberdade de opinião

De certo modo esta resume a própria liberdade de pensamento em suas várias formas de expressão. Por isso é que a doutrina a chama de liberdade *primária* e ponto de partida das outras.³³ Trata-se da liberdade de o indivíduo adotar a atitude intelectual de sua escolha: quer um pensamento íntimo, quer seja a tomada de posição pública; liberdade de pensar e dizer o que se crê verdadeiro.³⁴

28. Cf. *Direito constitucional: comentários à Constituição de 1946*, v. III/602.

29. Cf. Colliard, *ob. cit.*, p. 313.

30. Idem, *ibidem*.

31. Cf. *ob. cit.*, p. 384; cf. também Pe. José Scambini, *Liberdade religiosa nas Constituições brasileiras*, p. 103.

32. *Ob. cit.*, p. 385.

33. Cf. Colliard, *ob. cit.*, p. 316.

34. Cf. Jacques Robert, *ob. cit.*, p. 302.

A Constituição a reconhece nessas duas dimensões. Como pensamento íntimo, prevê a *liberdade de consciência* e de *crença*, que declara inviolável (art. 5º, VI), como a de *crença religiosa* e de *convicção filosófica* ou *política* (art. 5º, VIII). Isso significa que todos têm o direito de aderir a qualquer crença religiosa como o de recusar qualquer delas, adotando o ateísmo, e inclusive o direito de criar a sua própria religião, bem assim o de seguir qualquer corrente filosófica, científica ou política ou de não seguir nenhuma, encampando o ceticismo.

14.1 Escusa de consciência

Da liberdade de consciência, de crença religiosa e de convicção filosófica deriva o direito individual de *escusa de consciência*, ou seja, o direito de recusar prestar determinadas imposições que contrariem as convicções religiosas ou filosóficas do interessado. É comum que, por questões religiosas especialmente, alguém se recuse a prestar serviço militar. A Constituição diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, *salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei* (art. 5º, VIII, *fine*). Reconhece-se o direito da *escusa* ou *imperativo de consciência*, mas a lei pode impor ao recusante prestação alternativa, que, por certo, há de ser compatível com suas convicções. Há, assim, a liberdade de escusa, como um direito individual reconhecido mediante norma de eficácia contida,³⁵ contendo esta que só se concretiza por meio da referida lei restritiva, que fixe prestação alternativa. A prestação alternativa é que constitui a sanção, constitucionalmente prevista, para a escusa de consciência considerada nesse dispositivo. Mas se o titular do direito de escusa recusar também a prestação alternativa, é que ficará sujeito a qualquer penalidade estatuída na lei referida no artigo ora em comentário. O mais comum é o *imperativo de consciência* em relação à obrigação de prestar serviço militar, conforme se menciona no art. 143, § 1º, que estabelece competir às Forças Armadas, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz (não em tempo de guerra), após alistados, o alegarem para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. A lei aí referida já foi promulgada, Lei 8.239, de 4.10.91, para a qual *serviço militar alternativo* consiste no exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, em substituição às atividades de caráter essencialmente militar, e

35. Para o conceito de normas de eficácia contida, cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, pp. 91 e ss.

será prestado em organismos militares ou conveniados com os militares, findo o qual será conferido ao escusante um Certificado de Prestação Alternativa de Serviço Militar Obrigatório com os mesmos efeitos jurídicos do Certificado de Reservista. A recusa ou o cumprimento incompleto do serviço alternativo implica o não fornecimento do Certificado e fica o escusante inadimplente sujeito à suspensão de seus direitos políticos, de acordo com o § 2º do art. 4º da citada lei, consoante a previsão do art. 15, IV, da Constituição.

A liberdade de convicção filosófica e política passa sempre por períodos de crise. Tivemos longo tempo de restrições às convicções marxistas, que a atual Constituição não autoriza em hipótese alguma, como não admite restrição a qualquer outra corrente de pensamento. Apenas *veda partidos políticos de organização paramilitar* (art. 17, § 4º).

14.2 Formas de expressão

Como *aspecto externo* (a outra dimensão mencionada), a liberdade de opinião se exterioriza pelo exercício das liberdades de comunicação, de religião, de expressão intelectual, artística, científica e cultural e de transmissão e recepção do conhecimento, que estudaremos nos tópicos seguintes.

15. Liberdade de comunicação

15.1 Noção e princípios

A *liberdade de comunicação* consiste num conjunto de direitos, formas, processos e veículos, que possibilitam a coordenação desembaraçada da criação, expressão e difusão do pensamento e da informação. É o que se extrai dos incisos IV, V, IX, XII e XIV do art. 5º combinados com os arts. 220 a 224 da Constituição. Compreende ela as formas de *criação, expressão e manifestação do pensamento e de informação*, e a organização dos *meios de comunicação*, esta sujeita a regime jurídico especial de que daremos notícias no final desse tópico.

As formas de comunicação regem-se pelos seguintes princípios básicos: (a) observado o disposto na Constituição, não sofrerão qualquer restrição qualquer que seja o processo ou veículo por que se exprimam; (b) nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística; (c) é vedada toda e qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística; (d) a publicação de veículo impresso de comunicação in-

depende de licença de autoridade; (e) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens dependem de autorização, concessão ou permissão do Poder Executivo federal, sob controle sucessivo do Congresso Nacional, a que cabe apreciar o ato, no prazo do art. 64, §§ 2º e 4º (45 dias, que não correm durante o recesso parlamentar); (f) os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio.

15.2 Liberdade de manifestação do pensamento

A liberdade de manifestação do pensamento constitui um dos aspectos externos da liberdade de opinião. A Constituição o diz no art. 5º, IV: *é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato*, e o art. 220 dispõe que *a manifestação de pensamento, sob qualquer forma, processo ou veiculação, não sofrerá qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição, vedada qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística*.

Essa exteriorização do pensamento pode dar-se entre interlocutores presentes ou ausentes. No primeiro caso, pode verificar-se de pessoa a pessoa (em forma de diálogo, de conversação) ou de uma pessoa para outras (em forma de exposição, de conferência, palestras, discursos etc.), interferindo aqui com o direito de reunião e de associação, de que cuidaremos noutro lugar. No segundo caso, pode ocorrer entre pessoas determinadas, por meio de correspondência pessoal e particular sigilosa (carta, telegrama, telefone, ligados ao direito à privacidade, como foi visto), ou expressar-se para pessoas indeterminadas, sob a forma de livros, jornais, revistas e outros periódicos, televisão e rádio, que mereceram normas especiais na Constituição que discutiremos na frente.

Acrescente-se que, na liberdade de manifestação do pensamento, se inclui, também, o direito de tê-lo em segredo, isto é, o direito de não manifestá-lo,³⁶ recolhendo-o na esfera íntima do indivíduo. De tudo se conclui que não se pode impor a ninguém uma conduta ou obrigação que conflite com sua crença religiosa ou com sua convicção filosófica ou política. O direito de ficar calado passou a ser um direito individual inscrito na Constituição; quando, no art. 5º, LXIII, declara que o preso será informado de seus direitos, entre os quais *o de permanecer calado*, ela o está reconhecendo não só neste caso, mas como um direito de todos. Aqui foi especificado por razões óbvias no sistema policial brasileiro.

36. Cf. Paolo Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, p. 24.

A liberdade de manifestação do pensamento tem seu ônus, tal como o de o manifestante identificar-se, assumir claramente a autoria do produto do pensamento manifestado, para, em sendo o caso, responder por eventuais danos a terceiros. Daí por que a Constituição *veda o anonimato*. A manifestação do pensamento não raro atinge situações jurídicas de outras pessoas a que corre o *direito*, também fundamental individual, *de resposta*. O art. 5º, V, o consigna nos termos seguintes: *é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem*. Esse direito de resposta, como visto antes, é também uma garantia de eficácia do direito à privacidade. Esse é um tipo de conflito que se verifica com bastante frequência no exercício da liberdade de informação e comunicação.

Importante que a Constituição assume a tese da indenizabilidade do dano moral, problema controvertido na doutrina, mas já razoavelmente estudado.

15.3 Liberdade de informação em geral

Há que se fazer distinção entre liberdade de informação e direito à informação. Deste, que não é um direito pessoal nem profissional, mas um *direito coletivo*,³⁷ trataremos no lugar próprio.

A palavra informação designa “o conjunto de condições e modalidades de difusão para o público (ou colocada à disposição do público) sob formas apropriadas, de notícias ou elementos de conhecimento, idéias ou opiniões”.³⁸ Como esclarece Albino Greco, por “informação” se entende “o conhecimento de fatos, de acontecimentos, de situações de interesse geral e particular que implica, do ponto de vista jurídico, duas direções: a do *direito de informar* e a do *direito de ser informado*”.³⁹ O mesmo é dizer que a liberdade de informação compreende a *liberdade de informar* e a *liberdade de ser informado*. A primeira, observa Albino Greco, coincide com a liberdade de manifestação do pensamento *pela palavra, por escrito ou por qualquer outro meio de difusão*; a segunda indica o interesse sempre crescente da coletividade para que tanto os indivíduos como a comunidade estejam informados para o exercício consciente das liberdades públicas.⁴⁰

37. Cf. Freitas Nobre, *Comentários à Lei de Imprensa, Lei da Informação*, p. 6.

38. Cf. Fernand Terrou, *L'information*, citado por Freitas Nobre, *ob. cit.*, pp. 7 e 8.

39. Cf. *La libertà di stampa nell'ordinamento giuridico italiano*, p. 38, citando Chiola, *L'informazione nella costituzione*, p. 28.

40. Cf. *ob. cit.*, p. 40.

Nesse sentido, a *liberdade de informação* compreende a procura, o acesso, o recebimento e a difusão de informações ou idéias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada qual pelos abusos que cometer. O acesso de todos à informação é um direito individual consignado na Constituição, que também resguarda o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV). Aqui se ressalva o direito do jornalista e do comunicador social de não declinar a fonte onde obteve a informação divulgada. Em tal situação, eles ou o meio de comunicação utilizado respondem pelos abusos e prejuízos ao bom nome, à reputação e à imagem do ofendido (art. 5º, X).

15.4 Liberdade de informação jornalística

É nesta que se centra a liberdade de informação, que assume características modernas, superadoras da velha liberdade de imprensa. Nela se concentra a *liberdade de informar* e é nela ou através dela que se realiza o direito coletivo à informação, isto é, a *liberdade de ser informado*. Por isso é que a ordem jurídica lhe confere um regime específico, que lhe garanta a atuação e lhe coíba os abusos. A propósito da liberdade de imprensa, cabe recordar estas palavras de Marx: "A imprensa livre é o olhar onipotente do povo, a confiança personalizada do povo nele mesmo, o vínculo articulado que une o indivíduo ao Estado e ao mundo, a cultura incorporada que transforma lutas materiais em lutas intelectuais, e idealiza suas formas brutas. É a franca confissão do povo a si mesmo, e sabemos que o poder da confissão é o de redimir. A imprensa livre é o espelho intelectual no qual o povo se vê, e a visão de si mesmo é a primeira confissão da sabedoria".⁴¹

A *liberdade de informação jornalística* de que fala a Constituição (art. 220, § 1º) não se resume mais na simples liberdade de imprensa, pois esta está ligada à publicação de *veículo impresso* de comunicação. A *informação jornalística* alcança qualquer forma de difusão de notícias, comentários e opiniões por qualquer veículo de comunicação social. A Constituição não chega a precisar o que se entende por veículos ou meios de comunicação social, que ela menciona no art. 220, §§ 1º e 5º. Ao referir-se, em separado, a *veículo impresso de comunicação* (§ 6º), poder-se-ia entender que ela não inclui a imprensa escrita entre os meios de comunicação social. Talvez até nem o seja. Mas o § 1º do art. 220 ao garantir a plena liberdade de informação

41. Cf. "Debate sobre a liberdade de imprensa e comunicação" (série de artigos publicados no *Rheinische Zeitung*, em 5, 8, 10, 12 e 19.5.1842), in Karl Marx, *A liberdade de imprensa*, p. 42.

jornalística em *qualquer veículo de comunicação social* faz entrar aí também as informações jornalísticas impressas.

Temos, pois, informações jornalísticas que são publicadas mediante: (a) veículos impressos de comunicação; (b) veículo de difusão (radiodifusão) sonora, de sons e imagens.

A liberdade de informação não é simplesmente a liberdade do dono da empresa jornalística ou do jornalista. A liberdade destes é reflexa no sentido de que ela só existe e se justifica na medida do direito dos indivíduos a uma informação correta e imparcial. A liberdade dominante é a de ser informado, a de ter acesso às fontes de informação, a de obtê-la. O dono da empresa e o jornalista têm um *direito fundamental* de exercer sua atividade, sua missão, mas especialmente têm um *dever*. Reconhece-se-lhes o *direito de informar* ao público os acontecimentos e idéias, mas sobre ele incide o *dever de informar* à coletividade de tais acontecimentos e idéias, objetivamente, sem alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes o sentido original, do contrário, se terá não informação, mas deformação.⁴² Os jornalistas e empresas jornalísticas reclamam mais seu direito do que cumprem seus deveres. Exatamente porque a imprensa escrita, falada e televisada (como impropriamente se diz) constitui poderoso *instrumento de formação da opinião pública* (mormente com o desenvolvimento das máquinas interplanetárias destinadas a propiciar a ampla transmissão de informações, notícias, idéias, doutrinas e até sensacionalismos) é que se adota hoje a idéia de que ela desempenha uma *função social* consistente, em primeiro lugar, em "exprimir às autoridades constituídas o pensamento e a vontade popular, colocando-se quase como um quarto poder, ao lado do Legislativo, do Executivo e do jurisdicional", no dizer de Foderaro.⁴³ É que ela "*constitui uma defesa* contra todo excesso de poder e um forte *controle* sobre a atividade político-administrativa e sobre não poucas manifestações ou abusos de relevante importância para a coletividade".⁴⁴ Em segundo lugar, aquela função consiste em assegurar a expansão da liberdade humana.⁴⁵

Isto é que, em primeiro lugar, gera a repulsa a qualquer tipo de *censura* à imprensa, seja a *censura prévia* (intervenção oficial que impede a divulgação da matéria) ou a *censura posterior* (intervenção oficial que se exerce depois da impressão, mas antes da publicação, impeditiva da circulação de veículo impresso).⁴⁶ Em segundo lugar,

42. Cf. Albino Greco, *ob. cit.*, p. 53.

43. Cf. *Libertà di stampa*, pp. 11 e ss., in Albino Greco, *ob. cit.*, p. 52.

44. Cf. Albino Greco, *ob. cit.*, p. 53. Também Freitas Nobre, *ob. cit.*, pp. 6-8.

45. Cf. Afonso Arinos de Melo Franco, "Pela liberdade de imprensa", in *Estudos de direito constitucional*, p. 323.

46. Idem, *ibidem*.

é a mesma função social que fundamenta o condicionamento da sua liberdade, que, agora, se limitará à vedação do anonimato (em matéria não assinada, o diretor do veículo responde), ao direito de resposta proporcional ao agravo, indenização por dano material, moral ou à imagem e sujeição às penas da lei no caso de ofensa à honra de alguém (art. 5º, IV, V, X), pois nenhuma lei poderá embaraçar a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, nem se admite censura de natureza política, ideológica e artística (art. 220, §§ 1º e 2º).

15.5 Meios de comunicação

A liberdade de comunicação envolve também a escolha dos meios de exteriorização do pensamento e difusão das informações, que são basicamente os *livros*, os *jornais* e outros *periódicos*, os *serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens* e os *serviços noticiosos* (Lei 5.250/67, arts. 2º e 12, parágrafo único). Esses meios de comunicação estão sujeitos a regimes jurídicos próprios. Assim, a publicação de livros, jornais e outros periódicos (revistas, boletins etc.) não depende de licença de autoridade alguma (art. 220, § 6º); a lei exige que sejam matriculados em cartório de registro de pessoas jurídicas, sob pena de serem tidos como clandestinos (Lei 5.250/67, arts. 8º a 11). Os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens são explorados diretamente pela União ou mediante concessão, permissão ou autorização (art. 21, XII, a, e art. 223).

16. Liberdade religiosa

Ela se inclui entre as liberdades espirituais. Sua exteriorização é forma de manifestação do pensamento. Mas, sem dúvida, é de conteúdo mais complexo pelas implicações que suscita. Ela compreende três formas de expressão (três *liberdades*): (a) a *liberdade de crença*; (b) a *liberdade de culto*; (c) e a *liberdade de organização religiosa*. Todas estão garantidas na Constituição.

(a) *Liberdade de crença*: a Constituição de 1967/1969 não previa a liberdade de crença em si, mas apenas a *liberdade de consciência* e, na mesma provisão, assegurava aos crentes o exercício dos cultos religiosos (art. 153, § 5º). Então, a liberdade de crença era garantida como simples forma da liberdade de consciência. A Constituição de 1988 voltou à tradição da Constituição de 1946, declarando inviolável a *liberdade de consciência e de crença* (art. 5º, VI), e logo no inciso VIII estatui que *ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa*.

Fez bem o constituinte em destacar a liberdade de crença da de consciência. Ambas são inconfundíveis — di-lo Pontes de Miranda —, pois, “o descrente também tem liberdade de consciência e pode pedir que se tutele juridicamente tal direito”, assim como a “liberdade de crença compreende a liberdade de ter uma crença e a de não ter crença”.⁴⁷

Na liberdade de crença entra a *liberdade de escolha* da religião, a *liberdade de aderir* a qualquer seita religiosa, a *liberdade* (ou o *direito*) de *mudar de religião*, mas também compreende a *liberdade de não aderir a religião alguma*,⁴⁸ assim como a *liberdade de descrença*, a *liberdade de ser ateu* e de exprimir o agnosticismo. Mas não compreende a liberdade de embaraçar o livre exercício de qualquer religião, de qualquer crença, pois aqui também a liberdade de alguém vai até onde não prejudique a liberdade dos outros.

(b) *Liberdade de culto*: a religião não é apenas sentimento sagrado puro. Não se realiza na simples contemplação do ente sagrado, não é simples adoração a Deus. Ao contrário, ao lado de um corpo de doutrina, sua característica básica se exterioriza na prática dos ritos, no culto, com suas cerimônias, manifestações, reuniões, fidelidades aos hábitos, às tradições, na forma indicada pela religião escolhida.⁴⁹ Na síntese de Pontes de Miranda: “Compreendem-se na liberdade de culto a de orar e a de praticar os atos próprios das manifestações exteriores *em casa* ou *em público*, bem como a de recebimento de contribuições para isso”.⁵⁰ A Constituição do Império não reconhecia a liberdade de culto com essa extensão para todas as religiões, mas somente para a católica, que era a religião oficial do Império. As outras eram toleradas apenas “com seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de Templo” (art. 5º).

A Constituição ampliou essa liberdade e até prevê-lhe uma garantia específica. Diz, no art. 5º, VI, que é assegurado o *livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, proteção aos locais de culto e a suas liturgias*. Diferentemente das constituições anteriores não condiciona o exercício dos cultos à observância da ordem pública e dos bons costumes. Esses conceitos que importavam em regra de contenção, de limitação dos cultos já não mais o são. É que, de fato, parece impensável uma religião cujo culto, por si, seja contrário aos

47. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969, t. V/119.

48. Sobre essa temática, cf. Jacques Robert, *Liberté religieuse et le régime des cultes*, pp. 8, 9 e 101 e ss.

49. Idem, p. 9.

50. Ob. cit., p. 129; igualmente, Pe. José Scambini, ob. cit., p. 102.

bons costumes e à ordem pública. Demais, tais conceitos são vagos, indefinidos, e mais serviram para intervenções arbitrárias do que de tutela desses interesses gerais.

O dispositivo transcrito compõe-se de duas partes: *assegura a liberdade de exercício dos cultos religiosos*, sem condicionamentos, e *protege os locais de culto e suas liturgias*, mas aqui, *na forma da lei*. É evidente que não é a lei que vai definir os locais do culto e suas liturgias. Isso é parte da liberdade de exercício dos cultos, que não está sujeita a condicionamento. É claro que há locais, praças por exemplo, que não são propriamente locais de culto. Neles se realizam cultos, mais no exercício da liberdade de reunião do que no da liberdade religiosa. A lei poderá definir melhor esses locais não típicos de culto, mas necessários ao exercício da liberdade religiosa. E deverá estabelecer normas de proteção destes e dos locais em que o culto normalmente se verifica, que são os *templos*, edificações com as características próprias da respectiva religião. Aliás, assim o tem a Constituição, indiretamente, quando estatui a imunidade fiscal sobre “templos de qualquer culto” (art. 150, VI, *b*). Mas a liberdade de culto se estende à sua prática nos lugares e logradouros públicos, e aí também ele merece proteção da lei.

Enfim, cumpre aos poderes públicos não embaraçar o exercício dos cultos religiosos (art. 19, I) e protegê-los, impedindo que outros o façam. Nesse sentido já se pronunciou o STF em favor do ex-Bispo de Maura que constituiu uma igreja nacional, com o mesmo rito da católica, mas desvinculada do Pontífice Romano.⁵¹

(*c*) *Liberdade de organização religiosa*: essa liberdade diz respeito à possibilidade de estabelecimento e organização das igrejas e suas relações com o Estado.

Quanto à relação Estado-Igreja, três sistemas são observados: a *confusão*, a *união* e a *separação*, cada qual com gradações. Mal nos cabe dar notícias desses sistemas aqui. Na *confusão*, o Estado se confunde com determinada religião; é o Estado *teocrático*, como o Vaticano e os Estados islâmicos. Na hipótese da *união*, verificam-se relações jurídicas entre o Estado e determinada Igreja no concernente à sua organização e funcionamento, como, por exemplo, a participação daquele na designação dos ministros religiosos e sua remuneração.⁵² Foi o sistema do Brasil Império.

Realmente, a Constituição Política do Império estabelecia que a Religião Católica Apostólica Romana era a Religião do Império (art.

51. Cf. texto do acórdão em Pontes de Miranda, *ob. cit.*, pp. 133 e 135; Pe. José Scambini, *ob. cit.*, pp. 222 a 224.

52. Cf. Jacques Robert, *ob. cit.*, p. 21.

5º), com todas as conseqüências derivantes dessa qualidade de *Estado confessional*, tais como a de que as demais religiões seriam simplesmente toleradas, a de que o Imperador, antes de ser aclamado, teria que jurar manter aquela religião (art. 103), a de que competia ao Poder Executivo nomear os bispos e prover os benefícios eclesiásticos (art. 102, II), bem como conceder ou negar os beneplácitos a atos da Santa Sé (art. 102, XIV), quer dizer, tais atos só teriam vigor e eficácia no Brasil se obtivessem aprovação do governo brasileiro. Em verdade, não houve no Império liberdade religiosa, pois, se o culto católico gozava de certo privilégio e podia realizar-se livremente, muitas restrições existiam quanto à organização e funcionamento da religião oficial, a ponto de se reconhecer, hoje, que ela era uma religião “manietada e escravizada pelo Estado, através da sua intervenção abusiva na esfera da Igreja”.⁵³

A República principiou estabelecendo a liberdade religiosa com a separação da Igreja do Estado. Isso se deu antes da constitucionalização do novo regime, com Decreto 119-A, de 7.1.1890, da lavra de Ruy Barbosa, expedido pelo Governo Provisório.⁵⁴

A Constituição de 1891 consolidou essa separação e os princípios básicos da liberdade religiosa (arts. 11, § 2º; 72, §§ 3º a 7º; 28 e 29). Assim, o Estado brasileiro se tornou *laico*, admitindo e respeitando todas as vocações religiosas. O Decreto 119-A/1890 reconheceu personalidade jurídica a todas as igrejas e confissões religiosas. O art. 113, item 5º, da Constituição de 1934 estatuiu que as associações religiosas adquiriram personalidade jurídica nos termos da lei civil. Os princípios básicos continuaram nas constituições posteriores até a vigente. Quanto ao tema deste tópico — *liberdade de organização religiosa* — houve pequenos ajustes quanto às relações Estado-Igreja, passando de uma separação mais rígida para um sistema que admite certos contactos, que analisaremos rapidamente, tais como:

(a) *Separação e colaboração*. De acordo com o art. 19, I, é *vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público*. Pontes de Miranda esclareceu bem o sentido das várias prescrições nucleadas nos verbos do dispositivo: “estabelecer cultos religiosos está em sentido am-

53. Cf. Pe. José Scambini, *ob. cit.*, p. 57. Nessa obra, o autor faz amplo histórico e debate sobre as relações entre a Igreja e o Estado no Brasil, em face de todas as nossas constituições.

54. Cf. texto do decreto in Pe. José Scambini, *ob. cit.*, p. 89, nota 19. Antecedentes e apreciação do decreto no mesmo autor, *ob. cit.*, pp. 81 e ss.

plo: criar religiões ou seitas, ou fazer igrejas ou quaisquer postos de prática religiosa, ou propaganda. *Subvencionar cultos religiosos* está no sentido de concorrer, com dinheiro ou outros bens da entidade estatal, para que se exerça a atividade religiosa. *Embaraçar o exercício dos cultos religiosos* significa vedar, ou dificultar, limitar ou restringir a prática, psíquica ou material, de atos religiosos ou manifestações de pensamento religioso”.⁵⁵ Para evitar qualquer forma de embaraços por via tributária, a Constituição estatui imunidade dos templos de qualquer culto (art. 150, VI, *b*). Não se admitem também relações de dependência ou de aliança com qualquer culto, igreja ou seus representantes, mas isso não impede as relações diplomáticas com o Estado do Vaticano, porque aí ocorre relação de direito internacional entre dois Estados soberanos, não de dependência ou de aliança, que não pode ser feita. Mais difícil é definir o nível de *colaboração de interesse público* possibilitada na ressalva do dispositivo, *na forma da lei*. A lei, pois, é que vai dar a forma dessa colaboração. É certo que não poderá ocorrer no campo religioso.⁵⁶ Demais, a colaboração estatal tem que ser geral a fim de não discriminar entre as várias religiões. A lei não precisa ser federal, mas da entidade que deve colaborar. Se existe lei municipal, por exemplo, que prevê cessão de terreno para entidades educacionais, assistenciais e hospitalares, tal cessão pode ser dada em favor de entidades confessionais de igual natureza. A Constituição mesma já faculta que recursos públicos sejam, excepcionalmente, dirigidos a *escolas confessionais*, como definido em lei, desde que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, e assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades (art. 213). É mera faculdade que, por conseguinte, não dá direito subjetivo algum a essas escolas de receber recursos do Poder Público.

(*b*) *Assistência religiosa*. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva (penitenciárias, casas de detenção, casas de internação de menores etc.). Nas edições anteriores incluí nos parêntesis as *Forças Armadas* como entidade de internação coletiva. Melhor pensando, retifico, porque elas não têm essa qualidade (conforme observamos no nosso *Comentário Contextual à Constituição*, São Paulo, Malheiros Editores, no prelo, comentários ao inciso VII do art. 5º).

(*c*) *Ensino religioso*. Este deve constituir disciplina dos horários normais das *escolas públicas* de ensino fundamental (primeiro grau).

55. Cf. *ob. cit.*, t. II/185.

56. Cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Comentários à Constituição brasileira de 1988*, v. I/144.

Mas se tratará de matéria de *matrícula facultativa* (art. 210, § 1º). Vale dizer: é um direito do aluno religioso ter a possibilidade de matricular-se na disciplina, mas não lhe é dever fazê-lo. Nem é disciplina que demande provas e exames que importem reprovação ou aprovação para fins de promoção escolar. Note-se ainda que só as *escolas públicas* são obrigadas a manter a disciplina e apenas no ensino fundamental. As escolas privadas podem adotá-la como melhor lhes parecer, desde que não imponham determinada confissão religiosa a quem não o queira.

(*d*) *Casamento religioso*. O casamento válido juridicamente é o civil, mas o casamento religioso terá efeito civil, nos termos da lei (art. 226, §§ 1º e 2º). A Constituição de 1988 preferiu remeter a regulamentação da validade civil do casamento para a lei, ao contrário das constituições anteriores que já estabeleciam as condições e requisitos da equiparação, trazendo, a esse propósito, norma de eficácia plena. Agora, não, a norma é de eficácia limitada, pois dependerá da lei para sua efetiva aplicação.

17. Liberdade de expressão intelectual, artística e científica e direitos conexos

A liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (desta já tratamos) é assegurada no art. 5º, IX, da Constituição. As manifestações intelectuais, artísticas e científicas são formas de difusão e manifestação do pensamento, tomado esse termo em sentido abrangente dos sentimentos e dos conhecimentos intelectuais, conceptuais e intuitivos. A atividade intelectual é genérica. Não diremos que abrange também o conhecimento artístico, porque este é intuitivo. A arte ingênua, primitiva, certamente não é uma atividade intelectual. Mas por certo a atividade científica o é. A atividade intelectual é especialmente vinculada ao conhecimento conceptual⁵⁷ que abrange a produção científica e filosófica. Esta, como todas as manifestações artísticas, está protegida pela liberdade de que estamos nos ocupando. Todos podem produzir obras intelectuais, científicas ou filosóficas, e divulgá-las, sem censura e sem licença de quem quer que seja.

Determinadas expressões artísticas gozam de ampla liberdade, como as das artes plásticas, a música e a literatura. Certas manifesta-

57. Para uma distinção elementar entre o conhecimento conceptual e a intuição de que deriva a arte, cf. Benedetto Croce, *Breviário de estética*, São Paulo, Atena Ed., s.d.

ções artísticas, contudo, ficam sujeitas a uma regulamentação especial, consoante prevê o art. 220, § 3º, que declara competir à lei federal:

“I — regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;

“II — estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.”

Temos aí dois problemas: o das *diversões e espetáculos públicos* e o dos *programas de rádio e televisão*.

Há *diversões públicas* que não entram na noção de espetáculo público, embora, em certo sentido, os espetáculos públicos sejam também formas de divertimento. Os “parques de diversões”, certas casas de divertimentos e brinquedos eletrônicos, por exemplo, oferecem diversões públicas. Ficam sujeitos às limitações previstas em lei, na forma indicada no art. 220, § 3º, I, espécie de censura classificatória, para efeitos indicativos, prevista no art. 21, XVI. Os franceses chamam essas diversões públicas de *espetáculos de curiosidade*, distrações de conteúdo não intelectual.⁵⁸

Os *espetáculos* são de conteúdo variado. Envolvem “criação artística, que traduz certa visão do homem e da vida, uma estética, ou mesmo uma opção política” ou simples distração ao público evitando fazer pensar e que não põe qualquer problema de liberdade intelectual.⁵⁹ Assim num sentido extenso se fala em espetáculo a respeito de tudo o que chama a atenção, atrai e prende o olhar, mas no sentido de *espetáculo público*, referido na Constituição, trata-se de *representação teatral, exibição cinematográfica, rádio, televisão ou qualquer outra demonstração pública de pessoa ou conjunto de pessoas*.⁶⁰

A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão, segundo a Constituição (art. 221), deverão atender os seguintes princípios: I — preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; II — promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação; III — regionalização da produção cultural, artística e jornalística, confor-

58. Cf. Colliard, *Libertés publiques*, p. 506.

59. Cf. Jean Rivero, *Les libertés publiques*, v. II/283.

60. Cf. “Espetáculo”, in Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, *Novo Dicionário da Língua Portuguesa*, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, s.d.

me percentuais estabelecidos em lei; IV — respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. A lei poderá estabelecer regras de defesa da pessoa e da família de programas e programações que contrariem esses princípios. Não cabe censura, mas classificação, para efeitos indicativos (art. 21, XVI).

Cumpra, finalmente, lembrar aqui a proteção especial que a Constituição oferece aos produtores de obras intelectuais, artísticas e científicas. A primeira é tradicional: a garantia a autores do direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar (art. 5º, XXVII: é o direito autoral). Outras duas são inovações, asseguradas nos termos da lei: (a) proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; (b) aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem (art. 5º, XXVIII).

São direitos conexos com as liberdades de criação e expressão intelectuais, artísticas e científicas.

18. Liberdade de expressão cultural

Em certo sentido, a *liberdade de expressão cultural* já ficara delineada nas considerações supra. Mas a Constituição traz um capítulo sobre a cultura, no qual estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional, apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais populares, indígenas, afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório brasileiro (arts. 215 e 216).

Aí se manifesta a mais aberta liberdade cultural, sem censura, sem limites: uma vivência plena dos valores do espírito humano em sua projeção criativa, em sua produção de objetos que revelem o sentido dessas projeções da vida do ser humano.

19. Liberdade de transmissão e recepção do conhecimento

É uma das formas de comunicação e de manifestação do pensamento, tanto que todos podem comunicar e manifestar seu pensamento e seu conhecimento pela imprensa, pela radiodifusão, pelos livros e conferências. Mas a Constituição a destacou, em relação ao exercício do magistério, quando põe como um dos princípios do ensino a *liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber*, dentro de uma visão pluralista de idéias, de concepções

pedagógicas e de instituições públicas e privadas do ensino (art. 206, II e III). Trata-se do reconhecimento de liberdade de uma classe de especialistas na comunicação do conhecimento, que são os *professores*. A expressão *liberdade de cátedra* era mais restritiva, por estar vinculada à idéia de catedrático, que recebia conotação de titularidade de certos cargos de magistério.

A fórmula empregada agora é mais compreensiva porque se dirige a qualquer exercente de função de magistério, a professores de qualquer grau, dando-se liberdade de ensinar, e mais ainda porque também abrange a outra face da transmissão do conhecimento, o outro lado da liberdade de ensinar, ou seja, a liberdade de aprender, assim como a liberdade de pesquisar (modo de aquisição do conhecimento).

Tem-se, assim, que o enunciado compreende as duas dimensões do conhecer: o *subjetivo* e o *objetivo*. Na primeira, dá-se a relação dos sujeitos do conhecimento envolvendo a liberdade de *transmitir o conhecimento*, que cabe ao professor, e o *direito de receber o conhecimento* ou de *buscá-lo*, que cabe a alunos e pesquisadores. Na segunda, encontra-se a *liberdade de o professor escolher o objeto relativo do ensino a transmitir*. Dizemos *objeto relativo*, porque sua liberdade aqui fica condicionada aos currículos escolares e aos programas oficiais de ensino (art. 209). Dentro dessa baliza, impende ao professor ministrar o seu curso com a liberdade de crítica, de conteúdo, forma e técnica que lhe pareçam mais corretos. Nisso se consubstanciam aqueles dois direitos pertinentes à liberdade de cátedra, lembrados por Sampaio Dória: “o de ser o catedrático o único juiz da verdade sobre o que ensine, e o de só dele depender a técnica do seu ensino. Não há ciência oficial, nem método didático oficial. Cada catedrático é senhor de como se desempenha de sua missão”.⁶¹

O mesmo constitucionalista recorda os deveres correlatos àqueles direitos: assiduidade às aulas que cabem ao professor, e excelência do ensino a seu cargo.⁶² O professor tem o dever de esforçar-se para que seu ensino seja bom, eficiente e eficaz, pois o aluno tem o direito de reclamar um trabalho sério de seus mestres.

V. LIBERDADE DE AÇÃO PROFISSIONAL

20. Liberdade de escolha profissional: conceito e natureza

O que denominamos de *liberdade de ação profissional* não se encaixa em nenhum dos grupos anteriores das liberdades. Alguns cha-

61. Cf. *Direito constitucional: comentários à Constituição de 1946*, v. IV/778.

62. Idem, *ibidem*.

mam-na de *liberdade de trabalho*. Não é, porém, como a concebemos, porque essa terminologia não exprime bem a sua essência e porque não constitui direito social do trabalho, o qual merecerá consideração oportunamente. Será a *liberdade de escolha do trabalho um de seus aspectos*. É mais que isso, porque também é *liberdade de exercício de ofício e de profissão*, consoante o enunciado do art. 5º, XIII: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.

O teor do dispositivo, de si, já demonstra que estamos diante de simples *direito individual*, não daquilo que a doutrina chama liberdade do conteúdo social, pois que ali não se garante o trabalho, não se assegura o conteúdo do trabalho, nem a possibilidade de trabalho, nem o emprego nem tampouco as condições materiais para a investidura num ofício ou para a aquisição de qualquer profissão. Isso, sim, seria direito social.

O dispositivo confere liberdade de escolha de trabalho, de ofício e de profissão, de acordo com as propensões de cada pessoa e na medida em que a sorte e o esforço próprio possam romper as barreiras que se antepõem à maioria do povo. Confere, igualmente, a liberdade de exercer o que fora escolhido, no sentido apenas de que o Poder Público não pode constranger a escolher e a exercer outro. Quanto a saber se há ou não condições de aquisição de ofício ou de profissão escolhida, não é tema que preocupe o enunciado formal da norma. Como todo direito de liberdade individual, a regra se limita a conferi-lo sem se importar com as condições materiais de sua efetividade. Equivale a dizer, como a experiência o mostra, que, na prática, a liberdade reconhecida não se verifica em relação à maioria das pessoas, que não têm condições de escolher o trabalho, o ofício ou a profissão, sendo mesmo obrigadas a fazer o que nem sempre lhes apetece sob pena de não ter o que comer. As épocas de recessão são pródigas em demonstrar o quanto o texto constitucional em exame é formal. Não quer isso dizer que seja inútil. É necessário que exista e tem sua função importante, mormente se preenchido o vazio com medidas transformadoras da realidade econômico-social vigente. O que é realmente necessário é dar conteúdo a essa liberdade, estabelecendo condições materiais e efetivas de acessibilidade ao trabalho, ao ofício e à profissão.

21. Acessibilidade à função pública

Uma manifestação especial da liberdade aqui considerada é a *acessibilidade à função pública*. Há, porém, diferença que deve ser lembrada. A liberdade anunciada no art. 5º, XIII, beneficia a brasileiros e

estrangeiros residentes no País, enquanto a acessibilidade à função pública sofre, mais amplamente, restrições de nacionalidade. Em alguns casos, a acessibilidade à função pública só cabe aos brasileiros natos (art. 12, § 3º); outras vezes, a qualquer brasileiro, como é a hipótese de acesso aos cargos públicos, nos termos do art. 37, I e II, segundo o qual os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, dependendo, em princípio, de concurso público de provas ou de provas e títulos, como examinaremos oportunamente, inclusive para mostrar que esse acesso à função pública foi estendido aos estrangeiros, na forma da lei, e não só aos residentes.

22. Regras de contenção

O princípio é o da liberdade reconhecida. No entanto, a Constituição ressalva, quanto à escolha e exercício de ofício e profissão, que ela fica sujeita à observância das “qualificações profissionais que a lei exigir”. Há, de fato, ofícios e profissões que dependem de capacidade especial, de certa formação técnica, científica ou cultural. *Compete privativamente à União legislar sobre condições para o exercício de profissões* (art. 22, XVI). Só lei federal pode definir as qualificações profissionais requeridas para o exercício das profissões.

No respeitante à investidura e exercício em cargos, empregos e funções públicas, igualmente depende de preenchimento de requisitos estabelecidos em lei, mas esta será federal, estadual ou municipal, conforme se trate de função pública federal, estadual ou municipal.

Como o princípio é o da liberdade, a eficácia e aplicabilidade da norma é ampla, quando não exista lei que estatua condições ou qualificação especiais para o exercício do ofício ou profissão ou acessibilidade à função pública. Vale dizer, não são as leis mencionadas que dão eficácia e aplicabilidade à norma. Não se trata de direito *legal*, direito decorrente da lei mencionada, mas de direito constitucional, direito que deriva diretamente do dispositivo constitucional. A lei referida não cria o direito, nem atribui eficácia à norma. Ao contrário, ela importa em *conter* essa eficácia e aplicabilidade, trazendo norma de restrição destas.

VI. OS DIREITOS COLETIVOS

23. Direitos coletivos e liberdade de expressão coletiva

A categoria dos direitos coletivos como espécie dos direitos fundamentais do homem começa, agora, a se forjar e a merecer consideração constitucional específica. Já em anteriores edições deste livro,

destacamos as *liberdades de expressão coletiva*, tais as de reunião e de associação. Mas aqui, em realidade, temos direitos individuais, porque imputáveis aos indivíduos como tal, e não a uma coletividade de indivíduos. Consideramo-los de *expressão coletiva*, porque, se eram direitos individuais, o eram em função de uma pluralidade de pessoas entre si vinculadas dentro de uma coletividade. Não nos escapava, assim, o interesse coletivo que fundamentava o reconhecimento desses direitos aos indivíduos.

Outros direitos mais caracteristicamente coletivos, porque conferidos não em função de interesse individual, mas da coletividade, específica ou genérica, induziram-nos a mudar a categorização desse tópico, no qual discutiremos tanto os direitos tipicamente coletivos como aqueles que qualificávamos de “expressão coletiva”.

No processo de elaboração constitucional, houve forte tendência em abrir um capítulo especial para os *direitos coletivos*, em que se arrolariam os de reunião, de associação, de professar cultos por pregações, rituais e cerimônias públicas, de organização sindical, de manifestação coletiva de interesses grupais, associativos e sindicais, incluindo a de paralisação coletiva do trabalho, de sindicatos e associações obterem informações do Poder Público, de participação dos movimentos sociais organizados na Administração Pública, de entidades e associações defenderem em juízo os interesses dos respectivos associados e categorias, o direito ao meio ambiente sadio, à identidade histórica e cultural e o dos consumidores. Muitas propostas tinham sentido corporativo inaceitável.

A relatoria dos projetos eliminou o capítulo dos direitos coletivos e passou a intitular o capítulo dos direitos individuais de: “Direitos e deveres individuais e coletivos”. Mas nem todos os projetados direitos coletivos foram incluídos aí, nem seria adequado. Assim, por exemplo, os direitos de organização sindical e de greve foram incluídos no capítulo dos direitos sociais. O direito ao meio ambiente, à identidade histórica e cultural constam do título da ordem social. Restaram no capítulo dos direitos individuais e coletivos os direitos à informação, à representação associativa, do consumidor, de reunião e de associação, dos quais cuidaremos a seguir.

24. Direito à informação

Fizemos antes estudo sobre a *liberdade de informação*, observando que seria necessário distinguir entre ela e o *direito à informação*. Freitas Nobre já dissera que “a relatividade de conceitos sobre o direito à informação exige uma referência aos regimes políticos, mas, sempre, com a convicção de que este direito não é um direito pessoal, nem

simplesmente um direito profissional, mas um *direito coletivo*".⁶³ Isso porque se trata de um *direito coletivo da informação ou direito da coletividade à informação*.⁶⁴ O direito de informar, como aspecto da liberdade de manifestação de pensamento, revela-se um direito individual, mas já contaminado de sentido coletivo, em virtude das transformações dos meios de comunicação, de sorte que a caracterização mais moderna do *direito de comunicação*, que especialmente se concretiza pelos meios de comunicação social ou de massa, envolve a transmutação do antigo direito de imprensa e de manifestação do pensamento, por esses meios, em direitos de feição coletiva. Albino Greco notou essa transformação: "Já se observou que a liberdade de imprensa nasceu no início da idade moderna e se concretizou — essencialmente — num *direito subjetivo do indivíduo* de manifestar o próprio pensamento: nasce, pois, como *garantia de liberdade individual*. Mas, ao lado de tal direito do indivíduo, veio afirmando-se o *direito da coletividade à informação*".

A Constituição acolheu essa distinção. No capítulo da comunicação (arts. 220 a 224), preordena a liberdade de informar completada com a liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV). No mesmo art. 5º, XIV e XXXIII, já temos a dimensão coletiva do direito à informação. O primeiro declara *assegurado a todos o acesso à informação*. É o interesse geral contraposto ao interesse individual da manifestação de opinião, idéias e pensamento, veiculados pelos meios de comunicação social. Daí por que a liberdade de informação deixara de ser mera função individual para tornar-se função social.

O outro dispositivo trata de direito à informação mais específico, quando estatui que *todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado*. Aí, como se vê do enunciado, amalgamam-se interesses particulares, coletivos e gerais, donde se tem que não se trata de mero direito individual.

O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a) pode também revelar-se como direito coletivo, na medida em que pode ser usado no interesse da coletividade, e geralmente o é, mais do que no interesse individual.

25. Direito de representação coletiva

A legitimação para agir em juízo é tradicionalmente pessoal, como direito público subjetivo do indivíduo, tanto que, nas constituições

anteriores, se declarava que a lei não poderia excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão a *direito individual*. Agora se dispõe, como veremos, que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sem qualificá-lo. Em consequência, a Constituição já previu casos de representação coletiva de interesses coletivos ou mesmo individuais integrados numa coletividade.

É assim que se estabelece que *as entidades associativas, quando expressamente autorizadas* [certamente em seus estatutos], têm legitimidade para representar seus filiados em juízo ou fora dele (art. 5º, XXI), legitimidade essa também reconhecida aos sindicatos em termos até mais amplos e precisos, *in verbis*: *ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas* (art. 8º, III).

Põe-se aí, contudo, a questão das *associações de associações*, que são associações de segundo grau, que têm como filiados não indivíduos, mas outras associações. São pessoas jurídicas associativas que agregam, como filiadas, outras pessoas jurídicas associativas. Também essas *associações de segundo grau* têm, com base no dispositivo em questão, legitimidade para representar suas associações filiadas em juízo e fora dele. Isso vale para as associações sindicais.

A questão aqui é diversa daquela que tem merecido tratamento negativo do Supremo Tribunal Federal no que respeita à legitimação para a ação direta de inconstitucionalidade, consoante referimos antes. De fato, o Pretório Excelso tem decidido reiteradamente "que não se qualificam como entidades de classe aquelas que, congregando pessoas jurídicas, apresentam-se como verdadeiras *associações de associações*. Em tais hipóteses, tem-se-lhes negado a qualidade reclamada pelo texto constitucional, pois pessoas jurídicas, ainda que coletivamente representativas de categorias profissionais ou econômicas, *não formam classe alguma*".⁶⁵

26. Direito de participação

Distinguiremos aqui dois tipos de participação. Um é a *participação direta dos cidadãos no processo político e decisório*. A iniciativa legislativa popular, que consiste no direito de certo número de eleitores apresentar projetos de lei às Casas legislativas, o plebiscito e o referendo, modos de decisão popular, respectivamente, sobre uma questão política concreta ou sobre um projeto de lei aprovado e ain-

63. Cf. *ob. cit.*, p. 6.

64. Cf. Albino Greco, *ob. cit.*, pp. 40 e 41.

65. Cf. ADIn 79-DF, Rel. Min. Celso de Mello, RTJ 147/3. Cita inúmeros precedentes.

da não sancionado (arts. 14, I e II, 29, XIII, e 61, § 2º). Só se reputa direito coletivo porque só pode ser exercido por um número razoável de eleitores: uma coletividade, ainda que não organizada formalmente. O outro, que chamaríamos de *participação orgânica*, às vezes resvalando para uma forma de participação corporativa, é a participação prevista no art. 10: “É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos onde seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação”, e a representação assegurada no art. 11: “*Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores*”, as quais aparecem entre os direitos sociais. Melhor mesmo será sua caracterização como direito coletivo.

Coletivo, de natureza comunitária não-corporativa, é o direito de participação da comunidade, especialmente de trabalhadores, empresários e aposentados, na gestão da seguridade social (art. 194, VII), como a participação da comunidade nas ações e serviços públicos de saúde (art. 198, III).

Em certo sentido, também é da mesma natureza o direito de fiscalização popular previsto no art. 31 § 3º: “As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei”. É que o contribuinte entra aqui como defensor do interesse público e da coletividade.

27. Direito dos consumidores

Sente-se que a Constituição foi tímida no dispor sobre a proteção dos consumidores.⁶⁶ Estabeleceu que o Estado proverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (art. 5º, XXXII).⁶⁷

Realça de importância, contudo, sua inserção entre os direitos fundamentais, com o que se erigem os consumidores à categoria de titula-

66. A Constituição Portuguesa de 1976 foi a primeira a acolher normas de proteção do consumidor, de maneira bastante avançada (art. 110). A Constituição Espanhola de 1978 abeberou-se nela ao preordenar semelhante proteção (art. 51). Inspiramo-nos em ambas para propor perante a Comissão Afonso Arinos igual tutela (nosso Anteprojeto, art. 60), e o fizemos também entre os direitos fundamentais, mas como direito social. O Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos também o fez, em termos diferentes e de mistura com o direito ao meio ambiente (art. 36, § 1º).

67. A lei aí referida já foi promulgada, em cumprimento do art. 48 das Disposições Transitórias. É o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11.8.90), bem moderno. Cf. Juarez de Oliveira (coordenador), *Comentários do Código do Consumidor*, São Paulo, Saraiva, 1991.

res de direitos constitucionais fundamentais. Conjugue-se isso com a consideração do art. 170, V, que eleva a *defesa do consumidor* à condição de princípio da ordem econômica. Tudo somado, tem-se o relevante efeito de legitimar todas as medidas de intervenção estatal necessárias a assegurar a proteção prevista.⁶⁸ Isso naturalmente abre larga brecha na economia de mercado, que se esteia, em boa parte, na liberdade de consumo, que é a outra face da liberdade do tráfico mercantil fundada na pretensa lei da oferta e da procura.⁶⁹ A defesa dos consumidores “responde a um duplo tipo de razões: em primeiro lugar, razões econômicas derivadas das formas segundo as quais se desenvolve, em grande parte, o atual tráfico mercantil; e, em segundo lugar, critérios que emanam da adaptação da técnica constitucional ao estado de coisas que hoje vivemos”, imersos que estamos na chamada sociedade de consumo, em que o “ter” mais do que o “ser” é a ambição de uma grande maioria das pessoas, que se satisfaz mediante o consumo.⁷⁰

Lembra Luis M. Cazorla Prieto que “o constitucionalismo em sua fase mais recente aspira, como antes, a fazer eco das novas circunstâncias e a incorporar a realidade à norma suprema, enquanto isto supõe um passo muito qualificado para corrigir deficiências e situações indevidas. Como o problema dos consumidores não revestira a gravidade que hoje apresenta até datas relativamente recentes, não havia entrado nas Constituições até a portuguesa de 1976”.⁷¹ É bem verdade que as constituições brasileiras, desde 1946, inscreveram um dispositivo que poderia servir de base à proteção do consumidor, se fosse eficaz. Referimo-nos à repressão ao abuso do poder econômico, que, na Constituição de 1988, aparece com enunciado menos eficaz ainda, porque o fez depender da lei. Esta é que “reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (art. 173, § 4º). Ajudará, por certo, a caracterização do mercado interno como patrimônio nacional.

28. Liberdade de reunião

A liberdade de reunião está prevista no art. 5º, XVI, da Constituição, nos termos seguintes: “todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convo-

68. Cf. a esse propósito, J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, *Constituição da República Portuguesa anotada*, pp. 323 e 325.

69. Cf. Luis M. Cazorla Prieto, in Fernando Garrido Falla (coordenador), *Comentarios a la constitución*, p. 849.

70. Idem, pp. 850 e 851.

71. Idem, p. 853.

cada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente”.

Aí a *liberdade de reunião* está plena e eficazmente assegurada, não mais se exige lei que determine os casos em que será necessária a comunicação prévia à autoridade, bem como a designação, por esta, do local da reunião. Nem se autoriza mais a autoridade a intervir para manter a ordem, o que era utilizado para dificultar o exercício da liberdade de reunião e até para o exercício do arbítrio de autoridade. Agora apenas cabe um *aviso*, mero aviso, à autoridade que terá o dever, de ofício, de garantir a realização da reunião. Não tem a autoridade que designar local, nem sequer aconselhar outro local, salvo se comprovadamente já estiver ciente, por aviso insofismável, de que outra reunião já fora convocada para o mesmo lugar.

Reunião, aí, é qualquer agrupamento formado em certo momento com o objetivo comum de trocar idéias ou de receber manifestação de pensamento político, filosófico, religioso, científico ou artístico. *Reunião*, no dizer correto de Pontes de Miranda, “é a aproximação — especialmente considerada — de algumas ou muitas pessoas, com o fim de informar-se, de esclarecer-se e de adotar opinião (deliberar, ainda que só no foro íntimo)”.⁷² Não é propriamente um agrupamento organizado, como, às vezes, se diz, porque organização pressupõe acerto entre os componentes, estruturação interna, o que não se verifica na reunião. Nesta o agrupamento, a aproximação, dá-se pela simples atração do objetivo comum, que sequer precisa ser definido. A mera curiosidade em face de acontecimentos não é suficiente para dar ao agrupamento o seu sentido de reunião. É que esta, se não pressupõe acordo prévio entre seus componentes, funda-se, ao menos, numa avocação prévia sob a direção de alguém ou de uma comissão. Só na existência dessa coordenação ou direção da reunião é que se encontra um ligeiro elemento organizativo. É isso também que demarca a reunião em relação aos aglomerados instantâneos ou outros agrupamentos. Não são reuniões, pois, nem os ajuntamentos ocasionais nem os ajuntamentos por força de ordens legais.⁷³

A reunião é, por outro lado, uma formação grupal passageira, no que ela se estrema da associação, que é organização permanente e de base contratual, fundada portanto no acordo de vontades dos aderentes.

Incluem-se no conceito de reunião as *passeatas* e *manifestações* nos logradouros públicos, as quais são ajuntamentos de pessoas que se produzem em certas circunstâncias, para exprimir uma vontade co-

letiva ou sentimentos comuns, como a celebração de uma festa, a comemoração de um acontecimento, a expressão de uma homenagem ou de uma reivindicação, de um protesto, notando-se que a idéia e os sentimentos desses aglomerados se conhecem pelas insígnias, por cartazes, bandeiras, gritos e cantos.⁷⁴ A diferença entre passeata e simples manifestação está em que esta se realiza num só lugar, é imóvel, enquanto aquela se desloca nas vias públicas,⁷⁵ quando, então, os indivíduos exercem, ao mesmo tempo, duas liberdades fundamentais: a liberdade de locomoção (circulação) e a liberdade de reunião.

Aliás, a liberdade de reunião é daquelas que podemos denominar de liberdade-condição, porque, sendo um direito em si, constitui também condição para o exercício de outras liberdades: de manifestação do pensamento, de expressão de convicção filosófica, religiosa, científica e política, e de locomoção (liberdade de ir, vir e ficar).

Por isso é que, se o seu regime delineia limitações possíveis (regras de contenção), predomina sempre o princípio de que prima a liberdade. Há, agora, apenas uma limitação: que a reunião seja *sem armas*; e uma exigência: que se dê *prévio aviso à autoridade*. A necessidade de aviso não é limitação, mera comunicação. A reunião *sem armas* significa vedação à reunião de bandos armados com intenções belicosas, porque só se admitem reuniões com fins pacíficos, como expressamente consta do inciso constitucional em exame. Mas não quer isto dizer que a autoridade possa submeter todos os participantes, ou qualquer deles, a revistas para verificar ou não a existência de armas. *Sem armas* significa sem armas brancas ou de fogo, que denotem, a um simples relance de olho, atitudes belicosas ou sediciosas. Como não mais se exige lei sobre o direito de reunião, fica revogada a Lei 1.207, de 25.10.50, em tudo quanto contrariar o texto constitucional.

Fala-se no inciso constitucional em reunir-se *em locais abertos ao público*. Isto não é nem limitação nem exigência para o exercício da liberdade de reunião. Quer dizer apenas que as reuniões *privadas* são amplamente livres, porque estão amparadas por outros direitos fundamentais, como a inviolabilidade do lar ou a liberdade de associação em cuja sede se realizem. As *públicas* ocorrem em logradouros públicos ou em outros locais abertos ao público, como um terreno particular aberto, um estádio liberado ao público, uma igreja etc. A propósito, a Lei 1.207/50 previa que a autoridade policial de maior categoria em cada cidade fixasse as praças destinadas aos *comícios*

72. Cf. *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. V/596.

73. Cf. Pontes de Miranda, *ob. cit.*, p. 597.

74. Cf. Colliard, *ob. cit.*, p. 599.

75. Idem, *ibidem*.

(reunião, portanto, de caráter público e que se realizam em locais abertos ao público), dando publicidade ao ato. A Constituição não mais condiciona o exercício do direito de reunião (de reunião alguma, portanto, nem de comício) à designação de local pela autoridade. A escolha do local aberto ao público é parte da liberdade de reunião. É livre, sem que autoridade alguma tenha o poder de indicar o local onde possa dar-se. Essa liberdade de escolha só pode frustrar-se se outra reunião já estiver, comprovadamente, convocada para o mesmo local.

29. Liberdade de associação

Essa liberdade não constava da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Tampouco era reconhecida pela Constituição do Império brasileiro. Não eram, porém, vedadas as associações, tanto que medraram no século passado, especialmente as de caráter político — partidos políticos.

Ela ingressou no Direito Constitucional brasileiro pelo § 8º do art. 72 da Constituição de 1891, de mistura com o direito de reunião. É reconhecida e garantida, hoje, pelos incisos XVII a XXI do art. 5º, onde se estatui que “é plena a liberdade de associação para fins pacíficos, vedada a de caráter paramilitar”, que “a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização, vedada a interferência estatal em seu funcionamento”, que “as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado”, que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”, e que “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados em juízo e fora dele”, o que já comentamos no momento em que estudamos o direito coletivo de representação associativa.

Associação é — no dizer de Pontes de Miranda — “toda coligação voluntária de algumas ou de muitas pessoas físicas, por tempo longo, com o intuito de alcançar algum fim (lícito), sob direção unificante. Não está em causa a personalidade, nem, sequer, certa capacidade indireta de direito [...], como a de receber benefícios (e.g., *modus*). Por outro lado, não pode invocar o princípio constitucional a pessoa jurídica que se proponha a associar-se a outras pessoas jurídicas, ou a pessoas físicas; nem a que deseje aderir ao negócio jurídico de associação”.⁷⁶

76. *Ob. cit.*, t. V/608.

Seus elementos são: base contratual, permanência (ao contrário da reunião), fim lícito (fim não contrário ao direito). A ausência de fim lucrativo não parece ser elemento da associação, pois parece-nos que o texto abrange também as sociedades lucrativas. Então, a liberdade de associação inclui tanto as *associações em sentido estrito* (em sentido técnico estrito, associações são coligações de fim não lucrativo) e as *sociedades* (coligações de fim lucrativo). O texto também compreende as bases gerais e os fundamentos primeiros dos partidos políticos, que são espécies de associações com disciplina constitucional específica estabelecida no art. 17. Outro tipo é a *associação profissional ou sindical* (art. 8º), que merecerá consideração depois.

Mas agora a Constituição correlaciona as *cooperativas* com as associações (art. 5º, XVIII) e, num dispositivo da ordem econômica, dispõe que *a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo* (art. 174, § 2º). Aqui correlaciona associativismo e cooperativismo entre as instituições da ordem econômica, e até menciona uma cooperativa especial para o exercício da atividade garimpeira (art. 174, §§ 3º e 4º).

A liberdade de associação, de acordo com o dispositivo constitucional em exame, contém quatro direitos: *o de criar associação* (e *cooperativas na forma da lei*), que não depende de autorização; *o de aderir a qualquer associação*, pois ninguém poderá ser obrigado a associar-se; *o de desligar-se da associação*, porque ninguém poderá ser compelido a permanecer associado; e *o de dissolver espontaneamente a associação*, já que não se pode compelir a associação a existir. A cláusula “na forma da lei”, constante do inc. XVIII do art. 5º, só se refere à *criação* das cooperativas, não à *autorização* para essa criação. Quer isso dizer, repita-se, que tanto a criação de associação como de cooperativa independe de autorização. Referiu-se à *forma da lei* em relação à criação de cooperativas, para indicar que elas se regem por normas diversas das civis (ou comerciais) que regulam a criação das associações em geral, e só a elas, pois do contrário, as associações passariam a depender também de nova forma estabelecida na lei prevista no texto, e não mais da legislação existente.

Duas *garantias coletivas* (correlatas ao direito coletivo de associar-se) são estatuídas em favor da liberdade de associar-se: (a) vedada a interferência estatal no funcionamento das associações e das cooperativas, ainda que estas últimas possam ficar sujeitas à fiscalização do Poder Público, conforme dispuser a lei; (b) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. A suspensão das atividades, portanto, pode dar-se pela decisão judicial, mesmo pendente de recurso, o que é mau. Tam-

bém para tal caso dever-se-ia ter exigido o trânsito em julgado, e não apenas para dissolução.

Há duas restrições expressas à liberdade de associar-se: veda-se associação que não seja para fins lícitos ou de caráter paramilitar. E é aí que se encontra a sindicabilidade que autoriza a dissolução por via judicial. *No mais têm as associações o direito de existir, permanecer, desenvolver-se e expandir-se livremente.*

VII. REGIME DAS LIBERDADES

30. Técnica de proteção das liberdades

Esse é um tema que se insere no campo das garantias individuais, pelo que o reataremos mais embaixo, como capítulo do *título das garantias constitucionais* (Título VI).

31. Eficácia das normas constitucionais sobre as liberdades

As normas constitucionais que definem as liberdades consideradas neste capítulo são, via de regra, daquelas que denominamos de *eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata*, porque o legislador constituinte deu normatividade suficiente aos interesses vinculados à matéria de que cogitam. Vale dizer, não dependem de legislação nem de providência do Poder Público para serem aplicadas. Algumas normas podem caracterizar-se como de *eficácia contida*, mas sempre de aplicabilidade direta e imediata, caso em que a previsão de lei não significa que desta dependem sua eficácia e aplicabilidade, visto que tal lei não se destina a integrar-lhes a eficácia (que já têm amplamente), mas visa restringir-lhes a plenitude desta, regulando os direitos subjetivos que delas decorrem para os indivíduos ou grupos. Enquanto o legislador, neste caso, não produzir a normatividade restritiva, sua eficácia será plena.⁷⁷

É necessário estar atento ao que acaba de ser dito, para não supor que exista ou deva existir *norma reguladora do exercício das liberdades*. O exercício das liberdades não depende de normas reguladoras, porque, como foi dito, as normas constitucionais que as reconhecem são de aplicabilidade direta e imediata, sejam de eficácia plena ou de eficácia contida. Portanto, a expressão “falta de norma reguladora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais [...]” do inciso LXXI art. 5º não pode induzir a que as liberdades de-

pendam de normas reguladoras para serem viáveis. O texto será examinado em outro lugar, quanto, então, se mostrará o seu exato sentido.

32. Sistemas de restrições das liberdades individuais

A característica de normas de eficácia contida, apontada acima, tem extrema importância, porque é daí que vêm os *sistemas de restrições das liberdades públicas* consideradas neste capítulo. Vimos já que o legislador ordinário, quando expressamente autorizado pela Constituição, intervém para regular o direito de liberdade conferido. Algumas normas constitucionais, conferidoras de liberdades e garantias individuais, mencionam uma lei limitadora (art. 5º, VI, VII, XIII, XV, XVIII). Outras limitações podem provir da incidência de normas constitucionais (p. ex., art. 5º, XVI: reunir-se *pacificamente, sem armas*; XVII: *fins lícitos* e vedação de *caráter paramilitar*, para as associações, são conceitos limitadores; arts. 136, § 1º, e 139: restrições decorrentes de estado de defesa e estado de sítio).

Tudo isso constitui modos de restrições das liberdades, que, no entanto, esbarram no princípio de que é a liberdade, o direito, que deve prevalecer, não podendo ser extirpado por via da atuação do Poder Legislativo nem do *poder de polícia*. Este é, sem dúvida, um sistema importante de limitação de direitos individuais, mas só tem cabimento na extensão requerida pelo bem-estar social. Fora daí é arbítrio.

77. Sobre o tema, cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, pp. 91 e ss.

Capítulo V

DIREITO DE PROPRIEDADE

I. DIREITO DE PROPRIEDADE EM GERAL: 1. *Fundamento constitucional*. 2. *Conceito e natureza*. 3. *Regime jurídico da propriedade privada*. 4. *Propriedade e propriedades*. 5. *Propriedade pública*. II. PROPRIEDADES ESPECIAIS: 6. *Considerações gerais*. 7. *Propriedade autoral*. 8. *Propriedade de inventos, de marcas e de nome de empresas*. 9. *Propriedade-bem de família*. III. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE: 10. *Conceito e classificação*. 11. *Restrições*. 12. *Servidões e utilização de propriedade alheia*. 13. *Desapropriação*. IV. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE: 14. *Questão de ordem*. 15. *Conceito e natureza*. 16. *Função social e transformação do regime de propriedade*.

I. DIREITO DE PROPRIEDADE EM GERAL

1. Fundamento constitucional

O regime jurídico da propriedade tem seu fundamento na Constituição. Esta garante o direito de propriedade, desde que este atenda sua função social. Se diz: *é garantido o direito de propriedade* (art. 5º, XXII), e *a propriedade atenderá a sua função social* (art. 5º, XIII), não há como escapar ao sentido de que só garante o direito da propriedade que atenda sua função social. A própria Constituição dá consequência a isso quando autoriza a desapropriação, com pagamento mediante título, de propriedade que não cumpra sua função social (arts. 182, § 4º, e 184). Existem outras normas constitucionais que interferem com a propriedade mediante provisões especiais (arts. 5º, XXIV a XXX, 170, II e III, 176, 177 e 178, 182, 183, 184, 185, 186, 191 e 222).

Esse conjunto de normas constitucionais sobre a propriedade denota que ela não pode mais ser considerada como um direito individual nem como instituição do Direito Privado. Por isso, deveria ser prevista apenas como uma instituição da ordem econômica, como instituição de relações econômicas, como nas Constituições da Itália (art. 42) e de Portugal (art. 62). É verdade que o art. 170 inscreve a *propriedade privada* e a *sua função social* como *princípios da ordem econômica* (incs. II e III). Isso tem importância, porque, então, embora prevista entre os direitos individuais, ela não mais poderá ser conside-

rada puro direito individual, relativizando-se seu conceito e significado, especialmente porque os princípios da ordem econômica são preordenados à vista da realização de seu fim: *assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social*. Se é assim, então a propriedade privada, que, ademais, tem que atender a sua função social, fica vinculada à consecução daquele princípio. É claro que, também, não é sem consequência o fato de estar inserida, no seu aspecto geral, entre as normas de previsão dos direitos individuais. É que, previsto como tal, fica assegurada a instituição, não mais, porém, na extensão que o individualismo reconheceu. Com as novas disposições a Constituição dá ainda maior razão a Pontes de Miranda, quando escreve que às leis é que compete regular o *exercício* e definir o *conteúdo* e os *limites* do direito de propriedade, pois que, no art. 5º, XXII, só se *garante* a instituição de propriedade, sendo suscetíveis de mudança por lei seu conteúdo e limites.¹ Ver-se-á, no correr das considerações seguintes, que a Constituição mesma já traça notáveis transformações na velha concepção da propriedade.

2. Conceito e natureza

O *direito de propriedade* fora, com efeito, concebido como uma *relação* entre uma *pessoa* e uma *coisa*, de caráter absoluto, natural e imprescritível. Verificou-se, mais tarde, o absurdo dessa teoria, porque entre uma pessoa e uma coisa não pode haver relação jurídica, que só se opera entre pessoas. Um passo adiante, à vista dessa crítica, passou-se a entender o direito de propriedade como uma relação entre um indivíduo (sujeito ativo) e um *sujeito passivo universal* integrado por todas as pessoas, o qual tem o dever de respeitá-lo, abstraindo-se de violá-lo, e assim o direito de propriedade se revela como *um modo de imputação jurídica de uma coisa a um sujeito*.² Mas aí se manifesta uma visão muito parcial do regime jurídico da propriedade: uma perspectiva civilista, que não alcança a complexidade do tema, que é resultante de um complexo de normas jurídicas de Direito Público e de Direito Privado, e que pode interessar como *relação* jurídica e como *instituição* jurídica.³

1. Cf. *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. V/397. Cf. também Salvatore Pugliatti, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, Giuffrè, 1964, p. 52: "di fatti il vero contenuto del diritto di proprietà è determinato dalle disposizioni particolari di legge". Daí sua definição da propriedade como "diritto di godere e disporre, secondo determinazioni della legge, delle cose che possono formarne oggetto" (p. 51).

2. Cf. Ignacio Burgoa, *Las garantías individuales*, pp. 463 e ss.

3. Cf. Pietro Perlingieri, *Introduzione alla problematica della "proprietà"*, Scuola di perfezionamento di diritto civile dell'Università degli studi di Camerino, p. 135.

Demais, o caráter absoluto do direito de propriedade, na concepção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 (segundo a qual seu exercício não estaria limitado senão na medida em que ficasse assegurado aos demais indivíduos o exercício de seus direitos), foi sendo superado pela evolução, desde a aplicação da teoria do abuso do direito, do sistema de limitações negativas e depois também de imposições positivas, deveres e ônus, até chegar-se à concepção da propriedade como função social, e ainda à concepção da propriedade socialista, hoje em crise.

Essa evolução implicou também a superação da concepção da propriedade como direito natural, pois não se há de confundir a faculdade que tem todo indivíduo de chegar a ser sujeito desse direito, que é potencial, com o direito de propriedade sobre um bem, que só existe enquanto é atribuído positivamente a uma pessoa, e é sempre *direito atual*, cuja característica é a faculdade de usar, gozar e dispor dos bens, fixada em lei.⁴ É o que, aliás, decorre do nosso Direito positivo, ao estatuir que a *lei* assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens (CC, art. 524). É, assim, o Direito positivo, a lei ordinária mesma, que fixa o conteúdo desse direito que é institucionalmente garantido pela Constituição (art. 5º, XXII).⁵

3. Regime jurídico da propriedade privada

Os juristas brasileiros, privatistas e publicistas, concebem o regime jurídico da propriedade privada como subordinado ao Direito Civil, considerado direito real fundamental. Olvidam as regras de Direito Público, especialmente de Direito Constitucional, que igualmente disciplinam a propriedade. Confundem o princípio da função social com as limitações de polícia, como consistente apenas no “conjunto de condições que se impõe ao direito de propriedade a fim de

4. A propósito, Ignacio Burgoa, *ob. cit.*, pp. 465 e 466.

5. Estamos aqui reproduzindo considerações que constam de outro trabalho nosso, de que nos serviremos amplamente nas páginas seguintes. Cf. nosso *Direito urbanístico brasileiro*, pp. 88 e ss.

6. “Não prejudicar interesse social” é exigência que se satisfaz com a simples atuação do *poder de polícia*, que, precisamente, é concebido como mecanismo destinado a condicionar e restringir o *uso e gozo de bens* (assim, também, da propriedade), atividades e direitos individuais contrários, nocivos ou inconvenientes ao bem-estar social. Cf. Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, p. 113; Celso Antônio Bandeira de Mello, *Curso de direito administrativo*, p. 391. Fernando Andrade Oliveira, *Limitações administrativas à propriedade privada imobiliária*, Rio de Janeiro, Forense, 1982, boa monografia sobre as limitações, traz equivocada concepção sobre a função social da propriedade, ao considerá-la “como fator determinante das limitações que lhe são impostas pelo ordenamento jurídico” (p. 162, n.23). Ora, se se intro-

que seu exercício não prejudique o interesse social”, isto é, mero conjunto de condições limitativas.⁶

Essa é uma perspectiva dominada pela atmosfera civilista, que não leva em conta as profundas transformações impostas às relações de propriedade privada, sujeita, hoje, à estreita disciplina de Direito Público, que tem sua sede fundamental nas normas constitucionais. Em verdade, a Constituição assegura o direito de propriedade, mas não só isso, pois, como assinalamos, estabelece também seu regime fundamental, de tal sorte que o Direito Civil não disciplina a propriedade, mas tão-somente as *relações civis* a ela referentes. Assim, só valem no âmbito das relações civis as disposições do Código Civil que estabelecem as faculdades de *usar, gozar e dispor de bens* (art. 524), a *plenitude* da propriedade (art. 525), o caráter *exclusivo e ilimitado* (art. 527) etc., assim mesmo com as delimitações e condicionamentos que das normas constitucionais defluem para a estrutura do direito de propriedade em geral.

A doutrina se tornara de tal modo confusa a respeito do tema, que acabara por admitir que a propriedade privada se configurava sob dois aspectos: (a) como *direito civil subjetivo* e (b) como *direito público subjetivo*. Essa dicotomia fica superada com a concepção de que a função social é elemento da estrutura e do regime jurídico da propriedade; é, pois, princípio ordenador da propriedade privada; incide no conteúdo do direito de propriedade; impõe-lhe novo conceito.⁷ Por isso, a noção de *situação jurídica subjetiva (complexa)* tem sido usada para abranger a visão global do instituto, em lugar daqueles dois conceitos fragmentados.⁸ Nela resguarda-se o conjunto de faculdades do proprietário, dentro da delimitada esfera que a disciplina constitucional lhe traça.

Nessa conformidade é que se pode falar em *direito subjetivo privado* (ou civil) do proprietário particular, como pólo ativo de uma relação jurídica abstrata, em cujo pólo passivo se acham todas as demais pessoas, a que corre o dever de respeitar o exercício das três faculdades básicas: *uso, gozo e disposição* (CC, art. 524).

duziu princípio novo, além do poder de polícia já existente, é porque o constituinte desejou inserir, na estrutura mesma da concepção e do conceito de propriedade, um elemento de transformação positiva que a ponha ao serviço do desenvolvimento social. A atual Constituição, como se verá, no texto, é ainda mais enfática nesse sentido, de tal sorte que a propriedade não se concebe senão como função social.

7. Cf. Pedro Escribano Collado, *La propiedad privada urbana: encuadramiento y régimen*, pp. 122 e ss.; Stefano Rodotà, “Proprietà (Diritto vigente)”, in *Novissimo Digesto Italiano*, v. 15/139; Federico Spantigati, *Manual de derecho urbanístico*, p. 261.

8. Cf. Pietro Perlingieri, *ob. cit.*, p. 70; Rodotà, *ob. cit.*, p. 139; Fiorella D’Angelo, “Ius aedificandi: piani regolatori generali e particolareggiati”, in F. Santoro-Passarelli, *Proprietà privata e funzione sociale*, p. 135.

Vale dizer, enfim, que as normas de Direito Privado sobre a propriedade não que ser compreendidas de conformidade com a disciplina que a Constituição lhe impõe.

4. Propriedade e propriedades

A Constituição consagra a tese, que se desenvolveu especialmente na doutrina italiana, segundo a qual a propriedade não constitui uma instituição única, mas várias instituições diferenciadas, em correlação com os diversos tipos de bens e de titulares, de onde ser cabível falar não em propriedade, mas em *propriedades*.⁹ Agora, ela foi explícita e precisa. Garante o direito de propriedade em geral (art. 5º, XXII; garantia de um conteúdo mínimo essencial), mas distingue claramente a *propriedade urbana* (art. 182, § 2º) e a *propriedade rural* (art. 5º, XXVI, e, especialmente, arts. 184, 185 e 186), com seus regimes jurídicos próprios, sem falar nas regras especiais para outras manifestações da propriedade, que indicamos antes e veremos depois.

Em verdade, uma coisa é a *propriedade pública*, outra a *propriedade social* e outra a *privada*; uma coisa é a propriedade agrícola, outra a industrial; uma, a propriedade rural, outra a urbana; uma, a propriedade de bens de consumo, outra, a de bens de produção; uma, a propriedade de uso pessoal, outra a propriedade/capital.¹⁰ Pois, como alertou Pugliatti, há bastante tempo: “no estado das concepções atuais e da disciplina positiva do instituto, não se pode falar de um só tipo, mas se deve falar de tipos diversos de propriedade, cada um dos quais assume um aspecto característico”.¹¹ Cada qual desses tipos pode estar sujeito, e por regra estará, a uma disciplina particular, especialmente porque, em relação a eles, o princípio da função social atua diversamente, tendo em vista a destinação do bem objeto da propriedade.¹²

Tudo isso, aliás, não é difícil de entender, desde que tenhamos em mente que o regime jurídico da propriedade não é uma função do Direito Civil, mas de um complexo de normas administrativas, urbanísticas, empresariais (comerciais) e civis (certamente), sob fundamento das normas constitucionais.

9. Cf. Spantigati, *ob. cit.*, p. 260; Pietro Perlingieri, *ob. cit.*, pp. 135 e 136. A esse propósito é sugestivo o título de famoso artigo de Salvatore Pugliatti — “La proprietà e le proprietà”, ou seja, “A propriedade e as propriedades”, hoje compilado em seu *La proprietà nel nuovo diritto*, pp. 145 a 309.

10. Cf. Perlingieri, *ob. cit.*, p. 136, sem a extensão do texto.

11. *Ob. cit.*, p. 149.

12. Cf. Spantigati, *ob. cit.*, p. 292.

5. Propriedade pública

É a que tem como titular entidades de Direito Público: União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CC, arts. 65 a 68). Qualquer bem pode ser de propriedade pública, mas há certas categorias que são por natureza destinadas à apropriação pública (vias de circulação, mar territorial, terrenos de marinha, terrenos marginais, praias, rios, lagos, águas de modo geral etc.), porque são bens predispostos a atender o interesse público, não cabendo sua apropriação privada. Dessa natureza são também as *terras tradicionalmente ocupadas pelos índios*, que, por isso mesmo, são terras públicas de propriedade da União, constitucionalmente vinculadas aos direitos originários dos índios sobre elas, para sua habitação permanente, e à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e às necessidades de sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (arts. 20, XI, e 231).

A Constituição reconhece a *propriedade pública*: (a) ao incluir entre os bens da União aqueles enumerados no art. 20 e entre os dos Estados os indicados no art. 26; (b) ao autorizar *desapropriação*, que consiste na transferência compulsória de bens privados para o domínio público, e (c) ao facultar a exploração direta de atividade econômica pelo Estado (art. 173) e o monopólio (art. 177), que importam apropriação pública de bens de produção.

II. PROPRIEDADES ESPECIAIS

6. Considerações gerais

Além das disposições do art. 5º, XXII, que garantem a propriedade como instituição, existem outras que asseguram tipos especiais de propriedade, como a *propriedade de recursos minerais* (art. 176), a *propriedade urbana* e a *propriedade rural* (arts. 182, § 2º, e 184), a *propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens* (art. 222), das quais trataremos quando formos estudar a ordem econômica e os temas da comunicação social (p. 807), onde são previstas.

Consideraremos aqui apenas as propriedades especiais referidas entre os incisos do art. 5º: a *propriedade autoral*, a *propriedade de inventos e de marcas e patentes* e a *propriedade-bem de família*.

7. Propriedade autoral

O art. 5º, XXVII, que assegura o direito autoral, contém duas normas bem distintas. A primeira e principal confere aos autores o direito

exclusivo de utilizar, publicar e reproduzir suas obras, sem especificar, como faziam as constituições anteriores, mas, compreendido em conexão com o disposto no inc. IX do mesmo artigo, conclui-se que são *obras literárias, artísticas, científicas e de comunicação*. Enfim, aí se asseguram os *direitos do autor* de obra intelectual e cultural, reconhecendo-lhe, vitaliciamente, o chamado *direito de propriedade intelectual*, que compreende *direitos morais e patrimoniais*. A segunda norma declara que esse *direito é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar*.

A lei que protege os direitos autorais, Lei 9.610, de 19.2.1998, declara, no art. 7º, que são obras protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. O dispositivo apresenta em sequência, extensa enumeração exemplificativa. Inclui ela também a proteção do que chama de direitos conexos, ou seja, direitos de intérpretes, executantes, produtores fonográficos, cujos pormenores não cabem aqui.

O autor é titular de direitos morais e de direitos patrimoniais sobre a obra intelectual (ou seja: obras literárias, artísticas, científicas, musicais, dramáticas, dramático-musicais etc.) que produzir. São *direitos morais do autor*: (a) o de reivindicar, a qualquer tempo, a paternidade da obra; (b) o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; (c) o de conservá-la inédita; (d) o de assegurar-lhe a *integridade*, opondo-se a quaisquer modificações, ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la, ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; (e) o de modificá-la, antes ou depois de utilizada; (f) o de retirá-la de circulação, ou de lhe suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; (g) o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causa. Esses *direitos morais do autor* são inalienáveis e irrenunciáveis, mas, por morte do autor, transmitem a seus herdeiros os direitos a que se referem as letras "a" a "d" supra.

Os *direitos patrimoniais do autor* compreendem as faculdades de utilizar, fruir e dispor de sua obra, bem como de autorizar sua utilização ou fruição por terceiros no todo ou em parte. Esses direitos são alienáveis por ele ou por seus sucessores.

O *direito hereditário da propriedade intelectual* cabe aos herdeiros descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais, de acordo com a or-

dem de vocação hereditária estabelecida na lei civil, mas também se defere aos herdeiros testamentários. A herança dos direitos de autor vige pelo tempo que a lei fixar. Pode ser temporária ou vitalícia, conforme dispuser a lei. Vigora, como vimos, a Lei 9.610/98, que regula os direitos autorais. Dispõe que os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento obedecida a ordem sucessória da lei (Código Civil, art. 1.603), incluindo Estados, Distrito Federal ou União, na falta de herdeiro legítimo ou testamentário, o que não era consignado na lei anterior (Lei 5.988, de 14.12.73, ora revogada).

Se o autor morrer, *ab intestato* e sem deixar herdeiros, a obra cai no domínio público (Lei 9.610/98, art. 45), se ele não tiver alienado seus direitos para além da morte, o que só vale por tempo não superior a 70 anos. A lei das desapropriações (Decreto-lei 3.365/41) considera caso de utilidade pública, para desapropriação, a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária (art. 5º, p). Temos para nós que a desapropriação não pode ocorrer enquanto o autor da obra estiver vivo, já que conservá-la inédita ou fora de circulação se inclui entre seus direitos morais personalíssimos e inalienáveis.

A Constituição trouxe novidade conexa com o tema que nos ocupa aqui, ao envolver nele *obras de comunicação*, como as produções radiofônicas e televisivas. A norma do art. 5º, XXVII, se liga a isso, mas não só a isso, porque também as obras literárias e outras, ao assegurar, nos termos da lei: (a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; (b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem, aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Por certo que aí se tenta proteger, por exemplo, o direito dos participantes em obras como telenovelas e semelhantes que, vendidas para reapresentações até no exterior, reproduzem imagem e voz sem remuneração ulterior. Tenta-se evitar que a produtora se enriqueça com reproduções sucessivas, pagando uma só vez.

8. Propriedade de inventos, de marcas e de nome de empresas

O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica. Seu enunciado e conteúdo bem o denotam, quando a eficácia da norma fica dependendo de legislação

ulterior: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (art. 5º, XXIX). Vale dizer que o direito aí reconhecido decorrerá da *lei*, a que o constituinte remeteu a sua garantia. A lei, hoje, é a de n. 9.279, de 14.5.1996, que substituiu o Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772, de 21.12.71).

Trata-se de propriedade de bens incorpóreos: privilégio de invenção industrial, que assegura ao inventor (criador de objeto capaz de propiciar novos resultados industriais) o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade do invento (ou de modelo de utilidade, objeto prático suscetível da aplicação industrial, com nova forma ou disposição, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação) e o direito exclusivo de utilização do objeto da patente e o conseqüente direito de impedir que terceiro o faça; a proteção, pelo registro, à propriedade de desenhos industriais, das marcas e seu uso exclusivo; à propriedade das marcas de serviços; à exclusividade dos nomes de empresas e de outros signos distintivos.

O privilégio do inventor é, contudo, temporário. A lei marca-lhe o prazo máximo de 20 anos e mínimo de 10 anos para a patente de invenção, e máximo de 15 anos e mínimo de 7 anos para o modelo de utilidade, depois do que o objeto patenteado cai no domínio público. Está submetido ao princípio da função social. Uma vez patenteado, o invento terá que ser posto em funcionamento pelo próprio inventor ou por terceiro, mediante concessão (obrigatória após três anos, de acordo com a lei) da licença para sua exploração. Como a propriedade do privilégio é transferível, quem a adquire fica sub-rogado nos direitos e nas obrigações, evidentemente, inclusive na de exploração da patente de modo efetivo no País, dentro de três anos que se seguirem à sua expedição. A propriedade de marcas, de nomes de empresas e distintivos também, pela Constituição, fica submetida ao interesse social.

9. Propriedade-bem de família

O Código Civil (art. 70), como se sabe, permitiu aos chefes de família destinar um prédio para domicílio desta, com a cláusula de ficar isento de execução por dívidas. É a instituição de uma propriedade como *bem de família*, precisamente porque preestabelecido no interesse desta.

Essa é a natureza que se pode reconhecer ao instituto constante do art. 5º, XXVI, decorrente de proposta e intransigente defesa do Senador Nelson Carneiro, segundo o qual *a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento*. Aí também o interesse é o de proteger um patrimônio necessário à manutenção e sobrevivência da família.

III. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE

10. Conceito e classificação

Limitações ao direito de propriedade consistem nos condicionamentos que atingem os caracteres tradicionais desse direito, pelo que era tido como direito *absoluto, exclusivo e perpétuo*. *Absoluto*, porque assegura ao proprietário a liberdade de dispor da coisa do modo que melhor lhe aprouver; *exclusivo*, porque imputado ao proprietário, e só a ele, em princípio, cabe; *perpétuo*, porque não desaparece com a vida do proprietário, porquanto passa a seus sucessores, significando que tem duração ilimitada (CC, art. 527), e não se perde pelo não uso simplesmente.

Importa ter em mente esses caracteres, porque as limitações são classificadas em função deles. *Limitações* constituem gênero: tudo que afete qualquer dos caracteres do direito de propriedade, o que pode verificar-se com fundamento no Direito Privado ou no Direito Público. Daí a primeira classificação em *limitações de Direito Privado* (como as de direito de vizinhança) e *limitações de Direito Público* (como as urbanísticas e as administrativas). Importante, contudo, é observar as espécies de limitações, que são: *restrições, servidões e desapropriação*.

As *restrições* limitam o caráter *absoluto* da propriedade; as *servidões* (e outras formas de utilização da propriedade alheia) limitam o caráter *exclusivo*; e a *desapropriação*, o caráter *perpétuo*.¹³

11. Restrições

Como acabamos de dizer, as restrições limitam, em qualquer de suas faculdades, o caráter *absoluto* da propriedade, de que decorrem: (1) a *faculdade* (ou *direito*) de *fruição*, pelo qual o proprietário pode tirar dela todas as vantagens que ela possa dar, e abrange: (a) o *uso da*

13. Nesse sentido, Fernando Andrade Oliveira, *ob. cit.*, p. 138.

coisa, como melhor lhe aprouver; (b) a *ocupação da coisa*, em toda a sua extensão, profundidade e altura (CC, art. 526); (2) a *faculdade* (ou *direito*) de *modificação* (ou transformação), consistente na possibilidade de modificar ou alterar, no todo ou em parte, a coisa própria, inclusive destruir sua substância; (3) a *faculdade* (ou *direito*) de *alienação*, consistente em o proprietário poder alienar a sua propriedade, por qualquer dos meios por que pode ser adquirida.

Restrições à propriedade são, pois, condicionamentos a essas faculdades do seu caráter absoluto. Porque existem essas restrições é que se costuma dizer que não existe mais o direito absoluto da propriedade. Existem *restrições à faculdade de fruição*, que condicionam o uso e a ocupação da coisa; *restrições à faculdade de modificação da coisa*; *restrições à alienabilidade da coisa*, quando, por exemplo, se estabelece direito de preferência em favor de alguma pessoa.

12. Servidões e utilização de propriedade alheia

As *servidões* e a *utilização de propriedade alheia* são formas de limitação que lhe atinge o caráter *exclusivo* de modo singular e não em geral. Constituem ônus impostos à coisa. As servidões vinculam duas coisas: uma serviente (imóvel que sofre ônus) e outra dominante (bem em favor do qual se dá o ônus). A utilização de propriedade alheia pode ser pelo Poder Público ou por particular. No primeiro caso, tem-se, não tanto um ônus real, mas uma ocupação ou um uso temporário pelo Poder Público em caso de perigo iminente. É o que decorre do art. 5º, XXV: *no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano*. O direito anterior não ligava a indenização ao dano, de que se poderia extrair a idéia de que a mera ocupação era indenizável. Agora, está claro: *indenização, se houver dano*. A utilização particular, representada pelas várias modalidades de direitos reais sobre coisa alheia, é matéria de Direito Privado que não comporta exame aqui.

Existem *servidões públicas* que são instituídas em favor de um serviço ou obra pública nos termos da lei das desapropriações. O *direito de superfície*, hoje não regulado como tal, é outra forma de limitação do caráter exclusivo da propriedade, que pode ser de Direito Público também. Mas só agora se cogita de sua instituição entre nós especialmente no interesse de atuação *urbanística*, salvo a *concessão real de uso de terrenos públicos ou particulares* (Decreto-lei 271/67, art. 7º), que a ele se assemelha.

As servidões são indenizáveis, em princípio.

Outra forma são as *requisições do Poder Público* que incidam sobre bens de propriedade privada. Mas elas confinam com a desapropriação, porque, no mais das vezes, importam no apoderamento definitivo da propriedade particular. A Constituição permite as *requisições civis e militares*, mas tão-só *em caso de iminente perigo e em tempo de guerra* (art. 22, III). São também indenizáveis.

13. Desapropriação

É limitação que afeta o *caráter perpétuo* da propriedade, porque é meio pelo qual o Poder Público determina a transferência compulsória da propriedade particular, especialmente para o seu patrimônio ou de seus delegados, o que só pode verificar-se *por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição* (art. 5º, XXIV), que são as desapropriações-sanção por não estar a propriedade urbana ou rural cumprindo sua função social, quando, então, a indenização se fará mediante título da dívida pública ou da dívida agrária (arts. 182 e 184).

IV. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

14. Questão de ordem

A *propriedade atenderá a sua função social*, diz o art. 5º, XXIII, para a propriedade em geral. Essa disposição bastava para que toda forma de propriedade fosse intrinsecamente permeada daquele princípio constitucional, mas a Constituição não se limitou a isso. Reafirmou a instituição da *propriedade privada* e a *sua função social* como princípios da ordem econômica (art. 170, II e III), relativizando, assim, seu significado, como vimos. Além disso, inscreveu o *princípio da função social da propriedade*, com conteúdo definido em relação às propriedades urbana e rural, com sanções para o caso de não ser observado (arts. 182, 184 e 186). Trataremos dele aqui nos seus fundamentos, mas a ele teremos que voltar, porque ele ultrapassa o simples sentido de elemento conformador de uma nova concepção da propriedade como manifestação de direito individual, que ela, pelo visto, já não o é apenas, porque interfere com a chamada propriedade empresarial.

15. Conceito e natureza

A *função social da propriedade* não se confunde com os sistemas de limitação da propriedade. Estes dizem respeito ao exercício do direi-

to ao proprietário; aquela, à estrutura do direito mesmo, à propriedade.¹⁴

A funcionalização da propriedade é um processo longo. Por isso é que se diz que ela sempre teve uma função social. Quem mostrou isso expressamente foi Karl Renner, segundo o qual a função social da propriedade se modifica com as mudanças na relação de produção.¹⁵ E toda vez que isso ocorreu, houve transformação na estrutura interna do conceito de propriedade, surgindo nova concepção sobre ela, de tal sorte que, ao estabelecer expressamente que a *propriedade atenderá a sua função social*, mas especialmente quando o reputou princípio da ordem econômica, ou seja, como um princípio informador da *constituição econômica brasileira com o fim de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social* (art. 170, II e III), a Constituição não estava simplesmente preordenando fundamentos às limitações, obrigações e ônus relativamente à propriedade privada, *princípio também da ordem econômica* e, portanto, sujeita, só por si, ao cumprimento daquele fim. Limitações, obrigações e ônus são externos ao direito de propriedade, vinculando simplesmente a atividade do proprietário, interferindo tão-só com o exercício do direito, e se explicam pela simples atuação do poder de polícia.

A norma que contém o princípio da função social da propriedade incide imediatamente, é de aplicabilidade imediata, como o são todos os princípios constitucionais. A própria jurisprudência já o reconhece.¹⁶ Realmente, afirma-se a tese de que aquela norma “tem plena eficácia, porque interfere com a estrutura e o conceito da propriedade, valendo como regra que fundamenta um novo regime jurídico desta, transformando-a numa instituição de Direito Público, especialmente, ainda que nem a doutrina nem a jurisprudência te-

14. Cf. Karl Renner, *Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale*, pp. 65 e 66, trad. de Cornelia Mittendorfer; cf. também Angel Sustaeta Elutizia, *Propiedad y urbanismo*, pp. 290 e ss.; Francesco Santoro-Passarelli et al., *Proprietà privata e funzione sociale*, Padova, CEDAM, 1976; Pietro Perlingieri, *ob. cit.*, pp. 77 e ss.; M. S. Giannini, *Diritto pubblico dell'economia*, p. 105, mostra os graus de intervenção na propriedade, fora a desapropriação, que são: “1) le limitazioni amministrative al diritto di proprietà; 2) le imposizioni coattive di diritti reali parziali; 3) la conformazione procedimentale del bene; 4) la funzionalizzazione del diritto di proprietà. Come ora diremo, i primi due riguardano specificamente il bene, i secondi due precipuamente il diritto, o meglio le situazioni soggettive”.

15. Cf., *ob. cit.*, pp. 84 e ss.

16. Cf. acórdão, por maioria, proferido pela 3ª Câmara do 1º TAC-SP, na Apelação 291.722, relator Juiz José Osório, sob a Constituição anterior, muito menos enfática no estabelecer o princípio do que a atual, o que não deixa margem a dúvida sobre sua caracterização e operatividade imediata.

nham percebido o seu alcance, nem lhe dado aplicação adequada, como se nada tivesse mudado”.¹⁷

16. Função social e transformação do regime de propriedade

O princípio vai além do ensinamento da Igreja, segundo o qual “sobre toda propriedade particular pesa uma hipoteca social”, mas tendente a uma simples vinculação obrigacional.¹⁸ Ele transforma a propriedade capitalista, sem socializá-la. Condiciona-a como um todo, não apenas seu exercício, possibilitando ao legislador entender com os modos de aquisição em geral ou com certos tipos de propriedade, com seu uso, gozo e disposição. Constitui, como já se disse, o fundamento do regime jurídico da propriedade, não de limitações, obrigações e ônus que podem apoiar-se — e sempre se apoiaram — em outros títulos de intervenção, como a ordem pública ou a atividade de polícia.¹⁹ A função social, assinala Pedro Escribano Collado, “introduziu, na esfera interna do direito de propriedade, um *interesse* que pode não coincidir com o do proprietário e que, em todo caso, é estranho ao mesmo”, constitui um princípio ordenador da propriedade privada e fundamento da atribuição desse direito, de seu reconhecimento e da sua garantia mesma, incidindo sobre seu próprio conteúdo.²⁰

Com essa concepção é que o intérprete tem que compreender as normas constitucionais, que fundamentam o regime jurídico da propriedade: sua garantia enquanto atende sua função social, “implicando uma transformação destinada a incidir, seja sobre o fundamento mesmo da atribuição dos poderes ao proprietário, seja, mais concretamente, sobre o modo em que o conteúdo do direito vem positivamente determinado; assim é que a função social mesma acaba por posicionar-se como elemento qualificante da situação jurídica

17. Cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, 2ª ed., p. 134.

18. Cf. CNBB, *Solo urbano e ação pastoral*, p. 28, n. 84. É verdade que a evolução da concepção da propriedade nas encíclicas papais, de João XXIII para diante especialmente, autoriza a supor que o conceito de propriedade como *hipoteca social* tem alcance bem mais amplo do que simples limitações, admitindo-se mesmo a socialização. Cf. João Paulo II, *Sobre o trabalho humano* — “*Laborem exercens*”, n. 14. Sobre a temática delineada no texto, lê-se, com proveito, especialmente o cap. I, Antônio Iannelli, *La proprietà costituzionale*, Scuola de perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino, 1980; o cap. II dessa obra é dedicado à função social da propriedade, mas a matéria não ficou bem clara e chega-se ao fim com certa frustração. Dá a impressão de que o autor está procurando resolver um problema que ele próprio não quer resolver.

19. Cf. Pedro Escribano Collado, *ob. cit.*, p. 122; nosso *Direito urbanístico brasileiro*, p. 95.

20. Cf. *ob. cit.*, pp. 118, 122 e 123.

considerada, manifestando-se, conforme as hipóteses, seja como condição de exercício de faculdades atribuídas, seja como obrigação de exercitar determinadas faculdades de acordo com modalidades preestabelecidas".²¹ Enfim, a função social se manifesta na própria configuração estrutural do direito de propriedade, pondo-se concretamente como elemento qualificante na predeterminação dos modos de aquisição, gozo e utilização dos bens.²²

Mas é certo que o princípio da função social não autoriza a suprimir, por via legislativa, a instituição da propriedade privada. Contudo, parece-nos que pode fundamentar até mesmo a socialização de algum tipo de propriedade, onde precisamente isso se torne necessário à realização do princípio, que se põe acima do interesse individual. Por isso é que se conclui que o direito de propriedade (dos meios de produção especialmente) não pode mais ser tido como um direito individual. A inserção do princípio da função social, sem impedir a existência da instituição, modifica sua natureza, pelo que, como já dissemos, deveria ser prevista apenas como instituição do direito econômico.

21. Cf. Fiorella D'Angelo, *ob. cit.*, p. 135; nosso *Direito urbanístico brasileiro*, cit., p. 96.

22. Fiorella D'Angelo, *ob. cit.*, p. 156.

Título III

Direitos Sociais

Capítulo I

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS SOCIAIS

1. *Ordem social e direitos sociais.* 2. *Direitos sociais e direitos econômicos.* 3. *Conceito de direitos sociais.* 4. *Classificação dos direitos sociais.*

1. Ordem social e direitos sociais

A ordem social, como a ordem econômica, adquiriu dimensão jurídica a partir do momento em que as constituições passaram a discipliná-la sistematicamente, o que teve início com a Constituição mexicana de 1917. No Brasil, a primeira Constituição a inscrever um título sobre a ordem econômica e social foi a de 1934, sob a influência da Constituição alemã de Weimar, o que continuou nas constituições posteriores.

Os *direitos sociais*, nessas constituições, saíam do capítulo da ordem social, que sempre estivera misturada com a ordem econômica. A Constituição de 1988 traz um capítulo próprio dos *direitos sociais* (capítulo II do título II) e, bem distanciado deste, um título especial sobre a *ordem social* (título VIII). Mas não ocorre uma separação radical, como se os direitos sociais não fossem algo ínsito na ordem social. O art. 6º mostra muito bem que aqueles são conteúdo desta, quando diz que são *direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição*. Esta forma é dada precisamente no título da ordem social. Cindindo-se a matéria, como se fez, o constituinte não atendeu aos melhores critérios metodológicos, mas dá ao jurista a possibilidade de extrair, daqui e de lá, aquilo que constitui o conteúdo dos direitos relativos a cada um daqueles objetos sociais, deles tratando aqui, deixando para tratar, na *ordem social*, de seus mecanismos e aspectos organizacionais.

2. Direitos sociais e direitos econômicos

Não é fácil estremar, com nitidez, os direitos sociais dos direitos econômicos. Basta ver que alguns colocam os direitos dos trabalhadores entre os direitos econômicos,¹ e não há nisso motivo de censura, porque, em verdade, o trabalho é um componente das relações de produção e, nesse sentido, tem dimensão econômica indiscutível. A Constituição tomou partido a esse propósito, ao incluir o direito dos trabalhadores como espécie dos direitos sociais, e o trabalho como primado básico da ordem social (arts. 7º e 193). É posição correta.

O direito econômico tem uma dimensão institucional, enquanto os direitos sociais constituem formas de tutela pessoal. O direito econômico é o direito da realização de determinada política econômica,² ou, segundo Geraldo Vidigal "é a disciplina jurídica de atividades desenvolvidas nos mercados, visando a organizá-los sob a inspiração dominante do interesse social".³ Os direitos sociais disciplinam situações subjetivas pessoais ou grupais de caráter concreto. Em certo sentido, pode-se admitir que os direitos econômicos constituirão pressupostos da existência dos direitos sociais, pois, sem uma política econômica orientada para a intervenção e participação estatal na economia, não se comporão as premissas necessárias ao surgimento de um regime democrático de conteúdo tutelar dos fracos e mais numerosos.⁴

3. Conceito de direitos sociais

Assim, podemos dizer que os *direitos sociais*, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igual-

dade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade.

4. Classificação dos direitos sociais

Vamos discutir os direitos sociais à vista do Direito positivo. Por isso, sem preocupação com uma classificação rígida, e com base nos arts. 6º a 11, agrupá-los-emos nas seis classes seguintes: (a) *direitos sociais relativos ao trabalhador*; (b) *direitos sociais relativos à seguridade*, compreendendo os direitos à saúde, à previdência e assistência social; (c) *direitos sociais relativos à educação e à cultura*; (d) *direitos sociais relativos à moradia*; (e) *direitos sociais relativos à família, criança, adolescente e idoso*; (f) *direitos sociais relativos ao meio ambiente*.⁵

Há, porém, uma classificação dos direitos sociais do homem *como produtor e como consumidor*, que merece uma referência ligeira, por ser útil à compreensão do leitor e, também, porque vamos intitular o capítulo referente aos direitos sociais previstos no art. 6º com base nela.

Entram na categoria de *direitos sociais do homem produtor* os seguintes: a liberdade de instituição sindical (instrumento de ação coletiva), o direito de greve, o direito de o trabalhador determinar as condições de seu trabalho (contrato coletivo de trabalho), o direito de cooperar na gestão da empresa (co-gestão ou autogestão) e o direito de obter um emprego.⁶ São os previstos nos arts. 7º a 11.

Na categoria dos *direitos sociais do homem consumidor* entram: os direitos à saúde, à segurança social (segurança material), ao desenvolvimento intelectual, o igual acesso das crianças e adultos à instrução, à formação profissional e à cultura e garantia ao desenvolvimento da família,⁷ que são, como se nota, os indicados no art. 6º e desenvolvidos no título da ordem social.

1. Cf. M. L. Duchatelet, "Les perspectives d'une protection efficace des droits économiques et sociaux en Belgique", in Centre d'Études Européennes (org.), *Vers une protection efficace des droits économiques et sociaux?*, p. 119.

2. Cf. Washington Peluso Albino de Souza, *Direito econômico*, p. 3; Eros Grau, *Elementos de direito econômico*, p. 23.

3. Cf. *Teoria geral do direito econômico*, p. 213.

4. Cf. José Alfredo de Oliveira Baracho, *Participação nos lucros e integração social — PIS*, p. 22: "A incidência tutelar do Estado nos processos democráticos fez com que Ripert observasse o caráter abrangente da proteção aos fracos e mais numerosos, nos seguintes termos: 'La démocratie moderne assure la protection des faibles avec d'autant plus de complaisance que les faibles sont en fait les plus nombreux' (Georges Ripert, *Le régime démocratique et le droit civil moderne*, p. 121)".

5. Para uma classificação mais elaborada dos direitos sociais, cf. Cármen Lúcia Antunes Rocha, *Princípios constitucionais dos servidores públicos*, p. 48.

6. Cf. Pierre Duclos, *L'évolution des rapports politiques depuis 1750*, pp. 155 e 156.

7. Idem, pp. 154 e 155.

Capítulo II

DIREITOS SOCIAIS RELATIVOS AOS TRABALHADORES

I. QUESTÃO DE ORDEM: 1. *Espécies de direitos relativos aos trabalhadores.* II. DIREITOS DOS TRABALHADORES: 2. *Destinatários.* 3. *Direitos reconhecidos.* 4. *Direito ao trabalho e garantia do emprego.* 5. *Direitos sobre as condições de trabalho.* 6. *Direitos relativos ao salário.* 7. *Direitos relativos ao repouso e à inatividade do trabalhador.* 8. *Proteção dos trabalhadores.* 9. *Direitos relativos aos dependentes do trabalhador.* 10. *Participação nos lucros e co-gestão.* III. DIREITOS COLETIVOS DOS TRABALHADORES: 11. *Caracterização.* 12. *Liberdade de associação ou sindical:* 12.1 *Associação e sindicato;* 12.2 *Liberdade e autonomia sindical;* 12.3 *Participação nas negociações coletivas de trabalho;* 12.4 *Contribuição sindical;* 12.5 *Pluralidade e unicidade sindical.* 13. *Direito de greve.* 14. *Direito de substituição processual.* 15. *Direito de participação laboral.* 16. *Direito de representação na empresa.*

I. QUESTÃO DE ORDEM

1. *Espécies de direitos relativos aos trabalhadores*

Os direitos relativos aos trabalhadores são de duas ordens fundamentalmente: (a) *direitos dos trabalhadores em suas relações individuais de trabalho*, que são os direitos dos trabalhadores do art. 7º; e (b) *direitos coletivos dos trabalhadores* (arts. 9º a 11), que são aqueles que os trabalhadores exercem coletivamente ou no interesse de uma coletividade deles, e são os direitos de associação profissional ou sindical, o direito de greve, o direito de substituição processual, o direito de participação e o direito de representação classista.

II. DIREITOS DOS TRABALHADORES

2. *Destinatários*

O art. 7º relaciona os direitos dos trabalhadores *urbanos e rurais*, mas seu parágrafo único assegura à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos indicados nos incisos: IV — *salário mínimo*; VI — *irredutibilidade de salário*; VIII — *décimo-terceiro salário*; XV — *repouso semanal remunerado*; XVII — *férias anuais remuneradas*; XVIII — *licen-*

ça-gestante; XIX — *licença-paternidade*; XXI — *aviso prévio*; e XXIV — *aposentadoria e integração à previdência social*.

A questão de distinguir sobre o que são trabalhadores urbanos e rurais perde boa parte da importância que tinha antes, porque agora todos gozam dos mesmos direitos, inclusive quanto ao prazo prescricional relativo aos créditos resultantes da relação de trabalho, que é de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato (EC-28/2000). Importará mais estreimar os trabalhadores domésticos dos outros, porque seus direitos são mais limitados. Essas diferenças, contudo, já foram devidamente fixadas em face do direito anterior, que estabelecia regimes jurídicos inteiramente diversos para as três categorias, as quais ficam subordinadas à natureza da atividade do empregador. Se se trata de uma exploração agropastoril, o trabalhador, nela empregado, é rural; se a atividade é industrial, comercial ou de prestação de serviços não relacionados à exploração agropastoril, considera-se a pessoa nela empregada como trabalhador urbano; já *trabalhador doméstico* é aquele que presta serviços de auxiliares da administração residencial de natureza não lucrativa.

3. *Direitos reconhecidos*

São direitos dos trabalhadores os enumerados nos incisos do art. 7º, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Temos, assim, direitos expressamente enumerados e direitos simplesmente previstos. Dos enumerados, uns são imediatamente aplicáveis, outros dependem de lei para sua efetivação prática, questões estas que examinaremos caso a caso.

As normas que os definem, com eficácia imediata ou não, importam em obrigações estatais no sentido de proporcionar aos trabalhadores os direitos assegurados e programados. Toda atuação em outro sentido infringe-as.

4. *Direito ao trabalho e garantia do emprego*

O art. 6º define o *trabalho* como direito social, mas nem ele nem o art. 7º trazem norma expressa conferindo o *direito ao trabalho*. Este, porém, ressaí do conjunto de normas da Constituição sobre o trabalho. Assim, no art. 1º, IV, se declara que a República Federativa do Brasil tem como fundamento, entre outros, os *valores sociais do trabalho*; o art. 170 estatui que a ordem econômica funda-se na *valorização do trabalho*, e o art. 193 dispõe que a ordem social tem como base o *primado do trabalho*. Tudo isso tem o sentido de reconhecer o *direito*

social ao trabalho, como condição da efetividade da existência digna (fim da ordem econômica) e, pois, da dignidade da pessoa humana, fundamento, também, da República Federativa do Brasil (art. 1º, III). E aqui se entroncam o *direito individual* ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, com o *direito social ao trabalho*, que envolve o direito de acesso a uma profissão, à orientação e formação profissionais, à livre escolha do trabalho, assim como o direito à relação de emprego (art. 7º, I) e o seguro-desemprego, que visam, todos, entre outros, à melhoria das condições sociais dos trabalhadores.

A *garantia do emprego* significa o direito de o trabalhador conservar sua relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa. A Constituição não conferiu uma garantia absoluta do emprego. Os debates na Constituinte, neste tema, foram os mais acirrados, variando de uma postura de livre desfazimento unilateral do contrato de trabalho até uma vedação quase absoluta ao desfazimento. Prevaleceu uma fórmula que não é de todo satisfatória, conforme disposto no art. 7º, I, pela qual se assegura a *relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos*. Protege-se a relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. O que é que fica dependendo da lei complementar: a definição da proteção à relação de emprego ou a definição do que seja despedida arbitrária ou sem justa causa? Temos para nós que a garantia do emprego é um direito, por si bastante, nos termos da Constituição, ou seja, a norma do art. 7º, I, é por si só suficiente para gerar o direito nela previsto. Em termos técnicos, é de aplicabilidade imediata, de sorte que a lei complementar apenas virá determinar os limites dessa aplicabilidade, com a definição dos elementos (despedida arbitrária e justa causa) que delimitam sua eficácia, inclusive pela possível conversão em indenização compensatória da garantia de permanência no emprego. Indenização não é garantia da relação de emprego. Como se vê do texto, é uma medida compensatória da perda do emprego. Se a Constituição garante a relação de emprego, o princípio é o da sua conservação e não o da sua substituição. Compreendido o texto especialmente em conjugação com o § 1º do art. 5º, aplicável aos direitos do art. 7º, que se enquadram, também, entre os direitos e garantias fundamentais, chegaremos à conclusão de que a norma do citado inciso I é de eficácia contida.¹ É certo que, transitoriamente, a proteção ficou reduzida ao disposto no art. 10, I, das Disposições Constitucionais Transitó-

1. Sobre o conceito de normas de eficácia contida, cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, pp. 91 e ss.

rias, segundo o qual, até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, "fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6º, *caput* e § 1º, da Lei n. 5.107, de 13 de setembro de 1966". A porcentagem, que era de 10%, passou para 40%. Isso teve o efeito de identificar a proteção do emprego, ali previsto, em estabilidade absoluta. Pois, bem lembra Amauri Mascaro Nascimento:

"Proteger a relação de emprego é, em princípio, impedir que se extinga, que possa ser desfeita sem atender aos direitos do trabalhador.

"Assim, não é possível afastar a interpretação segundo a qual a proteção da relação de emprego consiste na adoção de medidas ordenatórias da dispensa imotivada do trabalhador, sendo uma forma de restrição ao direito potestativo de despedir. Coincidiria, de certo modo, com a idéia de estabilidade absoluta e seria mesmo identificável com ela, caso não tivesse a Constituição indicado a possibilidade de indenização de dispensa."²

Mas a lei complementar poderá reconhecer estabilidade após certo tempo de emprego e indenização compensatória. Mas pode também não conferir estabilidade, resolvendo-se a controvérsia sempre por via de indenização, progressiva ou não. Além disso, pode estabelecer outros direitos, que já não sejam previstos na própria Constituição. Há que ser direito novo. Por exemplo, poderá vedar despedidas coletivas, obrigar que o trabalhador admitido em lugar de outro despedido tenha o mesmo salário. Terá que definir o que seja despedida arbitrária e despedida sem justa causa, o que não é difícil, pois as leis trabalhistas em vigor já o fazem, e valem até que sejam modificadas, no particular, pela referida lei complementar. É que, na espécie, funciona o princípio da recepção, como complementar, da lei existente sobre assunto.

Relacionada à garantia de emprego é a *garantia de tempo de serviço*, prevista agora (art. 7º, III), não como alternativa à estabilidade, mas como um direito autônomo. Seus objetivos e natureza não podem ser mais os de *proteger o empregado despedido dos malefícios do desemprego, facilitando ao empregador a possibilidade de despedi-lo*, como a doutrina dizia antes.³ Primeiro, porque não é sucedâneo da garantia de relação de emprego do inciso I, nem objetiva facilitar a despedida; segundo, porque o que protegerá o empregado em caso de de-

2. Cf. *Direito do Trabalho na Constituição de 1988*, p. 47. Estamos revendo aí nosso entendimento anterior.

3. Cf. Aluísio Sampaio, *Fundo de garantia de tempo de serviço e estabilidade com indenização*, p. 27.

semprego voluntário é o *seguro-desemprego* previsto no art. 7º, II. O fundo de garantia passará a ser, dependendo de sua regulamentação, uma espécie de patrimônio individual do trabalhador, que servirá para suprir despesas extraordinárias para as quais o simples salário não se revele suficiente, como, por exemplo, aquisição de casa própria, despesas com doenças graves, casamento etc.

Ao lado disso, fica o *seguro-desemprego* para sua proteção no caso de desemprego involuntário, que será financiado pelo Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PIS/PASEP (art. 239).

Ainda correlacionado ao tema da garantia de emprego é o *aviso prévio* proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei (art. 7º, XXI);⁴ ele objetiva possibilitar ao trabalhador condições de obtenção de outro emprego antes do desligamento definitivo da empresa.

5. Direitos sobre as condições de trabalho

As condições dignas de trabalho constituem objetivos dos direitos dos trabalhadores. Por meio delas é que eles alcançam a melhoria de sua condição social (art. 7º, *caput*), configurando, tudo, o conteúdo das *relações de trabalho*, que são de dois tipos: *individuais* ou *coletivas*. Até agora, a relação de trabalho, entre nós, tem-se fundado quase só no chamado *contrato individual de trabalho*, que põe em confronto duas partes desiguais: o patrão forte e o trabalhador necessitado. Esta tem sido, até aqui, uma grave deficiência do nosso sistema constitucional dos direitos sociais, que não oferecia aos trabalhadores o instrumento de ação coletiva pelo qual pudessem emparelhar com a classe patronal em igualdade de posição, uma vez que da convenção coletiva do trabalho é que decorre o estatuto do trabalhador, seja em cada empresa, seja em cada categoria profissional, seja em determinada base territorial, porque ela possibilita a livre negociação das condições de trabalho e de salário num plano coletivo, ou seja, para um daqueles grupos,⁵ de tal sorte que os contratos individuais de trabalho já encontrariam seus elementos essenciais prefixados e assim protegidos os trabalhadores em suas relações de trabalho individuais.⁶

4. A lei é a CLT, arts. 487 e ss.

5. Cf. Gérard Lyon-Caen e Jeanne Ribettes-Tillhet, *Manuel de droit social*, pp. 11 e 12.

6. Esse é o objetivo básico da convenção coletiva de trabalho, consoante definição que lhe dá o art. 611 da CLT: "Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito

A Constituição de 1988 prestigia as relações coletivas de trabalho. *Reconhece, como um direito dos trabalhadores, as convenções e acordos coletivos de trabalho*. Ao firmar a autonomia sindical (art. 8º) e assegurar o direito de greve, em termos amplos (art. 9º), cria as bases para o desenvolvimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Chega até a ser despcienda, quando declara que é *obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho* (art. 8º, VI), como se isso não fosse uma das razões de ser dos sindicatos. Muitos dos direitos reconhecidos aos trabalhadores podem ser alterados por via de convenções ou acordo coletivo, assim: a irredutibilidade de salário, compensação de horário e redução da jornada de trabalho, jornada em turnos ininterruptos de revezamento (art. 7º, VI, XIII e XIV).

A Constituição não é o lugar para se estabelecerem as condições das relações de trabalho, mas ela o faz, visando proteger o trabalhador, quanto a valores mínimos e certas condições de salário (art. 7º, IV a X) e, especialmente, para assegurar a isonomia material, proibindo: (a) diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil; (b) discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência; (c) distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos, e garantindo a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso (art. 7º, XXX a XXXII e XXXIV), assim para garantir equilíbrio entre trabalho e descanso, quando estabelece (art. 7º, XIII a XV e XVII a XIX): (a) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (b) jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; vale dizer, se a empresa é daquelas que se mantêm em funcionamento todos os dias vinte e quatro horas por dia, ininterruptamente, tem que ter turnos de revezamento de seus trabalhadores; em tal caso, a jornada será de seis horas, e não oito; terá que ter quatro turmas de revezamento, não apenas três, como até agora; (c) repouso semanal, férias, licenças etc., como veremos adiante.

6. Direitos relativos ao salário

O sistema de salário constitui fundamental exigência para o estabelecimento de condições dignas de trabalho. Quanto a isso, há

das respectivas representações, às relações individuais de trabalho". Cf., para pormenores, Antônio Lamarca, *ob. cit.*, pp. 287 e ss.; F. Santoro-Passarelli, *Noções de direito do trabalho*, pp. 23 e ss.

dois aspectos básicos: o da *fixação* e o da *proteção do salário do trabalhador*.

Quanto à *fixação*, a Constituição vigente, ao contrário das anteriores, oferece várias regras e condições, tais como: (a) *salário mínimo*, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; (b) *piso salarial* proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; (c) *salário nunca inferior ao mínimo* para os que percebem remuneração variável, caso dos garçons, oficiais de barbeiros, por exemplo, que têm sua remuneração composta de salário, pago pelo empregador, e gorjetas; aquele não poderá mais ser inferior ao salário mínimo; (d) *décimo-terceiro salário* com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, pago por ocasião das festas natalinas, para que o trabalhador tenha recursos para festejar o Natal e o Ano-Novo; (e) determinação de que *a remuneração do trabalho noturno seja superior à do diurno*; (f) determinação de que *a remuneração do serviço extraordinário seja superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do trabalho normal*; (g) *salário-família* pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda; (h) respeito ao *princípio da isonomia salarial*, já mencionado, quando estudamos a igualdade perante a lei; (i) pode-se incluir aqui também o *adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei* (art. 7º, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XVI, XXIII e XXX a XXXIV). Essas normas tentam garantir a segurança do trabalhador contra decisões unilaterais dos empregadores, mas resta, ainda, margem razoável para o livre acordo sobre salário nos contratos individuais e nas negociações coletivas, bem como nas decisões normativas.

Quanto à *proteção do salário*, consta agora explicitamente da Constituição. Em certo sentido, aliás, o próprio salário mínimo e o piso salarial constituem formas de proteção salarial. Mas dois preceitos são específicos nesse sentido: o do art. 7º, VI, segundo o qual o *salário é irredutível*, que, no entanto, não é rígido, pois a Constituição permitiu que possa ser reduzido por cláusula de convenção ou acordo coletivo; e o do inciso X do mesmo artigo, que prevê a *proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa*; a lei é que indica a forma dessa proteção, e já o faz de vários modos: "contra o empregador, contra os credores do empregador, contra o empregado e contra os credores do empregado";⁷ por isso é que, além de irredutíveis,

7. Cf. Antônio Lamarca, *ob. cit.*, p. 210; e também a CLT, arts. 449, 455, 462, 464 e 468.

os salários são impenhoráveis, irrenunciáveis e constituem créditos privilegiados na falência e na concordata do empregador. A segunda parte do dispositivo já define como crime retenção dolosa do salário, o que, nos termos da legislação penal vigente, caracteriza apropriação indébita.

7. Direitos relativos ao repouso e à inatividade do trabalhador

O repouso do trabalhador é outro elemento que se inclui entre as condições dignas de trabalho. Fora desumano o sistema de submeter os trabalhadores a trabalho contínuo em todos os dias da semana e do ano, sem previsão de repouso semanal remunerado, sem férias e outras formas de descanso. Atenta a isso é que a Constituição, seguindo evolução que vem de cartas magnas anteriores, assegura: (a) *repouso semanal remunerado*, preferencialmente aos domingos; (b) *gozo de férias anuais*, remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, que devem ser pagas antes de seu início, pois se visa, com o terço a mais, possibilitar ao trabalhador efetivo gozo do período de descanso; não se especifica, no nível constitucional, quantos dias, mas a lei reconhece o direito a trinta dias, por princípio; (c) *licença à gestante*, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias; (d) *licença-paternidade*, nos termos fixados em lei, mas até que esta venha a disciplinar a matéria, a licença será de cinco dias (art. 10, § 1º, do ADCT); essa licença vincula-se ao parto da mulher do beneficiado, por isso deve ser outorgada a partir do dia do evento (art. 7º, XV e XVII a XIX).

Finalmente, cumpre lembrar o direito à inatividade remunerada, consubstanciado na *aposentadoria*, indicada no art. 7º, XXIV, mas disciplinada no art. 202, como uma das prestações da previdência social, referida entre os demais direitos sociais no art. 6º.

8. Proteção dos trabalhadores

A Constituição ampliou as hipóteses de *proteção dos trabalhadores*. A primeira que aparece, na ordem do art. 7º é a do inciso XX: *proteção do mercado de trabalho da mulher*, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; isso tem por fim dar à mulher condições de competitividade no mercado de trabalho, sem discriminações; a segunda já constava de normas constitucionais anteriores; é a do inciso XXII: *forma de segurança do trabalho*, mediante a *redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança*; a terceira é a importante inovação do inciso XXVII, que prevê a *proteção em face da automação, na forma da lei*; embora dependendo de lei,

essas normas criam condições de defesa do trabalhador diante do grande avanço da tecnologia, que o ameaça, pela substituição da mão-de-obra humana pela de robôs, com vantagens para empresários e desvantagens para a classe trabalhadora; o texto possibilitará a repartição das vantagens entre aqueles e estes; a quarta é a do inciso XXVIII, que estabelece o *seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa*.

Cabe observar que os dispositivos que garantem a isonomia e não discriminação (art. 7º, XXX a XXXIII) também possuem uma dimensão protetora do trabalhador. Destaca-se, nesse sentido, como novidade constitucional, o disposto no inciso XXXIV, que assegura a *igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso*. A proteção é especialmente destinada a este último. *Trabalhador avulso* é "aquele prestador de serviços na orla marítima e que realiza serviços para empresas marítimas, por conta destas, mediante rodízio controlado pelo sindicato da respectiva categoria que o agrupa".⁸ São os estivadores, os trabalhadores em alvarengas, conferentes de carga e descarga, consertadores de carga e descarga, vigias portuários, amarradores, trabalhadores avulsos de bloco, trabalhadores avulsos de capatazia, arrumadores etc. A natureza de seu trabalho não é eventual, mas constante, ainda que o tomador do serviço varie. Tem, pois, o avulso uma relação de trabalho constante e até permanente no sentido de que seu trabalho não é temporário, esporádico, nem é trabalhador que deve deslocar-se para outros lugares na busca de nova e aleatória oportunidade. O trabalhador que busca trabalho aqui e ali é *eventual*, não o avulso, que é fixo no seu posto de trabalho, esperando apenas ser *destacado* pelo seu sindicato para realizar o trabalho, segundo rodízio controlado. O trabalho *eventual* se caracteriza por ser de curta duração, passageiro, um acontecimento isolado (um evento), que se extingue por sua temporariedade, por sua natureza contingente. Por isso é que a relação jurídica que o vincula a terceiros se caracteriza pela descontinuidade, pela impossibilidade de fixação jurídica a uma fonte de trabalho e a curta duração.⁹ Não é ao prestador de trabalho dessa natureza que a norma constitucional se dirige, mas àquele outro que tem constância no tempo, ocupa sua posição por tempo indefinido com sua presença permanente no posto de trabalho, ou seja, no lugar onde existe o trabalho que requer a sua força, sua fixação a uma fonte de

trabalho constante, sendo por isso registrado como força de trabalho permanente junto a essa fonte de trabalho. Não se confunde ele também com o trabalhador autônomo, que trabalha quando quer, para quem quer, onde quer, características que não existem em relação ao trabalhador avulso que fica disponível e, em princípio, não pode recusar o trabalho, quando destacado para prestá-lo.¹⁰

9. Direitos relativos aos dependentes do trabalhador

Entre os direitos dos trabalhadores, há uns que são destinados a seus dependentes. O salário mínimo mesmo tem tal objetivo na medida em que deva ser capaz de satisfazer, não só as necessidades do trabalhador, mas também as de sua família. Mas este não é um direito específico para os dependentes dele, como o é o *salário-família* que a Constituição agora prevê *para os dependentes do trabalhador de baixa renda*, nos termos da lei (art. 7º, XII). Então, este é um direito que entra no campo do direito ao salário, mas apenas para o trabalhador que tenha dependentes (esposa, filhos, pais ou outros, que vivam sob sua dependência). Houve, na Constituinte, tentativa de conferir esse direito apenas ao trabalhador de pequena renda, primeiro porque os de renda média e alta não precisam deste achego, segundo porque, em assim sendo, seria possível oferecer um salário-família mais substancial, o que constituiria razoável ajuda ao trabalhador, especialmente porque essa é uma vantagem que se amplia em função do número de dependentes. Mas tal orientação não foi aceita, por um lado, lamentavelmente, porque seria um meio de redistribuição de rendas, mas, por outro lado ponderável, por conter um elemento inconveniente, qual seja um fator embutido de estímulo à elevada procriação, que, por seu turno, não se compadece com o disposto no art. 226, § 7º, propenso ao planejamento familiar.

Da maior importância social é o direito previsto no art. 7º, XXV, pelo qual se assegura *assistência gratuita aos filhos e dependentes do trabalhador desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas*.

São direitos que talvez deveriam estar previstos entre os demais direitos sociais, como a obrigação de o empregador oferecer ensino fundamental a seus empregados e dependentes, ou pagar, para tanto, o salário-educação (art. 212, § 5º).

8. Cf. Eugênio Haddock Lobo e Julio César do Prado Leite, *Comentários à Constituição Federal*, v. 1/254.

9. Cf. Amaury Mascaro do Nascimento, *Curso de direito do trabalho*, pp. 256 e 563.

10. Cf. Eugênio Haddock Lobo e Julio César do Prado Leite, *ob. cit.*, pp. 254 e 255.

10. Participação nos lucros e co-gestão

O art. 7º, XI, manteve o direito de participação nos lucros das empresas, que vem da Constituição de 1946, mas não foi aplicado, por falta de lei que o regulamentasse. O enunciado da norma agora é um pouco diferente, mas, quanto à eficácia e aplicabilidade, continua a depender de lei. Diz que é direito *dos trabalhadores a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa, conforme definido em lei*. O texto reconhece, assim, que os trabalhadores são elementos exteriores à empresa, como mera força de trabalho adquirida por salário, sendo de esperar que este venha a ser condizente com a valorização social do trabalho como condição de dignidade da pessoa humana (arts. 1º e 170).

A norma sugere duas formas de participação: (a) *participação nos lucros ou nos resultados*; (b) *participação na gestão*. Ambas correlacionam-se com o fim da ordem econômica de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Trata-se de promessa constitucional e, portanto, de norma de eficácia limitada e aplicabilidade diferida, que existe desde 1946, dependente de lei para efetivar-se.

Sempre se alegam dificuldades na estruturação da participação nos lucros das empresas. Para tanto, contudo, basta que a lei determine a separação da parte dos lucros para a formação de uma *reserva de participação* em cada empresa, que seria repartida, em cada exercício, alguns dias após o balanço, entre os trabalhadores na proporção dos respectivos salários. Essa reserva, como tantas outras da empresa, seria deduzida dos lucros para efeitos do imposto sobre a renda. O trabalhador que quisesse poderia receber sua parte em ações da empresa. É claro que a fiscalização do procedimento, além de feita pelos agentes do imposto sobre a renda, teria que caber à *coletividade de trabalho* (conjunto dos trabalhadores subordinados da empresa), por meio do representante eleito por ela, nos termos agora previstos no art. 11.

Não foi, porém, esse o caminho seguido pelo legislador, que regulou a matéria por Medidas Provisórias sucessivamente reeditadas e sempre com redação diferente. A última reedição é a de n. 1.982-77/2000, convertida na Lei 10.101 de 19.12.2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, fundada, porém, em negociação entre empresa e empregados, por um dos seguintes procedimentos, escolhidos pelas partes de comum acordo, conforme se lê no seu art. 2º: (a) comissão escolhida pelas partes, integrada, também por um representante indicado pelo sindicato da

respectiva categoria; (b) convenção ou acordo coletivo, devendo constar dos instrumentos da negociação regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios: (a) índice de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; (b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. Não se equiparam a empresa as pessoas físicas nem as entidades sem fins lucrativos nas condições estabelecidas no § 3º do art. 2º da lei. Declara-se que a participação não substitui nem complementa a remuneração devida ao trabalhador. A verdade, no entanto, é que essa é uma típica legislação simbólica, ou seja, destinada não tanto a instrumentar normativamente a matéria, mas a dar satisfação política aos destinatários da norma constitucional.¹¹

O texto fala em participação nos *lucros*, ou *resultados*. São diferentes? Certamente, são diferentes. *Resultados* consistem na *equação positiva ou negativa entre todos os ganhos e perdas* (operacionais e não-operacionais) da empresa no exercício. Os resultados podem ser, portanto, positivos ou negativos. Neles entram, por exemplo, a correção monetária, a reavaliação de bens. *Lucro bruto* é a diferença entre a receita líquida e custos da produção dos bens e serviços da empresa. *Lucro líquido* é isso mais ganhos líquidos eventuais menos provisões, doações, fundos etc.

A *participação na gestão das empresas* é admitida apenas excepcionalmente. Não se sabe bem por que o *excepcionalmente*, nem qual o seu alcance. Excepcionalmente em função de quê? Nesses termos, essa participação não chega a ser sequer uma possibilidade de *co-gestão*,¹² que importará real poder de co-decisão, sem que necessariamente os trabalhadores, por seus representantes, tenham que integrar a diretoria da empresa. Não raro se propõe a implementação do

11. Sobre o conceito de legislação simbólica, Marcelo Neves, *A constituição simbólica*, p. 32.

12. E não há confundir *co-gestão* com *autogestão*. A primeira é simples participação dos trabalhadores, por delegado, comissões ou representantes, nas decisões da empresa. A segunda é forma socializada de gestão pública e econômica; constitui um modo de gerir a *propriedade social dos meios de produção*. A *co-gestão* pressupõe que os trabalhadores sejam externos à empresa. Na *autogestão* os trabalhadores estão inseridos na empresa. Sobre a autogestão, cf. Milojko Drubovic, *A autogestão à prova*, Lisboa, Seara Nova, 1976; Pierre Rosanvallon, *L'âge de l'autogestion*, Paris, Ed. du Seuil, 1976; Henri Arvou, *L'autogestion*, Paris, PUF, "Collection que sais-je?", 1980.

texto constitucional mediante a eleição, em assembléia dos acionistas, de um ou dois trabalhadores da empresa para integrar sua diretoria. Ai, não ocorre a participação de trabalhadores na gestão da empresa, pois o eleito é representante dos acionistas. Outra forma, às vezes, sugerida é a da escolha de um ou dois membros da diretoria, dentre os trabalhadores da empresa, por eleição destes. Isso também não é satisfatório. Na França, por exemplo, a lei prevê a presença de quatro representantes do pessoal no Conselho de Administração das sociedades anônimas, mas sem poder de decisão; por isso, anotam Lyon-Caen e Ribettes-Tillhet, não se pode falar aí de participação na gestão.¹³

Participação na gestão da empresa só ocorrerá quando a coletividade de trabalhadora da empresa, por si ou por uma comissão, um conselho, um delegado ou um representante, fazendo parte ou não dos órgãos diretivos dela, disponha de algum poder de co-decisão ou pelo menos de controle.¹⁴ Para que não se deforme a relação coletiva do trabalho, com a fragmentação da organização dos trabalhadores, cumpre não esquecer de que o sindicato não pode ser despojado do monopólio de representação das categorias profissionais no plano destas como no da empresa. Vale dizer, os conselhos ou comissões de fábricas ou de empresa, que a Constituição não previu (mas não proíbe), não hão de substituir os sindicatos; hão de agir nos quadros destes, pelo que a participação na gestão e nos lucros da empresa precisa estar acoplada às convenções coletivas de trabalho, ao fortalecimento da estrutura sindical.

III. DIREITOS COLETIVOS DOS TRABALHADORES

11. Caracterização

Algumas fases de elaboração constitucional produziram anteprojetos que contemplavam, em capítulo separado, os *direitos coletivos*, entre os quais se encontravam a liberdade de reunião, a liberdade de associação, a liberdade de associação profissional e sindical e o

13. *Ob. cit.*, p. 286.

14. Sobre o tema em profundidade, embora com base na Constituição de 1946, cf. Elson Gottschalk, *A participação do empregado na gestão da empresa*, Salvador, Progresso, 1958, e mais recentemente, já em face da Constituição de 1988, cf. Antônio Alves da Silva, *Co-gestão no estabelecimento e na empresa*, p. 27, onde define a co-gestão nos seguintes termos: "Quando a participação se verifica na empresa, envolvendo a vontade do empregado ou do empregador, através de representação apropriada, recebe a participação o nome de co-gestão". E à p. 251 concorda conosco, quando argüimos que a participação excepcional na gestão da empresa, admitida na Constituição, não chega a ser efetiva co-gestão.

direito de greve. A Constituinte acabou por suprimir aquele capítulo, separando seu conteúdo entre o capítulo dos direitos individuais e coletivos, já vistos, e o dos direitos sociais, agora em exame. Vale dizer: *direitos coletivos dos indivíduos* foram incluídos entre os direitos individuais, enquanto os *direitos coletivos dos trabalhadores* passaram a integrar os direitos sociais a ele relativos, que são a *liberdade de associação profissional ou sindical*, *direito de greve*, *direito de substituição processual*, *direito de participação laboral* e *direito de representação na empresa*. Deles é que vamos tratar aqui.

12. Liberdade de associação ou sindical

12.1 Associação e sindicato

O art. 8º menciona dois tipos de associação: a *profissional* e a *sindical*. Em verdade, ambas são associações profissionais. A diferença está em que a *sindical* é uma associação profissional com prerrogativas especiais, tais como: (a) defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, até em questões judiciais e administrativas; (b) participar de negociações coletivas de trabalho e celebrar convenções e acordos coletivos; (c) eleger ou designar representantes da respectiva categoria; (d) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais representadas. Já a associação profissional não sindical se limita a fins de estudo, defesa e coordenação dos interesses econômicos e profissionais de seus associados.

No ordenamento brasileiro, até agora, não se formava sindicato diretamente. Primeiro, constituía-se uma associação profissional que, depois, seria reconhecida ou não reconhecida "como sindicato e investida nas prerrogativas definidas em lei" (CLT, art. 512). Essa solução parece não poder prevalecer em face do art. 8º, I, que dá inteira liberdade de fundação de sindicato. Também estão revogadas, por inconstitucionais, as leis ordinárias que proibiam a sindicalização de determinadas categorias de trabalhadores, pois até mesmo os servidores públicos gozam do direito de livre sindicalização (art. 37, VI).

12.2 Liberdade e autonomia sindical

A liberdade sindical emanou de árdua conquista dos trabalhadores e evoluiu "como um *direito autônomo*, mesmo que juridicamente possa ser posto ao lado da liberdade geral de associação e reunião. A chamada 'luta pela conquista da liberdade sindical' conduziu a esta separação conceitual dos dois direitos em face do conflito histó-

rico entre os ordenamentos sindical e estatal".¹⁵ A Constituição vigente elimina todos os entraves anteriores que restringiam a liberdade sindical, que, agora, é contemplada e assegurada amplamente em todos os seus aspectos.

A *liberdade sindical* implica efetivamente: (a) *liberdade de fundação de sindicato*, que significa que o sindicato pode ser constituído livremente, sem autorização, sem formalismo, e adquirir, de plano, direito, personalidade jurídica,¹⁶ com o mero registro no órgão competente, que é o registro das pessoas jurídicas, vedadas, ao Poder Público, a interferência e a intervenção na organização sindical, e é o que consta do art. 8º, I, que, assim, consagra, também, o *princípio da autonomia dos sindicatos*, ou seja, a sua desvinculação com qualquer poder ou entidade; (b) *liberdade de adesão sindical*, que consiste no direito de os interessados aderirem ou não ao sindicato de sua categoria profissional ou econômica, sem autorização ou constrangimento, liberdade que envolve também o direito de desligar-se dele quando o interessado desejar, pois "ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato", diz o art. 8º, V; (c) *liberdade de atuação*, garantia de que o sindicato persiga seus fins e realize livremente a representação dos interesses da respectiva categoria profissional ou econômica, manifestando-se aqui, mais acentuadamente, a *autonomia sindical*, agora devidamente definida no art. 8º, I, quando proíbe a interferência e a intervenção do Poder Público na organização sindical, e, pois, no seu funcionamento, de tal sorte que não mais se legitima a submissão dos sindicatos à tutela do Ministério do Trabalho ou de qualquer outro órgão, e menos ainda sua intervenção, como era comum no passado; (d) *liberdade de filiação* do sindicato a associação sindical de grau superior, também prevista no art. 8º, IV, que até autoriza a fixação de contribuição para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva.

12.3 Participação nas negociações coletivas de trabalho

Esta é uma prerrogativa importante dos sindicatos, pela qual lhes cabe representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou os interesses individuais dos associados e, especialmente, celebrar convenções coletivas de trabalho, que são o "acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de traba-

ho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho" (CLT, art. 611). Hoje, a questão assume natureza de participação, mais do que de simples representação, já que, por força do art. 8º, VI, "é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho". Isso prestigia os sindicatos e transforma as negociações coletivas num poderoso instrumento de solução de controvérsias trabalhistas.

12.4 Contribuição sindical

Tema controvertido que, no entanto, ficou admitido pelo art. 8º, IV, que autoriza a assembléia geral a fixar contribuição sindical que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Há, portanto, duas contribuições: uma para custeio de confederações e outra de *caráter parafiscal*, porque compulsória estatuída em lei, que são, hoje, os arts. 578 a 610 da CLT, chamada "Contribuição Sindical", paga, recolhida e aplicada na execução de programas sociais de interesse das categorias representadas.¹⁷

12.5 Pluralidade e unicidade sindical

Aqui se encontra outra temática de amplas controvérsias. Os que propugnam pela *pluralidade sindical* pretendem a livre possibilidade de constituir vários sindicatos (fragmentação sindical) para uma mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, enquanto a *unicidade sindical* consiste na possibilidade de criação de apenas um sindicato para cada categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. A Constituição tomou partido explícito na controvérsia e a solucionou pela unicidade sindical, conforme o art. 8º, II: "é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município". Mantém-se, em princípio, o sistema anterior, que concilia a *pluralidade de bases territoriais* com a *unicidade sindical* por categoria. Há *unicidade sindical* em cada base

15. Cf. Octávio Bueno Magano, *Novas Tendências do Direito do Trabalho*, p. 144.

16. Cf. Gérard Lyon-Caen e Jeanne Ribettes-Tillhet, *ob. cit.*, p. 249.

17. Existe disposição transitória sobre o tema, art. 10, § 2º: "Até ulterior disposição legal, a cobrança das contribuições para o custeio das atividades dos sindicatos rurais será feita juntamente com a do imposto territorial rural, pelo mesmo órgão arrecadador".

porque nela só poderá existir um sindicato de uma mesma categoria profissional ou econômica, mas, como existe *pluralidade de bases territoriais*, manifesta-se aí uma espécie de pluralidade sindical em nível supramunicipal.

A tendência, em verdade, é a de rever essa posição para adotar a pluralidade sindical. Hoje, conservadores e progressistas estão, no geral, coincidindo nesse ponto de vista. A unicidade era uma conveniência no sistema de sindicatos tutelados pelo Ministério do Trabalho, tutela que a Constituição não mais aceita. O fundamento que normalmente se dá para sustentar o pluralismo é o de que observa melhor a liberdade sindical e realiza o pluralismo político. Na realidade, o que se dará é a fragmentação sindical e isso nada tem a ver com pluralismo, pois este significa liberdade de formação de correntes de opinião divergente para a conquista do poder dentro de uma unidade de poder, o que é coisa diferente de formação de pluralidade de poder.

13. Direito de greve

A "greve é o exercício de um poder de fato dos trabalhadores com o fim de realizar uma abstenção coletiva do trabalho subordinado".¹⁸ Inicia-se com base num procedimento jurídico: acordo dos trabalhadores em assembléia sindical; por isso é que se diz tratar-se de "abstenção coletiva concertada".¹⁹ Ela, assim, se desencadeia e se desenvolve sob a égide do poder de representação do sindicato, pois é um instrumento dos trabalhadores coletivamente organizados para a realização de melhores condições de trabalho para toda a categoria profissional envolvida. Daí, também, a idéia de que a greve atua através de um *procedimento* que tem por escopo a formação de um futuro contrato coletivo de trabalho.²⁰ Vê-se, pois, que ela não é um simples direito fundamental dos trabalhadores, mas um direito fundamental de natureza instrumental e desse modo se insere no conceito de *garantia constitucional*, porque funciona como meio posto pela Constituição à disposição dos trabalhadores, não como um bem auferível em si, mas como um recurso de última instância para a concretização de seus direitos e interesses.

A Constituição assegura o *direito de greve*, por si própria (art. 9º). Não o subordinou a eventual previsão em lei. É certo que isso não

18. Cf. Giuliano Mazzoni, *Relações coletivas de trabalho*, pp. 223 e 224.

19. Idem, p. 234.

20. Idem, p. 244.

impede que lei defina os procedimentos de seu exercício, como exigência de assembléia sindical que a declare, de *quorum* para decidila e para definir abusos e respectivas penas. Mas a lei não pode restringir o direito mesmo, nem quanto à oportunidade de exercê-lo nem sobre os interesses que, por meio dele, devam ser defendidos. Tais decisões competem aos trabalhadores, e só a eles (art. 9º). Diz-se que a melhor regulamentação do direito de greve é a que não existe.²¹ Lei que venha a existir não deverá ir no sentido de sua limitação, mas de sua *proteção e garantia*.²² Quer dizer, os trabalhadores podem decretar *greves reivindicativas*, objetivando a melhoria das condições de trabalho, ou *greves de solidariedade*, em apoio a outras categorias ou grupos reprimidos, ou *greves políticas*, com o fim de conseguir as transformações econômico-sociais que a sociedade requeira, ou *greves de protestos*. Também não há mais limitações quanto à natureza da atividade ou serviços, como no sistema revogado, que vedava greve nas atividades ou serviços essenciais. A esse propósito, só cabe à lei definir quais serviços e atividades sejam essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º). O que se espera, como sempre aconteceu, é que os próprios trabalhadores promovam o atendimento dessas necessidades inadiáveis da comunidade, até para não tê-la contra si. Contudo, o constituinte ainda não teve a coragem de admitir o amplo direito de greve aos *servidores públicos*, pois, em relação a estes, submeteu o exercício desse direito aos termos e limites definidos em lei específica (art. 37, VII).

Finalmente, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei (art. 9º, § 2º).

14. Direito de substituição processual

Direito de substituição processual, no caso, consiste no poder que a Constituição conferiu aos sindicatos de ingressar em juízo na defesa de direitos e interesses coletivos e individuais da categoria. É algo diferente da representação nas negociações ou nos dissídios coletivos de trabalho. Claro que, aqui, o sindicato está no exercício de prerrogativa que lhe é conatural. O ingresso em juízo, e qualquer

21. Cf. Miguel Rodríguez-Piñero, Antonio Martín Valverde e Federico Durán, "La regulación del derecho de huelga y su problemática", in Fundación Friedrich Ebert (org.), *La huelga ante el desarrollo de la constitución*, V Encuentro entre Empresarios, Sindicalistas y Laboristas, Sevilla, de 3 a 6 de maio de 1979, p. 25.

22. Vale, para o caso, essa lição em sua essência dos autores do trabalho mencionado na nota anterior, p. 26. A propósito, já está em vigor a Lei 7.783, de 28.6.89, dispondo sobre o exercício do direito de greve e definindo as atividades essenciais, como previsto nos §§ 1º e 2º do art. 9º da Constituição.

juízo, ou mesmo na administração, para defender direitos ou interesses individuais, especialmente, mas também coletivos, da categoria, é atribuição inusitada, embora de extraordinário alcance social. Trata-se, a nosso ver, de *substituição processual*, já que ele ingressa em nome próprio na defesa de interesses alheios.

15. Direito de participação laboral

Não é um direito típico dos trabalhadores, porque também cabe aos empregadores. É direito coletivo de natureza social, previsto no art. 10, segundo o qual é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão.

16. Direito de representação na empresa

Está consubstanciado no art. 11, segundo o qual, *nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores*. Não se conseguiu introduzir na Constituição mais do que isso em matéria de delegado de fábrica. Houve tentativa de reconhecer, em nível constitucional, as comissões de fábrica, mas, no fim, a idéia foi abandonada, mas, por certo, não está proibida.

Capítulo III

DIREITOS SOCIAIS DO HOMEM CONSUMIDOR

I. DIREITOS SOCIAIS RELATIVOS À SEGURIDADE: 1. Considerações gerais. 2. Seguridade social. 3. Direito à saúde. 4. Direito à previdência social. 5. Direito à assistência social. II. DIREITOS SOCIAIS RELATIVOS À EDUCAÇÃO E À CULTURA: 6. Significação constitucional. 7. Objetivos e princípios informadores da educação. 8. Direito à educação. 9. Direito à cultura. III. DIREITOS SOCIAIS RELATIVOS À MORADIA: 10. Fundamento constitucional. 11. Significação e conteúdo. 12. Condição de eficácia. IV. DIREITO AMBIENTAL: 13. Direito ao lazer. 14. Direito ao meio ambiente. V. DIREITOS SOCIAIS DA CRIANÇA E DOS IDOSOS: 15. Proteção à maternidade e à infância. 16. Direitos dos idosos.

I. DIREITOS SOCIAIS RELATIVOS À SEGURIDADE

1. Considerações gerais

Os direitos sociais dos trabalhadores, que estudamos no capítulo anterior, caracterizam *direitos sociais do homem como produtor*, assim como os direitos sociais, indicados no art. 6º, que merecerão nossa atenção aqui, entram na categoria dos *direitos sociais do homem como consumidor*, conforme exemplificamos no capítulo primeiro deste título.

Aqui incluiremos, também, algumas considerações sobre o direito ambiental e o direito da criança, que não foram explicitados no art. 6º.

De tudo trataremos, de modo geral, para não invadir o campo reservado mais especificamente à ordem social. Em alguns aspectos os conteúdos do art. 6º e do título da ordem social se cruzam com dificuldades de fazer-se nítida separação. Procuraremos conciliá-los, esforçando-nos para evitar repetições.

2. Seguridade social

Em edições anteriores deste livro, pleiteamos a adoção do sistema de seguridade social, como meio de superar as deficiências da previdência social, que se caracteriza como espécie de *seguro social*,

porque destinatário de suas prestações é o *segurado*, aquele que paga uma contribuição para fazer *jus* a ele, e seus dependentes. Dissemos, então, que a seguridade social constitui "instrumento mais eficiente da liberação das necessidades sociais, para garantir o bem-estar material, moral e espiritual de todos os indivíduos da população, devendo repousar nos seguintes princípios básicos, enunciados por José Manuel Almansa Pastor: (a) *universalidade subjetiva* (não só para trabalhadores e seus dependentes, mas para todos indistintamente); (b) *universalidade objetiva* (não só reparadora, mas preventiva do surgimento da necessidade; protetora em qualquer circunstância); (c) *igualdade protetora* (prestação idêntica em função das mesmas necessidades; não distinta como na previdência em função da quantidade da contribuição); (d) *unidade de gestão* (só é administrada e outorgada pelo Estado); (e) *solidariedade financeira* (os meios financeiros procedem de contribuições gerais, não de contribuições específicas dos segurados)".¹

A Constituição acolheu uma concepção de seguridade social, cujos objetivos e princípios se aproximam bastante daqueles fundamentos, ao defini-la como "um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social" (art. 194), ao estabelecer seus objetivos (art. 194, parágrafo único) e o sistema de seu financiamento (art. 195), que examinaremos mais de perto no título da ordem social.² Essa concepção imanta os preceitos sobre os direitos relativos à seguridade, que hão de ser interpretados segundo os valores que informam seus objetivos e princípios.

3. Direito à saúde

É espantoso como um bem extraordinariamente relevante à vida humana só agora é elevado à condição de direito fundamental do homem. E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consagração em normas constitucionais.

O tema não era de todo estranho ao nosso Direito Constitucional anterior, que dava competência à União para *legislar sobre defesa e*

1. Cf. 4ª ed. deste livro, São Paulo, Ed. RT, 1987, p. 539, citando José Manuel Almansa Pastor, *Derecho a la seguridad social*, v. I/75 a 77.

2. A Lei 8.212, de 24.7.91, dispôs sobre a organização da Seguridade Social, instituiu o Plano de Custeio e deu outras providências. Foi ela regulamentada pelo Decreto 356, de 7.12.91.

proteção da saúde, mas isso tinha sentido de organização administrativa de combate às endemias e epidemias. Agora é diferente, trata-se de um direito do homem.

Creemos que foi a Constituição italiana a primeira a reconhecer a saúde como fundamental direito do indivíduo e interesse da coletividade (art. 32). Depois, a Constituição portuguesa lhe deu uma formulação universal mais precisa (art. 64), melhor do que a espanhola (art. 43) e a da Guatemala (arts. 93-100). O importante é que essas quatro constituições o relacionam com a seguridade social.

A evolução conduziu à concepção da nossa Constituição de 1988 que declara *ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, serviços e ações que são de relevância pública* (arts. 196 e 197). A Constituição o submete a conceito de seguridade social, cujas ações e meios se destinam, também, a assegurá-lo e torná-lo eficaz.

Como ocorre com os direitos sociais em geral, o direito à saúde comporta *duas vertentes*, conforme anotam Gomes Canotilho e Vital Moreira: "uma, de natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado (ou de terceiros) que se abstenha de qualquer acto que prejudique a saúde; outra, de natureza positiva, que significa o direito às medidas e prestações estaduais visando a prevenção das doenças e o tratamento delas".³ Como se viu do enunciado do art. 196 e se confirmará com a leitura dos arts. 198 a 200, trata-se de um direito positivo "que exige prestações de Estado e que impõe aos entes públicos a realização de determinadas tarefas [...], de cujo cumprimento depende a própria realização do direito",⁴ e do qual decorre um especial direito subjetivo de conteúdo duplo: por um lado, pelo não cumprimento das tarefas estatais para sua satisfação, dá cabimento à *ação de inconstitucionalidade por omissão* (arts. 102, I, a, e 103, § 2º) e, por outro lado, o seu não atendimento, *in concreto*, por falta de regulamentação,⁵ pode abrir pressupostos para a impetração do *mandado*

3. Cf. *Constituição da República portuguesa anotada*, 3ª ed., cit., p. 342. Recorde o leitor que "prestações estaduais", nos autores, significa, na terminologia brasileira, "prestações estatais", ou seja, do Poder Público, para não se confundir com prestações a serem cumpridas pelos Estados federados.

4. *Idem*, p. 342.

5. Cf. Lei 8.080, de 19.9.90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, e reafirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições in-

de injunção (art. 5º, LXXI), apesar de o STF continuar a entender que o mandado de injunção não tem a função de regulação concreta do direito reclamado (infra).

4. Direito à previdência social

Previdência social é um conjunto de direitos relativos à seguridade social. Como manifestação desta, a previdência tende a ultrapassar a mera concepção de instituição do Estado providência (*welfare state*), sem, no entanto, assumir características socializantes, até porque estas dependem mais do regime econômico do que do social.

A Constituição deu contornos mais precisos aos direitos de previdência social (arts. 201 e 202), mas seus princípios e objetivos continuam mais ou menos idênticos ao regime geral de previdência social consolidado na legislação anterior,⁶ ou seja: funda-se no princípio do seguro social, de sorte que os benefícios e serviços se destinam a cobrir eventos de doença, invalidez, morte, velhice e reclusão, apenas do segurado e seus dependentes. Isto quer dizer que a base da cobertura assenta no fator contribuição e em favor do contribuinte e dos seus.

O regime de previdência social, consubstanciado na Constituição, engloba prestações de dois tipos: (1) os *benefícios*, que são prestações pecuniárias, consistentes: (a) na *aposentadoria*, por invalidez (não incluída no § 7º do art. 201, mas sugerida no inciso I do mesmo artigo), por velhice, por tempo de serviço, especial e proporcional (art. 201, §§ 7º e 8º); (b) nos *auxílios* por doença, maternidade, reclusão e funeral (art. 201, I a III); (c) no *seguro-desemprego* (arts. 7º, II, 201, IV, 239); (d) na *pensão* por morte do segurado (art. 201, V); (2) os *serviços*, que são prestações assistenciais: médica, farmacêutica, odontológica, hospitalar, social e de reeducação ou readaptação funcional.

5. Direito à assistência social

O direito à assistência social constitui a face universalizante da seguridade social, porque “será prestada a quem dela necessitar, inde-

dispensáveis ao seu pleno exercício. Cf. também a Lei 8.142, de 28.12.90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde-SUS. Cf. ainda Guido Ivan de Carvalho e Lenir Santos, *Sistema único de saúde, comentário à Lei Orgânica da Saúde (Leis 8.080/90 e 8.142/90)*, São Paulo, Editora Hucitec, 1992.

6. Legislação essa consolidada, então, no Decreto 89.312/84. Hoje vigoram, com o mesmo sentido, a Lei 213, de 24.7.91, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social, e seu Regulamento baixado pelo Decreto 357, de 7.12.91. A Lei 7.998, de 11.1.90, regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador-FAT.

pendentemente de contribuição” (art. 203). Nela é que, também, assenta outra característica da seguridade social: a solidariedade financeira, já que os recursos procedem do orçamento geral da seguridade social e não de contribuições específicas de eventuais destinatários (art. 204), até porque estes são impensáveis *a priori*, porquanto se constituem daqueles que não dispõem de meios de sobrevivência: os *desvalidos em geral*. É aí que se situa “a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” que o art. 6º destacou como um tipo de direito social, sem guardar adequada harmonia com os arts. 194 e 203, que revelam como direito social relativo à seguridade o inteiro instituto da assistência social, que compreende vários objetos e não só aquele mencionado no art. 6º.⁷

II. DIREITOS SOCIAIS RELATIVOS À EDUCAÇÃO E À CULTURA

6. Significação constitucional

A Constituição de 1988 deu relevante importância à *cultura*, tomado esse termo em sentido abrangente da formação educacional do povo, expressão criadora da pessoa e das projeções do espírito humano materializadas em suportes expressivos, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, que se exprimem por vários de seus artigos (5º, IX, 23, III a V, 24, VII a IX, 30, IX, e 205 a 217), formando aquilo que se denomina *ordem constitucional da cultura*, ou *constituição cultural*,⁸ constituída pelo conjunto de normas que contêm referências culturais e disposições consubstanciadoras dos direitos sociais relativos à educação e à cultura.

7. Objetivos e princípios informadores da educação

O art. 205 prevê três objetivos básicos da educação: a) *pleno desenvolvimento da pessoa*; b) *preparo da pessoa para o exercício da cidadania*.

7. Cf. Lei 8.742, de 7.12.93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, considerada direito do cidadão e dever do Estado, é ela considerada por essa lei como Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Cf. também a Lei 7.843, de 24.10.89, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social.

8. Gomes Canotilho e Vital Moreira, *Constituição da República portuguesa anotada*, p. 361. *Constituição cultural* apenas no sentido de fundamentos constitucionais da cultura.

nia; c) *qualificação da pessoa para o trabalho*. Integram-se, nestes objetivos, valores antropológico-culturais, políticos e profissionais.

A consecução prática desses objetivos só se realizará num sistema educacional democrático, em que a organização da educação formal (via escola) concretize o *direito de ensino*, informado por alguns princípios com eles coerentes, que, realmente, foram acolhidos pela Constituição, tais são: *universalidade* (ensino para todos), *igualdade*, *liberdade*, *pluralismo*,⁹ *gratuidade do ensino público*, *valorização dos respectivos profissionais*, *gestão democrática da escola* e *padrão de qualidade*, princípios esses que foram acolhidos no art. 206 da Constituição, com pormenores que examinaremos no capítulo correspondente da ordem social.

8. Direito à educação

O art. 205 contém uma declaração fundamental que, combinada com o art. 6º, eleva a educação ao nível dos direitos fundamentais do homem. Aí se afirma que a *educação é direito de todos*, com o que esse direito é informado pelo princípio da universalidade. Realça-lhe o valor jurídico, por um lado, a cláusula — *a educação é dever do Estado e da família* —, constante do mesmo artigo, que completa a situação jurídica subjetiva, ao explicitar o titular do dever, da obrigação, contraposto àquele direito. Vale dizer: todos têm o direito à educação e o Estado tem o dever de prestá-la, assim como a família.

9. O texto aprovado em segundo turno pela Assembléia Nacional Constituinte, até mesmo na primeira votação na Comissão de Redação — Projeto de Constituição (B) — no então art. 211, III, dizia: “*pluralismo de idéias, de concepções pedagógicas e de instituições públicas e privadas*”. Um dos constituintes, na segunda discussão naquela Comissão, mostrando inteira ignorância sobre o pluralismo, propôs a redação que prevaleceu: “*pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino*”, sustentando que não existe pluralismo de instituições. A redação definitiva deformou a concepção de pluralismo. A teoria do pluralismo reconhece várias formas: pluralismo social, jurídico, político, de interesse, de idéias etc., que reconduzem a dois tipos básicos: *pluralismo ideológico*, que “designa la variété des croyances, des conceptions éthiques ou des valeurs que les individus ou les groupes tiennent pour fondamentales” (Burdeau, *Traité de science politique*, cit., t. VIII/144), em que entra a liberdade de religião, de pensamento, de idéias etc.; e *pluralismo institucional*, que compreende o desenvolvimento das autonomias e “il riconoscimento dei diritti delle ‘formazioni sociali’ quali la famiglia, le confessioni religiose, de comunità del lavoro, della scuola ecc.” (“*Pluralismo*”, in *Enciclopedia del diritto e dell'economia Garzanti*, Milano, Garzanti, 1985), e que, se quiser, pode ser desdobrado em três: *pluralismo político*, *pluralismo ideológico* e *pluralismo institucional*. Mas não foi à toa que o conservadorismo da Comissão de Redação adotou, correndo, a proposta de mudança, que pende para o privatismo, na medida em que coexistência de instituições públicas e privadas de ensino tende a igualizar os dois tipos. Os progressistas da Comissão não perceberam, e como simples Assessor Especial não podíamos intervir nos debates para alertá-los.

A norma, assim explicitada — “*A educação, direito de todos e dever do Estado e da família [...]*” (arts. 205 e 227) —, significa, em primeiro lugar, que o Estado tem que aparelhar-se para fornecer, a todos, os serviços educacionais, isto é, oferecer ensino, de acordo com os princípios estatuídos na Constituição (art. 206); que ele tem que ampliar cada vez mais as possibilidades de que todos venham a exercer igualmente esse direito; e, em segundo lugar, que todas as normas da Constituição, sobre educação e ensino, não que ser interpretadas em função daquela declaração e no sentido de sua plena e efetiva realização. A Constituição mesmo já considerou que o acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito, é *direito público subjetivo*; equivale reconhecer que é direito plenamente eficaz e de aplicabilidade imediata, isto é, direito exigível judicialmente, se não for prestado espontaneamente.

As normas têm, ainda, o significado jurídico de elevar a educação à categoria de serviço público essencial que ao Poder Público impende possibilitar a todos. Daí a preferência constitucional pelo ensino público, pelo que a iniciativa privada, nesse campo, embora livre, é, no entanto, meramente secundária e condicionada (arts. 209 e 213). Voltaremos a estes temas, como também ao da gratuidade, mais devagar, no exame da matéria no título da ordem social.

9. Direito à cultura

Os *direitos culturais* não foram arrolados no art. 6º como espécies de direito social, mas, se a educação o foi, aí também estarão aqueles, até porque estão explicitamente referidos no art. 215, consoante o qual *o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais*. Por aí também se vê que se trata de direitos informados pelo princípio da universalidade, isto é, direitos garantidos a todos.

Quais são esses direitos culturais reconhecidos na Constituição? São: (a) direito de criação cultural, compreendidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas; (b) direito de acesso às fontes da cultura nacional; (c) direito de difusão da cultura; (d) liberdade de formas de expressão cultural; (e) liberdade de manifestações culturais; (f) direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura, que, assim, ficam sujeitos a um regime jurídico especial, como forma de propriedade de interesse público. Tais direitos decorrem das normas dos arts. 215 e 216, que merecerão, ainda, exame mais aprofundado no título da ordem social.

III. DIREITOS SOCIAIS RELATIVO À MORADIA

10. Fundamento constitucional

O *direito à moradia* já era reconhecido como uma expressão dos direitos sociais por força mesmo do disposto no art. 23, IX, segundo o qual é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento”. Aí já se traduzia um poder-dever do Poder Público que implicava a contrapartida do direito correspondente a tantos quantos necessitem de uma habitação. Essa contrapartida é o direito à moradia que agora a EC-26, de 14.2.2000, explicitou no art. 6º.

11. Significação e conteúdo

O *direito à moradia* significa ocupar um lugar como residência; ocupar uma casa, apartamento etc., para nele habitar. No “morar” encontramos a idéia básica da habitualidade no permanecer ocupando uma edificação, o que sobressai com sua correlação com o *residir* e o *habitar*, com a mesma conotação de permanecer ocupando um lugar permanentemente. O direito à moradia não é necessariamente direito à casa própria. Quer-se que se garanta a todos um teto onde se abrigue com a família de modo permanente, segundo a própria etimologia do verbo *morar*, do latim “*morari*”, que significava *demorar*, *ficar*. Mas é evidente que a obtenção da casa própria pode ser um complemento indispensável para a efetivação do direito à moradia.

O conteúdo do direito à moradia envolve não só a faculdade de ocupar uma habitação. Exige-se que seja uma habitação de dimensões adequadas, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar, como se prevê na Constituição portuguesa (art. 65). Em suma, que seja uma habitação digna e adequada, como quer a Constituição espanhola (art. 47). Nem se pense que estamos aqui reivindicando a aplicação dessas constituições ao nosso sistema. Não é isso. É que a compreensão do direito à moradia, como direito social, agora inserido expressamente em nossa Constituição, encontra normas e princípios que exigem que ele tenha aquelas dimensões. Se ela prevê, como um princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), assim como o direito à intimidade e à privacidade (art. 5º, X), e que a casa é um asilo inviolável (art. 5º, XI), então tudo isso envolve, necessariamente, o direito à moradia. Não fosse assim seria um direito empobrecido.

12. Condição de eficácia

Esse é daqueles direitos que têm duas faces: uma *negativa* e uma *positiva*. A primeira significa que o cidadão não pode ser privado de uma moradia nem impedido de conseguir uma, no que importa a abstenção do Estado e de terceiros. A segunda, que é a nota principal do direito à moradia, como dos demais direitos sociais, consiste no direito de obter uma moradia digna e adequada, revelando-se como um direito positivo de caráter prestacional, porque legitima a pretensão do seu titular à realização do direito por via de ação positiva do Estado. É nessa ação positiva que se encontra a condição de eficácia do direito à moradia. E ela está prevista em vários dispositivos de nossa Constituição, entre os quais se destaca o art. 3º, que define como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade justa e solidária, erradicar a marginalização – e não há marginalização maior do que não se ter um teto para si e para a família –, e promover o bem de todos, o que pressupõe, no mínimo, ter onde morar dignamente. Além dessas normas e princípios gerais, há ainda o disposto no art. 23, X, que dá competência comum a todas as entidades públicas da Federação para combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, o que importa, só por si, criar condições de habitabilidade adequada para todos. Mas há, ainda, norma específica determinando ação positiva no sentido da efetiva realização do direito à moradia, quando, no mesmo art. 23, IX, se estabelece a competência comum para “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento”.

IV. DIREITO AMBIENTAL

13. Direito ao lazer

O art. 6º menciona o lazer entre os direitos sociais. *Lazer* e *recreação* são funções urbanísticas, daí por que são manifestações do direito urbanístico. Sua natureza social decorre do fato de que constituem prestações estatais que interferem com as condições de trabalho e com a qualidade de vida, donde sua relação com o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. “*Lazer* é entrega à ociosidade repoussante. *Recreação* é entrega ao divertimento, ao esporte, ao brinquedo. Ambos se destinam a refazer as forças depois da labuta diária e semanal. Ambos requerem lugares apropriados, tranquilos num, repletos de folguedos e alegrias em outro”.¹⁰

10. Cf. nosso *Direito urbanístico brasileiro*, p. 327.

A Constituição menciona o lazer no art. 6º e faz ligeira referência no art. 227, mas no art. 217, § 3º, declara que o Poder Público incentivará o lazer como forma de promoção social. Como visto, ele está muito associado aos direitos dos trabalhadores relativos ao repouso. Nesse sentido, ele fora definido no Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, art. 24: "Todos têm direito ao lazer e à utilização criadora do tempo liberado ao trabalho e ao descanso". É um direito social que vai depender de melhor definição na legislação ordinária.

14. Direito ao meio ambiente

Este não fora previsto, como tal, no art. 6º, mas um capítulo sobre o assunto integra o título da ordem social, onde se estatui que *todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações* (art. 225). É um campo que integra, na sua complexidade, a disciplina urbanística, mas se revela como social, na medida em que sua concreção importa em prestação do Poder Público, em termos que veremos ao estudar os aspectos institucionais da matéria no capítulo correspondente (parte 4, título II, capítulo III, n. 11).

V. DIREITOS SOCIAIS DA CRIANÇA E DOS IDOSOS

15. Proteção à maternidade e à infância

Está prevista no art. 6º como espécie de direito social, mas seu conteúdo há de ser buscado em mais de um dos capítulos da ordem social, onde aparece como aspectos do direito de previdência social (art. 201, II: "proteção à maternidade, especialmente à gestante"), do direito de assistência social (art. 203, I: "proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice"; II: "amparo às crianças e adolescentes carentes") e no capítulo da família, da criança, do adolescente e do idoso (art. 227), sendo de ter cuidado para não confundir o direito individual da criança (direito à vida, à dignidade, à liberdade) com o seu direito social que, aliás, salvo o princípio da prioridade, coincide, em boa parte, com o de todas as pessoas (direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer), com o direito civil (condições jurídicas dos filhos em relação aos pais) e com o direito tutelar do menor (art. 227, § 3º, IV a VII, e § 4º). Alguns direitos sociais, reconhecidos no art. 227, são pertinentes só à criança e ao adolescente, como o direito à profissionalização, à convivência familiar

e comunitária e a regras especiais dos direitos previdenciários e trabalhistas (art. 227, § 3º, I a III).¹¹

16. Direitos dos idosos

Não foram incluídos no art. 6º como espécie de direito social, mas, por certo, têm essa natureza. Uma dimensão integra o direito previdenciário (art. 201, I) e se realiza basicamente pela aposentadoria e o direito assistenciário (art. 203, I), como forma protetiva da velhice, incluindo a garantia de pagamento de um salário mínimo mensal, quando ele não possuir meios de prover à própria subsistência, conforme dispuser a lei. Mas o amparo à velhice vai um pouco mais longe, daí o texto do art. 230, segundo o qual a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, bem como a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e, tanto quanto possível a convivência em seu lar.¹²

11. Cf. Lei 8.069, de 13.7.90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cf. também Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Emílio García Mendez (Coordenadores), *Estatuto da criança e do adolescente comentado*, São Paulo, Malheiros Editores, 1992.

12. Cf. Lei 8.842, de 4.1.94, que dispõe sobre a política nacional do idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso.

Título IV

Direito de Nacionalidade

Capítulo I

TEORIA DO DIREITO DE NACIONALIDADE

1. Conceito de nacionalidade. 2. Natureza do direito de nacionalidade. 3. Nacionalidade primária e nacionalidade secundária. 4. Modos de aquisição da nacionalidade. 5. O polipátrida e o "heimatlos".

1. Conceito de nacionalidade

Vamos cuidar do elemento humano da noção de Estado — o povo — e suas relações com o território, do que decorre o vínculo da nacionalidade.

O conceito de povo, vimos antes, não se confunde com população nem com *habitante*. Estes termos referem-se ao conjunto dos residentes no território, quer sejam nacionais, quer sejam estrangeiros. O território do Estado, pois, é ocupado por uma população, que se submete à ordenação jurídico-política respectiva. Essa população compõe-se de pessoas nascidas no território ocupado e de pessoas que para ele imigram. Poder-se-ia dizer que os nascidos no território provêm da mesma origem, têm a mesma língua, os mesmos costumes e tradições de seus antepassados, formando uma comunidade de base sócio-cultural que denominamos *nação*. São os *nacionais*. Os outros não são nacionais, são *estrangeiros*.¹

Sociologicamente é certo que a nacionalidade indica a pertinência da pessoa a uma *nação*. Nesse sentido, nacionais seriam "todos

1. Cf., em geral, Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, cit., t. IV/345 e ss.; Dardeau de Carvalho, *Nacionalidade e cidadania*, pp. 8 e ss.; Francisco Alexandre, *Naturalização e outros aspectos da nacionalidade*, pp. 7 e ss.; Marcello Caetano, *Manual de ciência política e Direito constitucional*, t. V/122 e ss. (essa obra foi praticamente reproduzida como v. I da obra em dois volumes que o autor publicou no Brasil, *Direito constitucional*, pp. 158 e ss.); Washington de Barros Monteiro, "Da nacionalidade e da cidadania em face da nova Constituição", *RDA* 91/13 (nova Constituição, aí, é a de 67/69).

quantos nascem num certo ambiente cultural feito de tradições e costumes, geralmente expresso numa língua comum, atualizado num idêntico conceito de vida e dinamizado pelas mesmas aspirações de futuro e os mesmos ideais coletivos".² Não é, porém, esse o sentido dos termos *nacional* e *nacionalidade* no sistema jurídico. Aqui, *nacionalidade* é o vínculo jurídico-político de Direito Público interno, que faz da pessoa um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado, consoante conceito de Pontes de Miranda.³

Por causa dessa dubiedade de sentido, o termo *nacionalidade* tem sido criticado, aventando-se a palavra *estatalidade* ou mesmo *cidadania*, para substituí-lo.⁴ O neologismo não pegou, e o termo *cidadania* agrava ainda mais a dubiedade.

No Direito Constitucional brasileiro vigente, os termos *nacionalidade* e *cidadania*, ou *nacional* e *cidadão*, têm sentido distinto. *Nacional* é o brasileiro nato ou naturalizado, ou seja, aquele que se vincula, por nascimento ou naturalização, ao território brasileiro. *Cidadão* qualifica o nacional no gozo dos direitos políticos e os participantes da vida do Estado (arts. 1º, II, e 14).⁵

Surgem, assim, três situações distintas: a do *nacional* (ou da *nacionalidade*), que pode ser *nato* ou *naturalizado*; a do *cidadão* (ou da *cidadania*) e a do *estrangeiro*, as quais envolvem, também, condições jurídicas distintas, que serão objeto de nossa meditação sucessivamente.

2. Natureza do direito de nacionalidade

Cada Estado diz livremente quais são os seus nacionais. Os fundamentos sobre a aquisição da nacionalidade é *matéria constitucional*, mesmo naqueles casos em que ela é considerada em textos de lei ordinária. É da tradição pátria inscrever nas constituições as regras sobre nacionalidade, de sorte que, entre nós, o *direito de nacionalidade* é material e formalmente constitucional. Em outros países, como na França, Japão e Itália, a matéria é disciplinada em leis ordinárias, o que não exclui sua natureza constitucional, embora não o seja formalmente. Em todos os casos, o direito de nacionalidade integra o *direito público*, ainda quando venha configurado entre normas do Código Civil.

2. Para nos servirmos de elegante conceito de Marcello Caetano, *ob. cit.*, edição portuguesa, p. 352; ed. brasileira, p. 159.

3. *Ob. cit.*, p. 352; em essência, é também o conceito de Dardeau de Carvalho, *ob. cit.*, p. 9.

4. Cf. Dardeau de Carvalho, *ob. cit.*, p. 9; Pontes de Miranda, *ob. cit.*, pp. 346 e ss.

5. Sobre cidadania, não se há de perder de vista consideração que já fizemos antes no capítulo II do título II da primeira parte, advertindo que a Constituição deu sentido mais abrangente ao termo e, também, ao seu cognato *cidadão*.

3. Nacionalidade primária e nacionalidade secundária

A nacionalidade pode ser *primária* (também dita de *origem* ou *originária*) ou *secundária* (também dita, impropriamente, *adquirida*). A *primária* resulta de *fato natural* — o nascimento — “ou porque se determina qual a ligação de sangue à massa dos nacionais de um Estado, ou a ligação à ocorrência do nascimento em território de um Estado, ou qual a relação tida por suficiente pelo Estado de que se trata para que o nascimento firme o laço da nacionalidade”.⁶ A *secundária* é a que se adquire por *fato voluntário*, depois do nascimento, “ou porque, ao nascer, a pessoa tenha outra, ou outras nacionalidades, e não ainda a de que se trata, ou porque entre a aquisição da nacionalidade (secundária) e a data do nascimento medeie lapso de tempo em que o indivíduo não teve nacionalidade”.⁷

4. Modos de aquisição da nacionalidade

Os modos de aquisição da nacionalidade variam de Estado para Estado, mas, em qualquer deles, é *involuntária* a aquisição da nacionalidade primária, e decorre da ligação do *fato natural do nascimento* com um critério estabelecido pelo Estado, enquanto é *voluntária* a aquisição de nacionalidade secundária.

São dois os *critérios para a determinação da nacionalidade primária*: (a) o critério da *origem sangüínea*, ou *ius sanguinis*, pelo qual se confere a nacionalidade em função do vínculo de sangue, reputando-se nacionais os descendentes de nacionais; (b) o critério da *origem territorial*, ou *ius solis*, pelo qual se atribui a nacionalidade a quem nasce no território do Estado de que se trata.⁸ O *fato nascimento* é que, em verdade, determina a nacionalidade primária, relacionado, porém, a um daqueles critérios. A adoção de um ou de outro destes é problema político de cada Estado. Em geral, os Estados de emigração, como a maioria dos europeus, preferem a regra do *ius sanguinis*, com base na qual a diminuição de sua população pela saída para outros países não importará em redução dos integrantes da nacionalidade. Os Estados de imigração, como a maioria dos americanos, acolhem a do

6. Cf. Pontes de Miranda, *ob. cit.*, p. 351.

7. *Id.*, *ib.*, p. 351.

8. Os autores italianos costumam indicar mais dois critérios de atribuição da nacionalidade: (a) o de *relação familiar* (*ius communicatio*), seja por *matrimônio* em favor da mulher que adquire a nacionalidade do marido, como na Itália, seja por *filiação*, segundo o qual os filhos, não emancipados, seguem a sorte do genitor, de quem adquirem a nacionalidade. Cf. Biscaretti de Ruffia, *Diritto costituzionale*, p. 40; Costantino Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, v. I/113 e 114.

ius solis, pela qual os descendentes da massa dos imigrantes passam a integrar a sua nacionalidade, o que não ocorreria se perfilhassem o critério do sangue.

Os *modos de aquisição da nacionalidade secundária* dependem da *vontade*: (a) do *indivíduo*, nos casos em que se lhe dá o direito de escolher determinada nacionalidade, à vista de alternativas que se lhe oferecem, como se prevê no art. 12, I, c (esclarecimento *infra*), e II, a, da Constituição; (b) do *Estado*, mediante outorga ao nacional de outro, espontaneamente ou a pedido, como fora, para a primeira hipótese, a grande naturalização concedida pela Constituição de 1891 (art. 69, IV e V) e como é, agora, a hipótese do art. 12, II, b, em que se reconhece a aquisição da nacionalidade pelo *fato residência há mais de quinze anos no Brasil* (redação da ECR-3/94), bastando o pedido do interessado, havendo aqui uma combinação da vontade do indivíduo com a do Estado. Esses modos de aquisição da nacionalidade secundária variam de Estado para Estado. No Brasil é a *naturalização ordinária* ou *extraordinária* (radicação precoce e a conclusão de curso superior), que a Constituição já não contempla, mas a lei referida no art. 12, II, a, poderá fazê-lo,⁹ como veremos no capítulo seguinte.

5. O polipátrida e o “heimatlos”

Polipátrida é quem tem mais de uma nacionalidade, o que acontece quando sua situação de nascimento se vincula aos dois critérios de determinação da nacionalidade primária. Assim se dá, por exemplo, com filhos de oriundo de Estado que adota o critério do *ius sanguinis*, quando nasce num Estado que acolhe o do *ius solis*. É o caso de filhos de italiano nascidos no Brasil. Como este perfilha o critério do *ius solis*, os filhos de italiano aqui nascidos, se seus pais não estiverem a serviço de seu país, adquirirão, necessária e involuntariamente, a nacionalidade brasileira; como a Itália adota o critério do *ius sanguinis*, os filhos de italiano, mesmo nascidos fora do seu território, como é o caso do exemplo, são também, para ela, necessária e involuntariamente, italianos. Assim, os filhos de italianos, nascidos no Brasil, têm dupla nacionalidade (polipátrida), condição que agora ficou explicitada no art. 12, § 4º, II, a, adicionado pela ECR-3/94, segundo o qual não se perde a nacionalidade brasileira no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Outra hipótese de dupla nacionalidade, agora admitida por força do

9. A lei mencionada no art. 12, II, a, para aquisição da naturalização já existe: Lei 6.815/80 (título XI), alterada pela Lei 6.964/81, regulamentadas pelo Decreto 86.715/81, em vigor quanto ao tema.

acréscimo da alínea *b* àquele dispositivo pela mesma Emenda Constitucional de Revisão, se dá quando norma de outro Estado impõe a naturalização ao brasileiro nele residente, como condição de permanência em seu território ou do exercício de direitos civis. Evita-se, com isso, o constrangimento de brasileiros que, por força de contratos, tenham que exercer atividade profissional em países em que se requer se naturalize para trabalhar em seu território. No sistema anterior, a nosso ver, já não era caso de perda da nacionalidade brasileira, mas, como diremos mais adiante, essa explicitação é benéfica à compreensão das regras constitucionais.

Heimatlos (expressão alemã que significa *sem pátria, apátrida*) é também um efeito possível da diversidade de critérios adotados pelos Estados na atribuição da nacionalidade. Consiste na situação da pessoa que, dada a circunstância de nascimento, não se vincula a nenhum daqueles critérios, que lhe determinariam uma nacionalidade. Trata-se, pois, de situação inversa daquela outra, porquanto aqui o fato nascimento ocorreu em circunstância tal que a pessoa não adquire nacionalidade alguma. É o que pode verificar-se, por exemplo, em princípio, com um filho de brasileiro nascido na Itália, se seus pais não estiverem a serviço do Brasil. Não adquire a nacionalidade italiana, porque, adotando a Itália o princípio do *ius sanguinis*, ninguém será italiano só porque nasce no seu território, e não o será o filho de pessoa nacional de outro país. Não adquire, por outro lado, a nacionalidade brasileira, porque, acolhendo o Brasil o princípio do *ius solis*, ninguém será brasileiro só porque seja filho de brasileiro, e não o será o filho deste, nascido no estrangeiro. Em se tratando de filho de brasileiro, para que não seja um *heimatlos*, um *sem pátria*, a Constituição dá algumas soluções que estão inscritas no seu art. 12, I, *b* e *c*, como veremos depois.

São hipóteses, como se nota, de conflito de nacionalidade, que a diversidade de critérios de sua aquisição pode gerar. No primeiro caso, temos exemplos de *conflito positivo*, gerando o polipátrida, a *multinacionalidade*, porque dois ou mais Estados reconhecem uma só pessoa como seu nacional. Esse conflito não cria dificuldade alguma; em geral, até beneficia. O *conflito negativo* é que se afigura intolerável, porque impõe a determinada pessoa, por circunstância alheia à sua vontade, uma situação de *apátrida*, de *sem nacionalidade*, que lhe cria enormes dificuldades, porque lhe gera restrições jurídicas de monta em qualquer Estado em que viva. Ora, a nacionalidade é um direito fundamental do homem, sendo inadmissível uma situação, independente da vontade do indivíduo, que o prive desse direito. A *Declaração Universal dos Direitos Humanos* bem o reconhece, quando estatui que *toda pessoa tem direito a uma nacionalidade e ninguém será*

arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade (art. 15). Apesar disso, não se encontrou ainda um mecanismo adequado para impedir que surjam os *heimatlos*, sem falar no arbítrio ditatorial de alguns países que, sem o menor escrúpulo, desrespeitam a dignidade humana e violam aqueles preceitos universais, cassando nacionalidade de pessoas que ousam opor, a seus desígnios, as inquietantes — para eles — idéias democráticas.

Não é o caso do sistema constitucional brasileiro, que sempre ofereceu e continua a oferecer mecanismo normativo (art. 12, I, *b* e *c*) adequado para solucionar os conflitos de nacionalidade negativa em que, porventura, se vejam envolvidos filhos de brasileiros.

Capítulo II

DIREITO DE NACIONALIDADE BRASILEIRA

1. Formação do povo brasileiro. 2. Fonte constitucional do direito de nacionalidade. 3. Os brasileiros natos. 4. Os brasileiros naturalizados. 5. Condição jurídica do brasileiro nato. 6. Condição jurídica do brasileiro naturalizado. 7. Perda da nacionalidade brasileira. 8. Reaquisição da nacionalidade brasileira.

1. Formação do povo brasileiro

Não é preciso repetir o fato histórico conhecido de todos, segundo o qual os portugueses, quando aqui chegaram, encontraram os habitantes indígenas, organizados em tribos, espalhados por toda a terra, que chamavam *Pindorama*, os quais careciam de unidade cultural. Os próprios colonos portugueses vinham de variadas regiões de Portugal: Beira, Dentre D'Ouro e Minho, Algarve etc., todas com características próprias. Logo, introduziram no território um terceiro elemento, o africano, que traz profundas transformações à sociedade colonial incipiente. Os escravos africanos tentam, apesar de tudo, preservar seus costumes, os traços de sua cultura, e quando fogem e se reúnem em quilombos, refazem sua vida, tanto quanto possível, como dantes em África, como foi exemplo notável o Quilombo dos Palmares.¹

O branco (português) e sua cultura (considerada soma total de conhecimento e modo típico de vida de um povo) eram elementos de grande plasticidade, o que possibilitara viver em contacto com os negros e índios. Assim, a população da colônia se forma envolvida num entrelaçamento de várias culturas, várias entre os índios (ou, pelo menos, vários estágios de uma mesma cultura), várias entre os negros e a branca européia. Desse modo, o processo de aculturação, no Brasil, não se deu apenas entre três culturas típicas, mas entre várias, em diversos momentos, decorrendo daí uma cultura tipicamente brasileira, com grande contribuição do elemento africano e pouca do índio. Depois, no entanto, a cultura ocidental, com sua técnica mais desenvolvida e apurada, foi oprimindo a cultura negra, de

tal forma que o negro teve que abandonar a sua por aquela, aproximando-se, assim, da cultura portuguesa. Mais tarde — na segunda metade do séc. XIX — a imigração italiana, japonesa, alemã, especialmente, introduzira matizes na cultura em formação, mormente nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Além do contato das várias manifestações culturais em choque no Brasil colonial, houve um fato de extraordinária importância para a formação da nacionalidade brasileira: *o contato físico entre as raças em fricção*. Disso originou-se o *mestiço*. Deu-se, então, a formação étnica brasileira, porque o Brasil é, antes de tudo, um país de mestiços. E foram eles que desempenharam os papéis mais salientes nos movimentos nacionalistas do País. A evolução da composição étnica do nosso povo mostra-o muito bem: na época da Independência, a população do Brasil era de cerca de 3.960.800 habitantes, 1.147.500 escravos e 2.813.300 livres; em 1850, já era calculada em 8.020.000, sendo 2.500.000 escravos e 5.520.000 livres; em 1872, o recenseamento computou 10.112.061 habitantes, com 1.510.806 escravos e 8.601.255 livres. A abolição da escravatura operava novas alterações populacionais. De um lado, começam as correntes imigratórias, que vêm modificar a composição da população, aumentando consideravelmente a população branca em relação aos demais componentes, à vista do censo de 1872, que acusara: 3.818.403 *brancos*; 3.833.015 *mestiços*; 3.970.509 *negros*; por influência das correntes imigratórias, em 1890 a composição já era diferente: 6.302.198 *brancos*; 4.638.495 *mestiços*; 2.097.426 *negros*. Como a imigração não cessou, tanto que até 1970 se contam cerca de cinco milhões e quinhentos mil imigrantes, essa composição permanece mais ou menos estável, com tendência a diminuir relativamente à população negra, com a miscigenação contínua, e a aumentar, também relativamente, os mestiços. Essa população, quase toda, integra a nacionalidade brasileira, graças aos critérios que favorecem a sua aquisição, fundada no *ius solis* e na possibilidade da obtenção, sem grandes entraves, da nacionalidade secundária.

2. Fonte constitucional do direito de nacionalidade

Os modos de aquisição da nacionalidade brasileira estão previstos no art. 12 da Constituição. Só esse dispositivo diz quais são os brasileiros, distinguindo-os em dois grupos, com consequências jurídicas relevantes: os *brasileiros natos*, que correspondem aos de nacionalidade primária (art. 12, I), e os *brasileiros naturalizados*, que são os que adotam, como segunda nacionalidade, a do Brasil (art. 12, II).

Dois diplomas de lei ordinária integram esse dispositivo, especialmente quanto à forma de aquisição da nacionalidade secundária,

1. Cf. Edison Carneiro, *O Quilombo dos Palmares*, 2ª ed., São Paulo, Ed. Nacional, 1958; Ernesto Ennes, *As guerras dos Palmares*, v. I, São Paulo, Ed. Nacional, 1938.

perda e aquisição da nacionalidade. São a Lei 818, de 18.9.49 (revogada no que tange à condição jurídica do estrangeiro, inclusive naturalização, pelo Decreto-lei 941/69, já revogado pelo *Estatuto dos Estrangeiros* — Lei 6.815, de 19.8.80, com alterações da Lei 6.964, de 9.12.81, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil).

3. Os brasileiros natos

A Constituição reputa *brasileiro nato* aquele que adquire a nacionalidade brasileira pelo *fator nascimento*. É dizer: *brasileiro nato* é quem nasce na República Federativa do Brasil. Corresponde ao titular da *nacionalidade brasileira primária*, para cujo reconhecimento nossas constituições sempre adotaram o critério do *ius solis*, com ligeiras atenuações. Mas não se disse acima que brasileiro nato é só o que nasce no território brasileiro. O art. 12, I, da Constituição, e só ele, é que dá os critérios e pressupostos para que alguém seja considerado necessariamente, e de direito, brasileiro nato. Por ele se vê que não só o *ius solis* é fonte da nacionalidade primária entre nós; há concessões ao princípio do *ius sanguinis* combinado com outros elementos.

O exame daquele dispositivo revela quatro situações definidoras da nacionalidade primária no Brasil, reputando-se *brasileiros natos*:

(1) *os nascidos na República Federativa do Brasil* (regra do *ius solis*; melhor teria sido manter a expressão tradicional: *os nascidos no território brasileiro*), quer sejam filhos de pais brasileiros ou de pais estrangeiros, pois a origem do sangue aqui não importa, excetuados, porém, aqueles que sejam filhos de pais estrangeiros, quando estes estejam, no Brasil, a *serviço de seu país*; nesta ressalva, abre-se exceção ao *ius solis*, prevalecendo a regra do *ius sanguinis* combinada com o fato de o pai ou mãe estar a serviço de seu país; se este, no entanto, estiver aqui por conta própria, ou estiver a serviço de outro país *que não o seu*, seu filho, aqui nascido, será brasileiro nato. Cumpre, por outro lado, saber o *que se entende por República Federativa do Brasil* (e aqui é que se vê que a mudança de terminologia foi inadequada), para o fim de determinação da nacionalidade de quem nela nasce. *República Federativa do Brasil*, já vimos antes, é expressão que envolve o nome do Estado, sua organização territorial, a organização de seus poderes e o nome do País. Nessa extensão, compreende o *território*, que é o limite espacial dentro do qual o Estado exerce de modo efetivo e exclusivo o poder de império sobre as pessoas e bens. Nele se incluem: (a) as terras delimitadas pelas fronteiras geográficas, com rios, lagos, baías, golfos, ilhas, bem como o espaço aéreo e o mar territorial, formando o território propriamente dito; (b) os navios e aeronaves de guerra brasileiros, onde quer que se encontrem; (c) os

navios mercantes brasileiros em alto mar ou de passagem em mar territorial estrangeiro; (d) as aeronaves civis brasileiras em vôo sobre o alto mar ou de passagem sobre águas territoriais ou espaços aéreos estrangeiros;²

(2) *os nascidos no exterior, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil* (regra do *ius sanguinis* combinada com serviço do Brasil). Faz-se, aí, concessão ao princípio do *ius sanguinis*, pois a nacionalidade brasileira é reconhecida não em decorrência do nascimento no território pátrio, mas em função da nacionalidade do pai ou da mãe (ou, evidentemente, de ambos), embora não seja apenas essa a circunstância determinante, mas o fato de estar qualquer deles *a serviço da República Federativa do Brasil* (de qualquer entidade de Direito Público brasileira: União, Estado, Município, Distrito Federal, Território e até de entidades de administração indireta). Como se vê, o *ius sanguinis* aqui só importa como elemento vinculativo do genitor ou genitora à República Federativa do Brasil; utiliza-se desse critério, nesse passo, para favorecer a aquisição da nossa nacionalidade primária. Na hipótese examinada antes, dele se servira para recusá-la, em respeito às regras de relação internacional, pois se supõe que a pessoa a serviço de seu país não deve ter sua situação de nacionalidade modificada por outro Estado, mormente pelo Estado onde serve, porquanto, além do mais, isso poderia colocá-la em posição de suspeição para continuar a prestar o serviço. Esclareça-se, por oportuno, que não importa a natureza da nacionalidade do pai ou da mãe nem a da filiação, para que decorra o efeito previsto. Tanto faz que o pai ou a mãe seja nato ou naturalizado; é preciso, no entanto, que tenha nacionalidade brasileira no momento do nascimento do filho, para que este seja tido como brasileiro nato. Se for filho póstumo apura-se a nacionalidade brasileira do pai ou da mãe ao tempo da concepção.³ O que interessa, por outro lado, é que a pessoa seja *nascida* de pai ou mãe brasileiros. Isso envolve o disposto no art. 227, § 6º, segundo o qual os filhos, *havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações*, logo, qualquer que seja a origem da relação filial; a despeito de o texto usar o termo *nascido*, que indica filiação natural, parece que uma interpretação sistemática, com base no art. 227, não pode senão levar à conclusão supra; quanto aos nascidos fora da relação matrimonial, amparados pela origem sanguínea do pai ou mãe, a questão se resume a que a nacionalidade, então, só será auferida com a legitimação ou reconhecimento, que tem efi-

2. Cf. Dardeau de Carvalho, *Nacionalidade e cidadania*, p. 57.

3. Cf. Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. IV/450 e 451.

cácia *ex tunc*, ou seja, desde o nascimento, e não desde o dia do reconhecimento.⁴ Quanto à filiação por adoção, também referida no art. 227, tudo fica na dependência de verificar-se a legitimidade do procedimento adotivo; válida a adoção, o adotado adquire a condição de nacional como se filho havido da relação matrimonial;

(3) *os nascidos no exterior, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira* (regra do *ius sanguinis* com opção). Esse modo de adquirir a nacionalidade primária já vem da Constituição do Império (art. 6º, II), que não exigia opção, só filiação e residência; assim, também, a Constituição de 1891 (art. 69, 2º); ambas, porém, só concediam a nacionalidade ao filho de brasileira, quando ilegítimo, condição que desapareceu nas constituições subseqüentes. Além disso, a de 1934 suprimiu o requisito de vir o interessado a residir no Brasil; bastava ser nascido de brasileiros (pai ou mãe) e optar pela nacionalidade brasileira ao atingir a maioridade (art. 106, b); tal foi mantido na Carta de 1937 (art. 115, b). A de 1946 reuniu todos os requisitos das anteriores (art. 129, II, 2ª parte); as de 1967 (art. 140, I, c) e de 1969 (art. 145, I, c) seguiram a de 1946; a atual (art. 12, I, c) manteve esses requisitos, mas eliminou a condição temporal para a opção, que era de quatro anos após a maioridade. Nova redação foi dada ao dispositivo pela Emenda Constitucional de Revisão 3/94, suprimindo os requisitos temporais e de maioridade, de modo que a aquisição da nacionalidade brasileira por opção ficou sujeita a quatro condições: (a) nascimento no exterior ("no estrangeiro", diz o art. 12, I, c); (b) ser nascido de brasileiro ou brasileira, nato ou naturalizado; (c) vir, a qualquer tempo, residir no Brasil; (d) opção, também a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. Estruturou-se, assim, um modo de aquisição da nacionalidade primária, misto de *ius sanguinis* e vínculo territorial e manifestação da vontade do interessado, o que, por isso também, misturou elementos de aquisição primária com a secundária.

Manifestada a opção, não se pode recusar o reconhecimento da nacionalidade. Por isso, aqui antes de nacionalidade por opção, temos *nacionalidade potestativa*,⁵ pois o efeito pretendido depende exclusivamente da vontade do interessado.

Um problema que aflora consiste em saber qual a condição jurídica do optante, antes da opção. Ocorrendo esta, no termo indicado, concretiza-se, em definitivo, a nacionalidade primária, pois a opção

4. Idem, p. 452.

5. Cf. Humberto J. La Roche, *Instituciones constitucionales del Estado venezolano*, p. 367.

no caso não é formativa da nacionalidade, como bem ensina Pontes de Miranda, mas de sua definitividade.⁶ Vale dizer, então, que ele já era brasileiro nato, condição que se perdia, nos termos da Constituição anterior, se não exercesse a opção no prazo de quatro anos ali estabelecido. Mas agora não existe mais prazo, de sorte que o interessado poderá ficar a vida inteira sem optar. E agora? Agora parece que, dos termos do vigente texto constitucional, decorre, como antes, que o momento da fixação da residência no País constitui o fato gerador da nacionalidade, que fica sujeita a uma condição confirmativa, a *opção*, mas, como não há mais prazo para tal, a condição de brasileiro nato fica suspensa até a implementação da condição. A legislação ordinária terá que ser revista para reelaborar-se em função destas alterações, incluindo as da ECR-3/94. Fica sempre o problema sério da posição do nascido de pais brasileiros, no exterior, antes de vir a residir no Brasil, que, nesse caso, não é reputado brasileiro, o que o coloca, em alguns casos, carente de nacionalidade, situação essa que já merecera crítica de Pimenta Bueno, ao comentar o art. 6º, II, da Constituição do Império: "Daí resulta o absurdo de ficarem os filhos dos brasileiros que nascerem em França ou outros países estrangeiros sem pátria, porquanto as leis destes estados reconhecem a sua qualidade brasileira, e por isso mesmo não lhes dão a nacionalidade francesa ou outra; e o Brasil de sua parte não reconhece, ao menos antes que abandonando seus negócios venham estabelecer domicílio no império! Nesse entretanto não terão pátria!"⁷

(4) *os nascidos no exterior, registrados em repartição brasileira competente*. O estudioso atento há de se lembrar que a alínea c do inc. I do art. 12 estabelecia em sua primeira parte que seriam natos também os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que fossem registrados em repartição brasileira competente, regra que mereceu nosso comentário nas edições anteriores deste livro, quando mostramos tratar-se do acolhimento do *ius sanguinis*, embora encoberto por uma extensão de extraterritorialidade com o registro em repartição brasileira no exterior (consulado). Esse modo de aquisição da nacionalidade originária, criado pela Constituição de 1967, foi agora suprimido daquele dispositivo da ECR-3/94. Não se tem, nos anais do processo revisional, nenhuma justificativa dessa supressão, porque ela veio no bojo de um acordo parlamentar.

Pode-se estranhar que se tenha eliminado uma possibilidade da aquisição da nacionalidade originária que favorecia o brasileiro. A existência dessa possibilidade poderia gerar um brasileiro nato que

6. Ob. cit., p. 414.

7. Cf. *Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império*, p. 444.

nada teria com o Brasil, já que a concessão da nacionalidade, no caso, não estava na dependência de residência no território brasileiro, e, assim, poderia ocorrer até que um brasileiro nato nunca viesse a conhecer seu País e talvez nem se expressasse na língua portuguesa. Essa circunstância pode ter levado o constituinte revisor a eliminar o permissivo, já que tornou mais favorável a aquisição da nacionalidade brasileira por opção com a residência no País. Com essa mudança ficou reforçado o princípio da real vinculação territorial para a aquisição da nacionalidade brasileira nata.

Contudo, a supressão daquela possibilidade de registro consular pode trazer embaraço a filhos de brasileiros nascidos em Estados que prestigiem o princípio do *ius sanguinis*, caso em que eles ficarão sem nacionalidade. A providência, como anotamos nas edições anteriores, evitava que filho de brasileiro se tornasse *heimatlos*. Essa é uma situação intolerável para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estatui que todos têm direito a uma nacionalidade (art. XV, 1).

4. Os brasileiros naturalizados

A Constituição prevê a aquisição da nacionalidade secundária, pelo processo de *naturalização*, no art. 12, II. Não mais repete o texto do art. 69, IV e V, da Constituição de 1891, que concedeu *naturalização tácita* aos estrangeiros que, achando-se no Brasil em 15.11.1889, não declarassem, dentro em seis meses, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem, bem como aos estrangeiros que tivessem filhos brasileiros. A repetição seria, de fato, desnecessária, porque, depois de cem anos, não deve haver mais qualquer beneficiário daquela disposição, e, se houver, sua situação de brasileiro já está consolidada, sem retorno.

Agora, só se reconhece a *naturalização expressa*, aquela que depende de requerimento do naturalizando, e compreende duas classes: (a) *ordinária* e (b) *extraordinária*, da qual a Constituição dispôs apenas sobre uma forma, deixando de prever as baseadas na *radicação precoce* e na *conclusão de curso superior*, por considerar o constituinte que a lei referida no art. 12, II, já o faz;⁸ o que diminui a certeza e estabilidade dessas duas formas de naturalização. Delas, contudo, trataremos, porque a lei que as prevê continua a vigorar.

8. É o que consta dos arts. 115, § 2º, e 116 da Lei 6.964/81. O art. 115, § 2º, I, reconhece a naturalização em razão de *radicação precoce*, e o II, a naturalização em razão de *conclusão de curso superior*. O art. 116 complementa o art. 115, § 2º, I. A esses textos da lei ordinária remetemos o leitor, não cabendo mais discuti-los aqui, como fizemos nas edições anteriores deste livro, porque a Constituição já não contempla a matéria, como faziam as outras.

A *naturalização ordinária* é a que se concede ao estrangeiro, residente no país, que preencha os requisitos previstos na lei de naturalização, exigidas aos originários de países de língua portuguesa (ou seja: originários de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné Bissau, Açores, Cabo Verde, Príncipe, Goa, Gamão, Dio, Macau e Timor) apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral (art. 12, II, a).

A *naturalização extraordinária* prevista, expressamente, na Constituição é a reconhecida aos *estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira* (redação da ECR-3/94, que reduziu o tempo de 30 para 15 anos). É uma naturalização que se adquire pelo simples fato *residência, no País, por quinze anos ininterruptos, sem condenação penal*. É justa, porque quem vive mais de quinze anos ininterruptos no País, com vida digna, convivendo e colaborando com os brasileiros, merece essa consideração da Constituição, que, no entanto, não quis impor-lhes uma naturalização tácita, respeitando sua condição de originário de outra pátria, mas facilitando-a com o mero requerimento, simples manifestação de vontade. E isso é uma prerrogativa à qual o interessado tem direito subjetivo, preenchidos os pressupostos: quinze anos de residência ininterruptos e não condenação penal.

A naturalização não importa a aquisição da nacionalidade brasileira pelo cônjuge e filhos do naturalizado, nem autoriza estes a entrar ou radicar-se no Brasil, sem que satisfaçam as exigências legais.

5. Condição jurídica do brasileiro nato

A condição de brasileiro nato dá algumas vantagens ao nacional em relação ao brasileiro naturalizado, como a possibilidade de exercer todos os direitos conferidos no ordenamento pátrio, observados os critérios para isso, mas também fica sujeito aos deveres impostos a todos.

As distinções que há entre a condição de brasileiro nato e naturalizado são só aquelas consignadas na Constituição. Nisso, ela foi expressa no art. 12, § 2º, segundo o qual *"a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição"*. Não precisava dizê-lo; reforça, contudo, o princípio da não distinção e não preferências entre ambas as categorias de brasileiros (arts. 3º, IV, e 19, III) e o princípio da igualdade entre elas, que encontra arrimo no *caput* do art. 5º, de modo que qualquer tratamento desigual, para situações iguais, envolvendo-as, infringe o princípio da isonomia consignado naqueles dispositivos.

A regra a seguir nessa matéria é a seguinte: se a Constituição só fala em *brasileiro*, sem qualificativo, para qualquer fim, a expressão inclui o *nato* e o *naturalizado*; se quer excluir este último, expressamente menciona *brasileiro nato*.

6. Condição jurídica do brasileiro naturalizado

O princípio supra-indicado já seria suficiente para nos orientar sobre o assunto. Não será, porém, sem proveito explicitar as pouquíssimas limitações ao brasileiro naturalizado, que são só aquelas — repita-se — restrita e expressamente enunciadas pela Constituição, verificáveis nas hipóteses resumidas em seguida:

(1) são privativos de *brasileiro nato* os cargos de: Presidente e Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministro do Supremo Tribunal Federal; carreira diplomática; oficial das Forças Armadas; Ministro da Defesa (art. 12, § 3º);

(2) também é privativa de *cidadão brasileiro nato* a função de membro do Conselho da República (art. 89, VII);

(3) o brasileiro nato não pode ser extraditado, o que pode ocorrer com o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei (art. 5º, LI);

(4) o brasileiro *naturalizado* há menos de dez anos não pode ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 222).

7. Perda da nacionalidade brasileira

Perde a nacionalidade o brasileiro que: (1) *tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional*; (2) *adquirir outra nacionalidade* (art. 12, § 4º), salvo nos casos de: (a) *reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira*; (b) *imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis* (redação da ECR-3/94).

O brasileiro só perde a nacionalidade por uma das causas enumeradas acima; entre elas já não se incluem aquelas que constavam das constituições anteriores que declaravam que perderia a nacionalidade o brasileiro que aceitasse comissão, emprego ou pensão de governo estrangeiro, sem licença do Presidente da República.

O primeiro caso de perda da nacionalidade decorrerá da aplicação de pena principal ou acessória proferida em processo judicial,

em que se tenha propiciado ao interessado ampla defesa. Trata-se de *cancelamento de naturalização*, não de decretação de nulidade ou anulabilidade. O cancelamento pressupõe naturalização válida e eficaz. Só pode ocorrer por sentença judicial, comprovado o *exercício de atividade nociva ao interesse nacional*.⁹ O efeito do cancelamento é de desconstituição da naturalização, e atinge o ato com o trânsito em julgado da sentença, portanto é efeito *ex nunc*.

A segunda causa de perda da nacionalidade, indicada no art. 12, § 4º, II, decorre da aquisição de outra por *naturalização voluntária*, entendendo-se, aqui, por naturalização toda forma de aquisição de nacionalidade secundária dependente da vontade do interessado. Por outro lado, a voluntariedade compreende tanto o *pedido* como a *aceitação* da naturalização oferecida por outro Estado. A nova redação dada ao dispositivo a rigor não altera a aceção anterior, mas tem o sentido analítico de explicitar o que já se continha implicitamente na regra que declarava que a nacionalidade se perdia pela naturalização voluntária; logo, se a aquisição de outra nacionalidade não fosse voluntária, como agora se explicita nas alíneas acrescentadas, não haveria tal perda. Já dizíamos antes dessas mudanças que não estavam envolvidas as hipóteses de dupla nacionalidade originária nem a da mulher brasileira que adquire a nacionalidade do marido, só pelo fato casamento, como se dá com a estrangeira que contrai matrimônio com um italiano residente ou não na Itália (*ius communicatio*), e na hipótese de outorga automática da nacionalidade por outro Estado. Mas a explicitação é útil porque espanca dúvidas e porque a hipótese da alínea *b* fica mais bem caracterizada.

8. Reaquisição da nacionalidade brasileira

Aquele que teve a naturalização cancelada nunca poderá recuperar a nacionalidade brasileira perdida, salvo se o cancelamento for desfeito em ação rescisória. O que a perdeu por naturalização voluntária poderá readquiri-la, por decreto do Presidente da República, se estiver domiciliado no Brasil (Lei 818/49, art. 36). Aquele que, eventualmente, a tenha perdido, nos termos de constituições anteriores, por ter aceitado comissão, emprego ou pensão de governo estrangeiro, sem licença do Presidente da República, poderá agora recuperá-

9. A ação de cancelamento da naturalização tem seu procedimento previsto nos arts. 24 a 34 da Lei 818/49. Nesse caso ataca-se o ato de naturalização diretamente, sob o fundamento de que o naturalizado exerceu atividade nociva ao interesse nacional. Mas o cancelamento pode ser objeto também de pena acessória, no caso de condenação por crime contra o interesse nacional.

la sem mesmo renunciá-los, como se exigia antes, porquanto não constituiu mais causa de perda da nacionalidade.¹⁰

Cumpra-se notar que a re aquisição da nacionalidade opera a partir do decreto que a concede, não tendo efeito retroativo, mas o readquirente recupera a condição que perdera: se era brasileiro nato, voltará a ser brasileiro nato; se naturalizado, retomará essa qualidade.

Capítulo III

CONDIÇÃO JURÍDICA DO ESTRANGEIRO NO BRASIL

1. O estrangeiro. 2. Especial condição jurídica dos portugueses no Brasil. 3. Locomoção no território nacional. 4. Aquisição e gozo dos direitos civis. 5. Gozo dos direitos individuais e sociais. 6. Não aquisição de direitos políticos. 7. Asilo político. 8. Extradicação. 9. Expulsão. 10. Deportação.

1. O estrangeiro

Reputa-se *estrangeiro*, no Brasil, quem tenha nascido fora do território nacional que, por qualquer forma prevista na Constituição, não adquirira a nacionalidade brasileira. Há os estrangeiros residentes no País e os não residentes. Aqueles integram a população brasileira e convivem com os nacionais sob o domínio da ordenação jurídico-política pátria. Só estes, portanto, nos interessam aqui, para o fim de delinear-lhes a condição jurídico-constitucional.

O princípio fundamental é o de que os estrangeiros, residentes no País, gozem dos mesmos direitos e tenham os mesmos deveres dos brasileiros. Essa paridade de condição jurídica é quase total no que tange à aquisição e gozo dos direitos civis. Há, no entanto, limitações, dada a sua ligação com o Estado e nacionalidade de origem, que lhes condicionam um estatuto especial, que lhes define a situação jurídica, quanto aos direitos e aos deveres.¹

2. Especial condição jurídica dos portugueses no Brasil

A Constituição, contudo, favorece os portugueses residentes no País. Esse favorecimento, para além de eventuais acordos internacionais, vem desde o art. 199 da Constituição revogada, segundo o qual, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 145 (hipóteses de cargos privativos de brasileiros natos), as pessoas naturais de nacionalidade portuguesa não sofreriam qualquer restrição em virtude da condição de nascimento, admitida a reciprocidade em favor de brasileiro.

10. O procedimento para a re aquisição da nacionalidade consta da Lei 818/49, art. 36 e seus parágrafos.

1. Cf. Lei 6.815/80, arts. 95 a 110, com as alterações da Lei 6.964/81.

A Constituição de 1988 reproduziu esse dispositivo de modo muito defeituoso e incompreensível, quando declarou que *aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato, salvo os casos previstos nesta Constituição*. Ora, se se ressalvam casos previstos na Constituição, então é porque não se lhes reconheciam os direitos inerentes aos brasileiros natos, pois, em relação a estes, a Carta Magna não tem ressalva alguma; ou, por outra, se se reconheciam a eles os direitos inerentes aos brasileiros natos, é porque não teria aplicação qualquer ressalva constitucional, incompreensível no caso. Agora, a ECR-3/94 conserta o dispositivo, ainda não muito bem, mas, pelo menos, possibilita entendimento dos limites dos direitos outorgados. Consta do § 1º do art. 12 emendado a regra do seguinte teor: *Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição*. Essa cláusula final ("salvo os casos previstos nesta Constituição") é típica dos limites impostos ao brasileiro naturalizado. Só estes é que ficam sujeitos a tais ressalvas. Portanto, o que a Constituição concede aos portugueses aqui residentes é a condição de brasileiro naturalizado. Quer dizer que não podem exercer nenhum cargo, função ou atividade que a Constituição confere expressamente a brasileiros natos. Não há reciprocidade que afaste essa limitação. Por conseguinte, seria muito mais simples se a Constituição houvesse dito claramente que *seriam atribuídos a eles os direitos inerentes aos brasileiros naturalizados*.

Dois são os pressupostos para que os portugueses possam gozar dos direitos oferecidos: (a) que tenham residência permanente no Brasil; (b) que haja reciprocidade, ou seja, que o ordenamento jurídico português outorgue a brasileiros o mesmo direito requerido. Observados os dois pressupostos, o português não precisa naturalizar-se brasileiro para auferir o direito correspondente. Sua condição, contudo, é inferior à do brasileiro naturalizado, que não está sujeito àqueles pressupostos.

Reciprocidade significa tratamento a ambas as partes inversamente correspondente. Diz-se recíproca a relação em que o sentido dos dois termos "A" e "B" subsiste inversamente um no outro: "A" em "B" e "B" em "A". Ela normalmente ocorre em situações concretas em que ambos os lados declaram que se dão reciprocamente os direitos ou vantagens que indicam. No entanto, a Constituição deixou a questão em aberto, ficando a reciprocidade dependente do que Portugal oferecer aos brasileiros lá residentes. A Constituição portuguesa, contudo, é que impõe limites. De fato, seu art. 15º declara:

"Aos cidadãos dos países de língua portuguesa podem ser atribuídos, mediante convenção internacional e em condições de reciprocidade, direitos não conferidos a estrangeiros, salvo o acesso à titularidade dos órgãos de soberania e dos órgãos de governo próprio das regiões autônomas, o serviço das forças armadas e a carreira diplomática".

Vê-se que o texto apenas faculta a outorga de direitos (*podem ser atribuídos*), o que deixa a critério do governo atribuir ou não, enquanto a Constituição brasileira outorga diretamente os direitos, ocorrendo os dois pressupostos assinalados. Isto é, se o português tiver residência permanente aqui e Portugal reconhecer a brasileiro um determinado direito, não reconhecido a estrangeiro, o português pode reivindicar igual tratamento aqui. A Constituição portuguesa submete a outorga do direito à convenção internacional e em condição de reciprocidade. A Constituição brasileira não exige convenção ou qualquer outro instrumento internacional. Dado lá um direito a brasileiro, o português adquire o mesmo direito aqui, salvo os casos em que se o reconhece expressamente apenas a brasileiro nato. A Constituição portuguesa ressalva o acesso à titularidade dos órgãos de soberania e dos órgãos de governo próprio das regiões autônomas, o serviço das forças armadas e a carreira diplomática. Órgãos de soberania são, nos termos do art. 113 daquela Constituição, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e os Tribunais. À vista disso, está excluído o acesso ao cargo de Presidente da República, aos cargos de Deputado, de Primeiro-Ministro, de Ministros e de Secretários e Subsecretários de Estado (arts. 153 e 186 da Constituição portuguesa). A Constituição brasileira admite a possibilidade de o português residente aqui ser (se houvesse reciprocidade): Ministro de Estado, Senador, Deputado federal e estadual, Governador de Estado, Secretário de Estado, Prefeito e Vereador. O acesso a esses cargos e funções, contudo, está vedado aos portugueses aqui residentes, porque a Constituição de Portugal não permite que se outorgue a brasileiro o direito e acesso a cargos e funções correspondentes.

3. Locomoção no território nacional

A *liberdade de locomoção no território nacional* é assegurada a qualquer pessoa no art. 5º, XV. O estrangeiro residente no País goza dessa liberdade como qualquer brasileiro; assim, também, o estrangeiro não residente, que tenha ingressado regularmente no País. Em tempo de paz a liberdade de locomoção dentro do território nacional é ampla.

A lei, contudo, disciplina o direito de qualquer pessoa entrar no território nacional, nele permanecer ou dele sair, só ou com seus bens

(art. 5º, XV). A lei, que estabelece esses preceitos em relação ao estrangeiro, é o *Estatuto dos Estrangeiros* (Lei 6.815/80), alterada pela Lei 6.964/81).

Entrada — Todo estrangeiro poderá entrar no Brasil, desde que satisfaça as condições estabelecidas naquela lei, a primeira das quais consiste na obtenção de *visto* de entrada, conforme o caso: de trânsito, de turista, temporário, *permanente*, de cortesia; oficial ou diplomático. O visto poderá ser extensivo a pessoas que vivam sob sua dependência. Não se concederá, porém, visto ao estrangeiro menor de dezoito anos (salvo se viajar acompanhado de responsável) nem a estrangeiros nas situações enumeradas no art. 7º da Lei 6.815/80.² O visto não cria direito subjetivo, mas mera expectativa de direito.

Permanência — Entende-se como *permanência* a estada do estrangeiro no Brasil, sem limitação de tempo, assim a quem obtenha o visto com o intuito de fixar-se definitivamente aqui, como ao que, obtendo visto de turista ou temporário, resolva permanecer no País definitivamente, desde que preencha as condições para o visto permanente. Há que registrar-se no Ministério da Justiça, sendo-lhe fornecida a chamada *carteira de identidade de estrangeiros* (Decreto-lei 499/69).

Saída — O estrangeiro, como qualquer pessoa, pode deixar o território nacional, com visto de saída. Se for registrado como permanente, poderá regressar independentemente de visto, se o fizer dentro de dois anos. Findo esse prazo, o reingresso no País, como permanente, dependerá da concessão de novo visto.

4. Aquisição e gozo dos direitos civis

O princípio é o de que a lei não distingue entre nacionais e estrangeiros quanto à aquisição e ao gozo dos direitos civis (CC, art. 3º). Há, porém, limitações aos estrangeiros estabelecidas na Constituição, de sorte que podemos asseverar que eles só não gozam dos mesmos direitos assegurados aos brasileiros quando a própria Constituição autorize a distinção. Mas ela começa por dar competência à União para legislar sobre *emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros* (art. 22, XV).

Assim, por exemplo, ela determina que a lei regule e limite a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física

2. Ou seja: considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais; anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada; condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira, ou que não satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

ou jurídica estrangeira e estabeleça os casos em que tais negócios dependam de autorização do Congresso Nacional (art. 190).³ É função também da lei disciplinar os investimentos de capital estrangeiro e regular remessas de lucros para o exterior (art. 172).

É vedado autorizar ou conceder a estrangeiros, mesmo a residentes, a pesquisa e a lavra de recursos minerais ou o aproveitamento de potencial de energia hidráulica (art. 176, § 1º). Igualmente, não podem ser proprietários de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nem responsáveis por sua administração e orientação intelectual (art. 222).

Observe-se, por fim, que a sucessão em bens estrangeiros situados no Brasil rege-se pela lei brasileira, sempre que lhe não seja mais favorável a lei pessoal do *de cuius* (art. 5º, XXXI).

Prevê-se, também, agora, que a lei estabelecerá os casos e condições em que estrangeiros podem adotar crianças brasileiras (art. 227, § 5º).

5. Gozo dos direitos individuais e sociais

A Constituição assegura aos *estrangeiros residentes no País* a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, tanto quanto aos brasileiros (art. 5º, *caput*). Não diz aí que assegura os direitos sociais, mas, em verdade, ela não restringe o gozo destes apenas aos brasileiros. Vê-se bem ao contrário, por exemplo, no referente aos direitos dos trabalhadores, que são extensivos a todos, *urbanos e rurais*, sem restrições (art. 7º). Por esse lado, o texto do art. 5º não é bom, porque abrange menos do que a Constituição dá.

Por outro lado, não é bem como ali se diz, porque ela própria admite restrições, conforme já vimos, quanto ao direito de propriedade de determinados objetos (empresas jornalísticas, imóveis rurais). Podemos acrescentar, aqui, outro exemplo mais caracteristicamente enquadrável no conceito de direitos e garantias individuais, qual seja a impossibilidade de intentar ação popular (art. 5º, LXXIII).

6. Não aquisição de direitos políticos

Os estrangeiros não adquirem *direitos políticos*, só atribuídos a brasileiros natos ou naturalizados. Portanto, não são alistáveis elei-

3. Essa norma dá fundamento à Lei 5.709, de 7.10.71, elaborada com base na Constituição revogada (art. 153, § 34), regulando a aquisição de imóvel rural por estrangeiros.

tores nem, por consequência, podem votar ou ser votados (art. 14, § 2º). Por isso também é que não podem ser membros de partidos políticos, que é uma prerrogativa da cidadania.

7. Asilo político

O *asilo político* consiste no recebimento de estrangeiros no território nacional, a seu pedido, sem os requisitos de ingresso, para evitar punição ou perseguição no seu país de origem por delito de natureza política ou ideológica. Cabe ao Estado asilante a classificação da natureza do delito e dos motivos da perseguição. É razoável que assim seja, porque a tendência do Estado do asilado é a de negar a natureza política do delito imputado e dos motivos da perseguição, para considerá-lo comum.

A Constituição prevê a concessão do asilo político sem restrições, considerado como um dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil (art. 4º, X).

A natureza do asilo tem merecido divergência, no que tange a saber se é de direito interno ou de direito internacional. Os EUA não reconhecem nem subscrevem a doutrina do asilo político como parte do direito internacional público. A Convenção sobre asilo político firmada na VII Conferência Interamericana concebeu-o como instituição de caráter humanitário, pelo que não fica sujeito a reciprocidade. Todos podem ficar sob sua proteção, seja qual for a nacionalidade a que pertençam, sem prejuízo das obrigações que, na matéria, tenha contraído o Estado de que façam parte (art. 3º). Já a Convenção firmada na X Conferência Interamericana decidiu que todo Estado tem o direito de conceder asilo, mas não se acha obrigado a concedê-lo, nem a declarar por que o nega (art. 2º). Tudo isso dá a idéia de que se trata de assunto interno. Contudo, a Constituição o ligou às relações internacionais, como vimos. Se a questão da concessão do asilo interfere com as regras do direito internacional, a condição de asilado constitui problema de direito interno, embora ela deva ser estabelecida de modo que o asilado se atenha à observância de deveres que sejam impostos pelo direito internacional. Assim é no Brasil (Leis 6.815/80 e 6.964/81). Por isso, o estrangeiro admitido no território nacional na condição de asilado político ficará sujeito, além dos deveres que lhe forem impostos pelo direito internacional, a cumprir as disposições da legislação vigente e as que o governo brasileiro fixar. Não poderá sair do País sem prévia autorização do governo brasileiro, sob pena de renúncia ao asilo e de impedimento de reingresso nessa condição.

8. Extradicação

É o ato pelo qual um Estado entrega um indivíduo, acusado de um delito ou já condenado como criminoso, à justiça de outro, que o reclama, e que é competente para julgá-lo e puni-lo.⁴

Compete à União legislar sobre *extradição* (art. 22, XV), vigorando atualmente sobre ela os arts. 76 a 94 da Lei 6.815/80 (alterada pela Lei 6.964/81), mas a Constituição traça limites à possibilidade de extradição quanto à pessoa acusada e quanto à natureza do delito. Veda, assim, a concessão de extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião, e a de brasileiro nato de modo absoluto, e a de brasileiro naturalizado, salvo em relação a crime comum cometido antes da naturalização⁵ ou envolvido em tráfico de entorpecentes e drogas afins (art. 5º, LI). É, portanto, inconstitucional o § 1º do art. 77 da Lei 6.815/80 ao declarar que o fato político não impedirá a extradição quando constituir, principalmente, infração da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir fato principal. Ora, o fato principal, para a tutela constitucional, é sempre o crime político. Este é que imuniza o estrangeiro da extradição. Logo, onde ele se caracterize, onde ele exista, predomina sobre qualquer outra circunstância, e, portanto, não cabe a medida, pouco importando haja ou não delito comum envolvido, que fica submerso naquele.⁶

Cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ordinariamente a extradição solicitada por Estado estrangeiro (art. 102, I, g). E a Lei 6.815/80 lhe atribui, com exclusividade, a apreciação do caráter da infração, dando-lhe ainda a faculdade de não considerar crimes políticos os atentados contra Chefes de Estado ou qualquer outra pessoa que exerça autoridade, assim como os atos de anarquismo, terrorismo, ou sabotagem, ou que importem propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a ordem política e social (art. 77, §§ 2º e 3º), de onde se pode perceber que a lei tem tais delitos como de natureza política; apenas admite que o Supremo, dadas as circunstâncias de fato, possa reconhecer neles outra qualificação, quando, então, a extradição é suscetível de ser concedida. Quanto ao terrorismo bem certo é que a Constituição embasa a posição da lei,

4. Cf. Hildebrando Accioly, *Manual de direito internacional público*, p. 105.

5. Essa autorização constitucional torna válida, pelo princípio da recepção, a ressalva do art. 77, I, da Lei 6.815/80, que já permitia a extradição de brasileiro naturalizado quando a aquisição dessa nacionalidade se verificasse após o fato que motivasse o pedido.

6. A Lei 6.815/80, no seu art. 77, acrescenta outras hipóteses de descabimento da extradição, às quais remetemos o leitor.

ao repudiá-lo (art. 4º, VIII) e condená-lo como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (art. 5º, XLIII). O Supremo saberá atuar com prudência e visão do sentido da garantia constitucional, de sorte que, em havendo dúvida quanto à natureza política do delito, se decida por esta.

9. Expulsão

A extradição, como vimos, é modo de entregar o estrangeiro a outro Estado por delito nele praticado. A *expulsão* é um modo coativo de retirar o estrangeiro do território nacional por delito ou infração ou atos que o tornem inconveniente. Fundamenta-se na necessidade de defesa e conservação da ordem interna ou das relações internacionais do Estado interessado. A Constituição confere competência à União para legislar sobre ela (art. 22, XV). É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranqüilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à convivência e aos interesses nacionais, entre outros casos previstos em lei.⁷ Reserva-se exclusivamente ao Presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade da expulsão ou sua revogação, que se fará por decreto. Mas o ato expulsório fica sujeito ao controle de constitucionalidade e de legalidade pelo Poder Judiciário.

É que não se procederá a expulsão, se implicar extradição inadmitida pelo Direito brasileiro,⁸ ou quando o estrangeiro tiver: (a) cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de cinco anos, ou (b) filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente (Lei 6.815/80, art. 75).

10. Deportação

É outro modo de devolver o estrangeiro ao exterior. Consiste na saída compulsória do estrangeiro. Fundamenta-se no fato de o estrangeiro entrar ou permanecer irregularmente no território nacional.

Os dois institutos estudados anteriormente apóiam-se na prática do delito, distinguindo-se quanto ao local de sua ocorrência: se fora (extradição), se no território nacional (expulsão). A *deportação*

7. Cf. Lei 6.815/80, com alteração da Lei 6.964/81, arts. 65 a 75, sobre outros casos e processo de expulsão.

8. A expulsão não constitui sucedâneo da extradição, nem pode degenerar-se nesta, evidentemente.

não decorre da prática de delito em qualquer território, mas do não cumprimento dos requisitos para entrar ou permanecer no território,⁹ quando o estrangeiro não se retirar voluntariamente no prazo determinado. Far-se-á a deportação para o país de origem ou de procedência do estrangeiro, ou para outro que consinta recebê-lo. Não sendo ela exequível, ou existindo indícios sérios de periculosidade ou indesejabilidade do estrangeiro, proceder-se-á à sua expulsão. Mas não se dará a deportação se esta implicar extradição vedada pela lei brasileira (Lei 6.815/80).

Não há deportação nem expulsão de brasileiro. O envio compulsório de brasileiro para o exterior constituía *banimento*, que é pena excepcional, felizmente há muito banida do sistema brasileiro, proibido no art. 5º, XLVII, d.

9. Cf. art. 5º, XV, segunda parte, que prevê o condicionamento da lei para entrada e permanência no território nacional. Se os requisitos da lei não forem observados é que cabe a deportação.

Título V

Direito de cidadania

Capítulo I

DOS DIREITOS POLÍTICOS

1. Conceito e abrangência. 2. Direitos políticos, nacionalidade e cidadania. 3. Modalidades de direitos políticos. 4. Aquisição da cidadania.

1. Conceito e abrangência

O regime representativo desenvolveu técnicas destinadas a efetivar a designação dos representantes do povo nos órgãos governamentais. A princípio, essas técnicas aplicavam-se empiricamente nas épocas em que o povo deveria proceder à escolha dos seus representantes. Aos poucos, porém, certos modos de proceder foram transformando-se em regras, que o direito positivo sancionara como normas de agir. Assim, o direito democrático de participação do povo no governo, por seus representantes, acabara exigindo a formação de um conjunto de normas legais permanentes, que recebera a denominação de *direitos políticos*.

A Constituição traz um capítulo sobre esses direitos, no sentido indicado acima, como *conjunto de normas que regula a atuação da soberania popular* (arts. 14 a 16). Tais normas constituem o desdobramento do princípio democrático inscrito no art. 1º, parágrafo único, quando diz que o poder emana do povo, que o *exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente*.¹

A Constituição emprega a expressão *direitos políticos*² em seu sentido estrito, como conjunto de regras que regula os problemas eleito-

1. Inclui-se também entre os direitos da cidadania a previsão do mesmo dispositivo, segundo o qual o *poder pode ser exercido diretamente pelo povo*, que já estudamos noutro lugar. A doutrina, fundamentos e crítica do regime representativo e as bases da democracia participativa já foram apresentadas na Primeira Parte, título II, capítulo III, ns. 9 a 11.

2. Cumpre observar que a Constituição dá apenas os princípios básicos dos direitos políticos. Seus pormenores terão que constar do Código Eleitoral, da lei comple-

rais, quase como sinônima de direito eleitoral. Em acepção um pouco mais ampla, contudo, deveria incluir também as normas sobre partidos políticos.

Pimenta Bueno, que é, sem sombra de dúvida, um dos mais lúcidos publicistas brasileiro de todos os tempos, já conceituava os direitos políticos em face da Constituição do Império, naquele sentido estrito, como "as prerrogativas, os atributos, faculdades ou poder de intervenção dos cidadãos ativos no governo de seu país, intervenção direta ou só indireta, mais ou menos ampla, segundo a intensidade do gozo desses direitos".³ Nesse sentido, podemos, hoje, dizer que os *direitos políticos consistem na disciplina dos meios necessários ao exercício da soberania popular*, o que, em essência, equivale, para o regime representativo, à noção dada por Rosah Russomano, para quem os "direitos políticos, visualizados em sua acepção restrita, encarnam o poder de que dispõe o indivíduo para interferir na estrutura governamental, através do voto".⁴

2. Direitos políticos, nacionalidade e cidadania

Viu-se que Pimenta Bueno, de acordo com o art. 90 da Constituição do Império, falava em *cidadão ativo* para diferenciar do cidadão, em geral, que, então, se confundia com o nacional (arts. 6º e 7º). Cidadão ativo era o titular dos direitos políticos, que a referida Constituição também concebia em sentido estrito (art. 91). As constituições subsequentes misturaram ainda mais os conceitos.⁵ A de 1937 começou a distinção que as de 1967/1969 completaram, abrindo capítulos separados para a *nacionalidade* (arts. 140 e 141) e para os *direitos políticos* (arts. 142 a 148), deixando de fora os *partidos políticos* (art. 149).

Hoje, é desnecessária a terminologia empregada por Pimenta Bueno, para distinguir o nacional do cidadão, pois não mais se confundem nacionalidade e cidadania. Aquela é vínculo ao território estatal por nascimento ou naturalização; esta é um *status* ligado ao regime político.⁶ *Cidadania*, já vimos,⁷ qualifica os participantes da vida do Estado, é atributo das pessoas integradas na sociedade esta-

mentar de inelegibilidades e da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que, em face das novas normas constitucionais sobre o assunto, deverão sofrer profunda reelaboração. Esses diplomas albergam normas de natureza materialmente constitucional.

3. Cf. *Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império*, p. 458.

4. Cf. *Curso de direito constitucional*, p. 186.

5. Cf. a de 1891, arts. 69 a 71; a de 1934, arts. 106 a 112; a de 1937, arts. 115 a 121; a de 1946, arts. 129 a 140; a de 1967, arts. 141 e 142 a 149; a de 1969, arts. 145 a 152.

6. Cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de direito constitucional*, 17ª ed., cit., p. 99.

7. Cf. Primeira parte, título II, capítulo II, n. 5.

tal, atributo político decorrente do direito de participar no governo e direito de ser ouvido pela representação política. *Cidadão*, no direito brasileiro, é o indivíduo que seja titular dos direitos políticos de votar e ser votado e suas consequências. *Nacionalidade* é o conceito mais amplo do que cidadania, e é pressuposto desta, uma vez que só o titular da nacionalidade brasileira pode ser cidadão.

3. Modalidades de direitos políticos

O núcleo fundamental dos direitos políticos consubstancia-se no direito eleitoral de votar e ser votado, embora não se reduza a isso, mesmo quando se toma a expressão no seu sentido mais estreito.

Essa característica fundamental dos direitos políticos possibilita falar em *direitos políticos ativos* e *direitos políticos passivos*, sem que isso constitua divisão deles. São apenas *modalidades do seu exercício* ligadas à capacidade eleitoral ativa, consubstanciada nas condições do direito de votar, e à *capacidade eleitoral passiva*, que assenta na elegibilidade, atributo de quem preenche as condições do direito de ser votado. Os direitos políticos ativos (ou direito eleitoral ativo) cuidam do eleitor e sua atividade; os direitos políticos passivos (ou direito eleitoral passivo) referem-se aos elegíveis e aos eleitos. A distinção tem alguma importância prática, porque gera direitos fundados em pressupostos peculiares.

Não se deve, porém, confundir a distinção dos direitos políticos em ativos e passivos com outras duas modalidades, que se podem denominar *direitos políticos positivos* e *direitos políticos negativos*, que servirão de epígrafes aos dois capítulos seguintes. Os primeiros dizem respeito às normas que asseguram a participação no processo político eleitoral, votando ou sendo votado, envolvendo, portanto, as modalidades ativas e passivas, referidas acima. O segundo grupo constitui-se de normas que impedem essa atuação e tem seu núcleo nas inelegibilidades.

4. Aquisição da cidadania

Os direitos de cidadania adquirem-se mediante *alistamento eleitoral* na forma da lei. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição da pessoa como eleitor perante a Justiça Eleitoral. A qualidade de eleitor decorre do alistamento, que é *obrigatório* para os brasileiros de ambos os sexos maiores de dezoito anos de idade e *facultativo* para os analfabetos, os maiores de setenta anos e maiores de dezesseis e menores de dezoito anos (art. 14, § 1º, I e II). Não são

alistáveis como eleitores os estrangeiros e os conscritos durante o serviço militar obrigatório (art. 14, § 2º). *Conscritos* são os convocados para o serviço militar obrigatório; deixam de sê-lo se se engajarem no serviço militar permanente, de tal sorte que, hoje, soldados engajados, cabos, sargentos, suboficiais e oficiais das Forças Armadas e Polícias Militares são obrigados a se alistarem como eleitores.

O alistamento eleitoral depende de iniciativa da pessoa, mediante requerimento, em fórmula que obedece ao modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que apresentará instruído com comprovante de sua qualificação e de idade, dezesseis anos, no mínimo, até à data de eleição marcada; essa última circunstância não consta da Constituição mas é razoável admiti-la como no Direito Constitucional revogado. As providências para o alistamento hão de efetivar-se, para o brasileiro nato, até os dezenove anos de idade e, para o naturalizado, até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, sob pena de incorrerem em multa.

Pode-se dizer, então, que a cidadania se adquire com a obtenção da qualidade de eleitor, que documentalmente se manifesta na posse do *título de eleitor* válido. O *eleitor* é cidadão, é titular da cidadania, embora nem sempre possa exercer todos os direitos políticos. É que o gozo integral destes dependem do preenchimento de condições que só gradativamente se incorporam no cidadão. Não nos parece que isso importe em graus de cidadania política. Esta é atributo jurídico-político que o nacional obtém desde o momento em que se torna eleitor. Mas é certo que alguns direitos políticos só se adquirem em etapas sucessivas. Nestes casos, podemos admitir que a aquisição dos direitos políticos se opera por graus, apenas para denotar o fato de que a plenitude de sua titularidade se processa por etapas: (1) aos 16 anos de idade, o nacional já pode alistar-se tornando-se titular do direito de votar; (2) aos 18 anos, é obrigado a alistar-se, tornando-se titular do direito de votar, se não o fizera aos 16, e do direito de ser eleito para Vereador; (3) aos 21 anos, o cidadão (nacional eleitor) incorpora o direito de ser votado para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Deputado Distrital (Distrito Federal), Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; (4) aos 30 anos, obtém a possibilidade de ser eleito para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; (5) finalmente, aos 35 anos o cidadão chega ao ápice da cidadania formal com o direito de ser votado para Presidente e Vice-Presidente da República e para Senador Federal (art. 14, § 3º).

Capítulo II

DOS DIREITOS POLÍTICOS POSITIVOS

I. CONCEITO E INSTITUIÇÕES: 1. Conceito. 2. Instituições. II. DIREITO DE SUFRÁGIO: 3. Conceito e funções do sufrágio. 4. Formas de sufrágio. 5. Natureza do sufrágio. 6. Titulares do direito de sufrágio. 7. Capacidade eleitoral ativa. 8. Exercício do sufrágio: o voto. 9. Natureza do voto. 10. Caracteres do voto. 11. Organização do eleitorado. 12. O corpo eleitoral. 13. Elegibilidade e condições de elegibilidade. 14. Os eleitos e o mandato político — Remissão. III. SISTEMAS ELEITORAIS: 15. As eleições. 16. Reeleição. 17. O sistema majoritário. 18. O sistema proporcional. 19. O sistema misto. IV. PROCEDIMENTO ELEITORAL: 20. Noção e fases. 21. Apresentação das candidaturas. 22. O escrutínio. 23. O contencioso eleitoral.

I. CONCEITO E INSTITUIÇÕES

1. Conceito

Os direitos políticos positivos consistem no conjunto de normas que asseguram o direito subjetivo de participação no processo político e nos órgãos governamentais. Eles garantem a participação do povo no poder de dominação política por meio das diversas modalidades de direito de sufrágio: direito de voto nas eleições, direito de elegibilidade (direito de ser votado), direito de voto nos plebiscitos e referendos, assim como por outros direitos de participação popular, como o direito de iniciativa popular, o direito de propor ação popular e o direito de organizar e participar de partidos políticos.¹

2. Instituições

As instituições fundamentais dos direitos positivos são as que configuram o direito eleitoral, tais como o *direito de sufrágio*, com seus dois aspectos: *ativo* (direito de votar) e *passivo* (direito de ser votado); os *sistemas* e *procedimentos eleitorais*.

Seria cabível incluir-se, aí, também o direito partidário, se a Constituição não houvesse concebido os direitos políticos em sentido es-

1. Todos esses direitos estão previstos na Constituição: arts. 1º, parágrafo único; 5º e inc. LXXIII; 14, I a III, §§ 3º e 4º; 17; 18, §§ 3º e 4º; 27, § 4º; 29, XI; 49, XV, e 61, § 2º.

trito, em que as normas sobre partidos políticos ficaram de fora, para serem consideradas em capítulo a parte, como igualmente faremos aqui.

II. DIREITO DE SUFRÁGIO

3. Conceito e funções do sufrágio

As palavras *sufrágio* e *voto* são empregadas comumente como sinônimas. A Constituição, no entanto, dá-lhes sentidos diferentes, especialmente no seu art. 14, por onde se vê que o *sufrágio* é *universal* e o *voto* é *direto*, *secreto* e tem valor *igual*. A palavra *voto* é empregada em outros dispositivos, exprimindo a vontade num processo decisório.² *Escrutínio* é outro termo com que se confundem as palavras *sufrágio* e *voto*. É que os três se inserem no processo de participação do povo no governo, expressando: um, o direito (*sufrágio*); outro, o seu exercício (*voto*), e o outro, o modo de exercício (*escrutínio*).

O *sufrágio* (do latim *suffragium* = aprovação, apoio) é, como nota Carlos S. Fayt, um direito público subjetivo de natureza política, que tem o cidadão de eleger, ser eleito e de participar da organização e da atividade do poder estatal.³ É um direito que decorre diretamente do princípio de que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes *eleitos* ou diretamente. Constitui a instituição fundamental da democracia representativa e é pelo seu exercício que o eleitorado, instrumento técnico do povo, outorga legitimidade aos governantes. Por ele também se exerce diretamente o poder em alguns casos: plebiscito e referendo. Nele consubstancia-se o consentimento do povo que legitima o exercício do poder. E aí está a *função* primordial do sufrágio, de que defluem as *funções de seleção e nomeação* das pessoas que hão de exercer as atividades governamentais.⁴

2. Cf. o emprego da palavra *voto*, referente à eleição de alguém ou a deliberações sobre projetos ou composição de colegiados ou de julgamentos nos seguintes arts.: 52, III, IV, e seu parágrafo único, 53, §§ 3º e 7º, 60 §§ 2º e 4º, II (aqui, equivocadamente, fala em *voto universal*), 64 (votação de projeto); 65 (votação), 66, § 4º, 77, §§ 2º a 5º, 93, II, d, e VIII, 98 (aqui, também, com a mesma impropriedade: *voto universal*; não existe voto universal; voto é pessoal), 119, I, 120, § 1º, I, 128, § 5º, I, b, e isto sem falar em outros dispositivos em que o voto está subentendido, quando, p. ex., estabelecem aprovação ou deliberação por maioria absoluta.

3. Cf. *Sufragio y representación política*, pp. 7 e 21.

4. Cf. Carlos S. Fayt, *ob. cit.*, p. 8; o autor, além dessas, que denomina *funções eleitorais*, reconhece também *funções de participação governamental* que se vinculam às formas de democracia semidireta (p. 9); cf. também Jean-Marie Cotteret e Claude Emeri, *Les systemes électoraux*, p. 12; W. J. W. Mackenzie, *Elecciones libres*, pp. 27 e ss., misturando *voto* e *sufrágio*; Pierre Wigny, *Droit constitutionnel*, t. I/393; Fávila Ribeiro, *Direito Eleitoral*, pp. 43 e ss.

4. Formas de sufrágio

O regime político condiciona as *formas de sufrágio* ou, por outras palavras, as formas de sufrágio denunciam, em princípio, o regime. Se este é democrático, o sufrágio será *universal*. Não quer dizer que a existência de sufrágio universal configure, necessariamente, um regime democrático, porque este não se compõe apenas de formalidades eleitorais. Mas é certo que o sufrágio *restrito* revela um regime elitista, autocrático ou oligárquico,⁵ que, para tanto, procura vários meios de restringir ou de privar os indivíduos do direito de sufrágio.

Alguns autores consideram também, como forma de sufrágio, os atributos do voto e os tipos de escrutínios. Não se pode reputar errônea essa classificação, porque, afinal, o voto e o escrutínio são manifestações do direito de sufrágio. Mas aqui preferimos separar as coisas, como o fez a Constituição. Por isso, as formas de sufrágio, levadas em conta aqui, são as que se prendem ao esquema abaixo:

Quanto à extensão	<table><tr><td>(a) <i>Universal</i></td><td rowspan="2">{</td><td rowspan="2">Censitário</td></tr><tr><td>(b) <i>Restrito</i></td><td>Capacitário</td></tr></table>	(a) <i>Universal</i>	{	Censitário	(b) <i>Restrito</i>	Capacitário	
(a) <i>Universal</i>	{	Censitário					
(b) <i>Restrito</i>			Capacitário				
Quanto à igualdade	<table><tr><td>(c) <i>Igual</i></td><td rowspan="3">{</td><td rowspan="3">Plural</td></tr><tr><td rowspan="2">(d) <i>Desigual</i></td><td>Múltiplo</td></tr><tr><td>Familiar</td></tr></table>	(c) <i>Igual</i>	{	Plural	(d) <i>Desigual</i>	Múltiplo	Familiar
(c) <i>Igual</i>	{	Plural					
(d) <i>Desigual</i>					Múltiplo		
			Familiar				

(A) *Sufrágio universal*: A universalidade do direito de sufrágio é um princípio basilar da democracia política, que se apóia na identidade entre governantes e governados. Essa identidade será tanto mais real quanto mais se amplie o direito de sufrágio aos integrantes da nacionalidade. É o que caracteriza o *sufrágio universal*, acolhido no art. 14 da Constituição, que se funda na coincidência entre a qualidade de eleitor e a de nacional, de um país.⁶ Essa coincidência não é e nem pode ser absoluta; assim, no Brasil, uma pessoa, para ser eleitora, fica sujeita a um duplo condicionamento, sem desrespeito à universalidade do sufrágio: (a) um *de fundo*, porque precisa preencher os requisitos de *nacionalidade, idade e capacidade*; (b) outro *de forma*,

5. Cf. Carlos S. Fayt, *ob. cit.*, p. 30; Peter Bachrach, *Crítica de la teoría elitista de la democracia*, p. 22.

6. Cf. André e Francine Demichel, *Droit électoral*, p. 37.

porque precisa *alistar-se eleitora*,⁷ e, assim, tornar-se titular do direito de sufrágio (art. 14, § 1º).

Só se podem reputar compatíveis com o sufrágio universal as condições puramente técnicas e não discriminatórias, como nota Demichel,⁸ sendo-lhe opostas quaisquer exigências de ordem econômica e intelectual ou determinadas pautas de valor pessoal, como observa Fayt.⁹

Considera-se, pois, universal o sufrágio quando se outorga o direito de votar a todos os nacionais de um país, sem restrições derivadas de condições de nascimento, de fortuna e capacidade especial.

(B) *Sufrágio restrito*: Ao contrário do universal, *reputa-se restrito ou qualificado o sufrágio quando só é conferido a indivíduos qualificados por condições econômicas ou de capacidades especiais.*

Trata-se de sufrágio discriminatório e antidemocrático, que exclui do direito subjetivo de votar e de participar do processo político e do governo a massa do povo que não possua aquelas qualificações fortuitas e circunstanciais de fortuna e capacidade especial. Essa duplicidade de qualificação dá margem à distinção do sufrágio restrito em: (a) *sufrágio censitário* e (b) *sufrágio capacitário*.

O *sufrágio censitário* concede-se apenas ao indivíduo que preencha determinada qualificação econômica: posse de bens imóveis, de determinada renda ou pagamento de certa importância de imposto direto. Assim, por exemplo, estavam excluídos de votar nas eleições dos Deputados e Senadores do Império os que não tivessem renda líquida anual de duzentos mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego, e não eram elegíveis para Deputado os que não tivessem renda líquida de pelo menos quatrocentos mil réis, que era fortuna razoável para a época.¹⁰ As Constituições de 1891 (art. 70, § 1º, item 1º) e de 1934 (art. 108, parágrafo único, c) excluíam os *mendigos* do direito de sufrágio, o que revela aspecto censitário.

O *sufrágio capacitário* baseia-se em capacitações especiais, notadamente de natureza intelectual. Dá-se, assim, o direito de voto apenas àqueles que possuem certo grau de instrução. A exigência de que o eleitor seja alfabetizado, por exemplo, constitui um mínimo

7. A propósito dessas condições de fundo e de forma, cf. André e Francine Demichel, *ob. cit.*, p. 37.

8. *Ob. cit.*, p. 37.

9. *Ob. cit.*, p. 30.

10. Cf. Constituição Política do Império do Brasil, arts. 94, I, e 95, I; Pimenta Bueno, *ob. cit.*, pp. 464 e 465. Uma forma de sufrágio censitário existiu nos EUA até 1964, destinado a excluir os negros do direito eleitoral, subordinando o exercício do voto ao pagamento da taxa de um dólar, chamada *poll-tax*.

de sufrágio capacitário, que foi eliminado pela EC 25/85 à Constituição revogada e a Constituição de 1988 repeliu, conferindo direito de sufrágio aos analfabetos, que têm votado sem problema algum. Mas, no seu rigor, se acentua o sufrágio capacitário conceitual, se se exigir do indivíduo, para ser eleitor ou para votar em alguma eleição, a posse de determinado grau de instrução: diploma do curso fundamental, ou do curso secundário ou médio ou superior. Aqui, como no sufrágio censitário, caracteriza-se discriminação antidemocrática.

Pois, como muito bem assinala Carlos S. Fayt, o "sufrágio é um direito, não um privilégio concedido a certos indivíduos de elevadas condições de moralidade, inteligência ou cultura. Seu reconhecimento deriva do fato objetivo da nacionalidade e seu exercício não pode estar subordinado senão a condições mínimas de capacidade, liberdade e dignidade pessoal. Mas essa capacidade não está referida nem à instrução nem à educação, que, por si mesmas, não constituem garantia de capacidade ou competência política",¹¹ e menos ainda o garante, acrescentemos nós, a qualidade de proprietário, a posse de determinada renda ou outro bem de riqueza. O discernimento político cria-se e desenvolve-se no debate democrático livre e no respeito de opiniões alheias.

(C) *Sufrágio igual*: Outra exigência democrática é que o *sufrágio seja igual*. Não basta, portanto, que se reconheça a todos o direito de votar, observando-se a universalidade. É necessário também que cada eleitor disponha de número igual de votos dos demais. Trata-se, em verdade, da aplicação, no campo do direito político, do princípio de igualdade de todos perante a lei. Em seu sentido mais abrangente, significa atribuir a todos iguais pressupostos para ser eleitor e para elegibilidade.¹²

A *igualdade do direito de votar* se manifesta, em seu sentido mais rigoroso, no reconhecer a cada homem, a cada eleitor, um *único voto* (*one man, one vote*),¹³ pois cada "cidadão tem o mesmo peso político e a mesma influência qualquer que seja sua idade, suas qualidades, sua instrução e seu papel na sociedade".¹⁴ O que importa mesmo, para a realização do princípio do sufrágio igual, é que a nenhum eleitor seja atribuído mais voto que a outros.

11. *Ob. cit.*, p. 29; Pierre Wigny, *ob. cit.*, p. 411.

12. Cf. Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. IV/689.

13. Cf. Fávila Ribeiro, *ob. cit.*, pp. 54 e 55; Pierre Wigny, *ob. cit.*, p. 411; Jacques Cadart, *Institutions politiques et droit constitutionnel*, t. I/209; Carlos S. Fayt, *ob. cit.*, p. 32.

14. Cf. Jacques Cadart, *ob. cit.*, p. 109.

O Direito Constitucional brasileiro respeita o princípio da igualdade do direito de voto, adotando-se a regra de que cada homem vale um voto, no sentido de que cada eleitor de ambos os sexos tem direito a um voto em cada eleição e para cada tipo de mandato. O Brasil madrugou, em relação a muitos países, na adoção do voto feminino. Veio, como o voto secreto, da Revolução de 1930. Acolhido no Código Eleitoral de 1932, firmou-se, como norma constitucional, no art. 108 da Constituição de 1934, e mantém-se no art. 14 da Constituição vigente, que, também, expressamente, consigna a *igualdade do voto*, o *voto com valor igual*. Essa expressão — *voto com valor igual para todos*, constante do art. 14 — é mais do que a simples relação de igualdade de voto entre eleitores. Ela, além do princípio *one man, one vote*, traz a idéia da igualdade regional da representação, segundo a qual a cada eleito, no País, deve corresponder o mesmo número ou um número aproximado de habitantes. Contraria a regra do valor igual o fato de que um voto, por exemplo, no Acre, vale cerca de vinte vezes mais do que um voto em São Paulo, pois para se eleger um Deputado Federal naquele bastam cerca de dezesseis mil votos enquanto neste são necessários aproximadamente trezentos mil votos.

A *igualdade do direito de ser votado* constitui outro aspecto do princípio da igualdade do sufrágio. Caracteriza a desigualdade do direito da elegibilidade o fato de criarem-se condições discriminatórias para que alguém possa ser eleito a determinado cargo eletivo. Em princípio, pois, todo eleitor deverá ser elegível para cumprimento de mandatos, nas mesmas condições. Já vimos que não é assim no nosso Direito Constitucional, no qual eleitores analfabetos e menores de dezoito anos não são elegíveis a nada.

(D) *Sufrágio desigual*: O *sufrágio inigualitário* consiste basicamente em outorgar a determinados eleitores, por circunstância especial, o direito de votar mais de uma vez ou de dispor de mais de um voto para prover um mesmo cargo. Dá-se um ou mais votos suplementares.¹⁵ "Trata-se de reforçar em razão de pressupostos elitistas a participação de determinados eleitores".¹⁶ Este tipo de sufrágio reforçado manifesta-se no *voto múltiplo*, no *voto plural* e no *voto familiar*.

Pelo *voto múltiplo*, o eleitor fica com o direito de votar mais de uma vez, ou seja, em mais de uma circunscrição eleitoral, como se

15. Cf. Pierre Wigny, *ob. cit.*, p. 411.

16. Cf. Fávila Ribeiro, *ob. cit.*, p. 54; Fayt, *ob. cit.*, p. 33: "Así como el principio que informa el voto igual y único es el principio democrático, el voto reforzado, especialmente el voto plural y múltiplo, se nutre en principios aristocráticos y oligárquicos".

reconheceu, na Inglaterra até 1948, aos titulares de diploma universitário e a diretores de empresas e outros negócios, que poderiam votar na circunscrição do seu domicílio, na da universidade e na de sua empresa ou negócio. Os trabalhistas, no poder, suprimiram em 1948 essa forma de voto contrária à igualdade de sufrágio.¹⁷

Pelo *direito de voto plural*, o eleitor pode emitir mais de um voto de uma vez, mas numa única circunscrição onde poderá votar duas ou mais vezes.¹⁸ Aí está a diferença entre o voto plural e o voto múltiplo. Ambos os tipos, na verdade, consistem no atribuir a determinados eleitores mais de um voto: o múltiplo em mais de uma circunscrição (ou distrito); o plural em uma mesma circunscrição (ou distrito). Isso tem significado diferente onde, como na Inglaterra, se adote o sistema de eleição distrital, porque, pelo voto múltiplo, o eleitor pode contribuir para a eleição de mais de um candidato de sua classe (universitário, empresário, negociante), o que não se dá com o voto plural; mas este reforça a possibilidade do candidato no distrito do eleitor qualificado.

Pelo *direito de voto familiar*, o eleitor pai de família dispõe de um ou mais votos em função do número dos membros do núcleo familiar; vê-se, pois, que, além de desigual em função de circunstância especial, é também contrário ao voto feminino.

Como o sufrágio restrito, todas essas formas de sufrágio desigual constituem técnicas antidemocráticas, destinadas a propiciar regimes elitistas, infelizmente ainda reclamados por certos doutrinadores, sob o argumento de que o povo não está preparado para a democracia ou de que o homem mais instruído ou dono de fortuna tem mais capacidade, mais qualidade e mais discernimento para escolher os governantes e para participar do governo.

"O argumento tem sido descartado com razão. O bom senso não depende necessariamente do dinheiro, da hereditariedade, nem mesmo da instrução ou da educação. Pede-se ao corpo eleitoral sua manifestação sobre a linha geral de uma política, e não sobre medidas técnicas determinadas. Reclama-se sua confiança não em favor de um homem, mas de uma equipe que toma a responsabilidade de executar um programa. Não é preciso longos estudos para poder formular um julgamento em termos assim tão gerais.

"Além do mais, não é certo que as cabeças mais bem informadas seriam, ao mesmo tempo, mais desinteressadas. A experiência tem

17. Cf. Jacques Cadart, *ob. cit.*, p. 209.

18. Cf. Costantino Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, t. I/342: "Il voto plurimo consiste nell'attribuire ad ogni voto un valore superiore all'unità".

provado que as classes dirigentes por vezes aproveitam de sua superioridade eleitoral para defender seus privilégios particulares."¹⁹

5. Natureza do sufrágio

O sufrágio é um *direito público subjetivo democrático*, que cabe ao povo nos limites técnicos do princípio da universalidade e da igualdade de voto e de elegibilidade. É direito que se fundamenta, como já referimos, no princípio da soberania popular e no seu exercício por meio de representantes.

A distinção entre o direito de sufrágio e o voto, que encontra apoio na Constituição (art. 14 e seu § 1º), mostra que não tem cabimento discutir se o sufrágio é direito, função ou dever, porque ele é apenas direito, de que o voto é tão-só uma manifestação no plano prático, um dos atos de seu exercício.²⁰

6. Titulares do direito de sufrágio

O direito de sufrágio, como vimos, diz-se *ativo* (direito de votar) e *passivo* (direito de ser votado). Aquele caracteriza o *eleitor* (titular do direito de votar); o outro, o *elegível* (titular do direito de ser votado, de vir a ser eleito). O primeiro é pressuposto do segundo, pois, no direito brasileiro, ninguém tem o direito de ser votado (ninguém é elegível) se não for titular do direito de votar (se não for eleitor). O princípio deveria ser o da coincidência entre a qualidade de eleitor e a de elegível, mas, em verdade, nem todo eleitor é elegível.²¹ É que a *elegibilidade* (qualidade do elegível) depende do preenchimento de outras condições, que veremos depois.

Um princípio, porém, é certo: *ninguém é elegível se não for eleitor*. Por conseguinte, não é bem correta a norma do art. 14, § 4º, quando afirma que são inelegíveis os inalistáveis, pois, também são inelegíveis os não eleitores, ainda que alistáveis. São inelegíveis os não alistados, os analfabetos e os eleitores entre dezesseis e dezoito anos.

Eleitores são todos os brasileiros (natos e naturalizados, de qualquer sexo) que, à data da eleição, contem dezesseis anos de idade, alistados na forma da lei (art. 14, § 1º). Estes são, pois, os *titulares* do

19. Cf. Pierre Wigny, *ob. cit.*, p. 411.

20. Carlos S. Fayt, *ob. cit.*, pp. 10 e 11, bem acentua essa distinção: o sufrágio é direito, o voto um dos atos de exercício desse direito.

21. Cf. Demichel, *ob. cit.*, p. 77. A Constituição diz: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos (art. 14, § 4º), e também os eleitores entre 16 e 18, pois a idade mínima como condição de elegibilidade no art. 14, § 3º, é 18.

direito do sufrágio ativo e, potencialmente, do direito de sufrágio passivo, exceto, para este, os analfabetos e os eleitores entre 16 e 18 anos de idade, pelo visto acima.

7. Capacidade eleitoral ativa

Pelo exposto, podemos concluir que as condições requeridas no art. 14 constitucional, para que alguém se torne eleitor, são: (1) *nacionalidade brasileira*; (2) *idade mínima de dezesesseis anos*; (3) *alistamento na forma da lei*. Cumpre notar que a alistabilidade, embora obrigatória para os maiores de dezoito anos, é, sobretudo, um *direito subjetivo* de quantos, sendo brasileiros, tenham atingido a idade de dezesesseis anos. Estes, como os analfabetos e os maiores de setenta anos de idade, não estão obrigados a se alistarem eleitores, mas não poderão ser impedidos de fazê-lo, se preencherem as demais condições de alistabilidade. É que esta constitui um princípio dos direitos políticos, que decorre do art. 14, § 1º. A inalistabilidade, como restrição ao direito de alistar, é exceção que somente se dará no caso estritamente previsto na Constituição: apenas os *conscritos*, enquanto prestem serviço militar obrigatório.

Em suma, a capacidade eleitoral ativa depende do preenchimento das condições indicadas acima: *nacionalidade brasileira, idade mínima de dezesesseis anos, posse de título eleitoral e não ser conscrito em serviço militar obrigatório*.

8. Exercício do sufrágio: o voto

O direito de sufrágio exerce-se praticando atos de vários tipos. No que tange à sua função eleitoral, o *voto* é o ato fundamental de seu exercício, que se manifesta também como ato de alguma função participativa: plebiscito e referendo.

O voto é, pois, distinto do sufrágio, repita-se. Este é o direito político fundamental nas democracias políticas. Aquele emana desse direito. É sua manifestação no plano prático. Constitui seu exercício. Mas, como observa Carlos S. Fayt, o voto é uma determinação da vontade que compreende outras espécies, além do ato político que corresponde ao exercício do direito de sufrágio.²² Entendemos, no entanto, diferentemente dele, que os votos que se emitem nas assembleias legislativas, no exercício do mandato político, ainda são formas de exercício do sufrágio, porque, por meio deles, os represen-

tantes do povo deliberam, aprovando leis e outros atos legislativos, no cumprimento da representação justamente decorrente do exercício do sufrágio. Dá-se, aí, sem dúvida, uma forma de participação governamental, que é uma das funções do sufrágio. Não será, porém, dessa natureza o voto que se emite nos colegiados não fundados no direito político de sufrágio, como nas decisões dos tribunais ou de conselhos ou assembleias formados por nomeação, designação, coopção ou outra forma semelhante de investidura.

9. Natureza do voto

Carlos S. Fayt, na sua excelente monografia sobre o sufrágio, sustenta que a ação de emitir o voto configura um ato político e não um direito político.²³ Na verdade, não é a ação que é o ato. O voto é o ato político que materializa, na prática, o direito público subjetivo de sufrágio. É o exercício deste, como dissemos. Mas, sendo ato político, porque contém decisão de poder, nem por isso se lhe há de negar natureza jurídica. É ato também jurídico. Portanto, a ação de emitilo é também um direito, e direito subjetivo. Não fosse assim, o direito de sufrágio, que se aplica na prática pelo voto, seria puramente abstrato, sem sentido prático.

Com isso, inserimo-nos no contexto de tema amplamente discutido na doutrina, que é o que visa responder *qual a natureza do voto*.²⁴ A questão se oferece quanto a saber se o voto é um direito, uma função ou um dever.

Que é um direito já o admitimos acima: direito público subjetivo. Houve e há quem sustente que o voto é também uma *função*. Convém, no entanto, verificar em que sentido assim se poderá entender legitimamente dentro da concepção democrática, porque, se não se fizer distinção necessária, bem se pode incidir na concepção fascista de que o eleitor é um órgão do Estado e, portanto, exerceria uma função estatal ao emitir o voto. Essa concepção, de "forte conteúdo fascista de um Estado absorvente, que não reconhece o princípio democrático da soberania popular, identifica o interesse da coletividade com o dos detentores do poder, e coloca o cidadão a serviço destes, não lhe permitindo manifestação de vontade livre e autônoma, porque sujeita e subordinada a uma *razão de Estado*, ditada pelos interesses dominantes".²⁵ Nesses termos, claro está, não se pode acei-

23. Idem, *ibidem*.

24. Para essa discussão, cf., p. ex., Carré de Malberg, *Contribution à la théorie générale de l'état*, t. II/411 e ss.; Carlos S. Fayt, *ob. cit.*, pp. 10 e ss.

25. Cf. nossa *Ação popular constitucional*, pp. 184 e 185.

22. *Ob. cit.*, p. 10.

tar a tese de que o voto é uma função. É, sim, uma *função*, mas *função da soberania popular*, na medida em que traduz o instrumento de atuação desta. Nesse sentido, é aceitável a concepção de que seja "uma *função social*, que justifica sua imposição como um dever".²⁶

Daí se conclui que o voto é um direito público subjetivo, uma função social (função da soberania popular na democracia representativa) e um dever, ao mesmo tempo. *Dever jurídico* ou *dever social*? Não resta dúvida de que é um dever social, dever político, pois, "sendo necessário que haja governantes designados pelo voto dos cidadãos, como é da essência do regime representativo, o indivíduo tem o dever de manifestar sua vontade pelo voto".²⁷ Esse dever sócio-político do voto independe de sua obrigatoriedade jurídica. Ocorre também onde o voto seja facultativo. Mas, como simples dever social e político, seu descumprimento não gera sanção jurídica, evidentemente.

A Constituição declara, contudo, que o alistamento e o *voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos* (art. 14, § 1º, I). Por isso, a legislação eleitoral impõe sanções ao eleitor que deixe de votar sem justificação perante a Justiça Eleitoral, incorrendo em multa e ficando privado de vários direitos dependentes do gozo dos direitos políticos.

Convém entender bem o sentido da obrigatoriedade do voto, prevista no citado dispositivo constitucional, para conciliar essa exigência com a concepção da liberdade de voto. Aquela obrigatoriedade não impõe ao eleitor o dever jurídico de emitir necessariamente o seu voto. Significa apenas que ele deverá comparecer à sua seção eleitoral e depositar sua cédula de votação na urna, assinando a folha individual de votação. Pouco importa se ele votou ou não votou, considerado o voto não o simples depósito da cédula na urna, mas a efetiva escolha de representante, dentre os candidatos registrados. A rigor, o chamado voto em branco não é voto. Mas, com ele, o eleitor cumpre seu dever jurídico, sem cumprir o seu dever social e político, porque não desempenha a função instrumental da soberania popular, que lhe incumbia naquele ato.

10. Caracteres do voto

Para que o voto constitua legítima expressão da vontade do povo, para que seja função efetiva da soberania popular, "deve revestir-se

[como disse Meirelles Teixeira] de *eficácia política* e ainda que represente a *vontade* real do eleitor, vale dizer, que seja cercado de tais garantias que possa dizer-se *sincero* e *autêntico*", pois, acrescenta, se "um voto lançado na urna não repercutir, potencialmente embora, de algum modo, na formação dos poderes e dos órgãos do Estado, e, daí, no próprio governo da coisa pública, será um voto *ineficaz*", e se não for ainda "*autêntica expressão da vontade, do sentir, do consentimento de quem o dá*, falseada estará, em sua própria origem, a vontade da nação".²⁸ *Eficácia, sinceridade e autenticidade* são atributos que os sistemas eleitorais democráticos procuram conferir ao voto. Para tanto, hão de garantir-se-lhe dois caracteres básicos: *personalidade e liberdade*.

A *personalidade do voto* é indispensável para a realização dos atributos da sinceridade e autenticidade. Significa que o eleitor deverá estar presente e votar ele próprio, não se admitindo, no sistema brasileiro, os votos por correspondência ou por procuração. A identidade do eleitor verifica-se pela exibição do título de eleitor à mesa receptora; será, no entanto, admitido a votar, ainda que deixe de exibir, no ato de votação, o seu título, desde que seja inscrito na seção e conste da respectiva pasta a sua folha individual de votação. Há, contudo, variados meios de deformar a vontade popular nas urnas, que a legislação procura coibir, nem sempre com êxito.

A *liberdade de voto* é fundamental para a sua autenticidade e eficácia. Manifesta-se não apenas pela preferência a um candidato entre os que se apresentam, mas também pela faculdade até mesmo de depositar uma cédula em branco na urna ou de anular o voto. Essa liberdade deve ser garantida, daí por que mostramos que a obrigatoriedade do voto, exigida em nossa Constituição, não pode significar senão o comparecimento do eleitor, a deposição da cédula na urna e a assinatura da folha individual de votação. Quer dizer, é obrigatoriedade formal, que não atinge o conteúdo da manifestação da vontade do eleitor. O dever político-social do voto, já referido, é que exige uma tomada de posição positiva do eleitor, com efetiva participação no processo político e, por esse modo, nos órgãos governamentais por meio de seus representantes. Por isso é que também dissemos que, a rigor, o voto branco, o voto vazio, ou o voto nulo não são votos, porque não têm eficácia política.

A garantia da liberdade do eleitor na emissão de seu voto exige que este seja *secreto*, como a Constituição prescreve no art. 14. O segredo do voto consiste em que não deve ser revelado nem por seu autor nem por terceiro, fraudulentamente. O eleitor é dono do seu

26. Cf. Dalmo de Abreu Dallari, *Elementos de teoria geral do Estado*, p. 156; também Darcy Azambuja, *Teoria Geral do Estado*, pp. 335 e 336.

27. Cf. Darcy Azambuja, *ob. cit.*, p. 336.

28. Cf. J. H. Meirelles Teixeira, *Curso de direito constitucional*, pp. 515 e 516.

segredo após a emissão do voto e a retirada do recinto de votação. Mas no momento de votar, há que preservar o sigilo de seu voto, nem ele próprio pode dizer em quem votou ou como votou. É obrigação dos membros da mesa receptora não só oferecer condições para que o eleitor tenha respeitado o seu direito subjetivo ao sigilo da votação, mas também impedir que ele próprio o descumpra. É que o segredo do voto, sendo um direito subjetivo do eleitor, é outrossim uma garantia constitucional de eleições livres e honestas, porque evita a intimidação e o suborno, suprimindo, na raiz, a possibilidade de corrupção eleitoral, ou, pelo menos, reduzindo-a consideravelmente.²⁹ O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências legais:

(1) *uso de cédulas oficiais* em todas as eleições, de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral;

(2) *isolamento do eleitor em cabine indepassável* para o só efeito de assinalar na cédula o candidato de sua escolha e, em seguida, fechá-la;

(3) *verificação da autenticidade da cédula oficial* à vista das rubricas dos mesários;

(4) *emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente ampla para que não se acumulem as cédulas na ordem em que forem introduzidas pelo próprio eleitor, não se admitindo que outro o faça*.³⁰

Voto direto — Outra exigência de sinceridade, autenticidade e eficácia do voto decorre da determinação de que seja *direto*. Na verdade, a qualificação de *direto* prende-se mais ao sufrágio do que ao voto em si. O direito de escolha (sufrágio) é que pode ser direto ou indireto, caracterizando as eleições diretas ou indiretas. Mas também, como o voto é exercício do sufrágio, pode dizer-se, como geralmente se diz: *voto direto* e *voto indireto*. A Constituição consagra o voto direto, como princípio (art. 14), com uma única exceção: a da eleição de Presidente e Vice-Presidente da República pelo Congresso Nacional no caso de vacância de ambos os cargos nos últimos dois anos do mandato presidencial.

O *sufrágio* (ou o *voto*) é *direto* quando os eleitores escolhem, por si, sem intermediários, os seus representantes e governantes. É *indireto* quando estes são escolhidos por delegados dos eleitores. A *eleição direta* deve assegurar o caráter imediato da representação,

enquanto, na *indireta*, a designação dos verdadeiros representantes se realiza através de uma especial entidade intermediária:³¹ *Eleitores, Grandes Eleitores, Comissários, Delegados, Colégios Eleitorais* etc. A eleição indireta ainda pode ser de dois ou mais graus. É mais comum utilizar-se o sufrágio indireto para eleição de Chefes de Estado, e menos para membros de corporações legislativas. Há, porém, exemplos a mencionar, como ocorrera no Brasil Império para eleição de Deputados e Senadores, que era feito por *Eleitores Provinciais*, reunidos em Colégios Eleitorais, os quais, por sua vez, eram eleitos, à razão de um por quarenta votantes, pela massa dos cidadãos em assembleias paroquiais.³² Outro exemplo atual é o Senado francês, cujos membros são eleitos por sufrágio indireto, mas por um corpo eleitoral bastante amplo, cerca de cem mil pessoas, composto de deputados, conselheiros gerais e membros dos conselhos municipais.³³ Mas é bom que se saiba que esse órgão não tem, no sistema francês atual, característica de senado em qualquer de suas finalidades tradicionais. É, verdadeiramente, conselho econômico.³⁴ A eleição indireta para compor assembleias legislativas ou parlamentares é inequivocamente um elemento fortemente reacionário em toda a experiência histórica, quer porque reflete uma conotação aristocrática da organização política, quer porque introduz uma faceta corporativista no parlamento; portanto, um elemento fascista. O Brasil republicano sempre repeliu eleição indireta para composição de suas casas legislativas, com exceção da Carta ditatorial de 1937 (arts. 46 e 47), o que confirma a assertiva supra de que eleição indireta caracteriza autoritarismo, e nem assim foi aplicada, porque a eleição mesma foi eliminada no período de sua vigência. O exemplo recente, o que conspurcou a história constitucional brasileira, de eleição indireta de Senadores, marcados desde logo com a pecha de *Senadores Biônicos*, deve ser sepultado, de vez, no esquecimento.

Não é também comum a eleição indireta de membros do Executivo que exerçam função de governo. O que é comum é eleger-se indiretamente os Chefes de Estado nos sistemas parlamentaristas republicanos. Mas, nesses sistemas, como se sabe, não se atribuem funções governamentais aos Presidentes da República, porque tais

31. Cf. Nils Diederich, "Elecciones. Sistemas electorales", in *Marxismo y democracia: enciclopedia de conceptos básicos — política 3*, Madrid, Ed. Rioduero, 1975, trad. de Joaquín Sanz Guijarro, p. 5.

32. Cf. Constituição de 1824, art. 90, e art. 52 da Lei 387, de 1846, que foi a primeira lei eleitoral do Brasil.

33. Cf. Jacques Cadart, *ob. cit.*, t. II/785.

34. Idem, *ibidem*, p. 785; André Hauriou, *ob. cit.*, p. 871.

29. Cf. W. J. M. Mackenzie, *Elecciones libres*, pp. 157 e 158; André Hauriou, *Droit constitutionnel et institutions politiques*, pp. 158 e ss.; Marcel Prélot, *Institutions politiques et droit constitutionnel*, pp. 642 e ss.

30. Cf. Código Eleitoral (Lei 4.737/65), art. 103.

funções cabem ao Conselho de Ministros, sob a direção do seu Presidente ou Primeiro-Ministro, os quais dependem da confiança do Parlamento, que é composto de representantes do povo, eleitos diretamente. No sistema de governo misto, em que o Presidente da República não é mero Chefe de Estado e compartilha de funções governamentais, sua investidura tem sido por eleições diretas, como na França e em Portugal. O Brasil teve vinte anos de experiência de eleições indiretas, que provaram pessimamente.

Os exemplos dos EUA, cujo Presidente é eleito por sufrágio indireto, muitas vezes é invocado para sustentar o caráter democrático das eleições indiretas. O exemplo, para tanto, não colhe. É que lá, como salientam todos os publicistas,³⁵ a eleição do Presidente só é indireta formalmente. De fato, ele é escolhido por *Eleitores Presidenciais* (ou Grandes Eleitores), eleitos pela massa eleitoral exclusivamente para tal fim. Em cada eleição presidencial, no final da campanha, conhecidos todos os candidatos que desenvolveram ampla propaganda eleitoral, os eleitores comparecem às urnas (ou o equivalente eletrônico) e escolhem os eleitores presidenciais que também se apresentaram em campanha vinculados aos partidos e aos candidatos à presidência. "Os eleitores presidenciais, há mais de século, vêm votando nos candidatos do partido político em cuja chapa foram eleitos. Em muitos Estados, realmente, nem aparecem na cédula os nomes dos eleitores, e os votantes votam somente no partido do candidato presidencial que eles preferem. É verdade que, em teoria, os eleitores ainda mantêm o seu arbítrio constitucional de votar em qualquer pessoa que escolham. Na prática, porém, o poder dos eleitores nesse particular é tão destituído de sentido quanto muitas das prerrogativas que, em teoria, a Coroa britânica ainda possui. 'O eleitor que deixasse de votar no candidato de seu partido', declarou um ex-Presidente americano, 'seria objeto de execração, e, em época de grande agitação política, poderia ser até linchado'".³⁶ "Assim [como o mesmo autor dissera antes], nada mais resta aos eleitores, após a sua escolha, a não ser consignar os votos que já foram comprometidos; e, se um deles resolver exercer o seu discernimento independente, sua atitude será considerada como uma usurpação política, desonrosa para o indivíduo, e uma fraude contra os seus constituintes".³⁷ Tanto assim que Cadart acaba dizendo, com razão, que, "se juridicamente essa eleição é indireta, em realidade,

35. "Todos", no texto, não é força de expressão, é uma realidade. Basta conferir Bernard Schwartz, *Direito Constitucional Americano*, p. 120; F. A. Ogg e P. O. Fay, *Le gouvernement des États-Unis d'Amérique*, pp. 180 e ss.; Jacques Cadart, *ob. cit.*, t. I/213.

36. Cf. Bernard Schwartz, *ob. cit.*, p. 119.

37. Idem, *ibidem*.

de, politicamente, ela é direta, porque os eleitores do segundo grau se submetem, em verdade, a um mandato imperativo".³⁸ E acrescenta que, quando os eleitores de segundo grau são eleitos para funções variadas e diversas, esse mandato imperativo não existe,³⁹ valendo dizer que sua escolha não cumpre a vontade dos eleitores populares, o que importa em nítida deformação do princípio de soberania popular, como ocorrera nas eleições indiretas implantadas no Brasil, de 1964 a 1985.

Como disse Meirelles Teixeira, "se, como é óbvio, na eleição direta a ação dos eleitores se faz sentir mais eficazmente, e de um modo imediato na escolha dos governantes, é fácil concluir-se que a eleição direta constitui um processo mais democrático que a indireta".⁴⁰ A eleição indireta, especialmente quando feita por colégio eleitoral não eleito exclusivamente para procedê-la, como ocorreu no Brasil, em que, muito antes das eleições e de se conhecerem as candidaturas, já se sabia, em geral, quais eram os eleitores de segundo grau, certamente favorece: (a) a deformação da vontade dos eleitores populares; aliás, nem se pode dizer que se estará exprimindo essa vontade, porque se tratará de determinações pura e simplesmente dos eleitores de segundo grau; (b) a insinceridade e inautenticidade do sufrágio universal, que assim fica reduzido a verdadeiro sufrágio restrito e qualificado; (c) o suborno, as combinações políticas de bastidores, o conchavo, as pressões nas eleições de segundo grau. E tudo isso contraria o princípio democrático.

Enfim, podemos concluir essas considerações sobre os caracteres do voto com o seguinte resumo:

O voto pode ser	{	— <i>secreto</i> ou público (a descoberto)
		— <i>obrigatório</i> ou facultativo
		— <i>direto</i> ou indireto
		— <i>igual</i> ou desigual

Nossa Constituição consagra o voto *secreto*, *obrigatório* para os eleitores de 18 a 70 anos, *facultativo* para eleitores analfabetos, os de 16 a 18 anos e os maiores de 70 anos; *direto*, com a única exceção antes referida, e de valor *igual* (art. 14).

38. *Ob. cit.*, t. I/213.

39. Idem, *ibidem*.

40. *Ob. cit.*, p. 516.

11. Organização do eleitorado

O conjunto de todos aqueles que detêm o direito de sufrágio forma o *eleitorado*. Este se organiza primeiramente pelo alistamento, de que já cuidamos. Exigências técnicas, contudo, determinam se promove a organização territorial do eleitorado, o que significa, em última análise, organizar o sufrágio.⁴¹ De acordo com o direito eleitoral vigente, o eleitorado brasileiro está organizado segundo três tipos de divisão territorial, que são as *circunscrições eleitorais* e *zonas eleitorais* e, nestas, os eleitores são agrupados em *seções eleitorais* que não terão mais de 400 eleitores nas capitais e de 300 nas demais localidades, nem menos de 50, salvo autorização do Tribunal Regional Eleitoral em casos excepcionais (Código Eleitoral — Lei 4.737/65, art. 117).

As *zonas* são unidades territoriais de natureza jurisdicional sob a titularidade de um Juiz de Direito, na função de Juiz Eleitoral. Inserem-se, primordialmente, na organização da jurisdição eleitoral, menos que na organização do eleitorado. As *seções eleitorais* consistem, especialmente, na organização do exercício do voto. Sua finalidade cifra-se mormente na racionalização do escrutínio, ou seja, no aprimoramento do sistema de recolhimento do sufrágio, visando à comodidade do eleitor no momento da votação.

As *circunscrições eleitorais* é que constituem unidades destinadas a organizar territorialmente o eleitorado. Representam uma das duas formas básicas de distribuir o eleitorado no território do país, com base no seu domicílio eleitoral, em função dos candidatos a serem sufragados. A outra forma é o *distrito eleitoral*, não acolhido pela Constituição. Aquelas são adequadas ao sistema eleitoral proporcional que requer lista plurinominal de candidatos representativos de todas as correntes partidárias, dentre as quais cada eleitor votará naquele que julga afinar-se com sua tendência e interesses. Já o distrito é propício ao escrutínio uninominal, isto é, um candidato por corrente partidária, e ao princípio majoritário, de tal sorte que cada eleitor só tem a possibilidade de selecionar entre partidos, mas não entre candidatos do mesmo partido.

O sistema brasileiro adota a base circunscricional, nos termos do art. 86 do Código Eleitoral, segundo o qual, *nas eleições presidenciais, a circunscrição será o País; nas eleições federais e estaduais, o Estado; nas municipais, o respectivo Município*. Com isso, os eleitores ficam vinculados a votar nos candidatos indicados para a correspondente cir-

41. Cf., a propósito, Manuel Giménez Fernández, *Estudios de derecho electoral contemporaneo*, p. 73.

cunscrição eleitoral, já que a Constituição acolheu o *sistema proporcional* puro, que examinaremos mais adiante.

12. O corpo eleitoral

Certa tendência reacionária pretende dar sentido orgânico ao que se chama *corpo eleitoral*, chegando até à posição fascista que o tem como um órgão do Estado. Burdeau reconhece tal concepção incorporada na Constituição francesa de 1958,⁴² cuja orientação autoritária de fundo direitista é reconhecida. Aliás, Maurice Hauriou já sustentara a tese de que o corpo eleitoral deve ser tido como um poder do Estado, na doutrina da separação de poderes — poder de sufrágio.⁴³ Segundo ele, o corpo eleitoral é que adota as decisões através das quais se exercita o poder de sufrágio.⁴⁴ Tal concepção distingue entre corpo eleitoral — conjunto dos eleitores de um país ou de uma circunscrição ou de um distrito — e os eleitores em si. E Maurice Hauriou é expresso a esse respeito, dizendo que “o papel do corpo eleitoral é realizar uma função social”; é uma instituição representativa que obra em nome da nação, com o mesmo título que as Assembléias parlamentares;⁴⁵ já o papel “dos eleitores é participar nas operações do corpo eleitoral em virtude de um direito individual próprio, que é uma manifestação de sua soberania individual”.⁴⁶

Ora, essa doutrina escamoteia o princípio da soberania popular, cuja idéia básica, que dá fundamento à democracia, consiste na participação do povo no poder em todas as suas manifestações, como já vimos, e não apenas num pretenso “órgão” que, se fosse tal, ainda assim seria meramente intermediário. Seria, ademais, distorcer, consoante já vimos e repelimos, o conceito de povo, transferindo-o para o dito corpo eleitoral. Não existe corpo eleitoral, pois essa idéia pressupõe organicidade e isso não se verifica. Quando se fala em organização do eleitorado, refere-se, como o fizemos acima, apenas à técnica de sua distribuição territorial. A rigor nem chega a ser uma distribuição dos eleitores em áreas territoriais, pois a divisão do território nacional em circunscrições não é senão o meio de distribuir os candidatos por bases eleitorais, ficando os eleitores, domiciliados na área, vinculados a escolher dentre os da base que corresponde à sua circunscrição (ou

42. “De même que dans la précédente, dans le mécanisme de la Constitution de 1958, le corps électoral constitue le plus important des organes de l'État”. Cf. *Droit constitutionnel et institutions politiques*, p. 347.

43. Cf. *Derecho público y constitucional*, p. 384.

44. Idem, p. 507; igualmente, André Hauriou, *ob. cit.*, pp. 794 e ss.

45. *Ob. cit.*, p. 507, citando Esmein. Cf. também Manuel Giménez Fernández, *ob. cit.*, p. 68.

46. *Ob. cit.*, p. 507.

distrito, onde este é adotado). Ora, cada eleitor atua por si, mas certamente influenciado por suas circunstâncias, como já dissemos também. Não se fala em organização *institucional* dos eleitores, que seria contê-los numa instituição que acabaria por substituí-los, deformando sua vontade, como seria a idéia de um corpo eleitoral, nas concepções indicadas, o que é absolutamente inaceitável numa democracia.

13. Elegibilidade e condições de elegibilidade

Assim como a *alistabilidade* diz respeito à capacidade eleitoral ativa (capacidade de ser eleitor), a *elegibilidade* se refere à capacidade eleitoral passiva, à capacidade de ser eleito. Tem elegibilidade, portanto, quem preencha as condições exigidas para concorrer a um mandato eletivo. Consiste, pois, a *elegibilidade no direito de postular a designação pelos eleitores a um mandato político no Legislativo ou no Executivo*. Numa democracia, a elegibilidade deve tender à *universalidade*, tanto quanto o direito de alistar-se eleitor. Suas limitações não deverão prejudicar a livre escolha dos eleitores, mas ser ditadas apenas por considerações práticas, isentas de qualquer condicionamento político,⁴⁷ econômico, social ou cultural.

“Teoricamente, três soluções são possíveis: ou a elegibilidade coincide com o eleitorado (todo eleitor é elegível), ou é mais restrita (não basta ser eleitor para ser elegível), ou é mais ampla (pode-se ser elegível sem ser eleitor). Este último sistema, bastante ilógico, é raramente aplicado”.⁴⁸ Em compensação, o primeiro, que deveria ser o mais normal, poucos países o aplicam.⁴⁹ Mas é certo que, por regra, é necessário ser eleitor para ser elegível. No sistema brasileiro, como na maioria dos países, não basta ser eleitor para gozar da elegibilidade. O segundo sistema é, pois, o mais comum, havendo maior ou menor restrição conforme vigore menos ou mais intensamente o princípio democrático.

Enfim, para que alguém, entre nós, possa concorrer a uma função eletiva, é necessário que preencha certos requisitos gerais, denominados *condições de elegibilidade*, e não incida em nenhuma das *inelegibilidades* que examinaremos no capítulo seguinte, que precisamente constituem impedimentos à capacidade eleitoral passiva.⁵⁰ As condições de elegi-

47. Cf. Union Interparlementaire (org.), *Parlements*, p. 37.

48. Idem, *ibidem*.

49. Idem, *ibidem*.

50. O art. 3º do Código Eleitoral dispõe a esse propósito: “Qualquer cidadão [isto é, eleitor no gozo dos direitos políticos] pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade”.

bilidade e as inelegibilidades variam em razão da natureza ou tipo de mandato pleiteado. A condição básica e comum a todas as hipóteses é a de o postulante *estar no gozo dos direitos políticos* (ser eleitor), o que já envolve as condições de nacionalidade brasileira.

A Constituição arrola no art. 14, § 3º, as condições de elegibilidade, *na forma da lei*, isso porque algumas das condições indicadas dependem da forma estabelecida em lei, que são as hipóteses indicadas nos números (2) a (5) *infra*. As condições previstas são as seguintes: (1) nacionalidade brasileira, sendo que para Presidente e Vice-Presidente da República se exige a *condição de brasileiro nato*; (2) pleno exercício dos direitos políticos; (3) alistamento eleitoral (que já consta do número anterior); (4) domicílio eleitoral na circunscrição; (5) filiação partidária; (6) idade mínima de: (a) 35 anos para Presidente, Vice-Presidente da República e Senador Federal; (b) 30 anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; (c) 21 anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital (Deputado do Distrito Federal), Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; (d) 18 anos para Vereador; (7) não incorrer em nenhuma inelegibilidade específica, que não está arrolada no art. 14, § 3º, mas deve ser lembrada aqui, porque as inelegibilidades constam dos §§ 4º a 7º e 9º do mesmo artigo, além de outras que podem ser previstas em lei complementar.

Cumpra, no entanto, observar que a elegibilidade, condições de elegibilidade e inelegibilidade são matérias da Constituição Federal e de competência legislativa federal naquilo em que a própria Constituição permite seja objeto de lei complementar ou de lei ordinária, pois cabe à União legislar sobre *cidadania* (direitos políticos) e *direito eleitoral* (art. 22, I e XIII). Vale dizer, portanto, que não têm valor regras de constituição estadual ou de lei orgânica de Município que estatuem sobre o assunto.

14. Os eleitos e o mandato político — Remissão

Os eleitos — Assim será considerado o candidato que tenha recebido votação suficiente para lhe conferir o mandato. Se se trata de eleição majoritária, o eleito será o que recebeu a maioria dos votos, relativa ou absoluta, conforme o caso (que veremos). Se se cuida de eleição pelo sistema proporcional, serão eleitos, dentro de cada partido, os candidatos que tiverem obtido tantos votos quantos sejam precisos para formar o quociente eleitoral, matéria que também examinaremos adiante. Por agora, queremos apenas salientar que os *eleitos* serão diplomados pela Justiça Eleitoral (Código Eleitoral, art. 215), como que adquirem o direito à investidura no cargo para o qual foram eleitos, a fim de exercerem o mandato pelo tempo previsto na

Constituição, desde que não incorram ou venham a incorrer em alguma incompatibilidade para esse exercício. *Incompatibilidades* são situações jurídicas que impedem o eleito de exercer certas ocupações ou praticar certos atos cumulativamente com o mandato. São diferentes das *inelegibilidades*, como veremos a seu tempo.⁵¹

Mandato político — Uma vez eleito, o candidato não incompatível ou desincompatibilizado prestará compromisso e tomará posse do mandato. Daí decorrem direitos e privilégios que assinalaremos quando formos estudar o *estatuto dos congressistas*. Em resumo, tem o eleito o direito de exercer e manter o mandato, que é *mandato político representativo*, cuja doutrina e crítica, em síntese, já apresentamos noutro lugar, a que remetemos o leitor.⁵²

III. SISTEMAS ELEITORAIS

15. As eleições

A *eleição*, modernamente, não passa de um concurso de vontades juridicamente qualificadas visando operar a designação de um titular de mandato eletivo. “As *eleições* [escreve Nils Diederich] são procedimentos técnicos para a designação de pessoas para um cargo (outras maneiras de designação são a sucessão, a cooptação, a nomeação, a aclamação) ou para a formação de assembléias. *Eleger* significa, geralmente, expressar uma preferência entre alternativas, realizar um ato formal de decisão”.⁵³ Mas, nas democracias de partido e sufrágio universal, elas tendem a ultrapassar essa pura função designatória, para transmutarem-se num instrumento pelo qual o povo adere a uma política⁵⁴ e confere seu consentimento, e, por consequência, legitimidade, às autoridades governamentais. É o modo pelo qual o povo, nas democracias representativas, participa na formação da vontade do governo. Aliadas a outras técnicas participatórias, as eleições desempenham papel importante na realização do princípio democrático.

O conjunto de técnicas e procedimentos que se empregam na realização das eleições, destinados a organizar a representação do povo no território nacional, se designa *sistema eleitoral*.⁵⁵ Conjugua téc-

51. Para as *incompatibilidades*, cf. adiante “Incompatibilidades dos Congressistas” (terceira parte, título II, capítulo II, n. 17). Para as *inelegibilidades*, capítulo seguinte, n. IV.

52. Primeira parte, título II, capítulo III, n. 10.

53. *Ob. cit.*, p. 1.

54. Cf. Pierre Wigny, *ob. cit.*, t. I/400.

55. Para um estudo aprofundado dos sistemas eleitorais e seus efeitos jurídico-políticos, cf. Luís Virgílio Afonso da Silva, *Sistemas eleitorais, tipos, efeitos jurídico-políticos e aplicação ao caso brasileiro*, São Paulo, Malheiros Editores, 1999.

nicas, como a divisão do território em distritos ou circunscrições eleitorais, o método de emissão do voto, e os procedimentos de apresentação de candidatos e de designação dos eleitos de acordo com os votos emitidos. Forma com o *sistema de partidos* os dois mecanismos de coordenação, organização, instrumentação e expressão da vontade popular na escolha dos governantes.⁵⁶

A combinação daquelas técnicas e procedimentos é que proporciona o aparecimento de diferentes sistemas eleitorais, que, fundados no modo de realizar a representação, se distinguem em *sistema majoritário*, *sistema proporcional* e *sistema misto*, que serão objeto de consideração nos tópicos subseqüentes.

16. Reeleição

Reeleição significa a possibilidade que a Constituição reconhece ao titular de um mandato eletivo de pleitear sua própria eleição para um mandato sucessivo ao que está desempenhando. A tradição do Direito Constitucional brasileiro sempre foi a de admitir a reeleição de titulares de mandatos parlamentares (Senadores, Deputados e Vereadores) e a de proibir a reeleição para mandatos executivos. A EC 16, de 4.6.97, contudo, rompeu com esta última tradição, dando nova redação ao § 5º do art. 14 da Constituição de modo a possibilitar a reeleição do Presidente da República, de Governadores de Estado e do Distrito Federal, de Prefeitos e de quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato. Inverteu-se, pois, a regra do referido § 5º, que de conteúdo de direitos políticos negativos (inelegibilidade) se transformou em direitos políticos positivos ao assegurar o direito subjetivo de titulares daqueles mandatos executivos de participação no processo eleitoral subseqüente para o mesmo cargo, mas uma única vez — tal como nos EE UU de acordo com a Emenda Constitucional n. 22. Vice-Presidente, Vice-Governadores e Vice-Prefeitos sempre puderam pleitear sua recondução e continuam podendo, sem limitação, por quantos mandatos quiserem.

Trata-se de uma eleição como qualquer outra, de sorte que a ela se aplicam as mesmas regras e princípios. A única diferença está em que a ela pode também concorrer ocupante do cargo em disputa; por isso é que se vem chamando *recandidatura* a esse direito de participação, ou seja, candidatura ao cargo que já exerce, mas só por mais um único período subseqüente.

56. Cf., em sentido semelhante, Nils Diederich, *ob. cit.*, p. 1.

17. O sistema majoritário

Por esse sistema, a representação, em dado território (circunscrição ou distrito), cabe ao candidato ou candidatos que obtiverem a maioria (absoluta ou relativa) dos votos. Essa noção sugere diferenças dentro do sistema majoritário que devemos salientar sucintamente.

Em primeiro lugar, ele se conjuga com o sistema de eleições distritais, seja com *distritos uninominais ou unipessoais*, no quais o eleitor há de escolher entre candidatos individuais em cada partido, isto é, haverá apenas um candidato por partido; ou com *distritos plurinominais ou pluripessoais* (também chamado *sistemas de listas*), em que cada partido poderá apresentar uma lista de candidatos (uma pluralidade de nomes) à escolha dos eleitores distritais.

Em segundo lugar, o sistema majoritário pode ser *simples* (ou sistema de escrutínio a um só turno), pelo qual, por uma única eleição, se proclama o candidato que houver obtido a maioria simples ou relativa (por isso, também, às vezes, é denominado sistema de eleição por *maioria relativa*), como pode ser por *maioria absoluta* (por isso, é também conhecido como sistema eleitoral por maioria absoluta), segundo o qual somente se considerará eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos; se nenhum candidato o conseguir, efetivar-se-á nova eleição, geralmente entre os dois candidatos mais votados, a fim de decidir entre ambos, quando, então, um deverá alcançar a maioria absoluta de votos (por essa razão, dá-se-lhe também o nome de sistema majoritário a dois turnos, ou sistema de escrutínio a dois turnos).⁵⁷

Em terceiro lugar, por regra, em cada distrito se elege apenas um candidato, considerando-se derrotados os demais. No entanto, a preocupação com a representação das minorias foi introduzindo particularidades no sistema majoritário, especialmente combinando-o com base territorial mais ampla — circunscrições — em que se elegem, em cada uma, vários candidatos. Daí é que se progrediu até o sistema de representação proporcional, que, no entanto, só se aplica nas eleições parlamentares, enquanto o sistema majoritário serve tanto para eleições de membros dos órgãos coletivos (Parlamentos, Congressos, Senados, Câmaras e Assembléias) como para os órgãos singulares (Presidente da República, Governadores de Estado, Prefeitos).

O Direito Constitucional brasileiro vigente consagra o *sistema majoritário*: (a) *por maioria absoluta* (com dois turnos, se preciso, em termos

que veremos), para a eleição de Presidente e Vice-Presidente da República (art. 77), de Governador e Vice-Governador de Estado (art. 28) e de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal (art. 29, II; cf. p. 625); (b) *por maioria relativa*, para a eleição de Senadores Federais. E qual o sistema da eleição para *juiz de paz* (art. 98, II)? Só pode ser majoritária, pois se trata de cargo singular, para o qual é descabido o sistema proporcional; majoritário por maioria absoluta ou por maioria relativa? Acha-mos que poderá ser a relativa. Não é função política para cujo exercício necessite apoio popular maciço. A eleição aqui é tipicamente instrumento de investidura e para isso a maioria relativa é bastante. Mas a lei não está impedida de exigir maioria absoluta para este caso.

18. O sistema proporcional

A Constituição acolheu o *sistema proporcional* para a eleição de Deputados Federais (art. 45), o que significa a adoção de um princípio que se estende às eleições para as Assembléias Legislativas dos Estados e para as Câmaras de Vereadores (Câmaras Municipais). Pode surgir a indagação quanto a saber se *sistema proporcional* é a mesma coisa que *sistema de representação proporcional*. Acha-mos que sim, até porque a Constituição menciona a representação proporcional em relação à representação partidária em outro dispositivo (art. 58, §§ 1º e 4º), mas há modalidades de representação proporcional aí possibilitadas, como, por exemplo, a de eleição proporcional por votação distrital,⁵⁸ repele, porém, o sistema distrital misto e mesmo o proporcional misto tipo alemão.

Como não existe experiência de outro sistema proporcional, que não o de representação proporcional, é deste que vamos cuidar aqui. Por ele, pretende-se que a representação, em determinado território (circunscrição), se distribua em proporção às correntes ideológicas ou de interesse integrada nos partidos políticos concorrentes. Daí se vê que esse sistema, em princípio, só é compatível com circunscrições eleitorais amplas em que se devem eleger vários candidatos, o que, outrossim, mostra ser aplicável apenas a técnica de escrutínio de lista (sistema plurinomial). Há variações cujos pormenores descabem aqui, cumprindo notar que o sistema suscita os problemas de saber *quem é considerado eleito* e qual o número de eleitos por parti-

58. Já houve proposta nesse sentido no Brasil e nós próprios apresentamos uma em um Seminário sobre Representação Política, em maio de 1987, em Cuenca, Espanha, mas a nossa ainda se mantinha próxima do conceito de representação proporcional, embora baseado em distritos uninominais, sistema de votação distrital e eleição proporcional. Será reproduzido em estudos constitucionais separados, não cabendo reviver a proposta aqui.

57. Há variantes que não comportam desenvolvimento aqui. O leitor interessado poderá consultar, para mais pormenores, Carlos S. Fayt, *Sufragio y representación política*, pp. 49 e ss.; Demichel, *Droit électoral*, pp. 164 e ss., para o sistema francês; W. J. M. Mackenzie, *Elecciones libres*, pp. 55 e ss.

do. Para solucionar esses dois problemas fundamentais, é necessário determinar: (a) o número de votos válidos; (b) o quociente eleitoral; (c) o quociente partidário; (d) a técnica de distribuição dos restos ou sobras; (e) a determinação dos eleitos; (f) solução de casos em que há falta de quociente.

(A) *Votos válidos*: para a determinação do quociente eleitoral, contam-se, como válidos, os votos dados à legenda partidária (votação apenas em nome do partido) e os votos de todos os candidatos. Os votos nulos não entram na contagem. O parágrafo único do art. 106 do Código Eleitoral também manda contar, como válidos, os votos em branco. Essa regra não foi recebida pelo novo ordenamento constitucional, que dá clara indicação de que voto branco não é computável (art. 77, § 2º).

(B) *Quociente eleitoral*: determina-se o quociente eleitoral, dividindo-se o número de votos válidos pelo número de lugares a preencher na Câmara dos Deputados, ou na Assembléia Legislativa estadual, ou na Câmara Municipal, conforme o caso, desprezada a fração igual ou inferior a meio, arredondando-se, para 1, a fração superior a meio.

(C) *Quociente partidário*: é o número de lugares cabível a cada partido, que se obtém dividindo-se o número de votos obtidos pela legenda (incluindo os conferidos aos candidatos por ela registrados) pelo quociente eleitoral, desprezada a fração.

(D) *Distribuição dos restos*: feitas as operações supra-indicadas, ficar-se-á sabendo quantos candidatos elegeu cada partido. Acontece que podem sobrar lugares a serem preenchidos, em consequência de restos de votos em cada legenda não suficientes, de per si, para fazer mais um eleito. Há vários métodos para a distribuição dos lugares restantes entre os partidos que concorrem à eleição. Para solucionar esse problema da distribuição dos restos ou das sobras, o direito brasileiro adotou o método da *maior média*, que consiste no seguinte: *adiciona-se mais um lugar aos que foram obtidos por cada um dos partidos; depois, toma-se o número de votos válidos atribuídos a cada partido e divide-se por aquela soma; o primeiro lugar a preencher caberá ao partido que obtiver a maior média; repita-se a mesma operação tantas vezes quantos forem os lugares restantes que devam ser preenchidos, até sua total distribuição entre os diversos partidos* (Código Eleitoral, art. 109).

Note-se, porém, que somente concorrerão a essa distribuição os partidos que tiverem quociente eleitoral, isto é, o número de votos suficiente para a eleição de pelo menos um candidato.

Cumpra, ainda, observar que os lugares a preencher em cada Câmara são distribuídos por circunscrição, de tal sorte que as opera-

ções referidas acima são feitas em referência a cada uma delas. Isso, no entanto, só tem importância quanto às cadeiras a serem preenchidas na Câmara dos Deputados, que são distribuídas em proporção à população de cada circunscrição eleitoral, que, consoante já foi visto, corresponde, no caso, a cada Estado e Distrito Federal. Fixado, para cada eleição, o número de Deputados Federais a serem eleitos por Estado e Distrito Federal (art. 45, § 1º), aqueles elementos da representação proporcional — ou seja: votos válidos, lugares a preencher, quociente eleitoral, quociente partidário, distribuição de restos — apuram-se em cada um deles. Com relação às Assembléias Legislativas e às Câmaras Municipais, a questão é mais simples porque o território do Estado ou do Município funciona, respectivamente, como circunscrição das correspondentes eleições.

Exemplo: o exemplo abaixo ilustrará o que acaba de ser dito, sem necessidade de mais esclarecimentos, senão o de que ele supõe a eleição para a Câmara dos Deputados e também para uma Assembléia Legislativa, na qual se apuraram 8.000.000 (oito milhões) de votos válidos destinados ao preenchimento de 42 lugares cabíveis na primeira daquelas Casas a um suposto Estado e 70 lugares na segunda.

Então, temos, para a Câmara dos Deputados, o seguinte:

(1) *votos válidos*: 8.000.000;

(2) *cadeiras a preencher*: 42;

(3) *quociente eleitoral*: $8.000.000 \div 42 = 190.476$; isto é, cada partido fará tantos deputados quantas vezes sua votação contiver 190.476;

(4) *quociente partidário*, supondo aqui que seis partidos tenham disputado as eleições, encontram-se do modo que segue:

partido	votos		quociente eleitoral		quociente partidário		sobras
A	3.000.000	÷	190.476	=	15 cadeiras	e	142.860 votos
B	2.200.000	÷	190.476	=	11 cadeiras	e	104.764 votos
C	1.600.000	÷	190.476	=	8 cadeiras	e	76.192 votos
D	800.000	÷	190.476	=	4 cadeiras	e	38.096 votos
E	300.000	÷	190.476	=	1 cadeira	e	109.524 votos
F	100.000	÷	190.476	=	nenhuma cadeira		não se computa

Total de cadeiras preenchidas: 39. Restam pois, três a serem distribuídas de acordo com a técnica da *maior média*, já explicada, e conforme o seguinte cálculo:

Para a primeira cadeira a ser distribuída:

<i>partido</i>	<i>votos</i>		<i>quociente partidário + 1</i>	<i>médias</i>
A	3.000.000	÷	16(15 + 1)	187.500
B	2.200.000	÷	12(11 + 1)	183.333
C	1.600.000	÷	9(8 + 1)	177.777
D	800.000	÷	5(4 + 1)	160.000
E	300.000	÷	2(1 + 1)	150.000
F	já está fora por falta de quociente eleitoral		—	—

O partido A, por conseguinte, obteve a *maior média*, ficando com a primeira das três cadeiras. Repitamos a operação para verificar a qual deles cabe a segunda cadeira:

<i>partido</i>	<i>votos</i>		<i>quociente partidário + 1</i>	<i>médias</i>
A	3.000.000	÷	17(16 + 1)	176.470
B	2.200.000	÷	12(11 + 1)	183.333
C	1.600.000	÷	9(8 + 1)	177.777
D	800.000	÷	5(4 + 1)	160.000
E	300.000	÷	2(1 + 1)	150.000

Assim, a outra cadeira coube ao partido B. Note-se que a repetição da operação é simples, porque basta fazer novo cálculo em relação ao partido que obteve a nova cadeira, já que, em relação aos demais, os cálculos são os já feitos. Desse modo, agora, para descobrir que partido ficará com a terceira cadeira, é suficiente fazer novo cálculo com o partido B, que, tendo ganho outra cadeira, ficara efetivamente com 12, adicionando mais uma ficticiamente são 13, número pelo qual se dividirão 2.200.000, o que dá a média 169.230. Com isso, vê-se que as novas médias são: para A: 176.470; para B: 169.230; para C: 177.777 (maior delas); para D: 160.000; e para E: 150.000, de sorte que o partido C ficara com a terceira cadeira, e assim as 42 foram distribuídas na seguinte conformidade:

<i>Partido</i>	<i>Cadeiras</i>
A	16
B	12
C	9
D	4
E	1
F	0
	42

E, para a Assembléia Legislativa do Estado considerado, temos:

- (1) *votos válidos*: 8.000.000;
- (2) *cadeiras a preencher*: 70;
- (3) *quociente eleitoral*: $8.000.000 \div 70 = 114.145$;
- (4) *quociente partidário*:

<i>partido</i>	<i>votos</i>		<i>quociente eleitoral</i>		<i>quociente partidário</i>		<i>sobras</i>
A	3.000.000	÷	114.285	=	26 cadeiras	e	33.630 votos
B	2.200.000	÷	114.285	=	19 cadeiras	e	29.345 votos
C	1.600.000	÷	114.285	=	14 cadeiras	e	580 votos
D	800.000	÷	114.285	=	7 cadeiras	e	285 votos
E	300.000	÷	114.285	=	2 cadeiras	e	71.590 votos
F	100.000	÷	114.285	=	nenhuma cadeira		não se computa

Total de cadeiras preenchidas: 68. Restam duas, que, pelo cálculo da maior média, caberão a primeira ao partido A e a segunda ao partido B, de tal sorte que as 70 cadeiras ficam assim distribuídas: A = 27; B = 20; C = 14; D = 7; E = 2; F = 0.

(E) *Determinação dos eleitos*: definido, na forma acima, o número de cadeiras de cada partido, surge o problema da determinação dos eleitos, o que é simples, pois o *preenchimento dos lugares, com que cada partido for contemplado, far-se-á segundo a ordem de votação dos seus candidatos* (Código Eleitoral, art. 109, § 1º). Quer dizer: os candidatos mais votados, em cada legenda, serão os eleitos, para ocupar as cadeiras que lhes toquem. No caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso (Código Eleitoral, art. 110).

(F) *Falta de quociente eleitoral*: pode acontecer que nenhum partido consiga obter o quociente eleitoral. Ocorrendo isso, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. É solução dada pelo art. 111 do Código Eleitoral, o que é uma aplicação do princípio majoritário, que, agora, parece inteiramente inconstitucional, pois a Constituição não faz concessão no caso. A solução correta será considerar nula a eleição e fazer outra.

19. O sistema misto

Há mais de um tipo de *sistema eleitoral misto*. Um, que é o alemão, denominado *sistema de eleição proporcional "personalizado"*, que procura combinar "o princípio decisório da eleição majoritária com o modelo representativo da eleição proporcional, posto que divide cada voto em duas partes, computa-os em separado, elegendo-se a metade dos Deputados por circunscrições distritais e a outra metade em função de listas de base estadual".⁵⁹ Por esse sistema, que tem sido muito reivindicado para o Brasil, cada Estado será dividido em tantos distritos em número igual à metade dos lugares a preencher; cada partido apresentará um candidato para cada distrito e uma lista partidária para todo o Estado. O eleitor disporá de dois votos: o primeiro será atribuído a um dos candidatos do distrito, assinalando um nome, e o outro, a uma das listas partidárias, assinalando uma legenda (voto de legenda). Segundo o sistema alemão, para calcular o número de lugares que corresponde aos partidos, se tomará em consideração a porcentagem de votos obtidos pela legenda. Feito isso, se verificará quantos candidatos cada partido elegeu pelos distritos e quantos elegeu pelo sistema de listas. Disso se vê que o critério decisivo é o proporcional.⁶⁰

Bastante diferente é o sistema eleitoral misto em vigor no México, que, diante do sistema de partido dominante, só tem por finalidade abrir condições de representação das minorias. Assim é que, para a eleição de integrantes da Câmara dos Deputados, se estabelecem dois tipos de unidades eleitorais. A primeira é o *distrito eleitoral uninominal*, sendo o país dividido em trezentos deles distribuídos pelos trinta e um Estados e o Distrito Federal, observado que nenhuma unidade federativa pode ter representação menor do que dois Deputados. A segunda unidade eleitoral é a *circunscrição plurinominal*, em número de cinco para todo o país, e que constitui a base para a eleição de duzentos Deputados pelo princípio da representação proporcional. Vale dizer, a Câmara dos Deputados do Congresso da União

mexicana é integrada por 500 Deputados, 300 eleitos pelo sistema de maioria relativa nos distritos e 200 eleitos pelo sistema de representação proporcional. Nenhum partido pode ter reconhecidos mais de 350 Deputados ainda que sua votação o permita.⁶¹ Ao inverso do sistema alemão, o mexicano é um sistema misto de predomínio do sistema de maioria. É o que expressamente se admite: "O sistema acima exposto, em termos gerais, busca conservar o sistema eleitoral misto, mas com um aumento da representação proporcional, com predomínio do sistema de maioria".⁶²

No Brasil, houve tentativa de implantar um chamado *sistema misto majoritário e proporcional por distrito*, na forma que a lei dispusesse. A Emenda Constitucional 22/82 é que o previu. Um projeto de lei foi apresentado ao Congresso Nacional pelo Presidente da República regulando a matéria. Previa que nas eleições à Câmara dos Deputados os Estados e Distrito Federal seriam divididos em distritos em número igual à metade dos lugares correspondentes na Câmara dos Deputados. Previa também que, para essas eleições, cada partido poderia registrar dois candidatos por distrito, sendo eleito um pelo sistema majoritário, e outro pelo sistema proporcional. E nas eleições para as Assembléias Legislativas, cada partido poderia apresentar um candidato pelo sistema majoritário em cada distrito e até cinco pelo sistema proporcional. Não cabe aqui entrar nos pormenores do sistema. Basta apenas observar que ele abria, sem dúvida, possibilidades para a representação das minorias, mas a proporcionalidade não era a característica do princípio de representação proporcional, pois fundamentalmente consistia numa porcentagem de votos obtidos pelo candidato do partido em relação com o número de votantes do respectivo distrito. Seria considerado eleito o candidato do partido mais votado em cada distrito. Determinado pela porcentagem do partido o número de lugares a que cada um teria direito aplicando o sistema proporcional, considerando-se eleitos os candidatos classificados segundo a melhor posição conseguida nos diferentes distritos, até completar a porcentagem do respectivo partido. Basicamente o sistema coincidia com os distritos, porque os candidatos das listas se elegeriam também pelo distrito e sobre a base da relação existente entre sua votação com o número de votantes do mesmo distrito.⁶³

Tentativas de implantar o sistema eleitoral misto, de tipo alemão, na Constituinte e no processo revisional de 1994, fracassaram,

61. Cf. Comisión Federal Electoral, *La nueva legislación electoral mexicana*, pp. 8 e 9.

62. Idem, *ibidem*, p. 12.

63. Cf. o nosso "Representación proporcional, efectos corporativos en Brasil", in *Sistemas electorales y representación política en Latinoamérica*, v. 2/373-375.

59. Cf. Dieter Nohlen, *Sistemas electorales del mundo* p. 520.

60. Cf. Dieter Nohlen, *ob. cit.*, p. 520.

mas a tendência a isso se amplia cada vez mais, à vista dos notórios defeitos do sistema de representação proporcional puro que vigora atualmente.

IV. PROCEDIMENTO ELEITORAL

20. Noção e fases

O procedimento eleitoral compreende uma sucessão de atos e operações encadeadas com vista à realização do escrutínio e escolha dos eleitos. Desenvolve-se em três fases basicamente: (1) apresentação das candidaturas; (2) organização e realização do escrutínio; (3) contencioso eleitoral.

21. Apresentação das candidaturas

O procedimento eleitoral visa selecionar e designar as autoridades governamentais, especialmente os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, das Câmaras Municipais e Chefes de Poderes Executivos. A escolha, no entanto, não se faz *in abstracto*, mas entre candidatos previamente apresentados à opção popular por meio dos partidos políticos, pois, como vimos, a filiação partidária é uma das condições de elegibilidade. Portanto, o procedimento eleitoral há que começar pela *apresentação das candidaturas* ao eleitorado, o que compreende os atos e operações de designação de candidatos em cada partido, do seu registro no órgão da Justiça Eleitoral competente e da propaganda eleitoral que se destina a tornar conhecidos o pensamento, o programa e os objetivos dos candidatos.

Formação das candidaturas: as candidaturas formam-se em cada partido segundo processo por ele estabelecido, pois a Constituição garante-lhes autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento (art. 17, § 1º), e nisso entra o modo de designação de candidatos, que pode ser feita em convenções partidárias compostas de delegados ou por votação de todos os filiados ou militantes, ficando tudo na dependência do que dispuser o estatuto de cada partido, de modo que a rígida legislação sobre o assunto perde validade em face dele. Apesar do texto constitucional possibilitar isso que acaba de ser dito, lamentavelmente a Justiça Eleitoral continua a considerar válida a legislação eleitoral e partidária que impede aos partidos o exercício das liberdades constitucionalmente outorgadas, de sorte que as candidaturas continuam a formar-se nos estritos termos dessa legislação por via de designação feita em convenções partidárias.

Registro das candidaturas: efetuada a escolha dos candidatos, cumpre ao partido providenciar-lhes o registro consoante procedimento minucioso, hoje descrito nos arts. 87 a 102 do Código Eleitoral.

Propaganda das candidaturas: a propaganda eleitoral visa tornar conhecidas as candidaturas partidárias, o pensamento de cada candidato individualmente considerado, porque, além da disputa interpartidária, há também a disputa, não raro mais aguda, entre candidatos à eleição proporcional do mesmo partido (disputa intrapartidária), e especialmente o programa partidário. É minuciosamente regulada nos arts. 240 a 256 do Código Eleitoral. O princípio geral é que a propaganda eleitoral seja realizada sob a responsabilidade dos partidos políticos e por eles paga, garantindo a eles acesso gratuito ao rádio e à televisão para tanto (art. 17, § 3º). A propaganda somente pode ser iniciada depois da escolha dos candidatos.

22. O escrutínio

Este termo tem sido usado muitas vezes num sentido estrito, para designar apenas o *ato de contagem de votos*, assim como *escrutinar* se emprega com a acepção de verificar o *número de votos*, conferindo-os, e *escrutinador* aquele que conta e confere os votos.

Mas não é nesse sentido estreito que se usa o termo no processo eleitoral. Aqui ele tem conotações mais amplas, significando o *modo de exercício do voto*, "*in concreto*", envolvendo, assim, todas as operações eleitorais concretas destinadas a recolher e apurar os sufrágios. Compreende, pois, as operações de *votação* (depósito e recolhimento dos votos nas urnas) e as operações de *apuração dos votos* (abertura das urnas, conferência dos votos em face do número deles em referência a cada candidato). Tais operações estão reguladas no Código Eleitoral, arts. 135 a 157 (*Da votação*) e 158 a 233 (*Das Apurações*).

Escrutínio, no sentido indicado, é, pois, o *modo pelo qual se recolhem e apuram os votos nas eleições*. E é nesse momento que devem concretizar-se as garantias eleitorais do sigilo e liberdade do voto.

23. O contencioso eleitoral

Os conflitos de interesses eleitorais são compostos pela Justiça Eleitoral (arts. 118 a 121), à qual, desde 1932 (excetuando-se o período de vigência da Carta de 1937), se conferiu competência para a verificação de poderes (reconhecimento de quem foi eleito, mediante sua diplomação) e, finalmente, para dispor sobre toda a matéria eleitoral, observadas naturalmente as normas constitucionais e le-

gais. O *contencioso eleitoral* cabe a essa Justiça e tem por objetivo fundamental assegurar a eficácia das normas de garantias eleitorais e, especialmente, coibir a fraude, buscando a verdade e a legitimidade eleitoral: em suma, a *lisura dos pleitos*.

Capítulo III

DOS DIREITOS POLÍTICOS NEGATIVOS

I. SIGNIFICADO: 1. Conceito. 2. Conteúdo. 3. Interpretação. II. PRIVAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS: 4. Modos de privação dos direitos políticos. 5. Perda dos direitos políticos. 6. Suspensão dos direitos políticos. 7. Competência para decidir sobre perda e suspensão de direitos políticos. III. REAQUISIÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS: 8. Condições de re aquisição dos direitos políticos. 9. Re aquisição dos direitos políticos perdidos. 10. Re aquisição dos direitos políticos suspensos. IV. INELEGIBILIDADES: 11. Conceito de inelegibilidade. 12. Objeto e fundamentos das inelegibilidades. 13. Eficácia das normas sobre inelegibilidades. 14. Inelegibilidades absolutas e relativas. 15. Desincompatibilização.

I. SIGNIFICADO

1. Conceito

Denominamos *direitos políticos negativos* àquelas determinações constitucionais que, de uma forma ou de outra, importem em *privar o cidadão* do direito de participação no processo político e nos órgãos governamentais. São *negativos* precisamente porque consistem no conjunto de regras que *negam*, ao cidadão, o direito de eleger, ou de ser eleito, ou de exercer atividade político-partidária ou de exercer função pública.

2. Conteúdo

Os *direitos políticos negativos* compõem-se, portanto, das regras que *privam* o cidadão, pela perda definitiva ou temporária (suspensão), da totalidade dos direitos políticos de votar e ser votado, bem como daquelas regras que determinam restrições à elegibilidade do cidadão, em certas circunstâncias: as *inelegibilidades*.

Embora as regras sobre *reaquisição* dos direitos políticos, em si, não configurem aspecto negativo, delas trataremos aqui pela sua conexão com a matéria do capítulo.

3. Interpretação

O princípio que prevalece é o da plenitude do gozo dos direitos políticos positivos, de votar e ser votado.¹ A pertinência desses direitos ao indivíduo, como vimos, é que o erige em cidadão. Sua privação ou a restrição do seu exercício configura exceção àquele princípio. Por conseguinte, a interpretação das normas constitucionais ou complementares relativas aos direitos políticos deve tender à maior compreensão do princípio, deve dirigir-se ao favorecimento do direito de votar e de ser votado, enquanto as regras de privação e restrição não de entender-se nos limites mais estreitos de sua expressão verbal, segundo as boas regras de hermenêutica.

II. PRIVAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS

4. Modos de privação dos direitos políticos

O cidadão pode, excepcionalmente, ser privado, *definitivamente* ou *temporariamente*, dos direitos políticos, o que importará, como efeito imediato, na perda da cidadania política. Deixa, imediatamente, de ser eleitor, se já o era, ou torna-se inalistável como tal, com o que, por consequência, fica privado da elegibilidade e de todos os direitos fundados na qualidade de eleitor.

A *privação definitiva* denomina-se *perda* dos direitos políticos; a *temporária* é sua *suspensão*. A Constituição *veda a cassação de direitos políticos*, e só admite a *perda* e a *suspensão* nos casos indicados no art. 15, ou seja, em virtude de: (a) cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; (b) incapacidade absoluta; (c) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; (d) recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do art. 5º, VIII; (e) improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Como se nota, a Constituição não indica quais os casos de perda e quais os de suspensão, mas a tradição e a natureza do motivo de privação podem ajudar, de maneira que casos de suspensão configuram-se nos incs. II, III e V do art. 15; os outros são de perda. Para alguns casos, resta a dúvida de que autoridade é competente para

decidir sobre a perda ou suspensão. Tentaremos solucionar essas dúvidas, examinando as duas hipóteses separadamente.

5. Perda dos direitos políticos

Consiste, como dissemos, na privação definitiva dos direitos políticos, com o que o indivíduo perde sua condição de eleitor e todos os direitos da cidadania nela fundados.

As Constituições anteriores previam a perda dos direitos políticos em razão da perda da nacionalidade brasileira por aquisição voluntária de outra. Isso não mais ocorre. Assim esclarecida dúvida que a omissão desse dispositivo suscita, concluímos que são casos de perda dos direitos políticos: (a) o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; (b) a perda da nacionalidade brasileira com a aquisição de outra; (c) a recusa de cumprir obrigação imposta ou prestação alternativa.² O primeiro caso é simples; o segundo e o terceiro comporta discussão sucinta.

O art. 15, em verdade, não incluiu a *perda da nacionalidade* entre os motivos de perda ou de suspensão dos direitos políticos. Mas a interpretação sistemática leva à conclusão de que sua ocorrência, mediante a aquisição de outra, implicará a perda dos direitos políticos, na medida em que isso importa em transformar o brasileiro em estrangeiro, e como o estrangeiro não pode alistar-se eleitor, o eventual alistamento eleitoral daquele perde o pressuposto básico de existência. Ora, se a nacionalidade brasileira é pressuposto da posse dos direitos políticos, perde-os quem a perde com a aquisição de outra (art. 12, § 4º, II), ainda que isso não conste do art. 15.

A *escusa de consciência* (recusa de cumprir obrigação legal a todos imposta) é faculdade que a Constituição reconhece a todos em decorrência da liberdade de crença religiosa ou de convicções filosóficas ou políticas (art. 5º, VIII). Esse dispositivo, realmente, declara que “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, *salvo se as invocar para exi-*

1. Trata-se de princípio universal que já figurava no art. 6º da Declaração de Direitos de Virgínia (1776), no art. 6º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e, especialmente, figura ainda no art. 21, 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948): “Toda pessoa tem direito de participar no Governo de seu país, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos”.

2. Incluímos esse caso como de perda dos direitos políticos e não como hipótese de suspensão, porque esta se dá quando a situação causal indica temporariedade ou é previsível a cessação da privação dos direitos políticos. As constituições anteriores também a incluíam como causa de perda e não de suspensão dos direitos políticos. Contudo, a Lei 8.239/91 prevê, para a hipótese, a suspensão dos direitos políticos do inadimplente, que poderá, a qualquer tempo, regularizar sua situação mediante cumprimento das obrigações devidas. Talvez, porque o dispositivo preveja a possibilidade de recuperação dos direitos políticos é que falou em suspensão. No entanto, essa recuperação, a nosso ver, é simplesmente a possibilidade de reaquisição dos direitos

mir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei". Ora, por esse texto, a escusa de consciência não seria punível e nem importaria na perda de direito algum, porque o escusante teria que cumprir prestação alternativa. Então, a escusa de consciência se compensaria com a prestação alternativa. Qual a prestação alternativa, cabe à lei fixar, de acordo com o mesmo dispositivo. Agora, sim, fixada em lei qual a prestação alternativa, a recusa em cumpri-la é que seria punível pela forma que a lei estabelecesse. Tanto é assim que os Projetos de Constituição não previram, coerentemente, punição para o caso. Ao que nos parece, sequer foi aprovado em primeiro turno o texto do art. 15, IV, tendo surgido de sugestões de redação para o segundo turno, e assim foi aprovado, gerando incoerência e até um *sem sentido*, porque não é lógico que o art. 5º, VIII, mande o escusante cumprir uma prestação alternativa pela escusa de consciência que também possa ser motivo de perda dos direitos políticos, e assim mesmo ficar sujeito à prestação alternativa. Temos que conciliar os dispositivos. E o único meio coerente de fazê-lo é considerar que pela simples escusa de consciência não se perdem os direitos políticos, o que ocorre apenas se o escusante também recusar cumprir a prestação alternativa. Se, exercendo a faculdade de escusa de consciência, se submeter à prestação alternativa, não sofrerá perda de direitos. Tudo isso está na dependência do que a lei fixar. Antes disso, não poderá haver perda de direitos políticos para o caso.³

6. Suspensão dos direitos políticos

Consiste na *privação temporária* dos direitos políticos. Só pode ocorrer por uma destas três causas: (a) *incapacidade civil absoluta*; (b) *condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos*; (c) *improbidade administrativa*.

Os dois primeiros casos eram concebidos pela Constituição de 46 (art. 135, § 1º) como de *suspensão* e com razão porque fundados em pressupostos temporários. Então, a doutrina e a jurisprudência encontraram base nos dispositivos do Código Civil e do Código Penal para a aplicação correta da medida constitucional.

Concluíram, por um lado, que, sendo a *incapacidade civil absoluta* definida no art. 5º do Código Civil, bastava sua verificação judicial,

perdidos. No caso de suspensão, a recuperação é automática, em virtude da cessação da causa da privação.

3. A Lei 8.239/91 definiu a matéria no que se refere à prestação alternativa de serviço militar obrigatório ao regulamentar o art. 143, §§ 1º e 2º, da Constituição, que é o aspecto mais sensível da questão, por ser onde a escusa mais se realiza, e deu para esse aspecto a solução aventada no texto (art. 4º, § 2º).

mediante decretação da *interdição do incapaz*, nos termos dos arts. 446 e 462 do mesmo Código e dos dispositivos processuais aplicáveis, para que decorresse, como medida acessória, a privação provisória da cidadania do interdito.⁴

A *condenação criminal*, como causa de suspensão dos direitos políticos, enquanto durar seus efeitos, gerou alguma controvérsia sobre se o *sursis* (suspensão condicional da pena) é um dos efeitos da condenação, ou não. Houve quem sustentasse que não, e logo, uma vez obtido a suspensão condicional da pena, não se suspenderiam os direitos políticos. Outros achavam que sim, e, portanto, enquanto durasse o *sursis*, os direitos políticos ficariam suspensos. Entendemos que o *sursis* não é efeito da condenação, mas simplesmente um modo de seu cumprimento. Mas, a nós nos parece que esta discussão é inteiramente desnecessária para se chegar à conclusão de que o paciente continuará com seus direitos políticos suspensos, ainda que se beneficie do *sursis*. É que a suspensão de direitos políticos constitui uma das penas restritivas de direitos, às quais não se estende a suspensão condicional da pena (CP, arts. 43, II, 47, I, e 80). Se é assim, o benefício da suspensão condicional da pena não interfere com a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal. Vale pelo tempo que o juiz determinou, independentemente da observância ou não daquela.

A *improbidade administrativa* entra pela primeira vez no ordenamento constitucional como causa de suspensão de direitos políticos. O texto em que é prevista não tem, contudo, boa redação. É o art. 37, § 4º: "Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível". Mas dá a entender que a *improbidade administrativa* não é propriamente sinônimo de *imoralidade administrativa*. Esta teria um sentido mais amplo, de sorte que nem toda imoralidade administrativa conduziria, necessariamente, à suspensão dos direitos políticos, salvo como pena acessória em condenação criminal. A improbidade diz respeito à prática de ato que gere prejuízo ao erário público em proveito do agente. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo. O ímprobo administrativo é o devasso da Administração Pública.

Outra idéia que sai do texto seria a de que a suspensão dos direitos políticos por improbidade administrativa pode ser aplicada in-

4. Cf. Sampaio Dória, *Comentários à Constituição de 1946*, v. III/568; Dardeau de Carvalho, *Nacionalidade e cidadania*, pp. 297 a 299.

dependentemente de um processo criminal. É o que se extrai da parte final, segundo a qual todas as sanções indicadas antes são sem prejuízo da ação penal. Vale dizer, independentemente dessa ação. Ou seja, a suspensão dos direitos políticos, no caso, não constitui simples pena acessória. O problema é que não pode a suspensão ser aplicada em processo administrativo. Terá que ser em processo judicial, em que se apure a improbidade, quer seja criminal ou não.

7. Competência para decidir sobre perda e suspensão de direitos políticos

A Constituição não indicou, explicitamente, que autoridade é competente para decretar a perda e a suspensão dos direitos políticos. As constituições anteriores davam competência ao Presidente da República para decretar a perda em alguns casos e ao Poder Judiciário em outros. A suspensão só a este competia (CF de 1969, art. 149, § 2º). Pelo art. 15, já é fácil concluir que dependem de *decisão judicial* a perda dos direitos políticos conseqüente do cancelamento da naturalização e a suspensão em virtude de incapacidade civil absoluta e de condenação criminal, porque, em todos esses casos, a medida é conseqüência de outro julgamento. Vem como um efeito secundário da sentença. Parece-nos também que a suspensão em razão de improbidade administrativa terá que decorrer de decisão judicial, em processo principal civil ou penal, ou como pena acessória. Não há como fugir a essa tese, porque não se pode admitir a aplicação de penas restritivas de direito fundamental por via que não seja a judiciária, quando a Constituição não indique outro meio.

Resta saber a quem cabe aplicar a perda dos direitos políticos no caso de recusa de cumprir obrigações a todos impostas ou prestação alternativa. A Constituição revogada dava, expressamente, competência ao Presidente da República para a decretação da perda dos direitos políticos nessa hipótese. Mas a atual não o faz, logo não lhe caberá tal decisão. E se não imputa a ele essa competência, só resta ao Poder Judiciário, único que tem poder para dirimir a questão, em processo suscitado pelas autoridades federais em face de caso concreto.

III. REAQUISIÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS

8. Condições de re aquisição dos direitos políticos

A Constituição não estatui sobre a re aquisição dos direitos políticos perdidos ou suspensos. As Constituições anteriores, desde a de

1946, previam uma lei que deveria dispor sobre os casos e condições de re aquisição desses direitos. Sobre o assunto está ainda parcialmente em vigor a Lei 818/49.

9. Re aquisição dos direitos políticos perdidos

A re aquisição dos direitos políticos perdidos é regulada no art. 40 da Lei 818/49, que continua em vigor sobre a matéria, naquilo em que a atual Constituição manteve do sistema anterior. Desde já uma conclusão se manifesta: quem perdeu os direitos políticos em virtude do cancelamento da naturalização não os readquirirá mais, a menos que, por ação rescisória, se rescinda o julgado que impôs aquele cancelamento, de modo que o naturalizado recupere a nacionalidade brasileira. A regra é: quem perdeu os direitos políticos em razão da perda da nacionalidade brasileira, readquirida esta, ficará obrigado a novo alistamento eleitoral, reavendo, assim, seus direitos políticos.

A re aquisição dos direitos políticos perdidos em conseqüência da escusa de consciência está prevista no art. 40 da lei citada. Mas a situação não é mais a mesma. Pode-se, contudo, admitir uma analogia no caso, dizendo que o brasileiro que houver perdido aqueles direitos por não cumprir a prestação alternativa fixada em lei pode readquiri-los, declarando, perante a autoridade competente (Ministro da Justiça, p. ex.), que está pronto para suportar o ônus. A Lei 8.239/91 prevê essa re aquisição, quando diz que o inadimplente "poderá, a qualquer tempo, regularizar sua situação mediante cumprimento das obrigações devidas" (art. 4º, § 2º).

10. Re aquisição dos direitos políticos suspensos

Não há norma expressa que preveja os casos e condições de re aquisição de direitos políticos suspensos. Essa circunstância, contudo, não impossibilita a recuperação desses direitos que se dará automaticamente com a cessação dos motivos que determinaram a suspensão. Bem o disse Dardeau de Carvalho: "A omissão, contudo, em nada prejudica a perfeita inteligência do Texto Constitucional. A suspensão dos direitos políticos é medida transitória e só dura enquanto durar a causa que a determinou. Cessada a causa — a incapacidade civil ou a condenação criminal — cessam de pleno direito os seus efeitos".⁵ Acrescentemos que, no caso de suspensão por improbida-

5. Cf. *ob. cit.*, p. 304.

de administrativa, o tempo de suspensão ou suas condições de cessação há de constar da decisão que a aplicou, de modo que, ressarcido o erário, decorrido o prazo ou cumpridas as condições estabelecidas, o paciente recuperará seus direitos suspensos.

IV. INELEGIBILIDADES

11. Conceito de inelegibilidade

Inelegibilidade revela impedimento à capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado). Obsta, pois, à elegibilidade. Não se confunde com a *inalistabilidade*, que é impedimento à capacidade eleitoral ativa (direito de ser eleitor), nem com a *incompatibilidade*, impedimento ao exercício do mandato depois de eleito.

12. Objeto e fundamentos das inelegibilidades

As *inelegibilidades* têm por objeto proteger a probidade administrativa, a normalidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta (art. 14, § 9º).⁶ Entenda-se que a cláusula “contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função...” só se refere à *normalidade* e à *legitimidade* das eleições. Isso quer dizer que “a probidade administrativa” e “a moralidade para o exercício do mandato” são valores autônomos em relação àquela cláusula; não são protegidos contra a influência do poder econômico ou abuso de função etc., mas como valores em si mesmos dignos de proteção, porque a improbidade e imoralidade, aí, conspurcam só por si a lisura do processo eleitoral.

As inelegibilidades possuem, assim, um fundamento ético evidente, tornando-se ilegítimas quando estabelecidas com fundamento político ou para assegurar o domínio do poder por um grupo que o venha detendo, como ocorreu no sistema constitucional revogado. Demais, seu sentido ético correlaciona-se com a democracia, não podendo ser entendido como um moralismo desgarrado da base democrática do regime que se instaure.

6. A ECR-4/94 deu nova redação ao § 9º do art. 14 para acrescentar, como objeto de proteção das inelegibilidades, “a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato”, recuperando, assim, regras que figuravam no art. 151 da Constituição de 1969.

13. Eficácia das normas sobre inelegibilidades

A Constituição estabelece, diretamente, vários casos de inelegibilidades no art. 14, §§ 4º a 7º, que serão objeto de nossa consideração no próximo tópico. As normas contidas nesses parágrafos são de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Vale dizer: para incidirem, independem da lei complementar referida no § 9º do mesmo artigo.

A citada lei complementar está autorizada a estabelecer outros casos de inelegibilidades e os prazos de sua cessação, a fim de proteger aqueles valores, que são fundamentos do regime democrático. Não se pense que apenas essas outras inelegibilidades é que têm por objeto protegê-los. As estatuídas diretamente pela Constituição também o têm. A explicitação do objeto, quanto às inelegibilidades a serem criadas pela lei complementar, era necessária, porque, configurando elas restrições a direitos políticos, importa sejam delimitadas aos objetos e fundamentos clara e expressamente indicados. Por serem restritivas de direitos fundamentais (direitos à elegibilidade), é que a técnica sempre recomendou que fossem disciplinadas inteiramente em dispositivos constitucionais.

Com tais fundamentos é que a Constituição de 1946 as regulou completamente, de acordo com pronunciamento de Argemiro de Figueiredo, no debate da matéria na Constituinte de então: “se já estatuímos, em dispositivos já votados, todos os casos de *elegibilidades*, com maior razão devemos incluir, *expressamente*, em nossa Carta Magna os de *inelegibilidades*, porque estes são mais importantes, visto como significam restrições ao direito político do cidadão. O mesmo poder que cria o direito é o competente para impor limitações. Seria erro de técnica, e perigoso mesmo, deixarmos matéria de tamanha importância para o legislador ordinário”.⁷ A experiência do sistema revogado demonstrou, com sobradas razões, o acerto dessa lição de Argemiro Figueiredo, que a Constituinte de 1987/88, lamentavelmente, não aprendeu, deixando à lei complementar a possibilidade de criação de outros casos com o só limite de indicativos não muito definidos. O casuísmo da Lei Complementar 5/70 fez incluir, em seus dispositivos, casos de inelegibilidades absurdos. Essa lei foi substituída pelas Leis Complementares 64, de 18.5.90, e 81, de 13.4.94, que, embora mais sóbrias, sujeitando-se aos limites que a própria Constituição lhes impõe e aos que decorrem naturalmente do sentido excepcional que devem ter normas restritivas de direitos fundamentais, ainda mantém excessivo casuísmo.

7. Cf. José Duarte, *A Constituição brasileira de 1946*, v. II/516.

14. Inelegibilidades absolutas e relativas

As inelegibilidades podem ser consideradas sob dois critérios, no tocante à sua abrangência: *absolutas* e *relativas*.

As *inelegibilidades absolutas* implicam impedimento eleitoral para *qualquer cargo eletivo*. Quem se encontre em situação de inelegibilidade absoluta não pode concorrer a eleição alguma, não pode pleitear eleição para qualquer mandato eletivo e não tem prazo para desincompatibilização que lhe permita sair do impedimento a tempo de concorrer a determinado pleito. Ela só desaparece quando a situação que a produz for definitivamente eliminada. Por isso, ela é excepcional e só é legítima, quando estabelecida na própria Constituição. E esta somente consigna, como tal, a que decorre da *inalistabilidade* e a dos *analfabetos*, quando, no art. 14, § 4º, declara que *são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos*. Uma é genérica, apanhando quem quer que esteja em situação de alistabilidade, e tais são: os menores de 16 anos (ou de 18 não alistados), os conscritos e os que estiverem privados, temporária ou definitivamente, de seus direitos políticos. Outra é específica para um tipo de cidadãos alistados eleitores, a quem, apesar disso, a Constituição nega o direito de elegibilidade: os *analfabetos*. Rigorosamente absoluta, como se percebe, é apenas a inelegibilidade dos analfabetos e dos que perderam os direitos políticos, porque os demais têm, ao menos, uma expectativa de cessação do impedimento. Nota-se que os absolutamente inelegíveis são aqueles que não são titulares da elegibilidade. O *absoluto* está precisamente nisto: não podem pleitear eleição alguma, e nem dispõem de prazo de cessação do impedimento. Por isso, embora quem se encontre na situação das inelegibilidades arroladas nas alíneas *b* e *e* do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/90 não possa candidatar-se “para qualquer cargo”, não está em inelegibilidade absoluta, porque depende dele sair do impedimento, desincompatibilizando-se em tempo hábil. Não é absoluta a inelegibilidade quando se prevê prazo de desincompatibilização e meios de liberação do vínculo dependente do sujeito inelegível.

As *inelegibilidades relativas* constituem restrições à elegibilidade para determinados mandatos em razão de situações especiais em que, no momento da eleição, se encontre o cidadão. O relativamente inelegível é titular de elegibilidade, que, apenas, não pode ser exercida em relação a algum cargo ou função eletiva, mas o poderia relativamente a outros, exatamente por estar sujeito a um vínculo funcional, ou de parentesco ou de domicílio que inviabiliza sua candidatura na situação vinculada.

Não entraremos aqui no casuísmo da lei complementar, apenas nos ateremos às normas constitucionais, segundo as quais são relativamente inelegíveis:

(A) por motivos funcionais:

(1) *para os mesmos cargos, num terceiro período subsequente*: (a) o Presidente da República; (b) os Governadores de Estado e do Distrito Federal; (c) os Prefeitos; (d) quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito. A EC-16/97 abriu a possibilidade desses titulares de mandatos executivos pleitearem um novo mandato sucessivo para o mesmo cargo, mas só por mais um único mandato subsequente, valendo dizer que a inelegibilidade especial perdura para um terceiro mandato imediato. Trata-se, pois, de *privação da elegibilidade para o mesmo cargo que pela segunda vez está sendo ocupado pelo interessado*. Uma recondução é possível. A segunda é vedada. O de que se trata é mesmo de *proibição de uma segunda reeleição*; basta, para que se componha a inelegibilidade em causa, que o *titular*, originário ou sucessor, tenha exercido, *por um instante*, o cargo, no período de seu segundo mandato, ou o *substituto*, em qualquer momento, dentro dos seis meses anteriores ao pleito; se apenas tomar posse e não entrar em exercício do cargo, não se compõe a inelegibilidade;⁸ cumpre observar que o Vice-Presidente da República, o Vice-Governador de Estado ou do Distrito Federal e o Vice-Prefeito de Município não estão proibidos de pleitear a reeleição, indefinidamente, como também podem candidatar-se, sem restrição alguma, à vaga dos respectivos titulares, salvo se os sucederam (assim, passando a titular) ou os substituíram nos últimos seis meses antes do pleito do segundo mandato;

(2) *para concorrerem a outros cargos*, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos, salvo desincompatibilização, mediante renúncia aos respectivos mandatos, até seis meses antes do pleito; confirma-se aqui que os Vices são elegíveis a qualquer mandato, sem necessidade de renunciarem;

(B) *por motivo de parentesco*, no território de circunscrição do titular (o art. 14, § 7º, diz, erroneamente, *no território da jurisdição do titular*, porquanto, em relação a vínculo político-eleitoral, não se trata de jurisdição, mas de circunscrição), os *cônjuges* e os *parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção*, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, ou do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titulares de mandato eletivo e candidatos à reeleição. Essa inelegibilidade aproxima-se da absoluta, especialmente quanto ao cônjuge e aos parentes do Presidente da República, não titulares de mandato, que não podem pleitear eleição

8. Cf., com razão, Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1946*, v. III/143 e 144.

para cargo ou mandato algum. A diferença está em que ela decorre de situação especial com possibilidade de desaparecer pela vontade das pessoas envolvidas (a renúncia do Presidente, seis meses antes do pleito, desvincilha, da restrição, seu cônjuge e parentes) e com prazo certo para terminar;

(C) *por motivo de domicílio*, pois, como vimos, o *domicílio eleitoral na circunscrição* é uma das condições de elegibilidade, *na forma da lei* (art. 14, § 3º, IV), logo é *inelegível* para mandato ou cargo eletivo em circunscrição em que não seja domiciliado pelo tempo exigido em lei.⁹

15. Desincompatibilização

Dá-se também o nome de *desincompatibilização* ao ato pelo qual o candidato se desvincilha da inelegibilidade a tempo de concorrer à eleição cogitada. O mesmo termo, por conseguinte, tanto serve para designar o ato, mediante o qual o eleito sai de uma situação de incompatibilidade para o exercício do mandato, como para o candidato desembaraçar-se da inelegibilidade.

Com efeito, o candidato que incidir numa regra de inelegibilidade *relativa* deverá desincompatibilizar-se no prazo estabelecido, de sorte que, no momento em que requer o registro de sua candidatura, se encontre desembaraçado, sob pena de ver-se denegado o registro. O cônjuge e o parente inelegível ficam em posição incômoda, porque não são eles que estão na condição de desincompatibilização; nada podem fazer, por si, senão pressionar o cônjuge ou parente titular do cargo, para que renuncie a este, a fim de desvincilhá-los do embaraço.

Em algumas hipóteses, a desincompatibilização só se dará com o afastamento definitivo da situação funcional em que se ache o candidato, ou o cônjuge ou parente. Noutras, basta o licenciamento.

A regra é a de que deve afastar-se definitivamente, por renúncia ou exoneração, quem ocupe função ou cargo de Chefe de Executivo ou de sua confiança (Ministro, Secretário etc.). São, porém, casos de simples *licenciamento* a desincompatibilização de agentes que exer-

9. A Constituição não estabeleceu o tempo de domicílio necessário a compor a condição de elegibilidade. Remete a matéria à lei. E é a lei das inelegibilidades que sempre tratou do tema. Mas esta é lei complementar (art. 14, § 9º) e a lei prevista para a fixação do domicílio eleitoral é ordinária (art. 14, § 3º, IV). Nada impedia que a lei das inelegibilidades, assim mesmo, o fizesse, mas não o fez, de sorte que essa fixação do tempo do domicílio vem sendo estabelecida casuisticamente nas leis que regulamentam cada eleição, como o fez a Lei 8.713/94, para as eleições de 3.10.94, exigindo que o candidato estivesse domiciliado na circunscrição eleitoral respectiva desde 31.12.93 (9 meses e 5 dias antes das eleições).

çam cargos ou funções efetivas, tais como os do fisco, os do Ministério Público, os da polícia, bem como os da administração e representação de certas entidades, instituições ou empresas, para cujos ocupantes se estatuem inelegibilidades. Para as hipóteses que não requerem afastamento definitivo, a jurisprudência tem firmado a tese de que ocorre a desincompatibilização por qualquer forma que demonstre a desvinculação efetiva do exercício da função ou cargo, como férias, licença-prêmio, faltas injustificadas etc.¹⁰

As constituições anteriores também a incluíam como causa de perda e não de suspensão dos direitos políticos.

10. Cf. acórdãos ns. 61.759, 65.149, 61.756, do TRE de São Paulo, in Raul Motta Moreira e Henrique Soares de Oliveira, *ob. cit.*, pp. 135 e ss., ns. 205, 207 e 208.

Capítulo IV

DOS PARTIDOS POLÍTICOS

I. IDÉIA DE PARTIDO POLÍTICO: 1. Noção de partido político. 2. Origem e evolução dos partidos. 3. Sistemas partidários. 4. Institucionalização jurídico-constitucional dos partidos. Controles. 5. Função dos partidos e partido de oposição. 6. Natureza jurídica dos partidos. II. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA: 7. Liberdade partidária. 8. Condicionamentos à liberdade partidária. 9. Autonomia e democracia partidária. 10. Disciplina e fidelidade partidária. 11. Sistema de controles dos partidos brasileiros. III. PARTIDOS E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: 12. Partidos e elegibilidade. 13. Partido e exercício do mandato. 14. Sistema partidário e sistema eleitoral.

I. IDÉIA DE PARTIDO POLÍTICO

1. Noção de partido político

O partido político é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo. No dizer de Pietro Virga: "são associações de pessoas com uma ideologia ou interesses comuns, que, mediante uma organização estável (*Partei-Apparat*), miram exercer influência sobre a determinação da orientação política do país".¹

1. Cf. *Diritto costituzionale*, p. 243. É inaceitável o conceito que oferece Karl J. Friedrich: "un parti politique est un groupe d'être humains organisées de façon stable, ayant pour objectif de se rendre ou de rester maître du régime au profit de leurs dirigeants, ainsi que donner aux membres du parti, grâce à cette maîtrise, des bénéfices et avantages matériels et spirituels". Cf. *La démocratie constitutionnelle*, p. 450. Pois, se é certo que os dirigentes e membros do partido no poder se beneficiam com essa situação, verdade é que não deve ser esse o objetivo dos partidos, que hão de propor-se realizar programas de governo em favor da coletividade, ainda que não se possa negar a existência de profundas deformações nos termos daquele conceito. J. M. Gil Robles define o partido como "un grupo humano formado em torno a un contenido ideológico, que busca la defensa de unos intereses por la conquista legal del poder, inmediato o en un plazo de duración razonable". Cf. *Por un Estado de derecho*, pp. 121 e 122.

2. Origem e evolução dos partidos

Originaram-se, como nota Maurice Duverger, em primeiro lugar, da criação de grupos parlamentares; depois, da aparição dos comitês eleitorais; finalmente, do estabelecimento da ligação permanente entre esses dois elementos;² a partir da universalização do sufrágio, que requer entidade permanente que organize e coordene a vontade popular, os partidos foram-se firmando como instituições políticas indispensáveis na estrutura do Estado contemporâneo.

Anteriormente, as formações partidárias constituíam meras facções em favor de uma situação ou força política, como os Guelfos e Gibelinos, agrupamentos rivais italianos do séc. XII ao séc. XV, partidários respectivamente do Papa e dos imperadores germânicos na Itália. Quando os Estados Gerais se reuniram na Constituinte francesa (1789), os Deputados de uma mesma região começaram a encontrar-se para a troca de opiniões sobre a defesa de interesses locais, mas verificaram que tinham idéias comuns a respeito de problemas fundamentais da política nacional. Surge daí o "Clube Bretão". Mais tarde, esse clube transforma-se nos Jacobinos, enquanto outra facção se organiza, dando nascimento ao "Clube dos Girondinos".³ Por essa época, na Inglaterra, apareciam os partidos da Corte e do Campo; depois, formaram-se os partidos *Whig* e *Tory*, cuja evolução viera a dar nos Partidos Liberal e Conservador, mais tarde é que se formou o Partido Trabalhista, de origem sindicalista.⁴

Não foi diferente a forma de surgimento dos partidos no Brasil. José Bonifácio, em discurso na Constituinte do Império, referiu-se às facções de então, formadas relativamente à Independência. Eram

2. Cf. *Les partis politiques*, pp. 2 e ss. Para a evolução dos partidos no Brasil, Afonso Arinos de Melo Franco, *História e Teoria dos Partidos Políticos no Brasil*, 2ª ed., São Paulo, Alfa-Ômega, 1974, e Vamireh Chacon, *História dos Partidos Brasileiros*, Brasília, Ed. UnB, 1981; na Itália, Giorgio Galli, *I partiti politici in Italia 1861-1973*, Torino, UTET, 1975; nos EUA, Wilfred E. Binkey, *Partidos Políticos Americanos*, Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1961; no Chile, German Urzua Valenzuela, *Los partidos políticos chilenos*, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1968; na África Negra, Dmitri Lavroff, *Os Partidos Políticos na África Negra*, Amadora, Livraria Bertrand, 1975, trad. de Eduardo Cambezes; em Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, *Os Partidos Políticos no Direito Constitucional Português*, Braga, Liv. Cruz, 1983; Jorge Mario García Laguardia (org.), *Partidos políticos y democracia en Iberoamérica*, México, UNAM, 1981; Ignacio Burgoa et al., *El régimen constitucional de los partidos políticos*, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1975; III Jornadas de Derecho Constitucional y Político (La Plata, 24 e 25.4.81), *Partidos políticos*, Buenos Aires, Colegio de Abogados/Departamento Judicial de La Plata, 1982.

3. Cf. Maurice Duverger, *ob. cit.*, p. 2.

4. Cf. David Hume, *Ensaio Político*, São Paulo, Ibrasa, 1963, trad. de E. Jacy Monteiro.

partidários da Independência, separatistas e não separatistas. Os partidários da Independência distribuíram-se em quatro grupos: (a) os *corcundas*, queriam-na, mas não liberdade; (b) os *monárquicos-constitucionalistas*, não queriam nem a democracia nem o despotismo, mas liberdade com estabilidade; (c) os *republicanos*, de pouca expressão; (d) os *federalistas*, que “não queriam ser monárquicos-constitucionalistas, nem podiam ser corcundas, mas queriam ser republicanos de várias repúblicas”.⁵ Convocada, em 1826, a Assembléia Geral (Câmara dos Deputados e Senado), de acordo com a Constituição outorgada em 1824, as forças em choque pretenderam fazer-se representar, organizadas em *grupos e facções os exaltados* (ou *anarquistas*, ou *revolucionários*, que, em verdade, eram o povo em luta por suas reivindicações), os *moderados* (conservadores), depois, os *restauradores* etc. Os *exaltados* unidos aos *revolucionários* e *republicanos*, agruparam-se, entre 1834 a 1838, no *Partido Liberal*, que, por seu lado, compreendia uma ala radical e outra moderada. Na mesma época, os *moderados* e os *restauradores* se uniram formando o *Partido Conservador*. Essas duas formações partidárias revezaram-se no poder durante o Segundo Império, quando, também, os republicanos começaram a aglutinar-se nos *Clubes Republicanos*, até a organização do respectivo Partido (1870). O movimento republicano fragmenta-se nos Partidos Republicanos estaduais (PRP, PRM, PRRG, PRBa etc.) na Primeira República. Finda esta com a Revolução de 1930, surgem novas formações partidárias ainda de caráter regional: Partido Democrático em São Paulo, Partido Nacionalista em Minas Gerais, Partido Libertador no Rio Grande do Sul, além do Clube Três de Outubro e a Aliança Renovadora Nacional. Mas foi no período de 1946 a 1965 que floresceu um sistema partidário com alguma institucionalização efetiva com base em três partidos grandes de âmbito nacional — o Partido Social Democrático (PSD), a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) — e um conjunto de pequenos partidos de expressão basicamente regional (PSP, PL, PDC, PRT, PTN, MTR), embora o PDC estivesse mais desenvolvido, além do Partido Comunista na clandestinidade após 1948. Tais partidos foram extintos em 1965 por força do AI-2, dando margem ao surgimento do bipartidarismo artificial representado pela ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e MDB (Movimento Democrático Brasileiro), também extintos em 1979, quando recomeça a estrutura partidária, ainda em curso, com cerca de vinte partidos regularizados, com ponderável transformação, conforme demonstraram as eleições de 3.10.1994⁶

5. Sobre o tema, cf. Afonso Arinos de Melo Franco, *ob. cit.*, pp. 24 e ss.

6. Cf. *Folha de S. Paulo*, 18.10.94, p. 1/10; Miguel Reale, “Perfil das eleições”, *O Estado de S. Paulo*, 5.11.94, p. A2, com algumas diferenças.

e 4.10.1998, consoante mostramos nas edições anteriores (10^a a 21^a), situação razoavelmente modificada pelas eleições de 6.10.2002, com 19 partidos, que, em função das respectivas representações na Câmara dos Deputados, revelaram a existência de quatro grandes formações partidárias (PT-Partido dos Trabalhadores, PFL-Partido da Frente Liberal, PMDB-Partido do Movimento Democrático Brasileiro, outra vez à frente do PSDB-Partido da Social Democracia Brasileira, com 91, 84, 74 e 71 Deputados, respectivamente), um partido médio-alto (PPB-Partido Progressista Brasileiro, antiga ARENA, e anteriores PDS e PPR, com 49 Deputados, caiu em relação a 1998), quatro partidos médios (PTB-Partido Trabalhista Brasileiro, PL-Partido Liberal, PSB-Partido Socialista Brasileiro e PDT-Partido Democrático Trabalhista, com 26, 26, 22 e 21 Deputados cada, contra 2 em 1998 e inversão das posições entre o PL e o PSB, que subiram, saindo da condição de partidos pequenos), dois partidos pequenos (PPS-Partido Popular Socialista, ex-PCB, e PCdoB-Partido Comunista do Brasil, com 15 e 12 Deputados, respectivamente, com melhoria de posição de ambos, que passaram, respectivamente, de 11 para 15 e de 10 para 12 Deputados), quatro partidos minúsculos (PRONA-Partido da Reedificação da Ordem Nacional, PV-Partido Verde, PSD-Partido Social Democrático e PST-Partido Social Trabalhista, com 6, 5, 4 e 3 Deputados cada, respectivamente), quatro minipartidos (PMA-Partido da Mobilização Nacional, PSL-Partido Social Liberal, PSC-Partido Social Cristão e PSDC-Partido Social Democrata Cristão, com 1 Deputado cada) e, finalmente, oito micropartidos, nanicos (PSTU-Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PTN-Partido Trabalhista Nacional, PTdoB-Partido dos Trabalhadores do Brasil, PRT-Partido Republicano Trabalhista, PRTB-Partido Republicano dos Trabalhadores Brasileiros, PGT-Partido Geral dos Trabalhadores, PHS-Partido Humanista Social, PAN-Partido dos Aposentados Nacionais, que não fizeram nenhum congressista federal).

3. Sistemas partidários

Desde o século passado, os partidos políticos foram se impondo como realidade social e política, apesar de combatidos profundamente pelos filósofos políticos do século anterior.⁷ Dentre estes, David Hume percebeu claramente a força do fenômeno, tanto que condena severamente os partidos no plano teórico, como contrários à unidade do

7. Sobre alguns aspectos do tema, cf. Sergio Cotta, “Les partis et le pouvoir dans les théories politiques du début du XVIII^e siècle”, in *Le Pouvoir*, Paris, PUF, 1956, t. I/91 e ss.

Estado, ao império da lei, à solidariedade e à cooperação dos cidadãos, mas os reconhece. Por isso, é possível distinguir em seu pensamento um julgamento de *valor* e um julgamento de *fato*, de realidade. O primeiro condena os partidos: são um mal. O segundo afirma a realidade fenomenológica dos partidos: *são entidades históricas*. E tenta classificá-los, separando-os em *partidos pessoais* e *partidos reais*. Os primeiros partidos baseiam-se na amizade ou na animosidade entre os que compõem os partidos em luta; os segundos fundamentam-se em três tipos: *partidos de interesse*, *partidos de princípio* e *partidos de afeição*.⁸

Foi essa a primeira tentativa de classificar os partidos políticos. Hoje se fala em partidos de esquerda, partidos de centro e partidos de direita, e em suas combinações: partidos de centro-esquerda e partidos de centro-direita, esquema que tem sentido, tomando como ponto de referência a ordem econômico-social existente, não as posições subjetivas. A classificação de Lawrence Lowell, em certo sentido, justifica esse esquema quando entende possam os homens ser divididos em contentes e descontentes, e em favoráveis ou hostis às transformações da ordem estabelecida, de tal sorte que, combinando-se esses traços dois a dois, encontramos quatro grupos de homens: (a) contentes com a ordem estabelecida, contrários a qualquer mudança, que são os conservadores; (b) contentes, mas predispostos a aceitar certas alterações na ordem vigente, que são os liberais, ditos também de centro; (c) descontentes com a ordem estabelecida, postulando transformações, que são os socialistas, os esquerdistas em geral entre moderados e radicais; (d) descontentes com a ordem vigente, não porque desejem mudanças, mas porque acham que já se avançou demais, que já se ultrapassaram os limites razoáveis, que são os reacionários de todos os matizes, os direitistas em geral: integralistas, fascistas, nazistas e outras espécies.⁹

A formação de correntes partidárias, representativas dessas várias situações, conforme predominância ou equilíbrio de umas e outras, dá margem ao surgimento dos *sistemas de partidos políticos*, que, segundo lição de Duverger, consistem nas formas e modalidades de coexistência de diversos partidos em um país.¹⁰ Diríamos que *sistema de partido* consiste no modo de organização partidária de um país. Os diferentes modos de organização partidária possibilitam o surgimento de três tipos de sistemas: (a) o de *partido único*, ou *unipartidário*, ou, ainda, *unipartidarismo*; (b) o de *dois partidos*, ou *bipartidarismo*; (c) o de *três, quatro ou mais partidos*, denominado *sistema pluripartidário*, ou *multipartidário*, ou simplesmente *pluripartidarismo*, *multipartidarismo* ou

8. Cf. *Ensaio políticos*, pp. 76 e ss.

9. Cf. Karl J. Fiedrich, *ob. cit.*, p. 452.

10. *Ob. cit.*, p. 233.

polipartidarismo. Neste último se inclui o sistema brasileiro nos termos do art. 17.

4. Institucionalização jurídico-constitucional dos partidos. Controles

"O partido se manifesta sempre como uma *organização* de um grupo social, que se propõe influir na orientação política."¹¹ No plano sociológico, essa organização de fins políticos firmou-se no meado do século passado. O legislador do Estado Liberal prefere ignorá-la, reputando-a como um fenômeno extraconstitucional, ainda que no Direito Constitucional encontrasse sua base de sustentação como forma do exercício da liberdade de associação.

Mas a crescente importância dos partidos, convertidos em peças fundamentais do processo político democrático de nossos dias, não haveria de passar despercebida do legislador, que se viu na contingência de tê-los em conta nas leis eleitorais, nos regulamentos parlamentares e, finalmente, nas próprias constituições.¹² A ordenação constitucional e legal dos partidos traduz-se num condicionamento de sua estrutura, seu programa e suas atividades, que deu lugar a um sistema de controle mais ou menos amplo, consoante se adote uma regulamentação maximalista ou minimalista, correspondendo o primeiro critério à tendência a uma profunda intervenção do Estado na vida dos partidos e o segundo a uma menor interferência estatal.¹³

Virga e Biscaretti di Ruffia indicam três tipos de controles decorrentes da institucionalização dos partidos: (a) *controle de caráter externo*, que responde a uma regulamentação minimalista, pelo qual "o ordenamento jurídico se limita a exigir que a atividade dos partidos se desenvolva com observância das leis penais e de polícia, sendo vedado, portanto, apenas o recurso à violência e o abuso na afirmação de seu programa"; (b) *controle de caráter ideológico-programático*, pelo qual "o ordenamento prevê um controle sobre as ideologias e sobre os programas e a atividade política dos partidos, com o fim de

11. Cf. Jorge Xifras Heras, *Curso de derecho constitucional*, cit., t. II/202.

12. Assim, p. ex., as Constituições italiana, art. 49; da República Federal da Alemanha, art. 21; de Portugal de 1976, art. 117; da Espanha de 1978, art. 6º; da França de 1958, art. 4º. Sobre o tema no Direito Comparado, cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Os Partidos Políticos nas Constituições Democráticas*, Belo Horizonte, Ed. RBEP, 1966.

13. Cf. Jorge R. Vanossi, "Una cuadratura de círculo constitucional: el reconocimiento de los partidos políticos", in *El régimen constitucional de los partidos políticos*, p. 111, obra coletiva composta de trabalhos sobre o tema apresentados no I Congresso Nacional de Direito Constitucional, celebrado em Guadalajara, México, UNAM/ Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1975.

impedir a constituição e a atividade dos partidos subversivos e revolucionários"; (c) *controle de caráter interno*, segundo o qual "o ordenamento exige que não só o programa e a atividade política do partido sejam inspirados nos princípios democráticos, mas que também seja garantida a democraticidade da organização interna do partido".¹⁴

O sistema de partidos no Brasil percorrerá todas essas fases e tipos de controle. Desconhecidos pela Constituição e legislação imperiais, atuavam como associações inorgânicas, formadas com base nos interesses de grupos. No regime da Constituição de 1891, que também os ignorou, não passaram de instrumentos de expressão e de dominação das oligarquias estaduais. Indiretamente reconhecidos no art. 170, n. 9, da Constituição de 1934, já tinham sido, contudo, previstos no Código Eleitoral de 1932 (Decreto 21.076, de 24.2.32, arts. 99 e 100). Só no regime da Constituição de 1946 começaram eles a firmar sua institucionalização jurídica; ela faz explícita consignação aos *partidos nacionais*, aos quais seria assegurada a representação proporcional nas comissões parlamentares (art. 40, parágrafo único), dando-lhes, assim, uma ordenação minimalista, embora, no art. 141, § 13, vedasse a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer partido político ou associação cujo programa ou ação contrariasse o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. A Constituição de 1967 (art. 149) e, especialmente, a de 1969 (art. 152) foram maximalistas na institucionalização dos partidos, restringido a sua criação e funcionamento, impedindo o surgimento de partidos de tendência marxista. A Constituição vigente liberou a criação, organização e funcionamento de agremiações partidárias, numa concepção minimalista, sem controle quantitativo (embora o possibilite por lei ordinária), mas com previsão de mecanismos de controle qualitativo (ideológico), mantido o controle financeiro.

Vanossi é quem lembra os dois tipos de controles: *quantitativo* e *qualitativo*. O primeiro limita as provisões legais para o reconhecimento de um partido político ao cumprimento de exigências formais (carta orgânica, declaração de princípios, plataforma eleitoral) e à reunião de certa quantidade de filiados ou membros, cujo número se estabelece em uma proporção fixa sobre o total do corpo eleitoral do distrito ou do país (nos Estados federais e nos Estados unitários, respectivamente). A Constituição não mais traz exigências desse tipo, mas as admite, quando confere à lei o estabelecimento de preceitos de funcionamento parlamentar dos partidos (art. 17, IV). O segundo

avança outras exigências, somando, às anteriores, a necessidade da conformidade ideológica das postulações do partido com os fins do Estado constitucional que o há de reconhecer como tal. Assim, unicamente alcançarão o reconhecimento de "partidos" aquelas agrupações que afinem fervorosamente sua homogeneidade ideológica com o sistema imperante, quer dizer, com as pautas dominantes do regime político vigente, de tal modo que resulta inconcebível — para este critério — que sejam admitidos partidos de tendência autoritária ou monocrática num Estado que garanta o pluralismo ou, inversamente, que sejam legalizados partidos de orientação pluralista num Estado cujas bases de sustentação peculiarizam uma autocracia ou monocracia. Neste sistema "qualitativo", observa Vanossi, ao Estado se reserva abertamente o poder indispensável para aceitar no "jogo" político somente os partidos que professem as mesmas "regras do jogo" que a Constituição estabelece para a vida política do país, negando o reconhecimento e a legalidade às agrupações que aspirem a obter o reconhecimento estatal com a finalidade — conhecida ou encoberta — de transformar essas mesmas "regras do jogo" ou de encerrar o próprio "jogo".¹⁵ Veremos, depois, até que ponto a Constituição de 1988 manteve algum controle qualitativo dos partidos.

O *controle financeiro* impõe limites à apropriação dos recursos financeiros dos partidos, que só podem buscá-los em fontes estritamente indicadas, sujeitando-se à fiscalização do Poder Público.

5. Função dos partidos e partido de oposição

A doutrina, em geral, admite que os partidos têm por função fundamental organizar a vontade popular e exprimi-la na busca do poder, visando a aplicação de seu programa de governo. Por isso, todo partido político deveria estruturar-se à vista de uma ideologia definida e com um programa de ação destinado à satisfação dos interesses do povo.

As normas constitucionais e legais vigentes permitem-nos verificar que a função dos partidos brasileiros consiste em assegurar, resguardados a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo, a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos fundamentais da pessoa humana (Constituição, art. 17, e LOPP, art. 2º). A função deles vai além, pois existem para propagar determinada concepção de Estado, de sociedade e de governo, que intentam consubstanciar pela execução de um programa.

14. Pietro Virga, *ob. cit.*, pp. 147 e 248; Paolo Biscaretti di Ruffia, *ob. cit.*, pp. 760 a 763.

15. *Ob. cit.*, pp. 112 e 113.

Sugere-se, neste contexto, a questão do *papel dos partidos na oposição*. Se a Constituição põe a democracia e o pluralismo como princípios fundamentais, e ainda o *pluripartidarismo* como princípio de organização partidária, segue-se disso o acolhimento de um sistema de partidos que, implicando um consenso fundamental, reconhece o dissenso e a previsibilidade da alternância no poder, pois pluralismo — já o dissemos — envolve debates e divergências na solução dos problemas de governo. Pressupõe maioria governante e minoria discordante. O “direito da maioria pressupõe a existência do direito da minoria” e da proteção desta, que é função essencial dos direitos fundamentais do homem, como salienta Kelsen.¹⁶ Decorrem, pois, do texto constitucional (art. 17), a necessidade e os fundamentos de partidos de oposição.

Assim, o partido ou partidos da situação, além das funções próprias de todo partido político acima anotadas, desempenham a função governamental, procurando exercer o poder segundo a concepção de governo que informa seu programa. Enquanto isso, o partido ou partidos de oposição, também, ademais daquelas funções assinaladas a todo partido, desenvolvem a função de oposição, que consiste em “controlar a função governamental constituindo-se, além disso, numa alternativa válida para substituir o partido majoritário na condução do Estado”.¹⁷ Essa função de controle por parte dos partidos políticos [diz Maria E. Carrió] “deve ser exercida fundamentalmente pelas minorias parlamentares e, para que seja eficaz, deve garantir-se o direito de crítica e o acesso a toda informação estatal, deve contar, além disso, com meios idôneos para seu exercício, do contrário ela seria reduzida a uma mera oposição formal”.¹⁸

Na Inglaterra a função de oposição não é reconhecida apenas implicitamente. É institucionalizada. Trata-se da oposição ao governo de sua Majestade. Confere-se, mesmo, ao chefe da minoria um estipêndio. É que a “oposição política [como lembra J. M. Silva Leite] é um ‘fragmento’ essencial do Estado constitucional contemporâneo; a sua estrutura e o seu *status* servem uma função insubstituível no (cada vez mais amplo e diverso) quadro instituído por uma ordem constitucional, seja em abstracto seja o de uma ordem jurídico-política concreta”.¹⁹

16. Cf. Hans Kelsen, *I fondamenti della democrazia*, p. 62; cf. também Maria Elisa Carrió, “Institucionalización de los partidos de la oposición en la legislación comparada”, tese apresentada às III Jornadas de Derecho Constitucional y Político, realizadas em La Plata, Argentina, em 24 e 25.4.81.

17. Maria E. Carrió, *ob. cit.*

18. Idem, *ibidem*.

19. Cf. *Constituição e Direito de Oposição*, p. 174.

6. Natureza jurídica dos partidos

É tema assaz discutido na doutrina. Os italianos divergem quanto à sua fixação. Virga considera-os sob dois aspectos do ponto de vista jurídico: como *associação*, união de pessoas estavelmente organizadas e juridicamente vinculadas para a consecução de fins políticos comuns, e como *órgão do Estado*, no que tange à sua característica de grupo eleitoral e de grupo parlamentar.²⁰ Biscaretti di Ruffia repele essa concepção no direito italiano, pois entende serem *associações não reconhecidas*, não assumindo a natureza de *órgãos do Estado* nem de ente público controlado pelo mesmo. Concebe-os como *entidades auxiliares* do Estado, reconhecendo em sua atividade um *exercício privado de funções públicas*.²¹

Em face do Direito Constitucional brasileiro, essas concepções não prevalecem. A Constituição, agora, definiu-os como *pessoa jurídica de direito privado*, ao teor do art. 17, § 2º, segundo o qual os *partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral*. Se adquirem personalidade na forma da lei civil é porque são pessoas jurídicas de direito privado, devendo, pois, registrar-se no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, segundo o disposto na Lei dos Registros Públicos;²² depois disso é que seus estatutos serão levados a registro no TSE. Fica, pois, superado o disposto no art. 2º da Lei 5.682/71 que lhes reconhecia a natureza de pessoa jurídica de direito público interno, que nos mereceu reparos em edições anteriores deste livro, por entendermos artificial esse enquadramento legal, pois não é fácil encontrar as notas essenciais das pessoas jurídicas de direito público numa organização associativa formada pela adesão voluntária de particulares e destinada, não propriamente a realizar fins públicos, mas fins políticos. Os partidos somente prestam serviços públicos quando no exercício das funções governamentais, mas aí não são senão instrumentos da prestação desses serviços, que não são deles, mas do Estado, dos órgãos governamentais, que, com eles, não se confundem. O legislador deve ter suposto que a natureza de pessoa jurídica de direito público decorre da circunstância de a CF determinar que o registro dos partidos se faça na Justiça

20. Cf. *ob. cit.*, p. 245. A concepção de partido como órgão do Estado foi solidamente rebatida por Fávila Ribeiro, *Direito Eleitoral*, p. 226.

21. Cf., *ob. cit.*, pp. 771 e 773.

22. Art. 114 da Lei dos Registros Públicos, que é a Lei 6.015, de 31.12.1973. Esclareça-se que o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em São Paulo, Capital, é um anexo do Cartório de Títulos e Documentos; no Interior, em geral, é um anexo do Cartório de Registros de Imóveis. Em outros Estados, pode ser diferente, segundo a legislação de organização cartorária de cada um. No Rio de Janeiro, Capital, ao que me consta, é autônomo, como Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Eleitoral. Acontece que a natureza pública do órgão incumbido do registro não comunica igual natureza à entidade registrada. Trata-se de mero controle público, em vez de controle cartorário. Aliás, a inadequação é notável, precisamente porque uma das notas da pessoa jurídica de direito público é sua criação diretamente pela lei e a inexistência de registro de seus instrumentos constitutivos. O fato de precisarem de registro para sua formação, vale dizer, o fato de necessitarem de tal controle denota que não se cuida de pessoa jurídica de direito público. Os partidos não são criados por lei, e seria terrível se o fossem, pois deixariam de ser partidos para serem outra coisa (cf. 4ª ed. deste livro, p. 411). Agora, estão definidos como pessoas jurídicas de direito privado.

Liquida-se, com isso, qualquer pretensão de enquadrá-los como órgãos do Estado, pois, órgão, no sentido técnico, segundo a doutrina mais corrente, não tem personalidade jurídica, e menos ainda personalidade jurídica de direito privado. Serão eles *instituições* no sentido concebido por Maurice Hauriou: "idéia objetiva transformada em uma obra social por um fundador, idéia que recruta adesões no meio social e sujeita assim a seus serviços vontades subjetivas indefinidamente renovadas"²³ Tem-se instituição onde "exista a submissão estável de um corpo social a uma autoridade comum e a redução a unidade de elementos pessoais e materiais diversos mediante uma organização permanente"²⁴ O partido é uma associação de pessoas para fins políticos comuns e tem caráter permanente, no que se encontram os elementos básicos do conceito de instituição.

II. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA

7. Liberdade partidária

Afirma-se a liberdade de organização partidária no art. 17 da Constituição, nos termos seguintes: *É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana*, condicionados, no entanto, a serem de caráter nacional, a não receberem recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou a subordinação a estes, a prestarem contas à Justiça Eleitoral e a terem funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Esses aspectos serão examinados no correr desta exposição. O que importa agora é constatar que a liberdade partidária envolve: a de criá-los,

transformá-los e extingui-los, assim como, evidentemente, a de aderir ou não a um partido, de permanecer filiado ou de desligar-se dele. Mas também cabe ao partido, na sua autonomia, prevista no § 1º do art. 17, aceitar, ou não, proposta de filiação. Mais importante ainda é que a estrutura de poder não poderá interferir nos partidos, para extingui-los, por exemplo, como várias vezes acontece.

8. Condicionamentos à liberdade partidária

Não é, porém, absoluta a liberdade partidária. Fica ela condicionada a vários princípios que confluem, em essência, para seu compromisso com o *regime democrático* no sentido posto pela Constituição, consoante mostramos noutro lugar.²⁵ É isso que significa sua obrigação de resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.

Mas a liberdade de criar partido ainda é condicionada a que seja de caráter nacional; vale dizer, ninguém pode pretender criar partido de vocação estadual ou local. A Constituição, contudo, não indicou quando o partido se considera nacional. As normas constitucionais revogadas impunham critérios para que assim fosse tido. Era uma regra de funcionamento, segundo a qual os partidos dependiam da obtenção de 3% do eleitorado nacional, distribuídos pelo menos em cinco Estados com um mínimo de 2% em cada um deles. A Constituição não o disse, deixou essa questão para a lei, quando estabeleceu, como um dos preceitos a serem por eles observados, "*funcionamento parlamentar de acordo com a lei*". Esta é que vai definir o caráter nacional dos partidos, indicando critérios e exigências a serem preenchidos, a fim de que não pululem agremiações políticas de caráter puramente local.

O condicionamento mais severo consta do art. 17, § 4º, que veda a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

9. Autonomia e democracia partidária

Outra importante regra da organização e do funcionamento dos partidos encontra-se no art. 17, § 1º: "É assegurada aos partidos políticos *autonomia* para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidária". Destaque-se aí o *princípio da autonomia partidária*, que é uma conquista sem precedente, de tal sorte que a lei tem muito pouco a fazer em matéria de estrutura interna, organiza-

23. Cf. *Derecho público y constitucional*, p. 84.

24. Cf. Pietro Virga, *ob. cit.*, p. 25.

25. Cf. Primeira Parte, título II, capítulo III.

ção e funcionamento dos partidos. Estes podem estabelecer os órgãos internos que lhe aprouverem. Podem estabelecer as regras que quiserem sobre seu funcionamento. Podem escolher o sistema que melhor lhes parecer para a designação de seus candidatos: convenção mediante delegados eleitos apenas para o ato, ou com mandatos, escolha de candidatos mediante votação da militância. Podem estabelecer os requisitos que entenderem sobre filiação e militância. Podem disciplinar do melhor modo, a seu juízo, seus órgãos dirigentes. Podem determinar o tempo que julgarem mais apropriado para a duração do mandato de seus dirigentes. Não obstante, a Justiça Eleitoral insiste em submetê-los às exigências da velha Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei 5.682/71) que não lhes permite a livre estruturação que a Constituição lhes garante.

A idéia que sai do texto constitucional é a de que os partidos hão que se organizar e funcionar em harmonia com o regime democrático e que sua estrutura interna também fica sujeita ao mesmo princípio. A autonomia é conferida na suposição de que cada partido busque, de acordo com suas concepções, realizar uma estrutura interna democrática. Não é compreensível que uma instituição resguarde o regime democrático se internamente não observa o mesmo regime.

10. Disciplina e fidelidade partidária

A disciplina e a fidelidade partidárias passam a ser, pela Constituição, não uma determinante da lei, mas uma determinante estatutária (art. 17, § 1º). Não são, porém, meras faculdades dos estatutos. Eles terão que prevê-las dando conseqüências ao seu descumprimento e desrespeito. A disciplina não há de entender-se como obediência cega aos ditames dos órgãos partidários, mas respeito e acatamento do programa e objetivos do partido, às regras de seu estatuto, cumprimento de seus deveres e probidade no exercício de mandatos ou funções partidárias, e, num partido de estrutura interna democrática, por certo que a disciplina compreende a aceitação das decisões discutidas e tomadas pela maioria de seus filiados-militantes.

O ato indisciplinar mais sério é o da *infidelidade partidária*, que se manifesta de dois modos: (a) oposição, por atitude ou pelo voto, a diretrizes *legitimamente* estabelecidas pelo partido; (b) apoio ostensivo ou disfarçado a candidatos de outra agremiação.

Os estatutos dos partidos estão autorizados a prever sanções para os atos de indisciplina e de infidelidade, que poderão ir da simples advertência até a exclusão. Mas a Constituição não permite a perda do mandato por infidelidade partidária. Ao contrário, até o veda,

quando, no art. 15, declara vedada a cassação de direitos políticos, só admitidas a perda e a suspensão deles nos estritos casos indicados no mesmo artigo.

11. Sistema de controles dos partidos brasileiros

A Constituição, como dissemos antes, praticamente não impõe *controle quantitativo aos partidos*, mas contém a possibilidade de que venha a existir por via de lei, quando, entre os preceitos a serem observados, coloca o de "funcionamento parlamentar de acordo com a lei". É que o controle quantitativo se realiza pela instituição de mecanismos normativos que limitam as possibilidades de ampliação, *ad libitum*, dos partidos políticos, e atua não no momento da organização, mas no seu funcionamento, e pode consistir na exigência de que obtenham, em eleições gerais, para a Câmara dos Deputados, o apoio expresso em votos de uma percentagem mínima do eleitorado nacional em certo número de Estados, a fim também de vigorar, na prática, o caráter de nacionais.

Controle qualitativo (controle ideológico) é expressamente consignado na Constituição, em função do regime democrático. Os princípios que cabem aos partidos resguardar, regime democrático, plural-partidarismo e direitos fundamentais da pessoa humana, constituem, como vimos, condicionamentos à liberdade partidária. Funcionam, por isso, como forma de controle ideológico, controle qualitativo, de tal sorte que será ilegítimo um partido que, porventura, pleiteie um sistema de unipartidarismo ou um regime de governo que não se fundamente no princípio de que o poder emana do povo, que o exerce por seus representantes ou diretamente, base da democracia adotada pela Constituição, ou que sustente um monismo político em vez do pluralismo, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

Controle qualitativo ainda é o da vedação de utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, que significa repelir partidos fascistas, nazistas ou integralistas do tipo dos que vigoraram na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler e no Brasil de Plínio Salgado.

Resta o *controle financeiro*, que também está estabelecido no art. 17, II e III. O primeiro proíbe o recebimento pelos partidos de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; por certo que aí temos um preceito que constitui um desdobramento do dever de resguardo da soberania nacional. O segundo impõe aos partidos o dever de prestar contas de sua administração financeira à Justiça Eleitoral. Em compensação, prevê-se no

art. 17, § 3º, que têm eles direito a recursos do fundo partidário, que a lei já regula (Lei 4.740/65, arts. 95 a 109).

III. PARTIDOS E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

12. Partidos e elegibilidade

Os partidos exercem decisiva influência no governo dos Estados contemporâneos. Daí nasce a concepção do Estado de Partido, que melhor se diria *governo de partido*, para denotar o primado dos partidos na organização governamental de nossos dias. É que o fenômeno partidário permeia todas as instituições político-governamentais: como o princípio da separação de poderes, o sistema eleitoral, a técnica de representação política. Segundo nosso Direito positivo, os partidos destinam-se a assegurar a autenticidade do sistema representativo. Eles são, assim, canais por onde se realiza a representação política do povo, desde que, no sistema pátrio, não se admitem candidaturas avulsas, pois ninguém pode concorrer a eleições se não for registrado por um partido. Isso agora ficou explícito no art. 14, § 3º, V, que exige a *filiação partidária* como uma das condições de elegibilidade.

13. Partido e exercício do mandato

Uma das conseqüências da função representativa dos partidos é que o exercício do mandato político, que o povo outorga a seus representantes, faz-se por intermédio deles, que, desse modo, estão de permeio entre o povo e o governo, mas não no sentido de simples intermediários entre dois pólos opostos ou alheios entre si, mas como um instrumento por meio do qual o povo governa. Dir-se-ia — em tese, ao menos — que o povo participa do poder por meio dos partidos políticos. Deverão servir de instrumento para a atuação política do cidadão, visando influir na condução da gestão dos negócios políticos do Estado. De acordo com o sistema constitucional e legal brasileiro, os partidos políticos deverão desenvolver atividades que ofereçam várias manifestações, tais como: permitam aos cidadãos participar nas funções públicas; atuem como representantes da vontade popular e da opinião pública; instrumentem a educação política do povo; facilitem a coordenação dos órgãos políticos do Estado. Sua função primordial apóia-se em suas atividades eleitorais, tanto no momento de designar os candidatos como no de condicionar sua eleição e o exercício do mandato. Na prática, os nossos partidos não chegaram a isso ainda. Denotamos apenas uma visão teórica, cuja realização, no Brasil, talvez seja uma simples miragem.

Relembremos, no entanto, que tendem a transformar a natureza do mandato político, dando-lhe *feição imperativa*, na medida em que o representante está vinculado, pelo princípio de fidelidade, a cumprir programa e diretrizes de sua agremiação, com o que o exercício do mandato deixa de ser demasiadamente abstrato em relação ao povo para tornar-se mais concreto em função de vínculos partidários que interligam mandante e mandatário.

14. Sistema partidário e sistema eleitoral

O *sistema eleitoral* forma com o *sistema de partido* (já o dissemos) os dois mecanismos de expressão da vontade popular na escolha dos governantes. A circunstância de ambos se voltarem para um mesmo objetivo imediato — organização da vontade popular — revela a influência mútua entre eles, a ponto de a doutrina definir condicionamentos específicos do sistema eleitoral sobre o de partidos.²⁶ A esse respeito, tornou-se amplamente conhecida a doutrina de Maurice Duverger, segundo a qual *o sistema majoritário de escrutínio a um só turno tende ao bipartidarismo, enquanto o sistema majoritário de escrutínio a dois turnos e o de representação proporcional tendem ao multipartidarismo*.²⁷

Ele, contudo, jamais deu valor absoluto a essa influência. Ao contrário, realça que nunca a considerou como mais importante que as outras, acrescentando que, em verdade, “a ação dos sistemas de escrutínio poderia ser comparada à de um freio ou de um acelerador: certo regime eleitoral facilita a multiplicação dos partidos, provocada pela ação de outros fatores; outro regime lhe serve de obstáculo etc. Mas os modos de escrutínio não têm papel propriamente de motor; são as realidades nacionais, as ideologias, e sobretudo as estruturas sócio-econômicas que têm, em geral, a ação mais decisiva a esse respeito”.²⁸ Apesar disso, a doutrina, de modo geral, sem levar em conta esses pressupostos, passara a considerar aquela influência como mais importante e até a lhe atribuir caráter de condicionamento necessário, especialmente em relação ao efeito multiplicador da representação proporcional. Foi esta que imputou o exagerado pluripartidarismo do período de 1946 a 1965.

Nelson de Souza Sampaio, no entanto, demonstrara que a “proliferação de partidos decorreu de vários fatores: a) a falta de tradição

26. A esse propósito, cf. nosso estudo “Partidos políticos e sistemas eleitorais: o caso brasileiro”, cit.

27. Cf. *Les partis politiques*, cit., pp. 235 e 269.

28. Idem, p. 235.

de partidos nacionais; b) o personalismo ainda vigoroso na política brasileira; c) o regionalismo; d) o sistema de representação proporcional".²⁹

Uma análise mais aprofundada chegará à conclusão de que o sistema de representação proporcional nada tivera com a multiplicação dos partidos. E nem tem com o mesmo fenômeno que retorna nos nossos dias de liberdade partidária. Ora, tanto naquele período como agora, o que conseguia empolgar não eram as eleições parlamentares, mas as eleições para a Presidência da República, que atendiam (e voltaram a atender) ao princípio majoritário, como não poderia ser diferente. É que, na verdade, se a representação proporcional pode eventualmente influir na multiplicação dos partidos, isso só ocorre nos sistemas parlamentaristas de governo, porque, então, a polarização de forças se concentra nas eleições de parlamentares, não havendo a atração principal que se dá nos sistemas presidencialistas. Mas nem é esse o problema mais importante. O que realmente interferia (e talvez volte a interferir) era a relação de forças oligárquicas, que sempre presidiram à realidade política nacional. Enquanto puderam acomodar-se em partidos regionais, estaduais ou locais (facções municipais, filiadas ao partido estadual, como acontecia na Primeira República), não havia necessidade de criar partidos próprios. Mas, na medida em que o sistema constitucional passara a exigir *partidos nacionais* (ou, ao menos, a prestigiar partidos de âmbito nacional), como se verifica desde a Constituição de 1946 (exigência, hoje, reproduzida no art. 17, I), essas forças utilizaram o expediente de formação de partidos *formalmente nacionais, mas rigorosamente regionais*. Esse fenômeno se repetiu com o bipartidarismo imposto no período de 1965 até 1979. Nele as forças regionais e locais foram constrangidas a agrupar-se em dois partidos. Mas tais forças não se acomodavam, como nunca se acomodaram, a um mando político unitário em nível nacional. Por isso levaram para cada partido os conflitos de interesse de sempre, razão por que houve que se instituir o sistema de sublegendas que repartisse o partido em setores de dominação regional e local. A mesma base de fragmentação tende a reproduzir-se neste instante de transformação partidária, se não se estabelecerem regras de controle quantitativo que contenham a proliferação dos partidos.

Por outro lado, seria conveniente examinar a afirmativa de pluralidade partidária no regime de 1946. Pois, o que se deve entender por *pluripartidarismo* e por *bipartidarismo*? O próprio Duverger alertou

para a dificuldade de estremar os dois conceitos, "por causa da existência de pequenos grupos ao lado dos grandes partidos. Nos EUA, por exemplo, se encontram alguns pigmeus atrás dos dois gigantes democrata e republicano: Partido Trabalhista, Partido Socialista, Partido dos Fazendeiros, Partidos Proibicionistas, Partidos Progressistas".³⁰ Ora, se no Brasil, no período, fosse permitido criar partidos de âmbito regional, certamente muitos daqueles partidos aparentemente nacionais, como o PSP, o PRT, o PST, o PL, seriam praticamente desconhecidos na maioria dos Estados, embora pudessem ser importantes no Estado de sua base oligárquica. Tais partidos não tinham quase influência no contexto político nacional. Sua representação no Congresso Nacional era insignificante. A rigor, não tivemos mais do que três partidos: a UDN, o PSD e o PTB, que dominaram sempre cerca de setenta e cinco por cento das cadeiras nas duas Casas do Congresso. Isso mostra que o efeito que se atribui ao sistema de representação proporcional não se verificou nem se verifica. Acontece, ainda, que a estatística eleitoral sugere que, na medida em que as forças populares compreenderam a importância do voto universal no seu interesse, passaram a prestigiar os partidos populares, que cresceram. E a tendência era a polarização de forças em três partidos, como agora notamos uma tendência à formação de cinco ou seis com variações de crescimento e retraimento.

29. Cf. "Os partidos políticos na IV República", in Paulo Bonavides *et al.*, *As tendências atuais do direito público: estudos em homenagem ao Prof. Afonso Arinos*, p. 326.

30. *Ob. cit.*, p. 237.

Título VI

Garantias Constitucionais

Capítulo I

DIREITOS E SUAS GARANTIAS

1. *Garantia dos direitos*. 2. *Garantias constitucionais dos direitos*. 3. *Confronto entre direitos e garantias: a lição de Ruy Barbosa*. 4. *Classificação das garantias constitucionais*.

1. Garantia dos direitos

Não é o caso de retornar aqui à discussão geral sobre a distinção entre direitos e garantias dos direitos, que expendemos no capítulo II do título I desta Segunda Parte. O leitor verificará ali, em suma, que os direitos são bens e vantagens conferidos pela norma, enquanto as garantias são meios destinados a fazer valer esses direitos, são instrumentos pelos quais se asseguram o exercício e gozo daqueles bens e vantagens.

2. Garantias constitucionais dos direitos

Vimos, também, no citado capítulo, que as garantias dos direitos humanos fundamentais podem ser de dois tipos: (1) *garantias gerais*; (2) *garantias constitucionais*. E essas últimas também se distinguem em duas classes: (a) *garantias constitucionais gerais*, que são instituições constitucionais que se inserem no mecanismo de freios e contrapesos dos poderes e, assim, visam impedir o arbítrio, com o que constituem, ao mesmo tempo, técnicas assecuratórias de eficácia das normas conferidoras dos direitos fundamentais; tais são, por exemplo, a existência de *constituição rígida* que declare os direitos fundamentais e suas garantias e estructure *órgãos jurisdicionais* dotados de independência e imparcialidade, com capacidade, de fato e de direito, para solucionar conflitos de interesses interindividuais e, especialmente, os que se manifestam entre o indivíduo e o Estado; nisso é que se revela o *princípio da separação de poderes* como a matriz de to-

das as garantias dos direitos do homem; (b) *garantias constitucionais especiais*, que são prescrições constitucionais que conferem, aos titulares dos direitos fundamentais, meios, técnicas, instrumentos ou procedimentos para imporem o respeito e a exigibilidade desses direitos; são, portanto, prescrições do Direito Constitucional positivo (ou seja, das constituições rígidas) que, limitando a atuação dos órgãos estatais ou mesmo de particulares, protegem a eficácia, aplicabilidade e inviolabilidade dos direitos fundamentais de modo especial.

Pode-se, ainda, classificar as *garantias constitucionais* em *individuais*, *coletivas*, *sociais* e *políticas*, tendo em vista a natureza do direito garantido. É a classificação de que nos serviremos adiante.

Já vimos — mas não custa recordar aqui — que as garantias constitucionais, em conjunto, se caracterizam como imposições, positivas ou negativas, especialmente aos órgãos do Poder Público, limitativas de sua conduta, para assegurar a observância ou, no caso de inobservância, a reintegração do direito violado.

3. Confronto entre direitos e garantias: a lição de Ruy Barbosa

A *lição de Ruy Barbosa*, no estrear os direitos e as garantias, é o que de melhor se produziu no constitucionalismo brasileiro sobre o tema.

Já o mencionamos antes, mas a lição dele foi além dos parâmetros teóricos, empreendendo um confronto entre direitos e garantias constitucionais, com base na Constituição de 1891, separando “as disposições meramente *declaratórias*, que são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as disposições *assecuratórias*, que são as que, em defesa dos *direitos*, limitam o poder. Aquelas instituem os *direitos*; estas, as *garantias*; ocorrendo não raro juntar-se, na mesma disposição constitucional, ou legal, a fixação da garantia, com a declaração do direito”.¹

Parece útil atualizarmos a lição do mestre, fazendo o confronto entre direitos e garantias constantes do título II da Constituição vigente, adicionando que não raro o *direito fundamental* se exprime pela norma de garantia; está subentendido nesta. Isto se mostrará, no confronto seguinte, indicando entre parênteses o direito protegido, não explícito. Ver-se-á também que reputamos *garantias* hipóteses que Ruy teve como *direitos*.

1. Cf. Ruy Barbosa, *República: teoria e prática*, p. 124; Paulino Jacques, *Curso de direito constitucional*, p. 483.

DIREITOS	GARANTIAS
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza	XLI — a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. XLII — a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
(Liberdade de ação geral)	II — ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
(Direito à vida e à integridade física e moral)	III — ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante.
IV — é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.	V — é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
VI — é inviolável a liberdade de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos (liberdade de religião)	garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
VIII — por motivo de crença religiosa ou de convicções filosóficas ou políticas,	— ... ninguém será privado de direitos, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
IX — é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,	independentemente de censura ou licença.
X — são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (direito à privacidade)	assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

DIREITOS	GARANTIAS
(direito à intimidade) XI — a casa é o asilo inviolável do indivíduo, (direito à intimidade, ao recesso do lar)	XI — a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
(direito à intimidade das comunicações pessoais)	XII — é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas, salvo, neste último caso, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
XV — é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz	LXVIII — conceder-se-á <i>habeas corpus</i> sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
XVI — todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos,	independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
XVII — é plena a liberdade de associação	XVIII — a criação de associações independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal XIX — as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. XX — ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
XXII — é garantido o direito de propriedade XXIII — a propriedade atenderá a sua função social	XXIV — a lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

DIREITOS	GARANTIAS
XXXIII — todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral (direito coletivo à informação)	LXX — o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partidos políticos; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
(direito geral à legalidade da Administração — direito a uma atuação democrática dos Poderes Públicos)	XXXIV — são a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
(direito subjetivo à jurisdição)	XXXV — a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
(direito subjetivo à estabilidade dos negócios jurídicos)	XXXVI — a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
(direito ao juízo natural)	XXXVII — não haverá juízo ou tribunal de exceção.
(direito de liberdade — direito de não sofrer sanção por fato alheio — direito à incolumidade física e moral — direito de defesa — liberdade política e de opinião — enfim, direito à segurança em geral)	são protegidos pelas garantias penais que se acham inscritas, em geral, nos incs. XXXVII a LXVII do art. 5º.
(direitos públicos subjetivos, líquidos e certos)	LXIX — conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por <i>habeas corpus</i> ou <i>habeas data</i> , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

DIREITOS	GARANTIAS
(direito à intimidade e à incolumidade dos dados pessoais — direito de acesso às informações registradas em bancos de dados — direito de retificação de dados)	LXXII — conceder-se-á <i>habeas data</i> : [...]
(direito à probidade e à moralidade da Administração)	LXXIII — qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Esses exemplos são suficientes para ilustrar a distinção entre direitos e garantias. Cumpre, no entanto, não esquecer o que já dissemos anteriormente: que as garantias constitucionais são também *direitos*, não como outorga de um bem e vantagem em si, mas *direitos-instrumentais*, porque destinados a tutelar um *direito principal*.²

4. Classificação das garantias constitucionais

Já vimos uma primeira distinção: (a) *garantias constitucionais gerais*; (b) *garantias constitucionais especiais*. Só destas últimas cuidaremos daqui por diante, porque são prescrições de Direito Constitucional positivo, conforme conceituação que lançamos no n. 2 supra.

Significa, pois, dizer que aqui só vamos classificar as garantias constitucionais especiais, nos termos do Direito Constitucional positivo. Então, temos que elas se agrupam em:

2. Cf. Ignacio Burgoa, *Las garantías individuales*, p. 179: "Los derechos del hombre se traducen substancialmente en potestades inseparables e inherentes a su personalidad; son elementos propios y consubstanciales de su naturaleza como ser racional, independiente de la posición jurídico-positiva en que pudiera estar colocado ante el Estado y sus autoridades; en cambio, las garantías individuales equivalen a la consagración jurídico-positiva de esos elementos, en el sentido de investirlos de obligatoriedad e imperatividad para atribuirles respectabilidad por parte de las autoridades estatales y del Estado mismo". Não é bem nesse sentido que estamos compreendendo as garantias; o autor as considera, como se vê, positivação dos direitos do homem. A isso demos o nome de garantias gerais, não propriamente constitucionais.

(1) *garantias constitucionais individuais*, compreendendo:

(a) o *princípio da legalidade*;

(b) o *princípio da proteção judiciária*;

(c) a *estabilidade dos direitos subjetivos adquiridos, perfeitos e julgados*;

(d) o *direito à segurança*;

(e) os *remédios constitucionais*;

(2) *garantias dos direitos coletivos*;

(3) *garantias dos direitos sociais*;

(4) *garantias dos direitos políticos*.

A elas dedicaremos os capítulos seguintes.

Capítulo II

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS INDIVIDUAIS

I. BASES CONSTITUCIONAIS: 1. Conceito. 2. Classificação. II. O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: 3. Conceito e fundamento constitucional. 4. Lei e a expressão "em virtude de lei". 5. Legalidade e reserva de lei. 6. Legalidade e legitimidade. 7. Legalidade e poder regulamentar. 8. Legalidade e atividade administrativa. 9. Legalidade tributária. 10. Legalidade penal. 11. Princípios complementares do princípio da legalidade. 12. Controle de legalidade. III. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIÁRIA: 13. Fundamento. 14. Monopólio judiciário do controle jurisdicional. 15. Direito de ação e de defesa. 16. Direito ao devido processo legal. 17. Direito a uma duração razoável do processo. IV. ESTABILIDADE DOS DIREITOS SUBJETIVOS: 18. Segurança das relações jurídicas. 19. Direito adquirido. 20. Ato jurídico perfeito. 21. Coisa julgada. V. DIREITO À SEGURANÇA: 22. Considerações gerais. 23. Segurança do domicílio. 24. Segurança das comunicações pessoais. 25. Segurança em matéria penal. 26. Segurança em matéria tributária. VI. REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS: 27. Remédios, ações e garantias. 28. Direito de petição. 29. Direito a certidões. 30. "Habeas corpus". 31. Mandado de segurança individual. 32. Mandado de injunção. 33. "Habeas data".

I. BASES CONSTITUCIONAIS

1. Conceito

A positivação dos direitos individuais constitui elemento fundamental para a sua obrigatoriedade e imperatividade. Essa *consagração jurídico-positiva* dos direitos do homem é uma garantia de que se reconhece, na Carta Magna, uma relação jurídica entre governado (sujeito ativo) e o Estado e suas autoridades (sujeitos passivos).¹ Não é, porém, nesse sentido geral que vamos empregar aqui a expressão *garantia constitucional individual* (ou simplesmente *garantia individual*). Usá-la-emos para exprimir os meios, instrumentos, procedimentos e instituições destinados a assegurar o respeito, a efetividade do gozo e a exigibilidade dos direitos individuais, os quais se encontram ligados a estes entre os incisos do art. 5º.

2. Classificação

Não importa aqui fazer classificação rigorosa das garantias individuais, o que, de resto, talvez nem seja possível. Tratar-se-á ape-

1. Nesse sentido é a lição de Burgoa, *ob. cit.*, pp. 178 e 179.

nas de agrupá-las em função de seu objeto em *legalidade* (princípio da legalidade), *proteção judiciária*, *estabilidade dos direitos subjetivos*, *segurança jurídica* (direito à segurança) e *remédios constitucionais*, como lembramos antes.

II. O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

3. Conceito e fundamento constitucional

O princípio da legalidade é nota essencial do Estado de Direito. É, também, por conseguinte, um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, como vimos,² porquanto é da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se ao *império da lei*, mas da lei que realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da igualização das condições dos socialmente desiguais. Toda a sua atividade fica sujeita à lei, entendida como expressão da vontade geral, que só se materializa num regime de divisão de poderes em que ela seja o ato formalmente criado pelos órgãos de representação popular, de acordo com o processo legislativo estabelecido na Constituição. É nesse sentido que se deve entender a assertiva de que o Estado, ou o Poder Público, ou os administradores não podem exigir qualquer ação, nem impor qualquer abstenção, nem mandar tampouco proibir nada aos administrados, senão em virtude de lei.³

É nesse sentido que o princípio está consagrado no art. 5º, II, da Constituição, segundo o qual *ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei*. O texto não há de ser compreendido isoladamente, mas dentro do sistema constitucional vigente, mormente em função de regras de distribuição de competência entre os órgãos do poder, de onde decorre que o princípio da legalidade ali consubstanciado se funda na previsão de competência geral do Poder Legislativo para legislar sobre matérias genericamente indicadas, de sorte que a idéia matriz está em que só o Poder Legislativo pode criar regras que contenham, originariamente, novidade modificativa da ordem jurídico-formal,⁴ o que faz coinci-

2. Cf. Primeira Parte, título II, capítulo II, n. 18.

3. Cf. García Pelayo, *Derecho constitucional comparado*, p. 159; Elias Díaz, *Estado de derecho y sociedad democrática*, pp. 30, 32 e 35; Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. V/1; Hely Lopes Meirelles, *Direito Administrativo Brasileiro*, p. 82; Celso Antônio Bandeira de Mello, *Curso de Direito Administrativo*, p. 47.

4. Cf. nosso *Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional*, pp. 21 e 22.

dir a competência da fonte legislativa com o *conteúdo inovativo* de suas estatuições, com a consequência de distingui-la da competência regulamentar.⁵

4. Lei e a expressão "em virtude de lei"

Do que se disse acima, já se deduz que a palavra *lei*, para a realização plena do princípio da legalidade, se aplica, em rigor técnico, à *lei formal*, isto é, ao ato legislativo emanado dos órgãos de representação popular e elaborado de conformidade com o processo legislativo previsto na Constituição (arts. 59 a 69). Há, porém, casos em que a referência à lei na Constituição, quer para satisfazer tão-só as exigências do princípio da legalidade, quer para atender hipóteses de reserva (*infra*), não exclui a possibilidade de que a matéria seja regulada por um "ato equiparado", e *ato equiparado à lei formal*, no sistema constitucional brasileiro atual, serão apenas a *lei delegada* (art. 68) e as *medidas provisórias, convertidas em lei* (art. 62), as quais, contudo, só podem substituir a lei formal em relação àquelas matérias estritamente indicadas nos dispositivos referidos.

Mas o princípio da legalidade vincula-se a uma reserva genérica ao Poder Legislativo, que não exclui atuação secundária de outros poderes.

O art. 5º, II, ao estatuir que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa *senão em virtude de lei*, dá margem a controvérsia quanto ao significado da expressão "*em virtude de lei*", querendo alguns que basta a existência de uma lei autorizativa de atos com aquele conteúdo, enquanto outros entendem que o conteúdo do restritivo da ação há que decorrer diretamente da lei. Parece-nos, no entanto, que razão cabe a Massimo Severo Giannini, quando, examinando cláusula semelhante do direito italiano, esclarece que "não é necessário que a norma de lei contenha todo o procedimento e regule todos os elementos do provimento, pois, para alguns atos do procedimento estatuído e para alguns elementos do provimento pode subsistir discricionariedade".⁶ Isso quer dizer que os elementos essenciais da providência impositiva não que constar da lei. Só a lei cria direitos e impõe obrigações positivas ou negativas, ainda que o texto constitucional dê a entender que só estas últimas estão contempladas no princípio da legalidade. Há outras normas constitucionais que completam seu sentido.

5. Cf. Costantino Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, t. I/299.

6. Cf. *Direito administrativo*, v. II/1261.

5. Legalidade e reserva de lei

A doutrina não raro confunde ou não distingue suficientemente o *princípio da legalidade* e o da *reserva de lei*. O primeiro significa a submissão e o respeito à lei, ou a atuação dentro da esfera estabelecida pelo legislador. O segundo consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal. Embora às vezes se diga que o princípio da legalidade se revela como um caso de *reserva relativa*, ainda assim é de reconhecer-se diferença entre ambos, pois que o legislador, no caso de reserva de lei, deve ditar uma disciplina mais específica do que é necessário para satisfazer o princípio da legalidade.⁷

Em verdade, o problema das relações entre os princípios da legalidade e da reserva de lei resolve-se com base no Direito Constitucional positivo, à vista do poder que a Constituição outorga ao Poder Legislativo. Quando essa outorga consiste no poder amplo e geral sobre qualquer espécie de relações, como vimos antes, tem-se o princípio da legalidade. Quando a Constituição reserva conteúdo específico, caso a caso, à lei, encontramos-nos diante do princípio da reserva legal. Por isso é que Christian Starck, examinando a questão em face da Constituição da República Federal da Alemanha, esclarece que, junto à *reserva geral*, ela reconhece uma *série de reservas particulares*.⁸ E a seguinte lição de Crisafulli situa devidamente a questão:

“Tem-se, pois, *reserva de lei* quando uma norma constitucional atribui determinada matéria exclusivamente à lei formal (ou a atos equiparados, na interpretação firmada na praxe), subtraindo-a, com isso, à disciplina de outras fontes, àquela subordinadas”.⁹

Outra diferença importante entre o princípio da legalidade (genérica) e o princípio da reserva de lei (legalidade específica) está em que o primeiro envolve primariamente uma situação de *hierarquia* das fontes normativas, enquanto o segundo envolve questão de *competência*. Starck, numa linha, disse-o com precisão: “Estas reservas especiais garantem, como *normas de competência*, que o legislador será quem regule tudo o que afeta os direitos fundamentais”.¹⁰

Aí o autor menciona direitos fundamentais, porque está cuidando da reserva de lei na parte dita dogmática da Constituição, mas igual compreensão deixara expressa também a respeito da parte orgânica, que se transcreve em seguida, porque é lição adequada ao nosso sistema:

7. Cf. Alfonso di Giovine, *Introduzione allo studio della riserva di legge*, p. 170.

8. *El concepto de ley en la Constitución alemana*, p. 404.

9. Cf. *Lezioni di diritto costituzionale*, v. II, t. I/52.

10. *Ob. cit.*, p. 404.

“Se se consideram as inumeráveis reservas de lei e delegações de competências regulamentares ao legislador na parte orgânica da Lei Fundamental, adverte-se, à primeira vista, que umas e outras pressupõem uma lei formal”.¹¹

Estabelecidas essas regras gerais, cumpre agora descer a outras especificações sobre o princípio de reserva de lei (amplamente disseminado na Constituição). Com efeito, a doutrina distingue categorias de reserva de lei, conforme o ponto de vista que se coloque. Ainda que Alfonso di Giovine¹² não aceite tais distinções, a nós nos parece que elas existem consoante ensinamento de Costantino Mortati¹³ e Vezio Crisafulli,¹⁴ de que nos serviremos para estudar a matéria em face de nossa Constituição. Esta, de fato, permite distinguir as seguintes categorias de reserva de lei:

(1) *do ponto de vista do órgão competente*, pelo qual o exercício da função legislativa para determinadas matérias só cabe ao Congresso Nacional, sendo, pois, *indelegável*, como é o caso da formação das leis sobre as matérias referidas no § 1º do art. 68;

(2) *do ponto de vista da natureza da matéria*, pelo qual determinadas matérias são reservadas à *lei complementar*, enquanto outras o são à *lei ordinária*, como são as hipóteses expressamente enumeradas na Constituição;¹⁵ e há casos em que a reserva é de lei ordinária ou complementar estadual¹⁶ ou de lei orgânica local;¹⁷

(3) *do ponto de vista do vínculo imposto ao legislador*, a reserva pode ser *absoluta* ou *relativa*. Alguns admitem também uma terceira, dita *reserva reforçada*, que, na verdade, ingressa no campo da reserva absoluta.

É *absoluta* a *reserva constitucional* de lei quando a disciplina da matéria é reservada pela Constituição à lei, com exclusão, portanto, de qualquer outra fonte infralegal, o que ocorre quando ela emprega fórmulas como: “a lei regulará”, “a lei disporá”, “a lei complementar organizará”, “a lei criará”, “a lei poderá definir” etc.

É *relativa* a *reserva constitucional de lei* quando a disciplina da matéria é em parte admissível a outra fonte diversa da lei, sob a condição de que esta indique as bases em que aquela deva produzir-se validamente. Assim é quando a Constituição emprega fórmulas como

11. *Idem*, p. 47.

12. *Ob. cit.*, pp. 99 e ss.

13. *Ob. cit.*, v. II, pp. 300 e ss.

14. *Ob. cit.*, p. 53.

15. Cf. arts. 7º, I; 14, § 9º.

16. Por exemplo, art. 18, § 4º.

17. Cf. art. 29.

as seguintes: “nos termos da lei”, “no prazo da lei”, “na forma da lei”, “com base na lei”, “nos limites da lei”, “segundo critérios da lei”.

São, em verdade, hipóteses em que a Constituição prevê a prática de ato infralegal sobre determinada matéria, impondo, no entanto, obediência a requisitos ou condições reservados à lei. Por exemplo, é facultado ao Poder Executivo, *por decreto*, alterar alíquotas dos impostos sobre importação, exportação, produtos industrializados e operações de crédito etc., *atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei* (art. 153, § 1º).

6. Legalidade e legitimidade

O princípio da legalidade, num Estado Democrático de Direito, funda-se no princípio da legitimidade, senão o Estado não será tal. Os regimes ditatoriais também atuam mediante leis. Tivemos até recentemente uma legalidade extraordinária, fundada em atos institucionais e atos complementares, embasada no critério da força e não no critério da legitimidade. Prova de que nem sempre a ordem jurídica é justa. O princípio da legalidade só pode ser formal na exigência de que a lei seja concebida como *formal* no sentido de ser feita pelos órgãos de representação popular, não tem abstração ao seu conteúdo e à finalidade da ordem jurídica.

Por aí se vê que legitimidade e legalidade nem sempre se confundem. Lembra bem D'Entrève: “Legalidade e legitimidade cessam de identificar-se no momento em que se admite que uma ordem pode ser legal mas injusta”.¹⁸ Propõe, por isso, a recuperação do liame entre legalidade e legitimidade, sob bases diferentes, a partir do abandono da noção puramente formal da legalidade, definindo-a como “a realização das condições necessárias para o desenvolvimento da dignidade humana”, como quer nossa Constituição (art. 1º, III), pois o “princípio da legalidade não exige somente que as regras e as decisões que compõem o sistema sejam formalmente corretas”. Ele exige que elas sejam conformes a certos valores, a valores necessários “à existência de uma sociedade livre”, tarefa exigida expressamente do Estado brasileiro (art. 3º, I).

Enfim, no dizer ainda de D'Entrève, legalidade e legitimidade não podem identificar-se senão quando a legalidade seja a garantia

18. Cf. “Légalité et légitimité”, in P. Bastid *et al.*, *L'idée de légitimité*, p. 38. Sobre o tema da legitimidade, cf. ainda Carl Schmitt, *Legalidad y legitimidad*, Madrid, Aguilar, 1971, trad. de José Díaz García; Elias Díaz, *Legalidad e legitimidad en el socialismo democrático*, Madrid, Civitas, 1978; José Eduardo Faria, *Poder e Legitimidade*, São Paulo, Perspectiva, 1978; Seabra Fagundes, *A Legitimidade do Poder Político na Experiência Brasileira*, Recife, OAB/Seção Pernambucana, 1982.

do livre desenvolvimento da personalidade humana.¹⁹ Dentro desse contexto, cabem as observações de Norberto Bobbio, segundo o qual legalidade e legitimidade são atributos do poder, mas são duas qualidades diferentes deste: a legitimidade é a qualidade do título do poder e a legalidade a qualidade do seu exercício. “Quando se exige que um poder seja legítimo, pergunta-se se aquele que o detém possui um justo título para detê-lo; quando se invoca a legalidade de um poder, indaga-se se ele é justamente exercido, isto é, segundo as leis estabelecidas. O poder legítimo é um poder, cujo título é justo; um poder legal é um poder, cujo exercício é justo, se legítimo”.²⁰

Em conclusão, o princípio da legalidade de um Estado Democrático de Direito assenta numa ordem jurídica emanada de um poder legítimo, até porque, se o poder não for legítimo, o Estado não será Democrático de Direito, como proclama a Constituição (art. 1º). Fora disso, teremos possivelmente uma legalidade formal, mas não a realização do princípio da legalidade.

7. Legalidade e poder regulamentar

Cabe ao Presidente da República o *poder regulamentar para fiel execução de lei e para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na forma da lei* (art. 84, IV e VI). Igual poder costuma ser outorgado aos Governadores nas Constituições estaduais e certamente vai ser conferido aos Prefeitos na Lei Orgânica dos respectivos Municípios. Não se põe, portanto, em dúvida que o poder regulamentar é faculdade constitucionalmente outorgada aos Chefes de Poder Executivo nas três esferas governamentais que convivem no sistema brasileiro de autonomias, para a fiel execução das leis e para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração. Aí se reconhecem dois tipos de regulamentos: O *regulamento de execução* e o *regulamento de organização*. O sistema constitucional brasileiro não admite o chamado *regulamento independente ou autônomo*, fora o regulamento de organização que a doutrina, às vezes, também considera um tipo autônomo; agora, em face do inc. VI do art. 84, não pode ser considerado autônomo, porque se prevê que seja expedido “na forma da lei”; fica, pois, sujeito a uma reserva relativa de lei.

O princípio é o de que o poder regulamentar consiste num poder administrativo no exercício de função normativa subordinada, qualquer que seja seu objeto. Significa dizer que se trata de poder

19. Ob. cit., pp. 38 e 39.

20. Cf. Norberto Bobbio, “Sur le principe de légitimité”, in P. Bastid *et al.*, ob. cit., p. 49.

limitado. Não é poder legislativo; não pode, pois, criar normatividade de que inove a ordem jurídica. Seus limites naturais situam-se no âmbito da competência executiva e administrativa, onde se insere. Ultrapassar esses limites importa em abuso de poder, em usurpação de competência, tornando-se írrito o regulamento dele proveniente.²¹ A lição de Oswaldo Bandeira de Mello é lapidar quanto a isto: o “regulamento tem limites decorrentes do direito positivo. Deve respeitar os textos constitucionais, a lei regulamentada, e a legislação em geral, e as fontes subsidiárias a que ela se reporta.

“Ademais, sujeita-se a comportas teóricas. Assim, não cria, nem modifica e sequer extingue direitos e obrigações, senão nos termos da lei, isso porque o inovar originariamente na ordem jurídica consiste em matéria reservada à lei. Igualmente, não adia a execução da lei e, menos ainda, a suspende, salvo disposição expressa dela, ante o alcance irrecusável da lei para ele. Afinal, não pode ser emendado senão conforme a lei, em virtude da proeminência desta sobre ele.”²²

Sob o ponto de vista da maior ou menor relação de subordinação do regulamento à lei, fala-se em *regulamento vinculado* e *regulamento autônomo* (ou independente). Vinculado é chamado o regulamento de determinada lei, desenvolvendo-lhe os princípios, estabelecendo os pormenores de sua execução. É este o regulamento que o Executivo baixa para fiel execução das leis, quer porque estas expressamente o exigem em certo prazo, quer por sua própria iniciativa, quando o julgue indispensável ou conveniente. É esse o regulamento que encontra fundamento no art. 84, IV, em relação às leis federais.

O *regulamento autônomo*, no sentido em que é admitido no Direito Constitucional e no direito estrangeiro, não encontra guarida na Constituição. Dá ela, contudo, agora, em virtude da redação dada ao art. 84, VI, pela EC-32/2001, fundamento ao *regulamento de organização* como uma forma limitada de regulamento autônomo. Demais de ter que atender a forma da lei, em cada caso, só é admissível nos casos em que a Constituição não tenha reservado à lei a específica organização de determinada instituição. Dela própria é até possível induzir um princípio geral importante nessa questão, qual seja o de que, aos órgãos nela instituídos, ela reserva sua organização à lei ordinária ou complementar. Assim, p. ex., a emancipação municipal depende de *lei estadual*, dentro do período determinado por *lei complementar* federal (art. 18, § 4º, redação da EC-15/96); a organização de Territórios depende de lei (art. 33); regiões de desenvolvimento dependem de lei complementar (art. 43, § 1º); a organização e funcionamento do Conselho

da República e do Conselho de Defesa Nacional dependem de lei (arts. 90, § 2º, e 91, § 2º); organização e funcionamento do Ministério Público dependem de lei complementar (art. 128, § 5º), assim também a organização e funcionamento da Advocacia-Geral da União (art. 131).

Mostra Carlo Esposito a razão de ser da reserva de lei em tais casos: é que tal reserva “estabelece, em relação a competências regulamentares genéricas atribuídas ao Executivo, os casos excepcionais e as zonas particulares nas quais não são admissíveis regulamentos, mas só lei. Além disso, esta, quando a competência genérica é atribuída apontando o fim a atingir com o regulamento, indica de que meios o regulamento não pode utilizar-se para alcançar o fim. Da primeira espécie são hoje na Itália [como no Brasil] as disposições segundo as quais (concedido ao Executivo o poder de organização) são reservadas, às leis específicas, regras de organização”.²³

8. Legalidade e atividade administrativa

Posta a teoria geral supra, examinemos alguns casos particulares de aplicação do princípio, primeiro em relação à atividade administrativa, mais adiante em matéria penal e tributária. Lembra Hely Lopes Meirelles que a “eficácia de toda a atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei”.

“Na Administração Pública”, prossegue, “não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei, para o particular, significa ‘pode fazer assim’; para o administrador significa ‘deve fazer assim’”.²⁴

Este é agora um princípio estabelecido na Constituição, de modo expresso no art. 37, segundo o qual a Administração Pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da *legalidade*, *impessoalidade*, *moralidade*, *publicidade* e *eficiência*.

Na verdade, o regime de garantias constitucionais condiciona a atividade administrativa, prescrevendo uma série de normas que procuram dar efetiva consistência ao *princípio da legalidade*, desde sua expressa e específica previsão no art. 37 em relação a toda e qualquer Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, correlacionado aos princípios da *impessoalidade*, *moralidade* e *publicidade*, que o reforçam, até a afirmação dos princípios do “devido processo le-

21. Cf. nosso *O Prefeito e o Município*, pp. 183 e 184.

22. Cf. *Princípios Gerais de Direito Administrativo*, v. I/319.

23. Cf. *La validità delle leggi*, p. 127.

24. Cf. *Direito Administrativo Brasileiro*, 18ª ed., cit., pp. 82 e 83; na mesma linha de pensar, Celso Antônio Bandeira de Mello, *Curso de Direito Administrativo*, p. 47.

gal" (art. 5º, LIV) e do contraditório "em processo administrativo" (art. 5º, LV).

Remanesce a questão da *discrecionalidade* da Administração, ampliada com o aumento das funções estatais, pois, se a atividade discricionária e os atos conseqüentes não são arbitrários, certo é que não se subordinam a um estrito vínculo de legalidade. A doutrina, é certo, firmou já a orientação de que a discricionariedade é sempre *relativa e parcial*, porque, quanto à *competência*, à *forma* e à *finalidade do ato*, a autoridade está sempre subordinada ao que a lei dispõe; são eles, pois, aspectos vinculados do ato discricionário, pelo que este só se verifica quanto ao *motivo* e ao *objeto* do ato. E é aqui que se dá a distinção entre atos discricionários e vinculados. Se o motivo e o objeto forem expressos em lei, o *ato é vinculado*; se não o forem, resta um campo de liberdade ao administrador, e o *ato é discricionário*.²⁵ Mas aí entra um complicador: a *teoria dos motivos determinantes*, pois se o ato, proveniente de atividade discricionária, for motivado, reputa-se vinculado aos *motivos* que o determinaram, e assim ele fica vinculado aos *fins* propostos que, por seu turno, sempre se vinculam aos ditames da lei.

Outro princípio envolvido na problemática em exame é o da "*justiciabilidade*" do ato, ou seja: a possibilidade de submissão dos atos administrativos ao controle jurisdicional, para que o juiz declare sua conformidade à lei ou o anule. Sendo vinculado, o ato fica sempre sujeito a esse controle. Mas o problema da atividade discricionária se põe aí, porque, exatamente por não ser regulada em lei, refoge ao controle de legalidade, nos limites da discricionariedade, claro, ainda que o Judiciário venha ampliando esse controle, em observância daquelas regras antes não-jurídicas, mas agora constitucionalizadas (moralidade, probidade, finalidade pública, impessoalidade etc.), a que a Administração deve adequar-se para poder dar às suas decisões caráter de *razoabilidade*, de *logicidade*, de *congruência*, faltando o qual as decisões se manifestam viciadas de *excesso de poder*,²⁶ saindo, por assim dizer do campo da discricionariedade para ingressar no limiar da arbitrariedade.

9. Legalidade tributária

O fenômeno tributário, como atividade estatal, obedece ao princípio da legalidade, mas não à simples legalidade genérica que rege todos os atos e atividades administrativas. Subordina-se a uma lega-

25. Cf. Hely Lopes Meirelles, *ob. cit.*, p. 103; Caio Tácito, *Direito Administrativo*, pp. 68 e 124 e ss.; Celso Antônio Bandeira de Mello, *ob. cit.*, p. 199.

26. Cf. Costantino Mortati, *ob. cit.*, p. 319.

lidade específica, que, em verdade, se traduz no *princípio da reserva de lei*. Esta legalidade específica constitui *garantia constitucional do contribuinte*, em forma de limitação ao poder de tributar que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios *exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça* (art. 150, I).²⁷

Esse princípio da estrita legalidade tributária compõem-se de dois princípios que se complementam: o da *reserva de lei* e o da *anterioridade da lei tributária* (art. 150, I e III). Há exceções, pois ao Poder Executivo está facultado alterar as alíquotas dos impostos sobre a importação, exportação, produtos industrializados e operações financeiras, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei (art. 153, § 1º).

10. Legalidade penal

Trata-se também de garantia individual prevista no art. 5º, XXXIX, segundo o qual *não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal*, em que se consubstancia o princípio *nullum crimen nulla poena sine lege*. O dispositivo contém uma reserva absoluta de lei formal, que exclui a possibilidade de o legislador transferir a outrem a função de definir o crime e de estabelecer penas. Demais, a definição legal do crime e a previsão da pena não que preceder o fato tido como delituoso. Sem lei que o tenha feito não há crime nem pena.

O princípio se completa com outro: o *favor rei*, que prescreve a *não ultratividade* da lei penal, isto é, a aplicação da lei posterior àquela vigente no momento da comissão do crime quando essa tolha o caráter delituoso do fato, ou contenha dispositivos mais favoráveis ao réu, tudo junto no art. 5º, XL, que declara que *a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu*.

11. Princípios complementares do princípio da legalidade

Esses princípios que aqui serão lembrados são mais caracteristicamente *garantias do próprio regime de legalidade*, como é o caso da *inafastabilidade do controle jurisdicional* (art. 5º, XXXV), que precisamente objetiva verificar a conformidade do ato ou atividade do Poder Público com as normas legais. Sem esse controle, o princípio da legalidade não passaria de fórmula vazia. A proteção constitucional do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada também constitui garantia de permanência e de estabilidade do princípio da legalidade.

27. Para considerações mais amplas sobre o tema, cf. Alberto Xavier, *Os Princípios da Legalidade e da Tipicidade da Tributação*, São Paulo, Ed. RT, 1978; Gert Willi Rotmam, "O princípio da legalidade tributária", in *Direito Tributário*, pp. 153 e ss.

O princípio da irretroatividade das leis é também princípio complementar ao da legalidade, porque, se se permitisse a retroatividade das leis, estas alcançariam períodos não regidos por normas legais ou fatos não sujeitos a ditames legais, por via de uma ficção inaceitável, pelo menos quando obriga a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. É que a exigência constitucional de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa *senão em virtude de lei* significa lei existente no momento em que o fazer ou o deixar de fazer está acontecendo.

12. Controle de legalidade

A submissão da Administração à legalidade fica subordinada a três sistemas de controle: o *administrativo*, o *legislativo* e o *jurisdicional*.²⁸ Qualquer desses controles objetiva verificar a conformação da atividade e do ato às normas legais. Deles o jurisdicional é o mais importante e se realiza com base na garantia do acesso ao Judiciário, mediante procedimentos ordinários, sumaríssimos e especiais, mormente pela utilização de um dos remédios constitucionais adiante indicados.

III. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIÁRIA

13. Fundamento

O princípio da proteção judiciária, também chamado princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional,²⁹ constitui em verdade, a principal garantia dos direitos subjetivos. Mas ele, por seu turno, fundamenta-se no princípio da separação de poderes, reconhecido pela doutrina como garantia das garantias constitucionais. Aí se junta uma constelação de garantias: as da independência e imparcialidade do juiz, a do juiz natural ou constitucional, a do direito de ação e de defesa. Tudo ínsito nas regras do art. 5º, XXXV, LIV e LV.³⁰

28. Cf. Seabra Fagundes, *O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário*, p. 87; Hely Lopes Meirelles, *Direito Administrativo Brasileiro*, pp. 572 e ss.

29. Cf. Kazuo Watanabe, *Controle Jurisdicional*, p. 7; Ada Pellegrini Grinover, *As Garantias Constitucionais do Direito de Ação*, p. 133.

30. Garante-se no texto o processo, que envolve o direito à ação, o direito de defesa, o contraditório, a isonomia processual e a bilateralidade dos atos procedimentais. Cf. Frederico Marques, "O artigo 141, § 4º, da Constituição Federal", *Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Ceará*, n. 16, pp. 65 e ss., dez./62, refere-se à Constituição de 1946, mas com ensinamento válido ainda; idem, *A Reforma do Poder Judiciário*, pp. 69 e ss.; Ada Pellegrini Grinover, *ob. cit.*, tit. III; Kazuo Watanabe, *ob. cit.*; Luigi Paolo Comoglio, *La garanzia costituzionale dell'azione ed il processo civile*, Padova, CEDAM, 1970; Vincenzo Vigoritti, *Garanzie costituzionale del processo civile*, Milano, Giuffrè, 1973; Nicolò Trocer, *Processo civile e costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1974, trad. de Gian Antonio Micheli.

14. Monopólio judiciário do controle jurisdicional

O art. 5º, XXXV, declara: *a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*. Acrescenta-se agora *ameaça a direito*, o que não é sem consequência, pois possibilita o ingresso em juízo para assegurar direitos simplesmente ameaçados. Isso já se admitia, nas leis processuais, em alguns casos. A Constituição amplia o direito de acesso ao Judiciário, antes de concretização da lesão.

A primeira garantia que o texto revela é a de que cabe ao Poder Judiciário o monopólio da jurisdição, pois sequer se admite mais o contencioso administrativo que estava previsto na Constituição revogada. A segunda garantia consiste no direito de invocar a atividade jurisdicional sempre que se tenha como lesado ou simplesmente ameaçado um direito, individual ou não, pois a Constituição já não mais o qualifica de individual, no que andou bem, porquanto a interpretação sempre fora a de que o texto anterior já amparava direitos, p. ex., de pessoas jurídicas ou de outras instituições ou entidades não individuais, e agora hão de levar-se em conta os direitos coletivos também.

15. Direito de ação e de defesa

O art. 5º, XXXV, consagra o direito de invocar a atividade jurisdicional, como direito público subjetivo. Não se assegura aí apenas o direito de agir, o direito de ação. Invocar a jurisdição para a tutela de direito é também direito daquele contra quem se age, contra quem se propõe a ação. Garante-se a plenitude de defesa, agora mais incisivamente assegurada no inc. LV do mesmo artigo: *aos litigantes, em processo judicial e administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes*. Agora a seguinte passagem do magistério de Liebman tem ainda maior adequação ao Direito Constitucional brasileiro:

"O poder de agir em juízo e o de defender-se de qualquer pretensão de outrem representam a garantia fundamental da pessoa para a defesa de seus direitos e competem a todos indistintamente, pessoa física e jurídica, italianos [brasileiros] e estrangeiros, como atributo imediato da personalidade e pertencem por isso à categoria dos denominados *direitos cívicos*".³¹

16. Direito ao devido processo legal

O princípio do *devido processo legal* entra agora no Direito Constitucional positivo com um enunciado que vem da Carta Magna in-

31. Cf. *Manuale di diritto processuale civile*, v. I/10 e 11.

glesa: *ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal* (art. 5º, LIV). Combinado com o direito de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e o contraditório e a plenitude de defesa (art. 5º, LV), fecha-se o ciclo das garantias processuais. Garante-se o processo, e “quando se fala em ‘processo’, e não em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos da ordem jurídica. E isso envolve a garantia do contraditório, a plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e a bilateralidade dos atos procedimentais”, conforme autorizada lição de Frederico Marques.³²

17. Direito a uma duração razoável do processo

Esse direito foi instituído pela EC-45/2004 mediante o acréscimo do inc. LXXVIII ao art. 5º da Constituição, para estatuir que *a todos são asseguradas, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação*. Aqui interessa o processo judicial, que é o resultado do exercício do direito de acesso à Justiça previsto no inc. XXXV, de que já falamos supra. De fato, o acesso à Justiça só por si já inclui uma prestação jurisdicional em tempo hábil para garantir o gozo do direito pleiteado – mas crônica morosidade do aparelho judiciário o frustrava; daí criar-se mais essa garantia constitucional, com o mesmo risco de gerar novas frustrações pela sua ineficácia, porque não basta uma declaração formal de um direito ou de uma garantia individual para que, num passe de mágica, tudo se realize com declarado. Demais a norma acena para a regra da *razoabilidade* cuja textura aberta deixa amplas margens de apreciação, sempre em função de situações concretas. Ora, a forte carga de trabalho dos magistrados será, sempre, um parâmetro a ser levado em conta na apreciação da razoabilidade da duração dos processos a seu cargo. É, nesse contexto, que entra o outro aspecto da norma em análise, qual seja: a organização dos meios que garantam a celeridade da tramitação dos processos. A garantia de celeridade de tramitação dos processos constitui um modo de impor limites à textura aberta da razoabilidade, de sorte que, se o magistrado demora no exercício de sua judicatura por causa, por exemplo, de excesso de trabalho, a questão se põe quanto à busca de meios para dar maior celeridade ao cumprimento de suas funções, prevenindo-se

32. Cf. “O artigo 141, § 4º, da Constituição Federal”, cit., p. 71; cf. também Vincenzo Vigoritti, *ob. cit.*, pp. 39 e 40. Para uma apreciação mais ampla e mais profunda do tema, cf. Ada Pellegrini Grinover, *As Garantias Constitucionais do Direito de Ação*, São Paulo, Ed. RT, 1973.

mesmo que o Congresso Nacional promova alterações na legislação federal objetivando tornar mais amplo o acesso à Justiça e mais célere a prestação jurisdicional (EC-45/2004, art. 7º); se, no entanto, a morosidade decorrer de desídia do magistrado, o tribunal a que ele pertence, seja qual for sua condição, deve tomar as providências para o cumprimento das garantias asseguradas no inciso em apreço.

IV. ESTABILIDADE DOS DIREITOS SUBJETIVOS

18. Segurança das relações jurídicas

A temática deste número liga-se à sucessão de leis no tempo e à necessidade de assegurar o valor da *segurança jurídica*, especialmente no que tange à estabilidade dos direitos subjetivos. A *segurança jurídica* consiste no “conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida”.³³ Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza de que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída.

Realmente, uma lei é feita para vigorar e produzir seus efeitos para o futuro. Seu *limite temporal* pode ser nela mesma demarcado ou não. Seu texto, às vezes, delimita o tempo durante o qual ela regerá a situação fática prevista. Outras vezes ela é feita para regular situação transitória, decorrida a qual perde vigência e, conseqüentemente, a eficácia.

O mais comum, contudo, é que uma lei, uma norma, só perca o vigor quando outra a *revogue expressa* ou *tacitamente*. Se a lei revogada produziu efeitos em favor de um sujeito, diz-se que ela criou *situação jurídica subjetiva*, que poderá ser um simples interesse, um interesse legítimo, a expectativa de direito, um direito condicionado, um *direito subjetivo*. Este último é garantido jurisdicionalmente, ou seja, é um direito exigível na via jurisdicional. Recebe, assim, proteção direta, pelo que seu titular fica dotado do poder de exigir uma prestação positiva ou negativa.

A realização efetiva desse interesse juridicamente protegido, chamado *direito subjetivo*, não raro fica na dependência da vontade do seu titular. Diz-se, então, que o direito lhe pertence, já integra o seu patrimônio, mas ainda não fora exercido. Se vem lei nova, revogando aquela sob cujo império se formara o direito subjetivo, cogitar-se-á de saber

33. Cf. Jorge Reinaldo Vanossi, *El Estado de derecho en el constitucionalismo social*, p. 30.

que efeitos surtirá sobre ele. Prevalece a situação subjetiva constituída sob o império da lei velha, ou, ao contrário, fica ela subordinada aos ditames da lei nova? É nessa colidência de normas no tempo que entra o tema da proteção dos direitos subjetivos que a Constituição consagra no art. 5º, XXXVI, sob o enunciado de que *a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada*.

19. Direito adquirido

A doutrina ainda não fixou com precisão o conceito de direito adquirido. É ainda a opinião de Gabba que orienta sua noção, destacando como seus elementos caracterizadores: (1) ter sido produzido por um fato idôneo para a sua produção; (2) ter se incorporado definitivamente ao patrimônio do titular. A Lei de Introdução ao Código Civil declara que *se consideram adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem* (art. 6º, § 2º).³⁴

Para compreendermos um pouco melhor o que seja o direito adquirido, cumpre relembrar o que se disse acima sobre o *direito subjetivo*: é um direito exercitável segundo a vontade do titular e exigível na via jurisdicional quando seu exercício é obstado pelo sujeito obrigado à prestação correspondente. Se tal direito é exercido, foi devidamente prestado, tornou-se situação jurídica consumada (direito consumado, direito satisfeito, extinguiu-se a relação jurídica que o fundamentava). Por exemplo, quem tinha o direito de casar de acordo com as regras de uma lei, e casou-se, seu direito foi exercido, consumou-se. A lei nova não tem o poder de desfazer a situação jurídica consumada. A lei nova não pode descasar o casado, porque estabeleceu regras diferentes para o casamento.

Se o direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei nova, transforma-se em *direito adquirido*, porque era direito exercitável e exigível à vontade de seu titular. Incorporou-se no seu patrimônio, para ser exercido quando convier. A lei nova não pode prejudicá-lo, só pelo fato de o titular não o ter exercido antes. *Direito subjetivo* "é a possibilidade de ser exercido, de maneira garantida, aquilo que as normas de direito atribuem a alguém como próprio".³⁵ Ora, essa possibilidade de exercício continua no domínio da vontade do titular em face da lei nova.

34. Para pormenores, cf. Vicente Ráo, *O Direito e a Vida dos Direitos*, 2ª ed., v. I, t. III/361 e ss., São Paulo, Resenha Universitária, 1977; R. Limongi França, *Direito Intemporal Brasileiro*, pp. 426 e ss.

35. Cf. Miguel Reale, *Lições Preliminares de Direito*, p. 292.

Essa possibilidade de exercício do direito subjetivo foi adquirida no regime da lei velha e persiste garantida em face da lei superveniente. Vale dizer — repetindo: o direito subjetivo vira direito adquirido quando lei nova vem alterar as bases normativas sob as quais foi constituído. Se não era direito subjetivo antes da lei nova, mas interesse jurídico simples, mera expectativa de direito ou mesmo interesse legítimo, não se transforma em direito adquirido sob o regime da lei nova, que, por isso mesmo, corta tais situações jurídicas subjetivas no seu *iter*, porque sobre elas a lei nova tem aplicabilidade imediata, incide.

Não se trata aqui da questão da *retroatividade da lei*, mas tão-só de limite de sua aplicação. A lei nova não se aplica a situação objetiva constituída sob o império da lei anterior.

Vale dizer, portanto, que a Constituição não veda a retroatividade da lei, a não ser da lei penal que não beneficie o réu. Afora isto, o *princípio da irretroatividade da lei* não é de Direito Constitucional, mas princípio geral de Direito. Decorre do princípio de que as leis são feitas para vigorar e incidir para o futuro. Isto é: são feitas para reger situações que se apresentem a partir do momento em que entram em vigor. Só podem surtir efeitos retroativos quando elas próprias o estabeleçam (vedado em matéria penal, salvo a retroatividade benéfica ao réu), resguardados os direitos adquiridos e as situações consumadas evidentemente.

Direito adquirido e direito público. Cumpre fazer uma observação final a respeito da relação entre direito adquirido e direito público. Não é rara a afirmativa de que não há direito adquirido em face da lei de ordem pública ou de direito público. A generalização não é correta nesses termos. O que se diz com boa razão é que não corre direito adquirido contra o interesse coletivo, porque aquele é manifestação de interesse particular que não pode prevalecer sobre o interesse geral. A Constituição não faz distinção.

20. Ato jurídico perfeito

A Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º, § 1º, reputa *ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou*. Essa definição dá a idéia de que ato jurídico perfeito é aquela situação consumada ou direito consumado, referido acima, como direito definitivamente exercido. Não é disso, porém, que se trata. Esse direito consumado é também inatingível pela lei nova, não por ser ato perfeito, mas por ser direito mais do que adquirido, direito esgotado. Se o simples direito adquirido (isto é, direito que já integrou o patrimônio mas não foi ainda exercido) é protegido contra interferência da lei nova, mais ainda o é o direito adquirido já consumado.

A diferença entre direito adquirido e ato jurídico perfeito está em que aquele emana diretamente da lei em favor de um titular, enquanto o segundo é negócio fundado na lei. "O ato jurídico perfeito, a que se refere o art. 153, § 3º [agora, art. 5º, XXXVI], é o negócio jurídico, ou o ato jurídico *stricto sensu*; portanto, assim as declarações unilaterais da vontade como os negócios jurídicos bilaterais, assim os negócios jurídicos, como as reclamações, interpretações, a fixação de prazo para a aceitação de doação, as comunicações, a constituição de domicílio, as notificações, o reconhecimento para interromper a prescrição ou com sua eficácia (ato jurídico *stricto sensu*)".³⁶ Ato jurídico perfeito, nos termos do art. 153, § 3º [art. 5º, XXXVI], é *aquele que sob o regime da lei antiga se tornou apto para produzir os seus efeitos pela verificação de todos os requisitos a isso indispensável*.³⁷ É perfeito ainda que possa estar sujeito a termo ou condição.

21. Coisa julgada

A garantia, aqui, refere-se à *coisa julgada material*, não à coisa julgada formal. Ficou, pois, superada a definição do art. 6º, § 3º, da Lei de Introdução ao Código Civil. Prevalece, hoje, o conceito do Código de Processo Civil:

Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (art. 467).

Dizemos que o texto constitucional só se refere à coisa julgada material, em oposição à opinião de Pontes de Miranda,³⁸ porque o que se protege é a prestação jurisdicional definitivamente outorgada. A coisa julgada formal só se beneficia da proteção indiretamente na medida em que se contém na coisa julgada material, visto que é pressuposto desta, mas não assim a simples coisa julgada formal. Tutela-se a estabilidade dos casos julgados, para que o titular do direito aí reconhecido tenha a certeza jurídica de que ele ingressou definitivamente no seu patrimônio. A coisa julgada é, em certo sentido, um ato jurídico perfeito; assim já estaria contemplada na proteção deste, mas o constituinte a destacou como um instituto de enorme relevância na teoria da segurança jurídica.

A proteção constitucional da coisa julgada não impede, contudo, que a lei preordene regras para a sua rescisão mediante atividade

36. Cf. Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. V/102.

37. Cf. R. Limongi França, *ob. cit.*, p. 427.

38. *Ob. cit.*, p. 102.

jurisdicional. Dizendo que a lei não prejudicará a coisa julgada, quer-se tutelar esta contra atuação direta do legislador, contra ataque direto da lei. A lei não pode desfazer (rescindir ou anular ou tornar ineficaz) a coisa julgada. Mas pode prever licitamente, como o fez o art. 485 do Código de Processo Civil, sua rescindibilidade por meio de ação rescisória.

V. DIREITO À SEGURANÇA

22. Considerações gerais

O Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho arrola os *direitos à segurança* (direitos cujo objeto imediato é a segurança) como categoria de direitos individuais, não propriamente como *garantias individuais*.³⁹ E o *caput* do art. 5º fala em inviolabilidade do *direito [...] à segurança*, o que, no entanto, não impede seja ele considerado um conjunto de *garantias*, natureza que, aliás, se acha ínsita no termo *segurança*. Efetivamente esse conjunto de direitos aparelha situações, proibições, limitações e procedimentos destinados a assegurar o exercício e o gozo de algum direito individual fundamental (intimidade, liberdade pessoal ou a incolumidade física ou moral).

23. Segurança do domicílio

O art. 5º, XI, da Constituição consagra o direito do indivíduo ao aconchego do lar com sua família ou só, quando define a *casa* como o *asilo inviolável do indivíduo*. Aí o *domicílio*, com sua carga de valores sagrados que lhe dava a religiosidade romana. Aí também o direito fundamental da *privacidade*, da *intimidade*, que esse asilo inviolável protege. O recesso do lar é, assim, o ambiente que resguarda a privacidade, a intimidade, a vida privada. A segurança aparelhada no dispositivo consiste na proibição de na casa penetrar sem consentimento do morador, a não ser *em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial*. Essas exceções à proteção do domicílio ligam-se ao interesse da própria segurança individual (caso de delito) ou do socorro (desastre ou socorro) ou da Justiça, apenas durante o *dia* (determinação judicial), para busca e apreensão de criminosos ou de objeto de crime.

Importa o conceito de *dia*. O princípio é que, para fins judiciais, o dia se estende de 6 às 18 horas.

39. Cf. *Curso de Direito Constitucional*, pp. 274, 280 e ss.

O objeto de tutela não é propriedade, mas o respeito à personalidade, de que a esfera privativa e íntima é aspecto saliente.⁴⁰

A proteção dirige-se basicamente contra as autoridades. Visa impedir que estas invadam o lar. Mas também se dirige aos particulares. O crime de violação de domicílio tem por objeto tornar eficaz a regra da inviolabilidade do domicílio.

24. Segurança das comunicações pessoais

Trata-se de garantia constitucional que visa assegurar o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas (art. 5º, XII), que são meios de comunicação interindividual, formas de manifestação do pensamento de pessoa a pessoa, que entram no conceito mais amplo de liberdade de pensamento em geral (art. 5º, IV). Garantia também do sigilo das comunicações de dados pessoais, a fim de proteger a esfera íntima do indivíduo.

Ao declarar que é *inviolável* o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, a Constituição está proibindo que se abram cartas e outras formas de correspondência escrita, se interrompa o seu curso e se escutem e interceptem telefonemas. Abriu-se excepcional possibilidade de interceptar comunicações telefônicas, *por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual*. Vê-se que, mesmo na exceção, a Constituição preordenou regras estritas de garantias, para que não se a use para abusos. O "objeto de tutela é duplice: de um lado, a liberdade de manifestação de pensamento; de outro lado, o segredo, como expressão do direito à intimidade".⁴¹

A suspensão, sustação ou interferência no curso da correspondência, sua leitura e difusão sem autorização do transmitente ou do destinatário, assim como as interceptações telefônicas, fora das hipóteses excepcionais autorizadas no dispositivo constitucional, constituem as formas principais de violação do direito protegido. A legislação penal (Código Penal) e a especial (Código das Comunicações) prevêem sanções aplicáveis a esses crimes.

25. Segurança em matéria penal

Constitui-se de garantias que visam tutelar a liberdade pessoal. Figura ela no art. 5º, XXXVII a XLVII, mais a hipótese do inc. LXXV,

40. Sobre o tema, cf. Ada Pellegrini Grinover, *Liberdades Públicas e Processo Penal*, p. 192.

41. Cf. Ada Pellegrini Grinover, *ob. cit.*, p. 190.

sem falar no *habeas corpus*, incluído entre os remédios constitucionais (infra). Essas garantias penais ou criminais protegem o indivíduo contra atuações arbitrárias, e podem ser consideradas nos grupos seguintes:

(1) garantias jurisdicionais penais:

(a) *garantia da inexistência de juízo ou tribunal de exceção* (inc. XXXVII), acolhendo-se aí o princípio do *juiz natural*, pré-constituído, pelo qual é vedada a constituição de juiz *ad hoc* para o julgamento de determinada causa;⁴² admite-se, contudo, o foro privilegiado, mas apenas os indicados na própria Constituição, como o privilégio de Prefeito de ser julgado perante o Tribunal de Justiça (art. 29, X), o de Deputados Federais, de Senadores e Presidente da República de serem processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal;

(b) *garantia de julgamento pelo tribunal do júri nos crimes dolosos contra a vida* e ainda assim com as garantias subsidiárias da plenitude de defesa, do sigilo das votações dos jurados e da soberania dos veredictos (inc. XXXVIII), valendo dizer: outro tribunal não pode reformar o mérito da decisão do júri; pode anular o processo por vício de forma, não mudar o mérito do julgamento;

(c) *garantia do juiz competente* (incs. LIII e LXI), segundo a qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente e nem preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo flagrante delito e nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei;

(2) garantias criminais preventivas:⁴³

(a) *anterioridade da lei penal* (inc. XXXIX), de acordo com a qual não há crime sem lei anterior que o defina (regra do *nullum crimen sine lege*), nem pena sem prévia cominação legal (regra da *nulla poena sine lege*), proscrevendo assim ordenamento *ex post facto*;

(b) *garantia da irretroatividade da lei penal*, salvo quando beneficiar o réu (inc. XL);

(c) *garantia de legalidade e da comunicabilidade da prisão* (LXII), por isso que "a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade competente" (inc. LXV), e para maior eficácia desta garantia confere-se ao "preso o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório" (inc. LXIV);

(3) garantias relativas à aplicação da pena:⁴⁴

42. Cf. Frederico Marques, *A Reforma do Poder Judiciário*, pp. 75 e ss.

43. Cf. Paulino Jacques, *Curso de Direito Constitucional*, p. 483.

44. Cf. Paulino Jacques, *ob. cit.*, pp. 484 e 492.

(a) *individualização da pena* (inc. XLVI), ou seja, a aplicação da pena deve ajustar-se à situação de cada imputado;

(b) *personalização da pena* (inc. XLV), vale dizer: a pena não passará da pessoa do delinquent, no sentido de que não atingirá a ninguém de sua família, nem a terceiro, garantia, pois, de que ninguém pode sofrer sanção por fato alheio, salvo a possibilidade de extensão aos sucessores e contra eles executadas, nos termos da lei, da obrigação de reparar o dano e da decretação de perdimento de bens, até o limite do valor do patrimônio transferido;

(c) *proibição de prisão civil por dívida*, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel (inc. LXVII);

(d) *proibição de extradição de brasileiro*, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei (inc. LI);

(e) *proibição de extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião* (inc. LII), que já discutimos nas condições jurídicas dos estrangeiros;

(f) *proibição de determinadas penas* (inc. XLVII): de morte (salvo em caso de guerra declarada), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis;

(4) *garantias processuais penais*: de certo modo as anteriores também o são, mais especificamente, porém, podem ser citadas as seguintes:

(a) *instrução penal contraditória* (inc. LV), que tem como conteúdo essencial a garantia da plenitude ou ampla defesa, com os meios e recurso a ela inerentes (incs. XXXIV, a, e LV);

(b) *garantia do devido processo legal* (inc. LIV), segundo a qual ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, mas que, em verdade, tem sentido muito mais abrangente, pois significa também que alguém só pode ser julgado e condenado por juiz competente previamente estabelecido na ordem judiciária e por crime que previamente também seja definido como tal em lei, sendo assim garantia conexa com a do juiz competente e à da anterioridade da lei penal;

(c) *garantia da ação privada* (inc. LIX), que garante ao interessado promover a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal; aqui, em certo sentido, tem-se uma forma de controle do Ministério Público, que, em deixando de cumprir sua atribuição, fica sujeito à substituição pelo interessado (vítima ou seu representante);

(5) *garantias da presunção de inocência*, segundo as quais ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (inc. LVII) e o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei (inc. LVIII); na verdade o texto inicial dizia "salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei", mas uma proposta de redação do primeiro para o segundo turno eliminou o vocábulo, importante, "excepcionais"; a garantia de inocência e de que ninguém deve sofrer sanção sem culpa é que fundamenta a prescrição do inc. LXXV, segundo o qual "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença";

(6) *garantias da incolumidade física e moral*:

(a) *vedação de tratamento desumano e degradante* (inc. III);

(b) *vedação e punição da tortura*: ninguém será submetido à tortura (inc. III) e a prática desta será considerada, pela lei, crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (inc. XLIII);

(7) *garantias penais da não discriminação* (incs. XLI e XLII), valendo dizer: "a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais" e "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei"; deve-se observar, não obstante, que a inafiançabilidade e especialmente a imprescritibilidade revelam um retrocesso na ciência penal;

(8) *garantia penal da ordem constitucional democrática*: é o que consta do inc. XLIV do art. 5º: "constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático".

26. Segurança em matéria tributária

Essa segurança realiza-se nas garantias consubstanciadas no art. 150: (a) de que nenhum tributo será exigido nem aumentado senão em virtude de lei (inc. I); princípio da legalidade tributária, que já estudamos; (b) de que não se instituirá tratamento desigual entre contribuintes (inc. II); (c) de que nenhum tributo será cobrado em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado nem no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (inc. III); (d) de que não haverá tributo com efeito confiscatório (inc. IV).

VI. REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS

27. Remédios, ações e garantias

A Constituição inclui entre as *garantias individuais* o direito de petição, o *habeas corpus*, o mandado de segurança, o mandado de injunção, o *habeas data*, a ação popular, aos quais se vem dando, na doutrina e na jurisprudência, o nome de *remédios de Direito Constitucional*, ou *remédios constitucionais*, no sentido de meios postos à disposição dos indivíduos e cidadãos para provocar a intervenção das autoridades competentes, visando *sanar, corrigir*, ilegalidade e abuso de poder em prejuízo de direitos e interesses individuais. Alguns desses remédios revelam-se meios de provocar a atividade jurisdiccional, e, então, têm natureza de ação: são *ações constitucionais*.

São *garantias constitucionais* na medida em que são instrumentos destinados a assegurar o gozo de direitos violados ou em vias de ser violados ou simplesmente não atendidos. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, embora não ache errôneo o emprego da expressão "garantias de direito constitucional" em referência aos ditos remédios, denominação que também não lhe agrada, observa "que, rigorosamente falando, as garantias dos direitos fundamentais são as limitações, as vedações, impostas pelo constituinte ao poder público".⁴⁵ Permitimo-nos, contudo, lembrar que esses remédios não deixam também de exercer um papel limitativo da atuação do Poder Público, quer porque, em existindo, este se comporta de maneira a evitar sofrer-lhes a impugnação, quer porque o exercício desses direitos-remédios pelos titulares dos direitos ou interesses violados ou ameaçados ou não satisfeitos nos termos da Constituição importa em impor correção a seus atos e atividades, o que é um modo de limitar. E mais, tais remédios atuam precisamente quando as limitações e vedações não foram bastantes para impedir a prática de atos ilegais e com excesso de poder ou abuso de autoridade. São, pois, espécies de garantias, que, pelo seu caráter específico e por sua função saneadora, recebem o nome de *remédios*, e *remédios constitucionais*, porque consignados na Constituição.

28. Direito de petição

Sua origem é remota. Nasceu na Inglaterra durante a Idade Média. É o *right of petition* que resultou das Revoluções inglesas de 1628, especialmente, mas que já se havia insinuado na própria Magna Carta de 1215. Consolidou-se com a Revolução de 1689 com a declaração dos direitos (*Bill of Rights*). Consistia, inicialmente, em simples direito de o Grande Conselho do Reino, depois o Parlamen-

to, pedir ao Rei sanção das leis. Não foi, porém, previsto na Declaração francesa de 1789. Veio a constar, enfim, das Constituições francesas de 1791 (§ 3º do título I: *La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement*) e de 1793 (Declaração de Direitos, art. 32: *Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité*).

O direito de petição define-se "como o direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos poderes públicos sobre uma questão ou uma situação",⁴⁶ seja para denunciar uma lesão concreta, e pedir a reorientação da situação, seja para solicitar uma modificação do direito em vigor no sentido mais favorável à liberdade.⁴⁷ Ele está consignado no art. 5º, XXXIV, *a*, que assegura a todos o *direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder*. Há, nele, uma dimensão coletiva consistente na busca ou defesa de direitos ou interesses gerais da coletividade.

Esse direito vinha ligado ao direito de representação. Este não foi repetido. É que o constituinte deve ter raciocinado, e com razão, que a representação pode ser veiculada pela petição, de sorte que a legislação que regulamenta aquela permanece em vigor.

O que se tem observado é que o direito de petição é mais uma sobrevivência do que uma realidade.⁴⁸ Nota-se também que ele se reveste de dois aspectos: pode ser uma queixa, uma reclamação, e então aparece como um recurso não contencioso (não jurisdiccional) formulado perante as autoridades representativas; por outro lado, pode ser a manifestação da liberdade de opinião e revestir-se do caráter de uma informação ou de uma aspiração dirigida a certas autoridades.⁴⁹ Esses dois aspectos, que antes eram separados em direito de petição e direito de representação, agora se juntaram no só direito de petição.

O *direito de petição* cabe a *qualquer pessoa*. Pode ser, pois, utilizado por pessoa física ou por pessoa jurídica; por indivíduo ou por grupos de indivíduos; por nacionais ou por estrangeiros. Mas não pode ser formulado pelas forças militares, como tais, o que não impede reconhecer aos membros das Forças Armadas ou das polícias militares o direito individual de petição, desde que sejam observadas as regras de hierarquia e disciplina. Pode ser dirigido a qualquer autoridade do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário.

É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar

46. Cf. Claude-Albert Colliard, *Libertés publiques*, p. 131.

47. Cf. Jean Rivero, *Les libertés publiques: 1 — Les droits de l'homme*, p. 245.

48. Cf. Rivero, *ob. cit.*, p. 244.

49. Cf. Colliard, *ob. cit.*, p. 131.

pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação. Algumas constituições contemplam explicitamente o dever de responder (Colômbia, Venezuela, Equador). Bem o disse Bascuñan: "O direito de petição não pode separar-se da obrigação da autoridade de dar resposta e pronunciar-se sobre o que lhe foi apresentado, já que, separado de tal obrigação, carece de verdadeira utilidade e eficácia. A obrigação de responder é ainda mais precisa e grave se alguma autoridade a formula, em razão de que, por sua investidura mesmo, merece tal resposta, e a falta dela constitui um exemplo deplorável para a responsabilidade dos Poderes Públicos".⁵⁰ A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando se omite; para tanto, é preciso que fique bem claro que o peticionário esteja utilizando efetivamente o direito de petição, o que se caracteriza com maior certeza se for invocado o art. 5º, XXXIV, *a*. Cabe, contudo, o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, quando a petição visar corrigir abuso, conforme disposto na Lei 4.898/65.

29. Direito a certidões

Está assegurado a todos, no art. 5º, XXXIV, "independentemente do pagamento de taxas: [...] b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal". Não se exige, como nas Constituições anteriores, que lei regulará a expedição de certidões para os fins indicados, até porque sempre se teve a lei como desnecessária. A jurisprudência entendeu, desde os primeiros momentos da aplicação da Constituição de 1946, que tinha todos os requisitos de eficácia plena e aplicabilidade imediata o texto que previa o direito a certidões como meio de obter informações e elementos para instruir a defesa de direitos (aí seu caráter de garantia constitucional) e para esclarecimento de situações. Esta é uma garantia que não raro acaba por se realizar mediante outro remédio: o mandado de segurança, quando o pedido é negado ou simplesmente não é decidido.

30. "Habeas corpus"

Foi o primeiro remédio a integrar as conquistas liberais. Denota-se sua presença na Inglaterra antes mesmo da Magna Carta de 1215.

50. Cf. *Tratado de Derecho constitucional*, v. I/255 e 256.

Mas foi esta que lhe deu a primeira formulação escrita. O *writ of "habeas corpus"* evolui. No início não era vinculado à idéia de liberdade de locomoção, mas ao conceito do *due process of law*.⁵¹ Era usado até mesmo em matéria civil; mais tarde, ainda na Inglaterra, adquiriu várias modalidades: "habeas corpus ad prosequendum", "habeas corpus ad satisfaciendum", "habeas corpus ad deliberandum", "habeas corpus ad faciendum et recipiendum", "habeas corpus ad subjiciendum".⁵² Era então meio de levar alguém perante o tribunal. O "Habeas Corpus Amendment Act" de 1679 é que o configurou, com mais precisão, como um remédio destinado a assegurar a liberdade dos súditos e prevenir os encarceramentos em ultramar.

No Brasil, não ingressou na Constituição do Império, formalmente, mas Pontes de Miranda é de opinião que estava implicitamente previsto.⁵³ Formalmente, foi instituído no Código de Processo Criminal de 1832 (art. 340). Constitucionalizou-se por meio do § 22 do art. 72 da Constituição de 1891, em termos amplos, que deu margem à doutrina brasileira do *habeas corpus*, que o concebia como remédio tutelar dos direitos subjetivos de qualquer natureza, conforme a seguinte lição de Ruy Barbosa:

"Logo o *habeas corpus* hoje não está circunscrito aos casos de constrangimento corporal: o *habeas corpus* hoje se estende a todos os casos em que um direito nosso, qualquer direito, estiver ameaçado, manietado, impossibilitado no seu exercício pela intervenção de um abuso de poder ou de uma ilegalidade".⁵⁴

Disso decorria que as violações de direitos civis estavam também sujeitas à correção pelo *habeas corpus*. A Emenda Constitucional de 1926, contudo, limitou o seu cabimento à proteção da liberdade de locomoção, com um enunciado essencialmente idêntico ao que consta, hoje, do art. 5º, LXVIII: *conceder-se-á "habeas corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder*. Não cabe, porém, em relação a punições disciplinares militares (art. 142, § 2º).

É, pois, um remédio destinado a tutelar o direito de liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir, parar e ficar. Tem natureza de *ação constitucional penal*.

51. Cf. R. J. Sharpe, *The Law of "Habeas-Corpus"*, Oxford, p. 2; Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, cit., t. V/282 e ss.

52. Cf. Domingo García Belaund, *El habeas-corpus en el Peru*, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1979.

53. *Ob. cit.*, pp. 304 e 305.

54. Cf. *República: teoria e prática*, p. 173; cf. também Castro Nunes, *Do Mandado de Segurança*, p. 1.

31. Mandado de segurança individual

A Constituição contempla duas formas de *mandado de segurança*: (a) o *mandado de segurança individual* (art. 5º, LXIX), tal como previram as Constituições anteriores, desde a de 1934, com a finalidade de proteger *direito subjetivo individual* líquido e certo; e (b) o *mandado de segurança coletivo* (art. 5º, LXX). O primeiro, *garantia individual*, será estudado aqui. Do segundo, *garantia coletiva*, cuidaremos no próximo capítulo.

Dispõe a Constituição no art. 5º, LXIX: *conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público*.⁵⁵

Visa, como se nota, amparar direito pessoal líquido e certo. Só o próprio titular desse direito tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança individual, que é oponível contra qualquer autoridade pública ou contra agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, com o objetivo de corrigir ato ou omissão ilegal ou decorrente de abuso de poder. A doutrina e a jurisprudência já tinham estabelecido que, no conceito de *autoridade*, já entravam as autoridades públicas propriamente ditas, os dirigentes e administradores de autarquias e de entidades paraestatais, como as pessoas naturais ou agentes de pessoas jurídicas com funções delegadas do Poder Público.⁵⁶ O art. 5º, LXIX, amplia o espectro passivo do mandado de segurança, compreendido em dois grupos: (a) autoridades públicas; (b) agentes de pessoas jurídicas no exercício de atribuições do Poder Público. No primeiro grupo, entram todos os *agentes públicos*, expressão que abrange todas as pessoas físicas que exercem alguma função estatal, como os *agentes políticos*, os *agentes administrativos* e os *agentes delegados*, entrando neste último grupo os exercentes de funções delegadas⁵⁷ (concessionários e permissionários de obras

ou serviços, os serventuários, os notários e oficiais de registros públicos — para estes, art. 236 — e exercentes de atividades sujeitas à autorização do Poder Público). Logo, no segundo grupo entram todos os agentes de pessoas jurídicas privadas que executem, a qualquer título, atividades, serviços e obras públicas.

Já se vinha admitindo mandado de segurança até mesmo contra decisão jurisdicional especialmente para obter sua suspensão quando pendente de recurso com efeito não suspensivo, ou até independentemente da interposição deste.⁵⁸ Cabe também contra ato disciplinar, ainda que em contrário estipule o art. 5º, inc. III, da Lei 1.533/51. Esse dispositivo restritivo não pode prevalecer, como bem mostrou o Min. Carlos Mário da Silva Velloso em lição acolhida por Hely Lopes Meirelles em reexame de posição anterior.⁵⁹ Não tem cabimento contra lei em tese, salvo se se tratar de lei de efeito concreto.

“*Direito líquido e certo* [no conceito de Hely Lopes Meirelles, aceito pela doutrina e pela jurisprudência] é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.⁶⁰ Mas o próprio autor acha o conceito insatisfatório, observando que o “direito, quando existente, é sempre líquido e certo; os fatos é que podem ser imprecisos e incertos, exigindo comprovação e esclarecimentos para propiciar a aplicação do direito invocado pelo postulante”.⁶¹

O *mandado de segurança* é, assim, um remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

58. *Jurisprudência*: “Quando a ilegalidade é flagrante e capaz de subverter a ordem política, quer no plano do direito material como no formal, acolhe-se o mandado de segurança contra ato judicial independentemente da utilização de recurso cabível sem efeito suspensivo” (TFR — 1ª secção, MS n. 97.662 — Maranhão — Rel. Min. Evandro Gueiros Leite, em 13.4.83; votação unânime: DJU 5.5.83, p. 5.907).

59. Cf. Carlos Mário da Silva Velloso, “Do mandado de segurança”, RDP n. 55/56, p. 333; Hely Lopes Meirelles, *Mandado de Segurança e Ação Popular*, p. 21.

60. Cf. *Mandado de Segurança e Ação Popular*, p. 11.

61. *Idem*, p. 11, nota 1.

55. Para a história, o processo e outras questões relativas a mandado de segurança individual, cf. Castro Nunes, *Do Mandado de Segurança*, 8ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1980 (edição atualizada por José de Aguiar Dias); Celso Agrícola Barbi, *Do Mandado de Segurança*, 3ª ed., 3ª tiragem, Rio de Janeiro, Forense, 1980; Milton Flaks, *Mandado de Segurança: Pressupostos da Impetração*, Rio de Janeiro, Forense, 1980; Hely Lopes Meirelles, *Mandado de Segurança e Ação Popular*, 10ª ed., São Paulo, Ed. RT, 1985; Kazuo Watanabe, *Controle Jurisdicional e Mandado de Segurança contra Atos Judiciais*, São Paulo, Ed. RT, 1980.

56. Cf. Hely Lopes Meirelles, *Mandado de Segurança e Ação Popular*, pp. 8 e 9.

57. Cf. Hely Lopes Meirelles, *Direito Administrativo Brasileiro*, pp. 71 e ss., sobre conceito e classes de agentes públicos; também Celso Antônio Bandeira de Mello, *Apontamentos sobre os Agentes e Órgãos Públicos*, pp. 6 e ss.

32. Mandado de injunção

Mandado de injunção é uma nova garantia instituída no art. 5º, LXXI, da Constituição de 1988, com o seguinte enunciado: *conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania*.⁶²

Constitui um remédio ou ação constitucional posto à disposição de quem se considere titular de qualquer daqueles direitos, liberdades ou prerrogativas inviáveis por falta de norma regulamentadora exigida ou suposta pela Constituição. Sua principal finalidade consiste assim em conferir imediata aplicabilidade à norma constitucional portadora daqueles direitos e prerrogativas, inerte em virtude de ausência de regulamentação. Revela-se, neste quadrante, como um instrumento da realização prática da disposição do art. 5º, § 1º.

Daí seu objeto: assegurar o exercício (a) de *qualquer direito constitucional* (individual, coletivo, político ou social) não regulamentado; (b) de *liberdade constitucional*, não regulamentada, sendo de notar que

62. O *mandado de injunção* é um instituto que se originou na Inglaterra, no séc. XIV, como essencial remédio da *Equity*. Nasceu, pois, do *juízo de Equidade*. Ou seja, é um remédio outorgado, mediante um juízo discricionário, quando *falta norma legal* (*statutes*) regulando a espécie, e quando a *Common Law* não oferece proteção suficiente. A *equidade*, no sentido inglês do termo (sistema de estimativa social para a formulação da regra jurídica para o caso concreto), assenta-se na valoração judicial dos elementos do caso e dos princípios de justiça material, segundo a pauta de valores sociais, e assim emite a decisão fundada não no justo legal mas no *justo natural*. Na *injunction* inglesa como no mandado de injunção do art. 5º, LXXI, o juízo de equidade não é inteiramente desligado de pautas jurídicas. Não tem o juiz inglês da *Equity* o arbítrio de criar norma de agir *ex nihil*, pois se orienta por pauta de valores jurídicos existentes na sociedade (princípios gerais de direito, costumes, *conventions* etc.). E o juiz brasileiro também não terá o arbítrio de criar regras próprias, pois terá em primeiro lugar que se ater à pauta que lhe dá o ordenamento constitucional, os princípios gerais de direito, os valores jurídicos que permeiam o sentir social, enfim, os vetores do justo natural que se aúfer no viver social, na índole do povo, no evoluir histórico. Aí é que seu critério estimativo fundamenta sua decisão na falta de regulamentação do direito, liberdade ou prerrogativas objeto da proteção do mandado de injunção. Mas a fonte mais próxima deste é o *writ of injunction* do Direito norte-americano, onde cada vez mais tem aplicação na proteção dos direitos da pessoa humana, para impedir, p. ex., violações de liberdade de associação e de palavra, da liberdade religiosa e contra denegação de igual oportunidade de educação por razões puramente raciais, tendo-se estabelecido mediante julgamento favorável de uma *injunction* (caso *Brown v. Board of Education of Topeka*, 1954) o direito de estudantes negros à educação em escolas não segregadas; a Emenda 14 da Constituição norte-americana confere várias franquias inerentes à nacionalidade, à soberania popular e à cidadania, pois a proteção desses direitos e franquias tem sido crescentemente objeto de *injunction*, tal como agora se reconhece no Direito Constitucional pátrio. Cf. "Injunction", in *Encyclopaedia Britannica*, London, Willian Benton Publisher, 1968, v. 12, pp. 255 e 256.

as liberdades são previstas em normas constitucionais comumente de aplicabilidade imediata, independentemente de regulamentação; vale dizer, incidem diretamente; de modo que raramente ocorrerá oportunidade de mandado de injunção nessa matéria, mas há situações como a do art. 5º, VI, em que a liberdade de cultos religiosos ficou dependente, em certo aspecto, de lei regulamentadora, quando diz: "garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias"; (c) *das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania*, também quando não regulamentadas; *soberania* é a *soberania popular*, segundo dispõe o art. 14, não a soberania estatal; aqui igualmente não ocorrerão muitas hipóteses de ocorrência do mandado de injunção; é que as questões de nacionalidade praticamente se esgotam nas prescrições constitucionais que já a definem de modo eficaz no art. 12; apenas a naturalização depende de lei, mas esta, como vimos, já existe, portanto é matéria regulamentada, que, por isso mesmo, não dá azo ao mandado de injunção; as prerrogativas da soberania popular e da cidadania se desdobram mediante lei, mas estas já existem, embora devam sofrer profunda revisão, quais sejam o Código Eleitoral e a Lei Orgânica dos Partidos Políticos; a lei prevista no art. 5º, LXXVII, destinada à definição dos atos necessários ao exercício da cidadania, também já foi promulgada: Lei 9.265, de 12.2.1996.

Os pressupostos do remédio são: (a) a *falta de norma regulamentadora* do direito, liberdade ou prerrogativa reclamada; (b) *ser o impetrante beneficiário* direto do direito, liberdade ou prerrogativa que postula em juízo. O interesse de agir, mediante mandado de injunção, decorre da titularidade do bem reclamado, para que a sentença que o confira tenha direta utilidade para o demandante. Não pode, p. ex., reclamar acesso ao ensino fundamental quem já o fez antes. Não pode pleitear a garantia de relação de emprego quem está desempregado. Não pode pretender uma decisão judicial sobre aviso prévio proporcional quem não está empregado.

Resta saber o que se deve entender por *norma regulamentadora*. Muitos direitos constam de normas constitucionais que prevêem uma lei ordinária ou uma lei complementar para terem efetiva aplicação.⁶³ Nessas hipóteses, é fácil verificar a norma pendente de regulamentação. Há casos, contudo, em que a norma constitucional apenas supõe, por sua natureza, por sua indeterminação, a necessidade de uma

63. Vejam-se, p. ex., o art. 5º, VI ("na forma da lei"), XVIII ("na forma da lei"), XXVIII ("nos termos da lei"), XXIX ("a lei assegurará [...]"), XXXII ("na forma da lei"), LXXVII ("na forma da lei"); art. 7º, I ("nos termos de lei complementar"), IV (salário mínimo, "fixado em lei"), VII ("nos termos da lei"), X (proteção do salário "na forma da lei"), XXI (aviso prévio proporcional [...], "nos termos da lei"), XXIII (adicional de insalubridade etc., "na forma da lei").

providência do Poder Público para que possa ser aplicada.⁶⁴ Norma regulamentadora é, assim, toda “medida para tornar efetiva norma constitucional”, bem o diz o art. 103, § 2º. Nesses casos, a aplicabilidade da norma fica dependente da elaboração da lei ou de outra providência regulamentadora. Se ela não vier, o direito previsto não se concretizará. É aí que entra a função do mandado de injunção: fazer com que a norma constitucional seja aplicada em favor do impetrante, independentemente de regulamentação, e exatamente porque não foi regulamentada. Se tivesse sido regulamentada, o mandado de injunção não teria cabimento. O direito, a liberdade ou as prerrogativas estabelecidas em normas constitucionais regulamentadas, quando não satisfeitos, só podem ser reclamados por outro meio judicial (mandado de segurança, ação cautelar inominada, ação ordinária).

O mandado de injunção tem, portanto, por finalidade realizar concretamente em favor do impetrante o direito, liberdade ou prerrogativa, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o seu exercício. Não visa obter a regulamentação prevista na norma constitucional. Não é função do mandado de injunção pedir a expedição da norma regulamentadora, pois ele não é sucedâneo da ação de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º). É equivocada, portanto, *data venia*, a tese daqueles que acham que o julgamento do mandado de injunção visa a expedição da norma regulamentadora do dispositivo constitucional dependente de regulamentação, dando a esse remédio o mesmo objeto da ação de inconstitucionalidade por omissão. Isso quer apenas dizer que o mandado de injunção não passaria de ação de inconstitucionalidade por omissão *subsidiária*, a dizer: como os titulares dessa ação (art. 103) se omitiram no seu exercício, então fica deferido a qualquer interessado o direito de utilizar o procedimento injuncional para obter aquilo que primeiramente ocorria àqueles titulares buscar. A tese é errônea e absurda, porque: (1) não tem sentido a existência de dois institutos com o mesmo objetivo e, no caso, de efeito duvidoso, porque o legislador não fica obrigado a legislar; (2) o constituinte, em várias oportunidades na elaboração constitucional, negou ao cidadão legiti-

64. O art. 5º, L, p. ex., diz: “às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação”; por certo que essas condições precisam ser regulamentadas, nem que seja por portaria, ou por despacho, ou ordem de serviço, do próprio diretor do estabelecimento penal; são normas regulamentadoras simples, mas normas regulamentadoras; o art. 196 confere o direito à saúde, que é “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos [...]”; o estabelecimento de *políticas públicas* é, no caso, o modo de regulamentar esse direito; é já uma forma de regulamentação mais complexa, mas aí encontramos normas reguladoras necessárias para viabilizar o direito previsto.

dade para a ação de inconstitucionalidade; por que teria ele que fazê-lo por vias transversas?; (3) absurda mormente porque o impetrante de mandado de injunção, para satisfazer seu direito (que o moveu a recorrer ao Judiciário), precisaria percorrer duas vias: uma, a do mandado de injunção, para obter a regulamentação que poderia não vir, especialmente se ela dependesse de lei, pois o legislativo não pode ser constrangido a legislar; admitindo que obtenha a regulamentação, que será genérica, impessoal, abstrata, vale dizer, por si, não satisfatória de direito concreto; a segunda via é que, obtida a regulamentação, teria ainda que reivindicar sua aplicação em seu favor, que, em sendo negada, o levaria outra vez ao Judiciário para concretizar seu interesse, agora por outra ação porque o mandado de injunção não caberia.

Enfim, o conteúdo da decisão consiste na outorga direta do direito reclamado.⁶⁵ O impetrante age na busca direta do direito constitucio-

65. Foi esta sempre a preocupação do constituinte: aparelhar meios para a eficácia imediata das normas constitucionais. A elaboração constituinte do mandado de injunção seguiu sempre esse rumo. O Constituinte Gastone Righi, no dia 22.4.87 na 3ª reunião da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Garantias, clama pela criação de um *mandamus*, uma forma de processo pela qual alguém possa exercer um direito social, digamos o direito social à saúde ou o direito da criança à escola. A precedência é, porém, atribuída ao Senador Virgílio Távora, consoante informa a Dra. Herzeleide Maria Fernandes de Oliveira, que, como assessora, participou de sua formação. Cf. nesse sentido, Herzeleide Maria Fernandes de Oliveira, “O mandado de injunção”, *RIL*, n. 100, pp. 47 e ss.; também Sen. Alfredo Campos, “O mandado de injunção”, *Jornal Hoje em Dia*, Belo Horizonte, 17.10.88. Esclarece que o Senador alertado para o não cumprimento do “dever-poder” do Estado para com a educação, apresentou *Sugestões de Normas Constitucionais* versando sobre o mandado de injunção e sobre a inconstitucionalidade por omissão: a de n. 155-4: “Sempre que se caracterizar a inconstitucionalidade por omissão, conceder-se-á ‘mandado de injunção’, observando o rito processual estabelecido para o mandado de segurança”; a de n. 156-2: “A não edição de atos ou normas pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, visando a implementar esta Constituição, implica a inconstitucionalidade por omissão”; e a de n. 315: “Art. — [...] Parágrafo único. O acesso ao ensino básico é um direito público subjetivo, acionável contra o poder público mediante mandado de injunção”. O Constituinte Lysâneas Maciel propôs dois mecanismos: um na forma reclamada pelo Constituinte Gastone Righi, no art. 3º do seu Anteprojeto, segundo o qual o povo exerceria a soberania: VII — pelo mandado de garantia social por inexistência ou omissão de normas, atos jurisdicionais ou administrativos; o outro no art. 40: *Na falta de regulamentação para tornar eficaz a norma constitucional*, o Ministério Público ou qualquer interessado poderá requerer ao Judiciário a aplicação do direito assegurado. Aqui está delineado o mandado de injunção, por quem não conhecia o Direito anglo-americano. A mesma preocupação acutilava a Subcomissão dos Direitos Individuais e Garantias do Homem e da Mulher, no dia 26.5.87, pelo Relator da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, Deputado Constituinte Darcy Pozza, quando disse que, “no rol dos Direitos e Garantias Individuais, ao lado do Mandado de Segurança, como instrumento de defesa dos interesses do cidadão, incluímos o Mandado de Injunção, visando permitir que a letra

nal em seu favor, independentemente da regulamentação. Por isso é que dissemos que ele precisa ter interesse direto no resultado do julgamento. Compete ao Juiz definir as condições para a satisfação direta do direito reclamado e determiná-la imperativamente.⁶⁶ Não foi esta lamentavelmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que vem dando ao instituto a função de uma ação pessoal de declaração de inconstitucionalidade por omissão, com o que praticamente o torna sem sentido ou, pelo menos, muitíssimo esvaziado.

constitucional, à falta de Lei Complementar ou Ordinária que a regule, se torne realmente auto-aplicável. Darcy Pozza o colheu na Sugestão n. 367-1 do Constituinte Ruy Bacelar, que pedia se incluísse onde coubesse o seguinte: "Art. Os direitos conferidos por esta Constituição e que dependam da lei ou de providências do Estado serão assegurados por *mandado de injunção*, no caso de omissão do Poder Público. Parágrafo único. O *mandado de injunção* terá o mesmo rito processual estabelecido para o *mandado de segurança*". Na justificativa, não menciona se foi buscá-lo no Direito anglo-americano. Não importa. O Anteprojeto apresentado pelo Constituinte Darcy Pozza na Subcomissão contemplou o remédio com aquele sentido de tornar eficaz, *in concreto*, direitos garantidos na Constituição. Constatou do § 37 do artigo único, nos termos seguintes: *Conceder-se-á mandado de injunção, observado o rito processual estabelecido para o mandado de segurança, a fim de garantir direitos assegurados nesta Constituição, não aplicados em razão da ausência de norma regulamentadora, podendo ser requerido em qualquer Juízo ou Tribunal, observadas as regras de competência da Lei Processual*. Daí a proposta passou para o Substitutivo do Relator da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, Constituinte José Paulo Bisol, em termos essencialmente idênticos. O Projeto da Comissão de Sistematização o aprovou com duas modificações sérias, dizendo que seria concedido *na forma da lei*, aí sim tornando sua aplicação dependente de lei; a outra suprimindo a palavra "direitos", ficando a proteção apenas para as liberdades e prerrogativas, esvaziando a medida. Na votação do Primeiro Turno o texto foi recomposto, para ficar com a redação do art. 5º, LXXI. Todo o pensamento constituinte foi no sentido de estruturar um instrumento para assegurar imediatamente os direitos, liberdades e prerrogativas, na falta de regulamentação.

66. Cf. Wander Paulo Marotta Moreira, "Mandado de Injunção", *Estado de Minas*, 13.9.88, p. 2: "Compete ao Juiz de primeira instância criar a norma de proteção quando ela não existir, criando, por via de consequência, a regra do procedimento aplicável a cada caso concreto". Esse tem sido o ponto mais controvertido do mandado de injunção. Várias obras já foram publicadas com soluções as mais diversificadas. Cf. nosso *Mandado de Injunção e "Habeas Data"*, Ed. RT, 1989; Irineu Strenger, *Do Mandado de Injunção*, FU, 1988; Diomar Ackel Filho, "Writs" *Constitucionais*, Saraiva, 1988; Ulderico Pires dos Santos, *Mandado de Injunção*, Paumape, 1988; J. J. Calmon de Passos, *Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Injunção, "Habeas Data"*, Forense, 1989; Hely Lopes Meirelles, *Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e "Habeas Data"*, 21ª ed., Malheiros Editores, 1999; José Cretella Júnior, "Writs" *na Constituição de 1988*, FU, 1989; Vicente Greco Filho, *Tutela constitucional das liberdades*, Saraiva, 1989; Ivo Dantas, *Mandado de Injunção*, Aide Ed., 1989; Aricê Moacyr Amaral Santos, *O Mandado de Injunção*, Ed. RT, 1989; Raulo Gomes, *Mandado de Injunção*, Trabalhistas, 1989; Marcelo Figueiredo, *O Mandado de Injunção e a inconstitucionalidade por omissão*, Ed. RT, 1991; Regina Quaresma, *O mandado de injunção e a ação de inconstitucionalidade por omissão, teoria e prática*, 3ª ed., Forense, 1999.

Não importa a natureza do direito que a norma constitucional confere; desde que seu exercício dependa de norma regulamentadora e desde que esta falte, o interessado é legitimado a propor o mandado de injunção, quer a obrigação de prestar o direito seja do Poder Público, quer incumba a particulares. Vale dizer, cabe mandado de injunção nas relações de natureza pública como nas relações privadas, como, p. ex., nas relações de emprego privado, hipóteses de direitos previstos no art. 7º.

Finalmente, cumpre esclarecer que o disposto no art. 5º, LXXI, não depende de regulamentação para ser aplicado. O texto possui todos os elementos suficientes à sua imediata aplicação, reforçada essa aplicabilidade direta com o disposto no § 1º do mesmo artigo, o que "significa que os juízes não poderão deixar de atender a toda e qualquer demanda que lhes for dirigida", e não poderão deixar de decidir também, dado o monopólio jurisdicional (*non liquet*).⁶⁷

A competência para processar e julgar o mandado de injunção ficou mal estruturada no texto constitucional. Consta dos arts. 102, I, q, e II, a, e 105, I, h.

33. "Habeas data"

O *habeas data* (art. 5º, LXXII) é um remédio constitucional que tem por objeto proteger a esfera íntima dos indivíduos contra: (a) usos abusivos de registros de dados pessoais coletados por meios fraudulentos, desleais ou ilícitos; (b) introdução nesses registros de dados sensíveis (assim chamados os de origem racial, opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária e sindical, orientação sexual etc.); (c) conservação de dados falsos ou com fins diversos dos autorizados em lei.⁶⁸

Firmín Morales Prats emprega a expressão *habeas data* ao lado de *habeas scriptum* e *habeas mentem*. Este último como expressão jurídica da intimidade. Os dois primeiros, mais ou menos como sinônimos no sentido de direito ao controle da circulação de dados pessoais.⁶⁹ As Constituições da Espanha (art. 18) e de Portugal (art. 35) dispõem, respectivamente, sobre o controle do uso da informática e sobre o direito de conhecer o que constar de registros informáticos a seu respeito, mas

67. Cf. Régis Fernandes de Oliveira, "Idéias sobre o mandado de injunção", *O Estado de S. Paulo*, 20.11.88. Cf. também Wander Paulo Marotta Moreira, "Mandado de injunção", *Estado de Minas*, 13.9.88, p. 2. Ambos os autores eram magistrados.

68. Cf. Firmín Morales Prats, *La tutela penal de la intimidad: "privacy" e informática*, p. 329.

69. Ob. cit., p. 43. Sobre o tema, José Alfredo Baracho de Oliveira, "*Habeas data* ou *habeas scriptum*", *Jornal do Advogado*, Belo Horizonte, agosto/1988, p. 4.

nenhuma delas e nenhuma outra criou um meio específico de invocar a jurisdição para fazer valer esses direitos reconhecidos.⁷⁰ A Constituição de 1988 não traz um dispositivo autônomo que contemple o direito de conhecer e de retificar dados pessoais. Usou o mesmo processo que nas Constituições anteriores se reconhecia à liberdade de locomoção: através da previsão de sua garantia. O direito de conhecimento de dados pessoais e de retificá-los é outorgado no mesmo dispositivo que institui o remédio de sua tutela, *in verbis*:

“Art. 5º, LXXII — conceder-se-á *habeas data*:

“a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

“b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.”

Vê-se que o direito de conhecer e retificar os dados, assim como o de interpor o *habeas data* para fazer valer esse direito quando não espontaneamente prestado, é *personalíssimo* do titular dos dados, do impetrante que, no entanto, pode ser brasileiro ou estrangeiro. Mas uma decisão do ainda Tribunal Federal de Recursos (agora, STJ), em Plenário, admitiu que os herdeiros legítimos do morto ou se cônjuge supérstite poderão impetrar o *writ*.⁷¹ É uma decisão liberal que supera o entendimento meramente literal do texto, com justiça, pois não seria razoável que se continuasse a fazer uso ilegítimo e indevido dos dados do morto, afrontando sua memória, sem que houvesse meio de corrigenda adequado.

70. A partir dessas constatações, propusemos perante a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais (Comissão Afonso Arinos) um Anteprojeto de Constituição cujo art. 17 reconhecia o direito nos termos seguintes: “1. Toda pessoa tem direito de acesso aos informes a seu respeito registrados por entidades públicas ou particulares, podendo exigir a retificação de dados, e a sua atualização. 2. É vedado o acesso de terceiros a esse registro. 3. Os informes não poderão ser utilizados para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa ou vida privada, salvo quando se tratar do processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis. 4. Lei federal definirá quem pode manter registros informáticos, os respectivos fins e conteúdo”. No art. 31 instituíamos o remédio constitucional específico: “Conceder-se-á *habeas data* para proteger o direito à intimidade contra abusos de registros informáticos públicos e privados”, curto e seco como se vê. O Anteprojeto da Comissão acolheu a declaração do direito em seu art. 17 com aperfeiçoamentos e o remédio no art. 48: “Dar-se-á *habeas data* ao legítimo interessado para assegurar os direitos tutelados no art. 17”. Daí saiu para o debate constituinte, andando o direito e sua garantia específica em dispositivos separados até que no Projeto da Comissão de Sistematização fosse aprovado num único dispositivo, ou seja: reconhecia-se o direito mediante sua garantia específica (art. 6º, § 52). Daí sofreu modificações para pior até o texto do atual art. 5º, LXXII, objeto de nossas considerações no texto.

71. HD n. 001-DF, DJU, 2.5.89, Seção I, p. 6.774.

O objeto do *habeas data* consiste em assegurar: (a) o direito de acesso e conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais e de entidades de caráter público; (b) o direito à retificação desses dados, importando isso em atualização, correção e até a supressão, quando incorretos. Em relação ao direito de retificação, o dispositivo constitucional faculta ao impetrante o processo sigiloso, judicial ou administrativo, dando a entender que, se o processo for sigiloso, não será de *habeas data*, mas outra ação, o que não tem sentido algum. Nem serão necessários dois *habeas datas* para que uma mesma pessoa tome conhecimento dos dados e proponha sua retificação. Sustentar o contrário é pretender enquadrar instituto novo em velhos esquemas de um procedimentalismo superado. O processo do *habeas data* pode desenvolver-se em duas fases. Na primeira, o Juiz, de plano, manda notificar o impetrado para apresentar os dados do impetrante, constantes de seu registro, no prazo que estipule; juntados os dados, o impetrante terá ciência deles, devendo manifestar-se em prazo determinado. Se nada tiver a retificar, di-lo-á e se arquivará o processo. Se tiver retificação a fazer, dirá quais são, fundamentadamente, mediante aditamento à inicial, e então o Juiz determinará a citação do impetrado para a contestação, se quiser, prosseguindo-se nos termos do contraditório.⁷²

“Entidades governamentais” é uma expressão que abrange órgãos da administração direta ou indireta. Logo, a expressão “entidades de caráter público” não pode referir-se a organismos públicos, mas a instituições, entidades e pessoas jurídicas privadas que prestem serviços para o público ou de interesse público, envolvendo-se aí não só concessionários, permissionários ou exercentes de atividades autorizadas, mas também agentes de controle e proteção de situações sociais ou coletivas, como as instituições de cadastramento de dados pessoais para controle ou proteção do crédito ou divulgadoras profissionais de dados pessoais, como as firmas de assessoria e fornecimento de malas-diretas.

72. A questão é mais de Juiz culto, desemperrado, vocacionado, a fazer justiça democrática, do que de regras procedimentais. Assim, parece ter sido o Juiz da 10ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, que, conforme notícia na imprensa, num *habeas data*, acolheu a petição do advogado Idibal Piveta requerendo acesso às fichas originais com dados a seu respeito arquivadas na Polícia Federal e determinou ao seu superintendente, Marco Antonio Veronezzi, que enviasse no prazo de dez dias “as informações constantes de seus registros”. Bem se vê que, se esse Juiz ficasse preocupado em descobrir primeiro qual a natureza da ação e outras abstrações da teoria processual, para decidir primeiro o que fazer, para depois dar andamento à causa, por certo não teria dado esse despacho que demonstra descortino.

Essa doutrina, que já constava das edições anteriores, foi amplamente acolhida pela Lei 9.507, de 12.11.1997, que regulou o direito de acesso a informações e disciplinou o rito processual do *habeas data*, quando, no parágrafo único do art. 1º, considera de caráter público “todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações”.

O *habeas data*, instituído como remédio constitucional no Brasil, responde, no plano do Direito positivo, ao reclamo de Frosini e ao conteúdo básico, pensado por Firmín Morales Prats.

Frosini: “A história jurídica da liberdade pessoal no mundo moderno se funda sobre o *Habeas Corpus Act de 1679* [...] oposto à detenção ilegal. Pode-se dizer, com uma paráfrase de caráter metafórico, que na legislação dos Estados modernos se reclame hoje um *habeas data*, um reconhecimento do direito do cidadão de dispor dos próprios dados pessoais do mesmo modo que tem o direito de dispor livremente do próprio corpo”.⁷³

“O *habeas data*, ou conjunto de direitos que garante o controle da identidade informática [escreve Firmín Morales], implica o reconhecimento do direito de conhecer, do direito de correção, de subtração ou anulação, e de agregação sobre os dados depositados num fichário eletrônico. Esse elenco de faculdades, que derivam do princípio de acesso aos bancos de dados, constitui a denominada ‘liberdade informática’ ou direito ao controle dos dados que respeitam ao próprio indivíduo (biológicos, sanitários, acadêmicos, familiares, sexuais, políticos, sindicais...)”.⁷⁴

73. Cf. “La protezione della riservatezza nella società informatica”, in “Privacy” e *Banche dei Datti*, vários autores, Bologna, 1981, p. 44, citado por Firmín Morales Prats, *ob. cit.*, p. 47. Idem, “Bancos de datos y tutela de la persona”, REP, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, n. 30, nov./dez. 1982, pp. 21 e ss. Convém observar, para espantar dúvida sobre a novidade da formulação do *habeas data* na Constituição brasileira, que existem, no exterior, leis muito importantes sobre a proteção contra uso abusivo de dados pessoais, com definição de sanções rigorosas. A lei francesa, p. ex., possui normas muito claras sobre o direito de acesso aos fichários e de retificação, muito mais avançadas do que o adotado por nossa Constituição. Todas elas contêm sanções penais rigorosas. Mas nenhum desses países estrutura um remédio específico, como garantia constitucional, para amparar esse direito no caso de não ser atendido. Cf., para a República Federal da Alemanha, *Bundesdatenschutzgesetz* — BDSG, de 27.2.77 (Lei de Proteção contra o Emprego Abusivo de Dados de Identificação Pessoal no Âmbito do Tratamento de Dados, RF n. 272, pp. 423 e ss.), e, para a França, Lei 78-17, de 6.1.78, RF n. 272, pp. 431 e ss.

74. *Ob. cit.*, p. 47. Sobre o *habeas data* já se podem ler algumas monografias como as indicadas na nota 66 supra juntamente com o mandado de injunção e também Diva Prestes Malerbi, *Perfil do “habeas data”*, São Paulo, RT, 1989.

O rito processual do *habeas data* foi disciplinado pela Lei 9.507/97. Pressupõe uma fase administrativa prévia, que começa com o *requerimento do interessado* apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e que será deferido ou indeferido no prazo de quarenta e oito horas, comunicada a decisão ao requerente em vinte e quatro horas. Se deferido o requerimento, o depositário do registro ou banco de dados marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento das informações. Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado, em petição acompanhada de documentos comprobatórios, poderá requerer sua retificação, que deverá ser feita, no máximo, em dez dias. Indeferido o pedido de acesso às informações, ou verificado o transcurso do prazo de dez dias sem decisão, ou recusada a retificação pleiteada ou o decurso de mais de quinze dias sem decisão, ou ainda recusadas as anotações de explicação ou contestação apresentadas pelo requerente, então, sim, poderá ele recorrer ao Poder Judiciário, mediante petição na forma dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, pleiteado a concessão do *habeas data*, que lhe assegure o acesso às informações, as retificações solicitadas, bem como as anotações pleiteadas. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de dez dias, preste as informações que julgar necessárias. Feita a notificação, o serventuário em cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao coator, bem como a prova da sua entrega a este ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de dar recibo. Se o juiz julgar procedente o pedido, marcará data e horário para que o coator apresente: (a) ao impetrante as informações a seu respeito, constantes de registro e bancos de dados; (b) em juízo a prova da retificação ou da anotação feita nos assentamentos do impetrante. Da sentença cabe apelação, que só terá efeito devolutivo. O pedido de *habeas data* poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.

Existem disposições sobre a competência dos órgãos judiciários federais para processar e julgar o *habeas data* e figuram nos arts. 102, I, d, II, a; 105, I, b; 108, I, c; 109, VIII, e 121, § 4º, V, competência agora também especificada no art. 20 da Lei 9.507/97.

Capítulo III

GARANTIAS DOS DIREITOS COLETIVOS, SOCIAIS E POLÍTICOS

I. GENERALIDADES: 1. Colocação do tema. II. GARANTIAS DOS DIREITOS COLETIVOS: 2. Esclarecimentos prévios. 3. Mandado de segurança coletivo. 4. Mandado de injunção coletivo. 5. Ação popular. III. GARANTIAS DOS DIREITOS SOCIAIS: 6. Normatividade dos direitos sociais. 7. Tutela jurisdicional dos hipossuficientes. 8. Sindicalização e direito de greve. 9. Decisões judiciais normativas. 10. Garantias de outros direitos sociais. IV. GARANTIAS DOS DIREITOS POLÍTICOS: 11. Definição do tema — Remissão. 12. Eficácia dos direitos fundamentais.

I. GENERALIDADES

1. Colocação do tema

Vamos agora estudar as garantias dos direitos coletivos, dos direitos sociais e dos direitos políticos. Algumas delas já foram discutidas ao longo das páginas anteriores. Não as repetiremos aqui, apenas lembraremos delas, para que o leitor compreenda melhor a distinção entre direitos e suas garantias, ainda que, às vezes, ambos sejam formulados indistintamente no mesmo dispositivo constitucional.

II. GARANTIAS DOS DIREITOS COLETIVOS

2. Esclarecimentos prévios

Já examinamos antes o *mandado de segurança individual* como garantia da eficácia dos direitos subjetivos líquidos e certos. Cumpre-nos, agora, discorrer sobre o *mandado de segurança coletivo*, instituto novo, tendente a ter grande influência na realização de direitos de coletividades inteiras, para o que o *mandado de segurança individual* se revelava instrumento não totalmente satisfatório. Com certeza, o novo instituto acabará por repercutir no próprio conceito do *mandado de segurança*, especialmente num de seus pressupostos mais acalentados, o direito líquido e certo. Até que ponto ele é pressuposto também do *remédio coletivo*, é questão que suscitamos.

Será também examinado o *mandado de injunção* em sua dimensão de garantia de direitos coletivos, e logo a *ação popular* que é por natureza garantia de interesses coletivos.

3. Mandado de segurança coletivo

A Constituição institui o *mandado de segurança coletivo* no art. 5º, LXX, que pode ser impetrado por:

(a) *partido político com representação no Congresso Nacional;*

(b) *organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.*¹

O conceito de *mandado de segurança coletivo* assenta-se em dois elementos: um, *institucional*, caracterizado pela atribuição da legitimação processual a instituições associativas para a defesa de interesses de seus membros ou associados; outro, *objetivo*, consubstanciado no uso do *remédio* para a defesa de interesses coletivos.²

A primeira característica do *mandado de segurança coletivo* encontra-se no reconhecimento de legitimação para agir a uma entidade ou instituição representativa de uma coletividade: (a) *partidos políticos* com representação no Congresso Nacional, reforçando aqui a idéia de partidos de âmbito nacional exigida no art. 17, I; (b) *organização sindical, entidade de classe ou associação* legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano.

Celso Agrícola Barbi acha que a legitimação dessas entidades de classe e associativas se destina “a reclamar *direitos subjetivos individuais* dos membros dos sindicatos e dos associados de entidades de classe e associações”.³ Há ponderações a fazer quanto a isso, pois não se pode, p. ex., deixar de levar em conta o disposto no art. 8º, III, que dá aos sindicatos legitimidade para a defesa dos direitos e inte-

1. O *mandado de segurança coletivo* surgiu de sugestão da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emendas, conforme art. 29 do Anteprojeto que teve como Relator o Constituinte Nilton Friedrich.

2. Celso Agrícola Barbi tem entendimento semelhante em “As novas dimensões do *mandado de segurança*”, tese apresentada no *Seminário sobre os Novos Direitos Fundamentais na Constituição Brasileira*, Hotel Glória, Rio de Janeiro, de 12 a 16 de dezembro de 1988. Sobre o *mandado de segurança coletivo*, além das monografias citadas na nota 67 do capítulo anterior, cf. também Lucia Valle Figueiredo, *Perfil do mandado de segurança coletivo*, São Paulo, RT, 1989, e “Partidos políticos e mandado de segurança coletivo”, RDP 95/37 e ss.; Michel Temer, “Algumas notas sobre o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção e o *habeas data*”, RPGE 30/11 e ss.; Carlos Ari Sundfeld, “*Habeas data* e mandado de segurança coletivo”, RDP 95/190 e ss.

3. Idem, ibidem.

resses coletivos ou individuais da categoria, em juízo. Outra questão é saber se as associações podem impetrar mandado de segurança coletivo sem autorização ou se precisam desta, tal como prevê em geral o disposto no art. 5º, XXI, segundo o qual “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados *judicial* ou *extrajudicialmente*”. Aquela regra do mandado de segurança coletivo contém uma exceção à regra geral, ou a ela se subsume? Pensamos que a regra geral prevalece em todos os casos em que se reclama o *direito subjetivo individual* dos associados.⁴

Celso Agrícola Barbi acha “pouco provável que partidos políticos pudessem agir em defesa de direitos subjetivos de cidadãos, pela via do mandado de segurança coletivo”.⁵ É uma tese que também merece reflexão. As primeiras redações constituintes do mandado de segurança coletivo amarravam os partidos políticos no mesmo objetivo das demais entidades: *legitimação para defesa de interesses de seus membros e associados*. E a palavra “membros” aparecia muito em função dos integrantes das agremiações partidárias.⁶ A redação do texto, realmente, vincula a defesa de seus membros e associados às entidades relacionadas na alínea *b*, pelo que, sem nenhuma dúvida, não podem defender interesses de não membros ou não associados. Não se indicaram, porém, interesses de quem os partidos políticos podem defender pelo mandado de segurança coletivo. Questão aberta. Logo, entendemos que eles podem defender direito subjetivo individual de seus membros, desde que se admita, como se está admitindo, que o mandado de segurança coletivo também é meio hábil

4. Em sentido contrário, cf. Uadi Lamêgo Bulos, *Mandado de segurança coletivo (outros estudos)*, p. 25.

5. Idem, *ibidem*.

6. As redações nas várias fases de elaboração constitucional: Anteprojeto Nelson Friedrich, art. 29 — “O mandado de segurança coletivo para proteger direito líquido e certo não amparado por *habeas corpus*, pode ser impetrado por Partidos Políticos, organizações sindicais, órgãos fiscalizadores do exercício da profissão, associações de classe e associações legalmente constituídas e em funcionamento há, pelo menos, um ano na defesa dos interesses de seus membros ou associados”. Esta redação passou para o Projeto aprovado na Comissão de Sistematização (art. 6º, § 50), com a supressão da cláusula “para proteger direito líquido e certo não amparado por *habeas corpus*”. A redação sugerida pelo Relator Bernardo Cabral, para o primeiro turno e aí aprovada, despertou a atenção para a delimitação do objeto do mandado de segurança coletivo dos partidos. Veio ela no art. 5º, LXXI: “conceder-se-á mandado de segurança coletivo, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano”. A rigor, essa redação correspondia à que foi aprovada no Projeto da Sistematização. Houve, porém, reação ao enquadramento dos partidos nesses limites da legitimação, de onde, em negociação de lideranças, transpor-se aquela cláusula para o final da alínea *b*, vinculada apenas a entidades ali referidas.

para a defesa de direito subjetivo individual de integrantes da parte institucional legitimada.

No mais, parece-nos que assiste razão a Celso Agrícola Barbi quando entende que “a legitimação dos partidos políticos para requerer mandado de segurança coletivo é indicativa de que este pode ter por objeto interesses legítimos, difusos ou coletivos”. E aí estará, talvez, a mais fértil função do mandado de segurança coletivo, só que isso ergue um problema difícil. Fica o mandado de segurança coletivo sujeito ao requisito do direito líquido e certo?

Não consta essa exigência do dispositivo constitucional que o institui. O requisito constava da proposta inicial do remédio, mas foi logo eliminado nas sucessivas redações do texto. A alínea *b* do inc. LXX do art. 5º fala em “interesses” e não em “direitos”. Será isso suficiente para afastar o requisito, sabido que também na primeira proposta do instituto se destinava ele a “proteger direito líquido e certo”, mas na defesa de *interesses* de membros e associados das entidades referidas? Se o requisito do direito líquido e certo for eliminado, não se correrá o risco de perder-se a principal característica do instituto, que é sua celeridade?

Parece que a esse propósito poderemos tirar uma primeira conclusão: *o requisito do direito líquido e certo será sempre exigido quando a entidade impetra o mandado de segurança coletivo na defesa de direito subjetivo individual*. Quando o sindicato usá-lo na defesa de *interesse coletivo* de seus membros e quando os partidos políticos impetrarem-no na defesa de *interesse coletivo difuso* exigem-se ao menos a ilegalidade e a lesão do interesse que o fundamenta.⁷

4. Mandado de injunção coletivo

Já estudamos o mandado de injunção e não é o caso de voltar a ele aqui, senão para esclarecer que também pode ser um *remédio coletivo*, já que pode ser impetrado por sindicato (art. 8º, III) no interesse de Direito Constitucional de categorias de trabalhadores quando a

7. Celso Agrícola Barbi diz, a nosso ver com razão: “quando o pedido for de partido político, basta a simples ilegalidade e a lesão de interesse daquele tipo, não sendo caso de estabelecer qualquer vínculo entre o interesse e os membros ou filiados do partido” (tese citada), se bem que, como dissemos, entendemos possível também a defesa do interesse destes. No mesmo sentido, José da Silva Pacheco, *Mandado de segurança e outras ações constitucionais*, p. 220. Porém, Uadi Lamêgo Bulos, *ob. cit.*, p. 33, contesta a possibilidade de impetração do *writ* coletivo, nas hipóteses de interesse difuso, porque a Constituição silenciou a respeito e porque “não menciona a natureza do interesse, como então rotulá-lo de difuso?” Exatamente, porque o *interesse* não foi constitucionalmente qualificado é que esse signo é amplo e abrangente.

falta de norma regulamentadora desses direitos inviabilize seu exercício. Como, segundo o art. 8º, III, os sindicatos são partes legítimas para defender direitos e interesses da categoria, o mandado de injunção utilizado em tal situação, como o proposto por qualquer outra entidade associativa nos termos do art. 5º, XXI, assume a natureza de coletivo.

5. Ação popular

A origem das ações populares perde-se na história do Direito romano. O nome *ação popular* deriva do fato de atribuir-se ao povo, ou a parcela dele, legitimidade para pleitear, por qualquer de seus membros, a tutela jurisdicional de interesse que não lhe pertence, *ut singuli*, mas à coletividade. O *autor popular* faz valer um interesse que só lhe cabe, *ut universis*, como membro de uma comunidade, agindo *pro populo*. Mas a ação popular não é mera atribuição de *ius actionis* a qualquer do povo, ou a qualquer cidadão como no caso da nossa. Essa é apenas uma de suas notas conceituais. O que lhe dá conotação essencial é a natureza impessoal do interesse defendido por meio dela: *interesse da coletividade*. Ela há de visar a defesa de direito ou interesse público. O qualificativo *popular* prende-se a isto: *defesa da coisa pública, coisa do povo* (*publicum*, de *populicum*, de *populum*).

Toda ação popular consiste na possibilidade de qualquer membro da coletividade, com maior ou menor amplitude, invocar a tutela jurisdicional a interesses coletivos.

A ação popular constitucional brasileira consta agora do art. 5º, LXXIII, nos termos seguintes: *qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência*.

Trata-se de um remédio constitucional pelo qual *qualquer cidadão* fica investido de legitimidade para o exercício de um poder de natureza essencialmente política, e constitui manifestação direta da soberania popular consubstanciada no art. 1º, parágrafo único, da Constituição: *todo poder emana do povo*, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou *diretamente*. Sob esse aspecto é uma *garantia constitucional política*. Revela-se como uma forma de participação do cidadão na vida pública,⁸ no exercício de uma função

8. Sobre essa temática, cf. Elival da Silva Ramos, *Ação popular como instrumento de participação política*, especialmente pp. 203 e ss.

que lhe pertence primariamente. Ela dá a oportunidade de o cidadão exercer diretamente a função fiscalizadora, que, por regra, é feita por meio de seus representantes nas Casas Legislativas. Mas ela é também uma *ação judicial* porquanto consiste num meio de invocar a atividade jurisdicional visando a correção de nulidade de ato lesivo; (a) ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe; (b) à moralidade administrativa; (c) ao meio ambiente; e (d) ao patrimônio histórico e cultural. Sua finalidade é, pois, *corretiva*, não propriamente preventiva, mas a lei pode dar, como deu, a possibilidade de suspensão liminar do ato impugnado para prevenir a lesão.

Contudo, ela se manifesta como uma *garantia coletiva* na medida em que o *autor popular* invoca a atividade jurisdicional, por meio dela, na defesa da coisa pública, visando a *tutela de interesses coletivos*, não de interesse pessoal. Por isso a incluímos aqui e não entre as garantias políticas.

Quando a Constituição diz que *qualquer cidadão* pode propor ação popular, está restringindo a legitimidade para a ação apenas ao *nacional no gozo dos direitos políticos*, ao mesmo tempo em que a recusa aos estrangeiros e às pessoas jurídicas, entre estas os partidos políticos.

O objeto da ação popular foi ampliado, em nível constitucional, à proteção da moralidade administrativa, do *meio ambiente* e do patrimônio histórico e cultural. Este último já estava contemplado na lei que regula o processo popular. Não gera maior dificuldade a compreensão do que seja *meio ambiente*, que é conceito adotado pela Constituição (art. 225). Será mais difícil a compreensão da *moralidade administrativa*, como fundamento para anular ato que a lese. A *moralidade* é definida como um dos princípios da Administração Pública (art. 37). Todo ato lesivo ao patrimônio agride a moralidade administrativa. Mas o texto constitucional não se conteve nesse aspecto apenas da moralidade. Quer que a moralidade administrativa em si seja fundamento de nulidade do ato lesivo. Deve-se partir da idéia de que moralidade administrativa não é *moralidade comum*, mas *moralidade jurídica*. Essa consideração não significa necessariamente que o ato legal seja honesto. Significa, como disse Hauriou, que a moralidade administrativa consiste no “conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração”.⁹ A questão fica ainda presa quanto ao saber se a ação popular continuará a depender dos dois requisitos que sempre a nortearam: *lesividade* e *ilegalidade* do ato impugnado. Na medida em que a Constituição amplia o âmbito da ação popular, a tendência é a de erigir

9. Cf. Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, pp. 83 e ss.

a lesão, em si, à condição de motivo autônomo de nulidade do ato. Reconhece-se muita dificuldade para tanto. Se se exigir também o vício de ilegalidade, então não haverá dificuldade alguma para a apreciação do ato imoral, porque, em verdade, somente se considerará ocorrida a imoralidade administrativa no caso de ilegalidade. Mas isso nos parece liquidar com a intenção do legislador constituinte de contemplar a moralidade administrativa como objeto de proteção desse remédio. Por outro lado, pode-se pensar na dificuldade que será desfazer um ato, produzido conforme a lei, sob o fundamento de vício de imoralidade. Mas isso é possível porque a moralidade administrativa não é meramente subjetiva, porque não é puramente formal, porque tem conteúdo jurídico a partir de regras e princípios da Administração. No caso da defesa da moralidade *pura*, ou seja, sem alegação de lesividade ao patrimônio público, mas apenas de *lesividade* do princípio da *moralidade administrativa*, assim mesmo se reconhecem as dificuldades para se dispensar o requisito da ilegalidade, mas quando se fala que isso é possível é porque se sabe que a atuação administrativa imoral está associada à violação de um pressuposto de validade do ato administrativo. Rodolfo de Camargo Mancuso também acha isso possível porque a Constituição erigiu a “moralidade administrativa” em *fundamento autônomo* para a ação popular e “numa categoria jurídica passível de controle jurisdicional, *per se*”.¹⁰ A lei pode ser cumprida moralmente ou imoralmente. Quando sua execução é feita, p. ex., com intuito de prejudicar alguém deliberadamente, ou com o intuito de favorecer alguém, por certo que se está produzindo um ato *formalmente* legal, mas *materialmente* comprometido com a moralidade administrativa. Se um Prefeito, em fim de mandato, por ter perdido a eleição para seu adversário político, congela ou não atualiza o imposto sobre propriedade territorial urbana, com o intuito, aí transparente, de prejudicar a futura administração municipal, comete imoralidade administrativa, pouco importa se o ato fora ou não ilegal; é verdade que aí se vislumbra também lesão ao patrimônio público municipal que fica desfalcado de recursos financeiros a mais que arrecadaria no exercício seguinte.

Podemos, então, definir a ação popular constitucional brasileira como *instituto processual civil, outorgado a qualquer cidadão como garantia político-constitucional (ou remédio constitucional), para a defesa do interesse da coletividade, mediante a provocação do controle jurisdicional corretivo de atos lesivos do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural*.

10. Cf. *Ação popular*, São Paulo, Ed. RT, 1994, pp. 70 e 71.

III. GARANTIAS DOS DIREITOS SOCIAIS

6. Normatividade dos direitos sociais

A normatividade constitucional dos direitos sociais principiou na Constituição de 1934. Inicialmente se tratava de normatividade essencialmente programática. A tendência é a de conferir a ela maior eficácia. E nessa configuração crescente da eficácia e da aplicabilidade das normas constitucionais reconhecedoras de direitos sociais é que se manifesta sua principal garantia. Assim, quando a Constituição diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais os expressamente indicados no art. 7º, e quando diz que a saúde ou a educação é direito de todos, e indica mecanismos, políticas, para a satisfação desses direitos, está preordenando situações jurídicas objetivas com vistas à aplicação desses direitos.

Mas não é de esquecer-se que o sistema de proteção dos direitos sociais é ainda muito frágil.¹¹ Mesmo assim comporta suscitar o tema aqui, ao menos para começarmos a dar-lhe destaque, coisa que não tem ocorrido.

7. Tutela jurisdicional dos hipossuficientes

Se a primeira garantia constitucional dos direitos sociais se consubstanciou na sua inscrição na Constituição rígida, erigindo-os em instituições constitucionais, a segunda é ter propiciado o surgimento de um ramo de direito autônomo, desgarrado do direito civil comum, regulando as relações de trabalho com vista a tutelar os interesses dos trabalhadores, e daí a *garantia mais relevante* consistente na institucionalização de uma Justiça do Trabalho destinada a conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores e outras controvérsias oriundas de relação de trabalho, mediante a aplicação daquele ramo do Direito (art. 114).

Daí deriva uma especial tutela jurisdicional dos chamados hipossuficientes, que, não obstante toda a sua insuficiência, por certo tem prestado alguma proteção efetiva ao trabalhador, pelo menos no sentido de reconhecer-se que, sem a tutela dessa Justiça especializada, o trabalhador estaria bem mais ao desamparo.

8. Sindicalização e direito de greve

É, no entanto, na possibilidade de instituir sindicatos autônomos e livres e no reconhecimento constitucional do direito de greve (arts. 8º e 9º) que encontramos os dois instrumentos mais eficazes

11. Cf. Centre d'Études Européennes (org.), *Vers une protection efficace des droits économiques et sociaux?*, Bruxelles/Louvain, Bruylant/Vander, 1973.

para a efetividade dos direitos sociais dos trabalhadores. Vimos já que a sindicalização é um tipo de associação profissional cujo objetivo fundamental consiste na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores (art. 8º, III). Vimos também que o direito de greve é um direito-garantia, na medida em que ele não é uma vantagem, um bem, auferível em si pelos grevistas, mas um meio utilizado pelos trabalhadores para conseguir a efetivação de seus direitos e melhores condições de trabalho.

9. Decisões judiciais normativas

A importância dos sindicatos se revela ainda na possibilidade de celebrarem *convenções coletivas de trabalho* e, conseqüentemente, na legitimação que têm para suscitar *dissídio coletivo de trabalho*. Isso significa que se dá às decisões judiciais em tais casos extensão normativa que alcança toda a categoria profissional representada pelo sindicato suscitante, beneficiando mesmo aqueles trabalhadores que sequer sejam sindicalizados (art. 114, § 2º).

10. Garantias de outros direitos sociais

Diz-se que o núcleo central dos direitos sociais é constituído pelo direito do trabalho (conjunto dos direitos dos trabalhadores) e pelo direito de seguridade social. Em torno deles, gravitam outros direitos sociais, como o direito à saúde, o direito de previdência social, o de assistência social, o direito à educação, o direito ao meio ambiente sadio. A Constituição tentou preordenar meios de tornar eficazes esses direitos, prevendo, p. ex., fonte de recursos para a seguridade social, com aplicação obrigatória nas ações e serviços de saúde e às prestações previdenciárias e assistenciais (arts. 194 e 195), assim como a reserva de recursos orçamentários para a educação (art. 212). Aos direitos culturais, impõem-se ao Estado dar-lhe apoio, incentivos e proteção (art. 215). Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente, o § 1º do art. 225 define vários procedimentos, incluindo estudo prévio do impacto ambiental, a que se dará publicidade, no caso de instalação de obras e serviços causadores de degradação ao meio ambiente, assim como estatui meio de atuação repressiva de natureza penal, administrativa e civil (art. 225, § 3º). São ainda modulações cuja eficácia própria só a experiência vai confirmar.

IV. GARANTIA DOS DIREITOS POLÍTICOS

11. Definição do tema — Remissão

Garantias políticas são aquelas que possibilitam o livre exercício da cidadania. Tais são o sigilo do voto, a igualdade do voto. Inclui-se

aí também a determinação de que sejam *gratuitos, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania*.

Esses temas já foram objeto de consideração em outros lugares a que remetemos os leitores.

12. Eficácia dos direitos fundamentais

Finalmente, a garantia das garantias consiste na eficácia e aplicabilidade imediata das normas constitucionais. Os direitos, liberdades e prerrogativas consubstanciadas no título II, caracterizados como direitos fundamentais, só cumprem sua finalidade se as normas que os expressem tiverem efetividade. A Constituição se preocupou com a questão em vários momentos. O primeiro em uma norma-síntese em que determina que *as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata*.¹² Não é, pois, só a garantia dos direitos políticos, mas de todos os direitos fundamentais: individuais, coletivos, sociais, de nacionalidade e políticos. Essa declaração pura e simplesmente por si não bastaria se outros mecanismos não fossem previstos para torná-la eficiente. Vimos a propósito o mandado de injunção. Acrescentemos que a ação de inconstitucionalidade por omissão é da mesma natureza. A iniciativa popular pode muito bem ser eficiente instituto de busca da integração das normas constitucionais dependentes de lei ordinária ou complementar, especialmente daquelas normas que traduzam direitos de interesse social.

Sua existência só por si, contudo, estabelece uma ordem aos aplicadores da Constituição no sentido de que o princípio é o da eficácia plena e a aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos fundamentais: individuais, coletivos, sociais, de nacionalidade e políticos, de tal sorte que só em situação de absoluta impossibilidade se há de decidir pela necessidade de normatividade ulterior de aplicação.

Por isso, revela-se, por seu alto sentido político, como eminente garantia política de defesa da eficácia jurídica e social da Constituição.

12. Sobre o tema, nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, 1982.

TERCEIRA PARTE

**DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
E DOS PODERES**

Título I

Da Estrutura Básica da Federação

Capítulo I

DAS ENTIDADES COMPONENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA

1. Questão de ordem. 2. Componentes do Estado Federal. 3. Brasília. 4. A posição dos Territórios. 5. Formação dos Estados. 6. Os Municípios na federação. 7. Vedações constitucionais de natureza federativa.

1. Questão de ordem

Já estudamos os princípios do Estado Federal e sua aplicação à República Federativa do Brasil, de sorte que não há mais por que regressar a eles aqui.¹ Agora, nosso tema diz sobretudo respeito à estrutura do Estado Federal brasileiro: sua organização concreta, seus componentes, a técnica de repartição do poder autônomo entre as entidades federativas.

2. Componentes do Estado Federal

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende, como se vê do art. 18, a *União*, os *Estados*, o *Distrito Federal* e os *Municípios*. A Constituição aí quis destacar as entidades que integram a estrutura federativa brasileira: os *componentes do nosso Estado Federal*. Merece reparo dizer que é a organização político-administrativa que compreende tais entidades, como se houvesse alguma diferença entre o que aqui se estabelece e o que se declarou no art. 1º. Dizer que a República Federativa do Brasil é formada pela *união indissolúvel* dos Estados e Municípios e do Distrito Federal não é diverso de dizer que ela compreende União, Estados,

1. O leitor poderá rever essa temática nos ns. 1 a 3, especialmente, do capítulo II do título II da primeira parte desta obra.

Distrito Federal e Municípios, porque *união indissolúvel* (embora com inicial minúscula) do art. 1º é, a mesma União (com inicial maiúscula) do art. 18. Repetição inútil, mas que não houve jeito de evitar, tal o apego à tradição formal de fazer constar do art. 1º essa cláusula que vem de constituições anteriores, sem levar em conta que a metodologia da Constituição de 1988 não comportava tal apego destituído de sentido.

Enfim, temos aí destacados os componentes da nossa República Federativa: (a) União; (b) Estados; (c) Distrito Federal; e (d) Municípios. Resta saber se todos têm natureza de entidades federativas.

3. Brasília

Brasília é a Capital Federal (art. 18, § 1º). Com sua característica de cidade inventada, realiza o simbolismo da *civitas civitatum*, na magnífica visão da Esplanada dos Ministérios que culmina na Praça dos Três Poderes, com destaque para o poder de representação popular, o Congresso Nacional, com suas duas torres e as abóbadas invertidas dos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sublima o simbolismo a posição dos Ministérios do Exterior e da Justiça ocupando os cantos inferiores da Praça dos Três Poderes, a indicar as duas vertentes de irradiação do poder político; de um lado, seu relacionamento com outros povos, que se canaliza mediante o primeiro daqueles Ministérios, e, de outro lado, a sua primazia interna, que se manifesta na manutenção da ordem jurídica sob o segundo.²

Brasília, assim, assume uma posição jurídica específica no conceito brasileiro de cidade. Brasília é *civitas civitatum*, na medida em que é cidade-centro, pólo irradiante, de onde partem, aos governados, as decisões mais graves, e onde acontecem os fatos decisivos para os destinos do País. Mas não se encaixa no conceito geral de cidades, porque não é sede de Município. É *civitas* e *polis*, enquanto modo de habitar de sede do Governo Federal. Não era forma de participar, porque seu povo não dispunha do direito de eleger seus governantes nem seus representantes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, mas agora se integra na cidadania com a autonomia do Distrito Federal (art. 32). Brasília tem como *função* servir de Capital da União, Capital Federal e, pois, Capital da República Federativa do Brasil, e também sede do governo do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 6º da respectiva Lei Orgânica.

2. Cf. nosso "A cidade-capital: função do Estado moderno, integração nacional e relações internacionais", *RTJE* n. 43, pp. 5 e ss.

4. A posição dos Territórios

Os *Territórios Federais* não são mais considerados como componentes da federação, como equivocadamente o eram nas constituições precedentes. A Constituição lhes dá posição correta, de acordo com sua natureza de mera autarquia, simples descentralização administrativo-territorial da União, quando os declara integrantes desta (art. 18, § 2º).

Não há mais Territórios Federais, porque a própria Constituição transformou em Estados os de Roraima e Amapá, únicos que ainda existiam.³ Mas reconhece a possibilidade de sua criação, sua ulterior transformação em Estado ou sua reintegração no Estado de origem consoante regulamentação por lei complementar (art. 18, § 2º) e sua organização administrativa e judiciária por lei ordinária conforme disciplina o art. 33.

5. Formação dos Estados

Os Estados constituem instituições típicas do Estado Federal. São eles as entidades-componentes que dão a estrutura conceitual dessa forma de Estado. Sem Estados federados não se conhece federação, chamem-se Estados (EUA, Venezuela, Brasil), Províncias (Argentina), Cantões (Suíça), *Länder* (Alemanha). Não é o nome que lhes dá a natureza, mas o regime de autonomia.

Não há mais como formar novos Estados, senão por divisão de outro ou outros. A Constituição prevê a possibilidade de transformação deles por incorporação entre si, por subdivisão ou desmembramento quer para se anexarem a outros, quer para formarem novos Estados, quer, ainda, para formarem Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas (art. 18, § 3º, combinado com o art. 48, VI). "Incorporação entre si" aí significa "fusão", porque *incorporação*, só, consiste na reunião de um Estado a outro, perdendo o Estado incorporado sua personalidade que se integra no incorporador. Não há propriamente incorporação *entre si*, incorporação *entre dois*; há incorporação *de um a outro*. A fusão pode ser entre si, entre dois ou três, ou mais, com a consequência de todos perderem a primitiva personalidade, surgindo um novo Estado. Logo, em se tratando de "incorporação entre si", população *diretamente* interessada é a de cada um dos Estados que desejam fundir-se. "Subdivisão" significa separar um todo em várias partes, formando cada qual uma unidade in-

3. Cf. art. 14 do ADCT.

dependente das demais. “Os Estados podem subdividir-se” é inverso de “Os Estados podem incorporar-se entre si”. Quer dizer que um Estado pode dividir-se em dois ou mais Estados diferentes. Subdividem-se para formarem outros. Logo, população *diretamente* interessada, em se tratando de subdivisão de Estado, é a do Estado todo. “Desmembramento” é processo diverso da subdivisão. “Desmembrar” é separar uma ou mais partes de um todo, sem perda da identidade do ente primitivo. Desmembramento de Estado, portanto, quer dizer separação de parte dele, sem que ele deixe de ser o mesmo Estado. Continua com sua personalidade primitiva, apenas desfalcado do pedaço de seu território e população separados. A parte desmembrada poderá constituir novo Estado, ou anexar-se a outro, ou formar Território Federal. População *diretamente* interessada, no caso, é a da parte desmembrada, é a da parte que quer separar-se.

No caso de incorporação de Estados entre si, devem ser ouvidas todas as Assembléias dos Estados que desejam incorporar-se. No de subdivisão, para formação de novos Estados, só há uma Assembléia a ser ouvida. Se a subdivisão destinar-se a anexar-se a outro ou outros Estados, as Assembléias destes também precisam ser ouvidas, para dizerem se aceitam ou não a anexação. No caso de desmembramento, ouve-se só a Assembléia do Estado desmembrando, se o desmembramento visa formar novo Estado, mas se este se destina a anexar-se a outro ou outros, as Assembléias destes também devem ser auscultadas.

O plebiscito deve ser organizado pelos Tribunais Regionais Eleitorais. Verificado o pronunciamento plebiscitário favorável a qualquer das alterações mencionadas, o processo será remetido à Assembléia ou Assembléias competentes para pronunciamento no prazo legal, ou, na falta, em prazo indicado pela Justiça Eleitoral. Depois disso, o expediente seguirá para o Congresso Nacional, para decisão mediante lei complementar (art. 69). O Congresso não está vinculado nem ao pronunciamento plebiscitário nem ao das Assembléias, notando-se que estas não decidem, apenas opinam pela aprovação, pela rejeição ou simplesmente se abstêm de tomar partido.

6. Os Municípios na federação

A Constituição consagrou a tese daqueles que sustentavam que o Município brasileiro é “entidade de terceiro grau, integrante e necessária ao nosso sistema federativo”.⁴ *Data venia*, essa é uma tese

4. Cf. Hely Lopes Meirelles, *Direito municipal brasileiro*, p. 39. É tese também sustentada pelo IBAM, cujo Presidente, Dr. Diogo Lordello de Mello, em pronunciamento perante a Subcomissão dos Municípios e Regiões, na reunião de 22.4.87,

equivocada, que parte de premissas que não podem levar à conclusão pretendida. Não é porque uma entidade territorial tenha autonomia político-constitucional que necessariamente integre o conceito de entidade federativa. Nem o Município é essencial ao conceito de federação brasileira. Não existe federação de Municípios. Existe federação de Estados. Estes é que são essenciais ao conceito de qualquer federação. Não se vá, depois, querer criar uma câmara de representantes dos Municípios. Em que muda a federação brasileira com o incluir os Municípios como um de seus componentes? Não muda nada. Passaram os Municípios a ser entidades federativas? Certamente que não, pois não temos uma federação de Municípios. Não é uma união de Municípios que forma a federação. Se houvesse uma federação de Municípios, estes assumiriam a natureza de Estados-membros, mas poderiam ser Estados-membros (de segunda classe?) dentro dos Estados federados? Onde estaria a autonomia federativa de uns ou de outros, pois esta pressupõe território próprio, não compartilhado? Dizer que a República Federativa do Brasil é formada de união indissolúvel dos Municípios é algo sem sentido, porque, se assim fora, ter-se-ia que admitir que a Constituição está provendo contra uma hipotética secessão municipal. Acontece que a sanção correspondente a tal hipótese é a intervenção federal que não existe em relação aos Municípios. A intervenção neles é da competência dos Estados, o que mostra serem ainda vinculados a estes. Prova que continuam a ser divisões político-administrativas dos Estados, não da União. Se fossem divisões políticas do território da União, como ficariam os Estados, cujo território é integralmente repartido entre os seus Municípios? Ficariam sem território próprio? Então, que entidades seriam os Estados? Não resta dúvida que ficamos com uma federação muito complexa, com entidades superpostas.

Outro aspecto que mostra que os Municípios continuam a ser divisões dos Estados acha-se no fato de que sua criação, incorporação, fusão e desmembramento far-se-ão por *lei estadual*, dentro do período determinado por lei complementar federal (art. 18, § 4º, redação da EC-15/96), e dependerão de plebiscito (que é sempre consulta prévia) das *populações diretamente interessadas*. A Constituição aqui, diferentemente do que fez em relação aos Estados, usou “populações” no plural, a querer dizer que será consultada a população da área a ser desmembrada e da área de que se desmembra, ao contrário do que ocorreu sempre, quando o plebiscito importava apenas na consulta da população da área cuja emancipação se pleiteava.

propôs, entre várias sugestões, “a inclusão expressa do município como parte integrante da Federação”. Cf. *Diário da Assembléia Nacional Constituinte*, Suplemento n. 62, p. 25.

7. Vedações constitucionais de natureza federativa

O art. 19 contém vedações gerais dirigidas à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Visam o equilíbrio federativo. Uma, em função da natureza laica do Estado brasileiro, que não poderá admitir que qualquer das entidades autônomas da federação estabeleça cultos religiosos ou igrejas ou os subvencione (inc. I); outras, em função da liberdade religiosa e de culto, que proíbe embarçar o funcionamento de cultos ou igrejas ou com eles ou seus representantes manter relações de dependência ou aliança, possibilitada a colaboração de interesse público, na forma da lei (inc. I); que lei? A da entidade federativa envolvida. Outras, ainda, em função da credibilidade dos documentos públicos, que, por isso, sejam de que entidades públicas forem, fazem prova, valem formal e materialmente perante outra (inc. II). Finalmente, outro grupo de vedações prende-se mais estritamente ao princípio federativo da unidade de nacionalidade de todos os brasileiros, qualquer que seja o Estado ou Município de seu nascimento, bem como ao princípio da paridade entre as entidades da federação (inc. III).

A vedação de criar *distinções entre brasileiros* coliga-se com o princípio da igualdade. Significa que um Estado não pode criar vantagem a favor de seus filhos em detrimento de originários de outros, como não poderá prejudicar filhos de qualquer Estado em relação a filhos de outros, nem filhos de um Município em relação a filhos de outros. A União não poderá beneficiar nem prejudicar filhos de uns Estados ou Municípios ou do Distrito Federal mais do que filhos de outros. Tampouco os Municípios poderão fazê-lo. O ato discriminativo será nulo e a autoridade responsável por ele poderá incidir no crime previsto no art. 5º, XLI.

A paridade federativa encontra apoio na *vedação de criar preferências* entre um Estado federado e outro ou outros, ou entre os Municípios de um Estado e os de outro ou do mesmo Estado, ou entre Estado e Distrito Federal.

Capítulo II

DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

1. O problema da repartição de competências federativas. 2. O princípio da predominância do interesse. 3. Técnicas de repartição de competências. 4. Sistema da Constituição de 1988. 5. Classificação das competências. 6. Sistema de execução de serviços. 7. Gestão associada de serviços públicos.

1. O problema da repartição de competências federativas

A autonomia das entidades federativas pressupõe repartição de competências para o exercício e desenvolvimento de sua atividade normativa.¹ Esta distribuição constitucional de poderes é o ponto nuclear da noção de Estado federal. São notórias as dificuldades quanto a saber que matérias devem ser entregues à competência da União, quais as que competirão aos Estados e quais as que se indicarão aos Municípios.

Os limites da repartição regional e local de poderes dependem da natureza e do tipo histórico de federação. Numa descentralização é mais acentuada, dando-se aos Estados federados competências mais amplas, como nos Estados Unidos. Noutras a área de competência da União é mais dilatada, restando limitado campo de atuação aos Estados-membros, como tem sido no Brasil, onde a existência de competências exclusivas dos Municípios comprime ainda mais a área estadual. A Constituição de 1988 estruturou um sistema que combina competências exclusivas, privativas e principiologicamente com competências comuns e concorrentes, buscando reconstruir o sistema federativo segundo critérios de equilíbrio ditados pela experiência histórica.²

1. Cf. Raul Machado Horta, *A autonomia do Estado-membro no direito constitucional brasileiro*, p. 49.

2. A estrutura de repartição de competências adotada decorreu de proposta que fizemos na Comissão Provisória de Estudos Constitucionais (Comissão Afonso Arinos) em Anteprojeto de Constituição que ali apresentamos (arts. 85, 1 e 2, e 86, 1 e 2), acolhido pelo relator Prof. Raul Machado Horta com aperfeiçoamentos. Mas os Anteprojetos na Constituinte não adotaram o mesmo critério. A discussão para o preparo do Substitutivo do Relator Bernardo Cabral destinado à Comissão de Sistematização baseou-se em cinco Anteprojetos, chamados: *Cabral*, preparado pelo

2. O princípio da predominância do interesse

O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades componentes do Estado federal é o da *predominância do interesse*, segundo o qual à União caberão aquelas matérias e questões de *predominante interesse geral, nacional*, ao passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de *predominante interesse regional*, e aos Municípios concernem os *assuntos de interesse local*, tendo a Constituição vigente desprezado o velho conceito do peculiar interesse local que não lograra conceituação satisfatória em um século de vigência.

Acontece que, no Estado moderno, se torna cada vez mais problemático discernir o que é interesse geral ou nacional do que seja interesse regional ou local. Muitas vezes, certos problemas não são de interesse rigorosamente nacional, por não afetarem a Nação como um todo, mas não são simplesmente particulares de um Estado, por abrangerem dois ou mais deles. Os problemas da Amazônia, os do polígono da seca, os do Vale do São Francisco e do Vale do Paraná-Uruguaí, são exemplos que se citam na Federação brasileira.

3. Técnicas de repartição de competências

As constituições solucionavam o problema mediante a aplicação de três técnicas, que conjugam *poderes enumerados* e *poderes reservados* ou *remanescentes*, que consistem: (a) na *enumeração dos poderes da União*, reservando-se aos Estados os *poderes remanescentes*; é a técnica predominante (EUA, Suíça, Argentina, ex-URSS e Iugoslávia, México e Austrália são federações que a adotam); (b) na *atribuição dos poderes enumerados aos Estados e dos remanescentes à União*, ao inverso, pois, do sistema anterior, e que é empregado quase só pela Federação do Canadá; (c) na *enumeração das competências das entidades federativas* (Índia e Venezuela podem ser indicadas como exemplos, compreendendo ambas poderes concorrentes e atribuição de poderes residuais à União). Esse sistema de enumeração exaustiva de poderes para as entidades federativas vigora também no Brasil para a repartição de rendas tributárias, com competência residual para a União (arts. 145 a 162).

Relator Bernardo Cabral; *Hércules*, preparado pelo denominado Grupo dos 32, sob a coordenação do Senador José Richa; *Câmara*, preparado pela Câmara dos Deputados; *Afonso*, preparado por mim, e *Ferraz*, preparado por Sérgio Ferraz. Pois bem, no *Anteprojeto Afonso*, de nossa autoria, repropusemos no art. 55, 1, a competência material da União (art. 20 da Constituição); no art. 55, 2, a competência legislativa exclusiva da União (art. 21); no art. 56, 1, a competência material comum da União, Estados e Municípios (art. 22); e no art. 56, 2, a competência legislativa concorrente da União e dos Estados (art. 23).

À vista, porém, das dificuldades acima apontadas, da evolução do federalismo e da ampliação das tarefas do Estado contemporâneo, outras técnicas de repartição de competências foram surgindo a par do abandono do dualismo que separa as entidades federativas em campos exclusivos, mutuamente limitativas, para acolher formas de composição mais complexas que procuram compatibilizar a autonomia de cada uma com a reserva de campos específicos que designem áreas exclusivas ou simplesmente privativas com possibilidade de delegação, áreas comuns em que se prevêem atuações paralelas e setores concorrentes em que a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados a competência suplementar. É o sistema que se reconhece na República Federal da Alemanha (Constituição, arts. 70 a 75) e agora no Brasil em termos que se anotarão em seguida.

4. Sistema da Constituição de 1988

A nossa Constituição adota esse sistema complexo que busca realizar o equilíbrio federativo, por meio de uma repartição de competências que se fundamenta na técnica da *enumeração dos poderes da União* (arts. 21 e 22), com *poderes remanescentes para os Estados* (art. 25, § 1º) e *poderes definidos indicativamente para os Municípios* (art. 30), mas combina, com essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em que se prevêem atuações paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores concorrentes entre União e Estados em que a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União,³ enquanto se defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar.⁴

5. Classificação das competências

Competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões. *Competências* são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções.

Isso permite falar em espécies de competências, visto que as matérias que compõem seu conteúdo podem ser agrupadas em classes, segundo sua natureza, sua vinculação cumulativa a mais de uma

3. Cf. arts. 21, XIX, XX, XXI; 22, IX, XXI, XXIV, e 24, § 1º.

4. Cf. art. 24, §§ 2º e 3º, e art. 30, II.

entidade e seu vínculo a função de governo. Sob esses vários critérios, podemos classificar as competências primeiramente em dois grandes grupos com suas subclasses: (1) *competência material*, que pode ser: (a) *exclusiva* (art. 21); e (b) *comum, cumulativa ou paralela* (art. 23); (2) *competência legislativa*, que pode ser: (a) *exclusiva* (art. 25, §§ 1º e 2º); (b) *privativa* (art. 22);⁵ (c) *concorrente* (art. 24); (d) *suplementar* (art. 24, § 2º).

Essas competências, sob outro prisma, podem ser classificadas quanto à *forma, conteúdo, extensão e origem*.

Quanto à *forma* (ou o processo de sua distribuição), a competência será: (a) *enumerada, ou expressa*, quando estabelecida de modo explícito, direto, pela Constituição para determinada entidade (arts. 21 e 22, p. ex.); (b) *reservada ou remanescente e residual*, a que compreende toda matéria não expressamente incluída numa enumeração, reputando-se sinônimas as expressões *reservada* e *remanescente* com o significado de competência que sobra a uma entidade após a enumeração da competência de outra (art. 25, § 1º: cabem aos Estados as competências não vedadas pela Constituição), enquanto a *competência residual* consiste no eventual resíduo que reste após enumerar a competência de todas as entidades, como na matéria tributária, em que a competência residual — a que eventualmente possa surgir apesar da enumeração exaustiva — cabe à União (art. 154, I); (c) *implícita ou resultante* (ou *inerente ou decorrente*, porque decorre da natureza do ente), quando se refere à prática de atos ou atividades razoavelmente considerados necessários ao exercício de poderes expressos, ou reservados; por exemplo, no silêncio da Constituição de 1891, o STF decidiu que a expulsão de estrangeiros era da competência da União, embora isso não estivesse dito naquela Carta Magna.

Quanto ao *conteúdo*, a competência distingue-se em *econômica, social, político-administrativa, financeira e tributária*. É cabível falar-se, tam-

5. A diferença que se faz entre competência *exclusiva* e competência *privativa* é que aquela é indelegável e esta é delegável. Então, quando se quer atribuir competência própria a uma entidade ou a um órgão com possibilidade de delegação de tudo ou de parte, declara-se que *compete privativamente* a ele a matéria indicada. Assim, no art. 22 se deu competência *privativa* (não exclusiva) à União para legislar sobre: [...], porque parágrafo único faculta à lei complementar autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. No art. 49, é indicada a competência *exclusiva* do Congresso Nacional. O art. 84 arrola a matéria de competência *privativa* do Presidente da República, porque o seu parágrafo único permite delegar algumas atribuições ali arroladas. Mas a Constituição não é rigorosamente técnica neste assunto. Veja-se, por exemplo, que nos arts. 51 e 52 traz matérias de competência exclusiva, respectivamente, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas diz que se trata de competência *privativa*. Não é deste último tipo, porque são atribuições indelegáveis.

bém, numa área de *competência internacional*: direitos de paz e guerra, de legação e de fazer tratados, que, no Estado federal, é, por princípio, exclusiva da União, se bem que se permite aos Estados federados, geralmente autorizados por órgãos federais (Senado, no caso brasileiro, art. 52, V), realizar certos negócios externos.

Quanto à *extensão*, ou seja, quanto à participação de uma ou mais entidades na esfera da normatividade ou da realização material, vimos que a competência se distingue em: (a) *exclusiva*, quando é atribuída a uma entidade com exclusão das demais (art. 21); (b) *privativa*, quando enumerada como própria de uma entidade, com possibilidade, no entanto, de *delegação* (art. 22 e seu parágrafo único) e de *competência suplementar* (art. 24 e seus parágrafos); a diferença entre a exclusiva e privativa está nisso, aquela não admite suplementariedade nem delegação; (c) *comum, cumulativa ou paralela*, reputadas expressões sinônimas,⁶ que significa a faculdade de legislar ou praticar certos atos, em determinada esfera, juntamente e em pé de igualdade, consistindo, pois, num campo de atuação comum às várias entidades, sem que o exercício de uma venha a excluir a competência de outra, que pode assim ser exercida cumulativamente (art. 23);⁷ (d) *concorrente*, cujo conceito compreende dois elementos: (d.1) possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto ou matéria por mais de uma entidade federativa; (d.2) primazia da União no que tange à fixação de normas gerais (art. 24 e seus parágrafos); (e) *suplementar*,⁸ que é correlativa da competência concorrente, e significa o poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios ou normas gerais ou que supram a ausência ou omissão destas (art. 24, §§ 1º a 4º).

Quanto à *origem*, a competência pode ser: (a) *originária*, quando desde o início é estabelecida em favor de uma entidade; (b) *delegada*, quando a entidade recebe sua competência por delegação daquela

6. Há, porém, quem as entenda de modo diverso. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, p. ex., vê a *competência comum* sob dois ângulos: (a) o “de matérias que ficam entregues à ação conjugada dos poderes federais e estaduais”, como a competência para obter empréstimos externos por parte dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que dependem de autorização do Senado (art. 52, V); (b) o de “matérias, onde os órgãos federais são competentes para estabelecer os princípios, prescrevendo as normas gerais”, ficando os Estados encarregados de ditar disposições complementares e supletivas (cf. *Natureza jurídica do Estado Federal*, pp. 77 e 78), mas aqui se trata de competência concorrente, não comum.

7. Cf. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, *ob. cit.*, p. 79.

8. A Constituição de 1988 abandonou a tradição de falar-se em competência *complementar* ou *supletiva* que deu margem a controvérsia quanto a saber se eram ou não sinônimas ou que sentido teriam uma e outra. Usa agora o termo *competência suplementar* com o significado exposto no texto.

que a tem originariamente; sua possibilidade consta do parágrafo único do art. 22, que comete à lei complementar autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo, e também do parágrafo único do art. 23, que determina à lei complementar fixar normas para a cooperação entre a União e os Estados, Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

6. Sistema de execução de serviços

Outro problema que integra a estrutura do federalismo é o da *execução dos serviços* de competência das entidades que compõem o Estado federal. É que, neste, como se sabe, as entidades autônomas têm organização administrativa e serviços que se incluem nas respectivas competências. Mas sua execução nem sempre será feita por funcionários próprios. A indagação a ser respondida consiste, pois, em saber quem executa tais serviços: funcionários próprios ou de outra entidade federativa?

Sobre o assunto distinguem-se três sistemas: (a) *sistema imediato*, segundo o qual a União e os Estados mantêm, cada qual, sua própria administração, com funcionários próprios, independentes uns dos outros e subordinados aos respectivos governos, como é nos EUA, na Argentina, na Venezuela e no México; (b) *sistema mediato*, pelo qual os serviços federais, em cada Estado, são executados por funcionários deste, mantendo a União pequeno corpo de servidores incumbidos da vigilância e fiscalização desses serviços; assim, ocorre predominantemente na República Federal da Alemanha, na ex-URSS, na Índia; (c) *sistema misto*, que, combinando os dois anteriores, permite que certos serviços federais sejam executados por funcionários estaduais e outros por funcionários federais e, vice-versa, certos serviços estaduais são executados por funcionários federais; é o que se dá na Suíça e na Áustria.⁹

O *sistema brasileiro* é o de *execução imediata*. União, Estados, Distrito Federal e Municípios mantêm, cada qual, seu corpo de servidores públicos, destinados a executar os serviços das respectivas administrações (arts. 37 e 39).

A Constituição, porém, como vimos, incumbe à lei complementar fixar normas para a cooperação entre essas entidades, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (art. 23, parágrafo único).

9. Cf. Charles Durand, "El Estado federal en el derecho positivo", in *El federalismo*, p. 194; Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, *ob. cit.*, pp. 87 e ss.

7. Gestão associada de serviços públicos

Esse assunto não ficaria mal no item supra porque caracteriza mais uma exceção (ao lado da prevista no art. 23, parágrafo único, referida acima) ao sistema imediato de execução de serviços adotado pela Federação brasileira. De fato, a EC-19/98 deu novo conteúdo normativo ao art. 241 da Constituição, para estabelecer o seguinte: "A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos". Sente-se que era desnecessário esse dispositivo, porque tudo que nele se prevê poderá ser objeto da lei complementar indicada no art. 23, parágrafo único, da Constituição. Anota-se, de passagem, que as expressões *consórcios* e *convênios* aparecem no texto com sentidos diferentes. E, em verdade, são conceitos diversos. *Consórcio* designa acordo firmado entre entidades da mesma espécie (Município com Município, Estado com Estado); porque as partes são entidades públicas é que se trata de *consórcios públicos*. *Convênio* é um instrumento que veicula acordos de entidades de espécies diferentes (União-Estado, União-Município, Estado-Município); por isso a norma se refere a *convênios de cooperação entre os entes federados*. Existem também a possibilidade de convênios de entidades públicas com entidades ou instituições privadas. Mas, estes, em decorrência da competência geral de cada uma das entidades públicas. Por isso, o texto, ora em comentário, não os menciona. Por outro lado, só fala em convênios entre entes federados, mas não nos parece estar excluída a possibilidade de convênios entre uma entidade federada e uma autarquia vinculada a outra entidade federada.

Capítulo III

DA INTERVENÇÃO NOS ESTADOS E NOS MUNICÍPIOS

I. AUTONOMIA E INTERVENÇÃO: 1. Autonomia e equilíbrio federativo. 2. Natureza da intervenção. II. INTERVENÇÃO FEDERAL NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL: 3. Pressupostos de fundo da intervenção. Casos e finalidades. 4. Pressupostos formais. O ato de intervenção: limites e requisitos. 5. Controle político e jurisdicional da intervenção. 6. Cessação da intervenção: consequências. 7. O interventor. Responsabilidade civil. III. INTERVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS: 8. Fundamento constitucional. 9. Motivos para a intervenção nos Municípios. 10. Competência para intervir.

I. AUTONOMIA E INTERVENÇÃO

1. Autonomia e equilíbrio federativo

O Estado federal, como vimos antes, assenta no princípio da autonomia das entidades componentes e que se apóia em dois elementos básicos: existência de governo próprio e posse de competência exclusiva.

Autonomia é a capacidade de agir dentro de círculo preestabelecido, como se nota pelos arts. 25, 29 e 32 que a reconhecem aos Estados, Municípios e Distrito Federal, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição. É, pois, poder limitado e circunscrito e é nisso que se verifica o equilíbrio da federação, que rege as relações entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos nos termos da Constituição (art. 18). Esse equilíbrio federativo realiza-se por mecanismos instituídos na constituição rígida, entre os quais sobreleva o da *intervenção federal nos Estados* e agora também no *Distrito Federal* e dos *Estados nos Municípios*, que está prevista nos arts. 34 a 36.

2. Natureza da intervenção

A intervenção é ato político que consiste na incursão da entidade interventora nos negócios da entidade que a suporta. Constitui o *punctum*

dolens do Estado federal, onde se entrecruzam as *tendências unitaristas* e as *tendências desagregantes*.¹

Intervenção é antítese da autonomia. Por ela afasta-se momentaneamente a atuação autônoma do Estado, Distrito Federal ou Município que a tenha sofrido. Uma vez que a Constituição assegura a essas entidades a autonomia como princípio básico da forma de Estado adotada, decorre daí que a intervenção é medida excepcional, e só há de ocorrer nos casos nela taxativamente estabelecidos e indicados como exceção ao *princípio da não intervenção*, conforme o art. 34: "A União não intervirá nos Estados *nem* no Distrito Federal, *exceto* para [...]", e o art. 35: "O Estado *não* intervirá em seus Municípios, *nem* a União nos Municípios localizados em Território Federal, *exceto* quando: [...]", arrolando-se em seguida os casos em que é facultada a intervenção estreitamente considerados.

II. INTERVENÇÃO FEDERAL NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL

3. Pressupostos de fundo da intervenção. Casos e finalidades

Os *pressupostos de fundo da intervenção* federal nos Estados constituem situações críticas que põem em risco a segurança do Estado, o equilíbrio federativo, as finanças estaduais e a estabilidade da ordem constitucional. Trata-se de um instituto típico da estrutura do Estado federal que tem por finalidade:

(1) a *defesa do Estado* (País), quando, nos casos do art. 34, I e II, é autorizada a intervenção para: (a) manter a integridade nacional; (b) repelir invasão estrangeira;

(2) a *defesa do princípio federativo*, quando, nos casos do mesmo art. 34, II, III e IV, é facultada a intervenção para: (a) repelir invasão de uma unidade da Federação em outra; (b) pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; (c) garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;

(3) a *defesa das finanças estaduais*, quando, nos casos do art. 34, V, é permitida a intervenção para reorganização das finanças da unidade da Federação que: (a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo força maior;² (b) deixar de

1. Cf. Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, São Paulo, Ed. RT, 1970, pp. 200, 201 e 207.

2. O conceito de *dívida fundada* é jurídico-legal, conforme disposto no art. 98 da Lei 4.320/67: "A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a fi-

entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

(4) a *defesa da ordem constitucional*, quando o art. 34 autoriza a intervenção: (a) no caso do inciso VI, para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; (b) no caso do inciso VII, para exigir a observância dos seguintes princípios constitucionais: (b.1) forma republicana, sistema representativo, regime democrático; (b.2) direitos da pessoa humana; (b.3) autonomia municipal; (b.4) prestação de contas da administração pública, direta e indireta; (b.5) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a procedente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde (EC-29/2000).

4. Pressupostos formais. O ato de intervenção: limites e requisitos

Constituem *pressupostos formais da intervenção*: o modo de sua efetivação, seus limites e requisitos.

A intervenção federal efetiva-se por decreto do Presidente da República, o qual especificará a sua *amplitude, prazo e condições* de execução e, se *couber*, nomeará o *interventor* (art. 36, § 1º). Há, pois, intervenção sem interventor. É que ela pode atingir qualquer órgão do poder estadual. Se for no Executivo, o que tem sido a regra, a nomeação do interventor será necessária, para que exerça as funções do Governador. Se for no Legislativo apenas, tornar-se-á desnecessário o interventor, desde que o ato de intervenção atribua as funções legislativas ao Chefe do Executivo estadual. Se for em ambos, o interventor será também necessário para assumir as funções executivas e legislativas. O decreto de intervenção dependerá:

(1) nos casos dos incisos I, II, III e V, *a e b* do art. 34, da simples verificação dos motivos que a autorizam;

(2) no caso do inciso IV do art. 34, de *solicitação* do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de *requisição* do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;

nanciamentos de obras e serviços públicos". Parágrafo único — "A dívida fundada será escriturada com individualização e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros". Logo, só esse tipo de dívida fundamenta a intervenção na hipótese considerada, se o seu não pagamento não se dever a *força maior*, que também tem o seu conceito legal como "fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir" (CC, art. 1.058, parágrafo único).

(3) no caso de desobediência a ordem ou decisão judicial (inciso VI do art. 34),³ de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a matéria, não se diz no texto, mas evidentemente de conformidade com as regras de competência jurisdicional *ratione materiae*;

(4) no caso do inciso VII do art. 34, de *provimento*, pelo STF, de representação do Procurador-Geral da República; representação, essa, que caracteriza a *ação direta de inconstitucionalidade interventiva* (art. 36, III), a que já nos referimos antes;

(5) no caso de recusa à execução de lei federal, de *provimento* também pelo STF, de representação do Procurador-Geral da República (art. 34, III); aqui não se trata de obter declaração de inconstitucionalidade — portanto essa representação tem natureza diversa da referida na primeira parte do inciso III do art. 36; seu objeto consiste em garantir a executoriedade da lei federal pelas autoridades estaduais; digamos que seja uma *ação de executoriedade da lei*.

Note-se que a EC-45/2004 modificou a redação do inc. III do art. 36 para submeter ao controle do STF a hipótese de recusa à execução de lei federal que constava como de competência do STJ no inc. IV do mesmo artigo, inciso esse que ficou expressamente revogado pela mesma emenda constitucional.

Nos casos dos incisos VI e VII do art. 34, o decreto de intervenção limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade, isto é, se for suficiente para eliminar a infração àqueles princípios constitucionais neles arrolados. Aplica-se o processo estabelecido na Lei 4.337/64, com possibilidade de suspensão liminar do ato impugnado (Lei 5.778/72). Se, porém, a simples suspensão do ato não for bastante, efetivar-se-á a intervenção. Esta não é mera faculdade, mas também um dever que se impõe à União, e, portanto, ao Presidente da República, que terá de executá-la sempre que for necessária, uma vez que se cuida aí de medida de defesa da Constituição, mormente nas hipóteses de requisição dos Tribunais (art. 36, I a IV).

5. Controle político e jurisdicional da intervenção

O decreto de intervenção será submetido pelo Presidente da República à apreciação do Congresso Nacional no prazo de vinte e qua-

3. A Constituição usa no art. 34, VI, a expressão "decisão judicial" e no art. 36, na mesma situação, "decisão judiciária", sem consequência senão a de impropriedade técnica de usar na mesma situação termo diverso que escapou à revisão redacional.

tro horas, que será convocado extraordinariamente, no mesmo prazo, se não estiver funcionando, para conhecer do ato interventivo, dispensada a exigência se a suspensão do ato impugnado houver produzido seus efeitos nos casos de provimento à representação do Procurador-Geral da República (art. 36, §§ 1º a 3º).

É despidendo dizer que o Congresso Nacional não se limitará a tomar ciência do ato de intervenção, pois o decreto interventivo lhe será submetido para *apreciação*, o que envolve julgamento de aprovação e de rejeição, como, aliás, está expressamente estabelecido no art. 49, IV, que lhe dá competência exclusiva para *aprovar* ou *suspender* a intervenção.

Se *suspender a intervenção*, esta passará a ser ato inconstitucional, e deverá cessar imediatamente, pois, se for mantida, constituirá atentado contra os poderes constitucionais do Estado, caracterizando o crime de responsabilidade do Presidente da República previsto no art. 85, II, da Constituição, o qual fica sujeito ao processo e sanções correspondentes.

Controle jurisdicional. Não o há sobre o ato de intervenção nem sobre esta, porque se trata de ato de natureza política insuscetível de controle jurisdicional, salvo manifesta infringência às normas constitucionais, mormente naqueles casos em que a intervenção dependa de *solicitação* do poder coacto ou impedido ou de *requisição* dos Tribunais e elas não tenham sido feitas ou tenham sido feitas irregularmente. Outra hipótese de apreciação jurisdicional da intervenção se dará quando a intervenção tenha sido suspensa pelo Congresso Nacional e ela persista, pois, nesse caso, como dissemos acima, o ato perderá legitimidade e se tornará inconstitucional, sendo pertinente recorrer-se ao Judiciário para garantir o exercício dos poderes estaduais. Haverá também controle jurisdicional em relação aos atos do interventor em termos que veremos logo mais.

6. Cessação da intervenção: consequências

Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a eles voltarão, salvo impedimento legal (art. 36, § 4º). Vale dizer que a intervenção é *ato temporário*, cuja duração há que ficar estabelecida no decreto interventivo, como já dissemos, nos termos do § 1º daquele mesmo artigo. O afastamento das autoridades visa permitir a reposição da normalidade constitucional. Pode ocorrer que, terminado o prazo da intervenção e cessados os seus motivos, as autoridades afastadas estejam legalmente impedidas de voltar às respectivas funções, seja porque já findou seu mandato, seja

porque este foi cassado ou declarado extinto, ou porque tenham renunciado (ou até morrido); ou tenham tido suspensos ou perdidos, nos termos da própria Constituição, seus direitos políticos, o que impede a reassunção dos cargos. Em tais casos, salvo na primeira hipótese, deverão assumi-los aqueles que a Constituição estadual indicar como sucessor: Vice-Governador ou Presidente da Assembleia Legislativa.

7. O interventor. Responsabilidade civil

A *figura do interventor* não fora prevista pela Constituição de 1891. Por isso, graves dissídios doutrinários surgiram sobre sua admissão. O próprio Ruy Barbosa insurgira-se contra ela no caso da intervenção em Mato Grosso em 1906, admitindo-a incoerentemente depois, quando pediu intervenção no Estado do Amazonas. Na verdade, a figura do interventor e sua nomeação pelos poderes da União encontravam justificação jurídica na doutrina dos *poderes implícitos*, segundo a qual, se a Constituição confere um poder expresso para certo fim, há de *implicitamente* oferecer os meios para atingi-lo, caso não o faça explicitamente. Era o caso típico, que afinal venceu na prática constitucional da Primeira República. As demais Constituições instituíram expressamente a figura, incluindo a atual que determina que *o decreto de intervenção o nomeie, se for o caso* (art. 36, § 1º).

Disso decorre que o *interventor é figura constitucional e autoridade federal*, cujas atribuições dependem do *ato interventivo* e das *instruções* que receber da autoridade interventora. Suas funções, limitadas ao ato de intervenção, são *federais*. Mas também pratica atos de governo estadual, dando continuidade à administração do Estado nos termos da Constituição e das leis deste.

Quando, na qualidade de interventor, executa atos e profere decisões que prejudiquem a terceiros, a responsabilidade civil pelos danos causados (art. 37, § 6º) é da União. Mas, no exercício normal e regular da Administração estadual, tal responsabilidade é de imputar-se ao Estado.⁴

III. INTERVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS

8. Fundamento constitucional

O Município, como toda entidade dotada de autonomia, fica também sujeito a intervenção na forma e nos casos previstos na Consti-

4. Cf. Eduardo Espínola, *Constituição dos Estados Unidos do Brasil*, pp. 159 e ss.

tuição. É esta mesma que agora regula os casos e o processo de intervenção dos Estados em seus Municípios e da União nos Municípios localizados nos Territórios Federais (art. 35, quando forem criados outros, porque os dois únicos Territórios que existiam se transformaram em Estados). Não resta mais nada às Constituições Estaduais nessa matéria, ao contrário do que acontecia sob a égide da Constituição precedente.

Toda a doutrina sobre princípios, natureza, pressupostos de fundo e de forma, controle político e jurisdicional, nomeação e responsabilidade de interventor, referida à intervenção federal nos Estados, tem, *mutatis mutandis*, validade aqui, o que nos poupa de repeti-la.

Diversos são os motivos, a competência e pequenos aspectos procedimentais, a que dedicaremos os tópicos seguintes.

9. Motivos para a intervenção nos Municípios

O princípio aqui é também o da não intervenção, de sorte que esta só poderá lícitamente ocorrer nos estritos casos indicados no art. 35, a saber, quando: (1) deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; (2) não forem prestadas contas devidas, na forma da lei (arts. 30, III, e 31); (3) não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção do ensino (cf. art. 212) e nas ações e serviços públicos de saúde (EC-29/2000); (4) o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial, limitando-se o decreto de intervenção a suspender o ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade, o que se faz também com base no processo estabelecido na Lei 4.337/64, com possibilidade de suspensão liminar do ato impugnado (Lei 5.778/72). Acrescente-se apenas que a representação ao Tribunal de Justiça, como peça inicial da ação interventiva no Município, cabe ao Procurador-Geral da Justiça que funcione junto ao Tribunal de Justiça competente para conhecer da representação, seja na intervenção promovida por Estado, seja na promovida pela União em Municípios de Território Federal.

10. Competência para intervir

Compete ao Estado a intervenção em Municípios que se localizem em seu território, que se faz por *decreto* do respectivo Governador, enquanto a intervenção em Município de Território Federal, como

já mencionamos, é da competência da União por *decreto* do Presidente da República. Em qualquer caso, o decreto conterá a designação do interventor (se for o caso), o prazo de duração e os limites da medida, e será submetido à apreciação da Assembléia Legislativa (ou do Congresso Nacional, se Município de Território), no prazo de vinte e quatro horas, devendo ser convocada (ou convocado) extraordinariamente, em igual prazo, se estiver em recesso.

O interventor substituirá o Prefeito e administrará o Município durante o período de intervenção, visando restabelecer a normalidade, prestando contas de seus atos ao Governador (ou ao Presidente da República, se Município de Território), e, de sua administração financeira, ao Tribunal de Contas do Estado (ou da União, *idem*), bem como responderá pelos excessos que cometer. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades municipais afastadas de suas funções a elas retornarão, quando for o caso, sem prejuízo da apuração administrativa, civil ou criminal decorrente de seus atos.

Título II

Do Governo da União

Capítulo I

DA UNIÃO COMO ENTIDADE FEDERATIVA

I. NATUREZA DA UNIÃO: 1. Significado e conceito de União 2. União federal e Estado federal. 3. Posição da União no Estado federal. 4. União e pessoa jurídica de Direito Internacional. 5. União como pessoa jurídica de direito interno. 6. Bens da União. II. COMPETÊNCIAS DA UNIÃO: 7. Noção e classificação. 8. Competência internacional e competência política. 9. Competência administrativa. 10. Competência na área de prestação de serviços. 11. Competência em matéria urbanística. 12. Competência econômica. 13. Competência social. 14. Competência financeira e monetária. 15. Competência material comum. 16. Competência legislativa. III. ORGANIZAÇÃO DOS PODERES DA UNIÃO: 17. Poderes da União. 18. Sistema de governo.

I. NATUREZA DA UNIÃO

1. Significado e conceito de União

A União surge, no Direito Constitucional, ao lado dos Estados federados, como entidade essencialmente federativa. O designativo União bem poderia levar a pensar nela como uma associação das demais entidades autônomas, mas a leitura do art. 1º da Constituição dissuade esse entendimento ao declarar que a República Federativa do Brasil é que se forma da união dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Sucede que aí fica parecendo que a União se confunde com a República Federativa do Brasil, já que não é mencionada no dispositivo. Desfaz-se tal impressão ao exame do art. 18, que estabelece que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição. Aí ela é considerada como uma das entidades que compõem a República Federativa.

Existe tendência em identificar União e Federação. A União é que se constitui pela congregação das comunidades regionais autônomas que vêm a ser os Estados-membros. Então quando se fala em Federa-

ção se refere à *união* dos Estados. No caso brasileiro, seria a união dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Por isso se diz *União Federal*, que assim seria a federação de Estados, Distrito Federal e Municípios, não como associação de Direito Internacional, porque não se constituiria com base num pacto de Estados soberanos, mas de Direito Constitucional, visto que o nosso sistema federal se organizou como técnica constitucional de descentralização do Estado unitário.

A *União* é a entidade federal formada pela reunião das partes componentes, constituindo pessoa jurídica de Direito Público interno, autônoma em relação às unidades federadas (ela é unidade federativa, mas não é unidade federada) e a que cabe exercer as prerrogativas da soberania do Estado brasileiro. *Estado federal*, com o nome de *República Federativa do Brasil*, é o todo, ou seja, o complexo constituído da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dotado de personalidade jurídica de Direito Público internacional.

2. União federal e Estado federal

O território da União abrange todo o território físico estatal. O Estado chamado República Federativa do Brasil, entidade de Direito das Gentes, e a União, entidade de Direito Constitucional, têm o mesmo domínio territorial físico. Mas, em sentido jurídico, o território estatal brasileiro, o território como âmbito de validade da ordem jurídica do Estado federal, é mais amplo do que o território da União. Quer dizer, a ordem jurídica do Estado federal — da República Federativa do Brasil — é mais do que a ordem jurídica da União, porquanto abrange também as ordens jurídicas particulares das unidades regionais e locais autônomas. Ora, a ordem jurídica da União difere das ordens jurídicas dos Estados federados e dos Municípios.

A população constitutiva do Estado brasileiro é a mesma sobre que domina a ordem jurídica da União. Mas, porque a ordem jurídica daquele se forma de todas as ordens jurídicas particulares vigentes no interior do País, sua eficácia é mais do que a eficácia da ordem jurídica da União. A eficácia e a validade vertical, por assim dizer, da ordem jurídica da União só presidem aos fatos sobre que incide sua competência. A eficácia e a validade vertical da ordem jurídica do Estado federal, ao contrário, regem toda a vida no interior do País, porque abrangem a competência da União e a das demais unidades autônomas referidas no art. 18.

3. Posição da União no Estado federal

A essa altura, podemos delinear a posição da União no Estado federal. Constitui ela aquele aspecto unitário que existe em toda or-

ganização federal. Com efeito, todo Estado federal se forma de elementos unitários e de elementos federativos (disjuntivos). Se não houver elementos unitários, não será *um só* Estado, serão vários, não teremos *uma forma* de Estado, mas um conjunto de Estados, como entidades soberanas. São, conseqüentemente, esses elementos unitários que dão à federação sua essência de Estado, como instituição de Direito Internacional.

Todo Estado federal compreende, outrossim, elementos disjuntivos, que importam certos aspectos separativos do conjunto. Tais elementos são os federativos, porque se congregam, separadamente, numa União, e dão essência federal à forma de Estado. Se não existirem tais elementos, não será Estado federal.

O Estado federal é, assim, caracterizado por essas duas tendências: a *unitária* representada pela União e a *disjuntiva* (federativa) representada pelos Estados federados. O Estado federal significa a síntese jurídica de um processo político-social caracterizado, pois, pela antítese disjunção-integração. A tensão entre esses dois aspectos contraditórios tem proporcionado, ao longo de nossa história, as variações do federalismo brasileiro. Ora predominando a disjunção do estadualismo da Primeira República, ora a integração no centralismo do regime de 1964-1988. Espera-se que a Constituição de 1988 tenha encontrado o ponto de equilíbrio.

4. União e pessoa jurídica de Direito Internacional

A União, como mencionamos, é entidade de Direito Constitucional, não sendo certo que se caracterize também como pessoa jurídica de Direito Internacional. Isso, às vezes, se diz, tendo em vista que é pela União que a República Federativa do Brasil se representa nas relações internacionais. Isso quer apenas dizer que as relações internacionais do Estado brasileiro constituem matéria de competência exclusiva da União. Os Estados federados não dispõem dessa faculdade. São os órgãos da União que representam o Estado federal nos atos de Direito Internacional, porque o Presidente da República (Federativa do Brasil) é, a um tempo, Chefe do Estado brasileiro e Chefe do Governo Federal (Governo da União) — Chefe do Poder Executivo da União (art. 2º). Não é, realmente, a União que aparece nos atos internacionais, mas a República Federativa do Brasil, de que ela é apenas uma das entidades componentes (art. 18).

O Estado federal — a República Federativa do Brasil — é que é a pessoa jurídica de Direito Internacional. Na verdade, quando se diz que a União é pessoa jurídica de Direito Internacional, não se está dizendo bem, mas quer-se referir a duas coisas: (a) as relações internacio-

nais da República Federativa do Brasil realizam-se por intermédio de órgãos da União, integram a competência desta, conforme dispõe o art. 21, incs. I a IV;¹ (b) os Estados federados não têm representação nem competência em matéria internacional, nem são entidades reconhecidas pelo Direito Internacional, são simplesmente de direito interno.

5. União como pessoa jurídica de direito interno

Diversa é a situação quando encaramos a União sob o prisma do direito interno. É uma entidade de Direito Constitucional, porque criação deste, mas é também *pessoa jurídica de Direito Público interno* (CC, art. 14, I).

Nessa qualidade, é titular de direitos e sujeito de obrigações. Está sujeita, como qualquer pessoa, à responsabilidade pelos atos que pratica por seus órgãos e agentes e pode ser submetida aos Tribunais, como órgãos jurisdicionais do Estado. Como tal, tem seu domicílio na Capital Federal (art. 18, § 1º). Todavia, para fins processuais, a Constituição estabelece regras de foro especiais conforme seja autora ou ré (art. 109, §§ 1º a 4º).

6. Bens da União

Ainda como pessoa jurídica de Direito Público interno, a União é titular de direito real, e pode ser titular de direitos pessoais. O art. 98 do Código Civil declara que os bens públicos são os do domínio público nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. E o art. 20 da Constituição estatui que são *bens da União*: (1) os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; (2) as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; (3) os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; (4) as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e

1. Diz o art. 21: "Compete à União: I — manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais; II — declarar a guerra e celebrar a paz; III — assegurar a defesa nacional; IV — permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente". Essas disposições conjugam-se com o disposto no art. 49, I e II, e no art. 84, VII, VIII, XIX, XX e XXII, respectivamente sobre a competência do Congresso Nacional e do Presidente da República nessa matéria.

as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as áreas referidas no art. 26, II; (5) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; (6) o mar territorial; (7) os terrenos de marinha e seus acrescidos; (8) os potenciais de energia hidráulica; (9) os recursos minerais, inclusive os do subsolo; (10) as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; (11) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

II. COMPETÊNCIAS DA UNIÃO

7. Noção e classificação

Na teoria do federalismo costuma-se dizer que a repartição de *poderes autônomos* constitui o núcleo do conceito do Estado federal. “Poderes”, aí, significa a porção de matérias que a Constituição distribui entre as entidades autônomas e que passam a compor seu campo de atuação governamental, suas áreas de competência. *Competências* são, assim, as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções. *Competência*, vimos antes, consiste na esfera delimitada de poder que se outorga a um órgão ou entidade estatal, mediante a especificação de matérias sobre as quais se exerce o poder de governo.

A União ficou ainda bem aquinhoadada na partilha das competências federativas. Dispõe de *competência material exclusiva* conforme ampla enumeração de assuntos no art. 21, de *competência legislativa privativa* consoante discriminação constante do art. 22, de *competência comum* com Estados, Distrito Federal e Municípios arrolada no art. 23 e, ainda, de *competência legislativa concorrente* com os Estados sobre temas especificados no art. 24.

Tentaremos organizar a matéria sob outro critério, distinguindo as áreas de competência da União em *internacional*, *política*, *administrativa*, *prestação de serviços*, *urbanística*, *econômica*, *social*, *financeira* e *legislativa*, consoante se estudará nos tópicos subseqüentes.

8. Competência internacional e competência política

Competência internacional. É a que está indicada no art. 21: manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais; declarar a guerra e celebrar a paz; assegurar a defesa nacional; permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permane-

çam temporariamente. Cumpre mencionar, de passagem, que essas relações não que atender os princípios consignados no art. 4º.²

Competência política. Como *atribuição de natureza política de competência exclusiva* da União são enumeradas as seguintes: (a) o seu poder de decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal nos Estados e Municípios dos Territórios;³ (b) o seu poder de conceder anistia;⁴ (c) o seu poder de legislar sobre direito eleitoral.⁵

9. Competência administrativa

Entram na competência exclusiva da União as seguintes *atribuições administrativas*: (a) autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico; (b) administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada (administrativo-financeiro-monetária); (c) organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; (d) organizar e manter a polícia federal, as polícias rodoviária e ferroviária federais, bem como a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios (arts. 21, XIV, e 144, §§ 1º, 2º e 3º, conforme EC-19/98); (e) prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos, por meio de fundos próprios (art. 21, XIV, conforme EC-19/98); (f) organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional; (g) exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão; (h) planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações; (i) instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso; (j) organizar, manter e executar a inspeção do trabalho.⁶ Além disso, fazem parte de sua competência todas as funções administrativas decorrentes de sua organização, tais como as relativas a seu funcionalismo, seus serviços e órgãos.

10. Competência na área de prestação de serviços

Além da exploração e execução de serviços públicos decorrentes de sua natureza de entidade estatal, a Constituição conferiu à

2. Art. 21, I a IV.

3. Art. 21, V, c/c os arts. 34-35 e 136-137.

4. Art. 21, XVII.

5. Art. 22, I.

6. Art. 21, VI, VIII, XIII a XVI, XVIII, XIX e XXIV.

União, em caráter exclusivo, a competência para explorar determinados serviços que reputou públicos, tais como: (a) manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; (b) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais (EC-8/95); (c) explorar, igualmente mediante autorização, concessão ou permissão: (c.1) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; (c.2) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; (c.3) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; (c.4) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; (c.5) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; (c.6) os portos marítimos, fluviais e lacustres; (d) explorar os serviços de instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios: (d.1) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional; (d.2) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas; (d.3) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa.⁷

Faremos rápido esclarecimento sobre a matéria constante do art. 21, XI e XII (letras *b* e *c*, supra). Primeiro, para esclarecer que a EC-8/95 deu nova redação ao inc. XI e à alínea *a* do inc. XII e, com isso, mudou o regime de exploração dos serviços de telecomunicações, suprimindo o regime de monopólio da União para explorar, por si ou por empresa estatal, os serviços de telecomunicações em geral, razão por que também retirou da alínea *a* do inc. XII a referência a “demais serviços de telecomunicações”, que tinham ficado fora do regime de monopólio; uniformizou-se, desse modo, o regime de exploração dos serviços de telecomunicações, concentrados no inc. XI, enquanto os demais serviços de utilidade pública estão previstos no inc. XII. Segundo, para observar que o tratamento da matéria em incisos diferentes ainda se justifica, porquanto o texto passou a exigir regime especial de organização dos serviços de telecomunicação, nos termos de lei, inclusive com a criação de um órgão regulador e de outros aspectos institucionais,

o que não se aplica aos serviços referidos no inc. XII. Terceiro, para dar algumas definições ainda pertinentes, indispensáveis à compreensão do texto. As definições são as do Código de Telecomunicações, para o qual constituem *serviços de telecomunicações* a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético (CT, art. 4º). *Telefonia* é o processo de telecomunicação destinado à transmissão da palavra falada ou de sons, enquanto *telegrafia* é o processo de telecomunicação destinado à transmissão de escritos, pelo uso de código de sinais (CT, art. 4º). *Telecomunicação* é gênero que compreende todas as formas de comunicação à distância, por processos de telegrafia, telefonia, radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Os *serviços públicos* de telecomunicações são de duas espécies: (a) *serviço público em geral*, o destinado ao público em geral; (b) *serviço público restrito*, o que é facultado ao uso dos passageiros dos navios, aeronaves, veículos em movimento ou ao uso do público em localidades ainda não servidas por serviço público em geral (Código de Telecomunicações, art. 6º, *a* e *b*); cumpre notar que esse Código parece compreender como serviço público de telecomunicação apenas o geral, à vista do disposto no final da alínea *b* do art. 6º. Parece-nos, no entanto, que, à vista do texto constitucional, também o *restrito* se inclui no conceito de serviços públicos de telecomunicações ali mencionado, desde que seu uso pelos passageiros se destine a comunicação com o público em geral, e não apenas dentro das unidades da empresa transportadora. Assim é, porque a telecomunicação intra-órgão ou intra-unidades de uma empresa se classifica como *serviço limitado*, ou seja, o executado por estações não abertas à correspondência pública e destinado ao uso de pessoas físicas ou jurídicas nacionais, tais como: (a) o de segurança, regularidade, orientação e administração dos transportes em geral; (b) o de múltiplos destinos; (c) o serviço rural; (d) o de serviço privado (Código de Telecomunicações, art. 6º, *c*).

11. Competência em matéria urbanística

Nesse campo, são de apontar a competência da União para: (a) elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território; (b) instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; (c) estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação. Além disso, encontramos a competência não exclusiva para: proteger obras e bens de valor histórico e cultural (de natureza urbanística, se imóveis), paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, bem como o meio ambiente, e combater a poluição, competência esta que tem seu conteúdo preenchido com as prescrições constantes dos arts. 215,

7. Art. 21, X, XII e XXIII.

216 e 225. E, ainda, lhe cabe a competência concorrente com os Estados e Distrito Federal para legislar sobre direito urbanístico.⁸

12. Competência econômica

No *setor econômico*, cabe à União: (a) elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico; (b) estabelecer áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa; (c) intervir (sem exclusividade) no domínio econômico, explorar (sem exclusividade) atividade econômica e reprimir abusos do poder econômico; (d) explorar direta ou indiretamente a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica; (e) o monopólio da pesquisa, lavra e refinação de petróleo, assim como o da importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes daquelas atividades monopolizadas; (f) o monopólio da pesquisa e lavra de gás natural e outros hidrocarbonetos; (g) o monopólio do transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; (h) o monopólio da pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados; (i) a desapropriação por interesse social de imóvel rural para fins de reforma agrária nos termos dos arts. 184 a 186; (j) planejar e executar, na forma da lei, a política agrícola;⁹ (k) legislar (sem exclusividade) sobre produção e consumo.¹⁰

13. Competência social

No *setor social*, a Constituição reservou grandes tarefas à União, como: (a) elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvimento social; (b) planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações; (c) organizar a seguridade social; (d) estabelecer políticas sociais e econômicas visando proteger e recuperar a saúde do povo; (e) regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde; (f) estabelecer o sistema único de saúde; (g) estabelecer e executar planos de previdência social; (h) manter serviços de assistência social aos necessitados; (i) estabelecer, por lei, o plano nacional de educação; (j) enfim, legislar sobre direito social em suas várias manifestações.¹¹

14. Competência financeira e monetária

A administração financeira continuará, na vigência da Constituição de 1988, sob o comando geral da União, já que a ela cabe legislar sobre normas gerais de Direito tributário e financeiro e sobre orçamento,¹² restando aos Estados, Distrito Federal e Municípios a legislação suplementar.

Assim é que à União compete: (a) emitir moeda e legislar sobre sistema monetário; (b) administrar reservas cambiais e fiscalizar as operações de natureza financeira, de crédito, câmbio e capitalização;¹³ (c) instituir os tributos previstos nos arts. 145, 153 e 154, de que trataremos em separado, quando formos estudar o sistema tributário nacional; (d) estabelecer plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, de que cuidaremos quando formos examinar as bases constitucionais dos orçamentos públicos e demais assuntos financeiros.¹⁴

15. Competência material comum

Muitos dos assuntos do setor social, especialmente, referidos antes como de competência da União, não lhe cabem com exclusividade. A Constituição abriu a possibilidade de Estados, Distrito Federal e Municípios compartilharem com ela da prestação de serviços nessas matérias, mas, principalmente, destacou um dispositivo (art. 23), onde arrola temas de competência comum, tais como: (a) zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público; (b) cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (c) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; (d) impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; (e) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; (f) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; (g) preservar as florestas, a fauna e a flora; (h) fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; (i) promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; (j) combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

8. Arts. 21, IX, XX e XXI; 23, IV e VI; 24, I.

9. Arts. 21, IX e XXV; 172 a 174; 177; 184 a 186 e 187.

10. Art. 24, V.

11. Arts. 6º; 7º; 21, IX e XVIII; 194; 197 a 198; 200; 201; 203 e 214.

12. Arts. 24, I, e § 1º, 146 e 163.

13. Arts. 21, VII e VIII, e 22, VI.

14. Art. 165.

(k) registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; (l) estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

16. Competência legislativa

Toda a matéria de competência da União é suscetível de regulamentação mediante lei (ressalvado o disposto nos arts. 49, 51 e 52), conforme dispõe o art. 48 da Constituição. Mas os arts. 22 e 24 especificam seu campo de competência legislativa, que consideraremos em dois grupos: a *privativa* e a *concorrente*.

(A) *Competência legislativa privativa sobre*:¹⁵

(1) *Direito administrativo*: (a) desapropriação; (b) requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra; (c) água, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; (d) serviço postal; (e) sistema monetário (administrativo-monetário) e de medidas, títulos e garantias dos metais; (f) política de crédito, câmbio, seguros e transferências de valores (administrativo-monetário); (g) diretrizes da política nacional de transportes (administrativo-urbanístico); (h) jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (administrativo-minerário); (i) regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial; (j) trânsito e transporte; (k) emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros; (l) organização do sistema nacional de emprego (administrativo-social); (m) organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como a organização administrativa destes; (n) sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais; (o) sistemas de poupança, captação de recursos e garantia da poupança popular (administrativo-monetário); (p) sistema de consórcios e sorteios (administrativo-monetário); (q) competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federal; (r) registros públicos; (s) atividades nucleares de qualquer natureza; (t) defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional.

(2) *Direito material não administrativo*: civil, comercial (incluindo comércio exterior e interestadual, e propaganda comercial), penal, político-eleitoral, incluindo nacionalidade, cidadania e naturalização,

15. Corrigimos, aqui, uma impropriedade que aparecia em edições anteriores, em face do que ficou dito à p. 480, nota 5, sobre a competência privativa, conforme dispõe o art. 22 da Constituição. De fato, a matéria aqui arrolada, segundo aquele dispositivo, é de competência *privativa*, e não de competência *exclusiva*.

agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; populações indígenas; condições para o exercício de profissões; seguridade social.

(3) *Direito processual*: civil, penal, trabalhista etc.

(B) *Competência concorrente com Estados e Distrito Federal* sobre (art. 24, I a XVI): Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; orçamento; juntas comerciais; custas dos serviços forenses; produção e consumo; florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; educação, cultura, ensino e desporto; criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; procedimento em matéria processual; previdência social, proteção e defesa da saúde; assistência jurídica e defensoria pública; proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; proteção à infância e à juventude; organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

A legislação concorrente da União sobre as matérias indicadas supra se limitará a estabelecer *normas gerais*. Nisso a Constituição foi, às vezes, redundante. Por exemplo, no art. 22, XXIV, dá como privativo da União legislar sobre *diretrizes e bases da educação nacional*, enquanto, no art. 24, IX, combinado com o § 1º, declara caber-lhe legislar sobre *normas gerais de educação*. Não há nisso incoerência, como pode parecer. Legislar sobre *diretrizes e bases* da educação nacional e sobre *normas gerais* de educação somam, no fundo, a mesma coisa. A tradição arrastou os educadores da Constituinte a manter a regra que vem de 1946, que dava competência à União para legislar sobre *diretrizes e bases da educação nacional*, mas também não poderiam deixar de incluir na competência comum *legislar sobre educação*, situação em que a União só tem poderes para fixar normas gerais. Tudo somado, dá na mesma, com um dispositivo a mais sem necessidade. Por outro lado, foi omissa, quando deu à União competência privativa para legislar sobre *normas gerais*: (a) de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros (art. 22, XXI); (b) de licitação e contratação, em todas as modalidades, nas diversas esferas de governo, para a Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III (art. 22, XXVII). No entanto, não inseriu a matéria no art. 24, para indicar que Estados podem legislar também sobre essas matérias, como fez, por exemplo, relativamente à polícia civil. Não é, porém, porque não consta

na competência comum que Estados e Distrito Federal (este não sobre polícia militar, que não é dele) não podem legislar suplementarmente sobre esses assuntos. Podem e é de sua competência fazê-lo, pois que nos termos do § 2º do art. 24, a competência da União para legislar sobre *normas gerais* não exclui (na verdade até pressupõe) a competência suplementar dos Estados (e também do Distrito Federal, embora não se diga aí), e isso abrange não apenas as normas gerais referidas no § 1º desse mesmo artigo no tocante à matéria neste relacionada, mas também as *normas gerais* indicadas em outros dispositivos constitucionais, porque justamente a característica da *legislação principiológica* (normas gerais, diretrizes, bases), na repartição de competências federativas, consiste em sua correlação com competência suplementar (complementar e supletiva) dos Estados.

Tanto isso é uma técnica de repartição de competência federativa que os §§ 3º e 4º complementam sua normatividade, estabelecendo, em primeiro lugar, que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades, e, em segundo lugar, que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária. Note-se bem, o constituinte foi técnico: a lei federal superveniente não revoga a lei estadual nem a derroga no aspecto contraditório, esta apenas perde sua aplicabilidade, porque fica com sua eficácia suspensa. Quer dizer, também, sendo revogada a lei federal pura e simplesmente, a lei estadual recobra sua eficácia e passa outra vez a incidir.¹⁶

Ainda uma observação. A Constituição não situou os Municípios na área de competência concorrente do art. 24, mas lhes outorgou competência para *suplementar a legislação federal e a estadual no que couber*, o que vale possibilitar-lhes disporem especialmente sobre as matérias ali arroladas e aquelas a respeito das quais se reconheceu à União apenas a normatividade geral.

III. ORGANIZAÇÃO DOS PODERES DA UNIÃO

17. Poderes da União

Como entidade de Direito Público interno e como entidade político-federativa, a União possui seus órgãos próprios, seus Poderes Públicos, seu sistema de governo e sua organização política fundada no princípio da divisão de poderes nos termos do art. 2º, segundo o

16. Acolhe a Constituição doutrina que vínhamos sustentando desde a 1ª edição deste livro (Ed. RT, 1976, p. 66) até a última antes de sua promulgação (4ª ed., 2ª tiragem, Ed. RT, 1988. pp. 57 e 58).

qual são *Poderes da União*, independentes e harmônicos entre si, o *Legislativo*, o *Executivo* e o *Judiciário*. Já estudamos o significado teórico-doutrinário desse princípio, não cabendo aqui senão apenas destacá-lo em relação à União, visto como a estrutura, organização e funcionamento de cada um desses Poderes políticos serão objeto de consideração nos capítulos subseqüentes deste título.

18. Sistema de governo

Sistemas de governo são técnicas que regem as relações entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo no exercício das funções governamentais. O modo como se estabelece esse relacionamento, de sorte a preponderar maior independência ou maior colaboração entre eles, ou a combinação de ambos numa assembléia, dá origem aos três sistemas básicos: o presidencial (*presidencialismo, que é o sistema de governo da União e do Brasil*), o parlamentar (*parlamentarismo*) e o convencional (*de assembléia*).¹⁷

Neste último, ocorre o domínio do sistema político pela Assembléia, não havendo Executivo separado, e, se existe um Chefe de Estado, ele é figura decorativa, nem há governo separado, porque este é exercido por uma Comissão da Assembléia. Os exemplos são os da Suíça, da antiga URSS, da Polônia, da Hungria, da Romênia e da Bulgária (não com pureza).¹⁸

O *parlamentarismo* e o *presidencialismo* são sistemas predominantes. Desenvolve-se tendência universal para sistemas mistos que combinam instituições de ambos.

Presidencialismo. É um sistema de governo que tem as seguintes características: (a) é típico das Repúblicas; (b) o Presidente da República exerce o Poder Executivo em toda a sua inteireza; acumula as funções de Chefe do Estado, Chefe do Governo e Chefe da Adminis-

17. Sobre o assunto em geral, cf. Douglas V. Verney, *Análisis de los sistemas políticos*, Madrid, Tecnos, 1961, trad. de Mariano Berdejo Rivera; J. Ferrando Badía (org.), *Regímenes políticos actuales*, Madrid, Tecnos, 1985; Jorge Carpizo, *El presidencialismo mexicano*, 2ª ed., México, Siglo Veintiuno Ed., 1979; Edward D. Corwin, *El poder ejecutivo*, Buenos Aires, Ed. Bibliográfica Argentina, 1959, sobre presidencialismo norte-americano; Afonso Arinos de Melo Franco e Raul Pilla, *Presidencialismo ou parlamentarismo?*, Rio de Janeiro, José Olympio Ed., 1958; Miguel Reale, *Parlamentarismo brasileiro*, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1962; Raymundo Farias de Oliveira, *Parlamentarismo: plenitude democrática*, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1985; Jorge R. Vanossi, *Presidencialismo y parlamentarismo en el Brasil*, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1964.

18. Cf. Douglas V. Verney, *ob. cit.*, pp. 63 e ss.

tração Pública; cumpre um mandato por tempo fixo; não depende da confiança do órgão do Poder Legislativo nem para a sua investidura, nem para o exercício do governo; (c) o órgão do Poder Legislativo (Congresso, Assembléia, Câmara) não é Parlamento; seus membros são eleitos por período fixo de mandato; não está sujeito a dissolução; (d) as relações entre ambos os poderes são mais rígidas, prevalecendo o princípio da divisão de poderes independentes e autônomos, embora possam ser harmônicos; (e) os Ministros de Estado são simples auxiliares do Presidente da República que os nomeia e exonera ao seu livre alvedrio (salvo injunções políticas); agem, cada qual, como chefe de um grande departamento administrativo, o seu Ministério, exercendo suas funções, cada qual por si, isoladamente; o Ministério (conjunto dos Ministros) não tem organicidade, despachando cada Ministro com o Presidente da República sobre seus problemas, sem levar em conta as conexões com os outros; (f) eventual plano de governo, mesmo quando aprovado por lei, depende exclusivamente da coordenação do Presidente da República, que o executará ou não, bem ou mal, sem dar satisfação jurídica a outro poder (a não ser em prestações de contas financeiras e orçamentárias anuais, *a posteriori*); e se o executa mal, ou mesmo não o executa, continuará Presidente da República e os Ministros continuarão Ministros enquanto de sua confiança. Só se deve ter como sistema presidencialista aquele que tenha tais características e mais a investidura democrática das autoridades governamentais políticas: Presidente e Parlamentares. Se houver um Presidente da República que seja ditador ou com predominância autoritária sobre os demais Poderes, então tem-se sistema ditatorial e não presidencialismo.

Parlamentarismo. É o sistema de governo que tem as seguintes características: (a) é típico das monarquias constitucionais, de onde se estendeu às Repúblicas européias; (b) o Poder Executivo se divide em duas partes: um Chefe de Estado, exercido pelo Monarca ou pelo Presidente da República; e um Primeiro-Ministro ou Presidente do Conselho como Chefe do Governo que é exercido pelo Conselho de Ministros; (c) o governo é assim um corpo coletivo orgânico, de sorte que as medidas governamentais implicam a atividade de todos os Ministros e seus Ministérios; (d) o Primeiro-Ministro é indicado (ou mesmo nomeado) pelo Presidente da República; os demais Ministros são indicados ou nomeados pelo Primeiro-Ministro, ou indicados por este e nomeados pelo Presidente da República, mas sua investidura definitiva, como a sua permanência posterior nos cargos, depende da confiança da Câmara dos Deputados (às vezes, também do Senado); (e) a aprovação do Primeiro-Ministro e de seu Con-

selho de Ministros pela Câmara se faz pela aprovação de um plano de governo por eles apresentado, o que vale dizer que a Câmara assume responsabilidade de governo, aprovando o plano, empenhando-se assim politicamente perante o povo; (f) o Poder Legislativo assume no parlamentarismo funções político-governamentais mais amplas, e se transforma em Parlamento, na medida em que compreende também os membros do governo: Primeiro-Ministro e Conselho de Ministros, sejam ou não parlamentares; (g) o governo é responsável ante o Parlamento (Câmara dos Deputados), o que significa que o governo depende de seu apoio e confiança para governar; (h) o Parlamento é responsável perante os eleitores, de sorte que a responsabilidade política se realiza do governo para com o Parlamento e deste para com o povo; (i) significa que, se o Parlamento retirar a confiança no governo, ele cai, exonera-se, porque não tem mandato, nem investidura a tempo certo, mas investidura de confiança; perdida esta, que pode decorrer de um voto de censura ou moção de desconfiança, exonera-se, para dar lugar à constituição de outro governo; (j) mas, em vez da exoneração dos membros do governo que perdeu a confiança do Parlamento, pode-se preferir apurar a confiança do povo e, então, se utiliza o mecanismo da dissolução da Câmara, convocando-se eleições extraordinárias para a formação de outro Parlamento em torno do tema ou da questão de governo que gerou a crise, crise esta que se resolve politicamente, sem trauma, porque a flexibilidade do sistema possibilita mecânica adequada à solução de tensões políticas.

Convém observar, no entanto, que as quedas de Conselhos de Ministros no parlamentarismo contemporâneo ocorrem menos pela falta de confiança parlamentar, menos em decorrência de moção de censura e de desconfiança, do que pelo desfazimento de coligações partidárias que os sustentam.

Mas é certo que o sistema presidencialista não é institucionalmente apto para enfrentar graves situações de crise, para promover um consenso a partir de conflitos sociais ou políticos sérios, para controlar o exercício do poder sem obstáculo e para assegurar eficiência na tomada de decisões, conseqüentemente nem para assegurar a estabilidade, a continuidade e a eficácia de uma democracia pluralista, como a que foi instituída na Constituição. Tem sido notoriamente incapaz de canalizar soluções de crises. A concentração de poder no Presidente atrai as graves crises para a sua pessoa, com profundo desgaste pessoal, às vezes, fatal. A personalização do poder, por si, determina um dos problemas mais cruciantes e nunca bem resolvido: o problema da sucessão presidencial. Isso tudo sem falar das dificul-

dades de relacionamento entre Executivo e Legislativo nesse sistema, mormente num sistema multipartidário.¹⁹

Não nos parece, porém, que as crises brasileiras sejam devidas ao presidencialismo como soem afirmar, até porque prévio a isso se ergue a indagação, visando a saber se temos tido presidencialismo no Brasil, ou simples deformação dele, com pequenas exceções no período de 1946-1964. As crises, no mais das vezes, têm razões mais profundas. O que é plausível sustentar é que a rigidez do sistema as agrava ou, no mínimo, dificulta sua solução. O parlamentarismo dispõe de maleabilidade que ajuda a solucionar crises de poder; “o parlamentarismo, em verdade [diz bem Miguel Reale], não apresenta uma solução de problemas substanciais, mas antes um processo prático para encontrar e facilitar soluções”.²⁰ Estamos de pleno acordo com o ínclito filósofo do Direito quando, desdobrando aquela reflexão, escreve as seguintes palavras que, vindo da lavra de convicto parlamentarista, deveriam ser sempre lembradas pelos demais: “Parlamentarismo ou presidencialismo por si sós não resolvem os problemas do País. São simples peças ou instrumentos de ação política. Os problemas fundamentais da Nação devem ser tratados como tais, como problemas fundamentais. Não devemos dar ao presidencialismo ou ao parlamentarismo importância decisiva. Para mim são meras técnicas de composição do Governo, que envolvem outras questões básicas e outras atitudes não menos relevantes. Estas sim é que devem merecer mais diuturnamente os nossos cuidados e preocupações”.²¹

19. Sobre essa temática, cf. Consejo para la Consolidación de la Democracia (org.), *Reforma constitucional*, pp. 11 e ss.

20. *Ob. cit.*, p. XVII.

21. *Ibidem*, pp. 56 e 57.

Capítulo II

DO PODER LEGISLATIVO

I. ORGANIZAÇÃO: 1. O Congresso Nacional. 2. A Câmara dos Deputados. 3. O Senado Federal. 4. Organização interna das Casas do Congresso: Regimento Interno. Mesa. Comissões. Polícia. Serviços administrativos. 5. Comissão representativa. II. FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES: 6. Funcionamento do Congresso Nacional: Legislatura. Sessões legislativas. Reuniões. “Quórum” para deliberações. 7. Atribuições do Congresso Nacional. 8. Atribuições privativas da Câmara dos Deputados. 9. Atribuições privativas do Senado Federal. 10. Convocação e comparecimento de Ministros. III. PROCESSO LEGISLATIVO: 11. Conceito e objeto. 12. Atos do processo legislativo: Iniciativa legislativa. Emendas. Votação. Sanção e veto. Promulgação e publicação da lei. 13. Procedimentos legislativos: Procedimento legislativo ordinário. Procedimento legislativo sumário. Procedimentos legislativos especiais. IV. ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS: 14. Conteúdo. 15. Prerrogativas: Inviolabilidade Imunidade. Privilégio de foro. Isenção do serviço militar. 16. Direitos: Subsídio. 17. Incompatibilidades. 18. Perda do mandato: Cassação. Extinção.

I. ORGANIZAÇÃO

1. O Congresso Nacional

A função legislativa de competência da União é exercida pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, integrados respectivamente por Deputados e Senadores.

É da tradição constitucional brasileira a organização do Poder Legislativo em dois ramos, sistema denominado *bicameralismo*, que vem desde o Império, salvo as limitações contidas nas Constituições de 1934 e 1937, que tenderam para o *unicameralismo*, sistema segundo o qual o Poder Legislativo é exercido por uma única câmara. Debate-se muito sobre as vantagens e desvantagens de um ou de outro sistema. Mas a dogmática constitucional, desde a promulgação da Constituição dos EUA, recusa aceitar o unicameralismo nas federações, por entender que o Senado é câmara representativa dos Estados federados, sendo, pois, indispensável sua existência ao lado de uma câmara representativa do povo. Diz-se, em prol disso, que os “Estados Federais apresentam uma estrutura dualista. De uma parte, deve estar presente a nação, em sua unidade global, de outra parte,

te, os Estados-membros da federação, com sua autonomia particular".¹ Existe bicameralismo também em Estados unitários. Tem-se o bicameralismo como um sistema mais propício ao conservadorismo, enquanto o unicameralismo favoreceria os avanços democráticos, na medida em que canaliza e exprime melhor os anseios da soberania popular por transformações.

No bicameralismo brasileiro, não há predominância substancial de uma câmara sobre a outra. Formalmente, contudo, a Câmara dos Deputados goza de certa primazia relativamente à iniciativa legislativa, pois é perante ela que o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e os cidadãos promovem a iniciativa do processo de elaboração das leis (arts. 61, § 2º, e 64).

2. A Câmara dos Deputados

O ramo popular do Poder Legislativo federal é a Câmara dos Deputados. Compõe-se de representantes do povo, eleitos em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal pelo *sistema proporcional*. Quer dizer, como já observamos, cada uma dessas entidades territoriais forma uma circunscrição eleitoral dos Deputados Federais.

A Constituição não fixa o número total de Deputados Federais, deixando isso e a representação por Estado e pelo Distrito Federal para serem estabelecidos por lei complementar, que terá de fazê-lo em proporção à população, determinando reajustes pela Justiça Eleitoral, em cada ano anterior às eleições, de modo que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados. Essa regra que consta do art. 45, § 1º, é fonte de graves distorções do sistema de representação proporcional nele mesmo previsto para a eleição de Deputados Federais, porque, com a fixação de um mínimo de oito Deputados e o máximo de setenta, não se encontrará meio de fazer uma proporção que atenda o *princípio do voto com valor igual para todos*, consubstanciado no art. 14, que é aplicação particular do princípio democrático da igualdade em direitos de todos perante a lei. É fácil ver que um Estado com quatrocentos mil habitantes terá oito representantes enquanto um de trinta milhões terá apenas setenta, o que

1. Cf. Union Interparlementaire (org.), *Parlements*, p. 5; no mesmo sentido, Maurice Duverger, *Droit constitutionnel et institutions politiques*, v. I/141. Sobre o tema já discorremos amplamente no nosso *Princípios do processo de formação das leis no direito constitucional*, São Paulo, RT, 1961, pp. 61 a 73, onde expusemos os argumentos pró e contra, e demos nossa opinião contrária ao bicameralismo, mesmo no Estado Federal, achando que, no moderno sistema de partidos, não cabe mais falar em câmaras representativas dos Estados, o que, nos EUA, resultou de um compromisso histórico que não existiu no Brasil.

significa um Deputado para cada cinquenta mil habitantes (1:50.000) para o primeiro e um para quatrocentos e vinte e oito mil e quinhentos e setenta e um habitantes para o segundo (1:428.571).

Em qualquer matemática, isso não é proporção, mas brutal desproporção; "tal fato constitui verdadeiro atentado ao princípio da representação proporcional. A Câmara dos Deputados deve ser o espelho fiel das forças demográficas de um povo; nada justifica que, a pretexto de existirem grandes e pequenos Estados, os grandes sejam tolhidos e sacrificados em direitos fundamentais de representação".²

3. O Senado Federal

A dogmática federalista firmou a tese da necessidade do Senado no Estado Federal como câmara representativa dos Estados federados. Fundada nisso é que a Constituição de 1988, tal como as anteriores republicanas, declara que o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, elegendo, cada um, três Senadores (com dois suplentes cada), pelo *princípio majoritário*, para um mandato de *oito anos*, renovando-se a representação de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços (art. 46).

O argumento da representação dos Estados pelo Senado se fundamentava na idéia, inicialmente implantada nos EUA, de que se formava de delegados próprios de cada Estado, pelos quais estes participavam das decisões federais. Há muito que isso não existe nos EUA e jamais existiu no Brasil, porque os Senadores são eleitos diretamente pelo povo, tal como os Deputados, por via de partidos políticos. Ora, a representação é partidária. Os Senadores integram a representação dos partidos tanto quanto os Deputados, e dá-se o caso não raro de os Senadores de um Estado, eleitos pelo povo, serem de partido adversário do Governador, portanto defenderem, no Senado, programa diverso deste; e como conciliar a tese da representação do Estado com situações como esta?

4. Organização interna das Casas do Congresso

As Casas do Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, possuem órgãos internos destinados a ordenar seus trabalhos. A cada uma delas cabe *elaborar seu regimento inter-*

2. Cf. Miguel Reale, *Parlamentarismo brasileiro*, cit., p. 31, citando Sampaio Dória, que já profligava a desproporcionalidade no regime da Constituição de 1946, porque, dizia ele, a "representação é do povo, sem distinção de Estado"; a "lei não distingue o nascimento, ou o simples domicílio, para reconhecer, no direito de uns, mais valor que no direito de outros" (*Direito constitucional: comentários à Constituição de 1946*, v. 2/258).

no, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados apenas os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.³ Nisso se encontra um elemento básico de sua independência, agora reconquistada pela retomada de prerrogativas que lhes tinham sido subtraídas pela Constituição revogada.

Criam elas suas leis internas, que disciplinam sua organização sem interferência uma na outra ou de outro órgão governamental. Com o novo texto constitucional, o regimento interno de cada Casa e o regimento interno comum do Congresso Nacional⁴ recobram sua importância de principal fonte do Direito Parlamentar.⁵

A Constituição não contém tantas normas regimentais como a anterior. Assim mesmo ainda insere disposições sobre a formação e competência básica de seus principais órgãos internos: *Mesa, Comissões, Polícia e Serviços Administrativos*.

Mesas. Existem *Mesa* da Câmara dos Deputados, *Mesa* do Senado Federal e, agora, faz-se referência à *Mesa* do Congresso Nacional. São elas os órgãos diretores das Casas do Congresso Nacional. Sua composição é matéria regimental e cada Casa a disciplina como melhor lhe parecer. A regra tem sido que a *Mesa da Câmara dos Deputados* compreenda Presidente, dois Vice-Presidentes, quatro Secretários e quatro suplentes de Secretários, e a *Mesa do Senado Federal* constitua-se de Presidente, dois Vice-Presidentes, quatro Secretários e quatro suplentes de Secretários. Impõe-se, no entanto, atender, na constituição das Mesas, a *representação proporcional* dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa (art. 58, § 1º).

A exigência de autonomia das Câmaras Legislativas impõe sejam seus órgãos diretores compostos de membros pertencentes a seus quadros e eleitos pelos seus pares.⁶ Isso é um princípio geral da organização do Poder Legislativo que, entre nós, sempre foi seguido, consoante consta agora do art. 57, § 4º, que consagra as primeiras providências, no início de cada legislatura, de organização interna do Congresso Nacional, ao estatuir que *cada uma das Casas se reunirá em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura,*

3. Arts. 51, III e IV, e 52, XII e XIII.

4. O regimento comum e a criação de serviços comuns às duas Casas estão previstos no art. 57, § 3º, II.

5. Cf. nosso "El proceso legislativo como objeto del derecho parlamentario", in *Derecho parlamentario iberoamericano*, México, Porrúa, 1987, p. 94, obra que reúne os trabalhos apresentados ao 1º Curso de Direito Parlamentar promovido pelo Instituto de Investigaciones Jurídicas da Câmara dos Deputados do México, realizado de 4 a 9.5.87.

6. Cf. nossa *ob. cit.*, pp. 78 e ss.

para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Corta-se aí controvérsia que medrou com base na Constituição revogada, que vedava a reeleição sem mencionar para onde, o que a nós sempre pareceu, pelos princípios, que reeleição significa recondução ao mesmo cargo para o qual se elegeu — logo, a proibição se referia ao cargo ocupado anteriormente. Não foi a tese que prevaleceu, por entender-se que estava proibida recondução a qualquer cargo da Mesa. Com o texto agora em vigor está claro que o Presidente não pode pleitear sua recondução ao mesmo cargo, mas pode, por exemplo, para Vice-Presidente, enquanto este pode pretender eleger-se Presidente ou Secretário e este a qualquer daqueles.

Fica a questão de saber se isso só vale dentro da mesma legislatura, ou se também se aplica na passagem de uma para outra. O texto proíbe recondução para o mesmo cargo na *eleição imediatamente subsequente*; para nós isso significa, também, proibir a reeleição de membros da última Mesa de uma legislatura para a primeira da seguinte.

A *Mesa do Congresso Nacional* não é um organismo *per se stante*; não existe por si, não tem uma formação adrede, porque se constitui de membros das Mesas do Senado e da Câmara. É presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e do próprio Senado (art. 57, § 5º). Sua função consiste especialmente em dirigir os trabalhos do Congresso Nacional quando suas Casas se reúnem em sessão conjunta, mas a Constituição lhe reserva importante atribuição no art. 140, qual seja a de designar uma Comissão de cinco congressistas para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio, e por certo sua tarefa não se esgotará nessa designação, pois lhe há de caber também exigir a prestação de contas da Comissão sobre sua incumbência.

As atribuições das Mesas são contempladas nos regimentos internos, mas a Constituição menciona algumas de maior destaque, que fogem a uma consideração puramente regimental, como as referentes à convocação ou comparecimento de Ministros, à perda de mandatos de congressistas, à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, à liberação de pronunciamento de parlamentares durante o estado de sítio.⁷

Comissões parlamentares. São organismos constituídos em cada Câmara, compostos de número geralmente restrito de membros, encar-

7. Arts. 50, 55, §§ 2º e 3º, 103, II e III, 139, parágrafo único.

regados de estudar e examinar as proposições legislativas e apresentar pareceres.⁸

As *comissões* do Congresso e de suas Casas serão *permanentes* ou *temporárias* e constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento interno ou no ato de que resultar sua criação, assegurada a representação proporcional dos partidos ou de blocos partidários que participem da respectiva Câmara (art. 58, § 1º).

A Constituição realçou o papel das comissões. Menciona as seguintes:

(A) *Comissões permanentes*, as que subsistem através das legislaturas, são organizadas em função da matéria, geralmente coincidente com o campo funcional dos Ministérios. Cabem-lhes em razão da matéria de sua competência, além de outras consignadas em regimento interno, as seguintes atribuições (art. 58): (a) discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa (inc. I); adota-se aqui o critério da Constituição italiana (art. 72) de atribuir a comissões o exercício da função legislativa plena, que, num momento, se chamou *delegação interna*, mas parece ser mais uma função própria de substituição do que uma função delegada; (b) realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil (inc. II); (c) convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições (inc. III), o que já consta do art. 50 também; (d) receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas (inc. IV); isso tem que ter alguma consequência, porque não teria sentido ser mera recipiendária dessas postulações, mas qual? Que poderá ser feito para solucionar o problema e responsabilizar a autoridade? O texto possibilita tomar o depoimento da autoridade e também, conforme a gravidade do problema, é possível uma comissão de inquérito. Nada mais diz. Poderá o regimento fazer algo? Entendemos que não, mas o texto embasará lei nesse sentido; (e) solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão (inc. V); *qualquer autoridade* inclui o Presidente da República, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Câmara ou o do Senado? Acharmos que não, embora se trate de simples *solicitação* de depoimento, pois há regras de cortesia e de harmonia entre os poderes, no presidencialismo, que a repelem. Quanto aos dois primeiros, o princípio da separação de poderes o impede; quanto aos dois últimos, o próprio fato de serem Presi-

8. Cf. Joseph-Barthélemy, *Essai sur le travail parlementaire et les systèmes des commissions*, Paris, Librairie Delagrave, 1934; nosso *Princípios do processo de formação das leis no direito constitucional*, pp. 85 e ss.

dentes da instituição que contém a comissão mostra não serem passíveis da solicitação; (f) apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer (inc. VI); se as comissões usarem bem dessa faculdade, teremos aí um relevante instrumento de controle da Administração.

(B) *Comissões temporárias* (ou *especiais*), as que se extinguem com a terminação da legislatura ou, antes dela, quando, constituídas para opinarem sobre determinada matéria, tenham preenchido os fins a que se destinam.

(C) *Mistas*, as que se formam de Deputados e Senadores, a fim de estudarem assuntos expressamente fixados, especialmente aqueles que devam ser decididos pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta de suas Casas. Podem ser *permanentes* ou *temporárias*. A Constituição já institui uma importante *Comissão mista permanente*, que, talvez, venha a ser a mais poderosa comissão permanente no seio do Congresso Nacional. Referimo-nos à que está prevista no art. 166, § 1º, a que caberá: (1) examinar e emitir parecer sobre: (a) os projetos de plano plurianual, de lei de diretrizes orçamentárias, de orçamento anual e de créditos adicionais; (b) as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República; (c) os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas; (d) propostas de emendas aos projetos referidos na letra *a* supra;⁹ (2) solicitar às autoridades governamentais responsáveis que, no prazo de cinco dias, prestem esclarecimentos necessários acerca de despesas não autorizadas, solicitando ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria que, sendo pela irregularidade das despesas, investe-a do poder de propor ao Congresso Nacional sustação das ditas despesas, se entender que possam causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública.¹⁰

(D) *Comissões parlamentares de inquérito*, são organismos que desempenham e desempenham papel de grande relevância na fiscalização e controle da Administração, mas que tiveram sua organização e suas tarefas consideravelmente tolhidas no regime da Constituição revogada. Era esta uma de suas marcas autoritárias. Foram bastante prestigiadas pela Constituição vigente, a ponto de receber poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas. Não há limitação à sua criação. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em conjunto ou separadamente, poderão criar tantas comissões

9. Cf. art. 166, §§ 1º e 2º.

10. Cf. art. 72.

parlamentares de inquérito quantas julgarem necessárias. Essa liberdade de criação de comissões parlamentares de inquérito depende, contudo, do preenchimento de três *requisitos*: (a) requerimento de pelo menos um terço de membros de cada Casa, para as respectivas comissões, ou de ambas, para as comissões em conjunto (comissão mista); (b) ter por objeto a apuração de fato determinado; (c) ter prazo certo de funcionamento. Um dos problemas mais sérios das comissões parlamentares de inquérito consistiu sempre na ineficácia jurídica de suas conclusões, normalmente dependentes de apreciação do Plenário da respectiva Casa ou do Congresso Nacional, que, não raro, as enterrava nos escaninhos das injunções políticas. A Constituição traz o remédio para esse mal, ao dizer: *sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores* — significando que as conclusões de comissões parlamentares de inquérito são decisões definitivas, cuja executoriedade independe de apreciação ou aprovação de outro órgão. Nada impede que a comissão, por si, submeta suas conclusões ao Plenário, solicitando-lhe aprovação e providências de sua alçada.

Polícia e serviços administrativos. As Casas do Congresso Nacional mantêm um corpo de guardas próprio, destinado ao policiamento interno, bem como serviços administrativos, que são as Secretarias, incluindo serviços gráficos, bibliotecas e serviços de referência legislativa, assessorias, os quais são regulados nos respectivos regimentos internos.

5. Comissão representativa

Esta é uma comissão que tem natureza diversa das que estudamos no tópico anterior. Aquelas são comissões técnicas de estudo e investigação. A *Comissão representativa*, instituída agora no art. 58, § 4º, é novidade no nosso regime constitucional, e assim se chama porque tem por função representar o Congresso Nacional durante o recesso parlamentar. Isso importa em mudança importante, na medida em que tal atribuição sempre coube às Mesas (e mais especificamente aos Presidentes) das Câmaras em relação a cada uma delas e à Mesa (Presidente) do Senado em relação ao Congresso Nacional.

Haverá apenas uma Comissão representativa. Diz mal o art. 58, § 4º, quando dispõe que será “eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo”. Isso quer apenas dizer que os membros de cada uma das Casas, a integrarem a comissão, serão por elas eleitos na sessão ordinária do período legislativo. “Sessão ordinária”, como veremos, significa reunião normal dos trabalhos legislativos. “Período legislativo”, também veremos, é o período de funcionamento do Congresso Nacional, em cada semestre, ou seja: de 15 de fevereiro a 30

de junho (1º período) e de 1º de agosto a 15 de dezembro (2º período). Em cada um deles, elege-se uma Comissão representativa para o recesso que começará em seguida (1º: de 1º a 31 de julho; 2º: de 16 de dezembro a 14 de fevereiro do ano seguinte, salvo se este for o primeiro da legislatura, quando o recesso termina no dia 1º de fevereiro).

Serão estabelecidas no regimento comum as atribuições e a composição da Comissão representativa que reproduzirá, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

II. FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES

6. Funcionamento do Congresso Nacional

O Congresso Nacional desenvolve suas atividades por legislaturas, sessões legislativas ordinárias ou extraordinárias, sessões (reuniões) ordinárias ou extraordinárias.

A *legislatura* tem a duração de *quatro anos* e corresponde ao período que vai do início do mandato dos membros da Câmara dos Deputados até o seu término (art. 44, parágrafo único). Isso porque o Senado é contínuo por ser renovável apenas parcialmente em cada período de quatro anos (art. 46, § 2º). A legislatura reveste-se de grande importância, porquanto marca o período de funcionamento de *cada Congresso*, conceito norte-americano adotado no Brasil, pois muitas deliberações devem ser tomadas dentro dela ou em relação a ela, assim, por exemplo, a fixação da remuneração dos congressistas (art. 49, VII), a composição das comissões permanentes e a extinção das comissões temporárias, na forma regimental.

Sessão legislativa ordinária é período anual em que deve estar reunido o Congresso para os trabalhos legislativos. Divide-se em dois *períodos legislativos*: um que vai de 15 de fevereiro a 30 de junho e outro de 1º de agosto a 15 de dezembro (art. 57). Vale dizer que as sessões legislativas ordinárias se encerram no dia 15 de dezembro de cada ano; contudo, não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (art. 57, § 2º), isto é, dá-se um prolongamento da sessão legislativa ordinária, não convocação de sessão legislativa extraordinária. O princípio é: a sessão legislativa ordinária termina em 15 de dezembro. Sua interrupção é exceção, com uma finalidade específica: aprovação da lei de diretrizes orçamentárias (ou do orçamento, quando o fato é também previsto em relação à aprovação deste, como em São Paulo, CE, art. 9º, § 4º). Se a norma constitucional diz: “não se interrompe *sem a aprovação* de (...)”, é que o objetivo da continuidade é só para cumprir essa exigência: a aprovação só da matéria, cuja não aprovação causou aquele prolongamento. Vale dizer, para outras matérias a sessão legislativa ordinária se encerrara.

Os espaços que vão de 16 de dezembro a 14 de fevereiro (31 de janeiro, para o primeiro ano da legislatura) constituem o *recesso parlamentar*. Chama-se *recesso* porque, na origem dos parlamentos, os parlamentares se afastavam das reuniões, durante certo tempo, para retornar a seus distritos ou circunscrições eleitorais, a fim de confirmar seu mandato. Os objetivos hoje são diversos, mas o afastamento para lugar remoto (um dos significados da palavra *recesso*) — bases eleitorais — continua a ser uma necessidade parlamentar. Durante o *recesso*, o Congresso não funciona, salvo se for convocada *sessão legislativa extraordinária*. Agora, como vimos, funcionará uma *Comissão representativa* do Congresso Nacional, regulada pelo regimento comum.

A convocação do Congresso Nacional para *sessão legislativa extraordinária* far-se-á: (1) pelo *Presidente do Senado Federal*, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação do estado de sítio e para o compromisso e posse do Presidente e do Vice-Presidente da República; (2) pelo *Presidente da República*, pelos *Presidentes da Câmara dos Deputados* e do *Senado Federal*, ou a *requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas*, em caso de urgência ou interesse público relevante.

O Congresso Nacional, na sessão legislativa extraordinária, somente poderá deliberar sobre a matéria para a qual foi convocado, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao subsídio mensal (EC-19/98). Se é assim, se não pode tratar de mais nada nesse período que sempre coincide com o *recesso*, a conclusão é a de que a Comissão representativa também continuará em funcionamento conjuntamente com o Congresso convocado extraordinariamente, para exercer as outras atribuições que lhe sejam cometidas no período.

Sessões ordinárias. Os trabalhos legislativos realizam-se efetivamente nas *reuniões diárias* dos congressistas, chamadas *sessões ordinárias*, que se processam nos dias úteis (de segunda a sexta-feira). Os regimentos internos das Casas do Congresso Nacional é que disciplinam essas sessões, que, em regra, se prolongam por cinco horas, e dividem-se em três partes: (a) *Pequeno Expediente*, com duração aproximada de uma hora; (b) *Grande Expediente*, com duração de cerca de noventa minutos; (c) *Ordem do Dia*, com duração de cerca de cento e cinquenta minutos, prorrogáveis; é nesta parte que as Câmaras debatem, votam e deliberam. Às vezes, outra parte é prevista para *comunicação de lideranças*.

Nesse horário ou em outro, realizam-se também *sessões solenes* de comemoração de datas ou feitos históricos, de reverência à memória de pessoas ilustres ou de recepção de personalidades estrangeiras (Chefes de Estados, Primeiros-Ministros) em visita ao País. E, no início de cada legislatura, ocorrem a partir de 1º de fevereiro as *sessões preparatórias*, sessões de organização do Congresso e de suas Casas, como vimos.

Fora do horário preestabelecido, poderá ser convocada qualquer das Câmaras para *sessões extraordinárias*, para apreciar matéria determinada ou concluir a apreciação do que já tenha tido a discussão iniciada.

Reuniões conjuntas. O princípio do bicameralismo é que as Câmaras do Congresso Nacional funcionem e deliberem cada qual por si, separadamente. Mas a Constituição prevê hipóteses em que se reunirão em *sessão conjunta* (art. 57, § 3º), caso em que a direção dos trabalhos cabe à Mesa do Congresso Nacional (art. 57, § 5º). Isso se dará para: (a) a inauguração da sessão legislativa; (b) elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns; (c) receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República (art. 78); (d) conhecer do veto e sobre ele deliberar (art. 66, § 4º). A Constituição arrola os casos de sessão conjunta do art. 57, § 3º, *além de outros casos nela previstos*. Não os encontramos. O único que poderia suscitar alguma dúvida seria o da elaboração das leis financeiras e orçamentárias, referidas no art. 166, principalmente porque determina que são apreciadas na forma do regimento comum e dependentes de parecer de uma comissão mista de Deputados e Senadores, mas os dispositivos pertinentes ao assunto mostram muito claramente que a Constituição de 1988 quis afastar a sistemática que vigorara anteriormente de discussão e votação de projetos de leis orçamentárias em sessão conjunta do Congresso Nacional. Já no próprio art. 66 se estabelece que tais leis serão apreciadas pelas *duas Casas* do Congresso Nacional. Também as emendas a elas oferecidas serão apreciadas pelo Plenário das *duas Casas* do Congresso Nacional. Isso espanca qualquer dúvida. A legislação de urgência é, outrossim, discutida e votada pelas duas Casas, separadamente (arts. 62 e 64, §§ 1º a 4º). Assim, igualmente, emendas à Constituição (art. 60, § 2º).

Quórum para deliberações. Finalmente, cumpre esclarecer que as deliberações de cada Casa ou do Congresso em câmaras conjuntas, assim como de suas Comissões, serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição constitucional em contrário (art. 47). Realmente, em casos expressos, a Constituição contempla hipóteses de deliberação por *maioria absoluta* (arts. 55, § 2º, 66, § 4º e 69), por *três quintos* dos membros da Casa (art. 60, § 2º) e por *dois terços* dos membros da Casa (arts. 51, I, 52, parágrafo único, e 86). *Maioria absoluta* é mais da metade, constitui-se a partir do primeiro número inteiro acima da metade, sendo erro considerá-la como metade mais um, como não raro se ouve e se lê, visto que será impossível apurá-la quando a Câmara se compuser de número ímpar de membros.

7. Atribuições do Congresso Nacional

Vimos que o Congresso Nacional é o *órgão legislativo* da União. Apesar disso, suas atribuições não se resumem na competência para elaborar leis. Exerce outras de relevante importância, e todas podem ser classificadas em cinco grupos:

(1) *atribuições legislativas*, pelas quais lhe cabe, com a sanção do Presidente da República, elaborar as leis sobre todas as matérias de competência da União, conforme especifica o art. 48, o que é feito segundo o *processo legislativo*, estabelecido nos arts. 61 a 69, que será objeto de consideração logo em seguida;

(2) *atribuições meramente deliberativas*, envolvendo a prática de atos concretos, de resoluções referendárias, de autorizações, de aprovações, de sustação de atos, de fixação de situações e de julgamento técnico, consignados no art. 49, o que é feito por via de decreto legislativo ou de resoluções, segundo procedimento deliberativo especial de sua competência exclusiva, vale dizer, sem participação do Presidente da República, de acordo com regras regimentais;

(3) *atribuições de fiscalização e controle*, que exerce por vários procedimentos, tais como: (a) *pedidos de informação*, por escrito, encaminhados pelas Mesas aos Ministros ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República (art. 50, § 2º, redação da ECR-4/94), importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas; (b) *comissão parlamentar de inquérito*, nos termos do art. 58, § 3º, como vimos; (c) *controle externo* com auxílio do Tribunal de Contas e da Comissão mista a que se refere o art. 166, § 1º, que compreenderá toda a gama de medidas constantes dos arts. 71 e 72, culminando com o julgamento das contas que anualmente o Presidente da República há de prestar (art. 49, IX); (d) *fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo*, incluídos os da administração indireta (art. 49, X); (e) *tomada de contas* pela Câmara dos Deputados, quando o Presidente não as prestar no prazo que a Constituição assinala, ou seja, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, então até 15 de abril (arts. 51, II, e 84, XXIV);

(4) *atribuições de julgamento de crimes de responsabilidade*, com a particularidade de que, no julgamento do Presidente da República ou Ministros de Estado, a Câmara dos Deputados funciona como *órgão de admissibilidade do processo* e o Senado Federal como *tribunal político* sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal (arts. 51, I, 52, I, e 86), e, no julgamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e do Advoga-

do-Geral da União, o Senado Federal funcionará a um tempo como *tribunal do processo e do julgamento* (art. 52, II);

(5) *atribuições constituintes* mediante elaboração de emendas à Constituição (art. 60), com o que o Congresso cria normas constitucionais, como estudamos antes.

8. Atribuições privativas da Câmara dos Deputados

Possui a Câmara algumas *atribuições privativas*, que, na verdade, são *atribuições exclusivas*, porque insuscetíveis de delegação, e que ela exerce sozinha e por si, e são as seguintes: (a) autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado; (b) processar a tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, como determina o art. 84, XXIV; (c) elaborar seu regimento interno; (d) dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (tudo isso é feito por resolução interna, menos a fixação da remuneração dos cargos, empregos e funções, que depende de lei); (e) eleger dois dos membros-cidadãos do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII (art. 51).

9. Atribuições privativas do Senado Federal

Tem o Senado Federal as seguintes *atribuições privativas*: (a) *processar e julgar* o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; (b) *processar e julgar* os Ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça e os do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade; (c) *aprovar* previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados nos casos determinados na Constituição (arts. 101, parágrafo único, 104, parágrafo único, 111, § 1º, e 123), de Ministros do TCU indicados pelo Presidente da República (art. 73, § 2º, I), de Governador de Território, de presidente e diretores do banco central (com minúscula, para significar que será de qualquer banco, tenha o nome que tiver, que exerça as funções de banco central, que hoje é o Banco Central do Brasil), do Procurador-Geral da República (art. 128, § 1º) e de titulares de outros cargos que a lei determinar (abre-se aqui a possibilidade de ampliar

esse controle prévio do Senado Federal sobre as nomeações para cargos na esfera federal); (d) *aprovar* previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente; (e) *autorizar* operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios (acrescentou-se agora o controle das operações financeiras externas da União, entre os controles que incidiam apenas sobre as outras entidades); (f) *fixar*, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (trata-se do controle do endividamento dessas entidades, incluindo agora também o controle sobre o endividamento da União, já que antes só as outras entidades estavam sujeitas a esse controle); (g) *dispor sobre* limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal (controle sobre crédito público e também do endividamento das unidades indicadas, ampliando-se o controle à União e entidades autárquicas de todas elas e de outras entidades sob controle federal); (h) *dispor sobre* limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno (ainda aqui, controle sobre o crédito público); (i) *estabelecer* limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, Distrito Federal e Municípios (*dívida mobiliária* é a formada pela emissão de títulos da dívida pública; aqui já não abrange a União); (j) *suspender* a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (*em parte* não há de ser entendido como poder de admitir apenas uma parte do que foi declarado inconstitucional; se toda a lei foi declarada inconstitucional, a suspensão há de ser total, dela toda; o Senado não pode decidir fazê-lo apenas de parte; portanto, quando o texto fala suspender *em parte*, significa que também só parte foi declarada inconstitucional; de outro lado, esse procedimento não tem cabimento quando a declaração de inconstitucionalidade decorreu de ação direta nos termos do art. 103; é procedimento adequado à declaração de inconstitucionalidade *incidenter tantum*, ou seja, no caso concreto segundo a técnica do controle difuso, pois que sua razão de ser está precisamente em fazer expandir, a todos, os efeitos da decisão que, em si, só tem eficácia entre as partes; é a suspensão da execução da lei, já vimos, que confere efeitos *erga omnes* à sentença que decretou a inconstitucionalidade); (k) *aprovar*, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato; (l) *elaborar* seu regimento interno e *dispor* sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e fun-

ções de seus serviços e a iniciativa da lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (o que se faz por meio de resolução, em boa parte no próprio regimento interno, que também se baixa por resolução, exceto a fixação da remuneração, a qual, agora, depende de *lei* e não mais de resolução, cf. EC-19/98)); (m) *eleger* dois membros-cidadãos do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII; (n) avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, como consta do inc. XV do art. 52, acrescentado pela EC-42/2003. É mais uma interferência inconstitucional na autonomia das entidades federativas por via de emenda constitucional. Avaliar para quê, não se diz – mas certamente não há de ser apenas pela avaliação em si, mas, no mínimo, para propor soluções a problemas porventura constatados.

10. Convocação e comparecimento de Ministros

Desde a Constituição de 1934 (art. 37) os Ministros de Estado poderão ser convocados para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, perante órgãos legislativos (Câmara, Senado ou suas comissões), importando em crime de responsabilidade o seu não atendimento da convocação, sem justificção adequada, isto é, aceita pelo órgão convocante. Agora, a ECR-2/94 inclui entre os que podem ser convocados quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República (art. 50). É uma providência pertinente, já que se foram criando muitos órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, tais as Secretarias da Presidência com responsabilidades de verdadeiros Ministérios, cujos titulares ficavam imunes àquela convocação congressional. Por outro lado, também, desde então, se prevê a possibilidade de os Ministros, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, comparecerem ao Senado, à Câmara ou a qualquer de suas comissões, para exporem assunto de relevância de seu Ministério (art. 50, § 1º). Já aqui não houve mudança. Apenas aos Ministros se confere a prerrogativa do comparecimento espontâneo àqueles órgãos parlamentares para as finalidades ali indicadas.

Diz-se, às vezes, que esse procedimento quebra a rigidez do presidencialismo, ou até, não raro, se admite que se introduziu, com isso, um mecanismo parlamentarista no presidencialismo. Em verdade, nada tem de parlamentarismo nisso. O comparecimento do Ministro convocado ou espontaneamente não serve mais do que para ele, munido de documentação técnica e bem assessorado, utilizar uma tribuna popular para brilhar, sem nenhuma consequência, porque

suas informações não serão apreciadas pelo órgão. A rigor, tem sido um procedimento inútil.

III. PROCESSO LEGISLATIVO

11. Conceito e objeto

Por *processo legislativo* entende-se o conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, sanção, veto) realizados pelos órgãos legislativos visando a formação das leis constitucionais, complementares e ordinárias, resoluções e decretos legislativos.¹¹ Tem, pois, por objeto, nos termos do art. 59, a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.

As medidas provisórias não constavam da enumeração do art. 59, como objeto do processo legislativo, e não tinham mesmo que constar, porque sua formação não se dá por processo legislativo. São simplesmente editadas pelo Presidente da República. A redação final da Constituição não as trazia nessa enumeração. Um gênio qualquer, de mau gosto, ignorante, e abusado, introduziu-as aí, indevidamente, entre a aprovação do texto final¹² (portanto depois do dia 22.9.88) e a promulgação-publicação da Constituição no dia 5.10.88.

Nada se diz sobre o processo de formação dos decretos legislativos e das resoluções. Aqueles são atos destinados a regular matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49) que tenham efeitos externos a ele; independem de sanção e de veto. As resoluções legislativas são também atos destinados a regular matéria de competência do Congresso e de suas Casas, mas com efeitos internos; assim os regimentos internos são aprovados por resoluções. Contudo, são previstas algumas resoluções com efeito externo, como a de delegação legislativa e as do Senado sobre matéria financeira e tributária (arts. 68, § 2º, 52, IV a X, e 155, § 2º, V). Como a Constituição não dispôs sobre o processo de sua formação, isso ficou para os regimentos internos.

12. Atos do processo legislativo

Processo legislativo é um conjunto de atos preordenados visando a criação de normas de Direito. Esses atos são: (a) iniciativa legis-

11. Sobre o assunto, cf. nosso *Princípios do processo de formação das leis no direito constitucional*, São Paulo, Ed. RT, 1968; Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Do processo legislativo*, São Paulo, Saraiva, 1968; Nelson de Sousa Sampaio, *O processo legislativo*, São Paulo, Saraiva, 1968.

12. Cf. *Projeto de Constituição (D)*, redação final, aprovado pela Comissão de Redação nos dias 19 e 20.9.88 e pelo Plenário da Constituinte no dia 22.9.88. Não foi, pois, acréscimo da Comissão de Redação.

lativa; (b) emendas; (c) votação; (d) sanção e veto; (e) promulgação e publicação.

Iniciativa legislativa. É, em termos simples, a faculdade que se atribui a alguém ou a algum órgão para apresentar projetos de lei ao Legislativo. Em rigor, não é ato de processo legislativo. É conferida *concorrentemente* a mais de uma pessoa ou órgão, mas, em casos expressos, é outorgada com *exclusividade* a um deles apenas. Assim é que a iniciativa de emendas à Constituição cabe *concorrentemente* a um terço dos membros da Câmara dos Deputados, a um terço dos membros do Senado, ao Presidente da República e a mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação (art. 60); a iniciativa das leis complementares e ordinárias compete a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República e aos cidadãos (art. 61). Esclareça-se que esse dispositivo inclui o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores e o Procurador-Geral da República como detentores também do poder de iniciativa legislativa, não, contudo, de iniciativa concorrente, porquanto não podem eles iniciar qualquer lei, mas tão-só as que lhes são indicadas com exclusividade, salvo o Procurador-Geral da República que concorre com o Presidente da República na iniciativa da lei orgânica do Ministério Público (arts. 61, § 1º, II, b, e 128, § 5º).

Ao princípio da iniciativa concorrente a Constituição opõe algumas exceções em relação a determinadas matérias, estatuinto que é da competência exclusiva:

(1) *do Presidente da República a iniciativa das leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; disponham sobre:* (a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; (b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; (c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; (e) criação, estruturação e atribuição dos Ministérios e órgãos da administração pública; (f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoção, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva (EC-18/98);

(2) *do Supremo Tribunal Federal a iniciativa da lei complementar dispondo sobre o estatuto da magistratura (art. 93); as leis de criação*

e extinção de cargos e fixação de remuneração dos seus serviços auxiliares; por seu Presidente, a sua proposta orçamentária (art. 99, § 2º, I);

(3) *dos Tribunais Superiores a iniciativa* das leis de alteração do número dos membros dos tribunais inferiores; de criação e extinção de cargos e fixação de subsídios de seus membros, dos juizes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, e dos serviços auxiliares e os dos juizes que lhes forem vinculados;

Iniciativa popular. Aqui temos um instrumento de participação direta do cidadão nos atos de governo. Há outros institutos que já discutimos, quando, na primeira parte deste livro, tratamos da *democracia participativa*. Lembramos ali a disposição do art. 14 declarando que a iniciativa popular, o referendo e o plebiscito são modos de exercício da soberania popular. Aqui, no processo legislativo, é reconhecida a iniciativa popular, independentemente de regulamentação legal, porque o próprio texto constitucional (art. 61, § 2º) já estabelece os requisitos necessários e suficientes para o seu exercício imediato, que são: *projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.*

Iniciativa de Governadores e Assembléias. A um terço dos Governadores de Estado e do Distrito Federal, e a mais da metade das Assembléias Legislativas dos Estados e Distrito Federal, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, foi conferida a faculdade para iniciar a lei complementar que disciplina o imposto previsto no art. 155, II (EC-42/2003, que acrescentou o § 3º ao art. 61). É mera faculdade, mas, com isso, se abre exceção à competência exclusiva do Presidente da República para iniciar leis em matéria tributária (art. 61, § 1º, b). O art. 155, II, dá competência aos Estados e Distrito Federal para instituir o ICMS, e a lei complementar referida está prevista no inc. XII de seu § 2º.

Emendas. Constituem proposições apresentadas como acessórias a outra. O direito de propor emendas é uma faculdade de os membros ou órgãos de cada uma das Casas do Congresso Nacional sugerirem modificações nos interesses relativos à matéria contida em projetos de lei.¹³ A Constituição restituiu, aos congressistas, boa parte do poder de emendas que haviam perdido no regime constitucional anterior. Assim é que se admitem emendas, mesmo que importem em aumento de despesas, ao projeto de lei do orçamento anual ou a projetos que o modifiquem, desde que: (a) compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; (b) indiquem os

recursos necessários, mediante anulação de despesas que não sejam de dotações de pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para os Estados, Municípios e Distrito Federal; (c) sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. Também são permitidas emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias quando compatíveis com o plano plurianual.¹⁴

Fora disso, não se admitem emendas que aumentem despesas em projetos de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República nem nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público (art. 63).

Votação. A *votação* da matéria legislativa constitui ato coletivo das Casas do Congresso. É geralmente precedida de estudos e pareceres de comissões técnicas (permanentes ou especiais) e de debates em plenário. É o ato de decisão (arts. 65 e 66), que se toma por maioria de votos: *maioria simples* (ou *relativa*), isto é, maioria dos membros presentes (art. 47), para a aprovação de projetos de lei ordinária; *maioria absoluta* dos membros das Câmaras, para aprovação dos projetos de lei complementar (art. 69), e *maioria de três quintos* dos membros das Casas do Congresso, para aprovação de emendas constitucionais (art. 60, § 2º),

Sanção e veto. São atos legislativos de competência exclusiva do Presidente da República. A *sanção* e o *veto* somente recaem sobre *projetos de lei*. É errôneo dizer, por exemplo, que o Presidente sancionou ou vetou uma lei. Por outro lado, só são sancionáveis ou vetáveis projetos que disponham sobre as matérias indicadas no art. 48. A lei nasce com a sanção que é pressuposto de sua existência, a menos que seja vetada e o veto rejeitado, na forma que veremos infra.

Sanção é, pois, a adesão do Chefe do Poder Executivo ao projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Pode ser expressa ou tácita. Aquela ocorre se o Presidente emite o ato de sanção assinando o projeto. A outra se dará se, recebido o projeto para sanção, o Presidente silencia (não o assina) durante os quinze dias subseqüentes; na verdade, uma quinquena de dias úteis para harmonizar o disposto no § 3º com o § 1º do art. 66, pois que este último dá quinze dias *úteis* para vetar.

Veto é o modo de o Chefe do Executivo exprimir sua discordância com o projeto aprovado, por entendê-lo inconstitucional ou contrário a interesse público.¹⁵ Será *total* se recair sobre todo o projeto, e

13. Cf. nossa *ob. cit.*, pp. 161 a 180, onde discorremos amplamente sobre as emendas legislativas.

14. Essas possibilidades decorrem dos arts. 63, I, e 166, §§ 3º e 4º.

15. Sobre o veto, cf. Ernesto Rodrigues, *O veto no Brasil*, Rio de Janeiro, Forense, 1981.

parcial se atingir parte do projeto, mas este somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea (art. 66, § 2º). Com isso se corta o mau vazo de veto sobre palavra ou grupo de palavras que não raro importava em mudar o sentido do texto. Por exemplo: “esta lei entrará em vigor 60 dias após sua publicação”; vetando-se “60 dias”, ela entrará em vigor com sua publicação. Já houve veto desse tipo; agora, não mais.

O veto é relativo. Quer dizer, não tranca de modo absoluto o andamento do projeto. Será, mediante mensagem fundamentada, comunicado ao Presidente do Senado Federal no prazo de quarenta e oito horas, a fim de ser apreciado pelo Congresso, em sessão conjunta, em trinta dias a contar de seu recebimento, reputando-se rejeitado, se a maioria absoluta dos Deputados e Senadores (isto é, dos membros das Casas do Congresso), em escrutínio secreto, votar contra ele; em tal hipótese, o projeto se transforma em lei (sem sanção, como se vê), que deverá ser promulgada. Se aquela maioria não for alcançada, ficará mantido o veto, arquivando-se o projeto, que assim se tem por rejeitado.

Promulgação e publicação da lei. Não configuram atos de natureza legislativa. Rigorosamente, não integram o processo legislativo. Promulga-se e publica-se lei, que já existe desde a sanção ou veto rejeitado. É errado falar em promulgação de projeto de lei.

A *promulgação* não passa de mera comunicação, aos destinatários da lei, de que esta foi criada com determinado conteúdo. Nesse sentido, pode-se dizer que é o meio de constatar a existência da lei; esta é perfeita antes de ser promulgada; a promulgação não faz a lei, mas os efeitos dela somente se produzem depois daquela.¹⁶ O ato de promulgação tem, assim, como conteúdo, a presunção de que a lei promulgada é válida, executória e potencialmente obrigatória. Mas, no nosso entender, para que a lei se considere efetivamente promulgada, é necessária a publicação do ato, para ciência aos seus destinatários; não do ato de promulgação simplesmente, e sim com o texto promulgado. A lei só se torna eficaz (isto é, em condição de produzir seus efeitos) com a *promulgação publicada*. A promulgação é obrigatória. Cabe ao Presidente da República, mesmo das leis decorrentes de veto rejeitado (art. 66, § 5º). Se ele não o fizer dentro de quarenta e oito horas, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo (art. 66, § 7º).

A *publicação* da lei constitui instrumento pelo qual se transmite a promulgação (que concebemos como comunicação da feitura da lei e de seu conteúdo) aos destinatários da lei. A publicação é condição

para a lei entrar em vigor e tornar-se eficaz. Realiza-se pela inserção da lei promulgada no jornal oficial. Quem a promulga deve determinar sua publicação.

A Constituição foi promulgada pela Mesa da Assembléia Nacional Constituinte. Emendas constitucionais serão promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (art. 60, § 3º).

A elaboração de *leis delegadas* e de *medidas provisórias* não comporta atos de iniciativa, nem votação, nem sanção, nem veto, nem promulgação. Trata-se de mera *edição* que se realiza pela publicação autenticada. Por isso não é cabível falar-se em processo legislativo a respeito delas, mas de simples *procedimento elaborativo*. O que se faz mediante processo legislativo é a resolução do Congresso Nacional que outorga a delegação (art. 68, § 2º). Não têm sanção nem veto, como não os têm as várias resoluções do Senado Federal mencionadas na Constituição (art. 155, § 2º, IV e V). Mas são promulgadas pelo Presidente do Senado Federal, as primeiras na sua qualidade de Presidente da Mesa do Congresso Nacional, as segundas naquela qualidade mesma.

13. Procedimentos legislativos

Procedimento legislativo é o modo pelo qual os atos do processo legislativo se realizam. Diz respeito ao andamento da matéria nas Casas legislativas. É o que na prática se chama *tramitação do projeto*. No sistema brasileiro, podemos distinguir (1) *procedimento legislativo ordinário*; (2) *procedimento legislativo sumário*; e (3) *procedimentos legislativos especiais*.

(1) *Procedimento legislativo ordinário*. É o procedimento comum, destinado à elaboração das leis ordinárias. É mais demorado. Comporta mais oportunidade para o exame, o estudo e a discussão do projeto. Desenvolve-se em cinco fases: (a) a *introdutória*; (b) a *de exame do projeto nas comissões permanentes*; (c) a das *discussões*; (d) a *decisória*; (e) a *revisória*. A primeira efetiva-se pela apresentação do projeto. Na segunda, é estudado pelas comissões que emitem pareceres favoráveis ou desfavoráveis à sua aprovação, admitidas emendas e até substitutivos ao projeto. A terceira é a das discussões da matéria, com o parecer das comissões, em plenário da Câmara onde o projeto foi apresentado, sendo de notar que só não se iniciam na Câmara dos Deputados a discussão e votação dos projetos propostos por Senador ou comissão do Senado, daí por que aquela é quase sempre a Câmara iniciadora do processo legislativo; abre-se nesta fase oportunidade de oferecer emendas ao projeto, que deverão ser estudadas pelas comissões. Na quarta fase dá-se a decisão, quando o projeto é votado; se for aprovado, será remetido à outra Casa para revi-

16. Cf. nossa *ob. cit.*, pp. 208 e ss., e autores ali citados.

são (quinta fase); aí passará pelas mesmas fases (recebimento da matéria, remessa às comissões, discussão e votação); se também merecer aprovação, sem emendas, será remetido à sanção e promulgação; se houver emendas, voltará à Casa iniciadora, para apreciação destas, e, sendo elas aprovadas ou rejeitadas, o projeto irá à sanção. Poderá haver um ou dois turnos de discussão e votação, mas na fase de revisão só existirá um turno (art. 65).

Se o projeto for rejeitado em qualquer das Casas, será arquivado (art. 65), e a matéria somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional (art. 67).

Enfim, a Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto ao Presidente da República que, aquiescendo, o sancionará, promulgará e publicará a lei dele resultante (art. 66), ou, não aquiescendo, deixará correr a quinzena em silêncio, o que implicará sanção, ou vetá-lo-á no todo ou em parte, comunicando os motivos do veto ao Presidente do Senado Federal, a fim de ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, que poderá rejeitá-lo pela maioria dos seus membros; rejeitando-o, o projeto vira lei que deverá ser promulgada e publicada; acolhendo-o, será arquivado.¹⁷

(2) *Procedimento legislativo sumário*. Está previsto nos parágrafos do art. 64. Sua aplicação depende da vontade do Presidente da República, a quem a Constituição confere a faculdade de solicitar *urgência* para apreciação de projeto de sua iniciativa. A solicitação de urgência é pressuposto do procedimento sumário. Se o Presidente solicitar a urgência, o projeto deverá ser apreciado pela Câmara dos Deputados no prazo de *quarenta e cinco dias*, a contar de seu recebimento. Se for aprovado na Câmara, terá o Senado Federal *igual prazo* para sua apreciação. O prazo total é, pois, de *noventa dias* para o pronunciamento de ambas as Casas, mas, se o Senado emendar o projeto, as emendas deverão ser apreciadas pela Câmara em *dez dias*, com o que o prazo total fica dilatado para *cem dias*. Se a Câmara e o Senado não se manifestarem sobre a proposição, cada qual, sucessivamente, em quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação (EC-32/2001).

Ultimado o pronunciamento de ambas as Casas dentro dos prazos ou não, com a aprovação do projeto, este subirá à sanção.

O procedimento não se aplica a projetos de Códigos¹⁸ e aqueles prazos não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional.

17. Art. 66, §§ 1º a 7º.

18. Para pormenores sobre o conceito de *código*, cf. nosso *Manual do Vereador*, 3ª ed., Malheiros Editores, 1995, pp. 115 e 116. Em síntese, tem-se *codificação* quando se

O que se observa, agora, é que não há mais aprovação de projetos de lei por decurso de prazo. Terão que ser votados, no prazo ou fora do prazo, sendo aprovados ou rejeitados, com as mesmas consequências do art. 65.

(3) *Procedimentos legislativos especiais*. São os estabelecidos para a elaboração de *emendas constitucionais* (que já examinamos), de *leis financeiras* (lei do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei do orçamento anual e de abertura de créditos adicionais), de *leis delegadas*, de *medidas provisórias* e de *leis complementares*. Quanto a estas últimas nada mais carece dizer senão que só diferem do procedimento de formação das leis ordinárias na exigência do voto da maioria absoluta das Casas, para sua aprovação (art. 69), sendo, pois, formadas por procedimento ordinário com *quorum* especial.

O procedimento de formação das *leis financeiras* consta do art. 166, que merecerá nossa atenção quando formos estudar o sistema orçamentário instituído na Constituição. Resta, pois, para considerarmos aqui, apenas o procedimento elaborativo das leis delegadas e das medidas provisórias.

Na verdade, a Constituição não prevê como se formam as *leis delegadas*, senão que serão elaboradas pelo Presidente da República que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional, que a outorgará por *resolução* que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Em lugar de atribuir a delegação, a resolução poderá determinar a apreciação do projeto pelo Congresso, que se fará em uma única votação, vedada qualquer emenda (art. 68, § 3º).¹⁹ Vê-se desse dispositivo que o pedido de delegação inclui o projeto da lei que se quer elaborar. A delegação legislativa já existe no constitucionalismo pátrio há mais de vinte anos e jamais foi usada, porque havia decreto-lei, e vai continuar a não ser usada, porque existem as medidas provisórias que acabam sendo mais convenientes para o Executivo.

A Constituição especifica algumas matérias que não podem ser objeto de delegação, tais como: os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49), os de competência privativa da Câmara dos Deputados (art. 51) e os de competência privativa do Senado Federal (art. 52), bem como a legislação sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus

organiza sistematicamente, num corpo de normas, relativamente extenso, a totalidade das disposições e prescrições de um setor da ordem jurídica. Não é necessário que esse corpo de normas receba o nome de *código* para que tenha essa natureza. Estatutos do Funcionalismo, Estatuto da Criança e Adolescentes etc. são tipos de *código*.

19. Sobre delegações legislativas, cf. Vicente Ráo, *As delegações legislativas no parlamentarismo e no presidencialismo*, São Paulo, Max Limonad, 1966; Carlos Roberto de Siqueira Castro, *O Congresso e as delegações legislativas*, Rio de Janeiro, Forense, 1986.

membros; nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

As *medidas provisórias*, com força de lei, podem ser adotadas pelo Presidente da República, as quais, no entanto, para serem legítimas, hão de atender a pressupostos formais, materiais e, ainda, a regras de procedimento que agora se exigem no art. 62 da CF com o enunciado oferecido pela EC-32/2001. [Os formais] são a *relevância* e a *urgência*; os [materiais] dizem respeito à matéria que pode ser por elas regulamentada. As restrições para legislar mediante medidas provisórias sobre certas matérias foram consignadas agora no art. 62 pela EC-32/2001. Os pressupostos da *relevância* e da *urgência* já existiam, sempre apreciados subjetivamente pelo Presidente da República; nunca foram rigorosamente respeitados. Por isso, foram editadas medidas provisórias sobre assuntos irrelevantes ou sem urgência. Jamais o Congresso Nacional e o Poder Judiciário se dispuseram a apreciá-los para julgar inconstitucionais MPs que a eles não atendessem, sob o falso fundamento de que isso era assunto de estrita competência do Presidente da República. Agora a deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias depende de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais, tanto os formais quanto os materiais (art. 62, § 5º). Significa, por um lado, que tais pressupostos são sindicáveis; por outro lado, que o entendimento da Casa por onde se inicia a sua votação – a Câmara dos Deputados – no sentido de que foram atendidos não vincula a Casa revisora – o Senado Federal; e, de outra banda, ainda, que, sendo apreciáveis objetivamente, o Poder Judiciário não pode recusar sua apreciação quando, para tanto, invocado.

Os pressupostos materiais extraem-se do disposto no § 1º do art. 62, que arrola matérias vedadas às medidas provisórias, tais como: I – as relativas a (a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; (b) direito penal, processual penal e processual civil; (c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; (d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares; II – que visem a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; III – reservadas à lei complementar; IV – já disciplinadas em projeto aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Concluído pelo juízo prévio de admissibilidade da medida provisória, previsto no § 5º do art. 62, que ela versa qualquer dessas matérias, deve ser simplesmente arquivada, assim também se se concluir que falta um dos pressupostos formais *relevância* ou *urgência* – um ou outro, porque se exige sejam conjuntamente atendidos.

Não se proíbem, como se notou, medidas provisórias sobre matéria tributária, mas se estatui que se a medida implicar restituição ou majoração de impostos, salvo os previstos nos arts. 153, I, II, IV e V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada (art. 62, § 2º). Essa situação prova falta do pressuposto de urgência, mas assim mesmo a Constituição permite a medida.

Perdura a limitação às medidas provisórias introduzida pela EC-6/95, pela qual é vedada sua adoção na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995. O objetivo imediato consistiu em estabelecer limites de atuação do Poder Executivo quanto às leis mencionadas nas ECs-5, 6, 7 e 8 relativamente à regulamentação das matérias ali previstas que eram monopólios. E aí seu alcance é importante. Abriram-se os monopólios, mas se estabelece regra de controle dessa abertura pelo Congresso Nacional.

As medidas provisórias terão eficácia imediata, mas a perderão, desde sua edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias (que se suspende no recesso do Congresso Nacional), contados de sua publicação – prazo, esse, prorrogável uma vez por igual período se não tiverem sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional naquele prazo (art. 62, § 3º). Em certo sentido, há uma incoerência entre o disposto nos §§ 3º e 6º do art. 62, introduzidos pela EC-32/2001, porque o primeiro admite perda de eficácia de MPs que não forem apreciadas no prazo de 120 dias (60 dias mais prorrogação por igual período), enquanto o segundo preordena mecanismos que impõem ao Congresso Nacional sua apreciação, quando declara que se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. Por esse regime, todas as medidas provisórias terão que ser votadas, sendo, por isso, aprovadas ou rejeitadas, sem margem para a perda de eficácia por não apreciação como prevê o § 3º. Apesar disso, o § 10 do art. 62 (EC-32/2001) insiste em falar em MPs que tenham perdido eficácia por decurso de prazo, vedando reedições nesse caso e no de sua rejeição dentro da mesma sessão legislativa.

São, como se nota, medidas de lei (têm força de lei) sujeitas a uma condição resolutiva, ou seja, sujeitas a perder sua qualificação legal no prazo de 120 dias. Vale dizer, dentro deste prazo perdem sua condição de medidas provisórias por uma das três situações previstas no § 3º do art. 62: sua *conversão em lei* no prazo, sua *rejeição* ou,

não se verificando nem aquela, nem esta, a *perda de sua eficácia* (pelo visto, de difícil ocorrência). No caso de rejeição e de perda da eficácia é que incumbe ao Congresso Nacional disciplinar, por *decreto legislativo*, as relações jurídicas delas decorrentes. Se esse decreto legislativo não for editado até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória (insiste o § 11) as relações constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência continuarão por ela regidas.

O procedimento das medidas provisórias é simples. São apreciadas pelo Plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional em sessões separadas, após exame e parecer de uma comissão mista de deputados e senadores (art. 62, § 9º). Deve-se entender que se o parecer for pela aprovação da medida provisória a comissão apresentará com ele um projeto de lei de sua conversão. Prevê-se agora que a lei de conversão pode alterar a medida provisória. Se o projeto de lei de sua conversão propuser alteração no seu texto original, ela se manterá integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto (art. 62, § 12). Podem surgir problemas, aqui, sobre as relações jurídicas decorrentes da parte alterada da medida provisória que talvez comportem composição, mas para este caso não está prevista sua disciplina por decreto legislativo.

IV. ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS

14. Conteúdo

Por *estatuto dos congressistas* devemos entender o conjunto de normas constitucionais que estatuí o regime jurídico dos membros do Congresso Nacional, prevendo suas prerrogativas e direitos, seus deveres e incompatibilidades. Quase tudo está concentrado nos arts. 53 a 56.

15. Prerrogativas

São estabelecidas menos em favor do congressista que da instituição parlamentar, como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais. A CF/88 restituiu aos parlamentares suas prerrogativas básicas, especialmente a *inviolabilidade* e a *imunidade*, mantendo-se o *privilegio de foro* e a *isenção do serviço militar* e acrescentou a limitação ao *dever de testemunhar*, em termos que veremos.

A *inviolabilidade* sempre foi a exclusão de cometimento de crime de opinião por parte de Deputados e Senadores; mas, agora, com a redação da EC-35/2001 ao *caput* do art. 53, se estabelece que eles são invioláveis civil e criminalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Exclui-se assim os congressista também da responsabilidade civil. A *inviolabilidade*, que, às vezes, também é chamada

de *imunidade material*, exclui o crime nos casos admitidos; o fato típico deixa de constituir crime, porque a norma constitucional afasta, para a hipótese, a incidência da norma penal.

A *imunidade* (propriamente dita),²⁰ ao contrário da *inviolabilidade*, não exclui o crime, antes o pressupõe, mas *impede o processo*. Trata-se de prerrogativa processual. É esta a verdadeira imunidade, dita *formal*, para diferenciar da material. Ela envolve a disciplina da *prisão* e do *processo* de congressistas.

Quanto à *prisão*, estatui-se que, salvo flagrante de crime inafiançável, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos dentro do período que vai desde a sua diplomação até o encerramento definitivo de seu mandato por qualquer motivo, incluindo a não reeleição. Podem, pois, ser presos nos casos de flagrante de crime inafiançável, mas, nesse caso, os autos serão remetidos, dentro de 24 horas, à Câmara respectiva, para que, pelo voto da maioria (absoluta) de seus membros, resolva sobre a prisão (art. 53, § 2º, EC-35/2001). Convém ponderar a respeito da questão da afiançabilidade de crime, hoje importante, diante do disposto no art. 5º, LXVI, segundo o qual ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Se o crime for daqueles que admitem liberdade provisória, o tratamento a ser dado ao congressista há de ser idêntico ao dos crimes afiançáveis, ou seja: *vedada a prisão*.

Quanto ao *processo*, a nova redação dada ao art. 53 pela EC-35 trouxe importantes modificações, porque o processo não depende mais da licença prévia da Casa a que o congressista pertence. Agora, recebida a denúncia contra parlamentar, por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à Casa respectiva. Contudo, partido político nesta representado poderá pedir à referida Casa a sustação do andamento da ação, pedido esse que deverá ser apreciado pela Casa no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. Se a Casa aceitar o pedido pelo voto da maioria (absoluta) de seus membros, o processo será sustado, qualquer que seja a fase de seu desenvolvimento, antes da decisão final. Mas a sustação importa também a suspensão do prazo prescricional, enquanto durar o mandato (art. 53, §§ 3º, 4º e 5º, EC-35/2001).

20. Cf. Alcino Pinto Falcão, *Da imunidade parlamentar*, Rio de Janeiro, Forense, 1955; Raul Machado Horta, "Imunidades parlamentares", RDP 3/31 e ss.; Pedro Aleixo, *Imunidades parlamentares*, Belo Horizonte, Ed. RBEP, 1961; Fernanda Dias Menezes de Almeida, *Imunidades parlamentares*, Brasília, Câmara dos Deputados/Coordenação de Publicações, 1982; Zeno Veloso, "Imunidades parlamentares dos Vereadores", RIL 92/147 e ss.

Privilégio de foro. Embora a EC-35/2001 não tenha repetido o texto do § 4º do art. 53, o privilégio de foro de Deputados e Senadores continua, por força da referência contida no § 3º do mesmo artigo, que indiretamente o reconhece, ao dispor que serão submetidos a julgamento, em processo penal, perante o Supremo Tribunal Federal.

Limitação ao dever de testemunhar. Deputados e Senadores, em princípio, têm o dever de testemunhar em juízo sobre fatos que se suponham de seu conhecimento e indispensáveis à instrução do processo penal ou civil. Não podem ser intimados como qualquer testemunha, sob pena de serem conduzidos debaixo de vara. O Juiz do processo tem o dever de tratá-los com a cortesia que merece um membro de outro Poder. O princípio da harmonia entre os Poderes o exige. Devem ser convidados a prestar seu testemunho em dia e hora convenientes. Por outro lado, devem corresponder ao membro de outro Poder com a mesma lhanza, indicando dia e hora da maneira mais apropriada possível ao funcionamento do juízo. A Constituição não dá o privilégio de os parlamentares serem ouvidos em lugar por eles designado. Em princípio, fá-lo-ão em juízo, no dia e hora marcados. Contudo, os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações (art. 53, § 6º).

Isenção do serviço militar. É uma prerrogativa que se assemelha à imunidade, na medida em que o congressista fica *imune* a uma obrigação imposta pela Constituição a todos os brasileiros (art. 143). Mas, por ser um serviço compulsório cuja prestação importará impedir o exercício do mandato, o art. 53, § 7º, estabelece que a incorporação, às Forças Armadas, de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Casa respectiva. Por isso, mesmo que o congressista queira incorporar-se às Forças Armadas, não poderá fazê-lo por sua exclusiva vontade, salvo se renunciar ao mandato.

Imunidades e estado de sítio. As imunidades de Deputados e Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas, mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Vale dizer, se os atos forem praticados no recinto do Congresso Nacional a imunidade é absoluta, não comportando a suspensão pela Casa respectiva. É uma garantia importante, porque se harmoniza com o disposto no parágrafo único do art. 139 e porque afasta qualquer pretensão de aplicar a parlamentares as restrições previstas nos incisos desse artigo.

16. Direitos: subsídio

Os congressistas têm direitos genéricos decorrentes de sua própria condição parlamentar, como os de debater matérias submetidas à sua Câmara e às comissões, pedir informações, participar dos trabalhos legislativos, votando projetos de lei, salvo impedimento moral por interesse pessoal ou de parente próximo na matéria em debate, tudo na forma regimental. Muitos desses direitos são líquidos e certos e, portanto, amparáveis por mandado de segurança.

O *subsídio* dos Deputados e Senadores é um direito específico que a Constituição lhes reconhece. Ela o tinha abandonado em favor do genérico *remuneração*. Agora a EC-19/98 reincorporou-o, como forma de estipendiar os parlamentares em geral e outras categorias de agentes públicos, como veremos no n. 5 do Cap. III do Tít. IV desta Parte Terceira, quando apreciaremos outros aspectos desse conceito. Aqui basta observar que a Constituição, pela referida EC-19/98, rompeu com a tradição do *subsídio* parlamentar dividido em parte fixa e parte variável. Consoante o novo enunciado no art. 49, VII, o subsídio, idêntico para Deputados Federais e Senadores, será fixado *em parcela única* pelo Congresso Nacional, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Observar os arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, significa dar tratamento tributário aos subsídios dos congressistas igual ao de qualquer outro contribuinte e à incidência do imposto de renda e proventos de qualquer natureza informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei.

Um problema de interpretação, que convoca nossa atenção, se encontra na cláusula do art. 49, VII, que manda observar o art. 37, XI, juntamente com o art. 39, § 4º. É que este último já menciona o direito ao subsídio em parcela única etc., “obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”. Que significado tem o novo enunciado do art. 49, VII, quando diz que o subsídio observará o art. 37, XI, e também o art. 39, § 4º, repetindo aquele que já se contém neste? Há de haver alguma consequência, porque não se há de entender o fato como mera redundância. A consequência, parece-nos, é a de que esta explicitação específica do inc. XI do art. 37, para o caso, quer significar a exclusão do inc. X, referido também no art. 39, § 4º. Isso quer dizer que os subsídios dos congressistas ficam sujeitos ao teto previsto no art. 37, XI, mas não ficam sujeitos à regra do art. 37, X. Este estabelece que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”. A exclusão visa evitar um problema de interpretação,

porque resultaria contraditório mandar aplicar um dispositivo que prevê fixação e alteração de subsídio por *lei específica*, quando o subsídio dos congressistas é fixado e alterado por *decreto legislativo*. Está, então, proibida a revisão anual do subsídio dos congressistas? Parece que não. Primeiro, porque o texto emendado não prevê, como no original, que o subsídio seja fixado “em cada legislatura, para a subsequente”. Segundo, porque é de se aplicar o art. 37, X, por analogia. Não há perigo de abuso, porque o subsídio parlamentar está sujeito ao teto, que corresponde ao subsídio dos Ministros do STF e é fixado por lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da República e do próprio STF.

17. Incompatibilidades

São regras que impedem o congressista de exercer certas ocupações ou praticar certos atos cumulativamente com seu mandato. Constituem, pois, impedimentos referentes ao exercício do mandato. Referem-se ao eleito. Não interditam candidaturas, nem anulam a eleição de quem se encontre em situação eventualmente incompatível com o exercício do mandato. São estabelecidas expressamente no art. 54, determinando umas *desde a expedição do diploma do eleito*, outras apenas *desde a posse no mandato*. As incompatibilidades podem ser classificadas nos tipos seguintes:

(1) *incompatibilidades funcionais*, as que interditam: (a) *desde a diplomação*: aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis *ad nutum*, em pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresas públicas, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público (art. 54, I, b); (b) *desde a posse*: ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis *ad nutum* naquelas mesmas entidades (art. 54, II, b),²¹ ressalvado o de Ministro, de Governador de Território, de Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária (art. 56);

(2) *incompatibilidades negociais*, as que vedam, *desde a diplomação*: firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obede-

cer a cláusulas uniformes (art. 54, I, a). A caracterização de contrato de cláusulas uniformes, não alcançado pelas incompatibilidades, é controvertida em doutrina; típicos são os chamados *contratos de adesão*, tais como o de seguro, o de transporte, o de fornecimento de gás, luz e força, o de prestação de serviços de telefones, certos contratos bancários e alguns de direito marítimo;

(3) *incompatibilidades políticas*, as que proíbem os congressistas de serem titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo, o que vale dizer que a pessoa não pode ser ao mesmo tempo Deputado e Senador, ou Deputado e Vereador, ou Senador e Prefeito, ou Senador e Vice-Presidente, ou Deputado e Vice-Governador; ou Deputado e Vice-Prefeito, como aconteceu muito no regime da Constituição anterior, que vedava apenas exercer outro *cargo* eletivo, e aí a interpretação puramente literal chegou à conclusão (do ponto de vista literal, com razão) de que Vice não exerce cargo. Não se vá agora concluir que não exerce mandato e tudo fica na mesma;

(4) *incompatibilidades profissionais*, assim consideradas as que impedem aos congressistas *desde a posse*: (a) serem proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercerem função remunerada (art. 54, II, a); (b) patrocinarem causa em que seja interessada pessoa jurídica de direito público, autarquia, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público (art. 54, II, c). *Patrocínio da causa* é expressão técnico-processual e se refere ao exercício do *ius postulandi*, que só cabe a advogado, de sorte que essa incompatibilidade diz respeito ao impedimento de o congressista advogado defender interesses de constituinte seu em processo judicial contra aquelas entidades.

18. Perda do mandato

O regime jurídico dos congressistas disciplina também hipóteses em que ficam sujeitos à perda do mandato, que se dará por *cassação* ou por simples *extinção*.

Cassação “é a decretação da perda do mandato, por ter o seu titular incorrido em falta funcional, definida em lei e punida com esta sanção”.²² *Extinção do mandato* é o perecimento do mandato pela ocorrência de fato ou ato que torna automaticamente inexistente a investidura eletiva, tais como a morte, a renúncia, o não comparecimento a certo número de sessões expressamente fixado (desinteres-

21. Vê-se que o art. 54, I, b, veda aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado de que sejam demissíveis *ad nutum*, desde a diplomação; o mesmo art. 54, II, b, veda ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis *ad nutum*, nas mesmas entidades, desde a posse. Não houve jeito de convencer Relator e constituintes que essa redundância, sujeita a situações diversas, é pura tolice. Ora, aceitar e exercer não difere de ocupar. A única diferença é que em um se menciona emprego, em outro não.

22. Cf. Hely Lopes Meirelles. *Direito municipal brasileiro*, p. 513.

se, que a Constituição eleva à condição de renúncia), perda ou suspensão dos direitos políticos.²³

Fácil agora é verificar que são casos de *cassação de mandato* dos congressistas os previstos no art. 55, I, II e VI, que dependem de decisão da Câmara ou do Senado, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. É que aí se instaura um processo político de apuração das causas que justificam a decretação da perda do mandato, isto é, da cassação deste pela Casa a que pertencer o imputado. Trata-se de decisão constitutiva.

Os casos do art. 55, III, IV e V, são de simples *extinção do mandato*, de sorte que a declaração pela Mesa da perda deste é meramente declaratória, pois é apenas o reconhecimento da ocorrência do fato ou ato de seu perecimento; por isso é feito pela Mesa da Casa a que pertencer o congressista, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. A Constituição não disse como se define a perda de mandato no caso em que o congressista perde ou tem suspensos os seus direitos políticos, mas, à evidência, nesse caso, se dá a extinção do mandato como consequência direta daquele fato; não há nada mais a fazer, senão a própria Mesa da Casa do congressista reconhecer, por declaração, a perda do mandato.

Quando da chamada CPI do Orçamento que levou à renúncia e à cassação diversos parlamentares envolvidos em atos de corrupção na elaboração e execução orçamentária, relevante questão foi suscitada a respeito da posição jurídica de parlamentar submetido a processo que pudesse levá-lo à perda do mandato, no caso de que viesse, antes disso, renunciar ao seu mandato, visando a evitar as consequências da pena. Uns achavam (nós inclusive) que, nada tendo disposto a Constituição a respeito, a renúncia implicava simplesmente a perda do mandato por via dela, mas não a suspensão da elegibilidade (inelegibilidade) por oito anos, quando se tratasse de infração do disposto no art. 55, I e II, da Constituição, consoante prevê o art. 1º, I, *b*, da lei das inelegibilidades (Lei Complementar 64/90, com redação da Lei Complementar 81/94). Outros entendiam que a renúncia não poderia evitar essa consequência.

Diante dessas dúvidas, preparamos uma *proposta de emenda de revisão*, apresentada pelo Senador Mário Covas durante o processo revisional (PRE 016658-1), acrescentando o § 4º ao art. 55, com o teor seguinte: *Será inelegível pelo prazo de oito anos o congressista submetido a*

investigação parlamentar ou a processo de cassação de mandato que vier a renunciar ao mandato. Não foi bem assim que o Congresso Revisional solucionou a pendência. Preferiu determinar a suspensão dos efeitos do ato de renúncia, no termos seguintes: *A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º* (art. 55, § 4º, acrescentado pela ECR-6/94). O texto, como se nota, abrange todas as hipóteses de infração previstas no art. 55, e não apenas as dos incisos I e II desse artigo, que provocam a inelegibilidade referida no art. 1º, I, *b*, da lei das inelegibilidades. A remissão aos §§ 2º e 3º do art. 55 significa que a medida abrange tanto os processos que levam à extinção como os que conduzem à cassação do mandato, embora nem todos os casos resultem em inelegibilidades. Só as hipóteses de processo de cassação por infração das proibições estabelecidas no art. 54 ou por procedimento incompatível com o decoro parlamentar, nos termos do já citado dispositivo da lei das inelegibilidades.

É uma providência salutar, que merece aplausos.

23. Idem, Ibidem

Capítulo III

DO PODER EXECUTIVO

1. Noção e formas. 2. Chefe de Estado e Chefe de Governo. 3. Eleição e mandato do Presidente da República. 4. Substitutos e sucessores do Presidente. 5. Subsídio. 6. Perda do mandato do Presidente e do Vice. 7. Atribuições do Presidente da República. 8. Classificação das atribuições do Presidente da República. 9. Responsabilidade do Presidente da República.

1. Noção e formas

A expressão *Poder Executivo* é de conteúdo incerto.¹ Em nossa Constituição, ora exprime a função (art. 76), ora o órgão (cargo e ocupante, art. 2º). Seu conteúdo envolve poderes, faculdades e prerrogativas da mais variada natureza. Pode dizer-se, de modo geral, que se trata de órgão constitucional (supremo) que tem por função a prática de atos de chefia de estado, de governo e de administração.

Maurice Duverger mostra que o Executivo reveste na prática formas as mais diversas, encontrando-se *executivo monocrático* (Rei, Imperador, Ditador, Presidente), *executivo colegial* (para ele, é o exercido por dois homens com poderes iguais, como os cônsules romanos), *executivo diretorial* (grupos de homens em *comitê*, como era na ex-URSS e ainda é na Suíça) e *executivo dual* (próprio do parlamentarismo, um Chefe de Estado e um Conselho de Ministros, ou seja, um indivíduo isolado e um *comitê*).²

2. Chefe de Estado e Chefe de Governo

A Constituição estabelece que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado (art. 76). Vale dizer, segundo a classificação de Duverger, temos um *Executivo monocrático*, porque é exercido por um só indivíduo.

Isso caracteriza o *sistema de governo presidencialista*, como vimos, pois que o Presidente da República, como Chefe do Poder Executivo,

1. Cf. Edward S. Corwin. *El poder ejecutivo*, Buenos Aires. Ed. Bibliográfica Argentina, 1959, trad. de Laura E. Pelegrino; J. Djordjevic et al., *O papel do Executivo no Estado moderno*, Belo Horizonte, RBEP, 1964.

2. Cf. *Droit constitutionnel et institutions politiques*, v. I/135 e ss.

enfeixa as funções de Chefe de Estado e as de Chefe de Governo, e não depende da confiança do Congresso, para ser investido no cargo nem para nele permanecer, uma vez que tem mandato fixo de quatro anos, ao contrário do que ocorre no *sistema de governo parlamentar*, que a Constituinte recusou adotar para o Brasil, no momento, remetendo a um plebiscito a realizar-se a 7.9.93 a decisão de manter o presidencialismo ou acolher o parlamentarismo, em que as funções de Chefe de Estado são cumpridas por um indivíduo — Presidente eleito direta ou indiretamente, nas Repúblicas, ou Monarca, nas Monarquias — enquanto as funções de governo cabem a um órgão coletivo (Conselho ou Gabinete de Ministros), consoante verificamos em capítulo anterior. O plebiscito, que deveras se realizou, não naquela data inicialmente prevista, mas a 21.4.93, por força da EC 3/92, concluiu por grande maioria de votos pela manutenção da República presidencialista.

3. Eleição e mandato do Presidente da República

O Presidente da República é *eleito*, simultaneamente com um Vice-Presidente, dentre brasileiros natos que preencham as condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º. A eleição realizar-se-á, em primeiro turno, no primeiro domingo de outubro e, em segundo turno, se houver, no último domingo de outubro, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

A Constituição consolidou o direito do povo de eleger o Presidente da República pelo sufrágio universal e voto direto e secreto. Manteve também o princípio da maioria absoluta para a eleição presidencial, reputando-se eleito Presidente, por conseguinte, o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Se nenhum dos candidatos alcançar essa maioria, far-se-á uma segunda eleição, isto é, um segundo turno de votação, no dia indicado supra, concorrendo apenas os dois candidatos mais votados, tendo-se como eleito aquele que conseguir a maioria dos votos válidos. “Votos válidos” são todos os votos, expurgados os em branco e os nulos. Logo, no segundo turno também se requer a maioria absoluta de votos válidos, tanto quanto na primeira votação. “Maioria de votos válidos” entre dois candidatos (art. 77, § 3º) e “maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos” são expressões equivalentes (art. 77, § 2º).

O que se quer aqui firmar é a idéia de que o princípio não é o de dois turnos, como geralmente se diz. Dois turnos constituem nada mais nada menos do que uma técnica de realização do princípio da maioria absoluta, tanto que, conseguida esta no primeiro turno, tollitur quaestio, a questão está resolvida. Não o conseguindo é que se passa-

rá ao segundo turno, com dois candidatos apenas, e aí a maioria dos votos é sempre mais da metade e isso é maioria absoluta. Poder-se-á argumentar que, mesmo entre dois candidatos, é possível que a maioria absoluta dos eleitores não tenha sufragado o que obteve a maioria dos votos válidos. Isso é verdade, mas também o é em relação à primeira eleição, em que, também, os votos em branco e os nulos podem superar os do candidato que teoricamente tivera a maioria absoluta dos votos.

A preocupação em realizar o princípio da maioria absoluta é que levou o Constituinte a determinar que, se, antes do segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação (art. 77, § 4º). Isso visa a evitar conchavos entre os dois candidatos mais votados de modo a que um concordasse em desistir, com o que o outro seria considerado eleito, mesmo sem satisfazer o princípio da maioria absoluta. É verdade que é possível que todos os demais desistam, e nesse caso a Constituição não aponta a solução. Mas se tivermos em mente que o princípio é o da maioria absoluta, e não dos dois turnos, parece plausível admitir a anulação da eleição, que resultara fraudada, marcando-se outra dentro de vinte dias para realizar outro primeiro turno, passando-se ao segundo, se necessário. Finalmente, a regra do mais idoso figura no art. 77, § 5º, como modo de vencer eleição em caso de empate entre dois candidatos no segundo. Sorte é que a raridade do fato tornará esporádica a aplicação da regra.

O eleito conquista um *mandato de quatro anos* (art. 82),³ do qual tomará *posse*, no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição, perante o Congresso Nacional, em sessão conjunta, e, se este não estiver reunido, será convocado extraordinariamente pelo Presidente do Senado Federal. Aí prestará o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.⁴

Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago (art. 78, parágrafo único). Quem pode declarar a vacância, a Constituição não o diz, como faziam as anteriores, que o atribuíam ao Congresso Nacional. Se a Constituição não outorga esse poder a nenhum outro órgão, por sua natureza

política só pode caber ao Congresso Nacional. É ato político que só a ele incumbe, no silêncio da Carta Magna. Não é ato eleitoral, por exemplo, para se reconhecer competência ao Tribunal Superior Eleitoral. Afora esse aspecto, o dispositivo repete a Constituição revogada. E, como esta, o texto significa que o cargo será declarado vago se nenhum deles comparecer para a posse na Presidência. Se o Presidente não comparecer, mas comparecer o Vice, este assume o cargo de Presidente, definitivamente se a ausência do Presidente imotivada ou motivada gerar a impossibilidade de sua investidura. Foi a solução dada em consequência da morte do Presidente Tancredo Neves. Se nenhum dos dois comparecer, dá-se a vacância do cargo a ser reconhecida e declarada pelo Congresso Nacional, realizando-se eleição noventa dias depois (art. 81).

4. Substitutos e sucessores do Presidente

Com o Presidente será eleito um Vice-Presidente da República, que será seu companheiro de chapa. A eleição do Presidente implica automaticamente a eleição do Vice-Presidente com ele registrado, que sequer é votado. Foi a mecânica que o sistema constitucional engendrou para evitar que o Vice-Presidente eleito pertença a partido de oposição ao Presidente, como não poucas vezes acontecera, desde Floriano Peixoto.

Ao Vice-Presidente cabe substituir o Presidente, nos casos de impedimento (licença, doença, férias), e suceder-lhe no caso de vaga, e, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais (art. 79, parágrafo único).

Outros substitutos do Presidente são: o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal, que serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência da República, se ocorrer o impedimento concomitante do Presidente e do Vice ou no caso de vacância de ambos os cargos. Nesta hipótese, convocar-se-á eleição direta para noventa dias depois da última vaga, se esta ocorrer antes de iniciar os dois últimos anos de mandato presidencial, porque, se a última vaga se der nos últimos dois anos, a eleição será feita trinta dias depois pelo Congresso Nacional, na forma da lei.⁵ Ou seja, vacância nos primeiros dois anos, eleição popular direta; vacância nos dois anos derrá-

3. A ECR-5/94 reduziu de cinco para quatro anos o mandato do Presidente da República. A idéia era acompanhar essa redução com a possibilidade de reeleição para mais um período presidencial, mas a proposta de reeleição foi, então, rejeitada pelos revisores e agora adotada pela EC-16/97.

4. Cf. art. 57, §§ 3º, III, e 6º, I, c/c o art. 78.

5. Se ocorrer o fato e não houver essa lei, deve-se fazer a eleição com base em regras regimentais (ainda que por analogia), pois o texto constitucional é bastante para a prática do ato. Não se há que embarçar-se em controvérsias inúteis, quando o sistema constitucional possibilita alcançar o fim pretendido.

deiros, eleição indireta pelo Congresso Nacional. Em qualquer dos casos, os eleitos simplesmente completarão o período de seus antecessores.⁶ Essa regra de “mandato-tampão”, agora, é justificável em ambas as circunstâncias — na eleição indireta como na direta —, visto que a fixação de mandato para quatro anos teve a fundamentá-la o princípio da coincidência de mandatos federais e estaduais. Essa exigência requer que, em havendo vacância nos termos do art. 81, os novos eleitos apenas concluam o mandato presidencial em curso. Quer isso dizer que já não procede a observação que fizemos nas edições anteriores de que tal situação só se justificava na hipótese da eleição indireta nos dois últimos anos, porém não teria sentido no caso de eleição direta ali prevista. Agora, ao contrário, tem sentido.

5. Subsídios

O Presidente e o Vice-Presidente da República têm direito a estipêndios mensais pelo exercício de seus mandatos, em forma de subsídios em parcela única, que serão fixados pelo Congresso Nacional. De fato, a este cabe a competência exclusiva de fixar-lhes os subsídios (art. 49, VIII). Esse dispositivo, com o enunciado da EC-19/98, não estabelece o momento da fixação dos subsídios. Não se estipula, como foi da tradição constitucional, que os subsídios são fixados antes de findo o período governamental para vigorar no subsequente. A providência tem, porém, que preceder o início do exercício financeiro, logo, haverá que ser tomada antes de encerrar a sessão legislativa ordinária. O Congresso não está obrigado a tomar a providência. Se não o fizer, os subsídios do Presidente e do Vice continuarão os mesmos do exercício anterior. O texto emendado não repete a previsão original, segundo a qual os estipêndios seriam revistos anualmente. Então, é de se perguntar se essa falta de previsão impede essa revisão. Parece-nos que não impede, pois achamos pertinente a aplicação do art. 37, X, por analogia. Analogia, porque este fala em lei específica, enquanto os subsídios, em tela, são fixados por decreto legislativo. O art. 49, VIII, com o novo enunciado normativo, manda observar o art. 39, § 4º, que remete ao art. 37, X e XI, parecendo-nos, portanto, razoável pensar na situação analógica invocada, além de expressamente determinada a observância do teto, que são os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Esses subsídios estão, como qualquer outro rendimento do trabalho, sujeitos ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer

6. Tudo isso consta do art. 81 e seus dois parágrafos. Sobre o tema, cf. Dalmo de Abreu Dallari, “Substitutos eventuais de mandatários políticos”, *RFDUSP*, ano LXI — Fascic. II, São Paulo, 1966.

natureza, sendo esses nobres contribuintes tratados tal como os demais, aplicados aí também os critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade da tributação, na forma da lei, tudo com observância do que dispõem os arts. 150, II, e 153, III, § 2º, I, aos quais também remete o art. 49, VIII.

6. Perda do mandato do Presidente e do Vice

O Presidente e o Vice-Presidente da República perdem os respectivos mandatos nos seguintes casos:

(1) cassação, em virtude de decisão do Senado Federal nos processos de crime de responsabilidade, ou de decisão judicial como efeito da condenação em processo de crime comum; note-se, contudo, que a Constituição não prevê crimes de responsabilidade para o Vice-Presidente, enquanto tal; só será submetido ao julgamento do Senado quando assumir a Presidência, e aí incorrer no crime (arts. 52, parágrafo único, e 86);

(2) extinção, nos casos de morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos e perda da nacionalidade brasileira;

(3) declaração de vacância do cargo pelo Congresso Nacional, daquele ou de ambos quando não comparecerem para tomar posse dentro de dez dias da data para isso fixada; como a data fixada é 1º de janeiro, o prazo vence a 11 de janeiro, contando-o, de acordo com os princípios, a partir do dia seguinte (2 de janeiro, inclusive) (arts. 78 e 82); o não comparecimento no prazo indicado, salvo motivo de força maior, vale como renúncia, e, então, a hipótese é de extinção do mandato, e o ato congressional de seu reconhecimento é meramente declaratório;

(4) ausência do País, por mais de quinze dias, sem licença do Congresso Nacional, nos termos do art. 83, que declara que não poderão eles, sem licença do Congresso Nacional, se ausentar do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo. Quem é competente para aplicar a pena de perda do cargo nesse caso? Houve quem entendesse, no regime da Constituição de 1946, ser o Tribunal Superior Eleitoral. A matéria não é eleitoral, e não tendo sido dado expressamente a esse Tribunal tal cometimento, não pode ser ele o órgão competente no caso. Só pode ser o Congresso Nacional, porque se a ele cabe dar a licença (arts. 49, III, e 83), a ele também compete a verificação do não cumprimento da regra que a exige e, conseqüentemente, a aplicação da sanção correspondente. Demais, a ausência do País, por mais de quinze dias, salvo motivo de força maior, equivale a renúncia. Trata-se, portanto, de hipótese de extinção de mandato, não cabendo sua declaração a nenhum órgão jurisdicional, por cuidar-se de questão política.

7. Atribuições do Presidente da República

Compete privativamente ao Presidente da República: nomear e exonerar os Ministros de Estado; exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal; iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição; sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; vetar projetos de lei, total ou parcialmente; dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos e sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos; celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional (art. 49, I); decretar o estado de defesa e o estado de sítio; decretar a intervenção federal; remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias; conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei; exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos; nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do STF e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei (“quando determinado em lei” só se refere aos “outros servidores”); nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União; nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição (arts. 101, parágrafo único, 104, parágrafo único, 107, 111, §1º, 118, II, 120, III, e 123); nomear o Advogado-Geral da União (art. 131, § 1º); nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII; convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional; declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional (art. 49, II); celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional (art. 49, II); conferir condecorações e distinções honoríficas; permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente (arts. 21, IV, e 49, II); enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orça-

mento previstos na Constituição; prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62; exercer outras atribuições previstas na Constituição (tais como: convocar extraordinariamente o Congresso Nacional, art. 57, § 6º, II; elaborar leis delegadas, art. 68).

São essas as atribuições enumeradas, como *privativas* do Presidente, no art. 84 da Constituição, cujo parágrafo único, no entanto, permite que ele delegue as mencionadas nos incisos VI (*dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração, na forma da lei*), XII (*conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei*) e XXV, primeira parte (*prover os cargos públicos federais, na forma da lei*), aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão, *evidentemente*, os limites traçados nas respectivas delegações.

8. Classificação das atribuições do Presidente da República

Como se viu, múltiplas se mostram as atribuições do Presidente da República. Nos dispositivos indicados só se consignam as atribuições privativas e de prática diuturna. Outras, porém, existem por decorrência de sua posição constitucional.

Muitas tentativas têm sido feitas visando a classificá-las.⁷ Os critérios utilizados divergem, tampouco se trata de problema de grande relevo, para merecer maior preocupação, embora não seja destituído de valor didático apresentar classificação aceitável.

Achamos que as atribuições do Presidente da República se enquadram todas nestas três funções básicas do Poder Executivo:

(1) *Chefia do Estado*, com as matérias relacionadas no art. 84, VII, VIII, XVIII, segunda parte (convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional), XIV (apenas no que se refere à nomeação de Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, por ser função de magistratura suprema), XV (nomeação de um terço dos membros do TCU — órgão não executivo — nomeação sujeita ao controle do Senado, por isso ato nem da chefia do Governo, nem da chefia da

7. Cf. Edward S. Corwin, *ob. cit.*; Agustín de Vedia, *Derecho constitucional y administrativo*, pp. 390 e ss.; Alejandro Silva Bascunán, *Tratado de derecho constitucional*, t. III/251; Jorge Mário Quinzio Figueiredo, *Manual de derecho constitucional*, p. 429; Paulo Sarasate, *A Constituição do Brasil ao alcance de todos*, p. 388; Antônio de Sampaio Dória, *Comentários à Constituição de 1946*, v. III/370 e ss.; Eduardo Espínola, *Constituição dos Estados Unidos do Brasil*, v. II/408 e ss.; Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de Direito Constitucional*, pp. 196 e 197.

Administração), XVI, primeira parte (nomeação de magistrados: TRF, TRT, TRE, órgãos de outro Poder), XIX, XX, XXI e XXII;

(2) *Chefia do Governo*, com as matérias indicadas no art. 84, I, III, IV, V, IX, X, XI, XII (“conceder anistia e comutar pena” é atribuição de magistratura suprema da Nação, sempre encarnada no Chefe de Estado, mas a Constituição autorizou sua delegação, o que a desqualifica para mera função de governo), XIII, XIV (menos quanto à nomeação dos Ministros do STF e dos Tribunais Superiores), XVII (nomear membros do Conselho da República, não ato de mera chefia da Administração porque alguns são eleitos pelo Senado e pela Câmara de Deputados), XVIII, primeira parte (convocar e presidir o Conselho da República), XXIII, XXIV e XXVII;

(3) *Chefia da Administração federal*, com as matérias previstas no art. 84, II, VI, XVI, segunda parte (nomeação do Advogado-Geral da União, órgão do Poder Executivo), XXIV (também é em certo sentido ato de administração) e XXV.

9. Responsabilidade do Presidente da República

Nos regimes democráticos não existe governante irresponsável. Não há democracia representativa sem eleição. “Mas a só eleição, ainda que isenta, periódica e lisamente apurada, não esgota a realidade democrática, pois, além de mediata ou imediatamente resultante de sufrágio popular, as autoridades designadas para exercer o governo devem responder pelo uso que dele fizerem uma vez que ‘governo irresponsável, embora originário de eleição popular, pode ser tudo, menos governo democrático’”.⁸

No sistema parlamentarista, a responsabilidade do governo (Conselho de Ministros) apura-se perante o Parlamento, mediante mecanismos específicos, como o voto de desconfiança ou a moção de censura que obriga a demissão do Ministério.

No presidencialismo, o próprio Presidente é responsável, ficando sujeito a sanções de perda do cargo por infrações definidas como *crimes de responsabilidade*, apuradas em *processo político-administrativo* realizado pelas Casas do Congresso Nacional.

O Presidente da República poderá, pois, cometer crimes de responsabilidade e crimes comuns. Estes, definidos na legislação penal comum ou especial. Aqueles distinguem-se em *infrações políticas*: atentado contra a existência da União, contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação, contra o exercício dos

direitos políticos, individuais e sociais, contra a segurança interna do País (art. 85, I-IV), e *crimes funcionais*, como atentar contra a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais (art. 85, V-VII).

Todos esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento (art. 85, parágrafo único, já existindo a propósito a Lei 1.079/50), respeitados naturalmente as figuras típicas e os objetos materiais circunscritos nos incisos do art. 85.

O processo dos crimes de responsabilidade e dos comuns cometidos pelo Presidente da República divide-se em duas partes: *juízo de admissibilidade do processo e processo e julgamento*. A acusação pode ser articulada por qualquer brasileiro perante a Câmara dos Deputados. Esta conhecerá, ou não, da denúncia; não conhecendo, será ela arquivada; conhecendo, declarará procedente, ou não, a acusação; julgando-a improcedente, também será arquivada. Se a declarar procedente pelo voto de dois terços de seus membros, *autorizará a instauração do processo* (arts. 51, I, e 86), passando, então, a matéria: (a) à competência do Senado Federal, *se se tratar de crime de responsabilidade* (arts. 52, I, e 86); (b) ao Supremo Tribunal Federal, *se o crime for comum* (art. 86).

Recebida a autorização da Câmara para *instaurar o processo*, o Senado Federal se transformará em tribunal de juízo político, sob a Presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao Senado decidir se instaura ou não o processo. Quando o texto do art. 86 diz que, admitida a acusação por dois terços da Câmara, será o Presidente submetido a julgamento perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade, não deixa a este possibilidade de emitir juízo de conveniência de instaurar ou não o processo, pois que esse juízo de admissibilidade refoge à sua competência e já fora feito por quem cabia. Instaurado o processo, a primeira consequência será a suspensão do Presidente de suas funções (art. 86, § 1º, I). O processo seguirá os trâmites legais, com oportunidade de ampla defesa ao imputado, concluindo pelo *julgamento*, que poderá ser absolutório, com o arquivamento do processo, ou condenatório por dois terços dos votos do Senado, limitando-se a decisão à perda do cargo, com inabilitação por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis (art. 52, parágrafo único). É isso que caracteriza o chamado *impeachment*.

A regra, como se vê, declara que a decisão do Senado se limita à decretação da perda do cargo (a decisão decreta o *impeachment*), com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública. A idéia subjacente era a de que “com inabilitação” importava numa consequência advinda da decretação da perda do cargo. Mas o Senado

8. Cf. Paulo Brossard de Souza Pinto, O “*impeachment*”, p. 9.

Federal, no caso Collor de Mello, deu outra interpretação ao texto, de onde proveio a compreensão de que a renúncia ao cargo, durante o processo de julgamento, não implica sustação deste, que prosseguirá para confirmar a inabilitação pelo prazo indicado. Deu-se à perda do cargo pela renúncia o mesmo efeito da perda por decisão do juízo político. Note-se que a inabilitação decorre necessariamente da pena de perda do cargo, pois, no sistema atual, não comporta apreciação quanto a saber se cabe ou não cabe a inabilitação. “Com inabilitação” é uma cláusula que significa decorrência necessária, não precisando ser expressamente estabelecida nem medida, pois o tempo também é prefixado pela própria Constituição. No caso Collor de Mello, o Senado teve que se pronunciar precisamente, porque a renúncia se dava exatamente no momento do julgamento e cumpria verificar, à falta de precedentes, se o processo se encerrava ou se prosseguia o julgamento para concluir pela aplicação da pena de inabilitação para a função pública pelo prazo de oito anos. A decisão foi no sentido de que o julgamento prosseguia e, em prosseguindo, concluiu, como não poderia ser diferente, pela inabilitação, considerando esta decorrente da perda do cargo pela renúncia.

“As decisões do Senado são incontrastáveis, irrecuráveis, irrevogáveis, definitivas. Esta a lição, numerosa, de autores nacionais e estrangeiros”, ensina o Min. Paulo Brossard, em sua original e pioneira monografia sobre o *impeachment*⁹ e em vários votos emitidos no Supremo Tribunal Federal. Essa é a lição correta, pois a Constituição erigiu o Senado Federal, sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, em tribunal especial, para o julgamento político, que não é um tipo de julgamento próprio de tribunais jurisdicionais, porque estes não devem senão exercer a jurisdição técnico-jurídica. Apesar disso, no caso Collor de Mello, vimos o Pretório Excelso conhecer de propostas de revisão ou de anulação das decisões do juízo político.

Enfim, em se tratando de crimes comuns, autorizado o processo pela Câmara, este será instaurado pelo Supremo Tribunal Federal com o recebimento da denúncia ou queixa-crime, com a consequência, também imediata, da suspensão do Presidente de suas funções (art. 86, § 1º, I), prosseguindo o processo nos termos do Regimento Interno daquele Colendo Tribunal e da legislação processual penal pertinente. Nesse caso, a condenação do Presidente importa em consequência de natureza penal e somente por efeitos reflexos e indiretos implica perda do cargo, à vista do disposto no art. 15, III.

9. Cf. *ob. cit.*, p. 152, onde arrola inúmeros autores sobre o assunto.

Capítulo IV

DO PODER JUDICIÁRIO

I. JURISDIÇÃO: 1. A função jurisdicional. 2. Jurisdição e legislação. 3. Jurisdição e administração. 4. Órgãos da função jurisdicional. II. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 5. Jurisdição constitucional, guarda da Constituição e Corte Constitucional. 6. Composição do STF. 7. Competência. 8. Descumprimento de preceito constitucional fundamental. III. SÚMULAS VINCULANTES: 9. Súmulas vinculantes, súmulas impeditivas de recursos e efeito vinculante. 10. Súmulas vinculantes e assentos da jurisprudência. 11. Disciplina das Súmulas vinculantes. 12. Súmulas impeditivas de recurso. 13. Efeito vinculante. IV. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: 14. Controle externo do Poder Judiciário. 15. Composição do Conselho. 16. Funcionamento. 17. Competência. 18. Ouvidorias. V. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 19. Composição. 20. Competência. 21. Conselho da Justiça Federal. VI. JUSTIÇA FEDERAL: 22. Seus órgãos. 23. Tribunais Regionais Federais: Composição. Competência. 24. Juizes Federais: Organização da Justiça Federal de primeira instância. Competência. Foro das causas de interesse da União. VII. JUSTIÇA DO TRABALHO: 25. Organização. 26. Competência. 27. Recorribilidade das decisões do TST. VIII. JUSTIÇA ELEITORAL: 28. Organização e competência. 29. Recorribilidade de suas decisões. IX. JUSTIÇA MILITAR: 30. Composição. 31. Competência. X. JUIZADOS ESPECIAIS E DE PAZ: 32. Juizados especiais. 33. Justiça de paz. XI. ESTATUTO DA MAGISTRATURA E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO: 34. Princípios estatutários da magistratura. 35. Espécies de garantias do Judiciário. 36. Garantias institucionais do Judiciário. 37. Garantias funcionais do Judiciário. 38. Mecanismos de aceleração dos processos. 39. Escolas de magistrados.

I. JURISDIÇÃO

1. A função jurisdicional

Chegamos aqui ao terceiro Poder do Estado atribuído à União no Estado Federal brasileiro — o *Poder Judiciário* — que a Constituição organiza nos arts. 92 a 126. De passagem, já dissemos que os órgãos do Poder Judiciário têm por função compor conflitos de interesses em cada caso concreto. Isso é o que se chama *função jurisdicional* ou simplesmente *jurisdição*, que se realiza por meio de um *processo judicial*, dito, por isso mesmo, sistema de composição de conflitos de interesses ou sistema de composição de lides.

Os conflitos de interesses são compostos, solucionados, pelos órgãos do Poder Judiciário com fundamento em *ordens gerais* e *abs-*

tratas, que são *ordens legais*, constantes ora de corpos escritos que são as leis, ora de costumes, ou de simples normas gerais, que devem ser aplicadas por eles, pois está praticamente abandonado o sistema de composição de lides com base em *ordem singular* erigida especialmente para solucionar determinado conflito.

Divididas as funções da soberania nacional por três Poderes distintos, *Legislativo*, *Executivo* e *Judiciário*, os órgãos deste (juizes e tribunais) devem, evidentemente, decidir atuando o direito objetivo; não podem estabelecer critérios particulares, privados ou próprios, para, de acordo com eles, compor conflitos de interesses, ao distribuírem justiça. Salvo o *juízo de equidade*, excepcionalmente admitido, como referimos ao tratar do mandado de injunção, normalmente o juiz, no Brasil, pura e simplesmente aplica os critérios que foram editados pelo legislador.

A jurisdição hoje é monopólio do Poder Judiciário do Estado (art. 5º, XXXV). Anteriormente ao período moderno havia jurisdição que não dependia do Estado. Os senhores feudais tinham jurisdição dentro de seu feudo: encontravam-se *jurisdições feudais* e *jurisdições baronais*. Lembre-se de que os donatários das Capitânias Hereditárias no Brasil colonial dispunham da *jurisdição civil* e *criminal* nos territórios de seu domínio. No período monárquico brasileiro, tínhamos a *jurisdição eclesiástica*, especialmente em matéria de direito de família, a qual desapareceu com a separação entre Igreja e Estado. Agora só existe jurisdição estatal, confiada a certos funcionários, rodeados de certas garantias: os *magistrados*.

2. Jurisdição e legislação

Não é difícil distinguir *jurisdição* e *legislação*. Esta edita normas de caráter geral e abstrato e a jurisdição se destina a aplicá-las na solução das lides. Veja-se, por exemplo, um ato jurisdicional típico: a *sentença*. Esse ato, em termos muito simplificados, declara: "Condeno Fulano a restituir a Beltrano determinado imóvel, e mais os honorários do advogado e os frutos do imóvel pelo tempo que indevidamente o ocupou". Está aí o dispositivo de uma sentença. Dirige-se a determinada pessoa, com determinada ordem individualizada e concreta sobre um bem especificado. Compare-se com o ato legislativo, a *lei*, que diz, por exemplo: "Aquele que por vinte anos, independentemente de justo título e boa-fé, possui o imóvel como seu, adquiri-lhe-á o domínio". Dirige-se, indistintamente, a todas as pessoas. Não dá nada a ninguém especificamente. Confere a todos um direito abstratamente, e aquele que vier a encontrar-se na situação de fato descrita no texto da lei terá um direito subjetivo ao objeto nela indicado.

3. Jurisdição e administração

Mais difícil é estreimar a *jurisdição* da *administração*. Vários critérios têm sido propostos para estabelecer a distinção. Os processualistas preocupam-se com o assunto. Chiovenda, por exemplo, concebe a jurisdição como uma atividade secundária, ou coordenada, no sentido de que ela substitui a vontade ou a inteligência de alguém, cuja atividade seria primária, enquanto o administrador exerce atividade primária, ou originária, no sentido de que a desenvolve no seu próprio interesse. O juiz julga a respeito de outrem e em razão da vontade da lei concernente a outrem. A administração decide a respeito da própria atividade.¹ Outros, como Cristofolini e Luiz Eulálio de Bueno Vidigal, chegam à conclusão de que não há, realmente, distinção entre jurisdição e administração. Existem, na verdade, apenas *duas funções do Estado*, que são a *legislação* e a *aplicação da lei*, e esta se desdobra em *administração* e *jurisdição*.² Em verdade, o problema continuaria, pois, se administração e jurisdição constituem espécies do mesmo gênero *aplicação da lei*, se são espécies diferentes dessa função única, qual o critério distintivo das duas espécies? O próprio Cristofolini tentou resolver o problema. Diz que a distinção entre ambas não repousa tanto sobre uma base lógica quanto sobre uma base histórica e política, e conclui que a administração é atividade do Estado dirigida à consecução de suas funções mediante a substituição daquele interesse que o Estado considera seu, ao passo que a jurisdição é a atividade do Estado orientada para o fim de assegurar a substituição do interesse coletivo, a composição das lides mediante o estabelecimento de ordens concretas dirigidas aos titulares dos interesses em luta,³ o que, no fundo, é o mesmo que disse Chiovenda.

Essas idéias são úteis para o constitucionalista, que, no entanto, se satisfaz com o critério orgânico, considerando como de jurisdição aquilo que o legislador constituinte incluiu na competência dos órgãos judiciários e como administração o que conferiu aos órgãos do Executivo, que, em verdade, não se limita à execução da lei, consoante já vimos. Segundo esse critério, ato jurisdicional é o que emana dos órgãos jurisdicionais no exercício de sua competência constitucional respeitante à solução de conflitos de interesses.

1. Cf. Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, v. II/12; igualmente, J. Frederico Marques, *Instituições de Direito Processual Civil*, v. I/277 e ss.

2. Cf. Giovanni Cristofolini, "Efficacia dei provvedimenti di giurisdizione volontaria emessi da giudice incompetente", in *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda*, pp. 393 e 394; Luiz Eulálio de Bueno Vidigal, "Do mandado de segurança", in *Direito Processual Civil*, p. 38.

3. *Ob. cit.*

4. Órgãos da função jurisdicional

A função jurisdicional é exercida pelos seguintes órgãos do Poder Judiciário:

I – O Supremo Tribunal Federal;

I-A – O Conselho Nacional de Justiça;

II – O Superior Tribunal de Justiça;

III – Os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;

IV – Os Tribunais e Juízes do Trabalho;

V – Os Tribunais e Juízes Eleitorais;

VI – Os Tribunais e Juízes Militares;

VI – Os Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Mantivemos o texto conforme inclusão do inciso I-A pela EC-45/2004 com dois defeitos: o primeiro é o de incluir entre os *órgãos jurisdicionais* do Poder Judiciário um órgão que não tem a mesma natureza, imitando aí o critério da Constituição de 1969; o segundo consiste em ter criado um inciso I-A. Melhor seria redigir todos os incisos, incluindo (se tivesse que ser incluído aí) um inciso II, reenumerando os demais. Isso não implicaria longas mudanças; quando se trata de inserir um artigo novo, é razoável que isso se faça mediante o acréscimo de letras, porque, do contrário, ter-se-á que reenumerar todos os demais artigos da Constituição, o que seria um transtorno. Igual situação se criou também com o acréscimo de um inciso VIII-A no art. 93, sem nenhuma necessidade, pois se a todos os incisos, após o VII, foi dada nova redação, fácil seria deslocar esse VIII-A para IX, e assim por diante. Já que estão retalhando a Constituição, deveriam fazê-lo, pelo menos, com elegância técnica.

Enfim, temos aí a *ordem judiciária* do País, que compreende: (a) um órgão de cúpula, como guarda da Constituição e Tribunal da Federação, que é o Supremo Tribunal Federal; (b) um órgão de articulação e defesa do direito objetivo federal, que é o Superior Tribunal de Justiça;⁴ (c) as estruturas e sistemas judiciários, compreendidos nos

4. A criação do *Superior Tribunal de Justiça* — STJ foi proposta por mim em livro publicado em 1963: *Do Recurso Extraordinário no Direito Processual Brasileiro*, p. 456: “Esse é o defeito que precisa ser eliminado com a criação de, pelo menos, um Tribunal Superior, cuja função será a de exercer as atribuições de órgão de cúpula e de composição das estruturas judiciárias defeituosas, há pouco mencionadas.

“Tal órgão, que denominaríamos de *Tribunal Superior de Justiça* por uma questão de uniformidade terminológica relativamente aos já existentes, teria como competência fundamental [...]”, e então indicávamos a competência que veio a assumir pela atual Constituição. Por isso, *data venia* do ínclito Prof. Miguel Reale, que rei-

números 3 a 6 supra; (d) os sistemas judiciários dos Estados, Distrito Federal e Territórios.⁵ Logo, temos: (a) Supremo Tribunal Federal; (b) Tribunais Superiores federais, e, por conseguinte, Tribunais inferiores e juízes da organização judiciária federal; (c) Tribunais e juízes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Veja-se que a EC-45/2004 desdobrou o anterior parágrafo único em §§ 1º e 2º, só para acrescentar que o Conselho Nacional de Justiça tem sede na Capital Federal, tal como STF e os Tribunais Superiores que, além disso, têm jurisdição em todo o território nacional. O art. 92, como já fazia o art. 112 da Constituição de 1969, inclui os órgãos da justiça estadual entre os que exercem o Poder Judiciário; em assim fazendo, acolheu a doutrina que vem sustentando, pacificamente, aliás, a unidade da jurisdição nacional.⁶ Deles não trataremos aqui, mas como órgãos da estrutura governamental dos Estados. Mas agora se tem também que levar em conta o § 4º do art. 5º, no qual se declara que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma no dia 17.7.1998, a que aderiu e que está em vigor desde 1º.7.2002.

II. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

5. Jurisdição constitucional, guarda da Constituição e Corte Constitucional

A *jurisdição constitucional* emergiu historicamente como um instrumento de defesa da Constituição, não da Constituição considerada como um puro nome, mas da Constituição tida como expressão de valores sociais e políticos. Essa é uma questão fundamental, que se coloca em resposta aos tipos de ataques que a Constituição pode sofrer, surgindo disso dois sistemas: o norte-americano e o europeu.

vindica para si a proposta, que diz ter feito em 1965, num debate na Fundação Getúlio Vargas, a idéia originária é minha, com a máxima vênio do admirado mestre, da qual se serviu o Prof. Frederico Marques, citando-me (pois, ele honrou-me com o prefácio do livro), para sugeri-la ao Min. Milton Campos, mas foi recusada e até combatida pelo STF, por especial influência do Min. Vítor Nunes Leal. Mas é justo dizer que não fora por mim sugerida agora. Foi adotada na Comissão Afonso Arinos, aí sim por influência do Prof. Miguel Reale. Veja o esquema de toda a ordem judiciária nacional apresentada graficamente às pp. 461 e 479 da *ob. cit.* A única diferença está em que propus *Tribunal Superior de Justiça* — TSJ, porque assim se nomeiam os Tribunais Superiores: TSE, TST, enquanto a Constituição preferiu *Superior Tribunal de Justiça* — STJ, mais próximo de Supremo Tribunal Federal — STF.

5. Para essa concepção de ordem judiciária, estrutura judiciária e sistema judiciário, cf. nosso *Do Recurso Extraordinário no Direito Processual Brasileiro*, pp. 437 e ss.

6. Cf. nossa *ob. cit.*, pp. 8 e ss.

O norte-americano gerou um sistema, fundado no critério difuso, de natureza técnico-jurídica, a ponto de afirmar-se que não se caracteriza verdadeiramente como uma forma de jurisdição constitucional, não tanto por ter sido entregue o controle de constitucionalidade à jurisdição ordinária, mas pelo fato de que a jurisdição ordinária não aprecia a Constituição em função de seus valores políticos, não se configurando como guardião dos valores constitucionais, por ter como objetivo principal a decisão do caso concreto.⁷ Entendemos que também aí existe jurisdição constitucional, tomada a expressão no sentido de modo de compor litígios constitucionais.⁸ Apenas não se realiza com plenitude a função de guarda dos valores constitucionais, dada a preferência pela decisão do caso concreto.

O sistema europeu desenvolveu-se como resposta aos ataques político e ideológico da Constituição. O sistema de defesa não poderia ser senão de natureza política e ideológica. A evolução chegou à institucionalização das Cortes Constitucionais, a partir de 1920, como os únicos tribunais competentes para solucionar conflitos constitucionais, fundado no critério de controle concentrado.

O Brasil seguiu o sistema norte-americano, evoluindo para um sistema misto e peculiar que combina o critério de controle difuso por via de defesa com o critério de controle concentrado por via de ação direta de inconstitucionalidade, incorporando também agora timidamente a ação de inconstitucionalidade por omissão (arts. 102, I, *a*, e III, e 103). A outra novidade está em ter reduzido a competência do Supremo Tribunal Federal à matéria constitucional. Isso não o converte em Corte Constitucional.⁹ Primeiro porque não é o único órgão jurisdicional competente para o exercício da jurisdição constitucional, já que o sistema perdura fundado no critério difuso, que autoriza qualquer tribunal e juiz a conhecer da prejudicial de inconstitucionalidade, por via de exceção. Segundo, porque a forma de recrutamento de seus membros denuncia que continuará a ser um Tribunal que examinará a questão constitucional com critério puramente técnico-jurídico, mormente porque, como Tribunal, que ainda será, do recurso extraordinário, o modo de levar a seu conhecimento e julgamento as questões constitucionais nos casos concretos, sua preo-

7. Sobre essa temática, no sentido do texto, cf. Pedro de Vega, "Jurisdicción constitucional y crisis de la Constitución", in *Estudios políticos constitucionales*, pp. 285 e 291.

8. Concordamos, como se vê, com o mestre J. Frederico Marques, *A reforma do Poder Judiciário*, v. I/34.

9. Com todas as vênias do inclito Min. Oscar Dias Corrêa e de seu bem fundamentado livro *Supremo Tribunal Federal: Corte Constitucional do Brasil*, Rio de Janeiro, Forense, 1987.

cupação, como é regra no sistema difuso, será dar primazia à solução do caso e, se possível, sem declarar inconstitucionalidades.

É certo que o art. 102 diz que a ele compete, *precipualemente*, a guarda da Constituição. Mas não será fácil conciliar uma função típica de guarda dos valores constitucionais (pois, guardar a forma ou apenas tecnicamente é falsear a realidade constitucional) com sua função de julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância (base do critério de controle difuso), quando ocorrer uma das questões constitucionais enumeradas nas alíneas do inc. III do art. 102, que o mantém como Tribunal de julgamento do caso concreto que sempre conduz à preferência pela decisão da lide, e não pelos valores da Constituição, como nossa história comprova. Não será, note-se bem, por culpa do Colendo Tribunal, se não vier a realizar-se plenamente como guardião da Constituição, mas do sistema que esta própria manteve, praticamente sem alteração, salvo a inconstitucionalidade por omissão e a ampliação da legitimação para a ação direta de inconstitucionalidade. Reduzir a competência do STF à matéria constitucional não constitui mudança alguma no sistema de controle de constitucionalidade no Brasil.

6. Composição do STF

A composição do STF manteve-se tal como antes com *onze Ministros*, que serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos (brasileiros natos) com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

7. Competência

As matérias de competência do STF constam do art. 102, especificadas em três grupos: (1) as que lhe *cade processar e julgar originariamente*, ou seja, como Juízo único e definitivo, e são as questões relacionadas no inc. I; (2) as que lhe incumbe *julgar, em recurso ordinário*, e são as indicadas no inc. II; (3) e, finalmente, as que lhe toca *julgar, em recurso extraordinário*, e são as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida envolve uma das questões constitucionais referidas nas alíneas do inc. III.¹⁰

As atribuições judicantes previstas nos incisos do art. 102 têm, quase todas, conteúdo de litígio constitucional. Logo, a atuação do

10. Cf. essa competência que o art. 102, I, II e III, conferiu ao STF com a proposta de reforma que defendemos na nossa *ob. cit.*, pp. 457 e 458.

STF, aí, se destina a compor lide constitucional, mediante o exercício de *jurisdição constitucional*.¹¹ Esta, de fato, comporta conteúdos e objetivos diversos, que autorizam distinguir três modalidades que podem ser observadas na competência daquele Pretório Excelso:

(1) *Jurisdição constitucional com controle de constitucionalidade*: que, conforme já estudamos, pode ser por via de ação direta, interventiva ou genérica, e por via de exceção. A primeira está prevista no art. 102, I, *a e p*, como competência originária do STF para processar e julgar a *ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal*, assim também o *pedido de medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade*. Merece observar que não figura, neste inciso, a competência para o processo e julgamento da *ação direta de inconstitucionalidade por omissão*, que é admitida por via do disposto no § 2º do art. 103, e também não se outorga aí a competência ao STF para conhecer de arguição direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos municipais. A segunda consta do mesmo art. 102, III, que dá competência ao Pretório Excelso para julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, *quando a decisão contrariar dispositivo da Constituição, ou declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ou julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição*, ou, ainda, julgar válida lei local contestada em face de lei federal (EC-45/2004); note-se que esse motivo do recurso extraordinário é também do recurso especial (art. 105, III, *b*), atendendo-se aí a um velho julgado do Min. Sepúlveda Pertence, segundo o qual “os recursos que promanam a questão da validade de lei ou ato local em face de lei federal tanto podem traduzir uma questão constitucional quanto uma questão de mera legalidade” (RE n. 117.809). Em qualquer caso, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a sua admissão, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. É a chamada *questão de relevância* que era prevista no art. 119, § 1º, da Constituição de 1969, que retorna ao direito constitucional positivo – ainda que não tenha con-

11. Sobre a *jurisdição constitucional*, além da *ob. cit.* do Prof. Frederico Marques, nosso “Da jurisdição constitucional no Brasil e na América Latina”, *RPGE* n. 13-15, pp. 105 a 171; idem, “Tribunais constitucionais e jurisdição constitucional”, *RBEP* n. 60-61, pp. 495 a 524; Oscar Dias Corrêa, *Supremo Tribunal Federal: Corte Constitucional do Brasil*, Rio de Janeiro, Forense, 1987; Mauro Cappelletti, *La giurisdizione costituzionale delle libertà*, Milano, Giuffrè, 1974; idem, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Milano, Giuffrè, 1972; idem, *La justicia constitucional: estudios de derecho comparado*, México, UNAM/Facultad de Derecho, 1987.

corrido para melhorar a qualidade da jurisdição e sua celeridade quando vigorou.¹²

(2) *Jurisdição constitucional da liberdade*:¹³ assim se chama o exercício da jurisdição provocado por remédios constitucionais destinados à defesa dos direitos fundamentais, como o *Verfassungsbeschwerde* (agravo constitucional) da República Federal da Alemanha e o *juicio de amparo* mexicano. Como tal podemos incluir a competência do STF para *processar e julgar, originariamente*: (a) o *habeas corpus*, quando o paciente for o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros ou o Procurador-Geral da República (art. 102, I, *d*); (b) o *habeas corpus*, quando o coator ou o paciente for tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição, quando se trate de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância (art., 102, I, *i*); (c) o *mandado de segurança* e o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, do TCU, do Procurador-Geral da República e do próprio STF (art. 102, I, *d*); (d) a *extradição* solicitada por Estado estrangeiro (art. 102, I, *g*); (e) o *mandado de injunção* nos termos do art. 102, I, *q*. Entra também na categoria de jurisdição constitucional da liberdade a competência do STF *para julgar, em recurso ordinário* (art. 102, II, *a e b*), o *habeas corpus*, o *mandado de segurança*, o *habeas data* e o *mandado de injunção* decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, ou do próprio STF, assim como, em certo sentido, o *crime político*. Aqui, como se vê, é que a CF estabelece o foro privilegiado dos agentes políticos, que, de acordo com a jurisprudência, só prevalece enquanto o agente está no exercício do cargo, perdendo-o quando o deixa, mesmo que o fato tenha ocorrido durante aquele exercício. É um privilégio, que importa uma discriminação em favor de seu titular; por isso só é válido quando estabelecido pela própria CF. É inconstitucional, portanto, a Lei 10.628/2002, que, dando nova redação ao art. 84 do CPP, criou privilégio de foro não previsto na CF.

(3) *Jurisdição constitucional sem controle de constitucionalidade*: assim se entende “o exercício de atribuições judicantes, para compor litígio de natureza constitucional, mas diverso do que existe no controle da constitucionalidade das leis”.¹⁴ Inclui-se nesse caso a competência do STF para processar e julgar: os *crimes de membros de outros Poderes*, previstos no art. 102, I, *b e c*; os *litígios* entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou Território; as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a

12. Cf. n. III do cap. II do tit. I da Primeira Parte.

13. Sobre o tema, cf. Mauro Cappelletti, *La giurisdizione costituzionale delle libertà*, Milano, Giuffrè, 1974.

14. Cf. Frederico Marques, *ob. cit.*, pp. 38 e 39.

União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta (aqui, sua atuação é mais como *Tribunal da Federação* do que de jurisdição constitucional); a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais (essas três últimas hipóteses entram como forma de exercício da jurisdição constitucional, porque visam a tutela e preservação da competência constitucional do próprio STF: cf. art. 102, I, *b a o*); e, finalmente, os *conflitos de competência* entre o STJ e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.

Duas questões parecem não caracterizar matéria de jurisdição constitucional. São a competência para processar e julgar (a) as ações em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados, que poderá não raro suscitar problemas constitucionais e, então, se verificará o exercício da jurisdição constitucional; e (b) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.

Finalmente, cumpre esclarecer que a jurisdição constitucional não é função exclusiva do Pretório Excelso. Só o é a jurisdição constitucional concentrada suscitada por ação direta de inconstitucionalidade. Pois, a jurisdição constitucional que se exerce por via de exceção cabe, como já vimos, a qualquer Juiz ou Tribunal.

8. Descumprimento de preceito constitucional fundamental

O § 1º do art. 102 contém uma disposição de grande relevância, assim enunciada: “A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”.¹⁵ “Preceitos fundamentais” não é expressão sinônima de “princípios fundamentais”. É mais ampla, abrange estes e todas as prescrições que dão o sentido básico do regime constitucional, como são, por exemplo, as que apontam para a autonomia dos Estados, do Distrito Federal, e especialmente as designativas de *direitos e garantias fundamentais* (Tít. II).

15. A lei aí referida já veio, não com a abertura que o texto em sequência prognosticava: Lei 9.882, de 3.12.99. Sobre a arguição de preceito fundamental, cf. André Ramos Tavares, *Tratado da Arguição de Preceito Fundamental*, São Paulo, Saraiva, 2001, que é uma boa monografia sobre o tema.

E aí é que aquele dispositivo poderá ser fértil como fonte de alargamento da jurisdição constitucional da liberdade a ser exercida pelo nosso Pretório Excelso. A lei prevista bem poderia vir a ter a importância da Lei de 17.4.51 da República Federal da Alemanha que instituiu o *Verfassungsbeschwerde*, que se tem traduzido ao pé da letra por agravo constitucional ou recurso constitucional, mas que, em verdade, é mais do que isso, conforme se vê da definição que lhe dá Cappelletti: o “*recurso constitucional* consiste num meio de queixa jurisdicional perante o Tribunal Constitucional federal (com sede em Karlsruhe), a ser exercitado por particulares objetivando a tutela de seus *direitos fundamentais*, assim como de outras situações subjetivas constitucionais lesadas por um ato de qualquer autoridade pública” (ob. cit., p. 17). Em alguns casos ele serve para impugnar decisões judiciais, e, aí, sua natureza de meio de impugnação, de recurso, é patente. Em outros, contudo, é meio de invocar a prestação jurisdicional em defesa de direitos fundamentais. Parte de seus objetivos são cobertos pelo nosso mandado de segurança. Mas ele tem objetivos mais amplos do que este, e não está delimitado à defesa de direito líquido e certo, pessoal. O *Verfassungsbeschwerde* é originário da Baviera, cuja regulamentação legal prevê o cabimento de *Popularklage*, isto é, a atribuição do direito de ação a *quisquis de populo* (ação popular), declarando que a inconstitucionalidade por ilegítima restrição de um direito fundamental pode ser feita valer por qualquer pessoa, mediante “recurso” junto da Corte Constitucional.¹⁶ O texto, em exame, permite-nos avançar na mesma direção e será um instrumento de fortalecimento da missão que a Constituição reservou ao Supremo Tribunal Federal.

III. SÚMULAS VINCULANTES

9. Súmulas vinculantes, súmulas impeditivas de recursos e efeito vinculante

Façamos, primeiramente, algumas distinções entre *súmulas vinculantes*, *súmulas impeditivas de recursos* e *efeito vinculante*. As *súmulas vinculantes* são de competência do Supremo Tribunal Federal, consoante disposto no art. 103-A introduzido pela EC-45/2004. As *súmulas impeditivas de recurso* constam da parte da PEC-29/2000 que retornou à Câmara dos Deputados para apreciação de mudanças introduzidas no Senado Federal com possibilidade de aprovação, e, como tal, serão de competência do Superior Tribunal de Justiça (futuro art. 105-

16. Cf. Mauro Cappelletti, *La giurisdizione costituzionale delle libertà*, p. 71.

A, se aprovado) e do Tribunal Superior do Trabalho (futuro art. 111-B, se aprovado).

10. *Súmulas vinculantes e assentos da jurisprudência*

Um dos pontos controvertidos da reforma introduzida pela EC-45/2004 é o das *súmulas vinculantes*. Esse é um velho tema recorrente toda vez que se cuida de reforma do Judiciário. É a questão da adoção oficial de uma interpretação fixa, que se imponha a todos, e que foi objeto de larga discussão durante o Império. Assim é que José Thomaz Nabuco de Araújo apresentou um projeto, em 1843, conferindo ao mais alto tribunal do Império – o Supremo Tribunal de Justiça –, o direito de julgar definitivamente as causas em que concedesse revista, porque, para ele, era uma anomalia que os tribunais inferiores pudessem julgar, em matéria de direito, o contrário do que tinha decidido o primeiro tribunal do Império. Em 1855, A Seção de Justiça do Conselho de Estado, em face de arestos contraditórios dos tribunais inferiores, lembrava a conveniência de uma medida legislativa no sentido de “estabelecer uma interpretação com força dos antigos *assentos* da Casa de Suplicação”. Houve até parecer que aconselhava a proposta de uma lei que autorizasse o Conselho de Estado a dar autêntica interpretação às leis, o que foi repellido pela maioria esmagadora do próprio Conselho, com o argumento de que a interpretação autêntica de leis não poderia, sem subversão dos princípios do direito público, pertencer senão ao Poder Legislativo, cabendo a interpretação doutrinária inteira e necessariamente ao magistrado na aplicação da lei aos fatos, e “é por isso que os assentos são vedados aos nossos tribunais”.¹⁷ Essa doutrina do Conselho de Estado é da mais alta relevância, desde que se sabe que os *assentos da jurisprudência* eram, no passado, a figura correspondente às *súmulas vinculantes*, tal como os *prejulgados* que o Tribunal Superior do Trabalho estava autorizado a estabelecer pelo art. 902 da CLT, *prejulgados* que, uma vez estabelecidos, eram de observância obrigatória pelos Tribunais Regionais do Trabalho, pelas Juntas de Conciliação e Julgamento e pelos juízes de direito investidos de jurisdição da Justiça do Trabalho.

Em 1841, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado do Império, apresentaram-se projetos de lei autorizando o Supremo Tribunal de Justiça a “tomar assentos obrigatórios sobre a interpretação das leis. O pensamento era que os assentos fossem tomados com a mesma latitude e ao mesmo tempo as mesmas limitações que os da

antiga Casa de Suplicação”, aos quais era atribuída força de lei.¹⁸ Os assentos eram, pois, as *súmulas vinculantes* de outrora, com a mesma força de lei, como uma forma de interpretação oficial, impositiva, tal como as interpretações autênticas e, nesse sentido, subversivas dos princípios de direito público, já que interpretação oficial obrigatória só é legítima quando feita pelo Poder Legislativo. Apesar disso, foram elas acolhidas no art. 103-A introduzido pela EC-45/2004.

O conceito de *assentos*, oferecido por João Mendes Júnior como distinção dos *arestos*, nos ajuda a entender sua versão moderna revestida nas *súmulas vinculantes*: “Não confundamos os *arestos* com os *Assentos*. Os *Assentos* são atos do Poder Judiciário, não resolvem litígios *hic et nunc*, isto é, são determinações sobre a inteligência das leis, quando na execução delas ocorrem dúvidas manifestadas por julgamentos divergentes: os *arestos* são casos julgados entre certas e determinadas partes litigantes. Os *Assentos* associam o Poder Judiciário ao Poder Legislativo, ao passo que os *arestos* mantêm o Poder Judiciário na esfera de suas atribuições: os *Assentos* são leis, ao passo que os *arestos* são simples exemplos que podem ser seguidos ou não em casos semelhantes e que não obrigam senão às próprias partes”.

Os mesmos conceitos e distinções poderiam ser feitos hoje em relação aos *julgados* e às *súmulas vinculantes*.

11. *Disciplina das súmulas vinculantes*

As *súmulas vinculantes* são estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria. Têm por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a Administração Pública que acarretem grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Vinculam não só os órgãos do Poder Judiciário, mas também os órgãos da Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, e, assim, tolhem uma correta apreciação das alegações de lesão ou ameaça de direito que está na base do direito de acesso à Justiça, sem que se veja como elas podem reduzir o acúmulo de feitos perante o Supremo Tribunal Federal, pois só nesse âmbito têm aplicação. Não parecem reduzir os recursos, pois está previsto que se o ato administrativo ou a decisão judicial contrariar a súmula aplicável, caberá reclamação para o Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou

17. Cf. Joaquim Nabuco, *ob. cit.*, pp. 230 e 234.

18. *Idem ibidem*, p. 240.

cassará a decisão reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso (art. 103-A, § 3º). Na verdade, há uma mera troca de meios de impugnação: reclamação em vez de recurso ordinário ou extraordinário. Parece-nos que têm pouca utilidade relativamente ao âmbito da interpretação constitucional, para a qual está previsto o efeito vinculante (*infra*).

12. Súmulas impeditivas de recurso

As *súmulas impeditivas de recurso* têm os mesmos objetivos previstas para as súmulas vinculantes (*supra*), não tolhem o exercício da jurisdição nos juízos inferiores, porque se constituem apenas em impedimento à interposição de quaisquer recursos contra decisão que a houver aplicado, dizem os futuros arts. 105-A e 111-B, se aprovados (constam da parte da PEC-29/2000, que, aprovada pelo Senado, retornou à Câmara para reapreciação). Deve-se entender que impedem a interposição de qualquer recurso no âmbito de competência da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, conforme se trate de súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior do Trabalho. Ora, se esse é o limite da súmula impeditiva de recurso, ter-se-á um problema grave, qual seja: o do trânsito em julgado da decisão de primeiro grau que, nesses termos, é válida e eficaz. Suscito aqui a questão, que merece reflexão mais aprofundada. Contudo, as súmulas impeditivas de recurso podem ter um efeito benéfico, ao tolher a recorribilidade no âmbito de competência da Justiça Federal, que não atinge diretamente a cidadania, mas a prática da interposição de recursos pelo Poder Público Federal.

13. Efeito vinculante

Está previsto no § 2º do art. 102 acrescido pela EC-45/2004,¹⁹ segundo o qual “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. Essa é uma providência aceitável e conveniente. De certo modo, ela só explicita uma situação que é inerente à declaração de inconstitucionalidade abstrata, porque esta declaração, uma vez publicada, já tem, por natureza, o efeito de retirar a eficácia da lei ou ato normativo por ela fulminado. A declaração de constitucionalidade já era assim.

19. Conforme já vimos, cf. Primeira Parte, Tít. I, Cap. II, ns. 15 e 19.

Uma providência que a reforma deveria ter adotado, porque racional, seria declarar, numa disposição simples, que leis e atos normativos perderiam a eficácia a partir do dia seguinte ao da publicação da decisão definitiva que os tenha declarado inconstitucionais. Isso tanto para a declaração de inconstitucionalidade em ação direta como na via incidental, dando, dessa forma, efeito vinculante *erga omnes* a essa declaração só por si, suprimindo-se, em consequência, o disposto no inc. X do art. 52 da Constituição. Talvez aqui as súmulas vinculantes tenham alguma coisa que fazer, se vierem antes da suspensão, pelo Senado Federal, da eficácia da lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF, porque, depois da suspensão, será chover no molhado, já que esta tem o efeito, precisamente, de dar efeito geral e vinculante às declarações de inconstitucionalidade na via incidental.

Por todas essas razões percebe-se que esse “bicho papão” acaba não sendo assim tão feio, porque vai fazer aquilo que já decorre do próprio julgamento de inconstitucionalidade.

IV. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

14. Controle externo do Poder Judiciário

Outro ponto muito controvertido, sempre, foi o do chamado *controle externo do Poder Judiciário*. Esta expressão peca por sua má significação, porque transmite a idéia de que o Poder Judiciário seria controlado por um órgão externo. Isso seria inconcebível, porque então este órgão externo é que seria o Poder. Isso não exclui a necessidade de um órgão não-judiciário para o exercício de certas funções de controle administrativo, disciplinar e de desvios de condutas da magistratura, como é previsto em Constituições de vários países: Conselho Superior da Magistratura, na Itália (art. 105); França (art. 65); Portugal (art. 223); Espanha (art. 122); Turquia (arts. 143-144); Colômbia (arts. 254-257); Venezuela (art. 217).²⁰

Esse tipo de órgão externo é benéfico à eficácia das funções judiciais, não só por sua colaboração na formulação de uma verdadeira política judicial, como também porque impede que os integrantes do Poder Judiciário se convertam num corpo fechado e estratificado.²¹ Sob outro aspecto, não é desprezível a idéia de que esse tipo de órgão contribua para dar legitimidade democrática aos integrantes do

20. Para pormenores, cf. José Afonso da Silva, *ob. cit.*, pp. 161 e 162.

21. Assim se exprime H. Fix Zamudio, “Función del Poder Judicial en los sistemas constitucionales latinoamericanos”, no volume com o mesmo título, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 45.

Poder Judiciário, cuja investidura não nasce da fonte primária da democracia, que é o povo. O Conselho Nacional de Justiça, criado pelo art. 103-B introduzido na Constituição pela EC-45/2004, assume algumas dessas funções e, por isso, juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, certamente poderá prestar bons serviços ao sistema nacional de administração da Justiça, embora seja tipicamente um órgão interno do Poder Judiciário, pelo predomínio de magistrados em sua composição.

15. Composição do Conselho

De fato, o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, admitida uma recondução, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados os nomes pela maioria absoluta do Senado Federal, quais sejam: I – um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo Tribunal; II – um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo Tribunal; III – um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo Tribunal; IV – um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; V – um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; VI – um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; VII – um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; VIII – um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; IX – um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; X – um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República; XI – um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; XII – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; XIII – dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

Se as indicações aí previstas não forem efetuadas, no prazo legal, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal.

16. Funcionamento

O Conselho funcionará sob a presidência do Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado para compô-lo, que votará em caso de empate, ficando excluído da distribuição de processos naquele Tri-

bunal. Aí está um efeito danoso, porque um Tribunal sobrecarregado de processos vai privar-se da contribuição de um de seus membros pelo espaço de dois anos, tal como também se prevê para o Ministro do Superior Tribunal de Justiça a que incumbirá a função de Ministro-Corregedor, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: I – receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários; II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; III – requisitar e designar magistrados, delegando-lhe atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.

Finalmente, junto ao Conselho oficialarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil..

17. Competência

Ao Conselho compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

II – zelar pela observância do art. 37 da CF, e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;

III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro oficializados ou que atuem por delegação do poder público, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

IV – representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a Administração Pública ou de abuso de autoridade;

V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;

VI – elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;

VII – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.

18. Ouvidorias

A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará Ouvidorias de Justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. É preciso deixar bem claro que um tal tipo de *ouvidoria* não passa de arremedo da instituição chamada *ombudsman* que existe em alguns ordenamentos jurídicos europeus como delegado do Poder Legislativo. Criar ouvidorias, sem se lhes conferir poderes de apuração das reclamações e denúncias, não tem sentido. O que se está conferindo a elas, já se atribui ao Ministro-Corregedor (16 supra).

V. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

19. Composição

O *Superior Tribunal de Justiça* compõe-se de, no mínimo, 33 Ministros, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (1) $\frac{1}{3}$ dentre juízes dos TRFs e $\frac{1}{3}$ dentre desembargadores dos TJs, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal; (2) $\frac{1}{3}$, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes, de acordo com o art. 94 (Associação do Ministério Público Federal, art. 128, I, *a*, e o Conselho Federal da OAB), da qual o Tribunal formará lista tríplice, enviando-

a ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação (art. 104).²²

20. Competência

A competência do STJ está distribuída em três áreas: (1) competência originária para processar e julgar as questões relacionadas no inc. I do art. 105; (2) competência para julgar, em recurso ordinário, as causas referidas no inc. II; (3) competência para julgar, em recurso especial, as causas indicadas no inc. III.

Dentre essas atribuições judicantes do STJ algumas constituem matéria de jurisdição constitucional da liberdade, como sua *competência originária para processar e julgar os mandados de segurança* e o *habeas data* contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; o *habeas corpus*, quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas no art. 105, I, *a*, ou quando for Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; o *mandado de injunção*, assim como a competência para *julgar, em recurso ordinário*: os *habeas corpus* e os *mandados de segurança* decididos em única ou última instância pelos TRFs ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e de Territórios, quando a decisão for denegatória. Em recurso ordinário, ainda lhe cabe a competência para julgar as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País (cf. art. 105, I, *b*, *c* e *h*, e II, *a*, *b* e *c*).

Ainda é de sua *competência originária processar e julgar*: nos *crimes comuns*, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal; nos *crimes comuns* e de *responsabilidade*, os desembargadores dos TJs dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos TCs dos Estados e do Distrito Federal, os dos TRFs, dos TREs TRTs, os membros dos Conselhos ou

22. Compare o leitor a composição que a Constituição deu ao STJ com a nossa proposta de 1963. Sugerimos 25 Ministros inicialmente, mas ponderamos em seguida: “Também poderia, desde já, organizar-se com 26 Ministros, um presidente, e cinco turmas ou câmaras julgadoras, com cinco Ministros cada; três turmas seriam competentes para o julgamento dos recursos em matéria não penal, e duas em matéria penal.

“Os seus Ministros devem ser recrutados na magistratura superior, estadual e federal, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado, respeitadas as disposições constitucionais, que determinam que uma parte dos membros dos Tribunais sejam escolhidos entre advogados e membros do MP. É preferível se estabeleça que a nomeação dos Ministros se faça entre magistrados de carreira, porque se trata de Tribunal com características de especialização e tipicamente jurisdicional, donde ser mais fácil encontrar, naquela magistratura, homens afeitos ao trato de questões, mais ou menos, especializadas.”

Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; os conflitos de jurisdição entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, o, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos; as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União (cf. 105, I, a, d, f, e g); e a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do “exequatur” às cartas rogatórias; essa competência foi transferida do STF (antiga letra h do § 1º do art. 102, revogada pela EC-45/2004) para o STJ (art. 105, I, i) sem a possibilidade, que ali existia, de sua delegação ao Presidente do Tribunal.

O que dá característica própria ao STJ são suas atribuições de *controle da inteireza positiva, da autoridade e da uniformidade de interpretação da lei federal*, consubstanciando-se aí jurisdição de tutela do princípio da incolumidade do Direito objetivo que “constitui um valor jurídico — que resume certeza, garantia e ordem —, valor esse que impõe a necessidade de um órgão de cume e um instituto processual para a sua real efetivação no plano processual”.²³ Referimo-nos à sua competência para julgar, *em recurso especial*, as causas decididas, em única ou última instância, pelos TRFs ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, quando a decisão recorrida: (a) *contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência*; (b) *julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal*; (c) *der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal*;²⁴ (d) *contrariar a regulamentação de que trata o art. 155, § 2º, VIII, ou lhe der interpretação divergente da que lhe tenha atribuído outro tribunal* (EC-42/2003).

A questão suscitada no art. 105, III, b, não se limita a proteger a incolumidade da lei federal. Também o é, talvez principalmente o seja. Contudo, na base dela está uma *questão constitucional*, já que se tem que decidir a respeito da competência constitucional para legislar sobre a matéria da lei ou ato de governo legal. Pode acontecer que a validade seja mesmo da lei ou ato local, por ser matéria que a Constituição atribuiu aos Estados, Distrito Federal ou Municípios.²⁵ Sig-

23. Cf. nosso *Do Recurso Extraordinário ...*, cit., pp. 440, 441 e 444.

24. Essa foi a competência que atribuímos ao Superior Tribunal de Justiça em nossa proposta de sua criação. Cf. nossa *ob. cit.*, p. 456.

25. Sobre o tema, especialmente a compreensão do que seja “lei ou ato de governo local”, nossa *ob. cit.*, pp. 223 e ss.

nifica isso que a questão é suscetível de apreciação pelo STF, mediante recurso extraordinário.

A questão suscitada no art. 105, III, d, é inovação da EC-42/2003, que instituiu, no art. 155, § 2º, XII, g, um órgão colegiado com competência para editar a regulamentação única do imposto sobre circulação de mercadorias. Até agora o controle do STJ sobre a incolumidade do direito objetivo federal só se referia às leis. Com aquele mandamento entra nessa competência o controle da incolumidade de uma regulamentação que não é federal, mas interestadual, porque aquele colegiado se compõe de representantes de cada Estado e do Distrito Federal.

21. Conselho da Justiça Federal

Conforme vimos acima, a EC-45/2004 criou o *Conselho Nacional de Justiça*, com sede em Brasília e jurisdição sobre todos os órgãos de justiça existentes no território nacional, e manteve, no inc. II do parágrafo único do art. 105, o *Conselho da Justiça Federal*, junto ao STJ, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. A lei aí referida é, hoje, a Lei 8.472, de 14.10.1992, que dispôs especificamente sobre aquele Conselho. Estatui que, sob a presidência do Presidente do STJ, compõe-se de Vice-Presidente, e três membros Ministros do próprio STJ, eleitos por dois anos, e pelos Presidentes dos cinco TRFs, contando com igual número de suplentes, e especifica sua competência no art. 5º. Sua jurisdição é duplamente limitada: só incidirá sobre os TRFs e os Juízes Federais, e apenas sobre a gestão administrativa e orçamentária desses órgãos — o que, praticamente, reduz sua jurisdição somente sobre os TRFs, porque Juízes de primeira instância pouco têm a fazer em matéria administrativa e orçamentária.

VI. JUSTIÇA FEDERAL

22. Seus órgãos

O Tribunal Federal de Recursos foi uma criação da CF/1946. A CF/1967 previra a criação de mais dois: um em São Paulo, outro em Pernambuco, mas a malfadada Emenda Constitucional 7/77 eliminou essa possibilidade.²⁶ A estrutura adotada pela Constituição (art.

26. No Anteprojeto que apresentamos perante a Comissão Afonso Arinos, propugnamos por organização diferente dessa Justiça. Instituíamos: um Superior Tribunal de Recursos; a criação inicial de cinco Tribunais Federais de Recursos (Pará, Recife, São Paulo, Porto Alegre e Brasília) e Juízes Federais (art. 158).

106) para a Justiça Federal veio do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, que também previa como seus órgãos: os *Tribunais Regionais Federais* e os *Juizes Federais*.

23. Tribunais Regionais Federais

Composição. Os *Tribunais Regionais Federais* compõem-se de, no mínimo, 7 juízes,²⁷ recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo: (1) $\frac{1}{5}$ dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, indicados na forma do art. 94; (2) os demais mediante promoção de Juizes Federais com mais de 5 anos de exercício, alternadamente, por antiguidade e merecimento (art. 107).

O parágrafo único do art. 107 traz norma que merece pequena reflexão ao estabelecer que a *lei disciplinará a remoção ou a permuta de juizes dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede*.

O dispositivo declara, em primeiro lugar, que a lei disciplinará a *remoção* dos juizes dos TRFs. Quanto à permuta não há problema, porque depende sempre da vontade dos permutantes. A remoção não é bem assim. Então é preciso indagar se esse dispositivo autoriza a lei a afastar a incidência, para esses juizes, da garantia de *inamovibilidade* constante do art. 95, II. Nosso entendimento é de que não. Haver-se-ão de harmonizar os textos. Quando, no art. 107, parágrafo único, se estatui que a lei disciplinará a *remoção*, há que se entender que o fará nos limites autorizados no art. 95, II, com a aplicação do art. 93, VIII, e, no mais, somente a remoção a pedido do juiz.

Manda, em segundo lugar, que a lei determine a *jurisdição* e a *sede* dos juizes dos TRFs, ao passo que o art. 27, § 6º, do ADCT criou 5 TRFs, com a *jurisdição e sede que lhes fixasse o Tribunal Federal de Recursos*, o que foi cumprido pela divisão do País em 5 Regiões com as respectivas sedes: 1ª, *Brasília*, com jurisdição sobre Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Rondônia, Amapá, Roraima, Piauí, Acre, Maranhão e Tocantins; 2ª, *Rio de Janeiro*, com jurisdição sobre os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo; 3ª, *São Paulo*, com jurisdição sobre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul; 4ª, *Porto Alegre*, com jurisdição sobre os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; 5ª, *Recife*, com jurisdição sobre os Estados do Nordeste. Vale dizer, portanto, que a lei referida

no questionado dispositivo só terá função daqui para diante quando for necessário instituir novos TRFs.

Competência. Compete aos Tribunais Regionais Federais (art. 108):

(1) *processar e julgar originariamente*: (a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os magistrados federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho e os membros do Ministério Público, ressalvada, quanto a estes, a competência da Justiça Eleitoral; (b) as *revisões criminais* e as *ações rescisórias* de julgados seus ou dos Juizes Federais; (c) os *mandados de segurança* e os *habeas data* contra ato do próprio Tribunal ou de Juiz Federal da região; (d) os *habeas corpus*, quando a autoridade coatora for Juiz Federal; (e) os *conflitos de competência* entre Juizes Federais vinculados ao Tribunal;

(2) *julgar, em grau de recurso*, as causas decididas pelos Juizes Federais e pelos juizes estaduais no exercício da competência federal na área de sua jurisdição.

A reforma judiciária, estabelecida pela EC-45/2004, trouxe duas providências importantes para o bom funcionamento desses Tribunais; uma facultativa, qual seja a de que poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em todas as fases do processo; pena é que essa providência não seja impositiva como a outra, que determina que instalem justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Se a descentralização for implementada, esta segunda providência, por certo, será bem mais produtiva, porque o órgão de recurso estará por perto.

24. Juizes Federais

Assim se denominam os membros da Justiça Federal de primeira instância, reinstituída no Brasil em 1965. Ingressam no cargo inicial da carreira, que é o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com participação da OAB em todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, a ordem de classificação, conforme dispõe o art. 93, I, cujos incisos se aplicam à Justiça Federal (nosso comentário mais adiante). O concurso e a nomeação são da competência do TRF sob cuja jurisdição se achem os cargos a serem providos (art. 96, I, c e e). Prevê-se que a nomeação recairá em candidatos com mais de 25 anos, de reconhecida idoneidade moral, aprovados em concurso público de provas e títulos, além da satisfação de outros requisitos especificados em lei (Lei 5.677/71, art. 4º).

27. A Constituição denomina “juizes” aos membros dos TRF, mas, por emenda regimental, os TRF da 2ª e 3ª Regiões, por uma vaidade tola, atribuíram a seus membros a designação de “desembargadores federais”!

Competência. Compete aos Juízes Federais *processar e julgar*: as *causas* em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; as *causas* entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País, cabendo, neste caso, recurso para o TRF competente, nos termos do art. 108, e ainda recurso ordinário para o STJ (art. 105, II, c); essa é a interpretação literal do texto; melhor entendimento, contudo, deve ser o de suprimir a instância intermediária (apelação), para admitir apenas o recurso ordinário, entendimento que cabe à jurisprudência fixar; as *causas fundadas em tratado ou contrato* da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional; as *causas* referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização; os *crimes políticos*, neste caso com possibilidade de apelação para o TRF da região e recurso ordinário para o STF (art. 102, II, b); as *infrações penais* praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; os *crimes previstos em tratado ou convenção internacional*, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ocorrido ou deva ter ocorrido no exterior, ou reciprocamente; as *causas relativas a direitos humanos* a que se refere o § 5º do art. 109; os *crimes contra a organização do trabalho* e, nos casos determinados por lei, *contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira*; os *habeas corpus* em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; os *mandados de segurança* e os *habeas data* contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais; os *crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves*, ressalvada a competência da Justiça Militar; os *crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro*, a execução de carta rogatória, após o *exequatur*, e de sentença estrangeira, após a homologação; as *disputas sobre direitos indígenas* (art. 109).

Foro das causas de interesse da União. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde a outra parte tiver domicílio. As intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal (art. 109, §§ 1º e 2º).

Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca

não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça do Estado. Nessa hipótese, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau (art. 109, §§ 3º e 4º).

Incidente de deslocamento de competência. As causas relativas a direitos humanos, em princípio, são de competência dos juízes estaduais, mas, no caso de grave violação desses direitos, o Procurador-Geral da República, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, o *incidente de deslocamento de competência* para a Justiça Federal, que terá, assim, competência para seu julgamento nos termos do inciso V-A do art. 109, introduzido pela EC-45/2004. A transferência de competência, para a Justiça Federal, para o julgamento da violação dos direitos humanos que vinha sendo reclamada há muito tempo, tendo em vista a responsabilidade do Estado brasileiro em face de organismos internacionais de defesa dos direitos humanos, foi, assim, acolhida em forma de deslocamento da competência no caso concreto. Isso atende o essencial do problema, porque também não se justificava sobrecarregar a Justiça Federal transferindo para ela todas as causas relativas a direitos humanos, até porque, em muitas hipóteses, não será fácil distinguir entre violação de direito comum e violação de direitos humanos.

Organização da Justiça Federal de primeira instância. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Assim já se dispunha antes, mas até hoje quase tudo funciona nas Capitais. Quem sabe os TRFs tenham a sensibilidade de verificar a necessidade de descentralizar a Justiça Federal de primeira instância, ao menos nas principais cidades da região (art. 110).

Há, ainda, a previsão de que, nos Territórios Federais, inexistentes agora, a jurisdição e as atribuições cometidas aos Juízes Federais caberão aos juízes da justiça local. Quando, eventualmente, surgir algum Território, a regra está feita.

VII. JUSTIÇA DO TRABALHO

25. Organização

A Justiça do Trabalho fora instituída pelo art. 122 da CF/1934, e criada em 1942, mas como órgão vinculado ao Ministério do Trabalho. A CF/1946 integrou-a no Poder Judiciário, tornando-a assim, efetivamente, órgão de função jurisdicional destinado a solucionar conflitos de interesse decorrentes das relações de trabalho.

Sua organização compreende: (a) o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão de cúpula dessa justiça especializada; (b) os Tribunais Regionais do Trabalho; (c) Juízes do Trabalho (arts. 111 e 111-A, ECs 24/1999 e 45/2004).

Tribunal Superior do Trabalho. Compõe-se de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; II – os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior (art. 111-A).

Tribunais Regionais do Trabalho. A reforma judiciária (EC-45/2004) deu melhor formulação a esses Tribunais, definindo sua composição como de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; II – os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.

Remete-se à lei a função de criar varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Não mais se declara que à lei caberia dispor sobre a constituição, a investidura, a jurisdição, a competência, as garantias e as condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho como se continha do art. 113 da Constituição, declaração que reputávamos desnecessárias por já estarem consagradas nos arts. 93 a 96. Agora, as deficiências de formulação foram supridas, como observamos acima. Por isso esse art. 113 foi revogado expressamente; à vista disso, se o legislador reformista fosse um pouco mais técnico teria aproveitado o vazio deixado por essa revogação, em lugar de criar um art. 111-A. Bastaria por o texto deste no art. 112 e dar o atual conteúdo deste ao art. 113.

Resta observar, tal como fizemos em relação aos Tribunais Regionais Federais, que a reforma judiciária, estabelecida pela EC-45/2004, trouxe aqui também (cf. n. 13, *supra*) duas providências importantes para o bom funcionamento desses Tribunais: uma facultativa, qual seja a de que poderão funcionar descentralizadamente, constituindo

Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em todas as fases do processo; pena é que essa providência não seja impositiva como a outra, que determina que instalem justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Como já dissemos, se a descentralização for implementada, esta segunda providência, por certo, será bem mais produtiva, porque o órgão de recurso estará por perto.

26. Competência

O § 1º do art. 111-A remete à lei a função de dispor sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Contudo, ela também abrange o disposto no art. 114, que estabelece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; as ações que envolvam exercício do direito de greve; as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; os mandados de segurança, *habeas corpus* e *habeas data*, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o (conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais, entre os Tribunais Superiores, ou entre estes e quaisquer tribunais); as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; na forma da lei, outras controvérsias decorrentes de *dissídios individuais e coletivos* nas relações de trabalho. Por “entes de direito público externo” entendem-se as representações diplomáticas de outros países. Isso porque surgiram dúvidas, no regime anterior, se empregados de embaixadas, quando brasileiros regidos pela legislação trabalhista, estavam ou não sujeitos à Justiça do Trabalho, à vista de alegações de imunidade diplomática. Fica claro que esta Justiça é competente para examinar e decidir as relações de trabalho de brasileiros com essas representações estrangeiras.

Dissídio individual é o que se funda no contrato individual de trabalho; os interesses nele envolvidos são concretos de um ou al-

guns e a sentença que o resolve tem eficácia apenas entre as partes da relação jurídica processual. O *dissídio coletivo* visa a estabelecer normas e condições de trabalho; envolve interesse genérico e abstrato da categoria de trabalhadores; a sentença que o resolve tem por objetivo fixar essas normas e condições e sua eficácia se estende a todos os membros da categoria indistintamente.

Embora essa extensão normativa não seja mais prevista na Constituição como antes (art. 114, § 2º, redação anterior à EC-45/2004), parece razoável entender que decorre do sistema, já que seria sem sentido prestigiar as convenções coletivas de trabalho e a solução de dissídios delas decorrentes, se a decisão não tivesse caráter normativo e força extensiva sobre toda a categoria profissional e econômica em dissídio. O *dissídio coletivo* pressupõe negociação coletiva intersindical. Mas esta poderá frustrar-se por dois modos: por não chegarem as partes a um acordo, ou por se recusar uma delas à negociação. No primeiro caso, as partes poderão eleger árbitros. Esta é uma faculdade que a Constituição prevê no § 1º do art. 114. Se uma das partes recusar-se à negociação ou à arbitragem, será facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as disposições convencionadas anteriormente.

27. Recorribilidade das decisões do TST

As decisões do TST são irrecorríveis, salvo as que denegarem mandado de segurança, *habeas data* e mandado de injunção e as que contrariarem a CF ou declararem a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, caso em que caberá, respectivamente, recurso ordinário e recurso extraordinário para o STF. O STJ não tem competência para rever decisões da Justiça do Trabalho, como se pode ver pela leitura do art. 105, II e III, que excluem as causas decididas por ela das hipóteses recursais ali indicadas.

VIII. JUSTIÇA ELEITORAL

28. Organização e competência

A Justiça Eleitoral foi instituída entre nós pelo Código Eleitoral de 1932, de inspiração de Getúlio Vargas. Sua criação visou a substituir o então *sistema político* de aferição de poderes (feita pelos órgãos legislativos), pelo *sistema jurisdicional*, em que se incluíam todas as atribuições referentes ao direito político-eleitoral. É o *contencioso ju-*

risdicional eleitoral, peculiaridade constitucional brasileira, que tem revelado excelentes resultados, já existente em outros países.

A *organização* e a *competência* da Justiça Eleitoral serão dispostas em lei complementar (art. 121), mas a Constituição já oferece um esquema básico de sua estrutura. Assim é que ela se compõe de um *Tribunal Superior Eleitoral* (TSE), seu órgão de cúpula, de *Tribunais Regionais Eleitorais* (TRE), de *Juizes Eleitorais* e de *Juntas Eleitorais* (art. 118).

O *Tribunal Superior Eleitoral* compor-se-á, no mínimo, de 7 membros, escolhidos: (1) *mediante eleição*, pelo voto secreto: (a) 3 juizes dentre os Ministros do STF; (b) 2 juizes dentre os Ministros do STJ; (2) *por nomeação do Presidente da República*, 2 juizes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo STF (art. 119).

Seus Presidente e Vice-Presidente serão eleitos por seus membros, dentre os Ministros do STF. O Corregedor será eleito da mesma forma dentre os Ministros do STJ (art. 119, parágrafo único).

Os *Tribunais Regionais Eleitorais*, um na Capital de cada Estado e no Distrito Federal, serão compostos: (1) *mediante eleição*, pelo voto secreto: (a) de 2 juizes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; (b) de 2 juizes, dentre juizes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; (2) de *um juiz* do TRF com sede na Capital do Estado ou do Distrito Federal, ou, não havendo, de Juiz Federal, escolhido, em qualquer caso, pelo TRF respectivo; (3) *por nomeação do Presidente da República*, de 2 juizes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo TJ (art. 120). O TRE elegerá seu Presidente e Vice-Presidente dentre os desembargadores (art. 120, § 2º).

Os *juizes eleitorais* são os próprios *juizes de direito* da organização judiciária dos Estados ou do Distrito Federal e as *juntas eleitorais* são presididas por juizes eleitorais, se bem que a Constituição não mais lhes indica a composição nem as atribuições, remetendo o assunto à lei complementar (art. 121).

Os membros dos tribunais, os juizes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis, sendo que os juizes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, nunca por mais de dois biênios consecutivos, e terão substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria (art. 121).

29. Recorribilidade de suas decisões

Das decisões dos TREs somente caberá recurso para o TSE, quando: forem proferidas contra disposição expressa da CF ou de lei; ocor-

rer divergência na interpretação da lei entre dois ou mais tribunais eleitorais; versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais; anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais; ou denegarem *habeas corpus*, mandado de segurança, *habeas data* ou mandado de injunção.

São, porém, *irrecorríveis* as decisões do TSE, salvo as que denegarem o *habeas corpus*, o mandado de segurança, o *habeas data* e o mandado de injunção e as que contrariarem a CF, julgarem a inconstitucionalidade de lei federal, das quais caberá, respectivamente, recurso ordinário e recurso extraordinário para o STF. O STJ não tem competência para rever decisões da Justiça Eleitoral, como se pode confirmar pela leitura do art. 105, II e III.

IX. JUSTIÇA MILITAR

30. Composição

A Justiça Militar compreende: o *Superior Tribunal Militar*, que é o órgão de cúpula dessa Justiça; os *Tribunais e Juízes Militares* instituídos em lei, que são as Auditorias Militares, existentes nas circunscrições judiciárias, conforme dispõe a Lei de Organização Judiciária Militar (Decreto-lei 1.003/69).

O *Tribunal Superior Militar* compõe-se de *quinze Ministros vitalícios*, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais-generais da Marinha, 4 dentre oficiais-generais do Exército, 3 dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 civis (art. 123).

Os *Ministros civis* serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo: (1) 3, dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional; (2) 2, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar.

31. Competência

A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e *competência* da Justiça Militar. Mas a Constituição já determina que a ela compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Vale dizer, portanto, que a lei nada mais pode fazer, quanto à competência, que repetir e desdobrar esse núcleo de competência já constitucionalmente estabelecido: *processar e julgar os crimes militares*.

X. JUIZADOS ESPECIAIS E DE PAZ

32. Juizados especiais

A CF, no art. 98, I, impõe à União, no Distrito Federal e nos Territórios (inexistentes agora), e aos Estados a criação de *juizados especiais*, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. A EC-22/99, acrescentando parágrafo único no art. 98, autorizou a criação de juizados especiais também na Justiça Federal.

33. Justiça de paz

Essa é outra justiça que a Constituição determina seja criada pela União, no Distrito Federal e Territórios, e pelos Estados. Não é novidade no sistema brasileiro. Ao contrário, existiu, com as mesmas características de juizado eletivo e de conciliação, ao longo do Império e até recentemente em alguns Estados. De fato, a Constituição do Império exigia que se intentasse reconciliação prévia entre as partes, sem o que não começaria processo algum (art. 161), e acrescentava, no art. 162: “Para este fim haverá Juízes de Paz, os quais serão eletivos pelo mesmo tempo, e maneira, por que se elegem os Vereadores das Câmaras. Suas atribuições e distritos serão regulados por lei”. Igualmente foram mencionados na Constituição de 1946 (art. 124, X).

Agora a Constituição dá-lhe configuração semelhante, nos termos seguintes: “A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: *justiça de paz*, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação” (art. 98, II).

XI. ESTATUTO DA MAGISTRATURA E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO

34. Princípios estatutários da magistratura

O *Estatuto da Magistratura* será estabelecido por *lei complementar* de iniciativa do Supremo Tribunal Federal e conterà regras sobre a carreira da magistratura nacional, observados os princípios consti-

tucionais sobre o ingresso, a promoção, o acesso aos Tribunais, os vencimentos, a aposentadoria e seus proventos, a publicidade dos julgamentos e a constituição de órgão especial nos Tribunais.

Carreira. O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. Os magistrados serão *promovidos* de entrância para entrância, alternadamente, por antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas: (a) é *obrigatória a promoção do juiz* que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento; (b) a *promoção por merecimento* pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antigüidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar – vale dizer que não é mais possível promover por merecimento juiz de posição qualquer no quadro da magistratura; além de ter merecimento há que estar entre o quinto mais antigo; (c) *aferição do merecimento* conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; tenta-se aqui dar alguma objetividade à aferição do mérito; (d) na *apuração de antigüidade*, o tribunal somente poderá *recusar o juiz mais antigo* pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e *assegurada ampla defesa*, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação; (e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão; essa medida, introduzida pela EC-45/2004, destina-se a realizar o cumprimento do direito à duração razoável do processo nos termos do inc. LXXVIII acrescido ao art. 5º pela mesma emenda constitucional.

Em alguns Estados, é previsto um concurso para a promoção de juízes, a que se inscrevem os interessados, sem o que não serão promovidos por não ser de seu interesse; em outros Estados, contudo, promove-se quem preencha os requisitos, e aquele que não desejar a promoção manifesta sua recusa. O sistema de concursos evita esse constrangimento; se nenhum se apresentar, não haverá a promoção, que não pode ser forçada, uma vez que o juiz é protegido pela garantia constitucional da inamovibilidade, que impede inclusive promoção não desejada. A lei complementar, prevista no art. 93, poderá generalizar a toda a magistratura nacional o sistema de concurso de promoção, que não contraria norma constitucional, porque se limita apenas a formar uma lista de quem quer ser promovido por merecimento.

Acesso aos tribunais de segundo grau. Far-se-á por antigüidade e por merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou única entrância. Em qualquer hipótese, aplicar-se-ão, para o acesso, as regras vistas acima para a promoção de magistrados. O acesso do juiz de carreira, nos Estados e Distrito Federal, agora, se faz exclusivamente aos respectivos Tribunais de Justiça, uma vez que o art. 4º da EC-45/2004 extinguiu os Tribunais de Alçada, onde havia, determinando que seus membros passem a integrar os Tribunais de Justiça dos respectivos Estados, respeitadas a antigüidade e classe de origem – ou seja, quem era da carreira da magistratura ocupará, no Tribunal, vaga dessa natureza, quem subiu pelo quinto dos advogados ou de membros do Ministério Público assim continuará. A importância disso está no fato de que, na vacância do cargo no Tribunal, seu provimento há de fazer-se segundo a classe de origem do desembargador que o ocupava. A questão, como se vê, liga-se ao disposto no art. 94, ao estabelecer que um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios será composto, mediante acesso a eles, de membros do MP federal, estadual e do Distrito Federal, respectivamente, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes, ou seja, pela Associação do Ministério Público federal, estadual e do Distrito Federal, conforme o caso, e pelo Conselho Federal da OAB, ou pelo seu Conselho Seccional, tratando-se de provimento do cargo de magistrado estadual. Recebida a lista sêxtupla, o tribunal formará lista tríplex, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

Subsídios. A remuneração dos magistrados assumiu a forma de *subsídios*, por força de mudanças introduzidas nos arts. 48, XV, 93, V, 95, III, e 96, II, “b”, da CF, pela EC-19/1998; com os seguintes critérios: (a) o subsídio dos Ministros do STF será fixado por *lei* de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do STF, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I (sujeição à incidência do imposto de renda); (b) a fixação dos subsídios dos membros dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça dos Estados e dos juízes que lhes são vinculados será feita por lei específica propostas por esses Tribunais ao respectivo Poder Legislativo; (c) o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os Ministros do STF e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias de estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença en-

tre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º (a remissão ao art. 37, XI, era desnecessária, porque o § 4º do art. 39, invocado, já o faz. Trata-se do teto, que também já está nos próprios critérios indicados, e da regra segundo a qual a remuneração e o subsídio não de ser fixados por lei específica e sujeitos a revisão anual); (d) os subsídios são fixados em parcela única, não havendo mais adicionais, nem sexta-parte, nem qualquer outro acréscimo ou gratificação, salvo o 13º salário, o salário-família, o acréscimo de 30% no subsídio do mês de férias, ajuda de custo e diárias para indenização de despesas comprovadas.

Inatividade do magistrado. Existem duas formas de inatividade: a *aposentadoria* e a *disponibilidade*. A *aposentadoria dos magistrados* (assim como a pensão de seus dependentes) se subordina às normas do art. 40 da CF (EC-20/1998 e 41/2003), podendo ser, portanto: (a) *por invalidez*, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, casos em que os proventos serão integrais; (b) *compulsória*, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; (c) *voluntária*, desde que cumprido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo de magistrado, observadas as seguintes condições: (c.1) 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 de idade e 30 de contribuição, se mulher; (c.2) 65 anos de idade, se homem, e 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aplicáveis, ainda, as demais regras dos parágrafos do art. 40.²⁸ Há outra forma de *aposentadoria compulsória* que, tal como a *disponibilidade*, é aplicada, mediante voto da maioria absoluta do tribunal (frise-se do *tribunal*, não de eventual órgão especial, criado com base no art. 93, XI) ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Parece-nos que ela só pode recair em magistrado que já completara o tempo para aposentar-se e não o fizera, pois antes disso a inatividade compulsória há de ser a *disponibilidade*.

Como se disse acima, a inatividade dos magistrados rege-se pelo disposto no art. 40 da Constituição, o que quer dizer que, para o cálculo de seus proventos, serão consideradas os subsídios utilizados como base de suas contribuições previdenciárias. Em outras palavras, seus proventos de aposentadoria correspondem ao salário-contribuição, já que a EC-41/2003 extinguiu o princípio da integralidade e da paridade entre proventos e remuneração na atividade. Mas os

proventos da disponibilidade e da aposentadoria, no interesse público, são proporcionais ao tempo de contribuição, o que significa que ficarão abaixo do salário-contribuição.

Publicidade e motivação das decisões. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão *públicos*, e *fundamentadas* todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Requer-se que também as *decisões administrativas* dos tribunais sejam motivadas e em sessão pública, o que é o mesmo que fundamentadas e públicas como os julgamentos e decisões jurisdicionais, sendo as disciplinares, tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros (do tribunal, não de órgão especial), inclusive as de *remoção*, *disponibilidade* ou *aposentadoria por interesse público*, como visto.

Publicidade e motivação das decisões. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão *públicos*, e *fundamentadas* as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes. Não se exige que sejam públicos os julgamentos de natureza administrativa, mas requer-se que as *decisões administrativas* dos tribunais sejam motivadas, o que é o mesmo que fundamentadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros (do tribunal, não de órgão especial), exceto, evidentemente, aquelas que determinam *remoção*, *disponibilidade* ou *aposentadoria por interesse público*, que, como vimos, dependem do voto de 2/3 dos membros do tribunal.

Órgão especial. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais de competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno; quer-se, com isso, evitar uma composição só com os magistrados mais antigos, supondo que a eleição vai selecionar membros mais jovens para o órgão especial – o que poderá ocorrer, mas não necessariamente.

Não é mais obrigatória a constituição de órgão especial, como se impunha no regime da Constituição anterior (art. 144, V). Agora sua instituição é facultativa: cumpre apenas indagar facultativa para quem: para o legislador, ou para o próprio tribunal? Inclina-mo-nos para a segunda solução, que dá mais liberdade e independência de organiza-

28. Cf., para pormenores, à frente, o Capítulo “Dos Servidores Públicos”, n. 11.

ção interna aos tribunais, o que está em harmonia com os princípios da Constituição.

35. *Espécies de garantias do Judiciário*

Aos órgãos jurisdicionais, consoante vimos, incumbe a solução dos conflitos de interesses, aplicando a lei aos casos concretos, inclusive contra o governo e a administração. Essa elevada missão, que interfere com a liberdade humana e se destina a tutelar os direitos subjetivos, só poderia ser confiada a um poder do Estado, distinto do Legislativo e do Executivo, que fosse cercado de garantias constitucionais de independência.²⁹ Essas garantias assim se discriminam: (1) *garantias institucionais*, as que protegem o Poder Judiciário como um todo, e que se desdobram em *garantias de autonomia orgânico-administrativa e financeira*; (2) *garantias funcionais* ou de *órgãos*, que asseguram a independência e a imparcialidade dos membros do Poder Judiciário, previstas, aliás, tanto em razão do próprio titular mas em favor ainda da própria instituição.

36. *Garantias institucionais do Judiciário*

A Constituição assegura aos tribunais, como *formas de garantias institucionais*, como dissemos: a *garantia de autonomia orgânico-administrativa*, que compreende a sua independência na estruturação e funcionamento de seus órgãos; e a *garantia de autonomia financeira*, como independência na elaboração e execução de seus orçamentos.

A *garantia de autonomia orgânico-administrativa* consubstancia-se na competência privativa: (1) aos tribunais em geral, para: eleger seus órgãos diretivos; elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos; organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva; prover, na forma prevista na Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição; propor a criação de novas varas judiciárias (propor a quem? Ao legislativo competente); prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, em havendo: (a) prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (b) autorização específica em lei de diretrizes

orçamentárias (art. 169, parágrafo único); conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados; (2) ao STF, aos Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE, STM) e aos Tribunais de Justiça, para propor: a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados; a criação ou extinção dos tribunais inferiores; a alteração da organização e da divisão judiciária; (3) aos Tribunais de Justiça, para julgar os juízes estaduais, do Distrito Federal e dos Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

A *garantia de autonomia financeira* no poder que se reconheceu ao Judiciário de elaboração do próprio orçamento, de acordo com o qual: (1) cabe aos tribunais elaborar suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias (arts. 99, § 1º, e 165, II); (2) compete o encaminhamento da proposta orçamentária, ouvidos os outros tribunais interessados: (a) no âmbito da União, aos Presidentes do STF e dos Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE e STM), com a aprovação dos respectivos tribunais; (b) no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com aprovação dos respectivos tribunais.

Se os Tribunais, aí referidos, não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º do art. 99. Se encaminharem propostas em desacordo com os limites estipulados no mesmo § 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. E mais, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

Tudo isso está a mostrar que essa autonomia financeira não é assim tão pronunciada, é, ao contrário, bastante limitada e vai gerar mais problemas do que benefícios. As divergências e disputas entre tribunais, que devem aprovar as propostas, logo demonstrarão ao Poder Judiciário que assuntos de administração devem competir mesmo aos administradores e nunca aos julgadores, que precisam

29. Cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de Direito Constitucional*, pp. 212 e ss.; Pedro Lessa, *Do Poder Judiciário*, Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1951; Castro Nunes, *Teoria e prática do Poder Judiciário*, Rio de Janeiro, Forense, 1943.

ficar imunes a disputas que, no fundo, envolvem decisões políticas. A idéia de um órgão de controle externo da administração da Justiça que tivesse, entre suas incumbências, o planejamento e a preparação da proposta orçamentária do Poder Judiciário foi cogitada; mas o Conselho Nacional de Justiça que, em seu lugar, foi criado pela EC-45/2004 não recebeu essa atribuição, só cumprindo a ele, nesse particular, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário.

37. Garantias funcionais do Judiciário

As garantias, que a Constituição estabelece em favor dos juízes, para que possam manter sua independência e exercer a função jurisdicional com dignidade, desassombro e imparcialidade, podem ser agrupadas em duas categorias: (a) *garantias de independência dos órgãos judiciários*; (b) *garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários*.

As *garantias de independência dos órgãos judiciários* são: *vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos*.

Vitaliciedade. Diz respeito à vinculação do titular ao cargo para o qual fora nomeado, por concurso ou por acesso de advogados e membros do MP aos tribunais, como já vimos. Não se trata de um privilégio, mas de uma condição para o exercício da função judicante que exige garantias especiais de permanência e definitividade no cargo. É assim prerrogativa da instituição judiciária, não da pessoa do juiz. Uma vez tornado vitalício, isto é, titular do cargo por toda a vida, o juiz dele só pode ser afastado por vontade própria e apenas o perderá por sentença judiciária ou aposentadoria compulsória ou disponibilidade.

Tornam-se vitalícios: (1) a partir da posse, se já não o eram: (a) os Ministros do STF; (b) os Ministros do STJ; (c) os Juízes dos TRFs; (d) os Ministros e Juízes togados do TST e dos TRTs; (e) os Ministros do STM; (f) os desembargadores dos Tribunais de Justiça, os juízes dos Tribunais de Alçada e os juízes de segunda instância dos Tribunais Militares dos Estados; (2) *após dois anos de exercício* os juízes togados de primeiro grau, dependendo a perda do cargo, neste período, de deliberação do tribunal a que estiverem vinculados. Quando vitalício, o magistrado só perderá o cargo por sentença transitada em julgado (art. 95, I).

Inamovibilidade. Refere-se à permanência do juiz no cargo para o qual foi nomeado, não podendo o tribunal e menos ainda o governo designar-lhe outro lugar, onde deva exercer suas funções (art. 95, II). Contudo, poderá ser removido por interesse público em decisão pelo voto da maioria absoluta do tribunal a que estiver vinculado (art. 93, VIII). No entanto, o magistrado pode ser removido, a pedido ou por permuta com outro magistrado de comarca de igual entrância, aten-

didas, no que couber, as regras previstas nas alíneas *a, b, c e e* do inc. II do art. 93, referentes às promoções; mas pode também ser removido compulsoriamente, por interesse público por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.

Irredutibilidade de subsídio. Significa que o subsídio dos magistrados não pode ser diminuído nem mesmo em virtude de medida geral, mas a CF determina que fica sujeito aos limites máximos previstos no art. 37 e ao imposto de renda, como qualquer contribuinte, com a aplicação do disposto nos arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. O art. 95, III, diz o seguinte: os juízes gozam de *irredutibilidade de subsídio*, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

As *garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários* aparecem, na CF, sob forma de *vedações* aos juízes, denotando restrições formais a eles. Mas, em verdade, cuida-se aí, ainda, de proteger a sua independência e, conseqüentemente, do próprio Poder Judiciário. Assim é que a CF, no art. 95, parágrafo único, veda-lhes: (a) *exercer*, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; (b) *receber*, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; (c) *dedicar-se* à atividade político-partidária; (d) *receber*, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; (e) *exercer* a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Essas duas últimas vedações foram acrescentadas pela EC-45/2004, tornando, assim, expressas proibições que decorriam do sistema e a respeito das quais ninguém tinha dúvida, tanto que o magistrado que aquelas exercesse atividades vedadas cometia improbidade, sujeita à punição correspondente prevista na lei.

38. Mecanismos de aceleração dos processos

A reforma do Judiciário se preocupou com a morosidade da atividade jurisdicional. Por isso, adotou algumas providências que podem auxiliar no andamento mais rápido dos processos e a efetividade do direito consignado no art. 5º, LXXVIII, tudo introduzido pela EC-45/2004. Assim é que: (a) os magistrados gozam de 60 dias de férias coletivas, o que significava que as atividades jurisdicionais ficavam interrompidas nos meses de janeiro e julho, com prejuízo para os jurisdicionados. Tínhamos, pois, um poder estatal que não funcionava naquele período, o que era uma anomalia que a tradição consagrara. Agora, está estabelecido que a atividade jurisdicional é ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas nos juízos e tribunais de 2º

grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes de plantão permanente. Os juízes continuam com direito individual a 30 dias férias anuais remuneradas, como qualquer agente estatal. Fala-se em *tribunais de 2º grau*, o que, a rigor, não inclui nem o Supremo Tribunal Federal nem os Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE). Espera-se que esses tribunais, por seus regimentos internos, adotem a medida; (b) estatui-se que o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população, providência importante, levando-se em conta que, no Brasil atual, a relação é de um juiz para cada 25.000 habitantes, enquanto, na Espanha, é cerca de 1 para 8.000 e na Alemanha, é de 1 para cerca de 4.000; unidade jurisdicional é a comarca, o distrito judiciário, a circunscrição judiciária, de acordo com a organização judiciária; (c) determina-se que a distribuição de processos seja imediata, em todos os graus de jurisdição – inclusive, pois, no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais Superiores. É inacreditável que se tenha que cuidar de um tal problema por emenda constitucional; isso se tornou necessário em face do fato de que, nos Tribunais de Justiça, mas não só, os órgãos superiores não vinham distribuindo os processos na sua totalidade, sob o argumento de não poderem sobrecarregar os juízes; ora, tal procedimento era ilegal e até imoral, e deveria ter sido evitado pelos próprios dirigentes desses tribunais, sem necessidade de ordem constitucional para tanto; lamentavelmente, não foi assim; (d) outra providência que pode ajudar, mas que é de duvidosa pertinência, é a que autoriza a delegação da prática de atos de administração e atos de mero expediente, sem caráter decisório, a servidores do juízo; corre-se o risco de deformação, sobretudo se a autoridade delegante não exercer estrita vigilância no exercício da delegação (art. 93, XII-XV, inseridos pela EC-45/2004).

39. Escolas de magistrados

O *Estatuto da Magistratura* deverá prever cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados. O juiz se torna vitalício, como visto, após dois anos de exercício, condicionado, como se nota, à participação nos referidos cursos de formação e aperfeiçoamento de magistrado; mas o atual Estatuto (Lei Complementar 35/1979 e alterações posteriores) não previu os cursos indicados, embora os tribunais os tenham criado. Ora, enquanto a lei complementar prevista no *caput* do art. 93 da Constituição não dispuser sobre mencionados cursos

fica difícil dar cumprimento às exigências do inciso IV do mesmo artigo – salvo no que se refere à Justiça Federal, porque a EC-45/2004 inseriu um inciso II no parágrafo único do art. 105 e um inciso I no § 2º do art. 111-A da Constituição, determinando, respectivamente, o funcionamento, junto ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Superior do Trabalho, da escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados federais (aliás, já existente) e do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os concursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira.

Essas escolas de formação de magistrados podem ser úteis. Há, porém, quem tema que se tornem mecanismos de orientação unilateral aos magistrados, sem atender ao livre curso das idéias. Se isso se verificar, será uma deformação que contraria a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, assim como o pluralismo de idéias – previstos no art. 206, II e III, da Constituição, aplicáveis também a essas escolas de magistrados.

Capítulo V

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

I. FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA: 1. “*Nemo iudex sine actore*”. 2. Carreiras jurídicas e isonomia concreta. II. O ADVOGADO: 3. Uma profissão. 4. O advogado e a administração da justiça. 5. Inviolabilidade. III. O MINISTÉRIO PÚBLICO: 6. Natureza e princípios institucionais. 7. Estrutura orgânica. 8. Garantias. 9. Funções institucionais. 10. Conselho Nacional do Ministério Público. IV. A ADVOCACIA PÚBLICA: 11. Advocacia-Geral da União. 12. Representação das unidades federadas. Remissão. 13. Defensorias Públicas e a defesa dos necessitados.

I. FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA

1. “*Nemo iudex sine actore*”

Esta velha máxima, que significa, ao pé da letra, que não há juiz sem autor, exprime muito mais do que um princípio jurídico, porque revela que a Justiça, como instituição judiciária, não funcionará se não for provocada, se alguém, um agente (autor, aquele que age), não lhe exigir que atue. É um princípio basilar da função jurisdicional que “o juiz deve conservar [...] uma atitude estática, esperando sem impaciência e sem curiosidade que os outros o procurem e lhe proponham os problemas que há de resolver”.¹ “A inércia [lembra ainda Calamandrei] é, para o juiz, garantia de equilíbrio, isto é: de imparcialidade”, que, sendo “virtude suprema do juiz, é resultante de duas parcialidades que se combatem”² parcialidades dos advogados das partes em disputa.

Nisso se acha a justificativa das *funções essenciais à justiça*, compostas por todas aquelas atividades profissionais públicas ou privadas, sem as quais o Poder Judiciário não pode funcionar ou funcionará muito mal. São procuratórias e propulsoras da atividade jurisdicional, institucionalizadas nos arts. 127 a 135 da Constituição de 1988, discriminadamente: o *Advogado*, o *Ministério Público*, a *Advocacia-Geral da União*, os *Procuradores dos Estados e do Distrito Federal* (representação das unidades federadas) e a *Defensoria Pública*.

1. Cf. Piero Calamandrei, *Eles, os juízes, visto por nós, os advogados*, p. 50.

2. *Ob. cit.*, pp. 50 e 53.

2. Carreiras jurídicas e isonomia concreta

Mantivemos a rubrica acima só para esclarecer as mudanças operadas na matéria, que não mais lhes corresponde. De fato, os arts. 135 e 241 da Constituição mandavam aplicar às carreiras disciplinadas no seu Título IV e aos delegados de polícia a isonomia de vencimentos prevista no art. 39, § 1º. Foi com base nessa normatividade que sustentamos, nas edições anteriores deste livro, a ocorrência, no caso, de uma *isonomia concreta*, independente da isonomia geral contida no art. 5º. Esse tipo de *isonomia concreta* não é mais prevista, porque a EC-19/98, mudando o conteúdo normativo dos dispositivos identificados pelos ns. 39, § 1º, 135 e 241, a eliminou. O novo dispositivo do art. 135, agora, determina que as carreiras de Procuradores da União, dos Estados e do Distrito Federal, assim como os Defensores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios sejam remuneradas na forma do art. 39, § 4º, ou seja, mediante *subsídio*, em parcela única, sujeita a revisão geral anual e ao teto previsto no art. 37, XI.³ Os membros da magistratura e do Ministério Público, assim como os delegados de polícia, também serão remunerados na mesma forma, por *subsídios*, em termos que examinaremos mais adiante.

II. O ADVOGADO

3. Uma profissão

Trouxemos para o início deste capítulo as considerações sobre o advogado, que a Constituição prestigiou no art. 133. O advogado é um profissional habilitado para o exercício do *ius postulandi*.⁴ Constituintes, profissionais de outras áreas, estranharam (às vezes, impugnam ou censuraram) o fato de a Constituição destacar esse profissional, considerando-o inviolável. Certamente, a advocacia não é uma profissão nem superior nem mais nobre do que as outras. Todas as profissões e atividades laborativas humanas são nobres e importantes na medida em que todas contribuem à sua maneira para o progresso social. Pode-se dizer que a sociedade constitui uma coletividade de variadas profissões. O advogado não é o único profissional que mereceu referência direta da Constituição. O professor, o jornalista e o médico também mereceram atenção. Mas todas encontram nela seu ponto de apoio.

3. Limitado o subsídio mensal, em espécie, ao dos Ministros do STF.

4. Sobre o profissional do Direito, cf. Nelson Nogueira Saldanha, *Sociologia do direito*, pp. 162 e ss.

A advocacia não é apenas uma profissão, é também um *munus* e “uma árdua fadiga posta a serviço da justiça”.⁵ O advogado, servidor ou auxiliar da Justiça,⁶ é um dos elementos da administração democrática da Justiça. Por isso, sempre mereceu o ódio e a ameaça dos poderosos. Frederico, o Grande, que chamava os advogados de “sanguessugas e venenosos répteis”, prometia “enforcar sem piedade nem contemplação de qualquer espécie” aquele que viesse pedir graça ou indulto para um soldado, enquanto Napoleão ameaçava “cortar a língua a todo advogado que a utilizasse contra o governo”.⁷ Bem sabem os ditadores reais ou potenciais que os advogados, como disse Calamandrei, são “as supersensíveis antenas da justiça”.⁸ E esta está sempre do lado contrário de onde se situa o autoritarismo. Acresce ainda que a advocacia é a única habilitação profissional que constitui pressuposto essencial à formação de um dos Poderes do Estado: o Poder Judiciário. Tudo isso deve ter conduzido o constituinte à elaboração da norma do art. 133.

4. O advogado e a administração da justiça

A advocacia não é apenas um pressuposto da formação do Poder Judiciário. É também necessária ao seu funcionamento. “O ad-

5. Cf. Eduardo J. Couture, *Los mandamientos del abogado*, Buenos Aires, Depalma, 1951, pp. 11 e 31. Os Mandamentos elaborados pelo pranteado processualista são: “(1) ESTUDA. — O Direito se transforma constantemente. Se não segues seus passos, serás cada dia um pouco menos advogado. (2) PENSA. — O Direito se aprende estudando, mas se exerce pensando. (3) TRABALHA. — A advocacia é uma árdua fadiga posta a serviço da justiça. (4) LUTA. — Teu dever é lutar pelo direito; mas o dia em que encontrares em conflito o direito com a justiça, luta pela justiça. (5) SÊ LEAL. — Leal para com teu cliente, a quem não deves abandonar até que compreendas que é indigno de ti. Leal para com o adversário, ainda quando ele seja desleal contigo. Leal para com o juiz, que ignora os fatos e deve confiar no que tu lhe dizes; e que, quanto ao Direito, alguma que outra vez, deve confiar no que tu lhe invocas. (6) TOLERA. — Tolerar a verdade alheia na mesma medida em que queres que seja tolerada a tua. (7) TEM PACIÊNCIA. — O tempo se vinga das coisas que se fazem sem sua colaboração. (8) TEM FÉ. — Tem fé no Direito, como o melhor instrumento para a convivência humana; na justiça, como destino normal do direito; na paz, como substitutivo bondoso da justiça; e sobretudo, tem fé na liberdade, sem a qual não há direito, nem justiça, nem paz. (9) OLVIDA — A advocacia é uma luta de paixões. Se em cada batalha for carregando tua alma de rancor, chegará um dia em que a vida será impossível para ti. Concluído o combate, olvida tão prontamente tua vitória como tua derrota. (10) AMA A TUA PROFISSÃO. — Trata de considerar a advocacia de tal maneira que o dia em que teu filho te pedir conselho sobre seu destino, consideres uma honra para ti propor-lhe que se faça advogado”.

6. Cf. Frederico Marques, *Manual de direito processual civil*, v. I, p. 276, São Paulo, Saraiva, 1974.

7. Cf. E. Zaitsev e A. Poltorak, *La abocacia soviética*, Moscou, Ed. en Langues Extranjeras, 1939, pp. 63 e 64.

8. *Ob. cit.*, p. 57.

vogado é indispensável à administração da justiça”, diz a Constituição (art. 133), que apenas consagra aqui um princípio basilar do funcionamento do Poder Judiciário, cuja inércia requer um elemento técnico propulsor. O antigo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 4.215/63, art. 68) já o consignava. Nada mais natural, portanto, que a Constituição o consagrasse e prestigiasse, reconhecendo no exercício de seu mister a prestação de um serviço público.

Com base nela o novo Estatuto da Advocacia (Lei 8.906, de 4.7.94) o consigna, ao declarar:

“Art. 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça.

“§ 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social.”

Num primeiro momento, pareceu-me que o princípio da indispensabilidade do advogado impedia a postulação judicial por leigo nos processos trabalhistas e no de *habeas corpus*. *Res perpenso*, rendo-me ao argumento da jurisprudência, que não encontrou tal obstáculo (STJ, RHC 1.701-CE, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezini).

5. Inviolabilidade

A inviolabilidade do advogado, prevista no art. 133, não é absoluta. Ao contrário, ela só o ampara em relação a seus atos e manifestações no exercício da profissão, e assim mesmo, nos termos da lei. Equivoca-se quem pense que a inviolabilidade é privilégio do profissional. Na verdade, é uma proteção do cliente que confia a ele documentos e confissões da esfera íntima, de natureza conflitiva e, não raro, objeto de reivindicação e até de agressiva cobiça alheia, que precisam ser resguardados e protegidos de maneira qualificada.

III. O MINISTÉRIO PÚBLICO

6. Natureza e princípios institucionais

O Ministério Público vem ocupando lugar cada vez mais destacado na organização do Estado, dado o alargamento de suas funções de proteção de direitos indisponíveis e de interesses coletivos. A Constituição de 1891 não o mencionou, senão para dizer que um dos membros do Supremo Tribunal Federal seria designado Procurador-Geral da República, mas a Lei 1.030, de 1890, já o organizava como *instituição*. A Constituição de 1934 o considerou como *órgão de cooperação nas atividades governamentais*. A de 1946 reservou-lhe um título autônomo,

enquanto a de 1967 o incluiu numa seção do capítulo do Poder Judiciário e a sua Emenda 1/69 o situou entre os órgãos do Poder Executivo. Agora, a Constituição lhe dá o relevo de *instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis*.

Ainda assim não é aceitável a tese de alguns que querem ver na instituição um quarto poder do Estado, porque suas atribuições, mesmo ampliadas aos níveis acima apontados, são ontologicamente de natureza executiva, sendo, pois, uma instituição vinculada ao Poder Executivo,⁹ funcionalmente independente, cujos membros integram a categoria dos *agentes políticos*, e, como tal, hão de atuar “com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na Constituição e em leis especiais. Não são funcionários públicos em sentido estrito, nem se sujeitam ao regime estatutário comum. Têm normas específicas para sua escolha, investidura, conduta e processo por crimes funcionais e de responsabilidade, que lhes são privativos”.¹⁰

Essa foi a orientação doutrinária que informou a elaboração das normas constitucionais sobre o Ministério Público, que lhe afirmam os princípios institucionais da *unidade*, da *indivisibilidade* e da *independência funcional* e lhe asseguram *autonomia administrativa*, facultando-lhe, observado o disposto no art. 169, “propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas e de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira”. Dá-se-lhe, assim, o poder de iniciativa de lei nessas matérias. Cabe também a ele elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Mas não se lhe dá aí o poder de iniciativa da proposta orçamentária, devendo esta, por isso, integrar-se no orçamento geral a ser submetido ao Poder Legislativo pelo Poder Executivo.

A EC-45/2004 acrescentou a essas disposições que, se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. Se a proposta orçamentária for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. E, mais, durante a execução orçamentária do exercício

não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Essa autonomia financeira implica que as dotações orçamentárias que lhe cabem hão de ser-lhe entregues, em duodécimos, até o dia 20 de cada mês (art. 168).

7. Estrutura orgânica

Órgãos. Diz o art. 128 que o *Ministério Público* abrange: (1) o Ministério Público da União, que compreende: (a) o Ministério Público Federal; (b) o Ministério Público do Trabalho; (c) o Ministério Público Militar; (d) o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; (2) o Ministério Público dos Estados. Mas o art. 130 admite um Ministério Público especial, não mencionado no art. 128, junto aos Tribunais de Contas, portanto junto a órgão não jurisdicional.

Chefia. O *Ministério Público da União* integra os demais Ministérios Públicos da órbita federal sob a chefia unitária do Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução, mas, para cada recondução, repete-se o procedimento, de tal sorte que ela se efetiva por via de nova nomeação; não se limitou o número de reconduções (art. 128, § 1º). Já os *Ministérios Públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios* formarão *lista tríplice* dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha do Procurador-Geral (*da Justiça*; a Constituição não o disse, mas não há razão para refugar o nome, que se harmoniza com as funções essenciais do MP: funcionar junto de tribunais de justiça), que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo (Governadores nos Estados, Presidente da República para o Distrito Federal e Territórios), para mandato de dois anos, permitida uma recondução (art. 128, § 3º). Aqui, vê-se: é só uma recondução, sem necessidade de repetir o procedimento de nova eleição, de lista tríplice; basta a renomeação pelo Chefe do Executivo competente. No caso do Procurador-Geral da República, a repetição do procedimento se faz necessária, porque o Senado tem que aprovar a recondução, que é, no caso, forma de nomeação.

A Constituição fala em *mandato* dos Procuradores-Gerais, mas o regime dessa investidura não é de mandato. Não se trata de representação, nem mesmo em relação aos Procuradores-Gerais dos Estados, Distrito Federal e Territórios, provenientes de eleição dos integrantes da carreira. Não representam esses eleitores. A eleição aí é

9. Cf. Federico Marques, *ob. cit.*, pp. 291 e 292.

10. Cf. Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, p. 72.

mero elemento de ato complexo de investidura. Esse tipo de “mandato” é, na realidade, mera *investidura a tempo certo*, por isso mesmo é que pode ser interrompida antes de terminar o prazo, embora não ao inteiro alvedrio da autoridade nomeante, porque depende de autorização do Senado Federal por voto da maioria absoluta de seus membros, quando se tratar do Procurador-Geral da República (art. 128, § 2º), ou por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva, quando se tratar de Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios (art. 128, § 5º).

Note-se uma curiosa incoerência dos textos que se referem aos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos do Distrito Federal e dos Territórios em situação idêntica aos dos Estados, sem levar em conta que aqueles são organizados e mantidos pela União e integram, por essa razão, o Ministério Público da União. São provenientes de lista tríplice formada pelos seus integrantes, quando não assim é nem para o Procurador-Geral da República nem para os chefes dos outros Ministérios Públicos da União. Sua destituição depende de deliberação do Poder Legislativo que, como órgão da União, é o Congresso Nacional, enquanto a destituição do Procurador-Geral da República depende do Senado Federal, não do Congresso. Essa mesma garantia, aliás, não está prevista para os Chefes dos outros Ministérios Públicos integrantes da União. Daí decorre, em relação aos Ministérios Públicos do Distrito Federal e dos Territórios, que, embora integrantes do Ministério Público da União, foi-lhes conferida certa autonomia diante do Procurador-Geral da República, não cabendo a este indicar seus chefes nem exonerá-los como seus subordinados, como deverá ocorrer com os outros.

Unidade e indivisibilidade. Temos que verificar como se realizam os princípios da *unidade* e da *indivisibilidade* do Ministério Público dentro desta estrutura orgânica multifária e diversificada.

O art. 128 quer dar consequência ao *princípio da unidade* do Ministério Público. Por isso, trata todos os Ministérios Públicos enumerados nos seus incisos e alíneas como se constituíssem uma *instituição única*, ao afirmar que o “Ministério Público abrange [...]”. Quer-se, com esse modo de dispor, significar que a *instituição* do Ministério Público abrange todos os Ministérios Públicos ali indicados.

Realmente, a pretensão da unidade nesse sentido já constava da exposição de motivos da Comissão elaboradora dos estudos e do anteprojeto da antiga Lei Orgânica do MP (Lei Complementar 40/81 e consagrado na atual: Lei 8.625, de 12.2.93), segundo a qual o Ministério Público é, em seus lineamentos básicos, *uma só instituição*, quer atue no plano federal, junto à justiça comum ou especial, quer no plano dos

Estados, Distrito Federal e Territórios. Não é fácil construir uma *unidade* e *indivisibilidade* de instituições que se inserem no contexto da organização federativa, de si diversificante. Imagine-se, por exemplo, a questão da indivisibilidade que fundamenta a realização do princípio da devolução, que dá ao chefe o poder de avocar funções de subordinados, ou a realização do princípio da substituição que possibilita um membro cumprir funções de outro. Não há como efetivar isso entre os vários Ministérios Públicos. Só é realizável dentro de cada um deles.

O sentido, pois, daqueles princípios só se revela na maneira como o Prof. Frederico Marques assinalou nos termos seguintes: “No Brasil, em virtude da organização federativa, pode-se dizer que há um *parquet* em cada Estado, além do que constitui o Ministério Público Federal e dos que funcionam junto às jurisdições especiais. Dentro de cada *parquet* existe a unidade e indivisibilidade que estruturam a instituição como um corpo hierarquizado. De *parquet* para *parquet*, há apenas unidade funcional sob a base da lei, pois na aplicação do direito existem laços de coordenação e igualdade”.¹¹

Carreira. Ingressa-se na carreira por concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica, observada, nas nomeações, a ordem de classificação. As promoções na carreira e a aposentadoria seguem as regras estatuídas no art. 93, II e VI, já examinadas em relação à magistratura.

8. Garantias

Como *agentes políticos*, os membros do Ministério Público precisam de ampla liberdade funcional e maior resguardo para o desempenho de suas funções, não sendo privilégios pessoais as prerrogativas da *vitaliciedade*, a *irredutibilidade de subsídio*, na forma do art. 39, § 4º (EC-19/98) e a *inamovibilidade* (art. 128, § 5º, I), que se lhes reconhecem, a todos, mas *garantias* necessárias ao pleno exercício de suas elevadas funções que incluem até mesmo o poder-dever da ação penal contra membros dos órgãos governamentais. Admite-se, contudo, a *remoção por motivo de interesse público*, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Essas *garantias* da independência funcional já foram estudadas em relação à magistratura, sendo desnecessário rediscuti-las aqui.

11. Cf. *Instituições de direito processual civil*, v. 1/245, Rio de Janeiro, Forense, 1958.

Também se lhes preordenaram *garantias de imparcialidade* na forma de vedações (art. 128, § 5º, II): de *receber*, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; de *exercer*, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério; de *exercer* atividade político-partidária – essa, agora, é uma proibição absoluta, porque a EC-45/2004 eliminou a possibilidade de a lei estabelecer exceções a ela, com o que ficaram revogados os dispositivos de lei que as tenham e se tornará inconstitucional a que vier a fazê-lo, repercutindo-se também na disposição transitória (ADCT, art. 29, § 3º); de *exercer* a advocacia no âmbito jurisdicional em que desempenhava suas atribuições, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração (parece que, com esse enunciado, se atende à determinação de que aos membros do Ministério Público se aplica o disposto no inciso V do parágrafo único do art. 95, inserido pela mesma EC-45/2004).

A propósito da Instituição, podemos lembrar uma passagem de Calamandrei: “Entre todos os cargos judiciais, o mais difícil, segundo me parece, é o do Ministério Público. Este, como sustentáculo da acusação, devia ser tão parcial como um advogado; como guarda inflexível da lei, devia ser tão imparcial como um juiz.

“Advogado sem paixão, juiz sem imparcialidade, tal é o absurdo psicológico no qual o Ministério Público, se não adquirir o sentido do equilíbrio, se arrisca, momento a momento, a perder, por amor da sinceridade, a generosa combatividade do defensor ou, por amor da polêmica, a objetividade sem paixão do magistrado.”¹²

9. Funções institucionais

As *funções institucionais* do Ministério Público estão relacionadas no art. 129, em que ele aparece como: *titular* da ação penal, da ação civil pública para a tutela dos interesses públicos, coletivos, sociais e difusos, e da ação direta da inconstitucionalidade genérica e interventiva, nos termos da Constituição; *garantidor* do respeito aos Poderes Públicos e aos serviços de relevância pública; *defensor* dos direitos e interesses das populações indígenas, além de outras de *intervenção* em procedimentos administrativos, de *controle externo* da atividade policial, na forma da lei complementar, de *requisição* de diligências investigatórias e de *instauração* de inquérito policial, vedadas essas funções a quem não seja integrante da carreira, salvo quan-

to à legitimação para as ações civis que não impede seu exercício por terceiros.¹³ Ao Ministério Público junto aos Tribunais de Contas só compete o exercício de suas funções essenciais de *custos legis*, porque a representação das Fazendas Públicas, aí, como em qualquer outro caso, é função dos respectivos Procuradores, nos termos dos arts. 131 e 132. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da Instituição. Finalmente, a distribuição de processos no Ministério Público será imediata.

10. Conselho Nacional do Ministério Público

A EC-45/2004 inseriu o art. 130-A mediante o qual criou o Conselho Nacional do Ministério Público. Parece que isso era uma questão de honra para a magistratura, como quem diz “se criou um Conselho Nacional da Justiça, para nos controlar, há que se criar também um para vigiar o Ministério Público”. Vamos aqui nos limitar a dar notícias dele, sem entrar em pormenores como o fizemos em relação ao Conselho Nacional da Justiça, mais pormenorizadamente regulado.

Composição: O Conselho compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: I – o Procurador-Geral da República, que o preside; II – quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras; III – três membros do Ministério Público dos Estados; IV – dois juizes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; V – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VI – dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.

Competência. Ao Conselho compete o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: I – zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos admi-

13. Chamamos a atenção do leitor para as disposições transitórias sobre o Ministério Público e seus membros, constantes do art. 29 do ADCT.

12. Ob. cit., p. 59.

nistrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas; III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; IV – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano; V – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI, da Constituição.

Corregedor Nacional. O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes: I – receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares; II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral; III – requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.

Funcionamento. Nada se estabeleceu sobre o funcionamento do Conselho, nem se determinou que lei o fizesse, mas é evidente que isso tem que acontecer. Quanto a isso, apenas se previu que será presidido pelo Procurador-Geral da República e que o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto a ele, como também se prevê que o faça junto ao Conselho Nacional da Justiça, com o que a OAB vai consolidando sua posição de instituição constitucional.

Ouvidorias do Ministério Público. No dia 1º.1.1995, o Governador Mário Covas criou a ouvidoria da polícia do Estado de São Paulo, atendendo a uma proposta que lhe fiz quando ele me honrou nomeando Secretário da Segurança do Estado, durante o seu primeiro mandato. Depois disso, as ouvidorias viraram moda e, a torto e a direito, prevê-se a criação de uma. A EC-45/2004 determinou a criação de várias, como já referimos antes. Por isso, o § 5º do art. 130-A manda que leis da União e dos Estados criarem ouvidorias do Ministério Público (mais de uma, portanto), competentes para receber reclama-

ções e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, para fazer mais ou menos o mesmo que caberá ao Corregedor Nacional, previsto no § 3º do mesmo artigo, sem se levar em conta que a experiência mostra que, quando se distribui as mesmas atribuições a mais de um órgão, acontece que nenhum as realiza esperando que o outro o faça.

IV. A ADVOCACIA PÚBLICA

11. Advocacia-Geral da União

Instituição e organização. A Constituição desfez o bifrontismo que sempre existiu no Ministério Público Federal, cujos membros exerciam cumulativamente as funções de Ministério Público e de Procuradores da República no exercício da advocacia da União. Agora o Ministério Público da União com seus Ministérios Públicos especiais só cumpre as funções típicas da instituição. Não são mais advogados da União.

As funções de advocacia pública da União foram outorgadas a uma nova instituição que a Constituição denominou *Advocacia-Geral da União*, prevista no art. 131, que, “diretamente ou através de órgãos vinculados, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo”. Vê-se, pois, que lhe cabe, por si diretamente ou por órgãos vinculados (que são as procuradorias das autarquias e fundações públicas (LC 73/1993, art. 17), procuradorias essas que não se integrarão na Advocacia-Geral da União, mas simplesmente a ela serão vinculadas): (a) a representação da União em juízo e fora dele; (b) a consultoria jurídica do Poder Executivo; (c) o assessoramento do Poder Executivo. Mas o § 3º do artigo esclarece que, na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional, observado o disposto na lei (Lei Complementar 73/93).¹⁴

Isso não quer dizer que a Procuradoria da Fazenda Nacional constitui uma instituição à parte da Advocacia-Geral da União. A lei complementar que dispuser sobre a organização e funcionamento da Advocacia-Geral da União definirá sua posição. É lógico esperar que a instituição venha a compreender várias Procuradorias em ra-

14. Alertamos o leitor sobre a existência de normas transitórias sobre a Advocacia-Geral da União no art. 29 do ADCT.

ção da matéria: Procuradoria Judicial ou do Contencioso Federal, Procuradoria Administrativa, Procuradoria do Patrimônio da União e Procuradoria da Fazenda Nacional. A esta a Constituição já dá uma incumbência: a execução da dívida ativa, e a lei complementar poderá dar outras.

Chefia. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o *Advogado-Geral da União*, de livre nomeação do Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Carreira. Os membros da Advocacia-Geral da União, denominados Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional e Assistentes Jurídicos, são organizados em carreira, em cuja classe inicial ingressarão por concurso público de provas e títulos.

12. Representação das unidades federadas — Remissão

A representação judicial e a consultoria jurídica das unidades federadas (Estados e Distrito Federal) competem aos seus Procuradores, organizados em carreira, em que ingressarão por concurso público de provas e provas e títulos. Com isso se institucionalizam os serviços jurídicos estaduais, a que faremos referência mais devagar, quando formos estudar a organização dos Estados federados.

13. Defensorias Públicas e a defesa dos necessitados

Uma velha observação de Ovídio ainda vigora nos nossos dias, especialmente no Brasil: *Cura pauperibus clausa est*, ou no vernáculo: "O tribunal está fechado para os pobres".¹⁵ Os pobres ainda têm acesso muito precário à justiça. Carecem de recursos para contratar advogados. O *patrocínio gratuito* tem-se revelado de deficiência alarmante. Os Poderes Públicos não tinham conseguido até agora estruturar um serviço de *assistência judiciária aos necessitados* que cumprisse efetivamente esse direito prometido entre os direitos individuais. Aí é que se tem manifestado a dramática questão da desigualdade da justiça, consistente precisamente na desigualdade de condições materiais entre litigantes, que causa profunda injustiça àqueles que, defrontando-se com litigantes afortunados e poderosos, ficam na impossibilidade de exercer seu direito de ação e de defesa assegurado na Constituição.

A *assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos* vem configurada, relevantemente, como direito individual no art. 5º, LXXIV. Sua eficácia e efetiva aplicação, como outras prestações estatais, constituirão um meio de realizar o princípio da igualização das condições dos desiguais perante a Justiça.

Nesse sentido é justo reconhecer que a Constituição deu um passo importante, prevendo, em seu art. 134, a *Defensoria Pública* como *instituição* essencial à função jurisdicional, incumbida da orientação jurídica e defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.

A lei complementar, prevista no art. 134, parágrafo único, já foi promulgada. É a Lei Complementar 80, de 12.1.1994. Atendendo o disposto nesse dispositivo constitucional, referida lei organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, segundo as regras de competência estabelecidas nos arts. 21, XIII, e 22, XVII, e prescreve normas gerais para a organização das Defensorias Públicas estaduais, prevendo igual estrutura para todas essas entidades (art. 5º, 53 e 98) mas só às Defensorias Públicas estaduais a Constituição assegura autonomia funcional e administrativa, e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º (EC-45/2004); mas essa subordinação é destituída de sentido, porque não há como aplicá-la, na espécie. Essa autonomia implica que as dotações orçamentárias que lhes correspondem não de serem entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos (art. 168). Dita lei complementar, nos termos do dispositivo constitucional, estabeleceu a disciplina da carreira dos Defensores Públicos da União, do Distrito Federal e dos Territórios, e instituiu normas gerais sobre o regime jurídico da carreira dos Defensores Públicos estaduais (arts. 19, 65 e 110), com as garantias constitucionais de provimento, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos e de inamovibilidade e a vedação constitucional de exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

15. Cf. *Amores*, Liv. III, VIII, 55, citado por Cappelletti, *Proceso, ideología, sociedad*, p. 155.

Título III

Dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal

Capítulo I

DOS ESTADOS FEDERADOS

I. FORMAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ESTADOS: 1. Autonomia dos Estados. 2. Auto-organização e Poder Constituinte Estadual. 3. Formas de expressão do Constituinte Estadual. 4. Limites do Poder Constituinte dos Estados. 5. Princípios constitucionais sensíveis. 6. Princípios constitucionais estabelecidos. 7. Interpretação dos princípios limitadores da capacidade organizadora dos Estados. II. COMPETÊNCIAS ESTADUAIS: 8. Questão de ordem. 9. Competências reservadas aos Estados. 10. Competências vedadas aos Estados. 11. Competência exclusiva especificada. 12. Competências estaduais comuns e concorrentes. 13. Competências estaduais materiais: Econômicas. Sociais. Administrativas. Financeiras. 14. Competência legislativa. III. ORGANIZAÇÃO DOS GOVERNOS ESTADUAIS: 15. Esquema constitucional. 16. Poder Legislativo estadual. 17. Poder Executivo estadual. 18. Poder Judiciário estadual. 19. Funções essenciais à Justiça estadual. IV. CONTEÚDO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: 20. Considerações gerais. 21. Elementos limitativos. 22. Elementos orgânicos. 23. Elementos sócio-ideológicos. 24. Conclusão.

I. FORMAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ESTADOS

1. Autonomia dos Estados

A Constituição Federal assegura *autonomia* aos Estados federados que se consubstancia na sua capacidade de auto-organização, de autolegislação, de autogoverno e de auto-administração (arts. 18, 25 a 28).

A *capacidade de auto-organização e de autolegislação* está consagrada na cabeça do art. 25, segundo o qual os *Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição*.

A *capacidade de autogoverno* encontra seu fundamento explícito nos arts. 27, 28 e 125, ao disporem sobre os princípios de organização dos poderes estaduais, respectivamente: *Poder Legislativo*, que se ex-

pressa por Assembléias Legislativas; *Poder Executivo*, exercido pelo Governador; e *Poder Judiciário*, que repousa no Tribunal de Justiça e outros tribunais e juízes.

A *capacidade de auto-administração* decorre das normas que distribuem as competências entre União, Estados e Municípios, especialmente do art. 25, § 1º, segundo o qual *são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição*, que contém, como se nota, o princípio de que, na partilha federativa das competências, aos Estados cabem os poderes remanescentes, aqueles que sobram da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22, especialmente) e dos indicados aos Municípios (art. 30).

2. Auto-organização e Poder Constituinte Estadual

A *auto-organização* é, pelo visto, o primeiro elemento da autonomia estadual e se concretiza na capacidade de dar-se a própria Constituição. É o que exprime o art. 25: *os Estados organizam-se pelas Constituições que adotarem*. “Toda Constituição pressupõe a existência de um Poder capaz de formulá-la, de um Poder que não é instituído por ela, mas que a institui, de um Poder que, através dela, institui os demais poderes.”¹ Significa dizer que as Constituições estaduais implicam a existência de um Poder especial que, por meio delas, organiza, forma, *constitui* os respectivos Estados federados, e é o *Poder Constituinte* pertinente ao povo de cada uma dessas unidades federadas, de onde surge o primeiro problema relativo à organização, qual seja o da natureza e limites do constituinte estadual.

Há grave controvérsia doutrinária a respeito da natureza do poder constituinte estadual. Uns lhe negam verdadeiro caráter constituinte, porque é demasiadamente limitado, o que não se compadece com o conceito de poder constituinte, que, em princípio, se tem por juridicamente ilimitado. Outros entendem tratar-se de constituinte de segundo grau, subordinado, secundário e condicionado.² Manoel Gonçalves Ferreira Filho chama-o *Poder Constituinte Decorrente*, “aquele que, decorrendo do originário, não se destina a rever sua obra mas a institucionalizar coletividades, com caráter de estados, que a Constituição preveja”.³ Quer isso dizer que o Poder Cons-

1. Cf. Anna Cândida da Cunha Ferraz, *Poder constituinte do estado-membro*, p. 57, citando Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de direito constitucional*, pp. 29 e 30, e Carlos Sánchez Viamonte, *El poder constituyente*, p. 569.

2. Idem, p. 37.

3. Cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *Curso de direito constitucional*, p. 25; idem, *Direito constitucional comparado: I — o poder constituinte*, pp. 177 e ss.; Nelson Nogueira Saldanha, *O poder constituinte: tentativa de estudo sociológico e jurídico*, pp. 52 e 53, e Carlos Sánchez Viamonte, *ob. cit.*, p. 359.

tituinte das unidades federadas é criação do Poder Constituinte Originário.

Lembre-se da distinção entre soberania e autonomia. O *Poder Constituinte Originário*, aquele que é fonte da Constituição Federal, é poder supremo, é *soberano*, enquanto o *Poder Constituinte Estadual* é apenas autônomo. A soberania consiste na autodeterminação plena, nunca dirigida por determinantes jurídicas extrínsecas à vontade do soberano, que é o povo na sua expressão nacional, enquanto a autonomia, como poder próprio dentro de um círculo traçado por outro, pressupõe ao mesmo tempo uma zona de autodeterminação, que é o propriamente autônomo, e um conjunto de limitações e determinantes jurídicas extrínsecas, que é o heterônomo. A zona de autodeterminação e o conjunto de limitações são impostos pela Constituição Federal,⁴ que assegurou aos Estados a capacidade de auto-organizar-se por Constituição própria, observados os princípios dela.

3. Formas de expressão do Constituinte Estadual

As formas de expressão do *Poder Constituinte Decorrente* não correspondem exatamente às do Poder Constituinte Originário. Isso se explica no fato de que, sendo subordinado ao último, sua expressão depende de como lhe seja por ele determinado no ato constitucional originário. Por isso, não nos parece que a *outorga* de Constituição Estadual seja possível, pois falta ao Constituinte Estadual autodeterminação para tanto. Quando a Constituição Federal provém de outorga, por regra a autonomia dos Estados fica coartada e, portanto, não se exprime por Constituição própria. O máximo que pode acontecer é o Poder Central impor às coletividades regionais uma Constituição, mas, em tal situação, o resultado foi precisamente eliminar a capacidade de auto-organização que caracteriza a essência de Estados Federados.⁵

Isso se explica ainda no fato importante de que a autonomia é sempre uma marca democrática nos Estados Federais. Por conseguinte, o Poder Constituinte das unidades federadas se expressa comumente por via de procedimento democrático, por via de representação popular: seja *Convenção* (como nos EUA) ou *Assembleia Estadual Constituinte*, com ou sem participação popular direta.

No Brasil, o Constituinte Estadual sempre se exprimiu por via de *Assembleia Constituinte Estadual*. Quando assim não se procedeu,

foi porque a Constituição Federal, proveniente de movimento autoritário, determinara que os Estados reformassem suas Constituições para adaptá-las àquela (CF/67, art. 188), ou, ainda pior, mandara que suas disposições se incorporassem ao direito constitucional legislativo dos Estados (CF/69, art. 200).

A Constituição de 1988, nesse particular, também, não é muito democrática, porque não previu a convocação de Assembleias Constituintes com poderes especiais para elaborar suas Constituições. Por ela, a Assembleia Nacional Constituinte reconheceu às Assembleias Legislativas, eleitas com ela em 1986, *poderes constituintes*, para elaborar a Constituição do Estado (ADCT, art. 11). Em todo caso, como aquela fora eleita com poderes constituintes para fazer a Constituição Federal, e, na mesma eleição, também se elegeram os Deputados Estaduais que seriam incumbidos da tarefa constituinte estadual, a questão da legitimidade fica menos comprometida.

4. Limites do Poder Constituinte dos Estados

Dissemos, antes, que é a Constituição Federal que fixa a zona de determinações e o conjunto de limitações à capacidade organizatória dos Estados, quando manda que suas Constituições e leis observem os seus princípios.

Que princípios são estes, ela não os indica, a todos, explicitamente. Com facilidade, desde logo, descobre-se um grupo deles enunciados no art. 34, VII; a descoberta dos demais, no entanto, depende de pesquisa no seu texto constitucional. O art. 125 reafirma essa indeterminação explícita, mas oferece um indicativo, quando diz que os Estados organizarão sua Justiça, observados os *princípios estabelecidos nesta Constituição*, usando terminologia da Constituição de 1946, em face da qual, e igualmente da atual, os princípios, que circunscrevem a atuação do Constituinte Estadual, podem ser considerados em dois grupos: (a) os *princípios constitucionais sensíveis*,⁶ e (b) os *princípios constitucionais estabelecidos*.

A Constituição vigente, retomando critérios da Constituição de 1946, em prestígio do federalismo, praticamente eliminou os *princípios extensíveis*, aqueles que consubstanciavam regras de organização da União, cuja aplicação, nos termos da Constituição revogada, se estendia aos Estados. Restou apenas a regra segundo a qual os vencimentos dos magistrados (Desembargadores) não podem exce-

4. Cf. Felipe Tena Ramírez, *Derecho constitucional mexicano*, p. 135.

5. Veja-se que estamos aqui, lamentavelmente, discordando de Anna Cândida da Cunha Ferraz, *ob. cit.*, p. 103.

6. A terminologia é de Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. II/286. Ele não explica por que *sensíveis*.

der aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 93, V), que tem mais a ver com o exercício dos Poderes constituídos do que com limites do Poder Constituinte Decorrente. Vincula especialmente a capacidade de autolegislação, antes que a de auto-organização.

5. Princípios constitucionais sensíveis

O termo *sensíveis* está aí no sentido daquilo que é facilmente percebido pelos sentidos, daquilo que se faz perceber claramente, evidente, visível, manifesto;⁷ portanto, *princípios sensíveis* são aqueles clara e indubitavelmente mostrados pela Constituição, os *apontados, enumerados*. São *sensíveis* em outro sentido, como coisa dotada de sensibilidade, que, em sendo contrariada, provoca reação, e esta, no caso, é a intervenção nos Estados, exatamente para assegurar sua observância.

Esses princípios são aqueles que estão enumerados no art. 34, VII, que constituem o fulcro da organização constitucional do País, de tal sorte que os Estados federados, ao se organizarem, estão circunscritos à adoção: (a) da forma republicana do governo; (b) do sistema representativo e do regime democrático; (c) dos direitos da pessoa humana; (d) da autonomia municipal; (e) da prestação de contas da administração pública, direta e indireta.

São princípios que dizem respeito basicamente à organização dos poderes governamentais dos Estados, que envolve outros princípios particulares que destacaremos mais adiante. O princípio da prestação de contas atrai a observância dos princípios referentes ao sistema de controle externo e de controle interno a serem induzidos dos preceitos dos arts. 70 a 75 e, por conseguinte, a observância dos princípios orçamentários. O princípio da *autonomia municipal* impõe ao Poder Constituinte Estadual limites no tocante à organização dos Municípios, de vez que estes adquiriram capacidade de auto-organização, respeitados princípios estabelecidos na Constituição Estadual e na Constituição Federal, de modo que os Estados não podem senão indicar regras muito gerais sobre essa matéria.

A inclusão de normas na Constituição Estadual em desrespeito a esses princípios poderá provocar a representação do Procurador-Geral da República, visando à declaração de inconstitucionalidade, e decretação de intervenção federal, caso não tenha eficácia a simples suspensão da execução do ato impugnado, tudo nos termos e na forma estatuída no art. 36, III, § 3º.

7. "Sensível", in Caldas Aulete, *Dicionário contemporâneo da língua portuguesa*, Rio de Janeiro, Delta, 1958.

6. Princípios constitucionais estabelecidos

São [como notara Raul Machado Horta] os que limitam a autonomia organizatória dos Estados; são aquelas *regras* que *revelam*, previamente, a matéria de sua organização e as *normas* constitucionais de caráter vedatório, bem como os princípios de organização política, social e econômica, que determinam o retraimento da autonomia estadual, cuja identificação reclama pesquisa no texto da Constituição.⁸

Alguns deles são fáceis de localizar, porque se encontram organizados em blocos normativos que a Constituição manda que sejam observados pelos Estados, como, por exemplo, os princípios e preceitos constantes dos arts. 37 a 41 referentes à Administração Pública. Outros, porém, exigem maior atenção. Faremos aqui um esforço investigatório para tentar aflorá-los, senão na sua totalidade, ao menos numa amostra expressiva, por meio de uma consideração sistemática, notando que uns geram *limitações expressas*, outros *limitações implícitas* e outros, ainda, *limitações decorrentes* do sistema constitucional adotado, além do disposto nos parágrafos do art. 25 que fundamenta a repartição de competências aos Estados.

Limitações expressas ao Constituinte Estadual — São consubstanciadas em dois tipos de regras: umas de natureza *vedatória* e outras, *mandatórias*.

As primeiras proíbem explicitamente os Estados de adotar determinados atos ou procedimentos, tais como as dos arts. 19, 150 e 152 (pormenores infra), intervir nos Municípios, salvo ocorrência de um dos motivos estritamente considerados no art. 35, mas terá que regular o processo de intervenção, nas hipóteses possíveis, ao teor do art. 36.

As *mandatórias* consistem em disposições que, de maneira explícita e direta, determinam aos Estados a observância de princípios, de sorte que, na sua organização constitucional e normativa, hão que adotá-los, o que importa confranger sua liberdade organizatória aos limites positivamente determinados; assim, por exemplo, o Constituinte Estadual tem que dispor: (a) sobre *princípios da organização dos Municípios*, respeitada a autonomia destes, como consta do art. 29, incluindo regras sobre criação, incorporação, fusão e desmembramento deles, por *lei estadual* (não por outra forma), atendidos os pressupostos e requisitos indicados no art. 18, § 4º, prevendo ainda que seu Tribunal de Contas exerça o controle externo da administração municipal como auxílio às respectivas Câmaras Municipais (art. 31,

8. Cf. *A autonomia do Estado-membro no direito constitucional brasileiro*, Belo Horizonte, 1964, p. 225.

§ 1º); (b) sobre sua *Administração Pública*, mas não pode senão adotar os princípios referidos nos arts. 37 a 41; não só na organização constitucional estadual tais princípios hão de ser obedecidos — praticamente nada mais os Estados podem fazer senão transcrevê-los em sua essência — mas ainda terão que segui-los na sua legislação ordinária e nas práticas governamentais, sob pena de inconstitucionalidade; os Estados, contudo, poderão inovar no sentido mais rigoroso, por exemplo, na adoção dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade; *v. g.*, podem impor maiores restrições à publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, em função de seus interesses peculiares; (c) sobre *servidores militares*, à vista do disposto no art. 42, naquilo que for pertinente; (d) sobre *criação obrigatória de juizados especiais e justiça de paz* com os requisitos e exigências do art. 98; (e) sobre a *organização da sua Justiça*, definido já o seu Tribunal de mais alto grau, como *Tribunal de Justiça*, conforme o art. 125, respeitados os princípios previstos nos arts. 93, 94 e 95, que sequer precisam ser incorporados à Constituição Estadual, até porque vão figurar no Estatuto da Magistratura nacional, mas, entre as regras de competência da sua Justiça, terá que prever as que lhes sejam pertinentes, indicadas nos arts. 96 e 99; (f) sobre *inconstitucionalidades de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição Estadual*, vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão (art. 125, § 2º); ora, como a própria Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público, ou seja, ao Procurador-Geral da Justiça, *representação de inconstitucionalidade interventiva* (art. 129, IV), a *ação de inconstitucionalidade genérica* precisa ser definida pelo Constituinte Estadual na Constituição que produzir, devendo atribuir a legitimação para sua proposição a vários titulares; (g) sobre a *organização e competência do Ministério Público*, atendendo os princípios da unidade, da indivisibilidade, da independência funcional, da autonomia funcional e administrativa e com as garantias, conforme preceituam os arts. 127 a 130; (h) sobre sua *representação judicial e consultoria jurídica*, que hão de ser atribuídas a Procuradores dos Estados, organizados em carreira, com as garantias, direitos e prerrogativas indicados nos arts. 132 e 135; (i) sobre a *organização da Defensoria Pública* com as atribuições, direitos e garantias constantes dos arts. 134 e 135; (j) sobre *segurança pública* a ser garantida por organizações policiais civis (polícia civil) e militares (polícia militar) com as respectivas competências, conforme indicam o art. 144, seus incs. IV e V e seus §§ 4º a 7º.

Limitações implícitas ao Constituinte Estadual — Também aqui seria possível distinguir *limitações implícitas vedatórias* e *limitações implícitas mandatórias*. Mas não necessitamos descer a esses pormeno-

res, neste caso. Quando a Constituição, por exemplo, arrola no art. 21 a matéria de estrita competência da União, *implicitamente* veda ao Constituinte Estadual cuidar dela; assim, igualmente, quando dá à União competência privativa para legislar sobre a matéria relacionada no art. 22. Ao indicar a matéria de competência exclusiva dos Municípios, no art. 30, está, ao contrário, limitando os Estados nesse campo, limitação que se confirma com o princípio da autonomia municipal que são obrigados a respeitar, sob pena de intervenção federal (art. 34, VII, c), salvo um ponto ou outro (art. 30, VI, VII e IX) em que a matéria ingressa na competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23). Por princípio, a indicação de regras de competência, ainda que positivamente, envolve limitação da capacidade organizatória dos Estados, pois se trata de reger o comportamento do Constituinte Estadual. Alguns exemplos são suficientes para a compreensão do assunto. A Constituição diz que os Estados *poderão* instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (art. 25, § 3º), mas, se o fizerem, terão que obedecer os critérios e pressupostos indicados no dispositivo autorizativo; seu sistema tributário já consta da Constituição Federal, não precisam transportá-lo para sua Constituição; se o fizerem, estão adstritos a não prever outros tributos que não os indicados nos arts. 145 e 155.

Na organização dos Poderes Estaduais, o Poder Constituinte Decorrente terá que respeitar o princípio da divisão de poderes, que é um princípio fundamental da ordem constitucional brasileira (art. 2º), até porque, implicitamente, isso está previsto; quando a Constituição menciona a Assembléia Legislativa, o Governador do Estado e o Tribunal de Justiça e outros Tribunais e Juízes dos Estados (arts. 27, 28, 92, VII, e 125), está lhes indicando os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Está implícita, nos mesmos arts. 27 e 28, a determinação de Poder Legislativo Estadual *unicameral* e de Executivo *unipessoal*; isso significa também a obrigatoriedade do sistema presidencialista de governo nas unidades federadas.

Limitações ao Constituinte Estadual decorrentes do sistema constitucional adotado — São as geradas pelos princípios que defluem do sistema constitucional adotado, assim é que:

(1) *do princípio federativo*, decorre o respeito dos Estados entre si, pois constitui nota fundamental do Estado federal o princípio da *igualdade constitucional das unidades federadas*; a despeito de todas as diferenças de área territorial, de população e de estágio de desenvolvimento econômico, os Estados são iguais do ponto de vista de sua organização constitucional e legal; nenhum poder ou privilégio especial é conferido a qualquer deles, se bem que a Constituição agora

não repetiu a velha cláusula que vedava estabelecer preferências a favor de uma das pessoas jurídicas de direito público interno, e até abriu a possibilidade, não propriamente de beneficiar uns Estados mais que outros, mas de oferecer certas vantagens no interesse de regiões menos desenvolvidas, visando a redução das desigualdades regionais, como está previsto no art. 43, que prevê ação federal visando a redução da desigualdade,⁹ no art. 159, que prevê fundo de participação tributária especial para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,¹⁰ e no art. 165, § 1º, que determina que o plano plurianual seja regionalizado; mais tipicamente direcionado a um tratamento desigual entre Estados (e também entre Municípios) é o mandamento do art. 161, II: os critérios de rateio dos fundos previstos no art. 159, I, devem ser estabelecidos em lei complementar, “objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios”, o que vale dizer, não que ser desiguais para realizar a igualização entre unidades desiguais; mas, nestes casos, já não estamos mais no campo da organização dos Estados e, sim, no terreno de ação federal concreta para o futuro;

(2) *do mesmo princípio federativo*, tem fundamento a regra segundo a qual nenhuma das unidades federadas pode exercer qualquer coerção sobre outras nem, portanto, estabelecer em sua Constituição algo que vise beneficiar umas em lugar de outras, nem mesmo em favor de região, pois a Constituição, ao apontar possibilidades e vantagens regionais, só o faz na matéria estritamente indicada, não autorizando às unidades regionais, por si, introduzirem em suas Cartas Constitucionais qualquer norma discriminatória;

(3) *dos princípios do Estado Democrático de Direito* provém que as unidades federadas só possam atuar segundo o princípio da legalidade, da moralidade e do respeito à dignidade da pessoa humana (arts. 1º, 5º, II, e 37); daí também decorre que os Estados têm que atender os princípios constitucionais relativamente ao processo de formação das leis, tais como critério da iniciativa das leis, incluindo a iniciativa popular, e os de elaboração legislativa, compreendidas as regras sobre o veto e sanção de projeto de lei;

9. “Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais”. E prevê incentivos regionais (§ 2º).

10. “Art. 159. A União entregará: I — do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: [...]; c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer.”

(4) *do princípio democrático* (art. 1º, parágrafo único) resulta que a organização e funcionamento dos Estados não que respeitar e fazer respeitar em seu território os direitos fundamentais e suas garantias;

(5) *dos princípios da ordem econômica e social* dimana o dever dos Estados de se organizarem e planejarem seus serviços e obras com respeito aos princípios dos respectivos títulos: valorização do trabalho, justiça social, saúde e educação como direito de todos e obrigação das entidades estatais, defesa da cultura etc.

7. Interpretação dos princípios limitadores da capacidade organizadora dos Estados

Tais princípios limitam, como se viu, a autonomia organizatória do Constituinte Estadual. Significa isso que se cogita de normas limitativas de um dos princípios fundamentais da ordem constitucional brasileira: a autonomia dos Estados (art. 18), verdadeira decisão política fundamental, que é o princípio federativo que descansa na *autonomia das unidades federadas*, fulcro da estrutura do Estado brasileiro, tão importante o considerou o constituinte nacional que o erigiu em núcleo imutável por via de emenda constitucional (art. 60, § 4º). Daí sua preeminência em relação àqueles princípios que constituem limitações à capacidade organizatória dos Estados, salvo quanto aos que decorrem do sistema constitucional, há pouco mencionados, porquanto estes são superiores, dado que revelam os fins e fundamentos do próprio Estado brasileiro.

Afora a consideração desses últimos, os demais princípios enumerados ou estabelecidos pela Constituição Federal, que impliquem limitações à autonomia estadual — cerne e essência do princípio federalista —, não que ser compreendidos e interpretados restritivamente e segundo seus expressos termos. Admitir o contrário seria superpor a vontade constituída à vontade constituinte.

II. COMPETÊNCIAS ESTADUAIS

8. Questão de ordem

Já discutimos, mais de uma vez, a teoria da repartição de competência como ponto nuclear da noção de Estado federal, assim como sua conceituação e natureza, lembrando sempre que não se instituirão Estados federados se não se outorgar a eles um mínimo de matérias para o exercício exclusivo de sua atividade normativa. Pois bem, é disso que trataremos neste passo, recordando que, como vimos acima em seus lineamentos gerais, a base das competências estaduais

se acha nos poderes reservados, remanescentes, que merecerão nossa primeira preocupação em seguida.

9. Competências reservadas aos Estados

A Constituição manteve a técnica tradicional, que vem do Direito Constitucional americano, de enumerar os poderes (competências) da União, cabendo aos Estados os *poderes reservados*, isto é: os *poderes remanescentes*. A expressão *poderes* (ou competências) *reservados* é adequada à Federação americana, porque lá foram os Estados independentes que se uniram para a formação do Estado federal, abrindo mão de poderes soberanos, *reservando*, no entanto, o quanto entenderam satisfatório à sua existência autônoma. No Brasil não foi assim. Ao contrário, o Estado unitário descentralizou-se em Unidades federadas autônomas, *enumerando* para o governo central (federal) os poderes que se entenderam convenientes, deixando o *resto*, a *sobra* (isto é: o que remanesceu da enumeração dos poderes da União e da indicação dos poderes municipais), para os Estados. Por isso, para o sistema federativo brasileiro, a expressão *poderes* (ou competências) *remanescentes* é mais indicada do que *poderes* (ou competências) *reservados*. Mas esta foi a terminologia adotada pela Constituição, no seu art. 25, § 1º, que dispõe: *São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição*.

As Constituições anteriores *reservavam* aos Estados as competências que lhes não fossem vedadas explícita ou implicitamente nelas. O texto vigente, como se nota, não menciona “explícita ou implicitamente”, o que não importa, porque a vedação sempre será explícita ou implícita. Em verdade, não são só competências que não lhes sejam vedadas, que lhes cabem, pois também lhes competem competências enumeradas em comum com a União e os Municípios (art. 23), assim como a competência exclusiva referida no art. 25, §§ 2º e 3º.

10. Competências vedadas aos Estados

A determinação do que sobra aos Estados, na partilha das competências, no sistema federativo brasileiro, há de partir dos poderes que lhes sejam vedados, explícita ou implicitamente, pela Constituição, consoante lembramos no n. 6 supra.

Veda-se-lhes explicitamente: estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interesse público; recusar fé aos documentos públicos; criar distinções entre brasileiros ou preferência em favor de

qualquer das pessoas jurídicas de direito público interno (União, outros Estados, Distrito Federal e Municípios) (art. 19); suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei (art. 34, V). Além dessas, contam-se ainda as *vedações administrativas* (art. 37, XIII, XVI e XVII), as *vedações tributárias* (arts. 150 e 152) e as *financeiras* (art. 167), que examinaremos no lugar próprio.

Veda-se-lhes implicitamente tudo que tenha sido enumerado apenas para a União e para os Municípios. Assim, a matéria relacionada nos arts. 20, 21 e 22 explicitamente como de competência da União está implicitamente interdita aos Estados. Do mesmo modo, não podem os Estados interferir naquilo que a Constituição integrou na competência municipal (arts. 29 e 30).

11. Competência exclusiva especificada

Alguma competência exclusiva a Constituição especificou para os Estados, como: (a) a criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, por lei estadual, segundo requisitos estabelecidos em lei complementar, também estadual (art. 18, § 4º); (b) a exploração diretamente, ou mediante concessão, dos serviços locais de gás canalizado, na forma da lei (art. 25, § 2º, segundo a EC 5/95); não é fácil compreender a lógica do constituinte que, ao mesmo tempo que dá monopólio de pesquisa e lavra de gás natural à União, confere aos Estados aquela exploração direta ou por concessão, como se fosse dele; a conciliação será a União pesquisar e lavrar e depois outorgar aos Estados, que tenham condições, a distribuição; esta é que os Estados poderão explorar diretamente ou mediante concessão; (c) a faculdade de instituir, mediante lei complementar estadual, *regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões*, constituídas por agrupamento, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum (art. 25, § 3º); isso dá aos Estados maior poder de ordenação de seu território.

12. Competências estaduais comuns e concorrentes

O art. 23, como destacamos antes, arrola matérias de *competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios*, que já indicamos, sem maiores comentários, no n. 15 do capítulo I do título II. Não é necessário voltar ao assunto que não comporta, num livro didático da natureza deste, minuciosos esclarecimentos, assim como também nos permitimos não repisar aqui o que já foi dito sobre a *competência legislativa concorrente* entre Estados e União que figura no

n. 16 do mesmo capítulo mencionado acima. Com isso, pouparemos o leitor de repetições dispensáveis, chamando apenas a atenção para a correlação da matéria lá e cá.

13. Competências estaduais materiais

Classificação. Desde logo, cumpre advertir, mais uma vez, que os Estados federados não exercem competência de ordem internacional. Não mantêm relações com as nações estrangeiras nem com organismos internacionais, pois tais relações constituem manifestação de soberania, que é monopólio do Estado Federal, nesse aspecto representado pela União, conforme assinalamos noutro lugar. *União, Estados federados, Distrito Federal e Municípios* são entidades puramente constitucionais. Para os Estados estrangeiros e os organismos internacionais, a República Federativa do Brasil é que existe, isto é, *o todo*, e como *uma unidade*. E o governo da União, que é o governo federal, para eles, é simplesmente o governo da República.

Visto isso, compreendemos que a área de competência dos Estados federados se limita à seguinte classificação:

- (1) competência econômica;
- (2) competência social;
- (3) competência administrativa;
- (4) competência financeira e tributária.

(1) *Competência econômica*: não sobra muito espaço para os Estados em matéria econômica. Poderão, certamente, explorar diretamente atividades econômicas em caso de relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Essa exploração só poderá ser feita por empresas públicas, especialmente por sociedades de economia mista, e outras entidades com a observância dos limites e requisitos constantes dos arts. 37, XIX e XX, e 173. A Constituição lhes reconhece, expressamente, a competência, comum com União, Distrito Federal e Municípios, para fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar (art. 23, VIII) e, também, para legislar sobre *produção e consumo*, sobre os quais a União estabelecerá normas gerais (art. 24, V, e §§ 1º a 4º).

(2) *Competência social*: no *setor social*, contudo, os Estados federados têm competência mais ampla, cabendo-lhes prestar serviços de saúde, assistência e previdência social (esta limitada a seus servidores, art. 149, parágrafo único), desportos, educação, cultura, por seus sistemas de ensino (art. 212), proteção do meio ambiente, dos bens culturais, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, combater as cau-

sas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Enfim, o art. 23 é fonte importante da atuação dos Estados no setor social, mas as prestações sociais previstas no título da ordem social só pontualmente se fecham à competência estadual. De modo geral, o campo é aberto aos seus poderes.

(3) *Competência administrativa*: a estrutura administrativa dos Estados-membros é por eles fixada livremente, no exercício de sua autonomia constitucional de auto-administração, sujeitando-se a certos princípios que são inerentes à administração em geral, como são os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, eficiência e outras determinações constantes do art. 37, que se impõem a todas as esferas governamentais.

Assim, terão as Secretarias de Estado que convierem a seus serviços. Instituirão as autarquias que julgarem necessárias. Organizarão empresas públicas e sociedades de economia mista, se assim for necessário e o desejarem, destinadas, porém, à prestação de serviços de utilidade pública (transportes, energia, comunicações, dependendo nestes dois últimos casos de autorização ou concessão da União) e atividade econômica de produção (agrícola, pecuária e industrial, como produção de aço e cimento, entre outras) e consumo (silos, armazéns, abastecimento etc.).

Só a eles compete dividir-se em regiões administrativas, criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões.

É também de sua competência estatuir sobre seu funcionalismo, fixando-lhe o regime jurídico, observados, neste caso, os princípios constitucionais estabelecidos sobre o assunto (arts. 37 a 39).

(4) *Competência financeira*: têm os Estados encargos a cumprir para satisfazer as necessidades coletivas, em decorrência de sua qualidade de entidades federativas autônomas, dotadas de competência exclusiva, comum e concorrente para realizar serviços e obras públicas. Precisam de meios pecuniários para a realização de seus fins. Por isso, a Constituição, a par da autonomia, conferiu-lhes competência financeira exclusiva. Em razão disso, cabe-lhes instituir os tributos que lhes foram discriminados (arts. 145 e 155, como veremos oportunamente), legislar sobre direito financeiro e estabelecer normas orçamentárias, desde que respeitem as normas gerais expedidas pela União (arts. 24, §§ 1º a 4º, e 146).

Respeitadas essas normas, incumbe-lhes elaborar suas leis de diretrizes orçamentárias, seus orçamentos anuais e planos plurianuais, realizar despesas e aplicar recursos como melhor lhes parecer, segundo as necessidades de sua administração e população, mediante planos e programas de desenvolvimento econômico e social.

14. Competência legislativa

Não existe autonomia federativa sem capacidade normativa sobre determinada área de competência. Os Estados federados dispõem dessa capacidade, agora mais do que antes, mas sempre nos limites que a Constituição Federal lhes traçou. O campo de incidência de sua legislação, no entanto, não vai muito além do terreno administrativo, financeiro, social (competência comum), de administração, gestão de seus bens, alguma coisa na esfera econômica nos limites já apontados, e quase nada mais, tais como: elaborar e votar leis complementares à Constituição estadual; votar o orçamento e planos plurianuais; legislar sobre seus tributos, arrecadação e aplicação de suas rendas; dispor sobre a dívida pública estadual e autorizar abertura de crédito; criar e extinguir cargos públicos, fixando-lhes os vencimentos e vantagens; dispor sobre a divisão administrativa e judiciária de seu território; dispor sobre a organização do seu Ministério Público, da Defensoria Pública e da Procuradoria ou Advocacia-Geral do Estado; legislar plenamente ou suplementarmente sobre as matérias relacionadas no art. 24, com observância de seus parágrafos.

III. ORGANIZAÇÃO DOS GOVERNOS ESTADUAIS

15. Esquema constitucional

O governo dos Estados federados ressaí de esquemas genéricos da Constituição, sujeito, como vimos: (1) à forma republicana; (2) ao sistema representativo; (3) ao regime democrático (art. 34, VII, *a*). Daí decorre que todos os Estados têm idêntica estrutura governamental. E os poderes estaduais — Legislativo, Executivo e Jurisdicional — competem a três órgãos distintos, de acordo com o princípio fundamental da divisão de poderes (art. 2º), respectivamente: *Assembleia Legislativa, Governador do Estado e Poder Judiciário (Tribunal de Justiça e outros tribunais e juízes)*.

16. Poder Legislativo estadual

Assembleia Legislativa. É o órgão do Poder Legislativo estadual, que, nos Estados, é unicameral, não se admitindo a criação de Senado estadual. Compõe-se de Deputados, representantes do povo do Estado, eleitos diretamente pelo sistema proporcional, para um mandato de quatro anos.

O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos

forem os Deputados Federais acima de doze (art. 27). De onde se vê que será o triplo apenas nos Estados onde se elegerem no máximo doze Deputados Federais. Por exemplo, será de vinte e quatro o número de Deputados à Assembleia Legislativa do Estado a que corresponder eleger oito Deputados Federais. Será de trinta e seis se lhe couber eleger doze Deputados Federais. Se a representação de determinado Estado, na Câmara Federal, for de quarenta e dois Deputados, sua Assembleia Legislativa terá *trinta e seis* Deputados *mais tantos quantos forem os Deputados Federais nele eleitos acima de doze*: ou seja: extraíam-se 12 de 42 e some-se o resultado a 36, ter-se-á $36 + (42 - 12) = 66$. São Paulo deverá ter, a partir da atual legislatura, 70 Deputados Federais, logo sua Assembleia Legislativa compreenderá $36 + (70 - 12) = 94$ Deputados.

Funcionamento. Reúne-se a Assembleia Legislativa na Capital do Estado, em sessão legislativa ordinária, independentemente de convocação, na data fixada na Constituição estadual. A Constituição Federal não impõe aos Estados critérios sobre o funcionamento de seu Poder Legislativo, de sorte que o Poder Constituinte Estadual poderá dispor do assunto como melhor lhe parecer. É-lhe facultado adotar ou não o esquema das sessões legislativas previsto para o Congresso Nacional, que se reúne, anualmente, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, dividindo-se a sessão legislativa ordinária em dois períodos. Sua autonomia aí é praticamente total. Não é total, porque não pode deixar de fixar um período anual de funcionamento, já que existem exigências, como a de elaboração orçamentária, a de apreciação das contas do Governador e outras, que demandam trabalho legislativo durante o ano, e é evidente que, na medida em que a Constituição Federal outorgou mais poderes aos Estados, torna-se imprescindível maior atividade de seu Poder Legislativo, para cumprir suas funções de legislar, de deliberar, de fiscalizar e de controlar.

Mas os trabalhos das Assembleias Legislativas desenvolvem-se em *reuniões*, que podem ser sessões diárias, de segunda a sexta-feira, como no Congresso Nacional, ou não. A tradição sempre foi a da realização de reuniões de trabalho diariamente, que se abrem com a presença do número de Deputados previsto na Constituição estadual: 1/4, 1/3, 1/5. Esse é um *quorum* somente para a abertura dos trabalhos. Outro *quorum* será o das deliberações, que também cabe à Constituição do Estado estabelecer. A Constituição Federal não lhe impõe critério. Para o funcionamento das Casas do Congresso Nacional, está consignado que, *salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros* (art. 47). Houve proposta

de reduzir esse *quorum* para 2/5, o que foi recusado por descer a um nível muito baixo a possibilidade de aprovação de matérias importantes, já que basta a maioria simples, em muitas hipóteses, para a aprovação (portanto, bastaria um quinto mais um Deputado ou Senador para aprovação de matéria em votação). Se um *quorum* baixo facilita o funcionamento do Legislativo, certo é que debilita o resultado de seu trabalho. Há casos, por isso mesmo, em que a Constituição Federal exige *quorum* mais elevado para aprovação de matérias: *maioria absoluta* ou *dois terços* dos membros da Casa ou do Congresso. *Maioria absoluta* não é metade mais um, mas mais da metade dos membros da Casa (forma-se a partir do primeiro número inteiro acima da metade). Não tem sentido falar em maioria absoluta dos presentes. Maioria absoluta é conceito que se afere em função da totalidade do colegiado em referência. Mesmo onde não esteja especificado que se trata da maioria absoluta dos membros da Casa, assim deve ser entendido, se não se estabeleceu nada em contrário expressamente. Dois terços, três quintos também são quóruns possíveis, sempre em função da totalidade dos membros da Casa. Cabe à Constituição estadual definir essas questões.

Atribuições. É função do Poder Constituinte estadual definir também sobre que matéria cabe à Assembléia Legislativa legislar, com sanção do Governador, e sobre que matéria lhe compete dispor exclusivamente. Aí sua autonomia não é tão grande, primeiro porque fica delimitada ao âmbito de competência estadual; segundo porque tem que atender ao princípio da legalidade, segundo o qual determinadas matérias só podem ser estatuídas em lei, de acordo com o princípio de que ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (Constituição Federal, art. 5º, II).

Atribuições de competência exclusiva das Assembléias Legislativas serão aquelas que se vinculam a assuntos de sua economia interna, ou a seu controle prévio ou sucessivo de atos do Executivo, tais como: eleger sua Mesa e constituir suas comissões permanentes, temporárias ou especiais ou de inquérito; elaborar e votar seu regimento interno, regular a própria polícia e organizar seus serviços administrativos, compreendendo a criação ou extinção de cargos, empregos ou funções, fixação da respectiva remuneração, mas aí com alguns limites estabelecidos nos arts. 37 e 39 da Constituição Federal; dar posse ao Governador e ao Vice-Governador do Estado, conhecer-lhes da renúncia e apreciar seus pedidos de licença, bem como autorizá-los a ausentar-se do Estado, seguindo ou não os critérios da Constituição Federal em relação ao Presidente da República (art. 49, III: necessidade de autorização só quando a ausência exceder a quinze dias); julgar anualmente as contas prestadas pelo Governador refe-

rentes à administração direta ou indireta e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, e aqui não é uma questão de conveniência, porque o princípio da prestação de contas é previsão constitucional federal, sob pena de intervenção (art. 34, VII, d), logo a Constituição estadual há de estabelecer o seu julgamento pela Assembléia Legislativa; promover a responsabilidade do Governador, quando for o caso; apreciar a denúncia contra o Governador nos crimes de responsabilidade e nos delitos comuns; solicitar a intervenção federal no Estado para garantir o livre exercício de suas funções; apreciar vetos opostos pelo Governador a projetos de lei; autorizar o Governador a efetuar ou contrair empréstimos; autorizar ou aprovar convênios ou acordos em casos especificados; escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas do Estado, bem como aprovar os nomes do outro terço indicado pelo Governador; aprovar ou sustar o ato de intervenção estadual em Município, salvo quando decorrente de ação judicial; aprovar referendo e convocar plebiscito sobre tema de competência estadual; aprovar a alienação ou concessão de terras públicas estaduais; aprovar, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de presidente de bancos estaduais, do Procurador-Geral da Justiça e do Procurador-Geral do Estado, se se quiser seguir o modelo federal, não de observância obrigatória, nesse aspecto; se houver um Conselho do Estado (sem necessidade), nos moldes do Conselho da República, eleger os membros-cidadãos; convocar Secretários de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto de sua pasta, previamente determinado; mudar sua sede temporariamente; a iniciativa da lei de fixação dos subsídios do Governador e do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos próprios Deputados Estaduais, observado o que dispõem os arts. 37, X (teto), 39, § 4º (fundamento do subsídio), 150, II, 153, III, e 153, § 2º, da Constituição Federal.¹¹ Essas remissões todas aos arts. 150 e 153 envolvem matéria de estrita competência federal. Nada terá a Assembléia que dispor sobre ela. Rigorosamente, nem precisa fazer iguais remissões. Todas elas apenas querem dizer que os subsídios dos Deputados Es-

11. Tais dispositivos dizem o seguinte: o art. 150, II, estabelece que é vedado "instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos"; o art. 153, III, declara competir à União instituir imposto sobre "renda e proventos de qualquer natureza", e o art. 153, § 2º, estatui que o imposto sobre a "renda e proventos de qualquer natureza: I — será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei;". O inciso II do § 2º do art. 153 foi revogado pela EC-20/1999.

taduais, como o do Governador e Vice-Governador, dos membros da magistratura, como de qualquer outra pessoa, ficam sujeitos ao pagamento do imposto de renda.

Processo legislativo estadual. O processo legislativo, nos Estados, tem por objeto a formação de: (a) emendas à Constituição estadual; (b) leis ordinárias sobre matéria de competência estadual; (c) leis complementares estaduais, as já previstas na Constituição Federal (p. ex., arts. 18, § 4º, e 25, § 3º) como as que a própria Constituição do Estado vier a prescrever; (d) decretos legislativos regulando matéria de exclusiva competência da Assembléia Legislativa, com efeito externo; e (e) resoluções legislativas sobre matéria administrativa e outras de interesse interno da Assembléia Legislativa.

E medidas provisórias, podem as Constituições estaduais instituí-las? Em edições anteriores, respondemos que nada justificava sua existência no âmbito estadual, mas não víamos proibição em que o fizessem. Até onde sabemos, os Estados (e também os Municípios) evitaram adotá-las. E hoje, *re melius perpensa*, achamos ponderável o argumento de que, sendo exceção ao princípio da divisão de poderes, só valem nos limites estritos em que foram elas previstas na Constituição Federal, ou seja, apenas no âmbito federal, não se legitimando seu acolhimento nem nos Estados nem nos Municípios.

Leis delegadas também não são admissíveis no âmbito estadual.

O constituinte estadual, hoje, tem mais autonomia para organizar o processo legislativo, porque a Constituição de 1988 não impôs aos Estados a obrigação de observar o processo legislativo federal nela estruturado. Mas é evidente que os princípios básicos do processo legislativo, sem os quais este inexistiria, terão que coincidir nas esferas federal, estadual e municipal, e as regras sobre iniciativa legislativa concorrente e exclusiva, sobre emendas e suas limitações, sobre o processo de formação de leis orçamentárias. Cumpre, no entanto, notar que a Constituição de 1988 tendeu a prestigiar a atuação parlamentar no processo legislativo.

Estatuto dos Deputados Estaduais. O Estatuto dos Deputados Estaduais é matéria que compete ao constituinte de cada Estado definir na respectiva Constituição, mas a Constituição Federal já determina que lhes sejam aplicadas as regras sobre *sistema eleitoral* (sistema proporcional), *inviolabilidade*, *imunidades*, *subsídio*, *perda de mandato*, *licença*, *impedimentos* e *incorporação às Forças Armadas*, o que invoca o conteúdo do modelo federal constante dos arts. 53 a 56, cumprindo apenas acrescentar aí o *privilegio de foro* a ser previsto na Constituição estadual, para declarar que serão julgados pelo Tribunal de Justiça. A Constituição, conforme a EC-19/98, também já deu regras sobre

a fixação do subsídio dos Deputados Estaduais, dizendo que isso se dará por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. Essa limitação foi introduzida pela EC-1/92, confirmada agora na EC-19/98, para coibir abusos dos legisladores estaduais, que não foram dignos da liberdade que originariamente lhes foi conferida. 75% da remuneração estabelecida *em espécies* significa que, no cálculo, não podem entrar vantagens indiretas (telefone, correio, residência etc.) que os Deputados Federais tenham. A remissão ao art. 39, § 4º, tem consequências práticas, já que este manda observar o art. 37, X e XI, ou seja, exige lei específica para a fixação do subsídio, mas admite sua revisão anual, e sua sujeição ao teto: subsídio dos Ministros do STF.

17. Poder Executivo estadual

Governador do Estado. O Poder Executivo estadual é exercido por um Governador do Estado, eleito para um mandato de quatro anos, por sufrágio universal e voto direto e secreto em eleição que se realize, em primeiro turno, no primeiro domingo de outubro e, no segundo turno, se houver, no último domingo de outubro, do ano anterior ao do término do mandato em curso, tomando posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente, observado o princípio da maioria absoluta tal como está previsto para o Presidente da República no art. 77, que já foi objeto de nossas considerações, a que nos permitimos remeter o leitor.¹²

A posse se dá perante a Assembléia Legislativa, quando, nos termos da Constituição estadual, se prevê que o Governador preste o compromisso de cumprir a Constituição Federal e a do Estado, observar e fazer observar as leis e desempenhar lealmente o mandato em benefício dos interesses do povo, do País e do Estado.

Substitutos do Governador. A Constituição prevê a eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado. Este é o substituto nos impedimentos do Governador e seu sucessor no caso de vaga. A Constituição estadual poderá designar-lhe outras atribuições, e deve definir, também, que, na falta do Vice-Governador, sejam chamados à governança sucessivamente o Presidente da Assembléia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça. Há que estabelecer, outrossim, a situação que decorrer de inexistência concomitante de Governador e de Vice-Governador. Sabe-se que, em tal caso, o Presidente da Assembléia ou, no impedimento deste, o Presidente do Tribunal de Justiça será chamado

12. Cf. Terceira Parte, título 2, capítulo 3, n. 3.

ao exercício do cargo, mas por quanto tempo? Pois, esses substitutos eventuais não se transformam em Governador. São Presidentes no exercício da governança. As Constituições estaduais sempre deram solução diversificada a essa situação, umas prevendo nova eleição direta se a última vaga ocorresse nos primeiros três anos de mandato governamental e eleição pela Assembléia de novo Governador e Vice, completando o eleito, em qualquer caso, o mandato em curso; outras estatuíam que haveria eleição popular para Governador e Vice, se a vaga se desse nos três primeiros anos e, se no último ano, o substituto completaria o período. A primeira hipótese estará mais de acordo com o atual modelo federal, que não é obrigatório.

Atribuições do Governador. Serão definidas na Constituição do Estado, mas não com autonomia absoluta, já que o princípio da divisão de poder é que rege a distribuição de matérias entre os Poderes estaduais, de sorte que ao Governador não poderá ser entregue senão matéria de natureza executivo-administrativa, semelhantes às que cabem ao Presidente da República, tais como representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas, administrativas e sociais; exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da Administração estadual; sancionar e vetar os projetos de lei; promulgar e fazer publicar as leis; exercer o poder regulamentar; exercer o poder hierárquico e disciplinar sobre todos os servidores do Executivo, na forma que a lei estabelecer; prover e extinguir cargos públicos do Estado, com as restrições da Constituição do Estado e na forma da lei; nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado e demais ocupantes de cargos de provimento em comissão; nomear e exonerar os dirigentes de autarquias, observadas as condições estabelecidas na Constituição do Estado; decretar e fazer executar a intervenção municipal, na forma da Constituição; solicitar intervenção federal no Estado, nos termos da Constituição Federal; enviar à Assembléia Legislativa proposta orçamentária, prestar contas da administração do Estado à Assembléia Legislativa até a data fixada; apresentar à Assembléia Legislativa, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do Estado, solicitando as medidas que julgar de interesse do governo; iniciar o processo legislativo nos casos previstos na Constituição estadual; prestar as informações solicitadas pelos Poderes Legislativo e Judiciário; praticar, enfim, os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo.

Subsídios e impedimentos. À Constituição do Estado é que compete estabelecer critérios para a fixação dos *subsídios do Governador e do Vice-Governador* (e também do Secretário de Estado). Mas a Constituição Federal (EC-19/98) já deu as bases dessa fixação, prevendo que será feita por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, obser-

vado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, o que vale dizer que tais subsídios ficam sujeitos ao teto (subsídio dos Ministros do STF) e à tributação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, segundo o princípio da generalidade. Por outro lado, a remissão ao art. 39, § 4º, que dá os fundamentos gerais da remuneração por meio de *subsídios*, significa também fazer incidir na espécie os incs. X e XI do art. 37. O primeiro prevê que a fixação de subsídios, como de remuneração, deve ocorrer por lei específica com direito a revisão anual; o segundo prevê o teto. Ele é repetido, nesse aspecto, desnecessariamente, no texto reelaborado pela EC-19/98, a menos que se quisesse com isso dizer que não se aplicaria ao caso o inc. X do art. 37. Ora, se se quisesse esse efeito, o modo de fazer não seria a mera repetição de um dos incisos que já aparece no texto do art. 39, § 4º, também invocado na disposição em causa. Por esse meio não se exclui o inc. X do art. 37. Para que isso se desse, necessário seria dizê-lo: não se aplicando o inc. X do art. 37. De sorte que, por força da remissão, contida no art. 39, § 4º, temos que concluir que os subsídios do Governador e do Vice-Governador do Estado devem ser revistos anualmente.

Os *impedimentos do Governador* decorrem da natureza de suas atribuições, assim como ocorre com o Presidente da República, independentemente de previsão especificada na Constituição do Estado. Mas aqui queremos lembrar que, nos termos da Constituição de 1988 (art. 28, § 1º, cf. EC-19/98), perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse (sem exercício) em virtude de concurso, observado o disposto no art. 38, I, IV e V, ou seja, tomará posse e automaticamente ficará afastado para o exercício do mandato, contando o período deste como tempo de serviço naquele para todos os efeitos, menos para promoção por merecimento, assim como para benefícios previdenciários, como se no exercício do cargo estivesse. Acaba assim a situação, já irregular no regime constitucional anterior, de Governador se licenciar, por exemplo, para exercer cargo de Ministro. Se quiser exercê-lo, terá que renunciar ao mandato de Governador.

Crimes do Governador. Tendo em vista a natureza e o tribunal competente para o julgamento, os crimes do Governador do Estado podem ser considerados sob dois aspectos: (a) crimes de responsabilidade; (b) crimes comuns.

Os *crimes de responsabilidade* do Governador têm sido definidos em lei federal, porque prevalece o entendimento de que a Constituição estadual não os pode estabelecer, porque se julga ser matéria de competência da União. Esse entendimento decorre de verdadeiro equívoco quanto à natureza dos chamados crimes de responsabilidade, tendo-os como de natureza penal. Se assim fosse, a competên-

cia seria mesmo da União. Mas não têm tal natureza. Constituem simples infrações político-administrativas, cuja definição legal de modo algum se inclui na competência legislativa da União, salvo quanto aos do Presidente da República. Em nenhum dispositivo da Constituição da República veda-se às Constituições estaduais regular tais infrações. Se formos ao fundo do sistema constitucional, acabaremos concluindo exatamente o contrário, isto é, no sentido de que a matéria é mesmo da competência do constituinte estadual.

O processo e o julgamento dos crimes de responsabilidade do Governador são estabelecidos na respectiva Constituição, seguindo, *mutatis mutandis*, o modelo federal: previsão de um *juízo prévio de admissibilidade do processo* por voto de dois terços dos membros da Assembléia Legislativa, diante de denúncia que lhe tenha sido apresentada por qualquer pessoa ou instituição, e, se admitida assim a acusação, será ele submetido a *julgamento* perante o Superior Tribunal de Justiça, nos crimes comuns, ou, nos de responsabilidade, perante a Assembléia¹³ ou perante um Tribunal Especial (certo número de deputados sorteados por seus pares e igual número de desembargadores sorteados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que também o presidirá).¹⁴ A Assembléia ou o Tribunal Especial só poderá impor a sanção de perda do cargo no julgamento dos crimes de responsabilidade (*impeachment*).

As Constituições estaduais estabelecem, também, em regra, que o Governador ficará suspenso de suas funções, nos crimes comuns, recebida a denúncia pelo Superior Tribunal de Justiça e, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pela Assembléia Legislativa.

Até a 6ª edição, observáramos que, nos *crimes comuns*, não nos parecia mais possível definir, na Constituição estadual, que a admissibilidade do processo perante o Superior Tribunal de Justiça dependesse da autorização da Assembléia Legislativa. As Constituições estaduais, no entanto, tomaram rumo diverso, exigindo tal autorização. Em face disso, *re melius perpensa*, entendemos válida essa posição das Cartas dos Estados. É que o juízo prévio de admissibilidade da acusação, que requer o voto de dois terços da representação popular, é um prejudgamento que embasa a suspensão do acusado de suas altas funções, com aquela mesma idéia dos sistemas argentinos

13. Assim prevêem, p. ex., a Constituição de Alagoas (art. 110), a da Bahia (art. 107), a do Ceará (art. 90), a do Espírito Santo (art. 93), a de Minas Gerais (arts. 91, § 3º, e 92), a do Pará (art. 137), a da Paraíba (art. 88), a do Piauí (art. 104), a do Rio de Janeiro (art. 144), a do Rio Grande do Sul (art. 84) e a de Rondônia (art. 67).

14. É o caso, p. ex., das Constituições de Mato Grosso do Sul (art. 137) e de São Paulo (art. 49).

e norte-americano de que uma alta autoridade governamental não pode ser submetida a um processo político ou criminal, enquanto estiver no exercício de sua magistratura.¹⁵ Hamilton já advertia, faz dois séculos, que um tribunal bem constituído para julgar denúncias é não menos desejável do que difícil de se conseguir em um governo totalmente eletivo, pois as ofensas resultantes da conduta de irregularidades de homens públicos são de natureza *política*, de onde várias fórmulas sugeridas perante a Convenção de Filadélfia, entendendo que a solução encontrada de controle político prévio ao processo criminal fora um prudente meio-termo.¹⁶ O Brasil encontrou ainda um sistema mais adequado, submetendo o processo de imposição de sanção política ou criminal a uma condição prévia de oportunidade política a ser decidida pela representação popular, o que corresponde a uma exigência democrática de que o Governador, como o Presidente da República, só deva ser submetido a um processo que o afaste do cargo, para o qual foi eleito pelo povo, com o consentimento ponderado pelo voto de dois terços dos membros da respectiva assembléia representante desse mesmo povo.¹⁷

18. Poder Judiciário estadual

Jurisdição estadual. A Constituição, como já foi visto, inclui os Tribunais e Juizes estaduais entre os órgãos do Poder Judiciário nacional (e, por essa razão, não puramente federal, art. 92, VII), mas declara que os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição. É o acolhimento da tese da jurisdição nacional e descentralização judiciária.¹⁸

Órgãos da Justiça estadual. A reforma do Poder Judiciário (EC-45/2004) mexeu pouco com a Justiça estadual, até porque o poder de reforma tem limites em face do princípio federalista, que se inclui entre as regras do *núcleo duro* da Constituição. O que a reforma acrescentou, nesse capítulo, é legítimo e benéfico. Tudo isso quer dizer

15. Cf. Humberto Quiroga Lavié, *Derecho constitucional*, p. 551; Germán J. Bidart Campos, *El derecho constitucional del poder*, Buenos Aires, Ediar, 1967, v. I/384.

16. Cf., *O federalista*, LXV.

17. *Jurisprudência* (anterior à Constituição de 1988, mas com doutrina válida no seu regime): STF, unanimidade, HC 41.296, RDA 83/164 e ss.; STF, unanimidade, HC 42.108, RDA 81/288; STF, ReprInconst 999-AM (RTJ 81/332), 826-MT, 755-RJ, 749-RS (STF, *Representações por Inconstitucionalidade, Dispositivos de Constituições Estaduais*, t. I/387, 390 e 399 e t. II/55 e 317, Brasília, Senado Federal/Subsecretaria de Edições Técnicas, 1976). A questão ainda não está devidamente definida no sistema vigente. Tem sido, porém, acolhido o princípio exposto no texto, como na AP 15-MS, registro n. 8970671, com parecer nosso (abril de 1990).

18. A propósito, nosso *Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro*, pp. 9 e 10.

que os Estados continuam livres para estruturar sua Justiça, desde que prevejam o *Tribunal de Justiça* como órgão de cúpula da organização judiciária estadual, criem os juizados especiais e a justiça de paz, criem varas especializadas com competência exclusiva para dirimir conflitos fundiários e outras questões agrárias e mantenham o tribunal do júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII – porque estão configurados na Constituição Federal que até já lhes define algumas competências (arts. 93, III, 96, I e II, 98, 125 e 126).

Justiça militar estadual. É facultado à lei estadual criar Justiça Militar, por proposta do Tribunal de Justiça, composta de órgãos de primeiro grau e órgãos do segundo grau. Os primeiros compreendem: (a) os *juizes de direito do juízo militar*, aos quais compete processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares; (b) os *Conselho de Justiça*, a que cabe, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, ressalvada sempre a competência do júri quando a vítima for civil. Não se pode deixar passar sem uma observação crítica o surgimento desses chamados *juizes de direito do juízo militar*, que constitui um retrocesso em oposição às disposições da Lei 9.299, de 1996, que, modificando o Código Penal Militar, submeteu os crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, à competência da justiça comum.

Órgão de segundo grau dessa Justiça será o próprio Tribunal de Justiça estadual ou o *Tribunal de Justiça Militar* nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes, cabendo ao que for competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Controle de constitucionalidade. Está igualmente previsto que cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade (*rectius* ação direta de inconstitucionalidade) de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada, porém, a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. O que se quer, com isso, é abrir o leque da legitimação, tal como se fez em relação à ação direta de inconstitucionalidade prevista no art. 103 da Constituição. O paralelismo do art. 103 é uma pauta que oferece ao constituinte estadual, para, *mutatis mutandis*, prever que serão partes legítimas para a ação de inconstitucionalidade referida, por exemplo, o Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral da Justiça, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, federação sindical e entidade de classe de âmbito estadual, bem como, especialmente em

relação a leis ou atos municipais, o Prefeito do Município, o Presidente da Câmara ou Mesa da Câmara do Município interessado, o Procurador-Geral do Município, onde houver, e os partidos políticos com representação na Câmara do Município. Pode-se prever também (talvez *deva-se*) a *ação de inconstitucionalidade por omissão* em face de determinações da Constituição estadual. Assim, aliás, têm procedido as Constituições estaduais.

Descentralização e justiça itinerante. Observe-se, tal como fizemos em relação aos Tribunais Regionais Federais, que a reforma judiciária, estabelecida pela EC-45/2004, trouxe, aqui também, duas providências importantes para o bom funcionamento da Justiça estadual; uma facultativa, qual seja a de que o Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em todas as fases do processo; pena é que essa providência não seja impositiva como a segunda, que determina que ele instale *justiça itinerante*, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Se a descentralização for implementada, esta segunda providência, por certo, será bem mais produtiva, porque o órgão de recurso estará mais perto.

Organização interna de tribunais e juizes estaduais. A Justiça estadual compreende, como se viu, tribunais de segunda instância e juizes de primeira. O Tribunal de Justiça, órgão de cúpula da organização judiciária estadual, compõe-se de *desembargadores* em número e com as atribuições determinadas na Constituição e nas leis do Estado. Cabe ao Tribunal de Justiça propor à Assembleia Legislativa, observado o disposto no art. 169 da Constituição: (a) a alteração do número de seus membros e o número dos membros; (b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de subsídio de seus membros, dos juizes, e a remuneração dos serviços auxiliares e os dos juizes que lhes forem vinculados (secretarias, cartórios judiciais etc.) (art. 96).

No Tribunal de Justiça ou outro tribunal inferior com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído *órgão especial*, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno.

Em tudo isso, ressalta a competência do Tribunal de Justiça para propor ao Poder Legislativo estadual a alteração da *organização* e da *divisão judiciárias* do Estado.

A *divisão judiciária* compreende a criação, a alteração e a extinção das seções, circunscrições, comarcas, termos e distritos judiciais, bem como sua classificação.

A *organização judiciária* envolve: (1) constituição, estrutura, atribuições e competências dos Tribunais, bem como de seus órgãos de direção e fiscalização; (2) constituição, classificação, atribuições e competências dos juízes; (3) organização, disciplina e atribuições dos serviços auxiliares da justiça, inclusive tabelionatos e ofícios de registros públicos; (4) criação e extinção de cargos nos próprios tribunais, de juízes, de serviços auxiliares e de varas, como dissemos acima.

A competência dos tribunais e juízes estaduais é matéria da Constituição e leis de organização judiciária do Estado, sendo estas, conforme anotamos, de iniciativa do Tribunal de Justiça (art. 125, § 1º). Como vimos acima, a Constituição de 1988 indica algumas competências do Tribunal de Justiça (arts. 96 e 99).

Estatuto e garantias da magistratura estadual. Não há um Estatuto autônomo da Magistratura estadual. A lei complementar, prevista no art. 93, é que vai estabelecer o Estatuto da Magistratura Nacional, e assim também da estadual e da do Distrito Federal e Territórios, às quais se aplicam as regras e princípios já vistos relativamente *ao ingresso e promoção* na carreira, *ao acesso* aos tribunais, *aos vencimentos*, *à aposentadoria*, *remoção* e *disponibilidade*, *aos proventos* da inatividade e *à publicidade* do julgamento e sua motivação, consoante os princípios enunciados nos incisos do art. 93.

Igualmente já examinamos as garantias da magistratura em geral, que se aplicam, evidentemente, ao Poder Judiciário estadual e a seus magistrados, conforme disposto no art. 95.

19. Funções essenciais à Justiça estadual

Ministério Público estadual. Os conceitos fundamentais e os princípios sobre o Ministério Público já foram expostos, o que nos dispensa de retornar a eles aqui. Lembraremos que *lei complementar* de cada Estado, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça, estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto de seus Ministérios Públicos (art. 128, § 5º). Já comentamos antes também as regras sobre o provimento da chefia do Ministério Público dos Estados, suas garantias e vedações comuns a todos os outros, sua independência e autonomia funcional e administrativa e suas funções institucionais, tudo na forma estatuída nos arts. 127 a 130.

Procuradorias e consultorias estaduais. A carreira de Procurador do Estado e do Distrito Federal foi institucionalizada em nível de Constituição Federal. Isso significa a institucionalização dos órgãos estaduais de representação e de consultoria dos Estados, uma vez que os Procuradores, a que se incumbe essa função no art. 132 daquela Carta Magna, não de ser organizados em carreira dentro de uma estru-

tura administrativa unitária em que sejam todos congregados, ressalvado o disposto no art. 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que autoriza os Estados a manter consultorias jurídicas separadas de suas Procuradorias-Gerais ou Advocacias-Gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções (é o caso de Pernambuco).

Essa disposição transitória teve a vantagem de enunciar os órgãos a que, nos Estados e Distrito Federal, incumbem a respectiva representação judicial e serviços de consultoria, quais sejam: *Procuradorias-Gerais* (caso de São Paulo e da maioria dos Estados) ou *Advocacias-Gerais* (caso do Piauí; a Constituição da Paraíba fala em *Advocacia-Geral* do Estado, mas não no sentido orgânica, mas apenas no sentido funcional, de atividade, que é desempenhada institucionalmente pela Procuradoria-Geral do Estado). Então, temos, combinado o disposto no art. 132 e com o art. 69 do ADCT, a institucionalização das Procuradorias-Gerais dos Estados e Advocacias-Gerais, onde houver, sem prejuízo de que cada Estado fique com a liberdade de alterar a denominação, entre aquelas, mas não de mudar suas funções de representação e consultoria, nem a denominação de seus membros: *Procurador do Estado ou do Distrito Federal*, inclusive para o órgão com o nome de *Advocacia-Geral* do Estado.

Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, que receberão remuneração na forma de subsídio, consoante o art. 39, § 4º (EC-19/98), não de ser organizados em carreira, na qual ingressarão por concurso público de provas e títulos (art. 132), com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as suas fases, assegurada a eles a estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias (EC-19/98). É, pois, vedada a admissão ou contratação de advogados para o exercício das funções de representação judicial (salvo, evidentemente, impedimento de todos os Procuradores) e de consultoria daquelas unidades federadas, porque não se deram essas funções aos órgãos, mas foram diretamente imputadas aos Procuradores.

A chefia do órgão é problema de cada Estado e do Distrito Federal. Onde o órgão seja *Advocacia-Geral*, o chefe será coerentemente (e já o é no Piauí) *Advogado-Geral* do Estado (no entanto, seus integrantes no Piauí tem nome não de Advogados do Estado, mas de Procuradores do Estado); onde o nome é *Procuradoria-Geral*, o chefe será, correspondentemente, *Procurador-Geral* do Estado. Então, teremos: *Procurador-Geral* do Estado ou *Advogado-Geral* do Estado igual a chefes dos Procuradores do Estado; *Procurador-Geral* da Justiça igual a chefe do Ministério Público estadual.

Defensorias Públicas estaduais. Os Estados não têm a faculdade de escolher se instituem e mantêm, ou não, a Defensoria Pública. Trata-se de instituição já estabelecida para eles na Constituição Federal, sujeita até mesmo a normas gerais a serem prescritas em lei complementar federal para a sua organização em cada Estado, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes, como vimos (p. 589), a garantia de inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

Não satisfaz aos ditames do art. 134 a simples criação ou manutenção de procuradoria de assistência judiciária, subordinada à Procuradoria-Geral ou à Advocacia-Geral. A Constituição considera a Defensoria Pública uma *instituição essencial à função jurisdicional*, destinada à orientação jurídica e à defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. Se é uma *instituição* e ainda sujeita a *normas gerais* de lei complementar federal já promulgada (LC 80/94), a toda evidência, não pode ser órgão subordinado ou parte de outra instituição, que não ao próprio Estado, com autonomia ou subordinada a uma Secretaria (da Justiça ou da Promoção Social), segundo dispuser lei estadual,¹⁹ até porque a distribuição de seus membros — os Defensores Públicos — deve ser diferente da dos Procuradores do Estado. É de desejar que funcionem junto aos juízes e tribunais com carreira paralela à dos juízes e membros do MP, sendo desnecessária a mesma rigidez, para o adequado cumprimento de sua elevada missão.

IV. CONTEÚDO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

20. Considerações gerais

Uma consideração sobre o possível conteúdo da Constituição Estadual ajudará a compreender os limites do Poder Constituinte Decorrente e a faixa de autonomia dentro da qual pode ser criativo, a fim de dotar o respectivo Estado federado de uma Carta Constitucional que, sem ferir preceitos ou princípios da Constituição Federal,

19. A Lei Complementar 80, de 12.1.1994, entra em pormenores sobre a estrutura das Defensorias Públicas dos Estados e a carreira de Defensores Públicos, de duvidosa constitucionalidade, porque são minúcias para além da configuração de normas gerais. Seja como for, o fato de estabelecer que o Chefe das Defensorias Públicas estaduais é um Defensor Público-Geral, só por si, não lhe dá *status* de Secretaria de Estado e não exclui a possibilidade de seu enquadramento em uma Secretaria. Não caberia à lei federal, complementar ou não, definir essa matéria, porque é assunto da autonomia estadual.

retire desta todo o potencial de organização e de funcionamento que possa enriquecer-lhe a autonomia.

Na Constituição Estadual, podem-se distinguir os mesmos elementos que se notam em qualquer constituição: *elementos limitativos* (ou dogmáticos), *elementos orgânicos* e *elementos sócio-ideológicos*.

21. Elementos limitativos

Os *elementos limitativos* referem-se aos direitos fundamentais do homem: individuais, sociais, de nacionalidade e políticos que escapam à competência dos Estados federados, cabendo-lhes apenas zelar pela sua observância (art. 23, I). Esses direitos e garantias constituem a primeira limitação imposta pela Constituição Federal à autonomia das entidades federadas. Repeti-los no texto da Constituição do Estado não é só uma superfluidade, mas uma impropriedade.²⁰ A Constituição Estadual não tem que tratar dos direitos fundamentais que constam do título II da Constituição Federal. Contudo, como os direitos individuais consubstanciam limites à atuação das autoridades, e nesse sentido a Constituição Federal estabelece o mínimo, a Constituição do Estado pode ampliar a garantia relativamente às suas autoridades, desde que essas restrições não fiquem também dependentes de legislação federal, como, por exemplo, as regras sobre desapropriação (art. 5º, XXIV) ou sobre identificação criminal (art. 5º, LVIII). Os princípios da legalidade e da moralidade administrativa podem ser reforçados pela Constituição do Estado.

Os *direitos sociais* relativos aos trabalhadores não podem ser nem ampliados nem reduzidos pelo Constituinte Estadual, que nessa matéria é absolutamente limitado, como relativamente aos *direitos políticos* e de *nacionalidade*, não lhe cabendo, pois, incluir nada sobre isso na respectiva Constituição Federada.

22. Elementos orgânicos

No referente aos *elementos orgânicos*, as limitações ao Constituinte Estadual não são também pequenas. A primeira está em que terá que aceitar, como vimos, a forma republicana e representativa de governo, a participação direta do cidadão na formação das leis pela iniciativa popular (art. 27, § 4º), o sistema presidencialista unipessoal, o unicameralismo, o sistema eleitoral majoritário em dois turnos para Governador, o sistema de representação proporcional para Deputa-

20. Nesse sentido, para a Federação Mexicana, cf. Felipe Tena Ramírez, *ob. cit.*, p. 136.

dos Estaduais e o mandato de quatro anos com dia de início e término já prefixado (arts. 27 e 28), de tal sorte que sequer pertine a ele cuidar desses assuntos, definidos em definitivo na Constituição Federal.

Ainda no que tange aos *elementos orgânicos*, terá o Constituinte Estadual maior autonomia na organização do Poder Judiciário, estabelecendo os órgãos que melhor atendam aos interesses da Justiça local, mas terá que observar os princípios constitucionais (art. 125). Mas seu tribunal mais alto há que ser o Tribunal de Justiça. Poderá criar ou não Tribunal de Alçada, ou Tribunal de Justiça Militar estadual, mas é obrigado a criar juizados especiais e juízes de paz com os requisitos e atribuições previstos no art. 98, como já dissemos.

Nesse campo ainda, o Constituinte Estadual deverá estabelecer normas para a criação e organização dos Municípios, respeitada a autonomia destes.

23. Elementos sócio-ideológicos

Os *elementos sócio-ideológicos* são regras da ordem econômica e social. Com relação a estas, resta campo que pode ser explorado pela competência do Constituinte Estadual, assim no concernente à política urbana e à política agrícola sobra lugar para que a sua criatividade amplie as possibilidades de desenvolvimento nacional com participação efetiva dos Estados. Especialmente na ordem social, onde a Constituição reservou, na área da competência comum (arts. 23 e 24), espaço em que o Constituinte Estadual poderá favorecer a efetividade da prestação de ações e serviços de saúde, de educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, proteção do meio ambiente etc.

24. Conclusão

Vê-se, de tudo isso, que, embora a Constituição de 1988 tenha ampliado as bases do federalismo, com mais descentralização e autonomia às entidades federadas, ainda assim os seus contornos ficaram razoavelmente dependentes de preceitos e princípios limitadores nela estabelecidos. Resta ao Constituinte Estadual pesquisar nessa seara erigida de dificuldade o caminho mais amplo de sua atuação, enriquecendo o conteúdo da Constituição Estadual e, assim, contribuindo para o aperfeiçoamento de nossas instituições federativas.

Capítulo II

DOS MUNICÍPIOS

I. POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NA FEDERAÇÃO: 1. Fundamentos constitucionais. 2. Município, entidade federada? II. AUTONOMIA MUNICIPAL: 3. Base constitucional da autonomia municipal. 4. Capacidade de auto-organização municipal. 5. Lei Orgânica própria. 6. Competências municipais. III. GOVERNO MUNICIPAL: 7. Poderes municipais. 8. Poder Executivo municipal. 9. Poder Legislativo municipal. 10. Subsídio de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores.

I. POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NA FEDERAÇÃO

1. Fundamentos constitucionais

A Constituição de 1988 modifica profundamente a posição dos Municípios na Federação, porque os considera componentes da estrutura federativa. Realmente, assim o diz em dois momentos. No art. 1º declara que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e *Municípios* e do Distrito Federal. No art. 18 estatui que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os *Municípios*, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Acolhe-se assim a reivindicação de municipalistas clássicos, como Hely Lopes Meirelles e Lordelo de Melo, que pleitearam com insistência e veemência a inclusão dos Municípios no conceito de nossa Federação. Esses autores, aliás, já sustentavam que o Município é peça essencial da nossa Federação, desde a Constituição de 1946, que o erigiu em entidade estatal de terceiro grau, integrante e necessária ao nosso sistema federativo.

Nos termos, pois, da Constituição, o Município brasileiro é entidade estatal integrante da Federação, como entidade político-administrativa, dotada de autonomia política, administrativa e financeira. Essa é uma peculiaridade do Município brasileiro. A inclusão do Município na estrutura da Federação teria que vir acompanhada de consequências, tais como o reconhecimento constitucional de sua capacidade de auto-organização mediante cartas próprias e a ampliação de sua competência, com a liberação de controles que o sistema

até agora vigente lhe impunha, especialmente por via de leis orgânicas estabelecidas pelos Estados.

2. Município, entidade federada?

A característica básica de qualquer Federação está em que o poder governamental se distribui por unidades regionais. Na maioria delas, essa distribuição é dual, formando-se duas órbitas de governo: a central e as regionais (União e Estados federados) sobre o mesmo território e o mesmo povo. Mas, no Brasil, o sistema constitucional eleva os Municípios à categoria de entidades autônomas, isto é, entidades dotadas de organização e governo próprios e competências exclusivas. Com isso, a Federação brasileira adquire peculiaridade, configurando-se, nela, realmente três esferas governamentais: a da *União* (governo federal), a dos *Estados Federados* (governos estaduais) e a dos *Municípios* (governos municipais), além do *Distrito Federal*, a que a Constituição agora conferiu autonomia. E os Municípios transformaram-se mesmo em unidades federadas? A Constituição não o diz. Ao contrário, existem onze ocorrências das expressões *unidade federada* e *unidade da Federação* (no singular ou no plural) referindo-se apenas aos Estados e Distrito Federal, nunca envolvendo os Municípios.¹

II. AUTONOMIA MUNICIPAL

3. Base constitucional da autonomia municipal

A *autonomia municipal* é assegurada pelos arts. 18 e 29, e garantida contra os Estados no art. 34, VII, c, da Constituição. *Autonomia* significa capacidade ou poder de gerir os próprios negócios, dentro de um círculo prefixado por entidade superior. E é a Constituição Federal que se apresenta como poder distribuidor de competências exclusivas entre as três esferas de governo (já vimos isso). As Constituições até agora outorgavam aos Municípios só *governo próprio* e a *competência exclusiva*, que correspondem ao mínimo para que uma entidade territorial tenha autonomia constitucional.

Agora foi-lhes reconhecido o poder de *auto-organização*, ao lado do *governo próprio* e de *competências exclusivas*, e ainda com ampliação destas, de sorte que a Constituição criou verdadeiramente uma nova instituição municipal no Brasil. Por outro lado, não há mais qualquer hipótese de prefeitos nomeados. Tornou-se plena, pois, a capacidade de autogoverno municipal entre nós.

1. Cf. arts. 34, II, IV e V, 45, § 1º, 60, III, 85, II, 132, 159, § 2º, 225, § 1º, III; ADCT, arts. 13, § 4º, e 32, § 9º.

A autonomia municipal, assim, assenta em quatro capacidades:

(a) *capacidade de auto-organização*, mediante a elaboração de lei orgânica própria;

(b) *capacidade de autogoverno*, pela eletividade do Prefeito e dos Vereadores às respectivas Câmaras Municipais;

(c) *capacidade normativa própria*, ou capacidade de autolegislação, mediante a competência de elaboração de leis municipais sobre áreas que são reservadas à sua competência exclusiva e suplementar;

(d) *capacidade de auto-administração* (administração própria, para manter e prestar os serviços de interesse local).

Nessas quatro capacidades, encontram-se caracterizadas a *autonomia política* (capacidades de auto-organização e de autogoverno), a *autonomia normativa* (capacidade de fazer leis próprias sobre matéria de sua competência), a *autonomia administrativa* (administração própria e organização dos serviços locais) e a *autonomia financeira* (capacidade de decretação de seus tributos e aplicação de suas rendas, que é uma característica da auto-administração).

A autonomia, que a Constituição de 1988 outorga ao Município, contém uma qualificação especial que lhe dá um conteúdo político de extrema importância para a definição de seus *status* na organização do Estado brasileiro, inteiramente desconhecido no regime anterior. Antes, o reconhecimento da autonomia municipal tinha um sentido remissivo. Quer dizer, a Constituição remetia aos Estados o poder de criar e organizar seus Municípios. O dito sentido remissivo consistia em determinar aos Estados que, ao organizarem seus Municípios, lhes assegurassem a autonomia, mas apenas quanto às capacidades de auto-administração, autolegislação e autogoverno. Ao fazê-lo, os Estados haviam de respeitar a autonomia assegurada na Constituição Federal em termos genéricos relativos ao peculiar interesse local.

Veja-se a diferença fundamental da outorga da autonomia municipal: as normas constitucionais anteriores sobre ela se dirigiam aos Estados-membros, porque estes é que deveriam organizá-los, assegurando-a, mas, aí, se reservavam a eles poderes sobre os Municípios, que agora já não têm: o poder de organizá-los, de definir suas competências, a estrutura e competência do governo local e os respectivos limites. Agora não, as normas constitucionais instituidoras da autonomia dirigem-se diretamente aos Municípios, a partir da Constituição Federal, que lhes dá o poder de auto-organização e o conteúdo básico de suas leis orgânicas e de suas competências exclusivas, comuns e suplementares (arts. 23, 29, 30 e 182).

Isso significa que a ingerência dos Estados nos assuntos municipais ficou limitada aos aspectos estritamente indicados na Constitui-

ção Federal, como, por exemplo, os referentes à criação, incorporação, fusão e ao desmembramento de Municípios (art. 18, § 4º) e à intervenção (arts. 35 e 36).

4. Capacidade de auto-organização municipal

Os Municípios eram até agora criados e organizados pelos Estados conforme leis orgânicas de competência estadual. Só no Rio Grande do Sul, cada Município sempre teve sua própria lei orgânica, elaborada pela respectiva Câmara Municipal. Mais recentemente Curitiba e Salvador poderiam ter leis orgânicas próprias. Mas isso era exceção.

Pois bem, o art. 29 da Constituição estatui que o *Município se regerá por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado.*

5. Lei Orgânica própria

Em que consiste a *Lei Orgânica própria*? Qual o seu conteúdo?

Ela é uma espécie de constituição municipal. Cuidará de discriminar a matéria de competência exclusiva do Município, observadas as peculiaridades locais, bem como a competência comum que a Constituição lhe reserva juntamente com a União, os Estados e o Distrito Federal (art 23). Indicará, dentre a matéria de sua competência, aquela que lhe cabe legislar com exclusividade e a que lhe seja reservado legislar supletivamente.

A própria Constituição já indicou o *conteúdo básico da Lei Orgânica*, que terá que compreender, além das regras de eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, normas sobre (art. 29):

- (a) a posse do Prefeito e dos Vereadores e seus compromissos;
- (b) inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na circunscrição do Município;
- (c) proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto na Constituição Federal para os membros do Congresso Nacional e, na Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembléia Legislativa;
- (d) organização das funções legislativa e fiscalizadora da Câmara Municipal;
- (e) cooperação das associações representativas de bairro com o planejamento municipal;

(f) iniciativa legislativa popular sobre matéria de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através da manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

(g) perda do mandato do Prefeito, incluindo como uma de suas causas o fato de ele assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.

Certa "incisomania", na redação da Constituição, levou o constituinte a incluir como inciso do art. 29 matérias que não podem constituir conteúdo da Lei Orgânica municipal, porque não se trata de assunto de sua competência, tais como as referentes a definição de eleições, duração de mandato, pleito direto e simultâneo em todo o País (como que Município pode tratar disso?), época das eleições e princípio da maioria absoluta (dois turnos), número de Vereadores, referindo-se a mínimos e máximos na generalidade dos Municípios (como se isso pudesse ser objeto da Lei Orgânica), e até o privilégio de foro do Tribunal de Justiça, para julgamento do Prefeito. Enfim, toda a matéria constante dos incs. I, II, IV e VIII do art. 29 é de competência do constituinte nacional. Constituíam artigos, mas a preocupação em fazer a Constituição parecer com menor número de artigos, embora com a mesma quantidade de matéria, levou a Relatoria a transformá-los em incisos, inadequadamente, com sérios prejuízos para o bom entendimento do texto. A Lei Orgânica pode até repetir essa matéria, inutilmente.

6. Competências municipais

O art. 30 da Constituição já discrimina as bases da competência dos Municípios, tais como: (1) legislar sobre assuntos de interesse local, que consubstancia a área de competência legislativa exclusiva, incluindo aí, por conseguinte, a legislação tributária e financeira; (2) suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; aí, certamente, competirá aos Municípios legislar supletivamente sobre: (a) proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; (b) responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico local; (c) educação, cultura, ensino e saúde no que tange à prestação desses serviços no âmbito local; (d) direito urbanístico local etc.; (3) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; (4) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; (5) organizar e prestar diretamente ou sob regime de con-

cessão ou permissão os serviços públicos de interesse local; (6) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental; (7) prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, serviços de atendimento à saúde da população; (8) promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano; aliás, o plano urbanístico (plano diretor) será obrigatório para os Municípios com mais de vinte mil habitantes (art. 182, § 1º); (9) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Acrescente-se a isso sua competência exclusiva: (a) em matéria administrativa, para ordenar sua Administração, como melhor lhe parecer; (b) em matéria financeira, para organizar suas finanças, elaborar sua lei de diretrizes orçamentárias, sua lei orçamentária anual e sua lei do plano plurianual; (c) para instituir seus tributos nos termos dos arts. 145 e 156. Além disso, estão previstas, no art. 23, áreas de *competência comum* com a União e os Estados, que já indicamos ao tratar da competência da União, sendo desnecessário repetir a enumeração aqui.

Enfim, os Municípios poderão manter guardas municipais destinadas à proteção das instalações e dos serviços municipais (art. 144, § 8º). É mera faculdade. Não serão obrigados a manter tais guardas.

III. GOVERNO MUNICIPAL

7. Poderes municipais

O *governo municipal* é, como todos sabem, constituído só de Poder Executivo, exercido pelo *Prefeito*, e de Poder Legislativo, exercido pela *Câmara Municipal*. Os Municípios não têm e continuarão a não ter órgão jurisdicional próprio. O Poder Judiciário que atua nos Municípios (constituídos em comarca) é o estadual. Aos Municípios, pois, só foram atribuídas duas funções governamentais básicas: a *função legislativa* e a *função executiva*, no que tange à matéria de sua competência. *Legislação* e *Administração* constituem as funções fundamentais que integram a competência municipal. A primeira exercida pela Câmara Municipal, composta de Vereadores representantes dos munícipes; a segunda compreende as atribuições do Prefeito.

8. Poder Executivo municipal

Prefeito. Este é o chefe do Poder Executivo e chefe da administração local. Caberá à Lei Orgânica de cada Município discriminar as funções do Prefeito, que, *grosso modo*, se distinguem em *funções de*

governo e funções administrativas. As primeiras compreendem as *funções políticas*, tais como: representação do Município, direção geral dos negócios municipais, relações com outras autoridades; as *funções co-legislativas*, como: sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, vetar projetos de lei, enviar mensagens à Câmara sobre a situação do Município; e as *funções executivas estrito senso*, como a fixação de diretrizes do governo municipal, o planejamento da administração local, a direção dos negócios municipais etc. As segundas — as funções administrativas do Prefeito — absorvem grande parte de sua atividade. Dentre elas sobrepõem a execução das leis, pondo em movimento a máquina administrativa, a nomeação e exoneração de seus auxiliares, o provimento de cargos públicos municipais, a expedição de atos referentes à vida funcional dos servidores locais, a arrecadação e guarda das rendas municipais, tomando providências sobre sua aplicação, autorizando pagamentos; a gestão do patrimônio e bens municipais, enfim, supervisionando todos os serviços locais, executando obras públicas reclamadas pelo desenvolvimento da comunidade local.

É evidente que o Prefeito não realiza, por si, diretamente todas essas funções administrativas, que se subordinam à sua direção, que envolve, como vimos, comando, coordenação e controle de sua parte, sendo-lhe possível delegar certos atos de sua competência a auxiliares de sua confiança, consoante poderá prever a Lei Orgânica de seu Município.

Eleição. O Prefeito e o Vice-Prefeito (como os Vereadores) serão eleitos no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, para mandato de quatro anos, e tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente, aplicadas as regras do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores (art. 29, I e II). Quer dizer: nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores, a eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito atenderá o princípio da maioria absoluta; se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta na primeira votação, renovar-se-á a eleição no último domingo do mesmo mês de outubro em que se realizou a primeira votação, concorrendo ao segundo escrutínio somente os dois candidatos mais votados no primeiro, considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Se houver desistência de um dos dois candidatos mais votados, sua substituição caberá ao terceiro, e assim sucessivamente. Nos Municípios com menos de duzentos mil eleitores, será eleito o candidato que tiver a maior votação independentemente de ser ou não maioria absoluta.

Substitutos. Com o Prefeito é eleito um Vice-Prefeito ao qual cabe substituí-lo no caso de impedimentos ocasionais e sucedê-lo no caso

de vaga. Cabe à Lei Orgânica estatuir sobre os substitutos eventuais do Prefeito, quando ele e o Vice estiverem, concomitantemente, impedidos, bem como estabelecer regras sobre quem assumirá a Prefeitura na hipótese de vacância de ambos os cargos. O normal é atribuir ao Presidente da Câmara Municipal a competência para essas atribuições, mas não é raro ocorrer impedimento também do Presidente da Câmara, pelo que a Lei Orgânica deverá indicar quem responde pela Prefeitura; em tal caso, tem sido atribuída essa incumbência ao Secretário dos Negócios (ou Assuntos) Jurídicos, onde houver, ou ao Secretário da Prefeitura nas estruturas municipais mais simples. Cada Lei Orgânica disporá segundo a realidade local.

9. Poder Legislativo municipal

Funções da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, que é o órgão do Poder Legislativo local, deverá ter também suas atribuições discriminadas pela lei orgânica do respectivo Município, as quais se desdobram em quatro grupos:

(1) a *função legislativa*, que é exercida com a participação do Prefeito. No exercício dessa função é que ela legisla sobre as matérias de competência do Município. Por meio dela se estabelecem, como todos sabem, as leis municipais, e se cumpre, no âmbito local, o princípio da legalidade a que se submete a Administração. A lei orgânica do Município deverá indicar as matérias de competência legislativa da Câmara. Deverá também estabelecer o processo legislativo das leis em geral assim como do orçamento;

(2) a *função meramente deliberativa*, por meio da qual a Câmara exerce atribuições de sua competência privativa que envolvem a prática de atos concretos, de resoluções referendárias, de aprovação, de autorização, de fixação de situações, de julgamento técnico, que independem de sanção do Prefeito, as quais também deverão ser indicadas pela lei orgânica própria;

(3) a *função fiscalizadora*, de grande relevância, tanto que é prevista na Constituição, que declara que a fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios, onde houver (art. 31), e ainda acrescenta (art. 31, § 3º) que as contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição dos contribuintes, para exame e apreciação, e qualquer cidadão poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Mas a atividade fiscalizadora da Câmara efetiva-se mediante vários mecanismos, tais como pedido de informações ao Prefeito, convocação de auxiliares diretos deste, investigação mediante comissão especial de inquérito,

tomada e julgamento das contas do Prefeito, observando-se que só por voto de dois terços de seus membros pode ela rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas competente;

(4) a *função julgadora*, pela qual a Câmara exerce um juízo político, quando lhe cabe julgar o Prefeito e os Vereadores por infrações político-administrativas.

A essa podemos ainda acrescentar outra, que é o exercício do *poder organizativo municipal*, pois a Lei Orgânica própria terá que estabelecer regras para ser emendada, atribuindo à Câmara competência para tanto. Com isso também, como se vê, a Lei Orgânica própria assume uma característica de certa rigidez, pois como só pode ser elaborada com o voto de dois terços da Câmara, só poderá, igualmente, ser alterada com igual *quorum*. Assim as leis locais que a contrariarem serão ilegítimas e inválidas, desde que assim sejam declaradas pelo Judiciário.

Composição. A Câmara compõe-se de Vereadores, cujo número será fixado pela Constituição do respectivo Estado, proporcionalmente à população do Município, sendo o mínimo de 9 e o máximo de 21 nos Municípios de até 1 milhão de habitantes; o mínimo de 33 e o máximo de 41 nos Municípios de até 5 milhões de habitantes, e o mínimo de 42 e o máximo de 55 nos Municípios de mais de 5 milhões de habitantes.

O mandato do Vereador terá, como hoje, a duração de quatro anos.

Inviolabilidade dos Vereadores. Estabelece-se expressamente a *inviolabilidade* dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na circunscrição do Município. A *inviolabilidade*, como se sabe, significa que o beneficiado fica isento da incidência de norma penal definidora de crime. Vale dizer que, dentro da circunscrição do Município, o Vereador não comete crime de opinião. É claro, se não o comete, não poderá ser processado por aquelas ações. Contudo, não se previu a *imunidade processual* dos Vereadores em relação a outras infrações penais. Logo, se cometer qualquer crime, ficará sujeito ao respectivo processo, independentemente de autorização de sua Câmara.

10. Subsídios de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores

Finalmente, Prefeitos Vice-Prefeitos e Vereadores (e Secretários Municipais) têm direito a remuneração, em forma de *subsídios*, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição (EC-19/98) sujeita aos impostos gerais, inclusive o de renda e os extraordinários, tal como qualquer outro contribuinte, com observância do que dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e § 2º, I. O subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito será fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Assim também estava previsto para o subsídio dos Vereadores por força da EC-19/98.

Contudo, a EC-25, de 14.2.2000² alterou essa disposição para determinar que o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmara Municipais (não mais por lei de iniciativa da Câmara) em cada legislatura para a subsequente, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; em Município de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, essa proporção será de trinta por cento; em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, a proporção será de quarenta por cento; em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, a proporção será de cinquenta por cento; em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil, a proporção será sessenta por cento; em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, a proporção será de setenta e cinco por cento.

A mesma EC-25/2000 acrescentou à Constituição o art. 29-A para estabelecer que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: I - oito por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes; II - sete por cento para Municípios com população entre cem mil e um e trezentos mil habitantes; III - seis por cento para Municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes; IV - cinco por cento para Municípios com população acima de quinhentos mil habitantes, observando-se ainda que a Câmara Municipal não poderá gastar mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. O descumprimento desses limites constitui crime de responsabilidade imputável ao Presidente da Câmara. E o Prefeito, por seu lado, incorrerá em crime de responsabilidade se efetuar repasse que supere esses limites, assim como se não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês, ou envia-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária.

Como se está notando, minúcias de lei ordinária absolutamente inadequadas numa Constituição, por mais analítica que ela seja.

Capítulo III

DO DISTRITO FEDERAL

I. PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS: 1. Natureza. 2. Autonomia. 3. Auto-organização. 4. Competências. II. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL: 5. Poder Legislativo. 6. Poder Executivo. 7. Poder Judiciário. 8. Funções essenciais à Justiça no Distrito Federal.

I. PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS

1. Natureza

O Distrito Federal surgiu da transformação do antigo Município neutro, que era a sede da corte e capital do Império. A Constituição nos arts. 1º e 18 o inclui como um dos componentes da República Federativa do Brasil, considerado sempre como *unidade federada* ou *unidade da Federação*, onde essas expressões foram usadas.

Não é Estado. Não é Município. Em certo aspecto, é mais do que o Estado, porque lhe cabem competências legislativas e tributárias reservadas aos Estados e Municípios (arts. 32, § 1º, e 147). Sob outros aspectos, é menos do que os Estados, porque algumas de suas instituições fundamentais são tuteladas pela União (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia). É nele que se situa a Capital Federal (Brasília). Tem, pois, como *função* primeira servir de sede ao governo federal. Agora, goza de autonomia político-constitucional, logo não pode mais ser considerado simples autarquia territorial, como o entendíamos no regime constitucional anterior. Parece que basta concebê-lo como uma *unidade federada* com autonomia parcialmente tutelada.

2. Autonomia

A autonomia do Distrito Federal está, em termos, reconhecida no art. 32, onde se declara que se regerá por Lei Orgânica própria (n. 3, *infra*), como nos Municípios. O § 1º do citado artigo prevê as áreas de competência do Distrito Federal, enquanto os §§ 2º e 3º definem as regras de eleição do Governador, Vice-Governador e Deputados Distritais. Aí temos a base de uma autonomia que compreende, em prin-

2. O art. 3º dessa EC-25/00 dispôs que ela entrará em vigor em 1º de janeiro de 2001.

cípio, as capacidades de *auto-organização*, *autogoverno*, *autolegislação* e *auto-administração* sobre áreas de competência exclusiva.

Contudo, essas capacidades sofrem profundas limitações em questões fundamentais. Assim é que as capacidades de auto-organização e autogoverno não envolvem a organização e manutenção de Poder Judiciário, nem de Ministério Público, nem de Defensoria Pública, nem mesmo de polícia civil ou militar ou de corpo de bombeiros, que são organizados e mantidos pela União (art. 21, XIII e XIV), a quem cabe também legislar sobre a matéria. O governo do Distrito Federal não tem sequer a autonomia de utilização das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar, porque só poderá fazê-lo nos limites e na forma que dispuser a lei federal (art. 32, § 4º). Nesse aspecto é que dissemos que a autonomia do Distrito Federal é tutelada. Nisso ele fica muito aquém dos Estados.

3. Auto-organização

A capacidade de auto-organização do Distrito Federal efetiva-se mediante a elaboração de sua Lei Orgânica, a ser votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e se considerará aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição (art. 32). Essa Lei Orgânica definirá os princípios básicos da organização dessa unidade federada, suas competências e a organização de seus Poderes governamentais, em situação muito semelhante ao que se passa nos Municípios.

4. Competências

Ao Distrito Federal, como lembramos acima, são atribuídas as competências tributárias e legislativas que são reservadas aos Estados e Municípios (arts. 32, § 1º, 147 e 155). Isso quer dizer que ele dispõe de uma área de competências remanescentes correspondente aos Estados, segundo o art. 25, § 1º, assim também lhe cabe explorar diretamente, ou mediante concessão a empresas distritais, com exclusividade de distribuição, os serviços locais de gás canalizado (art. 25, § 2º). Competem-lhe as matérias relacionadas no art. 30, como de competência municipal, assim como instituir os tributos dos arts. 145, 155 e 156, e participar das receitas referidas nos arts. 157, 159, I, *a* e *c* (pois, pertence ao Centro-Oeste), e II. Mas está vedado a ele dividir-se em Municípios (art. 32).

Cumpre, entretanto, observar que nem tudo que cabe aos Estados foi efetivamente atribuído à competência do Distrito Federal.

Determinadas situações foram subtraídas de sua competência legislativa, embora sejam hipóteses de competência estadual, como legislar sobre a organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública no Distrito Federal, entregues à competência da União (art. 22, XVII).

II. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

5. Poder Legislativo

A *Câmara Legislativa* é o órgão que exerce o Poder Legislativo do Distrito Federal, com o que este adquire autonomia legislativa (autolegislação), de que carecia no regime constitucional anterior, quando era o Senado Federal que legislava para ele.

A *Câmara Legislativa* compõe-se de *Deputados Distritais* em número que corresponda ao triplo de sua representação na Câmara dos Deputados. Como esta é de oito, são vinte e quatro os integrantes do Legislativo distrital, representantes do povo daquela unidade federada, eleitos pelo sistema proporcional, para um mandato de quatro anos, aplicando-se-lhes as regras da Constituição, referidas aos congressistas, *mutatis mutandis* (arts. 53, 54 e 55), sobre inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas (art. 32, § 3º, *c/c* o art. 27).

6. Poder Executivo

O *Governador*. O Poder Executivo do Distrito Federal é exercido, como nos Estados, por Governador, que será eleito na mesma época em que são eleitos os Governadores dos Estados. Sua eleição, para um mandato de quatro anos, se realizará, pois, em primeiro turno, no primeiro domingo de outubro e, em segundo turno, se houver, no último domingo de outubro, do ano anterior ao término do mandato do que deva suceder, tomando posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente, e obedece ao princípio da maioria absoluta, tal como a eleição do Presidente da República, porque se lhe aplica o disposto no art. 77.

Substitutos do Governador. Com o Governador, elege-se o Vice-Governador, que, como acontece nos Estados, o substitui nos impedimentos ocasionais e o sucede no caso de vacância. Não cabe à Constituição Federal indicar os substitutos eventuais do Governador do Distrito Federal, do mesmo modo que não o faz em relação aos Governadores estaduais. A Lei Orgânica do Distrito Federal é que definirá quem assume o cargo na hipótese de impedimentos ou de vacância dos cargos de Governador e de Vice-Governador.

Nos Estados, a técnica das substituições eventuais, no caso de impedimento do Governador e do Vice ou na hipótese de vacância de ambos os cargos, consiste em se estabelecer, na Constituição estadual, que serão chamados sucessivamente ao exercício do cargo o Presidente da Assembléia e o Presidente do Tribunal de Justiça. Essa solução não pode ser inteiramente acolhida no Distrito Federal. Será lógico prever que o Presidente da Câmara Legislativa o faça até que se realize eleição popular para o provimento dos cargos vagos, conforme a época da vacância (três primeiros anos do mandato, como comumente ocorre nos Estados) e, se esta se der no último ano, qual o procedimento a ser adotado: ele próprio completa o período ou se faz eleição pela Câmara Legislativa para que o eleito o complete. Mas não cabe outorgar ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal essa prerrogativa pela simples razão, adiante referida, de que esse Tribunal não integra a estrutura do Poder governamental do Distrito Federal. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por um lado, não tem poder para definir competência, faculdade ou prerrogativa do Poder Judiciário, que não pertence àquela unidade da Federação, nem de seus membros e, por outro lado, não será adequado conferir a função de Governador de uma unidade autônoma a uma autoridade de fora de sua própria organização.

7. Poder Judiciário

É como acabamos de dizer: o Poder Judiciário *no* Distrito Federal, em verdade, não é dele, pois, nos termos do art. 21, XIII, compete à União *organizar e manter* o Poder Judiciário *do* Distrito Federal; “do” no texto constitucional não indica uma relação de pertinência, mas de simples localização, significando aquele que atua no território da unidade federada. Se é à União que cabe organizar e manter, isso significa que o órgão é dela, embora destinado ao Distrito Federal. Nesse particular, a autonomia deste ficou razoavelmente diminuída, como já observamos antes, uma vez que o Poder Judiciário que nele atua continuará na mesma situação do regime constitucional anterior, tanto que está igualmente previsto que é da competência da União legislar sobre a organização judiciária do Distrito Federal, como dissemos supra (art. 22, XVII).

Por isso também é que o art. 98 estatui que a União criará, no Distrito Federal, os juizados especiais e a justiça de paz nele configurados.

No mais, aplicam-se ao Poder Judiciário do Distrito Federal a mesma disciplina estatutária, as mesmas garantias e vedações que já examinamos em relação ao Poder Judiciário em geral, constantes dos

arts. 93 a 99, tendo o Tribunal de Justiça (expressamente mencionado no art. 105, I, *a*) e juízes de primeiro grau, na forma da lei de organização judiciária, que também poderá instituir Tribunal de Alçada e outros tribunais inferiores.

8. Funções essenciais à Justiça no Distrito Federal

Constituem-se, como nos Estados, do Ministério Público do (no) Distrito Federal, da Defensoria Pública do (no) Distrito Federal e da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. As duas primeiras instituições são também organizadas e mantidas pela União no Distrito Federal (art. 21, XIII). Não são dele, portanto. Por isso é que também, como dissemos, cabe à União legislar sobre sua organização (art. 22, XVII). Consequentemente, o art. 128 insere o Ministério Público do Distrito Federal no Ministério Público da União, e o parágrafo único do art. 134 declara que lei complementar (federal) organizará a Defensoria Pública do Distrito Federal, que é a Lei Complementar 80/94, como já vimos (p. 589).

Já a representação judicial e a consultoria jurídica do Distrito Federal serão exercidas por Procuradores do Distrito Federal, organizados em carreira na qual ingressarão por concurso público de provas e títulos (art. 132).

Título IV

Da Administração Pública

Capítulo I

ESTRUTURAS BÁSICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

I. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: 1. Noção de Administração. 2. Organização da Administração. 3. Administração direta, indireta e fundacional. II. ÓRGÃOS SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL: 4. Natureza e posição. 5. Os Ministros no parlamentarismo e no presidencialismo. 6. Atribuições dos Ministros. 7. Condições de investidura no cargo. 8. Responsabilidade dos Ministros. 9. Juízo competente para processar e julgar os Ministros. 10. Os Ministérios. III. CONSELHOS: 11. Generalidades. 12. Conselho da República. 13. Conselho de Defesa Nacional. 14. Conselho de Comunicação Social. IV. ÓRGÃOS SUPERIORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 15. Organização administrativa de Estados e Municípios. 16. Secretários de Estado. 17. Órgãos superiores municipais. V. REGIÕES: 18. Regiões e microrregiões. 19. Organismos regionais. 20. Regionalização orçamentária. 21. Regiões metropolitanas.

I. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1. Noção de Administração

O leitor deve estar lembrado de que, algures, escrevemos que o Estado se manifesta por seus *órgãos*, que são *supremos* (constitucionais) ou *dependentes* (administrativos). Aqueles são os a quem incumbe o exercício do poder político, cujo conjunto se denomina *governo* ou *órgãos governamentais*. Os outros estão em plano hierárquico inferior, cujo conjunto forma a Administração Pública.¹ Esta encontra suas bases, agora mais desenvolvidas, na Constituição, quer quando estrutura o Poder Executivo, referido às várias esferas de governo, quer quando, nos arts. 37 a 43, define os fundamentos de sua organização, os seus princípios e o regime do pessoal administrativo civil e militar.

1. Cf. n. 9 do cap. II do tit. II da Primeira Parte. Cf. também V. E. Orlando, *Principios de derecho administrativo*, p. 35; Renato Alessi, *Principi di diritto amministrativo*, v. I/78, Milano, Giuffrè, 1978.

Administração Pública é o conjunto de meios institucionais, materiais, financeiros e humanos preordenados à execução das decisões políticas. Essa é uma noção simples de Administração Pública que destaca, em primeiro lugar, que é subordinada ao Poder político;² em segundo lugar, que é meio e, portanto, algo de que se serve para atingir fins definidos e, em terceiro lugar, denota os seus dois aspectos: um conjunto de órgãos a serviço do Poder político e as operações, as atividades administrativas.

O art. 37 da Constituição emprega a expressão *Administração Pública* nos dois sentidos. Como conjunto orgânico, ao falar em Administração Pública *direta* e *indireta* de qualquer dos Poderes da *União*, dos *Estados*, do *Distrito Federal* e dos *Municípios*. Como atividade administrativa, quando determina sua submissão aos princípios de *legalidade*, *impeccabilidade*, *moralidade*, *publicidade*, *eficiência*, da *licitação* e os de *organização do pessoal administrativo*. Aqui vamos cuidar do primeiro aspecto, relativo à organização da Administração. O outro será objeto de consideração nos próximos capítulos.

2. Organização da Administração

A *organização administrativa* no Estado Federal é complexa, porque a função administrativa é institucionalmente imputada a diversas entidades governamentais autônomas, que, no caso brasileiro, estão expressamente referidas no próprio art. 37, de onde decorre a existência de várias Administrações Públicas: a federal (da União), a de cada Estado (Administração estadual), a do Distrito Federal e a de cada Município (Administração municipal ou local), cada qual submetida a um Poder político próprio, expresso por uma organização governamental autônoma.

3. Administração direta, indireta e fundacional

A complexidade aumenta se nos lembrarmos que cada qual dessas Administrações pode descentralizar-se, de onde a formação, de um lado, de *administração centralizada*, como conjunto de órgãos administrativos subordinados diretamente ao Poder Executivo de cada

2. Cf. Charles Debbasch, *Institutions administratives*, pp. 10-12; Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, p. 61, para quem, no sentido do texto, a "Administração é o instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do Governo"; Jean-Marie Aubry e Robert Ducos-Ader, *Institutions administratives*, Paris, Dalloz, 1996, p. 2: "A Administração é o conjunto dos organismos que, sob a autoridade do Governo, são destinados a assegurar as múltiplas tarefas de interesse geral, que incumbem ao Estado".

uma daquelas esferas governamentais autônomas — chamada, por isso, *Administração direta* —, e, de outro lado, de *administração descentralizada*, como órgãos integrados nas muitas entidades personalizadas de prestação de serviços ou exploração de atividades econômicas, vinculadas a cada um dos Poderes Executivos daquelas mesmas esferas governamentais — dita, por isso, *Administração indireta*, e ainda a *fundacional*.

A Constituição considera entidades da administração indireta as *autarquias*, as *empresas públicas* e as *sociedades de economia mista*; não assim as *fundações* instituídas pelo Poder Público, pois sempre menciona estas especificadamente quando usa a expressão administração indireta. *Entidade fundacional* ou *administração fundacional* são expressões sinônimas de fundação instituída pelo Poder Público. Numa das vezes, a Constituição emprega a expressão *fundação pública* ou *fundações públicas*. Na maior parte das vezes, contudo, emprega a expressão *fundações instituídas e mantidas* pelo Poder Público.³ Parece-nos, porém, que essas expressões são empregadas no mesmo sentido, tendo, assim, como fundações públicas aquelas instituídas e mantidas pelo Poder Público.

A regra que a Constituição estabelece é a de que *somente* por lei específica poderá ser *criada* autarquia e *autorizada* a instituição de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de fundações, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Assim se exprime o art. 37, XIX, com o novo enunciado oferecido pela EC-19/98. É de se observar: (a) o novo texto corrige o anterior, no sentido de que a lei *cria* autarquia, mas apenas *autoriza* o Poder Executivo a criar empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações; (b) não fala mais, como antes, em fundação pública, mas apenas em *fundações* e, agora, sem nenhuma dúvida, o termo envolve a idéia e todas as hipóteses de fundação instituída e mantida pelo Poder Público, já que se diz que a lei *autoriza a instituição delas*. A questão que sempre fica é a de saber se são ou não fundações públicas. São fundações instituídas pelo Poder Público, e, assim, são de caráter público. A cláusula “neste último” refere-se, ao que nos parece, apenas às fundações, valendo dizer que só em relação a elas a lei complementar referida vai definir a área de atuação. Isso porque, no respeitante às empresas públicas e sociedades de economia mista, o regime jurídico é definido no art. 173, onde se exige simples lei ordinária.

3. Cf. arts. 37, XVII e XIX (fundação); 39, § 7º; 40; 71, II e III; 150, VI, c e § 2º; 157, I; 158, I; 163 (fundação); 165, § 5º, I e III; 167, VIII; 169, § 1º; 202, §§ 3º e 4º. ADCT, arts. 8º, § 5º; 18; 19 (públicas); 35, § 1º, V; 64; 72, I.

Diz o art. 37, XX, que “depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada”. O inciso anterior menciona autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações, mas deve-se entender *subsidiárias* apenas de empresas públicas e de sociedades de economia mista, porque não é próprio de autarquia e fundações terem subsidiárias.

As empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias são as entidades de administração indireta pelas quais o Poder Público explora atividade econômica. Elas podem também ser utilizadas para a prestação de serviços públicos. Mas a exploração de atividade econômica pelo Poder Público (federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal) somente poderá realizar-se por essas entidades, por força do disposto no art. 173, § 1º, ficando elas, nesse caso, sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, e não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, evidentemente do mesmo ramo de negócio.

II. ÓRGÃOS SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

4. Natureza e posição

O Presidente da República, como vimos, exerce o Poder Executivo, entre cujas atribuições se acham as de natureza administrativa, para o cumprimento de seus fins governamentais. O art. 84, II, declara competir privativamente a ele “exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal”.

Os Ministros estão, assim, na cúpula da organização administrativa federal, fazendo como que a ligação entre o Poder político e a Administração Pública federal.

5. Os Ministros no parlamentarismo e no presidencialismo

A Constituição, como se recorda, consagra o sistema de governo presidencialista, mantendo, com algumas peculiaridades (comparecimento de Ministros ao Congresso Nacional), a orientação da primeira Lei Fundamental da República, que fora buscar o modelo na Carta Magna norte-americana. Essa decisão repercute fundamentalmente nas funções dos Ministros de Estado.

No parlamentarismo, estes, capitaneados pelo Primeiro Ministro (ou Presidente do Conselho de Ministros), é que exercem efetiva-

mente as funções de governo, enquanto, no presidencialismo, não passam de simples auxiliares do Presidente da República na condução dos assuntos do Poder Executivo e especialmente na direção superior da administração (arts. 76, 84, II, e 87).

6. Atribuições dos Ministros

Cada um deles dirige uma grande estrutura da administração federal, que se chama *Ministério*. Cabem-lhes, além de outras atribuições estabelecidas na Constituição e na lei: (1) a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República; (2) expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; (3) apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério; (4) praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.

O referendo ministerial, que é de pouca significação no presidencialismo, consiste na subscrição das leis, medidas provisórias e decretos do Chefe do Executivo que dizem respeito à sua pasta. Não interfere na validade do ato, mas empenha a responsabilidade do Ministro conexas com a do Presidente da República. Se referenda, ou não, é tema de seu relacionamento com o Presidente da República, sendo de praxe mesmo ordenar a publicação dos atos e só colher a assinatura dos Ministros que devam subscrevê-los após. Se ele não assinar, nem por isso o ato deixa de valer e ter eficácia. O máximo que pode acontecer e deve acontecer é que a discordância do Ministro implique sua exoneração, a pedido ou não.

7. Condições de investidura no cargo

São requisitos essenciais para que alguém seja investido no cargo de Ministro de Estado: (1) ser brasileiro (nato ou naturalizado, porque não é mais exigência que seja nato, como foi até agora); (2) ser maior de vinte e um anos de idade; (3) estar no exercício de seus direitos políticos (art. 87).

O cargo é de provimento em comissão e, conseqüentemente, de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da República (art. 84, I), de quem há de merecer confiança (à parte injunções políticas), ao contrário do sistema parlamentarista em que os Ministros (já o dissemos) dependem da confiança do Parlamento e devem exonerar-se, isolada ou coletivamente, quando ela lhes é retirada.

8. Responsabilidade dos Ministros

São crimes de responsabilidade dos Ministros: (1) falta de comparecimento, sem justificação adequada, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal ou a qualquer de suas Comissões, quando convocados para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado (arts. 50 e 58, III); (2) a prática, conjuntamente com o Presidente da República, de atos definidos como crime de responsabilidade (arts. 52, I, e 85).

9. Juízo competente para processar e julgar os Ministros

Os Ministros são processados e julgados: (1) pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns e nos de responsabilidade que cometerem sozinhos (art. 102, I, c); (2) pelo Senado Federal, após autorização do processo pela Câmara dos Deputados, em processo e julgamento idênticos aos do Presidente da República, nos crimes de responsabilidade (arts. 51, I, 52, I, parágrafo único, 85 e 86).

10. Os Ministérios

Os Ministérios são criados e estruturados por lei, que também disporá sobre suas atribuições (art. 88). Portanto, não se lhes aplica a disposição do art. 84, VI, pois a lei referida no art. 88 não se limita a dar a forma para sua criação, estrutura e atribuições. É ela própria que o faz.

São eles agrupados por objetivos a serem atingidos pela ação governamental nos setores político, econômico, social e militar. De acordo com a Lei 10.683, de 28.5.2003, com as modificações introduzidas pela MP 163, de 23.1.2004 (que os relaciona em ordem alfabética), agrupamos, segundo esses setores, do modo a seguir indicado:

I – Setor Político

1. Ministério da Justiça
2. Ministérios das Relações Exteriores

II – Setor econômico

3. Ministério Fazenda
4. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
5. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
6. Ministério do Desenvolvimento Agrário
7. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
8. Ministério dos Transportes

9. Ministério das Minas e Energia
10. Ministério da Integração Nacional
11. Ministério do Turismo
- III – *Setor social*
12. Ministério da Educação
13. Ministério da Saúde
14. Ministério do Trabalho e Emprego
15. Ministério da Previdência Social
16. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
17. Ministério da Cultura
18. Ministério do Esporte
19. Ministério da Ciência e Tecnologia
20. Ministério das Comunicações
21. Ministério do Meio Ambiente
22. Ministério das Cidades
- IV – *Setor militar*
23. Ministério da Defesa

Cada Ministério tem sua estrutura básica dividida em Secretarias Executivas (exceto o Ministério das Relações Exteriores), Gabinete do Ministério e Consultoria Jurídica (exceto o Ministério da Fazenda), além de Conselhos e Comissões. A Presidência da República está constituída pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pela Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, pela Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, pelo Gabinete de Segurança Institucional e pelo Gabinete Pessoal do Presidente da República. Diversas Secretarias Especiais integram a Presidência da República.

III - CONSELHOS

II. Generalidades

Conselhos são organismos públicos destinados ao assessoramento de alto nível e de orientação e até de deliberação em determinado campo de atuação governamental

Funcionam vários Conselhos juntos à Superior Administração Federal. Assim, integram a Presidência da República o Conselho de Governo, o de Desenvolvimento Econômico e Social, o de Segurança Alimentar e Nutricional, o de Política Energética, o de Políticas de

Transporte, e junto aos Ministérios merecem destaques o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Política Cultural, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Meio Ambiente e outros; e a lei poderá criar tantos outros quantos sejam necessários – mas não são instituições constitucionais, como o são os três de que vamos tratar rapidamente aqui.

12. Conselho da República

Função e competência. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República com competência para pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e sobre outras questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas (arts. 89 e 90). Revela-se, assim, como um Conselho de consolidação democrática, mas só a experiência vai confirmar a sua utilidade. Foi inspirado no Conselho de Estado instituído no arts. 144 a 149 da Constituição da República Portuguesa, e surgiu no bojo da proposta parlamentarista que, tendo caído, o deixou de herança dentro do presidencialismo, com certeza para não merecer a menor atenção do Presidente da República, que, no personalismo do sistema, não costuma consultar senão os seus próprios botões (às vezes).

Composição. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República, que se reúne por convocação e sob a presidência do Presidente da República (art. 84, XVIII) e do qual participam, nos termos do art. 89: o Vice-Presidente da República; os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal; o Ministro da Justiça; seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução. Mas o Presidente da República poderá convocar Ministros de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.

13. Conselho de Defesa Nacional

Função e competência. O Conselho de Defesa Nacional, inspirado no Conselho de Defesa Nacional previsto no Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos (arts. 423 e 424), vem como substituto do famigerado Conselho de Segurança Nacional do regime anterior, e é órgão (não se disse, sobre ele, que é órgão superior, como se fez em relação ao anterior, mas é órgão superior por sua função) de consulta do Presi-

dente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático. Competindo-lhe: *opinar* nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos da Constituição, bem como sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal (o que entra também na competência do Conselho da República; não havia necessidade dessa duplicidade de consulta); *propor* os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e *opinar* sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira (art. 20, § 2º) e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo; e, finalmente, *estudar, propor e acompanhar* o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

Composição. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa do Estado, que se reúne por convocação e sob a presidência do Presidente da República (art. 84, XVIII), e se compõe dos seguintes membros natos: Vice-Presidente da República, Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Ministro da Justiça, Ministro da Defesa, Ministro das Relações Exteriores e Ministro do Planejamento e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

14. Conselho de Comunicação Social

O Conselho de Comunicação Social vem do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos (art. 403). Esta foi uma das instituições que mais controvérsia gerou no seio da Constituinte. Inicialmente, como o que o inspirou, era um Conselho robusto, com funções de alto alcance social, depois foi sendo descaracterizado até ficar no esqueleto constante do art. 224: *Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei.* Primeiro, como se vê, tem que vir uma lei que indique a forma de sua instituição, composição e atribuições; depois, o Congresso o instituirá, talvez.

IV. ÓRGÃOS SUPERIORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS

15. Organização administrativa de Estados e Municípios

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem autonomia para estabelecerem os órgãos de seus governos na forma que lhes parecer mais conveniente ao desempenho dos encargos que lhes cabem na partilha de competências federativas. Podem, pois, estru-

turar os órgãos superiores de sua administração como quiserem, criando Secretarias, ou Departamentos, ou simples Serviços.

16. Secretários de Estado

O Governador exerce o Poder Executivo estadual auxiliado pelos Secretários de Estado, que, assim, têm, no âmbito estadual, posição semelhante aos Ministros de Estado. As Constituições estaduais, como sempre fazem, acabarão imitando o modelo federal, dizendo que ao Governador compete “exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual”.

Por isso, sempre exerceram e vão continuar a exercer, no Estado, as mesmas atribuições que acima apontamos como de competência dos Ministros, até porque as *Secretarias de Estado* correspondem, mais ou menos, aos Ministérios, salvo quanto àquelas funções de governo de estrita competência federal, como o de Relações Exteriores e os Militares. Por outro lado, pode haver Secretarias às quais não corresponda nenhum Ministério, como as de Turismo, existentes em alguns Estados. Nem todos têm o mesmo número de Secretarias. Em geral são: Secretarias da Justiça, do Interior (que em vários Estados constitui uma só, denominada Secretaria dos Negócios da Justiça e do Interior), da Fazenda (ou das Finanças), da Agricultura, de Viação e Obras Públicas (ou Obras e Meio Ambiente, de Transportes), da Segurança Pública, do Trabalho, da Administração, da Promoção Social, do Turismo e Esporte, da Cultura, da Indústria, Comércio e Tecnologia, da Educação, da Saúde, da Economia e Planejamento (ou só Planejamento) e Casas Civil e Militar com *status* de Secretarias.

17. Órgãos superiores municipais

Os Municípios também gozam de autonomia e de auto-administração, pelo que podem criar órgãos superiores de sua administração. Os de tamanho pequeno e médio não necessitam, porém, manter estruturas de Secretarias como órgãos de sua administração superior. As Prefeituras desses Municípios, que são as estruturas administrativas do Poder Executivo municipal, podem ter organização mais simples, tais como Departamentos, Coordenadorias, Serviços, Divisões, em vez de Secretarias, que são órgãos mais complexos, com certa conotação política, que se justificam nos grandes Municípios, especialmente os da Capital.

Assim é, por exemplo, que o Município da Capital de São Paulo tem quase vinte Secretarias Municipais, tais como a dos Negócios Jurídicos, a das Finanças, a de Obras, a de Vias Públicas, a do Gover-

no, a dos Negócios Extraordinários, a das Administrações Regionais, a do Planejamento, a da Educação, a da Cultura, a da Saúde e Assistência Social, a da Habitação e Desenvolvimento Urbano.

V. REGIÕES

18. Regiões e microrregiões

A Constituição trata de dois tipos de regiões: as *regiões de desenvolvimento* (ou administrativas, art. 43) e as *regiões metropolitanas* (art. 25, § 3º). Neste mesmo art. 25, § 3º, refere-se a microrregiões, que são regiões administrativas intra-estaduais, e ainda a *aglomerações urbanas*. Rapidamente, vamos nos tópicos seguintes abordar o assunto, dado que as regiões são formas especiais de organização administrativa do território.

19. Organismos regionais

A União poderá, para melhor articular sua ação num mesmo complexo geoeconômico e social, instituir, mediante lei complementar, *regiões administrativas*, visando o respectivo desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais (art. 43).

A lei complementar que instituir a região preverá os *organismos regionais* que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes (art. 43, § 1º). Dá-se aqui uma base para a articulação dos planos de desenvolvimento econômico e social. Daí pode evoluir-se para um sistema de planejamento em que o plano nacional de desenvolvimento econômico e social venha a ser um conjunto ordenado de diretrizes e bases, como, aliás, prevê o art. 174, § 1º, enquanto os planos regionais e os setoriais funcionem como instrumentos de execução daquelas diretrizes e bases e de transformação concreta da realidade. Esse conjunto de medidas deve ser complementado com *incentivos regionais*, que hão de ser articulados com as prioridades estabelecidas nos planos regionais e com a regionalização orçamentária, especialmente pela outorga de *incentivos regionais* nas condições previstas no art. 43, § 2º.

20. Regionalização orçamentária

A organização das regiões federais administrativas se torna necessária para que se possa dar efetividade à regra constante do art. 165, § 1º, segundo o qual a lei que instituir o plano plurianual estabele-

cerá, *de forma regionalizada*, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

21. Regiões metropolitanas

As regiões metropolitanas já constam do Direito Constitucional pátrio desde a Constituição de 1967. Então, estava previsto que competia à União instituí-las com Municípios que fossem parte de uma mesma comunidade sócio-econômica. Com base no disposto no art. 164 da Constituição de 1969 foi promulgada a Lei Complementar 14/73 instituindo as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza com o fim de organizar, planejar e prestar os serviços de interesse metropolitano enumerados no art. 5º da lei. A lei previu a criação de dois órgãos para desincumbir-se das tarefas relacionadas no referido dispositivo: o *Conselho Deliberativo* e o *Conselho Consultivo*, dois órgãos de fraca estrutura e de ineficiência comprovada. A União, na verdade, instituiu essas regiões metropolitanas, e mais tarde também a do Rio de Janeiro, mas não tomou praticamente mais conhecimento delas. Os Estados é que ficaram responsáveis por sua estruturação e funcionamento, criando empresas ou autarquias para dar-lhes efetividade.

Agora a Constituição atribui aos Estados a competência para, mediante lei complementar estadual, instituí-las, com agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Foi mais adiante a Constituição, pois reconheceu igualmente competência aos Estados para, do mesmo modo e para os mesmos fins, instituir *aglomerações urbanas* e *microrregiões*.

Região metropolitana constitui-se de um conjunto de Municípios cujas sedes se unem com certa continuidade urbana em torno de um Município-pólo. *Microrregiões* formam-se de grupos de Municípios limítrofes com certa homogeneidade e problemas administrativos comuns, cujas sedes não sejam unidas por continuidade urbana. *Agglomerados urbanos* carece de conceituação, mas, de logo, se percebe que se trata de áreas urbanas, sem um pólo de atração urbana, quer tais áreas sejam das cidades sedes dos Municípios, como na baixada santista (em São Paulo), ou não.

Capítulo II

DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. Colocação do tema. 2. Princípios da legalidade e da finalidade. 3. Princípio da impessoalidade. 4. Princípio da moralidade e da probidade administrativas. 5. Princípio da publicidade. 6. Princípio da eficiência. 7. Princípio da licitação pública. 8. Princípio da prescritibilidade dos ilícitos administrativos. 9. Princípio da responsabilidade civil da Administração. 10. Princípio da participação. 11. Princípio da autonomia gerencial.

1. Colocação do tema

A Administração Pública é informada por diversos princípios gerais,¹ destinados, de um lado, a orientar a ação do administrador na prática dos atos administrativos e, de outro lado, a garantir a *boa administração*, que se consubstancia na correta gestão dos negócios públicos e no manejo dos recursos públicos (dinheiro, bens e serviços) no interesse coletivo, com o que também se assegura aos administrados o seu direito a práticas administrativas honestas e probas.

Os princípios explicitados no *caput* do art. 37 são os da *legalidade*, da *impessoalidade*, da *moralidade*, da *publicidade* e da *eficiência*. Outros se extraem dos incisos e parágrafos do mesmo artigo, como o da licitação, o da prescritibilidade dos ilícitos administrativos e o da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público (inc. XXI e §§ 1º a 6º). O da *finalidade* não foi explicitado, nem era necessário, porque, a rigor, ele é ínsito no princípio da legalidade.

É de observar, por outro lado, que os incisos do art. 37, salvo o XXI, não contêm princípios informadores da Administração Pública, embora dependentes do *caput*. São incisos impróprios como tantos outros da Constituição, resultado de uma visão técnica equivocada. São, sim, normas gerais sobre a organização do funcionalismo e sobre entidades de Administração indireta, como denuncia a rubrica da seção.

2. Princípios da legalidade e da finalidade

Ao princípio da legalidade já dedicamos inúmeras páginas anteriormente, às quais nos permitimos remeter o leitor, porque tudo que ali foi dito tem integral aplicação aqui e o bastante.² Falta apenas dizer duas palavras sobre o princípio da finalidade administrativa, que não foi referido no art. 37, porque, certamente, o legislador constituinte o entendeu como um aspecto da legalidade. De fato o é na medida em que o ato administrativo só é válido quando atende o seu *fim legal*, ou seja, o fim submetido à lei. Logo, o fim já está sujeito ao princípio da legalidade, tanto que é sempre vinculado. Hely Lopes Meirelles destaca-o deste, para lhe dar consideração especial, para mostrar que ele “impõe que o administrador público só pratique o ato para o seu *fim legal*”, que a finalidade é inafastável do *interesse público*, de sorte que o administrador tem que praticar o ato com finalidade pública, sob pena de *desevio de finalidade*, uma das mais insidiosas modalidades de *abuso de poder*.³ Essas considerações querem apenas mostrar que o princípio da finalidade não foi desconsiderado pelo legislador constituinte, que o teve como manifestação do princípio da legalidade, sem que mereça censura por isso.

3. Princípio da impessoalidade

O princípio ou regra da impessoalidade da Administração Pública significa que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Este é um mero agente da Administração Pública, de sorte que não é ele o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Por conseguinte, o administrado não se confronta com o funcionário *x* ou *y* que expediu o ato, mas com a entidade cuja vontade foi manifestada por ele. É que a “primeira regra do estilo administrativo é a objetividade”, que está em estreita relação com a impessoalidade.⁴ Logo, as realizações administrativo-governamentais não são

2. V. capítulo II, n.11, do título VI da Segunda Parte.

3. Cf. *Direito administrativo brasileiro*, p. 86. O autor trata da finalidade no tópico da impessoalidade, igualando esta àquela. Para nós há diferença, conforme sai do nosso texto.

4. Cf. Agustín A. Gordillo, *Tratado de derecho administrativo*, t. II/XVIII-13 e XVIII-30 e 31, Buenos Aires, Ed. Macchi-Lopez, 1975. Essa objetividade revela a neutralidade da atividade administrativa, de que nos fala Carmen Lúcia Antunes Rocha, quando diz: “O princípio constitucional da impessoalidade administrativa tem como objeto a neutralidade da atividade administrativa, fixando como única diretriz jurídica válida para os compostamentos estatais o interesse público” (cf. *Princípios Constitucionais da Administração Pública*, p. 147).

1. Para maior profundidade, cf. Carmen Lúcia Antunes Rocha, *Princípios Constitucionais da Administração Pública*, 1994.

do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira. A própria Constituição dá uma consequência expressa a essa regra, quando, no § 1º do art. 37, proíbe que constem *nome, símbolos ou imagens* que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidades de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.

Por isso é que a responsabilidade, para com terceiro, é sempre da Administração, como veremos logo mais.

A *personalização*, ou seja, a individualização do funcionário, pode ser recomendável, quando atue não como expressão da vontade do Estado, mas como expressão de veleidade, capricho ou arbitrariedade pessoal.⁵ Então, como nota Gordillo, “o ataque ou impugnação concreta à pessoa do funcionário só é um meio direto de lograr que ela mesma ou seu superior corrija o fato ou omissão danosa”.⁶ A personalização vale assim para imputar ao funcionário uma falta e responsabilizá-lo perante a Administração Pública, a fim de que esta lhe imponha a punição cabível.

4. Princípio da moralidade e da probidade administrativas

A *moralidade* é definida como um dos princípios da Administração Pública (art. 37). Já discutimos o tema quando tratamos da ação popular, e vimos que a Constituição quer que a imoralidade administrativa em si seja fundamento de nulidade do ato viciado. A idéia subjacente ao princípio é a de que moralidade administrativa não é *moralidade comum*, mas *moralidade jurídica*. Essa consideração não significa necessariamente que o ato legal seja honesto. Significa, como disse Hauriou, que a moralidade administrativa consiste no conjunto de “regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração”.⁷

Pode-se pensar na dificuldade que será desfazer um ato, produzido conforme a lei, sob o fundamento de vício de imoralidade. Mas isso é possível porque a moralidade administrativa não é meramente subjetiva, porque não é puramente formal, porque tem conteúdo jurídico a partir de regras e princípios da Administração. A lei pode ser cumprida moralmente ou imoralmente. Quando sua execução é feita, por exemplo, com o intuito de prejudicar alguém deliberadamente, ou com o intuito de favorecer alguém, por certo que se está produzindo um ato *formalmente legal*, mas *materialmente* comprometido com a moralidade administrativa.

5. Idem, p. XVIII-13.

6. Ob. cit., p. XVIII-14.

7. Cf. Maurice Hauriou, *Précis de droit administratif et de droit public*, 10ª ed., Paris, Sirey, 1921, p. 424; Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, p. 83.

A *probidade administrativa* é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, § 4º). A *probidade administrativa* consiste no dever de o “funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer”.⁸ O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem.

A *moralidade administrativa* e assim também a *probidade* são tuteladas pela ação popular que já estudamos, de modo a elevar a imoralidade a causa de invalidade do ato administrativo, como vimos. A improbidade é tratada ainda com mais rigor, porque entra no ordenamento constitucional como causa de suspensão dos direitos políticos do ímprobo (art. 15, V, que já comentamos), conforme estatui o art. 37, § 4º, *in verbis*: “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Outra idéia que sai do texto é a de que a suspensão dos direitos políticos por improbidade administrativa pode ser aplicada independentemente de um processo criminal. É o que se extrai da parte final, segundo a qual todas as sanções indicadas antes o são sem prejuízo da ação penal. Vale dizer, independentemente dessa ação. Ou seja, a suspensão dos direitos políticos, no caso, não constitui simples pena acessória. O problema é que não pode a suspensão ser aplicada em processo administrativo. Terá que ser em processo judicial, em que se apure a improbidade, quer seja criminal ou não.

5. Princípio da publicidade

A *publicidade* sempre foi tida como um princípio administrativo, porque se entende que o Poder Público, por ser público, deve agir com a maior transparência possível, a fim de que os administrados tenham, a toda hora, conhecimento do que os administradores estão fazendo. Especialmente exige-se que se publiquem atos que devam surtir efeitos externos, fora dos órgãos da Administração.

8. Cf. Marcello Caetano, *Manual de direito administrativo*, 1ª ed. brasileira, t. II/684, Rio de Janeiro, Forense, 1970.

A publicidade, contudo, não é um requisito de forma do ato administrativo,⁹ “não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade. Por isso mesmo os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam para sua exequibilidade, quando a lei ou o regulamento a exige”.¹⁰

Agora é a Constituição que a exige. Em princípio, por conseguinte, não se admitem ações sigilosas da Administração Pública, por isso mesmo é pública, maneja coisa pública, do povo (*publicum* > *populicum* > *populum*; público = do povo). Mas a própria Constituição admite informações “sigilosas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado” (art. 5º, XXXIII), o que, porém, há de ser excepcional, sob pena de infringir o princípio que é o da publicidade.

A publicidade se faz pela inserção do ato no jornal oficial ou por edital afixado no lugar de divulgação de atos públicos, para conhecimento do público em geral e início de produção de seus efeitos. A publicação oficial é exigência da executoriedade do ato que tenha que produzir efeitos externos. Em alguns casos, a forma de publicidade exigida é a notificação pessoal ao interessado no ato ou a quem o ato beneficia ou prejudica.

Enfim, a “publicidade, como princípio da administração pública [diz Hely Lopes Meirelles], abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos como também de propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos concluídos e em formação, os processos em andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de julgamentos das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes. Tudo isto é papel ou documento público que pode ser examinado na repartição por qualquer interessado e dele obter certidão ou fotocópia autenticada para fins constitucionais”.¹¹

É de ponderar, contudo, que os pareceres só se tornam públicos após sua aprovação final pela autoridade competente; enquanto em poder do parecerista ainda é uma simples opinião que pode não se tornar definitiva. As certidões, contudo, não são elementos da publicidade administrativa, porque se destinam a interesse particular do requerente; por isso a Constituição só reconhece esse direito quando são requeridas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal (art. 5º, XXXIV, b), mas é certo que a Constituição

assegura a todos o direito de obter dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, salvo as sigilosas já mencionadas (art. 5º, XXXIII).

6. Princípio da eficiência

Eficiência não é um conceito jurídico, mas econômico; não qualifica normas; qualifica atividades. Numa idéia muito geral, *eficiência* significa fazer acontecer com racionalidade, o que implica medir os custos que a satisfação das necessidades públicas importam em relação ao grau de utilidade alcançado. Assim, o *princípio da eficiência*, introduzido agora no art. 37 da Constituição pela EC-19/98, orienta a atividade administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe e a menor custo. Regese, pois, pela regra da consecução do maior benefício com o menor custo possível. Portanto, o princípio da eficiência administrativa tem como conteúdo a relação meios e resultados.

A dificuldade está em transpor para a atividade administrativa uma noção típica da atividade econômica, que leva em conta a relação *input/output* (insumo/produto), o que, no mais das vezes, não é possível aferir na prestação do serviço público, onde nem sempre há um *output* (produto) identificável, nem existe *input* no sentido econômico. Por outro lado, na economia, a eficiência tem por objeto a alocação de recursos de modo a aumentar o bem-estar de pelo menos um consumidor sem diminuir, simultaneamente, o de outros.¹² Na Administração Pública as condições de eficiência são diferentes porque, em relação aos bens públicos, vale o princípio de não-exclusão, isto é, o consumo da parte de um agente econômico não exclui a possibilidade que outros consumam contemporaneamente o mesmo bem; enquanto no caso dos bens privados cada um consome diversas quantidades ao mesmo preço, no caso dos bens públicos (p. ex., a defesa nacional), todos consomem a mesma quantidade atribuindo-lhes valores diferentes. É que o financiamento do custo dos bens públicos decorre normalmente de imposição tributária, cujo montante é independente das preferências individuais, como ocorre nos preços de bens privados.¹³

Isso quer dizer, em suma, que a *eficiência administrativa* se obtém pelo melhor emprego dos recursos e meios (humanos, materiais e

9. Cf. Agustín A. Gordillo, *El acto administrativo*, 2ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1969, p. 323.

10. Cf. Hely Lopes Meirelles, *ob. cit.*, p. 86.

11. *Idem*, p. 87.

12. Cf. Bernt P. Stigum e Marcia L. Stigum, *Economia*, v. 1, p. 215.

13. Cf. *Enciclopedia del diritto e dell'economia* Garzanti, verbete “efficienza”, pp. 470-472.

institucionais) para melhor satisfazer às necessidades coletivas num regime de igualdade dos usuários. Logo, o *princípio da eficiência administrativa* consiste na organização racional dos meios e recursos humanos, materiais e institucionais para a prestação de serviços públicos de qualidade com razoável rapidez, consoante previsão do inciso LXXVIII do art. 5º (EC-45/2004) e em condições econômicas de igualdade dos consumidores. O princípio inverte as regras de competência, pois o bom desempenho das atribuições de cada órgão ou entidade pública é fator de eficiência em cada área da função governamental. A própria Constituição, pela EC-19/98, introduziu alguns mecanismos tendentes a promover o cumprimento do princípio da eficiência, como o da participação do usuário na Administração Pública e a possibilidade de aumentar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades da Administração direta e indireta, aos quais dedicaremos os itens 10 e 11 abaixo.

7. Princípio da licitação pública

Licitação é um procedimento administrativo destinado a provocar propostas e a escolher proponentes de contratos de execução de obras, serviços, compras ou de alienações do Poder Público. O *princípio da licitação* significa que essas contratações ficam sujeitas, como regra, ao procedimento de seleção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública. Constitui um princípio instrumental de realização dos princípios da moralidade administrativa e do tratamento isonômico dos eventuais contratantes com o Poder Público.¹⁴

O art. 37, XXI, alberga o princípio nos termos seguintes: “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual so-

14. Sobre o tema há vasta e boa literatura brasileira, cf. Hely Lopes Meirelles, *Licitação e Contrato Administrativo*, 13ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2002; José Afonso da Silva, “Licitações”, RDP 7/53; Celso Antônio Bandeira de Mello, *Licitação*, São Paulo, RT, 1980; Adilson Abreu Dallari, *Aspectos Jurídicos da Licitação*, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1980; Lucia Valle Figueiredo, *Direitos dos Licitantes*, 2ª ed., São Paulo, RT, 1981; Oswaldo Bandeira de Mello, *Da Licitação*, São Paulo, José Bushatsky Editor, 1978; Antônio Carlos Cintra do Amaral, *Licitações nas Empresas Estatais*, São Paulo, Editora McGraw-Hill, 1979; Américo Servídio, *Dispensa de Licitação Pública*, São Paulo, RT, 1979; Antônio Marcello da Silva, *Contratações Administrativas*, São Paulo, RT, 1971; Raul Armando Mendes, *Comentários ao Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos*, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1991; Toshio Mukai, *Estatutos Jurídicos de Licitações e Contratos Administrativos*, São Paulo, Saraiva, 1990; Ivan Barbosa Rigolin, *Manual Prático das Licitações*, São Paulo, Saraiva, 1991.

mente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. A ressalva inicial possibilita à lei definir hipóteses específicas de inexigibilidade e de dispensa de licitação.

Cumprido recordar, finalmente, que a licitação é um procedimento vinculado, ou seja, formalmente regulado em lei, cabendo à União legislar sobre *normas gerais de licitação e contratação*, em todas as modalidades, para a Administração Pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob seu controle (art. 22, XXVII). Portanto, aos Estados, Distrito Federal e Municípios compete legislar suplementarmente sobre a matéria no que tange ao interesse peculiar de suas administrações.

8. Princípio da prescritibilidade dos ilícitos administrativos

A *prescritibilidade*, como forma de perda da exigibilidade de direito, pela inércia de seu titular, é um princípio geral de direito. Não será, pois, de estranhar que ocorram *prescrições administrativas* sob vários aspectos, quer quanto às pretensões de interessados em face da Administração, quer quanto às desta em face de administrados. Assim é especialmente em relação aos ilícitos administrativos. Se a Administração não toma providência à sua apuração e à responsabilização do agente, a sua inércia gera a perda do seu *ius persequendi*. É o princípio que consta do art. 37, § 5º, que dispõe: “A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”. Vê-se, porém, que há uma ressalva ao princípio. Nem tudo prescreverá. Apenas a apuração e punição do ilícito, não, porém, o direito da Administração ao ressarcimento, à indenização, do prejuízo causado ao erário. É uma ressalva constitucional e, pois, inafastável, mas, por certo, destoante dos princípios jurídicos, que não socorrem quem fica inerte (*dormientibus non succurrit ius*). Deu-se assim à Administração inerte o prêmio da imprescritibilidade na hipótese considerada.

9. Princípio da responsabilidade civil da Administração

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º).

Responsabilidade civil significa a obrigação de reparar os danos ou prejuízos de natureza patrimonial (e, às vezes, moral) que uma

pessoa cause a outrem. O dever de indenizar prejuízos causados a terceiros por agente público foi por longo tempo recusado à Administração Pública. Predominava, então, a doutrina da irresponsabilidade da Administração, sendo que os particulares teriam que suportar os prejuízos que os servidores públicos lhes davam, quando no exercício regular de suas funções.

Tal posição, no entanto, não se compadecia com o Estado de Direito, por isso, o direito brasileiro inscreveu cedo a obrigação de a Fazenda Pública compor os danos que os seus servidores, nesta qualidade, causem a terceiros, pouco importando decorra o prejuízo de atividade regular ou irregular do agente. Agora a Constituição vai além, porque equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito público aquelas de direito privado que prestem serviços públicos (como são as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores, empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma posição dos agentes públicos no que tange à responsabilidade pelos danos causados a terceiros.¹⁵ Não se cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente para caracterizar o direito do prejudicado à composição do prejuízo, pois a obrigação de ressarcilo por parte da Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na doutrina do risco administrativo.¹⁶

A obrigação de indenizar é da pessoa jurídica a que pertencer o agente. O prejudicado há que mover a ação de indenização contra a Fazenda Pública respectiva ou contra a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, não contra o agente causador do dano. O princípio da impessoalidade vale aqui também.

O terceiro prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado. Cabe à pessoa jurídica acionada verificar se seu

agente operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação regressiva assegurada no dispositivo constitucional, visando a cobrir as importâncias despendidas com o pagamento da indenização. Se o agente não se houve com culpa ou dolo, não comportará ação regressiva contra ele, pois nada tem de pagar.

Resta apenas observar que a Constituição foi mais técnica desta vez, primeiro por incluir no campo da responsabilidade objetiva todas as pessoas que operam serviços públicos, segundo por ter abandonado o termo "funcionário", que não exprimia adequadamente o sentido da norma, substituído agora pelo termo preciso "agente".

10. Princípio da participação

O princípio da participação do usuário na Administração Pública foi agora introduzido pela EC-19/98, com o novo enunciado do § 3º do art. 37, que vamos apenas reproduzir, porque a efetivação do princípio depende de lei. Diz o texto: "A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: I — as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; II — o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X [respeito à privacidade] e XXXIII [direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse ou de interesse coletivo ou geral]; III — a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública".

11. Princípio da autonomia gerencial

A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta [diz o § 8º do art. 37, introduzido pela EC-19/98] poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: I — o prazo de duração do contrato; II — os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; III — a remuneração do pessoal. Cria-se aqui uma forma de contrato administrativo inusitado entre administradores de órgãos do poder público com o próprio poder público. Quanto ao contrato das entidades não há maiores problemas porque entidades são órgãos públicos ou parapúb-

15. Consagra-se, neste particular, tese de Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, pp. 558 e 559. Até onde pudemos conferir, o autor assumiu essa posição pelo menos desde a 4ª ed. da citada obra.

16. Cf. José de Aguiar Dias, *Da Responsabilidade Civil*, 4ª ed., v. II/595 e ss., Rio de Janeiro, Forense, 1960; Hely Lopes Meirelles, *ob. cit.*, pp. 542 e ss.; J. Guimarães Menegalle, *Direito administrativo e ciência da administração*, 2ª ed., v. I/333 e ss., Rio de Janeiro, Ed. Borsó, 1950; Onofre Mendes Júnior, *Direito administrativo*, 2ª ed., v. II/303 e ss., Belo Horizonte, Ed. Bernardo Álvares, 1961, sustentando a tese da socialização da responsabilidade civil do Estado; Celso Antônio Bandeira de Mello, *Elementos de direito administrativo*, São Paulo, RT, 1980, pp. 252 e ss.

blicos (paraestatais) com personalidade jurídica de modo que têm a possibilidade de celebrar contratos e outros ajustes com o poder público, entendido poder da administração centralizada. Mas os demais órgãos não dispõem de personalidade jurídica para que seus administradores possam, em seu nome, celebrar contrato com o poder público, no qual se inserem. Tudo isso vai ter que ser definido pela lei referida no texto. A lei poderá outorgar aos administradores de tais órgãos uma competência especial que lhes permita celebrar o contrato, que talvez não passe de uma espécie de *acordo-programa*. Veremos como o legislador ordinário vai imaginar isso.

Capítulo III

DOS SERVIDORES PÚBLICOS

I. AGENTES ADMINISTRATIVOS: 1. Agentes políticos e administrativos. 2. Acessibilidade à função administrativa. 3. Investidura em cargo ou emprego. 4. Contratação de pessoal temporário. 5. Sistema remuneratório dos agentes públicos. 6. Acréscimos pecuniários e regras de sua singeleza. 7. Isonomia, paridade, vinculação e equiparação de vencimentos. 8. Vedação de acumulações remuneradas. 9. Servidor investido em mandato eletivo. II. SERVIDORES PÚBLICOS: 10. Execução de serviços na Federação e organização do funcionalismo. 11. Aposentadoria, pensão e seus proventos. 12. Efetividade e estabilidade. 13. Vitaliciedade. 14. Sindicalização e greve de servidores públicos. 15. Direitos trabalhistas extensivos aos servidores. III. DOS MILITARES: 16. Conceito. 17. Direitos e garantias constitucionais dos servidores militares. 18. Direitos trabalhistas extensivos aos servidores militares.

I. AGENTES ADMINISTRATIVOS

1. Agentes políticos e administrativos

Relembremos que o Estado se exprime por seus *órgãos*, que são *instrumentos* ou *meios de ação* pelos quais se coloca em condições de querer, de atuar e de relacionar-se com outros sujeitos de direito. O órgão caracteriza-se como *um centro de competências delimitado por normas legais*. Nele distinguem-se dois elementos: (a) um: *subjetivo, pessoal e variável*, que é a pessoa ou conjunto de pessoas que, em última análise, expressa a vontade da entidade pública (União, Estados, Distrito Federal ou Município); (b) outro: *objetivo, abstrato, institucional e contínuo*, que é um centro de competência ou complexo de atribuições. O órgão é, assim, uma *unidade jurídica*, que compreende seu *titular* (elemento subjetivo) e suas *competências*, atribuições e seus meios técnicos, informativos, coativos etc., que caracterizam o *cargo, emprego ou função*.¹ A *função* entra na Constituição agora como um lugar que, para ser ocupado, exige o preenchimento pelo titular de requisitos estabelecidos em lei (art. 37, I), mas,

1. Cf. nosso *Os servidores públicos municipais*, p. 7, fundado na lição do Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior, Universidad de Barcelona, *La estructura del Estado*, pp. 9 e 10.

nela, os elementos objetivos ficam muito confundidos com o elemento subjetivo.

O elemento subjetivo do órgão público — o titular — denomina-se genericamente *agente público*, que, dada a diferença de natureza das competências e atribuições a ele cometidas, se distingue em: *agentes políticos*, titulares de cargos que compõem a estrutura fundamental do governo, e *agentes administrativos*, titulares de cargo, emprego ou função pública, compreendendo todos aqueles que mantêm com o Poder Público relação de trabalho, não eventual, sob vínculo de dependência, caracterizando-se, assim, pela *profissionalidade e relação de subordinação hierárquica*.²

Dos agentes políticos já cuidamos, quando estudamos os poderes governamentais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e dos órgãos superiores da Administração Pública. Aqui cabe-nos a tarefa de examinar a organização dos *agentes administrativos*, que se repartem em dois grandes grupos: (1) os *servidores públicos*, que compreendem quatro categorias (art. 37, I e IX): (a) servidores investidos em cargos (*funcionários públicos*), (b) servidores públicos investidos em empregos (*empregados públicos*), (c) servidores admitidos em funções públicas (*servidores públicos em sentido estrito*) e (d) servidores contratados por tempo determinado (*prestacionistas de serviço público temporário*); (2) os *militares*, que compreendem os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (art. 42) e os das Forças Armadas (art. 142, § 3º). A EC-18/98 eliminou a terminologia *servidores civis* e *servidores militares*, o que, a rigor, não muda nada, porque a distinção está subentendida, já que *militares* também são servidores públicos.

2. Acessibilidade à função administrativa

A *função administrativa* é exercida por agentes administrativos, ou seja, nos termos da Constituição, por *servidores públicos*, mediante a ocupação de um cargo, emprego, função autônoma (chamada função pública) ou por contratação.

Assumir uma dessas posições corresponde a ter acesso à função administrativa, para desempenhar uma atividade ou prestar serviços à Administração como servidor público.

2. Nossa *ob. cit.*, pp. 7 e 8, citando Celso Antônio Bandeira de Mello, *Apontamentos sobre os agentes públicos* pp. 3 a 6; cf. também Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, pp. 71 e ss., Cármen Lúcia Antunes Rocha, *Princípios constitucionais dos servidores públicos*, pp. 59 e ss. Para nossas finalidades não precisamos acrescentar outras categorias de agentes públicos que esses autores relacionam, como *agentes honoríficos* e *agentes delegados*, ou *particulares em atuação de colaboração com o Poder Público*.

A Constituição estatui que os *cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei* (art. 37, I, cf. EC-19/98). Há aí duas normas e dupla referência à lei. A primeira norma, que reconhece acessibilidade a todos os brasileiros, é de eficácia contida e aplicabilidade imediata, de sorte que a lei a ela referida não cria o direito previsto, antes o restringe ao prever requisitos para seu exercício. Essa lei está limitada pela própria regra constitucional, de tal forma que os requisitos nela fixados não poderão importar em discriminação de qualquer espécie ou impedir a correta observância do princípio da acessibilidade de todos ao exercício de função administrativa. Mas a EC-19/98 inovou criando a possibilidade de acesso do estrangeiro aos cargos, empregos e funções públicas. É a outra norma, só que esta é de eficácia limitada, pois que o exercício do direito nela estatuído depende de forma a ser estabelecida em lei. Assim também é o direito à admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros nas universidades, previsto no art. 207, § 1º (EC-11/96).

3. Investidura em cargo ou emprego

O princípio da acessibilidade aos *cargos e empregos públicos* visa essencialmente realizar o princípio do mérito que se apura mediante *investidura por concurso público* de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II). Deixa a Constituição, porém, uma grave lacuna nessa matéria, ao não exigir nenhuma forma de seleção para a admissão às funções (autônomas) referidas no art. 37, I, ao lado dos cargos e empregos. Admissões a funções autônomas sempre foram fonte de apadrinhamentos, de abusos e de injustiças aos concursados. As funções de confiança, previstas no art. 37, V, como os cargos em comissão (também de confiança), destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não comportam concurso público, estatuiu-se apenas que aquelas sejam exercidas por servidores ocupantes de cargos efetivos, e estes preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Prevê-se, também, a possibilidade de a lei estabelecer outros critérios de admissão para o preenchimento de certa percentagem de cargos ou empregos públicos por pessoas portadoras de deficiência (art. 37, VIII).

A exigência de aprovação prévia em concurso público implica a classificação dos candidatos e nomeação na ordem prioritária dessa classificação. Não basta, pois, estar aprovado em concurso para ter

direito à investidura. Necessário também é que esteja classificado e na posição correspondente às vagas existentes, durante o período de validade do concurso, que será de *até* dois anos, prorrogável uma vez, por igual período (art. 37, III). O texto diz "*até* dois anos", o que vale dizer que pode não ter prazo algum, ou seja, o concurso pode ter sido realizado para o preenchimento das vagas existentes no momento de sua abertura, constantes do edital. Isso parece significar que o prazo de validade de concurso não é um direito subjetivo a eventuais candidatos a cargos e empregos públicos. Há, porém, o texto dúbio declarando que, *durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira* (art. 37, IV). Examinado isoladamente, esse dispositivo parece criar um direito subjetivo dos concursados à convocação para a nomeação, ainda depois de esgotado o prazo do concurso e ainda que já existam novos concursados. Mas isso seria um contra-senso. Esse inciso tem que ser entendido em harmonia com o inciso III do mesmo artigo. Se aqui prevê prazo de validade de concurso e esse prazo foi estabelecido, o direito de ser convocado só perdura dentro desse prazo e de sua prorrogação. Se porventura se realiza novo concurso dentro do prazo de validade do anterior, aquele que foi aprovado neste não precisa impugnar sua realização, porque aí o seu direito de ser convocado, para ocupar o cargo ou emprego na carreira, permanece intacto, e essa abertura de novo concurso confirma seu direito, porque demonstra a existência de vagas. Aberto o novo concurso, dentro do prazo de validade do anterior, pode reivindicar, desde logo, sua nomeação para uma dessas vagas.

Independem de concurso as nomeações para *cargo em comissão* declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II). Justifica-se a exceção, porquanto tais cargos devem ser providos por pessoas de confiança da autoridade a que são imediatamente subordinadas. Prevê-se, agora, por força da EC-19/98, que as *funções de confiança* serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os *cargos em comissão* serão preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei (art. 37, V). Ambos se destinam, como vimos, às atribuições de direção, chefia e assessoramento. O tratamento diferenciado, no entanto, tem sua razão de ser porque os *cargos em comissão*, como qualquer outro cargo, têm previsão de remuneração própria, o que comporta exercício por especialistas e técnicos alheios aos quadros administrativos; de outro lado, a justificativa para definir que devam ser exercidos por servidores de carreira está no fato de serem vinculados à especialidade de cada carreira funcional (Promotor, Procurador,

Defensor Público, Médico, Engenheiro etc.). As *funções de confiança* correspondem, em geral, à estrutura administrativa de entidade de Administração indireta, mas não só; existem onde há necessidade de pessoal de direção, chefia e assessoramento, de confiança (e com mais flexibilidade na movimentação do pessoal), mas não há os cargos correspondentes, então é preciso designar alguém para seu exercício, e, como elas não dispõem de remuneração própria, decidiu-se que o designado seja ocupante de cargos. A razão disso é: a) o designado leva seus vencimentos do cargo, que são acrescidos de gratificação ou *pro labore*, pelo exercício de função; b) por não terem previsão remuneratória própria, não comporta designação de pessoa alheia à Administração.

4. Contratação de pessoal temporário

O art. 37, IX, prevê que a *lei* estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa é uma forma de prestação de serviço público diferente do exercício de cargo, de emprego e de função. O contratado é, assim, um prestacionista de serviços temporários.³

Que *lei*? Achamos que será a lei da entidade contratadora: lei federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, de acordo com as regras de competência federativa. Não há de ser lei federal com validade para todas as entidades, porque não se lhe reserva competência para estabelecer lei geral ou especial nessa matéria com validade para todas. A autonomia administrativa das entidades não o permite. A Lei 8.745, de 9.12.1993, está de acordo com essa doutrina, tanto que só regulou a contratação por órgãos da Administração Federal direta, autárquica e fundações públicas. Mas ela traz diretivas que devem ser seguidas por leis estaduais e municipais, como, por exemplo, a indicação de casos de *necessidades temporárias* (art. 2º), a exigência de processo seletivo simplificado para o recrutamento do pessoal a ser contratado (art. 3º), o tempo determinado e improrrogável da contratação (art. 4º).

5. Sistema remuneratório dos agentes públicos

Espécies remuneratórias. A EC-19/98 modificou o sistema remuneratório dos agentes públicos, com a criação do *subsídio*, como forma de remunerar agentes políticos e certas categorias de agentes admi-

3. Sobre a terminologia, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, *Princípios Gerais de Direito Administrativo*, v. II/320.

nistrativos civis e os militares. Usa a expressão *espécies remuneratórias*, como gênero, que compreende: o subsídio, o vencimento (singular), os vencimentos (plural) e a remuneração.

Subsídio. Termo que, tradicionalmente, designava a retribuição outorgada a pessoa investida em cargo eletivo. Chamava-se, assim, porque, originariamente, constituía simples auxílio, sem caráter remuneratório, pelos serviços prestados no exercício do mandato. Era mero achego, com o fim e a natureza de adjutório, de subvenção, pelo exercício da função pública relevante. Não tinha nem o sentido de remuneração nem de vencimento. Hodiernamente, contudo, já havia assumido caráter remuneratório, dado que o eleito deveria manter-se, a si e a sua família, com a quantia que se lhe pagava a título de subsídio, enquanto no exercício do mandato. Justificava-se a transformação de sua natureza, porquanto os eleitos não que dedicar-se quase exclusivamente às suas atribuições. O subsídio parlamentar, então, se dividia em duas partes: uma *fixa* e outra *variável*. Aquela era recebida mensalmente sem consideração ao comparecimento do parlamentar aos trabalhos legislativos, enquanto a parte variável correspondia ao comparecimento efetivo e participação nas votações.⁴

O *subsídio*, agora reincorporado à Constituição por força do art. 5º da EC-19/98, difere substancialmente daquele tipo referido acima, porque: (a) não é forma de retribuição apenas a titulares de mandato eletivo; (b) tem *natureza de remuneração*, é mesmo considerado pelo novo texto constitucional uma *espécie remuneratória*; (c) é fixado em parcela única. O subsídio é obrigatório ou facultativo. É *obrigatório* para detentores de *mandato eletivo* federal, estadual e municipal (Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos Municipais; Senadores, Deputados e Vereadores), para Ministros de Estado, Secretários de Estado e de Municípios, membros do Poder Judiciário (Ministros, Desembargadores e Juízes), membros dos Tribunais de Contas (por força das remissões contidas nos arts. 73, § 3º, e 75), membros do MP Federal e Estadual, Advogados da União, Procuradores de Estado e do Distrito Federal, Defensores Públicos e dos servidores policiais (civis ou militares).⁵ É *facultativo*, como forma de remuneração de servidores públicos organizados em carreira, se assim dispuser a lei (federal, estadual ou municipal, conforme a regra de competência).⁶

Consoante se disse acima, o subsídio é fixado em *parcela única*, “vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”. A remissão a esses dois incisos do art. 37 significa que: (a) o subsídio, excluído o de mandato eletivo, sujeito a regime próprio, só poderá ser fixado e alterado *por lei específica*; (b) é assegurada sua revisão anual, que só poderá ser para aumentá-lo, nunca para reduzi-lo, pois sua irreduzibilidade é também garantida no art. 37, XV, para ocupantes de cargos e empregos públicos, excluídos os subsídios de mandato eletivo; (c) fica sujeito ao teto que corresponde: (c.1) *no âmbito federal*, ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, fixado pela Lei 11.143, de 26.7.2005, referida no art. 48, XV, da Constituição, com o que o art. 8º da EC-41/2003, perdeu eficácia; (c.2) *nos Estados e Distrito Federal*, ao subsídio do Governador, no âmbito do Poder Executivo; ao subsídio dos Deputados Estaduais no âmbito do Poder Legislativo; e ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, incluindo nesse limite os membros do Ministério Público, os Procuradores e os Defensores Públicos; (c.3) *nos Municípios*, o subsídio do Prefeito (EC-41/2003). A EC-47/2005, contudo, faculta aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. A mesma emenda constitucional estabeleceu que não serão computadas, para os limites do inc. XI do art. 37, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.

O conceito de *parcela única* há de ser buscado no contexto temporal e histórico e no confronto do § 4º do art. 39 com outras disposições constitucionais, especialmente o § 3º do mesmo artigo. Sendo uma espécie remuneratória de trabalho permanente, significa que é pago periodicamente. Logo, a unicidade do subsídio correlaciona-se com essa periodicidade. A parcela é única em cada período, que, por regra, é o mês. Trata-se, pois, de *parcela única mensal*. Historicamente, subsídio era uma forma de retribuição em duas parcelas: uma fixa e outra variável. Se a Constituição não exigisse *parcela única*, expressamente, essa regra prevaleceria.

A primeira razão da exigência de *parcela única* consiste em afastar essa duplicidade de parcelas que a tradição configurava nos sub-

4. Essas notas sobre o subsídio constavam, em essência, das edições anteriores à CF-1988, quando vigorava o sistema de subsídio para os agentes políticos eleitos.

5. Cf. arts. 227, § 2º; 28, § 2º; 29, V e VI; 39, § 4º; 48, XV; 49, VII e VIII; 93, V; 128, § 5º, I, c; 135; e 144, § 9º, de acordo com enunciado da EC-19/98.

6. Cf. art. 39, § 8º.

sídios. A proibição expressa de acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória reforça o repúdio ao conceito tradicional e elimina o vazo de fragmentar a remuneração com múltiplos penduricalhos, que desfiguram o sistema retributivo do agente público, gerando desigualdades e injustiças. Mas o conceito de parcela única só repele os acréscimos de espécies remuneratórias do trabalho normal do servidor. Não impede que ele aufera outras verbas pecuniárias que tenham fundamentos diversos, desde que consignados em normas constitucionais. Ora, o § 3º do art. 39, remetendo-se ao art. 7º, manda aplicar aos servidores ocupantes de *cargos públicos* (não ocupantes de mandato eletivo, de emprego ou de funções públicas) algumas vantagens pecuniárias, nele consignadas, que não entram naqueles títulos vedados. Essas vantagens são: o *décimo-terceiro salário* (art. 7º, VIII), que não é acréscimo à remuneração mensal, mas um mês a mais de salário; *subsídio noturno maior do que o diurno* (art. 7º, IX); *salário-família* (art. 7º, XII); o subsídio de serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% ao do normal (art. 7º, XVI); o subsídio do período de férias há de ser, pelo menos, um terço a maior do que o normal (art. 7º, XVII). Como se vê, o subsídio, nesses casos, não deixa de ser em parcela única. Apenas será superior ao subsídio normal. Demais, o novo § 7º do art. 39 prevê a possibilidade de adicional e prêmio, no caso de economia com despesas correntes em cada órgão etc., quebrando ele próprio a unicidade estabelecida.⁷

Vencimento e remuneração dos servidores. Essas espécies remuneratórias perduram como forma geral de estipendiar servidores públicos, já que os subsídios só se aplicam nas hipóteses estritamente indicadas.

Os termos *vencimento* (no singular), *vencimentos* (no plural) e *remuneração* dos servidores públicos não são sinônimos. *Vencimento*, no singular, é a retribuição devida ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função, correspondente ao símbolo ou ao nível e grau de progressão funcional ou ao padrão, fixado em lei. Nesse sentido, a palavra não é empregada uma só vez na Constituição.⁸ *Vencimentos*, no plural, consiste no *vencimento* (retribuição correspondente ao símbolo ou ao nível ou ao padrão fixado em lei) acrescido das *vantagens pecuniárias* fixas. Nesse sentido, o termo é empregado

em vários dispositivos constitucionais.⁹ *Remuneração* sempre significou, no serviço público, uma retribuição composta de uma parte fixa (geralmente no valor de dois terços do padrão do cargo, emprego ou função) e outra variável, em função da produtividade (quotas-partes de multas) ou outra circunstância. É tipo de retribuição aplicada a certos servidores do Fisco (os *fiscais*) que, além de vencimentos (padrão mais adicionais etc.), tinham ou têm também o direito de receber quotas-partes de multas por eles aplicadas. Hoje se emprega o termo *remuneração* quando se quer abranger todos os valores, em pecúnia ou não, que o servidor percebe mensalmente em retribuição de seu trabalho. Envolve, portanto, *vencimentos*, no plural, e mais quotas e outras vantagens variáveis em função da produtividade ou outro critério. Assim, a palavra *remuneração* é empregada em sentido genérico para abranger todo tipo de retribuição do servidor público, com o que também envolve o seu sentido mais específico lembrado acima.¹⁰

Então, o termo *remuneração* pode ser empregado, e não raro está empregado, no sentido de *vencimentos*, mas este não é empregado em lugar de remuneração. Assim é que, em face da Constituição, é lícito dizer que o servidor tem direito a uma remuneração mensal pelo seu trabalho, que pode ser simplesmente os *vencimentos* (vencimento mais vantagens) ou a *remuneração* em sentido próprio: vencimentos (ou parte destes) acrescidos de quotas variáveis segundo critério legal; por exemplo, vencimentos e gratificação pelo comparecimento a reuniões de conselho, comissão etc. Quando a Constituição, no art. 39, § 5º, conforme redação da EC-19/98, declara que "lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI", usou intencionalmente o termo *remuneração* para abranger todos os valores integrantes da retribuição dos civis a fim de que nenhuma parcela fique fora da relação comparativa, obedecido o teto previsto no citado art. 37, XI, e também, agora, para indicar que os subsídios não estão abrangidos pelo dispositivo.

O dispositivo, em resumo, quer que a lei, em cada entidade da Federação, estabeleça, por exemplo, que a maior remuneração de servidor não seja superior a dez, quinze ou vinte vezes a menor, ou,

7. Resta observar que o STF, em decisão administrativa, entendeu que o subsídio só será aplicado após a fixação dos subsídios de seus Ministros pela lei de iniciativa conjunta prevista no art. 48, XV, que servirão de teto aos demais.

8. De fato, não localizamos *vencimento*, no singular, no sentido de estipêndio. O art. 39, § 1º, agora com a EC-19/98, fala em padrões de *vencimento*. O termo aparece duas vezes, nos arts. 46 e 47, § 5º, do ADCT, mas no sentido *termo final de um prazo*.

9. Ocorre, pelo menos, nos seguintes dispositivos: arts. 37, XII e XV, 40, § 5º, 73, § 3º, e 17 do ADCT. Sobre o conceito de *vencimento* e *vencimentos*, cf. nossa *ob. cit.*, p. 21; Hely Lopes Meirelles, *ob. cit.*, pp. 398 e ss.

10. O termo *remuneração* ocorre umas 25 vezes na Constituição, ligado a *salários*, a *vencimentos*, cf. arts. 7º, VII, VIII, IX, XI, XVI e XXIII, 37, X, XI (3 vezes), XIII, XV, 38, II e III, 40, § 4º, 51, IV, 52, XIII, 56, II, § 3º, 61, II, a, 151, II, 169, parágrafo único, 218, § 4º, 239, § 1º e § 3º, e ADCT, arts. 8º, § 1º, e 17. Foi suprimido onde se referia a

então, que a escala de remuneração não guarde distância acima de certa percentagem. Mas a remissão ao art. 37, XI, invoca, para o caso, o respeito ao teto que, como visto acima, depende do âmbito a que pertença o servidor. A EC-41/2003, no seu art. 9º, manda aplicar o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. O que o texto da Emenda pretende, na verdade, é afastar a invocação do direito adquirido às hipóteses por ela estabelecidas. Nesse sentido, o referido artigo é inconstitucional, porque, em verdade, está criando um novo dispositivo que elimina uma garantia constitucional, o que é vedado por emenda constitucional nos termos do art. 60, § 4º, IV, combinado com o disposto no art. 5º, XXXVI. O art. 17 do ADCT foi criado pelo poder constituinte originário à vista de situações ocorridas na passagem de um regime constitucional para outro, “não admitindo, *neste caso*, invocação do direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título”; “*neste caso*” é um signo normativo indicativo de contemporaneidade, que emenda constitucional não pode, legitimamente, estender a situações futuras por ela mesma criadas. A disposição transitória já estava esgotada e sua eficácia não pode ser restabelecida, validamente, por emenda constitucional.

Por outro lado, é correto o emprego da palavra *vencimentos* no mesmo art. 37, XII e XV. O primeiro a dizer que os *vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo*; em verdade, esse referencial nunca foi obedecido. O segundo, com a redação da EC-19/98, a estipular que o *subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º*. De fato, só os *vencimentos* (vencimento e vantagens fixas), e o *subsídio* (parcela única) podem ser irredutíveis. A *remuneração*, em sentido próprio, não precisamente porque um de seus componentes é necessariamente variável e, portanto, em um mês poderá ser maior ou menor do que em outro. Mas, qualquer que seja, sobre todas as suas parcelas somadas, incidirá o imposto sobre a renda (arts. 150, II, e 153, III, § 2º, I). Os *vencimentos*

estipêndios de parlamentares, Chefes do Poder Executivo, magistrados, membros do Ministério Público, substituído por *subsídio*, cf. arts. 27, §§ 1º e 2º, 29, V, 49, VII e VIII, 95, III, 128, § 5º, I, c.

irredutíveis significam que nem o padrão, nem os adicionais ou outras vantagens fixas poderão ser reduzidos.

6. Acréscimos pecuniários e regras de sua singeleza

Os *acréscimos pecuniários* ao padrão de vencimento dos servidores públicos continuam admitidos pela Constituição, em relação a vencimentos e remuneração; não aos subsídios, que não os admitem. Dos acréscimos se trata não tanto para erigi-los em direito dos servidores, mas para estabelecer limites, vedando seu cômputo ou acumulação, para fins de concessão de acréscimos ulteriores. É a proibição dos chamados “repicão” e “repiquíssimo”, que consistem na incidência de adicionais sobre adicionais, sobre sexta-parte, sobre salário-família, e reciprocamente. Significa dizer que só podem ser percebidos *singelamente*, sem acumulações ou repiques de qualquer natureza. Não se somam ao vencimento para a constituição de base sobre a qual eles mesmos incidiriam.

7. Isonomia, paridade, vinculação e equiparação de vencimentos

A EC-19/98 eliminou a determinação especial de isonomia de vencimentos, que constava do art. 39, § 1º. Isso não significa que a isonomia tenha deixado de existir nas relações funcionais. Não, porque o princípio geral continua intocável no *caput* do art. 5º, na tradicional forma da igualdade perante a lei. Se ocorrer nas relações funcionais, inclusive de vencimentos, remuneração ou mesmo subsídios, um tratamento desigual para situações iguais, aí se terá a aplicação do princípio da isonomia.

A isonomia se dá entre servidores do mesmo Poder e entre servidores de Poderes diferentes. Se isso é verdade, fica incompreensível a regra do art. 37, XII, que, como já vimos, determina que os *vencimentos* (não fala em subsídio) dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Se o princípio da isonomia é aplicável, a regra é que os *vencimentos* não podem ser superiores nem inferiores, mas iguais. Mas ele não é destituído de sentido. Ele significa que a aplicação da isonomia tem por referência os cargos do Executivo. Isto é, os servidores dos três Poderes têm direito à paridade isonômica de vencimentos, mas a parificação se faz com os cargos iguais ou assemelhados do Poder Executivo. Essa isonomia entre servidores de Poderes diversos é o que se chama *paridade de vencimentos*, que toma por base os fixados para os servidores do Poder Executivo.

Não há confundir isonomia e paridade com *equiparação* ou *vinculação* para efeitos de vencimentos. *Isonomia* é igualdade de espécies remuneratórias entre cargos de atribuições iguais ou assemelhados. *Paridade* é um tipo especial de isonomia, é igualdade de vencimentos a cargos de atribuições iguais ou assemelhadas pertencentes a quadros de Poderes diferentes. *Equiparação* é a comparação de cargos de denominação e atribuições diversas, considerando-os iguais para fins de se lhes conferirem os mesmos vencimentos; é *igualação* jurídico-formal de cargos ontologicamente desiguais, para o efeito de se lhes darem vencimentos idênticos, de tal sorte que, ao aumentar-se o padrão do cargo-paradigma, automaticamente o do outro ficará também majorado na mesma proporção. Na isonomia e na paridade, ao contrário, os cargos são ontologicamente iguais, daí devendo decorrer a igualdade de retribuição; isso está de acordo com o princípio geral da igualdade perante a lei: tratamento igual para situações reputadas iguais, é, em verdade, aplicação do princípio da isonomia material: trabalho igual deve ser igualmente remunerado. A *equiparação* quer tratamento igual para situações desiguais. *Vinculação* é relação de comparação vertical, diferente da *equiparação*, que é relação horizontal. Vincula-se um cargo inferior, isto é, de menores atribuições e menor complexidade, com outro superior, para efeito de retribuição, mantendo-se certa diferença de vencimentos entre um e outro, de sorte que, aumentando-se os vencimentos de um, o outro também fica automaticamente majorado, para guardar a mesma distância preestabelecida.¹¹

Os regimes jurídicos desses institutos são, por isso mesmo, diametralmente opostos. A *isonomia*, em qualquer de suas formas, incluída nela a paridade, é uma garantia constitucional e um direito do funcionário, ao passo que a *vinculação* e a *equiparação* de cargos, empregos ou funções, para efeito de remuneração, são vedadas pelo art. 37, XIII. É isso que o texto quer dizer na sua redação defeituosa. De fato, o dispositivo veda a vinculação ou equiparação de quaisquer *espécies remuneratórias* para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, quando, na verdade, o que se veda é a vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções para efeitos de remuneração. E assim é que deve entender-se o dispositivo.

11. *Jurisprudência*: Representação n. 1.370-GO, voto vencedor do Min. Célio Borja, RTJ 123/24 (janeiro/88): "no conceito constitucional de vinculação de vencimentos está incita a idéia de automatismo nas modificações da retribuição de cargos ou empregos públicos, de molde a acarretar o aumento ou a redução de todos os que estão ligados ao cargo-paradigma, toda vez que a remuneração deste é alterada. O que o constituinte quis impedir foi a subtração aos administradores da pecúnia pública da faculdade de dosar despesas de pessoal, de acordo com as possibilidades do Erário e a oportuna avaliação da utilidade dos cargos para o serviço público e da justa retribuição dos ocupantes". O argumento vale para as equiparações.

8. Vedação de acumulações remuneradas

A Constituição, seguindo a tradição, veda as acumulações remuneradas de cargos, empregos e funções na Administração direta e nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público (EC-19/98), significando isso que, ressalvadas as exceções expressas (*infra*), não é permitido a um mesmo servidor acumular dois ou mais cargos ou funções ou empregos, nem cargo com função ou emprego, nem função com emprego, quer sejam um e outros da Administração direta ou indireta, quer sejam um daquela e outro desta (art. 37, XVI e XVII).

Autorizam-se, contudo, exceções, para possibilitar a acumulação nos seguintes casos: (a) dois *cargos* de professor; (b) um *cargo* de professor com outro técnico ou científico; (c) dois *cargos* ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. As exceções, nos casos das letras *a* e *b*, só se referem a *cargos*; no da letra *c*, a *cargo* e *emprego*. Observe-se, também, que, em qualquer das hipóteses excepcionadas, a acumulação só será lícita em havendo compatibilidade de horário, notando-se que a Constituição não exige mais a correlação de matérias entre os cargos acumuláveis de professores ou um de professor e outro técnico ou científico. Mas a remuneração ou subsídio dos cargos acumulados não pode ultrapassar o teto do art. 37, XI.

Igualmente, é vedada a percepção simultânea de proventos da aposentadoria do art. 40 (titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e suas autarquias e fundações) ou dos arts. 42 (Polícia Militar) e 142 (Militares das Forças Armadas) com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição (cf. *supra*), os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração (EC-20/98), respeitado o teto do art. 37, XI.

9. Servidor investido em mandato eletivo

O servidor público *federal, estadual* ou *municipal*, da Administração direta autárquica e fundacional, eleito para cumprir mandato eletivo o exercerá com observância das seguintes regras:

(1) Se se tratar de *mandato eletivo federal* (Deputado Federal, Senador, Presidente e Vice-Presidente da República), *estadual* (Deputa-

do Estadual, Governador e Vice-Governador do Estado) ou *distrital* (Deputado, Governador e Vice-Governador do Distrito Federal), o servidor ficará afastado do seu *cargo, emprego ou função* (art. 38, I). O afastamento é automático; não depende de requerimento do eleito nem de ato declaratório da autoridade competente, embora seja recomendável uma comunicação do servidor eleito para fins de prontuário. Quando deve dar-se o afastamento? Recorra-se às regras de incompatibilidade do art. 54, I, *b*, e se concluirá que a resposta é: *desde a diplomação*, para parlamentares, e *desde a posse*, para cargo do Executivo. No caso, o afastamento é com prejuízo dos vencimentos, pois não há autorização constitucional para opção entre vencimentos e remuneração do mandato.

(2) Se a investidura for no *mandato de Prefeito*, o servidor será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Aqui, o afastamento se verifica com a posse, já que o dispositivo constitucional (art. 38, II) usa o termo “investido no mandato de Prefeito”, que significa “assumido” o cargo, emprego ou função, pois investidura efetiva-se com a posse, não valendo, a esse propósito, norma de Constituição estadual ou de lei orgânica de Município com solução diversa. Aqui, como o dispositivo diz “será afastado”, tornam-se necessários, especialmente se for servidor federal ou estadual, o pedido e o ato de afastamento, mas este não poderá ser negado, e se o interessado tomar posse sem o ato de afastamento nem por isso comete infração, devendo apenas fazer a comunicação do fato ou ser convidado a regularizar a situação.

(3) Em se tratando de servidor investido no *mandato de Vereador*, havendo compatibilidade de horário, exercerá cumulativamente o mandato com o cargo, emprego ou função. O servidor perceberá as vantagens deste ou desta (vencimentos etc.) sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não ocorrendo a compatibilidade de horário, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, facultando-se-lhe optar entre a remuneração de sua situação funcional e a do mandato. O afastamento também aqui se verifica com a posse (art. 38, III).

Em qualquer das hipóteses em que se exija o afastamento do servidor para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado *para todos os efeitos legais*, exceto para promoção por merecimento. Vale dizer: conta-se o tempo para aposentadoria, disponibilidade, adicionais, licença-prêmio, sexta parte (onde houver), benefícios previdenciários, caso em que os valores serão determinados como se no exercício estivesse, e para qualquer outra vantagem pecuniária ou funcional (art. 38, IV e V).

II. SERVIDORES PÚBLICOS

10. Execução de serviços na Federação e organização do funcionalismo

Já observamos noutra lugar que a Federação brasileira adotou o *sistema imediato de execução dos serviços*, que consiste no fato de cada entidade autônoma (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) executar seus serviços públicos diretos com seus próprios servidores. Por isso, existem quadros de servidores federais, quadros de servidores estaduais, quadros de servidores distritais e quadros de servidores municipais. Todas essas entidades têm autonomia para estabelecer a organização e o regime jurídico de seus servidores, mas todas elas estão adstritas à observância dos princípios a esse respeito estatuídos nos arts. 37 a 42 da Constituição.

O fundamento dessa autonomia está traduzido nos arts. 37 e 39, com o enunciado normativo da EC-19/98, que reconhecem à *União, Estados, Distrito Federal e Municípios a competência para dispor sobre regime jurídico* (não mais regime jurídico único, como se previa no texto original) *dos respectivos servidores públicos, observados os princípios, preceitos, direitos e restrições ali estabelecidos*. Já estudamos vários aspectos desse regime. Neste tópico, examinaremos direitos e vantagens específicas para os servidores públicos, não compreendidos aqui os militares.

11. Aposentadoria, pensão e seus proventos

Direitos previdenciários do servidor público — A aposentadoria, pensão e seus proventos são outros tantos direitos constitucionais dos servidores públicos. A Constituição, originariamente, estabeleceu a aposentadoria *por invalidez, por implemento de idade* (70 anos) e *por tempo de serviço*. A aquisição da aposentadoria por tempo de serviço era criticada por se entender não ser um fator adequado ao gozo de benefícios previdenciários. Esse fator foi agora substituído pelo tempo de contribuição, que merece os mesmos reparos. De fato, segundo a redação dada ao art. 40 pela EC-41/2003, aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Destaque-se que o direito aí previsto só cabe ao funcionário público estritamente considerado, que é o “servidor ti-

tular de cargo efetivo” de que fala o texto constitucional, sujeito agora à contribuição previdenciária, de que sempre esteve isento, em valor que preserve o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Observe-se que, nos termos da nova redação do dispositivo, também se impõe contribuição aos inativos e aos pensionistas. Essa determinação, que vem por via de emenda constitucional, parece-me inconstitucional, porque tal imposição não tem, no caso, natureza previdenciária, mas de simples imposto (sem causa) incidente sobre os proventos da inatividade e sobre as pensões com caráter de tributação da renda, gerando, assim, uma dupla tributação, com infringência ao princípio da igualdade.

Aposentadoria — A aposentadoria dos servidores abrangidos por esse regime previdenciário se dará: (1) por *invalidez permanente*, com *proventos integrais* quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, e *proporcional ao tempo de contribuição* nos demais casos; (2) *compulsoriamente*, aos setenta anos de idade com *proventos proporcionais* ao tempo de contribuição; (3) *voluntariamente*, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher, com *proventos* calculados, por ocasião de sua concessão, até o limite inicialmente fixado em R\$ 2.400,00, reajustável, tudo de acordo com o disposto no § 3º do art. 40, com a redação dada pela EC-41/2003, e com o art. 5º dessa mesma Emenda. Quer dizer, o princípio da integralidade e da paridade entre proventos da aposentadoria e remuneração ou subsídio do servidor em atividade só se aplica até aquele limite, não vigorando para servidores que percebam estipêndios mais elevados. Note-se, porém, que esse regime só será aplicado, desde que União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituam regime de previdência complementar, de natureza pública, para os respectivos servidores titulares de cargos efetivos. Enquanto isso não ocorrer, tem aplicação a todos o princípio da integralidade e da paridade (art. 40, § 14, não alterado pela EC-41/2003). Esses requisitos serão reduzidos de cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental (art. 40, § 5º); (b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com *proventos proporcionais ao tempo de contribuição*, note-se: a idade é que é o fator principal como era no art. 40, § 1º, III, d, do texto original, facultando-se a aposentadoria proporcional ao homem com sessenta e cinco anos de idade, e

à mulher com sessenta anos; a proporcionalidade, por sua vez, se faz em relação ao tempo de contribuição, sem limitação; completada a idade prevista, o servidor ou servidora pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, qualquer que seja esse tempo; eliminou-se a aposentadoria proporcional ao tempo de serviço que constava do citado art. 40, § 1º, III, c.

Em princípio é vedada a adoção de requisitos e critérios diferentes dos acima indicados para a concessão de aposentadoria, mas a EC-47/2005, admitiu, nos termos de lei complementar, ressalvas em favor de servidores que sejam portadores de deficiência, que exerçam atividades de risco, ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Lembra-se que o § 1º do art. 40, na redação originária, era específico, permitindo a redução de tempo de serviço de aposentadoria no caso de exercício de atividades consideradas *penosas, insalubres ou perigosas*. O texto da EC-20/98 é mais aberto, mas é razoável pensar que a lei complementar vai incluir as atividades penosas, insalubres e perigosas, que são as mais suscetíveis de prejudicar a saúde e a integridade física. Por isso, manteremos aqui a consideração que expendemos a respeito desses termos. “Penosas” são atividades que exigem desmedido esforço para seu exercício, e submetem o exercente a pressões físicas e morais intensas e, por tudo isso, geram nele profundo desgaste — quem sabe os mergulhadores sob pressão enorme das águas, que requer se alivie de tempo em tempo regressando à superfície; o metalúrgico submetido a altas temperaturas. “Insalubres” são atividades que submetem seu exercente a permanente risco de contrair moléstias profissionais. São “perigosas”, quando o servidor, pelas suas atribuições, fica sujeito, no seu exercício, a permanente situação de risco de vida, como certas atividades policiais. A lei complementar o dirá.

O art. 40, § 13, prevê a possibilidade de aposentadoria de quem ocupa, exclusivamente, cargo de provimento em comissão, de outros cargos temporários ou de emprego público. Lembre-se que o originário § 2º desse artigo remetia a solução do problema à lei ordinária. Agora, a norma constitucional regula diretamente o assunto, para declarar que esses servidores ficam sujeitos ao regime geral da previdência social (art. 201). Apesar disso, valem ainda, as considerações que fizemos sobre essa aposentadoria. Dissemos, então, que, em princípio, os titulares dos cargos em comissão não deveriam aposentar-se neles, pois os exercem a título de confiança, e, logo, deverão ser exonerados, para retornar à sua situação anterior. Se funcionário, volta a seu cargo efetivo. Se particular, regressa às suas atividades privadas. Contudo, o citado § 13 é expresso em prever a aposentadoria de titulares de emprego, também sujeitos ao regime geral da previdência, o

que a Constituição originariamente não havia feito. Não há menção a servidores no exercício de funções de confiança, porque a EC-19/98, dando nova redação ao art. 37, V, estabeleceu que elas são exercidas obrigatoriamente por servidores ocupantes de cargo efetivo; logo, se aposentam no regime destes.

Será computável integralmente o *tempo de contribuição federal, estadual ou municipal* para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço para efeito de disponibilidade, vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictícia (art. 40, §§ 9º e 10, enunciado da EC-20/98). Apenas para a aposentadoria é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os sistemas de previdência social envolvidos se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei (art. 201, § 9º).

A *aposentadoria*, como a *disponibilidade*, em qualquer de suas formas, é sempre remunerada, e é a própria Constituição que estabelece os requisitos dessa remuneração, que toma o nome de *provento*, enquanto a retribuição do servidor em atividade denomina-se *vencimento, vencimentos, remuneração ou subsídio*, nos termos que já examinamos. A soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, ou de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, fica sujeita ao teto previsto no art. 37, XI, como visto. Mas a Constituição garante sua *revisão* na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração (ou o subsídio) dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei (EC-41/2003, art. 7º). O dispositivo corta o vezo meio maroto de rever vencimentos de servidores na atividade por meio de alteração (transformação ou reclassificação) de sua escala de referências numéricas, elevando-as, de tal sorte que a melhoria não fosse extensiva aos inativos. Essas alterações agora beneficiam igualmente os aposentados e pensionistas.

Pensão – A EC-41/2003 golpeou fortemente o direito à *pensão*. Até sua superveniência o valor da pensão por morte era regido também pelo princípio da integralidade e da paridade, ou seja, a pensão correspondia ao total da remuneração percebida no cargo em que se tivesse dado a aposentadoria e suas atualizações posteriores. Agora, a lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor fale-

cido ou a totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, fixados hoje em R\$ 2.400,00 (EC-41/2003, art. 5º), acrescido de 70% da parcela excedente a este limite (art. 40, § 7º, redação da EC-41/2003). Vale dizer, se o servidor falecido tinha proventos ou remuneração de R\$5.000,00, a pensão por ele deixada para seu cônjuge e dependentes será de R\$ 2.400,00 mais 70% de R\$ 2.600,00 (que dá R\$ 1.820,00), ou seja: R\$ 2.400,00 + R\$ 1.820,00 = R\$ 4.220,00.

Regime de previdência complementar — O *regime de previdência de caráter contributivo*, que acabamos de ver, é, digamos assim, o regime *obrigatório* de previdência dos funcionários públicos efetivos. A ele estão obrigados a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em relação aos respectivos servidores titulares de cargo efetivo, com os níveis de proventos que indicamos acima.

Essas entidades da Federação, contudo, poderão instituir, como patrocinadoras, regime de *previdência complementar para os respectivos servidores*, observadas as normas gerais estabelecidas por lei complementar, de acordo com o disposto no art. 202.¹² É apenas uma faculdade que a Constituição reconhece a essas entidades (art. 40, §§ 14 a 16, segundo o enunciado da EC-20/98). Mas se elas resolverem patrocinar entidades de previdência complementar, necessariamente, hão de fazê-lo sob a forma de fundação obrigatoriamente de *natureza pública* e, é claro, sem fins lucrativos. As entidades assim patrocinadas pelo Poder Público são do tipo de entidade de previdência complementar fechada, porque destinadas apenas aos respectivos servidores. Quando formos examinar o regime geral de previdência social (Quarta Parte, Tít. II, Cap. II, n. 3, adiante) veremos que há também a possibilidade de constituição de entidades de previdência complementar *abertas* (ao público em geral), sob a forma de sociedades anônimas.

Se esse regime complementar for instituído, o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime contributivo obrigatório, referido mais acima, poderá ser fixado no limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 (art. 40, § 14). Enquanto, porém, não for instituído, as aposentadorias e pensões terão que ser concedidas com observância dos princípios da integralidade e da paridade, como visto

12. É a Lei Complementar 108, de 29.5.2001, que regula as relações das entidades públicas com as respectivas entidades fechadas de previdência complementar para os respectivos servidores. Tal relação fica, contudo, sujeita aos princípios estabelecidos na Lei Complementar 109, também de 29.5.2001, que regula o regime de previdência privada referido no art. 202 da CF.

antes. Na verdade, a remissão simplesmente ao art. 201 é incompleta, porque o limite máximo a que ele se refere, que se encontrava no art. 14 da EC-20/98, fixado em R\$ 1.200,00, passou para R\$ 2.400,00 por força do art. 5º da EC-41/2003, que terá que ser atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social, de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real.

Cumpra, finalmente, observar que o § 16 do art. 40 reserva o direito de opção pelo regime de previdência complementar ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de sua instituição. Somente poderá ser incluído nesse regime mediante prévia e expressa opção. Mas essa reserva de opção é conferida apenas aos servidores anteriores à instituição desse regime, o que vale dizer que os que ingressarem depois ficarão sujeitos à sua aceitação.

Ressalvas de direito preexistente — Não podemos entrar em pormenores aqui, mas queremos oferecer ao leitor a informação de que a EC-41/2003, como o fizera, também, a EC-20/98 ressaltou direitos adquiridos e até direitos em processo de aquisição. Assim: (a) o seu art. 3º assegura o direito adquirido do servidor público que, até a dada da publicação da Emenda, tenha cumprido os requisitos para obtenção do benefício (aposentadoria e pensão) no regime da lei anterior; (b) o art. 6º assegura ao servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a dada de sua publicação, a faculdade de aposentar-se, a qualquer tempo, com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição (caso dos professores), vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: (b.1) 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher; (b.2) 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher; (b.3) 20 anos de efetivo exercício do serviço público; e (b.4) 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; tem-se aqui o reconhecimento como que de um direito adquirido *in fieri*; dá-se estabilidade ao processo em curso de aquisição do direito, que pode ser exercido, no futuro, com as mesmas bases normativas que vigoravam antes da publicação da Emenda; (c) o art. 2º confere o direito de aposentar-se voluntariamente, com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição, a quem tenha ingressado regularmente (por concurso público) em cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação da EC-41/2003, quando, cumulativamente: (c.1) tiver 53 anos de idade, se homem, e 48

anos de idade, se mulher; (c.2) tiver 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; (c.3) contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: (c.3.1) 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher; (c.3.2) um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, na data da publicação da EC-41/2003, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. Note-se que esse art. 2º é igual ao art. 8º da EC-20/1998 (revogado), mas o modo de calcular os proventos é diverso, porque o § 3º, a que ambos remetem, tem conteúdo diverso. O § 3º da remissão do art. 8º da EC-20/1998 garantia proventos integrais; o § 3º da remissão do art. 2º, não.

12. Efetividade e estabilidade

A EC-19/98 transformou bastante o art. 41 da Constituição. Dizia: *São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso*. Agora diz: *São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público*. Antes aplicava-se a qualquer servidor nomeado em virtude de concurso público: para cargo ou emprego, nos termos do art. 37. Agora só se aplica a servidor nomeado em virtude de concurso para cargo de provimento efetivo. Adquiria-se a estabilidade, antes, após dois anos de efetivo exercício; agora, após três anos.

Cargo de provimento efetivo é aquele que, segundo a lei, deve ser preenchido em caráter definitivo, referindo-se essa característica à titularidade do cargo, para indicar que a pessoa nele investida o será como seu titular definitivo, em princípio, pois isso não impede remoção ou transferência. Opõe-se ao cargo de provimento em comissão, o que, segundo a lei, será ocupado em caráter transitório, querendo isso dizer que seu ocupante não é o seu titular definitivo, mas nele permanecerá apenas enquanto bem servir ou enquanto merecer a confiança da autoridade (daí, *cargo de confiança*) que o indicou ou nomeou. Outro é *cargo de provimento vitalício* que seria o provimento para toda a vida, mas essa idéia já não prevalece, porque seu titular fica sujeito à aposentadoria compulsória, além da voluntária.

A *efetividade*, como se vê, é um atributo do cargo, concernente à forma de seu provimento.¹³ Refere-se à titularidade do cargo definido em lei como de provimento em caráter efetivo. *Efetividade* dá-se no cargo. É vínculo do funcionário ao cargo, e constitui pressuposto da estabilidade, pois, pelo visto, só o servidor efetivo pode adquirir

13. Cf. Hely Lopes Meirelles, *ob. cit.*, p. 382.

la. A *estabilidade* não se dá no cargo, mas no serviço público. É garantia do servidor, não atributo do cargo. A *estabilidade* é, assim, um direito que a Constituição garante ao servidor público.

São requisitos para adquirir a estabilidade: (a) *nomeação por concurso* (art. 37, II) para cargo de provimento efetivo, de onde se vê que os nomeados para cargos em comissão, admitidos a funções e os contratados *nunca obtêm estabilidade*, podendo, pois, ser exonerados ou dispensados sem formalidade do processo administrativo; (b) *exercício efetivo após três anos*. Não basta, pois, a nomeação em virtude de concurso. É necessário que o servidor esteja no exercício no cargo para o qual fora nomeado, por mais de três anos, apenas um dia a mais, sem interrupção. A investidura em cargo público é um procedimento administrativo complexo, que envolve várias operações sucessivas: realização de concurso, aprovação neste, nomeação na ordem de classificação, posse e entrada em exercício. Desta última é que começa a fluir o tempo de três anos para a aquisição da estabilidade.

Esse período de três anos é definido nos estatutos dos servidores públicos como de *estágio probatório* (ou *estágio confirmatório*), durante o qual a administração apura a conveniência de sua confirmação no serviço, mediante a aferição dos requisitos de assiduidade, aptidão, eficiência, idoneidade moral etc.

Perde o cargo o servidor estável nos seguintes casos: (a) *por extinção ou declaração de sua desnecessidade*, ficando o servidor em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu aproveitamento em outro cargo; esse aproveitamento é obrigatório; (b) *por demissão*, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e, naturalmente, em virtude de sentença transitada em julgado, embora isso não seja mais expresso; (c) *insuficiência de desempenho* apurada por meio de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, mediante processo administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa (art. 41, § 1º, I, II e III e art. 247, parágrafo único, introduzido pela EC-19/98); (d) *por exoneração*, mediante *ato normativo motivado* com especificação da atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal, para cumprimento dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo estabelecidos em lei complementar (art. 169, § 7º), desde que, para tanto, a redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança não seja suficiente. Nesses dois últimos casos, dá-se a chamada *flexibilização da estabilidade*, reconhecida esta como princípio mas submetendo-a a limitações em razão de insuficiência de desempenho e excesso de despesa com pessoal, segundo normas gerais estabelecidas pelas leis complementares previstas no arts. 41, § 1º, III, e 169, § 7º, as quais, tam-

bém, estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado (art. 247).

Cumpra não confundir, como não raro acontece, *demissão* com *exoneração*. Ambas são atos administrativos que implicam o desligamento do servidor do serviço público. Mas a *demissão* é penalidade aplicada em consequência de delitos administrativos. A *exoneração* não constitui penalidade. É concedida a pedido do servidor ou, ao arbítrio da administração, quando o servidor, exonerável *ad nutum*, não mais merece a confiança da autoridade competente ou se torna dispensável ao serviço, ou quando, ainda em estágio probatório, não preencheu os requisitos de confirmação.

A *demissão* por ser penalidade, constitui ato administrativo vinculado, isto é, só pode ser aplicada com estrita observância das normas legais. Se isso não ocorrer, poderá ser anulada pela autoridade administrativa competente, ou por sentença judicial, caso em que o servidor, se estável, tem direito de ser reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço (art. 41, § 2º).

13. Vitaliciedade

Conceito diverso da estabilidade é a *vitaliciedade* que a Constituição assegura a certos agentes públicos: magistrados, membros de Tribunal de Contas e membros do Ministério Público. É, a um tempo, atributo do cargo e garantia do titular, que nele tem direito de permanecer por toda a vida ou até que complete setenta anos de idade, quando se aposentará compulsoriamente. Essa garantia não impede a *perda do cargo* pelo vitalício em duas hipóteses: (a) *extinção do cargo*, caso em que o titular ficará em disponibilidade com vencimentos integrais; (b) *demissão*, o que só pode ocorrer em virtude de sentença judicial.

14. Sindicalização e greve de servidores públicos

Deslocamos o estudo dessas duas questões para aqui, onde tratamos dos servidores públicos civis, porque só a eles dizem respeito, já que ao militar são expressamente proibidas a sindicalização e a greve (art. 142, § 3º, IV).

O problema da *sindicalização* e da *greve* dos servidores públicos, aqui, como em todo o mundo, foi sempre ardentemente discutido e intensamente controvertido. Na Europa o problema desapareceu há

muito tempo. Em geral todos os trabalhadores, privados ou públicos, têm o direito de sindicalização e de greve. A resistência no Brasil em admitir para os servidores públicos essas duas garantias dos trabalhadores sempre foi muito grande. As Constituições anteriores vedavam expressamente a greve no serviço público e nos serviços essenciais. Resquício dessa resistência transparece no texto constitucional que reconhece o direito de greve dos servidores (art. 37, VII).

Quanto à *sindicalização* não há restrições. Declara-se que “é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical” (art. 37, VI), mas quanto à *greve* o texto constitucional não avançou senão timidamente, estabelecendo que “o direito de greve dos servidores públicos será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica” – o que, na prática, é quase o mesmo que recusar o direito prometido, porque, se a lei não vier, o direito existirá, mas seus exercício, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, fica dependendo da promulgação da lei estabelecendo os termos e limites, os servidores não podem deflagrar qualquer greve (MI 20-4, rel. Min. Celso de Mello, in *Rev. LTr*, 58/647-654, 1994). Ora, o direito de greve, em tal caso, existe por força de norma constitucional, não por força de lei. Não é a lei que vai criar o direito. A Constituição já o criou. Nesses casos de norma de eficácia contida, a lei referida na norma, quando promulgada, é apenas restritiva do direito reconhecido, não geradora desse direito. Isso significa que enquanto a lei não vem, o direito há que prevalecer em sua amplitude constitucional. Reforça essa tese o fato de a Constituição ter garantido aos servidores públicos amplo direito à livre associação sindical (art. 37, VI) que implica, só por si, o direito à greve. Então, se a lei não vem, o direito existe, e, se existe, pode ser exercido.¹⁴

15. Direitos trabalhistas extensivos aos servidores

A declaração dos direitos e garantias dos servidores públicos civis completa-se com a disposição do art. 39, § 3º, que manda aplicar a eles vários direitos sociais previstos no art. 7º, para os trabalhadores rurais e urbanos, e que são os seguintes: (a) *salário mínimo*, nas condições do inc. IV daquele artigo; (b) *garantia de salário* (subsídio e vencimento), nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável (VII); (c) *décimo-terceiro salário* (vencimentos ou subsídios) com base na remuneração integral ou no valor da aposenta-

14. Cf. Arnaldo Süssekind, *Direito Constitucional do Trabalho*, 3ª ed., p. 468, onde também colhi a referência à citada decisão do STF; também Octávio Bueno Magano, *Organização Sindical Brasileira*, p. 84.

doria (VIII); (d) *remuneração ou subsídio do trabalho noturno superior à do diurno* (IX); (e) *salário-família* para os seus dependentes (XII); (f) *duração do trabalho normal* não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva, ou, em relação ao servidor, mediante lei (XIII); (g) *repouso semanal remunerado*, preferencialmente aos domingos (XV); (h) *remuneração ou subsídio do serviço extraordinário* superior, no mínimo, em 50% ao do normal (XVI); (i) *gozo de férias* anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário (vencimentos ou subsídios) normal (XVII); (j) *licença à gestante*, sem prejuízo do emprego e do salário (vencimentos ou subsídio), com a duração de cento e vinte dias (XVIII); (k) *licença-paternidade*, nos termos fixados em lei (cinco dias atualmente) (XIX); (l) *proteção do mercado de trabalho da mulher*, mediante incentivos específicos, nos termos da lei – vale para garantir a mulher no serviço público e lhe dar condições de trabalho (XX); (m) *redução dos riscos inerentes ao trabalho*, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (XXII); (n) *adicional de remuneração* para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei (XXIII); (o) *proibição de diferença de salários* (vencimentos), de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (XXX).

III. DOS MILITARES

16. Conceito

A EC-18/98 modificou a Seç. III do Cap. VII do Tít. III da Constituição, que compreendia e compreende apenas o art. 42. Determinou que a rubrica da seção, que era *Dos Servidores Públicos Militares* passasse a ser: *Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios*. Retirou do art. 42 a matéria referente aos militares das Forças Armadas, transferindo-a para o § 3º do art. 142, acrescentado por aquela emenda. A intenção confessada foi a de tirar dos militares o conceito de servidores públicos que a Constituição lhes dava, visando com isso fugir ao vínculo aos servidores civis que esta lhes impunha. Formalmente, deixaram de ser conceituados como servidores militares. Com isso, aliás, reforçou a característica militarista das Polícias Militares num momento em que parcela ponderável da sociedade busca desvinculá-las dessa conceituação. Ontologicamente, porém, nada mudou porque os militares são, sim, servidores públicos em sentido amplo como eram considerados na regra constitucional reformada. São agentes públicos, como qualquer outro prestador de serviço ao Estado. A diferença é que agora se pode separar as duas categorias, em lugar de servidores civis e servidores militares, embora assim

sejam, em *agentes públicos administrativos* e *agentes públicos militares*. Contudo, a EC-19/98 reenquadrou, ainda que indiretamente, os policiais militares no conceito de servidores, ao afirmar que a remuneração dos *servidores policiais militares* será fixada na forma de subsídio, segundo o previsto no art. 39, § 4º, da Constituição.

Sua organização e seu regime jurídico, desde a forma de investidura até as formas de inatividades, diferem fundamentalmente do regime dos servidores civis. Diferem até mesmo entre si. Por exemplo, os servidores militares das Forças Armadas, ou ingressam no serviço por via do recrutamento, que é forma de convocação para prestar o serviço militar, ou por via de exame de ingresso nos cursos de formação de oficiais. A obrigatoriedade do serviço militar (art. 143) não deixa margem à realização de concurso público à semelhança do que ocorre para os servidores civis. O ingresso nas polícias militares é voluntário, e, por conseguinte, os interessados se submetem a provas de seleção de vários tipos para sua investidura, incluindo também as escolas de formação de seus integrantes oficiais.

17. Direitos e garantias constitucionais dos servidores militares

A importância constitucional das Forças Armadas e das polícias militares, como forças auxiliares e reserva do Exército, levou o legislador constituinte a cercar seus integrantes de garantias e prerrogativas. Por isso, também, limita o ingresso à carreira de oficial das Forças Armadas aos brasileiros natos (art. 12, § 3º, VI). A Constituição distingue, porém, entre *oficiais* e *não oficiais*.¹⁵ Aqueles tem patente, títulos e posto, ao passo que os não oficiais, que são as praças,¹⁶ só possuem o título de nomeação e graduação.

Patentes, títulos, postos e uniformes. A *patente* era antigamente a carta régia de concessão de um título, posto ou privilégio militar de nível superior. Hoje é o ato de atribuição do título e do posto a oficial

15. Os oficiais e graduados são agrupados por círculos: (1) *Oficiais Gerais*, compreendendo: General de Exército, Almirante-de-Esquadra e Tenente-Brigadeiro; General-de-Divisão, Vice-Almirante, Major-Brigadeiro; General-de-Brigada, Contra-Almirante, Brigadeiro; (2) *Oficiais Superiores*, compreendendo: Coronel, Capitão-de-Mar-e-Guerra; Tenente-Coronel, Capitão-de-Fragata; Major, Capitão-de-Corveta; (3) *Oficiais intermediários*, compreendendo: Capitão, Capitão-Tenente; (4) *Oficiais Subalternos*, compreendendo: Primeiro-Tenente e Segundo-Tenente; (5) *Subtenentes, Suboficiais e Sargentos*, compreendendo: Subtenente, Suboficial; Primeiro-Sargento; Segundo-Sargento; Terceiro-Sargento; (6) *Cabos*, compreendendo: Cabo e Taifeiro-Mor; Marinheiro, Soldado, Fuzileiro Naval, Taifeiro de 1ª e 2ª classe especializado ou não.

16. *Praças* são os militares não oficiais: de Soldado a Subtenente, no Exército, e correspondentes nas outras Armas.

militar; por isso, é que Pontes de Miranda pôde dizer que quem tem a patente tem o título, o posto e o uniforme que a ela correspondem,¹⁷ bem como as prerrogativas, direitos e deveres a ela inerentes, diz a Constituição (art. 142, § 3º, I). Mas o *título* e o *posto* não se confundem, como pode dar a entender o texto desse autor. *Posto* é o lugar que o oficial ocupa na hierarquia dos círculos militares. O *título* é a designação da situação confiada ao titular dos postos (ex.: *posto*: General de Exército; *título*: Comandante de Exército). *Uniforme* é a farda, que não é privativa dos oficiais, mas, na forma e uso regulados em lei, o é dos militares. As patentes dos oficiais das Forças Armadas são conferidas pelo Presidente da República (art. 142, § 3º, I), e as dos oficiais das polícias militares e corpos de bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal, pelos respectivos Governadores (art. 42, § 1º).

Graduação: é o lugar da *praça* na hierarquia militar, mas sem garantias especiais de posto.

Militar da ativa e da inatividade militar. A Constituição garante as patentes dos oficiais da ativa, da reserva e dos reformados das Forças Armadas (art. 142, § 3º, I), das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal (art. 42, § 1º). Fala várias vezes em militar da ativa, transferência para a reserva, reforma e agregação, indicando, com esses termos, situações dos militares, que podem, em verdade, ser reduzidas a duas: *atividade* e *inatividade*. A primeira diz respeito ao militar que se encontra incorporado nas fileiras da tropa no exercício do serviço militar. É a situação do militar em efetivo exercício de seu posto ou graduação. A *inatividade* é o estado ou situação do militar afastado, temporária ou definitivamente, do serviço da respectiva força.¹⁸ A *inatividade*, assim, abrange a agregação, a transferência para a reserva e a reforma. Cabe à lei dispor sobre os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade (art. 142, § 3º, X, aplicável aos militares estaduais e do Distrito Federal por remissão do art. 42, § 1º), com os mesmos direitos referentes à revisão dos proventos da inatividade e sobre a pensão estatuídos para os servidores civis no art. 40, §§ 4º e 5º (e § 6º, só para os militares do Distrito Federal).

Militar no exercício da função civil. Os militares da ativa, como os em situação de inatividade, poderão ocupar cargos, empregos ou função pública.

Quanto ao *militar da ativa*, há que distinguir, como o faz a Constituição (art. 142, II e III), se é cargo público civil *permanente*, ou se é

17. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969, t. III/400.

18. Cf. Lei 5.774/71, que dispõe sobre a inatividade dos militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

cargo, emprego ou função pública temporária, e, sendo deste último tipo, se é eletivo ou não eletivo.

Se o militar da ativa for empossado em *cargo público civil permanente* (cargo de provimento em caráter efetivo), será imediatamente transferido para a reserva (art. 142, II). Se aceitar cargo, emprego ou função pública *temporária, não eletiva*, ainda que da Administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo reformado depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não. *Reforma* é a situação de inatividade (aposentadoria) definitiva do servidor militar, e é isso que quer dizer o art. 142, III, quando fala em transferência para a inatividade, após dois anos de *reserva* que também é inatividade. Se o *cargo for eletivo*, deverá: (a) *afastar-se da atividade*, se contar menos de dez anos de serviço (art. 14, § 8º, I, da Constituição); não se diz como e em que caráter se afastará da atividade, se para a reserva ou reforma; caberá à lei, prevista no inc. X do art. 142, resolver a questão; (b) *se contar mais de dez anos de serviço*, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade (reforma). É de observar, contudo, que o militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos políticos (art. 142, V).

Perda da patente e do posto militar. O oficial das Forças Armadas só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial em tempo de guerra (art. 142, VI).¹⁹

Tribunal militar permanente é o constante da organização judiciária preconstituída, integrante do Poder Judiciário, como são os Tribunais e Juízes Militares previstos nos arts. 92, VI, e 122, competentes para processar e julgar os crimes militares.

A *indignidade* e a *incompatibilidade* para com o oficialato dependem de declaração de um desses tribunais nas circunstâncias previstas. A mera *condenação a pena restritiva da liberdade* não induz, só por si, a perda da patente e do posto. Se o militar for condenado pela *justiça comum* ou *militar* à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento perante tribunal militar permanente em tempo de paz ou tribunal especial em tempo de guerra, para o fim de ser eventualmente declara-

do indigno do oficialato, ou com ele incompatível, com a consequência da perda da patente e do posto (art. 142, VII). Vê-se, por aí, que a condenação à pena restritiva de liberdade por mais de dois anos *não implicará perda da situação militar, mas importará no julgamento de indignidade e de incompatibilidade*. O tribunal militar não estará, contudo, obrigado a admitir estas, só por causa da condenação. A natureza do crime apenado é que levará à apreciação e reconhecimento da indignidade ou incompatibilidade e, portanto, à perda da patente e do posto. Se a condenação for a pena inferior a dois anos, não caberá o procedimento de apuração da indignidade e da incompatibilidade para com o oficialato, nem, por conseguinte, da perda da patente e do posto.

Finalmente, ao militar, como vimos, são proibidas a sindicalização e a greve (art. 142, IV).

18. Direitos trabalhistas extensivos aos servidores militares

Enfim, para terminar, cumpre apenas lembrar que os militares percebem remuneração em forma de subsídio, por força do art. 144, § 9º, introduzido pela EC-19/98, e que o art. 142, VIII, determina que são aplicáveis aos militares o disposto no art. 7º, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, ou seja: décimo-terceiro salário; salário-família; gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; licença a gestante (existem mulheres militares), sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias; e licença-paternidade.

19. Já discutimos o conceito de *tempo de paz* e *tempo de guerra* na nota n. 19 do cap. IV do tit. II da Segunda Parte.

Título V

Bases Constitucionais das Instituições Financeiras

Capítulo I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

I. DISPOSIÇÕES GERAIS DA TRIBUTAÇÃO: 1. Questão de ordem. 2. Componentes. 3. Empréstimo compulsório. 4. Contribuições sociais. 5. Normas de prevenção de conflitos tributários. 6. Elementos do sistema tributário nacional. II. LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR: 7. Poder de tributar e suas limitações. 8. Princípios constitucionais da tributação e sua classificação. III. DISCRIMINAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RENDAS TRIBUTÁRIAS: 9. Natureza e conceito. 10. Sistema discriminatório brasileiro. IV. DISCRIMINAÇÃO DAS RENDAS POR FONTES: 11. Atribuição constitucional de competência tributária. 12. Competência tributária da União. 13. Competência tributária dos Estados. 14. Competência tributária dos Municípios. V. DISCRIMINAÇÃO DAS RENDAS PELO PRODUTO: 15. Repartição de receitas e federalismo cooperativo. 16. Técnicas de repartição da receita tributária. 17. Normas de controle e disciplina da repartição de receita tributária.

I. DISPOSIÇÕES GERAIS DA TRIBUTAÇÃO

1. Questão de ordem

A Constituição diz mal quando intitula de *princípios gerais* a seção I do capítulo I do título VI, referindo-se ao *sistema tributário nacional*. Não há nela senão os princípios da personalização e o da capacidade contributiva, constante do art. 145, § 1º. Os princípios constitucionais gerais, especiais e específicos da tributação aparecem mesmo é na seção II, como expressão das limitações do poder de tributar.

Na primeira seção, o que temos são disposições gerais sobre a tributação, que sintetizam as bases constitucionais do sistema tributário nacional.

2. Componentes

O *sistema tributário nacional* compõe-se de *tributos*, que, de acordo com a Constituição, compreendem os *impostos*, as *taxas* e a *con-*

tribuição de melhoria (art. 145). Disso se conclui que ele cuida de três espécies tributárias: os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria, das quais o termo *tributo* é o gênero. Considera-se como tal *toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada, que não constitua sanção de ato ilícito* (CTN, art. 3º). Chama *fato gerador* a situação que faz nascer a obrigação de pagar a importância pecuniária correspondente.

Imposto é o *tributo* cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica em favor do contribuinte ou relativa a ele. Isso quer dizer que o imposto é uma prestação pecuniária que incide sobre fatos descritos em lei só pela atuação do contribuinte. Daí provêm os diferentes tipos de impostos discriminados nos arts. 153, 155 e 156.

Taxas são *tributos* cuja obrigação tem por fato gerador o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. À diferença do imposto, como se nota, o fato gerador da taxa é uma situação dependente de atividade estatal: o exercício do poder de polícia ou a oferta de serviço público ao contribuinte. São cobradas pela União, Estados, Distrito Federal e Município em razão dos respectivos poderes de polícia ou dos respectivos serviços públicos prestados ou postos à disposição do contribuinte.

A *contribuição de melhoria* é o *tributo* cuja obrigação tem por fato gerador a valorização de imóveis do contribuinte em decorrência da execução de obras públicas pela União, Estados, Distrito Federal ou Município.

3. Empréstimo compulsório

O *empréstimo compulsório* só pode ser instituído pela União, mediante lei complementar, *para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de desastre ambiental, de guerra externa ou sua iminência e no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional*. O *empréstimo compulsório para investimento* (art. 148, II) não poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o houver instituído. Um dos requisitos de legitimidade deste empréstimo é a *urgência* do investimento que financiará, mas a Constituição, incoerentemente, impede sua arrecadação imediata, ao vedar sua cobrança no mesmo exercício de sua instituição. O *empréstimo*, para os fins do art. 148, I, não está sujeito a essa limitação, como se expressa o § 1º do art. 150, num contexto em que se concebe o empréstimo compulsório como tributo – acolhendo, assim, a posição da doutrina dominante, diante do que me rendo, embora

entenda que a melhor concepção seria mesmo a de *contrato de empréstimo de direito público*.

4. Contribuições sociais

Também é da competência exclusiva da União instituir *contribuições sociais*, de *intervenção no domínio econômico* e de *interesse das categorias profissionais ou econômicas*, como instrumento nas respectivas áreas. Temos aí, portanto: (a) *contribuições sociais*, como as da seguridade social e previdenciária (arts. 195, I a III, e 201), as do PIS/PASEP (art. 239), as do seguro-desemprego (art. 239, § 4º), entre outras que a União poderá instituir por lei; (b) *contribuições de intervenção no domínio econômico*, como o chamado *confisco do café*, as do Instituto do Açúcar e do Alcool etc.; (c) *contribuições de interesse das categorias profissionais*, assim as contribuições às entidades dos profissionais liberais, as contribuições sindicais previstas no final do inc. IV do art. 8º; não, porém, a que cabe à assembléia geral instituir para custeio do sistema confederativo da representação sindical referida no mesmo inciso que, por isso, não é instituída pela União. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o art. 149, conforme redação das EC-33/2001 e 42/2003, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportações, mas incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços e poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível; poderão ter alíquotas *ad valorem*, tendo por base o faturamento bruto ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro, ou alíquota específica, tendo por base a medida adotada, equiparando-se, para tais efeitos, a pessoa natural destinatária das operações à pessoa jurídica, nos termos da lei, que também definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Essa Emenda ainda introduz o § 4º do art. 177 para dizer que a contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos (a) a alíquota da contribuição poderá ser: (a.1) diferenciada por produto ou uso; (a.2) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, a; (b) os recursos arrecadados serão destinados: (b.1) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; (b.2) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; (b.3) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transporte. Mantida essa destinação, 29% dos recursos assim arrecadados serão

distribuídos, na forma da lei, aos Estados e Distrito Federal (EC-44/2004, modificando nesse aspecto a EC-42/2003, que previa uma distribuição de 25%, cf. p. 731). Tratamos da matéria aqui porque, certamente, no art. 177 ela estaria deslocada, já que se trata de problema fiscal.

A Constituição autoriza os Estados, Distrito Federal e Municípios a instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, ou seja, o regime de previdência de caráter contributivo e solidário. São *contribuições previdenciárias* de competência dessas entidades, cuja alíquota, contudo, não poderá ser inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Essa regra veio da EC-41/2003 que, por essa imposição, restringe inconstitucionalmente a autonomia dessas entidades federativas (art. 60, § 4º, I).

Essas contribuições submetem-se ao regime das normas gerais tributárias, ao princípio da reserva de lei e ao princípio da anualidade (lei prévia ao exercício em que serão cobradas). Significa dizer: não podem ser instituídas nem aumentadas senão por lei e não podem incidir senão sobre fatos geradores e exercício financeiro posteriores à sua instituição (arts. 146, III, e 150, I e III). Contudo, as contribuições da seguridade social (art. 195, I a III) não se subsumem ao disposto no art. 150, III, b, porque o art. 195, § 6º, lhe dá outro regime, prevendo que poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído. A doutrina entende que todas essas contribuições compulsórias têm natureza tributária, reputadas como *tributos para-fiscais*, ou seja, tributos cuja arrecadação é da competência de entidades paraestatais ou autárquicas.

5. Normas de prevenção de conflitos tributários

Estamos chamando assim à disciplina normativa, por *lei complementar* e por *resoluções do Senado Federal*, da matéria tributária.

A *lei complementar* é requerida sete vezes no capítulo do sistema tributário nacional.¹ Isso não quer dizer que seja necessária, para cada ocorrência, uma delas. A rigor, trata-se de uma lei complementar apenas, que é o Código Tributário Nacional, mas, por sua desatualização, outras devem surgir para situações específicas e sua reelaboração.

É, pois, função da *lei complementar tributária*: (1) dispor sobre *conflitos de competência*, em matéria tributária, entre a União, os Estados,

1. Cf. arts. 146, 148, 153, VII, 154, I, 155, XII, 156, III, e 161.

Distrito Federal e Municípios; (2) regular as *limitações* constitucionais do *poder de tributar*; (3) estabelecer *normas gerais* de direito tributário sobre: (a) definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados na Constituição, aos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; (b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; (c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas (art. 146); (d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II; das contribuições previstas no art. 195, I, e §§ 12 e 13; e da contribuição a que se refere o art. 239; (4) *instituir outros impostos da União*, desde que sejam não-cumulativos e não tenham nem fato gerador nem base de cálculo idênticos aos discriminados nos arts. 153, 155 e 156; (5) *em relação ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços*: (a) definir seus contribuintes; (b) dispor sobre a substituição tributária; (c) disciplinar o regime de compensação do imposto; (d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços; (e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos semi-elaborados mencionados no art. 155, X, a; (f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e mercadorias; (g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados; (6) *em relação aos impostos municipais*: (a) fixar suas alíquotas máximas e mínimas do imposto sobre serviços de qualquer natureza; (b) excluir de sua incidência as exportações de serviços para o exterior; (c) regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados; (7) *em relação à repartição de receitas tributárias*: (a) definir valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, para o fim de fixar a quota dos Municípios, tendo em vista as operações tributadas nos respectivos territórios, na forma prevista no art. 158, parágrafo único, I; (b) estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inc. I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios; (c) dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários (Estados, Distrito Federal ou Municípios), do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159; (8) instituir um *regime único* de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

observado que: (a) será opcional para o contribuinte; (b) poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (c) o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; (d) a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes (EC-42/2003).

A EC-42/2003 criou também o art. 146-A, com o seguinte teor: “Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. O que o dispositivo quer dizer é que a lei complementar, no caso, situada no âmbito do sistema tributário, não exclui a competência que o art. 173, § 4º, dá à lei ordinária para reprimir o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Como é fácil verificar, cuida-se de uma normatividade complexa que complementa as normas constitucionais do sistema tributário nacional. Aí se encontra o conteúdo do Código Tributário Nacional. Muita coisa já consta dele e permanece em vigor. Outras, porém, demandam nova lei complementar que venha regular a matéria pertinente.

O *Senado Federal*, por via de resoluções aprovadas ora por maioria absoluta ora por dois terços de seus membros, desempenha papel importante na prevenção de conflitos tributários. Não é novidade da Constituição vigente. Desde a de 1934, ele vem recebendo incumbências nessa área, o que se acentuou com a Constituição de 1967.

O campo de atuação das resoluções do Senado Federal, em matéria tributária, circunscreve-se ao disposto no art. 155, § 2º, IV e V, e § 6º. O primeiro prevê que resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, *estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação*. Aqui, a resolução do Senado é requerida de modo peremptório. É, porém, facultativo o estabelecimento de *alíquotas mínimas*, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada por maioria absoluta de seus membros, assim também a *fixação de alíquotas máximas*, nas mesmas operações, para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros. É incompreensível esse jogo de circunstâncias: quando a resolução é de iniciativa de um terço dos membros, sua aprovação será da maioria absoluta deles; quando de iniciativa da maioria absoluta, inverte-se: a aprovação deverá

ser por dois terços. O § 6º do art. 155 foi incluído pela EC-42/2003 para atribuir ao Senado Federal também a fixação das alíquotas mínimas do imposto sobre propriedade de veículos automotores.

6. Elementos do sistema tributário nacional

Distinguem-se no sistema tributário nacional os seguintes elementos fundamentais, além das disposições gerais (arts. 145 a 149): (a) as limitações constitucionais do poder de tributar (arts. 150 a 152); (b) a discriminação da competência tributária, *por fontes* (arts. 153 a 156); (c) as normas do federalismo cooperativo, consubstanciadas nas disposições sobre a repartição das receitas tributárias, *discriminação pelo produto* (arts. 157 a 162).

II. LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

7. Poder de tributar e suas limitações

Embora a Constituição diga que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais do poder de tributar (art. 146, II), ela própria já as estabelece mediante a enunciação de *princípios constitucionais da tributação*. Tais princípios são plenamente eficazes, no sentido de não dependerem daquela lei complementar para sua incidência direta e imediata aos casos ocorrentes. A lei complementar poderá apenas estabelecer restrições à sua eficácia e aplicabilidade; no caso, não será *rigorosamente lei complementar*, pois não integra a eficácia das normas que contêm aqueles princípios; ao contrário, será lei restritiva da eficácia e aplicabilidade de referidas normas, que, por isso, se transformaram em verdadeiras *normas de eficácia contida*.²

8. Princípios constitucionais da tributação e sua classificação

O sistema tributário nacional subordina-se a vários princípios, que configuram garantias constitucionais dos contribuintes, conforme reconhece o art. 150, sem prejuízo de outras, e, em contrapartida, constituem limitações ao poder de tributar.³ Expressam-se em forma de vedações constitucionais às entidades tributantes. Podemos clas-

2. Para o conceito de normas constitucionais de eficácia contida, cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, 2ª ed., São Paulo, RT, 1982, pp. 91 a 105.

3. Cf. Aliomar Baleeiro, *Limitações constitucionais ao poder de tributar*, 5ª ed., Rio, Forense, 1977; Victor Uckmar, *Princípios comuns de direito constitucional tributário*, São Paulo, EDUC/RT, trad. de Marco Aurélio Greco, 1976; Fritz Neumark, *Principios de la imposición*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, trad. de José Zamit Ferrer, 1974.

sificá-los em: (a) *princípios gerais*, porque referidos a todos os tributos e contribuições do sistema tributário; (b) *princípios especiais*, previstos em razão de situações especiais; (c) *princípios específicos*, porquanto pertinentes a determinado tributo; (d) *imunidades tributárias*.

(A) *Princípios gerais*. Os princípios gerais são expressos ou decorrentes.

São expressos:

(A.1) *princípio da reserva de lei ou da legalidade estrita*, segundo o qual é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça (art. 150, I), mas a Constituição admite a alteração, por decreto, das alíquotas dos impostos sobre importação, exportação, produtos industrializados e operações financeiras, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei (art. 153, § 1º), o que vale dizer, ainda, respeito ao princípio da legalidade genérica;

(A.2) *princípio da igualdade tributária*, estabelecido no art. 150, II, veda às referidas entidades tributantes instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; a norma se refere a qualquer tributo, mas é mais expressivamente dirigida aos impostos pessoais e ao de renda; em relação a este, contudo, há que se levar em conta a regra da progressividade agora constitucionalizada no art. 153, § 2º, I. Aqui se cuida da igualdade “em sentido jurídico, como paridade de posição, com exclusão de qualquer privilégio de classe, religião e raça, de modo que os contribuintes, que se encontrem em idêntica situação, sejam submetidos a idêntico regime fiscal”, que coincide com a *generalidade da imposição*⁴ e que, para realizar a justiça fiscal, depende de ser complementado com a *igualdade em sentido econômico*, fundada no princípio da capacidade contributiva, que é nosso tema seguinte;

(A.3) *princípio da personalização dos impostos e da capacidade contributiva*, agora expressamente consignado no art. 145, § 1º, pelo qual, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à Administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. O *princípio da capacidade contributiva*, segundo o qual o ônus tributário deve se distribuído na medida da capacidade econô-

4. Cf. Victor Uckmar, *ob. cit.*, p. 54.

mica dos contribuintes, implica: (a) uma base impositiva que seja capaz de medir a capacidade para suportar o encargo; (b) alíquotas que igualem verdadeiramente esses ônus. A dificuldade está, dissemos de outra feita,⁵ na determinação correta da "capacidade tributária individual", como salienta Hugh Dalton.⁶ A doutrina fixou alguns critérios para isso, como o de "sacrifício igual", o de "sacrifício proporcional", o de "menor sacrifício" e o de "não altere a desigualdade das rendas, pela tributação".⁷ Mas o princípio tem o importante significado, destacado por Victor Uckmar, na medida em que reafirma "o princípio ou preceito da *igualdade* de posições dos cidadãos diante do dever tributário de prover às necessidades da coletividade", que implica "distribuição equânime dos ônus tributários".⁸ Recordamos o que certa vez escrevemos: "A justiça fiscal é ainda um ideal a ser alcançado, não por si só, mas em conexão com um sistema de justiça econômica e social". E concluímos: "A tentativa para basear um justo sistema fiscal sobre um injusto sistema de propriedade é, como disse uma vez Wicksell, uma tentativa para tirar uma parcela boa de um todo mau";⁹

(A.4) *princípio da prévia definição legal do fato gerador ou princípio da irretroatividade tributária*, de acordo com o qual é vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado (art. 150, III, *a*); isso, combinado com o princípio da anualidade comentado em seguida, significa que o tributo ou seus aumentos somente incidem sobre fatos geradores que ocorrerem no exercício financeiro seguinte ao de sua instituição ou majoração, ressalvadas as exceções constitucionalmente estabelecidas (*infra*);

(A.5) *princípio da anualidade do lançamento do tributo*, segundo o qual o lançamento dos tributos está vinculado a cada *exercício financeiro* (1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano), o que tem importância para a situação temporal do fato gerador da obrigação tributária; mas ele não está mais condicionado ao requisito da prévia autorização orçamentária, como foi tradicional no nosso ordenamento constitucional; apenas se liga agora à anterioridade da lei criadora ou majoradora do tributo, em relação ao exercício financeiro em que

5. Cf. nosso *Tributos e normas de política fiscal na Constituição do Brasil*, São Paulo, 1968, p. 88.

6. Cf. *Princípios de finanças públicas*, Rio de Janeiro, FGV, trad. de Maria de Lourdes Modiano, 1960, p. 79.

7. *Idem*, *ibidem*.

8. *Ob. cit.*, pp. 70 e 71.

9. Cf. nossa *ob. cit.*, p. 91; a citação é de Gunnar Myrdal, *Aspectos políticos da teoria econômica*, Rio de Janeiro, Zahar, trad. de José Auto, 1962, p. 206.

deverá ser cobrado, como dispõe o art. 150, III, *b*, que, no entanto, não se aplica ao empréstimo compulsório previsto no art. 148, I, nem aos impostos sobre importação, exportação, produtos industrializados, operações financeiras e impostos extraordinários, previstos nos arts. 153, I, II, IV e V, e 154, II, nem tampouco às contribuições de seguridade social, previstas no art. 195, § 6º. Quer dizer: estes tributos, excluídos da incidência do princípio, podem ser instituídos, aumentados e cobrados no curso do exercício financeiro.

(A-6) *princípio da carência*, segundo o qual é vedado cobrar tributos antes de decorridos *noventa dias* da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; mas esse prazo de carência não exclui a aplicação do princípio da anterioridade da lei. Ao contrário, ele só se aplica aos tributos que estão sujeitos a esse princípio. Vale dizer: aqueles tributos, que, por força do art. 150, III, § 1º, podem ser instituídos, aumentados e cobrados no curso do exercício financeiro; também estão excluídos daquele prazo de carência, assim como também o está a fixação da base de cálculo dos impostos sobre a propriedade de veículos automotores (art. 155, III) e sobre a propriedade predial e territorial urbana (art. 156, I). Em suma, estão *sujeitos* ao princípio da anterioridade da lei em relação ao exercício financeiro, assim como ao prazo de carência de noventa dias: os impostos federais sobre a renda, a propriedade territorial rural e sobre grandes fortunas, as taxas e contribuição de melhoria; todos os impostos, taxas e contribuição de melhoria estaduais e todos os impostos, taxas e contribuição de melhoria municipais, incluindo a impropriamente chamada contribuição de iluminação e de limpeza pública.

(A.7) *princípio da proporcionalidade razoável*, regra que veda utilizar tributo com efeito de confisco. Isso, na verdade, significa que o tributo não deve subtrair mais do que uma parte razoável do patrimônio ou da renda do contribuinte. Baleeiro já o tinha como princípio implícito no direito de propriedade, constitucionalmente garantido, ao declarar que dentre "os efeitos jurídicos do art. 153, §§ 1º, 11 e 22, se inclui o da proibição de tributos confiscatórios, como tal entendidos os que absorvem parte considerável do valor da propriedade, aniquilam a empresa ou impedem exercício da atividade lícita e moral".¹⁰

(A.8) *princípio da ilimitabilidade do tráfego de pessoas ou bens*, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público (art. 150, V). Essa é uma regra complementar do direito à livre circulação de pessoas e de bens. O pedágio não era considerado tribu-

10. *Ob. cit.*, p. 262. A referência de Baleeiro ao art. 153, §§ 1º, 11 e 22, remete à Constituição de 1969.

to, mas uma forma de preço público. Agora, ao fazer a ressalva dele em relação aos tributos, fica ainda maior dúvida quanto à sua natureza. Enfim, ele está efetivamente no limiar do conceito de tributo, tudo dependendo de se dar, ou não, razoável opção aos usuários quanto a outra via não sujeita ao pedágio; mas, na medida em que se expande a todas as rodovias, sua caracterização tributária se acentua.

São princípios gerais decorrentes:

(A.9) *princípio da universalidade*, decorrente da norma do art. 19, III, significa que todo aquele que praticar o fato gerador da obrigação tributária deverá pagar o tributo respectivo, salvo casos expressos de isenção fiscal outorgada em lei que especifique as condições e os requisitos para sua concessão; lembra-se que a Constituição menciona expressamente a *universalidade* e a *generalidade* apenas em relação ao imposto sobre a renda (art. 153, § 2º, I). Se fosse aplicável só a ele, seria um princípio específico, mas sendo uma regra que dimana do regime constitucional que veda fazer distinções entre brasileiros (art. 19, III), têm-lo como aplicável a qualquer tributo, não só ao imposto sobre a renda; mas, por certo que, prevendo-o especificamente para esse imposto, isso tem consequências especiais, como não admitir isenções senão também gerais e universais; quer dizer, se se dá isenção para determinado tipo ou classe de rendimento, todas as pessoas que auferem-no também ficam isentas;

(A.10) *princípio da destinação pública dos tributos*, mencionado por Baleeiro como *princípio implícito*, com a observação de que só para o Estado se tributa; não há tributo privado; “não o diz a Constituição, mas está implícito que esse poder extremo e fundamental corresponde aos encargos com o funcionamento dos serviços públicos, ou exercício das atribuições em que são investidas as três órbitas governamentais”.¹¹

(B) *Princípios especiais*. Constituem-se das vedações constantes dos arts. 151 e 152, que assim se discriminam:

(B.1) *princípio da uniformidade tributária*, segundo o qual é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País (art. 151, I). É princípio que se aplica aos tributos federais em geral e ao imposto sobre produtos industrializados em

particular. Ele encerra um sentido especial de política fiscal federalista. Não fosse assim, poderia ser que a União estabelecesse distinção ou preferência entre produtos vindos de uns Estados ou Municípios em detrimento de outros. A uniformidade geográfica da tributação federal mereceu críticas, por ser insustentável tal regra num país em que as desigualdades geoeconômicas são tão marcantes,¹² situação que, ao contrário, requer tratamento diferenciado, a fim de que se possa executar uma política fiscal niveladora da economia nacional; sente-se, dissemos em outro trabalho, que o tratamento uniforme de situações disformes contribui ainda mais para a deformação existente e para agravar as desigualdades regionais.¹³ O dispositivo constitucional em causa agora acolhe essas ponderações com o admitir incentivos destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

(B.2) *princípio da limitabilidade da tributação da renda das obrigações da dívida pública estadual ou municipal e dos proventos de agentes dos Estados e Municípios*, contido no art. 151, II, que veda à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações. Com a regra de que o imposto sobre a renda há de atender os critérios da generalidade e da universalidade (art. 153, § 2º, I), praticamente seria dispensável a reafirmação do princípio ora em exame;

(B.3) *princípio de que o poder de isentar é insito ao poder de tributar*, segundo o qual quem tem o poder de impor determinado tributo é que tem o poder de estabelecer isenções. Esse, na verdade, é um princípio geral da tributação, que foi rompido pelo regime constitucional anterior que atribuía à União o poder de estabelecer isenções de impostos estaduais ou municipais em certas circunstâncias. Pois bem, agora vem o art. 151, III, e se dirige à União (daí a inclusão aqui do princípio) *para proibi-la de instituir isenções de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios*. É uma reação ao sistema anterior, sem necessidade, pois, para recuperar o princípio, bastava não autorizar a União a instituir isenções de tributos dessas entidades tributantes. A regra do art. 155, § 2º, XII, g, que prevê que a lei complementar regule a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções e outros benefícios sejam concedidos, não contraria o princípio, porque são as

12. Cf. Antônio Sampaio Dória, *Discriminação de competência impositiva*, São Paulo, 1975, p. 185.

13. Cf. nosso opúsculo *Sistema tributário nacional*, São Paulo, IBDT/Resenha Tributária, 1975, pp. 28 e 29.

próprias entidades tributantes que vão deliberar sobre o assunto; mas se exige agora, por força do § 6º do art. 150, acrescido pela EC 3/93, que esses benefícios só podem ser concedidos mediante lei específica;

(B.4) *princípio da não-diferenciação tributária*, de acordo com o qual é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino (art. 152).

(C) *Princípios específicos*. Referem-se a determinados impostos especificamente, e assim se apresentam:

(C.1) *princípio da progressividade*, referido expressamente ao imposto sobre a renda (art. 153, § 2º, I) e ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (arts. 156, § 1º, e 182, § 4º, II). Imposto progressivo é aquele cuja alíquota aumenta à medida que aumenta o ingresso ou a base imponible;

(C.2) *princípio da não-cumulatividade do imposto*, aplicável aos impostos sobre produtos industrializados e sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços (arts. 153, IV, § 3º, II, e 155, II, e § 2º, I), segundo o qual será compensado o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Na prática, isso se faz mediante um sistema de crédito, pelo qual o contribuinte se credita de todo o imposto que pagou ao adquirir os produtos (ou matéria-prima, no caso do IPI) ou mercadorias ou serviços (no caso do ICMS) em dado espaço de tempo (um mês, p. ex.) fixado em lei, ao mesmo tempo em que debita todo o imposto incidente sobre as saídas dos produtos ou mercadorias do seu estabelecimento no mesmo período, e no momento de recolher os impostos do período é feita a compensação entre o crédito e o débito, recolhendo ele a diferença a mais ou continuando com crédito para o período seguinte se o crédito foi maior. Vale dizer, em cada operação o imposto incide efetivamente sobre o valor adicionado;

(C.3) *princípio da seletividade do imposto*, aplicável obrigatoriamente ao imposto sobre produtos industrializados, nos termos do art. 153, IV, e § 3º, I, segundo o qual esse imposto será seletivo em função da essencialidade do produto, sendo facultada a sua aplicação ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, em função da essencialidade desses objetos (art. 155, § 2º, III), o que permite o estabelecimento de alíquotas diversas para esses produtos, mercadorias e serviços tributados, tendo em vista sua *necessidade, utilidade e superfluidade*, fatores que caracterizam genericamente graus de *essencialidade*. Logo, não mais existe o *princípio*

da uniformidade da alíquota próprio do ICMS, princípio oposto ao da seletividade.

(D) *Imunidades*. As *imunidades fiscais*, instituídas por razões de privilégio, ou de considerações de interesse geral (neutralidade religiosa, econômicas, sociais ou políticas), excluem a atuação do poder de tributar. Nas hipóteses imunes de tributação, inócorre fato gerador da obrigação tributária. Nisso diferem imunidades e isenções, pois, relativamente a estas, dá-se o fato gerador da obrigação tributária, mas o contribuinte fica apenas isento do pagamento do tributo. As imunidades configuram privilégios de natureza constitucional e não podem estender-se além das hipóteses expressamente previstas na Constituição, que, em seu art. 150, VI, veda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituir impostos sobre: (a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (é a chamada *imunidade recíproca*); (b) templos de qualquer culto; (c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. Note-se que só existe imunidade quanto aos impostos.¹⁴ Ela não beneficia as taxas, nem a contribuição de melhoria nem as demais contribuições fiscais ou para-fiscais. Há outras *imunidades específicas*, que se acham nos dispositivos constitucionais sobre *não incidência* de determinado imposto em hipóteses indicadas; onde a Constituição começa um dispositivo com a norma “não incidirá”, temos uma imunidade: “não incidirá” o imposto previsto no art. 153, IV (§ 3º, III), sobre produtos industrializados destinados ao exterior: “não incidirá” o imposto territorial rural sobre pequenas glebas rurais (art. 153, § 4º); “não incidirá” o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços nas operações referidas no art. 155, § 2º, X; “não incide” o imposto municipal de transmissão de bens imóveis sobre a transmissão mencionada no art. 156, § 2º, I.

III. DISCRIMINAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RENDAS TRIBUTÁRIAS

9. Natureza e conceito

O sistema tributário brasileiro assenta-se na técnica de discriminação das rendas entre as entidades autônomas da Federação.

14. Há, porém, segundo anota Walter Barbosa Corrêa, um exemplo de imunidade aplicável à taxa, no art. 5º, XXXIV, referente ao direito de petição e de obtenção de certidão, independente do pagamento de taxa. Ai, de fato, a Constituição exclui a incidência da taxa. Torna imune desse tributo o fato indicado.

Sistema tributário e discriminação de rendas são, porém, conceitos inconfundíveis. Aquele constitui-se do conjunto dos tributos existentes em um Estado, considerado seja nas suas recíprocas relações, seja quanto aos efeitos globalmente produzidos sobre a vida econômica e social.¹⁵ Existirá em todo Estado, sem consideração de sua estrutura formal. A discriminação de rendas, ao contrário, constitui um dos aspectos nucleares da disciplina jurídica do Estado federal.¹⁶ É elemento da divisão territorial do poder político. Insere-se na técnica constitucional de repartição de competência.

Mas, no federalismo brasileiro, a técnica constitucional de discriminação de rendas difere fundamentalmente do sistema de repartição de poderes. A Constituição adotou, como nas anteriores, uma discriminação exaustiva, integral e completa. Contemplou, rígida e taxativamente, as quatro entidades autônomas da Federação: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A cada uma conferiu competência expressa para instituir impostos, taxas e contribuição de melhoria. Estabeleceu a privatividade tributária e tornou evidentemente exclusivo de cada esfera o tributo que lhe foi destinado. E essa atribuição não pode ser modificada por lei ordinária nem por lei complementar. Excepcionalmente admitiu a competência residual e a de necessidade, reservando à União, no art. 154, o poder de instituir: (1) *outros impostos*, mediante lei complementar, desde que não tenham fato gerador nem base de cálculo idênticos aos discriminados nos arts. 153, 155 e 156 e desde que sejam não-cumulativos; (2) *impostos extraordinários* na iminência ou no caso de guerra externa.

10. Sistema discriminatório brasileiro

A discriminação das rendas — acabamos de ver — envolve a competência material tributária de natureza federativa. Significa dizer que não haverá discriminação de rendas sem atribuição de poder tributante às entidades regionais e locais autônomas. A partir daí, a experiência histórica registra vários sistemas discriminatórios, rígidos, flexíveis,

15. Cf. Pierre Beltrame, *Les systèmes fiscaux*, Paris, PUF, 1975; Amílcar de Araújo Falcão, *Sistema tributário brasileiro*, Rio de Janeiro, Ed. Financieiras, 1965, p. 27; Rubens Gomes de Sousa, "O sistema tributário federal", *RDA* 72/5; Gérson Augusto da Silva, *Sistema tributário brasileiro*, 2ª ed., Rio de Janeiro, 1948, p. 45.

16. Cf. Amílcar de Araújo Falcão, *ob. cit.*, p. 9. Assim também Aliomar Baleeiro, *Discriminação de rendas*, Rio de Janeiro, Ed. Financieiras, 1953, p. 7; A. R. Sampaio Dória, *ob. cit.*, p. 15; Pinto Ferreira, *Princípios gerais do direito constitucional moderno*, 6ª ed., v. II/921 e ss., São Paulo, Saraiva, 1983; Pedro Manso Cabral, *Alguns problemas na discriminação de rendas no Brasil*, Salvador, Progresso, p. 14, ao contrário, sustenta que ela "se manifesta nos países unitários" também.

mistos de partilha de fontes próprias e distribuição de receitas, ou fontes próprias para umas entidades e adicionais para outras.¹⁷

O sistema brasileiro evoluiu para uma discriminação rígida e exaustiva, como vimos. Combina a outorga de competência tributária exclusiva, por fonte, designando expressamente os tributos de cada esfera governamental (União, Estados e Municípios, notando-se que ao Distrito Federal cabem os mesmos dos Estados e Municípios cumulativamente), com o sistema de participação no produto da receita tributária de entidade de nível superior.

Aí temos os dois aspectos da discriminação das rendas: a *discriminação pela fonte*, pela qual a Constituição indica o tributo que a cada entidade compete instituir (arts. 153, 155 e 156), e a *discriminação pelo produto*, pela qual umas entidades repartem sua receita com outras, ou, vendo do outro lado, estas participam na receita daquelas (arts. 157 a 162). "Da primeira diz-se ser originária porque toda a legislação tributária material (portanto, o esquema qualitativo e quantitativo da obrigação fiscal) provém do órgão que efetua a arrecadação e se apropria de seu resultado, dentro dos parâmetros traçados pela Constituição. A última se pode qualificar como derivada, porquanto a entidade beneficiada não recebe poder tributário direto, mas sim o produto de seu exercício atribuído à competência alheia."¹⁸ A *discriminação pela fonte* realiza-se em três planos: (a) *competência exclusiva*; (b) *competência nominalmente comum*; (c) *competência residual*, enquanto a *discriminação pelo produto* comporta as seguintes modalidades: (a) a *participação em impostos de decretação de uma entidade e percepção por outras*; (b) a *participação em impostos de receita partilhada segundo a capacidade da entidade beneficiada*; (c) *participação em fundos*.¹⁹

IV. DISCRIMINAÇÃO DAS RENDAS POR FONTES

11. Atribuição constitucional de competência tributária

A competência tributária é discriminada pela Constituição entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Compreende a competência legislativa plena, e é indelegável, salvo as funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária e outras de

17. A propósito, cf. Carvalho Pinto, *Discriminação de rendas*, São Paulo, Prefeitura Municipal, 1943, pp. 45 e ss., onde estudou os vários critérios da discriminação de rendas.

18. Cf. A. R. Sampaio Dória, *ob. cit.*, pp. 19 e 20.

19. Vê-se que seguimos A. R. Sampaio Dória, *ob. cit.*, pp. 20 e 21, com alguma diferença.

cooperação entre essas entidades públicas, conforme dispuser lei complementar (art. 23, parágrafo único).

Desde logo, fique acertado que ao Distrito Federal cabem os impostos estaduais e municipais, além das taxas de polícia e de serviços e, ainda, a contribuição de iluminação pública (EC-39/2002), assim como as mesmas participações nas receitas federais que são repartidas aos Estados ou ao Fundo de Participação dos Estados (arts. 147, 155, 157, 159, I, a, e II e seus parágrafos), assim como à União competem, em Territórios Federais, os impostos estaduais e, se eles não forem divididos em Municípios, cumulativamente os impostos municipais, de sorte que não precisamos mencionar Distrito Federal e Territórios (que, aliás, não existem mais) nas considerações subseqüentes.

12. Competência tributária da União

(A) *Tributos de competência exclusiva da União.* É de competência exclusiva da União instituir impostos em seguida indicados com suas características básicas, além do imposto extraordinário por motivo de guerra, do *empréstimo compulsório* já estudado (art. 148) e as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e no interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, também discutidas antes (art. 149). Vejamos os impostos.

(1) *Impostos sobre o comércio exterior.* A competência tributária exclusiva da União começa pela *tributação do comércio exterior* (art. 153, I e II), que compreende o imposto sobre a *importação* de produtos estrangeiros e o imposto sobre a *exportação*, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados, que são especialmente utilizados como instrumentos de política econômica, daí por que se lhes dá certa flexibilidade ao admitir a alteração de suas alíquotas pelo Poder Executivo; por isso são pouco empregados para fins fiscais de suprimimento de tesouraria, embora tenham sido, no Império, impostos de grande rentabilidade.

(2) *Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza* (art. 153, III). É o imposto mais importante e mais rentável do sistema tributário nacional; na sua concepção entram toda disponibilidade econômica ou jurídica proveniente do rendimento do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, assim como todo acréscimo ao patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas; é “um imposto que, além de captar receita adequada para os cofres públicos, é capaz, graças à flexibilidade de sua incidência, de promover a expansão econômica e corrigir as desigualdades da distribuição da renda social entre os

indivíduos e entre as regiões do País”,²⁰ mas não tem sido assim entre nós, pois sua administração fá-lo incidir mais onerosamente sobre as classes média-baixa e média-alta do que sobre as classes de rendas mais elevadas. É informado pelos critérios da *generalidade*, da *universalidade* e da *progressividade*, nos termos da lei, já estudados, e não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja renda seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho.

(3) *Imposto sobre produtos industrializados.* É um importante imposto de competência federal; é *tributação da produção industrial*, no sentido de que recai sobre o resultado do processo produtivo industrial, mas o é também sobre o consumo, porque só alcança o produto no momento em que sai do estabelecimento industrial ou equiparado para integrar o processo consuntivo, embora não seja o ato de consumo a situação geradora da obrigação tributária. Os princípios que o regem já foram vistos: *não-cumulatividade* e *seletividade*. Faculta-se ao Poder Executivo alterar suas alíquotas por decreto (art. 153, § 1º), visto como é um tributo que pode ser usado para consecução de resultados econômicos, já que seus valores integram a composição dos preços dos produtos tributados. Pela mesma razão a lei poderá reduzir seu impacto sobre a aquisição de bens de capital por seu contribuinte (EC-42/2003).

(4) *Imposto sobre operações financeiras.* É o nome sintético de um complexo de incidência tributária, constante do art. 153, V, que dá competência à União para instituir *impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários*. O campo de incidência, portanto, abrange: *operações de crédito, operações de câmbio, operações de seguros e operações relativas a títulos e valores mobiliários*. São utilizados como instrumentos de política monetária, daí por que também está prevista a faculdade de o Poder Executivo alterar suas alíquotas, a fim de lhes dar flexibilidade com o objetivo de ajustá-los à conjuntura monetária e inflacionária em cada momento, assim como à política de câmbio (art. 153, § 1º). A *tributação do ouro*, quando este é definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, fica sujeita ao mesmo regime tributário dos impostos sobre operações financeiras, sendo o imposto devido apenas na operação de origem, mediante alíquota mínima de um por cento, cabendo a sua arrecadação, por transferência, na proporção de trinta por cento aos Estados,

20. Exposição de Motivos ao Anteprojeto da Emenda 18 à Constituição de 1946.

Distrito Federal ou Territórios, conforme a origem, e setenta por cento ao Município de origem; portanto, sobre o ouro, nessas condições, não incidirá o imposto sobre circulação de mercadorias, nem o imposto sobre produtos industrializados; fora dessas condições a tributação por outros impostos é regular.

(5) *Imposto sobre a propriedade territorial rural*. É um dos impostos sobre o patrimônio. É de competência da União para funcionar como instrumento auxiliar da política agrária. Por essa razão é que será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, que, assim, contrariam sua função social (art. 184). Dele estão *imunes* (porque nelas não incidirá) as pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel (art. 153, § 4º).

Embora de competência da União, será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia (EC-42/2003), caso em que terão direito à totalidade da receita do imposto, e não apenas a metade (art. 158, II).

(6) *Tributação de grandes fortunas*. O art. 153, VII, confere um imposto novo à competência exclusiva da União: o *imposto sobre grandes fortunas*, que depende de definição por lei complementar. Será um imposto, se criado e bem administrado, de real importância para a redistribuição de rendas. Mas tem lá suas dificuldades. Veremos como a lei complementar vai instituí-lo e regulá-lo.

(7) *CPMF*. Seu nome todo é: *contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e débitos de natureza financeira*. Disse-se “provisória”, mas vai-se tornando definitiva por via de prorrogações sucessivas, sendo a última, até 31.12.2007, pelo art. 91 do ADCT, criado pela EC-42/2003. Foi instituída pela Lei 9.311/1996 autorizada pelo art. 74, incluído pela EC-12/1996 entre as Disposições Transitórias da Constituição. Seu fato gerador são as diversas formas de movimentação financeira ou transmissão de valores por instituições financeiras, tais como lançamento de débitos ou créditos em contas correntes, liquidação ou pagamentos de créditos etc. A base de cálculo é o valor movimentado ou transmitido. A alíquota inicial era de vinte centésimos por cento da base de cálculo. Subiu para trinta e oito centésimos por cento. É tributo de grande liquidez, de fácil arrecadação, de difícil sonegação e talvez o único que incide sobre a economia informal.

(B) *Tributos de competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios*. Assim são tidas as taxas e contribuição de melhoria, no sentido que veremos em sequência.

Taxas. Entram no conceito de tributo comum, porque todas as entidades tributantes podem instituí-las e arrecadá-las: (a) em razão do exercício do poder de polícia; e (b) pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição (art. 145, II), e não podem ter base de cálculo própria de impostos. Quando se diz que é um *tributo comum* à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, deve-se ter isso do ponto de vista *nominal*, porque, embora seja certo que assim se chama o tributo com fatos geradores semelhantes, ele deixa de ser comum, para se tornar privativo, na medida em que incide sobre exercício de poder de polícia e prestação de serviços que são próprios e privativos de cada uma daquelas entidades tributantes.

Contribuição de melhoria. Também é da competência da União instituí-la e cobrá-la em razão da valorização da propriedade imóvel decorrente de obras públicas por ela executadas (art. 145, III). A Constituição não entra em pormenores sobre o tributo como faziam as Cartas anteriores. Limita-se a dizer que à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios compete instituir contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Melhor assim. Deixa mais flexibilidade para cada entidade defini-la em função de sua realidade. É igualmente considerada tributo *comum*, mas também ela se torna privativa na medida que cada entidade tributante só poderá lançá-la sobre imóveis valorizados por suas próprias obras.

(C) *Tributos de competência residual*. Pertine, com exclusividade, à União instituir, mediante lei complementar, outros impostos que não tenham fato gerador nem base de cálculo idênticos aos impostos expressamente discriminados na Constituição, consoante vimos antes, e não podem ser cumulativos (art. 154, I).

13. Competência tributária dos Estados

(A) *Tributos de competência exclusiva dos Estados e do Distrito Federal*. São os impostos que indicaremos em seguida com seus elementos básicos.

(1) *Tributação da herança e das doações*. São dois os modos de transmissão da propriedade. O primeiro pela morte do titular do bem; é a *transmissão causa mortis*. O segundo pela liberalidade do dono do bem que o transmite a outrem gratuitamente, ato que também sofre a tributação, como forma de transmissão da propriedade móvel ou imóvel *inter vivos*. É garantido o direito de herança (art. 5º, XXX). Em compensação, fica ela sujeita ao imposto previsto no art. 155, I, segundo o qual compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre transmissão *causa mortis* e *doação*, de quaisquer bens ou

direitos. A Constituição anterior só autorizava a tributação da transmissão de bens imóveis, o que era injusto. O imposto, quando incidente sobre *imóveis e direitos* a eles relativos, compete ao Estado da sua situação; quando incidir sobre *móveis, títulos e créditos*, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador; terá competência para instituí-lo o Estado indicado em lei complementar, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se o *de cujus* (isto é, aquele que faleceu deixando herança) possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Por outro lado, suas alíquotas máximas serão fixadas pelo Senado Federal (art. 155, § 1º, IV). A Proposta de Emenda Constitucional 41/2003 dava nova redação ao inc. IV do § 1º do art. 155 estabelecia que o imposto sobre transmissão *causa mortis* (imposto sobre herança) seria *progressivo*, o que seria conveniente e justo, como vigorou nos Estados até 1965; o imposto comporta dois tipos de progressividade: uma em relação ao monte da herança: quanto maior, mais graduada a alíquota; outra em relação à distância das vocações hereditárias de modo que, quanto mais distante, mais gravosa a tributação. Sustentamos, nas edições anteriores, a possibilidade de o Senado fixar alíquotas progressivas, mas diante da rejeição daquela proposta, tenho que admitir que a Constituição não o autoriza.

(2) *Tributação da circulação das mercadorias*. É o agora conhecido ICMS, previsto no art. 155, II, segundo o qual compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Fato tributável é a operação sobre circulação de mercadorias, a entrada da mercadoria em circulação. Fato tributável é a operação sobre circulação de mercadorias; o momento do fato gerador pode ser: a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, o fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes ou similares, o desembaraço aduaneiro de mercadoria importada do exterior, ou o início de transportes terrestres, aéreos, aquáticos ou por outras vias, ou o ato final do transporte iniciado no exterior, ou a prestação onerosa de serviços de comunicação e outros, nos termos de lei complementar (LC-87/1996). É imposto complexo, cercado de voltas e contravoltas, de incidências e não incidências, de controles e mais regras de prevenção de conflitos entre Estados e de duplas incidências. Já vimos que é informado pelos princípios da não-cumulatividade e da seletividade (facultativa).

Sobre *mecanismos de fixação de suas alíquotas* em operações ou prestações, interestaduais e de exportação, e sobre alíquotas mínimas e

máximas nas *operações internas*, já nos manifestamos com base no art. 155, § 2º, IV e V, quando tratamos das normas de prevenção de conflitos tributários de competência do Senado Federal, por via de resolução (n. 5, supra), notando-se que, em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: (a) a *alíquota interestadual* quando o destinatário for contribuinte do imposto, ou seja, quando, por exemplo, o destinatário for um comerciante, um industrial ou um produtor, caso em que a diferença entre aquela alíquota interestadual cobrada pelo Estado de origem e a alíquota interna do Estado do destino será cobrada por este, pois que na técnica do tributo as alíquotas internas são mais elevadas; (b) a *alíquota interna* do Estado de origem da mercadoria, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, como é o caso, por exemplo, de uma remessa de alguma mercadoria para uma pessoa não comerciante, não industrial ou não produtor, que vai consumi-la por si. Mas, a *base de cálculo* sobre a qual incidem as alíquotas não compreenderá o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos; quer dizer, por exemplo, se o industrial A vende para o comerciante B geladeiras ao preço de 100, incluídos neste 10 de IPI, o ICMS será cobrado apenas sobre 90 (100 - 10), mas se A vende geladeira para C, consumidor final, ao preço de 100, incluídos 10 de IPI, o ICMS, que também incide na hipótese, é cobrado sobre o total 100.

A Constituição determina que o ICMS incida sobre: (a) a *entrada de bens ou mercadoria importada do exterior* por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade, assim como sobre os serviços prestados no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; resolve a controvérsia que deu origem a uma jurisprudência distorcida contra o interesse dos Estados; (b) o *valor total da operação*, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência dos Municípios; se o serviço for compreendido na competência municipal, o ICMS incide sobre a operação de circulação da mercadoria, e o imposto municipal sobre serviços; (c) operações relativas a *energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais* do País, objetos estes que só eram tributados, no regime constitucional anterior, pela União, mediante os chamados impostos únicos.

Finalmente, vêm as *regras de não incidência*. Por força do disposto no art. 155, X o imposto não incide: (a) sobre *operações* que destinem

mercadorias *para o exterior*, ou sobre *serviços prestados a destinatários no exterior*, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores (EC-42/2003); (b) sobre *operações* que destinem a *outros Estados* petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica; (c) o *ouro*, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º, já examinadas; (d) nas prestações de *serviço de comunicação* nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita (EC-42/2003).

Além de tudo isso, ainda se comete à lei complementar regular, definir, prever, fixar, excluir, dispor a respeito de situações relativas ao ICMS, que indicamos antes (n. 5, *supra*), agora com acréscimos e novas previsões especialmente sobre a tributação de combustíveis e lubrificantes, gás natural e derivados, introduzidos pela EC-33/2001.

(3) *Tributação de veículo automotor*. É o imposto que está previsto no art. 155, III, segundo o qual compete aos Estados instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores.²¹ Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, e poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização do veículo.

(B) *Tributos comuns*. São as taxas e contribuição de melhoria que, já vimos, podem ser cobradas também pelos Estados e Distrito Federal, tal como a União e os Municípios (art. 145, II e III).

14. Competência tributária dos Municípios

(A) Compete *exclusivamente* aos Municípios instituir os impostos adiante nomeados.

(1) *Tributação da propriedade urbana*. É o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (art. 156, I), que representa o gravame fiscal da propriedade imóvel, com ou sem edificação, localizada na zona urbana ou com destinação urbana. A EC-29/2000, dando nova redação ao § 1º do art. 156, solucionou a dúvida que surgiu quanto à *progressividade* nele originariamente prevista. Nas edições anteriores sustentamos que a progressividade desse parágrafo não se confundia com a prevista no art. 182, § 4º. Agora, aquela Emenda veio esclarecer a questão, dispondo que, sem prejuízo da progressividade no tempo referida no art. 182, § 4º, inc. II, o imposto sobre a propriedade urbana poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel, assim como poderá ter alíquota diferenciada de acordo com a localiza-

ção e o imóvel, possibilitando, assim, a aplicação de política fiscal de interesse urbanístico. A progressividade no tempo prevista no art. 182, § 4º, constitui sanção pelo não atendimento de regular e específica exigência do Poder Público Municipal ali indicada.

(2) *Tributação das transmissões de bens imóveis*. Uma forma de transmissão de bens (móveis ou imóveis), por herança ou doação, como vimos, é tributada por imposto estadual. Aqui, temos o imposto sobre as transmissões de bens *inter vivos*, a qualquer título, por ato oneroso (o que exclui as doações, tributadas pelos Estados), de *bens imóveis* (terrenos, casas, fazendas etc.), por natureza ou acessão física, e de *direitos reais sobre imóveis*, exceto os de garantia (hipoteca), bem como *cessão de direitos a sua aquisição*, que compete ao Município da situação do bem, mas que, no entanto, *não incide* sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

(3) *Tributação dos serviços*. Já vimos que alguns serviços são tributados pelo ICMS. Importa sabê-lo, porque a previsão do *imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza*, definidos em lei complementar, expressamente os exclui (art. 156, III). Trata-se aqui do ISS que já vem desde a Emenda 18/65 à Constituição de 1946. Não é a Constituição que indica os serviços tributáveis pelo ISS. Isso ela remeteu à lei complementar, que já existe, e faz a definição mediante uma lista de serviços. À lei complementar também cabe fixar suas *alíquotas máximas e mínimas*, excluir de sua incidência as exportações de serviços para o exterior, assim como regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados (EC 37/2002).²²

(B) *Tributos comuns*. São, como já sabemos, as taxas e contribuição de melhoria, que os Municípios podem instituir e cobrar do mesmo modo que a União e os Estados (art. 145, II e III).

(C) *Contribuição de iluminação pública*. Os Municípios, como o Distrito Federal, podem instituir, mediante lei, contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública, observados os princípios constantes do art. 150, I a III. Essa contribuição tem caráter retributivo dos serviços prestados, com a natureza de taxa. Por isso, se é para o custeio dos serviços, os contribuintes terão, no mínimo, o direito de

21. A Constituição previa ainda, para os Estados, um *adicional no imposto de renda* que foi eliminado pela EC 3/93, a partir de 1.1.96, reduzida sua alíquota a pelo menos 2,5% em 1995.

22. A EC 3/93 eliminou da competência municipal a tributação das vendas a varejo de combustíveis, a partir de 1.1.96, reduzida sua alíquota pelo menos a 1,5% em 1995.

saber o valor do seu custo, para verificarem se não se estará cobrando mais do que o necessariamente devido. Iluminação pública não é fato adequado à incidência de contribuição específica. Seu custo teria de ser suportado por recursos provenientes de imposto, já que é um serviço público geral e indivisível, de interesse de toda a comunidade e não só dos moradores das vias públicas.

V. DISCRIMINAÇÃO DAS RENDAS PELO PRODUTO

15. Repartição de receitas e federalismo cooperativo

Vimos já que o sistema discriminatório da Constituição combina a atribuição de fontes próprias com a técnica de participação de uma entidade na receita tributária de outra, ou técnica da distribuição ou *repartição da receita tributária*, que é a *discriminação das rendas pelo produto*.

Essa cooperação financeira entre as entidades autônomas da Federação, chamada *federalismo cooperativo*, integra a fisionomia do federalismo contemporâneo.²³ Ela só começou a desenvolver-se, em termos constitucionais, entre nós, a partir da Constituição de 1934 (art. 9º), mas foi a Carta de 1937 que inaugurou a prática da participação na receita de tributos (Lei constitucional 4/40). A Constituição de 1946 ampliou a técnica de cooperação financeira, que a Constituição de 1967 procurou racionalizar. Essas experiências são acolhidas pela Constituição de 1988 com expansão e aperfeiçoamento.

16. Técnicas de repartição da receita tributária

Predomina o critério da repartição em favor da entidade participante, mas é possível distinguir três modalidades de participação: (a) a *participação em impostos de decretação de uma entidade e percepção por outras*, caso em que os recursos, arrecadados pela própria entidade beneficiada, integram, desde logo, o seu patrimônio (arts. 157, I, e 158, I); (b) a *participação em impostos de receita partilhada segundo a capacidade da entidade beneficiada*, caso em que a participação se realiza por meio de uma percentagem no produto da arrecadação, coletada pela entidade titular do poder tributante, e devolvido o *quantum* respectivo às entidades beneficiadas, porque a elas pertence de direito, e pode ser exigido até judicialmente; (c) *participação em fundos*, caso em que a entidade beneficiada tem uma expectativa de receber certa quantia do fundo, conforme critério de redistribuição geográfica de

rendas que tais fundos visam realizar.²⁴ Vejamos como tudo isso está regulado na Constituição.

(A) *Participação no produto de impostos de decretação da União e percepção dos Estados, Distrito Federal e Municípios*, hipótese em que o poder tributante cabe à União, mas o produto da arrecadação percebido pelas outras entidades a elas pertence; são as formas de participação previstas nos arts. 157, I, e 158, I, segundo os quais *pertence aos Estados, Distrito Federal e Municípios* o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, *incidente na fonte*, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

(B) *Participação no produto de impostos de receita partilhada segundo a capacidade da entidade beneficiada*, hipótese em que a Constituição reparte o montante do imposto em percentagens entre a entidade tributante e a entidade beneficiada, de sorte que esta receberá sua percentagem à vista de circunstâncias a ela vinculadas. Assim é que está previsto que: (1) *pertencem aos Municípios*: (a) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial-rural, *relativamente aos imóveis neles situados*; quer dizer, tributados os imóveis rurais, segundo a alíquota e tudo mais pela lei federal, os Municípios têm direito a cinquenta por cento do montante arrecadado nos respectivos territórios, mas se o Município optar pela fiscalização e a cobrança do imposto por si próprio, terá direito à totalidade do produto do imposto (art. 158, II, e art. 153, § 4º); (b) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores *licenciados em seus territórios*; aqui também a percentagem que cabe a cada Município fica na dependência do volume de licenças de veículo em seu território (art. 158, III); (c) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (art. 158, IV); neste caso, as parcelas pertencentes aos Municípios serão creditadas conforme os seguintes critérios (art. 158, parágrafo único): (c.1) três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, *realizadas em seus territórios*; (c.2) até um quarto, de acordo com o que dispuser a lei estadual ou, no caso de Território, a lei federal; (d) aplicados estes mesmos critérios, também cabem aos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que os

23. Cf. Raul Machado Horta, *A autonomia do Estado-membro no direito constitucional brasileiro*, Belo Horizonte, 1964, pp. 267 e ss.

24. Cf. A. R. Sampaio Dória, *ob. cit.*, p. 21.

Estados receberem nos termos do art. 159, II, e § 3º, conforme indicado a seguir; (2) *pertencem aos Estados e Distrito Federal* dez por cento do imposto sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. A EC-44/2004 introduziu modificação no inc. III nesse art. 159 para determinar que seja distribuída aos Estados e Distrito Federal, na forma da lei, 29% do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, modificando, neste particular, a redação da EC-42/2003. Como se vê, as emendas vão quebrando a sistemática da Constituição. Aqui introduziu o parcelamento de contribuição social num esquema que só se aplicava aos impostos (cf. p. 708).

(C) *Participação em fundos*, conforme está previsto no art. 159, que determina que, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento serão entregues pela União na seguinte forma: (a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao *Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal* — FPE, excluindo do cálculo a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, Distrito Federal e Municípios (arts. 157, I, e 158, II), referida na letra A supra; (b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao *Fundo de Participação dos Municípios* — FPM; (c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer.

17. Normas de controle e disciplina da repartição de receita tributária

Cabe à lei complementar, consoante vimos, estabelecer regras e disciplina do sistema de repartição de receitas, impondo-se ao Tribunal de Contas da União a tarefa de efetuar o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação.

Veda-se a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego das receitas repartidas aos Estados, Distrito Federal e Municípios, compreendidos os adicionais e acréscimos relativos a impostos (art. 160). Significa isso que os recursos recebidos, por transferência de

receitas, por todas as formas de participação estudadas acima, pertencem, sem limitação, às entidades beneficiadas, que os podem utilizar do modo que lhes parecer melhor. Mas tal vedação não impede que a União e os Estados condicionem a entrega de recursos: a) ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; b) ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, II e III (EC-29/2000: aplicação pelos Estados e Municípios de percentagem do produto de impostos e transferências).

Para fins de controle, da população inclusive, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio, com a exigência de que os dados divulgados pela União sejam discriminados por Estado e por Municípios, e também Distrito Federal; os dos Estados, por Município.

Capítulo II

DAS FINANÇAS PÚBLICAS E DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

I. NORMAS SOBRE FINANÇAS PÚBLICAS: 1. Colocação do tema. 2. Normas gerais. 3. Função do banco central. II. ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS: 4. Instrumentos normativos do sistema orçamentário. 5. Orçamento-programa. III. PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS: 6. Conteúdo dos orçamentos. 7. Formulação dos princípios orçamentários. 8. O princípio da exclusividade. 9. O princípio da programação. 10. O princípio do equilíbrio orçamentário. 11. O princípio da anualidade. 12. O princípio da unidade. 13. O princípio da universalidade. 14. O princípio da legalidade. 15. Princípios da não-vinculação e da quantificação dos créditos orçamentários. IV. ELABORAÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS: 16. Leis orçamentárias. 17. Processo de formação das leis orçamentárias. 18. Rejeição do projeto de orçamento anual e suas consequências.

I. NORMAS SOBRE FINANÇAS PÚBLICAS

1. Colocação do tema

A Constituição abre um capítulo para as *finanças públicas*, nele cuidando de normas gerais sobre dívida pública, emissão de moeda, função do banco central e do sistema orçamentário. Esse será o conteúdo de nossas considerações aqui.

2. Normas gerais

O art. 163 declara que a *lei complementar* disporá sobre: (1) *finanças públicas*, que é uma expressão de ciência especulativa e não normativa, e por isso tem como conteúdo o estudo especulativo não jurídico da despesa e da receita públicas, do orçamento e do crédito públicos; (2) *dívida pública externa e interna*, incluídas as autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público, de onde se vê que se dá aí uma abrangência elástica da expressão dívida pública; (3) *concessão de garantias da dívida pública*; (4) *emissão e resgate de títulos da dívida pública*, o que já se inclui no inc. II; (5) *fiscalização das instituições financeiras*; (6) operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios; (7) compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.

3. Função do Banco Central

Anteriormente, com base no art. 21, VII, vimos que compete exclusivamente à União *emitir moeda* e a ela cabe legislar sobre sistema monetário. Essas normas se completam com a previsão do art. 164, de conformidade com o qual a sua competência para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo *banco central* (escrito sempre com minúsculo na Constituição, para indicar que se refere a qualquer instituição financeira que exerça as funções de banco central, que, hoje, pelo visto, é o Banco Central do Brasil, mas outrora foi a SUMOC — Superintendência da Moeda e do Crédito do Banco do Brasil), vedado a este conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira; com isso a Casa da Moeda passará a ser uma dependência do Banco Central, a que se faculta, outrossim, a compra e venda de títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.

Por outro lado, as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas hão de ser depositadas em instituições oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.

II. ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS

4. Instrumentos normativos do sistema orçamentário

O sistema orçamentário encontra fundamento constitucional nos arts. 165 a 169. O primeiro desses dispositivos indica os instrumentos normativos do sistema: a *lei complementar de caráter financeiro*, a *lei do plano plurianual*, a *lei de diretrizes orçamentárias* e a *lei orçamentária anual* (lei do orçamento anual).

A lei que instituir o plano plurianual, ou seja, a *lei do plano plurianual* (arts. 165, § 1º, e 166, § 6º), estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. É a lei complementar de caráter financeiro, vista acima, que vai definir vigência, prazos e modo de elaboração do plano plurianual, que é um plano de investimentos, com o qual deverão estar em consonância todos os planos e pro-

gramas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição (arts. 48, IV, e 165, § 4º).

A *lei complementar*, referida, está prevista no § 9º do art. 165, mas dela deveremos cuidar primeiro, dada a sua importância no estabelecimento de normas gerais de direito financeiro, que constituirão os fundamentos para a elaboração dos outros instrumentos normativos do sistema orçamentário. A ela é que cabe dispor sobre o *exercício financeiro*, a *vigência*, os *prazos*, a *elaboração* e a *organização do plano plurianual*, da *lei de diretrizes orçamentárias* e da *lei orçamentária anual*, bem como estabelecer *normas de gestão financeira e patrimonial* da administração direta e indireta, bem como condições para a *instituição e funcionamento de fundos*. É uma lei normativa permanente com característica de lei sobre as leis do sistema, já que todas, que são de caráter temporário, nela deverão fundamentar-se.

A *lei de diretrizes orçamentárias* compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento (art. 165, § 2º). Trata-se de lei anual. Não se estabelece quando ela deve ser submetida à consideração do Congresso Nacional. Dispôs-se apenas que o seu projeto, assim como os da lei do plano plurianual e do orçamento anual, seja enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar de caráter financeiro já indicada. Mas por sua natureza ela deve preceder à elaboração orçamentária, porque ela é que vai dar as metas e prioridades que hão de constar do orçamento anual.

A *lei orçamentária anual* englobará três orçamentos: (1) o *orçamento fiscal* referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; (2) o *orçamento de investimento das empresas* em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; (3) o *orçamento da seguridade social*, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. Mais adiante veremos como ficam os princípios da unidade e da universalidade em face dessa multiplicidade de orçamentos. Cumpre observar que, à vista do disposto nos incs. I e III, poderá haver duplicidade de previsão, porque ambos exigem que sejam abrangidos nos dois orçamentos indicados "órgãos da administração direta ou indireta", bem como "fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público". Corre-se o risco de dis-

torções orçamentárias com esse método, mediante dupla avaliação de uma coisa só.

5. Orçamento-programa

A Constituição institui um sistema orçamentário efetivamente moderno. Abre amplas possibilidades à implantação de um *sistema integrado de planejamento do orçamento-programa*, de sorte que o orçamento fiscal, os orçamentos de investimento das empresas e o orçamento da seguridade social passam a constituir etapas do planejamento de desenvolvimento econômico e social, ou, se se quiser, conteúdo dos planos e programas nacionais, regionais e setoriais, na medida em que estes têm que compatibilizar-se com o plano plurianual que é o instrumento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, que integrarão o orçamento anual, em cada ano, e por ela executadas anualmente.

Trata-se de *planejamento estrutural*, porque todos os planos e programas têm suas estruturas estabelecidas segundo o plano plurianual (art. 165, § 4º). Essa "integração do orçamento público com o econômico [como assinala Alejandro Ramirez Cardona] garante a necessária coordenação entre a política fiscal (intervencionismo indireto) e a política econômica (intervencionismo direto). Em realidade, assim como a política fiscal é parte da política econômica, igualmente o plano financeiro do Estado deve fazer parte do plano econômico do País. E, por outro lado, já que o equilíbrio financeiro nas finanças modernas se há de estabelecer em relação ao equilíbrio econômico geral, aquela integração é absolutamente indispensável".¹ Essa integração, agora bem caracterizada na sistemática orçamentária da Constituição, é que dá configuração à concepção de *orçamento-programa*.

Cumprido, contudo, observar que a integração, referida acima, tem caráter dinâmico, como é próprio das estruturas. Não se trata, por isso, de simples justaposição de planos, mas de uma vinculação permanente e contínua, que não admite interrupção, de sorte que os planos mais gerais ou globais abrangem os mais concretos e a execução destes leva à materialização daqueles.²

1. Cf. *Sistema de hacienda pública*, Bogotá, Themis, 1970, p. 484; nosso *Orçamento-programa no Brasil*, São Paulo, RT, 1973, pp. 71 e ss.

2. Esta é uma observação que já fazíamos na nossa *ob. cit.*, p. 74, citando a publicação do Governo de Minas Gerais, *Orçamento por programa*, p. 23.

III. PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

6. Conteúdo dos orçamentos

Depende da concepção do orçamento a fixação do que deve conter. O certo é que, qualquer que seja ele, entram como seu conteúdo básico a estimativa da receita e a autorização da despesa, que são apresentadas em forma de partidas dobradas em seu aspecto contábil. Mas o orçamento não se define mais como simples “atos de previsão e de autorização de receitas e de despesas públicas”.³ É uma peça de governo muito mais complexa do que isso, porque é o *processo e o conjunto integrado de documentos pelos quais se elaboram, se expressam, se aprovam, se executam e se avaliam os planos e programas de obras, serviços e encargos governamentais, com estimativa da receita e fixação das despesas de cada exercício financeiro*.

Os princípios que informam o orçamento público referem-se uns a seu conteúdo (princípio da exclusividade) e outros à sua forma. Sofreram profunda transformação com a evolução do orçamento clássico para o orçamento-programa, embora nominalmente sejam os mesmos, exceção feita ao princípio da programação, que não poderia existir no orçamento tradicional.

7. Formulação dos princípios orçamentários

Os princípios orçamentários foram elaborados pelas finanças clássicas, destinados, de um lado e principalmente, a reforçar a utilização do orçamento como instrumento de controle parlamentar e democrático sobre a atividade financeira do Executivo e, de outro lado, a orientar a elaboração, aprovação e execução do orçamento.

Eles estão direta ou indiretamente consagrados na Constituição. Não descenderemos a pormenores em sua análise. Limitar-nos-emos a enunciá-los e esclarecê-los tanto quanto baste à sua compreensão do ponto de vista constitucional. Avançar mais seria entrar no campo do direito financeiro, o que ultrapassaria os limites do Direito Constitucional que nos prendem aqui.⁴

Os princípios orçamentários são os seguintes:

- (1) princípio da exclusividade;
- (2) princípio da programação;
- (3) princípio do equilíbrio orçamentário;
- (4) princípio da anualidade;
- (5) princípio da unidade;
- (6) princípio da universalidade ou da globalização;
- (7) princípio da legalidade.

Há outros de menor importância, não constantes da Constituição, mas de leis financeiras. Os autores têm procurado classificar os princípios orçamentários adotando para tanto os critérios mais complicados às vezes, sem nenhuma utilidade para a sua compreensão. Não nos preocuparemos aqui com o tema.⁵

8. O princípio da exclusividade

Esse princípio foi introduzido no Direito Constitucional brasileiro pela Emenda Constitucional de 1926 no § 1º do art. 34 da Constituição de 1891.

Com redação essencialmente idêntica, o texto perdurou nas Constituições posteriores, e assim consta do art. 165, § 8º, da Constituição de 1988, vedando que a *lei orçamentária contenha dispositivo estranho à fixação da despesa e à previsão da receita*, não incluindo, porém, na proibição: (a) a autorização para abertura de créditos suplementares; e (b) a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Piorou aqui a redação, porque “contratação de operações de crédito” não é correto; ou é “contratação de crédito” ou “operações de crédito”; esta é contratação.

Esse princípio decorreu do abuso que se verificava na votação dos orçamentos durante a República Velha, quando, por meio de emendas à proposta do Executivo, Deputados e Senadores introduziam na lei orçamentária matérias absolutamente estranhas ao direito financeiro, o que gerava as chamadas *caudas orçamentárias* ou *orçamentos rabilongos* na expressão de Ruy Barbosa.

O princípio deve ser entendido hoje como meio de evitar que se incluam na lei orçamentária normas relativas a outros campos jurídicos, tais como as que modificam ou ampliam, por exemplo, o Código Civil, o Código Comercial e a legislação de pessoal. Esse é o

3. Ficou famosa a definição de orçamento de René Storm: “o orçamento do Estado é um ato contendo a aprovação prévia das receitas e das despesas públicas”, *Le budget*, 7ª ed., Paris, Librairie Félix-Alcan, 1912, p. 4, que foi completada pelo nosso Amaro Cavalcanti: “o orçamento do Estado é um ato contendo a aprovação prévia da despesa e receita públicas para um período determinado”. Cf. Alberto Deodato, *Manual de finanças públicas*, 10ª ed., São Paulo, Saraiva, 1967, p. 316; Maurice Duverger, *Finances publiques*, Paris, PUF, 1963, p. 205.

4. Para maior profundidade sobre o assunto, nossa *ob. cit.*

5. Quem desejar conhecer as várias classificações oferecidas na doutrina poderá consultar Sebastião Sant’Anna e Silva, *Os princípios orçamentários*, Rio de Janeiro, FGV, 1967, pp. 7 e ss.; Fonrouge, *Derecho financiero*, 2ª ed., v. I/147, Buenos Aires, Depalma, 1970.

objetivo do princípio da exclusividade, que não pode significar impedimento de inclusão de conteúdo programático.

9. O princípio da programação

O orçamento moderno deve ter conteúdo e forma de programação, que implica, em primeiro lugar, a formulação de objetivos e o estudo das alternativas da ação futura para alcançar os fins da atividade governamental; importa, em segundo lugar, na redução dessas alternativas de um número muito amplo a um pequeno e, finalmente, na prossecução do curso da ação adotada através do programa de trabalho.⁶

O princípio da programação orçamentária está ligado, como vimos, ao plano de ação governamental. É exigido pela Constituição, quando vincula os instrumentos normativos orçamentários e os planos e programas nacionais, regionais e setoriais nela previstos (arts. 48, II e IV, e 165, § 4º).

10. O princípio do equilíbrio orçamentário

Este fora a regra de ouro das finanças clássicas. Constituía o princípio fundamental dos orçamentos públicos, verdadeiro axioma. A concepção clássica condenava toda idéia de orçamento desequilibrado, e tomavam-se todas as medidas necessárias para mantê-lo em equilíbrio anual, sem levar em conta seus efeitos sobre a economia em geral.⁷

O equilíbrio do orçamento consubstancia-se na relação de equivalência entre o montante das despesas autorizadas e o volume da receita prevista para o exercício financeiro. Tratava-se, na concepção tradicional, da igualdade matemática entre ingressos e gastos públicos. Nesses termos, fora princípio expresso na Constituição de 1967 (art. 66, § 3º), eliminado pela Emenda 1/69 (Constituição de 1969).

O desequilíbrio orçamentário verifica-se: (a) quando o montante da despesa autorizada for superior à receita estimada, ocorrendo aí o *deficit*; (b) quando a estimativa da receita supera a despesa autorizada, caso em que se tem *superavit*. Ambas as formas eram e ainda são condenadas, mas a primeira é que se tinha (e se tem, ainda) como grave.

6. Cf. David Novick et al., *Programa Budgeting*, 2ª ed., New York, Holt, Rinehart and Winston, 1967, p. 91; Gonzalo Martner, *Planificación y presupuesto por programa*, 2ª ed., México, Siglo XXI Ed., 1969, pp. 54, 55, 256 e ss. e 350 e ss.

7. Cf. Felipe Herrera Lane, *Fundamentos de la política fiscal*, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1965, p. 128.

A Constituição não contempla o princípio do equilíbrio orçamentário, pelo que até se pode dizer, hoje, que ele desapareceu. De fato, desde a grande depressão de 1929, a tese do orçamento anualmente equilibrado passou a sofrer vigorosa contestação, até porque se concluiu que conseguir o *equilíbrio anual* se afigurava coisa impossível, e porque aspirar “a ter nivelado o orçamento anualmente, tanto nos anos bons como nos anos maus, originaria grandes flutuações nos programas governamentais de gastos, seguidas de variações muitas vezes perturbadoras nas alíquotas dos tributos, agravando as flutuações da atividade econômica privada, com todas as implicações”.⁸ A doutrina moderna concebeu outros princípios, com fundamento na análise dos ciclos econômicos, firmando a premissa básica de que não é a economia que deve equilibrar o orçamento, mas o orçamento é que deve equilibrar a economia, levando em conta que a tributação e os gastos públicos constituem mecanismos básicos da política compensatória, que, às vezes, requer uma política de *deficits* fiscais, outras vezes a sua contenção. “Não se pode examinar com uma mente clara e livre de preconceitos [adverte Hansen] a validade de um programa de gastos, empréstimos e impostos, se estivermos sob a influência do dogma de que o orçamento deve estar em equilíbrio”.¹⁰

11. O princípio da anualidade

O orçamento é previsão, programação de atividades e projetos a serem realizados no futuro. Como tal, supõe periodicidade, que tem interesse: (a) *do ponto de vista político*, por conceder ao Congresso Nacional a oportunidade de intervir periodicamente na atividade financeira, quer aprovando a proposta de orçamento para o período seguinte, quer fiscalizando a administração financeira do governo e tomando-lhe as contas; (b) *do ponto de vista financeiro*, porque marca um período durante o qual se efetuam a arrecadação e a contabilização dos ingressos e se comprometem as despesas autorizadas, encerrando as contas públicas em determinado momento; (c) *do ponto de vista econômico*, para o fim de influir nas flutuações dos ciclos econômicos.

O *período anual* tem sido preferido pela maioria das legislações estrangeiras, e é o adotado no Brasil desde a Constituição do Império. Está consagrado na Constituição vigente quando dá destaque e

8. Cf. Mateo Kaufmann, *El equilibrio del presupuesto*, p. 131; nossa *ob. cit.*, pp. 124 e ss.

9. Cf. Felipe Herrera Lane, *ob. cit.*, p. 129.

10. Cf. *Política fiscal y ciclo económico*, 3ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, trad. de Rafael Fernández Maza e Cristóbal Lara, 1970.

conteúdo específico à *lei orçamentária anual* (arts. 48, II, 165, II, e § 5º, e 166).

O princípio da *anualidade* supõe, claro está, o período de tempo de *um ano* para a execução do orçamento, mas não quer dizer que ele coincida com o ano civil.¹¹ No Brasil, como se vê do art. 165, § 9º, I, cabe à lei complementar dispor sobre o *exercício financeiro*, que, atualmente, de acordo com a Lei 4.320/64, vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ano civil, portanto.

Já vimos, no entanto, que a Constituição determina a elaboração do *plano plurianual* que estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública federal para as *despesas de capital e outras delas decorrentes* e para as *relativas aos programas de duração continuada*, que é, como se nota, um plano de investimentos públicos, cujo prazo de vigência vai depender do que dispuser a lei complementar referida no art. 165, § 9º, mas que, por certo, será de três anos para cima. Há mesmo um preceito constitucional, segundo o qual *nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade* (art. 167, § 1º). Pode-se até, a partir daí, reconhecer um novo princípio orçamentário, próprio da técnica de orçamento-programa, qual seja o *princípio da plurianualidade das despesas de investimento*. Isso, contudo, não fura o princípio da *anualidade*, porque as metas e programas e, portanto, as despesas de capital, constantes do plano plurianual, serão executadas *ano a ano* pelo orçamento anual. Significa isso que o *princípio da anualidade* sobrevive e revive no sistema, com caráter dinâmico-operativo, porquanto o plano plurianual constitui regra sobre a realização das despesas de capital e das relativas aos programas de duração continuada, mas não é operativo por si, e sim por meio do orçamento anual.

12. O princípio da unidade

Este foi também um dos mais caros à concepção clássica do *orçamento*, e certamente o mais violado. A exigência de que o *orçamento fosse uno*, como constava do art. 73 da Constituição de 1946 assentava-se em que todas as contas orçamentárias constassem de um só documento e de uma única caixa. Consistia, pois, em apresentar o orçamento de tal forma que fosse suficiente fazer duas somas para

11. Assim, de fato, não o é em vários países: Alemanha e Grã-Bretanha, de 1º de abril a 31 de março do ano seguinte; EUA (orçamento federal), de 1º de julho a 30 de junho. O mais comum, contudo, é a coincidência com o ano civil: Bélgica, Espanha, França, Holanda, Suíça e Argentina.

obterem-se o total das despesas e o total das receitas e uma subtração entre os dois totais para saber se o mesmo continha um equilíbrio, um excedente de receita (*superavit*) ou um *deficit*.

A evolução das tarefas estatais tornou impossível cumprir esse princípio tal como era formulado, porque foram surgindo *orçamentos paralelos* (de autarquias, de entidades paraestatais, de autônômias administrativas etc.). Além disso, apareceu uma multiplicidade de “orçamentos” dentro do orçamento geral, desde a distinção entre *orçamento ordinário* e *orçamento extraordinário*, *orçamento corrente* e *orçamento de capital*, *orçamento anual* e *orçamento plurianual*. Este especialmente veio conturbar o princípio da unidade por sua vinculação a planos de longo prazo (art. 165, § 4º). Então, em lugar da pretensão *unidocumental*, o orçamento moderno, por sua assinalada relação com o planejamento, tornou-se necessariamente *multidocumental*. Em vez da unidade formal, postula-se ainda a *unidade* relativamente ao sistema integrado de *planejamento/orçamento-programa*, realçando-se, em primeiro lugar, a necessidade de que os orçamentos de todos os órgãos do setor público se fundamentem em uma única *política orçamentária*, sejam *estruturados uniformemente* e se ajustem a um *método único*, relacionando-se com o princípio da programação.

“Conclui-se, pois, que o princípio da unidade orçamentária, na concepção do orçamento-programa, não se preocupa com a unidade documental; ao contrário, desdenhando-a, postula que tais documentos orçamentários se subordinem a uma *unidade de orientação política*, numa *hierarquização unitária dos objetivos a serem atingidos e na uniformidade de estrutura do sistema integrado*.”¹²

Essa posição, que consta das edições deste livro anteriores a 1988, foi agora sufragada pela Constituição, sobretudo pela vinculação dos instrumentos orçamentários e planos governamentais, segundo o disposto no art. 165 e seus §§ 1º a 5º, e, neste especialmente, consolidando orçamento fiscal, de investimento das empresas e da seguridade, numa lei orçamentária anual única.

13. O princípio da universalidade

O *princípio da universalidade* foi sempre considerado essencial a uma boa administração orçamentária. Ele se completa com a *regra do orçamento bruto*, de acordo com a qual as parcelas da receita e das despesas devem figurar *em bruto* no orçamento, isto é, sem qualquer dedução. Realiza-se, pois, o princípio da universalidade na exigên-

12. Cf. nossa *ob. cit.*, p. 144.

cia de que todas as rendas e despesas dos Poderes, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta sejam incluídas no orçamento anual geral.

Hoje, o princípio é entendido num sentido menos formal, um pouco diverso do tradicional. O orçamento-programa não o repele. Mantém-no, mas lhe dá nova configuração. Não insiste no requisito puramente formal de que sejam incluídas todas as receitas e despesas, eliminando-se inflexivelmente os “fundos especiais” e a autonomia financeira de certas empresas governamentais. O importante, como nota Amato, é reunir todos os elementos *substantivos* necessários à articulação do programa total do governo; especialmente, um orçamento deve conter explicações sobre os propósitos que o governo deseja lograr, as formas de organização, os métodos de trabalho, as medidas de qualidade, a utilização do pessoal, além das descrições quantitativas dos custos, produtividade, tempo, espaço, receitas e despesas.¹³ Quer dizer que deverão ser incluídos no orçamento os aspectos do programa de cada órgão, principalmente aqueles que envolvam qualquer transação financeira. Assim, a universalidade adquire característica de *totalização*, de *globalização*, transformando-se em *princípio do orçamento global*. Isso se descobre no art. 165, especialmente em seu § 5º, que reúne os orçamentos fiscais, de investimento das empresas e da seguridade social inter-relacionados com o plano plurianual que por sua vez se integra dos planos e programas nacionais, regionais e setoriais, de onde se percebe a íntima vinculação desse princípio com o da unidade há pouco visto.

14. O princípio da legalidade

O *princípio da legalidade* em matéria orçamentária tem o mesmo fundamento do princípio da legalidade geral, segundo o qual a Administração se subordina aos ditames da lei.

Constitui exigência constitucional expressa que leis de iniciativa do Presidente da República estabelecerão: o *plano plurianual*, as *diretrizes orçamentárias* e os *orçamentos anuais* (art. 165); estes são aqueles que integram a *lei orçamentária anual*, a saber: o *orçamento fiscal*, o *orçamento de investimento das empresas* e o *orçamento da seguridade social* (art. 165, § 5º).

Mas o princípio da legalidade em matéria orçamentária não se reduz ao aspecto mencionado. Estende-se também aos planos, pro-

gramas, operações de abertura de crédito, transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma programação para outra ou de um órgão para outro e a instituição de fundos (arts. 48, II e IV, 166, 167, I, III, V, VI e IX).

15. Princípios da não-vinculação e da quantificação dos créditos orçamentários

Juntamos aqui alguns princípios menos expressivos, porque referidos a aspectos parciais dos orçamentos,¹⁴ mas não menos importantes.

O *princípio da não-vinculação* ou da não afetação da receita está traduzido no art. 167, IV, que veda “a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 37, XXII, 198, § 2º, e 212, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo”. Mas não é só, porque o parágrafo único do art. 204 e o § 6º do art. 216 facultam a vinculação de até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida de apoio à inclusão e promoção social e de igual percentagem a fundo de fomento à cultura.

O *princípio da quantificação dos créditos orçamentários*, isto é, quantificação daquilo que o Executivo está autorizado a gastar, é de suma importância para a fiscalização e o controle por parte do Poder Legislativo. Ele está traduzido na *regra que veda a concessão ou utilização de créditos ilimitados* (art. 167, VII), que se completa com outras duas regras que proíbem: (a) a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários; (b) a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Esta última regra tem, ademais, o sentido da boa administração orçamentária, que não comporta operações de crédito para despesas de custeio, salvo as por antecipação da receita, que não é o caso.

A regra que veda a concessão ou utilização de créditos ilimitados impede a fixação da despesa por critério indexado, bem como a autorização para atualização monetária do orçamento, pois em tais

13. Pedro Muñoz Amato, *Orçamentos*, Rio de Janeiro, FGV, trad. de Benedito Silva, 1958, pp. 11 e 12.

14. Cf. nosso *Orçamento-programa no Brasil*, pp. 152 e ss.

casos temos formas de fixação de despesas indefinidas que equivalham a tornar ilimitados os créditos autorizados. Esse princípio está também vinculado ao do orçamento bruto, que só pode materializar-se mediante a quantificação expressa em totais definidos em moeda corrente.

IV. ELABORAÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS

16. Leis orçamentárias

Leis orçamentárias são as previstas no art. 165. Sua formação fica sujeita a procedimentos especiais. Pela sua natureza de leis temporárias, são de *iniciativa legislativa vinculada*, quer isso dizer que, no tempo definido, a autoridade a que se comete o poder de iniciativa delas, que é o Presidente da República por força do disposto nos arts. 165 e 166, terá que tomar as providências necessárias à remessa do respectivo projeto (proposta) ao Congresso Nacional. Além dos artigos citados, é expresso o art. 84, XXIII, ao estatuir que *compete privativamente ao Presidente da República enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos na Constituição*. O art. 166 repete essa determinação acrescentando que essa remessa se faça nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, que, consoante vimos, é que vai fixar o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e organização dessas leis.

17. Processo de formação das leis orçamentárias

Os projetos das referidas leis, assim como as leis de créditos adicionais (especiais e suplementares), serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Recebido o projeto a matéria será submetida à Comissão mista permanente composta de Deputados e Senadores, à qual caberá examiná-lo e sobre ele emitir parecer.

As emendas aos projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e serão apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional. Há, porém, distinção em relação a cada um desses projetos.

Se se tratar de *propostas de emendas ao projeto de lei do orçamento anual* ou a projetos que o modifiquem, somente podem ser aprovadas caso: (1) sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; (2) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, que não se-

jam de dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para Estados, Distrito Federal e Municípios; (3) sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do mesmo projeto.

Se as *emendas se destinarem a modificar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias*, só poderão ser aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual.

Em se tratando do *projeto de lei do plano plurianual*, o processo de emendas se rege pelas regras do art. 63, I, segundo o qual não será admitido o aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º, que se referem às emendas aos projetos de lei do orçamento anual e de diretrizes orçamentárias. O plano plurianual não entra aí. Logo, este não pode sofrer emendas que lhe aumentem as despesas.

Os projetos de leis, aqui referidos, e as propostas de emendas a eles serão votados pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional nos termos do art. 166, aplicadas as demais normas do processo legislativo (arts. 63 a 68), no que não contrariar o disposto nos arts. 165 a 169, podendo, portanto, ser *aprovados*, caso em que subirão à sanção presidencial, ou *rejeitados* (salvo quanto ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias), com o que serão arquivados. O Presidente da República poderá, por seu lado, vetar no todo ou em parte qualquer desses projetos aprovados, seguindo-se a tramitação regular da apreciação do veto nos termos do art. 66.

18. Rejeição do projeto de orçamento anual e suas conseqüências

Começamos por informar que a Constituição não admite a rejeição do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, porque declara, expressamente, que *a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias* (art. 57, § 2º). Mas admite a possibilidade da *rejeição do projeto de lei orçamentária anual*, quando, no art. 166, § 8º, estatui que os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou *rejeição do projeto de lei orçamentária anual*, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Essa possibilidade restitui ao Poder Legislativo uma de suas prerrogativas mais importantes, qual seja a de apreciar, discutir, votar, aprovar ou rejeitar qualquer tipo de projeto de lei. "Não se nega, antes reconhecemos e afirmamos, que é sumamente inconveniente a

rejeição da proposta orçamentária.”¹⁵ É preciso lamentar o que acontece com frequência, no âmbito municipal, em que Vereadores, por puro capricho ou espírito de vingança, rejeitam propostas de orçamento do Prefeito. A rejeição assim não é exercício de prerrogativa, é irresponsabilidade de quem não tem espírito público e jamais será estadista. A rejeição só deve ser praticada em situação extrema de proposta distorcida, incongruente e impossível de ser consertada por via de emendas, dadas as limitações para estas.

A consequência mais séria da rejeição do projeto de lei orçamentária anual é que a Administração fica sem orçamento, pois não pode ser aprovado outro. Não é possível elaborar orçamento para o mesmo exercício financeiro. A Constituição dá a solução possível e plausível dentro da técnica do direito orçamentário: as despesas, que não podem efetivar-se senão devidamente autorizadas pelo Legislativo, terão que ser autorizadas prévia e especificadamente, caso a caso, mediante leis de abertura de créditos especiais.

Capítulo III

DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

I. FISCALIZAÇÃO E SISTEMAS DE CONTROLE: 1. A função de fiscalização. 2. Formas de controle. 3. O sistema de controle interno. 4. O sistema de controle externo. II. TRIBUNAIS DE CONTAS: 5. Instituição do Tribunal de Contas da União. 6. Organização e atribuições do Tribunal de Contas da União. 7. Participação popular. 8. Tribunais de Contas estaduais e municipais. 9. Natureza do controle externo e do Tribunal de Contas. 10. Prestação de contas.

I. FISCALIZAÇÃO E SISTEMAS DE CONTROLE

1. A função de fiscalização

O princípio de que a Administração se subordina à lei — *princípio da legalidade* — revela-se como uma das conquistas mais importantes da evolução estatal. Seria, contudo, ineficaz, se não se previssem meios de fazê-lo valer na prática. A *função de fiscalização* engloba esses meios que se preordenam no sentido de impor à Administração o respeito à lei, quando sua conduta contrasta com esse dever, ao qual se adiciona o *dever de boa administração*,¹ que fica também sob a vigilância dos sistemas de controle.

A função de fiscalização, que surgira com o constitucionalismo e o Estado de Direito implantado com a Revolução francesa, sempre constituiu tarefa básica dos parlamentos e assembléias legislativas. No sistema de separação de poderes, cabe ao órgão legislativo criar as leis, por isso é da lógica do sistema que a ele também se impute a atribuição de fiscalizar seu cumprimento pelo Executivo, a que incumbe a *função de administração*. Por outro lado, no que tange ao aspecto específico que nos interessa aqui — *o do controle da administração financeira e orçamentária* — reserva-se ao Legislativo o poder financeiro, como uma de suas conquistas seculares, pela qual firmara mesmo sua autonomia, sendo, portanto, também de palmar evidência que a ele há de pertencer, em última análise, aquele controle, denominado *controle ex-*

15. Idem, p. 301.

1. Cf. Caio Tácito, “O controle da administração e a nova Constituição do Brasil”, RDA 90/24 (refere-se à Constituição de 1967).

terno, sem embargo de que se erija e desenvolva, na Administração moderna, eficiente sistema de *autocontrole* — o chamado *controle interno* — de que é titular cada um dos Poderes onde ele atua (art. 70).

2. Formas de controle

As expressões *formas de controle*, *tipos de controle* e *sistemas de controle* são empregadas pela doutrina sem muita precisão de sentido.² Vamos, neste passo, indicar essas divergências e citar o sentido em que elas devem ser usadas em face do Direito Constitucional brasileiro.

Quanto à *forma*, o controle orçamentário distingue-se: (1) *segundo a natureza das pessoas controladas*, em controle sobre os administrados e controle sobre os funcionários do serviço de contabilidade, exigindo-se que preste contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome dela, assuma obrigações de natureza pecuniária (art. 70, parágrafo único); (2) *segundo a natureza dos fatos controlados*, em controle contábil, controle financeiro (isto é, sobre as receitas e as despesas), controle operacional (que envolve o controle de resultado) e controle patrimonial (que visa verificar a legitimidade dos acréscimos e diminuições do patrimônio, em face da gestão financeira de cada exercício); (3) *segundo o momento do seu exercício*, em controle *a priori*, controle concomitante e controle *a posteriori*; (4) *segundo a natureza dos organismos controladores*, em controle administrativo (exercido por administradores), controle jurisdicional (exercido por órgãos do Poder Judiciário) e controle político (exercido pelo parlamento e seus prepostos e auxiliares).³

Quanto aos *tipos*, a Constituição reconhece os seguintes (arts. 70 e 74): (1) *controle de legalidade dos atos* de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; (2) *controle de legitimidade*, que a Constituição tem como diverso da legalidade, de sorte que parece assim admitir exame de mérito a fim de verificar se determinada despesa, embora não ilegal, fora legítima, tal como atender a ordem de prioridade estabelecida no plano plurianual; (3) *controle de economicidade*, que envolve também questão de mérito, para verificar se o órgão procedeu, na aplicação da despesa pública, de modo mais econômico, atendendo, por

2. Para se dar conta disso, cf. o nosso *Orçamento-programa no Brasil*, pp. 351 a 354, onde mostramos, p. ex., que Duverger inclui os controles legislativo, jurisdicional e administrativo entre as *formas de controle*, ao passo que Fonrouge os designa de *sistemas de controle*, e Aliomar Baleeiro, *tipos de controle*.

3. Cf. Duverger, *Finances publiques*, p. 323.

exemplo, uma adequada relação custo-benefício; (4) *controle de fidelidade funcional* dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos; (5) *controle de resultados, de cumprimento de programa de trabalho e de metas*, expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

Sistemas de controle financeiro-orçamentário, para a Constituição, são os modos pelos quais o controle é exercido por órgãos externos ou internos da administração controlada (arts. 70, 71 e 74). Vale dizer: a perspectiva para a diferenciação em sistemas de controle é a orgânica e, em função desta, os diferentes modos de seu exercício.

A base da distinção acha-se no art. 70 da Constituição, onde se declara que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta (está mal redigido, porque “da União” já é “da administração direta”) será exercida pelo Congresso Nacional, mediante *controle externo*, e pelo *sistema de controle interno* de cada Poder.

3. O sistema de controle interno

A Constituição estabelece que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, o controle interno. Trata-se de controle de natureza administrativa, exercido sobre funcionários encarregados de executar os programas orçamentários e da aplicação de dinheiro público, por seus superiores hierárquicos: Ministros, diretores, chefes de divisão etc., dentro das estruturas administrativas de qualquer dos Poderes, de sorte que não mais um controle só do Poder Executivo, como diziam as Constituições passadas, e é lógico, porque, se a Constituição alarga a autonomia administrativa dos outros Poderes, é coerente que também exija, de cada um deles, o exercício do controle interno, que tem como uma de suas finalidades apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Realmente, são *finalidades* do controle interno, constitucionalmente estabelecidas (art. 74): (1) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; (2) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; (3) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; e (4) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, por isso é que se exige dos responsáveis pelo controle interno que dêem ciência, ao Tribunal de Contas, de toda e qualquer irregulari-

dade ou ilegalidade de que vierem a ter conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária (art. 74, § 1º).

Embora as formas quanto ao momento de atuação do controle interno não estejam definidas na Constituição, convém relembrar que são três: “*a priori*”, *concomitante* e “*a posteriori*”. A atuação do controle interno varia, admitindo-se diversas maneiras de proceder. O mais seguro é o registro contábil, que é basicamente concomitante com os atos de execução da lei orçamentária; em certos casos, pode ser prévio (*a priori*), como a necessidade de ordem de pagamento que é espécie de controle sobre pagamento de despesa, mas que é também subsequente (*a posteriori*) em relação, por exemplo, à liquidação da despesa.

4. O sistema de controle externo

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, mediante *controle externo*, é coerente com o Estado Democrático de Direito, como se infere destas palavras de Alfredo Cecílio Lopes: “somente quando vigem os princípios democráticos em todas as suas conseqüências — e entre elas das mais importantes é a consagração da divisão dos poderes — e é o orçamento votado pelo povo através de seus legítimos representantes, é que as finanças, de formal, se tornam substancialmente públicas, e a sua fiscalização passa a constituir uma irrecusável prerrogativa da soberania popular”.⁴ Tem por *objetivo*, nos termos da Constituição, a apreciação das contas do Chefe do Poder Executivo, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, a apreciação da legalidade dos atos de admissões de pessoal, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Em suma, verificar da legalidade, da legitimidade e da economicidade dos atos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais da administração direta e indireta da União.

O controle externo é, pois, *função do Poder Legislativo*, sendo de competência do Congresso Nacional no âmbito federal, das Assembleias Legislativas nos Estados, da Câmara Legislativa no Distrito Federal e das Câmaras Municipais nos Municípios com o *auxílio* dos respectivos Tribunais de Contas. Consiste, assim, na atuação da função fiscalizadora do povo, através de seus representantes, sobre a administração financeira e orçamentária. É, portanto, um controle de natureza política, no Brasil, mas sujeito à prévia apreciação técnico-administrativa do Tribunal de Contas competente, que, assim, se apresenta

como órgão técnico, e suas decisões são administrativas, não jurisdicionais, como, às vezes, se sustenta, à vista da expressão “julgar as contas” referida à sua atividade (art. 71, II). A mesma expressão é também empregada no art. 49, IX, em que se dá ao Congresso Nacional competência para *julgar anualmente* as contas prestadas pelo Presidente da República, e nem por isso se dirá que ele exerce função judicante.

II. TRIBUNAIS DE CONTAS

5. Instituição do Tribunal de Contas da União

A tentativa de instituir Tribunal de Contas, no Brasil, por primeira vez foi idéia dos Senadores do Império, Visconde de Barbacena e José Inácio Borges, em 1826. Em 1845, novo projeto no mesmo sentido fora apresentado ao parlamento por Manoel Alves Branco. Se bem que a idéia volvesse com Pimenta Bueno, Silveira Martins, Visconde de Ouro Preto e João Alfredo, o Império não possuiu o seu Tribunal de Contas.⁵

Foi criado, logo no início da República, pelo Decreto 966-A/90, devido à iniciativa de Ruy Barbosa. Institucionalizou-se através do art. 89 da Constituição de 1891, que estatuiu: “É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso”. Daí passou para todas as outras Constituições, que lhe reservaram cada vez mais espaço, encontrando seu ponto alto na Constituição de 1946, onde alcançara grande prestígio, dadas as suas relevantes e independentes atribuições constantes do art. 77.

A Constituição de 1967 e suas alterações posteriores diminuíram substancialmente as prerrogativas do Tribunal, mas a Constituição de 1988 o eleva possivelmente mais além do que fora sob a égide da Constituição de 1946, especialmente porque dera ao Poder Legislativo maiores atribuições. As Cortes de Contas sempre seguem as posições do Poder Legislativo. Quando este está sufocado pelo autoritarismo ou pela perda de atribuições básicas, aquelas sofrem as conseqüências em grau mais profundo. Ora, o princípio da prestação de contas da administração pública, direta e indireta, constante do art. 34, VII, *d*, só tem eficácia de princípio do Estado Democrático enquanto as demais instituições de apuração dessas contas gozarem de autonomia e prestígio para o cumprimento dessa elevada missão, do contrário tudo não passará de mero exercício de formalidades vazias de resultados práticos.

4. Cf. *Ensaio sobre o Tribunal de Contas*, p. 10.

5. Cf. Alfredo Cecílio Lopes, *ob. cit.*, pp. 213 a 217; Pontes de Miranda, *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. III/224 e 225.

6. Organização e atribuições do Tribunal de Contas da União

O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional. Para garantia de sua independência orgânica, a Constituição lhe confere o exercício das competências previstas para os Tribunais judiciais, constantes do art. 96, no que couber, tais como: eleger seus órgãos diretivos; elaborar seu regimento interno; dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos administrativos; organizar sua secretaria e serviços auxiliares; prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração de seus órgãos, salvo, quanto ao concurso, os de confiança assim definidos em lei; conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos servidores que lhe sejam subordinados; propor ao Congresso Nacional a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros, e de serviços auxiliares (art. 73 c/c o art. 96).

Seus *membros*, que recebem a designação de Ministros, são nomeados dentre brasileiros de idoneidade moral e reputação ilibada, de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta anos de idade e com mais de dez anos de exercício de função e de efetiva atividade profissional correspondentes às especialidades indicadas acima. Serão *escolhidos*: (1) *um terço* (três, portanto) pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tripartite pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; (2) *dois terços*, ou seja *seis membros*, pelo Congresso Nacional. Terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos. Vale dizer que são *vitalícios, inamovíveis* e seus *vencimentos serão irredutíveis*, mas lhes é vedado, sob pena de perda do cargo: (a) exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; (b) receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processos sujeitos a seu despacho e julgamento; (c) dedicar-se à atividade político-partidária (art. 95).

Suas *atribuições*, nos termos do art. 71, se incluem num dos seguintes grupos: (1) *emissão de parecer prévio* sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, dentro de sessenta dias a contar de seu recebimento; (2) *julgamento das contas* dos administra-

dores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; não se trata de *função jurisdicional*, pois não julga pessoas nem dirime conflitos de interesses, mas apenas exerce um julgamento técnico de contas; (3) *apreciação, para fins de registro*, da “legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, *incluídas* as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, *excetuadas* as nomeações para cargo de provimento em comissão, *bem como* as das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, *ressalvadas* as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”;⁶ que significa “apreciar, para fins de registro”? Por certo que isso não há de ter sentido puramente cartorário. O texto significa que, se os atos forem legais, o Tribunal determina o registro; se forem ilegais, recusa o registro, assinará prazo para que o órgão ou entidade competente adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 71, IX), corrigindo e invalidando os atos viciados; (4) *inspeção e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial*, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissões técnicas ou de inquérito, nas unidades administrativas de todos os Poderes, quer da administração direta ou indireta, assim como nas fundações e sociedades instituídas ou mantidas pelo Poder Público; (5) *fiscalização* das contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo, assim como da aplicação de qualquer recurso repassado pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; (6) *prestação de informações* solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas ou Comissões, sobre fiscalização de sua competência e sobre resultados de inspeções ou auditorias; (7) *aplicação de*

6. É um texto feio, mal feito e mal redigido. Faz-se um jogo de inclusão e de exclusão confuso. Primeiro, forma-se uma cláusula principal: “apreciar [...] indiretas”, a esta se adere uma cláusula inclusiva: inclusive [...] Poder Público”, e então se exclui algo, por uma cláusula de exclusão de onde, de quê?: “excetuadas [...] comissões”, e aí se apresenta outra cláusula de inclusão, onde, em quê?: “bem como [...] pensões”, e nova cláusula de exclusão: “ressalvadas [...] concessório”. Poderia, para melhorar um pouco, ter sido feito assim: “apreciar, para fim de registro, a legalidade: a) dos atos de admissão do pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta e nas fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão; b) das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”.

sanções previstas em lei aos responsáveis, no caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas; (8) *assinação de prazos* a órgãos ou entidades para providências necessárias ao exato cumprimento da lei, quando verifique ocorrência de ilegalidade de atos ou procedimentos sob seu controle; (9) *sustação da execução de ato impugnado*, se não tomadas, no prazo assinado, as providências para a correção de ilegalidades e irregularidades, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; (10) *representação* à autoridade competente sobre irregularidades ou abusos apurados; (11) *elaboração de relatório* trimestral e anual a ser encaminhado ao Congresso Nacional, conforme consta do art. 71, § 4º.

Não lhe cabe, porém, sustar a execução de contrato. Se constatar ilegalidade ou irregularidade no processo de sua formação ou em qualquer de suas cláusulas, deverá representar ao Congresso Nacional, solicitando a sustação que, no caso, é ato de estrita competência deste. Nem é o caso de o Tribunal se dirigir ao Poder Executivo, pois também cabe ao Congresso solicitar, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Mas, se o Congresso ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivarem as medidas referidas acima, o Tribunal decidirá a respeito (art. 71, §§ 1º e 2º). A Constituição pára por aí, deixando ao intérprete algumas dúvidas. A primeira diz respeito à atitude do Congresso, que não é mero intermediário do Tribunal de Contas, no caso, como a imprecisão da norma pode dar a entender. Na verdade, ao Congresso cabe apreciar e decidir a solicitação de suspensão do contrato. Antes disso, solicita ao Executivo as medidas cabíveis, no prazo assinado. Depois disso, com ou sem as providências do Executivo, decidirá sobre a suspensão. Suspendendo ou não, porque sua decisão não é jurídica, mas política, à vista da oportunidade e da conveniência. Se não suspender, a execução do contrato prossegue. Se suspender, comunicará ao Tribunal de Contas para a responsabilização pertinente. Se o Congresso ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não tomar providências, ou seja, silenciar, aí sim é que cabe ao Tribunal decidir a respeito. Outra questão deixada ao intérprete refere-se ao conteúdo dessa decisão, que, a nós, nos parece ser a da declaração da nulidade do contrato e eventual imputação de débito ou multa com eficácia de título executivo (art. 71, § 3º). E cabe ao Tribunal providenciar a cobrança, determinando à Advocacia-Geral da União o ajuizamento da execução, sob pena de responsabilidade.

Função de controle externo importante desempenha a Comissão mista de Deputados e Senadores, prevista no art. 166, § 1º, de que nos eximiremos de cuidar, porque dela já dissemos o *quantum satis*, quando estudamos o sistema de Comissões parlamentares.

7. Participação popular

Abre-se, agora, ao cidadão, aos partidos políticos, às associações e aos sindicatos a oportunidade de participar do controle externo da Administração Pública, conforme expressamente consta do § 2º do art. 74: "Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União". O parágrafo está mal situado, pois, ligado ao controle externo, está vinculado ao artigo que trata do controle interno. Falha técnica. "Cidadão" é o eleitor. "Na forma da lei" diz o texto, como se para esse tipo de denúncia aquelas partes legítimas dependessem de lei que as autorizasse. Ora, primeiro, existe o direito de petição que independe de lei, e pode ser utilizado no caso; segundo, porque a denúncia poderá ser feita sempre, e o Tribunal a terá na conta que merecer. Será realmente de pasmar se não tomar conhecimento do fato, só porque eventualmente não existe lei que autorize aquela legitimação para agir perante ele. Se ele pode tomar conhecimento e tomar as providências cabíveis *de ofício*, então não há como recusar conhecer da denúncia.

8. Tribunais de Contas estaduais e municipais

A Constituição não prevê, diretamente, a criação de Tribunais de Contas nos Estados. Fá-lo indiretamente, nos arts. 31 e 75. Neste caso, sem deixar dúvidas quanto à obrigatoriedade de instituição de Tribunais de Contas pelos Estados para auxiliar o controle externo da administração direta e indireta estadual que é de competência da respectiva Assembléia Legislativa, já estatuiu que cada Constituição de Estado disporá sobre o respectivo Tribunal de Contas, que será integrado de sete Conselheiros. Uniformiza tudo. Não importa que um Estado tenha trinta milhões de habitantes e uma administração muito complexa e o outro tenha apenas trezentos mil habitantes com administração mais simples. São sete os membros, e acabou. Não são *até* sete. São sete, mesmo que o Estado ache muito.

No Município, a fiscalização, mediante controle externo, será exercida pela Câmara Municipal e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Aqui o controle interno é só do Executivo, não também da Câmara, mas nada impede que a lei o estenda a esta. O controle externo das Câmaras Municipais será auxiliado pelos "Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver". É quase incompreensível o texto, e fica ainda mais difícil quando o § 4º do art. 31 veda a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas

Municipais. Vale dizer, o sentido do texto se extrai da situação existente. Em alguns Estados, o controle das contas municipais é feito com o auxílio do próprio Tribunal de Contas estadual. Isso permanece. Em outros, criou-se um órgão especial para o controle dessas contas, e é o Conselho de Contas Municipais, que é, portanto, órgão estadual. Também perdurará como tal. Apenas dois Municípios possuem seus próprios Tribunais de Contas: o Município de São Paulo e o Município do Rio de Janeiro. Ficaram agora definitivamente institucionalizados por força do texto do art. 31, § 1º.

É a esses Tribunais de Contas estaduais e municipais e aos Conselhos de Contas Municipais (também estaduais) que se dirige o art. 75, para declarar que as normas estabelecidas nos arts. 70 a 74 se aplicam, no que couber, à sua organização, composição e fiscalização, assim como ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.

9. Natureza do controle externo e do Tribunal de Contas

O controle externo é feito por um órgão de natureza política que é o Congresso Nacional (ou as Assembléias Legislativas, nos Estados, e as Câmaras Municipais, nos Municípios). Daí deflui que se contamine de inegável teor político, que é amenizado pela participação do Tribunal de Contas, órgão eminentemente técnico.

Isso denota que o controle externo há de ser primordialmente de natureza técnica ou numérico-legal como diz Ramirez Cardona, com quem concordamos quando preleciona que, "já se trate de um controle técnico ou de uma vigilância meramente política, seu fundamento repousa no fato principal de que corresponde à coletividade, como cidadania ou como contribuinte, não só aprovar mas também vigiar a execução do plano prospectivo de ingressos e gastos na satisfação das necessidades públicas e regulação econômica e social através da atividade financeira". E logo conclui:

"Do Congresso, a quem compete o controle político, emana também o controle técnico ou numérico-legal, que, em realidade, é o mais decisivo. Dada a índole política que define a composição e funções do ramo legislativo do poder público, o controle técnico não pode exercer-se de modo direto por ele ou pelo Parlamento. Para isso institui-se um organismo especializado, chame-se-lhe Corte de Contas ou Controladoria-Geral, com independência do Poder Executivo de modo que se garanta a necessária imparcialidade nesta classe de vigilância da execução orçamentária por parte daquele".⁷

7. Ob. cit., p. 598.

Estamos assim também de acordo que o Tribunal de Contas é um órgão técnico, não jurisdicional. Julgar contas ou da legalidade de atos, para registros, é manifestamente atribuição de caráter técnico.

10. Prestação de contas

A prestação de contas da administração é um princípio fundamental da ordem constitucional brasileira (art. 34, VII, *d*). Todos os administradores e demais responsáveis pelos dinheiros, bens e valores públicos estão sujeitos à prestação e tomada de contas pelo sistema de controle interno, em primeiro lugar, e pelo sistema de controle externo, depois, através do Tribunal de Contas (arts. 70 e 71). Isso se aplica à administração direta e indireta, assim como às fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público. Finalmente, é obrigação constitucional do Presidente da República (como dos Governadores de Estado e Prefeitos Municipais) prestar, anualmente, ao Poder Legislativo, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior, e, se não o fizer, caberá à Câmara dos Deputados (Assembléias Legislativas, nos Estados, e Câmaras Municipais, nos Municípios) proceder à tomada das contas (art. 51, II).

Título VI

Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

Capítulo I

DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO

I. SISTEMA CONSTITUCIONAL DAS CRISES: 1. Defesa do Estado e compromissos democráticos. 2. Defesa das instituições democráticas. 3. Tipos de estados de exceção vigentes. II. ESTADO DE DEFESA: 4. Defesa do Estado e estado de defesa. 5. Pressupostos e objetivo. 6. Efeitos e execução do estado de defesa. 7. Controles. III. ESTADO DE SÍTIO: 8. Pressupostos, objetivos e conceito. 9. Efeitos do estado de sítio. 10. Controles do estado de sítio.

I. SISTEMA CONSTITUCIONAL DAS CRISES

1. Defesa do Estado e compromissos democráticos

O título em exame tem por rubrica "Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas". Nessa dimensão, inclui também um capítulo sobre as Forças Armadas e outro sobre a *segurança pública*. Correlacionando a defesa das instituições democráticas e Forças Armadas é forçoso convir que estas ficaram, na perspectiva constitucional, como instituições comprometidas com o regime democrático inscrito na Constituição de 1988, em termos que já estudamos antes, o que torna mais grave qualquer desvio, ainda que circunstancial, que envolva desrespeito aos direitos fundamentais do homem, incluindo os individuais, os sociais (aí o direito de sindicalização e o de greve), os políticos e de nacionalidade. Nesse mesmo compromisso ficam envolvidos os órgãos da segurança pública.

A *defesa do Estado* aparece expurgada da conotação geopolítica ou da doutrina da segurança nacional que informaram o regime revogado.

Aí defesa do Estado é defesa do território contra invasão estrangeira (arts. 34, II, e 137, II), é defesa da soberania nacional (art. 91), é defesa da Pátria (art. 142), não mais a defesa deste ou daquele regi-

me político ou de uma particular ideologia ou de um grupo detentor do poder.

2. Defesa das instituições democráticas

Diego Valadés observa, com David Easton, que "o equilíbrio é o elemento que caracteriza a ordem constitucional".¹ Acrescenta que "o equilíbrio constitucional consiste na existência de uma distribuição relativamente igual do poder, de tal maneira que nenhum grupo, ou combinação de grupos, possa dominar sobre os demais",² para concluir, agora com Catlin, que "a democracia é o equilíbrio mais estável entre os grupos de poder".³ Daí decorre, conforme os mesmos autores, que "a competição entre os distintos grupos sociais só é tolerável na medida em que esses mesmos grupos estejam subordinados aos procedimentos constitucionais".⁴ Isso quer dizer que, fora desses parâmetros, as competições pelo poder geram uma *situação de crise*, que poderá assumir as características de *crise constitucional*, e esta, se não for convenientemente administrada, governada, poderá provocar o rompimento do equilíbrio constitucional e, por conseguinte, pôr em grave risco as instituições democráticas.

Quando uma situação dessas se instaura é que se manifesta a função do chamado *sistema constitucional das crises*, considerado por Aricê Moacyr Amaral Santos "como o conjunto ordenado de normas constitucionais, que, informadas pelos princípios da necessidade e da temporariedade, tem por objeto as situações de crises e por finalidade a manutenção ou o restabelecimento da normalidade constitucional".⁵ São normas que visam a estabilização e a defesa da Constituição contra processos violentos de mudança ou perturbação da ordem constitucional,⁶ mas também a defesa do Estado quando a situação crítica derive de guerra externa. Então, a legalidade normal é substituída por uma legalidade extraordinária,⁷ que define e rege o estado de exceção.

Os princípios informadores do sistema constitucional das crises e, pois, dos estados de exceção foram bem lembrados por Aricê Moacyr Amaral Santos, e são o *princípio fundante da necessidade* e o *princípio da temporariedade*, cuja incidência "nos sistemas de legalidade especial determina: a) a declaração é condicionada à ocorrência

1. Cf. *La dictadura constitucional en América Latina*, p. 31, citando David Easton, *Política moderna*, pp. 177-278.

2. Idem, p. 32; idem, p. 306.

3. Idem, pp. 32 e 33.

4. Idem, *ibidem*.

5. Cf. *O estado de emergência*, p. 32.

6. Cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 184.

7. Cf. Aricê Moacyr Amaral Santos, *ob. cit.*, p. 33.

de pressuposto fático; b) os meios de resposta têm sua executoriedade restrita e vinculada a cada anormalidade em particular e, ainda, ao lugar e tempo; c) o poder de fiscalização política dos atos de exceção é de competência do Legislativo; d) o controle judicial *a tempore* e *a posteriori* é do Judiciário".⁸

Sem que se verifique a *necessidade*, o estado de exceção configurará puro golpe de estado, simples arbítrio; sem atenção ao princípio da *temporiedade*, sem que se fixe tempo limitado para vigência da legalidade extraordinária, o estado de exceção não passará de ditadura. Então, sempre se põe a grave questão: quem guardará a ordem constitucional contra as investidas dos próprios detentores do poder? Pois, "a dizer a verdade [lembra Diego Valadés] maior é a crise — enquanto signifique o perigo do desmoronamento constitucional — quando quem rompe o equilíbrio constitucional é um órgão próprio da Constituição",⁹ especialmente quando esse órgão é o Executivo, que, na América Latina, detém amplos poderes, sem freios que o retenham nos limites da ordem constitucional; daí por que é dele que provém, quase sempre, o maior perigo, ao lado das graves insurreições de militares golpistas. Nesses casos, os estados de exceção visam especialmente criar condições para a implantação de ditaduras, antes que para defender a Constituição. Quase sempre o estado de exceção funciona como instrumento de preservação do domínio de uma classe dominante, como lembrou Diego Valadés com inteira razão.¹⁰

No Brasil, isso aconteceu várias vezes no passado, com decretação de estado de sítio mais com o intuito de reprimir simples divergências político-partidárias que de defesa constitucional. A Constituição de 1937, implantando o regime ditatorial de Vargas, fê-lo declarando "em todo o país o estado de emergência" (art. 186). O Brasil viveu, de 1964 a 1978, num permanente regime de exceção, sob a normatividade excepcional instrumentada por Atos Institucionais. O AI 5, de 13.12.68, que vigorou até 13.10.78, foi certamente o instrumento mais arbitrário, mais ditatorial, que o País jamais conheceu. Com base nessa chamada legalidade extraordinária, *formada sem necessidade*, porque voltada apenas para coibir adversários políticos e sustentar os detentores do poder e os interesses das classes dominantes aliadas às oligarquias nacionais, e destinada a vigor enquanto esses detentores quisessem e pudessem (portanto, sem atender o princípio da temporiedade), tudo se podia fazer: fechar Casas Legislativas, cassar mandatos populares, demitir funcionários, suspender direitos políticos,

8. Idem, p. 33.

9. Ob. cit., p. 34.

10. Idem, p. 157.

aposentar e punir magistrados, militares etc. Mas, o que era ainda pior, é que não havia nada que impedisse a expedição de outros Atos Institucionais com qualquer conteúdo. Foi o estado de exceção (pura ditadura) que perdurou naquele período, mas suas conseqüências ainda permaneceram na Carta Constitucional de 1969, outorgada com base naquela mesma normatividade excepcionalíssima e em novos estados de exceção que a EC 11/78 incorporou a ela, como mecanismos de poder substitutivos dos Atos Institucionais, que não deixaram de exercer certa influência no Constituinte de 1987-1988, que não se contentara com o tradicional estado de sítio ao acolher também o estado de defesa idêntico ao estado de emergência daquele regime.

3. Tipos de estados de exceção vigentes

O estado de sítio fora, realmente, o tipo de estado de exceção que tradicionalmente vigorou no Brasil. O sistema da EC 11/78 configurava três instituições emergenciais: *medidas de emergência*, *estado de sítio* e *estado de emergência*.¹¹ A Constituição reformulou a questão, mas não retrocedeu ao sistema puro da Constituição de 1946, que só previa o *estado de sítio*, pois manteve também o estado de emergência com o nome de *estado de defesa*.

II. ESTADO DE DEFESA

4. Defesa do Estado e estado de defesa

Percebe-se que a palavra *estado* tem sentidos diferentes nas expressões "Defesa do Estado" e "estado de defesa". Na primeira, significa, como vimos noutro lugar, "uma ordenação que tem por fim específico e essencial a regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma dada população sobre um dado território". É escrita com inicial maiúscula precisamente para distinguir de outros sentidos comuns do termo, como o de "situação", "circunstância", "conjuntura", entre tantos, cuja precisão depende de qualificações. Assim, *estado de defesa* é uma situação em que se organizam medidas destinadas a debelar ameaças à ordem pública ou à paz social. Em outras palavras, em função do disposto no art. 136, *o estado de defesa consiste na instauração de uma legalidade extraordinária, por certo tempo, em locais restritos e determinados, mediante decreto do Presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, para preservar a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave*

11. Sobre eles, cf. Oscar Dias Corrêa, *A defesa do Estado de Direito e emergência constitucional*, pp. 59 e ss.

e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

5. Pressupostos e objetivo

Os fundamentos para a instauração do *estado de defesa* acham-se estabelecidos no art. 136, e são de *fundo* e de *forma*.

Constituem *pressupostos de fundo* do estado de defesa: (a) a existência de grave e iminente instabilidade institucional que ameace a ordem pública ou a paz social ou (b) a manifestação de calamidade de grandes proporções na natureza que atinja a mesma ordem pública ou a paz social. Naturalmente que não se há de tomar, por exemplo, a existência de greve, por mais prolongada e intensa que seja, como uma ameaça à ordem ou à paz social que justifique a decretação da medida. Se a Constituição reconhece o direito de greve sem limitações, é evidente que ela não pode ser tomada como algo fora da normalidade, para justificar a implantação de uma legalidade extraordinária. A calamidade é sempre um fato de desajuste no âmbito de sua verificação, mas, nos termos do texto constitucional, ela terá que ser de grandes proporções e ainda gerar situação de séria perturbação à ordem pública ou à paz social para servir de base à decretação do estado de defesa.

Os *pressupostos formais* do estado de defesa são: (a) prévia manifestação dos Conselhos da República e de Defesa Nacional; (b) decretação pelo Presidente da República, após a audiência desses dois Conselhos (arts. 90, I, 91, § 1º, II, e 136); (c) determinação, no decreto, do tempo de sua *duração*, que não poderá ser superior a trinta dias, podendo ser prorrogado apenas uma vez, por igual período (ou por período menor, evidentemente), se persistirem as razões que justificaram sua decretação; (d) especificação das áreas por ele abrangidas; (e) indicação de medidas coercitivas, dentre as discriminadas no art. 136, § 1º. A audiência dos Conselhos da República e de Defesa Nacional é obrigatória, sob pena de inconstitucionalidade da medida. Contudo, tais Conselhos são apenas *consultivos*, o que vale dizer que sua opinião é sempre de ser levada em consideração, mas não será vinculativa. Portanto, se opinarem contra a decretação da medida, o Presidente da República ficará com a grave responsabilidade de, desatendendo-os, assim mesmo decretá-la, se assim entender indispensável. Se o fizer e o Congresso a aprovar nos termos dos arts. 49, IV, e 136, §§ 4º e 6º, tudo fica conforme com a Constituição. Se o Congresso rejeitar a medida, poderá surgir hipótese de crime de responsabilidade do Presidente da República.

O estado de defesa tem por *objetivo* preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por aqueles fatores de crise.

6. Efeitos e execução do estado de defesa

A decretação do estado de defesa importa, como primeira consequência, na adoção de legalidade especial para a área em questão, cujo conteúdo depende do decreto que o instaurar, respeitados os termos e limites da lei, donde se vê que a Constituição, ao mencionar esse aspecto (art. 136, § 1º), está a requerer a elaboração de uma lei que discipline a utilização desse estado de exceção. É que se prevê, aí, que o decreto indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem durante o estado de defesa, dentre as relacionadas naquele dispositivo, a saber: (1) *restrições aos direitos* de: (a) *reunião*, ainda que exercida no seio das associações; (b) *sigilo de correspondência*; (c) *sigilo de comunicação telegráfica e telefônica*; (2) *ocupação e uso* temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de *calamidade pública*, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes; (3) *prisão*: (a) por crime contra o Estado, pelo executor da medida, que deverá comunicá-la, com declaração do estado físico ou mental do detido, ao juiz competente; (b) por outros motivos, nunca superior a dez dias, salvo autorização do Poder Judiciário.

7. Controles

O juízo de conveniência da decretação do estado de defesa cabe ao Presidente da República, quando ocorra pressuposto de fundo para tanto. Ele tem a faculdade de decretá-lo, ou não, mas se decidir fazê-lo terá que obedecer às normas constitucionais que o regem e à lei prevista no art. 136, § 1º, já referida. Vale dizer: o estado de defesa não é, e não pode ser, situação de arbítrio, mas situação constitucionalmente regradada. Por isso, fica sujeito a *controles político e jurisdicional*.

O *controle político* realiza-se em dois momentos pelo Congresso Nacional. O primeiro consiste na apreciação do decreto de instauração e de prorrogação do estado de defesa, que o Presidente da República terá que submeter a ele, dentro de vinte e quatro horas de sua edição, acompanhado da respectiva justificação. Se o Congresso estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias. Em qualquer caso, deverá apreciar o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento, continuando em funcionamento enquanto o estado de defesa vigorar. A apreciação da medida concluirá por sua *aprovação* ou por sua *rejeição* (arts. 49, IV, e 136, § 7º). Se aprovado, segue sua execução com os efeitos que já apontamos. Se rejeitado, cessarão imediatamente seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores (arts. 136, § 7º, e 141). O controle do Congresso Nacional, no segundo momento, é *sucessivo (a posteriori)*, porque atuará após o término do es-

tado de defesa e a cessação de seus efeitos, conforme dispõe o parágrafo único do art. 141, segundo o qual logo que cesse o estado de defesa, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.

E se o Congresso não aceitar a justificação dada pelo Presidente da República, se ele chegar à conclusão de que houve arbítrio, excesso? Parece-nos que, em tal caso, ficará caracterizado algum crime de responsabilidade do Presidente, especialmente o atentado a direitos individuais, pelo que pode ser ele submetido ao respectivo processo, previsto no art. 86 e regulado na Lei 1.079/50.

Prevê-se, ainda, um *controle político concomitante*, nos termos do art. 140, segundo o qual a Mesa do Congresso Nacional (art. 57, § 5º) designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa. Membros da Mesa ou do Congresso? Parece-nos que membros da Mesa do Congresso que é composta dos membros da Mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

O *controle jurisdicional* consta, por exemplo, do art. 136, § 3º, onde se prevê que a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por ele comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial; essa comunicação será acompanhada de declaração do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Também a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo autorização do Poder Judiciário; não havendo tal autorização, o constrangimento, além daquele período, é ilegal e passível de controle jurisdicional por via de *habeas corpus*. Demais, é vedada a incomunicabilidade do preso, o que vale dizer que a prisão fica sempre sujeita ao controle jurisdicional, para o cumprimento dessa vedação. Finalmente, cessado o estado de defesa, cessarão seus efeitos, mas sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Isso quer dizer que existirá a possibilidade de controle jurisdicional sucessivo sobre a conduta dos executores ou agentes da medida.

III. ESTADO DE SÍTIO

8. Pressupostos, objetivos e conceito

Causas do estado de sítio são as situações críticas que indicam a necessidade da instauração de correspondente legalidade de exceção

(extraordinária) para fazer frente à anormalidade manifestada. São as *condições de fato*, sem as quais o estado de sítio constituirá um abuso injustificado.¹² São *pressupostos de fundo* cuja ocorrência confere legitimidade às providências constitucionalmente estabelecidas.

Essas causas estão previstas no art. 137, consubstanciadas em dois casos: (1) *comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa*; (2) *declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira*. Há, portanto: (a) *estado de sítio em caso de comoção grave de repercussão nacional*, portanto um estado de crise que seja de efetiva rebelião ou de revolução que ponha em perigo as instituições democráticas e a existência do governo fundado no consentimento popular; (b) *estado de sítio em caso de ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa*, que corresponde, praticamente, na conversão deste em estado de sítio; (c) *estado de sítio em caso de declaração de guerra*; (d) *estado de sítio em caso de agressão armada* que exija pronta resposta, desembaraçada de situação interna que porventura a dificulte. Os dois últimos casos são de situação de guerra. No primeiro, trata-se de estado de guerra, juridicamente estabelecido, ou seja, guerra declarada nos termos dos arts. 49, II, e 84, XIX. No segundo, eventualmente em situação de guerra dependente de referendo do Congresso Nacional na conformidade dos mesmos artigos citados. *Guerra*, aí, pois, é sempre *guerra externa*, ou seja: só o estado de beligerância com Estado estrangeiro é que fundamenta o estado de sítio na hipótese.

A instauração do estado de sítio depende ainda de preenchimento de *requisitos (pressupostos) formais*, quais sejam: (a) audiência do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional; (b) autorização, por voto da maioria absoluta do Congresso Nacional, para sua decretação em atendimento a solicitação fundamentada do Presidente da República; (c) decreto do Presidente da República. Quer dizer, o estado de sítio é decretado pelo Presidente da República, ouvidos aqueles dois Conselhos e autorizado pelo Congresso Nacional, que, se estiver em recesso, será imediatamente convocado pelo Presidente do Senado Federal para reunir-se dentro de cinco dias, a fim de apreciar a solicitação, e, concedendo-a, permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas (arts. 137 e 138, §§ 2º e 3º). É o *decreto* do Presidente da República que instaura a normatividade extraordinária do estado de sítio pela indicação de: (a) sua *duração*, que não poderá ser superior a trinta dias, nem prorrogada, de cada vez (o que permite

12. Cf. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, *O estado de sítio*, p. 121; Aricê Moacyr Amaral Santos, *ob. cit.*, p. 98.

mais de uma prorrogação), por prazo superior, quando se tratar de estado de sítio com base no inc. I do art. 137; e por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira na hipótese do inc. II; (b) as *normas necessárias à sua execução*, ou seja, as instruções que devem reger a conduta dos executores da medida; (c) as *garantias constitucionais que ficarão suspensas*, dentre as autorizadas no art. 139. Publicado o decreto, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Esses condicionamentos visam situar o estado de sítio em limites estritamente necessários ao restabelecimento da normalidade, para que não se sirva dele como instrumento para obter resultado diametralmente contrário a seus *objetivos*, que são, pelo visto: (a) preservar, manter e defender o Estado Democrático de Direito e, por conseguinte, as instituições democráticas; (b) dar condições de livre mobilização de todos os meios necessários à defesa do Estado no caso de guerra.

O estado de sítio consiste, pois, na instauração de uma *legalidade extraordinária, por determinado tempo e em certa área* (que poderá ser o território nacional inteiro), *objetivando preservar ou restaurar a normalidade constitucional, perturbada por motivo de comoção grave de repercussão nacional ou por situação de beligerância com Estado estrangeiro*. A aplicação de medidas coercitivas e a suspensão de direitos e garantias constitucionais são apenas meios para a consecução de seus objetivos. São efeitos de sua decretação, a que dedicaremos as considerações que seguem.

9. Efeitos do estado de sítio

A decretação do estado de sítio importa, como primeira consequência, na substituição da legalidade constitucional comum por uma *legalidade constitucional extraordinária*. O conteúdo desta depende do decreto que instaura a medida, respeitados os limites indicados na Constituição. Tais limites, contudo, só são estabelecidos relativamente ao estado de sítio decretado por motivo de comoção grave ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia do estado de defesa, conforme o disposto no art. 137, I. Na vigência deste estado de sítio, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas coercitivas:

- (1) obrigação de permanência em localidade determinada;
- (2) detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, o que acaba por deter as pessoas em prisão dos quartéis da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica;
- (3) restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei, o que significa a

necessidade de elaboração de uma lei que preveja a possibilidade e limites dessas restrições, que, como se nota, importam em interceptação e censura aos meios de comunicação em geral; mas não se inclui, nessas restrições, a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa;

- (4) suspensão da liberdade de reunião;
- (5) busca e apreensão em domicílio, o que é uma derrogação da inviolabilidade do domicílio;
- (6) intervenção nas empresas de serviços públicos (empresas de telecomunicações, de transportes, de fornecimento de água etc.);
- (7) requisição de bens.

Cessado o estado de sítio, cessarão os seus efeitos sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes, que são, como foi dito, a legalidade extraordinária implantada com sua decretação e as providências de sua execução. Esta realiza-se por meio de delegado do Presidente da República, como executor das medidas específicas consubstanciadas no decreto, nomeado depois de sua publicação, mas nada impede seja nomeado no próprio decreto de instauração do estado de sítio. Em regra, são nomeadas autoridades militares que se incumbem de tomar as medidas coercitivas autorizadas no decreto.

10. Controles do estado de sítio

Tal como no estado de defesa, o juízo de conveniência da instauração do estado de sítio cabe ao Presidente da República quando ocorrer um dos pressupostos de fundo que o justificam. Ele tem a faculdade de decretar, ou não, a medida, mas se o fizer, terá que observar as normas constitucionais que a regem. Vale dizer, o estado de sítio, tanto quanto o estado de defesa, não é, nem pode ser, uma situação de arbítrio, porque é uma situação constitucionalmente regrada. Por isso, fica sujeito a *controles político e jurisdicional*.

O *controle político* realiza-se pelo Congresso Nacional em três momentos: (a) um *controle prévio*, porque a decretação do estado de sítio depende de sua prévia autorização (art. 137); (b) um *controle concomitante*, porque, nos termos do art. 140, a Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, deverá designar Comissão composta de cinco de seus membros (seus da Mesa, ao que nos parece) para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de sítio, tal como em relação ao estado de defesa, consoante vimos; (c) *sucessivo*, ou seja, após cessado o estado de sítio, as me-

didadas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.

O controle *jurisdicional* é amplo em relação aos limites de aplicação das restrições autorizadas. Se os executores ou agentes do estado de sítio cometerem abuso ou excesso de poder durante sua execução, é lógico que seus atos ficam sujeitos a correção por via jurisdicional, quer por via de mandado de segurança, quer por *habeas corpus*, quer por outro meio judicial hábil. Mesmo depois de cessados o estado de sítio e seus efeitos, poderá ocorrer hipótese de responsabilização jurisdicional de seus executores ou agentes por atos ou condutas ilícitos cometidos durante a execução da medida, conforme estatui o art. 141.

Mais uma vez se vê que o estado de sítio, como o estado de defesa, está subordinado a normas legais. Ele gera uma legalidade extraordinária, mas não pode ser arbitrariedade. Por isso, qualquer pessoa prejudicada por medidas ou providências do Presidente da República ou de seus delegados, executores ou agentes, com inobservância das prescrições constitucionais não excepcionadas e das constantes do art. 139, tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário para responsabilizá-los e pedir a reparação do dano que lhe tenha sido causado.

Capítulo II

DAS FORÇAS ARMADAS

1. Destinação constitucional. 2. Instituições nacionais permanentes. 3. Hierarquia e disciplina. 4. Componentes das Forças Armadas. 5. Fixação e modificação dos efetivos das Forças Armadas. 6. A obrigação militar. 7. Organização militar e seus servidores.

1. Destinação constitucional

A Constituição estabelece que as *Forças Armadas* são instituições nacionais permanentes e regulares que se destinam à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (art. 142).

Constituem, assim, elemento fundamental da organização coercitiva a serviço do Direito e da paz social. Esta nelas repousa pela afirmação da ordem na órbita interna e do prestígio estatal na sociedade das nações. São, portanto, os garantes materiais da subsistência do Estado e da perfeita realização de seus fins. Em função da consciência que tenham da sua missão está a tranquilidade interna pela estabilidade das instituições. É em função de seu poderio que se afirmam, nos momentos críticos da vida internacional, o prestígio do Estado e a sua própria soberania.¹

Dado o relevo de sua missão, nossas constituições sempre reservaram a elas posição especial. A do Império destacou-lhes um capítulo com seis artigos, em que se lhes traçam as linhas mestras (arts. 145 a 150). A primeira Constituição republicana não lhes abriu capítulo especial, mas delas cuida em vários dispositivos esparsos, reconhecendo-lhes a mesma destinação e relevo (arts. 14, 34, ns. 17 e 18, 48, ns. 3, 4 e 5, e arts. 73, 74, 76, 77 e 78). A Constituição de 1934 volta a destinar-lhes título específico denominado *Da Segurança Nacional* (Tít. VI) e a de 1937 desdobra a matéria em dois capítulos: um sobre os *Militares da Terra e Mar* (art. 160) e outro sobre a *segurança nacional*, técnica que tornou a ser adotada pelo constituinte de 1967 e 1969, que, em seções diferentes, cuidaram da segurança nacional e das Forças Armadas (res-

1. Cf. Seabra Fagundes, *As Forças Armadas na Constituição*, p. 11.

pectivamente, arts. 89 a 91 e 92 a 94, e 86 a 89 e 90 a 93), enquanto a Constituição de 1946 incluiu num só título as Forças Armadas e o Conselho de Segurança Nacional (Tít. VII, arts. 176 a 183).

A Constituição vigente abre a elas um capítulo do Título V sobre a *defesa do Estado e das instituições democráticas* com a destinação acima referida, de tal sorte que sua missão essencial é a da defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, o que vale dizer defesa, por um lado, contra agressões estrangeiras em caso de guerra externa e, por outro lado, defesa das instituições democráticas, pois a isso corresponde a garantia dos poderes constitucionais, que, nos termos da Constituição, emanam do povo (art. 1º, parágrafo único). Só subsidiária e eventualmente lhes incumbe a *defesa da lei e da ordem*, porque essa defesa é de competência primária das *forças de segurança pública*, que compreendem a polícia federal e as polícias civil e militar dos Estados e do Distrito Federal. Sua interferência na defesa da lei e da ordem depende, além do mais, de convocação dos legítimos representantes de qualquer dos poderes federais: Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Presidente da República ou Presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro não é poder constitucional. Juiz de Direito não é poder constitucional. Juiz Federal não é poder constitucional. Deputado não é poder constitucional. Senador não é poder constitucional. São simples membros dos poderes e não os representam. Portanto, a atuação das Forças Armadas convocada por Juiz de Direito ou por Juiz Federal, ou mesmo por algum Ministro do Superior Tribunal de Justiça ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional e arbitrária, porque estas autoridades, por mais importantes que sejam, não representam qualquer dos poderes constitucionais federais.

2. Instituições nacionais permanentes

As Forças Armadas são *instituições nacionais, permanentes e regulares*, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República (art. 142). Foi a Constituição de 1891 que as declarou *instituições nacionais permanentes* (art. 14), o que já se encontrava implícito na Constituição imperial de 1824, que se referia a *forças militares permanentes* de mar e terra (art. 146).

Concebendo-as como *instituições nacionais*, reconhece-lhes, a Constituição, importância e relativa autonomia jurídica decorrente de seu caráter institucional; declarando-as *permanentes e regulares*, vincula-as à própria vida do Estado, atribuindo-lhes a perduração deste.²

2. Idem, p. 14.

Essa posição constitucional das Forças Armadas importa afirmar que não poderão ser dissolvidas, salvo por decisão de uma Assembléia Nacional Constituinte. E, sendo regulares, significa que deverão contar com efetivos suficientes ao seu funcionamento normal, por via do recrutamento constante, nos termos da lei.

3. Hierarquia e disciplina

As Forças Armadas são organizadas com base na *hierarquia* e na *disciplina*, sob a autoridade suprema do Presidente da República (art. 84, XIII).

Hierarquia é o vínculo de subordinação escalonada e graduada de inferior a superior. Ao dizer-se que as Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia sob a autoridade suprema do Presidente da República, quer-se afirmar que elas, além da relação hierárquica interna a cada uma das armas, subordinam-se em conjunto ao Chefe do Poder Executivo federal, que delas é o comandante supremo (art. 84, XIII).

Disciplina é o poder que têm os superiores hierárquicos de impor condutas e dar ordens aos inferiores. Correlativamente, significa o dever de obediência dos inferiores em relação aos superiores. Declarar-se que as Forças Armadas são organizadas com base na disciplina vale dizer que são essencialmente obedientes, dentro dos limites da lei, a seus superiores hierárquicos, como dizia o art. 14 da Constituição de 1891.

Não se confundem, como se vê, hierarquia e disciplina, mas são termos correlatos, no sentido de que a disciplina pressupõe relação hierárquica. Somente se é obrigado a obedecer, juridicamente falando, a quem tem poder hierárquico. "Onde há hierarquia, com superposição de vontades, há, correlativamente, uma relação de sujeição objetiva, que se traduz na disciplina, isto é, no rigoroso acatamento pelos elementos dos graus inferiores da pirâmide hierárquica, às ordens, normativas ou individuais, emanadas dos órgãos superiores. A disciplina é, assim, um corolário de toda organização hierárquica."³ Essa relação fundamenta a aplicação de penalidades que ficam imunes ao *habeas corpus*, nos termos do art. 142, § 2º, que declara não caber aquele remédio constitucional em relação a punições disciplinares militares.

4. Componentes das Forças Armadas

As Forças Armadas brasileiras são constituídas pela *Marinha*, pelo *Exército* e pela *Aeronáutica* (art. 142). No Império, eram compostas

3. Idem, p. 23.

apenas das *forças de mar e de terra*, formando a Armada e o Exército. O aparecimento da aviação, neste século, e seu emprego como arma de guerra, para desgosto de Santos Dumont, fez surgir nova organização militar: a Aeronáutica.

Cada uma das três forças goza de autonomia relativa, subordinadas respectivamente aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, integradas no Ministério da Defesa, entrosadas hierárquica e disciplinarmente, e devem ser obedientes a um centro comum, que é o seu comando supremo exercido pelo Presidente da República.

5. Fixação e modificação dos efetivos das Forças Armadas

A fixação e a modificação dos efetivos das Forças Armadas, para o tempo de paz, dependem de lei de iniciativa do Presidente da República (art. 61, § 1º, I). Em tempo de guerra, não se cuidará propriamente de efetivos, mas de mobilização nacional, compreendida a convocação de reservistas e de outras forças militares, o que se faz por decreto do Presidente da República (art. 84, XIX).

A Constituição não adotou o princípio da periodicidade para a fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas, como fizeram a de 1824 que o previa de ano para ano, a de 1891 que manteve o princípio da fixação anual e as de 1934 e de 1946 que determinavam a fixação dos efetivos em cada legislatura. Pela atual, o Presidente da República poderá tomar a iniciativa de lei sobre o assunto quando julgar necessário.

6. A obrigação militar

Todas as Constituições brasileiras trouxeram normas que definiam as obrigações dos brasileiros referentemente à defesa da Pátria. A de 1891 estabeleceu que todo brasileiro era obrigado ao serviço militar, em defesa da Pátria e da Constituição, na forma das leis federais. Isso não era ainda o serviço militar obrigatório regular, mas nos momentos em que a defesa da Pátria ou da Constituição exigisse a convocação de todos. Foi a partir de campanha do poeta Olavo Bilac em favor do serviço militar obrigatório para todos que se revelassem aptos, dentro dos limites dos efetivos previstos em lei, por via de recrutamento anual, que afinal fora instituída a obrigação de todos servirem numa das Armas que compõem as Forças Armadas.

A Constituição vigente manteve o princípio da obrigatoriedade nos termos do seu art. 143. O princípio aí estatuído é o de que o serviço militar é obrigatório para todos nos termos da lei. Mas a Constituição reconhece a escusa de consciência no art. 5º, VIII, que desobriga o alistado ao serviço militar obrigatório, desde que cumpra prestação alternativa. O § 1º do art. 143 incumbe às Forças Armadas, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Outras isenções vêm no § 2º do mesmo artigo, ao declarar que as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

Em geral, o *serviço militar* consiste na incorporação do indivíduo às fileiras das tropas, de tiro de guerra ou cursos de preparação de oficiais da reserva, para receber adestramento e instruções militares, por determinado tempo, desincorporando-se, vencido este, na qualidade de reservista ou oficial da reserva. Os outros encargos são os de assistência religiosa, enfermagem etc.

Pode parecer estranho que a Constituição tenha que determinar a obrigatoriedade de serviços destinados à defesa da Pátria a todos os brasileiros, dado que essa defesa já decorreria da própria situação de cada um em função de sua exclusiva pertinência à comunidade nacional, o que, por si, implica a necessidade ética de cada membro dessa comunidade lutar por sua sobrevivência contra qualquer inimigo. Justifica-se, porém, a determinação constitucional, pois se trata de obrigação sumamente onerosa, não só por afastar o indivíduo do seio da família e de suas atividades, como por exigir, às vezes, o tributo da própria vida. A exigência constitucional tem ainda o sentido de que ninguém poderá deixar de prestar a obrigação militar fundado em especial condição social ou religiosa, ainda que agora a escusa de consciência em tempo de paz seja reconhecida nos termos vistos acima. Cuida-se de dever infungível, como nota Seabra Fagundes, cuja lição nos vem orientando neste passo, e é de caráter estritamente pessoal, não comportando, por isso, execução por substituição, como já se admitiu em outros países.⁴ Aquele que, convocado para o serviço militar, não se apresenta, fica considerado *insubmisso*, e aquele que estiver em serviço e abandoná-lo será tido como *desertor*, prevendo a lei penas rigorosas para esses crimes militares. Se alguém invocar imperativo de consciência para não servir e recusar-se a cumprir prestação alternativa, sujeitar-se-á à pena de perda dos direitos políticos (art. 15, IV).

4. *Ob. cit.*, pp. 63 e ss., especialmente p. 66.

7. Organização militar e seus servidores

Finalmente, cumpre apenas lembrar, com base no art. 142, § 1º, que cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas, assim como recordar que os integrantes das Forças Armadas têm seus direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos definidos no § 3º do citado art. 142, desvinculados, assim, do conceito de servidores públicos, por força da EC-18/98, conforme vimos às pp. 681 e ss.

Capítulo III

DA SEGURANÇA PÚBLICA

1. Polícia e segurança pública. 2. Organização da segurança pública. 3. Polícias federais. 4. Polícias estaduais. 5. Guardas municipais.

1. Polícia e segurança pública

“Polícia” e “segurança” são dois termos que demandam um esclarecimento prévio, antes que entremos na discussão da temática da *segurança pública* a que agora a Constituição reserva um capítulo, onde institui princípios sobre o assunto.

Na teoria jurídica a palavra “segurança” assume o sentido geral de garantia, proteção, estabilidade de situação ou pessoa em vários campos, dependente do adjetivo que a qualifica. “Segurança jurídica” consiste na garantia de estabilidade e de certeza dos negócios jurídicos, de sorte que as pessoas saibam de antemão que, uma vez envolvidas em determinada relação jurídica, esta mantém-se estável, mesmo se se modificar a base legal sob a qual se estabeleceu. “Segurança social” significa a previsão de vários meios que garantam aos indivíduos e suas famílias condições sociais dignas; tais meios se revelam basicamente como conjunto de direitos sociais. A Constituição, nesse sentido, preferiu o espanholismo *seguridad social*, como vimos antes. “Segurança nacional” refere-se às condições básicas de defesa do Estado. “Segurança pública” é manutenção da *ordem pública* interna.

Mas aí se põe uma petição de princípio, já que a *ordem pública* requer definição, até porque, como dissemos de outra feita, a caracterização de seu significado é de suma importância, porquanto se trata de algo destinado a limitar situações subjetivas de vantagem, outorgadas pela Constituição.¹ Em nome dela se têm praticado as maiores arbitrariedades. Com a justificativa de garantir a ordem pública, na verdade, muitas vezes, o que se faz é desrespeitar direitos fundamentais da pessoa humana, quando ela apenas autoriza o exercício regular do poder de polícia. *Ordem pública* será uma situação de pacífica convivência social, isenta de ameaça de violência ou de su-

1. Cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 96.

blevação que tenha produzido ou que supostamente possa produzir, a curto prazo, a prática de crimes.² Convivência pacífica não significa isenta de divergências, de debates, de controvérsias e até de certas rugas interpessoais. Ela deixa de ser tal quando discussões, divergências, rugas e outras contendas ameaçam chegar às vias de fato com iminência de desforço pessoal, de violência e do crime. A *segurança pública* consiste numa situação de preservação ou restabelecimento dessa convivência social que permite que todos gozem de seus direitos e exerçam suas atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites de gozo e reivindicação de seus próprios direitos e defesa de seus legítimos interesses. Na sua dinâmica, *é uma atividade de vigilância, prevenção e repressão de condutas delituosas*. Segundo a Constituição, *a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através da polícia federal, da polícia rodoviária federal, da polícia ferroviária federal, das polícias civis, das polícias militares e corpos de bombeiros militares* (art. 144).

A palavra *polícia* correlaciona-se com a segurança. Vem do grego *polis* que significava o ordenamento político do Estado. "Aos poucos [lembra Hélio Tornaghi] *polícia* passa a significar a atividade administrativa tendente a assegurar a ordem, a paz interna, a harmonia e, mais tarde, o órgão do Estado que zela pela segurança dos cidadãos".³ Acrescenta que *Polícia*, sem qualificativo, "designa hoje em dia o Órgão a que se atribui, exclusivamente, a função negativa, a função de evitar a alteração da ordem jurídica".⁴

A atividade de polícia realiza-se de vários modos, pelo que a *polícia* se distingue em *administrativa* e de *segurança*, esta compreende a *polícia ostensiva* e a *polícia judiciária*. A *polícia administrativa* tem "por objeto as limitações impostas a bens jurídicos individuais" (liberdade e propriedade). A *polícia de segurança* que, em sentido estrito, é a *polícia ostensiva* tem por objetivo a preservação da ordem pública e, pois, "as medidas preventivas que em sua prudência julga necessárias para evitar o dano ou o perigo para as pessoas". Mas, apesar de toda vigilância, não é possível evitar o crime, sendo pois necessária a existência de um sistema que apure os fatos delituosos e cuide da perseguição aos seus agentes. Esse sistema envolve as atividades de investigação, de apuração das infrações penais, a indicação de sua autoria, assim como o processo judicial pertinente à punição do agente. É aí que entra a *polícia judiciária*, que tem por objetivo precisamente aquelas atividades de investigação, de apuração das infrações pe-

nais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva das condutas criminosas, por via de ação penal pública.

Mas a segurança pública não é só repressão e não é problema apenas de polícia, pois a Constituição, ao estabelecer que a *segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos* (art. 144), acolheu a concepção do *I Ciclo de Estudos sobre Segurança*, segundo a qual é preciso que a questão da segurança seja discutida e assumida como tarefa e responsabilidade permanente de todos, Estado e população.⁵ Daí decorre também a aceitação de outras teses daquele certame, tal como a de que "se faz necessária uma nova concepção de ordem pública, em que a colaboração e a integração comunitária sejam os novos e importantes referenciais" e a de que, dada "a amplitude da missão de manutenção da ordem pública, o combate à criminalidade deve ser inserido no contexto mais abrangente e importante da proteção da população", o que requer a adoção de outro princípio ali firmado de acordo com o qual é preciso "adequar a polícia às condições e exigências de uma sociedade democrática, aperfeiçoando a formação profissional e orientando-a para a obediência aos preceitos legais de respeito aos direitos do cidadão, independentemente de sua condição social".

2. Organização da segurança pública

Indicamos, antes, que a segurança pública é exercida pelos seguintes órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Há, contudo, uma repartição de competências nessa matéria entre a União e os Estados, de tal sorte que o princípio que rege é o de que o problema da *segurança pública* é de competência e responsabilidade de cada unidade da Federação, tendo em vista as peculiaridades regionais e o fortalecimento do princípio federativo,⁶ como, aliás, é da tradição do sistema brasileiro.

Quando a Constituição atribui às *polícias federais* competência na matéria, logo se vê que são atribuições em campo e questões delimitadas e devida e estritamente enumeradas, de maneira que, afastadas essas áreas especificadas, a segurança pública é de competência da organização policial dos Estados, na forma mesma prevista no art. 144, §§ 4º, 5º e 6º. Cabe, pois, aos Estados organizar a segurança

2. Cf. Paulo Barile, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, CEDAM, 1953, p. 117.

3. Cf. *Processo penal*, Rio de Janeiro, Coelho Branco Editor, 1953, p. 255.

4. *Ob. cit.*, p. 256.

5. Cf. "25 sugestões para uma polícia melhor", *Polícia Militar, Revista da PMERJ*, outubro/85, 4/26.

6. Nesse sentido foi o pronunciamento do *I Ciclo de Estudos sobre a Segurança*, consubstanciado na sua 21ª sugestão, revista e lugar cits.

pública. Tanto é de sua responsabilidade primária o exercício dessa atividade que, se não a cumprirem devidamente, poderá haver ocasião de intervenção federal, nos termos do art. 34, III, que dá, como um dos objetivos da intervenção federal, "pôr termo a grave comprometimento da ordem pública".

Então, quando a Constituição determina que a *lei* disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, isso significa basicamente a *lei estadual*, mas também a *lei federal*, nos estritos limites de sua competência, relativamente às polícias federais (federal, rodoviária e ferroviária), ressalvada, é claro, a competência da União para estabelecer as normas gerais mencionadas nos arts. 22, XXI, e 24, XVI, respectivamente sobre as polícias militares e as polícias civis.

3. Polícias federais

Estão mencionadas três polícias federais no art. 144, I a III: a *polícia federal* propriamente dita, a *polícia rodoviária federal* e a *polícia ferroviária federal*. Todas elas são organizadas e mantidas pela União (art. 21, XIV), que também organiza e mantém a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar no Distrito Federal e nos Territórios. Todas elas hão de ser instituídas em lei, como órgãos permanentes estruturados em carreira.

A *polícia federal* destina-se:

(1) a apurar infrações penais contra a ordem política e social (*não contra a ordem pública*, note-se) ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

(2) a prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; *contrabando* e *descaminho* são duas modalidades de crimes parecidas mas não idênticas, embora comumente se chame tudo de *contrabando*; este consiste na introdução no território nacional ou na retirada dele de mercadorias proibidas; se se proíbe a importação ou a exportação de determinada mercadoria no interesse da política econômica, mas alguém, assim mesmo, atravessa as fronteiras nacionais com tal mercadoria, aí está cometendo o *crime de contrabando*; se essa pessoa, no entanto, introduz ou retira mercadorias, cuja importação ou exportação é permitida mediante pagamento de tributos, mas, no

caso, iludiu o fisco e não pagou o imposto pertinente, então cometeu o *crime de descaminho*;

(3) a exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;

(4) a exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

A *polícia rodoviária federal* e a *polícia ferroviária federal* destinam-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo, respectivamente, das rodovias e das ferrovias federais. Só *das federais*, porque o patrulhamento das rodovias e ferrovias estaduais é matéria de competência das polícias dos Estados.

4. Polícias estaduais

São *polícias estaduais*, responsáveis pelo exercício das funções de segurança pública e de polícia judiciária: a *polícia civil*, a *polícia militar* e o *corpo de bombeiros militar*.

À *polícia civil*, dirigida por delegado de carreira, em cada Estado, incumbem as funções de *polícia judiciária*, nos termos já definidos antes, e a apuração de infrações penais, exceto: (a) as de competência da polícia federal no âmbito restrito já assinalado; (b) as militares.

À *polícia militar*, em cada Estado, cabem a *polícia ostensiva* e a *preservação da ordem pública*, enquanto ao *corpo de bombeiros militar* de cada Estado compete, além de outras definidas em lei, como a de prevenção e debelação de incêndios, a execução de atividades de defesa civil. Essas polícias militarizadas dos Estados são consideradas *forças auxiliares* do Exército e se subordinam, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

As polícias civis e militares do Distrito Federal e dos Territórios são, porém, organizadas e mantidas pela União (art. 21, XIV), mas as dos Estados são por estes organizadas e mantidas, obedecidas, no entanto, normas gerais federais previstas nos arts. 22, XXI, e 24, XVI, sobre a organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros, e sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Estas últimas, pela primeira vez, ficam subordinadas a normas gerais federais, sem qualquer justificativa, para tanto, a não ser meros interesses corporativos que fizeram introduzir tal dispositivo na Constituição.

5. Guardas municipais

Os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de polícia municipal. Com isso, os Municípios

não ficaram com nenhuma específica responsabilidade pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que sendo entidade estatal não podem eximir-se de ajudar os Estados no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança e menos ainda de polícia judiciária.

A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir *guardas municipais* destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí certamente está uma área que é de segurança: assegurar a incolumidade do patrimônio municipal, que envolve bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais, mas não é de polícia ostensiva, que é função exclusiva da Polícia Militar.

QUARTA PARTE

DA ORDEM ECONÔMICA E DA ORDEM SOCIAL

Título I

Da Ordem Econômica

Capítulo I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

I. BASES CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA: 1. Questão de ordem. 2. Constitucionalização da ordem econômica. 3. Elementos sócio-ideológicos. 4. Fundamento e natureza da ordem econômica instituída. 5. Fim da ordem econômica. II. CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E SEUS PRINCÍPIOS: 6. Idéia de constituição econômica. 7. Princípios da constituição econômica formal. 8. Soberania nacional econômica. 9. Liberdade de iniciativa econômica. 10. Livre concorrência e abuso do poder econômico. 11. Princípios de integração. 12. Empresa brasileira e capital estrangeiro. III. ATUAÇÃO ESTATAL NO DOMÍNIO ECONÔMICO. 13. Capitalismo, socialismo e estatismo. 14. Serviço público e atividade econômica estatal. 15. Modos de atuação do Estado na economia. 16. Exploração estatal de atividade econômica. 17. Monopólios. 18. Intervenção no domínio econômico. 19. Planejamento econômico.

I. BASES CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA

1. Questão de ordem

As bases constitucionais do sistema econômico encontram-se nos arts. 170 a 192, compreendidos em quatro capítulos: um sobre os princípios da atividade econômica; outro sobre a política urbana; um terceiro sobre a política agrícola e fundiária e sobre a reforma agrária; e, finalmente, um quarto sobre o sistema financeiro nacional. Não daremos a mesma distribuição à matéria. Assim é que neste capítulo cuidaremos dos princípios da atividade econômica, tomada aqui a palavra *princípios* mais no sentido de fundamentos da ordem econômica do que apenas de normas-síntese informadoras do sistema, mas também destas. Num segundo capítulo estudaremos as propriedades na ordem econômica, envolvendo as questões minerais, de política urbana, da política agrícola e reforma agrária. Um terceiro capítulo será dedicado ao *sistema financeiro nacional*.

2. Constitucionalização da ordem econômica

A ordem econômica adquiriu dimensão jurídica a partir do momento em que as constituições passaram a discipliná-la sistematicamente, o que teve início com a Constituição mexicana de 1917. No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira a consignar princípios e normas sobre a ordem econômica, sob a influência da Constituição alemã de Weimar.¹ Isso não quer dizer que, nessa disciplina, se colhe necessariamente um “sopro de socialização”. Não, aqui, como no mundo ocidental em geral, a ordem econômica consubstanciada na Constituição não é senão uma forma econômica capitalista,² porque ela se apóia inteiramente na apropriação privada dos meios de produção e na iniciativa privada (art. 170). Isso caracteriza o *modo de produção capitalista*, que não deixa de ser tal por eventual ingerência do Estado na economia nem por circunstancial exploração direta de atividade econômica pelo Estado e possível monopolização de alguma área econômica, porque essa atuação estatal ainda se insere no princípio básico do capitalismo que é a apropriação exclusiva por uma classe dos meios de produção, e, como é essa mesma classe que domina o aparelho estatal, a participação deste na economia atende a interesses da classe dominante.

A atuação do Estado, assim, não é nada menos do que uma tentativa de pôr ordem na vida econômica e social, de arrumar a desordem que provinha do liberalismo. Isso tem efeitos especiais, porque importa em impor condicionamentos à atividade econômica, do que derivam os *direitos econômicos* que consubstanciam o conteúdo da constituição econômica, que examinaremos ainda neste capítulo. Mas daí não se conclui que tais efeitos beneficiem as classes populares. Sua função consiste em racionalizar a vida econômica, com o que se criam condições de expansão do capitalismo monopolista, se é que tudo já não seja efeito deste.

1. Para a evolução da matéria nas constituições brasileiras, cf. Josaphat Marinho, “A ordem econômica nas constituições brasileiras”, *RDP* 19/51; Fábio Lucas, *Conteúdo social nas constituições brasileiras*, Belo Horizonte, UFMG, 1959; Alberto Venâncio Filho, *A intervenção do estado no domínio econômico*, Rio de Janeiro, FGV, 1968; Modesto Carvalhosa, *A ordem econômica na Constituição de 1969*, São Paulo, RT, 1972. Para uma postura crítica da ordem econômica na Constituição de 1988: Eros Roberto Grau, *Contribuição para a interpretação e a crítica da ordem econômica na Constituição de 1988*, São Paulo, 1990.

2. Cf. Vital Moreira, *A ordem jurídica do capitalismo*, p. 35, onde esclarece que um “sistema econômico pode manifestar-se concretamente sob formas diversas. Aos vários modos de manifestação de um mesmo sistema econômico pode chamar-se forma econômica”. Cf. também Pierre Duclos, *L'évolution des rapports politiques depuis 1750*, pp. 148 e ss.

3. Elementos sócio-ideológicos

Recordaremos, aqui, apenas o que já deixamos escrito na Primeira Parte deste volume, quando estudamos, esquematicamente, os elementos das constituições, que decorrem de sua estrutura normativa. Então, mostramos que os *elementos sócio-ideológicos* são o conjunto de normas que revela o caráter de compromisso das constituições modernas entre o Estado liberal e o Estado social intervencionista. O primeiro firmou a restrição dos fins estatais, consagrando uma declaração de direitos do homem, como *estatuto negativo*, com a finalidade de proteger o indivíduo contra a usurpação e abusos do poder; o segundo busca suavizar as injustiças e opressões econômicas e sociais que se desenvolveram à sombra do liberalismo.

“Esse embate entre o liberalismo [escrevemos em outro livro] com seu conceito de democracia política, e o intervencionismo ou socialismo repercute nos textos das constituições contemporâneas, com seus princípios de direitos econômicos e sociais, comportando um conjunto de disposições concernentes tanto aos direitos dos trabalhadores como à estrutura da economia e ao estatuto dos cidadãos. O conjunto desses princípios forma o chamado conteúdo social das constituições. Mas é justo reconhecer que, nessa luta, as reivindicações sociais mal conseguem introduzir-se nas cartas constitucionais. Poucas têm conseguido firmar-se como normas plenamente eficazes. Muitas são traduzidas nos textos supremos apenas *em princípio*, como esquemas genéricos, simples programas a serem desenvolvidos posteriormente pela atividade dos legisladores ordinários. São estas que constituem as *normas constitucionais de princípio programático*”.³

São, apesar disso, normas de grande importância, porque procuram dizer *para onde* e *como* se vai, buscando atribuir *fins* ao Estado, esvaziado pelo liberalismo econômico, conforme lição de Pontes de Miranda.⁴ Essa característica teleológica confere-lhes relevância e função de princípios gerais de toda a ordem jurídica, como bem assinala Natoli,⁵ tendente a instaurar um regime de democracia substancial (mas ainda distante de uma democracia socialista), ao determinarem a realização de fins sociais, através da atuação de programas de intervenção na ordem econômica, com vistas à realização da justiça

3. Cf. nosso *Aplicabilidade das normas constitucionais*, p. 128. Essas palavras ainda se ajustam à Constituição de 1988, especialmente à vista de sua ordem econômica, que não avançou nada em relação ao sistema anterior. Antes regrediu. Mas também é justo reconhecer que a atual Constituição é muito mais progressista, no seu todo, do que as anteriores, conforme temos proclamado ao longo deste volume.

4. Cf. *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. I/127.

5. Cf. *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1952, p. 29.

social.⁶ Revelam, assim, um *compromisso* apenas entre as forças políticas liberais e tradicionais e as reivindicações populares de justiça social. Consubstanciam os *direitos econômicos e sociais*, embora nem sempre com eficácia capaz de atender ditas reivindicações de maneira satisfatória. A despeito disso, pode-se dizer que, assim como as declarações dos direitos do homem do século XVIII postularam a realização dos valores jurídicos da segurança, da ordem e da certeza, as declarações constitucionais dos direitos econômicos e sociais, reveladas nesses elementos sócio-ideológicos, pretendem a realização do valor-fim do Direito: a *justiça social*, que é uma aspiração do nosso tempo, em luta aberta contra as injustiças do individualismo capitalista.⁷

4. Fundamento e natureza da ordem econômica instituída

A Constituição declara que a ordem econômica é fundada na *valorização do trabalho humano* e na iniciativa privada. Que significa isso? Em primeiro lugar quer dizer precisamente que a Constituição consagra uma economia de mercado, de natureza capitalista, pois a *iniciativa privada* é um princípio básico da ordem capitalista. Em segundo lugar significa que, embora capitalista, a ordem econômica dá prioridade aos valores do trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de mercado. Conquanto se trate de declaração de princípio, essa prioridade tem o sentido de orientar a intervenção do Estado, na economia, a fim de fazer valer os valores sociais do trabalho que, ao lado da iniciativa privada, constituem o fundamento não só da ordem econômica, mas da própria República Federativa do Brasil (art. 1º, IV).

5. Fim da ordem econômica

A ordem econômica, segundo a Constituição, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da *justiça social*, observados os princípios indicados no art. 170, princípios estes que, em essência, como dissemos, consubstanciam uma ordem capitalista. Não nos enganemos, contudo, com a retórica constitucional. A declaração de que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, só por si, não tem significado substancial, já que a análise dos princípios que informam essa mesma ordem não garante a efetividade daquele fim.

A ordem econômica, configurada na Constituição, prevê apenas algumas medidas e princípios que, bem lembrou Josaphat Marinho

6. Cf. nossa *ob. cit.*, p. 139.

7. *Idem*, p. 130.

em termos válidos ainda, “poderão sistematizar o campo das atividades criadoras e lucrativas e reduzir desigualdades e anomalias diversas, na proporção em que as leis se converterem em instrumentos reais de correção das contradições de interesses privados.

“Mas, desses princípios e medidas advêm soluções de transição, apenas moderadoras dos excessos do capitalismo. São fórmulas tecnocráticas e neocapitalistas, que não suprimem as bases da ordem econômica individualista, fundada no poder privado de domínio dos meios de produção e dos lucros respectivos.”⁸

Assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da *justiça social*, não será tarefa fácil num sistema de base capitalista e, pois, essencialmente individualista. É que a justiça social só se realiza mediante equitativa distribuição da riqueza.⁹ Um regime de acumulação ou de concentração do capital e da renda nacional, que resulta da apropriação privada dos meios de produção, não propicia efetiva justiça social, porque nele sempre se manifesta grande diversidade de classe social, com amplas camadas de população carente ao lado de minoria afortunada. A história mostra que a injustiça é inerente ao modo de produção capitalista, mormente do capitalismo periférico.¹⁰ Algumas providências constitucionais formam agora um conjunto de direitos sociais com mecanismos de concreção que devidamente utilizados podem tornar menos abstrata a promessa de justiça social. Esta é realmente uma determinante essencial que impõe e obriga que todas as demais regras da constituição econômica sejam entendidas e operadas em função dela.¹¹

Um regime de justiça social será aquele em que cada um deve poder dispor dos meios materiais para viver confortavelmente segundo as exigências de sua natureza física, espiritual e política.¹² Não aceita as profundas desigualdades, a pobreza absoluta e a miséria. O reconhecimento dos direitos sociais, como instrumentos de tutela dos menos favorecidos, não teve, até aqui, a eficácia necessária para reequilibrar a posição de inferioridade que lhes impede o efetivo exer-

8. Cf. “A ordem econômica e social nas Constituições brasileiras”, *RDP* 19/59.

9. Sobre a noção de *justiça social*, cf. Modesto Carvalhosa, *ob. cit.*, pp. 56 e ss.; Eros Roberto Grau, *Elementos de direito econômico*, pp. 54 e ss.

10. Samir Amin sustenta mesmo a tese de que a estabilidade de repartição de renda nos países capitalistas do centro na época contemporânea não exclui, mas antes supõe, uma repartição de rendas muito mais desigual nos países capitalistas periféricos. Cf. *La déconnexion*, p. 167.

11. Sobre o valor das normas constitucionais sobre *justiça social*, cf. Celso Antônio Bandeira de Mello, “Eficácia das normas constitucionais sobre justiça social”, tese n. 8 à 9ª Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (Florianópolis, 2 a 6.5.82).

12. Cf. Pierre Duclos, *ob. cit.*, p. 149.

cício das liberdades garantidas.¹³ Assim, no sistema anterior, a promessa constitucional de realização da justiça social não se efetivara na prática. A Constituição de 1988 é ainda mais incisiva no conceber a ordem econômica sujeita aos ditames da justiça social para o fim de assegurar a todos existência digna. Dá à justiça social um conteúdo preciso. Preordena alguns princípios da ordem econômica — a *defesa do consumidor*, a *defesa do meio ambiente*, a *redução das desigualdades regionais e pessoais* e a *busca do pleno emprego* — que possibilitam a compreensão de que o capitalismo concebido há de *humanizar-se* (se é que isso seja possível). Traz, por outro lado, mecanismos na ordem social voltados à sua efetivação. Tudo depende da aplicação das normas constitucionais que contêm essas determinantes, esses princípios e esses mecanismos.

II. CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E SEUS PRINCÍPIOS

6. Idéia de constituição econômica

Seria sem propósito empreender aqui uma larga discussão sobre o conceito de constituição econômica. A doutrina ainda não firmou orientação segura sobre o tema.¹⁴ Reconhecemos valor ao conceito de constituição econômica, desde que não pensemos que as bases constitucionais da ordem econômica é que definem a estrutura de determinado sistema econômico, pois isso seria admitir que a constituição formal (superestrutura) *constitua* a realidade material (constituição material: infra-estrutura). Mas também não se trata de aceitar um determinismo econômico mecânico sobre a realidade jurídica formal. Se esta é forma, torna evidente que recebe daquela os fundamentos de seu conteúdo. Mas a forma também influi na modelagem da matéria.¹⁵ Aqui interessa considerar a *constituição econômica formal*, como a parte da Cons-

13. Nesse ponto, cf. Pietro Barcellona, *Diritto privato e processo economico*, p. 123.

14. Para aprofundar-se o tema, cf. Vital Moreira, *Economia e constituição*, Coimbra, Faculdade de Direito, 1974; idem, *A ordem jurídica do capitalismo*, Coimbra, Centelha, 1973; Francesco Galgano (Diretor), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* — v. I: *La costituzione economica*, Padova, CEDAM, 1977; Luiz Sánchez Agesta (Coordenador), *Constitución y economía: la ordenación del sistema económico en las constituciones occidentales*, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1977; Werter R. Faria, *Constituição econômica: liberdade de iniciativa e de concorrência*, Porto Alegre, Sérgio Antônio Fabris Editor, 1990.

15. Chamaria de *positivismo dialético* essa concepção do Direito como formado por influência da infra-estrutura, mas que a ela retorna como parte da realidade toda, influenciando-a, e assim modificada condiciona novas formas jurídicas que retomam... num processo dialético dinâmico de dominância do real à superestrutura jurídica e influência desta naquela, de modo que a compreensão do Direito legislado (ou não) depende da compreensão da realidade que o condiciona, porque ocorre aí uma conexão de sentido desta para aquele.

tuição que interpreta o sistema econômico, ou seja: que dá forma ao sistema econômico, que, em essência, é o capitalista. Vale dizer: a *constituição econômica formal brasileira* consubstancia-se na *parte da Constituição Federal que contém os direitos que legitimam a atuação dos sujeitos econômicos, o conteúdo e limites desses direitos e a responsabilidade que comporta o exercício da atividade econômica*.¹⁶

Não se trata de conceber a constituição econômica formal como simples disciplina jurídica fundamental da intervenção do Estado no domínio econômico, que seria concepção considerada, com razão, muito estreita e insuficiente.¹⁷ Procura-se fixar a idéia de que a *constituição econômica formal*, como objeto do Direito Constitucional positivo, consiste, não num conceito autônomo de constituição ao lado da constituição política, mas, sim, no conjunto de normas desta que, “garantindo os elementos definidores de um determinado sistema econômico”, estabelece os princípios fundamentais de “determinada forma de organização e funcionamento da economia” e constitui, “por isso mesmo, uma determinada ordem econômica”.¹⁸

7. Princípios da constituição econômica formal

Esta expressão, na verdade, equivale a dizer *princípios constitucionais da ordem econômica*. A Constituição os relaciona no art. 170, onde está dito que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

- (1) soberania nacional;
- (2) propriedade privada;
- (3) função social da propriedade;
- (4) livre concorrência;

16. Cf. Justino F. Duque Dominguez, “Iniciativa privada y empresa”, in *Constitución y economía*, p. 52.

17. A propósito, Vital Moreira, *Economia e constituição*, p. 137.

18. Vê-se que nos inspiramos em Vital Moreira, reduzindo, porém, seu conceito de constituição econômica (material) aos limites da constituição formal. O conceito do brilhante autor português é: “A CE é, pois, o conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os elementos definidores de um determinado sistema econômico, instituem uma determinada forma de organização e funcionamento da economia e constituem, por isso mesmo, uma determinada ordem econômica”. Cf. *Economia e constituição*, p. 35. Ficamos, assim, perto da lição do mesmo autor, quando, em outra obra importante, lembra que todas as constituições contêm uma *ordem econômica constitucional*, uma *constituição econômica formal*. Cf. *A ordem jurídica do capitalismo*, pp. 33 e ss.

- (5) defesa do consumidor;
- (6) defesa do meio ambiente;
- (7) redução das desigualdades regionais e sociais;
- (8) busca do pleno emprego;
- (9) tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Alguns desses princípios se revelam mais tipicamente como objetivos da ordem econômica, como, por exemplo, o da redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego. Mas todos podem ser considerados princípios na medida em que constituem preceitos condicionadores da atividade econômica. Da *propriedade privada* e de *sua função social* já tratamos antes, e o faremos no capítulo seguinte, dedicado ao estudo da propriedade na ordem econômica.

A par do exame desses princípios, em correlação com outras exigências constitucionais da ordem econômica, discutiremos as questões da atuação do Estado no domínio econômico, do monopólio possível e dos instrumentos de participação do Estado na economia, que são ingredientes disto que a doutrina costuma chamar de economia mista ou ordem econômica de compromisso.

8. Soberania nacional econômica

O art. 1º dá a *soberania* como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e, pois, do Estado Democrático de Direito em que ela se constitui, enquanto o art. 4º põe a *independência nacional* como princípio de suas relações internacionais. Então, quando o art. 170 declara que a *soberania nacional* é um dos princípios da ordem econômica, isso terá de ter consequências específicas nesse campo. Tratar-se-á de *soberania nacional econômica*.

Qual significado terá essa declaração?

Se formos ao rigor dos conceitos, teremos que concluir que, a partir da Constituição de 1988, a ordem econômica brasileira, ainda de natureza periférica, terá de empreender a ruptura de sua dependência em relação aos centros capitalistas desenvolvidos. Essa é uma tarefa que a Constituinte, em última análise, confiou à burguesia nacional, na medida em que constitucionalizou uma ordem econômica de base capitalista. Vale dizer, o constituinte de 1988 não rompeu com o sistema capitalista, mas quis que se formasse um capitalismo nacional autônomo, isto é, não dependente. Com isso, a Constituição criou as condições jurídicas fundamentais para a adoção do *desenvolvimento autocrático, nacional e popular*, que, não sendo sinônimo de isolamento

ou autarquização econômica, possibilita marchar para um sistema econômico desenvolvido, em que a burguesia local e seu Estado tenham o domínio da reprodução da força de trabalho, da centralização do excedente da produção, do mercado e a capacidade de competir no mercado mundial, dos recursos naturais e, enfim, da tecnologia.¹⁹

É claro que essa formação capitalista da Constituição de 1988 tem que levar em conta a construção do Estado Democrático de Direito, em que, como vimos, se envolvem direitos fundamentais do homem que não aceitam a permanência de profundas desigualdades, antes, pelo contrário, reclamam uma situação de convivência em que a dignidade da pessoa humana seja o centro das considerações da vida social.

Ou a burguesia nacional compreende esse sentido das normas constitucionais e empreende a soberania econômica nacional, ou corre o risco de, numa outra etapa posterior, um novo constituinte assumir, em definitivo, a tese da desconexão que significa *desvencilhar os critérios de racionalidade das escolhas econômicas internas daqueles que governam o sistema mundial*.²⁰ “Pois, se a burguesia é incapaz de *desconectar*, e se só uma aliança popular deve e pode convencer-se que a desconexão é uma necessidade incontornável de todo projeto de desenvolvimento popular, a dinâmica social deve conduzir a inscrever o projeto popular numa perspectiva para a qual não encontramos outro qualificativo senão o de socialismo”.²¹

9. Liberdade de iniciativa econômica

A *liberdade de iniciativa* envolve a liberdade de indústria e comércio ou liberdade de empresa e a liberdade de contrato. Consta do art. 170, como um dos esteios da ordem econômica, assim como de seu parágrafo único, que *assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo casos previstos em lei*.

É certamente o princípio básico do liberalismo econômico. Surgiu como um aspecto da luta dos agentes econômicos para libertar-se dos vínculos que sobre eles recaiam por herança, seja do período feudal, seja dos princípios do mercantilismo.²² No início, e durante o

19. Sobre o desenvolvimento autocrático e a temática conexa apresentada, cf. Samir Amin, *L'échange inégal et la loi de la valeur*, Paris, Anthropos, 1988, pp. 151 e ss., e *La déconnexion*, pp. 25 e ss.; Carlos Lopes, *Para uma leitura sociológica da Guiné-Bissau*, p. 128.

20. Cf. Samir Amin, *La déconnexion*, p. 39.

21. Idem, p. 40.

22. Cf. Vittorio Ottaviano, “Il governo dell'economia: i principi giuridici”, in *Tratato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia — v. I: La costituzione economica*, pp. 200 e 201.

século passado até a Primeira Grande Guerra (1914-1918), a liberdade de iniciativa econômica significava garantia aos proprietários da possibilidade de usar e trocar seus bens; garantia, portanto, do caráter absoluto da propriedade; garantia de autonomia jurídica e, por isso, garantia aos sujeitos da possibilidade de regular suas relações do modo que tivessem por mais conveniente; garantia a cada um para desenvolver livremente a atividade escolhida.²³

Ora, a evolução das relações de produção e a necessidade de propiciar melhores condições de vida aos trabalhadores, bem como o mau uso dessa liberdade e a falácia da “harmonia natural dos interesses” do Estado liberal, fizeram surgir mecanismos de condicionamento da iniciativa privada, em busca da realização de justiça social, de sorte que o texto supratranscrito do art. 170, parágrafo único, sujeito aos ditames da lei, há de ser entendido no contexto de uma Constituição preocupada com a justiça social e com o bem-estar coletivo.

Assim, a *liberdade de iniciativa econômica privada*, num contexto de uma Constituição preocupada com a realização da justiça social (o fim condiciona os meios), não pode significar mais do que “liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo poder público, e, portanto, possibilidade de gozar das facilidades e necessidade de submeter-se às limitações postas pelo mesmo”.²⁴ É legítima, enquanto exercida no interesse da justiça social.²⁵ Será ilegítima, quando exercida com objetivo de puro lucro e realização pessoal do empresário. Daí por que a iniciativa econômica pública, embora sujeita a outros tantos condicionamentos constitucionais, se torna legítima, por mais ampla que seja, quando destinada a assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Cumprido, então, observar que a liberdade de iniciativa econômica não sofre compressão só do Poder Público. Este efetivamente o faz legitimamente nos termos da lei, quer regulando a liberdade de indústria e comércio, em alguns casos impondo a necessidade de autorização ou de permissão para determinado tipo de atividade econômica, quer regulando a liberdade de contratar, especialmente no que tange às relações de trabalho, mas também quanto à fixação de preços, além da intervenção direta na produção e comercialização de certos bens.

23. Idem, p. 201.

24. Idem, p. 202.

25. Com razão, pois, Modesto Carvalhosa, quando a concebe como liberdade fundamental relativa e, assim, como instrumento da justiça social e do desenvolvimento nacional (cf. *ob. cit.*, pp. 114 e 115); cf. também, para uma discussão mais ampla do tema, Paolo Cavaleri, *Iniziativa economica privata e costituzione “vivente”*, Padova, CEDAM, 1978; Paolo de Carli, *Costituzione e attività economica*, Padova, CEDAM, 1978.

Acontece que o desenvolvimento do poder econômico privado, fundado especialmente na concentração de empresas, é fator de limitação à própria iniciativa privada, na medida em que a concentração capitalista impede ou estorva a expansão das pequenas iniciativas econômicas.

10. Livre concorrência e abuso do poder econômico

A *livre concorrência* está configurada no art. 170, IV, como um dos princípios da ordem econômica. Ela é uma manifestação da liberdade de iniciativa, e, para garanti-la, a Constituição estatui que *a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros* (art. 173, § 4º).

Os dois dispositivos se complementam no mesmo objetivo. Visam tutelar o sistema de mercado e, especialmente, proteger a livre concorrência, contra a tendência açambarcadora da concentração capitalista. A Constituição reconhece a existência do poder econômico. Este não é, pois, condenado pelo regime constitucional. Não raro esse poder econômico é exercido de maneira anti-social. Cabe, então, ao Estado intervir para coibir o abuso.

“Quando o poder econômico passa a ser usado com o propósito de impedir a iniciativa de outros, com a ação no campo econômico, ou quando o poder econômico passa a ser o fator concorrente para um aumento arbitrário de lucros do detentor do poder, o abuso fica manifesto.”²⁶

Essa prática abusiva, que decorre quase espontaneamente do capitalismo monopolista, é que a Constituição condena, não mais como um dos princípios da ordem econômica, mas como um fator de intervenção do Estado na economia, em favor da economia de livre mercado. Pululam leis antitrustes, sem eficácia.²⁷ O que cumpre reconhecer, na verdade, é que não existe mais economia de mercado nem livre concorrência, desde que o modo de produção capitalista evoluiu para as formas oligopolistas. Falar hoje em economia des-

26. Cf. Guilherme A. Canedo de Magalhães, *O abuso do poder econômico: apuração e repressão*, Rio de Janeiro, Artenova, 1975, p. 16; cf. também Benjamin M. Shieber, *Abuso do poder econômico*, p. 3, citando Agamenon Magalhães; Ruy de Souza, *Abuso do poder econômico*, p. 17.

27. No Brasil, vigora a Lei 8.384/1994 (dispõe sobre a repressão das infrações contra a ordem econômica); cf., além das citações anteriores, Gérard Farjat, *Droit économique*, Paris, PUF, 1971; J. A. Manzanedo, J. Hermano e E. Gómez Reino, *Curso de derecho administrativo económico*, pp. 645 e ss.; e, para o direito comparado, Luciano Labaure Casaravilla, *Monopolio trusts carteles: derecho comparado — antecedentes y legislación argentina y uruguaya*, Montevideo, A.M.F., 1963.

centralizada, como economia de mercado, é tentar encobrir uma realidade palpável de natureza diversa. A economia está centralizada nas grandes empresas e em seus agrupamentos. Daí por que se torna praticamente ineficaz a legislação tutelar da concorrência. É que a concentração capitalista não é um fenômeno patológico, mas uma realidade fundamental do novo Estado industrial, como bem observa Farjat: “A verdade é que não é preciso buscar, na regulamentação econômica da concorrência, o que não se encontra (ou jamais se encontrou). A concorrência não é (ou nunca foi) o que se acreditava que ela era, à época em que nasceram as legislações antitrustes. As combinações, as posições dominantes, as práticas restritivas, as concentrações não são, em si mesmas, fenômenos patológicos, mas constituem, ao contrário, uma realidade fundamental do novo Estado industrial — a ordem privada econômica”.²⁸ É uma realidade que não se modificará com mera determinação legal formal, senão com as transformações de seus próprios fundamentos.

11. Princípios de integração

Juntamos aqui considerações sobre a *defesa do consumidor*, a *defesa do meio ambiente*, a *redução das desigualdades regionais e sociais* e a *busca do pleno emprego*. Chamamo-los de *princípios de integração*, porque todos estão dirigidos a resolver os problemas da marginalização regional ou social. Todos já mereceram tratamento em outros lugares, como a *defesa do consumidor*, de que cuidamos, como um dos direitos coletivos consignados no art. 5º, e a ele nos reportamos como princípio da ordem econômica. A *defesa do meio ambiente* merecerá nosso exame mais devagar quando formos estudar a matéria do art. 225, mas é importante destacar aqui que, tendo-a elevado ao nível de princípio da ordem econômica, isso tem o efeito de condicionar a atividade produtiva ao respeito do meio ambiente e possibilita ao Poder Público interferir drasticamente, se necessário, para que a exploração econômica preserve a ecologia. A *redução das desigualdades regionais e sociais* é, também, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, III) e, já vimos, por um lado, que os direitos sociais e os mecanismos da seguridade social são preordenados no sentido de buscar um sistema que propicie maior igualização das condições sociais, e, por outro lado, consignamos, alhures, a preocupação constitucional com a solução das desigualdades regionais, prevendo mecanismos tributários (Fundo Especial) e orçamentários para tanto (regionalização, arts. 43 e 165, § 1º).

28. *Ob. cit.*, p. 239. Cf. também Fábio Konder Comparato, *O poder de controle na sociedade anônima*, São Paulo, RT, 1976, p. 419.

A *busca do pleno emprego* é um princípio diretivo da economia que se opõe às políticas recessivas. Pleno emprego é expressão abrangente da utilização, ao máximo grau, de todos os recursos produtivos. Mas aparece, no art. 170, VIII, especialmente no sentido de propiciar trabalho a todos quantos estejam em condições de exercer uma atividade produtiva. Trata-se do pleno emprego da força de trabalho capaz. Ele se harmoniza, assim, com a regra de que a ordem econômica se funda na valorização do trabalho humano. Isso impede que o princípio seja considerado apenas como mera busca quantitativa, em que a economia absorva a força de trabalho disponível, como o consumo absorve mercadorias. Quer-se que o trabalho seja a base do sistema econômico, receba o tratamento de principal fator de produção e participe do produto da riqueza e da renda em proporção de sua posição na ordem econômica.

12. Empresa brasileira e capital estrangeiro

O art. 170, IX, com redação da EC 6/95, arrola também como princípio da ordem econômica o *tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País*. Essa nova redação importa em profunda modificação no conceito de *empresa brasileira*, mormente tendo em vista a revogação do art. 171 da Constituição por força do art. 3º da mesma Emenda Constitucional. O texto nos remete, assim, ao novo conceito de empresa brasileira e também ao problema das microempresas.

Empresa brasileira. O conceito de *empresa brasileira* foi um dos mais debatidos e controvertidos no seio da Assembléia Nacional Constituinte. O debate nasceu na Comissão Afonso Arinos, cujo Anteprojeto, no art. 323, por proposta do ilustre Barbosa Lima Sobrinho, estabeleceu que só se consideraria empresa brasileira, para todos os fins de direito, aquela cujo controle de capital pertencesse a brasileiros e que, constituída e com sede no País, nele tivesse o centro de suas decisões. O conceito de empresa nacional sequer é novidade na ordem jurídica brasileira. A revogada lei das sociedades por ações (Decreto-lei 2.627/40) já conceituava como nacionais as sociedades organizadas na conformidade da lei brasileira e que tivessem no País a sede de sua administração (art. 60). Nada há que estranhar nisto, pois, como bem dizia Waldemar Ferreira, a propósito desse dispositivo, as *sociedades mercantis*, por isso mesmo que têm personalidade, *têm nacionalidade*, e acrescentava que não poucas vezes cuida a lei da nacionalidade dos sócios ou acionistas para que as sociedades possam realizar determinados objetivos.²⁹ Por isso mesmo, dizia que as

29. Cf. *Instituições de direito comercial*, v. 1, t. 2/477.

sociedades anônimas tanto podem ser nacionais, como estrangeiras,³⁰ porque esta é uma realidade concreta, a que, posteriormente a seus estudos, vieram juntar-se as empresas multinacionais. O que é de estranhar é os empresários brasileiros mesmos, a despeito do fato concreto dessas distinções, reagirem contrariamente à sua conceituação constitucional, ao seu reconhecimento normativo.

O certo é que, no fim das contas, as correntes divergentes chegaram a um acordo sobre o tema, que traduziram no art. 171, com base no qual se admitia a existência de *empresas brasileiras, empresas brasileiras de capital nacional e empresas não brasileiras* (empresas estrangeiras e empresas multinacionais ou transnacionais). O art. 171, I, considerava *empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e que tivesse a sua sede e administração no País*. Pois bem, com a revogação desse art. 171, desapareceu o conceito de empresa brasileira de capital nacional, ficando apenas o conceito de empresa brasileira tal como constava do seu inciso I, correspondente ao de sociedade nacional do revogado Decreto-lei 2.627/40, que decorre da nova redação do art. 170, IX, e também do art. 176, § 1º. Assim, temos, agora, empresas brasileiras e empresas não-brasileiras, com diferença exclusivamente formal entre elas, pois basta que a empresa estrangeira ou multinacional (ou parte dela) se organize aqui segundo as leis brasileiras e tenha sede aqui para ser reputada brasileira, pouco importando a nacionalidade de seu capital e a nacionalidade, domicílio e residência das pessoas que detêm o seu controle, de tal sorte que toda a discussão que as edições anteriores deste livro empreendiam a respeito do conceito de controle efetivo e sua titularidade direta ou indireta que cabia a pessoas físicas domiciliadas e residentes no País perdeu sentido em face da nova conceituação.³¹ Suprimido o conceito de empresa brasileira de capital nacional, com a revogação do art. 171, igualmente suprimidos ficaram os privilégios e preferências que a acompanhavam e que não se transferem para as empresas constituídas sob as leis brasileiras e com sede e administração no País, a não ser as indicadas nos citados arts. 170, IX, e 176, § 1º.

Microempresas. O princípio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte consta do art. 170, IX, como dissemos. A Constituição não se contentou com o simples enunciado do princípio, pois já estabeleceu que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às *microempresas* e às *empresas de pequeno porte*, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a

30. Idem, p. 687.

31. Para conhecimento do que dizíamos sobre o assunto, cf., na 10ª ed., pp. 729-731.

incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio da lei (art. 179). Reconhece aí dois tipos de pequenas empresas: as micro e as de pequeno porte, deixando à lei defini-las e distingui-las. Sem importância agora a discussão feita nas edições anteriores quanto a saber se o tratamento diferenciado, previsto no art. 179, aplicava-se apenas às microempresas e às empresas brasileiras de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no País ou se também se estendia às empresas de pequeno porte de capital nacional, porquanto não mais existe o conceito de empresas brasileiras de capital nacional. A nova redação dada ao art. 170, IX, fala apenas em empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País, não importando mais a origem do seu capital, nem a natureza de seu controle, nem sua titularidade. A discussão, do ponto de vista do direito constitucional positivo, desapareceu. Portanto, qualquer empresa de pequeno porte, tal como as microempresas, está abrangida pelo art. 179.

Capital estrangeiro. A Constituição não é contra o capital estrangeiro. Não se encontra nela nada que se oponha a ele; ao contrário, até prevê a possibilidade de sua participação em instituições financeiras (art. 192, III). Apenas estatui que *a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros*, o que constitui exercício regular do princípio da soberania econômica nacional, agora previsto no art. 170, I. Mesmo que não estivesse previsto explicitamente, o princípio decorre da soberania estatal, de que é manifestação em um campo específico. O próprio capital nacional é sujeito a regulamentação de vários tipos, desde a previsão legal de formas de sociedade e empresa, seu registro, fiscalização etc.; por que se há de escusar ou de censurar como xenófobo um dispositivo que apenas estatui a disciplina legal do capital estrangeiro, como certos setores empresariais o fizeram?

III. ATUAÇÃO ESTATAL NO DOMÍNIO ECONÔMICO

13. Capitalismo, socialismo e estatismo

Temos afirmado que a Constituição agasalha, basicamente, uma opção capitalista, na medida em que assenta a ordem econômica na livre iniciativa e nos princípios da propriedade privada e da livre concorrência (art. 170, *caput* e incs. II e IV). O princípio da propriedade privada envolve, evidentemente, a propriedade privada dos meios de produção, e o fato mesmo de admitir investimentos de capital

estrangeiro, ainda que sujeitos à disciplina da lei, de reconhecer o poder econômico como elemento atuante no mercado (pois só se condena o abuso desse poder) e a excepcionalidade da exploração direta da atividade econômica pelo Estado (art. 173), bem mostra que a Constituição é capitalista. Mas ela, apesar disso, abre caminho às transformações da sociedade com base em alguns instrumentos e mecanismos sociais e populares que consagrou, conforme já observamos no estudo anterior do conceito de Estado Democrático de Direito.

Se a ordem econômica estabelecida fosse mais progressista, por certo que a Constituição teria dado um passo importante, não necessariamente no sentido socialista, mas, quem sabe, ao menos, no sentido da construção de uma sociedade nacional popular pós-capitalista, em que transitoriamente se combinam, conflitualmente, as forças do socialismo, do capitalismo e do estatismo,³² como a realidade histórica mostra ser possível e talvez o modo possível de superar o capitalismo em sua forma mais grosseira e selvagem.

Embora o capitalismo assente-se na livre iniciativa e na apropriação privada dos meios de produção, não significa que a supressão dela, só por si, leve ao socialismo. Samir Amin é claro neste ponto: "a supressão da propriedade privada dos meios de produção essenciais, em proveito do Estado e das cooperativas, é tida por sinônimo de socialismo e da abolição da exploração das classes. De evidência, a realidade social e política impõe uma crítica desta redução do conceito de socialismo", pois este "implica muito mais", já que seu "conteúdo positivo implica o controle e o domínio social do desenvolvimento das forças produtivas pelos próprios trabalhadores".³³

A mera supressão da propriedade dos meios de produção poderá gerar, sim, uma sociedade pós-capitalista, não socialista, consubstanciada num modo de produção diverso, que Samir Amin denomina *estatismo* ou modo de produção "estatista".³⁴ O problema do *estatismo* é que ele nem sempre importa na libertação do homem; não raro é despótico, tecnocrático, burocrático e gerador de uma nova classe dominante, como se reconhece no Estado produzido pela revolução russa,³⁵ sem negar que o estatismo, assim mesmo, pode revelar-se uma força de progresso na medida mesma em que constitua uma ruptura com a mundialização do capitalismo.

32. Sobre essa temática, cf. as reflexões de Samir Amin, *La déconnexion* cit., pp. 5 e ss., e "Prefácio", in Carlos Lopes, *Para uma leitura sociológica da Guiné-Bissau*, pp. 5 e ss.

33. Cf. *La déconnexion*, p. 42.

34. Idem, p. 45.

35. O reconhecimento ainda é de Samir Amin, *ob. cit.*, pp. 46 e ss.

Outro problema do *estatismo* é que não se sabe exatamente para onde irá, se não será um novo sistema de classes, se não se transformará pura e simplesmente num capitalismo de Estado (e existem fortes sintomas nessa direção), o que será a consolidação de nova classe (tecnocrática e burocrática) dominante que importe na superexploração dos trabalhadores, ou se constituirá mesmo uma transição para o socialismo ou apenas se tratará de um impasse, ou se regredirá a uma nova forma de capitalismo com *perestroika* e outras "aberturas".

A estatização no Brasil, desses últimos tempos, não é propriamente o *estatismo*, de que estamos falando. Foi uma espécie de *estatização* no nível dos interesses das chamadas classes produtoras, o empresariado, os capitalistas. Constituiu-se, em verdade, numa alavanca de sustentação da frágil classe empresarial brasileira. Teve a sua imponência, por certo, e ainda tem. Mas essa estatização irracional, que importou especialmente em acudir situações desastrosas da iniciativa privada, demonstrou que esse tipo de participação do Estado na economia não só não beneficiou o progresso social das classes trabalhadoras, como até o prejudicou e comprimiu. A participação do Estado na economia será uma necessidade, enquanto, no sistema capitalista, se busque condicionar a ordem econômica ao cumprimento de seu fim de assegurar existência digna a todos, conforme os ditames da justiça social e por imperativo de segurança nacional.

14. Serviço público e atividade econômica estatal

O tema da atuação do Estado no domínio econômico exige prévia distinção entre *serviços públicos*, especialmente os de conteúdo econômico e social, e *atividades econômicas*, distinção que tem fundamento na própria Constituição, respectivamente art. 21, XI e XII, e arts. 173 e 174.

A *atividade econômica*, no regime capitalista, como é o nosso, desenvolve-se no regime da livre iniciativa sob a orientação de administradores da empresa privada. É claro que, consoante já vimos, numa ordem econômica destinada a realizar a justiça social, a *liberdade de iniciativa econômica privada* não pode significar mais do que "liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo Poder Público". É, sim, um direito fundamental, enquanto exercido no interesse da realização da justiça social, da valorização do trabalho e do desenvolvimento nacional.

O *serviço público* é, por natureza, estatal. Tem como titular uma entidade pública. Por conseguinte, fica sempre sob o regime jurídico de direito público. O que, portanto, se tem que destacar aqui e agora

é que não cabe titularidade privada nem mesmo sobre os serviços públicos de conteúdo econômico, como são, por exemplo, aqueles referidos no art. 21, XI e XII, que já estudamos quando comentamos o conteúdo desses dispositivos.

Tenham-se presentes essas distinções para a compreensão da natureza e limites das empresas estatais; pois sob o ponto de vista de sua função diferenciam-se em dois tipos: as prestadoras ou exploradoras de serviços públicos (como a CESP, a CEMIG, a Companhia do Metrô, a TELEBRÁS, a Rede Ferroviária Federal etc.) e as exploradoras de atividade econômica (como a PETROBRÁS, o Banco do Brasil etc.). O regime jurídico dessas empresas é diferente. As primeiras entram no conceito de descentralização de serviços pela personalização da entidade prestadora. Assim é que a Constituição diz que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, assim como os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, tudo nos termos da nova redação que a EC 8/95 deu aos incisos XI e XII do art. 21, abrindo-se a possibilidade de exploração dos serviços de telecomunicações também por empresas privadas.

O modo de gestão desses serviços públicos, entre outros, não só de competência da União, mas também dos Estados, Distrito Federal e Municípios, entra no regime da discricionariedade organizativa, ou seja, cabe à Administração escolher se o faz diretamente, ou por delegação a uma empresa estatal (pública ou de economia mista), ou por concessão (autorização ou permissão) a uma empresa privada.

Mazanedo, Hernando e Gómez, contudo, observam que orientações doutrinárias recentes destacam os inconvenientes da gestão de serviços públicos através de empresários privados, postulando uma transformação do atual regime de "discricionariedade organizativa" em favor da exclusiva gestão administrativa de serviços públicos. Esclarecem logo que a discricionariedade da Administração Pública para eleger o modo de gestão dos serviços públicos de conteúdo econômico deveria limitar-se pela finalidade do próprio serviço, incompatível com técnicas baseadas no lucro mercantil pelas exigências de absoluto controle de benefícios e mesmo de participação dos usuários na direção ou nos resultados, mediante diminuição de tarifas.³⁶

Cumpre observar que a exploração dos serviços públicos, conforme indicado acima, por empresa estatal não se subordina às limitações do art. 173, que nada tem com eles. Efetivamente, não tem cabi-

mento falar em excepcionalidade, ou subsidiariedade, em relação à prestação de serviços públicos por entidades estatais ou por seus delegados. Portanto, também não comporta mencionar, a respeito deles, a preferência da iniciativa privada. Significa dizer, pois, que a empresa estatal prestadora daqueles e de outros serviços públicos pode assumir formas diversas, não necessariamente sob o regime jurídico próprio das empresas privadas. A natureza das empresas estatais prestadoras de serviço público se assemelha às concessionárias de serviço público com diferenças importantes, quais sejam a de não se sujeitarem inteiramente aos ditames do art. 175, pois não se lhes aplicam as regras de reversão, nem de encampação, nem, rigorosamente, o princípio do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, já que os serviços não lhes são outorgados por via contratual, mas por via de lei instituidora, e porque são entidades do próprio concedente, salvo, é claro, hipóteses de outorga dos serviços a empresa estatal de outra entidade pública (da União para o Estado, por exemplo, em que a característica de concessionária fica mais nítida).

De fato, o art. 175 estabelece os princípios do regime da concessão e da permissão de serviços públicos a empresas particulares,³⁷ declarando que a outorga depende de licitação e que a lei disporá sobre tais empresas, assim como sobre: (a) o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação; (b) as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; (c) os direitos dos usuários; (d) a política tarifária; (e) a obrigação de manter serviço adequado. Que lei? A lei própria do poder concedente, que pode ser a União (lei federal), Estado (lei estadual), o Distrito Federal (lei distrital) e Município (lei municipal), pois o art. 175 não mais fala em lei federal mas apenas em lei, o que remete à competência das entidades constitucionais autônomas, com o que estas recuperaram sua plena autonomia normativa nessa matéria, apenas ficando sujeitas às normas gerais federais, à vista do disposto no art. 22, XXVII. Tal é também o sentir de Hely Lopes Meirelles, quando afirma: "pela Constituição de 1988, cabe à entidade concedente editar a lei regulamentar de suas concessões, o que não impede sobrevenha norma federal-nacional com preceitos gerais para todas as concessões (CF, art. 22, XXVII)",³⁸ lembrando que os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo já haviam editado as leis de concessões de seus serviços públicos: respectivamente, Lei 1.481, de 21.6.89, e Lei 7.835, de 8.5.92. A Lei federal 8.987, de

37. A matéria é de direito administrativo, não cabendo pormenores aqui. Para aprofundar, cf. Cármen Lúcia Antunes Rocha, *Estudos sobre concessão e permissão de serviço público no direito brasileiro*, São Paulo, Saraiva, 1996.

38. Cf. *Direito administrativo brasileiro*, p. 340.

13.2.95, assumiu a concepção aqui sustentada, quando no parágrafo único do art. 1º estatuiu que a “União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços”.

15. Modos de atuação do Estado na economia

A Constituição já não é tão clara, como as anteriores, quanto aos *modos de atuação do Estado na economia*. Fala em exploração direta da atividade econômica pelo Estado e do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica. Quer dizer: o Estado pode ser um agente econômico e um agente disciplinador da economia. Pode-se manter, em face da atual Constituição, a mesma distinção que surtia das anteriores, qual seja a de que ela reconhece duas formas de ingerência do Estado na ordem econômica: a *participação* e a *intervenção*. Ambas constituem instrumentos pelos quais o Poder Público ordena, coordena e atua a observância dos princípios da ordem econômica tendo em vista a realização de seus fundamentos e de seu fim, já tantas vezes explicitados aqui. É importante ter em vista essas razões que fundamentam a atuação do Estado brasileiro no domínio econômico, porque, se essa atuação não é princípio da ordem econômica, não pode também ser vista como simples exceção, na medida em que tanto a iniciativa privada como a estatal se destinam ao mesmo objetivo de realização daqueles fins, princípios e fundamentos.

16. Exploração estatal de atividade econômica

Há duas formas de exploração direta da atividade econômica pelo Estado, no Brasil. Uma é o *monopólio*, que estudaremos depois. A outra, embora a Constituição não o diga, é a *necessária*, ou seja, quando o exigir a segurança nacional ou interesse coletivo relevante, conforme definidos em lei (art. 173). Não se trata aqui de participação suplementar ou subsidiária da iniciativa privada. Se ocorrerem aquelas exigências, será legítima a participação estatal direta na atividade econômica, independentemente de cogitar-se de preferência ou de suficiência da iniciativa privada.

E isso não cabe só à União. A expressão *exploração direta da atividade econômica pelo Estado* abrange todas as entidades estatais (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Quando a Constituição emprega a palavra “Estado”, no sentido de ordenação jurídica soberana, refere-se a todas as unidades integrantes da República Federati-

va do Brasil. Quando não quer assim, menciona especificamente a União, ou qualquer outra unidade da Federação.

Instrumentos de participação do Estado na economia são a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades estatais ou paraestatais, como são as subsidiárias daquelas. As empresas e entidades que explorem atividade econômica deverão ter sua criação autorizada por lei específica, assim como depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de suas subsidiárias (art. 37, XIX e XX), cabendo à lei complementar definir as áreas de sua atuação (art. 37, XIX, enunciado da EC-19/98), a qual também estabelecerá o seu estatuto jurídico, dispondo sobre: I — sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; II — a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; III — licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; IV — a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com participação de acionistas minoritários; V — os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

Recordemos que essas exigências não se aplicam às empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades estatais ou paraestatais que explorem serviços públicos.

E, como qualquer entidade estatal pode explorar diretamente atividade econômica, bem se vê que União, Estados, Distrito Federal e Municípios podem, sempre por lei específica, criar e manter empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades destinadas à exploração das respectivas atividades econômicas, evidentemente segundo suas competências, sendo de lembrar, o que já dissemos antes, que pouco sobra para Estados, Distrito Federal e Municípios nessa matéria.

17. Monopólios

A Constituição não é favorável aos *monopólios*. Certamente que o *monopólio privado*, assim como os oligopólios e outras formas de concentração de atividade econômica privada, é proibido, pois está previsto que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. O *monopólio público* também ficou bastante limitado, pois já não se declara, como antes, a possibilidade de monopolizar determinada indústria ou atividade. Declara-se a possibilidade de ex-

ploração direta de atividade econômica quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (art. 173). Parece-nos que aí não entra o monopólio, que é reservado só para as hipóteses estritamente indicadas no art. 177 e agora com a flexibilização introduzida pela EC 9/95, que também veda a edição de medida provisória para regulamentar a matéria prevista nos incisos I a IV [(1) a (4) infra] do citado dispositivo, não sendo, porém, proibida para regulamentar a matéria do inciso V [(5) infra].

Esse dispositivo estabelece, com efeito, que constituem *monopólio da União*:

- (1) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
- (2) a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
- (3) a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos números anteriores;
- (4) o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;
- (5) a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados. A propósito, prevê-se que a lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional.

O § 1º do art. 177, na redação original, incluía, no monopólio, também o risco e o resultado das atividades nele mencionadas. A EC 9/95 deu nova redação a esse parágrafo, para declarar, ao contrário, que a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incs. I a IV do artigo [(1) a (4) supra], observadas as condições estabelecidas em lei; lei essa que disporá sobre (a) a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional; (b) as condições de contratação; e (c) a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União. Quer dizer, a flexibilização do monopólio das atividades constantes dos incs. I a IV do art. 177 foi estabelecida com certo cuidado, primeiro porque não opera diretamente da norma constitucional, mas de lei (Lei 9.478/97); segundo porque a própria Constituição impôs conteúdo à lei no sentido da preservação de privilégios do monopólio, consoante § 2º introduzido pela EC 9/95 ao art. 177.³⁹

39. A EC-35/2001 introduziu um § 4º nesse art. 177 para tratar de incidência da contribuição de intervenção no domínio econômico relativamente às atividades de

Vê-se, por esses dispositivos, que foi ampliado o campo do monopólio constitucionalmente estabelecido. Ele incide em três áreas, basicamente: petróleo, gás natural e minério ou minerais nucleares.

18. Intervenção no domínio econômico

Os autores costumam indicar várias modalidades possíveis de atuação estatal na economia, incluindo entre elas a atividade de polícia, que, a nosso ver, não o é. Não raro se emprega a expressão *intervenção no domínio econômico* num sentido amplo para abranger todas as formas de atuação do Estado na economia.⁴⁰ A Constituição vigente não repudia esta postura. Mas também não impede a distinção que estamos fazendo entre as duas modalidades de atuação estatal — a participação e a intervenção, tomada esta última em sentido restrito. A primeira com base nos arts. 173 a 177, caracterizando o Estado administrador de atividades econômicas; a segunda fundada no art. 174, em que o Estado aparece como *agente normativo e regulador da atividade econômica*, que compreende as funções de *fiscalização, incentivo e planejamento*, caracterizando o Estado regulador, o Estado promotor e o Estado planejador da atividade econômica.⁴¹

A intervenção por via de regulamentação da atividade econômica surgiu como pressão do Estado sobre a economia para devolvê-la à normalidade; normalidade, então, consistia em manter um regime de livre concorrência; por isso, as primeiras formas de intervenção manifestaram-se através de um conjunto de medidas legislativas que intentavam restabelecer a livre concorrência.⁴² Nesse sentido é o texto que embasa a legislação reprimidora do abuso do poder econômico, que deveria ser parágrafo do art. 174 e não do art. 173. Hoje existem muitos outros objetivos da regulamentação econômica, mediante a qual se disciplinam os preços, o consumo, a poupança e o investimento.⁴³ O art. 22 indica, como competência legislativa da

importação e comercialização de petróleo e gás natural. Tal matéria foi exposta na Terceira Parte, Tít. V, Cap. I, n. 4, sobre contribuições sociais, por ser ali o lugar adequado ao tratamento do assunto.

40. Nesse sentido, Alberto Venâncio Filho, *A intervenção do estado no domínio econômico*, Rio de Janeiro, FGV, 1968, distinguindo a intervenção em dois campos: *direito regulamentar econômico* e *direito institucional econômico*; cf. também o conceito de Mariano Baena del Alcazar, *Régimen jurídico de la intervención administrativa en la economía*, p. 37.

41. Cf. Lloyd D. Musolf, *O estado e a economia*, São Paulo, Atlas, trad. de Luiz Aparecido Caruso, 1968.

42. Cf. Mariano Baena del Alcazar, *ob. cit.*, pp. 73 e 79; cf. também Lloyd D. Musolf, *ob. cit.*, pp. 58 e ss.; e para pormenores sobre o *direito regulamentar econômico*, no sistema brasileiro, Alberto Venâncio Filho, *ob. cit.*, pp. 74 e ss.

43. Cf. Geraldo de Camargo Vidigal, *Teoria geral do direito econômico*, pp. 117, 132 e 150.

União, várias hipóteses que se inserem no tema da regulamentação econômica, como legislar sobre informática, política de crédito, câmbio, transferência de valores, comércio exterior e interestadual, diretrizes da política nacional de transportes, regime de portos, navegação, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, enquanto o art. 24 prevê a competência concorrente para legislar sobre *direito econômico*, que, por si só, é bastante para abranger todas as áreas de intervenção, sendo importante notar que aí se tem também a competência estadual, distrital (DF) e municipal, donde se vê que a tais entidades se reconhece o poder de intervenção na ordem econômica. É também dessa natureza a ordenação dos transportes aéreo, marítimo e terrestre, determinada no art. 178. A *fiscalização*, como toda fiscalização, pressupõe o poder de regulamentação, pois ela visa precisamente controlar o cumprimento das determinações daquele e, em sendo o caso, apurar responsabilidades e aplicar penalidades cabíveis. Não fora assim o poder de fiscalização não teria objeto.

Incentivo, como função normativa e reguladora da atividade econômica pelo Estado, traz a idéia do Estado promotor da economia. É o velho fomento, conhecido dos nossos ancestrais, que consiste em *proteger, estimular, promover, apoiar, favorecer e auxiliar*, sem empregar meios coativos, as atividades particulares que satisfaçam necessidades ou conveniências de caráter geral.⁴⁴ A própria Constituição já determinou apoio, estímulo e favorecimento a atividades específicas: o cooperativismo e o associativismo, as microempresas, nos termos dos arts. 174, §§ 3º e 4º, e 179.

O art. 174 declara que o Estado exercerá sua atividade de agente normativo e regulador, na forma da lei. Não se quer, com isso, dizer que a intervenção, nesses termos, dependa sempre de lei em cada caso específico. De fato, não se exige lei em cada caso para *estimular e apoiar* a iniciativa privada na organização e exploração da atividade econômica, como também não é mediante lei que se limitam atividades econômicas. Essas intervenções todas se realizam *mediante ato administrativo*, embora não possam efetivar-se senão de acordo com previsão legal. As limitações, sim, como ingerência disciplinadora, constituem formas de intervenção por via de regulamentação legal, mas o fomento nem sempre demanda lei, tal a implantação de infra-estrutura, a concessão de financiamento por instituições oficiais, o apoio tecnológico. A repressão do abuso do poder econômico é uma das formas mais drásticas de intervenção no domínio econômico e, no entanto, não é feita mediante lei, mas por ato administrativo do Conselho Ad-

ministrativo de Defesa Econômica (CADE), embora sempre nos termos da lei (Lei 8.884/94), no que se atende ao princípio da legalidade.

19. Planejamento econômico

Planejamento é um processo técnico instrumentado para transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente estabelecidos. O planejamento econômico consiste, assim, num processo de intervenção estatal no domínio econômico com o fim de organizar atividades econômicas para obter resultados previamente colimados. É, como diz Eros Grau, "a forma de ação estatal, caracterizada pela previsão de comportamentos econômicos e sociais futuros, pela formulação explícita de objetivos e pela definição de meios de ação coordenadamente dispostos, mediante a qual se procura ordenar, sob o ângulo macroeconômico, o processo econômico, para melhor funcionamento da ordem social, em condições de mercado".⁴⁵ O *planejamento econômico* é, assim, um instrumento de racionalização da intervenção do Estado no domínio econômico, ou como dispõe a Constituição: a lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do *desenvolvimento nacional* equilibrado (art. 174, § 1º). É uma técnica de intervenção, na lição de Washington Peluso Albino de Souza.⁴⁶ Essa doutrina foi acolhida pela Constituição no art. 174, que inclui o planejamento entre as funções do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica.

O processo de planejamento se *instrumenta* mediante a elaboração de *plano ou planos*. E o processo técnico que se traduz juridicamente em *planos*. Isso está consignado na Constituição em mais de uma oportunidade, ao dizer que o planejamento incorporará e compatibilizará os *planos nacionais e regionais* (art. 174, § 1º), ao estatuir que é função da lei dispor sobre *planos* e programas *nacionais, regionais e setoriais* de desenvolvimento (art. 48, IV) e que estes devam ser elaborados em consonância com o plano plurianual (arts. 48, II, e 165, § 4º), consubstanciando aí, como dissemos, os princípios do planejamento estrutural.

Um tema muito ao gosto da doutrina é o da *obrigatoriedade dos planos*. A questão se apresenta em face do valor jurídico do plano, no sentido de saber se os comandos das previsões do plano vinculam ou não os sujeitos econômicos. Se vincularem a todos, estaremos diante de um *plano imperativo*; no caso contrário, estaremos perante um

45. Cf. *Planejamento econômico e regra jurídica*, p. 45.

46. Cf. *Direito econômico*, São Paulo, Saraiva, 1980, p. 449; cf. também a crítica de Eros Grau, *A ordem econômica na Constituição de 1988*, p. 342.

44. Cf. Mariano Baena del Alcazar, *ob. cit.*, p. 94.

plano indicativo. “O primeiro se caracteriza no fato de que suas diretrizes são impositivas para a coletividade, como conjunto de normas obrigatórias de conduta, ao passo que no segundo esta é meramente sugerida pelo poder público àquela, e, se bem que ofereça estímulos para persuadir ou dissuadir os indivíduos (ou grupos) a ajustar-se aos seus ditames, não os impõe, e os indivíduos (ou grupos) são livres de ajustar-se ou não a eles”.⁴⁷ O primeiro consubstancia o planejamento socialista, o segundo o planejamento intervencionista.

“Em verdade, o que ocorre é que o plano se considera imperativo sempre para o setor público. Por isso, nos países de economia centralizada de tipo socialista, a imperatividade do plano é consequência de que as entidades econômicas são integrantes do setor público, não havendo distinção entre economia pública e economia privada, como se dá nos países de economia de mercado ou descentralizada. Nestes, o plano é imperativo também para o setor público, mas, como há um setor privado da economia, regido pelo princípio da iniciativa particular, o plano, em relação a ele, costuma ser indicativo, servindo-se de mecanismos indiretos para atraí-lo ao processo de planejamento.”⁴⁸ Assim pronunciamos-nos em edições anteriores, e agora a Constituição define expressamente a questão no mesmo sentido, estatuinto que o planejamento será *determinante para o setor público e indicativo para o setor privado* (art. 174).

Houve um tempo em que se discutiu muito sobre as relações entre planejamento econômico e democracia. Os conservadores negavam a possibilidade de um regime democrático realizar ação governamental planejada. Essa posição negativista fundava-se na idéia de que só há democracia e liberdade onde se deixe ao alvedrio da iniciativa privada toda atividade econômica. A questão está inteiramente superada. O constituinte não teve qualquer dúvida sobre a compatibilidade entre planejamento econômico e democracia, tanto que estruturou um Estado Democrático de Direito com previsão de sua intervenção na ordem econômica também por meio de planejamento econômico. Aceitou aí a tese de que não haverá democracia real onde não exista um mínimo de organização econômica planejada pelo Poder Público, visando a realização dos interesses populares. A questão se põe de outro modo, pois tanto pode haver planejamento num regime democrático — então se terá um *planejamento democrático* — como num regime ditatorial e então se terá um *planejamento autoritário*. O problema está sem-

47. Cf. Augusto de Ataíde, *Elementos para um curso de direito administrativo da economia*, pp. 222 e 223; cf. também Agustín A. Gordillo, *Derecho administrativo de la economía*, p. 423; Idem, *Introducción al derecho de la planificación*, pp. 39 e ss.; Fernando Garrido Falla, *Problemática jurídica de los planes de desarrollo económico*, pp. 95 e ss.

48. Cf. nosso *Direito urbanístico brasileiro*, pp. 112 e 114.

pre na dependência da participação do povo, pois, sendo o plano (expressão do planejamento) ato eminentemente político, requer previamente uma decisão política.⁴⁹ Por isso até se pensa que uma democracia econômica repousa no plano.⁵⁰ A adoção de um intervencionismo planejado revela a passagem do intervencionismo anárquico, pontual, para uma forma de *dirigismo* econômico.

Mais real, no entanto, é a dificuldade de conciliar o princípio federalista com o sistema de planejamento global (nacional) da economia, já que este pressupõe centralização de decisões e de controle, enquanto o federalismo é, por definição, descentralizador. Se se reconhece aos Estados e aos Municípios capacidade autônoma, inclusive para planejar suas atividades, torna-se problemático conseguir mecanismos que evitem entrechoques, contradição e incoerência entre os planos nacionais, os estaduais e os municipais.⁵¹ Por outro lado, impor uniformidade de cima para baixo consistirá em quebrar as autonomias das entidades regionais e locais. Um sistema integrado de planejamento harmônico é de difícil esquematização dentro de uma federação efetiva. A Constituição abre perspectivas nesse sentido, quando declara que *a lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento* (art. 174, § 1º). Uma forma possível é a integração por via de concertação entre União e Estados, de seus planos.

49. Cf. J. A. Manzanedo e outros, *ob. cit.*, p. 67.

50. Idem, *ibidem*: “El Plan, dentro de la estructura del Estado, deve ser la pieza maestra de una democracia económica, precisamente por su carácter global y por los pronunciamientos previos de tipo político que implica. De aquí la necesidad de buscar a toda costa el tipo de planificación que sea el instrumento adecuado para realizar una verdadera democracia económica”. E logo esses autores indicam os elementos dessa planificação democrática: (1) *caráter sistemático*; (2) *participação dos administrados*; (3) *a generalidade*; (4) *a coerência*; (5) *a vinculação do econômico com o social*; (6) *derivar sua unidade do fato de oferecer-se coletivamente como um projeto comunitário* (p. 68).

51. Cf. Jorge Gustavo da Costa, *Planejamento governamental*, pp. 505 e ss.; Guilherme Moojen, *Orçamento público*, p. 38: “A busca dos mesmos objetivos por duas ou três esferas de governo, cada uma planejando e agindo a seu modo, na mesma área física, tem ocasionado vultuosos desperdícios de recursos financeiros, os quais, em última análise, são pagos pelo mesmo contribuinte”.

Capítulo II

DAS PROPRIEDADES NA ORDEM ECONÔMICA

1. O princípio da propriedade privada. 2. Propriedade dos meios de produção e propriedade socializada. 3. Função social da empresa e condicionamento à livre iniciativa. 4. Propriedade de interesse público. 5. Propriedade do solo, do subsolo e de recursos naturais. 6. Propriedade de embarcações nacionais. 7. Política urbana e propriedade urbana. 8. Propriedade rural e reforma agrária.

1. O princípio da propriedade privada

A Constituição inscreveu a *propriedade privada* e a sua *função social* como *princípios da ordem econômica* (art. 170, II e III).¹ Já destacamos antes a importância desse fato, porque, então, embora também prevista entre os direitos individuais, ela não mais poderá ser considerada puro direito individual, relativizando-se seu conceito e significado, especialmente porque os princípios da ordem econômica são preordenados à vista da realização de seu fim: *assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social*. Se é assim, então a propriedade privada, que, ademais, tem que atender a sua função social, fica vinculada à consecução daquele fim. O regime da propriedade denota a natureza do sistema econômico. Se se reconhece o direito de propriedade privada, se ela é um princípio da ordem econômica, disso decorre, só por si, que se adotou um sistema econômico fundado na iniciativa privada. A Constituição o diz (art. 170).

Os conservadores da constituinte, contudo, insistiram para que a propriedade privada figurasse como um dos princípios da ordem econômica, sem perceber que, com isso, estavam relativizando o conceito de propriedade, porque submetendo-o aos ditames da justiça social, de sorte que se pode dizer que ela só é legítima enquanto cumpre uma função dirigida à justiça social.

2. Propriedade dos meios de produção e propriedade socializada

A *propriedade de bens de consumo e de uso pessoal* é, essencialmente, vocacionada à apropriação privada, porquanto são imprescindíveis à

1. Já observamos antes que a propriedade deveria ser prevista apenas como uma instituição da ordem econômica, como instituição de relações econômicas, como nas Constituições da Itália (art. 42) e de Portugal (art. 62).

própria existência digna das pessoas, e não constituem nunca instrumentos de opressão, pois satisfazem necessidades diretamente, isto é, "bens que servem diretamente ao sustento dos trabalhadores, tais como alimentos, roupas, alojamentos, etc."² A função social desses bens consiste precisamente na sua aplicação imediata e direta na satisfação das necessidades humanas primárias, o que vale dizer que se destinam à manutenção da vida humana. Disso decorre que sejam predispostos à aquisição de todos com a maior possibilidade possível, o que justifica até a intervenção do Estado no domínio da sua distribuição, de modo a propiciar a realização ampla de sua função social. E este é um princípio que se superpõe mesmo ao da iniciativa privada. Assim, a intervenção direta na distribuição de bens de consumo (conceito que inclui também os de uso pessoal duráveis: roupa, moradia etc.), para fomentar ou mesmo forçar o barateamento do custo de vida, constitui um modo legítimo de fazer cumprir a função social da propriedade.

Bens de produção, chamados também *capital instrumental*, são os que se aplicam na produção de outros bens ou rendas, como as ferramentas, máquinas, fábricas, estradas de ferro, docas, navios, matérias-primas, a terra, imóveis não destinados à moradia do proprietário mas à produção de rendas. Estes bens não são consumidos, são utilizados para a geração de outros ou de rendas. O regime de sua apropriação define a natureza do sistema econômico adotado. Se for o de apropriação social ou pública, será socialista. Quando se fala em propriedade socializada e em socialismo, refere-se a um sistema econômico em que os meios de produção não sejam suscetíveis, em princípio, de apropriação privada, com a observação, outra vez, de que não basta suprimir a propriedade privada dos meios de produção para se ter socialismo.

O sistema de apropriação privada, como no sistema de apropriação pública ou social, tende a organizar-se em *empresas*, sujeitas ao princípio da função social, como teremos que examinar em seguida. Vimos já que o nosso sistema é fundamentalmente o da propriedade privada dos meios de produção, o que revela ser basicamente capitalista, que a vigente Constituição tenta civilizar, buscando criar, no mínimo, um capitalismo social, se é que isso seja possível, por meio da estruturação de uma ordem social intensamente preocupada com a justiça social e dignidade da pessoa humana.

3. Função social da empresa e condicionamento à livre iniciativa

Já estudamos a *função social da propriedade*, quando examinamos o conteúdo do disposto no art. 5º, XXIII, segundo o qual a *propriedade atenderá a sua função social*. Isso aplicado ali à propriedade

2. Cf. Alfred Marshall, *Princípios de economia*, v. I/82.

em geral, significa estender-se a todo e qualquer tipo de propriedade. O art. 170, III, ao ter a função social da propriedade como um dos princípios da ordem econômica, reforça essa tese, mas a principal importância disso está na sua compreensão como um dos instrumentos destinados à realização da existência digna de todos e da justiça social. Correlacionando essa compreensão com a valorização do trabalho humano (art. 170, *caput*), a defesa do consumidor (art. 170, V), a defesa do meio ambiente (art. 170, VI), a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII) e a busca do pleno emprego (art. 170, VIII), tem-se configurada a sua direta implicação com a *propriedade dos bens de produção*, especialmente imputada à empresa pela qual se realiza e efetiva o poder econômico, o poder de dominação empresarial. Disso decorre que tanto vale falar de *função social da propriedade dos bens de produção*, como de *função social da empresa*, como de *função social do poder econômico*.³ Eros Grau é do mesmo sentir, quando escreve: "O princípio da função social da propriedade, para logo se vê, ganha substancialidade precisamente quando aplicado à propriedade dos bens de produção, ou seja, na disciplina jurídica da propriedade de tais bens, implementada sob compromisso com a sua destinação. A propriedade sobre a qual em maior intensidade refletem os efeitos do princípio é justamente a propriedade, *dinâmica*, dos bens de produção. Na verdade, ao nos referirmos à função social dos bens de produção em dinamismo, estamos a aludir à *função social da empresa*".⁴

Essas considerações complementam algumas idéias já lançadas, segundo as quais a iniciativa econômica privada é amplamente condicionada no sistema da constituição econômica brasileira. Se ela se implementa na atuação empresarial, e esta se subordina ao princípio da função social, para realizar ao mesmo tempo o desenvolvimento nacional, assegurada a existência digna de todos, conforme ditames da justiça social, bem se vê que a liberdade de iniciativa só se legitima quando voltada à efetiva consecução desses fundamentos, fins e valores da ordem econômica. Essas considerações são ainda importantes para a compreensão do princípio da necessidade que informa a participação do Estado brasileiro na economia (art. 173), pois a preferência da empresa privada cede sempre à atuação do Poder Público, quando não cumpre a função social que a Constituição lhe impõe.

3. Cf. Fábio Konder Comparato, *O poder de controle na sociedade anônima*, p. 419: "O poder econômico é uma função social, de serviço à coletividade". É esta a inteligência que dá ao princípio constante do art. 160, III, da Constituição revogada, igual ao disposto no art. 170, III, da Constituição de 1988.

4. Cf. *Elementos de direito econômico*, p. 128.

4. Propriedade de interesse público

São bens sujeitos a um regime jurídico especial e peculiar em virtude dos interesses públicos a serem tutelados, inerente à utilidade e a valores que possuem. Esse regime especial comporta vínculos, obrigações, deveres e ônus, relativamente à disponibilidade desses bens, que ficam assim sujeitos a circulação, uso e alienação controlados.⁵

Entre os bens de interesse público se incluem os integrantes do *meio ambiente cultural*, reconhecido como de notável beleza natural, de valor ou interesse histórico, artístico e arqueológico, assim como os constitutivos do meio ambiente natural (incluindo o patrimônio florestal) cuja qualidade deva ser tutelada em função da qualidade de vida: água, ar, recursos naturais etc.

A Constituição de 1988 deu relevante atenção a esses bens, fundamentando de maneira ampla e incisiva seu regime jurídico especial: quando abre um capítulo para a disciplina dos bens culturais incluídos no patrimônio cultural brasileiro (art. 216); quando outorga competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos (arts. 23, III, e 30, IX); e, especialmente, quando dedica um capítulo especial à proteção do meio ambiente, considerado bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225).

5. Propriedade do solo, do subsolo e de recursos naturais

Esse longo enunciado vale apenas para chamar a atenção sobre o regime especial da propriedade desses bens. O *solo* é, por regra, bem de propriedade privada (eventualmente, pública). Por princípio, a propriedade do solo abrange a do subsolo em toda a profundidade útil ao seu exercício (CC, art. 526). Esse princípio prevalece em face da atual Constituição. Esta, contudo, expressamente inclui entre os bens da União, no art. 20, VIII, IX e X, os *recursos minerais, inclusive os do subsolo, e os potenciais de energia hidráulica*. Por seu lado, o art. 176 estatui que as jazidas, em lavra ou não, e os demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica *constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União*. A pesquisa, a lavra e o aproveitamento desses recursos poderão ser efetuados por *brasileiros* (natos ou naturalizados) ou *empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País*, mediante autorização

5. Giuseppe Palma, *Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà*, pp. 9 a 11; Gastone Pasini, *La tutela delle bellezze naturali*, pp. 30 e ss. Nosso *Direito urbanístico brasileiro*, pp. 100, 101 e 439.

ou concessão da União, no interesse nacional, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas, cabendo ao concessionário o produto da lavra (art. 176, § 1º). Por aí se vê que a riqueza do subsolo, compreendidas as *cavidades naturais subterrâneas* e os *sítios arqueológicos e pré-históricos* (art. 20, X), como bens da União, constitui propriedade pública federal.

6. Propriedade de embarcações nacionais

Poucas palavras sobre o assunto, apenas para assinalar que a EC 7/95, que modificou o art. 178, abriu a possibilidade de estrangeiros serem proprietários de embarcações nacionais, bem como eliminou o monopólio nacional da navegação de cabotagem. Mas é ainda a lei que vai ordenar os transportes aéreos, aquáticos e terrestres, devendo, com relação à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade, assim como estabelecer as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem (que é a navegação entre portos do País) e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras.

7. Política urbana e propriedade urbana

A Constituição de 1988, pela primeira vez na história constitucional do País, consagra um capítulo à *política urbana*.

A concepção de política de desenvolvimento urbano da Constituição decorre da compatibilização do art. 21, XX, que dá competência à União para *instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano*, com o art. 182, que estabelece que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes e é executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Entenda-se: conforme as diretrizes instituídas por lei federal nos termos do art. 21, XX. Por certo também que essas diretrizes instituídas pela União é que consubstanciam a política de desenvolvimento urbano, pois que uma política há de ser uma *política nacional de desenvolvimento urbano* que, por seu turno, há de ser elemento da política nacional de desenvolvimento em geral. Foi com base nesse dispositivo que a União expediu o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).

Não nos parece boa a concepção de política de desenvolvimento urbano da Constituição, que só considerou objetivos intra-urbanos, pois é isso que significa desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Por isso também que sua execução cabe aos Municípios. Nesses termos a norma constitucional é coerente, pois que aí se situa um campo que deve mesmo ser de

estrita competência municipal. Mas essa política de desenvolvimento urbano fica bastante empobrecida e talvez não terá condições de implementar os objetivos importantes a ela assinados pelo art. 182, se não se vincular a uma política mais ampla que leve em conta também as dimensões interurbanas, como parte integrante de uma política de desenvolvimento econômico e social que ultrapassa o nível estritamente municipal, porquanto, como nota Jean Remy: “Dispor de uma rede urbana adequada é um dos problemas importantes pelos quais deve zelar uma política ciosa do crescimento das capacidades produtivas de uma economia e de melhoria do bem-estar das populações”.⁶

Essas observações não retiram a importância do texto constitucional sobre a matéria, mesmo porque ele não é excludente de uma política nacional de desenvolvimento urbano nos moldes suscitados. Releva ainda sua importância o ter previsto um instrumento básico da execução, pelos Municípios, da política de desenvolvimento urbano com os objetivos fixados no art. 182. É o que consta do § 1º desse dispositivo, quando determina que o *plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana*. E fica, desde logo, estabelecido que esse plano urbanístico — o plano diretor — depende de aprovação legislativa. Está sujeito ao princípio da legalidade.

O art. 182, § 2º, menciona expressamente a *propriedade urbana*, inserida no contexto de normas e planos urbanísticos, vinculando sua função social à ordenação da cidade expressa no plano diretor. A propriedade do *solo urbano* é especialmente considerada, no art. 182, § 4º, submetida à disciplina do plano urbanístico diretor. O *solo* qualifica-se como *urbano* quando ordenado para cumprir destino urbanístico, especialmente a *edificabilidade* e o *assentamento de sistema viário*. O citado art. 182, § 4º, consagra esse princípio de modo insofismável.

Com as normas dos arts. 182 e 183, a Constituição fundamenta a doutrina segundo a qual a propriedade urbana é formada e condicionada pelo direito urbanístico a fim de cumprir sua função social específica: realizar as chamadas funções urbanísticas de propiciar *habitação* (moradia), condições adequadas de *trabalho, recreação* e de *circulação humana*.

A utilização do solo urbano fica sujeita às determinações de leis urbanísticas e do plano urbanístico diretor. Isso decorre do disposto no art. 182 quando faculta ao Poder Público municipal, mediante lei

6. Cf. *La ville: phénomène économique — questions économiques, sociales et politiques*, p. 215; cf. também Jorge Guilherme Francisconi e Maria Adélia Aparecida de Souza, *Política nacional de desenvolvimento urbano: estudos e proposições alternativas*, pp. 7 e ss.

específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Vê-se, por aí, que, embora seja um avanço, é de exequibilidade praticamente inalcançável. Raramente se chegará à desapropriação prevista no texto.

Na verdade, a propriedade urbana pode ser desapropriada como qualquer outro bem de propriedade privada, mas a Constituição prevê dois tipos de desapropriação para o imóvel urbano. Um é a *desapropriação comum*, que pode ser por utilidade ou necessidade pública ou por interesse social nos termos dos arts. 5º, XXIV, e 182, § 3º, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. O outro é a *desapropriação-sanção*, que é aquela destinada a punir o não cumprimento de obrigação ou ônus urbanístico imposto ao proprietário de terrenos urbanos. Seu nome deriva, assim, do fato de que a privação forçada da propriedade, devido ao descumprimento de deveres ou ônus urbanísticos, fundados na função social da propriedade urbana, comporta redução da justa indenização, como se previa na lei urbanística espanhola, ou a substituição da indenização em dinheiro por indenização mediante títulos da dívida pública, como se estatui no art. 182, § 4º, III, como vimos acima.

Finalmente, o art. 183 institui o *usucapião pró-moradia*, em favor de quem possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O § 1º dispõe que: "O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil". Na verdade, não é o título de domínio e a concessão de uso, mas um ou outra, porque são institutos excludentes. Aliás, a bem da verdade, a concessão de uso não tem cabimento no caso, pois o usucapião é modo de aquisição da propriedade e não meio de obter mera concessão de uso. Consigna-se, outrossim, que esse usucapião não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez, no que o constituinte andou bem, pois quer-se que o imóvel não seja mais do que objeto de moradia. Veda-se, por outro lado, o usucapião, para tal fim, de imóveis públicos.

8. Propriedade rural e reforma agrária

Regime da propriedade rural. A propriedade rural, que se centra na propriedade da terra, com sua natureza de bem de produção, tem como *utilidade natural* a produção de bens necessários à sobrevivência humana, daí por que a Constituição consigna normas que servem de base à sua peculiar disciplina jurídica (arts. 184 a 191). É que a "propriedade da terra, bem que se presta a múltiplas formas de produção de riquezas, não poderia ficar unicamente em subserviência aos caprichos da natureza humana, no sentido de aproveitá-la ou não, e, ainda, como conviesse ao proprietário".⁷

A Constituição traz normas especiais sobre a propriedade rural que caracterizam seu regime jurídico especial, quer porque, como veremos, especificam o conteúdo de sua função social, quer porque instituem regras sobre a política agrícola e sobre a reforma agrária, com o fim de promover a distribuição da terra (arts. 184 a 191), quer porque inserem a problemática da propriedade agrária no título da ordem econômica (conferindo-lhe, assim, dimensão de direito econômico público) e, pois, como um elemento preordenado ao cumprimento de seu fim, qual seja: *assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social* (art. 170).

Essas disposições formam um conjunto de regras constitucionais que possibilita ampla intervenção do Poder Público nas relações de propriedade e de trabalho rural, com condicionamentos profundos, mas não fundamenta a socialização da terra. Ao contrário, a Constituição, nesse particular, foi tímida e muito conservadora, talvez mais do que o sistema que vigorava antes.

Função social da propriedade rural. O regime jurídico da terra "fundamenta-se na doutrina da função social da propriedade, pela qual toda a riqueza produtiva tem uma finalidade social e econômica, e quem a detém deve fazê-la frutificar, em benefício próprio e da comunidade em que vive".⁸ Essa doutrina, como observa Sodero, trouxe um novo conceito de direito de propriedade rural que informa que ela é um bem de produção e não simplesmente um bem patrimonial; por isso, quem detém a posse ou a propriedade de um imóvel rural tem a obrigação de fazê-lo produzir, de acordo com o tipo de terra, com a sua localização e com os meios e condições propicia-

7. Cf. L. Lima Stefanini, *A propriedade no direito agrário*, p. 99. Sobre a propriedade rural, cf. também Paulo Guilherme de Almeida, *Direito agrário: a propriedade imobiliária rural*, São Paulo, LTr, 1980; Luiz Olavo Baptista, "Conceito de propriedade e sua extensão ao direito agrário", RT 413/27.

8. Cf. Fernando Pereira Sodero, *Curso de direito agrário: 2 — o Estatuto da Terra*, p. 25.

dos pelo Poder Público, que também tem responsabilidade no cumprimento da função social da propriedade agrícola.⁹

Essa doutrina foi acolhida pela Constituição, que declara que toda propriedade atenderá sua função social (art. 5º, XXIII), que é um princípio da ordem econômica (art. 170, III). Por isso também se exige que a propriedade rural cumpra sua função social, mediante o atendimento, simultâneo, de cinco requisitos, que a Constituição apresenta no art. 186: (a) aproveitamento racional e adequado; (b) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis; (c) preservação do meio ambiente; (d) observância das disposições que regulam as relações de trabalho; (e) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Não basta que a propriedade cumpra um desses elementos. É necessário que atenda a todos simultânea e concomitantemente. Não requer, porém, que sejam eles observados sempre da mesma forma por todas as propriedades, independentemente de sua localização, tamanho e qualidade das terras. Por isso, determina que os requisitos serão cumpridos segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, mas, na falta desta, os princípios contidos nos requisitos devem ser observados.

A produtividade é um elemento da função social da propriedade rural. Não basta, porém, ser produtiva para que ela seja tida como cumpridora do princípio. Se ela produz, mas de modo irracional, inadequado, descumprindo a legislação trabalhista em relação a seus trabalhadores, evidentemente que está longe de atender a sua função social. Apesar disso, a Constituição estabeleceu que a lei garantirá tratamento especial à *propriedade produtiva* e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. De certo modo isso está previsto em relação a qualquer propriedade rural, pois é isso mesmo que significa a cláusula, constante do art. 186, ao estatuir que a função social será cumprida pela observância simultânea dos requisitos enumerados, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei. A proibição de desapropriação da propriedade produtiva, para fins de reforma agrária, com pagamento da indenização mediante títulos da dívida agrária, é, a nosso ver, absoluta, sendo inútil procurar interpretação diferente com base em nossos desejos. Isso não seria científico.

Reforma agrária. A sanção para o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social é a desapropriação por interesse social, para

9. *Ob. cit.*, pp. 25 e 31. É mesmo dever do Poder Público zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulando planos para a sua racional utilização, promovendo a justa remuneração e acesso do trabalhador aos benefícios do aumento da produtividade e ao bem-estar coletivo (Estatuto da Terra — Lei 4.504/64, art. 2º, § 2º, b).

fins de *reforma agrária*, mediante pagamento da indenização em títulos da dívida agrária, nos termos do art. 184. Não quer dizer que a reforma agrária possa fazer-se somente por esse modo. A desapropriação por interesse social, inclusive para melhor distribuição da terra, é um poder geral do Poder Público (art. 5º, XXIV), de maneira que a vedação de desapropriação, para fins de reforma agrária, da *pequena e média propriedade rural*, assim definida em lei e desde que seu proprietário não possua outra, e da *propriedade produtiva* configurada no art. 185 deve ser entendida em relação ao processo de reforma agrária constante do art. 184. Ou seja: o art. 185 contém uma exceção à desapropriação especial autorizada no art. 184, não ao poder geral de desapropriação por interesse social do art. 5º, XXIV. Quer dizer, desde que se pague a indenização nos termos do art. 5º, XXIV, qualquer imóvel rural pode ser desapropriado por interesse social para fins de reforma agrária e melhor distribuição da propriedade fundiária.

O conceito de *reforma agrária* sempre foi muito controverso. Aceita-se que não serão reforma agrária as intervenções que não importem na repartição direta da propriedade e do rendimento social agrícola.¹⁰ Não se confundem *reforma agrária* e *revolução agrária*. Se se faz uma transformação profunda das relações de produção agrárias, “que implique a destruição de um tipo de Estado, a abolição de uma classe dominante e também, naturalmente, a erradicação do modo de produção na agricultura”, como na ex-URSS e China de Mao, temos mais do que uma reforma, temos uma revolução agrária.¹¹ *Reforma agrária* é programa de governo, plano de atuação estatal, mediante intervenção do Estado na economia agrícola, não para destruir o modo de produção existente, mas apenas para promover a repartição da propriedade e da renda fundiária. Ao contrário, a concepção de reforma agrária, que se tem postulado no Brasil, até pelas esquerdas, e a Constituição consagrou (art. 189), reforça o modo de produção capitalista, na medida em que se pleiteia a redistribuição da terra em favor de unidade de produção familiar, o que difunde e consolida a propriedade agrária e cria resistências a uma transformação de tipo socialista.

10. Cf. Henrique de Barros, *Economia agrária*, v. III/243, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1954, para quem *reforma agrária* será “toda e qualquer intervenção (quer de carácter revolucionário, insurreccional, quer de índole estritamente legalista, ordeira e pacífica) de que resulte alteração sensível no esquema de repartição do rendimento social-agrícola, deslocando, em proveito de qualquer das classes interessadas (trabalhadores, capitalistas ou empresários), o modo até então vigente de dividir o grande ‘bolo’ comum”.

11. Cf. José Acosta Sánchez, “La reforma agraria y la modernización de las estructuras productivas”, in *Relaciones sociales en la agricultura* (obra que reúne os trabalhos debatidos no “XXI Encuentro entre Empresarios, Sindicalistas y Laboralistas”, realizado em Córdoba, Espanha, junho/83), Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1984, pp. 23 e ss.

Assim é o conceito do art. 16 do Estatuto da Terra: "A reforma agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do País, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio". Seu objetivo consiste em promover o acesso à propriedade rural mediante a distribuição ou a redistribuição de terras (art. 17). Não se exclui a conveniência e a importância desse tipo de reforma agrária. Mas é necessário desmistificar a falácia dos terratenentes que, desejando manter a estrutura agrária injusta vigente, tentam impingir a falsa concepção de que se trata de socialização ou comunicação.

Ao contrário disso, como observa José Acosta Sánchez, que, ao conceituar a reforma agrária como um plano do Estado para a redução na agricultura do modo de produção dominante, lembra que ela é feita exatamente para consolidar este modo de produção, não para destruí-lo.¹² A execução do plano de reforma agrária realiza-se mediante desapropriação do imóvel que não esteja cumprindo sua função social, mediante justa e prévia indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei, mas as benfeitorias serão indenizadas em dinheiro. Segundo o art. 184, § 3º, cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação, lei essa já promulgada: Lei Complementar 76, de 6.7.93, dispondo sobre o referido procedimento. Tudo isso dificulta a implementação da reforma agrária, mais do que previa o sistema constitucional anterior. Os imóveis desapropriados serão distribuídos, mediante título de domínio ou concessão de uso, ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente de estado civil, nos termos e condições previstos em lei. Aqui está uma característica conservadora da reforma agrária, consistente em distribuir a propriedade rural desapropriada por unidades de produção familiar, que é o tipo clássico das reformas agrárias do Estado burguês, em que, por razões ideológicas, "interessa assentar unidades de produção familiar, porque a unidade de produção familiar gera uma ideologia específica, geralmente conservadora, que salva-guarda o sistema, e politicamente e eleitoralmente propicia apoios à classe dominante".¹³ A saída progressista da reforma agrária, qualquer que seja a extensão da redistribuição da propriedade agrária, segundo José Acosta Sánchez, com razão, consiste em implantar nos terrenos expropriados unidades coletivas, cooperativas de produção ou

12. *Ob. cit.*, p. 25.

13. *Idem*, p. 26.

empresas (fazendas) comunitárias, com o que se desenvolve uma agricultura coletiva, sem ser coletivista.¹⁴ Esse tipo de reforma agrária parece-nos muito mais consoante com os princípios do Estado Democrático de Direito, do que o tipo clássico anotado acima.

Política agrícola. A política agrícola, cujas ações devem ser compatibilizadas com as da reforma agrária, será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, os instrumentos creditícios e fiscais, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização, o incentivo à pesquisa e à tecnologia, o seguro agrícola, o cooperativismo, a eletrificação rural e irrigação e a habitação para o trabalhador rural (art. 187). Neste artigo, a Constituição deixa bem claro que política agrícola, assistência financeira e técnica e outros estímulos não caracterizam reforma agrária, pois não importam em intervenção na repartição da propriedade e da renda da terra. Mas a Constituição, por certo, amparou mais a política agrícola do que a reforma agrária. Enquanto a esta se opuseram inúmeros obstáculos, àquela tudo corre liso e natural, porque aí o beneficiário é a classe dominante no campo.

Usucapião "pro-labore". É o que se prevê, no art. 191, em favor de quem, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia. Chama-se *pro-labore* esse usucapião especial, porque o título que o justifica decorre do fato de a área ter sido tornada produtiva *pelo trabalho* do beneficiário ou de sua família. Anota-se, contudo, que não se verifica usucapião de imóveis públicos.

Limitação ao estrangeiro. Consta do disposto no art. 190 que a lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. A Constituição dos Militares de 1969 era muito mais limitativa em matéria de propriedade rural, não só em relação a estrangeiro, como se pode lembrar, lendo o § 34 de seu art. 153, segundo o qual a lei disporia sobre a aquisição da propriedade rural por brasileiro e estrangeiro residente no País, assim como por pessoa natural ou jurídica, estabelecendo condições, restrições, limitações e demais exigências, para a defesa da integridade do território, a segurança do Estado e a *justa distribuição da propriedade*.

14. *Idem*, p. 27.

Capítulo III

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

1. Generalidades. 2. As alterações da EC-40/2003. 3. Lei complementar e recepção constitucional. 4. Sentido e objetivos. 5. Participação do capital estrangeiro nas instituições financeiras. 6. Cooperativas de crédito.

1. Generalidades

Há dois sistemas financeiros regulados na Constituição: o *público*, que envolve os problemas das finanças públicas e os orçamentos públicos, constantes dos arts. 163 a 169; e o *parapúblico*, que ela denomina de *sistema financeiro nacional*, que cuida das instituições financeiras creditícias, públicas ou privadas, de seguro, previdência (privada) e capitalização, todas sob estrito controle do Poder Público (art. 192). O banco central, que é instituição financeira, constitui, em verdade, um elo entre as duas ordens financeiras (arts. 164 e 192).

2. As alterações da EC-40/2003

A EC-40, de 29.5.2003, alterou profundamente o art. 192 da Constituição, eliminando todos os incisos e parágrafos. Transferiu para o *caput* do artigo a disciplina relativa à participação do capital estrangeiro nas instituições financeiras, que constava do inc. III, mas sem os condicionamentos que se previa nas alíneas *a* e *b* do inciso; passou também para o *caput* a previsão de disciplina das cooperativas de crédito, que figurava no inc. VIII. Com a eliminação dos parágrafos, a questão dos limites dos juros a 12%, que figurava no § 3º, desapareceu do texto constitucional.

Em virtude das alterações o dispositivo agora declara que o Sistema Financeiro Nacional será regulado por *leis complementares*. O texto modificado empregava “lei complementar” no singular; daí surgiu uma discussão quanto a saber se o Sistema teria que ser regulado por uma única lei complementar ou não. Nas edições anteriores, admitimos que o singular, no tocante à lei complementar, não significava uma lei só – o singular tinha sentido, não de único, mas

de generalidade –, e, portanto, o sistema poderia ser regulado por mais de uma lei complementar. A Emenda suprime as dúvidas.

3. Lei complementar e recepção constitucional

O *sistema financeiro nacional* será regulado em *leis complementares*. Fica valendo, como tal, pelo princípio da recepção, a Lei 4.595/1964, que precisamente instituiu o *sistema financeiro nacional* e outras leis que cuidam de aspectos do sistema financeiro nacional, como a Lei 4.380/1964, que disciplina o sistema financeiro da habitação. Não é, portanto, a Constituição que o está instituindo. Ela está constitucionalizando alguns princípios do sistema. Aquela lei vale, por conseguinte, como se lei complementar fosse. Sua alteração, pois, depende de lei complementar, ou seja, de lei formada nos termos do art. 69.

A continuidade da legislação precedente constitui um aspecto da *eficácia construtiva* das normas constitucionais, visto que essa legislação recebe da nova carta política outro jato de luz revivificadora que a revaloriza para a ordem jurídica nascente. São as normas anteriores como que recriadas pela Constituição que sucede. É esse o fenômeno que a técnica jurídico-constitucional denomina *recepção da lei anterior*.¹

Norberto Bobbio define a recepção como “o procedimento pelo qual um ordenamento incorpora no próprio sistema a disciplina normativa de uma dada matéria assim como foi estabelecida num outro ordenamento”. Isso tanto vale para a incorporação de uma norma de ordenamento jurídico estranho no ordenamento nacional como a incorporação de uma norma do ordenamento velho no ordenamento novo. Ainda é Bobbio quem nos dá a doutrina desse fenômeno:

“É um fato que, normalmente, parte do velho ordenamento passa para o novo, e apenas alguns princípios fundamentais referentes à Constituição do Estado se modificam. Como se explica essa passagem? A melhor explicação é aquela, que recorre à figura da *recepção*. No novo ordenamento tem lugar uma verdadeira e autêntica recepção de boa parte do velho; e entendem-se de fato recebidas todas aquelas normas que não sejam explícitas ou implicitamente abrogadas.

“O fato de o novo ordenamento ser constituído em parte por normas do velho não ofende em nada o seu caráter de novidade: as normas comuns ao velho e ao novo ordenamento pertencem apenas *materialmente* ao primeiro; *formalmente*, são todas normas do novo,

1. Cf. Norberto Bobbio, *Teoria do ordenamento jurídico*, p. 169; também em *Teoria generale del diritto*, p. 282.

no sentido de que elas são válidas não mais com base na norma fundamental do velho ordenamento, mas com base na norma fundamental do novo. Nesse sentido falamos de recepção, e não pura e simplesmente de permanência do velho no novo. A recepção é um ato jurídico com o qual um ordenamento acolhe e torna suas as normas de outro ordenamento, onde tais normas permanecem materialmente iguais, mas não são mais as mesmas com respeito à forma.”²

4. Sentido e objetivos

São importantes o sentido e os objetivos que a Constituição imputou ao sistema financeiro nacional, ao estabelecer que ele será *estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade*, de sorte que as instituições financeiras privadas ficam assim, também, e de modo muito preciso, vinculadas ao cumprimento de funções sociais bem caracterizadas. O dispositivo trata das relações institucionais do sistema financeiro, ou seja, aqui o que se busca regular são as relações do Poder Público com as instituições financeiras públicas ou privadas, não das relações entre as instituições financeiras e os usuários de seus serviços. Embora o controle do Poder Público sobre as instituições financeiras possa também amparar interesses dos usuários, isso não interfere diretamente com as relações destes com aqueles, que se regem por outras normas (direito comercial, direito bancário, direitos dos consumidores etc.), de sorte que as leis complementares só são exigidas na disciplina das relações institucionais, não nas relações negociais entre bancos e clientes, bancos e depositários, bancos e usuários dos serviços bancários. Essas relações negociais se regem pela legislação que lhe é própria. Significa isso que não há razão alguma que justifique a pretensão de exclusão da incidência do Código do Direito do Consumidor nas relações negociais entre bancos e clientela.³

5. Participação do capital estrangeiro nas instituições financeiras

As leis complementares (uma delas pelo menos) disporão sobre a participação do *capital estrangeiro* nas instituições que integram o sistema financeiro nacional, tendo em vista, especialmente, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País e o interesse da coletividade.

2. Cf. Bobbio, *Teoria do ordenamento jurídico*, p. 177; Hans Kelsen, *Teoría general del derecho y del Estado*, p. 138.

3. Jurisprudência: TJDF, Ap. Civ. 2001011045445-0, 3ª Turma Cível, Rel. Des. Wellington Medeiros, DJU 4.9.2002, Seção 3, p.70.

6. Cooperativas de crédito

O inc. VIII do art. 192, na redação primitiva, estatuiu que a lei complementar teria também que dispor sobre o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que pudessem ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições financeiras. A EC-40/2003, revogando aquele inciso, determinou, no entanto, que as leis complementares que dispuserem sobre o sistema financeiro nacional devem abranger também as cooperativas de crédito, e nada mais.

Título II

Da Ordem Social

Capítulo I

INTRODUÇÃO À ORDEM SOCIAL

1. Considerações gerais. 2. Base e objetivo da ordem social. 3. Conteúdo e princípios da ordem social.

1. Considerações gerais

Comentamos antes o conteúdo do art. 6º, que enumera os *direitos sociais*, que, pelo visto, encontram sua disciplina no título da ordem social. Ali, portanto, já examinamos o fundamental da matéria, deixando para esta parte a complementação daquele estudo, no que tange aos mecanismos e aspectos organizacionais da ordem social. É o que intentaremos neste título, sucintamente.

2. Base e objetivo da ordem social

A Constituição declara que a ordem social tem como *base* o primado do trabalho, e como *objetivo* o bem-estar e a justiça social. Neste particular, a ordem social se harmoniza com a ordem econômica, já que esta se funda também na valorização do trabalho e tem como fim (objetivo) assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, que já mereceu nossa consideração.

3. Conteúdo e princípios da ordem social

A Constituição deu bastante realce à ordem social. Forma ela com o título dos direitos fundamentais o núcleo substancial do regime democrático instituído.

Mas é preciso convir que o título da ordem social misturou assuntos que não se afinam com essa natureza. Jogaram-se aqui algumas matérias que não têm um conteúdo típico de ordem social. *Ciên-*

cia e tecnologia e meio ambiente só entram no conceito de ordem social, tomada essa expressão em sentido bastante alargado. Mesmo no sentido muito amplo, é difícil encaixar a matéria relativa aos *índios* no seu conceito.

Não tentaremos consertar isso. Nem vamos estudar a matéria exatamente segundo a capitulação constitucional. Separaremos os temas em quatro capítulos: (1) seguridade social; (2) ordem constitucional da cultura; (3) família, criança, adolescente e idosos, e, finalmente, (4) dos índios.

Capítulo II

DA SEGURIDADE SOCIAL

1. Conteúdo, princípios e financiamentos da seguridade social. 2. Saúde. 3. Previdência social. 4. Assistência social.

1. Conteúdo, princípios e financiamentos da seguridade social

A *seguridade social* compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à *saúde*, à *previdência* e à *assistência social*. São os *direitos sociais* relativos à seguridade que estudamos antes.¹ Rege-se pelos *princípios da universalidade da cobertura* (universalidade subjetiva) e do *atendimento* (universalidade objetiva), da *igualdade* ou equivalência dos benefícios, da *unidade de organização*, do caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados (art. 194, parágrafo único, VII) e da *solidariedade financeira*, porque será financiada por toda a sociedade de forma direta ou indireta, assim como de recursos provenientes dos orçamentos públicos e das seguintes contribuições sociais: (a) do *empregador, empresa ou entidade equiparada*, incidentes sobre: (a.1) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (a.2) receita ou faturamento, conforme setores de atividade econômica definidos em lei e segundo o princípio da não-cumulatividade; (a.3) lucro; em todas essas hipóteses, as contribuições podem ter base de cálculo diferenciada, em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho; (b) do *trabalhador e dos demais segurados da previdência social*, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; (c) *sobre receitas de concursos de prognósticos*; (d) dos *importadores de bens e servi-*

ços do exterior ou equiparado, também submetida ao princípio da não-cumulatividade. Tudo na forma pormenorizadamente estabelecidas nos incisos e parágrafos do art. 195, com as redações dadas pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.

2. Saúde

A *saúde* é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam.

As ações e serviços de saúde são de relevância pública, por isso ficam inteiramente sujeitos à *regulamentação, fiscalização e controle do Poder Público*, nos termos da lei, a que cabe executá-los diretamente ou por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Se a Constituição atribui ao Poder Público o *controle* das ações e serviços de saúde, significa que sobre tais ações e serviços tem ele integral poder de dominação, que é o sentido do termo *controle*, mormente quando aparece ao lado da palavra *fiscalização*.

O *sistema único de saúde*, integrado de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual o Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que tem no pólo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à promoção e à proteção da saúde é também um direito coletivo. O sistema único de saúde implica ações e serviços federais, estaduais, distritais (DF) e municipais, regendo-se pelos princípios da *descentralização*, com direção única em cada esfera de governo, do *atendimento integral*, com prioridade para as atividades preventivas, e da *participação da comunidade*, que confirma seu caráter de direito social pessoal, de um lado, e de direito social coletivo, de outro. É também por meio dele que o Poder Público desenvolve uma série de atividades de controle de substâncias de interesse para a saúde e outras destinadas ao aperfeiçoamento das prestações sanitárias. O sistema é financiado com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. A EC-29/2000, dando nova redação ao art. 198, previu que essas entidades apliquem, anualmente, em ações e serviços de saúde pública recursos do produto de suas arrecadações tributárias e de transferências em percentagens e critérios estabelecidos em lei complementar, mas o art. 77 do ADCT, acrescido pela mesma Emenda, já estabelece o percentual de 5% para a União, 12% para os Esta-

1. Cf. Segunda Parte, tit. III, cap. III.

dos e 15% para os Municípios e Distrito Federal, até a promulgação da referida lei complementar.

Responsável, pois, pelas ações e serviços de saúde é o Poder Público, falando a Constituição, neste caso, em *ações e serviços públicos de saúde*, para distinguir da *assistência* à saúde pela iniciativa privada, que ela também admite, e cujas instituições poderão participar complementarmente do sistema único de saúde, sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. O § 3º do art. 199 contém uma regra praticamente inócua, ao vedar a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei; como a lei pode prever todos os casos, não há limitação alguma. Talvez não fosse mesmo o caso de proibir a participação de empresas ou de capitais estrangeiros, mas apenas a remessa de lucros provenientes de serviços de assistência à saúde.

3. Previdência social

A *previdência social* será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e compreende prestações de dois tipos: *benefícios* e *serviços*.

Os *benefícios previdenciários* são *prestações pecuniárias* aos segurados e a qualquer pessoa que contribua para a previdência social na forma dos planos previdenciários, e são os seguintes:

(1) *auxílios* por doença, maternidade, reclusão e funeral (art. 201, I a III);

(2) *seguro-desemprego* (arts. 7º, II, 201, III, 239);

(3) *salário-família* e *auxílio reclusão* para os dependentes dos segurados de baixa renda;

(4) *pensão* por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, que não poderá ter valor inferior ao salário mínimo (art. 201, V, § 5º, e art. 202);

(5) sistema especial de *inclusão previdenciária* para atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo; a alteração introduzida pela EC-47/2005 não exclui a aposentadoria, como fazia o texto modificado; isso porque, por força do § 13 do art. 201, acrescido pela mesma emenda, esse sistema

especial de inclusão está sujeito a uma contribuição previdenciária, embora mediante alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social, do que decorre o correspondente direito à aposentadoria, uma vez compostos os requisitos desta;

(6) a *aposentadoria*, que é o mais importante dos benefícios, e é direito de todos os trabalhadores (art. 7º, XXIV) à inatividade remunerada com proventos calculados na forma ao art. 202, nos seguintes casos:

(a) por *invalidez*;

(b) por *tempo de contribuição*: (b.1) trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher (art. 201, § 7º, I); (b.2) trinta anos de contribuição, se professor, e vinte e cinco de contribuição, se professora, que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (art. 201, § 8º);

(c) por *idade*: aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

Assegura-se, em qualquer caso, a *contagem recíproca do tempo de contribuição* na Administração Pública e na atividade privada (art. 201, § 9º), mas é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Por regra, essas atividades são aquelas a que o art. 7º, XXIII, confere direito a um adicional de remuneração: atividades *penosas, insalubres e perigosas*, cujo sentido já mencionamos antes (p. 700).

A retribuição da aposentadoria, chamada *proventos*, será calculada com base no salário de contribuição. *Salário de contribuição* não é o mesmo que salário de retribuição de trabalho. É aquele sobre o qual recai a contribuição do empregado e do empregador para a previdência social, cujo máximo depende de fixação legal. Quer dizer, o segurado só se aposenta com retribuição igual ao seu salário quando este for igual ou inferior ao salário de contribuição. Quando o salário for superior a este, se o segurado quiser manter seu padrão terá de recorrer ao regime de previdência complementar, na forma do art. 202, dependente sua instituição e sistemática de lei complementar, pagando contribuição adicional. Isso, do ponto de vista social, é correto, porque a previdência pública destina-se a satisfazer os menos favoreci-

dos. As pessoas de altos salários podem complementar sua aposentadoria pagando contribuição adicional.

Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma de lei, mas, em compensação, também se assegura o reajustamento dos benefícios (proventos) para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critério definido em lei. O benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo, nem ultrapassar R\$ 2.400,00, reajustado, contudo, de forma a preservar permanentemente o seu valor real, de acordo com o disposto no art. 5º da EC-42/2003.

Os serviços *previdenciários* são hoje apenas o serviço social e o de habilitação e de reabilitação profissional. O *serviço social* constitui atividade auxiliar do seguro social e visa a prestar ao beneficiário orientação e apoio no que concerne à solução de problemas pessoais e familiares e à melhoria da sua inter-relação com a previdência social, para a solução de questões referentes a benefícios e obtenção de outros recursos sociais da comunidade. O *serviço de habilitação e de reabilitação* tem por objetivo proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a educação ou reeducação, de adaptação ou de readaptação profissional e social indicados para sua participação no mercado de trabalho e no contexto em que vivem.

Regime de previdência complementar – O art. 202, com a redação dada pela EC-20/98, estabelece regras para a instituição do regime de *previdência complementar*, a ser organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Este último é *público*, porque instituído e mantido pelo Poder Público, e *obrigatório*, porque a ele têm que se filiar todos os trabalhadores celetistas. O outro é *privado e facultativo*, baseado na contribuição de reservas que garantam o benefício contratual, regulado por lei complementar (Lei Complementar 109, de 29.5.2001). É *complementar*, porque destinado a suplementar os benefícios previdenciários para aqueles que a ele aderirem. Isso não quer dizer que a concessão dos benefícios pela previdência complementar dependa da concessão de benefício pelo regime geral da previdência (art. 68, § 2º, da Lei Complementar 109/2001).

Há dois tipos de entidades de previdência complementar: as *fechadas* e as *abertas*. As *fechadas* são aquelas acessíveis exclusivamente a empregados dos patrocinadores (empresas ou grupos de empresas),² ou associados ou membros dos *instituidores* (pessoas jurídicas

2. Já vimos anteriormente que as entidades do Poder Público só podem patrocinar entidades de previdência complementar *fechadas*, porque destinadas exclusivamente a seus servidores.

de caráter profissional, classista ou setorial), e serão organizadas sob forma de fundação ou sociedade civil de fins não-lucrativos. As *abertas*, constituídas unicamente sob forma de sociedade anônima, têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a qualquer pessoa física. Os filiados ao regime geral de previdência social são *segurados*; os aderentes ao regime de previdência complementar são *participantes*, sendo-lhes assegurado o acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.

As reservas técnicas, provisões e fundos das entidades de previdência complementar serão constituídas por contribuições do empregador (patrocinador/instituidor) e dos participantes, mas nem as contribuições daqueles integram o contrato dos segundos, nem os benefícios destes integram sua remuneração.

Reserva de direitos — Existem dispositivos que reservam direitos preexistentes, que constam dos arts. 3º e 9º da EC-20/98, especialmente. O primeiro ressalva o direito adquirido à aposentadoria e a pensão, nos termos de legislação anterior, aos segurados que tenham cumprido os requisitos para a obtenção desses benefícios. O segundo ressalva o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pela EC-20/98 para o regime geral de previdência social, assegurando o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado a esse regime, até a data de publicação da referida Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos: I — contar cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; II — contar tempo de contribuição igual, no mínimo a soma de: a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação da Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. O segurado, atendido os requisitos *supra* (art. 9º, *caput*), poderá ainda aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as condições indicadas nos ns. I e II *supra*. Também o professor que, até a data da publicação da EC-20/98, tenha exercido atividades de magistério, e que opte por aposentar-se na forma do disposto nos ns. I e II *supra* (art. 9º, *caput*), terá o tempo de serviço exercido até a publicação dessa Emenda contando com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício da atividade de magistério.

Observe-se que acima só estamos dando indicações gerais sobre os direitos reservados, o que não dispensa exame mais pormenorizado das normas do art. 3º e seguintes da EC-20/98 para melhor se inteirar desses direitos.

4. Assistência social

A assistência social não tem natureza de seguro social, porque não depende de contribuição. Os benefícios e serviços serão prestados a quem deles necessitar, caracterizados pela: (a) proteção à família, à maternidade, à velhice, à infância e à adolescência, compreendidos os carentes; (b) promoção da integração ao trabalho; (c) habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; (d) garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Além dessas hipóteses, ordena-se que a União ainda institua programa de renda mínima destinado a assegurar a subsistência das pessoas e das famílias, priorizando-se inicialmente as de baixa renda, podendo ser financiado e realizado por meio de convênio com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na forma da lei complementar. Note-se que a exigência de lei complementar se refere apenas à disciplina desse convênio, não à instituição do programa imposto à União, que pode efetivar-se por qualquer outra forma admitida em direito.

É financiada com recursos do orçamento da seguridade social, além de outras fontes, e organizada com base nas seguintes diretrizes: (a) *descentralização político-administrativa*, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estaduais e municipais, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; (b) *participação da população*, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Entre as outras fontes de financiamento da assistência social se encontra a faculdade de Estados e Distrito Federal vincularem até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida a programa de apoio à inclusão e promoção social, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de qualquer despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas.

Capítulo III

DA ORDEM CONSTITUCIONAL DA CULTURA

1. Questão de ordem. 2. Educação. 3. Princípios básicos do ensino. 4. Autonomia universitária. 5. Ensino público. 6. Ensino pago e ensino gratuito. 7. Cultura e direitos culturais. 8. Desporto. 9. Ciência e tecnologia. 10. Comunicação social. 11. Meio ambiente.

1. Questão de ordem

A Constituição de 1988, como observamos antes, deu relevante importância à *cultura*, tomado esse termo em sentido abrangente da formação educacional do povo, expressões criadoras da pessoa e das projeções do espírito humano materializadas em suportes expressivos, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, que se exprimem por vários de seus artigos (5º, IX, 23, III a V, 24, VII a IX, 30, IX, e 205 a 217), formando aquilo que se denomina *ordem constitucional da cultura*, ou *constituição cultural*,¹ constituída pelo conjunto de normas que contêm referências culturais e disposições consubstanciadoras dos direitos sociais relativos à educação e à cultura. É nesse sentido abrangente que trataremos do tema neste capítulo: *educação, ensino, cultura* (estritamente considerada), *desporto, ciência e tecnologia, comunicações sociais e meio ambiente*. Boa parte desses assuntos já foram discutidos como direitos sociais, cabendo aqui apenas debater temas conexos, que não comportariam tratamento naquela oportunidade.

2. Educação

A *educação* como processo de reconstrução da experiência é um atributo da pessoa humana,² e, por isso, tem que ser comum a todos. É essa concepção que a Constituição agasalha nos arts. 205 a 214, quando declara que ela é um *direito de todos e dever do Estado*.

1. Cf. Gomes Canotilho e Vital Moreira, *Constituição da República Portuguesa anotada*, p. 361.

2. Cf. Anísio Teixeira, "A pedagogia de Dewey", in John Dewey, *Vida e educação*, pp. 8 e 31.

Tal concepção importa, como já assinalamos, em elevar a educação à categoria de serviço público essencial que ao Poder Público impende possibilitar a todos, daí a preferência constitucional pelo ensino público, pelo que a iniciativa privada, nesse campo, embora livre, é, no entanto, meramente secundária e condicionada (arts. 209 e 213). É que, como lembra Anísio Teixeira: "Obrigatória, gratuita e universal, a educação só poderia ser ministrada pelo Estado. Impossível deixá-la confiada a particulares, pois estes somente podiam oferecê-la aos que tivessem posses (ou a 'protegidos') e daí operar antes para perpetuar as desigualdades sociais, que para removê-las. A escola pública, comum a todos, não seria, assim, o instrumento de benevolência de uma classe dominante, tomada de generosidade ou de medo, mas um direito do povo, sobretudo das classes trabalhadoras, para que, na ordem capitalista, o trabalho (não se trata, com efeito, de nenhuma doutrina socialista, mas do melhor capitalismo) não se conservasse servil, submetido e degradado, mas, igual ao capital na consciência de suas reivindicações e dos seus direitos".³

3. Princípios básicos do ensino

A consecução prática dos objetivos da educação consoante o art. 205 — *pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho* — só se realizará num sistema educacional democrático, em que a organização da educação formal (via escola) concretize o *direito ao ensino*, informado por princípios com eles coerentes, que, realmente, foram acolhidos pela Constituição, como são: *igualdade* de condições para o acesso e permanência na escola; *liberdade* de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; *pluralismo* de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; *gratuidade* do ensino público em estabelecimentos oficiais; *valorização dos profissionais do ensino* garantido na forma da lei; planos de carreira para o magistério público, com piso salarial e profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; *gestão democrática*; garantia de *padrão de qualidade* (art. 206).

4. Autonomia universitária

Não é o caso de reviver aqui as vicissitudes históricas da autonomia universitária. Basta consignar que a Constituição firmou a *autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira das Universidades*, que obedecerão ao princípio de *indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão* (art. 207). Não poderia ser de outro modo. Se se consagrou a

3. Cf. *Educação não é privilégio*, Rio de Janeiro, José Olympio Ed., 1957, p. 80.

liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber, como um princípio basilar do ensino (art. 206, II), a coerência exigia uma manifestação normativa expressa em favor da autonomia das Universidades, autonomia que não é "apenas a independência da instituição universitária, mas a do próprio saber humano", pois "as universidades não serão o que devem ser se não cultivarem a consciência da independência do saber e se não souberem que a supremacia do saber, graças a essa independência, é levar a um novo saber. E para isto precisam de viver em uma atmosfera de autonomia e estímulos vigorosos de experimentação, ensaio e renovação. Não é por simples acidente que as universidades se constituem em comunidades de mestres e discípulos, casando a experiência de uns com o ardor e a mocidade dos outros. Elas não são, com efeito, apenas instituições de ensino e de pesquisas, mas sociedades devotadas ao livre, desinteressado e deliberativo cultivo da inteligência e do espírito e fundadas na esperança do progresso humano pelo progresso da razão".⁴

A autonomia universitária ganhou um reforço com a EC 11/96, que acrescentou os §§ 1º e 2º ao art. 207, para facultar-lhes admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, *na forma da lei*, disposição que se aplica também às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Não se outorgou propriamente a possibilidade de os estrangeiros ingressarem na carreira docente na mesma condição dos brasileiros, pois não enquadrou essa admissão no regime do art. 37, II, nem é também a forma de contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. Com a nova disposição, a Constituição considera sempre de interesse público universitário a colaboração de estrangeiros no seu quadro docente, ainda que seja um quadro especial. De fato, ao falar em "admitir", usou um termo técnico, que pressupõe regime especial, que há de ser estabelecido na forma da lei referida no texto do novo dispositivo constitucional.

5. Ensino público

A preferência constitucional pelo *ensino público* importa em que o Poder Público organize os *sistemas de ensino* de modo a cumprir o respectivo dever com a educação, mediante prestações estatais que garantam, no mínimo: *ensino fundamental*, obrigatório e gratuito, assegurado, inclusive sua oferta gratuita a todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria (EC 14/96); *progressiva universalização do ensino médio gratuito* (EC 14/96); atendimento educacional especializado aos *portadores de deficiência*, preferencialmente na rede regular de

4. Cf. Anísio Teixeira, *A educação e a crise brasileira*, pp. 267 e 271.

ensino; atendimento em *creche e pré-escola* às crianças de zero a seis anos de idade; *acesso aos níveis mais elevados* do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; conteúdo mínimo para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais (arts. 208 e 210).

O *dever estatal* com a educação implica a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cada qual com seu *sistema de ensino* em regime de colaboração mútua e recíproca, destinando, anualmente, a União não menos de dezoito por cento da receita de impostos, e os Estados e Municípios, cada um, no mínimo, vinte e cinco por cento da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, com prioridade de aplicação no ensino obrigatório. Esses recursos, como qualquer outro recurso público, serão destinados à *escola pública*. Faculta-se, por exceção, dirigir recursos públicos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, inclusive por meio de bolsas de estudos a quem demonstrar insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública na localidade da residência do educando.

6. Ensino pago e ensino gratuito

O art. 206, IV, assume o *princípio* da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, devendo o Estado assegurá-lo, desde já, ao ensino fundamental e garantir a progressiva universalização do ensino médio gratuito (art. 208, I e II). O princípio do art. 206, IV, significa que onde o ensino oficial, em qualquer nível, já é gratuito não poderá passar a ser pago. Onde é pago, se for fundamental, deverá passar imediatamente a ser oferecido gratuitamente, e se for médio, a entidade pública mantenedora deverá tomar providência no sentido de que, progressivamente, se transforme em gratuito.

A gratuidade do ensino oficial nos três níveis — fundamental, médio e superior — é velha tradição do sistema educacional brasileiro.⁵ Pode-se, agora, dizer que essa tradição não era nada mais nada menos do que uma projeção futura, porquanto veio a ajustar-se à evolução que tornara a educação um serviço público integrante dos fins do Estado Democrático. Por isso é que a Constituição, acolhendo

a evolução, elevava a educação à categoria de direito de todos e, correlativamente, à categoria de dever do Estado.

Apesar disso, certas correntes de educadores e de publicistas ainda insistem em condenar a tradição e a evolução, assim como o sentido das normas constitucionais, postulando o ensino pago como “uma forma de praticar a justiça social”, pois que, segundo essa tese, há profunda desigualdade “entre a situação de alunos pobres, obrigados a pagar anuidades em estabelecimentos particulares, e alunos ricos, dispensados de fazê-lo em estabelecimentos oficiais”.⁶ De acordo com esse ponto de vista, a “exigência de pagamento corrigiria essa injustiça e a receita arrecadada dos alunos abastados financiaria o acesso e manutenção de maior número de estudantes carentes”.⁷ Diga-se, em primeiro lugar, que a desigualdade enunciada destaca alunos pobres pagando escolas particulares e alunos ricos auferindo a gratuidade nas escolas oficiais, desprezando a igualdade de alunos ricos e pobres recebendo ensino gratuito nas escolas públicas e pagando igualmente nas particulares.

É que a injustiça social, a desigualdade, não decorre da vida escolar de ambas as classes. Ela se instaura, como lembra Luiz Navarro de Britto, a partir do pré-escolar ou mesmo antes, acumulando-se e estreitando-se progressivamente as possibilidades de ascenso até o nível superior, e não será a Universidade e muito menos o ensino pago — acrescenta — que poderão corrigir a injustiça e as discriminações impostas pela estrutura sócio-econômica da comunidade.⁸

Há, ainda, a freqüente afirmativa de que as escolas oficiais gratuitas são de alcance muito mais fácil pelos alunos ricos, porque dispõem de condições mais favoráveis para superar as provas de ingresso, especialmente nas Universidades, já que podem pagar “cursinhos” caros para se prepararem, enquanto os pobres não o podem. Mas é aí que se situa a injustiça e a desigualdade de tratamento, pois compete ao Poder Público, desde a pré-escola, ou até antes, proporcionar, aos alunos carentes, *condições de igualização*, para que possam concorrer com os abastados em igualdade de situação. Com os “cursinhos” não cabe argumentar, porque são uma distorção do sistema escolar. Os exames de ingresso (seleção, vestibulares) revelam deficiências na oferta de escolas, que a extensão da rede precisa eliminar.

6. Cf. Armando Dias Mendes, “Declaração de voto”, in *Documenta*, Separata n. 249, Brasília, agosto/81, p. 21, contra o ensino oficial médio e superior pago defendido pela Prof^a Esther de Figueiredo Ferraz, na mesma *Documenta*, Separata, pp. 3 a 20.

7. Cf. Luiz Navarro de Britto, “Declaração de voto”, na citada *Documenta*, p. 27, também em oposição ao parecer mencionado da Prof^a Esther de Figueiredo Ferraz.

8. *Documenta*, pp. 27 e 28.

5. A gratuidade da educação é, em verdade, um princípio universal que se erigiu num direito fundamental do homem, nos termos do art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, subscrita pelo Brasil.

A verdade é que, se a Constituição estabeleceu que *a educação é direito de todos e dever do Estado*, significa que a elevou à condição de serviço público a ser prestado pelo Poder Público indiscriminadamente e, portanto, gratuitamente aos usuários, ficando seu custeio por conta das arrecadações gerais do Estado. Então, o Estado há de cobrar para cumprir seu dever? E o direito correlato tem que ser pago?

A tese de que o ensino pago visa realizar a justiça social é racionalização ideológica, porque esconde a ideologia de que o ensino particular “deve primar sobre o ensino oficial”.⁹ No fundo, portanto, a racionalização consiste na defesa da escola particular contra a escola pública nos níveis médio e superior, pois, passando o ensino oficial a ser pago, não há mais diferença entre o ensino público e o particular. Tanto fará, sob o ponto de vista dos custos dos alunos, matricular-se num como noutro. Por outro lado, logo se passará a demonstrar que não haverá mais razão para o Poder Público investir na ampliação da rede escolar média e superior, já que a rede particular terá condições de prestar esse serviço aos usuários, quando ricos mediante pagamento do próprio bolso, quando pobre mediante bolsas de estudos que o Poder Público deverá fornecer ou ficarão sem escola, o que será o mais provável.

Ora, o modo de fazer *justiça social dentro* da escola pública não depende de cobrança de contribuição dos alunos ricos. A justiça social dentro da escola pública, procurando igualar pobres e ricos, terá que ser feita por outros mecanismos, tais como: fornecimento de materiais e outros auxílios (inclusive de transportes) para os alunos que provarem, aí sim, falta ou insuficiência de recursos, que a Constituição prevê (arts. 208, VII, e 212, § 4º); aumento do imposto sobre a renda, por exemplo, de 5%, para quem aufera rendimentos líquidos acima de 20% ou 30% do *quantum* hoje previsto para o início da incidência do teto de 25%, destinada a importância arrecadada ao custeio da escola pública.

7. Cultura e direitos culturais

A Constituição estatui que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional, apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, destacadamente as populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Nesse sentido, já considerou tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

9. Cf. Antônio Sampaio Dória, *Direito constitucional*, v. IV/69.

Para se dar eficácia a essas normas que prevêm apoio e incentivo às manifestações culturais do art. 215, a EC-48, de 10.8.2005, introduziu um § 3º nesse artigo, para determinar que lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzam à: I – defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; II – produção, promoção e difusão de bens culturais; III – formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; IV – democratização do acesso aos bens de cultura; V – valorização da diversidade étnica e regional. Essa emenda constitucional era inteiramente desnecessária porque seu conteúdo já se extrai das normas dos arts. 215 e 216, até porque, para estabelecer um tal plano, não era necessário que fosse previsto na Constituição. Bastava a lei, já que não há proibição constitucional. Demais o § 6º do art. 216, introduzido pela EC-42/2003, já tinha tomado providência para a consecução dessa eficácia facultando aos Estados e Distrito Federal vincularem a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de qualquer despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas.

Define ela o *patrimônio cultural brasileiro*, como sendo constituído dos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, desde que portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, patrimônio esse que terá que ser protegido pelo Poder Público, com a colaboração da comunidade, por meio de *inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação*, e de outras formas de acautelamento e preservação. Vê-se daí que, hoje, o tombamento é apenas uma das formas possíveis de proteção do *patrimônio cultural*. Modernizam-se e ampliam-se, portanto, os meios de atuação do Poder Público na tutela do patrimônio cultural. Sai-se também do limite estreito da terminologia tradicional, para utilizarem-se técnicas mais adequadas, ao falar-se em patrimônio cultural, em vez de patrimônio histórico, artístico e paisagístico, pois há outros valores culturais que não se subsumem nessa terminologia antiga. Meios de repressão a danos e ameaças ao patrimônio cultural também são suscitados (art. 216, § 4º).

8. Desporto

É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observadas as diretrizes do art. 217.

A Constituição valorizou a *justiça desportiva*, quando estabeleceu que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias daquela. Mas impôs a ela um prazo máximo para proferir a decisão final, que é de sessenta dias, após o qual, evidentemente, o Poder Judiciário poderá conhecer da controvérsia.

9. Ciência e tecnologia

É incumbência do Estado promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. A Constituição distingue a pesquisa em *pesquisa científica básica*, que receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, e *pesquisa tecnológica*, que deverá voltar-se preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional; para tanto o Estado apoiará e estimulará a formação de recursos humanos nessas áreas do saber.

A regra do art. 219 deveria figurar entre os dispositivos da ordem econômica, onde melhor se enquadraria. Reza o dispositivo que o *mercado interno* integra o *patrimônio nacional* e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos da lei federal. É uma regra da ordem econômica mais do que de ciência e tecnologia, na qual a intervenção no domínio econômico encontra importante fundamento para o controle do mercado interno.

10. Comunicação social

Já estudamos a liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação, de maneira a abranger as questões fundamentais do capítulo da comunicação social. O único aspecto que ficou para considerar foi o art. 222, que estatui que a *propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens* é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que

tenham sede no País, cujas alterações de controle societário serão comunicadas ao Congresso Nacional, por determinação da EC-36/2002. Essa emenda abriu a possibilidade de participação do capital estrangeiro nessas empresas, até o montante de trinta por cento, na forma disciplinada em lei. Contudo, a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social. A mesma emenda dispôs que os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais.

11. Meio ambiente

Essa matéria entra, meio à cunha, nesse capítulo sobre a ordem constitucional da cultura. O capítulo do meio ambiente é um dos mais importantes e avançados da Constituição de 1988, do qual, contudo, não podemos tratar aqui senão em suas linhas gerais e fundamentais, além do que dele já dissemos.

A Constituição define o *meio ambiente* ecologicamente equilibrado como *direito de todos* e lhe dá a natureza de *bem de uso comum do povo* e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O art. 225, § 1º, arrola as medidas e providências que incumbem ao Poder Público tomar para assegurar a efetividade do direito reconhecido no *caput*, que nos limitaremos a enunciar, quais sejam: (1) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (2) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (3) definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (4) exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (5) controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (6) promover a

educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; (7) proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

A Constituição, além desses meios de atuação do Poder Público, impõe condutas preservacionistas a quantos possam direta ou indiretamente gerar danos ao meio ambiente. Assim, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei, e as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Dá ela ênfase à atuação preventiva, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação (art. 170, VI, EC-42/2003), mas não descuida das medidas repressivas, ao exigir a recuperação do meio ambiente degradado por atividades regulares, e especialmente ao sujeitar as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente a sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos causados. Cabe invocar, aqui, a tal propósito, o disposto no art. 173, § 5º, que prevê a possibilidade de responsabilização das pessoas jurídicas, independente da responsabilidade de seus dirigentes, sujeitando-se às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica, que tem como um de seus princípios a defesa do meio ambiente.

O art. 225, § 4º, declara *patrimônio nacional* a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira, não para torná-las estaticamente preservadas; ao contrário, sua utilização econômica, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, é admissível, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente.

A Constituição, com isso, segue, e até ultrapassa, as Constituições mais recentes (Bulgária, art. 31, ex-URSS, art. 18, Portugal, art. 66, Espanha, art. 45) na proteção do meio ambiente. Toma consciência de que a “qualidade do meio ambiente se transformara num bem, num patrimônio, num valor mesmo, cuja *preservação, recuperação e revitalização* se tornaram num imperativo do Poder Público, para assegurar a saúde, o bem-estar do homem e as condições de seu desenvolvimento. Em verdade, para assegurar o direito fundamental à vida”.¹⁰ As normas constitucionais assumiram a consciência de que o

10. Cf. nosso “Direito à qualidade do meio ambiente”, *Revista do Advogado* 18/46, junho/85, e nosso *Direito urbanístico brasileiro*, p. 436. Concluímos o primeiro des-

direito à vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais do homem, é que há de orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente. Compreendeu que ele é um valor preponderante, que há de estar acima de quaisquer considerações como as de desenvolvimento, como as de respeito ao direito de propriedade, como as da iniciativa privada. Também estes são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não podem primar sobre o direito fundamental à vida, que está em jogo quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente, que é instrumental no sentido de que, através dessa tutela, o que se protege é um valor maior: a *qualidade da vida humana*.¹¹

ses trabalhos propondo que o direito à qualidade do meio ambiente, como manifestação do direito à vida, merecesse na nova Carta Magna tratamento adequado e sugerimos um dispositivo que sintetizava o essencial do capítulo em estudo, nos termos seguintes: “Art. — (*direito à qualidade do meio ambiente*) 1. Todos têm direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, bem como o dever de defendê-lo. 2. Incumbe aos poderes públicos velar pela aplicação eficaz desse direito e pelo racional aproveitamento dos recursos naturais, salvaguardando sua capacidade de renovação e estabilidade ecológica, com o fim de proteger e melhorar a qualidade da vida e defender e restaurar o meio ambiente, apoiando-se na indispensável solidariedade coletiva. 3. Fica reconhecida a legitimação processual a qualquer brasileiro e a instituições brasileiras de fins ambientais e ecológicos para a defesa do meio ambiente no interesse da qualidade de vida. 4. A mesma legitimação cabe ao Ministério Público federal e estadual. 5. A lei fixará sanções penais, administrativas e civis para quem violar o disposto nas alíneas 1 e 2 deste artigo”.

11. Reproduzimos aqui considerações que constam do nosso artigo citado, *Revista do Advogado* 18/50.

Capítulo IV

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO

1. A família. 2. Tutela da criança e do adolescente. 3. Tutela dos idosos.

1. A família

A *família* é afirmada como base da sociedade e tem especial proteção do Estado, mediante assistência na pessoa de cada um dos que a integram e criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Não é mais só pelo casamento que se constitui a *entidade familiar*. Entende-se também como tal a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes e, para efeito de proteção do Estado, também, a *união estável* entre homem e mulher, cumprindo à lei facilitar sua conversão em casamento (cf. Lei 9.278, de 10.5.96). Em qualquer desses casos, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, especificando aqui o direito de igualdade entre ambos, já consignado no art. 5º, I (art. 226).

O *casamento* é civil e gratuita a sua celebração, mas o religioso terá efeito civil, nos termos da lei. Quer no primeiro caso, quer no segundo, pode ele ser dissolvido pelo *divórcio*, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos.

A *paternidade responsável*, ou seja, a paternidade consciente, não animalésca, é sugerida. Nela e na dignidade da pessoa humana é que se fundamenta o *planejamento familiar* que a Constituição admite como um direito de livre decisão do casal, de modo que ao Estado só compete, como dever, propiciar recursos educacionais e científicos para o seu exercício. A Constituição não se satisfaz com declarar livre o planejamento familiar. Foi mais longe, vedando qualquer forma coercitiva por parte de instituições sociais ou privadas (cf. Lei 9.263, de 12.1.96).

A família é uma comunidade natural composta, em regra, de pais e filhos, aos quais a Constituição, agora, imputa direitos e deveres re-

cíprocos, nos termos do art. 229, pelo qual os pais têm o dever de assistir, criar e educar os *filhos menores*, havidos ou não da relação do casamento (art. 227, § 6º), ao passo que os *filhos maiores* têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

2. Tutela da criança e do adolescente

Essa família, que recebe a proteção estatal, não tem só direitos. Tem o grave dever, juntamente com a sociedade e o Estado, de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais da criança e do adolescente enumerados no art. 227: direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão é exigência indeclinável do cumprimento daquele dever.

Ao Estado incumbe ainda promover programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, incluindo prevenção e atendimento especializado aos portadores de deficiência física, sensorial ou mental, dispondo a lei sobre normas que facilitem seu acesso a logradouros, edifícios públicos e a veículos de transportes coletivos.

A Constituição é minuciosa e redundante na previsão de direitos e situações subjetivos de vantagens das crianças e adolescentes, especificando em relação a eles direitos já consignados para todos em geral, como os direitos previdenciários e trabalhistas, mas estatui importantes normas tutelares dos menores, especialmente dos órfãos e abandonados e dos dependentes de drogas e entorpecentes (art. 227, § 3º). Postula punição severa ao abuso, violência e exploração sexual da criança e do adolescente.

O art. 227, § 6º, contém importante norma relativa ao *direito de filiação*, reconhecendo igualdade de direitos e qualificações aos filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, proibidas quaisquer designações discriminatórias a ela relativas. Ficam, assim, banidas da legislação civil expressões como filhos legítimos, filhos naturais, filhos adulterinos, filhos incestuosos. Por outro lado, expressamente é admitida a adoção de crianças brasileiras por estrangeiro, desde que seja assistida pelo Poder Público, na forma da lei e nos casos e condições por esta estabelecidos (art. 227, § 5º).

3. Tutela dos idosos

Os *idosos* não foram esquecidos pelo constituinte. Ao contrário, vários dispositivos mencionam a *velhice* como objeto de direitos es-

pecíficos, como do direito previdenciário (art. 201, I), do direito assistencial (art. 203, I), mas há dois dispositivos que merecem referência especial, porque o objeto de consideração é a pessoa em sua *terceira idade*.

Assim é que o art. 230 estatui que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as *pessoas idosas*, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, de preferência mediante programas executados no recesso do lar, garantindo-se, ainda, o benefício de um salário mínimo mensal ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por família, conforme dispuser a lei (art. 203, V), e, aos maiores de sessenta e cinco anos, independente de condição social, é garantida a gratuidade dos transportes urbanos.

A Lei 8.842, de 4.1.94, que dispôs sobre a política nacional do idoso e criou o Conselho Nacional do Idoso, considera *idoso*, para os seus efeitos, a pessoa maior de sessenta anos de idade. Segundo seu art. 1º a política do idoso tem por objetivo assegurar seus direitos sociais, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Traça ela os princípios e diretrizes da política do idoso, a organização e gestão dessa política, que incumbe ao Ministério responsável pela assistência e promoção social, e ainda estabelece as ações governamentais necessárias à implementação dessa política.

Capítulo V

DOS ÍNDIOS

1. Fundamentos constitucionais dos direitos indígenas. 2. Organização social dos índios: comunidade, etnia e nação. 3. Direitos sobre as terras indígenas. 4. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 5. O indigenato. 6. Posse permanente. 7. Usufruto exclusivo. 8. Mineração em terras indígenas. 9. Demarcação das terras indígenas. 10. Defesa dos direitos e interesses dos índios.

1. Fundamentos constitucionais dos direitos indígenas

A Constituição de 1988 revela um grande esforço da Constituinte no sentido de preordenar um sistema de normas que pudesse efetivamente proteger os direitos e interesses dos índios. E o conseguiu num limite bem razoável. Não alcançou, porém, um nível de proteção inteiramente satisfatório. Teria sido assim, se houvera adotado o texto do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, reconhecidamente mais equilibrado e mais justo.

É inegável, contudo, que ela deu um largo passo à frente na questão indígena, com vários dispositivos referentes aos índios,¹ nos quais dispõe sobre a propriedade das terras ocupadas pelos índios, a competência da União para legislar sobre *populações indígenas*, autorização congressual para mineração em terras indígenas, relações das comunidades indígenas com suas terras, preservação de suas línguas, usos, costumes e tradições. Os arts. 231 e 232 é que estabelecem as bases dos direitos dos índios.

2. Organização social dos índios: comunidade, etnia e nação

O art. 231 reconhece a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos índios, com o que reconhece a existência de minorias nacionais e institui normas de proteção de sua singularidade étnica, especialmente de suas línguas, costumes e usos. A propósito, a Constituição fala em *populações indígenas* (art. 22, XIV) e *comunidades indígenas* ou *dos índios* (art. 232), certamente como *comunidades cultu-*

1. Cf. arts. 20, XI, 22, IV, 49, XVI, 109, XL, 129, V, 176, § 1º, 210, § 2º, 215, § 1º, e especialmente 231 e 232, formando estes dois últimos o capítulo especial dos índios.

rais, que se revelam na identidade étnica, não propriamente como *comunidade de origem* que se vincula ao conceito de raça natural, fundado no fator biológico, hoje superado, dada a “impossibilidade prática de achar um critério que defina a pureza da raça”.² Nem é *comunidade nacional* que não é redutível a fatores particulares ou parciais, porque se integra de todos, enquanto realização do princípio do Estado nacional, traduzindo, no nosso caso, a unidade comunitária dos brasileiros que envolve a todos.

A Constituição recusou o emprego da expressão *nações indígenas*, baseada na falsa premissa e no preconceito de que *nação* singulariza o elemento humano do Estado ou se confunde com o próprio Estado, idéia há muito superada, quer porque se verificou que existem Estados multinacionais ou multiétnicos, que dá na mesma, quer porque existe Estado sem nação (o Vaticano) e até porque pode existir nação sem Estado como os judeus até a fundação do Estado de Israel, e, ao contrário, a nação pode estar dividida em vários Estados.³ É verdade que hoje tudo isso é muito discutível. Assim, p. ex., como nota Zippelius, “os suíços alemães e os próprios alemães não se consideram uma nação, apesar de uma origem, uma língua e uma cultura comuns”.⁴ Por quê? Porque, para além desses fatores, há outro mais forte que é o sentimento de pertinência nacional que solidifica uma comunidade de destino político.⁵ Por isso, é que os suíços de origem alemã, como os de origem italiana e francesa, são de nacionalidade suíça pelo sentimento de pertinência à comunidade nacional da Suíça, sem prejuízo do sentimento de pertinência a uma específica comunidade cultural (alemã, italiana e francesa). Por tudo isso também é que ficou inteiramente superado o incorreto conceito de Estado como nação politicamente organizada.

Se tomarmos o conceito de *nação* de Mancini, que se assemelha a todos os demais, por certo que poderá ser aplicado às comunidades indígenas, em face do art. 231 da Constituição. Nação, para ele, “é a reunião em sociedade de homens [‘seres humanos’, quer ele dizer], na qual a unidade de território, de origem, de costumes, de língua e a comunhão de vida criaram a consciência social”.⁶ Por outro lado, se se reconhece que a *língua comum* é um fator particularmente sig-

2. Cf. Reinhold Zippelius, *Teoría general del Estado*, pp. 78 e 79; também Hermann Heller, *Teoría del Estado*, 4ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1961, pp. 164 e ss. e 174 e ss.

3. Cf. Wilhem Sauer, *Filosofia jurídica y social*, p. 186.

4. *Ob. cit.*, p. 80.

5. Idem, *ibidem*.

6. Cf. Darcy Azambuja, *Teoria geral do Estado*, p. 27, ressalvem-se os parênteses explicativos nossos.

nificativo para a constituição da nação,⁷ então se pode falar em *nações indígenas*, na medida em que a comunidade lingüística as identifica. Mas, nesse sentido, o conceito de nação se confunde com o *conceito de etnia*, como esta vem sendo definida atualmente, ou seja: “etnia é uma entidade caracterizada por uma mesma língua, uma mesma tradição cultural e histórica, ocupando um dado território, tendo uma mesma religião e, sobretudo, a consciência de pertencer a essa comunidade”.⁸ É claro que um novo conceito de nação começa a surgir, diferente do conceito de etnia, e, como tal, não teria aplicação às comunidades indígenas, porque se confunde com o controle do aparelho do Estado. Diz-se, então, que a nação supõe a etnia, mas a sobrepassa. “De fato, ela aparece se, além disso, uma classe social, que controla o aparelho central do Estado, assegura uma unidade econômica à vida da comunidade.”⁹ Também não se lhes aplicará o termo *nação* no sentido corrente, embora tecnicamente incorreto, de povo de um país ou Estado, ou no de “comunidade de cidadãos de um Estado sob o mesmo regime”, porque, nesse sentido, se refere a todo o povo brasileiro, índios incluídos. O certo é que o termo confunde mais do que esclarece.

Enfim, o sentimento de pertinência a uma comunidade indígena é que identifica o índio. A dizer, é índio quem se sente índio. Essa auto-identificação, que se funda no sentimento de pertinência a uma comunidade indígena, e a manutenção dessa identidade étnica, fundada na continuidade histórica do passado pré-colombiano que reproduz a mesma cultura, constituem o critério fundamental para a identificação do índio brasileiro. Essa permanência em si mesma, embora interagindo um grupo com outros, é que lhe dá a continuidade étnica identificadora. Ora, a Constituição assume essa concepção, p. ex., no art. 231, § 1º, ao ter as terras ocupadas pelos índios como “necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”. A identidade étnica perdura nessa *reprodução cultural*, que não é estática; não se pode ter cultura estática. Os índios, como qualquer comunidade étnica, não param no tempo. A evolução pode ser mais rápida ou mais lenta, mas sempre haverá mudanças e, assim, a cultura indígena, como qualquer outra, é cons-

7. Cf. Reinhold Zippelius, *ob. cit.*, p. 79.

8. Cf. Carlos Lopes, *Para uma leitura sociológica da Guiné-Bissau*, pp. 36 e 37; no mesmo sentido, Samir Amin, *Le développement inégal*, p. 21: “L’ethnie suppose une communauté linguistique et culturelle et une homogénéité du territoire géographique et, surtout, la conscience de cette homogénéité culturelle, quand bien même celle-ci sera imparfaite, les variantes dialectiques différents d’une ‘province’ à l’autre, ou les cultes religieux”.

9. O conceito é atribuído a Selon Saad Zahran, cf. Samir Amin, *ob. cit.*, p. 21. É um conceito muito particular de nação, como se nota.

tantemente reproduzida, não igual a si mesma. Nenhuma cultura é isolada. Está sempre em contacto com outras formas culturais. A reprodução cultural não destrói a identidade cultural da comunidade, identidade que se mantém em resposta a outros grupos com os quais dita comunidade interage. Eventuais transformações decorrentes do viver e do conviver das comunidades não descaracterizam a identidade cultural. Tampouco a descaracteriza a adoção de instrumentos novos ou de novos utensílios, porque são mudanças dentro da mesma identidade étnica.¹⁰

3. Direitos sobre as terras indígenas

A questão da terra se transformara no ponto central dos direitos constitucionais dos índios, pois, para eles, ela tem um valor de sobrevivência física e cultural. Não se ampararão seus direitos se não se lhes assegurar a posse permanente e a riqueza das terras por eles tradicionalmente ocupadas, pois, a disputa dessas terras e de sua riqueza, como lembra Manuela Carneiro da Cunha, constitui o núcleo da questão indígena hoje no Brasil.¹¹ Por isso mesmo, esse foi um dos temas mais difíceis e controvertidos na elaboração da Constituição de 1988, que buscou cercar de todas as garantias esse direito fundamental dos índios. Da Constituição se extrai que, sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incidem os *direitos de propriedade* e os *direitos de usufruto*, sujeitos a delimitações e vínculos que decorrem de suas normas.

Declara-se, em primeiro lugar, que *essas terras são bens da União* (art. 20, XI). A outorga constitucional dessas terras ao domínio da União visa precisamente preservá-las e manter o vínculo que se acha embutido na norma, quando fala que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, ou seja, cria-se aí uma *propriedade vinculada* ou *propriedade reservada* com o fim de garantir os direitos dos índios sobre ela. Por isso, são terras *inalienáveis* e *indisponíveis*, e os direitos sobre elas, *imprescritíveis*.

São terras da União vinculadas ao cumprimento dos direitos indígenas sobre elas, reconhecidos pela Constituição como *direitos originários* (art. 231), que, assim, consagra uma relação jurídica fundada no *instituto do indigenato*, como fonte primária e congênita da posse territorial, consubstanciada no art. 231, § 2º, quando estatui que *as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e*

dos lagos nelas existentes. Disto também é que deriva o *princípio da irremovibilidade dos índios de suas terras*, previsto no § 5º do art. 231, só admitida a remoção *ad referendum* do Congresso Nacional e apenas em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Dali igualmente provêm as limitações a respeito da mineração nessas terras (*infra*) e a invalidade de atos contrários à efetividade dos direitos indígenas sobre elas.

De fato, consoante dispõe o art. 231, § 6º, *são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé*. A exceção final, quanto às benfeitorias, não autoriza ações e pedido de indenização contra os índios, pois não são acionáveis, mas apenas contra a União, à qual cabe velar e impedir a prática de atos atentatórios aos direitos dos índios sobre as terras por eles ocupadas, que são bens dela.

4. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios

São bens da União as *terras tradicionalmente ocupadas* pelos índios (art. 20, XI). São reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as *terras que tradicionalmente ocupam* (art. 231). As *terras tradicionalmente ocupadas* pelos índios destinam-se à sua posse permanente [...] (art. 231, § 1º). Essa reiteração constitucional requer conceituação que defina as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

A base do conceito acha-se no art. 231, § 1º, fundado em quatro condições, todas necessárias e nenhuma suficiente sozinha, a saber: 1) serem por eles *habitadas em caráter permanente*; 2) serem por eles *utilizadas para suas atividades produtivas*; 3) serem *imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar*; 4) serem *necessárias a sua reprodução física e cultural*, tudo segundo seus usos, costumes e tradições, de sorte que não se vai tentar definir o que é habitação permanente, modo de utilização, atividade produtiva, ou qualquer das condições ou termos que as compõem, segundo a visão civilizada, a visão do modo de produção capitalista ou socialista, a visão do bem-estar do nosso gosto, mas segundo o modo de ser deles, da cultura deles.

Terras tradicionalmente ocupadas não revela aí uma relação temporal. Se recorrermos ao Alvará de 1º de abril de 1680 que reconhecia aos

10. Sobre esses assuntos, cf. Manuela Carneiro da Cunha, *Os direitos do índio: ensaios e documentos*, pp. 22 e ss.

11. *Ob. cit.*, p. 32.

índios as terras onde estão tal qual as terras que ocupavam no sertão, veremos que a expressão *ocupadas tradicionalmente* não significa ocupação imemorial. Não quer dizer, pois, terras imemorialmente ocupadas, ou seja: terras que eles estariam ocupando desde épocas remotas que já se perderam na memória e, assim, somente estas seriam as terras deles. Não se trata, absolutamente, de *posse* ou *prescrição imemorial*, como se a ocupação indígena nesta se legitimasse, e dela se originassem seus direitos sobre as terras, como uma forma de *usucapião imemorial*, do qual emanariam os direitos dos índios sobre as terras por eles ocupadas, porque isso, além do mais, é incompatível com o reconhecimento constitucional dos direitos originários sobre elas.

Nem *tradicionalmente* nem *posse permanente* são empregados em função de *usucapião imemorial* em favor dos índios, como eventual título substantivo que prevaleça sobre títulos anteriores. Primeiro, porque não há títulos anteriores a seus direitos originários. Segundo, porque usucapião é modo de aquisição da propriedade e esta não se imputa aos índios, mas à União a outro título. Terceiro, porque os direitos dos índios sobre suas terras assentam em outra fonte: o *indigenato* (infra).

O *tradicionalmente* refere-se, não a uma circunstância temporal, mas ao modo tradicional de os índios ocuparem e utilizarem as terras e ao modo tradicional de produção, enfim, ao modo tradicional de como eles se relacionam com a terra, já que há comunidades mais estáveis, outras menos estáveis, e as que têm espaços mais amplos pelo qual se deslocam etc. Daí dizer-se que tudo se realize segundo seus usos, costumes e tradições.

5. O *indigenato*

Os dispositivos constitucionais sobre a relação dos índios com suas terras e o reconhecimento de seus direitos originários sobre elas nada mais fizeram do que consagrar e consolidar o *indigenato*, velha e tradicional instituição jurídica luso-brasileira que deita suas raízes já nos primeiros tempos da Colônia, quando o Alvará de 1º de abril de 1680, confirmado pela Lei de 6 de junho de 1755, firmara o princípio de que, nas terras outorgadas a particulares, seria *sempre* reservado o direito dos índios, *primários e naturais senhores delas*. Vindo a Lei 601/1850, os grileiros de sempre, ocupando terras indígenas, pretendiam destes a exibição de registro de suas posses. João Mendes Júnior, num texto que bem reflete o sentimento de autêntico jurista que era, rebateu a pretensão nos termos seguintes: "Desde que os índios já estavam aldeados com cultura e morada habitual, essas terras por eles ocupadas, se já não fossem deles, também não poderiam ser de posteriores posseiros, visto que estariam devolutas; em qualquer hipó-

tese, suas terras lhes pertenciam em virtude do direito à reserva, fundado no Alvará de 1º de abril de 1680, que não foi revogado, direito esse que jamais poderá ser confundido com uma posse sujeita a legitimação e registro".¹²

É que, conforme ele mostra, o *indigenato* não se confunde com a ocupação, com a mera posse. O *indigenato* é a fonte primária e congênita da posse territorial; é um direito congênito, enquanto a ocupação é título *adquirido*. O *indigenato* é legítimo por si, "não é um fato dependente de legitimação, ao passo que a ocupação, como fato posterior, depende de requisitos que a legitimem".

"O *indigenato*, primariamente estabelecido, tem a *sedem positio*, que constitui o fundamento da posse, segundo o conhecido texto do jurisconsulto Paulo (Dig. titul. de acq vel. amittr. possess., L.1), a que se referem Savigny, Molitor, Mainz e outros romanistas; mas o *indigenato*, além desse *ius possessionis*, tem o *ius possidendi*, que já lhe é reconhecido e preliminarmente legitimado, desde o Alvará de 1º de abril de 1680 como *direito congênito*". Só a posse por ocupação está sujeita a legitimação, porque, "como título de aquisição, só pode ter por objeto as coisas que nunca tiveram dono, ou que foram abandonadas por seu antigo dono. A ocupação é uma *apprehensio rei nullius* ou *rei derelictae* [...]; ora, as terras de índios, *congenitamente* apropriadas, não podem ser consideradas nem como *res nullius*, nem como *res derelictae*; por outra, não se concebe que os índios tivessem *adquirido*, por simples ocupação, aquilo que lhes é congênito e primário", de sorte que, em face do Direito Constitucional indigenista, relativamente aos índios com habitação permanente, não há uma simples posse, mas um reconhecido direito originário e preliminarmente reservado a eles.¹³

Acrescenta ainda João Mendes Júnior que "as terras do *indigenato*, sendo terras congenitamente possuídas, não são devolutas, isto é, são originariamente reservadas, na forma do Alvará de 1º de abril de 1680 e por dedução da própria Lei de 1850 e do art. 24, § 1º, do Decreto de 1854".¹⁴

Essas considerações, só por si, mostram que a relação entre o indígena e suas terras não se rege pelas normas do Direito Civil. Sua posse extrapola da órbita puramente privada, porque não é e nunca foi uma simples ocupação da terra para explorá-la, mas base de seu *habitat*, no sentido ecológico de interação do conjunto de elementos naturais e culturais que propiciam o desenvolvimento equi-

12. Cf. *Os indígenas do Brasil: seus direitos individuais e políticos*, p. 57; nosso "Auto-aplicabilidade do artigo 198 da Constituição Federal", RTJE 25/3 a 13.

13. Idem, pp. 58 e 59; idem, p. 5.

14. Idem, p. 62.

librado da vida humana. Esse tipo de relação não pode encontrar agasalho nas limitações individualistas do direito privado, daí a importância do texto constitucional em exame, porque nele se consagra a idéia de permanência, essencial à relação do índio com as terras que habita.¹⁵

6. Posse permanente

As considerações acima nos conduzem ao problema da *posse permanente* das terras habitadas pelos índios. A Constituição tem duas cláusulas sobre isso, referindo-se a terras *habitadas permanentemente* pelos índios e terras que se destinam à sua *posse permanente* (art. 231, §§ 1º e 2º).

A *posse* das terras ocupadas tradicionalmente pelos índios *não é* a *simples posse* regulada pelo direito civil; não é a posse como simples poder de fato sobre a coisa, para sua guarda e uso, com ou sem ânimo de tê-la como própria. É, em substância, aquela *possessio ab origine* que, no início, para os romanos, estava na consciência do antigo povo, e era não a relação material de homem com a coisa, mas um poder, um senhorio.¹⁶ Por isso é que João Mendes Júnior lembrou que a relação do indígena com suas terras não era apenas um *ius possessionis*, mas também um *ius possidendi*, porque ela revela também o direito que têm seus titulares de possuir a coisa, com o caráter de relação jurídica legítima e utilização imediata. Podemos dizer que é uma posse como *habitat* no sentido visto antes.

Essa idéia está consagrada na Constituição, quando considera as terras habitadas, segundo os usos, costumes e tradições dos índios. Daí a idéia essencial de *permanência*, explicitada pela norma constitucional.

Quando a Constituição declara que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios se destinam a sua *posse permanente*, isso não significa um pressuposto do passado como ocupação efetiva, mas, especialmente, uma garantia para o futuro, no sentido de que essas terras inalienáveis e indisponíveis são destinadas, *para sempre*, ao seu *habitat*. Se se *destinam* (*destinar* significa apontar para o futuro) à posse permanente é porque um direito sobre elas preexiste à posse mesma, e é o direito originário já mencionado.

O reconhecimento do direito dos índios ou comunidades indígenas à *posse permanente* das terras por eles ocupadas, nos termos do art. 231, § 2º, independe de sua demarcação, e cabe ser assegurado

pelo órgão federal competente, atendendo à situação atual e ao consenso histórico.

7. Usufruto exclusivo

Completa o conjunto de direitos dos índios, outorgado no art. 231 da Constituição, o reconhecimento de seu direito ao *usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras* que tradicionalmente ocupam. Aí está mais um elemento a afirmar a idéia, antes mencionada, de que a posse, no caso, não é simplesmente *ius possessionis*, mas também *ius possidendi*, ou seja, direito de possuir, porque posse imediata, não a título de propriedade (que cabe à União), mas *posse imediata de usufrutuário* exclusivo das riquezas referidas.

Esse usufruto é intransferível, lembra Pontes de Miranda, que acrescenta: “é pleno, compreende o uso e a fruição, quer se trate de minerais, de vegetais ou de animais”.¹⁷

8. Mineração em terras indígenas

Essa é uma questão ultra-sensível. Em torno dela giram interesses de toda ordem.

A busca de um equilíbrio que resguardasse os relevantes interesses dos índios, que, por si, são também relevantes interesses nacionais, e outros valores que, em cada momento, possam apresentar-se, constituiu uma grande preocupação, desde a Comissão Afonso Arinos, cujo texto sobre as populações indígenas (arts. 380 a 383) sustentamos ali, incluindo o art. 382 sobre exploração de minérios em terras indígenas, como privilégio da União, assim mesmo quando houvesse interesse nacional, assim declarado pelo Congresso Nacional em cada caso.

Essa norma equilibrada, justa e adequada, porque levava em conta os interesses relevantes envolvidos, mas só eles, sem abrir-se a outros interesses nacionais ou internacionais, não logrou aprovação na Constituinte, que, no entanto, não deixou inteiramente ao desamparo os interesses dos índios nessa questão, ao dispor, no art. 231, § 3º, que *o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei*.

15. Nossa *ob. cit.*, RTJE 25/5 e 6.

16. Cf. Roberto de Ruggiero, *Instituições de direito civil*, São Paulo, v. II/494.

17. Cf. *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, t. IV/456 e 457.

Ao Congresso Nacional se imputou o julgamento de cada situação concreta, para sopesar os direitos e interesses dos índios e a necessidade da prática daquelas atividades, reconhecido que o princípio é o da prevalência dos interesses indígenas, pois a execução de tais atividades, assim como a autorização do Congresso Nacional, só pode ocorrer nas condições específicas estabelecidas em lei (art. 176, § 1º); nem mesmo se admite a atividade garimpeira, em cooperativa ou não, mencionada no art. 174, §§ 3º e 4º, salvo, evidentemente, a atividade garimpeira dos próprios índios.

9. Demarcação das terras indígenas

Compete à União *demarcar as terras indígenas* (art. 231). O art. 67 do Ato das Disposições Transitórias determina que a União deveria concluir a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição. Não quer dizer que a União vai agora voltar a redemarcar tudo, recomeçar tudo. O que se quer é que ela execute esse trabalho de demarcação no prazo assinado, concluindo aquele que já começara e procurando demarcar aquelas terras onde a demarcação ainda não foi iniciada. De qualquer forma, não é da demarcação que decorre qualquer dos direitos indígenas. A demarcação não é título de posse nem de ocupação de terras. Como mencionamos há pouco, os direitos dos índios sobre essas terras independem da demarcação. Esta é constitucionalmente exigida no interesse dos índios. É uma atividade da União, não em prejuízo dos índios, mas para proteger os seus direitos e interesses. Está dito: *competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens* (art. 231).

10. Defesa dos direitos e interesses dos índios

Os *direitos e interesses dos índios* têm natureza de *direito coletivo, direito comunitário*. Como tal, concerne à comunidade toda e a cada índio em particular como membro dela. Essa idéia reconduz à comunidade de direito que existia no seio da gentilidade. “Os bens da *gens* pertenciam conjuntamente a todos os gentílicos. E este direito se distinguia do de cada um em particular, por não ser exclusivo, mas indiviso e inalienável e indissolavelmente ligado à qualidade de membro da coletividade.”¹⁸

Por isso é que a Constituição reconhece legitimação para defendê-los em juízo aos próprios índios, às suas comunidades e às organiza-

ções antropológicas e pró-índios, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo, que é da competência, em primeira instância, do Juiz Federal da seção onde estiverem situadas as terras por eles habitadas (arts. 109, XI, e § 2º, e 232) e, na segunda, do Tribunal Regional Federal da área. Pela mesma razão, ou seja, por se tratar de direitos e interesses coletivos, indisponíveis, de ordem pública, envolvidos, além do mais, com interesses da União, é que a Constituição também deu legitimação ao Ministério Público para defendê-los judicialmente (art. 129, V), e, se a competência é da Justiça Federal, o Ministério Público legitimado é o *Ministério Público Federal*.

18. A propósito, cf. Rudolf von Jhering, *L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement*, t. 1/204, § 17, por nós citado em nossa *Ação popular constitucional*, p. 12.

QUINTA PARTE

CONCLUSÃO GERAL

Capítulo Único

A questionada Revisão Constitucional, prevista no art. 3º das Disposições Transitórias, não conseguiu deformar o texto original da Constituição, mas uma sucessão de emendas, fundadas no art. 60, o vem fazendo sistematicamente, tornando-a cada vez mais minuciosa e incompulsável. Cada governo quer ter a “sua própria” Constituição e apresentado propostas de reformas que não reformam nada, ou se limitam a reformular algum instituto, como foram as chamadas reforma da previdência e do sistema tributário nacional. Todas elas, além de mudar dispositivos, vão acrescentando disposições transitórias sobre disposições transitórias e artigos extravagantes, de sorte que hoje temos três direitos constitucionais: o direito constitucional da Constituição remendada, retalhada e retaliada; o direito constitucional transitório, e o direito constitucional extravagante. Se não era no início uma Constituição isenta de contradições, às vezes minuciosa excessivamente, agora já o é muito mais, ainda que continue aberta para o futuro, até com alguma melhoria no campo social, com promessas de realização de um Estado Democrático de Direito que construa uma sociedade livre, justa e solidária, garanta o desenvolvimento nacional, erradique a pobreza e a marginalização, reduza as desigualdades regionais e sociais, promova, enfim, o bem-estar de todos sem discriminações de qualquer natureza (art. 3º); um Estado Democrático de Direito, portanto, que assegure o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia e comprometida com a solução pacífica das controvérsias (Preâmbulo). É o que o povo quer e espera.

Inegável que ela adota uma nova *idéia de direito* que informa uma nova concepção de Estado e da Sociedade, como postulamos em edições anteriores, tanto seja ela cumprida, aplicada, realizada.

Escrevemos em edição anterior: “precisamente neste domingo, 1.2.87, em que concluímos a revisão deste volume, para esta 4ª edição, está-se instalando a Constituinte, que estamos pleiteando desde a 2ª edição. Não é a Constituinte dos nossos sonhos, mas, assim mesmo, continuamos sonhando na esperança de que esse Congresso Constituinte, que hoje se instala, dote o país de uma Constituição

digna". Não podemos negar o esforço nesse sentido. Produziu-se a Constituição que as circunstâncias possibilitaram. Dentro e à vista dessas circunstâncias, fez-se uma obra, certamente imperfeita, mas digna e preocupada com os destinos do povo sofredor. Oxalá se cumpra, porque é nisso que está o drama das Constituições voltadas para o povo: cumprir-se e realizar-se, na prática, como se propõe nas normas, porque uma coisa têm sido as *promessas*, outra, a *realidade*.

BIBLIOGRAFIA CITADA

A

- Accioly, Hildebrando, *Manual de direito internacional público*, 8ª ed., São Paulo, Saraiva, 1968.
- Ackel Filho, Diomar, *Writs constitucionais*, São Paulo, Saraiva, 1988.
- Acosta Sánchez, José, "La reforma agrária y la modernización de las estructuras productivas", in *Relaciones sociales en la agricultura* (obra que reúne os trabalhos debatidos no "XXI Encuentro entre Empresarios, Sindicalistas y Laboristas", realizado em Córdoba, Espanha, junho/1983), Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1984.
- Afonso da Silva, José, *Ação popular constitucional*, São Paulo, Ed. RT, 1968.
- *Aplicabilidade das normas constitucionais*, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, 1982; 6ª ed., 3ª tir., Malheiros Editores, 2004.
- *Direito Ambiental Constitucional*, 4ª ed., 2ª tir., São Paulo, Malheiros Editores, 2003; 5ª ed., 2004.
- *Direito Urbanístico Brasileiro*, 3ª ed., Malheiros Editores, 2003; 5ª ed., 2005.
- *Manual do Vereador*, 3ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 1997.
- "Da jurisdição constitucional no Brasil e na América Latina", *RPGE*, n. 13-15, pp. 105 a 171.
- "Tribunais constitucionais e jurisdição constitucional", *RBEP*, n. 60-61.
- Representación proporcional; efectos corporativos en Brasil", in *Sistemas electorales y representación política en Latinoamérica*, v. 2, Madrid, Fundación Friedrich Ebert/Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1986.
- "A cidade-capital: função do Estado moderno, integração nacional e relações internacionais", *RTJE* n. 43.
- "Auto-aplicabilidade do artigo 198 da Constituição Federal", *RTJE* 25.
- "Direito à qualidade do meio ambiente", *Revista do Advogado* 18/46, junho/85.
- "El proceso legislativo como objeto del derecho parlamentario", in *Derecho parlamentario iberoamericano*, México, Porrúa, 1987.

- ____ "Jurisdição constitucional no Brasil e na América Latina", in *RPGE*, São Paulo, n. 13-15.
- ____ "Limitações ao poder de reforma constitucional", *RF* 159/75.
- ____ "Um sistema de equilíbrio", *Jornal da Tarde*, de 8.12.84, Caderno de Programas e Leituras, p. 6.
- ____ "Licitações", *RDP* 7/53.
- ____ *Mandado de injunção e habeas data*, São Paulo, Ed. RT, 1989.
- ____ *O Prefeito e o Município*, 3ª ed., São Paulo, CEPAM, 1982.
- ____ *Orçamento-programa no Brasil*, São Paulo, Ed. RT, 1973.
- ____ *Os servidores públicos municipais*, Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Municípios (Documento n. 10), 1971.
- ____ *Princípios do processo de formação das leis no Direito Constitucional*, São Paulo, Ed. RT, 1964; 2ª ed., Malheiros Editores, 2005.
- ____ *Sistema tributário nacional*, São Paulo, IBDT/Resenha Tributária, 1975.
- ____ *Tributos e normas de política fiscal na Constituição do Brasil*, São Paulo, 1968.
- ____ *Poder constituinte e poder popular*, São Paulo, Malheiros Editores, 2000.
- Aftalión (Enrique A.), Olano (Fernando García) e Vilanova (José), *Introducción al Derecho*, 7ª ed., Buenos Aires, La Ley, 1964.
- Agesta, Luis Sánchez, *Curso de Derecho constitucional comparado*, 5ª ed., 2ª reimpressão, Madrid, Universidad de Madrid/Facultad de Derecho/Sección de Publicaciones, 1974.
- Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, e outros, *Veinte años de evolución de los Derechos humanos*, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1974.
- Aleixo, Pedro, *Imunidades parlamentares*, Belo Horizonte, Ed. RBEP, 1961.
- Alessi, Renato, *Principi di diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1978.
- Alexandre, Francisco, *Naturalização e outros aspectos da nacionalidade*, Rio de Janeiro, Ed. A. Coelho Branco, 1956.
- Almeida, Fernanda Dias Menezes de, *Imunidades parlamentares*, Brasília, Câmara dos Deputados (Coordenação de Publicações), 1982.
- Almeida, Paulo Guilherme de, *Direito agrário: a propriedade imobiliária rural*, São Paulo, LTr, 1980.
- Amaral, Antônio Carlos Cintra do, *Licitações nas Empresas Estatais*, São Paulo, Editora McGraw-Hill, 1979.
- Amaral Gurgel, José Alfredo, *Segurança e Democracia*, 2ª ed., Rio de Janeiro, José Olympio, 1976.
- Amato, Pedro Muñoz, *Orçamentos*, Rio de Janeiro, FGV, trad. de Benedito Silva, 1958.

- Amin, Samir, *Le développement inégal*, Paris, Les Éditions de Minuit, s. d.
- ____ *La déconnexion*, Paris, Édition la Découverte, 1986.
- ____ *L'échange inégal et la loi de la valeur*, Paris, Antropos, 1988.
- Andrade, Adalmo de Araújo, *Diretrizes para classificação de cargos*, Belo Horizonte, ICEPS, 1960.
- Anhaia Mello, José Luiz de, *Da Separação de Poderes à Guarda da Constituição*, São Paulo, Ed. RT, 1968.
- Aristóteles, *Politique*, Paris, PUF, 1950, texto francês apresentado e anotado por Marcel Prélot.
- Arnou, Henri, *L'Autogestion*, Paris, PUF, "Collection Que-sais-je?", 1980.
- Auby, Jean-Marie, e Ducos-Ader, Robert, *Institutions administratives*, Paris, Dalloz, 1966.
- Aulete, Caldas, *Dicionário contemporâneo da língua portuguesa*, Rio de Janeiro, Delta, 1958.
- Azambuja, Darcy, *Teoria geral do Estado*, 4ª ed., Porto Alegre, Ed. Globo, 1963.

B

- Bachrach, Peter, *Crítica de la teoría elitista de la democracia*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, s.d.
- Balleiro, Aliomar, *Discriminação de rendas*, Rio de Janeiro, Ed. Financeiras, 1953.
- ____ *Limitações constitucionais ao poder de tributar*, 5ª ed., Rio, Forense, 1977.
- Balladore, Pallieri, Giorgio, *Diritto costituzionale*, 4ª ed., Milão, Giuffrè, 1955.
- Bandeira de Mello, Celso Antônio, *O conteúdo jurídico do princípio da igualdade*, 3ª ed., 13ª tir., São Paulo, Malheiros Editores, 2005.
- ____ *Curso de Direito Administrativo*, 16ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2003; 19ª ed., 2005.
- ____ *Elementos de direito administrativo*, São Paulo, Ed. RT, 1980.
- ____ *Licitação*, São Paulo, Ed. RT, 1980.
- ____ *Regime constitucional dos servidores da Administração direta e indireta*, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, 1991; 3ª ed., Malheiros Editores, 1995.
- ____ "Criação de secretarias municipais", *RDP*, n. 15, jan/mar 1971.
- Bandeira de Mello, Oswaldo Aranha, *Natureza Jurídica do Estado Federal*, Publicação da Prefeitura do Município de São Paulo (nova impressão), 1948.

- *Princípios gerais de direito administrativo*, Rio de Janeiro, Forense, 1969 e 1974.
- *Da Licitação*, São Paulo, José Bushatsky Editor, 1978.
- Baptista, Luiz Olavo, “Conceito de propriedade e sua extensão ao direito agrário”, *RT* 413.
- Baracho, José Alfredo de Oliveira, “*Habeas data* ou *habeas scriptum*”, *Jornal do Advogado*, Belo Horizonte, agosto/1988, p. 4.
- *Participação nos lucros e integração social* — PIS, Belo Horizonte, Ed. RBEP, 1972.
- *Teoria Geral do Federalismo*, Belo Horizonte, FUMARC/UFMG.
- Barbi, Celso Agrícola, *Do Mandado de Segurança*, 3ª ed., 3ª tiragem, Rio de Janeiro, Forense, 1980.
- “As novas dimensões do mandado de segurança”, tese apresentada no Seminário sobre os Novos Direitos Fundamentais na Constituição Brasileira, Hotel Glória, Rio de Janeiro, de 12 a 16 de dezembro de 1988.
- Barbosa, Ruy, *A Constituição e os Atos Inconstitucionais*, 2ª ed., 6 volumes, Rio de Janeiro, Atlântida, s.d.
- *Comentários à Constituição Federal Brasileira*, São Paulo, Saraiva, 1932, coligidos por Homero Pires.
- *República: Teoria e Prática (Textos doutrinários sobre direitos humanos e políticos consagrados na primeira Constituição da República)*, Petrópolis/Brasília, Vozes/Câmara dos Deputados, 1978.
- Barile, Paolo, *Le libertà nella Costituzione*, Padova, CEDAM, 1960.
- *Le libertà nella costituzione: lezioni*, Padova, CEDAM, 1966.
- *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 24.
- Barros, Henrique de, *Economia agrária*, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1954.
- Barthélemy, Joseph, *Essai sur le travail parlementaire et le systèmes des comissions*, Paris, Librairie Delagrave, 1934.
- Bascuñan, Alejandro Silva, *Tratado de Derecho Constitucional*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1963.
- Bastid, P., et al., *L'idée de légitimité*, Paris, PUF, 1967.
- Bazdresch, Luiz, *Curso elemental de garantías constitucionales*, México, Editorial Jus, 1977.
- Bear, Charles A., *Una interpretación económica de la constitución de los Estados Unidos*, Buenos Aires, Ed. Araiú, 1953, trad. de Héctor Sáenz y Quesada.
- Beccaria, Cesare, *Dei delitti e delle pene*, 2ª ed., Florença, Felice le Monnier, 1950.
- Beltrame, Pierre, *Les systèmes fiscaux*, Paris, PUF, 1975.

- Bidart Campos, Germán J., *El derecho constitucional del poder*, 2 volumes, Buenos Aires, Ediar, 1967.
- *Las elites políticas*, Buenos Aires, Ediar, 1977.
- *Derecho político*, 2ª ed., Buenos Aires, Aguilar, 1967.
- *Doctrina del Estado democrático*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1961.
- Biscaretti de Ruffia, Paolo, *Introduzione al diritto costituzionale comparato*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1970.
- *Diritto costituzionale*, 7ª ed., Napoli, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1965.
- Bonavides, Paulo, *Do Estado Liberal ao Estado Social*, 7ª ed., 2ª tir., São Paulo, Malheiros Editores, 2004.
- *Teoria do Estado*, São Paulo, Saraiva, 1967; 5ª ed., Malheiros Editores, 2004.
- Bonavides, Paulo, e Amaral Vieira, R. A., *Textos Políticos da História do Brasil*, Fortaleza, Imprensa Universitária da Universidade Federal do Ceará, s.d.
- Bonavides, Paulo, e Paes de Andrade, *História Constitucional do Brasil*, 3ª ed., São Paulo, Paz e Terra, 1991.
- Britto, Luiz Navarro de, “Declaração de voto”, *Documenta*, Separata n. 249.
- Bulos, Uadi Lamêgo, *Mandado de segurança coletivo (e outros estudos)*, Salvador, Editora Distribuidora de Livros, 1994.
- Burdeau, Georges, *Droit constitutionnel et institutions politiques*, 12ª ed., Paris.
- *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1966.
- *La democracia*, Caracas/Barcelona, Ariel, 1960 (verão portuguesa, *A Democracia*, 3ª ed., s.l., Publicações Europa-América, 1975).
- *Les libertés publiques*, Paris, LGDJ, 1972.
- *Traité de science politique*, 2ª ed., 10 volumes, Paris, LGDJ, 1966 a 1977.
- Burgoa, Ignacio, *Las garantías individuales*, 7ª ed., México, Porrúa, 1972.

C

- Cabral, Pedro Manso, *Alguns problemas da discriminação de rendas no Brasil*, Salvador, Progresso.
- Cadart, Jacques, *Institutions politiques et droit constitutionnel*, Paris, LGDJ, 1975.

- Caetano, Marcelo, *Manual de ciência política e direito constitucional*, 6ª ed., Lisboa, Coimbra Editora, 1970 (reproduzida no Brasil: *Direito constitucional*, Rio de Janeiro, Forense, 1977).
- *Manual de direito administrativo*, 1ª ed. brasileira, 2 tomos, Rio de Janeiro, Forense, 1970.
- Calamandrei, Piero, *Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados*, Lisboa, Livraria Clássica Ed., 1960.
- Calmon, Pedro, *História do Brasil*, Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 1959.
- Calmon de Passos, J. J., *Mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, "habeas data"*, Rio de Janeiro, Forense, 1989.
- Canotilho, J. J. Gomes, *Direito Constitucional*, 5ª ed., Coimbra, Almedina, 1991.
- *Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador*, Coimbra, Coimbra Editora, 1983.
- Canotilho, J. J. Gomes, e Moreira, Vital, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, 3ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1984.
- *Fundamentos da Constituição*, Coimbra, Coimbra Editora, 1991.
- Capelletti, Mauro, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Milano, Giuffrè, 1972.
- *La giurisdizione costituzionale delle libertà*, Milano, Giuffrè, 1974.
- *La justicia constitucional: estudios de derecho comparado*.
- *Proceso, ideologia, sociedad*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1974, trad. de Santiago Sentís de Melendo y Tomás A. Bazhaf.
- Carlo Lavagna, *Costituzione e socialismo*, Bologna, Il Mulino, 1977.
- Carneiro, Edison, *O Quilombo dos Palmares*, 2ª ed., São Paulo, Ed. Nacional (Brasileira), 1958.
- Carone, Edgar, *A Primeira República*, São Paulo, Difel, 1969, pp. 14 e 15.
- Carpizo, Jorge, *El presidencialismo mexicano*, 2ª ed., México, Siglo Veintiuno Ed., 1979.
- *La Constitución mexicana de 1917*, México, UNAM, 1979.
- Carré de Malberg, *Contribution a la théorie générale de l'état*, Paris, Recueil Sirey, 1920 (reimpressão de 1962), 2 tomos.
- Carvalho, Dardeau de, *Nacionalidade e cidadania*, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1956.
- Carvalho, Guido Ivan de, e Santos, Lenir, *Sistema Único de Saúde, Comentário à Lei Orgânica da Saúde (Leis 8.080/90 e 8.142/90)*, São Paulo, Editora Hucitec, 1992.

- Carvalho Pinto, Carlos Alberto, *Discriminação de rendas*, São Paulo, Prefeitura Municipal, 1943.
- Castro Nunes, José de, *Do mandado de segurança*, 8ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1980 (edição atualizada por José de Aguiar Dias).
- *Teoria e prática do Poder Judiciário*, Rio de Janeiro, Forense, 1943.
- Centre d'Études Européennes (org.), *Vers une protection efficace des droits économiques et sociaux?*, Bruxelles/Louvain, Bruylant/Vander, 1973.
- Chapelle, Philippe de la, *La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et le catholique*, Paris, LGDJ, 1967.
- Charles, Durand, "El Estado federal en el derecho positivo", in *El federalismo*, Madrid, Tecnos, 1965, trad. de Raul Morodo.
- Chenot, Bernard, *Organization économique de l'État*, Paris, Dalloz, 1965.
- Chiovenda, Giuseppe, *Instituições de Direito Processual Civil*, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1965, trad. de J. Guimarães Menegale.
- Cícero, *Da República*.
- CNBB, *Solo Urbano e Ação Pastoral*, São Paulo, Ed. Paulinas, 1982.
- Collado, Pedro Escribano, *La propiedad privada urbana: encuadramiento y régimen*, Madrid, Ed. Montecorvo, 1979.
- *Las vías urbanas*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1973.
- Colliard, Claude-Albert, *Libertés publiques*, Paris, Dalloz, 1972.
- Comisión Federal Electoral, *La nueva legislación electoral mexicana*, México, Secretaría Técnica, 1987.
- Comoglio, Luigi Paolo, *La garanzia costituzionale dell'azione ed il processo civile*, Padova, CEDAM, 1970.
- Comparato, Fábio Konder, *O poder de controle na sociedade anônima*.
- Constant, Benjamin, *Cours de politique constitutionnelle*, Paris, Guillaume, 1872 (edição espanhola, *Curso de política constitucional*, Madrid, Taurus, 1968, trad. de F. L. de Yturbe).
- Corrêa, Oscar Dias, *A defesa do estado de direito e emergência constitucional*, Rio de Janeiro, Forense, 1980.
- *Supremo Tribunal Federal: Corte Constitucional do Brasil*, Rio de Janeiro, Forense, 1987.
- Corwin, Edward S., *A Constituição Norte-Americana e seu Significado Atual*, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1986 (data do Copyright), trad. de Leda Boechaat Rodrigues, reimpressão.
- *El poder ejecutivo*, Buenos Aires, Ed. Bibliográfica Argentina, 1959, trad. de Laura E. Pelegrino.
- Costa, Jorge Gustavo da, *Planejamento governamental*, Rio de Janeiro, FGV, 1971.

- Costa Júnior, Paulo José da, *Agressões à intimidade*, São Paulo, Malheiros Editores, 1997.
- Cotteret, Jean-Marie, e Emeri, Claude, *Les systemes électoraux*, 2ª ed., Paris, PUF, 1973.
- Cretella Júnior, José, *Os writs na Constituição de 1988*, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1989.
- Crisafulli, Vezio, *La costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952.
- _____, *Lezioni di diritto costituzionale*, 3ª ed., Padova, CEDAM, 1975.
- Cristofolini, Giovanni, "Efficacia dei provvedimenti di giurisdizione volontaria emessi da giudice incompetente", in *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda*, Padova, CEDAM, 1927.
- Croce, Benedetto, *Breviário de Estética*, São Paulo, Atena Ed., s.d.
- Crosa, Emilio, *Lo Stato democratico*, Torino, UTET, 1946.
- Cunha, Manuela Carneiro da, *Os direitos do índio: ensaios e documentos*, São Paulo, Brasiliense, 1988.
- Cupis, Adriano de, "Riservatezza e segreto (Diritto a)", in *Novissimo digesto italiano*, Torino, UTET, 1969.
- Cury, Munir, et al. (Coordenadores), *Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado*, 6ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2003.

D

- Dallari, Adilson Abreu, *Aspectos Jurídicos da Licitação*, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1980.
- Dallari, Dalmo de Abreu, "Substitutos eventuais de mandatários políticos", *RFDUSP*, ano LXI — Fascic. II, São Paulo, 1966.
- _____, *Elementos de Teoria Geral do Estado*, 16ª ed., São Paulo, Saraiva, 1991.
- Dalton, Hubh, *Princípios de Finanças Públicas*, Rio de Janeiro, FGV, 1960, trad. de Maria de Lourdes Modiano.
- Dantas, Ivo, *Mandado de injunção*, Rio de Janeiro, Aide Ed., 1989.
- De Vergottini, Giuseppe, *Diritto costituzionale comparato*, 3ª ed., Padova, CEDAM, 1991.
- Debbasch, Charles, *Institutions administratives*, 3ª ed., Paris, LGDJ, 1975.
- Demichel, André e Francine, *Droit électoral*, Paris, Dalloz, 1973, p. 37.
- Deodato, Alberto, *Manual de finanças públicas*, 10ª ed., São Paulo, Saraiva, 1967.
- Dias, José de Aguiar, *Da Responsabilidade Civil*, 4ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1960.

- Díaz, Elias, *Estado de derecho y sociedad democrática*, Madrid, Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1973.
- _____, *Legalidad e legitimidad en el socialismo democrático*, Madrid, Civitas, 1978.
- _____, *Legalidad y legitimidad*, Madrid, Aguilar, 1971, trad. de José Díaz García.
- Diederich, Nils, "Elecciones, sistemas electorales", in *Marxismo y democracia (Enciclopedia de conceptos básicos): política 3*, Madrid, Ed. Rioduero, 1975, trad. de Joaquín Sanz Guijarro.
- Diniz, Carlos Francisco Sica, "Privacidade", in *Enciclopédia Saraiva de Direito*, São Paulo, Saraiva, 1981.
- Djordjevic, J., et al., *O papel do Executivo no Estado moderno*, Belo Horizonte, RBEP, 1964.
- Dotti, René Ariel, *Proteção da Vida Privada e Liberdade de Informação*, São Paulo, Ed. RT, 1980.
- Drubovic, Milojko, *A autogestão à prova*, Lisboa, Seara Nova, 1976.
- Duarte, José, *A Constituição brasileira de 1946, Exegese dos textos à luz dos trabalhos da Assembléia Constituinte*, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1947.
- Duclos, Pierre, *L'évolution des rapports politiques depuis 1750*, Paris, PUF, 1950.
- Duguit, Leon, *Traité de Droit Constitutionnel*, 3ª ed., Paris, Ancienne Librairie Fontémoin, 1930.
- Durand, Charles, "El Estado federal en el Derecho positivo", in Gaston Berger e outros, *El federalismo*, Madrid, Editorial Tecnos, 1965, trad. de Raul Morodo.
- Duret, Miguel Lanz, *Derecho constitucional mexicano*, 5ª ed., México, Companhia Editorial Continental, 1959.
- Duverger, Maurice, *Constitutions et documents politiques*, Paris, PUF, 1971.
- _____, *Finances publiques*, Paris, PUF, 1963.
- _____, *Os Regimes Políticos*, São Paulo, Difel, 1962, trad. de Geraldo Gerson de Souza.
- _____, *Droit constitutionnel et institutions politiques*, 4ª ed., 2 volumes, Paris, PUF, 1959.

E

- Easton, David, *Política moderna*, México, Editorial Letras, 1968.
- Elutizia, Angel Sustaeta, *Propiedad y urbanismo*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1978.

- Enciclopedia del diritto e dell'economia* Garzanti, "Eficienza" e "Razzismo", Milano, Edizioni Garzanti, 1985.
- Engels, Friedrich, *A origem da família, da propriedade e do Estado*, Rio de Janeiro, Editorial Vitória, 1960, trad. de Leandro Konder.
- Ennes, Ernesto, *As guerras dos Palmares*, São Paulo, Ed. Nacional, 1938.
- Espínola, Eduardo, *Constituição dos Estados Unidos do Brasil*, 2 volumes, Rio de Janeiro-São Paulo, Livraria Freitas Bastos, 1952.

F

- Falcão, Alcino Pinto, *Da imunidade parlamentar*, Rio de Janeiro, Forense, 1955.
- Falcão, Almir de Araújo, *Sistema tributário brasileiro*, Rio de Janeiro, Ed. Financeiras, 1965.
- Faria, Anacleto de Oliveira, *Do Princípio da Igualdade Jurídica*, São Paulo, Ed. RT/EDUSP, 1973.
- Faria, José Eduardo, *Poder e legitimidade*, São Paulo, Perspectiva, 1978.
- Fayt, Carlos S., *Sufragio y representación política*, Buenos Aires, Bibliográfica Omega, 1963.
- Ferrando Badía, Juan (org.), *Regímenes políticos actuales*, Madrid, Tecnos, 1985.
- "Teoría y realidad del Estado autonómico", separata da *Revista de Política Comparada*, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, n. III, 1980-1981.
- *Democracia Frente a Autocracia*, Madrid, Tecnos, 1980.
- *El Estado unitario, el federal y el Estado autonómico*, 2ª ed., Madrid, Editorial Tecnos, 1986.
- Ferraz, Anna Cândida da Cunha, *Poder constituinte do estado-membro*, São Paulo, Ed. RT, 1979.
- *Processos informais de mudança da constituição: mutações constitucionais e mutações inconstitucionais*, São Paulo, Max Limonad, 1986.
- Ferreira Filho, Manoel Gonçalves, *A Democracia Possível*, São Paulo, Saraiva, 1972.
- *Comentários à Constituição Brasileira de 1988*, São Paulo, Saraiva, 1990.
- *Curso de Direito Constitucional*, 17ª ed.
- *Direito constitucional comparado: I — O Poder Constituinte*, São Paulo, José Bushatsky, 1974.
- *Do processo legislativo*, São Paulo, Saraiva, 1968.
- *Estado de Direito e Constituição*, São Paulo, Saraiva, 1988.

- *O estado de sítio*, São Paulo, 1964.
- Ferreira Filho (Manoel Gonçalves), Grinover (Ada Pellegrini) e Cunha Ferraz (Anna Cândida da), *Liberdades Públicas: Parte Geral*, São Paulo, Saraiva, 1978.
- Ferreira, Waldemar, *Instituições de Direito Comercial*, São Paulo, Max Limonad, 1956.
- Figueiras, Leovigildo, *Discurso no Congresso Nacional*.
- Figueiredo, Lucia Valle, *Direitos dos Licitantes*, 4ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 1993.
- *Mandado de Segurança*, 5ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2004.
- *Perfil do mandado de segurança coletivo*, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1989; "Partidos políticos e mandado de segurança coletivo", RDP 95.
- Figueiredo, Marcelo, *O mandado de injunção e a inconstitucionalidade por omissão*, São Paulo, Ed. RT, 1991.
- Fischbach, Oskar Georg, *Teoría general del Estado*, 3ª ed., Barcelona, Editorial Labor, 1934, trad. espanhola de Rafael Luengo Tafía.
- Flaks, Milton, *Mandado de segurança: pressupostos da impetração*, Rio de Janeiro, Forense, 1980.
- Fonrouge, Carlso M. Giuliani, *Derecho financiero*, 2ª ed., Buenos Aires, Depalma, 1970.
- Forsthoff, Ernst, *Stato di diritto in trasformazione*, Milano, Giuffrè, 1973.
- Fragoso, Heleno, *Direito Penal*, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1959.
- França, R. Limongi, *Direito intertemporal brasileiro*, São Paulo, Ed. RT, 1968.
- Francisconi, Jorge Guilherme, e Souza, Maria Adélia Aparecida de, *Política nacional de desenvolvimento urbano: estudos e proposições alternativas*, Brasília, IPEA/IPLAN, 1976.
- Franco, Afonso Arinos de Melo, *Estudos de Direito Constitucional*, Rio de Janeiro, Forense, 1957.
- *Curso de Direito Constitucional Brasileiro*, 2 volumes, Rio, Forense, 1958.
- Franco, Afonso Arinos de Melo, e Pilla, Raul, *Presidencialismo ou parlamentarismo?*, Rio de Janeiro, José Olympio Ed., 1958.
- Frederico Marques, José, *A reforma do Poder Judiciário*, São Paulo, Saraiva, 1979.
- *Instituições de Direito Processual Civil*, 5 volumes, Rio de Janeiro, Forense, 1958.
- "O artigo 141, § 4º, da Constituição Federal", *Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Ceará*, n. 16.

G

- Gangemi, Lello, *Tratado de hacienda pública*, Madrid, Editorial de Derecho Financiero, 1964, trad. de Francisco Fernández.
- Garaudy, Roger, *La libertad*, Buenos Aires, Lautaro, 1960, trad. de Sara Manso.
- García Belaunde, Domingo, *El habeas corpus en el Peru*, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1979.
- García de Enterría, Eduardo, *La constitución como norma y el Tribunal Constitucional*, Madrid, Editorial Civitas, 1981.
- García-Pelayo, Manuel, *Derecho constitucional comparado*, 4ª ed., Madrid, Revista de Occidente, 1967.
- Garrido Falla, Fernando, e outros, *Comentarios a la constitución*, Madrid, Editorial Civitas, 1985.
- Giannini, M. S., *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, Il Mulino, 1977.
- Giménez Fernández, Manuel, *Estudios de derecho electoral contemporaneo*, 2ª ed., Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1977.
- Giovine, Alfonso di, *Introduzione allo studio della riserva di legge*, Torino, Giappichelli, 1969.
- Glitz, Gustave, *A Cidade Grega*, São Paulo, Difel, 1980, trad. de Henrique de Araújo Mesquita e Roberto Corte de Lacerda.
- Gomes, Randolpho, *Mandado de injunção*, Rio de Janeiro, Edições Trabalhistas, 1989.
- González Péres, Jesús, *La Dignidad de la Persona*, Madrid, Civitas, 1986.
- Gordillo, Agustín A., *El acto administrativo*, 2ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1969.
- *Tratado de derecho administrativo*, Buenos Aires, Ed. Macchi-Lopez, 1975.
- Gottschalk, Elson, *A participação do empregado na gestão da empresa*, Salvador, Progresso, 1958.
- Gournay (Bernard), Gournay (Jean-François Kesler) e Siwek-Pouydesseau (Jeanne), *Administration publique*, Paris, PUF, 1967.
- Grau, Eros Roberto, *Elementos de direito econômico*, São Paulo, Ed. RT, 1981.
- *A ordem econômica na Constituição de 1988*, 10ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005.
- Grecco, Albino, *La libertà di stampa nell'ordinamento giuridico italiano*, Roma, Bulzoni Editores, 1974.
- Greco Filho, Vicente, *Tutela constitucional das liberdades*, São Paulo, Saraiva, 1989.

- Grinover, Ada Pellegrini, *As garantias constitucionais do direito de ação*, São Paulo, Ed. RT, 1973.
- *Liberdades públicas e processo penal*, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, 1982.
- *Os Princípios Constitucionais e o Código de Processo Civil*, São Paulo, José Bushatsky, 1975.
- Groppali, Alexandre, *Doutrina do Estado*, São Paulo, Saraiva, 1953, trad. de Paulo Edmur de Souza Queiroz.
- Guerrero, Porfirio Marquet, *La estructura Constitucional del Estado mexicano*, México, UNAM, 1975.

H

- Haddock Lobo, Eugênio, e Prado Leite, Julio César do, *Comentários à Constituição Federal*, 1º vol., Rio, Edições Trabalhistas, 1989.
- Hall, Jerome, *Democracia e Direito*, Rio de Janeiro, Zahar, s.d.
- Hamilton (Alexander), Madison (James) e Jay (John), *O Federalista*, Brasília, Ed. UnB, 1984, trad. de Heitor Almeida Herrera (original, *The Federalist*, New York, Modern Library, s.d.).
- Hansen, Alvin H., *Política fiscal y ciclo económico*, 3ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, trad. de Rafael Fernández Maza e Cristóbal Lara, 1970.
- Hauriou, André, *Droit constitutionnel et institutions politiques*, 5ª ed., Paris, éd. Montchrestien, 1972.
- Hariou, Maurice, *Derecho público y constitucional*, 2ª ed., Madrid, Reus, s.d., trad. de Carlos Ruiz del Castillo.
- *Précis de droit administratif et de droit public*, 10ª d., Paris, Sirey, 1921.
- Heller, Hermann, *Teoría del Estado*, 4ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1961, trad. de Gerhart Niemeyer.
- Herrera Lane, Felipe, *Fundamentos de la política fiscal*, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1965.
- Horta, Raul Machado, "Imunidades parlamentares", *RDP* 3.
- "Regime político e a doutrina das formas de governo", *RF* 176.
- *A autonomia do estado-membro no direito constitucional brasileiro*, Belo Horizonte, 1964.

J

- Jacques, Paulino, *Curso de direito constitucional*, 8ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1977.

- ____ *Da Igualdade Perante a Lei*, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1957.
- Jefferson, Thomas, *Escritos Políticos*, São Paulo, Ibrasa, 1964, trad. de Leônidas Gontijo de Carvalho.
- Jemolo, Arturo Carlo, *I problemi pratici della libertà*, Milano, Giuffrè, 1972.
- Jhering, Rudolf von, *L'esprit du Droit Romain dans les diverses phases de son développement*, 2ª ed., Paris, A. Marescq Aîné, 1880, trad. de O. Meulenaere.
- Julien, Claude, *O Suicídio das Democracias*, Rio de Janeiro, Arte-nova, 1975, trad. de Marina Colasanti.

K

- Kaufmann, Mateo, *El equilibrio del presupuesto*, Madrid, Editorial de Derecho Financiero, 1964.
- Kayser, Pierre, *La protection de la vie privée: protection du secret de la vie privée*, Marseille, Presses Universitaires d'Aux-Marseille, 1984.
- Kelsen, Hans, *Teoria Pura do Direito*, 2ª ed., 2 volumes, Coimbra, Arménio Amado Editor, 1962, trad. de João Baptista Machado.
- ____ *Théorie pure du droit*, Paris, Dalloz, 1962, trad. de Charles Eisenmann.
- ____ *Teoría general del Derecho y del Estado*, 2ª ed., México, Imprenta Universitaria, 1958, trad. de Eduardo García-Maynez.
- ____ *Teoría generale del diritto e dello Stato*, 5ª ed., Milano, Etas Libri, 1974, trad. de Sergio Cotta e Giuseppino Treves.
- Kernig, C. D., e outros, *Marxismo y Democracia — Enciclopedia de Conceptos Básicos: Política 2*, Madrid, Ediciones Riodurero, 1975.

L

- La Roche, Humberto J., *Instituciones constitucionales del Estado venezolano*, 7ª ed., Maracaibo, Dipse, 1980.
- Lacroix, J., "De la démocratie libérale à la démocratie massive", *Esprit*, 1946.
- Lapierre, Jean-William, *Le pouvoir politique*, Paris, PUF, Collection Que sais-je?", 1953.
- Laski, Harold J., *Le gouvernement parlementaire en Angleterre*, Paris, PUF, 1950, trad. de Jacques Cadart e Jacqueline Prélôt.
- ____ *La crisis de la democracia*, Buenos Aires, Ed. Siglo Veinte, 1950, trad. de Armando Bazan.

- ____ *A Liberdade*, Salvador, Progresso Ed., s.d., trad. de Pinto de Aguiar.
- Lassale, Ferdinand, *Que es una constitución?*, Buenos Aires, Ed. Siglo Veinte, 1946, trad. de W. Rocas.
- Laubadère, André de, *Traité élémentaire de droit administratif*, Paris, LGDJ, 1970.
- Leclercq, C., *Le principe de la majorité*, Paris, Armand Colin, 1971.
- Lessa, Pedro, *Do Poder Judiciário*, Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1951.
- Liebman, Enrico Tullio, *Manuale di diritto processuale civile*, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1973.
- Linares Quintana, Segundo V., *Derecho Constitucional soviético*, Buenos Aires, Editorial Claridad, 1946.
- Locke, John, *Ensayo sobre el gobierno civil*, Buenos Aires, Aguilar, 1960, trad. de Ruis Rodrigues Aranda.
- Loewenstein, Karl, *Teoría de la constitución*, Barcelona, ed. Ariel, 1965, trad. espanhola de Alfredo Gallego Anabitarte (original alemão, *Verfassungslehre*, Tübingen, J. C. Mohr, 1959).
- Lucas Verdú, Pablo, *La lucha por el Estado de Derecho*, Bologna, Publicaciones del Real Colegio de España, 1975.
- ____ *Curso de Derecho político*, Madrid, Editorial Tecnos, 1974.
- Lyon-Caen, Gérard e Ribettes-Tillhet, Jeanne, *Manuel de droit social*, Paris, LGDJ, 1974.
- Lyra Tavares, A. de, *Território Nacional*, Rio de Janeiro, Companhia Editora Americana, 1955.

M

- Machiavelli, Nicolás, *Il principe*, Milano, Feltrinelli (I Classici), 1991.
- Mackenzie, W. J. W., *Elecciones libres*, Madrid, Tecnos, 1962.
- Magano, Octávio Bueno, *Novas tendências do direito do trabalho*, São Paulo, LTr, 1974.
- Malerbi, Diva Prestes, *Perfil do habeas data*, São Paulo, Ed. RT, 1989.
- Mancuso, Rodolfo de Camargo, *Ação popular*, São Paulo, Ed. RT, 1994.
- Maritain, Jacques, *Os Direitos do Homem*, 3ª ed., Rio de Janeiro, José Olympio Ed., 1967, trad. de Afrânio Coutinho.
- Marshall, Alfred, *Princípios de Economia*, São Paulo, Abril Cultural, 1982, trad. de Rômulo de Almeida e Ottolmy Strauch.

- Marshall, Geoffrey, *Constitutional Theory*, Oxford University Press, 1971 (tradução espanhola, *Teoría constitucional*, Madrid, Editorial Espasa-Calpe, 1982, trad. de Ramon García Cotarelo).
- Martins, Ives Gandra da Silva, e Mendes, Gilmar Ferreira (Coord.), *Ação declaratória de Constitucionalidade*, São Paulo, Saraiva, 1994.
- Martner, Gonzalo, *Planificación y presupuesto por programa*, 2ª ed., México, Siglo XXI Ed., 1969.
- Marx, Karl, *A Liberdade de Imprensa*, Porto Alegre, L&PM Editores, 1980, trad. de Cláudia Schiling e José Fonseca.
- e Engels, Friedrich, *O Manifesto Comunista*, 2ª ed., Rio de Janeiro, Zahar, 1978.
- Mazzoni, Giuliano, *Relações Coletivas de Trabalho*, São Paulo, Ed. RT, 1972.
- Mazzuoli, Valério de Oliveira, *Tratados internacionais*, 2ª ed., São Paulo, Ed. Juarez de Oliveira, 2004.
- *Direitos humanos, Constituição e tratado internacional*. São Paulo, Ed. Juarez de Oliveira, 2002.
- Meirelles, Hely Lopes, *Direito Administrativo Brasileiro*, 18ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 1993; 31ª ed., 2005.
- *Licitação e Contrato Administrativo*, 13ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2002.
- *Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e "habeas data"*, 15ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 1994; 28ª ed., 2005.
- Meirelles Teixeira, J. H., *Curso de Direito Constitucional*, São Paulo, Forense Universitário, 1991.
- Mendes, Armando Dias, "Declaração de voto", in *Documenta*, Separata n. 249, Brasília, agosto/81.
- Mendes, Gilmar Ferreira, *Controle de constitucionalidade, aspectos jurídicos e políticos*, São Paulo, Saraiva, 1990.
- Mendes, Raul Armando, *Comentários ao Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos*, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1991.
- Mendes Júnior, João, *Os indígenas do Brasil: seus direitos individuais e políticos*, São Paulo, Typ. Hennies Irmãos, 1912.
- Mendes Júnior, Onofre, *Direito administrativo*, 2ª ed., Belo Horizonte, Ed. Bernardo Álvares, 1961.
- Menegalle, J. Guimarães, *Direito administrativo e ciência da administração*, 2ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Borsói, 1950.
- Merriam, Charles E., *Que é democracia?*, São Paulo, Ed. Assunção, s.d.
- Miranda, Jorge, *Manual de Direito Constitucional*, 2ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1983.

- Mirkine-Guetzévitch, Boris, *Les Constitutions européennes*, Paris, PUF, 1951.
- Monreal, Eduardo Novoa, *Derecho a la vida privada y libertad de información*, 2ª ed., México, Siglo Veintiuno Editores, 1981.
- Monteiro, Washington de Barros, "Da nacionalidade e da cidadania em face da nova Constituição", *RDA* 91.
- Montesquieu, *De l'esprit des lois*, Paris, Édition Garnier Frères, 1956.
- Moojen, Guilherme, *Orçamento público*, Rio de Janeiro, Ed. Financeiras, 1959.
- Morales Prats, Firmín, "Bancos de datos y tutela de la persona", *REP*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, n. 30, nov./dez. 1982.
- *La tutela penal de la intimidad: "privacy" e informática*, Barcelona, Ed. Destino, 1984.
- Moreira, Wander Paulo Marotta, "Mandado de injunção", *Estado de Minas*, 13.9.88.
- Morgan, Lewis H., *La sociedad primitiva*, 3ª ed., Madrid, Editorial Ayuso, 1975, trad. de Editorial Pavolov, México.
- Mortati, Costantino, *Istituzioni di diritto pubblico*, 7ª ed., Padova, CEDAM, 1967.
- Mossé-Bastide, Rose-Marie, *La liberté*, Paris, PUF, 1974.
- Mukai, Toshio, *Estatutos Jurídicos de Licitações e Contratos Administrativos*, São Paulo, Saraiva, 1990.
- Myrdal, Gunnar, *Aspectos políticos da teoria econômica*, Rio de Janeiro, Zahar, trad. de José Auto, 1962.

N

- Nabuco, Joaquim, *Um estadista do Império*, Rio de Janeiro, Ed. Nova Aguilar, 1975.
- Nascimento, Amaury Mascaro do, *Curso de Direito do Trabalho*, 10ª ed., São Paulo, Saraiva, 1992.
- Neumann, Franz, *Estado Democrático e Estado Autoritário*. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1969, trad. de Luiz Corção.
- Neumark, Fritz, *Principios de la imposición*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, trad. de José Zamit Ferrer, 1974.
- Noblet, Albert, *A Democracia Inglesa*, Coimbra, Coimbra Ed., trad. de Fernando de Miranda, 1963.
- Nobre, Freitas, *Comentários à Lei de Imprensa, Lei da Informação*, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1978.
- Nohlen, Dieter, *Sistemas electorales del mundo*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981, trad. de Ramon García Cotarelo.

Novick, David et al., *Program Budgeting*, 2ª ed., New York, Holt, Rinehart and Winston, 1967.

O

Octávio, Rodrigo e Viana, Paulo, *Elementos de Direito Público e Constitucional Brasileiro*, 4ª ed., Rio de Janeiro, F. Briguiet, 1930.

Ogg, Frederic, e Ray, P. Orman, *Le gouvernement des États-Unis d'Amérique*, Paris, PUF, 1958, trad. francesa de Jacqueline Henri-Prélot.

Oliveira, Fernando Andrade, *Limitações Administrativas à Propriedade Privada Imobiliária*, Rio de Janeiro, Forense, 1982.

Oliveira, Juarez de (coordenador), *Comentários ao Código do Consumidor*, São Paulo, Saraiva, 1991.

Oliveira, Moacyr de, "Intimidade", in *Enciclopédia Saraiva do Direito*, São Paulo, Saraiva, 1980.

Oliveira, Raymundo Farias de, *Parlamentarismo: plenitude democrática*, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1985.

Oliveira, Régis Fernandes de, "Idéias sobre o mandado de injunção", *O Estado de S. Paulo*, 20.11.88.

Oliveira Filho, João, *Origem Cristã dos Direitos Fundamentais do Homem*, Rio de Janeiro, Forense, 1968.

Oliveira Vianna, Francisco José, *Evolução do Povo Brasileiro*, 4ª ed., Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 1956.

Ollero, Carlos, *El Derecho Constitucional de la posguerra*, Barcelona, Bosch, 1949.

Orlando, V. E., *Principios de derecho administrativo*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1978.

P

Pacheco, José da Silva, *Mandado de segurança e outras ações constitucionais*, São Paulo, Ed. RT, 1990.

Palma, Giuseppe, *Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà*, Napoli, Jovene, 1967.

Pannain, Remo, "Omicídio", in *Novissimo digesto italiano*, Torino, UTET, 1965.

Parga, Gimenes, *Los regímenes políticos contemporáneos*, Madrid, Tecnos, 1960.

Pasini, Gastone, *La tutela delle bellezze naturali*, Napoli, Morano, 1967.

Pastor, José Manuel Almansa, *Derecho a la seguridad social*, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 1977.

Peces-Barba, Gregorio, *Derechos fundamentales*, 2ª ed., Madrid, Biblioteca Universitaria, Guadiana, 1976.

Pereira, J. Matos, *Direito de Informação*, Lisboa, Associação Portuguesa de Informática, edição do autor, 1980.

Pereira Soderó, Fernando, *Curso de direito agrário: 2 — O estatuto da terra*, Brasília, Fundação Petrônio Portella/MJ, 1982.

Perelman, Charles, et al, *L'égalité*, Bruxelles, Établissements Émile Bruylant, 1971.

— "De la justice", in *Justice et raison*, Bruxelles, Établissements Émile Bruylant, 1963 (na tradução italiana, *La giustizia*, Torino, G. Giappichelli, s.d., trad. de Liliana Ribet com prólogo de Norberto Bobbio).

Pérez Luño (Antonio Enrique) Cascajo Castro (José), Castro Cid (Benito de) e Gómez Torres (Carmelo), *Los derechos humanos, significación, estatuto jurídico y sistema*, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1979.

Pergolesi, Ferruccio, *Diritto Costituzionale*, 15ª ed., Padova, CEDAM, 1972 (2ª reimpressão).

Peris, Manuel, *Juez, Estado y derechos humanos*, Valencia, Fernando Torres Editor, 1976.

Perlingieri, Pietro, *Introduzione alla problematica della "proprietà"*, Scuola di perfezionamento di diritto civile dell'Università degli studi di Camerino, Jovene, 1971 (data da impressão).

Phillips, O. Hood, *Constitutional and Administrative Law*, 5ª ed., London, Gweet & Mixwell, 1973.

Pimenta Bueno, José Antônio, *Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império*, Rio de Janeiro, Ministério da Justiça/Serviço de Documentação, 1958.

Pinto, Paulo Brossard de Souza, *O impeachment*, Porto Alegre, Livraria do Globo, 1965.

Pinto Ferreira, Luiz, *Da Constituição*, 2ª ed., Rio de Janeiro, José Konfino, 1956.

— *Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno*, 6ª ed., 2 volumes, São Paulo, Saraiva, 1983.

Piovesan, Flávia, *Direitos humanos e direito constitucional internacional*, 3ª ed., São Paulo, Max Limonad, 1997.

Pontes de Miranda, Francisco Cavalcanti, *Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969*, 2ª ed., 6 volumes, São Paulo, Ed. RT, 1970.

— *Comentários à Constituição de 1946*, Rio de Janeiro, Henrique Cahen Editor, 1947.

- Pound, Roscoe, *Desenvolvimento das Garantias Constitucionais da Liberdade*, São Paulo, Ibrasa, trad. de E. Jacy Monteiro, 1965.
- Prado Jr., Caio, *Dialética do conhecimento*, São Paulo, Brasiliense, 1955.
- Prélot, Marcel, *Institutions politiques et droit constitutionnel*, Paris, Dalloz, 1969.
- Pugliatti, Salvatore, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, Giuffrè, 1964.

Q

- Quaresma, Regina, *O mandado de injunção e a ação de inconstitucionalidade por omissão, teoria e prática*, 3ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1999.
- Quinzio Figueiredo, Jorge Mário, *Manual de derecho constitucional*, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1969.
- Quiroga Laviè, Humerto, *Derecho constitucional*, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1979.

R

- Ramírez, Manuel, *La participación política*, Madrid, Tecnos, 1985.
- Ramirez Cardona, Alejandro, *Sistema de hacienda pública*, Bogotá, Themis, 1970.
- Ramos, Elival da Silva, *Ação popular como instrumento de participação política*, São Paulo, Ed. RT, 1991.
- Ráo, Vicente, *As delegações legislativas no parlamentarismo e no presidencialismo*, São Paulo, Max Limonad, 1966.
- _____, *O direito e a vida dos direitos*, 2ª ed., São Paulo, Resenha Universitária, 1977.
- Reale, Miguel, *Lições preliminares do direito*, São Paulo, Bushatsky/EDUSP, 1973.
- _____, *Parlamentarismo brasileiro*, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1962.
- Remy, Jena, *La ville: phénomène économique — questions économiques, sociales et politiques*, Bruxelles, Éditions Vie Ouvrière, 1966.
- Renner, Karl, *Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale*, Bologna, Il Mulino, 1981.
- Requião, Rubens, *Curso de Direito Comercial*, São Paulo, Saraiva, 1977.
- Ribeiro, Fávila, *Direito eleitoral*, Rio de Janeiro, Forense, 1976.
- Rigolin, Ivan Barbosa, *Manual Prático das Licitações*, São Paulo, Saraiva, 1991.
- Ripert, Georges, *Le régime démocratique et le droit civil moderne*, 2ª ed., Paris, LGDJ, 1948.

- Rivero, Jean, *Les libertés publiques — 1. Les droits de l'Homme*, Paris, PUF, 1973.
- _____, *Les libertés publiques*, Paris, PUF, 1980.
- Robert, Jacques, *Liberté religieuse et le régime des cultes*, Paris, PUF, 1977.
- _____, *Libertés publiques*, Paris, Éditions Monchrétien, 1971.
- Rocha, Cármen Lúcia Antunes, "O direito constitucional à jurisdição", in Sálvio de Figueiredo Teixeira (Coord.), *As garantias do cidadão na justiça*, São Paulo, Saraiva, 1993.
- _____, "Constituição e mudança constitucional: limites ao exercício do poder de reforma constitucional", *Separata da Revista de Informação Legislativa*, Brasília, n. 120, outubro/dezembro 1993.
- _____, *O princípio constitucional da igualdade*, Belo Horizonte, Jurídicos Lê, 1990.
- _____, *Constituição e constitucionalidade*, Belo Horizonte, Jurídicos Lê, 1991.
- _____, *República e Federação no Brasil — Traços constitucionais da organização política brasileira*, Belo Horizonte, Del Rey, 1997.
- _____, *Princípios constitucionais na administração pública*, Belo Horizonte, Del Rey, 1994.
- _____, *Princípios constitucionais dos servidores públicos*, São Paulo, Saraiva, 1999.
- _____, *Estudo sobre a concessão e permissão de serviços públicos no direito brasileiro*, São Paulo, Saraiva, 1996.
- Rodotà, Stefano, "Proprietà (Diritto vigente)", in *Novissimo digesto italiano*, v. 15.
- Rodrigues, Ernesto, *O veto no Brasil*, Rio de Janeiro, Forense, 1981.
- Romano, Santi, *Principii di diritto costituzionale generale*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1947 (tradução brasileira de Maria Helena Diniz, *Princípios de Direito Constitucional Geral*, São Paulo, Ed. RT, 1977).
- Rosanvallon, Pierre, *L'âge de l'autogestion*, Paris, Ed. du Seuil, 1976.
- Rotman, Gert Willi, "O princípio da legalidade tributária", in *Direito tributário*, 5ª coletânea, São Paulo, Bushatsky, 1973.
- Rousseau, Jean Jacques, *Du contrat social*, Paris, Éditions Sociales, 1955.
- _____, "Quel'est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée", *Discours*, Paris, Éditions Sociales, s.d.
- Ruggiero, Roberto de, *Instituições de direito civil*, São Paulo, Saraiva, trad. de Ary dos Santos, 1971.
- Russomano, Rosah, *Curso de Direito Constitucional*, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1972.

S

- Saa Velasco, Ernesto, *Teoría constitucional geral*, Barraquilla, Ediciones Universidades Simon Bolívar, Libre de Pereira y Medellín, 1977.

- Sáchica, Luiz Carlos, *Derecho Constitucional de la libertad*, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 1980.
- *Democracia, representación, participación*, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), 1985.
- Saldanha, Nelson Nogueira, *O poder constituinte: tentativa de estudo sociológico e jurídico*, Recife, Imprensa Industrial, 1957.
- *Sociologia do direito*, São Paulo, Ed. RT, 1970.
- Sampaio, Aluysio, *Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Estabilidade com Indenização*, São Paulo, Ed. RT, 1971.
- Sampaio, Nelson de Sousa, *O processo legislativo*, São Paulo, Saraiva, 1968.
- *O poder de reforma constitucional*, Salvador, Livraria Progresso, 1954.
- Sampaio Dória, Antônio, *Direito Constitucional*, 3ª ed., São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1953.
- *Direito constitucional: comentários à Constituição de 1946*, 2 volumes, São Paulo, Max Limonad, 1960.
- Sampaio Dória, Antônio Roberto, *Discriminação de competência impositiva*, São Paulo, 1972.
- Santoro-Passarelli, Francesco, *Noções de Direito do Trabalho*, São Paulo, Ed. RT, 1973.
- Santoro-Passarelli, Francesco, et al., *Proprietà privata e funzione sociale*, Padova, CEDAM, 1976.
- Santos, Aricê Moacyr Amaral, *O mandado de injunção*, São Paulo, Ed. RT, 1989.
- Santos, Ulderico Pires dos, *Mandado de injunção*, São Paulo, Paumape, 1988.
- Sarasate, Paulo, *A Constituição do Brasil ao alcance de todos*, Rio de Janeiro-São Paulo, Livraria Freitas Bastos, 1967.
- Sarote, George, *O Materialismo Histórico no Estudo do Direito*, 2ª ed., Lisboa, Editorial Estampa, 1975, trad. do Dr. Joaquim Monteiro Matias.
- Sauer, Wilhelm, *Filosofía jurídica y social*, Madrid, Ed. Labor, trad. de Luis Legaz Lacambra, 1933.
- Scambini, Pe. José, *Liberdade Religiosa nas Constituições Brasileiras*, Petrópolis, Vozes, 1978.
- Schmit, Carl, *Teoría de la Constitución (Verfassungslehre)*, München, 1928, de que existe tradução espanhola, *Teoría de la constitución*, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, s.d.).
- *Legalidad y legitimidad*, Madrid, Aguilar, 1971, trad. de José Díaz García.
- Schwartz, Bernard, *The Great Rights of Mankind: A History of the American Bill of Rights*, New York, Oxford University Press, 1977.

- *Direito constitucional americano*, Rio de Janeiro, Forense, 1966, trad. de Carlos Nayfeld.
- Seabra Fagundes, Miguel, *A legitimidade do Poder Político na experiência brasileira*, Recife, OAB/Seção Pernambucana, 1982.
- *As Forças Armadas na Constituição*, Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército, 1955.
- *O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário*, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 1984.
- Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior-Universidad de Barcelona (org.), *La estructura del Estado*, Barcelona, Bosch, 1958.
- Servídio, Américo, *Dispensa de Licitação Pública*, São Paulo, Ed. RT, 1979.
- Sharpe, R. J., *The law of habeas corpus*, Oxford, Clarendon Press, 1976.
- Siches, Recasén, *Vida humana, sociedad y Derecho*, 3ª ed., México, Porrúa, 1952.
- Silva, Antônio Álvares da, *Co-gestão no Estabelecimento e na Empresa*, São Paulo, LTr, 1991.
- Silva, Antônio Marcello da, *Contratações Administrativas*, São Paulo, Ed. RT, 1971.
- Silva, Gérson Augusto da, *Sistema tributário brasileiro*, 2ª ed., Rio de Janeiro, 1948.
- Silva, Luís Virgílio Afonso da, *Sistemas eleitorais, tipos, efeitos jurídico-políticos e aplicação ao caso brasileiro*, São Paulo, Malheiros Editores, 1999.
- Silva, Sebastião Sant'Anna e, *Os princípios orçamentários*, Rio de Janeiro, FGV, 1967.
- Silva Buscuñan, Alejandro, *Tratado de derecho constitucional*, Santiago, 3 volumes, Ed. Juridica de Chile, 1963.
- Siqueira Castro, Carlos Roberto de, *O Congresso e as delegações legislativas*, Rio de Janeiro, Forense, 1986.
- Slaibi Filho, Jagib, *Ação Declaratória de Constitucionalidade*, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1994.
- Sousa, Rubens Gomes de, "O sistema tributário federal", *RDA* 72/5.
- Souza, Washington Peluso Albino de, *Direito Econômico*, São Paulo, Saraiva, 1980.
- Spantigati, Federico, *Manual de derecho urbanístico*, Madrid, Ed. Montecorvo, 1973.
- Starck, Christian, *El concepto de ley en la constitución alemana*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1979.
- Stefanini, L. Lima, *A propriedade no direito agrário*, São Paulo, Ed. RT, 1978.
- Stendardi, Gian Galeazzo, *La corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1955.

- Stigum, Bernt, e Marcia L. Stigum, *Economia micro-econômica*, São Paulo, Ed. Edgar Blucher-EDUSP, 1973.
- Storm, René, *Le budget*, 7ª ed., Paris, Librairie Félix-Alcan, 1912.
- Strenger, Irineu, *Do mandado de injunção*, Rio de Janeiro, FU, 1988.
- Sundfeld, Carlos Ari, "Habeas data e mandado de segurança coletivo", RDP 95.

T

- Tácito, Caio, "O controle da administração e a nova Constituição do Brasil", RDA 90/24.
- ____ *Direito administrativo*, São Paulo, Saraiva, 1975.
- Tavares, André Ramos, *Tratado da arguição de preceito fundamental*. São Paulo, Saraiva, 2001.
- Taylor, Philip E., *Economía de la hacienda pública*, Madrid, Aguilar, 1960, trad. de María Teresa Fuentes Quintana et al.
- Teixeira, Anísio "A pedagogia de Dewey", in John Dewey, *Vida e educação*, 5ª ed., São Paulo, Companhia Editora Nacional.
- ____ *A educação e a crise brasileira*, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1956.
- ____ *Educação não é privilégio*, Rio de Janeiro, José Olympio Ed., 1957.
- Teixeira, J. H. Meirelles, *Curso de direito constitucional*, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1991.
- Telles Júnior, Goffredo, *Direito Quântico*, 5ª ed., São Paulo, Max Limonad, 1980.
- Temer, Michel, "Algumas notas sobre o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção e o habeas data", RPGE 30.
- Tena Ramírez, Felipe, *Derecho constitucional mexicano*, México, Porrúa, 1968, 9ª ed.
- Tobeñas, José Castán, *Los Derechos del Hombre*, 2ª ed., Madrid, Reus, 1975.
- Trindade, Antônio Augusto Cançado, *A proteção internacional dos direitos humanos*, São Paulo, Saraiva, 1991.
- Trindade, Hégio, *Integralismo: o fascismo brasileiro da década de 30*, São Paulo, Difel, 1974.
- Trocer, Nicolò, *Processo civile e costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1974, trad. de Gian Antonio Micheli.
- Truyol y Serra, Antonio, *Los Derechos Humanos*, Madrid, Tecnos, 1971.

U

- Uckmar, Victor, *Princípios comuns de direito constitucional tributário*, São Paulo, EDUC/RT, trad. de Marco Aurélio Greco, 1976; 2ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 1999.

- Union Interparlementaire (org.), *Parlements*, Paris, PUF, 1961.

V

- Valadés, Diego, "Problemas de la reforma constitucional en el sistema mexicano", in Andueza Acuña et al, *Los cambios constitucionales*, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1977.
- ____ *La dictadura constitucional en América Latina*, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1974.
- Vanossi, Jorge Reinaldo A., *Teoría constitucional*, 2 volumes, Buenos Aires, Depalma, 1975.
- ____ *Presidencialismo y parlamentarismo en el Brasil*, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencia Sociales, 1964.
- ____ *El misterio de la representación política*, Buenos Aires, Ediciones América Actual, 1972.
- ____ *El Estado de derecho en el constitucionalismo social*, Buenos Aires, Ed. Universitaria, 1982.
- Vedia, Agustín de, *Derecho constitucional y administrativo*, 4ª ed., Buenos Aires, Ed. Macchi, 1969.
- Vega, Pedro de, "Jurisdicción constitucional y crisis de la Constitución", in *Estudios políticos constitucionales*, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1980.
- Velloso, Carlos Mário da Silva, "Do mandado de segurança", RDP 55/56.
- Veloso, Zeno, "Imunidades parlamentares dos Vereadores", RIL 92.
- Verney, Douglas V., *Análisis de los sistemas políticos*, Madrid, Tecnos, 1961, trad. de Mariano Berdejo Rivera.
- Viamonte, Carlos Sánchez, *El poder constituyente*, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica, Argentina, 1957.
- ____ *Manual de Derecho Constitucional*, 4ª ed., Buenos Aires, Kpelusz, 1959.
- Vidigal, Geraldo de Camargo, *Teoria Geral do Direito Econômico*, São Paulo, Ed. RT, 1977.
- Vidigal, Luiz Eulálio de Bueno, "Do mandado de segurança", in *Direito Processual Civil*, São Paulo, Saraiva, 1965.
- Vigoritti, Vincenzo, *Garanzie costituzionale del processo civile*, Milano, Giuffrè, 1973.
- Virga, Pietro, *Libertà giuridica e diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 1947.

W

Walcker, Harvey, *Public Administration in the United States*, New York, Ferrar & Rinehar Incorp. 1937.

Watanabe, Kazuo, *Controle jurisdicional e mandado de segurança contra atos judiciais*, São Paulo, Ed. RT, 1980.

Wigny, Pierre, *Droit constitutionnel*, Bruxelles, Établissements Émile Bruyant, 1952.

X

Xavier, Alberto, *Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação*, São Paulo, Ed. RT, 1978.

Xifras Heras, Jorge, *Curso de Derecho constitucional*, 2ª ed., 2 tomos, Barcelona, Bosch, Casa Editorial, 1957.

Y

Yardley, D. C. M., *Introduction to British Constitutional Law*, London, Butterworths, 1978.

Z

Zaitsev, E., e Poltorak, A., *La abocacia soviética*, Moscou, Ed. en Lenguas Extranjeras, 1959.

Zippelius, Reinhold, *Teoria general del estado*, México, UNAM, trad. de Héctor Fix-Fierro, 1985.

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

(Os números remetem às páginas)

A

Aborto em face da Constituição, 203

Abuso do poder econômico, 795

Ação

- direito a uma duração razoável do processo, 432
- direito de, 431
- profissional: liberdade, 256
- v. tb. verbete específico

Ação declaratória de constitucionalidade

- competência, 59
- efeitos da decisão, 60
- finalidade e objeto, 57
- legitimação e competência, 59
- questão constitucional, 56

Ação popular, 142

- regime constitucional, 462

Acessibilidade

- função administrativa, 678
- função pública, 257

Acréscimos pecuniários - Regras de singeleza, 686

- v. tb. Agentes públicos

Acumulação de cargos, empregos e funções - Vedação, v. Agentes administrativos**Administração e jurisdição**, 555**Administração estadual - Órgãos superiores**, 662-664**Administração federal**

- Conselhos, 660-662
- órgãos superiores
 - Ministérios, 657-660
 - Presidência da República, 657

Administração Municipal - Órgãos superiores, 662-664**Administração Pública**, 107

- direta, 655
- estruturas básicas, 654-665
- fundacional, 655
- impessoalidade, v. Princípios (da impessoalidade da Administração Pública)
- indireta, 655
- noção de administração, 654
- organização administrativa, 654-655
- participação do usuário, v. Usuário
- princípios constitucionais, 666-676
- responsabilidade civil, 673

Adolescente - Tutela, 849**Advocacia pública**

- Advocacia-Geral da União, 605-606
 - chefia, 606
 - instituição, 605
 - organização, 605
- defensorias públicas, 606
- função essencial à Justiça, 605
- representação das unidades federadas, 606

Advogado

- e administração da Justiça, 596
- função essencial à Justiça, 595
- inviolabilidade, 597

Aeronáutica, v. Forças Armadas**Agentes administrativos**, 677-678

- acessibilidade à função, 678
- acréscimos pecuniários, 687
- conceito, 677
- e agentes públicos, 677
- equiparação de vencimentos, 687
- investidos em mandato eletivo, 689
- investidura em cargo ou emprego, 679
- isonomia de vencimentos, 687
- paridade de vencimentos, 687

- pessoal temporário: contratação, 681
- servidores públicos, 691-701
 - empregados públicos, 678
 - funcionários públicos, 678
 - prestacionistas de serviço público temporário, 678
 - servidores em sentido estrito, 678
- vedação de acumulações remuneradas, 688
- vinculação de vencimentos, 687
- v. tb. Servidores públicos

Agentes públicos

- administrativos, 677-690
- políticos, 677
- sistema remuneratório, 681
 - remuneração, 684-686
 - subsídio, 682
 - vencimento e vencimentos, 684-686
- v. tb. Agentes administrativos; Militares

Aglomeraciones urbanas, 664

Aposentadoria, pensão e seus proventos, 691

Arguição de descumprimento de preceito constitucional fundamental – Competência do STF, 562

Asilo político, v. Estrangeiro

Assembleia Legislativa Estadual, 622

- atribuições, 624
- funcionamento, 623

Assistência social

- bases constitucionais, 836
- direito, 310
- direito social, 836

Associação – Liberdade de, 266

Atividade administrativa e princípio da legalidade, 427

Atividade econômica

- exploração estatal, 804
- princípios gerais, 785

Ato administrativo

- finalidade, 667
- publicidade, 669

Ato jurídico perfeito – Conceito e regime, 435

Atos institucionais – Regime, 86

Atuação do Estado na economia

- capitalismo, 799
- e serviço público, 801
- estatismo, 800
- exploração estatal de atividade econômica, 804
 - monopólios, 785
- intervenção no domínio econômico, 807
- modos, 804
- planejamento econômico, 809
- socialismo, 800

Autonomia

- dos Estados Federados, 608
- equilíbrio federativo, 484
- gerencial dos órgãos administrativos, 675
- intervenção, 484
- municipal
 - base constitucional, 640
 - capacidade de auto-organização, 642
 - lei orgânica própria, 642
- universitária, 838

B

Banco Central – Função, 735

Bem de família, 278

Bens da União, 495

Brasileiros

- natos, 326, 331
- naturalizados, 330, 332
- v. tb. Direito de nacionalidade brasileira

Brasília – Capital Federal, 472

C

Câmara dos Deputados

- atribuições privativas, 521
- representantes do povo, 510
- v. tb. Congresso Nacional

Câmara Legislativa do Distrito Federal, 651

- deputados distritais, 651

Câmara Municipal

- composição, 647
- funções, 646
 - deliberativa, 646
 - fiscalizadora, 646
 - julgadora, 647
 - legislativa, 646
 - poder organizativo municipal, 647
- vereadores, 647, 648

Candidaturas – Apresentação, 378

Capacidade eleitoral, 356

Capital estrangeiro, v. Empresa brasileira; Instituições financeiras

Capitalismo, socialismo e estatismo, 799

Cargo público, v. Agentes administrativos; Servidores públicos

Carreiras jurídicas e isonomia concreta, 595

Cassação de mandato, v. Estatuto dos Congressistas

Certidões – Direito a, 444

Cessação da intervenção – Consequências, 488

Chefe de Estado e de Governo – Conceito e funções, 542

Cidadania

- aquisição, 346
- conceito, 344
- e nacionalidade, 345
- fundamento do Estado brasileiro, 104
- v. tb. Democracia; Direito de cidadania

Cidadão – Conceito, 346

Ciência e tecnologia na Constituição, 844

Circulação – Liberdade de, 239

Classificação

- dos direitos fundamentais, 182
- dos direitos individuais, 193

Co-gestão – Conceito, 298

Coisa julgada – Garantia, 436

Colônia

- fragmentação do Poder, 70
- organização municipal, 72

Comissão representativa – Atribuições e funcionamento, 516

Comissões parlamentares, 513

Competência

- administrativa, 497
- econômica, 500
- financeira, 501
- internacional, 496
- material comum, 501
- política, 496
- prestação de serviços, 497
- social, 500
- urbanística, 499

Competência legislativa

- Estados federados, 622
- União Federal, 502

Competência tributária

- atribuição constitucional, 721
- discriminação das rendas tributárias, 721-732
- Estados, 725
- Municípios, 728
- União, 722

Competências

- classificação, 479
- da União: noção e classificação, 496
- estaduais materiais, 620
- municipais: bases constitucionais, 643

Comunicação

- liberdade de, 243
- meios de, 248
- social, 844
- v. tb. Conselho de Comunicação Social

Comunicações pessoais – Segurança, 438

Concorrência e abuso do poder econômico, 795

Condições de trabalho, v. Direitos sociais (dos trabalhadores)

Conflitos tributários – Normas de prevenção

- lei complementar, 709
- resoluções do Senado Federal, 711

Congressistas

- direitos, 537
- Estatuto, 534
- incompatibilidades, 538

- perda do mandato, 539
- Congresso Nacional**, 509
 - atribuições, 520
 - privativas da Câmara dos Deputados, 521
 - privativas do Senado Federal, 521
 - Câmara dos Deputados, 510
 - Comissão representativa, 516
 - convocação e comparecimento de Ministros, 523
 - funcionamento, 517
 - Mesa, 512
 - organização interna das Casas
 - Comissões Parlamentares, 513
 - Mesas, 512
 - polícia, 516
 - regimentos internos, 511
 - serviços administrativos, 516
 - Senado Federal, 511
 - v. tb. Estatuto dos Congressistas
- Conhecimento**
 - recepção de, 255
 - transmissão de, 255
- Conselho da Justiça Federal**, 573
- Conselho da República**
 - competência, 661
 - composição, 661
 - função, 661
- Conselho de Comunicação Social**, 662
- Conselho de Defesa Nacional**
 - competência, 661
 - composição, 662
 - função, 661
- Conselho Nacional de Justiça**, 567
 - competência, 569
 - composição e funcionamento, 568
 - ouvidorias, 570
- Conselho Nacional do Ministério Público**, 603
 - competência, 603
 - composição, 603
 - Corregedor Nacional, 604
 - funcionamento, 604
 - ouvidorias do Ministério Público, 604

- Constitucionalidade – Controle**, v. Ação declaratória de constitucionalidade; Controle de constitucionalidade; Estado Democrático de Direito; Supremo Tribunal Federal
- Constituição de 1891 – Formação e estrutura**, 78
- Constituição de 1934 – Ordem econômica e social**, 81
- Constituição de 1946 – Redemocratização**, 83
- Constituição de 1967 e sua Emenda 1**, 86
- Constituição de 1988**
 - plebiscito, revisão e emendas constitucionais, 90
 - seu sentido, 89
- Constituição econômica**
 - formal, 791
 - idéia, 790
 - princípios, 791
 - v. tb. Ordem econômica
- Constituição Estadual**
 - considerações gerais, 636, 638
 - conteúdo, 636
 - elementos limitativos, 637
 - elementos orgânicos, 637
 - elementos sócio-ideológicos, 638
- Constituição Federal**, 46
 - guarda, 559
 - v. tb. Arguição de descumprimento de preceito constitucional fundamental
- Constituições**
 - classificação, 40
 - conceito, 37
 - concepções, 38
 - conteúdo, 43
 - elementos, 44
 - emendas, 61
 - Imperial, 74
 - objeto e conteúdo, 43
 - rigidez e supremacia, 45
 - formal, 45
 - material, 45
- Constituições brasileiras (de 1824 a 1988)**, 74-90, 170, 171

- Consultorias estaduais – Função essencial à Justiça estadual**, 634
- Consumidores**
 - direitos, 262
 - direitos sociais, 307
- Contabilidade pública**, v. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária
- Contenção – Regras de**, 258
- Contencioso eleitoral**, 379
- Contratação – Pessoal temporário**, 681
- Contribuição de iluminação pública**, 729
- Contribuição de melhoria**, 707
- Contribuição sindical**, 303
- Contribuições sociais**, 708
- Controle**
 - externo, 752
 - financeiro, 751
 - interno, 751
 - jurisdicional, 431
- Controle de constitucionalidade**, 46, 50
 - doutrina, 46
 - exercício, 49
 - inconstitucionalidades, 46
 - por ação, 47
 - por omissão, 47
 - jurisdicional, 49-50
 - sistema brasileiro, 50
 - sistemas, 49
 - v. tb. Ação declaratória de constitucionalidade; Declaração de inconstitucionalidade; Reforma constitucional; Supremo Tribunal Federal
- Cooperativas de crédito**, 827
- Corregedor Nacional**, 604
- Corpo de bombeiros**, v. Polícia(s) (estaduais)
- Corpo eleitoral – Conceito**, 365
- Créditos orçamentários – Princípio da quantificação**, 745
- Criança – Direitos sociais**, 316
- Criança e adolescente – Tutela**, 849
- Crime**, v. Governador do Estado; Ministros de Estado; Presidente da República
- Cultura**
 - direito à cultura, 313

- direitos culturais, 842
- ordem constitucional, 837-847

D

- Decisões judiciais normativas**, 466
- Declaração da Virgínia**, 153
- Declaração de inconstitucionalidade – Efeitos**, 52
- Declaração do Povo Trabalhador e Explorado (México, 1918) – Significado**, 159
- Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789) – Significado**, 157
- Declaração norte-americana**, 155
- Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948)**, 162
- Declarações de direitos**
 - antecedentes, 149-161
 - Constituições brasileiras, 170
 - Constituições contemporâneas, 166
 - forma, 175
 - formação histórica das, 149
 - inglesas, 151
 - nas Constituições brasileiras, 170
 - nas Constituições contemporâneas, 166
 - universalização, 161
- Defensorias Públicas – Defesa dos necessitados**, 606
 - estaduais, 636
 - no Distrito Federal, 653
- Defesa – Direito de**, 431
- Defesa das instituições democráticas**, 761
 - estados de exceção, 763
 - estado defesa, 763-766
 - estado de sítio, 766-770
- Defesa do Estado**, 760
 - e estado de defesa, 763
- Defesa Nacional**, 662
 - Justiça Federal, 573
 - República, 662
- Defensorias Públicas**, 606
- Democracia**
 - conceito, 125, 134

- conceito de povo e, 134
- defesa das instituições democráticas, 761
- e direito constitucional brasileiro, 145
- e liberdade, 234
- e povo, 134
- Estado de Direito, 112
- exercício do poder democrático, 136
- mandato político representativo, 138
- participativa, 141
- partidária, 405
- pluralista, 143
- poder democrático, 136
- pressupostos, 126
- princípios e valores, 129
 - participação do povo no poder, 131
 - representação, 131
 - soberania popular, 131
- qualificações, 133
- representativa, 137
- valores, 129
- v. tb. Estado Democrático de Direito
- Deportação – Conceito e regime, 342**
- Deputados estaduais – Estatuto, 626**
- Desapropriação – Fundamentos, 281**
- Descumprimento de preceito constitucional fundamental – Arguição, 562**
- Desincompatibilização – Conceito, 392**
- Desporto – Regime constitucional, 844**
- Deveres – Individuais e coletivos, 195**
- Devido processo legal – Fundamento e noção, 431**
- Dignidade da pessoa humana – Fundamento do Estado brasileiro, 105**
- Direito**
 - ao meio ambiente, 315
 - e direito social, 316
 - significado, 315
 - ao trabalho, 289
 - autoral, 275
 - à assistência social, 310
 - a certidões, 444
 - à cultura, 313
 - à educação, 312
 - à existência, 198
 - à informação, 259
 - à integridade física, 199
 - à integridade moral, 201
 - à moradia, 314
 - condição de eficácia, 315
 - fundamento constitucional, 314
 - significação, 314
 - à previdência social, 310
 - à privacidade, 205-210
 - conceito, 205
 - conteúdo, 205
 - e informática, 209
 - honra das pessoas, 209
 - imagem das pessoas, 209
 - indenização pela violação, 210
 - intimidade, 206
 - vida privada, 208
 - violação, 210
 - à saúde, 308
 - à segurança, 437
 - segurança das comunicações pessoais, 438
 - segurança do domicílio, 437
 - segurança em matéria penal, 438
 - segurança em matéria tributária, 441
 - à seguridade social, 307
 - à assistência social, 310
 - à previdência social, 310
 - à vida, 197
 - a vida como objeto do direito, 197
 - direito à existência, 198
 - direito à integridade física, 199
 - direito à integridade moral, 201
 - e aborto, 203
 - e eutanásia, 202
 - e pena de morte, 201
 - e tortura, 203
 - ao lazer, 315
- Direito – Conceito, 33**
- Direito adquirido – Conceito e regime, 434**
- Direito a uma duração razoável do processo, 432**
- Direito constitucional**
 - natureza e conceito, 33

- objeto, 34
- Direito de ação e de defesa, 431**
- Direito de cidadania, 344-411**
- Direito de greve**
 - conceito e regime, 304
 - e sindicalização, 465
 - v. tb. Militares; Servidores públicos; Trabalhador
- Direito de igualdade, 211-229**
 - desigualdade, 212
 - discriminação por sexo, 217
 - discriminações e inconstitucionalidade, 227
 - doutrina, 211
 - igualdade jurisdicional, 218
 - igualdade perante a lei, 215
 - introdução ao tema, 211
 - isonomia formal e material, 214
 - Justiça, 213
 - perante a lei penal, 222
 - perante a tributação, 221
 - princípio da não discriminação, 227
 - sem distinção de qualquer natureza, 223-227
- Direito de liberdade, 230-269**
 - conceituação, 232
 - conteúdo histórico, 232
 - doutrina, 231
 - e democracia, 234
 - e liberação do homem, 233
 - e necessidade, 230
 - formas de liberdade, 234
 - de ação e legalidade, 235
 - de ação profissional, 256-258
 - de comunicação, 243-248
 - de expressão cultural, 255
 - de expressão intelectual, artística e científica e direitos conexos, 253
 - de pensamento, 241-243
 - de transmissão e recepção do conhecimento, 255
 - interna e externa, 231
 - pessoa física, 236-240
 - religiosa, 248
- Direito de nacionalidade**
 - conceito de nacionalidade, 318
- fonte constitucional, 325
- *heimatlos*, 321
- modos de aquisição da nacionalidade, 320
- nacionalidade primária e secundária, 320
- natureza, 319
- polipátrida, 321
- teoria, 318
- Direito de nacionalidade brasileira**
 - brasileiros natos, 326
 - condição jurídica, 331
 - brasileiros naturalizados, 330
 - condição jurídica, 332
 - fonte constitucional, 325
 - formação do povo brasileiro, 324
 - perda da nacionalidade brasileira, 332
 - reaquisição da nacionalidade brasileira, 333
- Direito de participação**
 - laboral, 306
 - noção, 261
- Direito de petição, 442**
- Direito de propriedade, 270-284**
 - conceito e classificação, 271
 - função social da propriedade, 281-284
 - fundamento constitucional, 270
 - limitações, 279-281
 - classificação, 279
 - conceito, 279
 - desapropriação, 281
 - restrições, 279
 - servidões, 280
 - utilização de propriedade alheia, 280
 - natureza, 271
 - propriedade e propriedades, 274
 - propriedade pública, 275
 - propriedades especiais, 275-279
 - regime jurídico da propriedade privada, 272
 - restrições, 280
- Direito de representação**
 - coletiva, 260
 - na empresa, 306
- Direito de substituição processual, 305**

Direito de sufrágio – Doutrina, 349

Direito dos consumidores – Fundamentos, 262

Direito individual

- classificação, 193
- conceito, 190
- destinatários, 191

Direitos

- da criança e dos idosos: direito social, 316
- garantia dos, 186, 412

Direitos coletivos

- conceito e regime, 195, 258
- dos trabalhadores, 300
- garantias, 458
- greve, 465
- liberdade de expressão, 258
- sindicalização, 465

Direitos dos trabalhadores

- aposentadoria, 295
- co-gestão, 298
- condições de trabalho, 292
- decisões judiciais normativas, 466
- destinatários, 288
- direito ao trabalho, 289
- direitos coletivos dos trabalhadores
 - caracterização, 300
 - liberdade sindical, 301-304
- direitos reconhecidos, 288
- direitos relativos aos dependentes, 297
- espécies, 288
- fundamentos, 288
- garantia do emprego, 289
- greve, 465
- inatividade, 295
- participação nos lucros, 298
- proteção, 295
- repouso, 295
- salário, 293
- sindicalização, 465

Direitos econômicos e direitos sociais, 286

Direitos fundamentais do homem

- caracteres, 180
- categorias, integração, 184

- classificação, 182
- conceito, 149, 175
- declarações de direitos, 149-171
- direito à privacidade, 205-210
- direito à vida, 197-205
- direito de cidadania, 344-411
- direito de igualdade, 211-229
- direito de liberdade, 230-269
- direito de nacionalidade, 318-334
- direito de propriedade, 270-284
- direitos coletivos, 195
 - à informação, 259
 - de participação, 261
 - de representação coletiva, 260
 - dos consumidores, 262
 - e liberdade de expressão coletiva, 258
 - liberdade de associação, 266
 - liberdade de reunião, 263
- direitos individuais
 - classificação, 194
 - conceito, 190
 - destinatários, 191
- direitos sociais
 - classificação, 287
 - conceito, 286
 - do homem consumidor, 307-317
 - e ordem social, 285
 - fundamentos constitucionais, 285
 - relativos aos trabalhadores, 288-306
- e deveres individuais e coletivos, 195
- e princípio democrático, 123
- eficácia, 467
- fundamentação, 172
- garantias, 186
- inspiração, 172
- normas, 179
- regime das liberdades, 268
 - normas constitucionais sobre liberdades, 268
 - restrições das liberdades individuais, 269
 - técnica de proteção das liberdades, 268
- teoria, 172
- v. tb. Declarações de direitos

Direitos indígenas – Fundamentos constitucionais dos, 851

Direitos políticos

- abrangência, 344
- aquisição da cidadania, 346
- conceito e regime, 344
- direito de sufrágio, 349-368
- e cidadania, 345
- e nacionalidade, 345
- garantias, 466
- modalidades, 346
- negativos, 381-393
 - conceito, 381
 - conteúdo, 381
 - inelegibilidades, 388-393
 - interpretação, 382
- positivos, 348-380
 - conceito, 348
 - instituições, 348
- privação: modos, 382
 - perda, 383, 386, 387
 - suspensão, 384, 386, 387
- readquirição, 386
- v. tb. Estrangeiro

Direitos sociais

- assistência social, 835
- classificação, 287
- conceito, 286
- da seguridade, 287
- do homem consumidor, 262, 307
- dos trabalhadores, 288
- e direitos econômicos, 286
- fundamentos, 285
- garantias, 458, 465
- normatividade, 465
- ordem social, 285
- previdência social, 832
- saúde, 831

Direitos subjetivos – Estabilidade

- ato jurídico perfeito, 435
- coisa julgada, 436
- direito adquirido, 434
- segurança das relações jurídicas, 433

Direitos trabalhistas

- extensão aos militares, 705
- extensão aos servidores públicos, 700

Disciplina – Forças Armadas, 773

Discriminação das rendas tributárias, 719, 732

Discriminações, v. Igualdade

Discriminações e inconstitucionalidade, 227

Disponibilidade, v. Servidores públicos

Dissídios trabalhistas, 579-580

Distrito Federal

- auto-organização, 650
- autonomia, 649
- competências, 650
- funções essenciais à Justiça
 - Defensoria Pública, 653
 - Ministério Público, 653
 - Procuradoria-Geral, 653
- governo, 651-653
- natureza, 649
- Poder Executivo, 651
- Poder Judiciário, 652
- Poder Legislativo, 651
- princípios organizacionais, 649
- v. tb. Intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal

Divisão de Poderes, 106, 108

- doutrina, 108
- exceções ao princípio, 111
- v. tb. Estado Democrático de Direito

Domicílio – Segurança, 437

Domínio econômico

- atuação estatal, 799
- intervenção, 807

E

Economia, v. Atuação do Estado na economia; Ordem econômica

Educação

- autonomia universitária, 838
- direito à educação, 312, 837
- ensino pago e ensino gratuito, 840
- ensino público, 839
- objetivos, 311
- princípios básicos do ensino, 311, 838
- princípios informadores, 311
- serviço público essencial, 837
- significação constitucional, 311

Efeito vinculante e súmulas impeditivas de recursos, 566, 563

Eficácia

- direitos fundamentais, 467
- normas sobre liberdade, 268

Eficiência da atividade administrativa, princípio da, 671

Elegibilidade – Condições, 366
– v. tb. Partidos políticos, Sufrágio

Eleições – Conceito, 368
– v. tb. Inelegibilidades; Prefeito municipal; Procedimento eleitoral; Sistema eleitoral; Sufrágio

Eleitor
– capacidade eleitoral ativa, 356
– corpo eleitoral, 365
– organização do eleitorado, 364
– v. tb. Sufrágio

Eleitorado – Organização, 364

Eleitos – Mandato político, 367

Emendas à Constituição, 61
– terminologia e conceito, 61
– poder constituinte, 64
– poder reformador, 64
• limitações, 65
– procedimento legislativo especial, 531
– sistema brasileiro, 63
– v. tb. Evolução político-constitucional brasileira; Processo legislativo; Reforma constitucional

Empregados públicos, v. Agentes administrativos

Emprego público
– acumulação, v. Agentes administrativos
– inexistência, v. Agentes administrativos

Empresa – Função social e condicionamento à livre iniciativa, 813

Empresa brasileira
– conceito, 797
– e capital estrangeiro, 799
– microempresas, 798

Empréstimo compulsório – Conceito e regime, 707

Ensino
– gratuito, 840
– pago, 840
– princípios básicos, 838
– público, 839
– v. tb. Educação

Equilíbrio federativo, v. Estado Federal

Equiparação de vencimentos, v. Agentes públicos

Escola de magistrados, 592

Escolha profissional – Liberdade de, 256

Escrutínio – Conceito, 379

Escusa de consciência – Liberdade de opinião, 242

Estabilidade – Servidor público, 697

Estado
– conceito, 97
– elementos
• fins, 98
• poder soberano, 98
• povo, 98
• território, 98
– organização, 471
– unitário, 98
– v. tb. Defesa do Estado; Forma de Estado; Intervenção estadual nos Municípios; Intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal

Estado brasileiro
– forma, 99
– fundamentos do, 104
– objetivos, 105
– princípios constitucionais, 97

Estado de defesa
– controle político e jurisdicional, 765-766
– e defesa do Estado, 763
– efeitos e execução, 765
– pressupostos e objetivo, 764

Estado de Direito
– conceito, 112
– e democracia, 112

Estado de sítio
– causas, 766
– conceito, 766
– controle jurisdicional e político, 769-770
– efeitos, 768
– objetivos, 766
– pressupostos, 766

Estado Democrático – Doutrina, 117

Estado Democrático de Direito, 112, 117
– caracterização, 119
– e a lei, 121
– poder democrático, 133
– princípio da legalidade, 121
– princípios

• da constitucionalidade, 122
• da divisão de Poderes, 122
• da igualdade, 122
• da justiça social, 122
• da legalidade, 122
• da segurança jurídica, 122
• democrático, 122
• sistema de direitos fundamentais, 122
– tarefa fundamental, 122
– vontade popular, 131
– v. tb. Democracia

Estado Federal
– autonomia federativa, 100, 484
• competências exclusivas, 100
• e equilíbrio federativo, 484
• e intervenção, 484
• órgãos governamentais próprios, 100
– componentes, 471
– conceito, 99-102
– federação, 101
– forma de governo, 102
– forma do Estado brasileiro, 99
– natureza jurídica, 100
– princípio da indissociabilidade, 101
– princípio republicano, 103
– repartição de competências, 100
– sistema de governo, 104
– unitário, 101
– v. tb. Administração Pública; Atuação do Estado na economia

Estado Federal brasileiro, 104
– declarações de direitos, 170
– direito constitucional brasileiro, 145
– e União Federal, 493
– Estado federal, 99
– fundamentos
• cidadania, 104
• dignidade da pessoa humana, 105
• pluralismo político, 105
• soberania, 104
• valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 105
– objetivos fundamentais, 105
– princípios constitucionais, 97

• Estado Democrático de Direito, 112-122
• poder e divisão de poderes, 106-112
• República Federativa do Brasil, 97-106
– regime político, 125
– v. tb. Direito de nacionalidade brasileira; Federação brasileira; Intervenção estadual nos Municípios; República Federativa do Brasil

Estado Novo – Instauração, 82

Estado Social de Direito – Conceito e doutrina, 115-117

Estados, 100

– poder estatal ou político, 107
– soberania, 107

Estados de exceção – Tipos, 763

Estados federados

– autonomia, 608
– auto-organização, 609
– competências
• comuns e concorrentes, 619
• exclusivas especificadas, 619
• legislativa, 622
• materiais, 620
• reservadas, 618
• tributária comum e exclusiva, 725, 728
• vedadas, 618
– formação, 473, 608
– poder constituinte estadual, 609
• formas de expressão, 610
• limites, 611
– princípios constitucionais
• estabelecidos, 613
• limitadores de sua capacidade organizadora, 617
• sensíveis, 612
– v. tb. Constituição estadual; Estados-membros; Federação; Governos estaduais; Tribunais de Contas (estaduais e municipais)

Estados-membros, 100

– organização administrativa, 662
– órgãos superiores, 662

Estágio probatório, v. Servidores públicos

Estatismo, 800

Estatuto da Magistratura, 583

Estatuto dos Congressistas

- conteúdo, 534
- direitos, 537
- incompatibilidades, 538
- perda do mandato
 - cassação, 539, 540
 - extinção, 540
- prerrogativas, 534
- subsídio, 537

Estatuto dos Deputados Estaduais, 626

Estrangeiro

- asilo político, 340
- conceito, 335
- condição jurídica no Brasil, 335
 - portugueses, 335
- deportação, 342
- direitos civis, 338
- direitos individuais e sociais: gozo, 339
- direitos políticos: não-aquisição, 339
- expulsão, 342
- extradição, 341
- locomoção no território nacional, 337
- v. tb. Propriedade(s) (rural)

Eutanásia, 202

Evolução político-constitucional brasileira

- capitanias hereditárias, 69
- governadores-gerais, 70
- fase colonial, 69
- fase monárquica, 72
- fase republicana, 77
- regime dos Atos Institucionais, 86

Execução de serviços públicos, v. Federação brasileira; Servidores públicos

Exército, v. Forças Armadas

Exoneração, v. Servidores públicos

Expressão – Formas, 241

Expressão coletiva – Liberdade de, 258

Expressão cultural – Liberdade de, 255

Expulsão

- conceito e regime, 342
- v. Estrangeiro

Extinção de mandato, v. Estatuto dos Congressistas

Extradição

- conceito e regime, 341
- v. Estrangeiro

F

Família – Conceito e regime, 848

Federação, 474, 638

- conceito, 99
- estrutura básica, 471
- fundamentos constitucionais, 639
- lei orgânica, 642
- Municípios na, 474
 - organização administrativa, 662
 - órgãos superiores, 663
 - Poderes municipais, 644
- v. tb. Estado Federal

Federação brasileira

- Capital Federal, 472
- competências federativas, 477
 - classificação, 479
- entidades componentes, 471
- Estados, 473
- estrutura básica, 471
- execução de serviços, v. Servidores públicos
- Municípios, 474
 - posição, 639
- repartição de competências federativas, 477
 - gestão associada de serviços públicos, 483
 - princípio da predominância do interesse, 478
 - sistema da Constituição de 1988, 479
 - sistema de execução de serviços, 482
 - técnicas, 478
- Territórios Federais, 473
- vedações constitucionais de natureza federativa, 476

Federalismo

- conceito, 99
- v. tb. Estado Federal

Federalismo cooperativo e repartição da receita tributária, 730

Fidelidade partidária, v. Partidos políticos

Filiação partidária, v. Partidos políticos

Finanças públicas

- colocação do tema, 734
- normas gerais, 734
- sistema orçamentário, 735

Fiscalização contábil, financeira e orçamentária

- formas de controle, 750
- função de fiscalização, 749
- prestação de contas da administração, 759
- sistemas de controle financeiro-orçamentário
 - conceito, 751
 - externo, 752, 758
 - interno, 751
- Tribunais de Contas, 753-759

Forças Armadas

- componentes, 773
- destinação constitucional, 771
- disciplina, 773
- efetivos, 774
- hierarquia, 773
- instituições nacionais permanentes e regulares, 772
- obrigação militar, 774
- organização militar, 776

Forma de Estado

- conceito, 98
- federação de Estados, 99
- Estado unitário, 98

Forma de governo

- conceito, 102
- v. tb. Estado Federal

Função

- jurisdicional, 553
- pública, acessibilidade, 257

Função social

- da empresa, 813
- da propriedade, 281, 819
- e livre iniciativa, 813

Funcionalismo – Regime, 677

Funcionamento da Justiça e Advocacia, 594

Funcionários públicos, v. Agentes administrativos; Servidores públicos

Funções essenciais

- Justiça, 594
- Justiça estadual, 634
- Justiça no Distrito Federal, 653

G

Garantia do emprego, 289

Garantias constitucionais

- classificação e conceito, 417, 419
- confronto com os direitos, 413
- de direitos, 186, 412
- direitos coletivos, 458
 - ação popular, 462
 - mandado de injunção coletivo, 461
 - mandado de segurança coletivo, 459
- direitos individuais, 191, 419
 - classificação, 419
 - direito à segurança, 437-441
 - direito a uma duração razoável do processo, 432
 - estabilidade dos direitos subjetivos, 433-437
 - legalidade, 420-430
 - proteção judiciária, 430-432
 - remédios constitucionais, 441-457
- direitos políticos, 466
- direitos sociais, 465
- direitos sociais relativos aos trabalhadores
 - decisões judiciais normativas, 466
 - greve, 465
 - sindicalização, 465
- eficácia dos direitos fundamentais, 467
- garantia dos direitos, 412
- garantias constitucionais dos direitos, 412
 - classificação, 417
- mecanismos de aceleração dos processos, 591
- outros direitos sociais, 464
- tutela jurisdicional dos hipossuficientes, 465

Governador do Estado, 627

- atribuições, 628
- crimes comuns e de responsabilidade, 629, 630
- impedimentos, 628
- subsídios, 628

- substitutos, 627
- v. tb. Administração estadual
- Governo**
 - conceito, 108
 - e distinções de funções do Poder, 107
 - v. tb. Forma de governo; Sistema de governo
- Governo da União – Sistema**, 492
- Governo do Distrito Federal – Assento constitucional**, 651
- Governos estaduais**
 - esquema constitucional, 622
 - Poder Executivo, 627-631
 - Poder Judiciário, 631-634
 - Poder Legislativo, 622-627
- Governos municipais**
 - Poder Executivo, 644-646
 - Poder Legislativo, 646-647
 - Poderes Municipais, 644
 - v. tb. Municípios
- Greve**
 - direito, 304
 - militares: proibição, 705
 - servidores públicos, 699
 - trabalhadores, 304
- Guardas municipais**, 781
 - instituição, 781

H

- Habeas corpus*, 444
- Habeas data*, 453
- “Heimatlos” – Situação*, 321
- Hipossuficientes – Tutela jurisdicional**, 465
- Honra e imagem das pessoas**, 209

I

- Idoso**
 - direitos sociais, 317
 - tutela, 849
- Igualdade**
 - desigualdade e justiça, 212
 - e lei penal, 222
 - e tributação, 221
 - homens e mulheres, 217
 - jurisdicional, 218
 - perante a lei, 215
 - perante a lei penal, 222
- perante a tributação, 221
- princípio da não discriminação, 227
- sem distinção de qualquer natureza, 223-227
- v. tb. Direitos fundamentais do homem; Estado Democrático de Direito
- Ilícito administrativo – Prescritibilidade**, 673
- Iluminação pública – Contribuição**, 729
- Impedimentos**, v. Governador do Estado
- Impessoalidade da Administração Pública**, 667
- Impostos**, v. Tributos
- Improbidade administrativa**, 669
- Inafastabilidade do controle jurisdicional**, v. Princípio(s) (da proteção judiciária)
- Inatividade**, v. Direitos sociais (dos trabalhadores); Militares
- Incompatibilidades**, v. Estatuto dos Congressistas
- Inconstitucionalidade**
 - conceito, 46
 - discriminações não autorizadas pela Constituição, 227
 - efeitos da declaração, 52
 - por ação ou por omissão, 47
- Indenização – Violação da privacidade**, v. Direitos fundamentais do homem
- Indigenato – Significado**, 856
- Indignidade para com o oficialato**, v. Militares
- Índios**
 - defesa de seus direitos e interesses, 860
 - direitos indígenas: fundamentos constitucionais, 851
 - indigenato, 856
 - organização social: comunidade, etnia e nação, 851
 - terras indígenas, 854, 855
 - demarcação, 860
 - mineração, 859
 - posse permanente, 858
 - usufruto exclusivo das riquezas, 859
- Inelegibilidades**
 - absolutas, 390
 - conceito, 388

- desincompatibilização, 392
- eficácia das normas sobre, 389
- fundamentos, 388
- normas: eficácia, 389
- objeto, 388
- relativas, 390

Infância – Proteção, 316, 849

Infidelidade partidária, v. Partidos políticos

Informação

- direito à, 259
- jornalística, 246
- liberdade, 245

Informática e direito à privacidade, 209

Iniciativa legislativa, v. Processo legislativo

Iniciativa popular, 141

Instituições democráticas – Sistema de defesa, 760

Instituições financeiras

- bases constitucionais, 706
- capital estrangeiro, 826
- disciplina das, 734
- v. tb. Finanças públicas; Fiscalização contábil, financeira e orçamentária; Sistema orçamentário nacional; Sistema tributário nacional

Intervenção

- cessação, 488
- controle, 487
- e autonomia, 484
- limites e requisitos, 486
- natureza, 484
- pressupostos, 485

Intervenção estadual nos Municípios

- competência, 490
- fundamento constitucional, 489
- motivos, 490

Intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal

- ato interventivo, 486
- casos, 485
- cessação, 488
- controle político e jurisdicional, 487
- finalidade, 485
- interventor, 489
 - responsabilidade civil, 489
- pressupostos de fundo, 485
- pressupostos formais, 486

Intervenção no domínio econômico, 807

Interventor – Responsabilidade civil, 489

Intimidade – Direito, 206

Inventos – Propriedade, 277

Investidura em cargo ou emprego público, 679

Inviolabilidade do advogado, 579

Isonomia – Igualdade perante a lei, 215

- forma e material, 215
- paridade etc., 687
- v. tb. Direitos fundamentais do homem

Isonomia de vencimentos, v. Agentes públicos

J

Juizados especiais e de paz, 583

Juizes do Trabalho, 578

Juizes eleitorais, 581

Juizes federais – Competência, 575

- incidente de deslocamento de competência, 577

Jurisdição

- conceito, 553
- e administração, 555
- e legislação, 554
- função jurisdicional, 553
 - órgãos, 556
- v. tb. Poder Judiciário da União

Jurisdição constitucional, v. Supremo Tribunal Federal

Justiça

- funcionamento
 - carreiras jurídicas e isonomia concreta, 595
- funções essenciais, 594
 - Advocacia Pública, 605-607
 - advogado, 595-597
 - Ministério Público, 597-587

Justiça de Paz – Previsão, 583

Justiça do Trabalho

- competência, 579
 - dissídios individuais e coletivos, 579, 580
- organização, 577
 - Juizes do Trabalho, 578

- Tribunais Regionais do Trabalho, 578
- Tribunal Superior do Trabalho, 578

Justiça Eleitoral

- competência, 580-581
- decisões, 581
- organização, 580, 581
- juízes eleitorais, 581
- Tribunais Regionais Eleitorais, 581
- Tribunal Superior Eleitoral, 581

Justiça estadual

- Estatuto da Magistratura Estadual, 634
- descentralização e justiça itinerante, 633
- funções essenciais, 634-636
- garantias da Magistratura Estadual, 634
- organização interna de tribunais e juízes estaduais, 633
- órgãos, 631

Justiça Federal

- juízes federais, 575
- Tribunais Regionais Federais
- composição, 574
- incidente de deslocamento de competência, 577
- organização e competência, 575

Justiça itinerante e descentralização, 633

Justiça Militar

- competência, 582
- composição, 582
- estadual, 632

Justiça social, v. Estado Democrático de Direito

L

Lazer – Direito, 315

Legalidade

- atividade administrativa, 427
- conceito, 420
- controle, 430
- e legitimidade, 424
- e liberdade de ação, 235
- e poder regulamentar, 425
- e reserva de lei, 422
- fundamento constitucional, 420
- penal, 429

- princípios complementares, 429
- tributária, 428
- v. tb. Estado Democrático de Direito; Princípios (da legalidade)

Legislação e jurisdição, 554

Legitimidade *ad causam* – Ação declaratória de constitucionalidade, 57

Legitimidade e princípio da legalidade, 424

Lei – “Em virtude de”, 421

- v. tb. Competência legislativa; Princípios (da legalidade); Processo legislativo; Processo legislativo estadual

Lei complementar

- prevenção de conflitos tributários, 709
- procedimento legislativo especial, 531

Lei delegada – Procedimento legislativo especial, 529, 531

Lei financeira – Procedimento legislativo especial, 531

Lei orgânica, v. Municípios

Lei penal e princípio da igualdade, 222

- anterioridade, 429

Lei tributária, 428

- anterioridade, 429

Leis orçamentárias

- elaboração, 746
- formação, 746
- v. tb. Sistema orçamentário nacional

Liberais – Ideal federalista, 76

Liberdade

- conceituação, 232
- conteúdo histórico, 232
- de ação e legalidade, 235
- de ação profissional
- acessibilidade à função pública, 257
- liberdade de escolha profissional, 256
- regras de contenção, 258
- de associação, 266
- de circulação, 239
- de comunicação
- liberdade de informação em geral, 245
- liberdade de informação jornalística, 246
- liberdade de manifestação do pensamento, 244
- meios de comunicação, 248
- noção, 243
- princípios, 243

- de conhecimento, 255
- de expressão coletiva, 258
- de expressão cultural, 255
- de expressão intelectual artística e científica e direitos conexos, 253
- de informação, 246-248
- de iniciativa econômica, 793
- de locomoção, 237
- de opinião, 241
- de pensamento
- conceito, 241
- escusa de consciência, 242
- formas de expressão, 241-243
- liberdade de opinião, 241-243
- de transmissão e recepção do conhecimento, 255
- de reunião, 263
- e democracia, 234
- e liberação do homem, 233
- e liberdades, 234
- e necessidade, 230
- externa, 231
- formas da, 234
- interna, 231
- legalidade, 235
- partidária, 404
- pessoa física, 236
- pessoal: segurança em matéria penal, 438
- profissional, 256
- religiosa, 248
- sindical, 301

Liberdades

- e liberdade, 234
- eficácia, 268
- regime, 268
- sistemas de restrições, 269
- técnica das, 268

Licitação – Princípio da, 672

Limitações ao direito de propriedade, v. Direito de propriedade

Limitações do poder de tributar, v. Princípios constitucionais tributários

Livre concorrência e abuso do poder econômico, 795

Livre iniciativa

- e função social da empresa, 813
- valor social, 105

Locomoção – Liberdade de, 237

Lucros e resultados – Participação dos trabalhadores, 298

M

Magistratura

- Escola de magistrados, 592
- Estatuto da Magistratura, 583
- princípios estatutários
- acesso aos tribunais de segundo grau, 585
- carreira, 584
- inatividade do magistrado, 586
- Órgão Especial, 587
- publicidade e motivação das decisões, 587
- subsídios, 585

Mandado de injunção, 448

- coletivo, 461

Mandado de segurança

- coletivo, 459
- individual, 446

Mandato político

- doutrina, 138, 367
- partidos, 408

Manifestação do pensamento – Liberdade, 244

Marcas – Propriedade, 277

Marinha, v. Forças Armadas

Maternidade – Proteção, 316

Medidas Provisórias, 532-534

Meio ambiente

- direito, 316
- tutela, 845

Meios de comunicação, 248

Meios de produção – Propriedades, 812

Mesas do Congresso, do Senado e da Câmara, 512, 513

Microempresa, 798

Microrregiões, 664

Militares

- conceito, 701
- da ativa, 703
- direitos e garantias constitucionais, 702
- direitos trabalhistas a eles extensivos, 705
- exercício de função civil, 703
- graduação, 703

- greve: proibição, 705
- inatividade, 703
- incompatibilidade ou indignidade para com o oficialato, 704
- patente ou posto, 702
 - perda, 704
- sindicalização: proibição, 705
- título, 702
- tribunal militar permanente, 704
- uniforme, 702
- v. tb. Justiça Militar

Mineração – Terras indígenas, 859

Ministério Público do Distrito Federal, 653

Ministério Público estadual, 634

Ministério Público

- Conselho Nacional, 603
- Corregedor Nacional, 604
- estrutura orgânica
 - carreira, 601
 - chefia, 599
 - indivisibilidade, 600
 - órgãos, 599
 - unidade, 600
- função essencial à Justiça, 597
- funções institucionais, 602
- garantias, 601
- natureza, 597
- ouvidorias, 604
- princípios institucionais, 597

Ministérios, 659

- setor econômico, 659
- setor militar, 660
- setor político, 659
- setor social, 660

Ministros de Estado

- atribuições, 658
- convocação pelo Congresso Nacional, 523
- investidura no cargo, 658
- no parlamentarismo, 657
- no presidencialismo, 658
- processo e julgamento: juízo competente, 659
- responsabilidade, 659

Monarquia

- centralização, 75
- influências, 73
- Reino Unido a Portugal, 72

Monopólios, 805

Moradia – Direito, 314

Moralidade da Administração Pública, 668

Municípios, 100

- auto-organização, 642
- autonomia municipal
 - base constitucional, 640
 - capacidade de auto-organização, 642
 - competência, 643
 - competência comum, 729
 - competência tributária
 - contribuição de iluminação pública, 729
 - exclusiva, 728
 - lei orgânica própria, 642
- entidade federada?, 640
- fundamentos constitucionais, 639
- governo municipal, 644-648
- posição na federação, 639
- v. tb. Federação brasileira; Intervenção estadual nos Municípios; Tribunais de Contas (estaduais e municipais)

N

Nacionalidade

- aquisição, 320
- cidadania, 345
- conceito, 318-319
- direito de, 319
- perda, 332
- primária, 320
- reaquisição, 333
- secundária, 320
- v. tb. Direito de nacionalidade

Nemo iudex sine actore e advocacia, 594

Nome de empresas – Propriedade, 277

Norma

- conceito, 91
- e princípio, 91

Normas constitucionais sobre liberdades, 268

Normas de prevenção de conflitos tributários

- lei complementar, 709
- resoluções do Senado Federal, 711

Nova República – Constituição de 1988, 88

O

Obrigação militar – Serviço militar, 774

Opinião – Liberdade de, 241

Orçamento – v. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária; Princípios constitucionais orçamentários; Regiões administrativas; Sistema orçamentário nacional

Orçamento-programa – Conceito, 737

Orçamentos públicos – Estrutura, 735

Ordem constitucional da cultura

- ciência e tecnologia, 844
- comunicação social, 844
- cultura e direitos culturais, 842
- desporto, 843
- educação, 837-842
- meio ambiente, 845

Ordem econômica

- atuação estatal no domínio econômico, 799-811
- bases constitucionais, 785
- constitucionalização, 786
- constituição econômica, 790-799
- elementos sócio-ideológicos, 787
- empresa brasileira
 - conceito, 797
 - e capital estrangeiro, 799
 - microempresas, 798
- finalidade, 788
- fundamento e natureza, 788
- idéia, 790
- liberdade de iniciativa econômica, 793
- livre concorrência
 - e abuso do poder econômico, 795
- natureza, 788
- princípios constitucionais, 785, 790
- princípios de integração, 796
- propriedades na ordem econômica, 812-823
- soberania nacional econômica, 792

Ordem social

- base e objetivo, 828
- considerações gerais, 828
- conteúdo, 828
- e direitos sociais, 285
- família, criança, adolescente e idoso, 848-850

- índios, 851-861
- ordem constitucional da cultura, 837-847
- princípios constitucionais, 828
- seguridade social, 830-836

Organismos regionais – Previsão, 664

Organização administrativa – Conceito, 654

Organização militar e seus servidores, 776

Organização partidária, v. Partidos políticos

Órgão Especial nos Tribunais, v. Magistratura

Órgãos administrativos – Autonomia gerencial, 675

Órgãos do Estado

- administrativos, 107
- governamentais, 107

Órgãos superiores

- estaduais, 662
- municipais, 663

Ouvidorias

- Conselho Nacional de Justiça, 570
- do Ministério Público, 604

P

País – Conceito, 97

Paridade de vencimentos, v. Agentes públicos

Parlamentarismo, v. Ministros de Estado; Sistema de governo

Participação

- direito de, 261
- do povo no Poder, 122, 131, 757
- do usuário na administração pública, 675
- laboral, 306
- na administração pública, 675
- nos lucros, 298
- v. tb. Direitos fundamentais do homem

Participação nos lucros, 298

Partidos políticos

- autonomia, 405
- controles, 399, 407
- de oposição, 401
- democracia partidária, 405
- disciplina e fidelidade, 406

- e representação política
 - elegibilidade, 408
 - exercício do mandato, 408
 - sistema eleitoral, 409
 - sistema partidário, 409
- evolução, 395
- exercício do mandato, 408
- filiação partidária, 408
- função, 401
- institucionalização jurídico-constitucional, 399
- liberdade partidária, 404
- natureza jurídica, 403
- noção, 394
- oposição, 401
- organização partidária, 404
- origem e evolução, 395
- princípios constitucionais da organização partidária
 - autonomia partidária, 405
 - democracia partidária, 405
 - disciplina partidária, 406
 - fidelidade partidária, 406
 - infidelidade partidária, 406
 - liberdade partidária, 404, 405
 - sistema de controles, 399, 407
- sistemas partidários, 397

Patente militar, v. Militares

Pena de morte e direito à vida, 201

Pensamento – Liberdade de, 241

Pensão, v. Servidores públicos

Pessoa

- liberdade de circulação, 239
- liberdade de locomoção, 237
- segurança pessoal, 240

Pessoa jurídica de direito público interno – União Federal, 495

Pessoa temporário – Contratação, v. Agentes administrativos

Planejamento econômico, 809

Plebiscito, 142

- revisão constitucional, 90
- v. tb. Evolução político-constitucional brasileira

Pluralismo político

- fundamento do Estado brasileiro, 105
- v. tb. Democracia

Poder

- conceito, 106, 108

- democrático, v. Estado Democrático de Direito
- divisão de Poderes, v. Divisão de Poderes
- e divisão de Poderes, 106, 108
- estatal ou político, v. Poder político
- funções, 107, 108
- fundamentos, 109
- harmonia entre os Poderes, 109
- independência entre os Poderes, 109
- princípio da divisão de Poderes, v. Divisão de Poderes

Poder constituinte e poder reformador, 64

- v. tb. Emendas à Constituição

Poder constituinte estadual

- formas de expressão, 610
- limites, 611
- v. tb. Constituição estadual; Estados Federados

Poder de tributar – Limitações, 712-719

Poder democrático – Exercício, 136

Poder econômico – Abuso, 795

Poder estatal, v. Poder político

Poder Executivo

- Distrito Federal, 651
- estadual, 627
- federal, 542-552
- municipal, 644
- noção e formas, 542

Poder Judiciário da União, 553-593

- *Conselho Nacional de Justiça*, 567
 - competência, 569
 - composição e funcionamento, 568
 - ouvidorias, 570
- garantias constitucionais
 - espécies, 588
 - funcionais, 590
 - institucionais, 588
- incidente de deslocamento de competência, 577
- órgãos, 556
- v. tb. Juizados especiais e de paz; Justiça do Trabalho; Justiça Eleitoral; Justiça Federal; Justiça Militar; Magistratura; Superior Tribunal de Justiça; Supremo Tribunal Federal

Poder Judiciário do Distrito Federal, 652

Poder Judiciário estadual, 631

- jurisdição estadual, 631
- justiça itinerante e descentralização, 633
- órgãos, 631-632
- v. tb. Justiça estadual

Poder Legislativo da União, 509-541

- v. tb. Congresso Nacional; Processo legislativo

Poder Legislativo do Distrito Federal

- Câmara Legislativa, 651

Poder Legislativo estadual

- Assembléia Legislativa, 622-627
- Estatuto dos Deputados estaduais, 626
- processo legislativo, 626

Poder Legislativo municipal – Câmara Municipal, 646-647

Poder político, 106

- funções, 108
 - executiva, 108
 - jurisdicional, 108
 - legislativa, 108
- indelegabilidade, 107, 108
- indivisibilidade, 107, 108
- unidade, 107, 108

Poder regulamentar e princípio da legalidade, 425

Poderes da União – Organização, 504

Poderes municipais – Organização, 644

Polícia(s)

- estaduais, 781
- federais: assento constitucional, 780
- segurança pública, 777

Polipátrida – Conceito, 321

Política urbana e propriedade urbana, 816

Portugueses – Condição jurídica especial no Brasil, 335

Povo

- conceito e democracia, 134
- participação no Poder, 131

Povo brasileiro

- formação, 324
- v. tb. Direito de nacionalidade brasileira

Preceito constitucional fundamental – Arguição de descumprimento, 562

Prefeito municipal, 644

- eleição, 645
- subsídios, 647
- substitutos, 645

Prescrição dos ilícitos administrativos, 673

Presidência da República, 657

Presidencialismo, v. Ministros de Estado; Sistema de governo

Presidente da República

- atribuições, 548
 - classificação, 549
- chefe de Estado e chefe de governo, 542
- eleição, 543
- mandato, 543
- perda do mandato, 547
- reeleição, 369, 391
- responsabilidade, 550
 - crimes comuns, 550-552
 - crimes de responsabilidade, 550-552
- subsídios, 546
- substitutos e sucessores, 545
- v. tb. Presidência da República

Prestação de contas da Administração, v. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária

Prestação de serviços – Competência da União Federal, 497

Prestacionistas de serviço público temporário

- contratação, 681
- v. tb. Agentes administrativos

Previdência social

- direito à, 310
- direito social, 310
- princípios, 832
- v. tb. Seguridade social; Servidores públicos

Princípios

- da anualidade, 741
- da autonomia gerencial, 675
- da constitucionalidade, 122
- da divisão de Poderes, 106, 108, 111, 122
- da eficiência administrativa, 671

- da exclusividade: princípio constitucional orçamentário, 739
- da finalidade administrativa, 667
- da igualdade: isonomia perante a lei, 215
- da impessoalidade da administração pública, 667
- da inafastabilidade do controle jurisdicional, 431
- da indissociabilidade, v. Estado Federal
- da isonomia, 212-229
- da justiça social, 122
- da legalidade administrativa
 - conceito, 420
 - controle da legalidade, 430
 - e atividade administrativa, 427, 667
 - e legitimidade, 424
 - e poder regulamentar, 425
 - e reserva de lei, 422, 428-429
 - “em virtude de lei”, 421
 - fundamento constitucional, 420
 - garantia constitucional individual, 419
 - legalidade penal, 429
 - legalidade tributária, 428
 - “lei”, 420
 - princípios complementares, 429
- da legalidade, 667
 - e função de fiscalização, 749
 - v. tb. Estado Democrático de Direito; Princípios constitucionais orçamentários
- da licitação pública, 672
- da moralidade administrativa, 668
- da não discriminação, 227
- da não-intervenção, 485, 489
- da não-vinculação, 745
- da participação do povo no Poder, 131, 675
- da prescritibilidade dos ilícitos, 673
- da probidade administrativa, 669
- da proteção judiciária
 - direito a uma duração razoável do processo, 432
 - direito ao devido processo legal, 431
- direito de ação, 431
- direito de defesa, 431
- fundamento, 430
- monopólio judiciário do controle jurisdicional, 431
- da publicidade do ato administrativo, 669
- da representação, 131
- da responsabilidade civil da Administração, 673
- da segurança jurídica, 122
- da soberania popular, 131
- da unidade, 742
- da universalidade, 743
- democrático
 - conceito, 91
 - e garantia dos direitos fundamentais, 123
 - e norma, 91
 - v. tb. Estado Democrático de Direito
- do equilíbrio orçamentário, 740
- fundamentais constitucionais
 - conceito e conteúdo, 93
 - função e relevância, 95
 - princípios gerais do Direito Constitucional, 95
- participativo, 141
- republicano, 103
- v. tb. Direitos fundamentais do homem; Estado Democrático de Direito; Igualdade; Tributação

Princípios constitucionais

- do Estado brasileiro, 97-122
- do Estado Democrático de Direito, 122
- e normas, 91
- estabelecidos, 613
- fundamentais, 91, 93
 - e princípios constitucionais gerais, 95
 - função, 95
 - relevância, 95
- positivos, 92
 - jurídico-constitucionais, 93
 - político-constitucionais, 93
- sensíveis, 612

- v. tb. verbete específico e Administração Pública; Constituição econômica; Estado Democrático de Direito; Ordem econômica; Partidos políticos; Poder; Princípios (republicano)

Princípios constitucionais orçamentários

- anualidade, 741
- classificação, 736
- equilíbrio orçamentário, 740
- exclusividade, 739
- formulação, 736
- legalidade, 744
- não-vinculação, 745
- programação, 740
- quantificação dos créditos orçamentários, 745
- unidade, 742
- universalidade, 743

Princípios constitucionais tributários

- classificação, 712-719
- limitações constitucionais do poder de tributar, 712-719

Privacidade e informática, 209

Probidade administrativa, 668

Procedimento eleitoral, 378-380

Procedimentos legislativos

- conceito, 529
- especiais, 531
- ordinário, 529
- sumário, 530

Processo legislativo

- atos, 524
- conceito e objeto, 524
- emendas constitucionais, 526
- iniciativa legislativa, 525
- iniciativa popular, 526
- promulgação, 528
- publicação, 528
- sanção, 527
- veto, 527
- votação, 527

Processo - Mecanismos de aceleração do, 591

Processo legislativo estadual, 626

Procuradoria-Geral do Distrito Federal, 653

Procuradorias estaduais - Função essencial à Justiça estadual, 634

Profissão, 595

- inviolabilidade, 597

Projeto de orçamento anual - Rejeição, 747

Propriedade(s)

- alheia: utilização, 280
- autoral, 275
- bem de família, 278
- de embarcações nacionais, 816
- de interesse público, 815
- direito de, 270
- dos meios de produção, 812
- e propriedades, 274
- especiais, 278
- função social
 - conceito, 281
 - e transformação do regime de propriedade, 283
 - natureza, 281
- fundamento constitucional, 270
- privada, 812
- pública, 275
- recursos naturais, 815
- regime jurídico, 272
- rural
 - e reforma agrária, 819
 - função social, 819
 - limitação ao estrangeiro, 823
 - política agrícola, 823
 - regime, 819
 - usucapião *pro labore*, 823
- socializada, 812
- solo e subsolo e de recursos naturais, 815
- urbana e política urbana, 816

Proteção

- à maternidade e à infância, 316
- judiciária, 430
- trabalhadores, 295

Publicidade das decisões - Poder Judiciário, 587

Publicidade do ato administrativo, 669

R

Receita tributária - Repartição

- e federalismo cooperativo, 730

- normas de controle e disciplina, 732
- técnicas de, 730
- Recorribilidade das decisões do TST**, 580
- Recurso**, v. Tribunais Regionais Eleitorais; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral
- Recursos naturais**, v. Propriedade(s)
- Reeleição – Conceito**, 369
- Referendo popular**, 142
- Reforma agrária**, v. Propriedade(s)
- Reforma constitucional**
 - controle de constitucionalidade, 68
 - limitações, 65
 - v. tb. Emendas à Constituição
- Regime político**, 123, 125
 - brasileiro, 125
- Regimentos internos**, v. Congresso Nacional
- Regiões administrativas**, 664
 - regionalização orçamentária, 664
- Regiões metropolitanas**, 664, 665
 - e microrregiões, 664
- Regionalização**
 - orçamentária, 664
- Regras de contenção – Caracterização**, 258
- Relações jurídicas – Segurança**, 433-437
- Religião – Liberdade religiosa**, 248
- Remédios constitucionais**
 - conceito, 442
 - direito a certidões, 444
 - direito de petição, 442
 - *habeas corpus*, 444
 - *habeas data*, 453
 - mandado de injunção, 448
 - mandado de segurança individual, 446
 - remédios, ações e garantias, 442
- Remuneração**, v. Agentes públicos
- Rendas tributárias**
 - discriminação constitucional, 719-720, 732
 - discriminação pelo produto, 730
 - discriminação por fontes, 721
 - natureza e conceito, 719
- Repartição da receita tributária**, 730
 - controle e disciplina, 732

- técnicas, 730
- Repartição de competências**
 - Constituição de 1988, 479
 - federativas, 477
- Repouso – Direito**, 295
- Representação**
 - direito de, 260
 - na empresa, 306
- República – Conceito**, 102-104
- República Federativa do Brasil**, 97-98
 - e pessoa jurídica de direito internacional, 494
 - Estado brasileiro, 97
 - Estado Federal, 99
 - forma de Estado, 98
 - forma de governo, 102
 - fundamentos, 104
 - objetivos fundamentais, 105
 - país brasileiro, 97
 - território, 98
 - v. tb. Estado Federal brasileiro; Federação brasileira, União Federal
- Reserva de lei e princípio da legalidade**, 422
- Resoluções do Senado Federal – Prevenção de conflitos tributários**, 711
- Responsabilidade civil**
 - da Administração Pública, 673
 - do interventor nos Estados e no Distrito Federal, 489
- Responsabilidade penal**, v. Governador do Estado; Ministros de Estado; Presidente da República
- Revolução de 1930 e a questão social**, 81

S

- Salário – Direito do trabalhador**, 293
- Sanção**, v. Processo legislativo
- Saúde**
 - direito, 308, 831
 - sistema único, 831
- Secretários de Estado**, 663
- Segurança**
 - comunicações pessoais, 438
 - direito à, 437
 - domicílio, 437
 - matéria penal, 438
 - matéria tributária, 441
 - pessoal, 240
 - relações jurídicas, 433
- Segurança jurídica**, v. Direitos subjetivos – Estabilidade; Estado Democrático de Direito
- Segurança pública**
 - e polícia, 777
 - guardas municipais, 781
 - organização, 779
 - polícias estaduais, 781
 - polícias federais, 780
- Seguridade social**, 307
 - assistência social, 835
 - conteúdo, 830
 - direito social, 310
 - financiamento, 830
 - previdência social, 832
 - regime de previdência complementar, 834
 - reserva de direitos, 835
 - princípios, 830
 - saúde, 831
 - sistema único de saúde, 831
- Senado Federal**
 - atribuições privativas, 521
 - representação dos Estados, 511
- Separação de Poderes**, v. Divisão de Poderes; Estado Democrático de Direito; Poder
- Serviço militar**, v. Forças Armadas
- Serviço público**
 - e atividade econômica, 801
 - e atuação estatal no domínio econômico, 801
 - execução, v. Federação brasileira
 - gestão associada, v. Federação brasileira
 - v. tb. Prestação de serviços; Servidores públicos
- Serviço público temporário – Prestacionista**, v. Agentes administrativos
- Servidões**, v. Direito de propriedade
- Servidores públicos**
 - aposentadoria, 691
 - demissão, 698
 - direito preexistente: ressalva, 696
 - direitos previdenciários, 691

- direitos trabalhistas a eles extensivos, 700
- disponibilidade, 694
- efetividade, 697
- estabilidade, 697
- estágio probatório, 698
- execução de serviços, 691
- exoneração, 698
- organização do funcionalismo, 691
- mandato eletivo, 689
- militares, 701
- pensão, 691
- perda do cargo, 698
- previdência complementar, 695
- regime jurídico, 691
- sindicalização e greve, 699
- tempo de contribuição, 693
- tempo de serviço, 693
- vitaliciedade, 699
- v. tb. Agentes administrativos; Militares
- Sindicalização**, v. Direitos sociais (dos trabalhadores); Militares; Servidores públicos
- Sindicato – Direito de substituição processual**, 305
- Sistema constitucional das crises**, 760-761
- Sistema de controle**
 - externo, 752
 - interno, 751
- Sistema de direitos fundamentais**, v. Estado Democrático de Direito
- Sistema de governo – Conceito**, 505
- Sistema eleitoral**
 - conceito, 368
 - e sistema partidário, 409
 - majoritário, 370
 - misto, 376
 - proporcional, 371
- Sistema financeiro nacional**
 - alterações da EC-40/2003, 824
 - cooperativas de crédito, 827
 - generalidades, 824
 - lei complementar e recepção constitucional, 825
 - objetivos, 826

- participação do capital estrangeiro nas instituições financeiras, 826
- Sistema orçamentário nacional**
 - conteúdo dos orçamentos, 738
 - e finanças públicas, 734
 - instrumentos normativos, 735
 - leis orçamentárias, 746
 - processo de formação, 746
 - projeto de orçamento anual: rejeição e suas consequências, 747
 - orçamento-programa, 737
 - princípios orçamentários, 738-746
 - conteúdo dos orçamentos, 738
 - formulação, 738
- Sistema partidário**
 - caracterização, 397
 - e sistema eleitoral, 409
- Sistema remuneratório dos agentes públicos**, 681
- Sistema tributário nacional**
 - contribuições sociais, 708
 - discriminação constitucional das rendas tributárias
 - conceito, 719
 - natureza, 719
 - discriminação constitucional das rendas tributárias pelo produto
 - normas de controle e disciplina da repartição da receita tributária, 732
 - repartição da receita tributária e federalismo cooperativo, 730
 - técnicas de repartição da receita tributária, 730
 - discriminação constitucional das rendas tributárias por fontes
 - atribuição constitucional de competência tributária, 721
 - competência tributária da União, 722
 - competência tributária dos Estados, 725
 - competência tributária dos Municípios, 728
 - elementos, 712
 - empréstimo compulsório, 707
 - limitações do poder de tributar
 - princípios constitucionais da tributação, 712-719
 - normas de prevenção de conflitos tributários
 - lei complementar, 709
 - resoluções do Senado Federal, 711
 - questão de ordem, 706
 - tributos
 - contribuição de melhoria, 707
 - impostos, 707
 - taxas, 707
- Sistemas de governo**
 - conceito, 505
 - parlamentarismo, 506, 543
 - presidencialismo, 505, 542
 - v. tb. Estado Federal
- Sistemas eleitorais**
 - eleições, 368
 - majoritário, 370
 - misto, 376
 - proporcional, 371
 - reeleição, 369
- Soberania**
 - do Estado, 107
 - fundamento do Estado brasileiro, 104
- Soberania nacional econômica**, 792
- Soberania popular**, 131
- Socialismo**, 800, 812
- Sociedade pluralista**, 143
- Solo – Propriedade**, 815
- Subsídio**
 - agentes públicos, 681
 - deputado estadual, 626
 - deputado federal, 537
 - governador e vice-governador, 628
 - magistrado, 585
 - militares, 705
 - prefeito e vice-prefeito, 628
 - presidente e vice-presidente, 546
 - procuradores dos Estados e do Distrito Federal, 653
 - senador, 537
 - vereador, 647
- Subsolo – Propriedade**, 815
- Substituição processual**, v. Sindicato
- Sufrágio**
 - conceito, 349
 - condições de elegibilidade, 366

- direito de sufrágio, 349
 - exercício, 356
 - titulares, 355
 - e voto, 356
 - caracteres, 358
 - natureza, 357
 - elegibilidade, 366
 - eleitos, 367
 - formas, 350
 - funções, 349
 - mandato político dos eleitos, 367
 - natureza, 355
 - titulares, 355
 - Súmulas impeditivas de recursos**, 566
 - e efeito vinculante, 563
 - Súmulas vinculantes**, 563
 - disciplina, 565
 - e assento da jurisprudência, 564
 - Superior Tribunal de Justiça**
 - competência, 571
 - composição, 570
 - Conselho da Justiça Federal, 573
 - Supremacia da Constituição**, v. Constituição; Constituição Federal
 - Supremo Tribunal Federal**
 - competência, 559
 - arguição de descumprimento de preceito constitucional fundamental, 562
 - jurisdição constitucional com controle de constitucionalidade, 560
 - jurisdição constitucional da liberdade, 561
 - jurisdição constitucional sem controle de constitucionalidade, 561
 - composição, 559
 - Corte Constitucional, 557
 - guarda da constituição, 557
 - jurisdição constitucional, 557
 - Súmula vinculante, 563
- T**
- Taxas**, v. Tributos
 - Tecnologia**, 844
 - Tempo de contribuição**, v. Servidores públicos
 - Tempo de serviço**, v. Servidores públicos
 - Terras indígenas**, 854, 845
 - demarcação das, 860
 - direitos sobre, 854
 - mineração em, 859
 - posse permanente, 858
 - usufruto exclusivo, 859
 - Território – Conceito**, 98
 - Territórios Federais**, 473
 - Tortura – Crime**, 203
 - Trabalhadores**
 - dependentes dos, 297
 - direitos coletivos, 300
 - direitos dos, 288
 - liberdade sindical, 301
 - associação, 301
 - contribuição sindical, 303
 - direito de greve, 304
 - direito de participação laboral, 306
 - direito de representação na empresa, 306
 - direito de substituição processual, 305
 - negociações coletivas de trabalho, 302
 - pluralidade sindical, 303
 - sindicato, 301
 - unicidade sindical, 303
 - v. tb. Direitos sociais (dos trabalhadores); Direitos trabalhistas; Dissídios trabalhistas
 - Trabalho – Valor social**, 105
 - Tribunais de Contas**
 - conceito e natureza, 753
 - estaduais e municipais, 757-758
 - Tribunais Regionais do Trabalho**, 578
 - Tribunais Regionais Eleitorais**, 581
 - recorribilidade de suas decisões, 581-582
 - Tribunais Regionais Federais**
 - competência, 576
 - composição, 574
 - Tribunal de Contas da União**
 - atribuições, 754, 758
 - instituição, 753
 - organização, 754

- participação popular, 757
- Tribunal militar permanente**, 704
- Tribunal Superior do Trabalho**, 578
 - recorribilidade das decisões, 580
- Tribunal Superior Eleitoral**, 581
 - irrecorribilidade de suas decisões, 581
- Tributação**
 - disposições gerais, 706
 - e princípio da igualdade, 221
 - princípios constitucionais, 712
 - v. tb. Princípios constitucionais tributários; Sistema tributário nacional
- Tributos**
 - contribuição de melhoria, 707
 - impostos, 707
 - segurança em matéria tributária, 439
 - taxas, 707
 - v. tb. Legalidade (tributária); Tributação
- Tutela jurisdicional – Hipossuficientes**, 465

U

- União Federal**, 100
 - Advocacia-Geral, 605
 - bens, 495
 - competência tributária
 - comum, 724
 - exclusiva, 722
 - residual, 725
 - competências
 - administrativa, 497
 - classificação, 496
 - econômica, 500
 - financeira, 501
 - internacional, 496
 - legislativa, 502
 - matéria urbanística, 499
 - material comum, 501
 - monetária, 501
 - noção, 496
 - política, 496
 - prestação de serviços, 497
 - social, 500
 - conceito, 492

- e Estado Federal, 493
- entidade de direito constitucional, 494
- entidade federativa, 492
- foro, 576
- governo, 505
- natureza, 492
- organização dos Poderes
 - Poder Executivo, 542-552
 - Poder Judiciário, 553-593
 - Poder Legislativo, 509-541
 - Poderes, 504
 - sistemas de governo, 505
- pessoa jurídica de direito internacional, 494
- pessoa jurídica de direito público interno, 495
- posição no Estado Federal, 493
- significado, 492
- v. tb. Federação brasileira; Intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal; República Federativa do Brasil; Tribunal de Contas da União

Unidades federadas – Representação, 606

Universidade – Autonomia, 838

Urbanismo – Competência da União Federal, 499

Usuário – Participação na Administração Pública, 675

Usucapião *pro labore*, v. Propriedade (rural)

Utilização de propriedade alheia, v. Direito de propriedade

V

Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa – Fundamento do Estado brasileiro, 105

Vencimento(s), v. Agentes públicos

Vereadores

- inviolabilidade, 647
- subsídios, 647

Veto, v. Processo legislativo

Vice-Prefeito, v. Prefeito Municipal

Vice-Presidente da República, v. Presidente da República

Vida

- objeto do Direito, 197
- privada: direito, 205-210

Vinculação de vencimentos, 684

Violação da privacidade, 205

Vitaliciedade – Conceito e efeito, 699

Vitória das forças republicano-federalistas, 77

Vontade popular, 131

Voto

- caracteres, 358
- natureza, 357
- sufrágio, 349

I — ABREVIATURAS E SIGLAS DE PERIÓDICOS

- DJU — *Diário da Justiça da União* (Brasília)
RBEP — *Revista Brasileira de Estudos Políticos* (Belo Horizonte)
RDA — *Revista de Direito Administrativo* (Rio de Janeiro)
RDP — *Revista de Direito Público* (São Paulo)
REP — *Revista de Estudios Políticos* (Madrid)
RF — *Revista Forense* (Rio de Janeiro)
RFDUSP — *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo* (São Paulo)
RIL — *Revista de Informação Legislativa* (Brasília)
RPGE — *Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo* (São Paulo)
RT — *Revista dos Tribunais* (São Paulo)
RTJ — *Revista Trimestral de Jurisprudência* (Brasília)
RTJE — *Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados* (São Paulo)

II — OUTRAS ABREVIATURAS E SIGLAS

- ADCT — Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
AI — Ato Institucional
AP — Ação Penal
art. — artigo
c/c — combinado com
CC — Código Civil (Lei n. 3.071/16)
CF — Constituição Federal
CPC — Código de Processo Civil (Lei n. 5.869/73)
CLT — Consolidação das Leis do Trabalho (aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452/43)
CTN — Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/66)
DF — Distrito Federal
EC — Emenda Constitucional
FGTS — Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
HC — *Habeas Corpus*
HD — *Habeas Data*
ICMS — Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
inc. — inciso
LICC — Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei n. 4.657/42)
LOPP — Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n. 5.682/71)
MP — Ministério Público
MS — Mandado de Segurança

- OAB — Ordem dos Advogados do Brasil
Ob. cit — Obra citada
p. ex. — por exemplo
PASEP — Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PIS — Programa de Integração Social
RE — Recurso Extraordinário
ReprInconst — Representação por Inconstitucionalidade
STF — Supremo Tribunal Federal
STJ — Superior Tribunal de Justiça
STM — Superior Tribunal Militar
TAC-SP — Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
TASP — Tribunal de Alçada de São Paulo (extinto)
TFR — Tribunal Federal de Recursos (extinto)
TJ — Tribunal de Justiça
TRE — Tribunal Regional Eleitoral
TRF — Tribunal Regional Federal
TSE — Tribunal Superior Eleitoral
TRE — Tribunal Regional Eleitoral
TST — Tribunal Superior do Trabalho
v.g. — por exemplo (*verbi gratia*)

OBRAS DO AUTOR PELA MALHEIROS EDITORES

- Aplicabilidade das Normas Constitucionais*, 6ª ed., 3ª tir., 2004;
Cadernos de Soluções Constitucionais 1 (Co-edição ABCD, Presidente José Afonso da Silva), 2003;
Comentário Contextual da Constituição, 2005;
Curso de Direito Constitucional Positivo, 25ª ed., 2005;
Direito Ambiental Constitucional, 5ª ed., 2004;
Direito Urbanístico Brasileiro, 3ª ed., 2000;
Manual da Constituição de 1988, 2002;
Manual do Vereador, 5ª ed., 2004;
Ordenação Constitucional da Cultura, 2001;
Poder Constituinte e Poder Popular, 1ª ed., 2ª tir., 2004.